JORGE DE FIGUEIREDO DIAS

DIREITO PENAL

PARTE GERAL

TOMO I

2ª EDIÇÃO

QUESTÕES FUNDAMENTAIS
A DOUTRINA GERAL DO CRIME



Coimbra Editora

DIREITO PENAL

PARTE GERAL

TOMO I

Questões Fundamentais
A Doutrina Geral do Crime

2.ª EDIÇÃO

JORGE DE FIGUEIREDO DIAS

DIREITO PENAL

PARTE GERAL

TOMO I

Questões Fundamentais
A Doutrina Geral do Crime

2.ª EDIÇÃO



Coimbra Editora

2007

Composição e impressão
Coimbra Editora, Limitada

ISBN 972-32-1287-0 (Obra completa)
ISBN 978-972-32-1523-6 — Tomo I, 2.ª ed.
(ISBN 972-32-1288-9 — Tomo I, 1.ª ed.)

Depósito Legal n.º 219 795/2004

Agosto de 2007

A todos os meus "discípulos" que tornaram possível e deram vida ao *Liber Discipulorum para Figueiredo Dias* — com laços de gratidão e amizade tão fortes que comigo viverão para sempre

PREFÁCIO DA 2.ª EDIÇÃO

Dois anos e meio após a publicação deste livro decido-me a dar à estampa uma 2.ª edição. Porque a receptividade do leitor fez com que a edição inicial, se bem que estendida depois, relativamente ao número de exemplares inicialmente previstos, se encontre esgotada. Mas sobretudo porque as alterações e complementos introduzidos no texto, e que o aumentaram de cerca de 300 páginas, são a meus olhos suficientemente significativas para justificar que a presente edição possa ser considerada como "obra diferente". Fruto de um esforço de actualização legislativa, jurisprudencial e doutrinal, que incidiu sobretudo nos problemas "novos" do direito penal deste princípio de século. Mas fruto — e este foi para mim o motivo essencial — de uma mudança do propósito anunciado no Prefácio da 1.ª edição.

Escrevi eu naquele Prefácio que esperava ter tempo para, num Tomo II desta obra, tratar uma parte ainda em falta da doutrina geral do crime: a relativa às tradicionalmente chamadas "formas especiais do crime". Verdade é porém que escrevi aquelas palavras apenas em nome de uma por mim suposta consideração editorial de índole pragmática, a sobrepor-se aos fundamentos dogmáticos que reputo mais correctos. Os meus alunos sempre me ouviram insistir em que as teorias da "tentativa" e da "comparticipação" constituem, de corpo inteiro, capítulos integrantes do ilícito típico dos delitos dolosos de acção, dos delitos de omissão e (em parte) dos delitos negligentes, só o "concurso" podendo justificar-se como "forma especial de aparecimento do(s) crime(s)". Quando a *Coimbra Editora* — cuja disponibilidade e compreensão tão amigas me é grato agradecer aqui — me comunicou que a consideração editorial por mim suposta, num incómodo *sacrificium intellectus*, não existia, nada mais foi necessário para que me decidisse por esta nova edição, na qual são tratados, nos lugares sistemáticos que julgo devidos, os temas da tentativa, da comparticipação e do concurso. Em suma, pois, esta edição contém na sua totalidade a "doutrina

geral do crime". Se a este tomo se seguirá um Tomo II, dedicado exclusivamente às "consequências jurídicas do crime", depende de muitas condições que não posso dominar, mas corresponde à minha mais funda esperança. Mesmo que, tal como com esta nova edição em larga medida sucedeu, a obra só venha a ser realizada (se posso usar as palavras de Shakespeare, no *King Lear*) "assim fora de horas, dobando os fios das trevas da noite".

Também desta vez tenho, felizmente, muitos agradecimentos a fazer, acompanhados de sentimentos do mais profundo e fiel afecto. À Susana Aires de Sousa, que não só me acompanhou passo a passo e me ajudou, por formas várias mas sempre competentes, nas aulas que dediquei aos temas aqui pela primeira vez versados, como revelou por eles um interesse que a conduziu a investigar alguns de forma autónoma e pessoal, nomeadamente, os relativos aos bens jurídicos colectivos, à comunicabilidade e incomunicabilidade das circunstâncias na comparticipação, ao concurso; ao que acresceu o trabalho insano de refazer o índice de matérias e de auxiliar na revisão de provas. À Cláudia Cruz Santos, pelas longas conversas que comigo manteve a propósito da instigação como forma de autoria e da categoria do "domínio da decisão". Ao Pedro Caeiro, por não apenas me ter ajudado a actualizar e completar as referências em tema de direito penal internacional e europeu, mas me ter dado conta de importantes dúvidas e sugestões em sede de *actiones liberæ in causa*. Ao Nuno Brandão, por ter lido e comigo discutido as questões ligadas à "obediência devida" e me ter chamado a atenção para importantes decisões jurisprudenciais portuguesas. À Paula Ribeiro de Faria, pelas reacções que o meu texto lhe suscitou em matéria, sobretudo, de tipo de ilícito objectivo. À Cristina Líbano Monteiro, pela troca de pontos de vista sobre a natureza da pena do concurso. À Helena Moniz, pela análise a que submeteu as minhas referências aos crimes agravados pelo resultado e a própria noção jurídico-penal de resultado. Ao André Leite, pela minuciosa consideração das posições que avanço em matéria de delitos de omissão. À Sónia Fidalgo, por ter tomado sobre si o esforço beneditino de rever as provas do livro e a esse propósito me ter suscitado muitas dúvidas e oferecido várias sugestões. Para a Rita Mano Lopes, que uma vez mais arcou com inumeráveis e pesados trabalhos de secretariado, vai a minha gratidão pela sua paciência e empenho e, acima de tudo, pela sua rara capacidade de me "inventar" o tempo disponível para consecução das tarefas científicas.

À medida que os anos avançam, a persistência e a teimosia indispensáveis para que, no trabalho intelectual, ultrapasse os escolhos e as dificuldades vão naturalmente enfraquecendo: só o clima de fraterna amizade pessoal e de convivialidade académica que continua a rodear-me pôde evitar que se tivessem erguido barreiras inultrapassáveis que me levassem a parar e a desistir.

Coimbra, em Junho de 2007

Jorge de Figueiredo Dias

PREFÁCIO DA 1.ª EDIÇÃO

Post tantos tantosque labores surge o há já décadas sonhado e a espaços trabalhado Tomo I do meu *Direito Penal, Parte Geral*. Entre ele e o livro que publiquei em 1993 — *Direito Penal Português. Parte Geral II. As Consequências Jurídicas do Crime* — permanece ainda uma lacuna relativa às "Formas Especiais do Crime". Confio em que os fados me sejam favoráveis e me permitam colmatá-la em prazo breve, elaborando o Tomo II da obra que agora dou a público e que deverá conter, para além do tratamento das referidas formas especiais, uma reelaboração da matéria relativa às consequências jurídicas do crime.

Sobre o tempo e o modo em que surge o presente escrito já tive ocasião de me pronunciar no Prefácio que se contém no meu aludido livro de 1993 e neles, por isso, não insistirei. Como tão-pouco nos propósitos e nas características que assume a exposição sistemática que se segue, confiando em que resultarão dela por si mesmos com clareza bastante, e abrindo deste modo um espaço mais amplo à crítica que com ela queira entretecer-se. Limitar-me-ei por isso a duas considerações.

A primeira para dizer que a publicação desta obra sempre se assumiu para mim como um imperativo intelectual e universitário. A segunda para confessar que, de algum modo, este tratamento constitui uma espécie de testemunho: quer porque, em muitas partes, insiste em certas concepções básicas que me possuem quase desde os tempos em que comecei a laborar sobre o direito penal mas que — perdoe-se-me a imodéstia — continuo a pensar exactas; quer porque o direito penal está posto de modo irremediável, neste dealbar de século, perante grandes desafios que, muito provavelmente (com a aceleração histórica de que sofrem hoje também as coisas do espírito), conduzirão em alguns anos, se não a uma nova imagem, a uma sua deslocação para o tratamento de problemas novos. Tenho por isso clara consciência de que este livro deve, naquela acepção,

muito mais ao passado do que ao futuro. Mas talvez que uma leitura atenta de algumas das suas páginas possa dar a perceber que muitos desses novos e grandes problemas palpitam — embora com a leveza e o silêncio do bater das asas de uma borboleta — sob a pesada carga dogmática tradicional de que a obra fundamentalmente se nutre.

Nesta data em que perfaço, dia por dia, 45 anos de docência universitária, seja-me permitida uma palavra ainda sobre o sentido da dedicatória com que abro esta obra. Nunca entendi a vida universitária como exercício individual e regozijo solitário. Pelo contrário, desde cedo me apercebi de que a via do estudo só pode alimentar a diferença se, ao mesmo tempo, se nutrir da partilha com os outros. Neste ir e vir perpétuo se faz o universitário, a meio-caminho das suas convicções imprescindíveis e da resposta irrecusável daqueles para quem escreve e fala. Por isso se compreenderá que aquilo que mais fundamente me tocou ao longo da minha carreira universitária tenha sido a relação cooperativa, solidária e fraterna que entre mim e os meus discípulos sempre floresceu, em autenticidade plena. A quem pois, se não a eles, podia este livro ir dedicado, corporizando-os nos que tiveram a generosidade de tornar possível e me oferecer a mais bela dádiva — o *Liber discipulorum* — que recebi em toda minha vida universitária?

Agradeço de modo particular e muito pessoal a Pedro Caeiro, Nuno Brandão, João Salgado, Joana Trindade, Rita Lopes e Inês Horta a colaboração amiga que, de forma vária mas estreita, me prestaram ao longo do último e intenso período de trabalho que conduziu a esta publicação.

Coimbra, 3 de Novembro de 2004

Jorge de Figueiredo Dias

ÍNDICE GERAL

Págs.

ÍNDICE DE ABREVIATURAS XXXV

PARTE I

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

TÍTULO I

O DIREITO PENAL E A SUA CIÊNCIA NO SISTEMA JURÍDICO ESTADUAL

1.º CAPÍTULO

O DIREITO PENAL EM SENTIDO FORMAL

I. O conceito de direito penal 3
1. Definição e designação 3
2. Direito penal e *ius puniendi* 6

II. O âmbito do direito penal 6
1. Direito penal substantivo, direito penal executivo e direito processual penal 6
2. A parte geral do direito penal e as suas componentes 8

2.º CAPÍTULO

A LOCALIZAÇÃO DO DIREITO PENAL NO SISTEMA JURÍDICO

I. Direito penal intra-estadual e direito internacional penal 10
II. O direito penal como parte do direito público 13
III. O direito penal perante os outros ramos do direito. Autonomia e dependência do direito penal 14

3.º CAPÍTULO

A CIÊNCIA CONJUNTA DO DIREITO PENAL

I. Da "enciclopédia das ciências criminais" à "ciência conjunta do direito penal" 18
II. A evolução do estatuto das ciências criminais 21
1. No contexto do Estado de Direito formal (liberal-individualista) e do positivismo jurídico 21
2. No contexto do Estado social e do sociologismo jurídico 23

Págs.

III. O estatuto das ciências criminais no quadro do Estado de Direito contemporâneo e de um sistema jurídico-penal teleológico-funcional e racional 26
1. Dogmática jurídico-penal e política criminal 27
1.1. A transformação da função da dogmática jurídico-penal 27
1.2. A posição de domínio e transcendência da política criminal 33
1.3. Conclusão 37
2. Dogmática jurídico-penal e criminologia 38

IV. Síntese conclusiva 41

TÍTULO II
A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL

4.º CAPÍTULO
FINALIDADES E LEGITIMAÇÃO DA PENA CRIMINAL

I. O problema dos "fins" da pena criminal 43
II. Teorias absolutas: a pena como instrumento de retribuição 45
III. Teorias relativas: a pena como instrumento de prevenção 49
1. Consideração geral 49
2. A pena como instrumento de prevenção geral 50
3. A pena como instrumento de prevenção especial ou individual 54
4. A "concertação agente-vítima" e a reparação dos danos 58

IV. Teorias mistas ou unificadoras 60
1. Teorias em que reentra ainda a ideia da retribuição 60
2. Teorias da prevenção integral 62

V. O problema dos fins das penas e a doutrina do Estado, nomeadamente à luz da sua evolução em Portugal 64
1. As finalidades e a justificação da pena na época das Luzes e no CP de 1852 66
2. As finalidades e a justificação da pena na época liberal e no CP de 1886... 69
3. As finalidades e a justificação da pena na época do Estado corporativo.... 73
4. A evolução posterior à institucionalização do Estado de Direito 75

VI. Finalidades e limite das penas criminais 78
1. A natureza exclusivamente preventiva das finalidades da pena 78
2. Ponto de partida: as exigências da prevenção geral positiva ou de integração 79
3. Ponto de chegada: as exigências da prevenção especial, nomeadamente da prevenção especial positiva ou de socialização 81
4. A culpa como pressuposto e limite da pena 82
5. Conclusão 84

5.º CAPÍTULO

FUNDAMENTO, SENTIDO E FINALIDADES DA MEDIDA DE SEGURANÇA CRIMINAL

Págs.

I. As medidas de segurança criminais no sistema sancionatório ... 86
II. Finalidades e legitimação da medida de segurança ... 88
1. O problema das finalidades ... 88
1.1. Finalidade prevalente: a prevenção especial em função de um facto ilícito-típico ... 88
1.2. Finalidade secundária: a prevenção geral ... 92
2. O problema da legitimação ... 95

III. O relacionamento da pena com a medida de segurança: a questão do "monismo" ou "dualismo" do sistema ... 99
1. Medida de segurança e pena ... 99
2. O dualismo do sistema ... 100
3. Monismo e dualismo: estado actual da controvérsia e perspectivas futuras ... 102

6.º CAPÍTULO

O COMPORTAMENTO CRIMINAL E A SUA DEFINIÇÃO: O CONCEITO MATERIAL DE CRIME

I. O conteúdo material do conceito de crime ... 106
1. A perspectiva positivista-legalista: do conceito "formal" ao conceito "material" de crime ... 106
2. A perspectiva positivista-sociológica ... 108
3. A perspectiva moral (ético)-social ... 111
4. A perspectiva racional: a função de tutela subsidiária de bens jurídicos dotados de dignidade penal (bens jurídico-penais) ... 113
4.1. Uma primeira aproximação à noção de bem jurídico. Evolução ... 114
4.2. Bem jurídico, sistema social e sistema jurídico-constitucional ... 117
4.3. Consequências da orientação defendida ... 123
4.4. A jurisprudência do TC ... 126
5. O critério da "necessidade" (ou da "carência") de tutela penal ... 127
5.1. Necessidade de tutela penal e princípio jurídico-constitucional da proporcionalidade em sentido amplo ... 127
5.2. A questão das imposições constitucionais implícitas de criminalização ... 129
5.3. O princípio da não-intervenção moderada e o movimento da descriminalização ... 131

II. A definição social do crime ... 132
III. A crise actual do "direito penal do bem jurídico" ... 133
1. O paradigma penal das sociedades democráticas contemporâneas, o direito penal do bem jurídico e os desafios da "sociedade do risco" ... 133
2. Tentativas de resolução do problema ... 137
2.1. A concepção antropocêntrica (monista-pessoal) do bem jurídico-penal ... 137
2.2. A funcionalização intensificada da tutela penal: o abandono do "direito penal do bem jurídico" em favor de um "direito penal do risco" ... 138

Págs.

2.3. O direito penal de tutela de "relações da vida como tais" 139
2.4. Posições intermédias 141
2.4.1. A "expansão do direito penal" 141
2.4.2. Os bens jurídicos dotados de "referente pessoal" 142
2.4.3. Os bens jurídico-penais "instrumentais" 143
3. A subsistência do modelo do direito penal do bem jurídico na sociedade do risco 144
3.1. Para uma análise das concepções expostas 145
3.2. Um princípio de solução: os "bens jurídicos colectivos" 148
3.3. Conclusão 154

7.º CAPÍTULO

OS LIMITES DO DIREITO PENAL

I. Direito penal e direito de mera ordenação social (direito das contra-ordenações): penas criminais e coimas 155
1. Do direito penal administrativo ao direito de mera ordenação social 155
2. Fundamentos e sentido da autonomização do direito de mera ordenação social 160
2.1. A autonomia material do ilícito 161
2.2. A autonomia da sanção 165
3. Um juízo conclusivo 167

II. Direito penal e direito disciplinar: penas criminais e sanções (medidas) disciplinares 168
III. Direito penal e direito processual: penas criminais e sanções (medidas) de ordenação ou conformação processual 173
IV. Direito penal e direito privado: penas criminais e penas privadas 174

TÍTULO III

A LEI PENAL E A SUA APLICAÇÃO

8.º CAPÍTULO

O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DA INTERVENÇÃO PENAL

I. O princípio *nullum crimen, nulla pœna sine lege* 177
1. Função, sentido e fundamentos 177
2. *Nullum crimen sine lege* 180
3. *Nulla pœna sine lege* 181

II. O plano do âmbito de aplicação 183
III. O plano da fonte 184
IV. A determinabilidade do tipo legal 185
V. A proibição da analogia 187
1. Interpretação e analogia em direito penal 187
2. Âmbito da proibição de analogia 192

VI. A proibição de retroactividade. O âmbito de validade temporal da lei penal ou problema da "aplicação da lei penal no tempo" 193
1. Aplicação da lei penal no tempo e princípio da irretroactividade 193
2. Determinação do *tempus delicti* 194

Págs.

3. Âmbito de aplicação da proibição 195
4. O princípio da aplicação da lei mais favorável 198
4.1. As hipóteses de descriminalização 199
4.2. As hipóteses de atenuação da consequência jurídica 201
4.3. As leis intermédias 203
4.4. O regime 204
4.5. As chamadas "leis temporárias" 205

9.º CAPÍTULO

ÂMBITO DE VALIDADE ESPACIAL DA LEI PENAL

I. O sistema de aplicação da lei penal no espaço e os seus princípios constitutivos... 207
II. Conteúdo e sistema de combinação dos princípios aplicáveis 209
1. O princípio básico da territorialidade 209
1.1. Justificação e conteúdo 209
1.2. O problema da "sede do delito" 211
1.3. Problemas particulares 214
1.4. O chamado "critério do pavilhão" 215
1.5. Uma nova extensão da competência da lei penal portuguesa: certos factos praticados a bordo de aeronaves civis 215
2. O princípio complementar da nacionalidade 216
2.1. Justificação e conteúdo 216
2.2. Condições de aplicação 218
2.2.1. Que o agente seja encontrado em Portugal 218
2.2.2. Que o facto seja também punível pela legislação do lugar em que tiver sido praticado 218
2.2.3. Que o facto constitua crime que admita extradição e esta não possa ser concedida 219
2.3. Extensão do princípio da nacionalidade 223
3. O princípio complementar da defesa (da protecção) dos interesses nacionais... 224
4. O princípio complementar da universalidade 226
5. O princípio complementar da administração supletiva da justiça penal..... 228

III. Condições gerais de aplicação da lei penal portuguesa a factos cometidos no estrangeiro 229

PARTE II

A DOUTRINA GERAL DO CRIME

TÍTULO I

A CONSTRUÇÃO DA DOUTRINA DO CRIME (DO FACTO PUNÍVEL)

10.º CAPÍTULO

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

I. Sentido, método e estrutura da conceitualização do facto punível 235
II. Sobre a evolução histórica da doutrina geral do facto punível 238
1. A concepção "clássica" (positivista-naturalista) 239
1.1. Exposição sumária 239
1.2. Apreciação crítica 240

Págs.

2. A concepção neoclássica (normativista) 242
2.1. Exposição sumária 242
2.2. Apreciação crítica 243
3. A concepção finalista (ôntico-fenomenológica) 244
3.1. Exposição sumária 244
3.2. Apreciação crítica 246

III. Fundamentos de uma construção teleológico-funcional e racional do conceito de facto punível 248
1. Preliminares 248
2. A discussão à roda do conceito de acção e as formas básicas de aparecimento do crime 251
2.1. As funções atribuíveis ao conceito de acção dentro de um sistema categorial-classificatório 251
2.2. O conceito final de acção 254
2.3. O conceito social de acção 255
2.4. O conceito "negativo" de acção 257
2.5. O conceito pessoal de acção 257
2.6. Conclusões 259
2.6.1. Necessidade de a teoria da acção ceder a primazia à teoria da realização típica do ilícito 259
2.6.2. Distinção das formas básicas, tipicamente cunhadas, do facto punível 261
3. As categorias dogmáticas 262
3.1. O tipo de ilícito 265
3.1.1. Tipicidade, ilicitude e causas de justificação 265
3.1.2. A questão da "localização sistemática" do dolo e da negligência 270
3.2. O tipo de culpa 274
3.2.1. Significado e função da culpa na construção da doutrina do facto punível 274
3.2.2. Tipos de culpa, dolo e negligência 277
3.2.3. As questões da "culpa" e da "responsabilidade" na sua expressão sistemática 278
3.3. A punibilidade 280

TÍTULO II

OS FACTOS PUNÍVEIS DOLOSOS DE ACÇÃO

SUBTÍTULO 1

O TIPO DE ILÍCITO

SECÇÃO 1

OS TIPOS INCRIMINADORES

II.º CAPÍTULO

O TIPO OBJECTIVO DE ILÍCITO

A. QUESTÕES GERAIS DE TIPICIDADE 284

I. Determinações conceituais: tipo de garantia, tipo de erro e tipo de ilícito 284
II. Desvalor de acção e desvalor de resultado 285

Págs.

III. Elementos típicos descritivos e normativos 288
IV. Tipos abertos, elementos valorativos globais e adequação social 290
1. A construção de Welzel 290
2. Apreciação crítica 292

B. A CONSTRUÇÃO DOS TIPOS INCRIMINADORES 295

I. O autor 295
1. Princípio geral 295
2. A questão da responsabilidade penal dos entes colectivos 295
3. O autor individual. Crimes comuns e crimes específicos 303

II. A conduta. Crimes de resultado e crimes de mera actividade 305
III. O bem jurídico. Crimes de dano e crimes de perigo; crimes simples e crimes complexos 308
1. Bem jurídico e objecto da acção 308
2. Crimes de dano e crimes de perigo 308
3. Crimes simples e crimes complexos 311
4. As dicotomias crimes de mera actividade e de resultado e crimes de perigo e dano 312

IV. Grupos de tipos e figuras típicas de estrutura especial 313
1. Crime fundamentais, qualificados e privilegiados 313
2. Crimes instantâneos, crimes duradouros (ou permanentes) e crimes habituais 314
3. Crimes de empreendimento 315
4. Crimes qualificados pelo resultado 315
4.1. O *versari in re illicita* 316
4.2. O crime preterintencional 316
4.3. O crime agravado pelo resultado 318

12.º CAPÍTULO

A IMPUTAÇÃO OBJECTIVA DO RESULTADO À ACÇÃO

I. Sentido do problema 322
II. Primeiro degrau: a categoria da causalidade 323
III. Segundo degrau: a causalidade jurídica sob a forma da teoria da adequação 327
IV. Terceiro degrau: a conexão de risco 331
1. Criação de um risco não permitido 332
2. A potenciação do risco 335
3. A concretização do risco não permitido no resultado típico 336
4. A produção de resultados não cobertos pelo fim e pelo âmbito de protecção da norma 339

V. A questão da "causalidade virtual" 342
VI. Problemas especiais 343
1. Relativos aos crimes de perigo 343
2. Relativos à criminalidade de massa própria da "sociedade do risco" 345
3. Relativos a crimes de organização ou de entes colectivos 346

13.º CAPÍTULO

O TIPO SUBJECTIVO DE ILÍCITO

Págs.

I. A construção do tipo subjectivo de ilícito 348
II. O dolo do tipo 349
1. A estrutura do dolo do tipo 349
2. O momento intelectual do dolo 351
2.1. O conhecimento das circunstâncias do facto 352
2.1.1. O conhecimento dos elementos normativos 352
2.1.2. A actualidade da consciência intencional da acção 355
2.1.3. O erro sobre a factualidade típica 356
2.2. A previsão do decurso do acontecimento 358
2.2.1. O erro sobre o processo causal 358
2.2.2. O chamado *dolus generalis* 360
2.2.3. A aberratio *ictus vel impetus* 361
2.2.4. O *error in persona vel objecto* 362
2.3. O conhecimento da proibição legal 363
3. O momento volitivo do dolo 366
3.1. O dolo directo 366
3.2. O dolo eventual 368
3.2.1. Termos da distinção entre dolo eventual e negligência consciente 368
3.2.1.1. Teorias da probabilidade 369
3.2.1.2. Teorias da aceitação 370
3.2.1.3. Teorias da conformação 371
3.2.1.4. Conclusão 374
3.2.2. Consequências da distinção 377
4. A conexão entre o dolo do tipo e a sua realização 378

III. Os especiais elementos subjectivos do tipo 379
1. Intenções 380
2. Outros elementos subjectivos especiais do tipo 382

SECÇÃO II

OS TIPOS JUSTIFICADORES (CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO OU DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE)

14.º CAPÍTULO

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

I. Especificidades dos tipos justificadores face aos tipos incriminadores relativamente ao problema da ilicitude 384
1. Complementaridade funcional e diversidade estrutural. Consequências ... 384
2. Causas de justificação e princípio da unidade da ordem jurídica 387

II. Tentativas de sistematização das causas de justificação 390
III. Elementos subjectivos dos tipos justificadores 391
IV. A aceitação errónea da verificação dos pressupostos de uma causa de justificação 396

Págs.
V. Causas de justificação e imputação objectiva 400
VI. O efeito das causas de justificação 401

15.º CAPÍTULO

A LEGÍTIMA DEFESA

I. Fundamento 404
II. A situação de legítima defesa: requisitos 408
1. Agressão de interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro 408
1.1. O comportamento agressivo 408
1.2. Os interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro 410
2. A actualidade da agressão 411
2.1. O início da actualidade da agressão 411
2.2. O término da actualidade da agressão 413
3. A ilicitude da agressão 414
III. A acção de defesa: requisitos 418
1. A necessidade do meio 419
2. A necessidade da defesa 423
2.1. Agressões que não importam uma desatenção unívoca pelos direitos do agredido 424
2.1.1. Agressões não culposas 424
2.1.2. Agressões provocadas 425
2.2. Crassa desproporção do significado da agressão e da defesa 427
2.3. Posições especiais 430
2.4. Actos de autoridade 431
3. O elemento subjectivo 433
4. A acção de defesa que recaia sobre terceiros 433
IV. O auxílio necessário 434
V. O direito de legítima defesa jurídico-civil (art. 337.º do CC) 435

16.º CAPÍTULO

OS ESTADOS DE NECESSIDADE JUSTIFICANTES

I. A evolução da doutrina do estado de necessidade 438
II. O direito de necessidade do art. 34.º 441
1. A situação de necessidade 441
1.1. Os interesses juridicamente protegidos em conflito 441
1.2. O perigo que ameaça o bem jurídico 443
1.3. A "provocação" do perigo 444
2. O princípio do interesse preponderante 445
2.1. Os pontos de vista relevantes para a ponderação 445
2.1.1. As molduras penais 446
2.1.2. A intensidade da lesão do bem jurídico 447
2.1.3. O grau do perigo 448
2.1.4. A autonomia pessoal do lesado 449
2.1.5. A "imponderabilidade" da vida de pessoa já nascida 450
2.2. A "sensível superioridade" do interesse salvaguardado 456
3. A "adequação do meio" 458

Págs.
4. O auxílio de terceiro 459
5. Requisitos subjectivos 459

II. O estado de necessidade defensivo jurídico-penal 460
III. O estado de necessidade jurídico-civil (art. 339.º do CC) 464
IV. O conflito de deveres de actuar justificante do art. 36.º 466

17.º CAPÍTULO

OS CONSENTIMENTOS JUSTIFICANTES

I. O consentimento real ou efectivo (ou simplesmente "consentimento") 470
1. O pensamento fundamental 470
2. O estatuto dogmático-sistemático do consentimento 472
3. A questão do "objecto" do consentimento 477
4. Pressupostos de eficácia do consentimento justificante 478
4.1. O carácter pessoal e a disponibilidade do bem jurídico lesado 478
4.2. A não contrariedade do facto consentido aos "bons costumes" 481
4.3. O acto de *auto*determinação 483
4.3.1. Incapacidade e representação 483
4.3.2. Falta de liberdade da vontade 484
4.3.3. Formalismo 487
4.4. O conhecimento do consentimento 488
5. O consentimento dito "hipotético" 488

II. O consentimento presumido 489
1. Pensamento fundamental 490
2. Requisitos de eficácia 491

18.º CAPÍTULO

OUTRAS CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO

I. A actuação oficial 494
II. Ordens oficiais ou de serviço 497
III. Autorizações oficiais 500
IV. Actuação no lugar de um órgão oficial ("agere pro magistratu") 504
1. Detenção em flagrante delito 504
2. Acção directa (art. 336.º do CC) 505

V. O direito de correcção 506

SUBTÍTULO II

O TIPO DE CULPA

SECÇÃO I

A FUNDAMENTAÇÃO DA CULPA

19.º CAPÍTULO

QUESTÕES BÁSICAS DA DOUTRINA DA CULPA

I. A história dogmática do conceito 511
II. O conteúdo material da culpa jurídico-penal 514
1. Introdução 514

Págs.

2. A liberdade como "livre-arbítrio" e as teses da culpa da vontade 515
2.1. Culpa e poder concreto e individual de agir de outra maneira na situação 515
2.2. Tentativas de "abstracção" ou "generalização" do "poder de agir de outra maneira" 518
2.3. A "culpa do (ou pelo) carácter" 520
3. A liberdade pessoal e a tese da culpa da pessoa 522
3.1. A concepção básica 522
3.2. As consequências 525

20.º CAPÍTULO

O TIPO DE CULPA DOLOSO

I. Culpa e tipo de culpa doloso 529
II. Dolo e falta de consciência do ilícito (erro sobre a ilicitude, art. 17.º) 531
1. Consideração preliminar 531
2. Evolução do tratamento legislativo e doutrinal 532
2.1. A tese da irrelevância para a culpa da falta de consciência do ilícito... 532
2.2. As teses da relevância para a culpa e para o dolo da falta de consciência do ilícito 535
2.2.1. Consciência do ilícito, culpa e dolo 535
2.2.2. A "teoria do dolo estrita" 536
2.2.3. A "teoria do dolo limitada" 537
2.3.4. A "teoria da culpa estrita" 539
2.2.5. A "teoria da culpa limitada" 541
2.3. Conclusão intermédia 542
3. O critério de autonomia da falta censurável de consciência do ilícito e a culpa dolosa 543
4. Delimitação da falta de consciência do ilícito e suas espécies 549
4.1. Consciência do ilícito e consciência da imoralidade da acção 550
4.2. Consciência do ilícito e consciência da punibilidade 550
4.3. Cindibilidade (tipicidade) da consciência do ilícito 552
4.4. Consciência do ilícito (concreto) e não da ilicitude (abstracta) 553
4.4.1. Desconhecimento da lei (da proibição) e consciência do ilícito... 553
4.4.2. Conhecimento da lei (da proibição legal) e falta de consciência do ilícito 554
4.5. A chamada "consciência condicionada (ou eventual) do ilícito"..... 556

III. Elementos especiais dos tipos de culpa dolosos 557

SECÇÃO II

A NEGAÇÃO DA CULPA

21.º CAPÍTULO

A INIMPUTABILIDADE

A. INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DE ANOMALIA PSÍQUICA 560

I. Fundamentos da sua natureza de obstáculo à determinação da culpa 560
1. O paradigma biopsicológico 561

Págs.

2. O paradigma normativo ... 564
3. O paradigma "compreensivo" ... 566
3.1. Um paradigma emergente sobre o Direito e o Homem ... 566
3.2. A inimputabilidade como obstáculo à comprovação da culpa ... 568
3.3. Consequências do ponto de vista expendido ... 572

II. Elementos ... 574
1. A conexão biopsicológica ... 574
1.1. As psicoses ... 575
1.2. A oligofrenia ... 576
1.3. As psicopatias, as neuroses e as anomalias sexuais ... 576
1.4. As perturbações profundas da consciência ... 577
2. A conexão normativo-compreensiva ... 579
3. A conexão fáctica (típica) ... 581

III. O problema dito da "imputabilidade diminuída" ... 583
IV. A "actio libera in causa" (a. l. i. c.) ... 588

B. INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DA IDADE ... 594

I. Fundamento ... 594
II. Regime ... 596

22.º CAPÍTULO

A INEXIGIBILIDADE

I. Fundamento e âmbito da exclusão da culpa ... 602
1. O sentido originário do problema e as suas consequências ... 602
2. Desenvolvimentos doutrinários posteriores ... 603
2.1. A inexigibilidade como causa de diminuição substancial da culpa e de renúncia da ordem jurídica à sua punição (causa de "desculpa") ... 603
2.2. A inexigibilidade como causa de exclusão da "responsabilização pelo facto" (*Tatverantwortung*, Maurach) ... 604
2.3. A inexigibilidade como causa de exclusão da ilicitude ... 605
2.4. A inexigibilidade como causa de exclusão da "responsabilidade" (*Verantwortlichkeit*, Roxin) ... 606
2.5. Consideração crítica ... 606
3. Inexigibilidade e exclusão da culpa ... 608

II. O estado de necessidade desculpante do art. 35.º ... 611
1. O perigo actual e não removível de outro modo ... 612
2. Os bens susceptíveis de serem lesados ... 613
3. A cláusula de inexigibilidade e o seu significado ... 615
4. O elemento subjectivo ... 618
5. A possibilidade de atenuação especial ou de dispensa de pena ... 618
6. A aceitação errónea de uma situação de estado de necessidade desculpante ... 619

III. O excesso de legítima defesa desculpante ... 622

23.º CAPÍTULO

A FALTA DE CONSCIÊNCIA DO ILÍCITO NÃO CENSURÁVEL

Págs.

I. A possibilidade de uma falta de consciência do ilícito como causa de exclusão da culpa 628
II. O critério da inevitabilidade ou invencibilidade do erro 630
III. A "rectitude" da consciência errónea como critério da não censurabilidade da falta de consciência do ilícito 635
1. Pensamento fundamental 635
2. Requisitos 637

IV. A questão da atenuação da culpa 641
1. A tese da atenuação especial obrigatória. Crítica 641
2. A tese da atenuação especial facultativa 642

24.º CAPÍTULO

A OBEDIÊNCIA INDEVIDA DESCULPANTE

I. O problema e a sua razão de ser 645
II. O regime legal 646

25.º CAPÍTULO

O FACTO DE CONSCIÊNCIA

I. Do "facto de convicção" ao "facto de consciência" 652
II. Decisão de consciência e liberdade de consciência 655
1. O facto por "decisão de consciência" 655
2. A liberdade de consciência (CRP, art. 41.º-1) 656
3. O conflito subsistente 658

III. O facto punível como limite imanente da liberdade de consciência 660
IV. O facto de consciência e a exclusão da culpa jurídico-penal 662
1. Facto de consciência, responsabilidade e culpa 662
2. O facto de consciência e as causas legais de exclusão da culpa 663
3. Recondução, por analogia, do facto de consciência ao regime da falta de consciência do ilícito não censurável 665

26.º CAPÍTULO

A PUNIBILIDADE

I. Evolução dogmática 668
II. Punibilidade e dignidade penal do facto 671
III. Punibilidade e carência de pena 678

SUBTÍTULO IV
A PREPARAÇÃO E A TENTATIVA

27.º CAPÍTULO
OS ESTÁDIOS DE REALIZAÇÃO DO CRIME (*ITER CRIMINIS*)

Págs.
I. A resolução criminosa ... 681
II. Os actos preparatórios ... 682
III. A tentativa ... 684
IV. A consumação e a terminação ... 686

28.º CAPÍTULO
A TENTATIVA

I. Fundamento da punibilidade da tentativa ... 688
1. As teorias objectivas ... 688
2. As teorias subjectivas ... 689
3. As teorias da "impressão" ... 690
II. Os elementos da tentativa ... 692
1. A decisão de cometer o facto ... 693
1.1. Caracterização geral ... 693
1.2. Tentativa negligente? ... 693
1.3. Tentativa e dolo eventual ... 694
2. Os actos de execução ... 695
2.1. As teorias formais objectivas ... 696
2.2. As teorias materiais objectivas ... 698
2.3. As teorias subbjectivas ... 700
2.4. Um ensaio de concretização jurídico-positiva ... 701
2.4.1. A al. *a)* do art. 22.º-2 ... 702
2.4.2. A al. *b)* do art. 22.º-2 ... 703
2.4.3. A al. *c)* do art. 22.º-2 ... 705
2.4.4. Critérios concretizadores ... 707
3. A não-consumação ... 709

III. Tentativa, tentativa acabada e frustração ... 710
IV. A delimitação da tentativa punível ... 711
1. Em função da pena aplicável ao crime consumado ... 711
2. A chamada "tentativa impossível" ou "inidónea" ... 713
2.1. A punibilidade da tentativa impossível e a questão geral do fundamento de punibilidade da tentativa como um todo ... 714
2.2. Consequências ... 716
2.2.1. A impunibilidade da tentativa dita irreal ou supersticiosa ... 716
2.2.2. A *manifesta* inaptidão do meio ou carência do objecto ... 717
3. Tentativa impossível e crime putativo ... 719
4. Um caso especial: a impossibilidade da tentativa em função do autor ... 722

V. A tentativa em hipóteses especiais ... 724

29.º CAPÍTULO

A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA TENTATIVA

Págs.

I. Fundamento jurídico da impunidade da desistência voluntária da tentativa 727
1. Doutrinas 727
2. Apreciação e conclusão 730

II. Relacionamento dos requisitos da desistência com o estádio alcançado pela tentativa 733
1. Tentativa inacabada e acabada 733
1.1. Termos de distinção 733
1.2. Casos duvidosos 735
2. A tentativa dita "fracassada" 737

III. A desistência da tentativa inacabada: o abandono da prossecução do crime ... 738
IV. A desistência da tentativa acabada: o impedimento da consumação 740
V. A "desistência" em caso de consumação 743
VI. A desistência em casos especiais 745
1. A desistência parcial 745
2. A desistência nos crimes agravados pelo resultado 746

VII. A voluntariedade da desistência 747
1. A teoria 747
2. O tratamento dos casos 751

VIII. Efeitos e localização sistemática 754

SUBTÍTULO V

A COMPARTICIPAÇÃO NOS CRIMES DOLOSOS DE ACÇÃO

30.º CAPÍTULO

A CONCEPÇÃO GERAL DA AUTORIA

I. A delimitação entre autoria e participação 757
II. Os modelos e as concepções básicas 759
1. A teoria formal-objectiva 759
2. A teoria material-objectiva assente na "causalidade" 760
3. As teorias subjectivas 764
4. A teoria do "domínio do facto" 765
5. Conclusões 768
6. Limites do critério do domínio do facto 770

III. O direito português vigente 773

31.º CAPÍTULO

AS CONCRETAS FORMAS DA AUTORIA

I. A autoria imediata 775

Págs.

II. A autoria mediata ... 775
1. O instrumento (homem-da-frente) actua atipicamente ... 777
1.1. Por não praticar uma acção ... 777
1.2. Por intervir quanto a ele uma causa de exclusão da tipicidade ... 778
1.3. Por ser a própria vítima ... 778
1.4. Por actuar sem dolo do tipo ... 779
2. O instrumento actua licitamente ... 781
3. O instrumento actua sem culpa ... 782
3.1. Por falta de imputabilidade ... 783
3.2. Por actuar sem consciência do ilícito ... 784
3.3. Por actuar em estado de necessidade desculpante ... 785
4. Ao instrumento falta a qualificação ou a intenção tipicamente requeridas ... 785
5. O "instrumento" actua de forma plenamente responsável (?) ... 786
5.1. Os casos ditos de erro sobre o "sentido concreto da acção" ... 787
5.2. Os "aparelhos organizados de poder" e o "domínio da organização" ... 788

III. A co-autoria ... 791
1. Conceito e âmbito da co-autoria ... 791
2. A decisão conjunta ... 791
3. A execução conjunta do facto ... 794
3.1. A participação directa na execução ... 794
3.2. Características da contribuição para o facto ... 795
4. A punição da co-autoria ... 797

IV. A instigação como autoria ... 797
1. A instigação entre a autoria e a participação ... 797
2. A "instigação" que é autoria e a "indução" que é cumplicidade ... 798
3. Críticas previsíveis e sua refutação ... 802
4. Casos de pretensa autoria mediata que são de instigação ... 804
4.1. Pequenas deficiências da autodeterminação do homem-da-frente ... 804
4.2. Erro sobre o sentido concreto da acção ... 805
4.3. Factos cometidos no quadro de um aparelho organizado de poder ... 805
4.4. O aliciamento ... 807
5. A exigência legal de execução ou começo de execução ... 808
6. O dolo na instigação ... 810
7. A "instigação em cadeia" ... 813
8. Instigação e domínio do facto. Conclusão ... 816

V. A "autoria paralela" ... 817
VI. O início da tentativa ... 818
1. Na autoria mediata ... 818
2. Na co-autoria ... 821
3. Na instigação ... 822

32.º CAPÍTULO

A CUMPLICIDADE

I. Cumplicidade e participação ... 824
II. Fundamento de punição da cumplicidade ... 825

Págs.

III. A acessoriedade da cumplicidade 828
1. A acessoriedade dita qualitativa ou interna 828
2. A acessoriedade dita quantitativa ou externa 831
3. O momento temporal da cumplicidade 832

IV. O dolo na cumplicidade 834
V. Espécies de cumplicidade 835
VI. A punição do cúmplice 838
VII. Cumplicidade e tentativa 839
1. Cumplicidade na tentativa 839
2. Tentativa de cumplicidade (cumplicidade "falhada" ou sem êxito) 839

33.º CAPÍTULO

QUESTÕES COMUNS À AUTORIA E À CUMPLICIDADE

I. A desistência da tentativa na comparticipação (art. 25.º) 842
1. O círculo das pessoas abrangidas pela norma 843
2. O estádio alcançado pelo facto 844
3. O modelo da desistência da tentativa na comparticipação 845

II. O problema chamado da "comunicabilidade e incomunicabilidade das circunstâncias" (arts. 28.º e 29.º) 848
III. A chamada "comparticipação necessária" 854

TÍTULO III

OS CRIMES NEGLIGENTES

34.º CAPÍTULO

FUNDAMENTOS GERAIS

I. Consideração dogmática e político-criminal 859
II. Relação entre negligência e dolo 860
III. Definição legal da negligência. Negligência consciente e inconsciente 861
IV. Estrutura dogmática do facto negligente 864
1. O tipo de ilícito 864
2. O tipo de culpa 864
3. A doutrina do "duplo escalão" 865

35.º CAPÍTULO

O TIPO DE ILÍCITO NEGLIGENTE

I. Consideração fundamental 866
II. O tipo de ilícito negligente como violação de um dever de cuidado 868
1. Violação do dever de cuidado e imputação objectiva. Crimes negligentes de resultado e de mera actividade 868
2. Critérios concretizadores do cuidado devido 871
2.1. Intervenção de critérios individualizadores do dever de cuidado 871

Págs.

2.2. Fontes concretizadoras do dever de cuidado, sua função e alcance... 875
2.2.1. As fontes normativas ... 875
2.2.2. A função indiciária ... 876
2.3. A chamada negligência na assunção ou aceitação ... 879
3. O princípio da confiança como princípio delimitador dos deveres de cuidado em caso de pluralidade de agentes ... 881
3.1. Consideração geral ... 881
3.2. Princípio da confiança e auto-responsabilidade de terceiro ... 882
3.3. Perante factos dolosos de terceiro ... 884
4. Tipo de ilícito subjectivo negligente? ... 886

III. Os tipos justificadores ... 888
1. Questões gerais ... 888
2. Os concretos tipos justificadores ... 890

IV. Autoria e cumplicidade no facto negligente ... 893

36.º CAPÍTULO

O TIPO DE CULPA NEGLIGENTE

I. Consideração geral ... 896
II. Capacidades pessoais ... 898
III. Exigibilidade ... 901
IV. O problema da "negligência grosseira" ... 902

TÍTULO IV

OS CRIMES DE OMISSÃO

37.º CAPÍTULO

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

I. A omissão como forma específica de realização típica ... 905
II. A distinção entre acção e omissão ... 908
III. A distinção entre crimes puros (ou próprios) e impuros (ou impróprios) de omissão ... 913
IV. A equiparação da omissão à acção nos crimes impróprios ou impuros de omissão ... 917
1. A questão do fundamento ... 917
2. A questão da constitucionalidade ... 923

V. A atenuação especial da pena nos crimes impróprios de omissão ... 925

38.º CAPÍTULO

O TIPO DE ILÍCITO DOS CRIMES DE OMISSÃO

A. O TIPO DE ILÍCITO DOLOSO ... 927

I. O tipo de ilícito objectivo ... 927
1. A "situação típica" e a ausência da acção esperada ... 927
2. A possibilidade fáctica de acção ... 928

Págs

3. O problema da imputação objectiva 929
4. A posição de garante 933

II. A posição de garante nos tipos de ilícito impróprios de omissão 933
1. A teoria formal do dever jurídico e das posições de garantia 934
2. A teoria das funções 936
3. Uma teoria "material-formal" 938
3.1. Deveres de protecção e assistência a um bem jurídico carecido de amparo 939
3.1.1. Relações de protecção familiar e análogas 939
3.1.2. Assunção de funções de guarda e assistência 941
3.1.3. Comunidade de vida e de perigos 943
3.2. Deveres de vigilância e segurança face a uma fonte de perigos 944
3.2.1. O dever de obstar à verificação do resultado por força de uma acção anterior perigosa ("ingerência") 945
3.2.2. O dever de fiscalização de fontes de perigo no âmbito de domínio próprio 946
3.2.3. O dever de garante face à actuação de terceiros 949
3.3. As ditas "posições de monopólio" 950
4. A verificação, no caso, de uma pluralidade de deveres de garante 953

III. "Posição" de garante e "dever" de garante 953
IV. O tipo de ilícito subjectivo 954
1. O dolo do tipo omissivo 954
1.1. O problema da "decisão" 955
1.2. O conhecimento ou representação da "posição de garante" 956
1.3. Outras questões 957
2. Elementos especiais do tipo subjectivo doloso 957

V. Os tipos justificadores 958

B. O TIPO DE ILÍCITO NEGLIGENTE 959

39.º CAPÍTULO

O TIPO DE CULPA DOS CRIMES DE OMISSÃO

I. O tipo de culpa doloso 961
1. A fundamentação da culpa 961
2. A exclusão da culpa 962

II. O tipo de culpa negligente 965

40.º CAPÍTULO

A TENTATIVA E A COMPARTICIPAÇÃO

I. Preparação e tentativa 966
1. Admissibilidade da tentativa 966
2. O início da tentativa 968
3. A desistência voluntária 969

Págs.

II. Autoria e cumplicidade nos crimes dolosos de omissão 970
1. Autoria imediata 970
2. Outras formas de autoria 972
3. Cumplicidade 974

TÍTULO V
O CONCURSO

41.º CAPÍTULO
UNIDADE E PLURALIDADE DE CRIMES

I. Introdução ao problema 977
II. Critérios distintivos da unidade e pluralidade de crimes 981
1. Consideração geral 981
2. O critério da unidade ou pluralidade de acções praticadas 982
2.1. Apreciação geral 982
2.2. A "unidade típica de acção" 983
2.3. A "unidade natural de acção" 984
2.4. A "unidade continuada de acção" 984
2.5. Valoração crítica 985
3. O critério da unidade ou pluralidade de tipos legais violados 985
4. Solução proposta: o critério da unidade ou pluralidade de sentidos sociais de ilicitude do comportamento global 988

42.º CAPÍTULO
UNIDADE DE NORMA OU DE LEI

I. Pensamento fundamental 992
II. As formas de unidade de norma ou de lei 993
1. Especialidade 994
2. Subsidiariedade 997
2.1. Subsidiariedade expressa 997
2.2. Subsidiariedade implícita 999
3. Consumpção? 1000

III. O regime jurídico da unidade de norma ou de lei 1002

43.º CAPÍTULO
CONCURSO DE CRIMES

I. O concurso de crimes efectivo, puro ou próprio 1006
II. O concurso de crimes aparente, impuro ou impróprio 1011
1. Consideração básica 1011
2. Explanação doutrinal 1012
2.1. Antecedentes 1012
2.2. Critérios de determinação 1015
2.2.1. O critério da unidade de sentido do acontecimento ilícito global-final 1016

Págs.

2.2.2. O critério do crime instrumental ou crime-meio 1018
2.2.3. A unidade de desígnio criminoso 1020
2.2.4. A conexão espácio-temporal das realizações típicas 1020
2.2.5. Os diferentes estádios de evolução ou de intensidade da realização global 1021
2.3. Distonia das molduras penais aplicáveis ao ilícito dominado 1023

III. O crime continuado 1027
1. Consideração geral 1027
2. Requisitos 1028
2.1. A conexão objectiva 1029
2.2. A conexão subjectiva 1030
3. Consideração conclusiva 1032

IV. O exercício habitual ou profissional do facto 1033
V. O regime jurídico da punição do concurso de crimes 1034
1. Do concurso de crimes efectivo, puro ou próprio 1034
2. Do concurso de crimes aparente, impuro ou impróprio 1035
3. Do crime continuado 1038

ÍNDICE DE MATÉRIAS 1043

ÍNDICE DE ABREVIATURAS (*)

A., AA.	Autor, Autores
a. l. i. c.	actio libera in causa
AA.VV.	Autores vários
Ab Uno ad Omnes	Ab Vno ad Omnes — 75 Anos da Coimbra Editora. Orgs.: Antunes Varela, Diogo Freitas do Amaral, Jorge Miranda e J. J. Gomes Canotilho. 1998
Ac.	Acórdão
Actas I, II	Actas das Sessões da Comissão Revisora do Código Penal. Parte Geral. I, 1965. II, 1966
Actas 1979	Actas das Sessões da Comissão Revisora do Código Penal. Parte Especial. 1979
Actas 1993	Código Penal. Actas e Projecto da Comissão Revisora. 1993
AcTC	Acórdãos do Tribunal Constitucional
ADPCP	Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales
AE	Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches, Allgemeiner Teil. 1966
AE BT (Sexualdelikte)	Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches, Besonderer Teil. Sexualdelikten — Straftaten gegen Ehe, Familie und Personenstand — Straftaten gegen den religiösen Frieden und die Totenruhe. 1968
AIDP	Association Internationale de Droit Pénal
AK	Kommentar zum Strafgesetzbuch (Reihe Alternativkommentare). Bd. 1, 1990; Bd. 3, 1986
Anteprojecto 2007	Projecto de Proposta de Lei n.º 98/X de alteração ao Código Penal

(*) Artigos de lei sem indicação do diploma em que se contêm devem entender-se referidos ao Código Penal vigente em Junho de 2007.

anot.	anotação
AöR	Archiv des öffentlichen Rechts
AR	Assembleia da República
ArchPC	Archives de Politique Criminelle
Ass.	Assento do Supremo Tribunal de Justiça
AT	Allgemeiner Teil
BELEZA, Teresa, I, II	Teresa Beleza, Direito Penal. I, 2.ª ed. revista e actualizada, 1985. II, 1980 (copiografado)
BELING	Ernst Beling, Grundzüge des Strafrechts, 11.ª ed. 1930
BETTIOL	Giuseppe Bettiol, Diritto Penale: Parte Generale, 11.ª ed. 1982
BETTIOL / MANTOVANI	Giuseppe Bettiol / Luciano Pettoello Mantovani, Diritto Penale: Parte Generale, Padova: Cedam, 12.ª ed. 1986
BFD	Boletim da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra
BGH	Bundesgerichtshof [Tribunal Federal alemão]
BINDING, Handbuch	Karl Binding, Handbuch des Strafrechts, I, 1885
BINDING, Normen	Karl Binding, Die Normen und ihre Übertretung. Eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts, 4 vols, 1919-1922
BITENCOURT, Cezar	Cesar Roberto Bitencourt, Manual de Direito Penal, Parte Geral, 4.ª ed. 1997
BMJ	Boletim do Ministério da Justiça
BT	Besonderer Teil
CAETANO, Marcello	Marcello Caetano, Lições de Direito Penal, Lisboa, 1939
CANOTILHO / MOREIRA	J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.ª ed. 1993, 4.ª ed. 2007, Artigos 1º a 107º
CARVALHO, Taipa de, I	Américo Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, Volume I Questões Fundamentais, 2003
CARVALHO, Taipa de, II	Américo Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, Volume II, Teoria Geral do Crime, 2004
CC	Código Civil
CE	Código da Estrada
cit.	citado
CJ	Colectânea de Jurisprudência

CJ STJ	Colectânea de Jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça
Coimbra-Symposium Roxin	Bausteine des europäischen Strafrechts: Coimbra-Symposium für Claus Roxin. Orgs.: Bernd Schünemann e Jorge de Figueiredo Dias. 1995. (Há tradução espanhola sob o título Fundamentos de un Sistema Europeo del Derecho Penal, ed. de Silva Sánchez, 1995)
Comentário Conimbricense, I, II, III	Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial. Dirigido por Jorge de Figueiredo Dias. Tomo I, 1999. Tomo II, 1999. Tomo III, 2001
CORREIA, Eduardo, I, II	Eduardo Correia, Direito Criminal. Com a colaboração de Figueiredo Dias. I, 1963. II, 1965
CORREIA, Eduardo, Lições 1949	Eduardo Correia, Direito Criminal. Lições ao Curso do V Ano Jurídico, coligidas por Pereira Coelho e Rosado Coutinho, 1949
CORREIA, Eduardo, ProjPG	Eduardo Correia, Código Penal. Projecto da Parte Geral. Separata do Boletim do Ministério da Justiça n.º 127. Lisboa: Ministério da Justiça. 1963
CORREIA, Eduardo, Studium	Eduardo Correia, Direito Criminal. I. Tentativa e Frustração. II. Comparticipação Criminosa. III. Pena conjunta e pena unitária. Colecção Studium. 1953
CORREIA, Eduardo, Unidade	Eduardo Correia, Unidade e Pluralidade de Infracções. 1945
CP	Código Penal
CPA	Código do Procedimento Administrativo
CPP	Código de Processo Penal
CRP	Constituição da República Portuguesa
CRSEPM	Comissão para a Reforma do Sistema de Execução de Penas e Medidas
CT	Código do Trabalho
CTF	Ciência e Técnica Fiscal
DIAS / ANDRADE	Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade, Criminologia. O Homem Delinquente e a Sociedade Criminógena. 1984
DIAS, Figueiredo, DP II	Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português. Parte Geral. II. As Consequências Jurídicas do Crime. 1993
DIAS, Figueiredo, DPP	Jorge de Figueiredo Dias, Direito Processual Penal. I Vol. 1974 (ed. fac-similada de 2004)

DIAS, Figueiredo, Liberdade	Jorge de Figueiredo Dias, Liberdade — Culpa — Direito Penal. 1.ª ed. 1978 (para a qual reenviam as citações). 3.ª ed. 1995
DIAS, Figueiredo, O Problema	Jorge de Figueiredo Dias, O Problema da Consciência da Ilicitude em Direito Penal. 1.ª ed. 1969 (para a qual reenviam as citações)
DJ	Direito e Justiça. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa
DJT	Deutsche Juristentag
DL	Decreto-Lei
DR	Diário da República. I Série (salva indicação diferente)
E 1962	Entwurf eines Strafgesetzbuches mit Begründung. Bundesratsvorlage. 1962
e. g.	exempli gratia
ed.	edição
EdD	Enciclopedia del Diritto
Escritos Silva Franco	Escritos em Homenagem a Alberto Silva Franco. 2003
Estudos Almeida Costa	Estudos Dedicados ao Prof. Doutor Mário Júlio de Almeida Costa. Coordenação de Júlio Gomes. 2002
Estudos Beleza dos Santos	Estudos "in memoriam" do Prof. Doutor José Beleza os Santos. Suplemento XVI do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra. 1966
Estudos Cunha Rodrigues	Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues. Orgs.: Jorge de Figueiredo Dias et alii.
Estudos Eduardo Correia	Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correia. Números Especiais do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra. 1989 e ss.
Estudos Ferrer Correia	Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor A. Ferrer Correia. Números Especiais do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra. I, 1986. II, 1989. III, 1991
Estudos Paulo Merêa e Braga da Cruz	Estudos em Homenagem aos Profs. Doutores M. Paulo Merêa e G. Braga da Cruz. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra n.º 58. 2 vols. 1982
Estudos Rogério Soares	Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares. Orgs.: Aníbal de Almeida et alii. 2001
Estudos Teixeira Ribeiro	Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Teixeira Ribeiro. Números Especiais do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra. 1978

EuropJCL&Crim	European Journal of Criminal Law & Criminology
FDUC	Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
FDUL	Faculdade de Direito da Universidadde de Lisboa
FERRÃO	F. da Silva Ferrão, Theoria do Direito Penal aplicada ao Código Penal Portuguez. 1856-7
FERREIRA, Cavaleiro de, 1940	Manuel Cavaleiro de Ferreira, Lições de Direito Penal ao Curso do IV Ano Jurídico. Publicadas por Carmindo Rodrigues Ferreira e Henrique Vaz Lacerda. 1940/1
FERREIRA, Cavaleiro de, 1981	Manuel Cavaleiro de Ferreira, Direito Penal Português. Parte Geral. 2 vols. 1981
FERREIRA, Cavaleiro de, 1992	Manuel Cavaleiro de Ferreira, Lições de Direito Penal. Parte Geral. I. A Lei Penal e a Teoria do Crime no Código Penal de 1982. 4.ª ed. 1992
FEUERBACH	Ludwig von Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts. 9.ª ed. 1826
FIANDACA / MUSCO	Giovanni Fiandaca e Enzo Musco, Diritto Penale. Parte generale. 3.ª ed. 1995
FIPP	Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire
Fisco	Fisco. Doutrina. Jurisprudência. Legislação
FRANCO / STOCO (orgs.)	Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial. Coordenação de Alberto Silva Franco e Rui Stoco. Vol. I. Tomo I. Parte Geral. 6.ª ed. 1997
FRANK	Reinhard Frank, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 18.ª ed. 1931/36
FS, FG	Festschrift, Festgabe
GA	Goltdammers Archiv für Strafrecht
GS	Gedächtnisschrift
Id., ibid.	Idem, ibidem
IDPEE	Instituto de Direito Penal Económico e Europeu
JA	Juristische Arbeitsblätter
JAKOBS	Günther Jakobs, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre. 2.ª ed. 1991
JDC 1983	O Novo Código Penal Português e Legislação Complementar: Jornadas de Direito Criminal, I fase. Centro de Estudos Judiciários. 1983
JESCHECK	Hans-Heinrich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 4.ª ed. 1988

JDC 1996	Jornadas de Direito Criminal. Revisão do Código Penal. Centro de Estudos Judiciários. Vol. I. 1996
JESCHECK / WEIGEND	Hans-Heinrich Jescheck / Thomas Weigend, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5.ª ed. 1996
JOCE	Jornal Oficial das Comunidades Europeias
JORDÃO	Levy Maria Jordão, Comentário ao Código Penal Portuguez. 1853-4
Jornadas FDUL	Jornadas sobre a Revisão do Código Penal. Orgs.: Maria Fernanda Palma, Teresa Pizarro Beleza et alii. 1998
JR	Juristische Rundschau
Juris et de jure	Juris et de jure. Nos Vinte Anos da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa — Porto. 1998
JurS	Juristische Schulung
Jus	Jus, Rivista di scienze giuridici
JZ	Juristenzeitung
KÖHLER	Michael Köhler, Strafrecht, Allgemeiner Teil. 1997
KÜHL	Kristian Kühl, Strafrecht. Allgemeiner Teil. 3.ª ed. 2000
L	Lei
Liber Discipulorum Figueiredo Dias	Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias. Orgs.: Manuel da Costa Andrade, José de Faria Costa, Anabela Miranda Rodrigues e Maria João Antunes. 2003
LISZT / SCHMIDT	Franz von Liszt / Eberhard Schmidt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 25.ª ed. 1927
LK	Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. 11.ª ed. a partir de 1992
loc. cit.	local (locução) citado(a)
LTE	Lei Tutelar Educativa, aprovada pela Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro
M / GÖSSEL	Reinhart Maurach / Karl Heinz Gössel / Heinz Zipf, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Teilband 2. 7.ª ed. 1989
M / ZIPF	Reinhart Maurach / Heinz Zipf, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Teilband 1. 7.ª ed. 1987
Madrid-Symposium Tiedemann	Bausteine des europaeischen Wirtschaftsstrafrechts: Madrid-Symposium für Klaus Tiedemann. Orgs.: Bernd Schünemann e Carlos Suárez González. 1994
MANTOVANI	Ferrando Mantovani, Diritto Penale. Parte Generale. 4.ª ed. 2001

MARINUCCI / DOLCINI, Corso	Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini, Corso di Diritto Penale. 3.ª ed. 1. 2001
MARINUCCI / DOLCINI, Manuale	Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale. 2004
MATTA, Caeiro da, I, II	José Caeiro da Matta, Direito Criminal Português. 2 vols. 1911
MAURACH	Reinhart Maurach, Deutsches Strafrecht. Allgemeiner Teil. 4.ª ed. 1971 (Há tradução espanhola da 1.ª ed. 1962)
MAYER, H.	Hellmuth Mayer, Strafrecht. Allgemeiner Teil. 1967
MAYER, M. E.	Max Ernst Mayer, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts. 1915
MDR	Monatschrift für deutsches Recht
MEZGER	Edmund Mezger, Strafrecht. 3.ª ed. 1949
MEZGER / BLEI	Edmund Mezger / Hermann Blei, Strafrecht. I-Allgemeiner Teil. Ein Studienbuch. 10.ª ed. 1963
MEZGER, *Stb*	Edmund Mezger / Hermann Blei, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Ein Studienbuch. 4.ª ed. 1955
MUÑOZ CONDE / GARCÍA ARAN	Francisco Muñoz Conde / Mercedes García Aran, Derecho Penal: Parte General. 3.ª ed. 1998
NStZ	Neue Zeitschrift für Strafrecht
Niederschriften	Niederschriften über die Sitzungen der grosse Strafrechtskomission. 13 tomos. 1958-60
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NK	Nomos Kommentar zum Strafgezetzbuch, a partir de 1995
Nov. Dig. it.	Novissimo Digesto italiano
org(s).	organizador(es), compilador(es)
p. ex.	por exemplo
PE	Parte Especial
PG	Parte Geral
PINTO, Sousa	Lições de Direito Criminal Portuguez. Coimbra. 1861
PRADEL	Jean Pradel. Droit pénal général. 15.ª ed. 2004
ProjPG	Código Penal, Projecto da Parte Geral. 1963
RBCC	Revista Brasileira de Ciências Criminais
RC	Tribunal da Relação de Coimbra

RDE	Revista de Direito e Economia
RDES	Revista de Direito e de Estudos Sociais
RDP	Revista de Direito Penal (Brasil)
RDPC	Revista de Direito Penal e Criminologia
RDPCrim	Revue de Droit Pénal et de Criminologie
RE	Tribunal da Relação de Évora
Revista Penal	Revista Penal, Publicación semestral de LA LEY
RG	Reichsgericht [Tribunal do Império alemão]
RGIT	Regime Geral das Infracções Tributárias (Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho)
RIntDP	Revue Internationale de Droit Pénal
RItalDPP	Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale
RJ	Revista Jurídica
RL	Tribunal da Relação de Lisboa
RLJ	Revista de Legislação e de Jurisprudência
RMP	Revista do Ministério Público
ROA	Revista da Ordem dos Advogados
Rodríguez Devesa / Serrano Gómez	J. M. Rodriguez Devesa / A. Serrano Gomez, Derecho Penal Español. Parte General. 15.ª ed. 1992
Romano	Mario Romano, Commentario Sistematico del Codice Penale. 2.ª ed. 2 vols. 1987
Roxin I	Claus Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen. Aufbau der Verbrechenslehre. 4.ª ed. 2006
Roxin II	Claus Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band II. Besondere Erscheinungsformen der Straftat. 2003
Roxin, Täterschaft	Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft. 1.ª ed. 1963 (7.ª ed. 2000)
Roxin, Kriminalpolitik	Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. 2.ª ed. 1973. (Há tradução espanhola da 1.ª ed.)
RP	Tribunal da Relação do Porto
RPCC	Revista Portuguesa de Ciência Criminal
RScCrim	Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé
S / S / [nome do(s) comentador(es)]	Schönke / Schröder, Strafgesetzbuch Kommentar. 26.ª ed. 2001
s(s).	seguinte(s)

SANTOS, Beleza dos, Direito Criminal	José Beleza dos Santos, Direito Criminal. Lições coligidas por Hernâni Marques. Coimbra. 1936
SANTOS, Beleza dos, Introdução	José Beleza dos Santos, Ensaio sobre a Introdução ao Direito Criminal. 1968
SANTOS, Beleza dos, Lições	José Beleza dos Santos, Lições de Direito Penal, coligidas por Belmiro Pereira. Coimbra. 1930
SANTOS, Beleza dos, Obstáculos	Lições de Direito Penal. Obstáculos à Ilicitude e à Culpabilidade. Lições preleccionadas e revistas pelo Ex.mo Prof. Dr. Beleza dos Santos e coligidas por Fausto Gaito. 1949
sc.	quer dizer, isto é
SCHMIDHÄUSER	Eberhard Schmidhäuser, Allgemeiner Teil. Lehrbuch. 1970
ScIvr	Scientia Ivridica
ScPos	La Scuola Positiva
SILVA, Henriques da	António Henriques da Silva, Lições de Direito Penal coligidas por João Ferreira Gomes, Heitor da Cunha Oliveira Martins e Luís Teixeira de Macedo e Castro. 1898-1899
SILVA, Marques da, I, II, III	Direito Penal Português, Parte Geral. I. 2.ª ed. revista, 2001. II, 1998. III — Teoria das Penas e das Medidas de Segurança, 1999
s. n.	sublinhado nosso
s. n. o.	sublinhado no original
SK	Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch. Bd. 1. Allgemeiner Teil. 5.ª ed. a partir de 1993
StGB	Strafgesetzbuch
STJ	Supremo Tribunal de Justiça
STRATENWERTH	Günter Stratenwerth, Strafrecht. Allgemeiner Teil I. Die Straftat. 4.ª ed. 2000
STRATENWERTH / KUHLEN	Günter Stratenwerth e Lothar Kuhlen, Strafrecht. Allgemeiner Teil I. Die Straftat. 5.ª ed. 2005
Sub Judice	Sub Judice. Justiça e Sociedade
TC	Tribunal Constitucional
TJ	Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (Luxemburgo)
TPI	Tribunal Penal Internacional (Permanente)
VDAT	Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts. Allgemeiner Teil. 1905

VDBT	Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts. Besonderer Teil. 1908
v. g.	verbi gratia
WK	Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch. Orgs.: Foregger e Nowakowski. A partir de 1977
ZStR	Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Revue Pénale Suisse
ZStW	Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

PARTE I

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

TÍTULO I

O DIREITO PENAL E A SUA CIÊNCIA NO SISTEMA JURÍDICO ESTADUAL

1.º CAPÍTULO

O DIREITO PENAL EM SENTIDO FORMAL

I. O conceito de direito penal

1. Definição e designação

§ 1 Chama-se **direito penal** ao conjunto das normas jurídicas que ligam a certos comportamentos humanos, os **crimes**, determinadas consequências jurídicas privativas deste ramo de direito. A mais importante destas consequências — tanto do ponto de vista quantitativo, como qualitativo (social) — é a **pena**, a qual só pode ser aplicada ao agente do crime que tenha actuado com *culpa*. Ao lado da pena prevê porém o direito penal consequências jurídicas de outro tipo: são as **medidas de segurança**, as quais não supõem a culpa do agente, mas a sua *perigosidade*.

§ 2 Considerando a dupla categoria de efeitos jurídicos previstos por este ramo de direito, o designativo direito **penal** surge como demasiado estreito. Para efeito de designação melhor pareceria dar relevo, antes que a uma só das espécies de consequências jurídicas — a pena —, ao conjunto dos pressupostos de que aquela consequência depende — o crime —, chamando a esta disciplina direito **criminal** (1). Como dissemos porém as medidas de segurança ligam-se a comportamentos levados a cabo sem culpa, ou em todo o caso independentemente da consideração dela; e sendo

---

(1) Assim, SANTOS, Beleza dos, *Introdução*, p. 26[1], e CORREIA, Eduardo, I, n.º 1.

a culpa elemento essencial do conceito de crime, não pode também em rigor considerar-se "criminal" o direito das medidas de segurança. Desde que se não perca esta dupla consciência podem reputar-se *equivalentes*, na sua exactidão (em todo o caso só) aproximada, os designativos "direito penal" e "direito criminal". De um ponto de vista formal é todavia de **preferir o primeiro designativo** ao segundo: quer porque se chama Código Penal o diploma legislativo em que o respectivo direito se contém, quer porque "Direito Penal" é o nome escolar oficial da nossa disciplina.

§ 3 O designativo "direito penal" só ganhou preponderância entre nós — bem como de resto noutros países, *v. g.*, em França e na Alemanha, onde é preferentemente usado — durante o séc. **XIX**, e sobretudo a partir do movimento da **codificação**. Anteriormente, se bem que as designações "pena" e "penal" (derivadas das expressões latina *pœna* e grega *poine*) não fossem raras, a preferência era concedida ao designativo "criminal". O que foi depois reforçado com a introdução no sistema português, pela Reforma Prisional (DL 26 643, de 28-5-1936), de medidas de segurança (aliás já substancialmente existentes entre nós, embora sem a designação correspondente, desde 1892 e 1896: deportação de delinquentes de difícil ou tardia corrigibilidade e de vadios, mendigos e equiparados). Talvez por essa razão, a reforma das Faculdades de Direito de 1945 (DL 38 450, art. 3.º) alterou para *Direito Criminal* a nomenclatura da disciplina respectiva. Mas o nome *Direito Penal* foi reposto pela reforma das Faculdades de Direito de 1972 (DL 364/72, de 28-9) e mantém-se desde então.

§ 4 Já se defendeu que a designação "direito penal" teria, perante a de "direito criminal", um **valor simbólico e programático** que conduziria a conferir-lhe preferência: o de dar a entender que o sistema legal português seguiria, em matéria de sanções criminais, uma via declaradamente *monista*, uma *via única*, em que verdadeiras medidas de segurança só seriam aplicáveis a agentes incapazes de culpa ou inimputáveis. Mas, para além das dúvidas fundadas que podem suscitar-se ao carácter monista (pelo menos na acepção acima indicada) do sistema vigente entre nós (infra, 5.º Cap., § 26 e ss.), o argumento conduziria, quando pensado até ao fim, a eliminar o direito das medidas de segurança do âmbito da nossa disciplina, o que — se bem que não tenha deixado de ser advogado e continue ainda a ser sugerido (2) — nos não parece em definitivo adequado à evolução da história das ideias no seio daquela e à sua actual compreensão.

§ 5 Segundo uma certa doutrina alemã, por outra parte, a expressão "direito criminal" apontaria para uma **pré-determinação extralegal** das valorações da ilicitude e da culpa do facto criminoso, enquanto a expressão "direito penal" daria prevalência

(2) Nesta direcção, por último, ANTUNES, Maria João, *Medida de Segurança de Internamento e Facto de Inimputável em Razão de Anomalia Psíquica*, 2003, *passim*.

ao *princípio da legalidade* (infra, 8.º Cap.), próprio do Estado de Direito, no processo de criminalização. Mas esta asserção não parece suficientemente fundada. É certo que crimes há cuja valoração da ilicitude e da culpa pode ser reconduzida a uma mais ampla — e, em certo sentido, "prévia" — valoração moral, social e/ou cultural (*delicta in se, delicta naturaliter proba*); enquanto noutros aquela valoração surge como consequência da proibição legal (*delicta mere prohibita*) (3). Nuns e noutros, porém, o princípio da reserva de lei formal cumpre uma função garantística verdadeiramente essencial à ideia do Estado de Direito, de tal modo que antes da intervenção legislativa não existe legitimidade para se falar nem de "pena", nem de "crime".

§ 6 Em última análise, não só de uma perspectiva formal, mas também *de um ponto de vista teleológico e funcional* o designativo "direito penal" merece preferência (embora deva reconhecer-se, depois de quanto ficou dito, que completamente exacto seria só o designativo "**direito das penas e medidas de segurança criminais**"). Assim se dá a entender que neste ramo do direito tudo haverá de ser função da especificidade da *consequência jurídica* — da pena ou da medida de segurança criminais — que nele tem lugar. Mesmo que devam fazer-se os maiores esforços (e eles serão feitos: infra, 6.º Cap.) para definir materialmente o *crime*, a verdade é que um preceito legal pertencerá apenas ao nosso ramo do direito se e quando, para sancionamento de um certo comportamento ilícito ou antijurídico que prevê, for prescrita uma *pena* ou uma *medida de segurança criminais*: são estes instrumentos sancionatórios que, em definitivo, determinam a pertinência da matéria ao ramo do direito aqui em estudo. Este modo de consideração virá, de resto, a revelar-se essencial em todo o tratamento dogmático. Todo o direito penal e a sua ciência devem ser perspectivados a partir das *valorações político-criminais* imanentes ao sistema; as quais, por seu turno, se exprimem por excelência nas **consequências jurídicas** próprias deste ramo de direito. Deve, nesta acepção, afirmar-se que o direito penal e a sua ciência se orientam "para o resultado" (*sc.*, para a consequência jurídica) e devem, a partir dele, ser definitivamente adquiridos e fixados (4).

---

(3) Cf. infra, 6.º Cap., §§ 7 e 22; e, agora, DIAS, Silva, *"Delicta in se" e "Delicta mere prohibita": uma Análise das Descontinuidades do Ilícito Penal Moderno à Luz da Reconstrução de uma Distinção Clássica*, 2003.

(4) Pensamento metódico este vivamente preconizado por LUHMANN, *Rechtssystem u. Rechtsdogmatik*, 1974, pp. 14 e 31 e ss., e feito frutificar para o direito penal especialmente por ROXIN I e II e *Kriminalpolitik, passim*. Pioneiro neste reconhecimento revelou-se SCHMIDHÄUSER, Zur Systematik der Verbrechenslehre, *Radbruch-GS*, 1968, p. 276 (contra ele, todavia, ANDRADE, Costa, *Consentimento e Acordo em Direito Penal*, 1990, pp. 21 e 221). Cf., depois,

2. Direito penal e *ius puniendi*

§ 7 O que deixámos formalmente definido constitui o direito penal *em sentido objectivo* (**ius pœnale**). Deste costuma distinguir-se (5) o direito penal *em sentido subjectivo* (**ius puniendi**), como poder punitivo do Estado resultante da sua soberana competência para considerar como crimes certos comportamentos humanos e ligar-lhes sanções específicas. Deste ponto de vista pode afirmar-se que o direito penal objectivo é expressão ou emanação do poder punitivo do Estado.

§ 8 O valor heurístico do conceito de direito penal subjectivo é diminuto e, nomeadamente por força do apelo ao poder "soberano" do Estado, pode tornar-se equívoco, ao apontar para uma competência irrestrita do legislador, típica do ideário positivista e do Estado de Direito liberal. Reconhece-se hoje, na verdade, haver **limites** materialmente impostos e juridicamente consagrados ao poder de criminalização do legislador, ainda que formalmente legitimado; enquanto, de outra parte, não devem em princípio ser reconhecidas *obrigações* ou *imposições implícitas de criminalização*, derivadas de forma imediata de valorações jurídico-constitucionais ou mesmo extra-jurídicas e, assim, transcendentes relativamente à política criminal (infra, 6.º Cap., §§ 21 e ss., 39 e s.).

II. O âmbito do direito penal

1. Direito penal substantivo, direito penal executivo e direito processual penal

§ 9 Quando, na linguagem jurídica actual, se fala em "direito penal" é, em regra, tão-só o *direito penal substantivo* (ou, nesta acepção, direito penal *material*) que se quer abranger. Refere-se contudo também, por vezes, a existência de um direito penal **em sentido amplo** ou de um **ordenamento jurídico-penal** que abrange, para além do direito penal substantivo, o *direito processual penal, adjectivo ou formal*, e o *direito de execução das penas e medidas de segurança* ou *direito penal executivo* (6).

DIAS, Figueiredo, Sobre o estado actual da doutrina do crime, *RPCC 1*, 1991, p. 23, e *DP II*, § 3; e, agora, LAMPE, Zur funktionalen Begründung des Verbrechenssystems, *Roxin-FS*, 2001, pp. 45, 67, e MUÑOZ CONDE, Dogmática penal afortunada y sin consecuencias, Comentario, *in*: Eser / Hassemer / Burkhard, *La Ciencia del Derecho penal ante el nuevo milenio*, 2004, p. 233 e ss.

(5) Cf., por último, SILVA, Marques da, I, p. 19 e ss.

(6) Sendo, relativamente a este último, ainda hoje corrente (embora inexacto) o designativo "*direito penitenciário*".

§ 10 A *distinção de princípio* entre estes três "sectores de um idêntico ordenamento jurídico" (7) não oferece, de **um ponto de vista teorético**, dificuldades de maior. O *direito penal substantivo* visa, como vimos, a definição dos pressupostos do crime e das suas concretas formas de aparecimento; e a determinação tanto em geral, como em espécie das consequências ou efeitos que à verificação de tais pressupostos se ligam (penas e medidas de segurança), bem como das formas de conexão entre aqueles pressupostos e estas consequências. Renunciando à determinação das formas de realização concreta do dever-ser que comina, o direito penal substantivo distingue-se claramente do *direito processual penal*, ao qual cabe a regulamentação jurídica dos modos de realização prática do poder punitivo estadual, nomeadamente através da investigação e da valoração judicial do crime indiciado ou acusado. Como claramente se distingue do *direito penal executivo*, ao qual pertence a regulamentação jurídica da efectiva execução da pena e/ou da medida de segurança decretadas na condenação proferida no processo penal.

§ 11 Se a distinção teorética entre estes ramos do ordenamento jurídico-penal total é relativamente fácil e concludente, já no entanto se suscitam, **de um ponto de vista prático-jurídico**, as mais sensíveis dificuldades quanto à "pertinência" de concretas normas ou institutos jurídicos a cada um dos ramos. Isto tem a ver, antes de tudo (8), com a circunstância de muitas destas normas e institutos — *v. g.*, a queixa e a acusação particular: arts. 111.º a 116.º; a prescrição do procedimento e da pena: arts. 117.º a 124.º; a amnistia e o indulto: arts. 126.º e 127.º — possuírem uma *dupla natureza*, em parte substantiva, em parte processual. Como tem a ver, por outro lado, com a dupla natureza própria do direito penal executivo e da circunstância de a sua regulamentação se encontrar repartida por uma lei especial (DL 265/79, de 1-8) e fragmentariamente pelo CPP (art. 467.º e ss.) e pelo próprio CP (arts. 44.º-2, 45.º e s., 49.º, 55.º e s., 60.º, 90.º, 99.º, etc.).

§ 12 Sejam porém quais forem as dificuldades de determinação do carácter substantivo, processual ou executivo de certas normas jurídico-penais, uma tal determinação é **relevante para muitos efeitos** e não deve ser escamoteada. Assim, p. ex., para efeito de proibição de retroactividade da lei (comparem-se os arts. 1.º-1 e 2.º-1 com o art. 5.º do CPP), de proibição de aplicação da norma por analogia (compare-se o art. 1.º-3 com o art. 4.º do CPP), de aplicação da lei no espaço (comparem-se os arts. 4.º a 7.º com o art. 6.º do CPP). Ponto é que a atribuição da norma ou instituto

(7) BELING, *Derecho procesal penal* (trad. espanhola do original alemão, 1943), § 2, I. Cf., sobre o que se segue, mais pormenorizadamente, DIAS, Figueiredo, *DPP*, p. 27 e ss.

(8) Em pormenor, DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 1056 e ss.

ao direito penal, ao direito processual penal ou ao direito penal executivo não seja levada a cabo numa base puramente lógico-formal e conceitualista, mas por apelo a considerações teleológicas, axiológico-normativas e político-criminais decisivas no contexto de um sistema funcional e racional.

2. A parte geral do direito penal e as suas componentes

§ 13 O direito penal em sentido estrito — e, assim também, o próprio CP — compõe-se de uma **parte geral**, na qual se definem os pressupostos de aplicação da lei penal, os elementos constitutivos do conceito de crime e as consequências gerais que da realização de um crime, total ou parcial, derivam: as penas e as medidas de segurança; e de uma **parte especial**, na qual se estabelecem os crimes singulares (homicídio, violação sexual, furto, abuso de confiança, genocídio, falsificação de documento, incêndios e explosões, sabotagem, corrupção, etc.) e as consequências jurídicas que à prática de cada um deles concretamente se ligam.

§ 14 De um ponto de vista teorético e dogmático torna-se complexíssimo estabelecer a espécie e a natureza concretas das relações que, aos mais diversos propósitos, intercedem entre a PG e a PE do direito (e do próprio Código) penal (9). Seria demasiado simplista reconduzi-lo simplesmente a uma qualquer distinção ideal entre o abstracto e o concreto, entre o comum e o particular ou mesmo entre a principiologia e a concretização. Importante neste enquadramento é acentuar que, de um ponto de vista funcional e racional, a autonomização de uma PG do direito penal (10) serve o controlo racional da aplicação jurídico-penal, através do esclarecimento fundamental da *matéria* da regulamentação jurídica e do domínio dos *critérios da valoração*. De modo a evitar, até onde é possível, tanto as *contradições normativas*, como uma *jurisprudência sentimental* e, deste modo, a propiciar a "descoberta" da **justiça do caso** (infra, 3.º Cap., § 23 e s.).

§ 15 A doutrina da parte geral do direito penal — produto, como se referiu, de uma abstracção das concretas espécies de crime em ordem à eleição dos seus pressupostos e das suas consequências gerais — divide-se, por sua vez, em dois tratamentos fundamentais. O primeiro começa por abar-

---

(9) Sobre o ponto, entre nós, COSTA, Faria, Relações entre a *Parte Geral* e a *Parte Especial* do Código Penal, *BFD LXXI*, 1995, p. 117, e *Direito Penal Especial. Contributo a uma Sistematização dos Problemas "Especiais" da Parte Especial*, 2004, p. 13 e ss.; SCHROEDER, F.-C., Die Anziehungskraft vorgelagerter Gliederungselemente, *Roxin-FS*, 2001, p. 33.

(10) Que remonta, segundo SCHMIDT, Eb., *Einführung in die Geschichte der Strafrechtspflege*, 1965, p. 150, à doutrina penal do séc. XVI.

car os **fundamentos gerais** de todo o direito penal, considerando sucessivamente a determinação do lugar do direito penal no sistema jurídico, a função do direito penal no sistema social e os seus limites, as fontes e o âmbito de vigência, temporal e espacial, da lei penal. E estuda em seguida a construção dogmática do **conceito do facto (punível)**, ou **doutrina geral do crime**, considerando sucessivamente os elementos constitutivos daquele conceito, em relação seja à forma básica ou geral, seja a formas particulares ou especiais de aparecimento do crime. Aquele primeiro tratamento corresponde ao disposto nos arts. 1.º a 39.º O segundo tratamento abarca a matéria das **consequências jurídicas do crime**, onde assume especial destaque, já o sabemos, o estudo das sanções criminais (penas e medidas de segurança). Ele corresponde fundamentalmente, deste modo, ao disposto nos arts. 40.º a 130.º; se bem que o referido art. 40.º constitua uma espécie de *pivot* entre os dois tratamentos, uma vez mais de acordo com a ideia exposta (supra, § 6) segundo a qual é a partir da natureza da *consequência* que pode em definitivo estabelecer-se a estrutura e a função do *pressuposto*.

§ 16 O tratamento seguinte versará exclusivamente a parte geral do direito penal e, dentro desta, apenas as matérias relativas à primeira parte acima mencionada, isto é, os temas relativos aos fundamentos gerais e à doutrina geral do crime. Ocorre precisar ainda que as considerações posteriores deixarão de lado, em princípio, os fenómenos, as normas e os institutos que se inscrevam com especificidade no âmbito de **direitos penais especiais**, *v. g.*, no direito penal militar ou de menores, e só aí ganhem relevo. Isto não significa porém que a nossa atenção se restrinja rigidamente ao âmbito do chamado direito penal **primário, de justiça** ou **clássico** — fundamentalmente correspondente ao que se contém no CP —, com exclusão do direito penal **acessório, secundário** ou **económico-social** (infra, 6.º Cap., § 26 e ss.). Sejam quais forem as suas especificidades, o direito penal secundário, contido embora em leis extravagantes, participa plenamente, ao menos no que toca à doutrina geral do crime, da problemática do direito penal geral e deve merecer consideração conjunta. Tanto mais que frequentemente, por mor da sua particular teleologia, ele assume altíssimo valor pedagógico e de contraprova das soluções preconizadas para o direito penal de justiça.

2.º CAPÍTULO

A LOCALIZAÇÃO DO DIREITO PENAL NO SISTEMA JURÍDICO

I. Direito penal intra-estadual e direito internacional penal

§ 1 O direito penal é ainda hoje essencialmente direito intra-estadual, que encontra a sua fonte formal e orgânica na produção legislativa estadual e é aplicado por órgãos nacionais. Todavia, a partir da última década do séc. XX assistiu-se a um prodigioso incremento da **relevância do direito internacional em matéria penal**. Existem, desde logo, múltiplas *normas* de direito internacional (*v. g.*, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos) de conteúdo jurídico-penal e de relevo indiscutíveis para a aplicação do direito penal. Depois, há que ter em conta os cada vez mais numerosos *instrumentos de direito internacional em matéria penal* (a título de exemplo, a Convenção para a Prevenção e para a Sanção do Delito de Genocídio, a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas e, noutro plano, a Convenção Relativa à Extradição entre os Estados Membros da União Europeia), onde se contêm certas opções de política criminal internacionalmente convencionadas, que implicam para o Estado Português, enquanto parte dos mesmos, a obrigação de editar normas internas que lhes dêem corpo (cf. o art. 243.º e s. do CP). Por fim, existem alguns *princípios* de direito internacional geral ou comum que podem servir como lei penal incriminadora, à luz do disposto no art. 29.º-2 da CRP, assim se quebrando o clássico princípio de direito internacional segundo o qual este só poderia conceder direitos e impor-se aos Estados e aos poderes públicos estaduais, não às pessoas ou aos cidadãos. A verdade porém é que, em todos estes casos, tanto as nor-

mas, como os princípios de direito internacional penal vigoram na ordem jurídica portuguesa — ao lado ou mesmo acima das leis ordinárias — não por si mesmos, mas em último termo (mesmo em face de uma teoria como a da "adopção", segundo a qual o direito internacional não se transforma em direito interno ([1])) por força da credencial constante do art. 8.º da CRP.

§ 2 O que ficou dito não deve fazer esquecer que o direito internacional penal conheceu recentemente **desenvolvimentos** de magnitude sem precedentes, com a instituição dos Tribunais Penais Internacionais *ad hoc* para a antiga Jugoslávia (TPIJ) e para o Ruanda (TPIR) e com a aprovação do Estatuto do TPI (Estatuto de Roma). Em todos estes casos trata-se de verdadeira aplicação, por órgãos internacionais ou mesmo nacionais, de direito internacional penal, embora essa competência seja limitada ao conhecimento de certos crimes. O que significa que o direito penal já não é, no momento presente, **monopólio** da legislação e da jurisdição dos Estados. Assim se compreendendo que comece a assistir-se a tentativas de domínio *dogmático* deste novo direito penal ([2]). De resto, a L 31/2004, de 22-7, veio justamente adaptar a legislação penal portuguesa ao Estatuto do TPI, tipificando as condutas que constituem crimes de violação do direito internacional humanitário.

§ 3 O TPIJ e o TPIR foram criados, respectivamente, pelas Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas 827 (1993) e 955 (1994), com vista à punição dos crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos naqueles territórios nos primeiros anos da década de 90 e os seus Estatutos contêm uma delimitação típica das condutas que, integrando crimes contra o direito internacional (*delicta iuris gentium*), caem sob a sua jurisdição, que é também limitada *ratione temporis* e *ratione loci*.

§ 4 O Estatuto de Roma, aprovado em 1998 por uma Assembleia de Estados sob os auspícios das Nações Unidas, visou a instituição de um Tribunal Penal Internacional permanente (para assim evitar as críticas que, com razão, se dirigiam aos tribunais *ad hoc*), com competência para conhecer, exclusivamente, dos *delicta iuris gentium*. As duas notas marcantes

---

([1]) CANOTILHO / MOREIRA, art. 8.º, anot. 2.

([2]) De que constitui uma das primeiras e claras manifestações AMBOS, *Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts. Ansätze einer Dogmatisierung*, 2002 (tradução — parcial — em espanhol de Ezequiel Malarino, 2004).

desta nova jurisdição ([3]) são o **princípio da vinculação voluntária** e o **princípio da subsidiariedade**. De acordo com o primeiro, a jurisdição do Tribunal não é imposta aos Estados; diversamente do que sucedeu com o TPIJ e, em boa parte, com o TPIR, a jurisdição do TPI vincula apenas os Estados que se tornem Partes no Estatuto (ou que decidam colaborar com o Tribunal com base num acordo *ad hoc*). Este princípio encontra a sua expressão positiva na disposição que regula os pressupostos do exercício da jurisdição: tal exercício só é possível se o Estado em cujo território o facto tiver ocorrido, *ou* o Estado de que a pessoa acusada é nacional, forem Partes no Estatuto ou, não o sendo, aceitarem a jurisdição do Tribunal naquele caso (art. 12.º do Estatuto) ([4]). De acordo com o princípio da subsidiariedade (verdadeira "pedra angular do Estatuto" ([5])), o TPI só poderá exercer a sua jurisdição se os Estados com competência para conhecer do facto não o conhecerem ou não puderem fazê-lo (art. 17.º do Estatuto).

§ 5 Enfim, a doutrina da essencial intra-estadualidade do direito penal não se modifica, apesar de tudo, em face dos problemas (em todo o caso e em alguma medida específicos) suscitados pelo processo de **integração europeia** ([6]). No estado actual desta integração — e sem menosprezar o progressivo relevo que a União tem conferido à matéria penal, claramente expresso nas sucessivas alterações introduzidas nos Tratados e na actividade política dos órgãos comunitários — **não existe ainda um direito penal comunitário**, e como tal supranacional, de aplicação directa pelos Estados Membros. A este propósito, o TJ pronunciou-se várias vezes, no passado, no sentido de a Comunidade Europeia não possuir uma competência penal, pelo que a intervenção das instâncias europeias em matéria penal se considerava limitada ao âmbito e aos procedimentos previstos no Tratado da União Europeia (art. 29.º e ss.). Todavia, tal jurisprudência parece ter sido abandonada no recente Ac. do TJ de 13-9-2005 ([7]), que anu-

---

([3]) V., por último, CARVALHO, Taipa de, I, § 399 e ss.

([4]) O princípio da vinculação voluntária encontra uma *excepção* nos casos em que o impulso processual é desencadeado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, nos termos do art. 13.º/*b)*; nesses casos o TPI adquire jurisdição universal, não se tornando necessária a verificação dos pressupostos de jurisdição referidos no texto.

([5]) WILLIAMS, Sharon A., *in*: Triffterer (org.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 1999, p. 384.

([6]) Importante sobre este ponto, CAEIRO, Pedro, Perspectivas de formação de um direito penal da União Europeia, *RPCC 6*, 1996, p. 189.

([7]) Que pode ser lido em www.curia.europa.eu.

lou a Decisão-quadro 2003/80/JAI, de 27-1-2003, com o fundamento de que as medidas de protecção penal do ambiente aí contidas poderiam ter sido validamente adoptadas com base no art. 175.º do Tratado da Comunidade Europeia, pelo que a dita Decisão-quadro terá violado o art. 47.º do Tratado da União, ao invadir indevidamente as competências da Comunidade. Deste modo, o Acórdão admite expressamente que a *Comunidade* Europeia tem o poder de obrigar os Estados Membros a adoptarem normas de índole penal "quando a aplicação de sanções penais efectivas, proporcionadas e dissuasivas pelas autoridades nacionais competentes constitua *uma medida indispensável para lutar contra os atentados graves*" aos interesses que lhe estão confiados. Porém, a decisão não se pronuncia sobre a questão de saber se essa competência penal pode ser exercida através da aprovação de normas directamente aplicáveis pelos tribunais nacionais (regulamentos), ou se se limita à possibilidade de impor certas obrigações de criminalização aos Estados-membros, através de directivas.

§ 6 Seguro é, de todo o modo, que pode falar-se de um *ius puniendi* **negativo** das instâncias comunitárias, é dizer, da legitimidade para impor normas que se projectam no estreitamento ou recuo do direito penal estadual. Dada a prevalência do direito comunitário sobre o direito nacional (cf. art. 8.º-4 da CRP) — e face ao entendimento válido do princípio da *unidade da ordem jurídica* contido no art. 31.º: infra, § 9 e s., e 14.º Cap., § 7 e ss. —, o legislador nacional não poderá qualificar como penalmente ilícitas condutas exigidas ou autorizadas pelo direito comunitário ([8]).

II. O direito penal como parte do direito público

§ 7 O direito penal constitui, por excelência, um ramo ou uma parte integrante do **direito público**. Porventura em nenhuma outra disciplina jurídica como nesta surgirá uma tão nítida relação de supra / infra-ordenação entre o Estado soberano, dotado do *ius puniendi*, e o particular submetido ao império daquele; como em nenhuma outra será tão visível a função estadual de preservação das condições essenciais da existência comu-

([8]) Sobre o problema, logo, TENREIRO, Mário, Crime de aborto e direito comunitário, *RPCC* 2, 1992, p. 353; e, depois, CAEIRO, Pedro, nota 6, p. 199 e *passim*, RODRIGUES, Anabela / MOTA, Lopes da, *Para uma Política Criminal Europeia*, 2002, p. 31, e BRANDÃO, Nuno, *Branqueamento de Capitais: O Sistema Comunitário de Prevenção*, 2002, p. 61.

nitária e o poder estadual de, em nome daquela preservação, infligir pesadas consequências para a liberdade e o património — quando já não, como infelizmente ainda (ou de novo) em tantos países, para a vida e para o corpo — dos cidadãos. Por tudo isto tanto a doutrina do crime, como a dos seus efeitos jurídicos assumem uma estreitíssima conexão com o **direito constitucional** e com a **teoria do Estado**. Conexão esta reforçada ainda por uma dupla circunstância: pelo facto, por um lado, de os instrumentos sancionatórios específicos do direito penal — as penas e as medidas de segurança — representarem, pela sua própria natureza, negações ou fortíssimas limitações de direitos fundamentais das pessoas; e pelo de, por outro lado, se verificar a necessidade de uma relação de mútua referência entre a ordem axiológica jurídico-constitucional e a ordem legal dos bens jurídicos que ao direito penal cumpre tutelar (CRP, art. 18.º-2; infra, 6.º Cap., § 24 e s.). Decerto, a esfera de actuação pessoal do cidadão — a sua autonomia e auto-realização — constitui como veremos, a muitos títulos, um *limite* à intervenção penal do Estado. Verificados porém os pressupostos da intervenção, o *ius puniendi* estadual surge como coisa pública, por inteiro subtraída à vontade dos particulares. O que sucede é só que, pelo seu relevo prático e pela especificidade da sua elaboração teórica, o direito penal autonomizou-se historicamente, desde há muitos séculos e de forma definitiva e irreversível, daquilo que complexivamente continua a chamar-se o "direito público" e passou a constituir uma disciplina inteiramente própria.

III. O direito penal perante os outros ramos do direito. Autonomia e dependência do direito penal

§ 8 Se quisermos definir mais exactamente o **lugar** do direito penal dentro do sistema jurídico estadual, através da posição relativa que assume perante os outros ramos do direito, o quadro a esboçar é plurifacetado e nem sempre de fácil apreensão. Relativamente ao **direito constitucional** o direito penal assume um carácter de *dependência* análogo ao de qualquer outro ramo do direito ordinário; e isto é tudo quanto importará dizer no presente contexto formal-sistemático; sem todavia deixar de insistir-se desde já em que, de um ponto de vista material, o relacionamento entre o direito constitucional e o direito penal constitui uma das questões mais complexas de toda a nossa disciplina. Mais questionado tem sido todavia o posicionamento do direito penal face a **outros ramos do direito ordinário**, nomeadamente o direito civil, o direito administrativo e o direito proces-

sual, que prevêem, também eles, sanções de natureza específica — e por vezes mesmo "penas", se bem que de natureza não criminal — para a violação das normas respectivas.

§ 9 Uma tese vai no sentido de pôr em evidência o carácter "dependente", "acessório", "subordinado" ou "secundário" de todo o direito penal face a estes outros ramos do direito. Estes seriam criadores de verdadeira *ilicitude*, ao contrário do direito penal, a quem pertenceria uma **função puramente sancionatória**: a de intervir com o arsenal dos seus meios e instrumentos próprios para sancionar certos ilícitos criados pelos outros ramos de direito; e a de intervir com os seus meios próprios apenas quando as sanções impostas para o ilícito por outros ramos do direito se revelassem ineficazes ou insuficientes ([9]). Deste ponto de vista estaria pois justificado falar-se da **dependência** do direito penal relativamente aos outros ramos do direito, estes sim, "criadores" de ilicitude.

§ 10 Esta concepção arranca da *teoria das normas* de Binding e da sua distinção entre "**norma**" e "**lei penal**". A primeira antecede conceitualmente e, em regra, também cronologicamente a segunda e contém um mandato *imperativo* de fazer ou não fazer, o qual, se for violado, dá origem à ilicitude da acção ou da omissão. À segunda, à lei penal, apenas pertence sancionar com meios específicos, sob certas condições, aquela ilicitude ([10]). A partir daqui foi só um passo — dado decididamente por Bierling — até à afirmação de que importa distinguir as *normas primárias* (de direito civil, administrativo, etc.), que contêm imposições ou proibições, das *normas secundárias* (de direito penal), que visam conferir protecção e efectividade a certas normas primárias, assegurando o seu cumprimento através de sanções de espécie particular. Nesta teoria das normas escorou Beling a afirmação da **unidade da ilicitude**: não há uma ilicitude especificamente penal, civil ou administrativa, antes, se uma acção viola um imperativo jurídico qualquer, ela constitui-se, por força do *princípio da unidade da ordem jurídica* de que mais tarde falaria Thon, em ilícito para todos os ramos do direito.

([9]) Assim, SANTOS, Beleza dos, *Introdução*, p. 79 e ss., e CORREIA, Eduardo, I, n.º 7.

([10]) BINDING, *Normen*, I, pp. 4 e ss. e 108 e ss., e *Handbuch*, I, 1885, p. 9; sobre ele, KAUFMANN, Armin, *Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie*, 1954, pp. 3 e ss. e 36 e ss.; e sobre toda a evolução a seguir apontada, ENGISCH, *Die Einheit der Rechtsordnung*, 1935, p. 55 e ss. e *passim*. Cf., também, entre nós, por último, CARVALHO, Taipa de, I, § 184 e s.

§ 11 A tese apontada — e que persistiu até à actualidade, sobretudo através da ideia da unidade da ordem jurídica e da consequente **unidade de todo o ilícito** — não parece correcta. E fazendo embora apelo a muitas ideias num certo contexto exactas, nomeadamente à ideia do carácter *acessório* e *fragmentário* da específica *função de tutela* do direito penal —, ela pode conduzir aos mais graves equívocos. Justamente porque a função do direito penal radica na protecção das condições indispensáveis da vida comunitária (e, neste sentido, a sua função é em verdade subsidiária, fragmentária e, *hoc sensu*, "acessória"), cumpre-lhe seleccionar, dentre os comportamentos em geral ilícitos, aqueles que, de uma perspectiva *teleológica*, representam um ilícito geral *digno* de uma sanção de natureza criminal ([11]). Esta tarefa de selecção ou eleição não pode ser levada a cabo sem uma valoração ético-social do comportamento e não se dilui por isso no "delito geral de desobediência" de que falava Binding. O fenómeno da criminalização e da descriminalização é decerto inseparável da evolução sócio-cultural no seu mais amplo sentido; mas ele depende sempre, em último termo, das finalidades que com o direito penal se procuram servir, da sua teleologia específica e das intenções político-criminais, não da forma como a valoração seja levada a cabo por outros ramos do direito. Nesta acepção o direito penal é **autónomo** e **criador de uma específica ilicitude penal**, correspondente à especificidade e à qualificação das consequências jurídicas que a um tal ilícito se ligam: à especificidade da consequência tem de corresponder se não logicamente, ao menos teleologicamente a especificidade dos pressupostos (do *Tatbestand*, no sentido da Teoria Geral do Direito) de que aquela depende, e antes de tudo a especificidade do ilícito (mas não só dele, como também da culpa e dos restantes pressupostos de punibilidade).

§ 12 Em que se traduz esta especificidade, esta particular "**dignidade**" da matéria penal, é coisa cujo esclarecimento fica reservado ao lugar em que seja analisada a função do direito penal (infra, Título II). Cumpre só acentuar desde já que contra a concepção aqui defendida não deverá argumentar-se com o princípio da "unidade da ordem jurídica". Dado que a qualificação de um ilícito como penal representa, considerada a função e a teleologia próprias do direito penal, o grau máximo de contra-

([11]) Cf. DIAS, Figueiredo. Sobre o estado actual da doutrina do crime, *RPCC 2*, 1992, p. 34 e ss., e ANDRADE, Costa, A "dignidade penal" e a "carência de tutela penal" como referências de uma doutrina teleológico-racional do crime, *RPCC 2*, 1992, p. 173 e ss. COSTA, Faria, *O Perigo em Direito Penal*, 1992, p. 371[26], pretende operar aqui com a distinção entre uma fragmentaridade de 1.º e de 2.º grau.

riedade à ordem jurídica, o aludido princípio é aceitável se com ele se quiser significar apenas que não pode ser ilícito face à lei penal tudo aquilo que for permitido por qualquer outro ramo do direito; mas é inaceitável se com ele se pretender concluir que o que é ilícito à face de um direito não penal também tem de o ser à face da lei penal, mesmo que por outras razões não venha em definitivo a ser penalmente punido. E isto é tudo quanto pode ser retirado, para o direito penal, do princípio da unidade da ordem jurídica.

§ 13 A progressiva autonomização do direito penal relativamente aos restantes ramos do direito tem-se revelado prenhe de consequências, nomeadamente no que respeita à libertação dos **conteúdos** e das **técnicas conceituais** tanto em face do direito privado, como do direito público. Bem se compreende, deste modo, que a tipicização de certos substratos como ilícitos jurídico-penais possa revelar *maiores exigências* do que as que são postas pelos restantes ramos de direito, mesmo quando os conceitos utilizados são idênticos ou similares. Como se aceitará, em consequência, que nenhum conceito extra-penal possa ser transposto para o direito penal, na parte incriminatória, sem antes se ter determinado, através de cuidada hermenêutica, se ele corresponde por inteiro à intencionalidade e à teleologia específicas do ilícito jurídico-penal. Os exemplos que poderiam fornecer-se a propósito são inúmeros e com muitos se deparará no tratamento posterior.

3.º CAPÍTULO

A CIÊNCIA CONJUNTA DO DIREITO PENAL (*)

I. Da "enciclopédia das ciências criminais" à "ciência conjunta do direito penal"

§ 1 Desde há muito e por toda a parte se reconhece que o "crime" constitui um fenómeno de **patologia social** diversificado, que releva não apenas de condicionalismos exógenos (externos, sociais), mas também de substratos endógenos (internos, individuais) componentes da mais complexa de todas as realidades: a realidade humana; que releva do Homem total e da sua condição. Isto faz compreender que, ao longo do séc. XIX, quando se estabeleceu (julgava-se que definitivamente) o estatuto do pensamento científico moderno, o crime se tenha tornado em objecto de uma multiplicidade de ciências. Antes de tudo, da ciência (normativa) do *direito* penal, é dizer, da *dogmática jurídico-penal* e das suas disciplinas jurídicas auxiliares: a história, a filosofia, a metodologia jurídico-penais. Mas objecto também da generalidade das ciências sociais e humanas, a ponto de ter dado muitas vezes lugar ao surgimento, no domínio delas, de uma vasta gama de disciplinas (pelo menos *relativamente*) autónomas relacionadas com o crime: a sociologia criminal, a antropologia criminal, a psicologia criminal, a psiquiatria criminal, a caracterologia criminal, a genética criminal. A este conjunto vastíssimo de disciplinas científicas que

---

(*) O essencial das ideias expostas neste capítulo, de forma particular no que ao estatuto da política criminal e às suas relações com a dogmática respeita, encontra-se já em trabalhos anteriores nossos: Os novos rumos da Política Criminal e o direito penal português do futuro, *ROA 43*, 1983, p. 7, Les nouvelles tendances de la politique criminelle au Portugal, *ArchPC 6*, 1983, p. 193 e ss., e Sullo stato dei rapporti fra politica criminale e dogmatica giuridico-penale, *in: Il diritto penale alla svolta di fine milennio. Atti del Convegno in ricordo di Franco Bricola, a cura di Stefano Canestrari*, 1998, p. 216.

têm o crime por objecto chamou von Liszt a "enciclopédia das ciências criminais" (1).

§ 2 Os conhecimentos provenientes de todas estas ciências não podem hoje deixar de ser tomados em conta pela **ciência estrita do direito penal** ou **dogmática jurídico-penal**. Para a compreensão científica da tarefa de *aplicação* do direito penal não basta o conhecimento das normas jurídico-penais, antes se torna indispensável o domínio das contribuições que a gama das ciências criminais pode validamente fornecer. O que não significa tornar a dogmática jurídico-penal em uma *ciência interdisciplinar* (2). Uma tal concepção não se adequaria nem à teleologia, nem à funcionalidade próprias da dogmática jurídico-penal. Esta é e deve permanecer *aplicação do direito*, dotada dos seus pressupostos metodológicos específicos e comandada por finalidades prático-normativas autónomas. Por isso o conjunto das referidas ciências criminais não passa, neste sentido, de uma "enciclopédia" e cada uma delas não pode aspirar a outro estatuto que não seja o de **ciência auxiliar** da ciência estrita do direito penal.

§ 3 Até finais do séc. XIX a dogmática jurídico-penal era a *única* ciência que servia a aplicação do direito penal e, por conseguinte, a única que o jurista podia e devia legitimamente cultivar. Posteriormente, contudo, reconheceu-se que a tarefa social de controlo do crime não podia bastar-se com uma ciência puramente jurídica, normativa e dogmática. A consecução com êxito daquela tarefa dependia antes também, em alto grau, de uma *definição das estratégias de controlo social* do fenómeno da criminalidade, cujas quotas aumentavam por todo o lado: era o domínio por excelência da **política criminal**. Como dependia do *conhecimento empí-*

---

(1) V. LISZT, Der Begriff des Rechtsguts im Strafrecht und in der Enzyklopädie der Rechtswissenschaften, *ZStW 8*, 1888, p. 133. O designativo foi depois divulgado, no espaço ibérico, por ASÚA, Jiménez de, *Tratado de derecho penal*, I, ³1964, p. 92.

(2) Isto é, em uma ciência assente na reunião de campos especiais e de métodos diversificados num trabalho comum; mas capaz de coordenar correctamente os resultados parcelares especializados dentro de uma consideração unitária e nova do seu objecto global: DIAS / ANDRADE, p. 114 e ss. Sobre a influência das ciências sociais no direito penal cf., por último, PORTILLA, Contreras, La influencia de las Ciencias sociales en el derecho penal: la defensa del modelo ideológico neoliberal en las teorías funcionalistas y en el discurso ético de Habermas sobre la elección de interesses penales, *in:* Arroyo Zapatero / Neumann / Nieto Martín (orgs.), *Crítica y justificación del derecho penal en el cambio de siglo*, 2003, p. 99.

rico da criminalidade, dos seus níveis e das suas causas, que precisamente uma nova ciência então nascente pretendia abarcar e desenvolver: era o domínio por excelência da **criminologia** (3). Foi mérito de von Liszt ter criado, na base das *especiais* relações intercedentes entre estes vários pensamentos do crime — relações que assim se não confundem com as anteriormente referidas dentro da enciclopédia das ciências criminais —, o *modelo tripartido* do que chamou a **ciência conjunta (total ou global) do direito penal**: a *gesamte Strafrechtswissenschaft* (4). Uma ciência conjunta, esta, que compreenderia como ciências autónomas: a *ciência estrita do direito penal* (ou *dogmática jurídico-penal*), concebida, ao sabor do tempo, como o conjunto de princípios que subjazem ao ordenamento jurídico-penal e devem ser explicitados dogmática e sistematicamente; a *criminologia*, como ciência das causas do crime e da criminalidade; e a *política criminal*, como "conjunto sistemático dos princípios fundados na investigação científica das causas do crime e dos efeitos da pena, segundo os quais o Estado deve levar a cabo a luta contra o crime por meio da pena e das instituições com esta relacionadas" (5). Mas ciências só "relativamente" autónomas: visando por esta via encarecer sobretudo a autonomia da política criminal e da criminologia perante o estudo estritamente jurídico do crime e o seu tratamento "dogmático" e "sistemático", o modelo da "ciência conjunta" tinha como ponto essencial dar a compreender que qualquer uma das suas três vertentes seria em último termo relevante para a tarefa da aplicação do *direito* penal e, por aí, para a tarefa sócio-política de controlo do fenómeno do crime.

§ 4 Esta ideia de von Liszt (6), como todas as ideias verdadeiramente precursoras, não conseguiu impor-se no âmbito jurídico-penal sem antes ter acarretado ao seu autor muitas **críticas**, e mesmo a mais decidida oposição. Nesta se tendo distinguido Karl Binding, que acusou as concepções "globais" deste tipo de abandonar o solo firme da lei, do seu tratamento dogmático-sistemático, do seu conhecimento e da sua aplicação precisos, para, cedendo a "impulsos diletantes", penetrar no terreno movediço e interdito a juristas enquanto tais das investigações de carácter *político* e

(3) Sobre isto e quanto se segue, de novo, DIAS / ANDRADE, p. 93 e ss.

(4) V. LISZT, *Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge*, I, 1905, p. 293 e s., e II, 1905, p. 285.

(5) V. LISZT, nota 4, I, p. 292.

(6) Sustentada logo depois também, no essencial, por penalistas como van Hamel e Prins, sobretudo no âmbito da *Union Internationale de Droit Pénal*.

científico-natural (7). Apesar de todas estas críticas, porém, a ideia mestra da ciência conjunta do direito penal não se perdeu mais e constituiu ao longo de todo o séc. XX — como continua ainda hoje a constituir — ponto de referência obrigatório (8) de uma compreensão exacta e abrangente do estatuto de mútuo relacionamento da dogmática jurídico-penal, da política criminal e da criminologia.

II. A evolução do estatuto das ciências criminais

§ 5 Desde o momento em que von Liszt cunhou a ideia de uma ciência conjunta ou global do direito penal até aos nossos dias não se tornou pacífico o **estatuto** que dentro dela deveria caber a cada uma das três ciências que a compõem, nem tão-pouco a sua **hierarquia** e o **modo** como elas devem relacionar-se entre si. Isto ficou a dever-se a uma dupla circunstância: à evolução que entretanto sofreram quer os supostos metodológicos, quer a própria compreensão do sentido, do objecto e (sobretudo) da função da dogmática, da política criminal e da criminologia dentro do sistema social; e à evolução da compreensão do sistema social, ele mesmo, no contexto próprio de um Estado de Direito.

1. No contexto do Estado de Direito formal (liberal-individualista) e do positivismo jurídico

§ 6 Apesar de todo o relevo que von Liszt concedia à política criminal e à criminologia no seio da ciência conjunta do direito penal, era a **dogmática jurídico-penal** que, no seu pensamento, devia continuar a ocupar o *primeiro lugar* na hierarquia das ciências criminais. Esta conclusão apresentava-se, por um lado, como fruto da necessidade de se defender das críticas de desjuridificação da ciência do direito penal; e nomeadamente da acusação de substituir o sentido garantístico do princípio da legalidade jurídico-penal e o significado da exigência de culpa num direito penal do facto pela asserção sociológica moderna de que a

(7) BINDING, *Grundriß des deutschen Strafrechts, AT*, 71907, p. V. Em pormenor sobre a controvérsia, SCHÖCH, Verstehen, Erklären, Bestrafen. Vergangenes und Aktuelles zur gesamten Strafrechtswissenschaft, *in*: *Rechtswissenschaft und Rechtsentwicklung*, 1980, p. 305 e ss.

(8) Cf. só, além das obras de DIAS / ANDRADE, p. 93 e ss., e de SCHÖCH, nota 7, os estudos de MAIHOFER, Gesamte Strafrechtswissenschaft, *Henkel-FS*, 1974, p. 75, e de LEFERENZ, Rückkehr zur gesamte Strafrechtswissenschaft?, *ZStW 93*, 1981, p. 199.

política criminal conduz à legitimação da ordem jurídico-penal para se defender de todos os agentes perigosos e para os neutralizar, se e enquanto aquela perigosidade persistir (9). Como era fruto, por outro lado, da ideia de von Liszt de que a política criminal se devia remeter (e limitar) à função específica de revelar os caminhos da *reforma penal*, de actuar exclusivamente, por conseguinte, *iure constituendo*: ela não detinha competência para influenciar de qualquer forma a compreensão, a sistematização e, em definitivo, a aplicação das normas jurídico-penais, não se encontrava titulada para agir *iure constituto* (10). Precisamente para o sublinhar formulou von Liszt uma proposição básica acerca da hierarquização e das relações entre a dogmática jurídico-penal e a política criminal: "**o direito penal** [e portanto, a dogmática jurídico-penal] **constitui** — escreveu ele, em frase lapidar — **a barreira intransponível da política criminal**" (11).

§ 7 Esta proposição continua a concitar a atenção e a exegese dos estudiosos e a dar lugar às interpretações mais diversas. Ela assume um conteúdo ainda hoje justificado: o de que, em um Estado de Direito, o *princípio da legalidade* (o princípio *nullum crimen, nulla pœna sine lege*: infra, 8.º Cap.) constitui a fronteira inultrapassável da punibilidade — e, com isto, também a fronteira de todo o fenómeno *criminal*. Parece no entanto que não era só este conteúdo que von Liszt entendia caber-lhe, mas ainda (pelo menos) o de que é à dogmática jurídico-penal que pertence assinalar à política criminal o seu objecto preciso; sendo por isso à dogmática que cabe a função *primária* dentro da ciência conjunta do direito penal, por ser aquela a única competente para a explicitação das normas jurídico-penais no seu encadeamento interno, é dizer, sistematicamente. Numa palavra: deste ponto de vista, a política criminal (como, de resto, a criminologia) continuaria a não poder ser outra coisa que uma simples **ciência auxiliar** do direito penal (12).

§ 8 Tudo isto se compreende, desde logo, em **perspectiva ideológica**. O tempo de von Liszt era o do *Estado de Direito formal*, de vertente *libe-*

---

(9) Assim, por último, ROXIN I, § 7, n.ºs 69 e, sobre o que se segue, 75 e ss.

(10) Assim, ainda, ZIPF, Literaturbericht. Kriminalpolitik, *ZStW 89*, 1977, p. 708, e GARCIA-PABLOS, Momento actual da reflexão criminológica, *RBCC 0*, 1992, p. 19 e s.

(11) V. LISZT, nota 4, II, p. 80.

(12) Assim, ainda, CORREIA, Eduardo, I, n.º 3.

ral e *individualista*; isto é ([13]), de um Estado subordinado a esquemas rígidos de legalidade formal, mas alheio à valoração das conexões de sentido, dos fundamentos axiológicos e das intenções de justiça material ínsitos nos *conteúdos* definidos através daqueles esquemas. Como era ainda o tempo da *metodologia jurídica positivista* ([14]), se bem que enriquecida já pela dimensão do *social* (na qual justamente von Liszt tanto insistiu). A competência para definir o sentido e os limites — dito de outra forma: o "quê", o "se" e o "como" — da punibilidade não podia, neste contexto, pertencer a outra instância que não fosse a *ciência estrita do direito penal*, isto é, a das normas legais do direito penal e da vontade do legislador histórico, onde se pensava deparar com as únicas vias para afastar a aplicação do direito penal do acaso e do arbítrio. Para a **política criminal** restava a função de, baseada nos conhecimentos da análise da realidade criminal, naturalística e empírica — baseada, numa palavra, na **criminologia** tal como ela era então concebida —, dirigir ao legislador recomendações e propor-lhe directivas em tema de reforma penal. No que toca porém a uma incidência directa sobre o direito penal tanto a política criminal, como a criminologia só a podiam alcançar *dentro* de um certo ordenamento jurídico-positivo, subordinadas à aparelhagem conceitual e à plenitude sistemática daquele e sem que sobre o sistema e os seus conceitos pudessem exercer qualquer influência directa.

2. No contexto do Estado social e do sociologismo jurídico

§ 9 Os pressupostos jurídico-políticos e metodológicos que sustentavam a concepção acabada de desenhar pertencem ao passado. O Estado de Direito formal, de vertente liberal e individualista, foi substituído, na teorização das doutrinas do Estado, pelo paradigma do **Estado social**: de um Estado que atenuou as exigências de legalidade formal (quando as não abandonou, pondo em risco a salvaguarda dos direitos da pessoa) em favor da promoção e da realização das condições de desenvolvimento harmónico e equilibrado do sistema social. Se, no paradigma antecedente, era o domínio absoluto da legalidade formal sobre o social, agora, ao contrário,

---

([13]) Sobre a caracterização que se segue, DIAS, Figueiredo, Direito penal e Estado de Direito material, *RDP 31*, 1983, p. 38 e s.

([14]) Fundamentais para a sua compreensão, WELZEL, *Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht*, 1935, e CORREIA, Eduardo, *Unidade*, p. 79 e ss. e *passim*.

é a hora do predomínio absoluto do social e de um certo menosprezo do jurídico. De modo que se pode falar, com razão — sobretudo, mas não só, no espaço político-cultural inglês e norte-americano —, de um **divórcio** da ciência social e da ciência jurídica, à custa desta última.

§ 10 Tinha assim chegado a hora da **independência da política criminal** face ao direito penal e à sua dogmática. As relações da política criminal com a dogmática jurídico-penal pareciam terminadas — quando se não tivessem tornado em estranhas relações de antagonismo ou de afrontamento —, para serem substituídas por uma espécie de "ligação directa" de cada uma das antigas disciplinas integrantes da ciência conjunta do direito penal ao *sistema social* como tal. Dito por outra forma: a função integradora da ciência conjunta do direito penal era agora substituída pelo sistema social ele mesmo, como máximo denominador comum da política criminal, da criminologia e (também, ao menos em uma certa medida) da dogmática jurídico-penal. Não se estranhará que, desta perspectiva, a política criminal e a criminologia não somente se tenham autonomizado completamente do direito penal e da sua dogmática, mas verdadeiramente lhe tenham voltado as costas.

§ 11 Não é por acaso, com efeito, que passa então a sublinhar-se que o **objecto** da política criminal é de todo o ponto diverso do objecto da dogmática jurídico-penal ([15]). Este continua a ser constituído pelo crime, tal como ele seja estritamente definido por lei votada no Parlamento; diferentemente, o objecto da política criminal não é constituído apenas pelo crime, mas por todos os fenómenos de patologia social substancialmente aparentados com aquele, sejam de marginalidade social, sejam em último termo — numa palavra criada pela sociologia norte-americana, mas rapidamente acolhida em qualquer latitude — de *deviance* ou "desvio social". Como não é por acaso que passa a sublinhar-se com insistência (o que, de resto, se deveria ter tornado evidente desde o primeiro momento) que os **métodos científicos** da política criminal e da criminologia nada têm em comum com os da dogmática jurídico-penal; sobretudo com a metódica de raiz positivista, com os seus dogmas logicistas do caracter "intocável" da lei na sua expressão formal e da actividade puramente silogística do aplicador — a lembrarem ainda a palavra de Montesquieu segundo a qual "les juges de la nation ne sont (...) que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur" ([16]). Nem é por acaso,

([15]) Fundamental, DELMAS-MARTY, Mireille, *Les grands systèmes de politique criminelle*, 1992, pp. 13 e ss. e 44 e ss.; e já antes, da mesma, *Modèles et mouvements de politique criminelle*, 1983, e *Le flou du droit*, 1986.

([16]) MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, *in*: *Œuvres*, Dalibon, 1822, livro 11, cap. 35.

enfim, que o estudo da política criminal e da criminologia não logrou nunca alcançar lugar próprio no ensino das Faculdades de Direito e foi por regra desterrado (primeiro nas Universidades norte-americanas, depois também nas europeias) para as Faculdades de Ciências Políticas e de Sociologia.

§ 12 Uma concepção como a que acaba de referir-se apresenta **vantagens** relativamente à concepção anteriormente considerada. À sua luz se compreende que o jurídico e a sua dogmática não são algo de diferente e de separado do sistema social, mas, pelo contrário, se apresentam como verdadeiros *subsistemas* do sistema social. Como se compreende que a política criminal não é uma simples *ciência auxiliar* do direito penal e da sua dogmática, que só actuaria dentro dos limites que lhe são assinados pelas normas jurídicas aprovadas no Parlamento. Como se torna claro que o direito penal constitui apenas *um dos* componentes do sistema global de controlo social e se encontra por isso numa rede de múltiplas relações e interdependências com outras formas de resolução de conflitos sociais. Há porém que perguntar **a que custo** se obtêm e se compreendem estas vantagens. Se o objecto da política criminal não se esgota na infracção penal, mas é algo de diferente, determinado de modo imediato a partir do sistema social; se o jurista é reduzido à condição de fazedor de silogismos, enquanto no seu anterior lugar se coloca agora o cientista social — se isto é assim, então esta concepção soa como dobre a finados por uma qualquer colaboração frutuosa entre a política criminal e a dogmática jurídico-penal, o simples diálogo entre as duas torna-se impossível ou transforma-se num diálogo de surdos. Numa palavra, à desejável *cooperação* entre as ciências integrantes da antiga "ciência conjunta" do direito penal substitui-se a *ignorância mútua*. Por uma parte, o jurista como tal nada mais terá a dizer a nível *de lege ferenda*, da reforma penal, em suma, de uma contribuição válida para um funcionamento efectivo e eficaz do sistema social. Por outra parte, adversamente, os ensinamentos e os comandos da política criminal, baseados nos conhecimentos da criminologia, não mais poderão almejar uma consideração directa e imediata por parte do jurista, não mais poderão aspirar a influenciar de uma maneira qualquer os problemas prático-normativos da aplicação do direito penal; em suma, não mais poderão gozar de uma consideração *dogmática* no seio do sistema jurídico-penal.

§ 13 Tudo isto com uma consequência fundamental e funesta: se e quando as proposições político-criminais se dirigirem em um sentido diferente daquele que o jurista considere ser legalmente imposto, a solução do

diferendo, relativamente a um qualquer caso jurídico-penal concreto, não poderá ser senão a de *abandonar as conclusões reputadas mais correctas do ponto de vista político-criminal* — que terão forçosamente de esperar sempre por uma reforma ou uma alteração da lei para se impor —, em favor daquelas que mais facilmente permitam uma redução conceitual e uma integração sem entraves no sistema jurídico-penal. Até porque o jurista dirá que, de outra maneira, sofreriam inapelavelmente os direitos e as liberdades das pessoas, que só o sistema jurídico e, de uma forma muito particular, a Constituição — não directamente o conhecimento do sistema social e do seu funcionamento — podem garantir com justiça e eficácia. Nesta "guerra" de posições e de trincheiras, serão pois os comandos político-criminais que terão de se adaptar ou de ceder, no plano da aplicação do direito, às exigências dogmáticas do direito penal e de se limitar a jogar no campo que por estas lhes seja rigorosamente definido. E eis como afinal, apesar de toda a modificação de concepções fundamentais, a política criminal não deixava, na perspectiva do jurista, de ser uma **ciência auxiliar somente competente para a reforma penal**. Continuando por conseguinte, neste plano, a valer ilimitadamente o aforismo de von Liszt do direito penal como barreira intransponível da política criminal.

III. O estatuto das ciências criminais no quadro do Estado de Direito contemporâneo e de um sistema jurídico-penal teleológico-funcional e racional

§ 14 A evolução do estatuto da política criminal perante a dogmática jurídico-penal e a criminologia em direcção a um novo estádio foi cumprida quando as concepções próprias do Estado de Direito formal, de natureza liberal e individualista, e do Estado social, mais preocupado com o funcionamento do sistema social do que com o império da regra de direito, cederam o lugar à concepção que, de forma compreensiva, será referida aqui como a do **Estado de Direito material** contemporâneo ([17]). Sob esta designação quer-se compreender todo o Estado democrático e social que mantém intocada a sua ligação ao direito, e mesmo a um esquema rígido de legalidade, e se preocupa por isso antes de tudo com a consistência dos direitos, das liberdades e das garantias da pessoa; mas que, por essa

([17]) Sobre o conceito, de novo, DIAS, Figueiredo, nota 13; cf., depois, FRANCO, Alberto Silva, *in*: Franco / Stocco (orgs.), I-I, p. 29 e ss.

razão mesma, se deixa mover, dentro daquele esquema, por considerações de justiça na promoção e na realização de todas as condições — políticas, sociais, culturais, económicas — do desenvolvimento mais livre possível da personalidade ética de cada um. Não se trata pois tanto aqui de tomar qualquer posição na moderna controvérsia acerca da subsistência do Estado-providência ou do regresso a um Estado-liberal, quanto de caracterizar o Estado, fundamentalmente e na sua acepção social mais lata, como um *Estado de Justiça*.

1. Dogmática jurídico-penal e política criminal

1.1. A transformação da função da dogmática jurídico-penal

§ 15 No contexto deste Estado de Direito material a função e a tarefa da **dogmática jurídico-penal** transformam-se profundamente. O jurista deixa de ser considerado um simples fazedor de silogismos, que se limita a deduzir do texto da lei as soluções dos concretos problemas jurídicos da vida, para se tornar em alguém sobre quem recai a indeclinável responsabilidade de procurar e encontrar — se bem que de modo jurídico-formalmente válido — a solução *mais justa* para cada um daqueles problemas. Deste modo, a *questão metodológica* volta a adquirir particular ressonância, nomeadamente quanto a saber — dizendo-o através de uma fórmula aproximativa, mas que ganhou foros de cidadania na mais recente metodologia — até onde o **pensamento do problema** se pode introduzir no (ou mesmo se sobrepor ao) **pensamento do sistema**, em geral dominante na dogmática jurídico-penal.

§ 16 Uma das vertentes da questão respeita à decisão sobre se a dogmática jurídico-penal deve apresentar cunho estritamente **normativo** ou se, pelo contrário, deve considerar-se pré-determinada pela **estrutura ontológica** — melhor se diria, *ôntica* ou *lógico-material* — dos conceitos que utiliza (como foi suposto básico da doutrina da acção final: infra, 10.º Cap., §§ 16, 20). Na resposta a esta pergunta continua ainda hoje válida uma consideração diferenciada ([18]). A **matéria** de regulamentação

([18]) Cf. ROXIN, *Täterschaft*, p. 20, ENGISCH, *Wahrheit und Richtigkeit im juristischen Denken*, 1963, p. 20, e DIAS, Figueiredo, Sobre o estado actual da doutrina do crime, *RPCC 1*, 1991, p. 12 e ss., e antes, já, *O Problema*, § 1. É interessante anotar como a questão — há algum

jurídica e de consideração dogmática não retira o seu conteúdo de sentido da valoração do legislador ou do aplicador, antes é "previamente dada" através de princípios e estruturas de desenvolvimento ônticos, através da "natureza da coisa". Mas com o reconhecer isto não fica resolvido o *problema* jurídico: importará sempre ainda escolher, de entre os diversos sentidos de juridicidade que os dados apriorísticos permitem, através de uma *valoração autónoma*, aquele que deve constituir o fundamento da regulamentação ou da resolução do concreto problema jurídico-penal em causa. Assim se erige a autonomia da valoração dogmática jurídico-penal — pelo menos uma autonomia relativa, dentro das possibilidades que lhe são oferecidas pela pré-determinação não jurídica do substrato — em momento essencial do pensamento jurídico-penal. Quando porém, em seguida, se afronta a questão do **critério de valoração**, não é suficiente dizer que o legislador o escolhe em inteira liberdade e que o intérprete só terá de o ir buscar à lei. A solução terá antes de se alcançar por uma via apontada para a "descoberta" (*hoc sensu*, a "criação") de uma solução *justa* do caso concreto e simultaneamente adequada ao (ou comportável pelo) sistema jurídico-penal. O que supõe a "penetração axiológica" do problema jurídico-penal, a qual, no âmbito da dogmática, tem de ser feita por apelo ou com referência teleológica a finalidades valorativas e ordenadoras de natureza político-criminal, numa palavra, a **valorações político-criminais imanentes ao sistema**.

§ 17 Por esta via se rejeita o puro dedutivismo conceitualista (típico de uma "jurisprudência dos conceitos", ainda que "teleológica") que infelizmente se não pode dizer de todo ultrapassado na dogmática jurídico-penal. Mas por igual se rejeita a legitimidade para, a partir de estruturas ônticas ou lógico-materiais pré-jurídicas, extrair delas, por necessidade, a solução de problemas jurídico-penais práticos. Também nas questões de que trata a dogmática jurídico-penal a atenção prioritária deve ser concedida ([19]) a

---

tempo como que "adormecida" — volta de novo a agitar-se: SCHÜNEMANN, Strafrechtsdogmatik als Wissenschaft, e MORENO Hernández, Über die Verknüpfgung von Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik (Ontologismus versus Normativismus?), ambos *in*: *Roxin-FS*, 2001, pp. 1 e 69; e como SCHÜNEMANN (*ibidem*, pp. 23 e ss., 32), num sentido que julgamos próximo ao do texto, se pronuncia por uma "síntese necessária" no sentido de um "normativismo racional-final". Sobre este concreto entendimento, por último, MIR Puig, Grenzen des Normativismus im Strafrecht, *in*: Hefendehl (org.), *Empirische und dogmatische Fundamente, kriminalpolitischer Impetus, Schünemann-Symposium*, 2005, p. 77.

([19]) Como, de resto, foi afirmado porventura pela primeira vez, de forma sistemática, pela chamada *jurisprudência dos interesses* que, embora ainda numa lógica positivista, manda aten-

considerações de concreta justiça material (e nesta acepção ao **pensamento do problema**) no seio do sistema político-criminalmente dirigido, não a ilações retiradas dos dados pré-jurídicos ou do sistema formal-legal. Também relativamente àquelas questões a função primordial da dogmática haverá de consistir em — partindo de uma *casuística* tão larga mas escolhida quanto possível ([20]) — estabelecer a formulação de critérios de valor teleológico-funcionalmente orientados, os quais não serão, no fim de contas, coisa substancialmente diversa de "princípios" ou "tópicos" ([21]) servidores do discurso, da argumentação e do consenso.

§ 18 Torna-se previsível a objecção ([22]) de que o conteúdo de sentido do princípio da legalidade jurídico-penal (*nullum crimen, nulla pœna sine lege*) haverá de conduzir à recusa, ao menos em extensas zonas da dogmática jurídico-penal, do essencial do pensamento problemático, de características tópicas e argumentativas; quando não obrigue mesmo à aceitação de uma metodologia conceitualista e subsuntiva, para a qual a lei formal constituiria em todos os casos não só o limite, mas o próprio fundamento. Uma tal objecção, porém, não logra prevalecer. Há de facto na dogmática jurídico-penal, para efeitos de fundamentação ou de agravação da responsabilidade, um momento "inicial" de mera subsunção formal, em que o princípio da legalidade (aliás, ele mesmo, político-criminalmente fundado e participante, por aí, da específica teleologia do sistema!) impõe que *o texto da lei* constitua um limite absoluto de toda a tarefa da aplicação, por só deste modo poder cumprir a função de garantia que lhe cabe nos quadros do Estado de Direito. Para além deste momento, contudo — correspondente à subsunção do comportamento no *tipo de garantia* ou *tipo legal de crime* que o princípio da legalidade jurídico-constitucionalmente postula —, a dogmática do direito penal não se encontra submetida a qualquer outra exigência formal-subsuntiva e deve ser integrada completamente na orientação metodológica aqui sugerida ([23]).

---

der à causa da lei, à valoração que a informa, aos interesses e valores que estão por detrás dela e impõe a sua leitura a esta luz: HECK, Gesetzauslegung und Interesenjurisprudenz, *Archiv für civilisische Praxis 112*, 1914, p. 1 e ss., ANDRADE, Manuel de, *Ensaio sobre a Teoria da Interpretação das Leis*, 1933, NEVES, Castanheira, v. "Interpretação", *Enciclopédia Polis*, III, p. 659 e ss.

([20]) ENGISCH, *Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit*, 1953, e HASSEMER, *Tatbestand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik*, 1968.

([21]) Respectivamente, ESSER, *Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts*, 1956, e VIEHWEG, *Topik und Jurisprudenz*, ²1963.

([22]) Concluindo de forma próxima à do texto, se bem que com ela não de todo coincidente, ROXIN I, § 7, n.º 70.

([23]) Completamente neste sentido cf. agora FARIA, Paula Ribeiro de, *A Adequação Social da Conduta no Direito Penal ou o Valor dos Sentidos Sociais na Interpretação da Lei Penal*, 2005, pp. 720, 1132 e s.

§ 19 O lugar cimeiro que assim se concede ao "pensamento do problema" na dogmática jurídico-penal não significa porém negligenciar ou sequer minimizar o papel irrecusável que nela continua a pertencer ao **pensamento do sistema**. Como bem diz Claus Roxin, "o sistema é um elemento irrenunciável do direito penal de um Estado de Direito" ([24]). O trabalho com os "casos" jurídico-penais seria sem ele irrealizável. E não só por razões ligadas à *segurança* na aplicação do direito, aliás particularmente imposta tanto pela ordem de legitimação, como pela própria teleologia da intervenção penal; mas porque fora do sistema ou independentemente dele não haveria nunca garantia de ser encontrada a solução *justa* e *adequada* para um caso jurídico-penal. Por isso o pensamento do problema tem, no âmbito de que se trata, de *coexistir* forçosamente com o pensamento do sistema. Sendo impossível explicitar pormenorizadamente aqui a forma como uma tal coexistência deve ser entendida, temos de bastar-nos com assinalar a sua possibilidade e a via pela qual pode ser alcançada a (indispensável) **interpenetração** ou **integração**.

§ 20 O sistema jurídico-penal — constituindo embora um subsistema do sistema jurídico como um todo, o qual constitui por sua vez um subsistema do sistema social — possui de todo o modo a sua *teleologia* própria, a sua específica índole *funcional* e a sua *racionalidade* estratégica; bem podendo afirmar-se que ele é, nesta acepção e nesta medida, mais que um sistema autónomo, um *sistema autopoiético* ([25]). Esta confissão a favor de um sistema teleológico-funcional e teleológico-racional da dogmática jurídico-penal não significa porém a recusa da intervenção de considerações axiológicas, de pontos de vista de valor, de critérios de validade e de intencionalidade normativas na dogmática, nem, muito menos, o pronunciamento a favor de argumentos de pura "engenharia social" ([26]). Os desenvolvimentos mais recentes e significativos da dogmática jurídico-penal e dos seus pressupostos fundamentais revelam que uma tal oposição não é necessária e que, em vez dela, o que entre aquelas concepções deve

---

([24]) ROXIN I, § 7, n.º 50. Fundamental, ENGISCH, Sinn und Tragweite juristischer Systematik, *Studium Generale*, 1957, p. 173.

([25]) Na acepção de TEUBNER, *Recht als autopoietisches System* (tradução portuguesa de Engrácia Antunes: *O Direito como Sistema Autopoiético*, 1993), 1989. Cf., também, ANDRADE, Costa, *Consentimento e Acordo em Direito Penal*, 1990, p. 110 e ss.

([26]) Sobre esta oposição, NEVES, Castanheira, O actual problema metodológico da realização do Direito, *Estudos Ferrer Correia*, III, 1990, p. 11.

interceder é uma relação dialéctica capaz de conduzir, no fim, a uma **unidade axiológico-funcional**.

§ 21 Assim, *por exemplo*, a **legitimação da intervenção penal** não pode hoje ser vista como unicamente advinda de qualquer ordem transcendente e absoluta de valores, mas tem de ser coada por critérios funcionais de *necessidade* (e de consequente *utilidade*) *social*. Daí também que a pena não mais possa fundar-se em exigências de retribuição ou expiação da culpa, mas apenas em propósitos de prevenção (nomeadamente de *integração positiva*), geral e especial (infra, 4.º Cap.). O que por sua vez conduz a uma directa ligação desta via de legitimação à questão da função do direito penal, que agora não pode ser vista na defesa, promoção ou realização de uma qualquer ordem moral, mas na tutela subsidiária de bens jurídicos, necessariamente referida à ordem axiológica constitucional (infra, 6.º Cap.). Ora estes pontos de vista, que se poderia ser tentado a desqualificar como relevando da pura tecnologia ou engenharia social — de todo o modo, de um *approach sistémico-funcional* —, são os primeiros responsáveis pelos *ganhos axiológicos do sistema jurídico-penal* mais significativos das últimas décadas; ao mesmo tempo que têm contribuído da forma mais decisiva para um tratamento *justo* e *adequado* dos casos jurídico-penais.

§ 22 Para definição de um sistema teleológico-funcional e racional da dogmática jurídico-penal é, como já ficou sugerido, decisivo o estabelecimento das **finalidades político-criminais primárias do sistema**. Neste contexto podem eleger-se ([27]) cinco princípios básicos: o princípio da legalidade, o da referência jurídico-constitucional da ordem legal dos bens jurídicos, o da culpa, o da socialidade e o da preferência pelas sanções criminais não detentivas face às detentivas. Ora, é difícil excogitar princípios mais claramente do que estes determinados finalisticamente, segundo um programa de utilidade e de estratégia sociais. E no entanto este mesmo programa, se condiciona hoje, como se disse, toda a dogmática jurídico-penal (devendo os conceitos integrantes ser, todos eles, teleológico-funcionalmente determinados a partir dele), radica por outro lado em claras ideias axiológicas, critérios de valor e intencionalidades normativas. O que se passa com o conceito de *culpa* é disto mesmo prova evidente: é justamente a legitimação da intervenção penal através da função de tutela dos bens jurídicos que conduz a eliminar a compensação da culpa (ou "retribuição") do âmbito das finalidades da pena. Mas é por sua vez esta eliminação — e a correspondente função de *limite* da intervenção penal que à culpa se assinala — que permite dissociar o conceito jurídico-penal de culpa das querelas irresolúveis sobre o livre-arbítrio e do (pernicioso e político-criminalmente insustentável) dogma da "culpa da vontade", para o ancorar na exigência (absoluta! e eticamente relevante) de respeito pela dignidade da pessoa

([27]) DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 52 e ss.; de forma próxima, ANDRADE, Costa, *Código Penal* (Quid Iuris), Nota introdutória, [3]1998, p. 31 e ss. E preconizando — em nosso modo de ver com inteira razão — que os quatro primeiros princípios mencionados no texto sejam arvorados em princípios do direito penal europeu, COSTA, A. M. Almeida, Alguns princípios para um direito e um processo penais europeus, *RPCC 4*, 1994, p. 202.

humana (infra, 4.º Cap.). Ideia esta a menos pragmática e tecnológica e, pelo contrário, a mais terminantemente axiológica e normativa de todo o sistema jurídico de um Estado de Direito; mas que por isso mesmo pode, de uma certa perspectiva, revelar-se "disfuncional" ou "irritativa" do próprio sistema ([28]), sendo aí que reside a sua precípua função.

§ 23 Ficam assim apontadas as coordenadas essenciais da assunção de uma atitude metodológica correcta no trabalho sobre a dogmática jurídico-penal. Do que nela se trata é, em último termo, de encontrar **soluções justas e adequadas para concretos problemas** da vida de relação comunitária. Esta tarefa não pode porém ser cumprida com êxito apelando directamente para objectividades ou intencionalidades ínsitas na Ideia de Direito, ou mesmo para puros princípios ou considerações de valor fundados em uma qualquer axiologia pressuposta. Pois assim se tornaria a solução do caso e o alcance da almejada "justiça material" função de um puro *jogo de lotaria* ([29]), individual e comunitariamente insuportável e que representaria o retrocesso de mais de um século na evolução da dogmática jurídico-penal. Antes o caso concreto tem de ser projectado no contexto do sistema teleológico-funcional e racional do direito penal, aí tratado e — ao menos de forma provisória — resolvido. Não fica com isto de todo excluída a possibilidade (ainda que rara) de a solução encontrada se revelar injusta ou disfuncional à luz da própria teleologia político-criminal imanente ao sistema. Nesta hipótese, a "justiça do caso" deve em definitivo sobrepor-se a considerações puramente sistemáticas; mas deve também conduzir então ao reexame ou ao reajustamento do significado meramente operacional e coadjuvante dos conceitos para a aplicação do direito. Assim se revela verdadeiramente o sistema jurídico-penal, antes que "cerrado", um **sistema aberto** ([30]): um sistema que em cada dia se vai refazendo porque em cada dia a dogmática vai sendo confrontada com novos problemas; ou com problemas velhos mas que, à luz de uma nova ou mais perfeita compreensão da teleologia, da funcionalidade e da racionalidade do sistema, reclamam novas soluções.

([28]) Sobre a ideia da "irritação" dos sistemas, LUHMANN, *Soziale Systeme*, 1984, pp. 26 e ss. e 244 e ss.

([29]) De que falou GIMBERNAT Ordeig, *Problemas actuales de derecho penal y processal*, 1971, p. 93.

([30]) Assim, o nosso *O Problema*, § 1, III. Cf. PALMA, Fernanda, Do ensino histórico do ensino do Direito Penal na Universidade Portuguesa à actual questão metodológica, *RPCC 9*, 1999, p. 432 e ss. E por último, de forma muito próxima, ROXIN I, § 7, n.º 58.

§ 24 Em conclusão, continua ainda hoje válida a asserção segundo a qual também na dogmática jurídico-penal é da problematicidade própria de cada "**caso**" que tem de partir-se para a determinação da totalidade normativa, sistematicamente enquadrada ou enquadrável. Foi von Savigny quem ensinou ser tarefa da dogmática jurídica "estabelecer os princípios que subjazem a um direito positivo e explicitá-los sistematicamente". Mas foi ele também quem afirmou que "cada caso deve ser tomado como se fosse o ponto de partida de toda a ciência, a qual deveria ser forjada a partir dele" ([31]). Não existe aqui qualquer dissonância ou contradição: a dialéctica já assinalada entre "sistema" e "problema" deve valer completamente para a dogmática jurídico-penal.

1.2. A posição de domínio e transcendência da política criminal

§ 25 Foi precisamente o alargamento, que acaba de referir-se, da função da dogmática jurídico-penal que permitiu à política criminal não somente reforçar a sua posição, já adquirida, de *autonomia*, mas ganhar uma posição de **domínio** e mesmo de **transcendência** face à própria dogmática ([32]). Daquele alargamento resultam, com efeito, algumas consequências fundamentais que servirão para uma caracterização mais exacta do novo estatuto da política criminal no contexto de uma renovada ciência conjunta do direito penal.

§ 26 A primeira consequência ([33]) é a de que as categorias e os conceitos básicos da dogmática jurídico-penal devem agora ser não simplesmente "penetrados" ou "influenciados" por considerações político-criminais: eles devem ser **determinados** e **cunhados** a partir de proposições político-

([31]) V. SAVIGNY, *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 1914, p. 30.

([32]) De forma extrema, agora, HASSEMER, Das Symbolische am symbolischen Strafrecht, *Roxin-FS*, 2001, p. 1002: "o direito penal é uma parte da política criminal". Cf. sobre o tema os esclarecedores estudos de SILVA SÁNCHEZ, Retos científicos e retos políticos de la Ciencia del Derecho Penal, e de MILITELLO, Dogmatica penal y politica criminal desde una perspectiva europea, ambos *in*: Arroyo Zapatero / Neumann / Nieto Martín (orgs.), nota 2, pp. 25 e ss. e 41 e ss.

([33]) Foi mérito de ROXIN, *Kriminalpolitik*, p. 25 e ss. e *passim*, ter posto em evidência esta dimensão e tê-la feito frutificar dogmaticamente; por último, dando conta da evolução a respeito, ROXIN I, § 7, n.ºs 26 e ss., 75 e ss. Em Itália BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politica criminale, *RitalDPP*, 1988, p. 3 e ss., e Teoria generale del reato, *Nov. Dig. it. XIX*, 1973, p. 7 e ss.

-criminais e da função que por estas lhes é assinalada no sistema. Quando, para dar um só exemplo, a dogmática jurídico-penal estuda os conceitos integrantes da noção de facto punível — a acção, a tipicidade, a ilicitude, a culpa, a punibilidade —, não os deve ela tomar em si e por si mesmos, ou fazê-los derivar, como todavia é ainda frequente, de considerações lógicas, filosóficas ou mesmo metafísicas. Ela deve sim construí-los como unidades funcionalizadas à consecução dos propósitos, das finalidades, do *thelos* político-criminal que o sistema jurídico-penal lhes assinala.

§ 27 A partir daqui se compreende a segunda consequência. A política criminal, de ciência simplesmente competente para as tarefas da reforma penal, cujas proposições, por conseguinte, não podiam ser levadas em conta pelo jurista senão no plano *de iure constituendo*, torna-se em ciência competente para, em último termo, **definir os limites da punibilidade**. Na medida em que a política criminal quer atingir as finalidades que a si mesma se comete *através* do direito penal, ela terá de o fazer respeitando os princípios estruturais deste direito: o direito penal constitui nesta acepção — na expressão paradigmática de Claus Roxin — "a forma por intermédio da qual as proposições de fins político-criminais se vazam no *modus* da validade jurídica" (34). Mas por isso mesmo não mais tem sentido a manutenção da aparelhagem conceitual dogmático-sistemática quando ela não seja tratada em termos tais que funcionalmente se adequem às exigências político-criminais, tal como hoje se fazem sentir, em autonomia plena. Parafraseando uma afirmação antecipadora de Kohlrausch, dir-se-á que uma ciência jurídico-penal que nada tenha a oferecer às necessidades correctamente entendidas da política criminal não só se torna em peça decorativa inútil, como é falsa (35). A esta luz, numa palavra, todas as categorias e todos os conceitos da dogmática jurídico-penal devem apresentar-se funcionalmente determinados pelas (e ligados às) finalidades eleitas pela política criminal. Logo nesta vertente se devendo afirmar a existência de uma *unidade funcional* entre a política criminal e a dogmática jurídico-penal.

§ 28 As duas consequências acabadas de alinhar permitem uma inferência à qual, em face do seu relevo fundamental, se poderá conferir auto-

(34) ROXIN, *Kriminalpolitik*, p. 77.

(35) KOHLRAUSCH, *Sollen und Können als Grundlagen des strafrechtlichen Zurechnung*, 1910, p. 7.

nomia. Se o aparelho conceitual da dogmática jurídico-penal deve ser determinado a partir de proposições político criminais; e se desta forma, mas por outro lado, é à política criminal que pertence definir as fronteiras da punibilidade — então, sem por isso perder a sua intenção especificamente (e dir-se-á mesmo: autenticamente) jurídica, a política criminal surge como uma ciência *transpositiva, transdogmática e trans-sistemática* face a um qualquer direito penal positivo. A sua função última consiste em servir de **padrão crítico** tanto do direito constituído, como do direito constituendo, dos seus limites e da sua legitimação. Neste sentido se deverá compreender a afirmação de que a política criminal oferece o critério decisivo de determinação dos limites da punibilidade e constitui, deste modo, a pedra angular de todo o *discurso legal-social da criminalização / descriminalização* ([36]). E todavia, apesar da predominância que assim se atribui à política criminal no contexto da ciência conjunta do direito penal, ela haverá em todo o caso de se condicionar estritamente pelos fundamentos jurídico-políticos da concepção do Estado ([37]). Se a política criminal (poderá também dizer-se assim) é, como acaba de ver-se, extra-sistemática relativamente ao direito penal, ela é todavia *intra-sistemática relativamente à concepção do Estado*, quer dizer, ela é **imanente ao sistema jurídico-constitucional**. A esta luz surgirá especialmente justificada a afirmação anterior de que não é exacto que a política criminal possa e deva fazer apelo directo e imediato ao sistema social como tal para estabelecimento das suas finalidades e das suas proposições. Exacto é antes que as finalidades e as proposições político-criminais devem, elas também, ser procuradas e estabelecidas no interior do quadro de valores e de interesses que integram o consenso comunitário mediado e positivado pela Constituição. Apenas desta maneira poderá de resto a política criminal, como deve, conceder uma importância primária à protecção dos direitos, das liberdades e das garantias de *toda e qualquer pessoa*, incluído o delinquente mais empedernido.

§ 29 Muito recentemente veio Jakobs repudiar esta proposição fundamental. Pretendendo — com pelo menos duvidosa razão ([38]) — louvar-se

([36]) Assim, já, DIAS, Figueiredo, Lei criminal e controlo da criminalidade. O problema legal-social de criminalização e de descriminalização, *ROA* 36, 1976, p. 69.

([37]) BRICOLA, *RitalDPP*, nota 33.

([38]) Como acentua CAEIRO, Pedro, "Direito penal do inimigo", em vias de publicação na *RPCC*. Cf., também, RODRIGUES, Anabela, Política Criminal — Novos desafios, velhos rumos, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 210 e ss.

num pensamento de Kant ([39]), sustenta ele que o direito penal do cidadão, aplicável a todos os que pertencem a uma "comunidade legal", *não deve valer* para aqueles que se recusam a participar nela, tentando obter a aniquilação dessa comunidade (os "terroristas") ou violando repetida e persistentemente as normas que os regem (os "delinquentes por tendência perigosos"). Assim, nas palavras do A., "o **direito penal do cidadão** é o direito de todos, o **direito penal do inimigo** o daqueles que se unem contra o inimigo; face ao inimigo há apenas coacção física, até chegar à guerra" ([40]).

§ 30 Esta concepção é de todo em todo **inadmissível**, logo por poder descambar em um "direito penal do agente" (cf. infra, 10.º Cap., §§ 1 e 3) sob as formas mais agressivas que assumiu no Estado nacional-socialista alemão, mas, sobretudo e em definitivo, por contrária ao fundamento primário do Estado de direito ([41]) e à concepção de **pessoa** que lhe dá fundamento. Na afirmação de Eser, "que os inimigos não sejam tidos 'como pessoas', é uma consideração que já conduziu muitas vezes à negação do Estado de Direito" ([42]). Ou nas palavras paradigmáticas de Pedro Caeiro: "Ao sustentar que o inimigo não deve ser tratado como pessoa, Jakobs normativiza por completo aquele que é o arrimo último do Estado de Direito: a pessoa deixa de ser *substantiva*, dotada de realidade própria por força do nascimento, para passar a ser um *atributo eventual*, algo de semelhante à *persona* romana e ao *subjectum* medieval — pessoa é, então, não a pessoa humana, mas 'aquilo que se predica de cada indivíduo na cidade'. Ora, foi precisamente este discurso que legitimou a escravatura e o holocausto. E é, evidentemente, uma ruptura civilizacional intolerável" ([43]).

([39]) Zum ewigen Frieden, *Werke* (ed. Weischedel), IX, p. 195.

([40]) JAKOBS, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, *in*: Jakobs / Cancio Meliá, *Derecho Penal del enemigo*, 2003, p. 19 e ss. (existe agora edição em português, tradução de Callegari e Giacomelli, 2005); de novo, por último, JAKOBS, Terroristen als Personen im Recht, *ZStW 117*, 2005, p. 839. Cf. agora, para uma análise de todas as perspectivas relevantes para o problema, a obra monumental dirigida por Cancio Meliá / Gómez-Jara Díez, *Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión* (orgs.), 2006.

([41]) Assim, CANCIO MELIÁ, *in*: Jakobs / Cancio Meliá, nota 40, CAEIRO, Pedro, nota 38; ROXIN I, § 2, n.º 126 e ss., e ALBRECHT, P., Krieg gegen der Terror — Konsequenzen für eine rechtsstaatlicher Strafrecht, *ZStW 117*, 2005, p. 853.

([42]) ESER, Consideraciones finales, *in*: Eser / Hassemer / Burkhardt, *La ciencia del Derecho penal ante el nuevo milenio*, 2004, pp. 467 e 472.

([43]) CAEIRO, Pedro, nota 38. Cf., por último, MUÑOZ CONDE, De nuevo sobre el derecho penal del enemigo, *Revista Penal 16*, 2005, p. 61.

§ 31 Silva Sánchez faz agora notar que os binómios "inimigo / cidadão" e "não-pessoa / pessoa" se não confundem necessariamente. É, diz, "em teoria possível a sua combinação, dando lugar a um 'direito penal dos cidadãos para pessoas' e a um 'direito (penal) dos cidadãos para não pessoas'; e a um 'direito (penal) de inimigos para pessoas, assim como a um direito (penal) de inimigos para não pessoas". Absolutamente inadmissível seria só a recusa de protecção penal ao "**excluído**" — tido como "não pessoa", caso do feto face a uma interrupção voluntária da gravidez que seja legalmente considerada como não punível —, não necessariamente ao "inimigo" — os inimputáveis ou os imputáveis especialmente perigosos (máxime, terroristas) — que "não é considerado, realmente, em termos absolutos, 'não pessoa para o Direito" ([44]).

§ 32 Estamos certos de que, mesmo com esta precisão e distinção, um "direito penal do inimigo" continua a ser democrativamente inaceitável. **Também o inimputável ou o imputável especialmente perigoso têm de gozar, na íntegra, dos direitos e da protecção que lhe são devidos em nome da sua eminente dignidade como pessoas**. Ou uma tal protecção lhe é integralmente assegurada e o apelo a um direito penal do inimigo não só é inútil como, sobretudo, equívoco e insuportavelmente perigoso; ou lhe não é integralmente assegurada e aquele apelo mal serve de capa à violação mais ilegítima do primeiro mandamento do Estado de Direito. O que (segundo a informação disponível, recentemente confirmada por uma decisão da *Supreme Court* norte-americana ([45])) se passa hoje em Guantanamo constitui a este propósito um caso exemplar que deveria ser meditado.

13. Conclusão

§ 33 À concepção que defendemos neste capítulo pode ser assinalado o perigo de diluir as fronteiras entre a dogmática jurídico-penal e a polí-

([44]) Silva Sánchez, Os indesejados como inimigos: a exclusão de seres humanos do *status personæ*, *RPCC 16*, 2006, p. 7.

([45]) Referimo-nos ao caso *Hamdan v. Rumsfeld*, julgado a 29-06-2006. A *Supreme Court*, decidindo contra a pretensão da administração norte-americana, reconheceu competência aos tribunais norte-americanos para apreciarem as queixas de detenção ilegal invocada por prisioneiros de *Guantanamo Bay*. A decisão está disponível em www.supremecourtus.gov. Cf., por último, a propósito, além de Muñoz Conde, nota 43, Fletcher, Cuidadanos o personas? Análise de las sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos en los casos Hamdan, Padilla y las prisiones de Guantánamo, *Revista Penal 16*, 2005, p. 61.

tica criminal ([46]). Mas não é esse nem o seu propósito, nem o entendimento que se lhe deve conferir. Assinalar à política criminal competência para definir os limites últimos da punibilidade não significa depreciar a dogmática, como bem assinala Eduard Dreher, como mero "estômago da política criminal" ([47]). Por outra parte, defender que todas as categorias e conceitos dogmáticos devem ser determinados a partir de proposições político-criminais tão-pouco significa ceder à tentação de construir uma "*unidade sistemática* entre política criminal e direito penal" ([48]). A concepção aqui exposta quer significar, simples e precisamente, que a extensão, o sentido e a aplicação do direito penal ficam em última análise dependentes da *teleologia*, das *valorações* e das *proposições político-criminais inerentes ao sistema*. Nesta acepção se pode concluir que o problema, tal como deve ser hoje solucionado, das relações entre política criminal e dogmática jurídico-penal não é, como muito certeiramente assinalou Zipf, o da introdução de um âmbito no outro, mas uma questão de *optimização da colaboração entre ambos* ([49]); e que por isso, melhor do que de uma unidade sistemática será falar de uma **unidade cooperativa** ou de uma **unidade funcional** entre as duas disciplinas.

2. Dogmática jurídico-penal e criminologia

§ 34 A forma como se estabeleceu o estatuto da política criminal face à dogmática jurídico-penal acaba por fornecer, do mesmo passo, a chave da compreensão das relações que devem interceder entre esta última e a criminologia. Desde logo, somente uma política criminal concebida nos termos expostos pode — no contexto de uma ciência conjunta do direito penal — desempenhar a função de **intermediária** entre a criminologia e a dogmática jurídico-penal, tal como estas devem ser compreendidas no momento presente. Pelo contrário, um relacionamento *imediato* da criminologia com a dogmática jurídico-penal desde sempre se revelou não só problemático, como pouco útil, nessa dificuldade residindo a razão do divórcio — que até aos anos 60 do séc. XX se revelou praticamente

([46]) Crítica que poderia porventura dirigir-se à posição de ROXIN, *Kriminalpolitik*, *Nachtrag* da 2.ª ed.

([47]) DREHER, *Schröder-GS*, 1978, p. 366.

([48]) Como queria ROXIN, *Kriminalpolitik*, p. 9. De "impossível identificação" fala agora também MILITELLO, nota 32, p. 47 e ss.

([49]) M / ZIPF, 1, § 3, n.º 24.

total — entre as duas ciências. Desde o momento, porém, em que se quebrou a "assepsia" científica e metódica em que durante décadas viveu a ciência criminológica e em que pôde reconhecer-se que esta devia transformar-se, de ciência puramente explicativa, em ciência **crítica**, também ela passou a deixar-se penetrar por supostos básicos e, em definitivo, por valorações jurídico-criminais. O que, por um lado, determinou um sensível alargamento do seu objecto, que, do crime (e eventualmente também da personalidade criminosa), na sua vertente puramente etiológica (ou causal), passou a ser *o inteiro sistema da justiça penal*; e assim permitiu, por outro lado, a sua inclusão, sem contradições, em uma ciência conjunta do direito penal por via do entreposto constituído pela política criminal ([50]).

§ 35 Com efeito, a criminologia nasceu por inteiro subordinada ao **paradigma monista e reducionista das ciências da natureza** e, por conseguinte, na veste de uma ciência puramente empírica, causal e explicativa. Neste estádio de evolução o relacionamento da criminologia com a dogmática jurídico-penal revelava-se tarefa impossível. Mesmo que esta dogmática surgisse também, como surgia, subordinada a um modelo quanto possível naturalístico e a uma metodologia positivista, não era viável lançar sobre o mesmo denominador comum uma ciência (em todo o caso irremediavelmente) *normativa*, como a dogmática, e uma outra que se pretendia completamente sujeita ao monismo próprio das ciências empíricas. Isto mesmo fez com que toda esta criminologia, fosse ela de base endógena (de que constituía paradigma a chamada "criminologia clínica") ou exógena (a criminologia chamada "sociológica"), se tivesse divorciado progressivamente da ciência jurídico-penal. O que se justificaria porque era irremediavelmente diverso quer o seu *objecto*, constituído não pelo "crime", mas por todo o comportamento (socialmente) "desviante"; quer o seu *método*, que iria buscar-se seja às diversas disciplinas científicas integrantes (a biologia, a psicologia, a psiquiatria, a sociologia, a medicina...), seja a uma ideia de interdisciplinaridade ou mesmo de integração, que todavia não podia esconder o fosso que a separava de uma consideração jurídico-normativa; quer consequentemente as *técnicas de investigação*.

§ 36 A situação não se alterou de um modo significativo mesmo quando a criminologia se tornou, de forma dominante ou mesmo exclusiva, em uma **criminologia sociológica**. Também esta mantém o dogma da sua pureza ou neutralidade perante quaisquer juízos de valor axiológicos, práticos ou de oportunidade política. Tal lhe seria imposto pelos cânones epistemológicos vigentes na época e que se reconduziam, em última instância, ao modelo aristotélico de uma separação irredutível entre a *ciência*, enquanto *epistheme* ou saber apodíctico, e a *phronesis* ou saber pragmático. Deste ponto de vista podia ainda Max Weber falar da "absoluta heterogeneidade entre o problema

([50]) Sobre todo este ponto, DIAS / ANDRADE, pp. 41 e ss., 63 e ss., 96 e ss. Cf., também, BELEZA, Teresa, I, p. 251 e ss.

científico e o problema político" ([51]). É verdade que, neste momento da evolução, o paradigma monista e reducionista da criminologia, que a colocava ao mesmo nível de qualquer outra ciência da natureza, se encontrava ultrapassado. Era reconhecido já então que a criminologia se situava entre as ciências sociais e humanas e que por essa razão não podia renunciar a referências inevitáveis a sentidos e a valores. E todavia, continuava a considerar-se que este relacionamento com os valores e os sentidos não devia, em todo o caso, turvar a objectividade e a cientificidade das ciências sociais e, portanto, também da criminologia, que persistiam como *ciências da realidade*, isentas de quaisquer tomadas de posição valorativas e políticas. Foi justamente neste enquadramento que se alcançou a ideia de uma separação total entre a criminologia, enquanto "ciência", e a política criminal, enquanto forma de utilização pragmática e política dos "dados" criminológicos.

§ 37 A situação mudou radicalmente com o aparecimento da chamada "**criminologia dos anos 60**" (do séc. XX) e as suas principais manifestações, a saber, o interaccionismo (ou *labeling approach*), a etnometodologia e a criminologia dita "radical", de inspiração marxista. O que em todas estas direcções existe de novo — e foi mérito indiscutível do *labeling approach* tê-lo posto em relevo — é a consciência de que a criminologia não é só (e nem é tanto) uma ciência encerrada em um paradigma estritamente etiológico-explicativo, mas é, também ela, uma ciência *compreensiva* do fenómeno criminal na sua integralidade, que assenta em supostos básicos jurídico-políticos e, por aqui, em uma política *criminal*. Assim, sem deixar de ser na essência uma ciência empírica e interdisciplinar, com anseio de integração, o seu objecto não é tanto constituído pelo fenómeno *social* enquanto tal, mas reconverte-se em larga medida ao fenómeno *jurídico-criminal*; deixando todavia, por outro lado, de se limitar estreitamente à investigação das causas do facto criminoso e da pessoa do delinquente, para passar a abranger a **totalidade do sistema de aplicação da justiça penal**, nomeadamente as instâncias formais (a polícia, o ministério público, o juiz, a administração penitenciária, os órgãos de reinserção social e, em definitivo e antes de todas, a própria lei penal) e informais (a família, a escola, as associações privadas de ajuda social, etc.) de controle da delinquência; para passar a abranger, numa palavra, o **inteiro "processo de produção" da delinquência**.

§ 38 Esta perspectiva interaccionista não visa *substituir* a vertente etiológica tradicional, mas *alargá-la* e *completá-la* pela consideração do processo de socialização no seu todo: da integração do indivíduo no ambiente social e nos sistemas normativos

([51]) Citado em DIAS / ANDRADE, p. 108.

vigentes. Por isso a criminologia passa a relacionar-se também estreitamente com o *processo penal* e com *o direito executivo penal* (52), como partes integrantes do processo de aplicação do direito penal. E por isso também a criminologia deixa de assumir a característica quase exclusivamente sociológica que a marcou até aos anos 60 do séc. XX, para abranger também a consideração da individualidade da pessoa — não só do criminoso, mas de todo o participante no sistema da justiça penal — e do âmbito de variação das suas possibilidades de decisão. Se é lícito invocar um pensamento que preside à última concretização da filosofia de Niklas Luhmann (53), dir-se-á que em toda esta criminologia nova, graças à sua ligação privilegiada com a política criminal, à consideração do sistema social vem juntar-se a consideração do *sistema pessoal*, a autonomia da pessoa, erigida agora em um outro sistema auto-referente e auto-legitimador, como ser dotado de um círculo incompressível de direitos, liberdades e garantias fundamentais.

IV. Síntese conclusiva

§ 39 Assim, em jeito de conclusão, pode afirmar-se o seguinte: sabemos hoje, por um lado, que é à política criminal que pertence competência para definir quer no plano do direito constituído, quer do direito constituendo, os limites da punibilidade; como, por outro lado, que a dogmática jurídico-penal não pode evoluir sem atenção ao trabalho "prévio" de índole criminológica. Mas também este não pode evoluir sem uma mediação político-criminal que lance luz sobre as finalidades e os efeitos que se apontam à (e se esperam da) aplicação do direito penal. Política criminal, dogmática jurídico-penal e criminologia são assim, do ponto de vista científico, três âmbitos autónomos, ligados porém, em vista do integral processo da realização do direito penal, em uma unidade teleológico-funcional (54). É a esta unidade que continua hoje a convir o antigo conceito de von Liszt de "ciência conjunta do direito penal".

---

(52) Assinale-se agora o propósito de Wolter de construir um "sistema *integral* do direito penal" que compreenda explicitamente também o processo penal: WOLTER, Kriminalpolitik und Strafprozessrechtssystem, *Roxin-FS*, 2001, p. 1141, e Estudio sobre la dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del sobreseimiento del proceso, de la renuncia a la pena y de la atenuación de la misma. Estructuras de un sistema integral que abarque el delito, el proceso penal y la determinación de la pena, *in*: Wolter / Freund (orgs.), *El sistema integral del derecho penal. Delito, determinación de la pena y proceso penal*, 2004, p. 31. Cf., também, SIEBER, Die Kollision von materiellen und prozessualen Strafrecht — Ein Grundlagenproblem des Strafrechtssystems, *Roxin*-FS, 2001, p. 1113. Sobre a questão, por último, ROXIN I, § 7, n.º 10 e ss.

(53) *Soziale Systeme*, nota 28.

(54) Por último, sobre a questão, HEFENDEHL, Kriminologie, Dogmatik, Kriminalpolitik: ein Leben in friedlicher Koexistenz?, *Schünemann-Symposium*, nota 18, p. 3.

TÍTULO II

A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL

A função do direito penal no sistema dos meios de controlo social e na ordem jurídica total haverá de apreender-se não só através da natureza do seu *objecto* (o facto ou comportamento criminoso, *hoc sensu*, o "crime"), como também da especificidade das *consequências jurídicas* que àquele se ligam, as penas e as medidas de segurança. Já se referiram (supra, 1.º Cap., § 6) as razões metodológicas e materiais por que, dentre estes dois elementos, é o segundo que assume a primazia: nomeadamente porque é a sua especificidade — conferida pelo seu fundamento, o seu sentido e as suas finalidades — que reage sobre o conteúdo material do crime e a definição dos seus elementos integrantes. Por isso, dentro deste título dedicado à função do direito penal, começaremos por estudar a **pena**, depois a **medida de segurança** e só depois defrontaremos a questão do conteúdo material do conceito de **crime**. Importa considerar ainda que da conjugação das sanções criminais com o conceito de crime resultam igualmente os **limites** materiais do direito penal face a outras disciplinas que — sobretudo pela utilização de meios também sancionatórios, mas não criminais — lhe estão próximas.

4.º CAPÍTULO

FINALIDADES E LEGITIMAÇÃO DA PENA CRIMINAL

I. O problema dos "fins" da pena criminal

§ 1 O problema dos fins (*rectius*, das finalidades) da pena criminal é tão velho quanto a própria história do direito penal e tem sido discutido, vivamente e sem soluções de continuidade, pela filosofia (tanto pela filosofia geral, como pela filosofia do direito), pela doutrina do Estado e pela

ciência conjunta do direito penal. A razão de um tal interesse e da sua persistência ao longo dos tempos está em que, à sombra do problema dos fins das penas, é no fundo toda a **teoria penal** que se discute e, com particular incidência, as questões fulcrais da *legitimação*, *fundamentação* e *função* da intervenção penal estatal. Neste sentido se pode dizer que a questão dos fins das penas constitui a *questão do destino* do direito penal e do seu *paradigma*. Por isso também qualquer análise dos fundamentos do direito penal não pode ainda hoje furtar-se à tentativa de fazer o ponto da querela sobre as finalidades da pena criminal e de divisar os caminhos do futuro próximo. Até porque, quantas vezes, sob o manto de problemas e de designativos velhos se escondem novidades emergentes ou mesmo progressos já consolidados.

§ 2 De um ponto de vista *lógico-hermenêutico*, questões como as mencionadas — da legitimação, da fundamentação e da função do direito penal — podem certamente ser cindidas do problema dos fins da pena. Tais questões, dir-se-á, relevam para a conclusão sobre aquilo que deve ser considerado o "crime", consequentemente ameaçado com uma pena criminal; mas não têm necessariamente de se ligar à essência desta, à sua natureza e às suas finalidades. A perspectiva correcta no entanto, começámos logo por acentuá-lo, pode e deve ser outra. O sentido, o fundamento e as finalidades da pena criminal são determinações indispensáveis para decidir de que forma deve aquela actuar para cumprir a função do direito penal: elas reagem por conseguinte sobre o próprio conceito material de crime (sobretudo através do *princípio da necessidade*: infra, 6.º Cap., § 37 e ss.) e codeterminam, por aí, a resposta à questão da função do direito penal.

§ 3 As respostas dadas ao longo de muitos séculos ao problema dos fins da pena — seja pela ciência do direito penal, seja pela teoria do Estado ou pela própria filosofia — reconduzem-se a duas (*rectior*, a três) teorias fundamentais: as **teorias absolutas**, de um lado, ligadas essencialmente às doutrinas da *retribuição* ou da *expiação*; as **teorias relativas**, de outro lado, que se analisam em dois grupos de doutrinas: as doutrinas da *prevenção geral*, de uma parte, as doutrinas da *prevenção especial* ou *individual*, de outra parte. Toda a interminável querela à roda dos fins das penas é recondutível a uma destas posições ou a uma das múltiplas variantes através das quais se tem tentado a sua **combinação**. De cada uma destas teorias será dada, em seguida, notícia sucinta (1). Para depois se ten-

(1) Uma exposição minuciosa desta temática logo em SANTOS, Beleza dos, *Introdução*, p. 117 e ss.

tar a sua introdução na história das doutrinas penais e, por esta via, acabar por se dar a conhecer o ponto de vista próprio sobre o problema.

II. Teorias absolutas: a pena como instrumento de retribuição

§ 4 Para este grupo de teorias a essência da pena criminal reside na **retribuição, expiação, reparação** ou **compensação do mal do crime** e nesta essência se esgota. Se, apesar de ser assim, a pena pode assumir efeitos reflexos ou laterais socialmente relevantes (de intimidação da generalidade das pessoas, de neutralização dos delinquentes, de ressocialização), nenhum deles contende com a sua essência e natureza, nem se revela susceptível de a modificar: uma tal essência e natureza é função exclusiva do facto que (no passado) se cometeu, é a *justa paga* do mal que com o crime se realizou, é o *justo equivalente* do dano do facto e da culpa do agente. Por isso a medida concreta da pena com que deve ser punido um certo agente por um determinado facto não pode ser encontrada em função de outros pontos de vista (por mais que eles se revelem socialmente valiosos e desejáveis) que não sejam o da *correspondência* entre a pena e o facto. Qualquer outra teoria dos *fins* das penas (entendendo por estes os efeitos socialmente úteis que com elas se pretenda alcançar) torna o facto em mero *ensejo* de aplicação da pena e falha completamente a sua vera essência e natureza: pune-se *porque* se "pecou" ou, na formulação que se foi buscar a parte de uma afirmação (crítica) de Protágoras (485? a. C.-415? a. C.), que recebeu o aval de Platão (427-347 a. C.) e foi transmitida por Séneca († 65 d. C.), *punitur quia peccatum est*. Só deste modo se corresponderia à dignidade histórica que a pena desde tempos imemoriais assumiu; como só deste modo se estaria em sintonia com o sentimento cultural comunitário generalizado que desde sempre entendeu a pena como um *castigo* e uma *expiação* do mal do crime.

§ 5 Esta concepção da pena, para além da indiscutível dignidade histórica que lhe assiste e da correspondência a sentimentos profundamente ancorados na comunidade, pode legitimamente reivindicar-se da fundamentação que desde sempre lhe foi oferecida por um certo **pensamento filosófico**. Arrancando do *princípio do talião* — "olho por olho, dente por dente" — (2), tendo-se deixado penetrar durante a *Idade Antiga* de representações mitológicas e durante a *Idade Média* de racionalizações reli-

(2) Sobre ele, EBERT, Talion und Vergeltung im Strafrecht, *in*: Jung et alii (orgs.), *Recht und Moral*, 1991, p. 249.

giosas, as teorias absolutas da retribuição louvam-se basicamente na ideia de que a realização da Justiça no mundo, como mandamento de Deus, conduz à legitimação da aplicação da pena retributiva pelo juiz como representante terreno da justiça divina. Na *Idade Moderna e Contemporânea* o sustentáculo desta doutrina vai sobretudo buscar-se à filosofia do *idealismo alemão*. Kant qualificava a pena (a "lei penal") como um "imperativo categórico", por isso que, "quando a justiça desaparece, não tem mais valor que os homens vivam na terra"; e concluía afirmando que, ainda quando o Estado e a Sociedade devessem desaparecer, "teria o último assassino que se encontrasse na prisão de ser previamente enforcado, para que assim cada um sinta aquilo de que são dignos os seus actos e o sangue derramado não caia sobre o povo que se não decidiu pela punição, porque ele poderia então ser considerado como comparticipante nesta violação pública da justiça" (3). Hegel, por seu turno, considerava o crime como a negação do direito e a pena como negação da negação, como "anulação do crime, que de outro modo continuaria a valer" e, por isso, como "restabelecimento do Direito". E acrescentava que inquinar esta consideração absoluta da pena com quaisquer fins de prevenção seria como "levantar um pau contra um cão e tratar o ser humano não segundo a sua honra e liberdade, mas como um cão" (4).

§ 6 A discussão acerca do fundamento das teorias absolutas da retribuição centrou-se durante longo tempo sobre a forma como deveria ser determinada a "compensação" ou **igualação** a operar entre o "mal do crime" e o "mal da pena". Ultrapassado o período do talião, acabou generalizadamente por reconhecer-se que a pretendida igualação não podia ser fáctica, mas tinha forçosamente de ser **normativa**. Ainda aqui restava porém um largo campo para dúvidas e controvérsias, nomeadamente, quanto a saber se a pretendida retribuição assumia o carácter de uma *reparação* do dano real, do dano ideal ou de qualquer outra grandeza, se ela ocorria em função do desvalor do facto ou antes da culpa do agente (5). Neste plano a controvérsia pode hoje dizer-se terminada: a "compensação" de que a retribuição se nutre só pode ser função da *ilicitude* do facto e da *culpa* do agente. Logo porque se esta doutrina se reivindica antes de tudo das exigências da "Justiça", essas implicam que cada pessoa seja tratada segundo a sua culpa e não segundo a lotaria da sorte e do azar em que na vida se jogam os comportamentos humanos e as suas consequências.

---

(3) KANT, *Die Metaphysik der Sitten, Zweites Blatt, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*, § 49, E, "Vom Straf- und Begnadigungsrecht", I, 1798 (= *Kant. Werke*, W. Weischedel (org.), VII, pp. 455 e 457).

(4) HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, ³1821 (org. Lasson), §§ 99 e 101 e adição ao § 99.

(5) SANTOS, Beleza dos, *Introdução*, p. 242 e ss., e CORREIA, Eduardo, I, n.os 12 e 17.

Depois, e coerentemente, porque se o que está em causa é o tratar o homem segundo a sua liberdade e a sua dignidade pessoais, então isso conduz directamente ao *princípio da culpa* como máxima de todo o direito penal humano, democrático e civilizado; ao princípio segundo o qual *não pode haver pena sem culpa e a medida da pena não pode em caso algum ultrapassar a medida da culpa*. Aqui reside justamente o **mérito** das doutrinas absolutas: qualquer que seja o seu valor ou desvalor como teorização dos fins das penas, a concepção retributiva teve — histórica e materialmente — o mérito irrecusável de ter erigido o princípio da culpa em princípio absoluto de toda a aplicação da pena e, deste modo, ter levantado um veto incondicional à aplicação de uma pena criminal que viole a eminente dignidade da pessoa.

§ 7 Deve em todo o caso notar-se que a obrigatória correspectividade entre pena e culpa *não é biunívoca* (6). Com isto quer-se significar que, se toda a pena supõe a culpa, nem toda a culpa supõe a pena, mas só aquela culpa que simultaneamente acarrete a necessidade ou carência de pena (7). Neste plano do sentido (e só neste, não no de lucubrações lógico-formais de uma distinção eidética entre "fundamento" e "pressuposto" ou "limite" (8)) se pode correctamente afirmar que **a culpa é pressuposto e limite, mas não fundamento da pena**.

§ 8 Como teoria dos **fins da pena**, porém, a doutrina da retribuição deve ser **recusada** (9). Logo porque ela não é (verdadeiramente não quer ser, nem pode ser) uma teoria dos *fins* da pena. Ela visa justamente o contrário, isto é, a consideração da pena como **entidade independente de fins**, como entidade que, no dizer de Maurach, louvado na lição de Hegel,

---

(6) ROXIN, Concepción bilateral y concepción unilateral del principio de culpabilidad, na sua colectânea *Culpabilidad y Prevención en Derecho Penal* (trad. de Muñoz Conde, 1981), p. 187 e ss. E também RODRIGUES, Anabela, *A Determinação da Medida da Pena Privativa de Liberdade*, 1993, pp. 123 e ss., 449 e s. e 462 e ss.

(7) O que aliás se pode comprovar, num direito positivo como o português, através de um instituto como o da *dispensa de pena* (art. 74.º; cf. o nosso *DP II*, § 467 e ss.). No sentido de uma certa desvalorização do argumento que da consagração deste instituto deve retirar-se para a discussão referida em texto, CARVALHO, Taipa de, Condicionalidade sócio-cultural do direito penal. Análise histórica. Sentido e limites, *Estudos Paulo Merêa e Braga da Cruz*, II, 1985, p. 1032 e s. (cf. todavia, agora, do mesmo, I, § 107); e no sentido da sua recusa, COSTA, Faria, *O Perigo em Direito Penal*, 1992, p. 373 e ss.

(8) Como se afirma do lado dos (pretensamente únicos) defensores de uma concepção "ética" da culpa, na linha — porventura exasperada — de considerações de KAUFMANN, Arthur, *Das Schuldprinzip*, 1961, p. 201 e ss.

(9) Assim, também, RODRIGUES, Anabela, nota 6, p. 152 e ss.

existe na sua *zeckgelöste Majestät*, na sua majestade dissociada de fins ([10]). A partir daqui é só um jogo de palavras desinteressante ([11]) saber se a concretização de uma ideia — no caso, a ideia da Justiça — não é, também ela, um "fim"; ou se como tal devem antes ser consideradas só finalidades empírico-sociais: quando se pergunta pelo fim da pena indaga-se de efeitos relevantes *na* e *para a* vida comunitária.

§ 9 A doutrina da retribuição deve ser recusada ainda pela sua **inadequação à legitimação, à fundamentação e ao sentido da intervenção penal**. Estas podem apenas resultar da necessidade, que ao Estado incumbe satisfazer, de proporcionar as condições de existência comunitária, assegurando a cada pessoa o espaço possível de realização livre da sua personalidade. Só isto pode justificar que o Estado furte a cada pessoa o mínimo indispensável de direitos, liberdades e garantias para assegurar os direitos dos outros e, com eles, da comunidade. Para cumprimento de uma tal função a retribuição, a expiação ou a compensação do mal do crime constituem meios inidóneos e ilegítimos. O Estado democrático, pluralista e laico dos nossos dias não pode arvorar-se em entidade sancionadora do pecado e do vício, tal como uma qualquer instância os define, mas tem de limitar-se a proteger bens jurídicos; e para tanto não pode servir-se de uma pena conscientemente dissociada de fins, tal como é apresentada pela teoria absoluta (do latim *ab-soluta*, terminologicamente: des-ligada). Daí que tão-pouco possa ver-se o Estado como instância destinada à realização terrena da ideia pura da "Justiça" como uma espécie de *Ersatz* da justiça divina ([12]).

§ 10 Mas ainda de um outro ponto de vista, socialmente interessado — e portanto, deve reconhecer-se, de uma perspectiva estranha às intenções próprias de uma teoria absoluta —, as doutrinas da retribuição devem ser repudiadas. Uma pena retributiva esgota o seu sentido no *mal* que faz sofrer ao delinquente como compensação ou expiação do mal do crime ([13]); nesta medida é uma doutrina puramente **social-negativa**, que

([10]) MAURACH, § 7 B.

([11]) Como assinala ROXIN I, § 3[4].

([12]) Importante neste contexto, em perspectiva histórica, CATROGA, Fernando, *Entre Deuses e Césares. Secularização, Laicidade e Religião Civil*, 2006.

([13]) Aprofundadamente, CORREIA, Eduardo, *ProjPG*, 1963, p. 45 e ss., concluindo que a pena não deve ser perspectivada, negativamente, através do *mal* em que se traduz para o delin-

acaba por se revelar não só estranha a, mas no fundo inimiga de qualquer tentativa de *socialização* do delinquente e de *restauração da paz jurídica* da comunidade afectada pelo crime; inimiga, em suma, de qualquer *actuação preventiva* e, assim, da pretensão de controlo e domínio do fenómeno da criminalidade.

III. Teorias relativas: a pena como instrumento de prevenção

1. Consideração geral

§ 11 Contrariamente às teorias absolutas, as teorias relativas (do latim *referre*: referir-se a) são, com plena propriedade, teorias *de fins*. Também elas reconhecem que, segundo a sua essência, a pena se traduz num *mal* para quem a sofre. Mas, como instrumento político-criminal destinado a actuar no mundo, não pode a pena bastar-se com essa característica, em si mesma destituída de sentido social-positivo; para como tal se justificar tem de usar desse mal para alcançar a finalidade precípua de toda a política criminal, a **prevenção ou profilaxia criminal**. Na frase inteira de Séneca, reportando-se a Protágoras e a Platão (e já acima parcialmente citada): "Nam, ut Plato ait, 'nemo prudens punit quia peccatum est, *sed ne peccetur*'". Só deste modo, de resto, se adequando o instrumento "pena" à própria função do direito penal de tutela subsidiária de bens jurídicos.

§ 12 A **crítica geral**, proveniente dos adeptos das teorias absolutas, que ao longo dos tempos mais se tem feito ouvir às teorias relativas é a de que, aplicando-se as penas a seres humanos em nome de fins utilitários ou pragmáticos que pretendem alcançar no contexto social, elas transformariam a pessoa humana em objecto, dela se serviriam para a realização de finalidades heterónomas e, nesta medida, **violariam a sua eminente dignidade** ([14]). Dito de outra forma, seria precisamente o seu carácter relativo que se ergueria como violação do absoluto da dignidade pessoal. Nesta medida acabando a razão por pertencer a Kant, ao definir a lei penal como imperativo categórico, bem como a Hegel, ao sustentar que uma pena

---

quente, mas, positivamente, através do esforço ressocializador que o seu conteúdo deve assumir. Isso significa todavia, do ponto de vista do texto, que a pena não pode ser "retribuição".

([14]) De acordo com a palavra de KANT, nota 3: "O homem não pode nunca ser utilizado meramente como meio para os propósitos de outro e ser confundido com os objectos do direito das coisas, contra o que o protege a sua personalidade inata".

finalista é como um pau com que se bate num cão e não como um mal com que se castiga o mal feito por um homem livre.

§ 13 Um tal criticismo é destituído de fundamento. Houvesse razão na crítica e teria então de concluir-se pela ilegitimidade total de todos os instrumentos destinados a actuar no campo social e a realizar finalidades socialmente úteis — desde que a actuação de tais instrumentos pudesse limitar liberdades da pessoa. A verdade é antes que para o funcionamento da sociedade cada pessoa — embora só na medida indispensável — **tem de prescindir de direitos que lhe assistem** e lhe são conferidos em nome da sua eminente dignidade. A questão da preservação da dignidade da pessoa é por isso, em definitivo, estranha à questão das finalidades da pena e deve ser resolvida independentemente dela. Problema é saber se não a pena, mas a sua *aplicação* não deve fazer-se em termos que respeitem aquela intocável dignidade; e aqui a resposta não pode ser senão afirmativa. Esse é porém um problema que contende já não com os *fins* das penas, mas com os *limites* que, sejam quais forem aqueles fins, à pena têm necessariamente de ser postos pelas *condições da sua aplicação*. Que contende, por outras palavras, com o limite inultrapassável que à forma como se resolva o problema dos fins das penas tem de ser posto pela extensão, pelo conteúdo e pelo sentido *absolutos* do princípio da culpa. Que contende, em definitivo, com a função e a materialidade do conceito de culpa jurídico-penal e não com as finalidades do conceito de pena.

2. A pena como instrumento de prevenção geral

§ 14 Nas teorias preventivas há que começar por distinguir tanto historicamente, como segundo o sentido entre as doutrinas da *prevenção geral* e as doutrinas da *prevenção especial* ou *individual*. O **denominador comum das doutrinas da prevenção geral** radica na concepção da pena como instrumento político-criminal destinado a *actuar (psiquicamente) sobre a generalidade dos membros da comunidade, afastando-os da prática de crimes* através da *ameaça* penal estatuída pela lei, da realidade da sua *aplicação* e da *efectividade* da sua execução. A aludida actuação estatal sobre a generalidade das pessoas assume porém ainda uma *dupla perspectiva*. A pena pode ser concebida, por uma parte, como forma estatalmente acolhida de *intimidação* das outras pessoas através do sofrimento que com ela se inflige ao delinquente e cujo receio as conduzirá a não cometerem factos puníveis: fala-se então a este propósito de **prevenção**

geral negativa ou **de intimidação**. Mas a pena pode ser concebida, por outra parte, como forma de que o Estado se serve para manter e reforçar a *confiança* da comunidade na validade e na força de vigência das suas normas de tutela de bens jurídicos e, assim, no ordenamento jurídico-penal; como instrumento por excelência destinado a revelar perante a comunidade a inquebrantabilidade da ordem jurídica, apesar de todas as violações que tenham lugar e a reforçar, por esta via, os padrões de comportamento adequado às normas: neste sentido se fala hoje de uma **prevenção geral positiva** ([15]) ou **de integração** ([16]). Nela se tornou comum distinguir diversos "efeitos", nomeadamente o aludido "efeito de *confiança*", o de "*aprendizagem*" (resultante da demonstração dos custos do facto punível) e o de "*integração* verdadeira e própria" (resolução do conflito social suscitado pelo crime) ([17]).

§ 15 Em perspectiva moderna, a primeira formulação acabada de uma doutrina da prevenção geral fica a dever-se, como é corrente asseverar-se, a um dos fundadores do direito penal moderno, Paul Johann Anselm von Feuerbach: a conhecida doutrina da **coacção psicológica**, segundo a qual a finalidade precípua da pena residiria em criar no espírito dos potenciais criminosos um *contra-motivo* suficientemente forte para os afastar da prática do crime. A alma do criminoso potencial seria assim uma arena onde se digladiam as motivações conducentes ao crime e as contra-motivações derivadas do conhecimento do mal da pena, em definitivo importando que estas últimas sejam em regra suficientemente poderosas para vencer as primeiras e, deste modo, contribuir eficazmente para a prevenção ([18]). O essencial da doutrina da prevenção geral veio a receber até certo ponto confirmação das doutrinas da *psicologia da profundidade*, bem como das *doutrinas psicanalíticas* ([19]): quer através da ideia de que muitas pessoas só são capazes de dominar as suas tendências criminosas face ao reconhecimento de que quem se decide pela via do crime acaba por sofrer mais danos pessoais do que vantagens; quer pela conclusão de que a pena tem como função primordial a legitimação da ordem vigente e a manutenção da estabilidade e da paz jurí-

([15]) JAKOBS, 1/1-52.

([16]) ROXIN, Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit im Strafrecht, *Bockelmann-FS*, 1979, p. 305 e s. (há tradução espanhola na colectânea cit. na nota 6, p. 147 e ss.); e logo também, DIAS, Figueiredo, Quelques considérations sur le fondement, le sens et l'application des peines en droit pénal économique, *in*: *Les sanctions en matière de délinquance économique*, Journées de Kristiansand de la Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire, 1983, p. 33. Uma análise minuciosa encontra-se em RODRIGUES, Anabela, nota 6, p. 317 e ss., e em Schünemann / v. Hirsch / Jareborg (orgs.), *Positive Generalprävention*, 1998.

([17]) ROXIN I, § 3, n.º 27.

([18]) V. FEUERBACH, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts*, [14]1847 (a 1.ª ed. é de 1801), §§ 13 e 16.

([19]) Cf., sobretudo, FREUD, *Totem e Tabu* (ed. portuguesa de 1974), p. 361.

dicas ([20]). Um contributo decisivo para o reforço das doutrinas da prevenção geral em nova veste (positiva) é oferecido pelas actuais *teorias sistémico-sociais*: seja pela via da reacentuação da *função* do direito penal como tutela subsidiária de bens jurídicos, que não pode deixar de reflectir-se na natureza e legitimação dos seus instrumentos específicos, máxime, da pena; seja pela via da redução da função da pena no sistema social à sua *expressão simbólica* de reafirmação contrafáctica da fidelidade devida às normas jurídicas de um dado ordenamento positivo ([21]).

§ 16 O **ponto de partida** das doutrinas da prevenção geral é prezável, logo porque — ao contrário do que sucede com as doutrinas da retribuição — ele se liga directa e imediatamente **à função do direito penal** de tutela subsidiária de bens jurídicos ([22]). Do ponto de vista desta bem se compreende que se exija da pena uma actuação preventiva sobre a generalidade dos membros da comunidade seja no momento da sua ameaça abstracta, seja no da sua concreta aplicação, seja no da sua efectiva execução. Só assim se correspondendo à tão antiga, quanto exacta (e hoje mesmo, em larga medida, empiricamente comprovada) asserção de Montesquieu segundo a qual "*si on examine la cause de tous les relâchements, on vera qu'elle vient de l'impunité des crimes et non de la modération des peines*" ([23]). E nada vale contra-argumentar que os índices da criminalidade por toda a parte crescente (em todo o caso: não da criminalidade real, que continua uma grandeza desconhecida, mas da criminalidade registada ou "conhecida pela polícia" ([24])) mostram a inefectividade de se apontar à pena uma finalidade de prevenção geral. Logo por ser indiscutível que uma tal finalidade acaba por se cumprir relativamente à maioria (a uma esmagadora maioria, felizmente!) da população; e depois porque o argumento só poderia provar alguma coisa — se provasse — contra a efectividade da pena e nada contra a finalidade que lhe é assinalada.

([20]) Em perspectiva criminológica, DIAS / ANDRADE, p. 178 e ss.

([21]) Uma discussão ampla em RODRIGUES, Anabela, nota 6, pp. 254 e ss. e 270 e ss., e depois em HAFFKE, Die Legitimation des staatlichen Strafrechts zwischen Effizienz, Freiheitsverbürgung und Symbolik, e HASSEMER, Das Symbolische aus symbolischen Strafrecht, ambos em *Roxin-FS*, 2001, pp. 955 e 1001. A função *simbólica* de que fala o texto não deve em todo o caso confundir-se com uma outra que com igual nome é atribuída à pena e acaba por contender com os *slogans* da "justiça de classe" e do "direito alternativo": cf. ODONE Sanguine, Função simbólica da pena, *RPCC 5*, 1995, p. 77.

([22]) Ponto que vimos de há muito afirmando: DIAS, Figueiredo, A reforma do direito penal português, *BFD ILVIII*, 1972, p. 131 e ss.

([23]) MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, *Œuvres* (Dalibon, 1822), livro VI, cap. XII.

([24]) Sobre estes conceitos, DIAS / ANDRADE, pp. 130 e ss. e 447 e ss.

§ 17 O grande argumento que sempre se repete contra as doutrinas da prevenção geral é aquele que já deixámos apontado (supra, § 12) relativamente a todas as doutrinas da prevenção: o de que, comandadas apenas por considerações pragmáticas e eficientistas, elas fazem da pena um instrumento que viola, de forma inadmissível, a **eminente dignidade da pessoa humana** à qual se aplica. Já então tivemos ocasião de criticar, em geral, o argumento. Mas, improcedente embora, ele aponta uma indiscutível fragilidade teorética e prática das doutrinas da prevenção geral, quando consideradas exclusivamente no seu cariz negativo, como formas de intimidação da generalidade dos cidadãos. Quer porque não se torna possível determinar empiricamente o *quantum* de pena necessário para alcançar tal efeito. Quer porque, não logrando a erradicação do crime, fica próxima a tendência para se usarem para o efeito penas cada vez mais severas e desumanas; a ponto de o direito penal poder descambar, como tantas vezes historicamente descambou, num *direito penal do terror* absolutamente *desproporcional* e por isso, este sim, directa e imediatamente violador da eminente dignidade da pessoa.

§ 18 O argumento já não será procedente, porém, se a prevenção geral se perspectivar na sua vertente positiva, como **prevenção de integração**, de tutela da confiança geral na validade e vigência das normas do ordenamento jurídico, ligada à protecção dos bens jurídicos e visando, em último termo, a *restauração da paz jurídica*. Em primeiro lugar, este critério permite que à sua luz se encontre uma pena (não uma pena exacta, mas em todo o caso um espaço ou uma moldura punitivos) que, em princípio, se revelará também uma pena *justa* e *adequada à culpa* do delinquente. Em segundo lugar, já ficou dito que a medida concreta da pena a aplicar a um delinquente, sendo embora fruto de considerações de prevenção geral positiva, deve ter *limites* inultrapassáveis ditados pela culpa, que se inscrevem na vertente liberal do Estado de Direito e se erguem justamente em nome da inviolável dignidade pessoal ([25]). Deste ponto de vista, a doutrina da prevenção geral oferece um entendimento racional e político-criminalmente fundado ao problema dos fins das penas; e também um entendimento susceptível de se fazer frutificar para a solução de muitos e complexos problemas dogmáticos.

([25]) Sobre a questão, FRISCH, Schwächen und berechtigte Aspekte der Theorie der positiven Generalprävention — Zur Schwierigkeiten des "Abchieds von Kant und Hegel", *in*: Schünemann / von Hirsch / Jareborg, nota 16, p. 133 e ss.

3. A pena como instrumento de prevenção especial ou individual

§ 19 As doutrinas da prevenção especial ou individual têm por *denominador comum* a ideia de que a pena é um instrumento de actuação preventiva sobre **a pessoa** do delinquente com o fim de evitar que, no futuro, ele cometa novos crimes. Neste sentido se deve falar de uma finalidade de **prevenção da reincidência** (26). Neste corpo teórico unitário, porém, divergências profundas surgem quando se pergunta *de que forma* deve a pena cumprir aquela sua finalidade (27).

§ 20 Para uns, a "correcção" dos delinquentes seria uma *utopia*, pelo que a prevenção especial só poderia dirigir-se à sua *intimidação individual*: a pena visaria, em definitivo, atemorizar o delinquente até um ponto em que ele não repetiria no futuro a prática de crimes. Enquanto para outros a prevenção especial lograria alcançar um efeito de pura *defesa social* através da *separação* ou *segregação* do delinquente, assim procurando atingir-se a *neutralização* da sua perigosidade social. Bem podendo então falar-se, em qualquer destas hipóteses, de uma **prevenção especial negativa** ou de **neutralização**.

§ 21 De certo modo no outro extremo se situam aqueles que pretendem dar à prevenção individual a finalidade de alcançar a **reforma interior (moral)** do delinquente, uma sua autêntica *metanoia* — aquilo que bem poderia designar-se como a *emenda* do criminoso, lograda através da sua adesão íntima aos valores que conformam a ordem jurídica. Bem como aqueles outros para quem a finalidade terá de traduzir-se não na emenda moral, mas verdadeiramente no **tratamento** das tendências individuais que conduzem ao crime, exactamente no mesmo plano em que se trata um doente e, por isso, segundo um modelo estritamente *médico* ou *clínico*.

---

(26) A feliz e exactíssima expressão é de ESER, Resozialisierung in der Krise?, *Peters-FS*, 1974, p. 511.

(27) A discussão que se segue encontrou logo expressão na tripartição das funções especial-preventivas (de neutralização, de intimidação e de correcção) que constava do célebre *Programa de Marburgo*: v. LISZT, Der Zweckgedanke im Strafrecht, *ZStW 3*, 1883, p. 1. Importante sobre esta matéria, CORREIA, Eduardo, A influência de v. Liszt sobre a reforma penal portuguesa, *BFD 46*, 1970, p. 1, e HÜNERFELD, *Die Entwicklung der Kriminalpolitik in Portugal*, 1971, p. 73 e ss. Também em perspectiva histórica, COSTA, A. M. Almeida, *O Registo Criminal*, 1985, pp. 30 e ss., 113 e s. e 120.

§ 22 Em definitivo, do que deve tratar-se no efeito de prevenção especial é, bem mais modestamente, de — com respeito pelo modo de ser do delinquente, pelas suas concepções sobre a vida e o mundo, pela sua posição própria face aos juízos de valor do ordenamento jurídico — criar as condições necessárias para que ele possa, no futuro, continuar a viver a sua vida sem cometer crimes. Neste último sentido se podendo afirmar com justeza que a finalidade preventivo-especial da pena se traduz — e se traduz só — na "prevenção da reincidência". Todas estas doutrinas se irmanam, todavia, no propósito de lograr a *reinserção social*, a *ressocialização* (ou talvez melhor: a *inserção social*, a *socialização*, porque pode tratar-se de alguém que foi desde sempre um dessocializado) do delinquente e merecem, nesta medida, que elas se considerem como doutrinas da **prevenção especial positiva** ou **de socialização** ([28]).

§ 23 As doutrinas da prevenção especial afirmaram-se com particular vigor na 2.ª metade do séc. XIX, por força nomeadamente — segundo a convicção corrente na doutrina penalista — das escolas positivistas sociológicas italiana e alemã. Uma consideração histórica da evolução do direito penal português (e também, numa certa medida, do espanhol e do brasileiro) obriga no entanto a corrigir esta ideia e a colocar a influência decisiva das doutrinas da prevenção especial num momento historicamente anterior, a saber, aquele em que na Península Ibérica se instauraram as teses próprias da chamada **escola correccionalista**. Teses que — tendo a sua origem ideológica numa franca oposição da filosofia de Krause ([29]), e depois também da filosofia jurídico-penal de Roeder ([30]), às teses de Kant sobre o conceito de direito e sobre as suas relações com a moral, e que logo foi vivamente saudada pela filosofia jurídica portuguesa, nomeadamente por Vicente Ferrer Neto Paiva ([31]) — convergiam na ideia de que todo o homem é, por sua natureza, susceptível de ser corrigido, pelo que a pena deve, antes de tudo, propor-se operar a correcção do delinquente como única (e melhor) forma de evitar que ele, no futuro, continue a cometer crimes ([32]). Uma plêiade de

---

([28]) RODRIGUES, Anabela, *A Posição Jurídica do Recluso*, 1982, p. 142 e ss., e também Política Criminal — Novos desafios, velhos rumos, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 216 e ss., recusando a denominada "nova penologia" por contrária ao ideal socializador.

([29]) Sobre ela CALHEIROS, Maria Clara, Krause: entre humanismo e humanitarismo, *in: Estudos em Comemoração do 10.º Aniversário da Licenciatura em Direito da Universidade do Minho*, 2004, p. 529, e, mais em geral, a sua importante monografia *A Filosofia Jurídico-Política do Krausismo em Portugal*, 2006.

([30]) Sobre este movimento filosófico, a colectânea *Vicente Ferrer Neto Paiva. No Segundo Centenário do seu Nascimento. A Convocação do Krausismo*, *Stvdia Ivridica 45*, 1999.

([31]) *Elementos de Direito Natural ou de Philosophia do Direito*, 1844, e *Princípios Gerais de Philosophia do Direito*, 1850.

([32]) Do ponto de vista filosófico-jurídico, MONCADA, L. Cabral de, O Idealismo Alemão e a Filosofia do Direito em Portugal, *Boletim do Instituto Alemão da Faculdade de Letras de*

penalistas portugueses, entre os quais é de justiça destacar os nomes de Levy Maria Jordão (1831-1876) e de Ayres de Gouvêa (1828-1916) fizeram desta concepção básica o seu estandarte (33), o qual esteve por sua vez na origem de importantes (e decisivas) inovações — algumas de carácter pioneiro — da política criminal e do direito penal portugueses (infra, V, 2).

§ 24 O pensamento da prevenção especial — nomeadamente quando se assume como prevenção especial *positiva ou de socialização* — é decerto, a muitos títulos, tão prezável, quanto indispensável (34). Tal como se viu suceder com o pensamento da prevenção geral, ele revela desde logo uma particular sintonia com a **função do direito penal** como direito de tutela subsidiária de bens jurídicos; pois não é outra coisa que se pretende senão aquela tutela quando com a pena se visa actuar sobre o delinquente no sentido da prevenção da reincidência. Ao que acresce que o Estado só se afigura instância legítima para infligir ao delinquente uma pena que de todo o modo constitui um mal quando a esse mal pode ser assacado carácter *social-positivo*, tal como se encontra no pensamento da socialização; e mesmo no da *defesa social*, nos casos excepcionais em que a socialização se revele inalcançável ou desnecessária, mas os interesses de segurança da generalidade prevaleçam notoriamente sobre o mal que com a pena se faz sofrer ao delinquente. E ao que acresce ainda que o Estado tem o dever de auxiliar os membros da comunidade colocados em situação de maior necessidade e carência social, a eles **oferecendo** — não impondo! — os meios necessários à sua (re)inserção social. De todos estes pontos de vista o pensamento da prevenção individual constitui uma componente irrenunciável das finalidades da pena para a qual se não divisa ainda hoje alternativa.

§ 25 Nem por isso, todavia, o pensamento da prevenção especial deixa de se debater com **dificuldades** sensíveis e que, quando não correctamente ultrapassadas, podem conduzir à sua condenação. Tanto mais quanto, como se disse, aquele pensamento assume formas muito diversificadas e cujo sen-

---

Coimbra 8, 1938, pp. 228 e 247 e ss., bem como os contributos produzidos na homenagem a Vicente Ferrer Neto Paiva prestada pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em Dezembro de 1998, nota 30; e do ponto de vista jurídico-penal, HÜNERFELD, nota 27, p. 73 e ss.

(33) JORDÃO, *O Fundamento do Direito de Punir*, 1853; GOUVÊA, Ayres de, *A Reforma das Cadeias em Portugal*, 1860, esp. p. 15 e ss.

(34) Assim, com insistência, na doutrina brasileira moderna, ZAFFARONI / PIERANGELI, *Manual do Direito Penal Brasileiro, Parte Geral*, n.º 30.

tido fundamental está longe de ser unívoco. É hoje seguramente de recusar uma acepção da prevenção especial no sentido da *correcção ou emenda moral* do delinquente, mesmo que seja só no sentido de substituir às concepções pessoais daquele os juízos de valor e a *Weltanschauung* próprios do ordenamento jurídico. Para tanto falece ao Estado em absoluto legitimação. De recusar será igualmente o *paradigma médico ou clínico* da prevenção especial, sempre que ele se tome como tratamento *coactivo* das inclinações e tendências do delinquente para o crime. Ainda aqui não cabe ao Estado uma tal tarefa, a qual se apresentaria como violadora da liberdade de autodeterminação da pessoa do delinquente e, por conseguinte, de princípios jurídico-constitucionais imperativos como o da preservação da eminente dignidade pessoal (CRP, arts. 1.º, 13.º-1 e 25.º-1). Só, por isso, o *conteúdo mínimo da socialização* — a **prevenção da reincidência** — pode passar a prova de fogo de um direito penal próprio do Estado de Direito.

§ 26 Mesmo nesta acepção, porém, o pensamento da prevenção especial não pode assumir-se como finalidade **única** da pena. Fosse assim e teria então de concluir-se que a pena deveria durar por todo o tempo em que ainda persistisse a perigosidade social do delinquente, em que a sua socialização não tivesse sido lograda (uma pena, por conseguinte, de duração *absolutamente indeterminada* ([35])). O que se, por sua vez, se ligar à ideia da "incorrigibilidade" de certos delinquentes, conduziria à solução monstruosa de se aplicarem a pequenos delitos — para cuja prática repetida, porém, o delinquente possui uma tendência incontrolável: p. ex., o pequeno ratoneiro ou o pequeno burlão — penas de segurança ou de neutralização (máxime, penas de prisão) perpétuas.

§ 27 Por fim, o pensamento da prevenção individual positiva depara com dificuldades naqueles casos em que uma socialização se mostra **desnecessária**, em que o agente se não revela *carente de socialização*. Também por aqui se concluindo que o pensamento da prevenção especial positiva não pode valer, só por si, como solução *integral* do problema dos fins da pena. Nos casos em que aquela desnecessidade realmente se verifique só há lugar — se houver — para uma prevenção especial negativa, de pura defesa social.

([35]) Sobre esta espécie de pena no nosso direito anterior, ALBUQUERQUE, Pinto de, A consagração de um novo direito securitário na Reforma Prisional de 1936. *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 433. Já não assim, porém, uma *pena relativamente indeterminada*, tal como a aceita o direito penal português vigente relativamente à chamada "criminalidade habitual" (CP, art. 83.º e ss., o nosso *DP II*, § 875 e ss.).

§ 28 No entanto, tais casos de desnecessidade de socialização serão **muito menos frequentes** do que aquilo que uma certa doutrina — aliás difundida — supõe, máxime, nos temas do crime económico e, em especial, naqueles que a ciência criminológica chama, na esteira de Sutherland, "crimes de colarinho branco" ([36]). Ela alega que, ao menos na generalidade dos casos, o "colarinho branco" não se revela carente de socialização, dado precisamente o seu *status* económico-social, a respeitabilidade do seu modo de vida e a estabilidade da sua inserção comunitária. Mas esta alegação deve ser contraditada, por ter na base um deficiente entendimento do que seja a "socialização" que constitui finalidade da pena: também o crime económico — desvio de subvenções, fraude fiscal, actuações ilícitas sobre o mercado, contrabando, etc. — revela em princípio um defeito de socialização do agente, donde promana para o Estado o dever de pôr à sua disposição os meios de prevenir a reincidência ([37]). Sem prejuízo de casos existirem — nomeadamente, no que respeita a certos delinquentes *por convicção* (ou, ainda mais claramente, *por decisão de consciência*: infra, 25.º Cap.), *ocasionais* ou puramente *situacionais* — em que será difícil, quando não impossível, divisar fundadamente uma carência de socialização do agente.

4. A "concertação agente-vítima" e a reparação dos danos

§ 29 Refere-se hoje, cada vez com maior insistência, como uma *autónoma* e *nova* finalidade da pena o propósito de com ela se operar a possível concertação entre o agente e a vítima ([38]) através da *reparação dos danos* — não apenas necessariamente patrimoniais, mas também morais — causados pelo crime ([39]).

§ 30 Ainda aqui Claus Roxin surge como um dos autores que tanto do ponto de vista político-criminal, como dogmático preconiza mais veementemente um novo estatuto para esta ideia ([40]), tenta fazê-la frutificar através de propostas legislativas ([41]) e procura mesmo, através dela, erigir um sistema tripartido de sanções penais: penas,

---

([36]) Fundamental, SUTHERLAND, *White-Collar Crime*, 1961. Cf., entre nós, SANTOS, Cláudia, *O Crime de Colarinho Branco*, 2001.

([37]) Assim, DIAS, Figueiredo, nota 16, p. 36 e s., e *DP II*, § 333.

([38]) A chamada, na literatura e na dogmática jurídico-penal alemãs, *Täter-Opfer-Ausgleich*.

([39]) STRATENWERTH, *Was leistet die Lehre von der Strafzwecken?*, 1995, p. 13 e ss., e § 1, n.º 29.

([40]) ROXIN, Die Stellung des Opfers im Strafsystem, *Recht und Politik*, 1988, p. 69 e ss., Wiedergutmachung und Strafrecht, *in*: Schöch (org.), *Neue kriminologische Schriften 4*, 1987, p. 37 e ss., e *in*: Eser / Kaiser / Madlener (orgs.), *Neue Wege der Wiedergutmachung im Strafrecht*, 1990, p. 367 e ss.

([41]) No seio de um grupo de trabalho que preparou um projecto alternativo sobre a matéria: Baumann et alii, *Alternativ-Entwurf Wiedergutmachung*, 1992, e de que é porventura (modesta) manifestação o § 46a do StGB.

medidas de segurança e reparação dos danos (42). A discussão, nestes planos, centra-se hoje sobretudo (43) em determinar o exacto relevo do tema para a teoria dos fins das penas criminais, a concreta conformação que devem assumir as medidas de concertação e a delimitação precisa do seu âmbito de aplicação; nomeadamente, se devem ser aplicadas só a crimes contra bens jurídicos individuais ou também contra bens jurídicos supra-individuais e se apenas no âmbito da pequena, eventualmente também da média ou até mesmo da (de certa; e qual?) grande criminalidade. Todo este "novo" conjunto de ideias, radicado em uma concepção emergente da política criminal, deve desde logo ser reconhecido como um dos mais importantes factores sociais de legitimação da pena. Ele deve e pode, na verdade, integrar-se num mais amplo *paradigma político-criminal* que começa a correr sob o designativo da justiça restaurativa (**restorative justice**): de uma justiça, na conhecida definição de Tony Marshall, como "processo através do qual todas as partes implicadas numa específica infracção se juntam para resolver em conjunto como tratar com as consequências daquela e com as suas implicações no futuro" (44). Uma justiça penal, esta, que recorre cada vez com maior frequência e em maior extensão às chamadas "técnicas de *diversão*" e encontra nos processos de *mediação* o seu instrumento por excelência (45).

§ 31 O direito penal português confere a todo este pensamento político-criminal, por diversas formas, um relevo muito particular: seja, *v. g.*,

---

(42) ROXIN I, § 3, n.º 66, e Zur Wiedergutmachung als einer "dritten Spur" im Sanktionensystems, *Baumann-FS*, 1992, p. 243 e ss.

(43) Em data recente, SCHÜLER-SPRINGORUM, Von Spuren keine Spur. SCHÖCH, Wege und Irrwege der Wiedergutmachung im Strafrecht e SCHAFFSTEIN, Überlegungen zum Täter-Opfer-Ausgleich und zur Schadenswiedergutmachung, todos em *Roxin-FS*, 2001, respectivamente pp. 1021 e ss., 1045 e ss. e 1065 e ss. E, entre nós, MONTE, Mário, Da reparação penal como consequência jurídica autónoma do crime, e FARIA, Paula Ribeiro de, A reparação punitiva — Uma "terceira via" na efectivação da responsabilidade penal, ambos no *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, pp. 129 e 293. Cf., ainda, CARVALHO, Taipa de, *DP*, § 197 e ss., e SANTANA, Selma, *A Reparação como Consequência Jurídico-Penal Autónoma do Delito*, 2006. Também SOUSA, Susana Aires de, *Os Crimes Fiscais. Análise Dogmática e Reflexão sobre a Legitimidade do Discurso Criminalizador*, 2006, p. 307 e ss., aborda esta questão no âmbito específico da criminalidade fiscal.

(44) MARSHALL, The evolution of Restorative Justice in Britain, *EuropJCL&Crim 4*, 1996, p. 37. Cf., sobre o todo, CERETTI / MANNOZZI, Restorative Justice. Theoretical aspects and applied models, *Cahiers de défense sociale*, 1999, p. 13.

(45) Sobre estes conceitos, DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 44 e s. E sobre o tema — hoje na ordem do dia entre nós, por força de uma Decisão-quadro do Conselho da UE de 2001 e do Anteprojecto elaborado no Ministério da Justiça, que visa introduzir a mediação penal de adultos em Portugal —, Ministério da Justiça (org.), *A Introdução da Mediação Vítima / Agressor no Ordenamento Jurídico* Português, 2005, ALMEIDA, Carlota de, A propósito da Decisão-quadro do Conselho de 15-3-2001: algumas considerações (e interrogações) sobre a mediação penal, *RPCC 15*, 2005, p. 391, e SANTOS, Cláudia, A mediação penal, a justiça restaurativa e o sistema criminal, *RPCC 16*, 2006, p. 85 e ss.

considerando a reparação do dano como condição de legitimidade de aplicação de certas "penas de substituição" (art. 51.º-1) ou como condição da "dispensa de pena" (art. 74.º-1/*b*)), para além de admitir o lesado a pedir a reparação dos danos civis no próprio processo penal (arts. 71.º e ss. e 82.º-A do CPP ([46])). Sendo já assim entre nós, torna-se questionável a necessidade de fazer da "reparação" um *tertium genus* das sanções penais ([47]); como não será porventura adequado erigi-la em finalidade *geral* da pena. Para além de que uma tal finalidade não pode valer para as sanções aplicáveis a certos tipos de crimes nem esgotar em tais casos o conteúdo sancionatório, sucede que a reparação — como manifestação por excelência de uma justiça na sua essência "consensual" — poderia conduzir a que o sancionamento penal ficasse, em rigor, numa larga e inadmissível disponibilidade (de aceitação) da vítima e/ou do próprio agente. Como ideia geral, pois, a concertação agente-vítima só pode ter o sentido de contributo (valiosíssimo!) para o *restabelecimento da confiança e da paz jurídicas* abaladas pelo crime, o qual, como vimos, constitui o cerne mesmo da **prevenção geral positiva**. Enquanto, por outro lado, aquela concertação conforma uma vertente decisiva para uma correcta avaliação, no caso, das exigências de **prevenção especial positiva**.

IV. Teorias mistas ou unificadoras

§ 32 Nas últimas décadas e ainda hoje, a maioria das doutrinas sobre os fins das penas radica em tentativas, as mais variadas, de **combinar**, sob diversos pontos de vista, algumas ou todas as doutrinas que atrás ficaram referenciadas ([48]). Há todavia, ainda aqui, que considerar com certa autonomia *dois grupos* de teorias mistas ou unificadoras, consoante na combinação entrem ainda a ideia retributiva ou apenas ideias preventivas. O juízo que sobre um grupo e o outro se faça não é o mesmo; e o compreendê-lo permite porventura, a muitos títulos, uma melhor penetração da solução que deve hoje conferir-se a todo o problema dos fins da pena.

1. Teorias em que reentra ainda a ideia da retribuição

§ 33 Se quiser reduzir-se a multiplicidade de pontos de vista que visam combinar a tese fundamental da retribuição com as do pensamento

([46]) Sobre tudo isto o nosso *DP II*, § 60 e ss.

([47]) Como pretende ROXIN I, § 3, n.º 72 e ss. Criticamente o nosso *DP II*, § 64 e ss.

([48]) SANTOS, Beleza dos, *Introdução*, p. 214 e ss., e CORREIA, Eduardo, I, n.º 15.

preventivo, geral e especial, reconduzindo-as a um corpo doutrinal predominante, poderá este ser definido como o de uma **pena retributiva no seio da qual procura dar-se realização a pontos de vista de prevenção, geral e especial**; ou, diferentemente no que toca à hierarquização das perspectivas integrantes, para todavia se exprimir no fundo a mesma ideia, como o de uma **pena preventiva através de justa retribuição**. Numa e noutra formulação estará presente a concepção da pena, segundo a sua essência — e nesta acepção primariamente —, como retribuição da culpa e subsidiariamente como instrumento de intimidação da generalidade e, na medida possível, de ressocialização do agente (49). Concepção esta que pode de algum modo ligar-se a uma outra que se designa *teoria diacrónica* dos fins da pena: no momento da sua ameaça abstracta a pena seria, antes de tudo, instrumento de prevenção geral; no momento da sua aplicação ela surgiria basicamente na sua veste retributiva; na sua execução efectiva, por fim, ela visaria predominantemente fins de prevenção especial (50).

§ 34 Todo este grupo de concepções unificadoras é porém, enquanto teorias dos fins das penas, inaceitável. Porque, fazendo entrar na composição desejada, como quer que ela concretamente se estabeleça, a **ideia retributiva**, está a chamar para o problema das finalidades da pena um vector que, como procurou mostrar-se, não deve ser tomado em consideração neste contexto: a retribuição ou compensação da culpa não é nem pode constituir uma finalidade da pena. Nisto reside o essencial e decisivo da crítica global, não sendo outras considerações senão consequências decorrentes desta proposição fundamental. Até porque, entrando na fórmula combinada — repete-se: como quer que ela concretamente se componha — a ideia da retribuição, então esta, como ideia "absoluta" que se pretende, não pode deixar de ganhar *predominância* sobre as ideias ("relativas") da prevenção. Por isso valem contra uma tal fórmula, completamente, as objecções que, em sede de legitimação, à ideia retributiva se devem opor e ficaram consignadas supra, § 9.

---

(49) Exemplares, na doutrina portuguesa, CORREIA, Eduardo, I, n.º 17, e, na estrangeira, M / ZIPF, §§ 6-8.

(50) Assim a doutrina mais antiga de ROXIN, Sinn und Grenzen staatlicher Strafen, *JurS*, 1969, p. 397 (tradução espanhola de Luzón Peña, na colectânea: ROXIN, *Problemas básicos del derecho* penal, 1976). Na doutrina brasileira, TOLEDO, Assis, *Princípios Básicos de Direito Penal*, 5ª1994, p. 3 e 6ª.

§ 35 Haverá ainda que sublinhar, por outro lado, que quando se misturam doutrinas absolutas com doutrinas relativas fica definitivamente sem se saber qual o ponto de partida para se encontrar o **fundamento** teorético e a razão de **legitimação** da intervenção penal. Doutrinas absolutas e doutrinas relativas são, na verdade, irremediavelmente diversas e provêm de concepções básicas diferentes, quando não antagónicas (com razão chamando por isso Roxin a estas concepções "doutrinas unificadoras *aditivas*" ([51])). Haverá que sublinhar, em suma, que concepções deste tipo revelam uma oscilação inadmissível em convicções fundamentais. A mesma crítica atinge, de resto, aquela que se chamou uma concepção diacrónica dos fins da pena. Ela pode ser considerada razoavelmente adequada a uma visão imediatista do problema por parte dos destinatários das normas penais; mas esquece, de todo o modo, que a pena é uma instituição unitária em qualquer um dos momentos temporais da sua existência e como tal deve ser perspectivada, mesmo no que respeita ao problema das suas finalidades.

2. Teorias da prevenção integral

§ 36 O **ponto de partida** destas teorias, em si correcto, é o de que a combinação ou unificação das finalidades da pena só pode ocorrer a nível da prevenção, geral e especial, com exclusão de qualquer ressonância retributiva, expiatória ou compensatória. Deste ponto de vista se tentou, desde os tempos mais antigos aos mais recentes ([52]), lograr a concordância prática possível das ideias da prevenção geral e da prevenção especial, a sua optimização à custa de mútua compressão, de modo a atribuir a cada uma a máxima incidência na prossecução de um ideal de prevenção integral. Mas também esta concepção unificadora deve ser *globalmente recusada*. Se é denominador comum de todas as doutrinas cabidas nesta concepção a ideia de negar *in limine* à concepção retributiva legitimidade para entrar na composição das finalidades da pena, daí elas concluem pela **recusa do pensamento da culpa e do seu princípio como limite do problema**: ou porque procuram substituí-lo pela categoria da *perigosidade*; ou, como modernamente sucede com alguma frequência, pelo princípio jurídico-constitucional da *proporcionalidade*; ou por uma manipulação da ideia da culpa como mero *derivado da prevenção*. Com

([51]) ROXIN, nota 50.

([52]) Respectivamente: v. LISZT, Der Zweckgedanke im Strafrecht, *ZStW 3*, 1883, p. 1; EXNER, *Theorie des Sicherungsmittel*, 1914, e Sinnwandel in der neuesten Entwicklung der Strafe, *Kohlrausch-FS*, 1944; GRAMATICA, *Principii di difesa sociale*, 1961; GIMBERNAT Ordeig, Hat die Strafrechtsdogmatik ein Zukunft?, *ZStW 82*, 1970, p. 379; ELLSCHEID / HASSEMER, Schuld ohne Vorwurf, *in*: Lüderssen / Sack (orgs.), *Abweichendes Verhalten 2*, 1975, p. 266; JAKOBS, *Schuld und Prävention*, 1976, p. 7.

o que, porém, fazem perder à intervenção penal o seu pressuposto e o seu limite irrenunciáveis — pode dizer-se, o seu "axioma antropológico" (53) —, a saber, o respeito pela *eminente dignidade da pessoa* (54). E com esta perda não é só o problema da culpa jurídico-penal que completamente se falha: *é a própria questão das finalidades da pena* — das finalidades *preventivas* da pena — *que à partida se erra e desde o momento inicial se inquina.*

§ 37 Desta crítica não é passível uma concepção como a de Roxin. Ele conclui, em plena consonância com o ponto de vista aqui defendido, que a pena serve exclusivamente finalidades de prevenção geral e especial; mas nem por isso perde a clara consciência de que recusar a intervenção da retribuição na querela sobre as finalidades da pena não significa nem abandonar, nem minimizar **o pensamento e o princípio da culpa** na construção do facto punível e na legitimação da intervenção penal, nem tão-pouco esquecer o significado essencial que aquele princípio e pensamento assume na querela. A culpa é com efeito — e não pode deixar de ser — *pressuposto* da pena e *limite* inultrapassável da sua medida. A medida da pena pode porém ser fixada abaixo desse limite máximo, se tal se tornar necessário à luz de exigências da prevenção especial e a tanto se não opuserem as exigências *mínimas* da prevenção geral sob a forma das necessidades irrenunciáveis de *tutela do ordenamento jurídico* (55).

§ 38 Só que, do mesmo passo afirma Roxin que a medida da culpa é dada não por um ponto exacto da escala penal, mas através de uma **moldura da culpa**; e que, em princípio, é dentro desta moldura da culpa que — ressalvados os casos especiais acima referidos de particulares exigências de prevenção especial — o juiz deverá fixar a medida concreta da pena. A questão específica referente à problemática da medida da pena pode por ora restar sobre si (cf. infra, VI); mas não aquilo que a solução para ela preconizada por Roxin implica para a teoria unificadora preventiva dos fins da pena. É que com ela, com a construção de uma *moldura da*

---

(53) A excelente expressão — usada todavia em contexto de natureza jurídico-publicística — é de MELO, Barbosa de, *Democracia e Utopia*, 1980, p. 17.

(54) DIAS, Figueiredo, Schuld und Persönlichkeit, *ZStW 95*, 1983, p. 227 (= *Liberdade*, p. 240).

(55) ROXIN, Acerca da problemática do direito penal da culpa, *BFD LIX*, 1983, p. 6 e ss., Das Schuldprinzip im Wandel, *Arthur Kaufmann-FS*, 1993, p. 519 e § 3, esp. n.º 37 e ss.

culpa como espaço *nevrálgico* de aplicação da pena, é ainda de novo a ideia da compensação da culpa, a ideia mestra da retribuição, que reivindica — se bem que só de forma latente — o seu regresso à cena das finalidades da pena, degradando os propósitos preventivos, que deviam ser únicos, para meros "correctores" da fundamental correspondência entre culpa e pena (56). Assim se minimiza o papel central que à prevenção geral (positiva) deveria caber, logo como lídima tradução, ao nível das finalidades da pena, da função do direito penal de tutela subsidiária de bens jurídicos; para lhe conferir a modestíssima função de "mínimo dos mínimos" da pena, abaixo do qual as exigências de prevenção geral positiva não podem encontrar satisfação.

V. O problema dos fins das penas e a doutrina do Estado, nomeadamente à luz da sua evolução em Portugal

§ 39 Se o problema das finalidades da pena se conexiona directamente com a questão da legitimação do direito de punir estatal, então é seguro que toda esta questão — que, com razão, se considera frequentemente, na teoria jurídico-penal, sob a epígrafe das "doutrinas penais" — se encontra co-naturalmente ligada à própria doutrina do Estado e à sua evolução. O caso português é, a este propósito, exemplar a vários títulos. Uma sua sumária exposição, em perspectiva histórica, antecederá as proposições conclusivas que exporemos (infra, VI) sobre todo o tema em análise.

§ 40 Presente embora desde sempre na discussão teórica, bem se compreende que o problema dos fins da pena só tenha ganho um *explícito* relacionamento com a doutrina do Estado desde que se iniciou a história da **codificação** em sentido moderno (57); quando precisamente começou também a questionar-se, em termos racionais secularizados, a própria fundamentação e legitimação do poder punitivo estatal. Bem podendo afirmar-se que até aí se procurava compreender teoricamente a pena como instrumento de justiça divina delegada, enquanto praticamente ela se assumia como instrumento destinado a cumprir — quantas vezes pelo terror — a vontade e os propósitos políticos do soberano. Assim aconteceu também

(56) DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 296 e ss. Na mesma direcção, RODRIGUES, Anabela, nota 6, pp. 335 e ss. e 539 e ss., qualificando a doutrina de Roxin, nesta parte, como uma "versão disfarçada da retribuição" e reconhecendo a "contradição normativa inaceitável" que no nosso livro citado havíamos imputado àquela doutrina.

(57) MARQUES, Reis, *A Codificação e os Paradigmas da Modernidade*, 2001.

em Portugal ([58]), sem prejuízo de dever assinalar-se que uma certa tradição de compilação das leis penais — no sentido permitido pelas concepções jurídicas medievais — se instaurou praticamente *desde os primeiros tempos da nacionalidade* ([59]).

§ 41 Já na Espanha visigótica o chamado *Codex Legum Visigothorum*, que chegou a exercer influência directa nos primeiros tempos também do reino de Portugal, continha inúmeras disposições jurídico-penais, tendentes sobretudo a combater as formas privadas de reacção criminal. É verdade que cedo este conjunto de disposições foi subvertido, na sua aplicação prática, pelo direito consuetudinário, com o recrudescimento inevitável dos institutos da vingança privada e da perda da paz. Com o fortalecimento do poder público e o renascimento do direito canónico e romano, no entanto, desde 1221 que se restaurou a tendência para a publicização do *ius puniendi*, à qual correspondeu um esforço de elaboração legal, embora casuística, de todo o direito penal. As *Ordenações Afonsinas* (1446) compilaram, reformaram e completaram esta legislação extravagante, contendo no seu livro 5.º (o chamado *liber terribilis*) aquilo que bem pode considerar-se o primeiro Código Penal e de Processo Penal português. A estas Ordenações se seguiram as *Ordenações Manuelinas* (1521) e as *Ordenações Filipinas* (1603), que vigoraram, no que ao direito penal respeita, até ao CP português de 1852 ([60]). A legislação penal das Ordenações era caracterizada pela ausência de uma parte geral, por uma parte especial de natureza eminentemente casuística e por penalidades em regra não previamente fixadas, desproporcionadas, desiguais e cruéis. Em suma, todas as características que em geral se apontam como traduzindo o espírito do direito penal europeu até ao Iluminismo se encontravam presentes no direito penal português coevo, cuja singularidade maior residia, como se disse, em dispor já do esboço de uma sua "codificação".

§ 42 Na evolução da sempre renovada discussão entre doutrinas retributivas e preventivas podem divisar-se — quando se considera a evolução do pensamento jurí-

([58]) Uma síntese da evolução histórica do problema em Portugal, através da consideração do pensamento dos seus principais teorizadores e do seu contributo para o ensino do direito penal português, encontra-se em PALMA, Maria Fernanda, Do ensino histórico do direito penal na Universidade portuguesa à actual questão metodológica, *RPCC 9*, 1999, p. 354 e ss.

([59]) Sobre isto e a matéria do parágrafo seguinte, SECO, Henriques, Da historia do direito criminal portuguez desde os mais remotos tempos, *RLJ 4*, 1872, p. 483; CORREIA, Eduardo, I, n.º 22; DIAS, Figueiredo / COSTA, A. M. Almeida, La réforme pénale portugaise, *RDPCrim*, 1985, p. 4; e DIAS, Figueiredo, "Introduzione" a *Il Codice Penale Portoghese — Casi, Fonti e studi per il diritto penale racolti da Sergio Vinciguerra* (tradução de Giovanna Torre), 1997, p. 1 e ss.

([60]) E também no Brasil, até à entrada em vigor do Código Criminal do Império: cf. DOTTI, René, *Casos Criminais Célebres*, 1998, p. 272 e ss. E sobre o "vintismo penal" tenham-se em conta os subsídios e a análise importantes de BELEZA, José Manuel, A pena de prisão, a reforma das cadeias e o Ensayo sobre o plano mais conveniente para a fundação das cadêas (Notas para a história do direito penal vintista), *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 365.

dico-penal português durante a época da codificação penal moderna — certos períodos fundamentais. O primeiro, determinado pela recepção, a nível jurídico-penal, da ideologia própria do Estado liberal e individualista, corresponde à vigência do CP de 1852. O seguinte, iniciado com a publicação da Reforma Penal de 1884, encontra expressão no CP de 1886 e, se bem que com múltiplos aditamentos e modificações — determinados, também eles, pelas alterações sofridas pelo étimo fundante da doutrina jurídico-política do Estado, nomeadamente durante a vigência do Estado Corporativo —, estende-se até 1982. O último período tem início com a entrada em vigor deste CP, reformado em 1 de Outubro de 1995; e pretende traduzir a Constituição político-criminal própria de um Estado de Direito contemporâneo, de cariz social e democrático ([61]).

1. As finalidades e a justificação da pena na época das Luzes e no CP de 1852

§ 43 Foi a Constituição portuguesa de 1822 que, também no domínio do direito penal, veio pôr fim à ideologia própria do *ancien régime* e propiciar a introdução dos princípios humanísticos e racionais do *Iluminismo*. Declarando solenemente, no seu art. 10.°, que "nenhuma lei, muito menos a penal, será estabelecida sem absoluta necessidade"; e no artigo seguinte que "toda a pena deve ser proporcionada ao delito e nenhuma deve passar da pessoa do delinquente. Ficam abolidas a tortura, a confiscação dos bens, a infâmia, o baraço e o pregão, a marca de ferro quente e todas as penas cruéis e infamantes", a Lei Fundamental portuguesa dissociava definitivamente o direito penal das suas origens místicas (ligadas àquilo que se entendia ser a vontade divina), que clara e fortemente o haviam dominado durante toda a Idade Média e mesmo durante a inteira vigência das Ordenações; para o tomar na sua correcta veste de instituição humana estatal, subordinada a uma política criminal imanente e a uma teleologia racional. Assim o colocava, numa palavra, mesmo no centro histórico-espiritual daquilo que havia constituído o poderoso movimento — tão poderoso que ainda hoje se deve considerar longe de esgotado — do **Iluminismo Penal**. O seu propósito político principal era dirigido à eliminação das penas arbitrárias e à limitação do poder do Estado absoluto no que respeita à medida da pena. A legitimação do direito de punir só podia provir agora dos termos do *contrato social* e conduzia a assinalar à pena uma finalidade

([61]) Sobre a matéria dos n.os 1 e 2 que se seguem, CORREIA, Eduardo, A evolução histórica das penas, *BFD LIII*, 1979, p. 51 e ss.

primária de **prevenção geral de intimidação**; limitada, em todo o caso, por uma ideia de **proporcionalidade** com a gravidade do crime e a *culpa* do agente. Nesta medida se podia dizer que a finalidade da pena residiria em alcançar a prevenção geral indispensável através daquilo que se considerava uma *justa retribuição*.

§ 44 Já em Montesquieu, com efeito, a **justa proporcionalidade** entre o crime e a pena constituía o ponto nevrálgico de aferição de um direito penal humano. Não porque uma tal proporcionalidade fosse imposta por uma qualquer ideia absoluta, mas porque ela se revela utilitária ou finalisticamente (diríamos hoje: funcionalmente) justificada, na medida em que limita a intimidação ao *quantum* necessário de compressão das liberdades para o bom funcionamento da sociedade ([62]). E de forma análoga em Beccaria, confessado discípulo de Montesquieu, que apela expressamente ao "**contrato social**" para justificar a existência de uma pena dotada de finalidades exclusivamente preventivas e na verdade, uma vez mais, primariamente de prevenção geral negativa ("o fim da pena não é outro que retrair os demais cidadãos da prática de outros crimes"), embora subsidiariamente integrados por fins de prevenção especial, máxime de segurança ("impedir que o réu cause novos danos aos seus concidadãos") ([63]). Todo este património de ideias vem a culminar, em termos da ciência jurídico-penal, na obra de Feuerbach, cuja orientação em matéria de finalidades da pena já acima foi considerada. Em Portugal, o maior arauto da Ilustração Penal foi Mello Freire, autor de um Projecto de Código de Direito Criminal (1789) ([64]) — que não chegou no entanto a entrar em vigor — e sobretudo de uma obra doutrinal de valia, as *Institutiones Iuris Criminalis Lusitani*, onde é particularmente visível a influência do pensamento de Beccaria.

§ 45 Em 1833 José Manuel da Veiga apresentou um Projecto de Código Criminal que — atenuando decididamente o rigor punitivo das Ordenações e mesmo do Projecto de Mello Freire, eliminando as penas bárbaras e fazendo da pena de prisão o nódulo de todo o sistema sancionatório — representava a primeira manifestação legislativa coerente e concertada do Liberalismo Penal. Este projecto, porém, se bem que aprovado em 1837, não chegou a ser posto em execução. A primeira codificação penal portuguesa só teve lugar por intermédio do **CP de Dezembro de 1852**, que

([62]) MONTESQUIEU, nota 22, livro VI, cap. XVI.

([63]) BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, 1776 (tradução portuguesa de Faria Costa, 1998, com estudos introdutórios do tradutor e de Giorgio Marinucci), p. 63 e ss.

([64]) Cf., sobre ele — bem como sobre o seu *O Novo Código de Direito Público de Portugal*, que continha normas importantes também em matéria penal —, CORREIA, Eduardo, I, n.º 24. E (temperando em todo o caso, com razão, a ideia de considerar Mello Freire o arauto da "modernidade penal"), BELEZA, José Manuel, nota 60, p. 367 e s.

veio finalmente pôr termo à vigência formal do direito penal medieval das "Ordenações". Aquele código foi considerado pelos seus principais comentadores como uma cópia — pouco mais que mera tradução, que de resto nem sempre teria sido cuidada e fiel — do CP napoleónico de 1810 (65). Um tal juízo representa uma exageração, cientificamente inadmissível, de uma ideia exacta: a de que o CP de 1852 mergulhava bem as suas raízes no mesmo património ideológico que presidira ao CP napoleónico e, nomeadamente, no **património ideológico do Iluminismo Penal**. Mas apresentava em todo o caso notáveis diferenças logo no ponto que aqui muito particularmente se encontra em consideração: o do sentido e das finalidades da pena.

§ 46 Tal como o código napoleónico, o CP português de 1852 concebia a pena como instrumento visando primariamente finalidades de prevenção geral e, na verdade, de **prevenção geral de intimidação**. Dele se não pode porém dizer — como se pode do seu modelo gaulês — que fosse um código de *penas fixas*, de intimidação geral *tarifada* e, por conseguinte, de todo estranho a ideias de limitação, no que toca à pena e à sua medida, do intervencionismo estatal. Bem pelo contrário (66) — em virtude da influência que sobre a sua feitura exerceram o CP brasileiro de 1830 (67) e o espanhol de 1848 —, se algumas penas fixas consagrava, a generalidade delas eram todavia "*penas temporárias*" ou "*variáveis*", cuja medida abstracta oscilava entre um máximo e um mínimo legalmente estatuídos e onde o encontro da medida concreta da pena só poderia ser função do juiz, não do legislador. E se é exacto, por outro lado, que faltava no código a definição de um critério geral de procedimento judicial de determinação da medida concreta das penas variáveis, ele continha já extensas listas de circunstâncias, agravantes (art. 19.º) e atenuantes (art. 20.º), que serviam para graduar a pena consoante a influência que exercessem na "*culpa* do criminoso" (arts. 20.º-11 e 80.º).

§ 47 O que isto significa para o nosso problema é agora óbvio. A concepção das finalidades da pena que presidia ao diploma português de 1852 não pode de modo algum dizer-se o de uma prevenção geral de

---

(65) Assim foi enfatizado pelos principais comentadores deste código: JORDÃO, *passim*, e FERRÃO, *passim*.

(66) DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 241.

(67) Sobre este ponto, em síntese, DOTTI, René, nota 60, p. 286 e s.

intimidação sem limites, mas era — como afinal correspondia rigorosamente ao pensamento de Montesquieu e de Beccaria — uma **prevenção geral limitada por um princípio estrito de proporcionalidade** e, na verdade, segundo a sua forma mais perfeita, pela ideia da **culpa**; se bem que certamente uma culpa que nada ficava a dever a considerações absolutas de retribuição ou expiação. O que talvez possa justificar a conclusão de que aquele código, vilipendiado como tradução medíocre do código francês, era afinal muito mais do que isso, a saber, a **expressão mais pura do património ideológico-cultural do Iluminismo Penal**.

2. As finalidades e a justificação da pena na época liberal e no CP de 1886 (68)

§ 48 As críticas de que o CP de 1852 foi objecto, provenientes de sectores importantes da doutrina portuguesa, foram de ordem tal que ainda em 1852 foi nomeada uma comissão com o encargo de proceder à sua revisão! Foi assim que em 1861 se elaborou um Projecto que, depois de corrigido, haveria de ser oficialmente proposto aos poderes públicos em 1864. Sob influência das doutrinas correccionalistas de Roeder, já acima mencionadas — que terão sido carreadas sobretudo por Levy Maria Jordão, secretário e membro preponderante daquela Comissão —, o projecto revelava claramente uma orientação de **prevenção especial**, privilegiando a inclinação do direito penal para a correcção e o melhoramento do delinquente (69). Donde se propusesse um adoçamento substancial das penas e a eleição da pena de prisão como núcleo de todo o sistema punitivo, para além de pela primeira vez se erigir um sistema penitenciário coerente, baseado no chamado "sistema de Filadélfia" (isolamento quanto possível total do detido, com trabalho celular, como forma óptima de alcançar a sua indispensável *metanoia* ou reforma espiritual e interior); e também se propusesse já a criação de estabelecimentos correccionais e de refúgio de menores e institutos como os da liberdade condicional, da detenção suplementar, do patronato e do registo criminal. Nenhum dos mencionados

(68) Sobre a matéria deste número, DIAS, Figueiredo / COSTA, A. M. Almeida, nota 59, p. 3 e ss.

(69) Inclinação esta que correspondia à perspectiva já então dominante na literatura jurídico-penal portuguesa da época, mesmo daquela não enfeudada aos pressupostos da escola correccionalista e antes adepta da chamada "escola ecléctica" de Rossi, Guizot e De Broglie: cf. FERRÃO, I, *passim*, e PINTO, Sousa, p. 89 e ss., esp. p. 98 e ss., e já em *O Instituto*, 1852, p. 2 e ss.

projectos de reforma entrou em vigor. Mas nem por isso as principais inovações neles sugeridas deixaram de ser consagradas em leis especiais: a *lei de 1863 relativa ao registo criminal*; e a de *1 de Julho de 1867* que, para além de **abolir (até hoje!) as penas de morte e de trabalhos forçados**, adoptou o modelo penitenciário de Filadélfia. Todo este regime se manteve em vigor até 1913.

§ 49 Apesar das reformas assinaladas, o CP de 1852 persistia como lei vigente, revelando uma cada vez mais funda dessintonia entre os postulados em que repousava, nomeadamente na questão dos fins da pena, e uma nova compreensão dos supostos filosóficos e jurídico-políticos em que assentava a doutrina do Estado. Toda a doutrina do Estado liberal da segunda metade do séc. XIX não pôde, efectivamente, manter-se estranha à formidável influência da **filosofia idealista alemã** de Kant e de Hegel, tanto mais quanto ela, ao menos na interpretação então dominante, servia os interesses e os propósitos da burguesia em ascensão e já, em alguns lados, triunfante. O que não podia deixar de se repercutir na compreensão básica da ciência penal. Sem abandono dos princípios fundamentais que haviam sido introduzidos pelo constitucionalismo na esteira do Iluminismo Penal e haviam conduzido a um primeiro estádio da que mais tarde ficaria conhecida como a *Escola Clássica* da ciência penal, esta assume agora uma nova caracterização essencial, que lhe é emprestada pela elevação da **concepção ético-retributiva** a elemento essencial das finalidades da pena. Isto ocorreu no pensamento jurídico-penal português, no entanto, com duas notas características. Por um lado, a resultante da circunstância de aquela elevação se fazer em nome de uma certa influência hegeliana, antes que kantiana. Por outro lado, e sobretudo, a que derivava do acolhimento que em Portugal haviam merecido, desde o primeiro momento, as teses correccionalistas da prevenção especial. Teses que antecipavam de algumas décadas a *Escola Moderna* ou *Escola Positiva* que, pelo dobrar do século, havia de se impor em Itália — sobretudo pela mão de criminólogos como Lombroso (1876), Ferri (1892) e Garofalo (1885) — e na Alemanha — sobretudo por obra de Franz von Liszt e do seu célebre *Programa de Marburgo* (1882), que valeria como estandarte da nova Escola; e que haviam de conduzir, no que aqui interessa, à substituição do referente ético-retributivo pelo **especial-preventivo** em matéria de justificação e de finalidades da pena. O que, seja relembrado, assinalou o momento inicial de uma acerada *luta de escolas* — a Escola Clássica e a Escola Moderna — que haveria de marcar toda a evolução da ciência penal até aos anos 60 do séc. XX.

§ 50 Assim se compreende que a referida evolução tivesse determinado a morte do CP português de 1852. Mas que esta não tivesse conduzido à substituição da sua concepção da pena por uma concepção ético-retributiva, antes tivesse dado origem a um **ponto de vista ecléctico** quanto aos fundamentos do direito de punir, onde a ideia ético-retributiva se procurava casar com as novas orientações da prevenção, sobretudo da prevenção especial correccionalista. Foi isto o que no essencial se passou com a *Nova Reforma Penal* de 1884 que, aplicada ao CP português de 1852, havia de conduzir a uma "nova" codificação penal, o chamado **CP de 1886** (70). Assim se aproximou a reforma, em matéria de finalidades da pena, da teoria da *reparação moral* de Welcker, através da qual se procurava harmonizar, como finalidades da sanção criminal, a retribuição, a prevenção especial e a própria prevenção geral: nos limites de uma pena retributiva visava-se satisfazer tanto as necessidades de reinserção social do delinquente, como as exigências de intimidação individual e colectiva (71).

§ 51 A ideia que, deste modo, se imputa ao CP de 1886 de erigir a **retribuição** em fundamento e finalidade da pena não pode aceitar-se. Pelo contrário, não é difícil censurar-lhe, ao fim e ao cabo, uma **regressão**, relativamente ao CP de 1852, do pensamento da culpa, sobretudo na medida em que no catálogo de penas constante do art. 55.º e ss. se continha uma generalidade de *penas fixas*, como tais insusceptíveis de tomarem em consideração a culpa do agente. Com o que, de resto, não deixavam de eliminar-se praticamente as vantagens que se poderiam esperar da circunstância de no art. 88.º se consagrar pela primeira vez um critério de medida (de determinação concreta ou judicial) da pena em função da "gravidade do crime" (72). Por isso deve concluir-se que a confissão, constante do relatório da reforma, a favor das doutrinas retributivas não passava da afirmação de um princípio — que todavia nem sequer conduziu, da parte da lei e da própria jurisprudência, à eliminação da responsabili-

---

(70) Cf. o Relatório da Proposta de Lei da Nova Reforma Penal de 1884, *RLJ 18*, 1885; e, depois, CORREIA, Eduardo, I, n.º 25. Dizemos obviamente o "chamado" CP de 1886 porque na verdade, como evidenciámos, em rigor e formalmente de mais nada se trata neste que de uma reforma do CP de 1852.

(71) Cf. Relatório citado na nota anterior, pp. 225 ss. e 321 ss., e SANTOS, Beleza dos, *Introdução*, p. 157, nota 1. E, sobre a doutrina de Welcker, ROEDER, *Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el delito y la pena*, trad. espanhola de F. Giner, 1876, p. 213 e ss.

(72) Cf. o nosso *DP II*, § 242.

dade penal objectiva ou sem culpa — de fundamentação ou justificação filosófica da pena; enquanto na questão concreta das suas finalidades persistia e mesmo se acentuava uma *orientação preventiva*, nomeadamente de prevenção especial de *correcção*.

§ 52 O bom fundamento da última afirmação revela-se, de resto, nas inovações que, sobretudo em **legislação especial**, iam ser introduzidas no ordenamento jurídico-penal português. Neste contexto se deve dar ênfase particular à Carta de Lei de 21 de Abril de 1892, que instituiu a sanção (que hoje se qualificaria com razão como "medida de segurança": infra, 5.º Cap.) da *relegação* para os chamados delinquentes habituais (cf. depois também a Lei de 3 de Abril de 1896) (73); ao Decreto de 6 de Julho de 1893, que consagrou os institutos da *suspensão da pena (sursis)* e da *liberdade condicional* (74); ao Decreto de 27 de Maio de 1911, que reorganizou, em termos altamente progressivos para a época, todo o direito tutelar e penal relativo a *menores*; e à Lei de 29 de Janeiro de 1913 que ordenou a substituição do sistema penitenciário de Filadélfia pelo "sistema penitenciário de Auburn" (isolamento em princípio só no período nocturno e aceitação do princípio do trabalho em comum, como via para alcançar a ressocialização ou reforma *social* do delinquente).

§ 53 A conclusão a retirar de quanto em síntese ficou exposto relativamente à longa época do Estado liberal português (1820-1926) é a de que a doutrina da pena e das suas finalidades — correspondente embora, no essencial, aos pressupostos subjacentes à chamada "Escola Clássica" — não assumiu nunca o carácter rígido, absoluto e intolerante que constituiu, na ciência jurídico-penal de outros países, como que a imagem de marca desta orientação. Tal ficou sobretudo a dever-se à particular permeabilidade da ciência e da legislação jurídico-penais portuguesas, desde estádios particularmente precoces da evolução, ao pensamento da **prevenção especial positiva**, sob a égide do *pensamento correccionalista*. Pensamento este — e não será ocioso sublinhá-lo desde já — que todavia se não autonomizou, no sentido de transformar todo o direito penal português em um direito de *pura* prevenção especial, de *tratamento* do delinquente, livre das barreiras ético-jurídicas da culpa, como haveria de ser pretensão da Escola Positiva; mas antes se manteve sempre, em geral, dentro dos limites garantísticos e de respeito pelos direitos individuais que constituíram património inalienável do Iluminismo e do Liberalismo penais e da chamada Escola Clássica.

---

(73) Cf. o nosso *DP II*, § 654 e ss.

(74) Cf. o nosso *DP II*, respectivamente §§ 508 e ss. e 836 e ss.

3. As finalidades e a justificação da pena na época do Estado corporativo

§ 54 Não parece cientificamente legítimo afirmar que os pressupostos antidemocráticos e antiliberais que caracterizaram o chamado *Estado Corporativo* ou *Estado Novo* influenciaram em geral e directamente a doutrina ou mesmo a legislação jurídico-penais portuguesas ([75]), no sentido de as aproximar das que, com diferentes características, foram esboçadas ou se consolidaram em Estados totalitários como os da Alemanha nacional-socialista, da Itália fascista ou da URSS comunista. Em todo este longo período (1926-1974) os pressupostos garantísticos essenciais — como os dos princípios da legalidade, da culpa e da humanização do sistema punitivo — foram mantidos tanto na legislação, como na doutrina, e em certos casos e em certas épocas mesmo acentuados. Para isto terá contribuído em larga medida a pretensão de se assumir aquilo que se considerava o carácter e a missão *éticos* do Estado e que levaram a que a concepção retributiva da pena não tivesse sido nunca posta radicalmente em causa; como levaram a que nunca fossem abandonados os limites que todo o pensamento preventivo a si mesmo tem de se impor em nome da defesa da dignidade da pessoa. O que caracterizou todo este período de evolução da concepção da pena no ordenamento jurídico português não foi nunca, por isso, uma conversão às teses puramente especial-preventivas da escola moderna ou positiva ([76]); mas o desejo de levar tão longe quanto fosse possível a **compatibilização** entre uma **fundamentação ético-retributiva da pena**, que se desejava manter a todo o custo ([77]), e uma sua **finalidade de prevenção especial positiva ou de socialização** à qual o direito penal português nunca se mostrou disposto a renunciar.

§ 55 A questão fulcral — questão teorética, mas com eminentes repercussões a nível da reforma penal, máxime, em matérias como as da

---

([75]) Assim, já, DIAS, Figueiredo, nota 59, p. 7 e s. Neste sentido, também, CAEIRO, Pedro, "Ut puras servaret manus", *RPCC 11*, 2001, p. 40 e ss.

([76]) CARLOS, A. da Palma, *Os Novos Aspectos do Direito Penal*, 1934, todavia discorrendo em supostos democráticos. O que não é de estranhar numa época em que as teses da Escola Positiva valiam como sinal de modernidade e progressismo, enquanto as da Escola Clássica eram reputadas retrógradas e obscurantistas.

([77]) Precisamente por isso é que mesmo doutrinas "mistas" em matéria de fins das penas, mas em todo o caso essencialmente especial-preventivas, como a do movimento da *defesa social*, nunca lograram convencer a ciência jurídico-penal portuguesa então dominante: cf. a crítica acerada de CORREIA, Eduardo, I, pp. 67 e 94 e s., e *ProjPG*, p. 12 e ss.

imputabilidade diminuída, do tratamento de delinquentes perigosos, do monismo ou dualismo das reacções criminais — era assim a de saber como poderiam articular-se, sem contradição, as exigências de que a **culpa** (que se pensava estar co-naturalmente ligada a uma concepção ético-retributiva da pena) continuasse a ser considerada fundamento da punição; e de que à **prevenção**, sobretudo na forma de prevenção especial de socialização, fosse concedido o espaço necessário para que todo o sistema punitivo desse resposta mínima às necessidades político-criminais correcta e razoavelmente entendidas. Uma tal articulação foi tentada, na ciência jurídico-penal portuguesa — com claros reflexos na legislação —, através da **referência da culpa,** antes que (ou não só) ao facto, à (ou também à) **personalidade do agente**. E esta tentativa foi em Portugal levada à exaustão dogmática por doutrinas como a do *monismo prático de penas e medidas de segurança* de Beleza dos Santos (1940), a da *pena de segurança* de Cavaleiro de Ferreira (1943) e sobretudo a da *culpa na formação* (ou *pela não formação*) *da personalidade* de Eduardo Correia (1945) ([78]). De tal modo e a tal ponto que este conjunto de concepções, qualquer que seja a concordância ou discordância que hoje elas devam merecer, passou a constituir um dos traços mais característicos e mesmo, em larga medida, mais originais da doutrina portuguesa do direito penal. Mais originais e, no fim, **mais dignos de apreço** quando se repare como, por esta via, se cortava o passo a eventuais tentativas de (des)consideração dos delinquentes especialmente perigosos (infra, § 56), imputáveis ou inimputáveis, como **objectos** da intervenção penal: tentativas hoje de novo na ordem do dia, por exemplo através de construções como a do "direito penal do inimigo" (supra, 3.º Cap., § 29 e ss., e infra, 5.º Cap., § 21).

§ 56 Pedra de toque por excelência das tentativas acima aludidas é constituída pelo tratamento legislativo da complexivamente chamada **criminalidade especialmente perigosa** ([79]). Foi a Reforma Prisional de 1936 — que teve em Beleza dos Santos o principal mentor — que criou uma possibilidade de *prorrogação da pena* aplicável a imputáveis especialmente perigosos que duraria até que cessasse a perigosidade (sem limites pré-determinados, por conseguinte). Esta ideia passou no essencial para

([78]) Cf., respectivamente, SANTOS, Beleza dos, Delinquentes habituais, vadios e equiparados", *RLJ 70*, 1937-8, p. 337; FERREIRA, Cavaleiro de, *A Personalidade do Delinquente na Prevenção e na Repressão*, 1943, p. 48 e ss.; CORREIA, Eduardo, A doutrina da culpa na formação da personalidade, *RDES 1*, 1945, p. 24 e ss., e *ProjPG*, p. 17 e ss.

([79]) Sobre a história do problema, entre nós, ALBUQUERQUE, Pinto de, nota 35, p. 433 e ss., com esgotantes indicações bibliográficas e de fontes.

o CP português através da sua *Reforma de 1954*, levada a cabo pelo Ministro da Justiça da altura, o penalista Manuel Cavaleiro de Ferreira. O art. 67.º do CP então vigente, relativo aos delinquentes (imputáveis) ali chamados "de difícil correcção" — nos quais englobava os *delinquentes habituais*, caracterizados pela prática repetida de crimes, e os *delinquentes por tendência*, reveladores de perversão ou malvadez geradora de uma especial perigosidade —, permitia que a sua pena fosse prorrogada por períodos sucessivos de 3 anos, até que o condenado mostrasse que tinha idoneidade para seguir vida honesta ou deixasse de ser perigoso; e idêntica estatuição continha o art. 68.º para os chamados delinquentes imputáveis criminalmente perigosos em razão de anomalia mental; finalmente, o art. 93.º ordenava que, independentemente do disposto nos artigos anteriormente referidos, a pena aplicada a quem fosse considerado delinquente habitual ou por tendência sofresse uma *agravação extraordinária*. Toda esta situação só veio a ser modificada pela *Reforma de 1972* do CP, que limitou a prorrogação a *dois* períodos sucessivos de 3 anos, se bem que no caso do art. 68.º, quando após as prorrogações a perigosidade ainda se mantivesse, o tribunal pudesse aplicar ao agente a *medida de segurança* de internamento em manicómio criminal prevista no art. 70.º-1.

§ 57 Se quisermos, em jeito conclusivo, reduzir a uma fórmula o sentido e as finalidades que presidiram à compreensão da pena durante todo este período, ela não poderá andar longe da seguinte: **pena retributiva com finalidades de prevenção especial**. Prevenção especial que todavia, relativamente a casos particulares (os casos de especial perigosidade, nos quais lamentavelmente se incluía por presunção — é preciso não o esquecer — toda a "criminalidade política" e onde a prevenção especial se exprimia, praticamente de forma exclusiva, com um cariz puramente negativo, como prevenção especial de segurança), assumia *valor autónomo*; sem prejuízo de ser limitada, em toda a medida possível, por uma ideia de *culpa referida à personalidade* do agente.

4. A evolução posterior à institucionalização do Estado de Direito

§ 58 Por ser assim, não seria exacto pensar que a democratização da vida pública portuguesa após 25 de Abril de 1974 teria introduzido uma *modificação sensível* nestas matérias da fundamentação e das finalidades da pena. O Projecto da Parte Geral de um novo CP, elaborado por Eduardo Correia em 1963 ([80]), era, neste tema como em outros, o espelho fiel e expressivo do pensamento político-criminal e dogmático do seu Autor.

([80]) CORREIA, Eduardo, *ProjPG*.

O art. 2.º daquele Projecto continha, numa fórmula lapidar, a conclusão acima exposta: "Quem age sem *culpa* não é punível. A medida da pena não pode exceder *essencialmente* a da culpa do agente pelo seu facto ou pela sua personalidade criminalmente *perigosa*". Esta concepção era **compatível**, em boa parte, **com os princípios do Estado de Direito**, tomado este tanto na sua vertente liberal, como na social. Embora *o não fosse completamente*, porque aqueles princípios impõem que *em caso algum* a medida da pena exceda, essencialmente ou não, a medida da culpa (infra, VI). As razões da entorse continham-se, todavia, em limites ainda suportáveis à época: quando, na maioria do direito penal legislado das mais consolidadas democracias, o princípio da culpa não tinha ainda ganho ilimitada validade. E era tanto mais suportável quanto, como se disse, a entorse era motivada não por razões de prevenção geral negativa, muito menos de utilidade ou de pragmatismo políticos, mas pelo vasto campo que se pretendia conceder à prevenção especial de socialização e a uma política criminal nela assente. Residindo aqui porventura a mais funda razão por que os Projectos de Eduardo Correia não conseguiram consagração legislativa nos tempos da ditadura corporativa.

§ 59 Quando por isso, depois do Movimento de 25 de Abril de 1974, em 1976, os trabalhos de revisão do CP foram retomados, os fundamentos em que assentava a concepção da pena no Projecto de 1963 não foram essencialmente questionados. Já porém quando, em 1982, o novo CP foi finalmente publicado, uma circunstância importante perturbou a clareza com que as opções político-criminais fundamentadoras da pena se encontravam vertidas no Projecto. Essa circunstância é compreensível ([81]). Dado o carácter então ainda não definitivamente institucionalizado da democracia portuguesa e as ainda estreitas margens dos consensos comunitários alcançados, o **CP de 1982** procurou — atento o particular condicionalismo sócio-cultural e político em que foi aprovado e entrou em vigor — apresentar-se como um diploma *descomprometido* até ao limite possível de supostos subjacentes tanto em matéria político-criminal, como dogmática ([82]); o que — entre outras alterações — fez com que desaparecesse o citado art. 2.º do ProjPG, sem que ele fosse substituído por qual-

([81]) DIAS, Figueiredo, Oportunidade e sentido da Revisão do Código Penal Português, *JDC 1996*, p. 28 e ss.

([82]) Assim, logo, DIAS, Figueiredo, Pressupostos da punição e causas que excluem a ilicitude e a culpa, *JDC 1983*, p. 44 e s.

quer outro preceito à luz do qual se pudesse ganhar clareza sobre o problema que nos ocupa. Se um tal propósito, todavia, terá facilitado o processo político da aprovação, a breve trecho teve de reconhecer-se que ele dificultava em elevadíssimo grau **a interiorização das opções político-criminais e dogmáticas** que ao novo código continuavam a presidir ([83]). Até um grau tão elevado que conduziu a erros de aplicação directamente relacionados com a pena, a sua fundamentação, o seu sentido e as suas finalidades; e que conduziu, nos pontos mais fundamentais, mesmo a um — quase sempre latente, mas por vezes mesmo patente — processo ilegal de *desaplicação da lei*. Matérias como as da medida da pena e da sua fundamentação, da subsidiariedade da pena de prisão, da aplicação de penas de substituição ou mesmo (se bem que em menor grau) de medidas de segurança são exemplos frisantes do que acaba de afirmar-se.

§ 60 O "descomprometimento" referido do CP português de 1982 conduziu a que, mesmo em tema de fundamentação e de finalidades da pena, tivessem lugar os entendimentos substancialmente mais díspares. Para citar só um exemplo, enquanto Eduardo Correia continuou a entender a pena, de acordo com aquilo que terá sido sempre o seu pensamento, como uma **instituição** ([84]), como justa retribuição com finalidades preventivas, nomeadamente de prevenção especial de socialização, já nós considerámos o CP de 1982 baseado numa **pena exclusivamente preventiva**, com finalidades de protecção de bens jurídicos e visando alcançar, em toda a medida possível, a socialização do delinquente; e a culpa como um elemento estranho ao fundamento e à substância das finalidades da pena, mas constituindo em todas as situações um seu limite inultrapassável ([85]).

§ 61 A Comissão Revisora de 1991 — de cujas propostas resultou a **Reforma do CP de 1995** — trabalhou num quadro sócio-cultural e político inteiramente diverso daquele em que havia decorrido a parte final da elaboração e aprovação do diploma de 1982: num quadro típico já de uma democracia e de um Estado de Direito estabilizados e consolidados. Ela pôde, por outro lado, servir-se da inestimável experiência do que foram as dificuldades, os êxitos e os fracassos de aplicação do Código durante o primeiro decénio da sua vigência. Estava por isso em condições de apresentar

([83]) BRITO, Sousa e, A medida da pena no novo Código Penal, *Estudos Eduardo Correia*, III, 1990, p. 563 e ss.

([84]) CORREIA, Eduardo, nota 26, p. 21 e ss.

([85]) DIAS, Figueiredo, Os novos rumos da política criminal e o direito penal português do futuro, *ROA*, 1983, p. 28 e ss., e depois *DP II*, §§ 55 e ss. e 73.

com clareza o seu programa político-criminal e dogmático, bem como a sua leitura do programa político-criminal e dogmático subjacente à codificação de 1982, nomeadamente em tema de fundamentação, de sentido e de finalidades da pena. Um tal programa consubstancia-se em quatro proposições político-criminais fundamentais, em larga medida resultantes já das considerações anteriormente feitas neste capítulo, mas que valerá a pena agora apresentar como sendo aquelas que, pelo melhor, resumem o pensamento que aqui se pretendeu desenvolver e justificar.

§ 62 Tanto quanto é público, no momento em que escrevemos, o Anteprojecto 2006 mantém integralmente os dados relevantes sobre a legitimação, a fundamentação e as finalidades da pena no ordenamento jurídico-penal português. Nomeadamente, aquele projecto mantém a integral vigência e validade do disposto no art. 40.º vigente (infra, § 74), em nada afectando, por isso, o que no presente capítulo se preconiza e defende.

VI. Finalidades e limite das penas criminais

1. A natureza exclusivamente preventiva das finalidades da pena

§ 63 A base da solução aqui defendida para o problema dos fins da pena reside em que estes **só podem ter natureza preventiva** — seja de prevenção geral, positiva ou negativa, seja de prevenção especial, positiva ou negativa —, não natureza retributiva. O direito penal e o seu exercício pelo Estado fundamentam-se na necessidade estatal (*hoc sensu*, contratualista social) de subtrair à disponibilidade (e à "autonomia") de cada pessoa o *mínimo* dos seus direitos, liberdades e garantias indispensável ao funcionamento, tanto quanto possível sem entraves, da sociedade, à preservação dos seus bens jurídicos essenciais; e a permitir por aqui, em último termo, a realização mais livre possível da personalidade de cada um enquanto indivíduo e enquanto membro da comunidade. Se assim é, então também a pena criminal — na sua ameaça, na sua aplicação concreta e na sua execução efectiva — só pode perseguir a realização daquela finalidade, *prevenindo a prática de futuros crimes* ([86]).

([86]) Neste sentido, reportando-se expressamente ao art. 40.º do nosso CP, ROXIN I, § 3[63]. Contra, no sentido de uma pena ético-retributiva: COSTA, Faria, nota 7, p. 373, e VELOSO, J. A., Pena Criminal, *ROA 59*, 1999, p. 519.

§ 64 Desta concepção básica resulta que se não justifica, nem é conveniente, nem eficaz, assinalar à pena ou **só** finalidades de prevenção geral, ou **só** de prevenção especial. *Umas e outras devem coexistir e combinar-se* da melhor forma e até ao limite possíveis, porque umas e outras se encontram no propósito comum de prevenir a prática de crimes futuros. Se porém, em muitos casos, se tratará aqui de *finalidades aditivas* — porque, na generalidade das hipóteses, a pena será susceptível de visar, simultaneamente e sem contradição, finalidades de prevenção geral *e* de prevenção especial —, já casos existirão em que as duas espécies de finalidades poderão em certa medida *conflituar*. E, mais importante ainda, há *em todos os casos* que ganhar clareza sobre a questão de saber como devem comportar-se mutuamente as duas espécies de finalidades no momento decisivo de o juiz determinar o *quantum* exacto de pena com que concretamente vai punir um certo crime (operação chamada de determinação "concreta" ou "judicial" da pena ou, *rectior et simpliciter*, de *medida da pena*). Por isso vem a doutrina mais recente ([87]) sublinhando que o problema do **conflito dos fins das penas** é afinal, de forma paradigmática, o problema da determinação do **modelo de medida da pena**, e inversamente.

2. Ponto de partida: as exigências da prevenção geral positiva ou de integração

§ 65 Primordialmente, a finalidade visada pela pena há-de ser a da **tutela necessária dos bens jurídico-penais no caso concreto**; e esta há-de ser também por conseguinte a ideia mestra do modelo de medida da pena. Tutela dos bens jurídicos não obviamente num sentido retrospectivo, face a um crime já verificado, mas com um significado *prospectivo*, correctamente traduzido pela necessidade de tutela da *confiança* (de que falava já Beleza dos Santos) e das expectativas da comunidade na manutenção da vigência da norma violada; sendo por isso uma razoável forma de expressão afirmar como finalidade primária da pena o **restabelecimento da paz jurídica comunitária abalada pelo crime**. Uma finalidade que, deste modo, por inteiro se cobre com a ideia da *prevenção geral positiva* ou *prevenção de integração*; e que dá por sua vez conteúdo ao princípio da *necessidade da pena* que o art. 18.º-2 da CRP consagra de forma paradigmática. A ponto de se poder defender que onde a aplicação de uma pena — e a determinação da sua medida — não fosse essencialmente comandada por esta finalidade, aí se divisaria uma infracção ao espírito (se não à própria letra) da referida norma constitucional.

([87]) Cf. DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 281, e RODRIGUES, Anabela, nota 6, p. 44 e s.

§ 66 A Günther Jakobs se fica devendo a fórmula — emitida na esteira de Luhmann — segundo a qual a finalidade primária da pena reside na **estabilização contrafáctica das expectativas comunitárias na validade da norma violada**. Para Jakobs, porém, esta função estabilizadora da pena seria coisa diferente da função de *protecção de bens jurídicos*: esta última não caberia, ao menos de forma primordial, ao direito penal, por isso que "a sociedade não é nenhuma instância para a conservação e muito menos para a maximização de bens" ([88]). A exasperada "normativização", que nesta afirmação se reconhece, da ideia da estabilização da norma e do restabelecimento da confiança comunitária implica, porém, um perigoso resvalamento da pena e do direito penal em direcção a uma função *simbólica*; e mesmo a uma função simbólica puramente *negativa* (supra, nota 21), que seria usada pelas classes dirigentes na via da autodefesa dos seus privilégios e do aumento exponencial das margens da "exclusão social". Pese à identidade de formulações, é toda uma outra, neste ponto, a nossa concepção ([89]). Função social primária do direito penal é, na verdade, a tutela subsidiária dos bens jurídicos, sendo a ideia da estabilização das expectativas comunitárias apenas uma forma de tradução, segundo a função, daquela ideia essencial no plano da confiança comunitária na validade do seu sistema normativo de protecção. Num sentido próximo — se não coincidente — com a nossa opinião se exprime agora Alcácer Guirao: "o fim do Direito Penal radica primordialmente na protecção de bens jurídicos e só secundariamente na protecção da vigência da norma — fins (...) intimamente vinculados do ponto de vista funcional" ([90]).

§ 67 Afirmar que a prevenção geral positiva ou de integração constitui a finalidade *primordial* da pena e o ponto de partida para a resolução de eventuais conflitos entre as diferentes finalidades preventivas traduz exactamente a convicção de que existe uma **medida óptima de tutela dos bens jurídicos** e das expectativas comunitárias que a pena se deve propor alcançar; medida esta que não pode ser excedida (princípio da necessidade) por considerações de qualquer tipo, nomeadamente por exigências (acrescidas) de prevenção especial, derivadas de uma particular perigosidade do delinquente. É verdade porém que esta "medida óptima" de prevenção geral positiva não fornece ao juiz um *quantum* exacto de pena. Abaixo do ponto óptimo ideal *outros existirão em que aquela tutela é ainda efectiva e consistente* e onde portanto a pena concreta aplicada se pode ainda situar sem que perca a sua função primordial de tutela dos bens jurídicos. Até se alcançar um *limiar mínimo* — chamado de *defesa do orde-*

([88]) JAKOBS, 1/23. Criticamente também, CARVALHO, Taipa de, Prevenção, Culpa, Pena. Uma concepção preventivo-ética do Direito Penal, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 323 e s.

([89]) DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 303.

([90]) ALCÁCER Guirao, Protecção de bens jurídicos ou protecção da vigência do ordenamento jurídico?, *RPCC 15*, 2005, p. 511 (p. 554).

namento jurídico —, abaixo do qual já não é comunitariamente suportável a fixação da pena sem se pôr irremediavelmente em causa a sua função tutelar de bens jurídicos. Bem podendo assim dizer-se, a concluir, que é a prevenção geral positiva que fornece uma **moldura de prevenção** dentro de cujos limites podem e devem actuar considerações de prevenção especial ([91]); e não a culpa, como tradicional e ainda hoje maioritariamente se pensa ([92]), que fornece uma "moldura da culpa". Fica por esta via esvaziada de conteúdo uma das questões mais vivamente discutidas a propósito do papel da prevenção geral na doutrina dos fins das penas: a de saber se seria lícita uma qualquer elevação da pena em nome de exigências de **prevenção geral negativa** ou **prevenção de intimidação** da generalidade. A intimidação da generalidade, sendo sem dúvida um efeito a considerar — e seria hipocrisia desconhecê-lo ou ocultá-lo — *dentro* da moldura de prevenção geral positiva, não constitui todavia por si mesma uma finalidade autónoma da pena ([93]), somente podendo surgir como um efeito lateral (porventura, em certos ou em muitos casos desejável) da necessidade de tutela dos bens jurídicos.

3. Ponto de chegada: as exigências da prevenção especial, nomeadamente da prevenção especial positiva ou de socialização

§ 68 Dentro da moldura ou dos limites consentidos pela prevenção geral positiva ou de integração — entre o ponto óptimo e o ponto ainda comunitariamente suportável de medida da tutela dos bens jurídicos (ou de "defesa do ordenamento jurídico") — devem actuar, em toda a medida possível, pontos de vista de **prevenção especial**, sendo assim eles que **vão determinar, em última instância, a medida da pena**. Isto significa que releva neste contexto qualquer uma das funções que o pensamento da prevenção especial realiza: seja a função *positiva* de socialização, seja

([91]) DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 301 e ss. (§ 306); essencialmente neste sentido, por último, RODRIGUES, Anabela, O modelo de prevenção na determinação da medida concreta da pena, *RPCC 12*, 2002, p. 177 e ss., com uma síntese (p. 148 e ss.) da história do problema no nosso direito.

([92]) Também em Portugal: CORREIA, Eduardo, II, p. 318, e *Actas PG*, II, p. 123, FERREIRA, Cavaleiro de, II, 1989, p. 103 e ss., CARVALHO, Taipa de, nota 7, p. 1096 e ss. (mas cf., agora, I, § 105); BRITO, Sousa e, nota 83; e, na jurisprudência, o Ac. do STJ de 10-7-1991, *CJ*, 4-1991, p. 15.

([93]) Contra, LUZÓN PEÑA, *Medición de la pena y sustitutivos penales*, 1979.

qualquer uma das funções *negativas* subordinadas de advertência individual ou de segurança ou inocuização. A medida da **necessidade de socialização** do agente é no entanto, em princípio, o critério *decisivo* das exigências de prevenção especial, constituindo hoje — e devendo continuar a constituir no futuro — o vector mais importante daquele pensamento. Ele só entra em jogo porém se o agente se revelar *carente de socialização*. Se uma tal carência se não verificar tudo se resumirá, em termos de prevenção especial, em conferir à pena uma função de suficiente *advertência;* o que permitirá que a medida da pena desça até perto do limite mínimo da "moldura de prevenção" ou mesmo que com ele coincida ("defesa do ordenamento jurídico").

§ 69 Sobre o critério da *carência de socialização* já supra, § 27 e s., ficou dito o essencial. Se, por outro lado, casos houver em que não sejam legítimas fundadas esperanças de êxito na socialização do agente — casos, *hoc sensu*, de "incorrigibilidade" (cuja existência Eduardo Correia sempre contestou, invocando nesse sentido a "tradição correccionalista" portuguesa (94)) —, ficam só em aberto as possibilidades de necessária *intimidação individual* ou de indispensável *segurança individual* (inocuização). Constituindo as medidas de segurança, sem dúvida, o campo por excelência de actuação desta dimensão preventivo-especial (infra, 5.º Cap.), não pode excluir-se que ela tenha também lugar, em certos casos, no âmbito da pena.

4. A culpa como pressuposto e limite da pena

§ 70 Se a retribuição não tem qualquer palavra a dizer em matéria de finalidades da pena, a ela pertence, segundo a sua história e segundo o seu conteúdo (como acima se acentuou já), o mérito indeclinável de ter posto em evidência a essencialidade do princípio da culpa e do significado deste para o problema das finalidades da pena. Segundo aquele princípio "não há pena sem culpa e a medida da pena não pode em caso algum ultrapassar a medida da culpa". A verdadeira função da culpa no sistema punitivo reside efectivamente numa incondicional *proibição de excesso*; a culpa não é *fundamento* da pena (95), mas constitui o seu **pressuposto necessário** e o seu **limite inultrapassável**: o limite inultrapassável por quaisquer considerações ou exigências preventivas — sejam de preven-

(94) CORREIA, Eduardo, nota 27.

(95) Contra, COSTA, Faria, nota 7, p. 373. Por último, detidamente sobre a evolução deste problema na Alemanha, em particular na concepção de Roxin, NEVES, Curado, *A Problemática da Culpa nos Crimes Passionais*, 2006, p. 387 e ss.

ção geral positiva de integração ou antes negativa de intimidação, sejam de prevenção especial positiva de socialização ou antes negativa de segurança ou de neutralização. A função da culpa, deste modo inscrita na vertente *liberal* do Estado de Direito, é, por outras palavras, a de estabelecer o máximo de pena ainda compatível com as exigências de preservação da dignidade da pessoa e de garantia do livre desenvolvimento da sua personalidade nos quadros próprios de um Estado de Direito democrático. E a de, por esta via, constituir uma barreira intransponível ao intervencionismo punitivo estatal e um veto incondicional aos apetites abusivos que ele possa suscitar.

§ 71 Na realidade das coisas, **conflitos** frequentes podem surgir **entre a culpa e a prevenção especial**, seja negativa ou mesmo positiva, bem como entre a culpa e a **prevenção geral de intimidação**. Mas já não será fácil excogitar hipóteses em que o ponto óptimo ou ainda aceitável de tutela dos bens jurídicos venha a situar-se *acima* daquilo que a adequação à **culpa** permite. Com efeito, como insistentemente tem acentuado Roxin, as razões de diminuição da culpa são, em princípio, também comunitariamente compreensíveis e aceitáveis e determinam que, no caso concreto, as exigências de tutela dos bens jurídicos e de estabilização das normas sejam menores. Em princípio pois não se antevêem conflitos insanáveis entre culpa e prevenção geral de integração. O que não significa todavia que a prevenção de integração seja apenas um outro *nome*, ou uma outra *perspectiva*, da mesma realidade que seria a *culpa*. De toda a exposição anterior resulta que se trata ali de realidades diferentes, que possuem diferentes fundamentos e exercem funções diferenciadas dentro do sistema e dentro do problema das finalidades da pena.

§ 72 Assim entendidas as coisas, parece dispensável — se não for mesmo equívoca — a ideia de que (não as finalidades, mas) a **legitimação da pena** repousa substancialmente num **duplo fundamento**: o da prevenção e o da culpa; e isto porque a pena só seria legítima "quando é necessária de um ponto de vista preventivo e, para além disso, é justa", não se tratando deste modo de uma "união ecléctica de elementos heterogéneos", mas de uma "justificação cumulativa" ([96]). Esta "acumulação", na parte

([96]) Assim, agora, ROXIN, Conclusiones finales, reportando-se a von HIRSCH, Retribución y prevención como elementos de justificación de la pena, ambos *in*: Arroyo Zapatero / Neu-

em que é exacta, já encontra plena tradução na ideia de que a culpa é pressuposto indispensável e limite inultrapassável da pena, não se tornando necessário turvar a limpidez da natureza exclusivamente preventiva das *finalidades* da pena com exigências (se bem que justificadas) de justiça e de merecimento da sua aplicação. **Toda a pena que responda adequadamente às exigências preventivas e não exceda a medida da culpa é uma pena justa.**

5. Conclusão

§ 73 A teoria penal aqui defendida ([97]) pode resumir-se do modo seguinte: (1) Toda a pena serve finalidades exclusivas de prevenção, geral e especial; (2) A pena concreta é limitada, no seu máximo inultrapassável, pela medida da culpa; (3) Dentro deste limite máximo ela é determinada no interior de uma moldura de prevenção geral de integração, cujo limite superior é oferecido pelo ponto óptimo de tutela dos bens jurídicos e cujo limite inferior é constituído pelas exigências mínimas de defesa do ordenamento jurídico; (4) Dentro desta moldura de prevenção geral de integração a medida da pena é encontrada em função de exigências de prevenção especial, em regra positiva ou de socialização, excepcionalmente negativa, de intimidação ou de segurança individuais.

§ 74 O programa político-criminal que, na sua extensão enorme, se consubstancia nas proposições conclusivas acabadas de enunciar decorre directamente, repete-se ainda uma vez, do art. 18.º-2 da CRP e foi coerentemente assumido pelo legislador penal português de 1995, que o precipitou nos n.os 1 e 2 do art. 40.º do CP. O n.º 1 declara paradigmaticamente que "**a aplicação de penas (...) visa a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade**"; e o n.º 2 estatui, em termos "absolutos", que "**em caso algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa**". É a confirmação plena, por parte de um texto legislativo, do

---

mann / Nieto Martín, *Crítica y justificación del derecho penal en el cambio de siglo*, 2003, pp. 319 (a que pertencem as citações) e 125 e ss., e I, § 3, n.º 59 e ss. Como no texto, RODRIGUES, Anabela, nota 91, p. 156 e s.; e no essencial, se bem cremos, também CARVALHO, Taipa de, nota 88, p. 323: "a prevenção é a finalidade legitimadora da pena, mas (...) a culpa desempenha uma função na determinação da medida da pena, não sendo exclusivamente seu pressuposto e seu limite máximo".

([97]) E também por RODRIGUES, Anabela, notas 6 e 91.

percurso doutrinário que acaba de percorrer-se e das conclusões a que conduziu. A acusação de que uma disposição deste teor inscrita num CP excederia a competência de qualquer legislador, porque teria a singular pretensão de decidir da milenar controvérsia filosófico-doutrinal dos fins da pena, tem de ser repudiada como infundamentada ([98]). É ao legislador democraticamente legitimado — e, entre nós, exclusivamente à AR (art. 165.º-1*/c)* da CRP) — que compete vazar proposições de política criminal no *modus* da validade jurídica.

([98]) Assim, também, RODRIGUES, Anabela, nota 91, p. 154, contraditando a opinião de BRITO, Sousa e, *Actas 1993*, pp. 464 e s., 475. Cf., deste último, ainda, Os fins das penas no Código Penal, *in*: *Problemas Fundamentais de Direito Penal. Homenagem a Claus Roxin*, 2002, p. 157.

5.º CAPÍTULO

FUNDAMENTO, SENTIDO E FINALIDADES DA MEDIDA DE SEGURANÇA CRIMINAL

I. As medidas de segurança criminais no sistema sancionatório

§ 1 O sistema das sanções jurídico-criminais do direito penal português assenta, como sabemos já, em dois pólos: o das penas e o das medidas de segurança. Enquanto as primeiras têm a *culpa* por pressuposto e por limite, as segundas têm na base a *perigosidade (individual)* do delinquente. Logo neste sentido o nosso sistema é pois um sistema **dualista**, diversamente do que sucedeu nas ordens jurídicas do passado e continua ainda hoje, se bem que raramente, a suceder (1). A consciência **dogmática** da existência de uma categoria de sanções criminais como algo de diferente das penas só despontou com o Projecto de CP suíço de Carl Stoos (1893) e o "Contra-Projecto" de v. Liszt e Kahls (1911); se bem que não deva ser esquecido, com anterioridade, o requisitório de Ferri — e já mesmo de Despines e de Lombroso — a favor de um sistema de medidas de *defesa social* que substituísse o sistema de penas tradicional (2). Não significa isto que, em ordenamentos penais anteriores (3), não existissem já sanções que, em termos dogmáticos modernos, devessem ser reconduzidas à categoria das

---

(1) Uma informação completa a este propósito em JORGE Barreiro, A crise actual do dualismo no Estado Social e Democrático de Direito, *RPCC 11*, 2001, p. 527, e ANTUNES, Maria João, *Medida de Segurança de Internamento e Facto de Inimputável em Razão de Anomalia Psíquica*, 2002.

(2) FERRI, *Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, 1881. Sobre a origem destas medidas, JORGE Barreiro, As medidas de segurança aplicáveis aos doentes mentais no CP espanhol de 1995, *RPCC 10*, 2000, p. 37.

(3) Incluído o português (supra, 4.º Cap., § 52), mas de que é uso citar o *Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten*, de 1874, na esteira da ideia apresentada pela primeira vez por E. F. Klein: JESCHECK / WEIGEND, § 9, I.

medidas de segurança; significa que só a partir dos estudos legislativos citados se ganhou clara consciência de que o sistema das penas, qualquer que fosse, devia ser **integrado** (ou "**flanqueado**", na feliz expressão de Zipf (4)) por um sistema de medidas que possuíam uma intenção político-criminal e uma expressão dogmática diversas das que presidem às penas.

§ 2 A indispensabilidade das medidas de segurança faz-se desde logo e principalmente sentir a um *primeiro nível*, ao nível do tratamento jurídico a dispensar aos chamados agentes **inimputáveis**. Quem comete um facto ilícito-típico mas é inimputável — e isto significa, logo por definição, *incapaz de culpa* —, *v. g.*, um menor de tenra idade ou, em princípio, um esquizofrénico ou um oligofrénico profundos, não pode ser sancionado com uma pena; e todavia, se o facto praticado e a personalidade do agente revelarem a existência de uma grave perigosidade o sistema sancionatório criminal não pode deixar de intervir, sob pena de ficarem por cumprir tarefas essenciais de defesa social que a uma política criminal racional e eficaz sem dúvida incumbem.

§ 3 Um *segundo nível* — mais duvidoso e problemático, mas nem por isso menos importante — ao qual se faz sentir a indispensabilidade da medida de segurança é o seguinte: mesmo que o facto ilícito-típico tenha sido praticado por um imputável (logo: *capaz de culpa*), bem pode suceder que os princípios que presidem à culpa e, por via desta, ao limite máximo de medida da pena (supra, 4.º Cap., § 70 e s.), se revelem *insuficientes* para ocorrer a uma **especial perigosidade** resultante das particulares circunstâncias do facto e (ou) da personalidade do agente. Também neste âmbito, por conseguinte, fica próxima a ideia de *complementar* a aplicação da pena, limitada pela culpa, com a aplicação de uma medida de segurança dirigida à especial perigosidade do agente. A existência desta segunda fonte de necessidade da medida de segurança no sistema jurídico-penal arrasta consigo aquela que continua ainda hoje a ser a questão mais complexa (e de mais relevantes implicações no sistema) de toda a problemática: a de saber se, de acordo com a regra do Estado de Direito, o sistema jurídico-penal sancionatório deve assumir, relativamente a agentes *imputáveis*, natureza *monista* ou antes *dualista*. Mas também uma correcta dilucidação desta questão supõe que se ganhe previamente clareza sobre as

(4) M / ZIPF, § 67, n.º 2.

finalidades e a legitimação que à medida de segurança pertencem — como instrumento sancionatório *unitário*, que deve assumir a mesma natureza a qualquer um dos dois níveis referidos — num ordenamento jurídico-penal próprio do Estado de Direito contemporâneo.

II. Finalidades e legitimação da medida de segurança

1. O problema das finalidades

1.1. Finalidade prevalente: a prevenção especial em função de um facto ilícito-típico

§ 4 De acordo com a razão histórica e político-criminal do seu aparecimento, as medidas de segurança visam a finalidade genérica de prevenção do perigo de cometimento, no futuro, de factos ilícitos-típicos pelo agente. Elas são por isso orientadas, ao menos prevalentemente, por uma finalidade de **prevenção especial** ou **individual** da repetição da prática de factos ilícitos-típicos. Por outras palavras, as medidas de segurança visam obstar, no interesse da segurança da vida comunitária, à prática de factos ilícitos-típicos futuros através de uma actuação especial-preventiva sobre o agente perigoso. A finalidade de prevenção especial ganha assim, também neste enquadramento, uma **dupla função**: por um lado, uma função de *segurança*, por outro lado, uma função de *socialização* (5). Mas já é questão complexa e discutida saber qual destas duas funções deve assumir a *primazia*.

§ 5 Se é a protecção específica dos interesses de segurança da vida comunitária que aqui está, de uma forma geral, em questão, poderia supor-se que também, em concreto, a função de *segurança* deve prevalecer sobre a função de *socialização*. Mas uma tal suposição não seria exacta. Exacto é, pelo contrário, que **o propósito socializador deve, sempre que possível, prevalecer sobre a finalidade de segurança**, como é imposto pelos prin-

(5) Se bem que — certamente no propósito de afastar a questionabilidade política e político-criminal da medida de segurança (sobretudo quando ela implica o *internamento* do agente) — não falte doutrina (máxime, uma parte da doutrina italiana) que pretende assinalar àquela uma finalidade *exclusiva* de educação ou de cura: cf., p. ex., MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, *Jus*, 1974, p. 498, e ROMANO, pré-art. 1, n.º 46.

cípios da socialidade e da humanidade que dominam a constituição político-criminal do Estado de Direito contemporâneo; e, consequentemente, que a segurança só pode constituir finalidade autónoma da medida de segurança se e onde a socialização não se afigure possível. Até porque através da segurança como tal não se torna possível lograr a socialização; enquanto esta, quando tenha lugar no quadro de uma medida privativa da liberdade, arrasta consigo um elemento de segurança pelo tempo do internamento respectivo.

§ 6 Esta doutrina deve pelo menos ser defendida como doutrina *de princípio*. O que significa que poderão existir **casos excepcionais** em que, por razões justificáveis, ela deva ser alterada (6). Uma excepção interessante (e político-criminalmente justificável) é constituída pelo preceito legal contido no art. 4.º da L 19/86, de 19-7, segundo o qual "quando qualquer dos crimes previstos nos artigos anteriores [*incêndios florestais*] seja cometido por indivíduo inimputável, ser-lhe-á aplicada, nos termos e limites da lei, a medida de segurança prevista no art. 91.º do CP, sob a forma de *internamento intermitente e coincidente com a época normal de fogos*". Que, neste caso, *a finalidade de segurança prevalece* sobre a de socialização (sem que, com isto, esta deva ter-se por abandonada), parece inquestionável.

§ 7 Também nas medidas de segurança, porém, como nas penas, a primazia concedida à função socializadora sobre a de segurança não deve induzir a pensar que é aquela função como tal que *justifica*, por si mesma, a aplicação de uma medida. O que a justifica é sempre e só a necessidade de prevenção da prática futura de factos ilícitos-típicos (e, nesta acepção, uma função de "segurança" em sentido amplo) (7). A partir daqui logo se torna indispensável a verificação da **perigosidade** *do agente*, do perigo de cometimento por ele, no futuro, de outros factos ilícitos-típicos. Mas não é isto bastante: a tentativa de operar uma socialização reputada necessária e possível encontra-se, ainda e sempre, na *dependência da prática, pelo agente, de um facto* qualificado pela lei como um **ilícito-típico**. Facto que não possui unicamente, contra o que ainda hoje pensa uma doutrina largamente dominante (8), o valor de "*sintoma*" de uma necessidade de socialização e do qual aquela se possa sem mais deduzir.

---

(6) Assim, na doutrina alemã, STRATENWERTH / KUHLEN, § 1, n.º 43.

(7) No sentido do texto, ANTUNES, Maria João, *O Internamento de Imputáveis em Estabelecimentos Destinados a Inimputáveis*, 1990, p. 156.

(8) Uma aprofundada consideração do ponto encontra-se em ANTUNES, Maria João, nota 1, p. 73 e s., e *passim*, sob o designativo das concepções do "facto desencadeador" e do "facto pressuposto".

§ 8 Nesta dupla exigência reside o *punctum saliens* de uma concepção moderna da medida de segurança, que corrige a concepção tradicional sobre a essência e a natureza daquela em vista da sua indispensável harmonização com a estadualidade de direito. Fundamento, se quisermos dizer assim, de aplicação de qualquer medida de segurança criminal não é em exclusivo a perigosidade do agente, como se pensava e ainda hoje prevalentemente se pensa. É sim — *e logo em nome da função de prevenção especial* de índole criminal cumprida pela medida de segurança — **aquela perigosidade apenas se e quando revelada através da prática pelo agente de um facto ilícito-típico**; facto que, deste modo, vem a assumir valor *constitutivo* da aplicação da medida de segurança e a conformar, ao lado da perigosidade, um dos dois fundamentos da sua aplicação.

§ 9 Numa recente e aprofundada investigação monográfica Maria João Antunes contesta esta função "constitutiva" ou "fundamentadora" do *facto ilícito-típico* para aplicação da medida de segurança *de internamento* a um agente *declarado inimputável em razão de anomalia psíquica*; sustentando que o facto *pressuposto* daquela aplicação não é o facto ilícito-típico, mas o "**facto do agente declarado inimputável em razão de anomalia psíquica**". Como contesta, coerente e consequentemente, a **transposição** (e eventual **correcção**) das categorias dogmáticas do facto do imputável — tipicidade, ilicitude, culpa, punibilidade (infra, 10.° Cap. e ss.) — para o facto do inimputável. Tendo a sua tese, para além do mais, a "vantagem de não supor a caracterização *dupla* do facto" (9).

§ 10 Cremos existir nesta argumentação um equívoco que importa esclarecer. Não é obviamente imperioso fazer valer o facto do agente *declarado* inimputável como o facto que é relevante para a *comprovação* da inimputabilidade. Sejam ou não idênticas as características dos "dois factos", uma coisa é o facto a que se refere o art. 20.°-1, outra coisa o facto a que se refere o art. 91.°-1 (10). Distinção a que Maria João Antunes não consegue todavia furtar-se quando se depara com a incondicional necessidade de preexistência de um facto que — para o distinguir do facto do declarado inimputável — chama "**facto concreto praticado**"; e relativamente ao qual

(9) ANTUNES, Maria João, nota 1, pp. 365 (s. n. o.) e ss., 433 e ss., 449 e ss.

(10) O que a própria A. acaba por reconhecer, quando repetidamente aceita a necessidade de "reequacionar o facto" e de um "retorno ao plano do facto e do crime": ANTUNES, Maria João, nota 1, p. 343, p. ex.

se poderia afirmar, assim argumenta, "que, afinal, a redacção primitiva do art. 91.º-1 — 'facto descrito num tipo legal de crime' — era adequada, com a vantagem de não pressupor o critério dominante da transposição das características do crime do agente imputável para o facto do agente inimputável" ([11]). Mas esta argumentação não procede. Mesmo a formulação original do art. 91.º-1 implicava *pelo menos* que o facto fosse um facto típico, objectiva e subjectivamente, já nele incluídos por conseguinte problemas dogmáticos dos mais árduos, como veremos (infra, 12.º Cap. e ss.) que são os da imputação objectiva, do âmbito e do fim de protecção da norma, do acordo, dos elementos subjectivos do tipo, do dolo e da negligência do tipo, etc. Por aqui, contra as melhores intenções da A. e pela via do seu "facto concreto praticado", **todo o problema que chama da transposição e eventual correcção renasce e clama por esclarecimento**.

§ 11 Em suma, também o facto do inimputável para efeito de comprovação da inimputabilidade e, por esta via, para indagação da perigosidade do agente e de eventual aplicação de uma medida de segurança (e não apenas de internamento) é, segundo a teleologia implicada nos propósitos político-*criminais* que presidem ao instituto das medidas de segurança criminais, o facto ilícito-típico, eventualmente acrescido dos supostos adicionais de punibilidade que ao facto se refiram ([12]): **facto ilícito-típico** e **perigosidade constituem os dois fundamentos autónomos da medida de segurança criminal**, de internamento ou outra. A alternativa ([13]) seria considerar, em definitivo, que o direito *penal* não deve continuar a intervir na contenção social da perigosidade dos inimputáveis, importando porventura pôr termo a uma fase "transitória" daquele em que à sanção natural do nosso ramo do direito (a pena) se juntou uma sanção só contextualmente imposta (a medida de segurança). Alternativa que todavia não podemos compartilhar pelos perigos que lhe vemos inevitavelmente ligados para a vertente garantística do Estado de Direito (também infra, § 17

([11]) ANTUNES, Maria João, nota 1, p. 377.

([12]) Cf. infra, 21.º Cap., § 41 e ss. E, sobre toda a questão, o nosso *DP II*, § 734 e s.

([13]) Pela qual ANTUNES, Maria João, nota 1, *passim*, nutre indisfarçável simpatia, sem todavia chegar a desimplicá-la nas suas consequências político-criminais e dogmáticas. Importante neste contexto é a problemática (jurídico-*administrativa*, mas estreitamente ligada às máximas do direito e do processo penal, em virtude da sua particular conexão com a protecção dos direitos, liberdades e garantias da pessoa) do *internamento compulsivo de doentes mentais*. Sobre o estado legal e doutrinário do problema, entre nós, AA.VV., *A Lei de Saúde Mental e o Internamento Compulsivo*, 2000.

e ss.); e porque a medida de segurança desempenha um papel importante e insubstituível na função de contenção e tratamento social do fenómeno da *criminalidade*.

1.2. Finalidade secundária: a prevenção geral

§ 12 A exigência da prática pelo agente de um facto ilícito-típico como pressuposto da aplicação de uma medida de segurança vem, deste modo, suscitar uma outra questão importante (e até agora praticamente inconsiderada na doutrina): o papel que a finalidade de prevenção *geral* deve jogar aqui. A resposta largamente dominante é a de que uma tal finalidade **não possui qualquer autonomia** no âmbito da medida de segurança: ela só pode ser conseguida de uma forma reflexa e dependente, na medida em que a privação ou restrição de direitos em que a aplicação e execução da medida de segurança se traduz (privação ou restrição da liberdade física, interdição de profissões, actividades ou exercício de direitos, etc.) possa servir para afastar a generalidade das pessoas da prática de factos ilícitos-típicos. Nomeadamente, quando aplicada a inimputáveis, diz-se, as exigências de prevenção geral não se fazem sentir, porque a comunidade compreende bem que a reacção contra a perigosidade individual é ali fruto exclusivo de condições endógenas anómalas; as quais não põem em causa as expectativas comunitárias na validade da norma violada, porque o homem normal não tende a tomar como exemplo o comportamento do inimputável ([14]).

§ 13 Esta consideração é, em princípio, bem fundada. E, todavia, parece incontestável que, relativamente a certas medidas de segurança, o legislador terá tido de forma autónoma em vista, ao criá-las, também o seu efeito de prevenção geral, mesmo sob a forma da (admissível) **prevenção geral negativa.** Como com razão sublinha Roxin, uma medida de segurança como a de *cassação da licença de condução de veículo motorizado* (art. 101.º) "actua sobre a generalidade de uma forma mais intimidante do que a pena cabida ao delito de tráfego" ([15]). Para além disto, porém,

([14]) Assim, ROXIN, Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit im Strafrecht, *Bockelmann-FS*, 1979, p. 303 (= ROXIN, *Culpabilidad y prevención en derecho penal*, trad. de Muñoz Conde, 1981, p. 176). Para Portugal, ANTUNES, Maria João, nota 7, pp. 54 e 155 e ss.; e para Espanha, por outros, LUZÓN PEÑA, *Medición de la pena y sustitutivos penales*, 1979, p. 46.

([15]) ROXIN I, § 3, n.º 64.

mesmo no que toca, de uma forma particular, às medidas de segurança *de internamento*, há razões político-criminalmente válidas (e também dogmaticamente fundadas) que induzem o convencimento de que uma finalidade de *prevenção geral positiva* deve estar ainda aqui presente de forma autónoma e não apenas da forma reflexa e dependente acima assinalada.

§ 14 Se a aplicação da medida de segurança se liga não apenas à perigosidade, mas sempre também à prática de um facto ilícito-típico, então isso só pode acontecer porque ela participa ainda da função de **protecção de bens jurídicos** e de consequente tutela das expectativas comunitárias ([16]). Depois, importa considerar que pressuposto da aplicação de uma medida de segurança não deve ser — logo por razões político-criminais óbvias, decorrentes das exigências da estadualidade de direito, directamente ligadas ao requisito da *proporcionalidade* como limite indispensável à aplicação de qualquer medida limitativa de direitos fundamentais — a prática de um *qualquer* facto ilícito-típico, mas só de um facto ilícito-típico *grave*. Poderá alegar-se que a gravidade do facto é aqui requerida apenas como *sintoma* de perigosidade e (ou) de necessidade de socialização. Mas o argumento não convence. Se assim fosse, a perigosidade deveria ser deduzida da gravidade do facto cometido; e não o é: o juízo sobre a perigosidade é autónomo e, na verdade, o mais importante e difícil dos juízos que há que formular em matéria de aplicação de medidas de segurança ([17]). Fica por isso próxima e fundada a convicção de que a exigência de que se trate de facto ilícito-típico *grave* é feita (ou é feita também, *mas já com autonomia*) em nome do abalo social por aquele causado na comunidade e da necessária estabilização das expectativas comunitárias na validade da norma violada.

§ 15 O bom fundamento desta afirmação parece assegurado, no ordenamento jurídico-penal português, face a uma norma como a do art. 91.º-2, ao dispor que quando "o facto cometido pelo inimputável corresponder a

([16]) Assim, mas sem retirar depois as conclusões que pareceriam devidas, ANTUNES, Maria João, nota 7, p. 155 e ss.

([17]) MONTEIRO, Cristina Líbano, *Perigosidade de Inimputáveis e "in dubio pro reo"*, 1997. Sobre o relacionamento da proporcionalidade da medida à gravidade do facto e à perigosidade do agente JORGE Barreiro, nota 1, pp. 46 e ss. e 90 e s. Sobre toda a questão, com muito interesse, FRISCH, *Prognoseentscheidungen im Strafrecht*, 1983, e Strafrechtliche Prognoseentscheidungen aus rechtswissenschaflicher Sicht, *in:* Frisch / Vogt (orgs.), *Prognoseentscheidungen in der strafrechtlichen Praxis*, 1994, p. 55.

crime contra as pessoas ou a crime de perigo comum puníveis com pena de prisão superior a 5 anos, *o internamento tem a duração mínima de 3 anos, salvo se a libertação se revelar compatível com a defesa da ordem jurídica e da paz social*". Antes da Reforma do CP de 1995 — que acrescentou ao art. 91.º-2 a ressalva acabada de referir — não faltava quem pretendesse estarmos perante uma mera *presunção legal de duração da perigosidade*; o que afastaria a hipótese de uma qualquer intervenção de ideias de prevenção geral de integração ([18]). Mas: mesmo que se tratasse daquela presunção, qual a finalidade que ela serve? E porque é ela feita neste caso e não noutros? Que não podem estar na sua base puras razões de prevenção especial (de segurança ou de socialização), mostra-o a circunstância de a presunção persistir — e com ela o internamento — mesmo que possa demonstrar-se que a perigosidade cessou, até ao ponto de expressamente se proibir a revisão da situação do internado (art. 93.º-3). Um tal regime é sinal de que se não trata aqui de uma presunção de duração da perigosidade, mas se trata de que, tendo sido cometido um crime grave de certa natureza, há razões particulares de *tranquilidade social* e de *tutela da confiança comunitária nas normas* a que — suposta sempre a perigosidade do agente à luz do facto cometido — a política criminal tem de responder, mesmo perante inimputáveis, através da aplicação de uma medida de segurança ([19]). Como o demonstra aliás a fórmula final utilizada pelo preceito legal em questão ("salvo se a libertação se revelar compatível com *a defesa da ordem jurídica e da paz social*"), que constitui a tradução mais fiel e terminante, justamente, do critério da prevenção geral positiva. A conclusão não pode pois deixar de ser a de que também no âmbito das medidas de segurança (embora não de forma prevalente, como sucede no âmbito das penas, antes meramente secundária) a finalidade de **prevenção geral positiva** cumpre a sua função e, na verdade, uma função autónoma, se bem que no momento da aplicação se exija incondicionalmente a sua associação à perigosidade. Com o que, de resto, ganharão nova luz exigências como as da prática de um ilícito-típico grave e de proporcionalidade enquanto pressupostos de aplicação da medida de segurança ([20]).

([18]) Assim, ANTUNES Maria João, nota 7, p. 97.

([19]) Contra, todavia — mesmo após a Reforma de 1995 —, ANTUNES, Maria João, Alterações ao sistema sancionatório — as medidas de segurança, *RPCC 8*, 1998, p. 58 e s., e nota 1, p. 477 e ss., bem como MONTEIRO, Cristina Líbano, nota 17, p. 146 e ss.

([20]) Esta nossa concepção recebeu agora o aplauso e um reforço de fundamentação da parte de NEVES, Curado, *A Problemática da Culpa nos Crimes Passionais*, 2006, que conclui

§ 16 Não deixa, de resto, de ser curioso (e importante, no presente contexto) acentuar que a sensibilidade perante a questão posta se tem afinado a um ponto tal, no contexto das preocupações actuais com a aferição dos pressupostos da estadualidade de direito do regime das medidas de segurança criminais, que ela foi levada — a propósito justamente das normas do CP português acabadas de referir, se bem que na redacção anterior à Reforma de 1995 — à sindicância do **Tribunal Europeu dos Direitos do Homem** de Estrasburgo, sob alegação de que aquelas normas violariam o disposto no art. 5.º-4 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Por sentença de 15-11-1996 o Tribunal decidiu — de acordo com o ponto de vista aqui defendido — que uma tal violação *não existia*, por isso que, face à alta gravidade do crime, se justificava razoavelmente a privação da liberdade pelo menos durante 3 anos ([21]).

2. O problema da legitimação

§ 17 Se o problema das finalidades da medida de segurança deve assim resolver-se no sentido de uma doutrina da *prevenção integral*, que combina (tal como a pena, embora de forma e em medida diferentes) finalidades de prevenção especial e de prevenção geral, a verdade é que a diferença essencial entre pena e medida de segurança, derivada de a aplicação daquela supor sempre a culpa e a desta a perigosidade, vem a ganhar reflexo primordial na questão da *legitimação* da medida de segurança. Esta legitimação decorre da sua aludida finalidade global de **defesa social**: de prevenção de ilícitos-típicos futuros pelo agente perigoso que cometeu um ilícito-típico grave. Deste modo se podendo compreender as exigências jurídico-constitucionais — que devem ser válidas em todo o ordenamento onde vigore a regra do Estado de Direito — de que a aplicação de medidas de segurança seja monopólio do poder judicial (art. 205.º-1 da CRP), por um lado; e de que, por outro, a sua aplicação fique na dependência dos princípios da necessidade, da subsidiariedade e da proporcionalidade ou proibição de excesso (art. 18.º-2 da CRP). Isto é, concretamente: que uma medida de segurança só possa ser aplicada para **defesa de um interesse comunitário preponderante** e em medida que se não revele **desproporcional** à gravidade do ilícito-típico cometido e à perigosidade do agente ([22]). Como só deste modo poderá aceitar-se que a aplicação da medida de segu-

(p. 493): "é assim inegável, como Figueiredo Dias tem afirmado, que a medida de internamento tem também em consideração fins de prevenção geral de integração".

([21]) Cf. GASPAR, António Henriques / ANTUNES, Maria João, Anotação à decisão de 15-11-1996 do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, "Caso Silva Rocha c. Portugal", *RPCC 7*, 1997, p. 131 e ss.

([22]) Minuciosamente sobre estas questões, JORGE Barreiro, nota 1, p. 539 e ss.

rança, não sendo função da ideia jurídico-penal de culpa, nem encontrando nesta o seu limite, todavia constitua uma reacção aceitável nos quadros do Estado de Direito como respeitadora da dignidade da pessoa. O princípio da defesa social assume, por conseguinte, a sua função legitimadora não quando considerado na sua veste puramente fáctica, naturalística e pragmática, antes sim, como justamente notou Nowakowski e é agora largamente aceite (23), quando conjugado com o **princípio da ponderação de bens conflituantes**. Com o princípio segundo o qual a liberdade da pessoa (de qualquer pessoa, mesmo do inimputável) só pode ser suprimida ou limitada, como escreve Roxin, "quando o seu uso conduza, com alta probabilidade, a prejuízo de outras pessoas que, na sua globalidade, pesa mais do que as limitações que o causador do perigo deve sofrer com a medida de segurança" (24).

§ 18 Fica com isto afastada uma concepção — extremamente perigosa e de todo o modo hoje inaceitável nos quadros do Estado de Direito (25) — segundo a qual para legitimação da medida de segurança criminal necessário se tornaria considerá-la dentro da categoria das **medidas puramente administrativas** (na doutrina italiana genericamente chamadas "medidas de prevenção" (26)). Uma tal concepção, por uma parte, lançaria a teoria da medida de segurança para fora do campo do direito penal e da política criminal (27), amputando esta e aquele de instrumentos sancionatórios essenciais à realização da sua função e das suas finalidades; e, de todo o modo, não conseguiria explicar a necessária jurisdicionalização *comum* da medida de segurança, nem tão-pouco a sua ligação indispensável a um ilícito-típico, que só na constituição político-*criminal* encontram a sua verdadeira razão de ser (28).

---

(23) NOWAKOWSKI, Zur Rechtsstaatlichkeit der vorbeugenden Massnahmen, *v. Weber-FS*, 1963, p. 98.

(24) ROXIN I, § 3, n.º 66.

(25) No entanto muito difundida, se não mesmo, em muitas doutrinas, ainda agora dominante: cf., p. ex., para Espanha, RODRÍGUEZ Devesa / SERRANO Gómez, *Derecho penal español, PG*, 15 1992, p. 987.

(26) Cf. AA. VV., *Le misure di prevenzione*, 1975, e, por último, FRAGOLA, *Le misure di prevenzione*, 1992.

(27) Como dissemos, supra, nota 13, que parece estar, ao menos para os inimputáveis, na linha de pensamento de Maria João Antunes.

(28) Nesta base chegou SAX, *Grundsätze der Strafrechtspflege*, *in*: Bettermann / Nipperdey / Scheuner (orgs.), *Die Grundrechte*, III/2, 1976, p. 964 e ss., a propor uma legitimação da medida de segurança através da ideia ("ético-jurídica") da "legítima defesa da comunidade".

§ 19 A **"administrativização" das medidas de segurança** encontrava apoio claro, em Portugal, na evolução por elas sofrida no período do Estado Corporativo, nomeadamente as que eram aplicadas a delinquentes políticos ([29]). Isso explica, por um lado, que muitos Autores, que inicialmente tinham dado o seu aplauso à ideia (que se pensava "progressista") da integração no sistema penal das medidas de segurança, tenham passado posteriormente a combatê-la ([30]). Como explica, por outro lado, que penalistas fiéis aos ideais democráticos tenham acabado por tentar expurgar do campo do direito penal a problemática das medidas de segurança, afastando-a para o campo das medidas puramente administrativas, como forma — todavia perversa! — de manter incólumes os princípios fundamentais da teoria e da política criminais; ao mesmo tempo que advogavam a consagração de um **sistema monista**, como forma de ilegitimar a aplicação de medidas de segurança a imputáveis, máxime, a delinquentes políticos ([31]). É óbvio, porém, que motivações deste tipo se encontram hoje ultrapassadas em toda a parte onde valha a regra do Estado de Direito e o princípio democrático e não devem, por isso, desempenhar qualquer papel nas orientações político-criminais e dogmáticas do momento presente.

§ 20 Só que, se é assim — pensou-se em uma outra vertente, oposta à que acaba de referenciar-se —, importa então **"eticizar" o fundamento da medida de segurança**, à semelhança do que se faz com a pena ao conexionar indissoluvelmente a sua aplicação com o pensamento da culpa jurídico-penal. E, nesta via, porque a conexão culpa / medida de segurança se torna impossível logo à partida, procurou Welzel estabelecê-la através do pensamento seguinte: o de que só estão legitimados para participar livremente na vida externo-social aqueles que possuem liberdade e autonomia interno-pessoal e podem por isso ser influenciados pelas normas. Ou dito por outra forma: toda a liberdade externo-social se legitima só, em último termo, perante a posse da liberdade moral interior, a qual não pertence nem aos doentes mentais, nem tão-pouco àqueles que, em virtude de más inclinações, herdadas ou adquiridas, se não encontram em condições de uma livre decisão a favor da norma. Por isso não podem estes ter

---

([29]) Sobre esta história, ALBUQUERQUE, Pinto de, A consagração de um novo direito securitário na reforma prisional de 1936, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 433 e ss. Em especial sobre o tratamento da criminalidade política, ID., ibidem, pp. 436, 447 e ss.

([30]) Cf., sobretudo, CARLOS, A. da Palma, Medidas de Segurança, *Jornal do Foro 26*, 1962, p. 18; e a controvérsia, que a propósito se estabeleceu, gerada por uma crítica dirigida àquele estudo e contida no *BMJ 126*, p. 495, bem como a resposta de CARLOS, A. da Palma, *Jornal do Foro*, 1964, p. 37 e ss., contendo uma carta de apoio de Cavaleiro de Ferreira.

([31]) Este terá sido o caso do ensino de Eduardo Correia. Como terá sido esta a razão por que o seu *ProjPG* de 1963 não encontrou nunca aceitação oficial até ao momento da democratização do Estado português, e foi logo aceite mal esta se verificou.

direito à plena liberdade externo-social, legitimando-se, quanto a eles, a aplicação de medidas de segurança privativas da liberdade ([32]).

§ 21 **Esta concepção** — à qual, guardadas as devidas proporções e intenções, se pode imputar uma certa semelhança com a criticada (supra, 3.º Cap., § 29 e s.) defesa de Jakobs de um "direito penal do inimigo" — **é, de todo o ponto, inaceitável** ([33]). Porque, para além do mais, as suas consequências seriam terríveis para quem, como os inimputáveis e os criminosos empedernidos ou habituais, são, em todo o caso, plenamente "pessoas". Uma concepção tal levaria, no extremo, a furtar a liberdade externo-social às pessoas não em nome dos factos ilícitos-típicos que houvessem cometido (e também neste contexto se revela a essencialidade deste pressuposto de aplicação de qualquer medida de segurança criminal), não em face do perigo que revelassem da sua repetição e da consequente necessidade comunitária de deles se defender; mas pura e simplesmente em nome da doença que os atingiu, da carga hereditária ou adquirida que sobre eles pesa e da consequente incapacidade de se deixarem motivar pelas normas. Numa palavra: *em nome da negação da própria liberdade*! Princípios que subjazem à teoria da medida de segurança em toda a parte onde vale a regra do Estado de Direito — nomeadamente, os princípios da tutela de interesses públicos preponderantes e da proibição de excesso — não teriam aqui sentido e lugar.

§ 22 Fala-se por vezes — é conveniente notá-lo — de uma "eticização" das medidas de segurança num sentido completamente diverso do que acaba de ser considerado: em vista do relacionamento da aplicação de medidas de segurança com a prática pelo agente de um **facto ilícito-típico** ([34]) e das consequências que daí decorrem, máxime, em matéria de conexão daquelas medidas com a matriz da prevenção geral (positiva) e de limitação legal da sua duração. Mas a referência, com este sentido, a uma "eticização" das medidas de segurança é equívoca e, com os fins acabados de referir, inútil, devendo por isso ser evitada. De "eticização" só será admissível falar — embora, ainda aqui, a equivocidade persista — para dar a entender que na legitimação da medida de segurança intervém, como se acentuou, um princípio de defesa

([32]) WELZEL, § 32, III.

([33]) Também JORGE Barreiro, nota 1, p. 542. Uma consideração das categorias dos inimputáveis e dos delinquentes habituais face aos binómios cidadão / inimigo e pessoa / não pessoa, agora, em SILVA Sánchez, Os indesejados como inimigos: a exclusão dos seres humanos do *status personæ*, *RPCC 16*, 2006, p. 7; cf. já supra, 3.º Cap., § 31 e s.

([34]) Assim, CORREIA, Eduardo, *in*: *Actas PG*, II, p. 265.

social não em pura veste naturalística, mas conexionado com uma *ponderação de bens conflituantes* e (sobretudo) limitado pela máxima absoluta da *preservação da dignidade da pessoa*, aqui assumida, como se dirá infra, §§ 24 e 31, em termos da exigência de *proporcionalidade*.

III. O relacionamento da pena com a medida de segurança: a questão do "monismo" ou "dualismo" do sistema

1. Medida de segurança e pena

§ 23 A conclusão a retirar de quanto fica exposto é a de que, em matéria de *finalidades* das reacções criminais, não existem diferenças fundamentais entre penas e medidas de segurança. Diferente é apenas a **forma de relacionamento entre as finalidades de prevenção geral e especial**. Na pena, a finalidade de prevenção geral positiva assume o primeiro e indisputável lugar, enquanto finalidades de prevenção especial de qualquer espécie actuam só no interior da moldura de prevenção construída dentro do limite da culpa. Na medida de segurança, diferentemente, as finalidades de prevenção especial (de socialização e de segurança) assumem lugar dominante, não ficando todavia excluídas considerações de prevenção geral de integração sob uma forma que, a muitos títulos, se aproxima das (ou mesmo se identifica com as) *exigências mínimas de tutela do ordenamento jurídico*.

§ 24 Não é pois no quadro das finalidades, mas fora dele e exactamente, como se exprime Roxin, na sua **mútua delimitação** que se suscita a diferença *essencial* entre penas e medidas de segurança ([35]): na circunstância de ser pressuposto irrenunciável da aplicação de qualquer pena a rigorosa observância do *princípio da culpa*, princípio que não exerce papel de nenhuma espécie no âmbito das medidas de segurança; e de, consequentemente, a medida de segurança ser determinada, na sua gravidade e na sua duração, não pela medida da culpa, mas pela existência da perigosidade, todavia estritamente limitada por um princípio de *propor-*

([35]) Insistindo todavia na "tensão" entre pena e medida de segurança, SCHÜLLER-SPRINGORUM, Von Spuren keine Spur, *Roxin-FS*, 2001, p. 1021; para concluir todavia, na linha do texto, que "não é mais a separação das águas entre penas e medidas de segurança que hoje caracteriza o pensamento e a argumentação político-criminais, mas o peso relativo da 'segurança' e do 'melhoramento' nos dois âmbitos" (p. 1043).

cionalidade ([36]). Daqui resultaria, ainda segundo Roxin ([37]), uma certa aproximação ao sistema **monista** das sanções criminais; no sentido de que as duas espécies de sanções todavia existentes, penas e medidas de segurança, seriam estabelecidas, segundo as suas finalidades, num sentido único e só na sua delimitação correriam vias distintas.

§ 25 Esta concepção é, como resulta de quanto ficou dito, de sufragar. Mas ela apenas aflora um problema nuclear de toda a matéria da adequação da medida de segurança criminal ao princípio do Estado de Direito. Problema ao qual a doutrina penalista portuguesa se tem mostrado, desde os anos 30 do século passado, extremamente sensível e no qual — já o dissemos supra, 4.º Cap., § 55 *in fine* — alcançou mesmo conclusões, doutrinais e legislativas, em larga medida originais. E problema que ainda hoje, apesar de menos intensamente debatido do que outrora na generalidade das doutrinas, ou mesmo até um pouco farisaicamente ignorado, é fonte de incontáveis equívocos e mesmo de eventuais entorses à plena democraticidade do sistema: o problema do *monismo* ou *dualismo* do sistema sancionatório ([38]).

2. O dualismo do sistema

§ 26 Há em primeiro lugar que esclarecer *o que seja* um sistema sancionatório criminal monista ou dualista. Como se acentuou (supra, § 1), pode um sistema ser considerado como *dualista* tão-só porque conhece, no seu arsenal sancionatório criminal, não somente penas, mas também medidas de segurança. Não é este, porém, o entendimento que deve estar em causa quando se afronta a questão monismo *versus* dualismo do sistema. Se este conhece a existência de medidas de segurança, mas as aplica apenas a **inimputáveis**, bem pode afirmar-se que nem por isso o sistema perde a sua característica monista, para assumir cariz dualista. Aqui, pena e medida de segurança têm os seus campos de aplicação *a priori* e diferentemente definidos, de tal modo que não existe sobreposição entre eles. E não existe ainda mesmo quando ao mesmo agente possa aplicar-se uma pena *e* uma medida de segurança, se bem que *por factos diferentes*. É perfeitamente possível, por exemplo, que o agente de um crime de violação, a que se seguiu o roubo da vítima, venha a ser declarado inimputável relativamente à violação (*v. g.*, porque actuou sob influência de uma neurose

([36]) ROXIN I, § 3, n.º 58.

([37]) Loc. cit.

([38]) É precisamente mérito assinalável de JORGE Barreiro, nota 1, ter em data recente reafirmado a importância e a actualidade do problema.

grave, determinante de uma tara de natureza sexual); mas seja já considerado imputável relativamente ao roubo. Caso em que lhe deverá ser aplicada uma pena pelo roubo *e*, eventualmente, uma medida de segurança pela violação. Ainda aqui, porém, o monismo do sistema não será afectado, porque não existe uma **acumulação** da pena com a medida de segurança como formas de reacção contra a criminalidade, antes, talvez possa dizer-se assim, pena e medida de segurança "convivem" numa sua divisão horizontal.

§ 27 Para Eduardo Correia o sistema não perderia a sua característica monista nem pelo facto de aplicar, ao lado de penas a imputáveis, medidas de segurança a inimputáveis (o que, como dissemos, pode aceitar-se), nem tão-pouco pelo facto de aplicar medidas de segurança a imputáveis, desde que tais medidas de segurança possuíssem **carácter não-detentivo**; pelo contrário, porém, a aplicação de medidas de segurança de internamento a um imputável faria sempre perder o cunho monista ao sistema, mesmo que, no caso, não houvesse lugar à aplicação de uma pena ([39]). Mas a redução da discussão entre monismo e dualismo às sanções detentivas (privativas de liberdade), se pode compreender-se por ser nesse domínio que se levantam os problemas mais graves, frequentes e que dão lugar a maiores dificuldades de execução, não é, em definitivo, fundada. A discussão político-criminal e dogmática de princípio entre monismo e dualismo deve ser colocada exactamente nos mesmos termos, trate-se de sanções privativas ou não privativas de liberdade.

§ 28 A verdadeira alternativa monismo / dualismo só surge quando se pergunta se o sistema é um tal que permite a **aplicação cumulativa ao mesmo agente, pelo mesmo facto**, de uma pena e de uma medida de segurança. Neste sentido se pode falar, para além de "sistema dualista", de **sistema de dupla via** ou de **duplo binário** ([40]). É aqui e só aqui que surge o problematismo específico da alternativa e esta se torna incontornável: saber se — relativamente às hipóteses em que, perante um facto ilícito-típico praticado por agente imputável, se verifica contradição entre as exigências acrescidas de prevenção da perigosidade (e de consequente defesa social) e o limite da culpa, insuficiente para dar resposta àquelas exigências — ainda é possível, legítimo e conveniente estender o conceito de culpa e a medida da pena até um ponto em que a intervenção de uma

([39]) CORREIA, Eduardo, I, n.º 17 (p. 72), e *ProjPG*, p. 61; segue-o ROCHA, M. A. Lopes, O novo Código Penal Português. Algumas considerações sobre o sistema monista das reacções criminais, *in:* AA.VV., *Para uma Nova Justiça Penal*, 1983, p. 33 e ss.

([40]) Assim, ANTUNES, Maria João, nota 7, p. 127 e ss. No mesmo sentido, na doutrina brasileira, já FRAGOSO, Heleno, Sistema do duplo binário, *RDPC 32*, 1981, p. 7 e nota 5.

medida de segurança se torne dispensável. Se a questão receber uma resposta afirmativa, pode então pensar-se na adopção de um sistema monista, ao qual são imputadas claras vantagens do ponto de vista da *execução* da sanção. Se, pelo contrário, a resposta for negativa, então a adopção de um sistema dualista parece impor-se em definitivo.

§ 29 Sendo estes os verdadeiros limites da controvérsia "monismo *versus* dualismo", bem pode afirmar-se que ela se suscita não só como questão teorética geral da doutrina das medidas de segurança, mas como problema específico da resposta *legislativa* a dar à questão dos *delinquentes especialmente perigosos*. E é assim, na verdade, que ela tem sido considerada desde sempre pela doutrina portuguesa mais representativa (41).

3. Monismo e dualismo: estado actual da controvérsia e perspectivas futuras

§ 30 Qualquer sistema dualista na acepção acabada de precisar — apesar de continuar a ser, nas diversas legislações, porventura dominante — está hoje sujeito a uma crítica pesada, centrada sobretudo na consideração de que, por esta forma, se põem irremediavelmente em causa o princípio da culpa e os fundamentos político-constitucionais em que este repousa. Por esta razão se fala frequentemente de uma "crise actual do dualismo", que todavia era já conhecida e analisada aprofundadamente pela doutrina portuguesa, como dissemos, desde os anos 30 do séc. XX. Não tem sentido, argumenta-se, aplicar uma pena estritamente sujeita ao *princípio da culpa*, para depois a **complementar** com uma medida de segurança que, por definição, não está limitada pela culpa e se funda numa qualidade "naturalística" da personalidade do agente como é a da sua perigosidade social. Perante uma solução deste tipo, acrescenta-se, continuar a afirmar o carácter (político-constitucionalmente e político-criminalmente) intocável do princípio da culpa constituirá puro farisaísmo (42).

---

(41) Cf. SANTOS, Beleza dos, *Nova Organização Prisional*, 1947, p. 1 e ss., Medidas de segurança e prescrição, *RLJ 80*, 1947, p. 213, e Récidivistes et délinquants d'habitude, *RScCrim*, 1954, p. 710; FERREIRA, Cavaleiro de, *A Personalidade do Delinquente na Repressão e na Prevenção*, 1943, p. 55 e ss.; CORREIA, Eduardo, I, n.º 17; e DIAS, Figueiredo, *Liberdade*, p. 254 e ss. Uma minuciosa análise encontra-se em HÜNERFELD, *Die Entwicklung der Kriminalpolitik in Portugal*, 1971, pp. 214 e ss., 225 e ss. e 235 e ss., e agora em ALBUQUERQUE, Pinto de, nota 29, p. 442 e ss. V., também, SILVA, Marques da, I, p. 75 e s., e CARVALHO, Taipa de, I, § 110 e ss.

(42) Assim, com veemência, CORREIA, Eduardo, *ProjPG*, p. 31, e, na doutrina italiana, também, ROMANO, pré-art. 1.º, n.º 44. Num sentido mais atenuado e próximo do texto, RODRIGUES, Anabela, A fase de execução da pena, *BMJ 380*, 1988, p. 54.

§ 31 Há neste argumento muito de verdade, podendo ele constituir um poderoso convite a que se *limite* por todas as formas possíveis o sistema dualista, nomeadamente no que toca ao tratamento dos delinquentes especialmente perigosos. Em definitivo, porém — por mais impressionante que à primeira vista possa parecer —, ele não é fundado. As exigências de defesa social perante a criminalidade constituem, também elas, **um postulado do Estado de Direito e de uma política criminal eficiente e racional**, por um lado. Por outro lado, se é exacto que a preservação da eminente dignidade da pessoa humana constitui, como atrás já variamente se acentuou, o fundamento da exigência incondicional de culpa como pressuposto de aplicação da pena, não menos exacto é que, sendo a culpa a forma *óptima* de limitação do poder sancionatório do Estado, não é todavia a *única*. Se o fosse, o princípio da culpa, com um sentido e um conteúdo substancialmente análogos aos que lhe presidem no direito penal, teria de ser um princípio jurídico-constitucional de *todo* o ordenamento jurídico sancionatório (civil, administrativo, etc.); e não o é. Outras formas existem, na verdade, que não a da exigência de culpa em sentido jurídico-penal, de limitação do poder do Estado, também elas podendo e devendo ser reconduzidas a expressões da eminente dignidade da pessoa. É o que sucede, nomeadamente, com o **princípio da proporcionalidade** (ainda ele um princípio jurídico-constitucional) que preside, como foi já sublinhado, à aplicação de qualquer medida de segurança. Se a tal princípio acrescentarmos outros como os da *necessidade* e da *subsidiariedade*, teremos de concluir ser um **sistema dualista** por um lado legítimo à luz dos princípios do Estado de Direito (nomeadamente, do princípio basilar da preservação da dignidade da pessoa), por outro lado político-criminalmente adequado às exigências de uma defesa social racional. O problema do dualismo não está pois tanto aqui, quanto em lograr uma correcta **articulação entre a pena e a medida de segurança** — nomeadamente, quando uma e outra sejam *privativas da liberdade* — **sempre que cumulativamente aplicáveis ao mesmo delinquente**.

§ 32 Essa articulação é alcançável através de um equilibrado sistema de **vicariato na execução**. Um sistema, isto é, em que a execução de ambas as sanções, na expressão paradigmática de Zipf, possa ser concebida "como *unidade de efeitos reciprocamente determinados*" (43). Se

(43) Zipf, *in*: Roxin et alii, *Einführung in das neue Strafrecht*, 1974, p. 106.

isto for possível, e na medida em que o seja, ficará afastada uma outra objecção que sempre se opõe ao sistema do duplo binário: a de que a execução (em princípio sucessiva) das duas espécies de sanção sobre o mesmo agente porá inevitavelmente em causa o propósito socializador que constitui a finalidade por excelência da medida de segurança e uma das finalidades que, sempre que possível, deve também ser almejada pela pena ([44]).

§ 33 Também neste argumento existe muito de procedente. Se a primeira das sanções a executar tiver cumprido a sua finalidade socializadora, surge então o cumprimento da segunda sem sentido à luz desta finalidade, quando não mesmo a prejudique e ponha em causa o cariz socialmente positivo que coube à execução da primeira. E, com isto, é o próprio princípio da estadualidade de direito da constituição político-criminal que fica em causa. Mas à procedência deste argumento se tem procurado atalhar, justamente, através da ideia do "vicariato" na execução. Ideia que só há relativamente pouco tempo começou a fazer caminho, que é entendida nas diversas doutrinas e legislações que a consagram com um sentido e uma extensão muito diversos ([45]), mas que é redutível a um núcleo essencial. Esse **núcleo essencial** deve residir nas traves seguintes ([46]): (1) a medida de segurança deve ser executada *antes* da pena de prisão e nela descontada, por ser esta a solução em princípio mais favorável à socialização do delinquente; (2) na segunda sanção a cumprir devem ser imputados todos os efeitos úteis que com a execução da primeira tenham sido alcançados; (3) à execução no seu todo devem ser aplicadas as medidas de substituição e os incidentes de execução que possam favorecer a socialização, nomeadamente a suspensão da execução e (ou) a libertação condicional.

§ 34 Se este programa — e é ele que hoje se contém, de forma suficientemente explícita, no art. 99.º após a Reforma de 1995 — for realizado com êxito e na medida em que o seja, não parecerá justificado o pessimismo de quem pensa que o princípio do vicariato só ajuda dentro de estreitos limites; antes devendo, pelo contrário, dizer-se que deste modo se

([44]) SANTOS, Beleza dos, *Nova Organização*, nota 40, p. 20 e s.; e CORREIA, Eduardo, A doutrina da culpa na formação da personalidade, *RDES I*, 1945, p. 35.

([45]) MARQUARDT, *Dogmatische und kriminalpolitische Aspekte des Vikariiens*, 1972, p. 34, ANTUNES, Maria João, nota 7, p. 135 e ss., e nota 19, p. 60 e ss., JORGE Barreiro, nota 1, p. 568 e ss., CARVALHO, Taipa de, I, § 162 e ss.

([46]) Também ANTUNES, Maria João, nota 19, p. 60 e ss.

abrem vias de realização aos sistemas dualistas que, de outra forma, ficariam fechadas. Ao mesmo tempo que se abre a possibilidade de consagração de um **sistema monista prático**, que reage contra a criminalidade especialmente perigosa com instrumentos formalmente considerados como penas mas que constituem, de um ponto de vista substancial, verdadeiras medidas de segurança ([47]).

§ 35 É o que sucede com o CP português, ao punir a categoria dos delinquentes especialmente perigosos com uma **pena relativamente indeterminada**: uma pena que tem um mínimo correspondente a 2/3 da pena que concretamente caberia ao crime cometido e um máximo correspondente a esta pena acrescida de 6, de 4 ou de 2 anos (cf. arts. 83.º a 90.º); e cuja duração concreta só durante a execução será determinada (art. 90.º e CPP, art. 509.º) ([48]). Esta pena relativamente indeterminada — diferentemente do que pensava Eduardo Correia ([49]) — não pode conceber-se na sua inteireza como uma *pena da culpa*. É antes (como se tornou em definitivo claro, repete-se, após a Reforma de 1995 do CP) um *misto de pena e de medida de segurança*: de pena até ao limite da sanção que concretamente caberia ao facto, eventualmente agravada já em função da "culpa da personalidade"; de medida de segurança na parte restante, comandada pela persistência da perigosidade do delinquente. Mas solução, em todo o caso, político-criminalmente preferível à da mera "adição" de uma pena e de uma medida de segurança aplicadas ao agente pelo mesmo facto, na medida em que permite alcançar por forma óptima as finalidades que se propõe o sistema do vicariato. Solução que assim realiza — dentro de pressupostos inatacáveis do ponto de vista da regra do Estado de Direito — aquele **monismo prático** que a doutrina de Beleza dos Santos propunha e que justifica que o sistema português das sanções criminais possa ser considerado, com inteira propriedade, um **sistema tendencialmente monista** ([50]).

([47]) No mesmo sentido, ANTUNES, Maria João, nota 19, p. 64.

([48]) Em pormenor sobre o instituto, DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 875 e ss.

([49]) *ProjPG*, p. 56 e ss.

([50]) Na conclusão também, SILVA, Marques da, I, p. 76. Qualifica através destas mesmas palavras o actual sistema espanhol, JORGE BARREIRO, nota 1, p. 570 e ss.

6.º CAPÍTULO

O COMPORTAMENTO CRIMINAL E A SUA DEFINIÇÃO: O CONCEITO MATERIAL DE CRIME

I. O conteúdo material do conceito de crime

1. A perspectiva positivista-legalista: do conceito "formal" ao conceito "material" de crime

§ 1 À pergunta sobre o que seja *materialmente* o crime pode antes de tudo responder-se (e essa foi a resposta dada durante todo o longo período em que na ciência do direito vigoraram as concepções próprias do positivismo legalista) que ele será **tudo e só aquilo que o legislador considerar como tal**. Seria unicamente a circunstância de o legislador ter ameaçado a prática de determinado facto com uma pena criminal que "transforma" aquele facto em comportamento criminal; com o que o conceito *material* de crime viria a corresponder afinal ao que se disse ser o seu conceito *formal* (supra, 1.º Cap., § 1).

§ 2 Uma tal concepção é **inaceitável** e **inútil**. Quando se pergunta pelo conceito material de crime procura-se uma resposta, antes de tudo, à questão da **legitimação material** do direito penal, isto é, à questão de saber qual a fonte de onde promana a legitimidade para considerar certos comportamentos humanos como crimes e aplicar aos infractores sanções de espécie particular. Questão esta que, nos quadros da concepção agora em análise, fica inteiramente sem resposta, ao identificar a legitimação *material* com a observância do procedimento *formal* adequado ao Estado de Direito, isto é, com a mera observância do *princípio da legalidade* em sentido amplo. Pressuposta a plena capacidade do legislador para dizer o que é e o que não é crime, nada fica a saber-se sobre quais as *qualidades* que o comportamento deve assumir para que o legislador se encontre legitimado a submeter a sua realização a sanções criminais.

§ 3 Em segundo lugar, uma concepção como a exposta não permite ligar a questão do conceito material de crime ao problema, em que aquela verdadeiramente se inscreve, da **função** e dos **limites** do direito penal. A pergunta por um conceito material de crime só tem sentido se um tal conceito se situar *acima* ou *atrás* — mas, em todo o caso, sempre *fora* — do direito penal legislado. O conceito material de crime é, neste sentido, *previamente dado* ao legislador e constitui-se em *padrão crítico* tanto do direito vigente, como do direito a constituir, indicando ao legislador aquilo que ele pode e deve criminalizar e aquilo que ele pode e deve deixar fora do âmbito do direito penal (1). Com um tal conceito deve poder medir-se a correcção ou incorrecção político-criminal de cada uma das incriminações constituídas ou a constituir; alimentar a discussão científica sobre a criminalização e a descriminalização; e lograr a ligação referida supra, 3.º Cap., § 39, entre os três domínios da ciência penal global: o da política criminal, o da dogmática jurídico-penal e o da criminologia, bem como a colaboração frutuosa entre estes domínios e a "enciclopédia das ciências criminais" ou ciências auxiliares do direito penal. Todas estas *funções* do conceito de crime — e por aí do próprio direito penal — se tornam inalcançáveis (e na verdade sem sentido) perante um conceito de crime como o agora em consideração.

§ 4 A *autonomização* do conceito material face ao conceito formal de crime constitui uma necessidade científica já sentida desde os tempos de Beccaria e do seu fundamental *Dei delitti e delle pene* (1764). Bem podendo dizer-se que, a partir de então, não mais ela foi estranha ao labor dos penalistas, dos cultores da política criminal e da criminologia. Presente, de uma forma acabada, em v. Liszt (2), a tarefa ocupou depois, de forma particular, a ciência criminológica, que sempre se recusou, a justo título, a trabalhar com um conceito de crime que resultasse acriticamente de um certo ordenamento positivo jurídico-penal. Os esforços para erigir, em vez do conceito jurídico de crime (que seria o conceito legal-formal), um conceito **criminológico** de crime — o *comportamento desviante* — não representam senão fases da tentativa de

(1) A questão vem deste modo a reverter àquilo que no 3.º Cap., III, 1, 1.2, caracterizámos como a essência mesma da *política criminal* no seu sentido actual. Aceitando esta proposição, mas emitindo um juízo muito céptico sobre a "capacidade de rendimento" de um conceito material de crime, por último, KUHLEN, Es possible limitar el derecho penal por medio de un concepto material de delito?, *in*: Wolter / Freund (orgs.), *El sistema integral del derecho penal. Delito, determinación de la pena y processo penal*, 2004, p. 129 e ss.; temperando em larga medida este cepticismo — em nosso modo de ver com razão —, FRISCH, Delito y sistema del delito, *ibidem*, p. 193 e ss. Completamente no sentido do texto, ROXIN I, § 2, n.º 1.

(2) Der Begriff des Rechtsguts im Strafrecht und in der Enzyklopädie der Rechtswissenschaften, *ZStW 8*, 1888, p. 133.

construção de um conceito material de crime (3). Com isto, porém, encontramo-nos já no domínio da perspectiva que em seguida será considerada.

2. A perspectiva positivista-sociológica

§ 5 Um esforço sério e continuado de ultrapassar as deficiências notórias com que se debateu a concepção positivista-legalista do crime residiu na tentativa de encontrar o conteúdo deste numa **noção sociológica** (4). O que importaria seria divisar, atrás da multiplicidade das manifestações legais do crime, aquilo que em termos de objectividade e universalidade pudesse, à luz da realidade social, ser como tal considerado; de algo que, no dizer de Garofalo, "existiria na sociedade humana [como crime] independentemente das circunstâncias e exigências duma dada época ou concepção particular" (5).

§ 6 Historicamente, a primeira tentativa nesta via é a de Garofalo, para quem o crime deveria corresponder à *violação de sentimentos altruísticos* fundamentais: a *piedade*, que constituiria o sentimento geral violado pelos crimes contra as pessoas, e a *probidade*, sentimento violado pelos crimes contra o património. Assim se construiria a noção de **delito natural**, a qual seria "sensivelmente igual para todos os povos de idêntica raça e civilização" e teria como denominador comum a característica de possuir na sua base uma *conduta socialmente danosa*. Na mesma linha se poderá referir a construção posterior de Durkheim que, todavia, começando por determinar os sentimentos cuja violação constituiria o crime não em termos de comunidade civilizacional, mas nos parâmetros mais circunscritos de uma formação social concreta, politicamente organizada, acabava por abandonar a tentativa de determinação material dos sentimentos violados e por optar por uma sua caracterização formal: serem *comuns* à consciência colectiva, *fortes* e *precisos*. A única característica comum a todos os crimes residiria assim no facto de "constituírem actos universalmente reprovados pelos membros de cada sociedade" (6). Neste contexto ainda, e de uma forma que se tornou paradigmática, afirmou v. Liszt: "Crime é a agressão, tida na perspectiva do legislador como especialmente danosa para uma dada ordenação social, a interesses juridicamente protegidos, pelo lado da perigosidade social revelada em tal agressão por uma personalidade responsável" (7).

---

(3) Sobre isto, em perspectiva criminológica, DIAS / ANDRADE, p. 63 e ss.

(4) De novo, DIAS / ANDRADE, p. 70 e ss. E com grande pormenor, DIAS, Silva, *"Delicta in se" e "delicta mere prohibita": uma Análise das Descontinuidades do Ilícito Penal Moderno à Luz da Reconstrução de uma Distinção Clássica*, 2003, p. 147 e ss.

(5) GAROFALO, *Criminologia*, 1885.

(6) DURKHEIM, *A Divisão do Trabalho Social*, 1893, I (tradução portuguesa de 1977), p. 91 e ss.

(7) V. LISZT, nota 2.

§ 7 Convém acentuar, de resto, que a ideia de Garofalo de construção de um "delito natural" merece ainda apreço de um outro ponto de vista que hoje se revela extremamente frutuoso para o trabalho da dogmática jurídico-penal: o de chamar a atenção para a circunstância de, na generalidade das ordens jurídico-penais, coexistirem crimes (os *delicta in se* ou *delicta naturaliter proba*, de que já falava a doutrina do direito romano) cujas condutas são **axiologicamente relevantes** — porque lhes preexiste uma valoração negativa do ponto de vista social, moral ou cultural — antes e independentemente de serem considerados como crimes pelo legislador, com outros crimes (os *delicta mere prohibita*) cujo comportamento é constituído em ilícito somente *através da sua proibição pela lei*, uma vez que as condutas consideradas são, no sentido exposto, **axiologicamente neutras** (8). E de chamar ainda a atenção para que só o primeiro grupo, não o segundo, deveria ser elevado à categoria de verdadeiro *crime*. É esta ideia básica que continua hoje no centro das discussões à roda do critério essencial de distinções como as que intercedem entre "direito penal" e "direito de mera ordenação social" (ou "das contra-ordenações": infra, 7.º Cap., I) ou entre autênticas faltas de consciência do ilícito e meros erros sobre proibições legais (9).

§ 8 A tentativa de definir materialmente o crime como uma **unidade de sentido sociológico**, autónoma e anterior à qualificação jurídico-penal legal, passou a constituir uma ideia básica adquirida da dogmática do direito penal. A ponto de ainda hoje o propósito de uma parte extensa e substancial da doutrina italiana de traduzir aquela unidade através do conceito de **ofensividade** (*offensività* (10)) dever reconduzir-se no essencial a esta linha metodológica. Como igualmente a concepção, porventura prevalente no pensamento penal anglo-americano, de ver no crime em sentido material a expressão de um **princípio do dano** (*harm principle*) que já em 1859 John Stuart Mill colocava, no seu escrito célebre *On liberty*, como princípio fundamental da criminalização e da consequente limitação do poder estadual (11). Em favor de toda esta orientação há que reconhecer que, com ela, se procura pela primeira vez — descontada, naturalmente, toda

---

(8) Sobre esta distinção romanista e sobre a sua evolução, já o nosso *O Problema*, § 2, I, e § 5, III. Numa via completamente diferente, DIAS, Silva, nota 4, *passim*, pretende traçar a linha entre as duas espécies de delitos por sobre a fronteira que separa a validade / legitimação (*delicta in se*) da invalidade / ilegitimação — e consequente inconstitucionalidade (*delicta mere prohibita*) — jurídico-penal. Cf. infra, § 22 e ss.

(9) De novo o nosso *O Problema*, § 20, e infra, 13.º Cap., § 31 e ss. Cf., também, os arts. 16.º-1, 2.ª parte, e 17.º-1.

(10) Sobre esta ideia, COSTA, Faria, *O Perigo em Direito Penal*, 1992, p. 620 e ss.

(11) Por aqui se ligando ele à doutrina do Iluminismo penal europeu. Sobre esta concepção agora, em síntese, ROXIN I, § 2, n.º 123 e ss., sobretudo na base de FEINBERG, *The moral limits of the criminal law*, 4 vols., 1984-8.

a *tradição jusnaturalista* que atravessou a antiguidade clássica, a escolástica medieval e o pensamento moderno ([12]) — estabelecer, de forma concertada e sistemática, um **conceito pré-legal de crime**; um conceito que, como tal, possui viabilidade para se arvorar naquele padrão crítico do direito vigente e do direito a constituir sem o qual o conceito material de crime se torna imprestável.

§ 9 Se bem que verdadeiras na sua essência e louváveis nos seus propósitos, as concepções acabadas de referir revelam uma muito menor "capacidade de rendimento" na determinação do conceito material de crime do que aquelas que o traduzem na *tutela subsidiária de bens jurídico-penais* e que infra, § 15 e ss., serão expostas. Deve-se-lhes desde logo censurar a sua **imprecisão**, que se torna insuportável quando se queira, como se quer, erigi-las em padrão crítico de toda a criminalização. Décadas de especulação à volta do problema não foram capazes de determinar com um mínimo de segurança em que consistiria a ofensividade ou a danosidade sociais determinantes da "essência" do crime. Acresce que, para além da sua imprecisão, estas concepções se revelam **demasiado largas** para por elas se alcançarem — e é esse, a par da legitimação funcional, o outro propósito primário desta investigação — os *limites da criminalização*. Mesmo que possa concordar-se que todo o crime se traduz num comportamento determinante de uma danosidade ou ofensividade social, a verdade é que nem toda aquela danosidade deve legitimamente constituir um crime. O apelo à danosidade social é pois um elemento constitutivo do conceito material de crime mas não pode sem mais fazer-se valer por aquele conceito ([13]). Isto mesmo terá compreendido o legislador português de 1995 (supra, 4.º Cap., § 74), ao adscrever à pena e à medida de segurança criminais a função de *tutela de bens jurídicos* e não de protecção perante uma qualquer ofensividade ou danosidade social.

§ 10 Para se avançar com *exemplos* evidentes, o comportamento mentiroso acarreta as mais das vezes consigo danosidade social, mas é seguro que nem toda a mentira socialmente danosa deve constituir um crime; e o mesmo se diga do com-

([12]) Sobre ela, pormenorizadamente, DIAS, Silva, nota 4, pp. 44-157.

([13]) No essencial da conclusão, depois de uma larga indagação, também agora FARIA, Paula Ribeiro de, *A Adequação Social da Conduta no Direito Penal — ou o Valor dos Sentidos Sociais na Interpretação da Lei Penal*, 2003, pp. 41 e ss., 67 e ss. Cf., por último, ABANTO VASQUEZ, Acerca de la teoria de bienes jurídicos, *Revista Penal 18*, 2006, p. 3.

portamento socialmente grosseiro ou mal-educado, do comportamento desleal (mesmo em matéria negocial), etc. Mas o principal é — para além destes casos óbvios — que os critérios da ofensividade ou da danosidade social não auxiliam a resolver os casos de fundada dúvida sobre a legitimidade de incriminações de condutas como, *v. g.*, o do mero consumo de drogas, o do incesto entre adultos, o do auxílio à prostituição consciente e desejada, o da prática em círculo privado de jogo de fortuna ou azar, o da tentativa de suicídio, etc., quando não apontam para uma solução incorrecta do problema. Não é impossível — bem pelo contrário — considerar a generalidade daquelas condutas, ao menos em muitas hipóteses, como socialmente ofensivas ou danosas, sem que por isso deva logo concluir-se pela legitimidade da sua criminalização (infra, § 31 e ss.).

3. A perspectiva moral (ético)-social

§ 11 À passagem do Estado de Direito formal ao Estado de Direito material correspondeu a introdução no conceito material de crime de um ponto de vista moral (ético)-social que leva a ver na "essência" daquele a **violação de deveres ético-sociais elementares ou fundamentais**. Paradigmática, a este propósito, é a lição de Welzel, para quem a "tarefa central" do direito penal residiria em "assegurar a validade dos valores ético-sociais positivos de acção": "a tarefa primária do direito penal" — escreveu ele logo em 1947 — "consiste na protecção dos valores elementares de consciência, de carácter ético-social, e só por inclusão na protecção dos bens jurídicos particulares"; "missão do direito penal é a protecção dos bens jurídicos mediante a protecção dos elementares valores de acção ético-sociais" ([14]). Como não menos paradigmática é a lição de Jescheck, segundo o qual são os "valores fundamentais da ordem social", consubstanciados em normas ético-sociais, que ao direito penal cabe tutelar ([15]).

§ 12 Esta concepção corresponde, para além do mais, a uma atitude enraizada no espírito da generalidade das pessoas, para quem o direito penal constituiria a tradução, no mundo terreno, das noções de pecado e de castigo, vigentes na ordem religiosa, ou de imoralidade e de censura da

([14]) WELZEL, § 1, I, 1 e 2 (a 1.ª ed. é de 1947 e nela se encontravam já formulações idênticas às transcritas). Preceu-nos aproximar-se agora desta concepção, em alguma medida, PALMA, Fernanda, *O Princípio da Desculpa em Direito Penal*, 2005, p. 122 e ss., embora porventura apenas como uma espécie de "limite negativo" da legitimidade da intervenção penal. No sentido deste entendimento também, NEVES, Curado, *A Problemática da Culpa nos Crimes Passionais*, 2006, p. 318.

([15]) JESCHECK / WEIGEND, § 1, I.

consciência, vigentes na ordem moral. Mas nem por isso pode uma tal concepção merecer, no plano da ordem jurídica estatal e, em particular, da ordem jurídico-penal, aceitação. **Não é função do direito penal** nem primária, nem secundária **tutelar a virtude ou a moral**: quer se trate da moral estadualmente imposta, da moral dominante, ou da moral específica de um qualquer grupo social. Para isso não está legitimado o direito penal, como ordem terrena que tem de respeitar a liberdade de consciência de cada um (art. 41.º da CRP) e só pode valer como "uma triste *necessidade* num mundo de seres imperfeitos que são os homens" ([16]). Nem, por outro lado, os instrumentos de que se serve para a sua actuação, as penas e as medidas de segurança criminais, se revelam adequados para fazer valer no corpo social as normas da virtude e da moralidade. Nem, ainda por outro lado, para aplicação de um direito com um tal sentido se encontram credenciados os magistrados e os tribunais, por isso que instâncias legitimadas para castigo do pecado e da imoralidade só podem ser, respectivamente, a divindade e a consciência.

§ 13 Uma concepção deste teor é pois absolutamente inadequada à estrutura e às exigências (mesmo, ou sobretudo, às exigências *éticas*!) das sociedades democráticas e pluralistas dos nossos dias. Não porque, como já houve quem criticasse, uma tal concepção redundasse necessariamente numa confusão inextricável — contrária ao pensamento e à tradição iluministas — entre o direito (penal) e a moral, pois que o direito constituiria em todo o caso apenas, no conhecido dizer de Georg Jellinek, um "mínimo ético", que já de si conferiria à tutela penal um carácter inevitavelmente fragmentário e lacunoso, a contrastar com a natureza (tendencialmente) completa e total da tutela religiosa e da tutela moral. E talvez nem tanto porque a concepção em exame conferisse ao direito penal uma função de mera "conservação" das concepções morais-sociais vigentes, a ela furtando à partida a possibilidade de contribuir para a *promoção* de valores sociais, culturais e económicos própria do Estado de Direito social; por isso que uma tal função de "promoção" deve prioritariamente ser reservada a meios não penais de política social, sendo muito limitado (embora em alguma medida existente, ao menos como coadjuvante) o papel que legitimamente se pode aí atribuir ao direito penal. Mas porque, em definitivo,

---

([16]) Expressão paradigmática — e hoje mil vezes repetida — do *AE*, a propósito da justificação do sentido da pena criminal.

uma tal concepção não se adequa ao **pluralismo ético-social** das sociedades contemporâneas, onde, em maior ou menor medida, coexistem — por vezes de forma pacífica, por outras de forma tensa — zonas de consenso com zonas de conflito ([17]), o que nem sequer permite que uma tal concepção possua hoje capacidade para se arvorar em padrão crítico de um ordenamento jurídico-penal positivo constituído ou a constituir; como se não adequa às exigências da moral própria de sociedades secularizadas ([18]), onde se torna instante a palavra já tão antiga, quanto sábia de Tomás de Aquino segundo a qual o legislador não deve deixar-se seduzir pela tentação de tutelar com os meios do direito penal todas as infracções à "moral objectiva" ([19]).

§ 14 Pode fixar-se de algum modo o reconhecimento da insustentabilidade da concepção agora em análise, em termos de legitimação, no momento (1966 e anos seguintes) em que na Alemanha surgiu o *Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches*, redigido por 14 professores de direito penal como resposta às objecções que na sociedade alemã ocidental havia suscitado a publicação do Projecto governamental de CP (E1962), profundamente conservador. Compreensivelmente, a questão começou por se centrar no direito penal *sexual*, por isso que o projecto governamental alemão continuava a considerar puníveis condutas como a da homossexualidade entre adultos, a sodomia, a "desmoralização" *(Kuppelei)*, a pornografia e outros comportamentos análogos. Consideração que o Projecto Alternativo substituía pela ideia político-criminal rigorosa e incensurável — e de que a reforma do CP português de 1995 dá testemunho ([20]) — de que não deve ser punível qualquer conduta sexual que tenha lugar em privado e entre adultos que nela consentem. Mas a questão cedo transbordou dos limites (em todo o caso paradigmáticos) do direito penal sexual para se transformar na questão central da *essência do conteúdo material do conceito de crime* e da *função primária* do direito penal no sistema social.

4. A perspectiva racional: a função de tutela subsidiária de bens jurídicos dotados de dignidade penal (bens jurídico-penais)

§ 15 A controvérsia acabada de referir conduziu à introdução, na temática da função do direito penal ligada ao conceito material de crime, de uma perspectiva que, com particular razão, se pode qualificar de teleológico-funcional e racional. De *teleológico-funcional*, na medida em que

([17]) Sobre o ponto, em perspectiva criminológica, DIAS / ANDRADE, pp. 88 e ss. e 249 e ss.

([18]) Sobre a questão, no sentido do texto, ANDRADE, Costa, *Consentimento e Acordo em Direito Penal*, 1990, p. 385 e s.

([19]) AQUINO, Tomás de, *Summa Theologica*, 1.ª 2ª, q. 96, art. 2.

([20]) Cf. DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 163.º e ss.

se reconheceu definitivamente que o conceito material de crime não podia ser deduzido das ideias vigentes *a se* em qualquer ordem extra-jurídica e extra-penal, mas tinha de ser encontrado no horizonte de compreensão imposto ou permitido pela própria *função* que ao direito penal se adscrevesse no sistema jurídico-social. De *racional*, na medida em que o conceito material de crime vem assim a resultar da função atribuída ao direito penal ([21]) de **tutela subsidiária (ou de *ultima ratio*) de bens jurídicos dotados de dignidade penal (de "bens jurídico-penais")**; ou, o que é dizer o mesmo, *de bens jurídicos cuja lesão se revela digna e necessitada de pena*. Bens jurídicos nos quais afinal se concretiza e se limita, em último termo, a noção sociológica fluida da danosidade ou da ofensividade sociais supra aludida. Dito isto, porém, fica por esclarecer uma extensa série de problemas e questões, dos quais os mais importantes serão desde já expostos e debatidos.

4.1. Uma primeira aproximação à noção de bem jurídico. Evolução

§ 16 A noção de bem jurídico (seja ela embora, como já se vê, uma noção fulcral de toda a nossa disciplina) não pôde, até ao momento presente, ser determinada — e talvez jamais o venha a ser — com uma nitidez e segurança que permita convertê-la em conceito fechado e apto à subsunção, capaz de traçar, para além de toda a dúvida possível, a fronteira entre o que legitimamente pode e não pode ser criminalizado. Há todavia hoje um consenso relativamente largo sobre o seu *núcleo essencial* ([22]). Antecipando desde já a conclusão das considerações seguintes, poderá definir-se bem jurídico ([23]) como a **expressão de um interesse, da pessoa ou da comunidade, na manutenção ou integridade de um certo estado, objecto ou bem em si mesmo socialmente relevante e por isso juridicamente reconhecido como valioso** ([24]). A esta conclusão só se chegou porém depois de uma evolução longa, muitas vezes pluri-significativa ou

([21]) Nos termos que se seguem, ROXIN I, § 2. Em sentido próximo, também, FRANCO, Silva, em Franco / Stocco, I-I, p. 37 e ss.

([22]) Isto parece esquecer, entre outras, a crítica de STRATENWERTH / KUHLEN, § 2, n.º 7 e ss.

([23]) Sobre o que se segue cf., de entre uma bibliografia praticamente inabarcável, já o nosso *O Problema*, § 4, II; e, com minúcia e abundante informação, ANDRADE, Costa, nota 18, p. 51 e ss.

([24]) *Sic* já, DIAS, Figueiredo, *O Problema*, p. 79[53] (1969).

mesmo equívoca e quase sempre eivada de dúvidas e controvérsias que ainda hoje se não encontram definitivamente decididas.

§ 17 O autor que pela primeira vez — segundo uma opinião generalizada, embora não incontestada — apelou para esta noção, Birnbaum, visava com ela abranger um conjunto de substratos, de conteúdo eminentemente *liberal*, que oferecessem base suficiente à punibilidade dos comportamentos que os ofendessem (25). Assim se compreendendo que a noção tenha primeiramente assumido um **conteúdo individualista**, identificador do bem jurídico com os interesses primordiais do indivíduo, nomeadamente a sua vida, o seu corpo, a sua liberdade e o seu património. Daqui até à identificação tendencial da noção de bem jurídico com os *direitos subjectivos fundamentais* da pessoa individual — que já Feuerbach havia utilizado num contexto análogo e prenunciador (26) — foi só um passo; um passo que a generalidade da doutrina penalista liberal deu e aplaudiu e se consubstancia na feliz expressão de Rupp, quando afirma que a concepção exasperadamente liberal do bem jurídico fez dele um "*monolito jurídico corporizado*" (27). Mas já é menos segura a conexão (histórica) da noção com os propósitos funcionais que animavam o direito penal iluminista, nomeadamente, o de reduzir a mancha da punibilidade às condutas que se apresentassem feridas de *danosidade social* (supra, § 8 e ss.).

§ 18 Uma viragem decidida na compreensão do conceito teve lugar a partir da segunda década do nosso século, com o aparecimento do chamado **conceito metodológico** do bem jurídico de raiz exasperadamente normativista, ligada aos pressupostos neokantianos próprios da chamada Escola jurídica sul-ocidental alemã ou Escola de Baden (de Windelband, de Rickert, de Lask) (28). Reagindo decididamente contra a compreensão legalista e positivista do direito, e acentuando nele a vertente *teleológica* imposta pela especificidade do mundo jurídico como entreposto entre os mundos do ser e do dever-ser e, por isso, como entidade referencial da realidade a específicos valores jurídicos, esta concepção faz dos bens jurídi-

---

(25) BIRNBAUM, Über das Erfordernis eines Rechtsverletzung zum Begriff des Verbrechens, *Archiv des Criminalrechts*, 1834, p. 149 e ss.

(26) FEUERBACH, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*, 1801, § 19 e ss.

(27) RUPP, *Grundfragen der heutigen Verwaltungsrechtslehre*, 1965, p. 224.

(28) Sobre esta Escola, CORREIA, Eduardo, I, n.º 44, II, e *Unidade*, p. 79 e ss.

cos meras **fórmulas interpretativas** dos tipos legais de crime, capazes de resumir compreensivamente o seu conteúdo e de exprimir "o sentido e o fim dos preceitos penais singulares" (Honig), meras "abreviaturas do pensamento teleológico" que os penetra (Grünhut), em suma, expressões da *ratio legis* que lhes preside (Schwinge) ([29]).

§ 19 Uma tal compreensão do bem jurídico deve ser hoje liminarmente rejeitada. Com ela, o conceito, ao tornar-se intra-sistemático, *perde completamente* — porventura contra os seus melhores propósitos — *a ligação a qualquer teleologia político-criminal* e deixa de poder ser visto como padrão crítico de aferição da legitimidade da criminalização; perde, numa palavra, todo o seu interesse para a determinação do conceito material de crime. O legislador, ao editar um preceito, tem sempre com ele em vista a tradução de um sentido e a obtenção de uma finalidade quaisquer; pelo que com a mera existência do preceito ficaria dada, *eo ipso*, a existência de um bem jurídico. A atribuição ao bem jurídico de uma **função puramente *hermenêutica*** significaria, em suma, o seu esvaziamento de conteúdo e a sua transformação num conceito legal-formal que nada adianta face à fórmula conhecida (e respeitável) da interpretação teleológica da norma.

§ 20 Uma **concepção teleológico-funcional e racional do bem jurídico** — que hoje se impõe, para que a noção se legitime — exige dele que obedeça a uma série mínima, mas irrenunciável de condições. O conceito deve traduzir, em primeira linha, um qualquer **conteúdo material**, uma certa "corporização" (deve ser, nesta acepção, "substanciável"), para que possa arvorar-se em indicador útil do conceito material de crime; não bastando por isso que se identifique com os preceitos penais cuja essência pretende traduzir, ou com qualquer técnica jurídica de interpretação ou de aplicação do direito. Ele deve servir, em segundo lugar, como **padrão crítico** de normas constituídas ou a constituir, porque só assim pode ter a pretensão de se arvorar em critério legitimador do processo de criminalização e de descriminalização; nesta acepção, pois, ele só pode surgir, não como imanente ao sistema normativo jurídico-penal e dele resultante, mas antes como noção *transcendente* — e neste sentido *trans-sistemática* — relativamente àquele. Ele deve finalmente ser **político-criminalmente orien-**

([29]) Precisamente no sentido dos três últimos autores citados, CORREIA, Eduardo, *Unidade*, p. 108 e ss.

tado e nesta medida, intra-sistemático relativamente ao sistema social e, mais concretamente, ao sistema jurídico-constitucional. O problema é determinar de que forma pode o conceito obedecer a todas estas exigências e, do mesmo passo, lograr a materialidade e a concreção indispensáveis para que se torne utilizável na tarefa prática de aplicação do direito penal.

4.2. Bem jurídico, sistema social e sistema jurídico-constitucional

§ 21 Uma resposta possível para o problema acabado de formular — e que, na verdade, vem sendo dada com alguma insistência por uma parte da doutrina mais actual que se reivindica da necessária funcionalidade de todo o sistema jurídico — é pedida directamente à **teoria da sociedade**, seja sob a forma da *teoria crítica*, seja sob a da *teoria do sistema social* ([30]). Assim, por exemplo, Amelung ensaia a tentativa de basear o conceito material de crime — e por aí o conceito de bem jurídico, que nessa direcção seria reconvertido — imediatamente na noção de *dano social*, cujo conteúdo vai agora encontrar na teoria do sistema social, tal como ela surge em Parsons. Essencial para a determinação da ordem dos bens jurídicos seria a *disfuncionalidade sistémica* dos comportamentos a que deveria obstar-se pela utilização das sanções criminais ([31]). Não longe desta via se encontram, de resto, aqueles que genericamente afirmam — de forma, em todo o caso, notoriamente mais cautelosa — que toda a análise da questão tem de entrar em linha de conta com o sistema social de uma comunidade legitimado pela Lei Fundamental ([32]). De outra parte Jakobs, se bem que acentuando a insuficiência da função jurídico-penal de protecção de bens jurídicos (supra, 4.º Cap., § 66), não deixa de reconhecer que a noção de crime é determinada através da danosidade social e esta aferida em função do sistema respectivo ([33]).

§ 22 Baseando-se directamente na análise sociológica de Jürgen Habermas, Augusto Silva Dias levou recentemente a cabo mais uma ten-

---

([30]) Esclarecedores, HABERMAS / LUHMANN, *Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie?*, 1982.

([31]) AMELUNG, *Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft*, 1972, p. 330 e ss.

([32]) Cf., nesta direcção, por último, os contributos de SCHÜNEMANN e de HASSEMER *in*: Hefendehl / von Hirsch / Wohlers, *Die Rechtsgutstheorie*, 2003, p. 57 e ss.

([33]) JAKOBS, 1/23. Cf., por último, SACHER, Mariane, Systemtheorie und Strafrecht Kritik der rollenbezogene Zurechnungslehre, *ZStW 118*, 2006, p. 574.

tativa de traduzir directamente categorias da teoria social em termos de **validade / legitimação jurídico-penal**. Fazendo assentar esta nos seguintes pressupostos essenciais: o "mundo da vida", por contraposição à "função", de um lado, a "interacção comunicativa" ligada ao "reconhecimento pessoal recíproco", do outro ([34]). O que conduziria a definir o bem jurídico como objecto de valor que exprime o reconhecimento intersubjectivo e cuja protecção a comunidade considera essencial para a realização individual do cidadão participante ([35]). Este seria o domínio dos *delicta in se*. Fora da validade jurídico-penal — com a consequência incontornável da sua *inconstitucionalidade material* — ficariam assim *todos* os *delicta mere prohibita* (*v. g.*, os delitos contra a ordem económica e financeira), que não pertenceriam ao mundo da vida e da experiência prática consensualmente assumida pela comunidade, mas relevam unicamente de uma razão de ser *sistémica* e contemplam lesões de meros interesses *funcionais*.

§ 23 Uma construção deste teor revela, julgamos que de forma patente, os **perigos de recurso directo a uma (qualquer) teoria da sociedade** para definição imediata dos termos da validade / legitimação jurídico-penal. Em primeiro lugar, um tal discurso só poderia servir (se servisse) o processo legitimador de *todo o Direito*, não especificamente do direito penal ou mesmo só de uma parte do direito penal positivo (os chamados *delicta in se*). Em segundo lugar, ela esquece que o "**sistema**" é simultaneamente "ambiente" e constitui nesta medida uma **dimensão do próprio modo-de-ser pessoa**: não existe um mundo da vida *cindido* do sistema (uma tal cisão seria sempre subjectiva e arbitrária) ou *sem* sistema, pelo que a protecção do sistema participa da própria protecção da dignidade da pessoa. Em terceiro lugar (*volente, nolente!*), por esta via se retira à Constituição (ou em todo o caso se minimiza de forma inadmissível) o papel director que materialmente lhe cabe da ordem legal dos bens jurídico-penais. A ordem económica ou financeira, como a ordem política, a fiscalidade, o mercado, a organização europeia... conformam valores jurídico-constitucionalmente reconhecidos, mesmo que sistémico-funcionalmente condicionados ou mesmo determinados e, nesta medida, fundamentos de uma criminalização legítima e válida. Falece por isso razão para rescrever todo o direito penal positivo, extraindo dele, por materialmente incons-

([34]) DIAS, Silva, nota 4, p. 287 e ss.
([35]) DIAS, Silva, nota 4, p. 655 e ss.

titucional, a totalidade das infracções sistémico-funcionais (os *delicta mere prohibita* na acepção de Silva Dias) só por o serem. Como bem reconheceu António Manuel Almeida Costa, ao advogar de há muito a categoria que chama dos "bens jurídicos instrumentais", "bens jurídicos-meio" ou "bens jurídicos de perigo" como autênticos bens jurídico-penais (sem prejuízo de porventura eles encontrarem "o seu campo privilegiado no direito de mera-ordenação-social"). Bens — é o que aqui queremos enfatizar; cf. depois infra, § 60 — de clara orientação sistémico-funcional na medida em que se caracterizam por "consubstanciarem, em si mesmos, objectivos organizatórios e funcionais", mas relativamente aos quais se verifica, "todavia, uma *fusão íntima* com os bens jurídicos fundamentais a que servem de suportes, como consequência de se mostrarem indispensáveis à respectiva conservação" (36).

§ 24 A crítica que, em suma, deve dirigir-se a este conjunto (muito longe de homogéneo em todo o caso, como se viu) de concepções não é tanto, em todo o caso, a da sua inexactidão, quanto a da sua irremediável **insuficiência para os efeitos práticos da aplicação do direito**. É exacto ser no sistema social como um todo — de qualquer modo: nele incluído o Homem e o seu "sistema pessoal" — que deve ver-se em último termo a fonte legitimadora e produtora da ordem legal dos bens jurídicos. Mas com apelo *directo* a um tal sistema é absolutamente impossível emprestar ao conceito de bem jurídico a indispensável concretização. Com uma via para a alcançar só se depara quando se toma em conta que os bens do sistema social se transformam e se concretizam em *bens jurídicos dignos de tutela penal* (em *bens jurídico-penais*) através da **"ordenação" axiológica jurídico-constitucional** (37). Como, aliás, desde os anos 70 do séc. XX o vem reconhecendo uma parte altamente significativa da doutrina italiana (38),

---

(36) COSTA, A. M. Almeida, Sobre o crime de corrupção, *Estudos Eduardo Correia*, I, 1984, p. 141 e ss., *Comentário Conimbricense*, II, antes do art. 262.º, § 15 e ss., e III, art. 372.º, § 9 (de onde provêm as citações; s. n. o.), e A propósito do novo Código do Trabalho: bem jurídico e pluralidade de infracções no âmbito das contra-ordenações relativas ao "trabalho suplementar" — Subsídio para uma dogmática do direito de mera-ordenação-social-laboral, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, 2003, p. 1057 e s.

(37) Nem de outra forma poderia ser entre nós: CRP, arts. 3.º-2 e 18.º-2.

(38) Na esteira sobretudo de BRICOLA, Teoria generale del reato, *Nov. Dig. it. XIX*, 1973, p. 82 e ss. Chegando DOLCINI / MARINUCCI, Constituição e escolha dos bens jurídicos, *RPCC 4*, 1994, p. 151, a afirmarem que esta ideia é defendida pela "maioria da doutrina italiana, seguida substancialmente pela jurisprudência do Tribunal Constitucional". Importante também

que procura ler a categoria da ofensividade à luz da proposição segundo a qual só bens jurídicos de nível jurídico-constitucional podem ser legitimamente protegidos pelo direito penal.

§ 25 Logo por aqui se deve concluir que um bem jurídico político-criminalmente tutelável existe ali — e só ali — onde se encontre *reflectido* num valor jurídico-constitucionalmente reconhecido em nome do sistema social total e que, deste modo, se pode afirmar que "preexiste" ao ordenamento jurídico-penal. O que por sua vez significa que entre a ordem axiológica jurídico-constitucional e a ordem legal — jurídico-penal — dos bens jurídicos tem por força de verificar-se uma qualquer **relação de mútua referência**. Relação que não será de "identidade", ou mesmo só de "recíproca cobertura", mas de **analogia material**, fundada numa essencial *correspondência de sentido e* — do ponto de vista da sua tutela — *de fins*. Correspondência que deriva, ainda ela, de a ordem jurídico-constitucional constituir o quadro obrigatório de referência e, ao mesmo tempo, o critério regulativo da actividade punitiva do Estado. É nesta acepção que os bens jurídicos protegidos pelo direito penal devem considerar-se concretizações dos valores constitucionais expressa ou implicitamente ligados aos direitos e deveres fundamentais e à ordenação social, política e económica ([39]). É por esta via ([40]) — e só por ela, em definitivo — que os bens jurídicos se "transformam" em *bens jurídicos dignos de tutela penal* ou com **dignidade jurídico-penal**, numa palavra, em **bens jurídico-penais**.

§ 26 A forma de relacionamento entre a ordem axiológica constitucional e a ordem legal dos bens jurídicos dignos de tutela penal permite,

---

neste contexto o estudo de PALAZZO, Ofensività e raggionevolezza nel controllo di costituzionalità nel contenuto delle leggi penali, *RitalDPP*, 1998, p. 350.

([39]) Nestes precisos termos — e também nos da exposição seguinte —, DIAS, Figueiredo, Os novos rumos da política criminal e o direito penal português do futuro, *ROA*, 1983, p. 14. Para uma dogmática do direito penal secundário, *RLJ 117*, 1984, p. 10 e s., e Vom Verwaltungsstrafrecht zum Nebenstrafrecht, *Jescheck-FS*, I, 1985, p. 79. Uma correcta análise desta nossa proposição, conexionando-a com o princípio da proporcionalidade em sentido amplo, em COSTA, A. M. Almeida, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, nota 36, p. 1065. Com razão afirma agora PEREIRA, Margarida Silva, Bens jurídicos colectivos e bens jurídicos políticos, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 316, ser "um encontro mais intenso, mais conclusivo, entre o direito constitucional e o direito penal que se ambiciona, pois sem a articulação de ambos o direito penal não cumpre (...) a sua missão de integração e identificação com o mundo social e político que suporta o seu sentido normativo".

([40]) Sobre este momento do processo de criminalização, se bem que criticamente na conclusão, DOLCINI / MARINUCCI, nota 38, p. 164 e ss.

de resto, alcançar e fundamentar uma distinção que a cada dia se revela mais importante para a política criminal e a dogmática jurídico penal: a distinção entre o chamado direito penal **de justiça**, direito penal "**clássico**" ou direito penal **primário**, de um lado, essencialmente correspondente àquele que se encontra contido nos códigos penais; e de outro lado o direito penal **administrativo**, direito penal **secundário** ou direito penal **extravagante**, por isso contido em leis avulsas não integradas nos códigos penais. A diferença entre estas duas categorias ([41]), à primeira vista de carácter formal e ocasional, acaba no fundo por radicar essencialmente, de um ponto de vista material, no diferente âmbito de relacionamento do bem jurídico com a ordenação axiológica constitucional. Pois enquanto os crimes do direito penal de justiça se relacionam em último termo, directa ou indirectamente, com a ordenação jurídico-constitucional relativa aos *direitos, liberdades e garantias das pessoas*, já os do direito penal secundário — e de que se encontram exemplos por excelência no direito penal económico (da empresa, do mercado de trabalho, da segurança social...), financeiro, fiscal, aduaneiro, etc. — se relacionam essencialmente com a ordenação jurídico-constitucional relativa aos *direitos sociais e à organização económica*. Diferença que radica, por sua vez, na existência de duas zonas relativamente autónomas na actividade tutelar do Estado: uma que visa proteger a esfera de actuação especificamente *pessoal* (embora não necessariamente "individual") do homem: do homem "como este homem"; a outra que visa proteger a sua esfera de actuação *social*: do homem "como membro da comunidade".

§ 27 Urge reconhecer que estes dois âmbitos do ordenamento jurídico-penal, o de justiça e o secundário, não se apresentam histórica e socialmente estanques. Bem pelo contrário, as considerações precedentes a propósito do bem jurídico já dão a compreender a sua eminente **mutabilidade**, não faltando exemplos de bens jurídicos emergentes e de bens jurídicos evanescentes, bem como de bens jurídicos secundários que, após um mais ou menos longo processo de estabilização — produto, em regra, de a uma zona social de conflito se ter substituído progressivamente uma zona social de consenso —, devem passar a ser considerados bens jurídicos primários ou de justiça. Se a função do direito penal é em último termo, como se tem acentuado, a de tutelar bens jurídicos essenciais à realização mais livre possível do homem na comu-

([41]) A concepção que a seguir se expõe foi por nós apresentada nos estudos referidos na nota anterior, *RLJ 117* e *Jescheck-FS* e tem encontrado audiência: cf. só COSTA, A. M. Almeida, nota 36, e MONTE, Mário, *Legitimación penal del derecho penal tributario. En particular, el delito de facturas falsas desde el derecho penal portugues*, diss. de doutoramento europeu, Pamplona, 2003, *passim*.

nidade, então tudo dependerá daquilo que em cada momento se revela como *fundamental* a este propósito e a esta luz (42).

§ 28 Com o que se torna igualmente compreensível assinalar como uma das notas mais relevantes do direito penal secundário — e que, como tal, o contrapõe ao e o distingue do direito penal de justiça — a **relação de codeterminação recíproca entre o bem jurídico e a conduta típica**. Sem que todavia a partir daqui se deva concluir (43) que no direito penal secundário o bem jurídico é um *posterius* e não um *prius*, um *constituto* e não um *constituens* relativamente à estrutura do ilícito e à matéria proibida. Exacto é apenas que, nestas hipóteses (*v. g.*, num crime económico), a matéria proibida assume uma relevância sistémica e funcional muito maior do que em crimes definitivamente consolidados à escala planetária (como é o caso do homicídio); e que essa maior relevância não deve ser desatendida ou minimizada em sede de hermenêutica e de aplicação do direito. Mas nem por isso o bem jurídico deixa de ser o fundamento e o padrão-crítico do ilícito constituído e serve portanto essencialmente às mesmas funções dos bens jurídicos do direito penal de justiça.

§ 29 Não constituindo o bem jurídico um conceito fechado e apto à subsunção, bem se compreende que, apesar de toda a evolução e progresso verificados, continuem hoje a discutir-se várias questões relativas à sua **concreta verificação**, como a de saber se protegem autênticos bens jurídicos incriminações como, *v. g.*, as do homicídio a pedido da vítima, da propaganda do suicídio, da interrupção voluntária da gravidez, da poluição ou do cultivo para consumo de drogas. Uma consideração capaz de cada um destes casos levaria a discussões que só num tratamento sistemático da parte especial do direito penal podem ter cabimento (44). Baste aqui a afirmação apodíctica de que atrás de todas estas incriminações **é possível divisar a existência de um bem jurídico-penal** no sentido que acabou de

---

(42) Nesta conclusão se concorda com HASSEMER, *Theorie und Soziologie des Verbrechens — Ansätze zu einer praxisorientierten Rechtsgutslehre*, 1973, e ROXIN I, § 2, n.º 15. Mas de Hassemer nos afastamos quando se tratar de determinar o que é *fundamental* à realização do homem na *comunidade*: cf. infra, §§ 51 e ss., 61 e ss.

(43) Cf., todavia, DIAS / ANDRADE, O crime de fraude fiscal no novo direito penal tributário português. Considerações sobre a factualidade típica e o concurso de infracções, *RPCC 6*, 1996, p. 81, e DIAS, Silva, O novo direito penal fiscal não aduaneiro (DL 20-A/90, de 15 de Janeiro). Considerações dogmáticas e político-criminais, *O Fisco*, Julho de 1990, p. 29. No sentido que se segue em texto, por último, SOUSA, Susana Aires de, *Os Crimes Fiscais: Análise Dogmática e Reflexão sobre a Legitimidade do Discurso Criminalizador*, 2006, § 9.4.

(44) Cf. ANDRADE, Costa, COSTA, Faria, DIAS, Figueiredo, e RODRIGUES, Anabela, em comentário, respectivamente, dos arts. 134.º, 139.º, 142.º e 279.º, *Comentário Conimbricense*, I e II; e, sobre a questão do consumo de drogas, DIAS, Figueiredo, Uma proposta alternativa ao discurso da criminalização / descriminalização das drogas, *Sclvr*, 1994, p. 193.

estabelecer-se (o que não tem de significar, sem mais, concordância com a existência da incriminação respectiva: cf. infra, § 37 e ss.). O que sucede é apenas que relativamente a certas destas incriminações não estará tanto em causa a preexistência ou não de um bem jurídico, quanto o *grau legítimo de antecipação da sua protecção* e, consequentemente, o momento a partir do qual o direito penal deve sentir-se autorizado para intervir em seu favor. Com isto se toca um ponto verdadeiramente essencial de toda esta problemática, v. infra, §§ 50, 72 e ss.

§ 30 Tudo ponderado, estamos convictos de que também no futuro a tarefa exclusiva do direito penal como preservação das *condições fundamentais da mais livre realização possível da personalidade de cada homem na comunidade* poderá continuar a ser sufragada no essencial. A esta conclusão conduz, por um lado, uma correcta solução da questão da **legitimação** do direito de punir estatal: esta provém muito simplesmente da exigência — já claramente inscrita no paradigma do "contrato social — de que o Estado só deve tomar de cada pessoa o *mínimo* dos seus direitos e liberdades que se revele indispensável ao funcionamento sem entraves da comunidade. A ela conduz, por outro lado, a **regra do Estado de Direito democrático**, segundo a qual o Estado só deve intervir nos direitos e liberdades fundamentais na medida em que isso se torne imprescindível ao asseguramento dos direitos e liberdades fundamentais *dos outros* ou da *comunidade enquanto tal*. A ela conduz, ainda por outro lado, o carácter **pluralista e secularizado (laico)** do Estado de Direito contemporâneo, que o vincula a que só utilize os seus meios punitivos próprios para tutela de bens de relevante importância da pessoa e da comunidade e nunca para a instauração ou reforço de ordenações axiológicas transcendentes. É só isto — mas também tudo isto — que quer significar o art. 18.º-2 da CRP ao dispor que as restrições de direitos, liberdades e garantias devem "limitar-se ao necessário para salvaguardar outros *direitos* ou *interesses* constitucionalmente protegidos". E que quer significar o CP português, na versão de 1995, quando no seu art. 40.º estatui, em total consonância com o referido normativo constitucional, que "a aplicação de penas e de medidas de segurança visa a *protecção de bens jurídicos*".

4.3. Consequências da orientação defendida

§ 31 Da concepção que vê na tutela de bens jurídico-penais a específica função do direito penal e assim o elemento constitutivo mais rele-

vante do conceito material de crime resulta uma série de consequências da mais decisiva importância, algumas das quais, na esteira de Roxin, devem aqui ser sublinhadas ([45]).

§ 32 Desde logo, **puras violações morais** não conformam como tais a lesão de um autêntico bem jurídico e não podem, por isso, integrar o conceito material de crime. A evolução do direito penal sexual (supra, § 14) constitui exemplo paradigmático desta asserção: àquela luz ele tem por força de deixar de ser (como era designado pela generalidade dos códigos penais anteriores à segunda metade do séc. XX e ainda o é hoje por alguns) um direito tutelar da "honestidade", dos "costumes" ([46]) ou dos "bons costumes" — e onde por isso caberia a punibilidade de práticas sexuais que, à luz dos "sentimentos gerais de moralidade sexual" ([47]), devessem ser consideradas "desviadas", "anormais", "viciosas" ou "contra a natureza" ([48]): numa palavra, "imorais" (a homossexualidade e a prostituição incluídas). Para se tornar num direito tutelar de um bem jurídico perfeitamente definido e que reentra, de pleno direito, no capítulo dos crimes contra as pessoas: o bem jurídico da *liberdade e autodeterminação da pessoa na esfera sexual*. Há, deste ponto de vista, que criticar por exemplo a nova formulação dada pela L 99/2001, de 25-8, ao crime de lenocínio do art. 170.º-1, eliminando a exigência de que o favorecimento da prostituição se ligasse necessariamente à "exploração de situações de abandono ou de necessidade económica". Só por aqui, com efeito, o facto podia referir-se ao bem jurídico da liberdade ou autodeterminação sexual da prostituta. Agora uma tal ligação perdeu-se, surgindo a incriminação referida à tutela de puras situações tidas pelo legislador como imorais. Deste modo — contra o que julgou o TC nos seus Acs. 144/2004, de 10-3, e 196/2004, de 23-3 — a incriminação tornou-se, em nossa opinião, materialmente inconstitucional ([49]).

([45]) ROXIN I, § 2, n.º 13 e ss.

([46]) Assim, ainda, p. ex., o Título VI da Parte Especial do CP brasileiro.

([47]) Assim, ainda, o art. 205.º-3 do CP português na versão de 1982 e, por conseguinte, até à Reforma de 1995.

([48]) Assim, ainda, o art. 71.º-4 do CP português de 1886, vigente até 1983.

([49]) No sentido do texto, RODRIGUES, Anabela, *Comentário Conimbricense*, I, art. 170.º, § 1 e ss., e O papel dos sistemas legais e a sua harmonização para a erradicação do tráfico de pessoas, *RMP* 27, n.º 84, p. 24 e ss. Cf., também, LOPES, Mouraz, *Os Crimes contra a Liberdade e a Autodeterminação Sexual*, [3]2002, p. 70 e ss., e RAPOSO, Vera, Da moralidade à liberdade: o bem jurídico tutelado na criminalidade sexual, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 949 e ss. Também Carlota Pizarro de Almeida, em anotação do Ac. do TC 144/2004 (*Jurisprudência Constitucional* 7, 2005, p. 21 e ss.), conclui que "deverá a incriminação consagrada no art. 170.º

§ 33 Do mesmo modo não conformam autênticos bens jurídicos **proposições (ou imposições de fins) meramente ideológicas**. *V. g.*, pôr em causa a pureza da raça, propagar doutrinas contrárias a uma certa religião ou a uma determinada concepção do Estado, ou mesmo fazer a apologia de uma qualquer doutrina religiosa, moral, política, económica, social ou cultural (ressalvada, naturalmente, a eventual ilicitude penal dos *meios* utilizados) são condutas que não podem legitimamente constituir objecto de criminalização. Nesta categoria reentrariam igualmente, segundo Roxin, casos como o da criminalização da aquisição ou posse de droga para consumo, em nome da "existência de uma sociedade livre de drogas" ou da criminalização integral do comércio de órgãos em nome da "autêntica doação de órgãos, liberta de motivações económicas". Ainda aqui, os pretensos "bens jurídicos" perderiam a sua função crítica para se tornarem em fórmulas interpretativas dos tipos legais de crime respectivos ([50]).

§ 34 Objecto de criminalização não deve ainda constituir, por igual motivo, a **violação de valores de mera ordenação**, subordinados a uma certa política estatal e por isso de entono claramente jurídico-administrativo. A questão toca aqui, todavia, o problema mais amplo e discutível da distinção entre direito penal e direito de mera ordenação social ou das contra-ordenações. Para os direitos que não conhecem a categoria *não-penal* (antes administrativa) das "contra-ordenações", mas diferentemente mantêm dentro do seu ordenamento *penal* a categoria das "contravenções", dir-se-ia que o problema mencionado se não suscita. Mas não seria isso exacto, havendo ainda aí que perguntar, à luz da orientação aqui defendida, se os bens jurídicos tutelados pelas contravenções constituem, materialmente, bens jurídico-*penais*. Por essa razão não pode concordar-se com quem defende ser impossível delimitar os crimes e as contra-ordenações na base de que os primeiros, mas já não as segundas, tutelariam bens jurídicos ([51]).

— aliás, eivado de incoerências e contradições internas, precipitadas por uma certa hipocrisia latente — ser considerada incompatível com o princípio da necessidade de pena, na medida em que abranja situações em que nenhum bem penalmente protegido é posto em perigo" (p. 35).

([50]) ROXIN I, § 2, n.º 14 e ss. e Rechtsgüterschutz als Aufgabe des Strafrechts?, in: Hefendehl (org.), *Empirische und dogmatische Fundamente, kriminalpolitischer Impetus, Schünemann-Symposium*, 2005, p. 135. Última manifestação da aludida — e inconstitucional — transformação de meras proposições ideológicas em "bens" jurídico-penais encontra-se, p. ex., no art. 39.º da L 32/2006, de 26-7 (criminalização da maternidade de substituição a título oneroso).

([51]) Entre outros, ROXIN I, § 2, n.º 60 e ss. E na conclusão também, entre nós, ANDRADE, Costa, Contributo para o conceito de contra-ordenação (A experiência alemã), *RDE VI-VII*, 1980-1, p. 109 e ss.

É certo que também a categoria jurídico-administrativa das contra-ordenações tem atrás de si bens jurídicos (como o tem toda a ilicitude administrativa, disciplinar ou mesmo civil). A verdade porém é que não se pode dizer aqui — como nos crimes — que estes bens são bens jurídico-*penais*, que *preexistem* à proibição e possuem uma referência obrigatória à ordenação axiológica jurídico-constitucional; antes se trata de bens jurídico-administrativos que, como tal, são constituídos *através da proibição* e *por força dela*. Não é pois unicamente em função do *princípio da subsidiariedade*, mas logo também ao nível do *bem jurídico — sc.*, da distinção entre bens jurídico-penais e bens jurídico-administrativos — que a distinção entre crimes e contra-ordenações deve ser levada a cabo (52).

§ 35 Decisivo, de todo o modo, é sublinhar que o interesse das consequências que acabam de apontar-se não se esgota na pura especulação teorética, antes possui o mais eminente **interesse normativo-prático**. Se, como se espera ter mostrado, a função do direito penal de tutela subsidiária de bens jurídico-penais se revela jurídico-constitucionalmente credenciada em qualquer autêntico regime democrático e pluralista (entre nós: CRP, art. 18.º-2), então tal deve ter como consequência inafastável a de que toda a norma incriminatória na base da qual não seja susceptível de se divisar um bem jurídico-penal claramente definido é **nula, por materialmente inconstitucional**, e como tal deve ser declarada pelos tribunais para tanto competentes.

4.4. A jurisprudência do TC

§ 36 Não pode afirmar-se que, até hoje, o nosso TC tenha assumido uma posição clara e terminante sobre as questões de saber se são, como aqui defendemos e nos parece resultar com segurança do disposto no art. 18.º-2 da CRP, inconstitucionais todas as incriminações das quais não possa com razoável segurança afirmar-se que elas se destinam à protecção de um bem jurídico-penal. Há mesmo decisões face às quais é legítimo duvidar que lhes tenha presidido um tal entendimento (53). Não faltam outras,

---

(52) Para uma análise mais detalhada, cf. infra, 7.º Cap., I. De importância sobre o ponto PINTO, Costa, O direito de mera ordenação social e a erosão do princípio da subsidiariedade da intervenção penal, *RPCC* 7, 1997, p. 11 e ss.

(53) Cf. as referidas supra, § 32, *in fine*. E cf. sobretudo, completamente no sentido do texto, a "Declaração de voto da Relatora" (Maria João Antunes) aposta ao AcTC n.º 247/2005.

porém, onde essa concepção está, cremos que com clareza bastante, patenteada. Como se escreveu no Ac. do TC 211/95, "o que justifica a inclusão de certas situações no direito penal é a subordinação a uma lógica de estrita necessidade das restrições de direios e interesses que decorrem da aplicação de penas públicas (artigo 18.º, n.º 2, da Constituição). E é também ainda a censurabilidade imanente de certas condutas, isto é, prévia à normativização jurídica, que as torna aptas a um juízo de censura pessoal. Em suma, é, desde logo, a exigência de dignidade punitiva prévia das condutas enquanto expressão de uma elevada gravidade ética e merecimento de culpa (artigo 1.º da Constituição, do qual decorre a protecção da essencial dignidade da pessoa humana) que se exprime no princípio constitucional da necessidade das penas (e não só da subsidiariedade do direito penal e da máxima restrição das penas que pressupõem apenas, em sentido estrito, a ineficácia de outro meio jurídico)" (54). Vemos aqui contida uma adesão essencial ao modelo (jurídico-constitucional) do direito penal do bem jurídico que temos vindo a traduzir

5. O critério da "necessidade" (ou da "carência") de tutela penal

5.1. Necessidade de tutela penal e princípio jurídico-constitucional da proporcionalidade em sentido amplo

§ 37 Se, na concepção teleológico-funcional e racional que vimos ensaiando, não pode haver criminalização onde se não divise o propósito de tutela de um bem jurídico-penal, já a asserção inversa se não revela exacta: a asserção, isto é, segundo a qual sempre que exista um bem jurídico digno de tutela penal aí deve ter lugar a intervenção correspondente. O que significa, no fim, que o conceito material de crime é essencialmente constituído pela noção de bem jurídico dotado de dignidade penal; mas que a esta noção tem de acrescer ainda um qualquer **outro critério** que torne a criminalização legítima. Este critério adicional é — como, de resto, uma vez mais directamente se conclui a partir do já tantas vezes referido art. 18.º-2 da CRP — o da *necessidade (carência) de tutela penal* (55).

---

(54) *DR*, II, de 24-6-95. Cf. ainda, no sentido de o art. 18.º-2 constituir critério aferidor da legitimidade constitucional das incriminações, os AcsTC n.ºs 634/93, 650/93, *DR*, II, de 31-3-94, e 958/96, *DR*, II, de 19-12-96.

(55) Sobre a questão, com referência à lição de Beccaria, Dias, Figueiredo, A propos de Beccaria et de la politique criminelle portugaise actuelle, *International Congress "Cesare Becca-*

A violação de um bem jurídico-penal não basta por si para desencadear a intervenção, antes se requerendo que esta seja absolutamente indispensável à livre realização da personalidade de cada um na comunidade. Nesta precisa acepção o direito penal constitui, na verdade, a **ultima ratio** da política social e a sua intervenção é de natureza definitivamente **subsidiária**.

§ 38 A limitação da intervenção penal acabada de referir derivaria sempre, de resto, do princípio jurídico-constitucional da *proporcionalidade em sentido amplo* (56), que faz parte dos princípios inerentes ao Estado de Direito. Uma vez que o direito penal utiliza, com o arsenal das suas sanções específicas, os meios mais onerosos para os direitos e as liberdades das pessoas, ele só pode intervir nos casos em que todos os outros meios da política social, em particular da política jurídica não-penal, se revelem *insuficientes* ou *inadequados*. Quando assim não aconteça, aquela intervenção pode e deve ser acusada de contrariedade ao princípio da proporcionalidade, sob a precisa forma de violação dos princípios da **subsidiariedade** e da **proibição de excesso**. Tal sucederá, p. ex., quando se determine a intervenção penal para protecção de bens jurídicos que podem ser *suficientemente tutelados* pela intervenção dos meios civis (a legitimidade ou ilegitimidade de criminalização do cheque sem provisão, quando não constitua um crime de burla, constitui, a este propósito, um exemplo instrutivo (57)), pelas sanções do direito administrativo (entrando aqui, de pleno, toda a controvérsia sobre as fronteiras que devem separar o direito penal do direito de mera ordenação social ou das contra-ordenações ou do direito disciplinar: infra, 7.º Cap., I e II). Como o mesmo sucederá sempre que se demonstre a *inadequação* das sanções penais para prevenção de determinados ilícitos, nomeadamente sempre que a criminalização de certos comportamentos seja factor da prática de muitíssimas mais violações do que as que se revela susceptível de evitar (o que pode suceder sobretudo no domínio dos criminologicamente denominados "crimes sem vítima" (58) como, *v. g.*, o consumo de drogas ou de álcool, a prostituição, a pornografia,

---

ria and modern criminal policy", 1990, p. 226 e ss. De interesse sobre o ponto, também, DOLCINI / MARINUCCI, nota 38, p. 170 e ss.

(56) Sobre este princípio, o nosso *DP II*, § 705 e ss.; e também SILVA, Marques da, I, n.º 17.2.

(57) De grande interesse, CAEIRO, Pedro, Crime de emissão de cheques sem provisão — A linguagem dos números, *RPCC 4*, 1994, p. 281.

(58) O designativo foi criado por SCHUR, *Crimes without Victims*, 1965.

etc. ([59])); caso em que fica próxima a afirmação de que a prevenção e controlo de tais comportamentos, quando se repute socialmente desejável, deve ser deixada por inteiro à intervenção de *meios não penais de controlo social*. Neste sentido se pode e deve afirmar, em definitivo, que a função precípua do direito penal — e desta deriva o conceito material de crime — reside na tutela **subsidiária (de ultima ratio) de bens jurídico-penais**.

5.2. A questão das imposições constitucionais implícitas de criminalização

§ 39 O exposto leva a avançar ainda mais um passo, de extrema importância, no que toca ao relacionamento material entre direito penal e direito constitucional, em espécie, à relação entre a ordem axiológica constitucional e a ordem legal dos bens jurídicos. Disse-se supra, § 25, ter de existir entre as duas ordens uma relação de implicação, no sentido de que todo o bem jurídico penalmente relevante tem de encontrar uma referência, expressa ou implícita, na ordem constitucional dos direitos e deveres fundamentais. Mas, justamente em nome do critério da necessidade e da consequente subsidiariedade da tutela jurídico-penal, a inversa não é verdadeira: no preciso sentido de que **não existem imposições jurídico-constitucionais implícitas de criminalização** ([60]). Naturalmente: onde o legislador constitucional aponte *expressamente* a necessidade de intervenção penal para tutela de bens jurídicos determinados, tem o legislador ordinário de seguir esta injunção e criminalizar os comportamentos respectivos, sob pena de inconstitucionalidade por omissão (embora, ainda aqui, fique uma larga e incontornável margem de liberdade à legislação ordinária no que toca ao exacto âmbito e à concreta forma da criminalização, bem como, em princípio, às sanções com que os comportamentos devem ser ameaçados e à sua medida). Onde, porém, inexistam tais injunções constitucionais expressas, da existência de um valor jurídico-constitucionalmente reconhecido como integrante de um direito ou de um dever fundamentais não é legítimo deduzir *sem mais* a exigência de criminalização

([59]) Sobre o ponto, já, DIAS, Figueiredo, Lei criminal e controle da criminalidade, *ROA 36*, 1976, p. 84 e ss.

([60]) Assim, já, DIAS, Figueiredo, nota 55, p. 226 e ss. No sentido desta conclusão, com particular clareza e impressividade, DOLCINI / MARINUCCI, nota 38, pp. 178 e ss., 184. Contra, a partir de uma ideia de protecção do núcleo fundamental dos direitos baseada na protecção da dignidade humana, LOUREIRO, João, *Constituição e Bio-Medicina*, 2003, p. 947 e s.

dos comportamentos que o violam. Precisamente porque não pode ser ultrapassado o inevitável entreposto constituído pelo critério da **necessidade** ou da **carência de pena**. Critério que, em princípio, caberá ao legislador ordinário utilizar e que só em casos gritantes poderá ser jurídico-constitucionalmente sindicado, nomeadamente, por violação eventual do princípio da proporcionalidade em sentido estrito (*v. g.*, quando o legislador ordinário entendesse sancionar o homicídio doloso apenas com sanções jurídico-civis; ou quando ele decidisse [61] subverter por completo a ordenação axiológica constitucional, descriminalizando totalmente a lesão de valores pessoais e criminalizando de forma maciça a lesão de valores patrimoniais!).

§ 40 A questão da existência ou não de imposições jurídico-constitucionais implícitas de criminalização tem gerado uma acesa e ainda não terminada controvérsia, doutrinal e jurisprudencial. Do ponto de vista doutrinal, acabámos de emitir opinião. A controvérsia jurisprudencial tem estado a cargo, sobretudo, dos tribunais constitucionais de vários países, quase sempre a propósito da extensão (e dos métodos: das "indicações" e dos "prazos") da impunibilidade da **interrupção voluntária da gravidez** face à incriminação do aborto [62]; máxime, depois que o TC alemão declarou inconstitucional um puro método de prazos, com o argumento de que o legislador ordinário não está constitucionalmente autorizado a renunciar completamente — seja embora apenas dentro de um certo prazo — à tutela penal de um bem jurídico como o do produto da concepção: ele pode, seja apenas "nos casos mais excepcionais, quando nomeadamente a protecção imposta pela Constituição não possa ser alcançada por outra forma (...), ser obrigado a usar o meio do direito penal para tutela da vida em desenvolvimento" [63]. Não parece porém que as especificidades desta questão possam contrariar ou modificar o que sobre ela, em geral, acima se expôs. Sempre será questão da competência do legislador ordinário, nos limites acima indicados, decidir se uma tal tutela — mesmo no caso de um bem jurídico como o da vida intra-uterina ou do produto da concepção — não será melhor lograda através da restrição do âmbito da criminalização e da sua "compensação" por meios não penais de política social. Neste preciso contexto ganha o seu mais profundo significado e a sua mais exacta expressão a palavra de Bachof sobre a "primazia política do legislador" ordinário [64].

---

[61] Exemplo avançado por ANDRADE, Costa, O novo Código penal e a moderna Criminologia, *JDC 1983*, p. 189.

[62] Importante, a propósito, MULLER-DIETZ, Zur Problematik verfassungsrechtlicher Pönalisierungsgebote, *Dreher-FS*, 1977, p. 108 e ss.; e, entre nós, CUNHA, Conceição Ferreira da, *Constituição e Crime*, 1995. Cf., depois, DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 142.°, e, agora, SILVA SÁNCHEZ, Os indesejados como inimigos: a exclusão de seres humanos do *status personæ*, *RPCC 16*, 2006, p. 9 e ss. e *passim*.

[63] BVerfGE 39, p. 1.

[64] BACHOF, Estado de Direito e poder político. Os tribunais constitucionais entre o Direito e a Política, *BFD LVI*, 1980, p. 9 e s.

O mesmo se dirá, de resto, do reconhecimento de um **direito geral dos cidadãos à segurança** e dos correspondentes deveres de tutela estatal que daquele resultariam (65).

5.3. O princípio da não-intervenção moderada e o movimento da descriminalização

§ 41 A restrição da função do direito penal à *tutela de bens jurídico-penais*, por um lado, e o carácter *subsidiário* desta tutela em sintonia com o princípio da necessidade, por outro, conduzem à justificação de uma proposição político-criminal fundamental (66): a de que, para um eficaz domínio do fenómeno da criminalidade dentro de cotas socialmente suportáveis, o Estado e o seu aparelho formalizado de controlo do crime devem intervir **o menos possível**; e devem intervir só na precisa medida requerida pelo asseguramento das condições essenciais de funcionamento da sociedade. A esta proposição se dá o nome de *princípio da não-intervenção moderada* — corrigindo em parte o princípio da *não-intervenção radical* avançado por Schur (67) —, que assim se arvora em trave-mestra de todo um programa político-criminal.

§ 42 Deste programa devem só destacar-se, com particular relevo para a matéria da determinação do conceito material de crime, duas implicações. A primeira é a de que do âmbito deste conceito têm de ser expurgados todos os comportamentos que *não acarretem lesão (ou perigo de lesão) para bens jurídicos* claramente definidos; ou que, ainda quando a acarretem, possam razoavelmente ser *contidos ou controlados por meios não penais* de política jurídica ou mesmo de política social não jurídica. Esta implicação está na base do movimento da **descriminalização**, claramente prosseguido, de resto, pela legislação penal portuguesa codificada, como se revela por uma comparação entre as partes especiais do CP de 1886 e de 1982 e pela Reforma deste último em 1995. A segunda, na outra vertente, é a de que processos novos de criminalização (chamados processos de **neocriminalização**) só devem ser aceites como legítimos onde novos fenómenos sociais, anteriormente inexistentes, muito raros ou socialmente pouco significativos, revelem agora a emergência de novos bens jurídicos para cuja protecção se torna indispensável fazer intervir a tutela penal em detrimento de um paulatino desenvolvimento de estratégias não criminais de controlo social (também infra, § 67 e ss.).

---

(65) Cf., sobre o assunto, RODRIGUES, Cunha, Liberdade e segurança, *RPCC 4*, 1994, p. 299, PEREIRA, Miranda, Seguros ou não? O efeito psicológico das penas, *RPCC 6*, 1996, p. 463, e, por último, MOURA, J. Souto de, Justiça, Ministério Público, criminalidade económica, *RPCC 13*, 2003, p. 7.

(66) SCHUR, *Radical non-intervention*, 1973.

(67) Sobre este programa, em pormenor, o nosso *DP II*, § 37 e ss., com indicações bibliográficas. E na literatura brasileira, FRANCO, Alberto Silva, Do princípio da intervenção mínima ao princípio da máxima intervenção, *RPCC 6*, 1996, p. 175.

II. A definição social do crime

§ 43 Ficaram expostas as notas essenciais constitutivas do conceito material de crime, daquilo que "em si" constitui o crime. A **realidade** do crime, porém, não resulta apenas do seu *conceito*, ainda que material, mas depende *também* da **construção social** daquela realidade: ele é em parte ([68]) produto da sua definição social, operada em último termo pelas *instâncias formais* (legislador, polícia, ministério público, juiz) e mesmo *informais* (família, escolas, igrejas, clubes, vizinhos) de controlo social. Numa palavra: a realidade do crime não deriva exclusivamente da qualidade "ontológica" ou "ôntica" de certos comportamentos, mas da *combinação* de determinadas qualidades materiais do comportamento com o processo de *reacção social* àquele, conducente à *estigmatização* dos agentes respectivos como criminosos ou delinquentes. Na formulação paradigmática de Becker, o fundador do *labeling approach*: "são grupos sociais que criam a *deviance* ao elaborar as normas cuja violação constitui a *deviance* e ao aplicar estas normas a pessoas particulares, estigmatizando-as como marginais" ([69]).

§ 44 A referida "combinação" assume aliás, como exactamente o pôs em evidência a perspectiva criminológica interaccionista, o carácter de um autêntico *processo de selecção* do crime e do criminoso ([70]). A perseguição criminal, na sua sistemática redução da complexidade social de certas expressões da vida, beneficia aqueles que estão em condições de influenciar e dirigir uma tal redução, desfavorecendo aqueles que se não encontram naquelas condições. Por outras palavras, a "competência de acção" e o consequente poder de regateio, sendo, em geral, mediatizados pelos processos sociais, são *diferencialmente* distribuídos em função dos chamados *mecanismos de selecção*, isto é, dos operadores genéricos que imprimem sentido ao exercício da discricionariedade real das instâncias formais de controlo (*v. g.*, o *poder relativo* dos sujeitos potenciais do processo, os *estereótipos*, etc.); e que, deste modo, permitem explicar as regularidades da presença ou ausência desproporcionada de membros de certos estratos e profissões nas estatísticas oficiais da criminalidade ou entre os clientes das instâncias formais de controlo (seja por sobre-representação, como acontece com toda

([68]) Mas não *exclusivamente*, como pretendeu a escola criminológica do *labeling approach*, à qual se deve a introdução desta perspectiva fundamental na consideração criminológica (sobre ela, DIAS, Figueiredo, A perspectiva interaccionista na teoria do comportamento delinquente, *Estudos Teixeira Ribeiro*, III, 1981, DIAS / ANDRADE, pp. 42 ss., 159 ss., 342 ss., 365 ss., e DIAS, Silva, nota 4, p. 181 e ss.).

([69]) BECKER, *Outsiders*, 1963, p. 9.

([70]) Com pormenor sobre este ponto — verdadeiramente essencial, mesmo fora de supostos marxistas — na criminologia actual, cf. SANTOS, Cláudia, *O Crime de Colarinho Branco*, Stvdia Ivridica 56, 2001, p. 125 e ss.; e já DIAS / ANDRADE, p. 384 e ss.

a espécie de "marginais" — proletários, drogados, homossexuais, prostitutas, ciganos, etc. —, seja por sub-representação — como sucede, *v. g.*, com os chamados "delinquentes de colarinho branco").

§ 45 Esta perspectiva assume relevo decisivo na investigação que aqui se processa. Na medida, justamente, em que serve para *relativizar* a imagem do crime — com o seu quê de intemporal, de essência parménica — que poderia resultar da análise do seu conceito material. Relatividade que lhe advém não apenas da relatividade das normas aplicáveis, mas sobretudo de a criminalidade *real* só o ser relativamente a alguém (a uma instância) que como tal a considera. Assim se substituindo a visão falsa, que pareceria resultar da análise do seu conceito material, do crime como fenómeno típico de classes marginais, do ponto de vista da moral social, pela ideia exacta de uma extensa *normalidade* e *ubiquidade* do fenómeno criminal ([71]). Ideia, em todo o caso, que não deve ser exagerada ([72]). A verdade definitiva é que o comportamento criminal tem duas componentes irrenunciáveis — a do comportamento em si e a da sua definição como criminal —, pelo que qualquer doutrina que a ele se dirija não pode esquecer nenhuma delas. Na síntese final (naquilo que com razão se poderá designar o *paradigma integrativo*) tem de entrar **o comportamento e a sua definição social**; por outras palavras, o conceito material de crime tem de ser completado pela referência aos processos sociais de selecção, determinantes em último termo daquilo que é concreta e realmente (e também juridicamente) tratado como crime.

III. A crise actual do "direito penal do bem jurídico" ([73])

1. O paradigma penal das sociedades democráticas contemporâneas, o direito penal do bem jurídico e os desafios da "sociedade do risco"

§ 46 O paradigma penal das sociedades democráticas do nosso tempo — como resulta das considerações expendidas neste capítulo (bem como

---

([71]) Neste sentido, também, ROXIN, Wandlungen der Strafrechtswissenschaft, *JA 4*, 1980, p. 226 e s.

([72]) Como todavia o foi por adeptos da criminologia dita "crítica" ou "radical": cf., sobre o ponto, DIAS / ANDRADE, p. 56 e ss., e SANTOS, Cláudia, nota 70, p. 149 e ss.

([73]) Cf. o nosso O direito penal entre a "sociedade industrial" e a "sociedade do risco", *Estudos Rogério Soares*, 2001, p. 583 e, já antes (2000), a nossa curta intervenção Algumas reflexões sobre o direito penal na "sociedade de risco", *Problemas Fundamentais de Direito Penal, Colóquio Internacional de Direito Penal em Homenagem a Claus Roxin*, 2002, p. 209.

nos 3.º, 4.º e 5.º Caps.) — consubstancia-se (para além das teses da proeminência da *política criminal* no seio da "ciência conjunta do direito penal" e da natureza unicamente *preventiva* das sanções penais) na **função exclusiva do direito penal de tutela subsidiária de bens jurídico-penais**. As *raízes longínquas* deste paradigma devem procurar-se no *pensamento filosófico ocidental a partir do séc. XVII* e, pelo que directamente respeita ao âmbito jurídico-penal, no movimento do *Iluminismo Penal*; e exprimem-se por excelência no *racionalismo cartesiano*, na *doutrina jurídico-política do individualismo liberal* e na *mundividência antropocêntrica e humanista* que comandou o movimento a favor dos direitos humanos. No momento presente, porém, começa a perguntar-se com insistência crescente se um tal paradigma terá capacidade para persistir no século que iniciámos. Ou se, pelo contrário, existem no horizonte sinais da necessidade de uma nova *revolutio* nas concepções básicas, nomeadamente e sobretudo no que toca à compreensão da função do direito penal no sistema social e, por conseguinte, à manutenção, alteração ou superação do modelo do direito penal do bem jurídico.

§ 47 A pergunta formulada põe hoje o estudioso perante o *topos* que, na esteira do sociólogo Ulrich Beck, se tornou conhecido como o da "sociedade do risco" ([74]), ligado às problemáticas **da pós-modernidade** e da **globalização** ([75]). Esta ideia suscita ao direito penal problemas novos, ao pôr em evidência uma transformação radical da sociedade em que vivemos e que seguramente se acentuará no futuro. Ela anuncia o fim de uma sociedade industrial em que os riscos para a existência, individual e comunitária, ou provinham de acontecimentos naturais (para tutela dos quais o direito penal é incompetente), ou derivavam de acções humanas próximas e definidas, para contenção das quais era bastante a tutela dispensada a clássicos bens jurídicos como a vida, o corpo, a saúde, a propriedade, o património, em suma, o catálogo próprio de um direito penal *liberal* e extremadamente *antropocêntrico*. Anuncia o fim desta sociedade e a sua substituição por uma sociedade exasperadamente tecnológica, massificada e global, onde a acção humana, as mais das vezes anónima, se revela sus-

([74]) BECK, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, 1986 (tradução espanhola de Jorge Navarro, Daniel Jiménez e M.ª Rosa Borrás, 1998).

([75]) Também esta última tratada monograficamente por BECK, *Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus — Antworten auf Globalisierung*, 1997 (tradução espanhola de Bernardo Moreno e M.ª Rosa Borrás, 1998).

ceptível de produzir **riscos globais** ou tendendo para tal, susceptíveis de serem produzidos em *tempo* e em *lugar* largamente distanciados da acção que os originou ou para eles contribuiu e de poderem ter como consequência, pura e simplesmente, a *extinção da vida*.

§ 48 Ora, diz-se, para tutela destes riscos não está preparado o direito penal de vertente liberal. Não o está desde logo no plano da **legitimação substancial**, se teimar em ancorá-la no modelo do "contrato social" rousseauniano, todavia fundamento de princípios político-criminais tão essenciais como o da função do direito penal exclusivamente protectora de bens jurídicos, o da secularização, o da intervenção mínima e de *ultima ratio*. Querer manter estes princípios, alega-se, significará ([76]) a confissão resignada de que ao direito penal não pertence nenhum papel na *protecção das gerações futuras* ([77]); como, entre outros, os temas dos atentados ao ambiente, da manipulação genética, da desregulação da actividade produtiva se vão encarregando de mostrar ou de prenunciar. A adequação do direito penal à "sociedade do risco" implica por isso uma **nova política criminal**, que abandone a função minimalista de tutela de bens jurídicos e aceite uma função promocional e propulsora de valores orientadores da acção humana na vida comunitária.

§ 49 Mas a impreparação do direito penal para a contenção dos novos e grandes riscos revela-se não apenas no plano da legitimação substancial, mas ainda em um outro plano que contende com o próprio **modelo de racionalidade** ([78]), até aqui exemplarmente traduzido na fórmula "Caim

([76]) Assinalou-o STRATENWERTH em duas conferências notáveis: Zukunftssicherung durch die Mitteln des Strafrechts?, *ZStW 105*, 1993, p. 679, e *Das Strafrecht in der Krise der Industriegesellschaft*, Rektoratsrede Basel, 1993. Cf., por último, de forma mais temperada, STRATENWERTH / KUHLEN, § 2, n.º 7 e ss. Uma minuciosa análise de toda esta problemática encontra-se agora em DIAS, Silva, nota 4, p. 213 e ss. (e já, do mesmo, *Protecção Penal dos Interesses dos Consumidores*, [1]1999 e [3]2001), filtrada pelas categorias habermasianas e luhmanianas do "mundo da vida" e da "função" (supra, § 22 e s.). Também em SOUSA, Susana Aires de, nota 43, p. 201 e ss.

([77]) Sobre o específico tema, DIAS, Figueiredo, O papel do direito penal na protecção das gerações futuras, *BFD LXXV*, 2002. De interesse, a generalidade das comunicações e conclusões contidas nas colectâneas: Arroyo Zapatero / Neumann / Nieto Martín (orgs.), *Crítica y justificación del derecho penal en el cambio de siglo*, 2003, e Eser / Hassemer / Burkhardt / Muñoz Conde (orgs.), *La Ciencia del Derecho Penal ante el nuevo milenio*, 2004; Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt / Universidad Pompeo Fabra (orgs.), *La insostenible situación del Derecho Penal*, 2000.

([78]) Assim, de novo, STRATENWERTH, *Das Strafrecht*, nota 76, p. 6 e ss.

matou Abel, pelo que incorre na pena *x*". Também este modelo de racionalidade parece revelar-se insuficiente ou inadequado àquela contenção, sobretudo no que toca ao *modelo de imputação objectiva e subjectiva* que lhe está na base e segundo o qual são pressupostos irredutíveis de uma condenação a demonstração em tribunal de que uma acção ou omissão concreta de pessoa determinada pôs uma causa sem a qual o efeito lesivo não teria tido lugar e que tal pessoa pode ser pessoalmente censurada por essa acção ou omissão. Com o que se fica a um passo de preconizar o aparecimento de uma **nova dogmática jurídico-penal** disposta a abandonar e substituir princípios até aqui tão essenciais como os da individualização da responsabilidade penal e a considerar a nova luz questões como as da causalidade, da imputação objectiva, do erro e da culpa, da autoria. E, assim, de novo a um passo de se propugnar o abandono do direito penal do bem jurídico ou, pelo menos, a sua complementação por um outro modelo capaz de responder às novas exigências assinaladas.

§ 50 A ciência do direito penal começa a reagir a estas dificuldades. Reconhecendo que não pode ficar à espera que se verifiquem resultados lesivos das condições de vida da humanidade — trate-se de lesões ecológicas, genéticas, económico-financeiras, terroristas... — para só então fazer intervir o arsenal punitivo: este deverá ser chamado, se quiser ser minimamente eficaz, logo relativamente a qualquer **contributo significativo para o potencial de perigo** do qual o resultado lesivo irá, num futuro porventura longínquo, derivar, por mais quotidiano e anódino que esse contributo pareça, em si mesmo considerado. Problema que se agrava extraordinariamente quando as condutas perigosas têm lugar no seio de **empresas, de grupos ou de equipas** com complexa divisão de tarefas e a suspeita da sua prática recai sobre um grande e indeterminável número de pessoas, cuja interacção, coordenada ou casual, é fonte do perigo que, por sua vez, contribui para a verificação de um risco global. Particularmente aqui, perante aquilo que se vai chamando já o fenómeno actual da *irresponsabilidade organizada* ([79]), o modelo tradicional da imputação jurídico-penal parece falhar rotundamente; como também quando se persista em manter um modelo puramente *individual* de responsabilidade penal, que empresta nova e mais forte razão à alegação de que o sistema penal está de há muito pensado em termos de atingir preferencialmente os estratos e os membros

([79]) Sobre isto, de novo, STRATENWERTH, *Das Strafrecht*, nota 76, p. 8.

socialmente mais desfavorecidos ou excluídos da população. Por isso a ciência do direito penal começa a perguntar-se por **possíveis soluções**. A dificuldade maior provém não tanto da incapacidade de criar novos modelos de legitimação que possam substituir-se, total ou parcialmente, ao modelo "iluminista" esboçado, quanto sobretudo de esses novos modelos poderem vir a pôr em causa princípios, também eles básicos, de civilização e de humanidade, por cuja efectividade vimos lutando há mais de dois séculos e que merecem sem dúvida persistir e ser aperfeiçoados. Que caminhos pois para o direito penal do futuro próximo quando ele se avalia face à constelação problemática central que preside a estas considerações?

2. Tentativas de resolução do problema

2.1. A concepção antropocêntrica (monista-pessoal) do bem jurídico-penal

§ 51 Perante as dificuldades apontadas, traduzidas nas aporias que a tutela dos novos riscos parece apresentar ao direito penal, há quem sustente que o direito penal não deve nem pode arvorar-se em instrumento de tutela dos novos e grandes riscos próprios da sociedade presente e, ainda mais, da sociedade do futuro. Há, pelo contrário, — sustentam — que guardar o património ideológico do Iluminismo Penal, reservando ao direito penal o seu **âmbito clássico de tutela** (os direitos fundamentais dos indivíduos) e os seus **critérios experimentados de aplicação**; e inclusivamente que reforçar a ideia de que se está perante um autêntico bem jurídico-penal somente quando ele se possa conceber como expressão de um interesse do indivíduo. É o pensamento que no essencial — se bem que por vezes de forma algo atenuada — surge como denominador comum da chamada ([80]) "Escola de Frankfurt".

§ 52 Deste ponto de vista, para protecção perante os mega-riscos da sociedade pós-industrial só pode ser pedido auxílio a *outros ramos de direito* (não penal) e, porventura sobretudo, a *meios não jurídicos* de con-

([80]) Não autodenominada, mas assim chamada, cremos que pela primeira vez, por SCHÜNEMANN, Kritische Anmerkungen zur geistigen Situation der deutschen Strafrechtswisenschaft, *GA*, 1995, p. 203; o designativo, de todo o modo, tornou-se de uso comum na ciência do direito penal.

trolo social ([81]). Outra concepção, como a que preside às tentativas de estabelecimento de um "direito penal do risco", conduziria a uma excessiva antecipação da tutela, através da eleição de bens jurídicos vagos, incapazes de cumprir a função crítica que lhe é reconhecida e suporte de um aumento excessivo de crimes de perigo abstracto. Por isso pode afirmar Hassemer que "são imensos os riscos de um direito penal do risco para a função de garantia do direito penal" ([82]). À categoria de bem jurídico-penal cabe assim a função de lançar para fora da normatividade penal todos os fenómenos sociais patológicos incapazes de lesar ou pôr em perigo objectos dignos de serem considerados autênticos bens jurídicos, quer no domínio dos novos riscos, quer no domínio estatal e económico. De tal modo que, no limite, um direito penal reduzido ao seu núcleo essencial deveria ser exaurido, entre outros, dos crimes económicos, dos crimes tributários, dos crimes ambientais, dos crimes relacionados com estupefacientes ([83]). De outro modo, ao aceitar-se generosamente os bens jurídicos universais, corre-se o "risco de aceitar o direito não já como *ultima ratio*, mas como *prima* ou mesmo *sola ratio* da protecção de bens jurídicos" ([84]).

2.2. A funcionalização intensificada da tutela penal: o abandono do "direito penal do bem jurídico" em favor de um "direito penal do risco"

§ 53 No outro extremo se perfilam aqueles que preconizam a criação de um direito penal por inteiro **funcionalizado às exigências próprias da sociedade do risco**. E que implicariam, antes de tudo, uma *alteração do modo próprio de produção legislativa* em matéria penal, retirando aos Parlamentos a reserva de competência neste domínio, para a atribuir aos

([81]) Esta posição corresponde no essencial à defendida — entre outros — por autores como HASSEMER, Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts, *ZRP*, 1992, p. 383, e Perspectivas del Derecho penal futuro, *Revista Penal 1*, 1997, p. 37, e HERZOG, Limites del derecho penal para controlar los riesgos socials, *Poder Judicial 32*, 1993, p. 80 e ss., e Algunos riesgos del derecho penal del riesgo, *Revista Penal 4*, 1999, p. 54. Por último, HASSEMER, *in*: Eser / Hassemer / Burkhard / Muñoz Conde, nota 77, p. 21. Mais amplas indicações bibliográficas em SOUSA, Susana Aires de, nota 43, p. 204 e ss.

([82]) HASSEMER, Lineamentos de una teoria teoria personal del bien jurídico, *Doctrina Penal 12*, 1989, p. 284.

([83]) MARINUCCI / DOLCINI, Diritto penale 'minimo', e nuove forme di criminalità, *RitalDPP XLII*, 1999, p. 809.

([84]) HASSEMER, nota 82, p. 284.

Executivos; depois, uma *antecipação decidida da tutela penal* para estados prévios (e mesmo ainda muito distantes) da lesão de interesses socialmente relevantes, mesmo correndo o risco de assim se perder a ligação, perceptível aos destinatários das normas de proibição, entre a conduta proibida e o bem jurídico tutelado; enfim, e em consequência, alterações dogmáticas radicais no sentido da atenuação ou mesmo do *abandono de princípios básicos* que presidem à individualização da responsabilidade penal, à imputação objectiva e subjectiva, à autoria, etc. ([85]).

§ 54 Esta linha de evolução torna-se particularmente evidente quando se atenta no teor que o tópico da "sociedade do risco" está a assumir em um certo pensamento penal norte-americano. O que este investiga é a possibilidade de levar ainda mais longe, neste campo, o dogma da razão técnico-instrumental sob a forma de uma razão *calculadora* ou *actuarial*. Até ao ponto de aí se falar já de uma *actuarial justice* ([86]), cujo propósito não seria mais o de actuar sobre o comportamento de pessoas individuais, propondo-se definir a sua responsabilidade, fazendo os culpados "pagar pelos seus crimes" ou transformando-os, mas o de *regular certos grupos* (de pessoas "perigosas") *como parte de uma estratégia de gestão dos riscos*. O que conduz a um **abandono puro e simples do direito penal do bem jurídico e da sua base de legitimação**, agora procurada na máxima *eficiência do sistema* "em matéria — segundo a justa análise de Pedro Caeiro — de redução dos danos globais inerentes ao crime através de uma adequada redistribuição dos riscos tanto no plano da prevenção como no plano da repressão" ([87]).

2.3. O direito penal de tutela de "relações da vida como tais"

§ 55 Merecedora, a nossos olhos, de particular atenção e apreço se afigura a posição — a muitos títulos pioneira — de Stratenwerth no pro-

---

([85]) Com uma discussão do tema depara-se em HILGENDORF, Gibt es ein "Strafrecht der Risikogesellschaft"?, *NStZ*, 1993, p. 15, e *Strafrechtliche Produzentenhaftung in der "Risikogesellschaft"*, 1998, p. 24 e ss., e, entre nós, em DIAS, Silva, *Protecção*, nota 76, p. 5 e ss.

([86]) Fundamentais, muitos dos artigos inseridos em O'Malley (org.), *Crime and the risk society*, 1998, em particular o de FREELEY, M. / SIMON, J., Actuarial Justice: The Emerging New Criminal Law, p. 375.

([87]) CAEIRO, Pedro, Legalidade e oportunidade: a perseguição penal entre o mito da "justiça absoluta" e o fetiche da "gestão eficiente" do sistema, *RMP 84*, 2000, p. 44.

blema que nos ocupa ([88]). Partindo de uma análise da situação problemática coincidente com a que supra, §§ 45-49, esboçámos, ele imputa-a certeiramente ao domínio ilimitado, na sociedade actual, da **razão técnico-instrumental, calculadora ou actuarial**. De uma razão — na excelente síntese de Anselmo Borges — em cuja formação incorreram o idealismo e o naturalismo, tanto num como no outro cabendo papel decisivo à concepção da objectividade científica como "objecto" e à do sujeito como mera "consciência universal", intemporal e impessoal. Donde uma razão instrumental de domínio, profundamente imperialista, que concebe o saber como poder (Bacon) e vê no homem, inebriado pela "doença da razão" (Horkheimer), o dominador absoluto do mundo e da natureza; e haveria de encontrar na racionalidade do *homo œcomomicus* e no espírito do capitalismo a sua versão sócio-económica acabada, assente no dogma do progresso material ilimitado da humanidade. Esta é "a razão técnico-instrumental moderna. Reconhecendo-se embora os benefícios que a tecnociência permitiu, é cada vez maior a consciência dos perigos e ameaças que desabam sobre a humanidade e põem em perigo a própria sobrevivência do planeta" ([89]).

§ 56 Stratenwerth aceita e proclama, por outro lado, a função irrenunciável que — até por razões morais — cabe ao direito penal na **tutela das gerações futuras**. Função relativamente à qual, porém, parece impossível falar-se em tutela de *bens jurídico-penais* na acepção tradicional e ainda hoje dominante. Ao que acrescerá a circunstância de uma tal tutela das gerações futuras perante riscos globais implicar o afastamento de um direito penal do resultado, para se tornar em um **direito penal do comportamento**, através do qual se penalizem puras relações de vida como tais. Por outras palavras, o desempenho da função penal passa pela tutela de "normas de comportamento", afastando-se do dano e mesmo do perigo de dano, pois de perigo só pode falar-se com referência a bens jurídicos concretos. Ora, justamente, a categoria do bem jurídico-penal, enquanto figura ligada à tutela de interesses individuais concretos, falha completamente nos crimes referidos ao futuro. Perante a impossibilidade de resol-

([88]) STRATENWERTH, nos estudos citados nota 76. Cf., depois, STRATENWERTH, Kriminalisierung bei Delikten gegen Kollektivrechtsgüter, *in*: Hefendehl / von Hirsch / Wohlers (orgs.), nota 32, p. 260.

([89]) BORGES, Anselmo, O crime económico na perspectiva filosófico-teológica, *RPCC 10*, 2000, p. 7.

ver os problemas surgidos no limiar do séc. XXI com os instrumentos (dogmáticos) do séc. XVIII, uma tutela eficaz das potenciais vítimas do futuro deve ser prosseguida também pelo direito penal; mas deve sê-lo não tanto através da estrutura típica dos crimes de perigo, nomeadamente de perigo abstracto, referida à protecção de bens jurídicos, mas através de normas que assegurem o controlo do comportamento. A categoria de bem jurídico deve por isso, pelo menos nestes casos, ser abandonada e substituída pela tutela directa de relações ou contextos de vida enquanto tais (*Lebenszusammenhänge als solche*) (90).

2.4. Posições intermédias

2.4.1. A "expansão do direito penal"

§ 57 Perante as posições extremas que imputámos, por um lado, à "escola de Frankfurt" e, por outro lado, ao "direito penal do risco" vêm surgindo diferentes vias intermédias. Uma delas — que corre na doutrina sob a epígrafe da "expansão do direito penal" (91) — pretende responder ao problema através de uma política e de uma dogmática criminais duais ou dualistas. Deve, segundo ela, manter-se a existência de um **cerne** do direito penal, relativamente ao qual valham, imodificados, os princípios do direito penal clássico, dirigido à protecção subsidiária de bens jurídicos individuais, assente na individualização da responsabilidade e consequentemente na acção, na imputação objectiva e subjectiva, na culpa e na autoria também puramente individuais. Mas deve existir também uma **periferia** jurídico-penal, especificamente dirigida à protecção contra os grandes e novos riscos, onde aqueles princípios se encontrem amortecidos ou mesmo transformados, dando lugar a outros princípios, de "flexibilização controlada" (92), assentes na protecção antecipada de interesses colectivos mais ou menos indeterminados, sem espaço, nem tempo, nem autores, nem vítimas, definidos ou definíveis e por conseguinte, numa palavra, de "menor intensidade garantística" (93). Mas princípios estes, em todo o caso — e aqui residiria o ponto principal e a especificidade desta concepção —,

(90) STRATENWERTH, nota 76, p. 689 e ss., e nota 88.

(91) SILVA SÁNCHEZ, *La expansion del derecho penal — Aspectos de la politica criminal en las sociedades postindustriales*, 1999.

(92) SILVA SÁNCHEZ, nota 91, p. 125.

(93) FRANCO, Silva, nota 67, p. 223.

ainda formalmente pertencentes ao direito penal, embora substancialmente aparentados com os princípios do direito sancionatório de carácter *administrativo*. Com a reserva absoluta em todo o caso — segundo Silva Sánchez — de que todos os comportamentos ameaçados com penas privativas de liberdade deveriam ser imputados, por razões claras de defesa dos direitos, liberdades e garantias, ao núcleo duro (clássico) do direito penal, não à sua flexível periferia.

2.4.2. Os bens jurídicos dotados de "referente pessoal"

§ 58 Uma outra concepção intermédia, muito difundida — ainda próxima, a alguns títulos, dos pressupostos da escola de Frankfurt ([94]) — reconhece que nem toda a intervenção do direito penal dos novos riscos é ilegítima ou tem de conduzir à substituição da categoria do bem jurídico por um conjunto de perigos indeterminados. Neste domínio, é ainda possível comprovar a existência de bens jurídicos, pessoais e patrimoniais, possuidores de novas características, mas dotados de um núcleo essencial capaz de actuar como padrão crítico da incriminação. Trata-se de bens que têm ainda um referente pessoal e por isso, se mostram capazes de conceder materialidade à ideia de dano e de ofensividade: também um ataque a estes bens jurídico-penais há-de ser experimentado como **uma perda ou dano pessoal** e não como lesão de um mero interesse funcional ([95]). Muito próximo de uma concepção deste tipo se situa, entre nós, Augusto Silva Dias, para quem um bem jurídico-penal há-de possuir necessariamente um referente pessoal. Na medida em que só merece o qualificativo de bem aquele objecto tido consensualmente como valioso pela comunidade de participantes, o referente pessoal subjacente fundamenta uma estrutura relacional daquele bem, o que permite distinguir esta categoria de bens, que são da sociedade civil, dos "bens colectivos", onde aquele referente está ausente e que pertencem ao Estado. Assim se alcança uma **concepção dualista de bens jurídico-penais**: os bens jurídicos individuais por um lado, e por outro os bens jurídicos supra-individuais dotados de referente

([94]) Lembre-se só que — numa das suas últimas posições sobre o problema, é verdade — no próprio HASSEMER, *Strafen im Rechtsstaat*, 2000, p. 166, se pode ler que devem ser aceites bens jurídicos universais desde que "eles se deixem comprovar como interesses — mediatos — do indivíduo".

([95]) Cf., com indicações bibliográficas, a exposição de SOUSA, Susana Aires de, nota 43, p. 210 e ss.

pessoal e de base antropocêntrica, na medida em que, apesar de não serem de uso exclusivo de um indivíduo, são susceptíveis de serem fruídos individualmente (*v. g. o ambiente*). Do domínio penal deveria excluir-se, por isso, a lesão de interesses funcionais pela ausência de algo que possa ser intersubjectivamente experimentado como uma perda ou dano pessoal: é a incapacidade de ser consumível individualmente, e consequentemente, a ausência de referência pessoal que transparece nos chamados bens colectivos (*v. g.*, a segurança do Estado) e que impediria a sua tutela penal (96).

§ 59 Uma concepção dualista análoga é proposta pela doutrina também em outros ordenamentos jurídicos. Por exemplo, **em Itália**, a concepção de Sérgio Moccia, que, referindo-se ao crescente interesse pela análise de bens colectivos relacionados com a evolução tecnológica e com o desenvolvimento económico, sublinha a necessidade de distinguir, dentro deste conjunto complexo de situações, as que impregnam em si verdadeiros bens jurídicos fundamentadores de tutela penal daquelas que têm em vista a tutela de meras funções (97). **Em Espanha**, uma concepção pessoal dualista é também proposta por Corcoy Bisadolo, que define os bens jurídico supra-individuais a partir de um referente individual capaz de funcionar como critério averiguador da necessidade, utilidade e legitimidade da incriminação (98).

2.4.3. Os bens jurídico-penais "instrumentais"

§ 60 Partindo da noção de bem jurídico-penal como portador de valores essenciais à existência humana, há autores que, ao lado dos valores essenciais como a vida, a integridade física, a liberdade e a propriedade, colocam outros "**valores-meios ou instrumentos**", sustentáculos da efectivação daqueles valores essenciais. Tratar-se-ia neles de bens jurídicos cujo domínio de eleição se situa as mais das vezes no direito de mera ordenação social, mas que, tendo em conta o seu valor instrumental na protecção das condições essenciais necessárias à existência humana, assumiriam relevância penal, constituindo como que uma técnica de tutela antecipada dos "**valores-fins**" essenciais. Uma solução deste teor é proposta entre nós por

(96) Dias, Augusto Silva, nota 4, pp. 690 e ss., 787 e ss., 822 e ss.

(97) Moccia, De la tutela de bienes a la tutela de funciones: entre ilusiones postmodernas y reflujos iliberales, *in*: *Política criminal y Nuevo Derecho Penal. Libro Homenage a Claus Roxin*, 1997, p. 118 e ss. E já também, do mesmo, *Il diritto penale tra Essere e Valores*, 1992. De novo sobre o ponto, Sousa, Susana Aires de, nota 43, p. 214.

(98) Corcoy Bidasolo, *Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales*, 1999, p. 139 e ss.

Almeida Costa. O A. toma por base a contraposição, feita por W. Stern, entre os bens que possuem um «valor em si» (*Selbswert*) e os que têm um "valor deduzido" ou "emprestado". A fusão íntima de alguns destes valores instrumentais com os bens jurídicos fundamentais, a que servem de suporte, faz irradiar sobre aqueles a mais valia destes; longe de integrarem um fim em si mesmos, aqueles valores representam um simples fim-meio, cujo significado se esgota no estabelecimento de uma protecção mediata ou, se se preferir, de uma guarda avançada em relação à defesa de outros bens jurídicos fundamentais ([99]). Os delitos que ofendem estes bens valores-meios não seriam simples crimes de perigo, uma vez que se trata neles de bens jurídico-criminais independentes: ao contrário do que acontece nos crimes de perigo, onde este integra uma nota caracterizadora da conduta do agente, o "perigo" converte-se agora no elemento fundamentador e constitutivo do próprio bem jurídico ([100]).

3. A subsistência do modelo do direito penal do bem jurídico na sociedade do risco

§ 61 É altura de ensaiarmos uma análise crítica das tentativas apontadas de dissolução das aporias entre o direito penal do bem jurídico e a sociedade do risco e de apontarmos a via pela qual, em nosso parecer, uma tal tentativa pode ser lograda. De um ponto de vista político-criminal, a questão básica, como Roxin lapidarmente a definia ([101]), reside em saber se a introdução do *topos* da sociedade do risco no direito penal tem por força de significar **o fim da protecção de bens jurídicos**, "*das Ende der Rechtsgüterschutzes*". Ora, para se circunscrever exactamente, logo à partida, o âmbito problemático, deverá afirmar-se que reconhecer como função exclusiva do direito penal a tutela subsidiária de bens jurídicos não implica limitar a intervenção da sanção criminal apenas aos casos em que se verifique uma **efectiva lesão do bem jurídico**. Está aí a atestá-lo, sem mais, a punição da **tentativa** — inclusivamente, entre nós, da chamada "tentativa impossível (art. 23.º e infra, 28.º Cap., § 45 e ss.) — em que, por definição, não chega a lesar-se o objecto da acção: punição que em nada contradiz a função penal de tutela de bens jurídicos. Mas comprova-o

([99]) Cf. COSTA, A. M. Almeida, *Estudos Eduardo Correia*, nota 36, p. 91.
([100]) Cf. COSTA, A. M. Almeida, *Comentário Conimbricense*, antes do art. 262.º, § 15.
([101]) Até à 3.ª ed. do seu *Lehrbuch*: ROXIN I[3], § 2, n.º 25 e ss.

também a circunstância de muitas vezes o legislador antecipar a tutela penal, criando crimes de perigo cuja realização típica não pressupõe a lesão, mas antes a mera colocação em perigo do bem jurídico protegido. É assim (como veremos: infra, 11.º Cap., § 43 e ss.) nos **crimes de perigo concreto**, em que o perigo surge como elemento do tipo de ilícito, *v. g.*, no art. 138.º; mas é-o igualmente nos **crimes de perigo abstracto**, em que o perigo não constitui elemento do tipo, mas somente motivo da proibição penal, *v. g.*, no art. 292.º É verdade que não tem faltado contestação à legitimidade, e consequente constitucionalidade, desta espécie de delitos ([102]). Mas esta contestação não pode considerar-se procedente. A "antecipação" da tutela penal justifica-se e é legítima, como muito bem formulou e decidiu o nosso TC, desde que com ela se não perca de vista "a função de protecção dos bens jurídicos que constitui o fundamento legitimador de qualquer sistema jurídico-penal característico de um Estado de direito" ([103]). Neste sentido e nesta medida, a punição da tentativa, como dos crimes de perigo, está ainda ao serviço da tutela de bens jurídicos. Apesar desta limitação do âmbito problemático deve no entanto perguntar-se de novo e directamente: constituirá a tutela dos grandes e novos riscos da sociedade pós-industrial o fim do modelo do direito penal do bem jurídico?

3.1. Para uma análise das concepções expostas

§ 62 Sem dúvida que sim, quando se esteja disposto a aceitar uma funcionalização intensificada da tutela penal às exigências próprias da sociedade do risco. Contudo, mesmo para além da questão mais funda que suscita — a *questão da legitimação*, a cujo entendimento iluminista importa guardar fidelidade (supra, § 30) —, o que nela avulta é a verdadeira **inimizade** pelo *axioma onto-antropológico* do direito penal e por uma *ordem axiológica* (mínima, mas nem por isso menos essencial) que daí por força há-de resultar. Nem a "eficiência", descarnada daquele axioma, pode constituir base de legitimação democrática; nem pode aceitar-se uma revolução do paradigma penal que passe por pôr em perigo a defesa consistente dos direitos humanos, o pluralismo ideológico e axiológico, a secularização. Por

([102]) Entre muitos outros, HERZOG, *Gesellschaftliche Unsicherheit und strafrechtliche Daseinsvorsorge*, 1991, p. 70.

([103]) *AcTC 20*, 1991, p. 423 e ss.

isso deve manter-se a recusa de qualquer concepção penal baseada na *extensão* da criminalização, que transforme o direito penal em instrumento diário de governo da sociedade e em promotor ou propulsor de fins de pura política estadual.

§ 63 Mas um direito penal do bem jurídico terá igualmente de ser abandonado na sociedade do risco se se considerar que, para que o bem jurídico cumpra a função de critério legitimador e de padrão crítico da incriminação, se torna indispensável guardar um seu carácter **extremadamente antropocêntrico**, que dele só permite falar quando estão em causa interesses reais, tangíveis e portanto também actuais do indivíduo (como pretende a concepção *monista-pessoal* do bem jurídico ([104]) que referimos supra, § 51 e s.). Para além de que esta via de resolução da crise não parece dar o lugar devido à necessidade de superação do dogma da razão técnico-instrumental, ela minimiza, em medida inaceitável, a função do direito penal no corpo social. Para controlo das fontes dos novos riscos tornam-se indispensáveis normas de comportamento cuja violação, nos casos mais graves, exige uma punição **penal**. Esperar uma tutela capaz de meios não jurídicos de política social — como o fomento de formas de *auto-protecção da vítima* ou das *forças auto-reguladoras do mercado* — afigura-se expectativa inconsistente ([105]). Como inconsistente parece ser a esperança depositada em meios jurídicos não penais, nomeadamente na *tutela jurídico-civil* ([106]) ou numa *tutela jurídico-administrativa intensificada* ([107]). Hipóteses diversificadas bem presentes hoje no espírito de todos — *v. g.*, as da danificação da camada de ozono, dos lixos tóxicos, da clonagem reprodutiva de seres humanos, da disseminação do HIV ou da BSE — mostram como a punição dos agentes responsáveis não pode bastar-se com

([104]) HASSEMER, Symbolisches Strafrecht und Rechtsgüterschutz, *NStZ*, 1989, p. 553 e ss., e em *AK*, 1990, antes do § 1, n.º 274 e ss.

([105]) Deste ponto de vista há que concordar com NELLES, *in*: Eser / Hassemer / Burkhardt / / Muñoz Conde, nota 77, p. 457, quando teme que esta via possa provocar — ou esteja a provocar, associada a outros factores — uma inadmissível *erosão* do direito penal formal.

([106]) Menos pessimista, no que toca aos danos ambientais, CANOTILHO, Gomes, Actos autorizativos jurídico-públicos e responsabilidade por danos ambientais, *BFD 69*, 1993, pp. 1 e ss. e 55 e ss.

([107]) Baseada num "direito de intervenção preventivo" que representaria, tanto quanto se pode perceber, uma espécie de direito das contra-ordenações (infra, 7.º Cap., § 20) com sanções mais diversificadas e mais graves, porventura próximas das medidas de segurança (administrativas? criminais?): HASSEMER, *Revista Penal*, nota 81, p. 40. Tentou um aprofundamento daquele direito, SCHWARTZ, *Strafrechtliche Produkthaftung*, 1999, p. 145 e ss.

sanções civis ou mesmo administrativas, ainda que intensificadas. Uma tal solução significaria **pôr o princípio jurídico-penal de subsidiariedade e de *ultima ratio* de pernas para o ar**, ao subtrair à tutela e às sanções penais precisamente as condutas tão gravosas que põem do mesmo passo em causa a vida planetária, a dignidade das pessoas e a solidariedade com as outras pessoas, com as que existem e com as que hão-de nascer.

§ 64 Igualmente terá de ser abandonado o direito penal do bem jurídico quando se defenda — como vimos supra, § 58 e s. que o faz a chamada concepção **antropocêntrica moderada** ou **pessoal-dualista** — que bens jurídicos da comunidade só podem ser reconhecidos se e na medida em que eles se constituam em meros *mediadores* também com bens jurídicos individuais ([108]). Claro que também os bens jurídicos colectivos só existem *por causa do Homem* de acordo com o antiquíssimo brocardo latino *omne ius hominis causa constitutum*. Mas isto é uma coisa, outra pretender que, entre os bens supra-individuais, só possam ser erigidos em bens jurídicos aqueles cuja razão de tutela seja em último termo recondutível à protecção de bens jurídicos individuais e que portanto se encontrem "dotados de referente pessoal" ([109]), possuam um "núcleo personalizável" ou sejam "unicamente... dedutíveis a partir de bens jurídicos individuais" ([110]): com a inevitável consequência de que tais bens jurídicos estariam sempre hierarquicamente subordinados aos bens jurídicos individuais, sendo a sua violação, por princípio, menos gravosa.

§ 65 Não parece, por outro lado, que a solução dos problemas colocados pela sociedade do risco passe por uma espécie de "**direito penal a duas velocidades**" ([111]). Antes este se revela equívoco e, em definitivo,

---

([108]) De novo, HASSEMER, *AK* nota 104.

([109]) Repetidamente, DIAS, Silva, *Protecção*, nota 76, p. 29 e ss., e nota 4, *passim*, como fideicomisso teórico de toda a validade jurídico-penal.

([110]) HOHMANN, *Das Rechtsgut der Umweldelikte*, 1991, p. 189. E no mesmo sentido HASSEMER, *in*: Scholler / Philipps, *Jenseits des Funktionalismus*, 1989, pp. 85 e 92. No pólo oposto acentua agora PEREIRA, Margarida Silva, nota 39, p. 304 e ss., a dimensão *colectiva* dos bens jurídicos individuais e, nesta medida, a infidelidade da concepção em crítica às raízes históricas da evolução da noção de bem jurídico: aquilo que esta pensou ser "o preço da sua cidadania é em termos teóricos a negação do espírito crítico e político-criminal que se quis sempre, nas melhores épocas e na melhor doutrina, anunciar como próprio dele". No sentido do texto também, TORRÃO, Fernando, Os novos campos de aplicação do direito penal e o paradigma da mínima intervenção (Perspectiva pluridisciplinar), *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 345 e ss.

([111]) SILVA SÁNCHEZ, nota 91, p. 124.

inadequado à resolução daqueles problemas. Que, no seio do direito penal, deva distinguir-se o direito penal clássico, primário ou de justiça e o direito penal secundário ou administrativo, este dotado de alguns princípios político-criminais e dogmáticos autónomos, é coisa que reputamos absolutamente exacta (supra, § 26). Mas um tal direito penal administrativo nem histórica, nem materialmente tem o que quer que seja a ver com a contenção dos mega-riscos da sociedade pós-industrial, antes sim com os problemas económico-sociais típicos da sociedade industrial (infra, 7.º Cap., § 4 e ss.). Seriam por esta via porventura flanqueadas algumas das *dificuldades dogmáticas* que se suscitam quando ao direito penal se queira assinalar uma função de contenção dos mega-riscos que ameaçam a humanidade. Mas persistiria a contradição — ínsita também, como vimos, na tese da "Escola de Frankfurt" — de impedir a aplicação das *penas mais graves e de maior eficácia preventiva* (se privativas da liberdade) precisamente às condutas dotadas de maior potencial de risco para os bens mais importantes da humanidade. Além de que, quando pensada para a sociedade do risco, a sugestão agora em análise acaba por trazer para o direito penal **dois paradigmas diferentes e incompatíveis**, que a breve prazo haverão de conduzir ao domínio de um sobre o outro — quando não ao esmagamento de um pelo outro — sob a forma, muito provavelmente, de uma invasão incontrolável do "cerne" pela "periferia" ([112]).

§ 66 No que toca, finalmente, às concepções do direito penal do comportamento e dos bens jurídicos instrumentais, é nossa opinião que elas representam contributos importantes para a solução do problema aqui em análise, sem todavia constituírem, em si mesmas, propostas bastantes de solução. Elas devem ser postas em conexão com a aceitação da existência autónoma de "bens jurídicos colectivos" e ser por isso tidas em conta no contexto das considerações seguintes.

3.2. Um princípio de solução: os "bens jurídicos colectivos"

§ 67 É nossa convicção que à questão básica suscitada, de saber se na sociedade do risco pode ainda manter-se o modelo do direito penal do bem jurídico, deverá em definitivo responder-se que *sim*, na medida em que

([112]) Ao contrário do que pensam HASSEMER / MUÑOZ Conde, La responsabilidad por el producto en el derecho penal, 1999, pp. 37 e ss., 187 ss. No sentido da conclusão do texto, DIAS, Silva, *Protecção*, nota 76, p. 35 e ss., e, no essencial, também, VOGLER, La responsabilidad penal por el producto en Alemania: Situación actual y perspectivas de futuro, *Revista Penal 8*, 2001, p. 102 e ss.

possa e deva afirmar-se que — sem prejuízo do axioma onto-antropológico sobre o qual repousa toda a matéria penal —, ao lado dos bens jurídicos individuais ou dotados de referente individual *e ao mesmo nível de exigência tutelar autónoma*, existem autênticos bens jurídicos **sociais, comunitários, universais, colectivos**, ou como quer que prefiramos exprimir-nos a propósito ([113]). Se pretender conferir-se ao direito penal uma função de tutela perante os mega-riscos ameaçadores da subsistência da humanidade, ainda aí é preciso assentar em que o problema jurídico-penal é modestamente um problema de *ordenação social*; em concreto, o de saber como é possível promover ou conservar os bens públicos relativos aos fundamentos naturais da vida perante, sobretudo, a natureza trágica da relação entre o agente racional em seu próprio proveito e os bens colectivos ([114]). Bem podendo aliás convocar-se neste contexto a noção (próxima, embora não necessariamente coincidente, por mais restrita do que a que aqui defendemos de bem jurídico "colectivo") de bem jurídico *instrumental*, bem jurídico-*meio* ou bem jurídico *de perigo*, entre nós trabalhada por António Manuel Almeida Costa e que aplica a crimes como os de corrupção e de moeda falsa ([115]). Em todos estes domínios a criminalização é legítima e pode afigurar-se necessária. *Legítima*, porque tais bens — como se torna em particular visível numa lei fundamental como a CRP ([116]) — encontram refracção legitimadora expressa na ordem axiológica constitucional relativa aos direitos sociais, económicos, culturais e ecológicos. *Necessária*, de um ponto de vista de prevenção geral *negativa*, porque será razoável esperar que a punibilidade se revele susceptível de influenciar o cálculo vantagem / prejuízo ([117]) de modo a promover a obediência à norma. Mas também e sobretudo de um ponto de vista de prevenção geral *positiva*, de modo a reforçar a disposição de obediência à norma da parte do cidadão em geral fiel ao direito.

([113]) Cf. agora a importante monografia de HEFENDEHL, *Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht*, 2002. E entre nós, PEREIRA, Margarida Silva, nota 39, p. 293, que a propósito conclui (p. 312 e s.): "Os bens jurídicos colectivos têm legitimidade dogmática, carta de cidadania no direito penal. Não sofrem de uma diminuição por (...) não representarem igualmente esferas essenciais de protecção. Podem muito bem desempenhar esse papel (...)".

([114]) Assim e como se segue — a propósito, concretamente, do direito penal do ambiente —, KUHLEN, Umweltstrafrecht — auf der Suche nach einer neuen Dogmatik, *ZStrW 105*, 1993, p. 720 e ss.

([115]) COSTA, A. M. Almeida, locs. cits. na nota 36.

([116]) ANDRADE, Costa, nota 18, pp. 51 e ss. e 180 e ss.

([117]) Que pesem as teorias da escolha racional e as "técnicas de neutralização" (sobre estas DIAS / ANDRADE, p. 235 e ss.), que nestes domínios intervirão com particular força.

§ 68 Os bens jurídicos colectivos devem por conseguinte ser aceites como **autênticos bens jurídicos** ([118]). Que também esta categoria de bens jurídicos possa reconduzir-se, em último termo, a *interesses legítimos* da pessoa — e até que tanto possa constituir condição da sua aceitabilidade —, é coisa que bem pode reconhecer-se. O carácter colectivo do bem jurídico não exclui a existência de interesses individuais que com ele convergem: se todos os membros da comunidade (ou de uma certa comunidade) se vêem prejudicados por condutas pesadamente poluidoras, cada um deles não deixa, individualmente, de sê-lo também e de ter um interesse legítimo na preservação das condições vitais. Mas se, por exemplo, uma descarga de petróleo no mar provoca a morte de milhares de aves marinhas e leva, inclusivamente, à extinção de alguma espécie rara, também aí se verifica a lesão de um bem jurídico colectivo merecedor e carente de tutela penal, ainda que tais aves sejam absolutamente insusceptíveis de utilização — por exemplo, para fins alimentares — por parte do homem. Não é possível descortinar aqui, ao menos em via de princípio, ofensa, sequer mediata, de um qualquer bem jurídico individual, possibilidade de referência a ele ou cadeia dedutiva que a ele conduza. Como tão-pouco parece possível falar a seu propósito de um bem jurídico-meio como forma de tutela de um bem jurídico-fim. E todavia, as aves referidas, se bem que não "utilizáveis" por quem quer que seja, constituem um património de todos e *como tal* devem ser tuteladas.

§ 69 A verdadeira característica do bem jurídico colectivo ou universal reside pois ([119]) em que ele deve poder ser gozado por todos e por cada um, sem que ninguém deva poder ficar excluído desse gozo: nesta **possibilidade de gozo** reside o interesse individual legítimo na integridade do bem jurídico colectivo ([120]). Certamente, existe neste uma **relação difusa** com os usuários, o que porém não significa o carácter difuso do bem jurídico universal como tal; como existe — há que reconhecê-lo — uma certa **funcionalização** da noção de bem jurídico, quando comparada com aquele

([118]) Por último, DIAS, Figueiredo, Sobre a tutela penal do ambiente — um quarto de século depois, *Estudos Cunha Rodrigues*, I, 2002, p. 380 e ss.

([119]) KUHLEN, nota 114, p. 704.

([120]) O critério a utilizar para determinar os contornos de um bem jurídico colectivo pode ser comparado ao *princípio da não exclusão* usado na linguagem económica para definir os bens públicos. Também segundo este princípio, bens colectivos são aqueles cuja utilidade aproveita a todos sem que ninguém possa dela ser excluído. Neste sentido e aplicando este conceito ao bem jurídico protegido nos crimes fiscais, SOUSA, Susana Aires de, nota 43, p. 263 e ss.

"monólito jurídico corporizado" que formou a concepção acirradamente liberal e vemos agora no essencial reeditada pela chamada Escola de Frankfurt. Mas nada disto servirá para condenar em definitivo a categoria dos bens jurídicos colectivos ([121]). A relevância autónoma dos bens jurídicos colectivos — generosos e em nada egoístas — provirá precisamente da potencial multiplicação indeterminada de interesses de toda e qualquer pessoa, se bem que não individualizáveis em concreto. Decerto: tais bens apresentam-se, por sua própria natureza, como muito mais *vagos* e carentes de definição precisa, de mais duvidosa *corporização* ou mesmo de impossível *tangibilidade*. Mas a circunstância de o direito penal ser chamado a tutelá-los não impõe uma mudança ou qualquer abrandamento na proposição penal básica segundo a qual é função exclusiva do direito penal a tutela subsidiária de bens jurídico-penais; porque também neste âmbito é de verdadeiros bens jurídico-penais que se trata.

§ 70 Resta a objecção, insistentemente repetida ([122]), de que a multiplicidade de condutas perigosas para a manutenção das condições gerais da vida, na complexidade que podem chegar a assumir e na constante modificação a que, por força da evolução tecnológica, estão submetidas, conduz a que o delito colectivo perca a sua **determinabilidade** numa medida insuportável face ao princípio da legalidade (infra, 8.º Cap., § 16 e s.) e que o bem jurídico por aquele protegido se torne imperscrutável para os seus destinatários. Tanto mais quanto uma protecção penal de bens jurídicos colectivos minimamente eficaz conduzirá a que o ilícito material respectivo possa ter de ser ancorado em condutas socialmente irrelevantes ou insignificativas na sua singularidade, só se tornando em socialmente danosas em associação com condutas análogas ocorridas em quantidade inumerável e com uma frequência devastadora. Foi isto que terá levado Stratenwerth — correndo paralelamente a uma progressiva *juridificação das relações sociais enquanto tais* — a preconizar a substituição da função de protecção de bens jurídicos pela tutela directa de "relações da vida como tais" ([123]).

([121]) Neste sentido agora, HEFENDEHL, nota 113, p. 111 e ss., e PEREIRA, Margarida Silva, nota 39, p. 314: "não há motivos para entender que o primado da pessoa impeça a incriminação por uma lesão de bens colectivos desde que não se tenha verificado um perigo para a pessoa, mesmo que abstracto".

([122]) Sobre ela, DIAS, Figueiredo, nota 73, *passim*, e nota 118, *passim*, com indicações bibliográficas. E agora, HEFENDEHL, nota 113, p. 147 e ss.

([123]) STRATENWERTH, *ZStW*, nota 76, p. 692 e ss.

O que significaria no fundo um *requiem* pelo paradigma iluminista do direito penal e um regresso a um direito penal protector da moral ou de uma certa moral ([124]) e, assim, a um pequeno passo de se tornar em promotor ou propulsor de fins puramente ideológicos.

§ 71 **Não cremos que tenha de ser assim.** Em conta tem de se ter que o conteúdo integral do ilícito dos delitos colectivos terá frequentemente de se exprimir em função de normas extra-penais, nomeadamente administrativas; terá, numa palavra, de se encontrar sujeito a uma cláusula de **acessoriedade administrativa**. Esta suscita à dogmática jurídico-penal, é exacto, um cortejo de problemas para os quais ainda mal se divisam soluções consensuais (também infra, 18.º Cap., § 16 e s.). Mas estas dificuldades têm de ser assumidas, como tem de se trabalhar na redução do seu âmbito problemático, aliás de há muito conhecido sem que em seu nome se tenha clamado por uma substituição do paradigma penal.

§ 72 Quanto à questão da **construção típica dos delitos colectivos**, é igualmente verdade que, seja qual for a arquitectura típica que acabe por ser eleita, ela não pode eliminar a aludida distância entre condutas na sua singularidade insignificantes e lesões certas ou muito prováveis de bens jurídicos colectivos; distância que pode ser de tal maneira grande que, com ela, é a própria *referência da conduta ao bem jurídico* que pode tornar-se questionável. Isto só significa porém que, em sede de construção típica, estes delitos têm uma natureza material análoga à dos *delitos de perigo abstracto*, cuja legitimidade deve aceitar-se, suposto que (como já dissemos supra, § 61, e a isso voltaremos infra, 11.º Cap., § 46) se encontrem respeitados em espécie os *parâmetros mínimos de determinabilidade do tipo de ilícito* e a *referência ao bem jurídico que em última instância se visa proteger*. De outra parte, se é certo que muitas das ofensas colectivas jurídico-penalmente relevantes terão de ser consideradas no quadro dos tipos chamados **aditivos** ou **acumulativos** ([125]), a sua punição só se revelará legítima se as condutas que venham somar-se às do agente e contribuem assim para a lesão forem, mais que *possíveis*, indubitavelmente *previsíveis* e *muito prováveis*, para não dizer *certas*. A partir daqui, é ao

([124]) STRATENWERTH, *ZStW*, nota 76, p. 694 e s.

([125]) Por último, HEFENDEHL, nota 113, p. 182 e ss. Também, na doutrina espanhola, ALCÁCER Guirao, La protección del futuro y los daños cumulativos, *ADPCP LIV*, 2001, p. 163 e ss. E, entre nós, SOUSA, Susana Aires de, nota 43, § 8.

legislador ordinário e só a ele que, dentro dos referidos parâmetros constitucionais, pertence ponderar e decidir a questão político-legislativa de saber se, para uma tutela dos bens jurídicos colectivos (ou de certos deles) minimamente eficaz, se torna *necessário* punir comportamentos em razão da sua provável acumulação e quais deles devem ser puníveis. Tomada a decisão de punir, não tem sentido agitar a objecção de que uma responsabilização por comportamentos aditivos ou cumulativos significaria uma inadmissível responsabilização por facto de outrem. Como igualmente parece dispensável excogitar e acolher estruturas anómalas ou atípicas de imputação, objectiva e subjectiva, da responsabilidade penal.

§ 73 Entre nós, veio Augusto Silva Dias insistir na **invalidade** e consequente **inconstitucionalidade material** da incriminação e punição de contributos acumulativos. E isto porque, afirma, as incriminações acumulativas radicariam inevitavelmente num puro contexto sistémico-funcional, conducente por um lado a uma inválida administrativização do direito penal, por outro a uma flexibilização das categorias centrais da imputação, nomeadamente a violações dos princípios da ofensividade e da culpa ([126]).

§ 74 Discordamos desta alegação, se bem que no presente contexto não tenhamos ainda que nos ocupar de considerações dogmáticas (por natureza, político-criminalmente subordinadas), mas unicamente do **discurso legitimador** subjacente. O que reafirmamos é por isso tão-só a inteira legitimação do legislador para, nomeadamente face à necessidade colectiva de contenção de mega-riscos globais, criar, se indispensável, incriminações acumulativas, protectoras de bens jurídicos colectivos. Se, p. ex., o legislador, baseado nos conhecimentos científicos disponíveis, conclui que a utilização maciça de produtos (mesmo que simples perfumes ou desodorizantes) sob a forma de *sprays* pode aumentar os danos da camada de ozono, está absolutamente legitimado para criminalizar o fabrico, a venda, a utilização, etc., de quaisquer produtos sob aquela forma. Tratar-se-á então patentemente de um delito acumulativo que todavia, em

([126]) DIAS, Silva, "What if everybody did it?": sobre a (in)capacidade de "ressonância" do direito penal à figura da acumulação, *RPCC 13*, 2003, p. 303. Cf., também, do mesmo A., nota 4, pp. 870 e ss., 879 e s. Interessante — embora duvidemos que possa contribuir para uma nova via de solução dos problemas dogmáticos que aqui se suscitam — a ideia de D'AVILA, Fabio, *Ofensividade e Crimes Omissivos Próprios (Contributo à Compreensão do Crime como Ofensa ao Bem Jurídico)*, 2003, p. 431 e ss., da "ofensividade em contextos instáveis" e em "hipóteses complexas".

nome de um bem jurídico colectivo de indiscutível referência jurídico-constitucional, é digno de pena; e se, ademais, os aludidos dados das ciências empíricas revelarem a necessidade da sua protecção, nada mais será necessário para a validade / legitimidade da incriminação. Tanto basta no presente contexto. Outra coisa — e subordinada, e posterior — serão os problemas dogmáticos que porventura se torne ainda necessário resolver (e que serão referidos, na medida necessária e possível, nos contextos respectivos). Mas mal iria ao direito penal se os propósitos político-criminais fundamentais tivessem de esperar a estabilização do trabalho dogmático sobre eles para só então se poderem impor; a história do direito penal mostra felizmente ser o contrário aquilo que sempre tem sucedido. Mas seja como for quanto a este ponto, podemos avançar desde já que, face a incriminações como a que imaginámos, não se vê que obstáculos possam levantar-se a nível de princípios como os da ofensividade e da culpa.

3.3. Conclusão

§ 75 Nesta medida acabamos por nos aproximar de certo modo, é verdade, da ideia de Stratenwerth segundo a qual a tutela dos grandes riscos e das gerações futuras pode em certos casos passar pela assunção de um *direito penal do comportamento* ([127]) em que são penalizadas e punidas puras *relações da vida como tais*. Não se trata com isto, porém, de uma alternativa ao direito penal do bem jurídico: ainda aqui **a punição imediata de certas espécies de comportamentos é feita em nome da tutela de bens jurídicos colectivos** e só nesta medida se encontra legitimada. Desta maneira se manterá a fidelidade possível ao paradigma jurídico-penal iluminista que nos acompanha e se espera possa continuar a ser fonte de desenvolvimentos e de progresso; e possa continuar assim a assumir o seu papel insubstituível na contenção dos mega-riscos da sociedade pós-industrial e na função tutelar dos interesses também das gerações futuras ([128]).

([127]) Criticamente, em definitivo, STELLA, *Giustizia e modernità*, ²2002, p. 419 e ss.

([128]) Essencialmente no sentido desta conclusão nos parece que se encontrava também DIAS, Silva, *Protecção*, nota 76, p. 32, ao escrever: "a protecção penal perante os grandes riscos abstrai das consequências (catastróficas) dos mesmos, para se centrar na proibição das condutas que socialmente os produzem (...). Mas a caracterização destes crimes (...) decorre da espécie de relação entre os comportamentos neles descritos e o bem jurídico protegido".

7.º CAPÍTULO

OS LIMITES DO DIREITO PENAL

§ 1 Da função do direito penal, por um lado, e da específica natureza das sanções criminais, por outro, derivam os **limites materiais** do próprio direito penal; limites que ganham particular relevo sob perspectivas várias — desde as jurídico-constitucionais, no que respeita ao modo de produção das leis, às jurídico-processuais e outras — e que são produto das especiais exigências da indispensável garantia dos direitos dos cidadãos em matéria penal. Mas limites que por vezes deparam com graves dificuldades em zonas penumbrosas da distinção. O que deriva sobretudo da circunstância de também em outros ramos do direito que não o penal — nomeadamente, no direito administrativo, no direito disciplinar, no direito processual e mesmo no direito privado (direito civil) — o legislador se servir de "penas", que todavia assumem o carácter de **penas não criminais**. Isto deixa perceber que, em último termo e uma vez mais, seja à natureza das *consequências jurídicas*, derivada do seu fundamento e das suas finalidades, que terá de ir buscar-se a fronteira da delimitação.

I. Direito penal e direito de mera ordenação social (direito das contra-ordenações): penas criminais e coimas

1. Do direito penal administrativo ao direito de mera ordenação social (1)

§ 2 A complexa tessitura da ordem jurídica dos Estados contemporâneos ultrapassa em muito o âmbito das normas respeitantes aos funda-

---

(1) A questão agora em consideração constitui desde há muito um dos temas preferidos do pensamento jurídico-penal português, sobre ele se tendo formado uma literatura particularmente abundante, de entre a qual se podem destacar: SILVA, Henriques da, Crimes, delitos e contravenções,

mentos ético-sociais da vida em comunidade, para tal tendo contribuído, com significado crescente, a **ordem administrativa**. Foi no tempo do *Estado de Polícia* iluminista que surgiu uma ampla esfera da Administração e um profuso ordenamento policial, todavia ainda sem subordinação a preceitos jurídicos (2). Com a *Revolução Francesa* porém a Administração juridifica-se e submete-se à legalidade, ao mesmo tempo que a actividade policial se concentra na protecção antecipada de perigos indeterminados para a consistência dos direitos subjectivos do cidadão (3); direitos subjectivos estes por sobre cujo âmbito essencialmente se demarcava também a função protectiva do direito penal. De sorte que, quando foi necessário procurar um enquadramento jurídico para as ofensas ao exercício da referida actividade policial da Administração, ele foi encontrado no conceito de **contravenção** e assim ainda **dentro** do direito penal e das suas formas de infracção (4).

§ 3 A situação altera-se — por razões económicas, sociais, políticas e culturais bem conhecidas, que estiveram na base das duas Grandes Guerras — com a transformação da Administração numa "Administração conformadora", que assume funções pertencentes a círculos progressivamente mais amplos do "cuidado com a existência" próprio do *Estado Social*. Neste tipo de Estado o interesse de uma Administração racional reside em cumprir as tarefas crescentes e cada vez mais complexas daquele "cuidado", na medida do possível, sem estorvos e de forma dinâmica. Apre-

---

Estudos Jurídicos, I, 1903, p. 410; FERREIRA, Cavaleiro de, I, p. 215 e ss.; SANTOS, Beleza dos, *Introdução*, p. 94 e ss.; CORREIA, Eduardo, *Lições 1949*, p. 213 e ss., e Direito Penal e Direito de mera Ordenação Social, *BFD 49*, 1973, p. 259 e ss.; BELEZA, Teresa, I, p. 129 e ss.; DIAS, Figueiredo, O movimento da descriminalização e o ilícito de mera ordenação social, *JDC 1983*, p. 315, Para uma dogmática do direito penal secundário, *RLJ 116*, 1983-4, p. 263, e *117*, 1984-5, p. 7, e Vom Verwaltungssatrafrecfht zum Nebenstrafrecht, *Jescheck-FS*, I, 1985, p. 79; ANDRADE, Costa, COSTA, Faria, MACHADO, Pedrosa e PINTO, Costa, todos *in*: IDPEE (org.), *Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários*, I, 1998; e, por último, DIAS, Silva, *"Delicta in se" e "Delicta mere prohibita": uma Análise das Descontinuidades do Ilícito Penal Moderno à Luz da Reconstrução de uma Distinção Clássica*, 2003, *passim*.

(2) Sobre o ponto, SOARES, Rogério, *Interesse Público, Legalidade e Mérito*, 1955, p. 56 e s.

(3) Para caracterização deste período, de novo, SOARES, Rogério, nota 2, p. 69 e ss.

(4) Daqui a célebre *concepção tripartida* da infracção penal que dava conteúdo ao art. 1.º do CP de Napoleão: *crimes, délits, contraventions*. Pormenorizadamente sobre toda esta evolução, DIAS, Silva, nota 1, p. 91 e ss., deixando todavia na penumbra a distinção de natureza entre o ilícito de polícia, filho do intervencionismo típico do despotismo esclarecido, e as contravenções, que representam apenas uma tentativa de protecção antecipada e indeterminada de direitos individuais fundamentais.

sentando-se as penas criminais como medidas coactivas dotadas de particular efectividade, tornou-se inevitável a tendência para as fazer intervir sempre que se julgava necessário revestir os imperativos estaduais, mesmo os de carácter administrativo, de uma particular força de vigência. Numa palavra, o legislador foi-se deixando seduzir pela ideia — perniciosa, mas difícil de evitar — de pôr o aparato das sanções criminais ao serviço dos mais diversos fins de política social; e assim deu ênfase ao fenómeno da *hiper-criminalização* e ao surgimento daquilo que se chamou o **direito penal administrativo**.

§ 4 É óbvio que uma tal situação não podia persistir à luz de uma política criminal, como a dos nossos dias, comandada pelo movimento da descriminalização (5). A consequência foi a de, no âmbito complexo e multifacetado daquilo que se chamava direito penal administrativo, se levar a cabo uma distinção fundamental, consoante as condutas por ele proibidas devessem ainda considerar-se **relevantes** à luz de uma qualquer valoração prévia de carácter ético-social — caso em que elas se manteriam dentro do domínio do direito penal e, na verdade, como constitutivas do que veio a ser chamado o *direito penal secundário*; ou pelo contrário devessem considerar-se ético-socialmente **neutras**, com a respectiva ilicitude só constituída materialmente pela proibição — caso em que elas foram atiradas para *fora* do direito penal e consideradas constitutivas de um ilícito administrativo. Assim surgiram as **contra-ordenações** que, no seu conjunto, conformavam o que passou a chamar-se o **direito** (administrativo, não penal!) **de mera ordenação social** e que coincidia com o cariz que havia entretanto assumido a velha categoria (penal) das contravenções. Com uma dupla consequência: a de que o âmbito do direito penal se enriquecia com a assunção plenamente penal (se bem que em certa medida autónoma) do direito penal secundário, quase sempre sob a forma de direito penal "extravagante"; e a de que a história das contravenções jurídico-*penais* chegava ao fim, devendo a categoria ser pura e simplesmente eliminada e substituída pela categoria jurídico-*administrativa* das contra-ordenações.

§ 5 A primeira consagração legislativa desta concepção teve lugar na **República Federal Alemã** logo após a II Grande Guerra com a promulgação, em 1949, da *Lei Penal da Economia* e, em 1952, da *Lei das Contra-Ordenações*. Assim se deu

(5) Especificamente sobre a relação entre o movimento da descriminalização e o direito de mera ordenação social, DIAS, Figueiredo, *JDC 1983*, nota 1, p. 315.

expressão legislativa aos estudos e recomendações de Eb. Schmidt no sentido da criação da **contra-ordenação** (*Ordnungswidrigkeit*) como categoria que visaria a satisfação de três ordens diferentes de **objectivos**: (1) a exigência de que se retirasse dos quadros do direito penal um larguíssimo número de infracções de nula ou duvidosa relevância ético-social, remetendo-as para os quadros do direito administrativo; (2) a necessidade de que essas infracções não fossem ameaçadas com penas criminais, mas com meras "advertências" sociais, sanções ordenativas ou coimas, onde ganhasse preponderância o carácter dissuasor próprio das sanções unicamente pecuniárias; e (3) a conveniência de revestir o processamento destas infracções de especificidades que permitissem a aplicação das sanções pelos agentes administrativos encarregados da fiscalização e controlo das respectivas actividades. Este modelo alemão das contra-ordenações não conseguiu durante muito tempo obter eco sensível a nível internacional (6). Já porém em 1962 Eduardo Correia o adoptou e o considerou como aquele que seria mais adequado ao direito penal português do futuro (7). A lei suíça de 23-3-1974 aproximou-se dele em muitos pontos, seguindo-se-lhe a Áustria; e o mesmo sucedeu com a Itália através da lei n.º 689 de 24-11-1981. Sobretudo depois que a *Association internationale de droit pénal* consagrou ao tema um dos seus congressos (Viena 1989), bem pode dizer-se que o modelo em análise é agora seguido com crescente atenção como sendo um dos caminhos por excelência para se operar uma adequada e conveniente descriminalização.

§ 6 O ilícito de mera ordenação social foi entre nós pela primeira vez consagrado no **DL 232/79, de 14-7**, ainda na vigência, por conseguinte, do CP de 1886. Numa postura maximalista, que excedia mesmo a solução consagrada no direito alemão até 1975, aquele diploma eliminou *sem resto* a categoria das contravenções puníveis com pena de multa, ao estabelecer no art. 1.º-3 que "são equiparáveis às contra-ordenações as contravenções ou transgressões previstas pela lei vigente a que sejam aplicáveis sanções pecuniárias". Logo porém o DL 411-A/79, de 1-10, revogou aquele art. 1.º-3, impedindo deste modo que se consumasse a preconizada transformação, em bloco e automática, das contravenções vigentes e puníveis só com multa em contra-ordenações. O DL 232/79 foi depois revogado e substituído pelo **DL 433/82, de 27-10**, que instituiu o novo regime geral do direito de mera ordenação social e do respectivo processo (8). Este

(6) Com uma análise minuciosa depara-se em MATTES, *Untersuchungen zur Lehre von den Ordnungswidrigkeiten*, I, 1977, e II (org. Herta Mattes), 1982. Do Tomo I há tradução espanhola de Rodríguez Devesa: *Problemas de Derecho Penal Administrativo. Historia y Derecho Comparado*, 1979.

(7) CORREIA, Eduardo, *ProjPG*, p. 68 e s.

(8) Diploma este que de "novo" pouco tem, na medida em que quase se limitou a acrescentar ao articulado do DL 232/79 o regime processual do *concurso* entre crime e contra-orde-

diploma foi depois reformulado — em pontos pouco significativos — pelo DL 356/89, de 17-10, e posteriormente pelo DL 244/95, de 14-9, e pela L 109/2001, de 24-12. Reformulação, a destes últimos diplomas, que pretende cobrir-se com a necessidade de uma mais consistente defesa dos direitos e garantias dos arguidos, mas que, em muitos pontos, se aproxima lamentavelmente de uma "*contra-revolução contra-ordenacional*" (9), a sugerir um regresso aos tempos passados do modelo (penal e processual penal) das contravenções (10).

§ 7 Ponto importante a assinalar é que, de uma perspectiva político-criminal, a **persistência da categoria penal das contravenções** a par de um ilícito de mera ordenação social legalmente institucionalizado é contraditória e sem sentido (11): ou um comportamento possui dignidade punitiva e deve constituir um crime, pertença este ao direito penal primário ou antes ao secundário; ou não a possui e deve ser descriminalizado e passar, se disso for caso, a constituir uma contra-ordenação punível com uma coima. E além de político-criminalmente contraditória e sem sentido, poderia a persistência da dualidade acabar por conduzir ao aniquilamento prático da categoria das contra-ordenações, se o legislador continuasse no futuro a deixar-se seduzir pelo vício da hiper-criminalização, criando novas contravenções. No entanto, a solução encontrada pelo legislador de 1982 — e que ainda hoje, já lá vão mais de 20 anos, persiste — pode ser explicada por ter o legislador receado os efeitos práticos nocivos que poderiam ligar-se a uma *global e automática transformação* da multidão de contravenções então ainda vigentes em contra-ordenações; tanto mais quanto essa transformação não poderia ser *total*, por haver ainda inúmeras contravenções puníveis só, ou também, com penas de prisão e que por isso não poderiam (ou deveriam) ser automaticamente convertidas em contra-ordenações. Daqui resultavam para o legislador português duas con-

nação, que o legislador governamental de 1979 se não teria sentido (compreensivelmente) legitimado para regular sem autorização da AR.

(9) No sentido desta conclusão, ao que nos pareceu, também, PINTO, Costa, O ilícito de mera ordenação social e a erosão do princípio da subsidiariedade da intervenção penal, *RPCC* 7, 1997, p. 147 e ss.

(10) Modelo este sempre defendido, em oposição ao das contra-ordenações e aos fundamentos em que este se louva, por FERREIRA, Cavaleiro de, I, p. 107 e ss. Ao invés, no mesmo sentido da nossa crítica, SILVA, Marques da, I, n.º 37.

(11) Neste sentido, logo, CORREIA, Eduardo, As grandes linhas da reforma penal, *JDC 1983*, p. 37; e também BELEZA, Teresa, I, p. 121.

dições que deveria cumprir: a primeira — à qual na verdade se manteve fiel — seria a de não criar nem mais uma contravenção, remetendo a totalidade das infracções a criar ou para o domínio dos crimes e do direito penal, primário ou secundário, ou para o domínio das contra-ordenações e do direito administrativo; a segunda seria a de proceder a um levantamento sistemático das contravenções ainda subsistentes no sistema e, uma vez ele feito, decidir quais delas deveria revogar, quais deveria transformar em contra-ordenações e quais deveria converter em crimes.

§ 8 Foi esse levantamento que o Governo levou recentemente a cabo, tarefa que culminou com a apresentação à AR de três propostas de lei visando converter em contra-ordenações todas as contravenções e transgressões subsistentes no ordenamento jurídico português. A conversão foi realizada pela L 25/2006, de 30-6 (no que diz respeito às transgressões ocorridas em matéria de infra-estruturas rodoviárias onde seja devido o pagamento de taxas de portagem), pela L 28/2006, de 4-7 (quanto às transgressões ocorridas em matéria de transportes colectivos de passageiros), e pela L 30/2006, de 11-7, art. 35.º (pela qual todas as restantes contravenções e transgressões previstas na legislação em vigor passam a assumir a natureza de contra-ordenações). Assim, **revogou o legislador português agora** — como o alemão em 1975 —, em definitivo, **as normas relativas a contravenções**, pondo termo à situação político-criminalmente inadmissível, e mesmo caricata, de terem continuado entre nós em vigor até 2006 normas penais e processuais penais ([12]) relativas a contravenções.

2. Fundamentos e sentido da autonomização do direito de mera ordenação social

§ 9 Os fundamentos em seu tempo apontados por Eb. Schmidt para a autonomização do direito de mera ordenação social e para a sua consideração substancial como direito administrativo, antes que como direito penal, permanecem intocados na sua essência: seja o relacionado com a natureza do ilícito, seja o relacionado com a natureza da sanção, seja o relacionado com as especificidades processuais. Decisivos no contexto das nossas preocupações se revelam porém unicamente os dois primeiros, que

([12]) Para estas últimas, DL 17/91, de 10-1.

assim serão em seguida considerados ([13]). Não porém sem antes se fazer notar que, segundo o disposto no art. 1.º-1 do DL 433/82, "constitui contra-ordenação todo o facto ilícito e censurável que preencha um tipo legal no qual se comine uma coima". É por conseguinte através de um **índice conceitual-formal** que o legislador decidiu operar praticamente a distinção entre crimes e contra-ordenações: se entende que um certo facto deve constituir uma contra-ordenação tem forçosamente de lhe aplicar, como sanção, uma **coima**. Esta decisão legislativa é de aplaudir. Dada a natureza altamente questionável, no plano doutrinal, dos critérios substanciais avançados para a distinção entre crimes e contra-ordenações, bem como (ainda mais) a patente dificuldade que quase sempre representa a aplicação de tais critérios a um concreto facto, pode mesmo afirmar-se que aquela solução é a única praticamente exequível. Ela não significa porém que *atrás* da decisão legislativa não estejam (e devam estar) razões de ordem **substancial** que a comandam e que ela deva respeitar.

2.1. A autonomia material do ilícito

§ 10 Já se pensou — e continua a pensar-se, na Alemanha mesmo predominantemente — em negar a possibilidade de delimitação *material* do ilícito penal e do ilícito de mera ordenação social na base de não poder reconhecer-se a existência de um **ilícito** *ético-socialmente indiferente*, mesmo que ele seja de "mera" ordenação social. Quem sustente esta impossibilidade tem, quanto a nós, razão. Mas já a não tem quando daqui pretenda concluir pela impossibilidade de delimitação material entre os dois ilícitos. Necessário é que a perspectiva da "indiferença ético-social" se dirija não imediatamente aos *ilícitos* — que supõem já realizada a valoração legal —, mas às **condutas** que os integram ([14]). Existem na verdade condutas às quais, antes e independentemente do desvalor da ilicitude, corresponde, e condutas às quais não corresponde um mais amplo desvalor moral, cultural ou social. A conduta, independentemente da sua proibição

([13]) Sem prejuízo de dever reconhecer-se que também as especificidades do processo contra-ordenacional (sobre elas, em síntese, DIAS, Figueiredo, *JDC 1983*, nota 1, p. 334 e ss.) ajudam — a muitos títulos, poderosamente — a consolidar a distinção material entre o direito penal e o direito das contra-ordenações.

([14]) No sentido que em seguida se expõe, já, DIAS, Figueiredo, *O Problema*, § 20, II. A favor deste critério, SILVA, Marques da, I, p. 157; contra, CARVALHO, Taipa de, I, §§ 222, 235 e ss.

legal, é no primeiro caso **axiológico-socialmente relevante**, no segundo caso **axiológico-socialmente neutra**. O que no direito de mera ordenação social é axiológico-socialmente neutro não é o *ilícito*, mas a *conduta em si mesma*, divorciada da proibição legal; sem prejuízo de, uma vez conexionada com esta, ela passar a constituir substrato idóneo de um desvalor ético-social. É este o critério decisivo que está na base do princípio normativo fundamentador da **distinção material** entre ilícito penal e ilícito de mera ordenação social.

§ 11 Do exposto resulta que no primeiro caso estamos perante condutas cujos elementos constitutivos, no seu conjunto, suportam imediatamente uma valoração — social, moral, cultural — na qual se contém já a valoração da ilicitude. No segundo caso, pelo contrário, não se verifica uma correspondência imediata da conduta a uma valoração mais ampla daquela espécie; pelo que se, não obstante ser assim, se verifica que o direito valora algumas destas condutas como ilícitas, tal só pode acontecer porque o **substrato da valoração jurídica** não é aqui constituído apenas pela conduta como tal, antes por esta acrescida de um elemento novo: a **proibição legal**. Não se tratando tão-pouco, por isso ([15]), de que, no caso das contra-ordenações "a proibição (...) transforma o sentido primeiro e eticamente neutro da conduta em eticamente relevante". Do que se trata é só de que nelas é o substrato complexo formado pela conduta *e* pela decisão legislativa de a proibir que suporta a valoração da ilicitude; a conduta em si mesma considerada, independentemente da proibição, não é, pelo contrário, substrato idóneo do juízo de desvalor próprio da ilicitude. Por isso aliás terá de condenar-se também a pretensão ([16]) de distinguir o direito penal e o de mera ordenação social porque só o primeiro, não o segundo, protegeria **bens jurídicos**. Pode afirmar-se, pelo contrário, que *todo o ilícito ofende um "bem" juridicamente protegido*; mas também isto não obsta a que, enquanto em certas infracções — os crimes — o bem jurídico protegido existe independentemente da proibição, noutras — as contra-ordenações —

([15]) Como agora critica DIAS, Silva, nota 1, p. 38 e ss.

([16]) Que, remontando a Merkel, ocupou boa parte da história da distinção entre direito penal de justiça e direito "penal" administrativo. Contra também, CORREIA, Eduardo, I, p. 28, DIAS, Figueiredo, nota 13, e agora, também, COSTA, A. M. Almeida, A propósito do novo Código do Trabalho: bem jurídico e pluralidade de infracções no âmbito das contra-ordenações relativas ao "trabalho suplementar". Subsídio para uma dogmática do direito de mera-ordenação-social-laboral, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 1035.

só se desenha quando a conduta se conexiona com a regra legal que a proíbe. Neste contexto é uma razoável forma de expressão — "forma de expressão", repetimos, não necessariamente proposição dogmática, à qual tenham de ligar-se extensas cadeias dedutivas produtoras de consequências em diversos lugares da doutrina geral do crime, máxime, em tema de dolo, de culpa e de erro — dizer-se, com Lange, que no direito de mera ordenação o bem jurídico é só *motivo* e não *conteúdo* do tipo, ou que a ilicitude é só *consequência* e não *causa* da proibição legal ([17]).

§ 12 Perde deste modo alguma acuidade a questão — que tem sido e continua a ser discutidíssima — de saber se o aludido critério de distinção entre o ilícito penal e o contra-ordenacional é **qualitativo** (como era ideia de Eb. Schmidt e, entre nós, de Eduardo Correia) ou meramente **quantitativo** ([18]). Postas as coisas no pé em que foram colocadas, deve afirmar-se que a distinção é sempre **material** e não meramente formal e que o ilícito de mera ordenação social não tem que ser reduzido a infracções bagatelares ([19]). O que não obsta a que ao aludido critério material o legislador acrescente em certos casos *critérios adicionais de distinção* (ainda no que toca aos ilícitos); e mesmo critérios de "*quantidade*", quando esta como que se converte em qualidade, isto é, quando seja condição da relevância axiológico-social de uma conduta o facto de que ela assuma um certo limiar de gravidade objectiva. O que se passa com a *alcoolemia* ao volante é, em nosso parecer, exemplo claríssimo do que afirmamos. Se o condutor circula com um grau de alcoolemia entre 0,5 e 0,8 g/l isso constitui juridicamente uma contra-ordenação grave (CE, art. 145.º/*l*)); se o grau se situa entre 0,8 e 1,2 g/l a contra-ordenação é muito grave (CE, art. 146.º/*j*)); se a alcoolemia é igual ou superior a 1,2 g/l a conduta respectiva constitui crime (art. 292.º-1). Não teria razão quem pensasse que nestas diferenciações está em causa um critério puramente formal-quantitativo. O que está presente é sim a consideração decisiva de que perante 1,2 g/l ou valor superior de álcool no sangue a conduta torna-se ético-socialmente relevante e passa a constituir substrato susceptível de a ele se ligar a respectiva criminalização, atento o salto "qualitativo" que naquele limite sofre a perigosidade social da conduta e a sua censurabilidade ética (nisto se cifrando a sua correspondência a uma prévia e mais ampla valoração), independentemente de qualquer juízo jurídico de ilicitude.

([17]) LANGE, Nur eine Ordnungswidrigkeit?, *JZ*, 1957, p. 325. Cf., depois, MICHELS, *Strafbare Handlung und Zuwiderhandlung*, 1963. No sentido do texto, também, SILVA, Marques da, I, n.º 37.

([18]) Assim, ANDRADE, Costa, nota 1, p. 98 e ss.

([19]) Importante sobre este ponto, KRÜMPELMANN, *Die Bagatelldelikte*, 1966, e PALIERO, "*Minima non curat prætor*". *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatelari*, 1985. Aplica o critério que defendemos ao domínio das infracções fiscais, SOUSA, Susana Aires de, *Os Crimes Fiscais. Análise Dogmática e Reflexão sobre a Legitimidade do Discurso Criminalizador*, 2006, p. 265 e s.

§ 13 Uma última referência neste contexto é devida ao relacionamento de um e outro direito com a ordem axiológica constitucional: compreende-se que o atrás assinalado relativamente ao relacionamento com aquela ordem (supra, 6.º Cap., § 26 e s.) só possa valer para o direito penal, não para o direito das contra-ordenações. Devemos insistir em que não é à Constituição que pode pedir-se que decida em cada caso, de forma imediata e definitiva, se uma certa conduta pode constituir um crime ou antes uma contra-ordenação. Mas é a ela que em último termo terá de recorrer-se para saber, em casos duvidosos, se foi ou não respeitado o critério material que há-de estar na base da decisão de qualificação jurídica e comandá-la. Tanto mais quanto uma tal qualificação releva sob pontos de vista jurídicos decisivos. São diferentes os **princípios jurídico-constitucionais, materiais e orgânicos**, a que se submetem a legislação penal e a legislação das contra-ordenações (CRP, art. 165.º-1*c)* e *d)*). Por isso, através de uma qualificação de todo o ponto injustificada (exs. de escola: considerar o homicídio doloso como contra-ordenação, ou como crime ambiental o desfolhar uma modesta flor selvagem numa mata nacional), o legislador ordinário poderia subtrair-se à incidência dos preceitos jurídico-constitucionais que ao caso devessem caber. Decerto, a *tradução prática da distinção* constitui, nos termos que ficaram apontados, uma questão discricionária para o legislador ordinário. Mas ela terá sempre de respeitar o critério fundamental de distinção substantiva entre os dois ilícitos. Assim se tornando possível individualizar, a partir da ordem axiológica constitucional, condutas que indiscutivelmente pertencem ou ao direito penal ou ao direito das contra-ordenações e sindicar consequentemente, pela via da fiscalização constitucional, uma decisão em contrário do legislador ordinário.

§ 14 Da autonomia do ilícito de mera ordenação social resulta uma larga **autonomia dogmática** do direito das contra-ordenações, como aliás se revela nos primeiros 16 artigos do DL 433/82. Autonomia relativa, é certo, logo porque, nos termos do art. 32.º, as normas do CP constituem *direito subsidiário* perante o direito substantivo das contra-ordenações; o que bem se compreende considerando que o direito das contra-ordenações se não é direito penal, é em todo o caso direito sancionatório de carácter punitivo (tal como o são os direitos que nos apartados seguintes serão considerados). Mas autonomia, em todo o caso, que se revela amplamente ([20]) em matérias, entre outras, como as do âmbito de vigência da lei contra-ordenacional, da responsabilização das pessoas colectivas, da culpa, do erro e da autoria.

([20]) Cf., sobre o ponto, DIAS, Figueiredo, *JDC 1983*, nota 1, p. 331 e s.

§ 15 No que toca à **culpa**, temos considerado por demais discutível a eliminação, levada a cabo pelo DL 244/95, do antigo n.º 2 do art. 1.º do DL 433/82, segundo o qual "a lei determinará os casos em que uma contra-ordenação pode ser imputada independentemente do carácter censurável do facto". Esta consideração tem sido variamente criticada ([21]), como se no nosso pensamento estivesse que as contra-ordenações poderiam ser imputadas independentemente da culpa e, portanto, a título de responsabilidade *objectiva*. Admitimos que essa seja uma interpretação possível de qualquer afirmação por nós feita anteriormente, mas não foi nunca essa a ideia que quisemos exprimir. Foi sim a de que, não sendo a conduta contra-ordenacional, em si mesma tomada, um substrato axiologicamente relevante, a culpa contra-ordenacional não pode ser igualada à (e confundida com a) culpa jurídico-penal; da mesma forma que desde o nosso primeiro escrito ([22]) defendemos acontecer com a *culpa jurídico-civil*. Reconhecendo que, em matéria de culpa contra-ordenacional, a última palavra pertence à ciência do direito administrativo, não cremos que ela possa vir a ser materialmente concebida (como diremos que sucede no direito penal, infra, 19.º Cap.) como o ter o agente que responder pela personalidade — pela atitude pessoal — que se exprime no facto ilícito-típico e o fundamenta; com o cortejo de implicações dogmáticas e prático-normativas que aquela determinação material contém. A nossa afirmação baseia-se pois na convicção de que era para uma tal diferenciação que apontava o texto original do art. 1.º-2 do DL 433/82 e não quer pôr em causa o princípio, que sempre também defendemos, segundo o qual a exigência de culpa constitui uma garantia em princípio válida para todo o domínio sancionatório.

2.2. A autonomia da sanção

§ 16 Já acima ficou dito o essencial sobre a natureza da sanção das contra-ordenação, a **coima**. Trata-se nela de uma sanção exclusivamente patrimonial (que pode, nos termos do art. 17.º do DL 433/82, oscilar entre € 3,74 e € 3.740,98 para as pessoas singulares e ser elevada até € 44.891,81 para as pessoas colectivas) que todavia claramente se diferencia, na sua essência e nas suas finalidades, da pena criminal. Tal como na pena criminal, também na coima o pensamento da retribuição não joga qualquer papel, pelo que em questão podem estar apenas finalidades preventivas. Certo é, em todo o caso, que a coima se não liga, ao contrário da pena criminal, à personalidade do agente e à sua atitude interna (consequência da diferente natureza e da diferente função da culpa na responsabilidade pela contra-ordenação), antes serve como mera admo-

([21]) Por último, COSTA, A. M. Almeida, nota 16, p. 1043[10] e [13], e bibliografia concordante por ele citada.

([22]) DIAS, Figueiredo, Sobre a reparação de perdas e danos arbitrada em processo penal, *Estudos Beleza dos Santos*, p. 87.

nição, como especial **advertência** ou **reprimenda** relacionada com a observância de certas proibições ou imposições legislativas. Deste ponto de vista pode afirmar-se que as finalidades da coima são em larga medida **estranhas a sentidos positivos de prevenção**, nomeadamente de prevenção especial de socialização. Por isso que, como logo acentuou com razão Eb. Schmidt, falta à coima o "*pathos* ético" que à pena criminal, sem prejuízo da concepção puramente preventiva das suas finalidades, sempre cabe. Desta específica natureza da sanção contra-ordenacional resultam algumas consequências importantes para o **regime** respectivo. Desde logo, a de o efeito da falta de pagamento da coima só poder ser a *execução* da soma devida, nos termos do art. 89.º do DL 433/82 e *nunca a da sua conversão em prisão subsidiária*, como sucede com a pena de multa criminal (art. 49.º).

§ 17 O art. 89.º-A do DL 433/82, acrescentado pelo DL 244/95, veio todavia permitir que, a requerimento do condenado, possa o tribunal ordenar que a coima aplicada seja total ou parcialmente substituída por "**prestação de trabalho a favor da comunidade**" (n.º 1), sendo a correspondência das duas sanções "regulada por legislação especial" (n.º 2) — legislação que até ao momento não foi editada ([23]), permanecendo por isso esta possibilidade, felizmente, como mera *law in the book*. A prestação de trabalho a favor da comunidade é uma pena criminal de substituição da pena criminal de prisão (art. 58.º e s.), com um sentido, uma natureza e umas finalidades específicas — onde avulta a prevenção especial positiva ou de socialização — e que não deve por isso, através de uma qualquer "burla de etiquetas", ser transformada sem mais numa sanção contra-ordenacional. Idêntica burla de etiquetas pode divisar-se — e aqui a regulamentação provém já, ao menos no essencial, da redacção original do DL 433/82 — em alguns aspectos da matéria relativa às **sanções acessórias** (arts. 21.º a 26.º), *v. g.*, perda de objectos, interdição do exercício de profissões ou actividades, privação do direito a subsídio ou benefício, como de participar em feiras, mercados, arrematações, concursos, etc., encerramento de estabelecimento, suspensão de autorizações, licenças ou alvarás. A natureza de algumas destas sanções, uma vez mais, aproxima-se sensivelmente da das sanções criminais, sejam penas ou medidas de segurança, quando com ela por vezes pura e simplesmente se não confunde ([24]). Na medida em que assim seja, a regulamentação respectiva pode vir a ser declarada inconstitucional. Tanto mais quanto nem sempre funcionam aqui — ou podem não funcionar — princípios jurídico-constitucionais imperativos como os da *subsidiariedade* e da *proporcionalidade* que devem todavia considerar-se válidos não apenas para a matéria penal, mas para toda a matéria sancionatória.

([23]) O DL 375/97, de 24-12, que veio regulamentar os aspectos técnicos e procedimentais da prestação de trabalho a favor da comunidade, restringe claramente o seu campo de aplicação à prestação de trabalho a favor da comunidade enquanto *pena* (arts. 2.º/*a*) e 15.º), não sobrando espaço para a sanção contra-ordenacional.

([24]) DIAS, Figueiredo, *JDC 1983*, nota 1, p. 324.

§ 18 De algum modo ligada a esta problemática está a questão de saber se, de um ponto de vista material, se manterá a essência acabada de evidenciar da "coima" quando o legislador designe como tal **sanções aplicáveis a título principal** que, sendo ainda porventura sanções administrativas, todavia não possuem o carácter estritamente *patrimonial* assinalado. A questão suscita-se legitimamente p. ex. perante a L 30/2000, de 29-11, relativa ao consumo de drogas ([25]). No domínio das sanções acessórias do direito das contra-ordenações sempre existiram sanções de carácter não patrimonial; mas elevar estas sanções, ou outras análogas, à categoria de sanções principais é procedimento que pode estar político-administrativamente e formal-legislativamente justificado, mas que põe em risco a racionalidade e a funcionalidade da distinção entre sanções penais e sanções administrativas.

3. Um juízo conclusivo

§ 19 Estabelecida pela forma que fica descrita, a distinção entre ilícito penal e ilícito administrativo resulta clara, tanto quanto possível, e fundamentada. Ela adequa-se, por outro lado, ao devir histórico, ideológico, social e político dos dois ramos de direito desde os meados do séc. XVIII e não constitui um simples epifenómeno de lucubrações doutrinárias obscuras e injustificadas, antes oferece legitimação a uma paulatina evolução e a um crítico desenvolvimento. Mais de um quarto de século de pacífica vigência do ilícito de mera ordenação social e das contra-ordenações mostra a sem razão dos que viram neles o fruto de uma acrítica importação de complicadas construções dogmáticas germânicas ([26]) ou do "devaneio doutrinário de um jurista... [obviamente, Eduardo Correia] que será deferentemente citado nos manuais germânicos da especialidade" ([27]). Concluir como concluímos não significa porém desconhecer os perigos que se perfilam para aquela evolução e desenvolvimento e que, se avaliamos correctamente a situação das coisas, provêm de duas fontes.

§ 20 Uma primeira fonte radica na tendência — claramente inscrita na chamada "Escola de Frankfurt" — de alargar o âmbito de incidência do

---

([25]) MONTEIRO, Cristina, O consumo de droga na política e na técnica legislativas: comentário à Lei 30/2000, *RPCC 11*, 2001, p. 71 e ss. Cf., também, em tese, para o direito contra-ordenacional em matéria laboral, COSTA, A. M. Almeida, nota 16, p. 1050 e s.

([26]) Como foi o caso de FERREIRA, Cavaleiro de, I, pp. 7, 43 e ss.

([27]) *Expresso* de 28-7-1979. Talvez que — como aí se suspeita — haja milhões de portugueses que morram sem saber o que é uma contra-ordenação e uma coima; mas é razoável supor que muitos outros milhões dos seus filhos saibam o que é uma contra-ordenação, se bem que já não saibam o que haja sido uma contravenção.

ilícito administrativo à custa do ilícito penal; para que sobre aquele, e não sobre este, pese a responsabilidade de obviar aos grandes e novos riscos da sociedade pós-industrial através da construção de um **"direito de intervenção preventivo"** dotado de *sanções (administrativas) mais fortes, pesadas e diversificadas* relativamente às coimas. A crítica desta abordagem já foi feita (supra, 6.º Cap., § 63). Aqui cumpre apenas dar ênfase ao facto de que um tal procedimento corre o sério perigo de misturar inextricavelmente as duas espécies de ilícito: quer na medida em que o ilícito administrativo passe a assumir competência exclusiva para sancionar certos ilícitos **dignos e carentes de pena**; quer na medida em que as sanções administrativas aplicáveis deixem de ser a coima para constituir, com diferente etiqueta, verdadeiras **penas ou medidas criminais**.

§ 21 Mas estes perigos podem ter outra proveniência. Mesmo independentemente de qualquer assumida exigência de alteração do paradigma penal actual, há por toda a parte uma apetência dos Executivos — só controlável pelas jurisprudências constitucionais e não certamente com meios políticos — para a criação de contra-ordenações e de coimas (cada vez mais pesadas) em lugar da via correcta da criminalização. O que fica a dever-se a propósitos de utilização de meios sancionatórios para diuturno **governo da sociedade** e de subtracção ao sempre custoso e demorado **processo parlamentar de produção legislativa** em matéria penal. Se também o legislador parlamentar se deixar seduzir — como entre nós sucedeu com o DL 244/95, de 14-9 (supra, § 6) —, mesmo a coberto de uma mais consistente defesa dos direitos fundamentais das pessoas, pela aplicação de princípios garantísticos especificamente penais à matéria administrativa (contra-ordenacional) a que são substancialmente estranhos; e pela criação de verdadeiras sanções penais, principais ou acessórias, travestidas de meras sanções contra-ordenacionais — então a distinção entre o ilícito penal e o administrativo será de novo seriamente posta em causa e, por via dela, serão afinal os direitos fundamentais das pessoas que sofrerão grave e irreparável dano.

II. Direito penal e direito disciplinar: penas criminais e sanções (medidas) disciplinares

§ 22 O direito disciplinar e as respectivas sanções conformam porventura o domínio que, de um ponto de vista teorético, **mais se aproxima** do direito penal e das penas criminais. Diferentemente do que sucede com o direito das contra-ordenações, os comportamentos integrantes do

ilícito disciplinar **não podem dizer-se axiologicamente neutros**, como tão-pouco pode afirmar-se que o ilícito respectivo é aqui constituído também pela proibição.

§ 23 A essência do ilícito disciplinar e das medidas disciplinares encontra a sua justificação no especial significado e função que o **serviço público** — e nele os agentes, empregados ou funcionários públicos — assume nos quadros do Estado de Direito democrático: passado o tempo em que aquele se traduzia essencialmente em um puro *dever de obediência* do agente relativamente ao seu superior hierárquico (infra, 18.º Cap., § 7 e ss.), o serviço público é hoje perspectivado pelo cumprimento de uma função própria e insubstituível no processo dinâmico de integração das funções específicas do Estado, estritamente subordinado ao *princípio da legalidade da Administração*. Daqui resulta para o agente administrativo o asseguramento de uma série de direitos profissionais, mas também a imposição de especiais *deveres* no interesse da comunidade jurídica: a relação de serviço jurídico-pública é antes de tudo uma abrangente **relação de dever** que serve o interesse público em nome da integridade e da confiança. Se através de um certo comportamento o funcionário viola aquela relação de dever (que lhe incumbe pela posição em que está investido e pela função que cumpre) e, por aí, a **integridade** e a **confiança** de que o serviço deve gozar, comete, sob determinados pressupostos, um ilícito disciplinar e torna-se passível de medidas (sanções) disciplinares.

§ 24 Por esta via se alcançam os **critérios fundamentais de distinção** entre o ilícito penal e o ilícito disciplinar. Desde logo se deve dizer que o ilícito disciplinar é, ao contrário do ilícito penal, um ilícito **interno**, exclusivamente virado para o serviço, que se pode constituir ainda quando com ele se não tenha verificado um abalo da autoridade estadual ou da Administração; diversamente do que sucede com o ilícito penal próprio dos "crimes cometidos no exercício de funções públicas" — aqueles relativamente aos quais a distinção dos dois ilícitos se torna mais difícil e questionável —, que se constitui apenas quando se verifica uma lesão ou perigo de lesão daquela autoridade (ou, como muito justamente se diz também, da "autonomia intencional do Estado" ([28])). E já por aqui se

([28]) Para a sua caracterização como bem jurídico específico da maioria dos crimes cometidos no exercício de funções públicas, COSTA, A. M. Almeida, Sobre o crime de corrupção,

pode fundadamente afirmar que o ilícito disciplinar não é simplesmente um *minus*, mas verdadeiramente um *aliud* relativamente ao ilícito penal ([29]). Em segundo lugar porém, e por outro lado, o que fica dito não afecta decisivamente a conclusão de ser a distinção um âmbito largamente dominado pelo **princípio da subsidiariedade**. É indiscutível que muitas violações dos deveres de serviço não assumem a gravidade suficiente para serem ameaçadas com penas criminais, enquanto relativamente a outras tais penas se revelam necessárias. Nesta acepção, também aqui razões de "quantidade" são susceptíveis de se transformar em razões de "qualidade" e de ser legitimamente chamadas à distinção entre os dois ilícitos. Da tensão entre os dois critérios apontados de distinção resultam *consequências* da maior importância para o regime do ilícito disciplinar e da sua confrontação com o ilícito penal.

§ 25 Importa desde logo contrariar a doutrina, muito difundida, segundo a qual a sanção disciplinar se distinguiria da criminal por ser completamente estranha àquela qualquer fundamentação ou **finalidade retributiva**. Isto é em si exacto; mas sendo igualmente exacto para a pena criminal, não pode divisar-se aqui qualquer critério válido de distinção das duas espécies de sanções. Fundada é apenas a verificação de que a medida disciplinar esgota a sua função e finalidade — diversamente do que sucede com a pena criminal — no asseguramento da funcionalidade, da integridade e da confiança do serviço público. Por isso mesmo, diversamente do que sucede com a pena criminal, não pode apontar-se à medida disciplinar uma finalidade primária (nem, na verdade, secundária) de **prevenção geral**, seja ela positiva ou negativa ([30]), mas apenas de **prevenção especial**.

§ 26 Contestada deve igualmente ser a doutrina ([31]) segundo a qual a essência e o fundamento do ilícito disciplinar conduziriam à conclusão de que nele se trata de um **direito referido ao agente**, diversamente do que sucede com o direito penal próprio de um Estado de Direito democrático que tem de ser por força um **direito referido ao facto** (infra, 10.º Cap., § 1

Estudos Eduardo Correia, I, 1989, p. 139 e ss., e *Comentário Conimbricense*, III, art. 371.º, § 7 e ss.

([29]) M / ZIPF, § 1, n.º 17 e s.

([30]) Assim, também, ROXIN I, § 2, n.º 136.

([31]) Também ela muito difundida entre nós: por todos, CAETANO, Marcelo, *Do Poder Disciplinar no Direito Administrativo Português*, 1932, p. 23 e ss.

e ss.). O que estaria ligado sobretudo à circunstância de as exigências da **tipicidade** das infracções — e consequentemente também da **culpa** — se encontrarem no direito disciplinar extremamente amortecidas relativamente ao que sucede, por força do estrito princípio de legalidade (infra, 8.º Cap., § 16 e s.), no direito penal. Não deve ser assim; e não é assim segundo o direito disciplinar português vigente. Sem prejuízo de dever reconhecer-se que o direito disciplinar é, em maior medida que o direito penal, *orientado para o agente*, não pode esquecer-se que se trata aqui de *direito sancionatório* e que por isso uma consistente defesa dos direitos dos arguidos impõe que sejam respeitados no essencial os princípios garantísticos que presidem ao direito penal. Por isso o Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local (DL 24/84, de 16-1), se não tipicizou as infracções — os tipos de factos — que dão origem à responsabilidade disciplinar, descreveu em todo o caso e na medida possível os deveres, desde o dever geral dos funcionários e agentes aos seus concretos deveres de isenção, de zelo, de obediência, de lealdade, de sigilo, de correcção, de assiduidade e de pontualidade, cuja violação sujeita os funcionários e agentes ao poder disciplinar (art. 3.º do DL 24/84). Com isto se terá posto fim a uma longa querela que, na esteira da doutrina do séc. XIX fundada na concepção de Duguit, se estabeleceu quanto a saber se também o chamado **hábito externo** (dito "estatuto negativo") do funcionário — a condução da sua vida particular — poderia fundar uma responsabilidade disciplinar. A esta questão deve hoje responder-se **negativamente**: só na medida em que aquela condução da vida do funcionário ou agente conduza à violação de um dos citados deveres pode o funcionário ser disciplinarmente responsabilizado; é sempre a violação do *dever funcional*, nunca aquela condução, que fundamenta a responsabilidade ([32]).

§ 27 Não pode, por último, fazer-se a contraposição entre os dois ilícitos na base de que o penal seria orientado para a lesão do **bem jurídico** (*hoc sensu*, desvalor de resultado), enquanto o disciplinar se constituiria através da **violação do dever** (*hoc sensu*, desvalor de acção). Esta última afirmação é em princípio exacta ([33]). Mas em definitivo nem o ilícito disciplinar — no seu estado de compreensão actual — deve considerar-se

([32]) Substancialmente já no sentido desta conclusão, CORREIA, Eduardo, *Lições 1949*, p. 39 e s.

([33]) Assim, também, BORGOA Arenales, Elena, A relação entre o ilícito disciplinar e o direito penal e os crimes de funcionários, *Estudos Cunha Rodrigues*, I, 2001, p. 219.

estranho à função de tutela de bens jurídicos (se bem que não jurídico-penais); nem, muito menos, o ilícito penal é exclusivamente fundado no desvalor de resultado, antes sim abrange também o desvalor de acção (infra, 11.º Cap., § 6 e ss.), o qual se analisa primordialmente, em muitos casos — sobretudo no dos chamados "crimes específicos" (infra, 11.º Cap., § 34 e ss.) —, na violação de um dever.

§ 28 Os fundamentos apontados de autonomia do ilícito disciplinar perante o ilícito penal dão todavia a compreender que ainda hoje possa defender-se — como sempre a doutrina portuguesa dominante pensou — que, relativamente ao mesmo facto, a medida disciplinar seja **cumulável** com a pena criminal. Desde logo, não existe óbice jurídico-constitucional a esta solução, uma vez que o princípio *ne bis in idem* é limitado à proibição de "ser julgado mais do que uma vez pelo mesmo *crime*" (CRP, art. 29.º-5). A solução era particularmente questionável quando o direito penal (como entre nós aconteceu até 1995) conhecia uma sanção penal acessória de *demissão da função pública* (art. 66.º do CP de 1982) cujo conteúdo era exactamente o mesmo que o da medida do mesmo nome no direito disciplinar ([34]); situação que todavia se alterou com a reforma de 1995, a qual eliminou a pena criminal acessória de demissão e a substituiu pela de *proibição (temporária) de assunção ou exercício da função pública*. Não há pois hoje nenhuma objecção de princípio à cumulação. Mas nem por isso deixará de poder questionar-se a sua bondade político-criminal e de perguntar-se se em vez dela não seria preferível um sistema que deixasse seguir até ao fim o processo criminal e, uma vez que este conduzisse à aplicação da sanção acessória de proibição de exercício da função, se considerasse *consumido* o poder disciplinar conducente à demissão; sem prejuízo de, no tempo intermédio, poder decretar-se a medida disciplinar de suspensão do exercício da função. Se assim deve ser ou não é coisa porém que não pertence em definitivo ao legislador penal decidir, antes sim ao legislador disciplinar.

§ 29 A situação é ainda mais grave no que toca à **prisão disciplinar** existente no direito disciplinar militar (arts. 27.º e 28.º do Regulamento de Disciplina Militar — DL 142/77, de 9-4, ainda em vigor) ([35]). Não fosse a credencial específica que lhe

([34]) Sobre o ponto, criticamente do ponto de vista jurídico-penal, o nosso *DP II*, §§ 207 ss., 227 ss.

([35]) O TC declarou inconstitucionais as normas que mandam aplicar a prisão a não militares (*v. g.*, agentes da PSP: Ac. do TC 103/87, de 24-3-1987).

é oferecida pelo art. 27.º-3/*d)* da CRP e a conclusão pela sua inconstitucionalidade material pareceria inevitável. O art. 3.º do citado Regulamento procura salvar os problemas que poderiam suscitar-se em matéria de concorrência da responsabilidade penal e disciplinar pelo mesmo facto, ao estatuir que "infracção de disciplina punível por este regulamento é toda a omissão ou acção contrária ao dever militar que *pelo CJM* [Código de Justiça Militar] *não seja qualificada crime*". Sem pleno êxito deve dizer-se, na medida em que o "crime" pode como tal ser qualificado não pelo Código de Justiça Militar, mas pelo CP ou outra lei penal não militar. Parece-nos insustentável que, *pelo mesmo facto*, o agente possa sofrer uma privação de liberdade disciplinar e uma privação de liberdade criminal. Sendo duvidoso que o instituto do *desconto* (arts. 80.º e 82.º do CP ([36])), mesmo extensivamente interpretado, ofereça saída bastante e razoável para os problemas que neste ponto podem suscitar-se. Também aqui a consideração de uma "*consumpção*" do direito disciplinar pelo direito penal parece ser a que pode conduzir a soluções mais correctas e mais justas.

III. Direito penal e direito processual: penas criminais e sanções (medidas) de ordenação ou conformação processual

§ 30 Sanções de ordenação processual são medidas aplicadas a comportamentos que violam a ordenação legal-formal (isto é, as formalidades de uma tramitação sem entraves) de um processo ou representam um abuso intolerável de poderes ou de situações processuais. Assim, e no que respeita ao processo penal, podem ser aplicadas tais sanções — em princípio sob a forma de **unidades de conta processual (UCs)** ([37]) —, *v. g.*, a quem apresente um requerimento de recusa do juiz ou de aceleração processual manifestamente infundado; a quem, regularmente convocado ou notificado, falte injustificadamente a acto processual; ao perito substituído que o juiz considere que violou grosseiramente os deveres que lhe incumbiam; ao arguido que requeira a revogação ou substituição da medida de coacção processual que lhe tenha sido aplicada, ou que requeira o *habeas corpus*, quando o juiz considere o requerimento manifestamente infundado; ao

([36]) Sobre o instituto, DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 434 e ss.

([37]) A criação da UC teve lugar por força da al. *h)* do n.º 1 do art. 1.º do CPP de 1987. O preceito foi porém revogado pelo art. 8.º/*b)* do DL 212/89 que pretendeu unificar a UC processual do CPP com a unidade de conta de custas (UCC), posteriormente criada, em uma única unidade de conta processual. Como tal é considerada "a quantia em dinheiro equivalente a um quarto da remuneração mínima mensal mais elevada, garantida, no momento da condenação, aos trabalhadores por conta de outrem, arredondada, quando necessário, para a unidade de euros mais próxima ou, se a proximidade for igual, para a unidade de euros imediatamente inferior" (art. 5.º-2 do DL 212/89, na redacção do DL 323/2001, de 17-12). No triénio de 2007 a 2009 uma UC tem o valor de 96 euros (DL 238/2005, de 30-12).

recorrente que veja o seu recurso rejeitado por falta de motivação ou manifesta improcedência, ou por manifesta falta de fundamento no caso da revisão; etc. (cf., respectivamente, os arts. 45.º-5 e 110.º; 116.º-1; 153.º-4; 212.º-4, 221.º-4 e 223.º-6; 420.º-4 e 456.º, todos do CPP).

§ 31 Às sanções processuais em questão são em princípio estranhas — para além, obviamente, de qualquer entono ético-retributivo — a finalidades de *prevenção positiva, geral e especial*. O que fica, por isso, é simplesmente uma ameaça — *hoc sensu*, uma **intimidação** — que esgota a sua finalidade na observância das (ou na conformação do comportamento com as) formalidades legais do processo. Por outro lado, e ainda mais claramente do que em relação ao ilícito disciplinar, desempenha aqui papel indisfarçável o **princípio de subsidiariedade** ([38]): trata-se nestas infracções, em si mesmas consideradas, de ilícitos para sancionamento dos quais as sanções penais não se revelam nem *adequadas*, nem *necessárias*. Até um ponto em que não é fácil (se é possível) excogitar uma possibilidade de *cumulação* das sanções processuais com sanções penais. Se e quando o for, não existem instrumentos legais que permitam a imputação processual na sanção penal; o que não significa que uma tal imputação não seja político-criminalmente aceitável e mesmo desejável.

§ 32 Coisa diferente das sanções processuais consideradas são as chamadas **medidas de coacção processual**, *v. g.*, o termo de identidade, a caução e (sobretudo) a prisão preventiva (art. 196.º e ss. do CPP). Trata-se aqui de medidas estritamente destinadas a ocorrer à consecução de finalidades processuais de natureza **cautelar** (arts. 196.º e 204.º do CPP) e relativamente às quais, por isso, se não pode suscitar com sentido nenhum problema de distinção com as penas criminais.

IV. Direito penal e direito privado: penas criminais e penas privadas

§ 33 Uma distinção de carácter geral, como tradicionalmente se tentava nos tratamentos sistemáticos do direito penal, entre o **ilícito civil** e o **ilícito penal** não apresenta particular interesse no contexto das nossas preocupações. Trata-se aí do domínio, por excelência, de actuação dos princípios da subsidiariedade e da necessidade da tutela penal, pelo que o problema ficou suficientemente — se bem que indirectamente — resolvido pelo tratamento a que sujeitámos o comportamento criminal e a sua defi-

([38]) Assim, também, ROXIN I, § 2, n.º 139.

nição (supra, 6.º Cap.). No plano dogmático anote-se em todo o caso, desde já, a resistência que desde sempre se tem feito sentir, da parte da ciência jurídico-civilista, à aceitação de uma concepção do ilícito que contemple um **desvalor de acção** ao lado do desvalor de resultado (sobre estes conceitos, infra, 11.º Cap., § 6 e ss.). Sem prejuízo de tentativas esparsas de fazer frutificar na dogmática do direito civil algumas das concepções da acção final (sobre esta, infra, 10.º Cap., § 16 e ss.) ([39]), pode afirmar-se que a dogmática do direito civil continua hoje a operar quase exclusivamente, mesmo no domínio hermenêutico, com os conceitos próprios da determinação do devalor de resultado, minimizando de forma sistemática os do desvalor de acção da conduta ([40]).

§ 34 Interesse tem, no presente enquadramento, operar a distinção entre as **penas criminais** e certas sanções de direito privado, as (neste sentido) chamadas **penas privadas**. Todas as sanções não criminais até agora consideradas têm em comum com as sanções criminais a circunstância de serem sanções **jurídico-públicas**, nas quais o sancionado se apresenta perante o poder sancionatório numa relação de sujeição ou de infra-ordenação. Diferentemente, o direito privado conhece sanções, a muitos outros títulos análogas às sanções criminais, baseadas numa relação paritária ou igualitária: são as sanções privadas, fundadas na **submissão voluntária** dos interessados ao poder sancionatório; e de que se apresenta como exemplo clássico a **cláusula penal** do direito civil: "As partes podem (...) fixar por acordo o montante da indemnização exigível; é o que se chama cláusula penal" (CC, art. 810.º-1). Qualquer que seja a exacta natureza jurídico-civil desta medida — indemnizatória, punitiva, mista ([41]) — e a sua verdadeira extensão (parecendo que o conceito de cláusula penal abrange entre nós a generalidade, se não a totalidade das penas privadas), a sua distinção relativamente às penas criminais torna-se absolutamente segura por força da circunstância apontada.

([39]) Pioneiro nesta direcção, a edição de 1953 do *Tratado* de NIPPERDEY, e, valorando dados jurisprudenciais alemães, DEUTSCH, Finalität, Sozialadäquanz und Schuldtheorie als zivilrechtliche Strukturbegriffe, *Welzel—FS*, 1974, p. 227 e ss.; e, entre nós, ASCENSÃO, Oliveira, A teoria finalista e o direito civil, *Rev. da FDUL XXVII*, 1986, p. 9, e FARIA, Jorge Ribeiro de, Algumas notas sobre o finalismo em direito civil, 1991.

([40]) Completamente no sentido do texto FARIA, Paula Ribeiro de, *A Adequação Social da Conduta no Direito Penal ou o Valor dos Sentidos Sociais na Interpretação da Lei Penal*, 2005, p. 267 e ss.

([41]) Sobre o instituto, MONTEIRO, Pinto, *Cláusula Penal e Indemnização*, 1990.

§ 35 De um ponto de vista político-criminal, o requisitório a favor das penas privadas como forma de limitação do âmbito do direito penal — isto é, a aplicação de penas privadas, em certos casos, **em vez de penas criminais** — não tem parado de crescer nos nossos tempos. Para além da referida sugestão de se obviar aos grandes e novos riscos da sociedade pós-industrial não através de meios penais, mas jurídico-civis (supra, 6.º Cap., § 63), lembre-se a proposta de fazer das sanções civis o modelo sancionatório da **justiça na empresa** relativamente a pequenos delitos (patrimoniais, contra a honra, etc.), bem como o especial sancionamento de furtos em grandes superfícies (super e hipermercados, shoppings, etc.) (42), operando-se na outra vertente a respectiva descriminalização, de direito ou de facto. Proposta consubstanciada na Alemanha em dois projectos, da autoria de Artz *et alii*, o *Entwurf eines Gesetzes gegen den Ladendiebstahl* (1974) e o *Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Betriebsjustiz* (1975), e que, a partir da concepção que atrás se defendeu sobre a definição do comportamento criminal e das suas sanções, não pode deixar de ser em princípio saudada (43). Deve reconhecer-se todavia que muitos problemas de concretização desta justiça "privada" e de consistente defesa dos direitos, liberdades e garantias das pessoas esperam ainda por uma sua adequada resolução. Talvez por isso as mencionadas tentativas de reforma não tenham sido até hoje — com excepção dos "tribunais de camaradas" próprios dos antigos regimes comunistas — reconhecidas pelos legisladores (44).

---

(42) BURGSTALLER, *Der Ladendiebstahl und seine private Bekämpfung*, 1981, e KAISER / METZGER-PREISIGER, *Betriebsjustiz*, 1976.

(43) Cf., também, FARIA, Paula Ribeiro de, nota 40, p. 420 e ss.

(44) Sobre a questão, DIAS / ANDRADE, pp. 136, 415 s., 426.

TÍTULO III

A LEI PENAL E A SUA APLICAÇÃO

8.º CAPÍTULO

O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DA INTERVENÇÃO PENAL

I. O princípio *nullum crimen, nulla pœna sine lege*

1. Função, sentido e fundamentos

§ 1 O princípio do Estado de Direito conduz, como na exposição anterior já por várias vezes se revelou, a que a protecção dos direitos, liberdades e garantias seja levada a cabo não apenas **através** do direito penal, mas também **perante** o direito penal (1). Até porque uma eficaz prevenção do crime, que o direito penal visa em último termo atingir, só pode pretender êxito se à intervenção estadual forem levantados *limites estritos* — em nome da defesa dos direitos, liberdades e garantias das pessoas — perante a possibilidade de uma intervenção estadual arbitrária ou excessiva. A esta possibilidade de arbítrio ou de excesso se ocorre submetendo a intervenção penal a um rigoroso **princípio de legalidade**, cujo conteúdo essencial se traduz em que **não pode haver crime, nem pena que não resultem de uma lei prévia, escrita, estrita e certa** (*nullum crimen, nulla pœna sine lege*).

§ 2 O princípio da legalidade da intervenção penal encontra já de algum modo expressão na *Magna Charta Libertatum* de João sem Terra (1215) e mais tarde, de forma particular, no *Bill of Rights* (1689). Mas a sua consagração em termos modernos ocorre pela primeira vez — fruto, também ela, dos princípios do Iluminismo Penal e

(1) A afirmação paradigmática pertence a ROXIN I, § 5, n.º 1.

em especial da doutrina do "contrato social" (2) — na Constituição de alguns dos Estados Unidos da América (Virgínia, Maryland) no ano de 1776 e encontra a sua expressão definitiva na *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* francesa de 1787, daí tendo derivado para, pode dizer-se, a totalidade dos instrumentos internacionais de protecção dos direitos humanos (*v. g.*, art. 11.º-2 da *Declaração Universal dos Direitos do Homem* de 10-12-1948, art. 7.º-1 da *Convenção Europeia dos Direitos do Homem* de 4-11-1950, art. 15.º-1 do *Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos* de 19-12-1966, etc.) e das Constituições dos Estados democráticos. Entorses declaradas ao princípio encontravam-se em textos legais como o do § 2 do CP alemão nacional-socialista (que permitia a punição criminal de acordo com o pensamento fundamental de uma lei penal e com o *são sentimento do povo!*) ou como o dos arts. 1.º e 16.º do CP da URSS de 1924 e 1926 (que permitiam a punição de actos, mesmo não expressamente previstos, que ofendessem "a ordem jurídica estabelecida pelo Governo dos operários e agricultores para a época de transição para o Estado comunista" (3)). Entre nós o princípio encontra hoje consagração no art. 29.º-1 da CRP ("Ninguém pode ser sentenciado criminalmente senão em virtude de lei anterior que declare punível a acção ou a omissão, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados em lei anterior"), aliás materialmente correspondente ao art. 1.º do CP (nomeadamente aos seus n.os 1 e 2).

§ 3 A norma contida no art. 29.º-2 da CRP confere jurisdição aos tribunais portugueses para conhecerem de certos **crimes contra o direito internacional** (os *crimina iuris gentium*), mesmo que as condutas visadas **não sejam puníveis à luz da lei positiva interna**. Necessário é porém que se trate de crimes à luz dos "princípios gerais de direito internacional comummente reconhecidos" (cf., também, o art. 8.º-1 da CRP) e a punição só pode ter lugar "nos limites da lei interna", que define os termos do processo e as sanções aplicáveis. A ideia de que o direito internacional pode impor directamente deveres de natureza penal aos indivíduos consolidou-se a partir dos julgamentos de Nuremberga e de Tóquio, onde as potências aliadas julgaram e condenaram membros das forças do Eixo por violações graves do direito internacional (crimes contra a paz e a humanidade e crimes de guerra) que não eram punidas pela lei interna desses países. Deste modo, no art. 29.º-2 da CRP parece ter-se adoptado

(2) Fundamentais, LOCKE, *Two treatises of government*, 1690, II, § 137, e MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, 1748, I, 1, 11.º Cap., 6. Uma história do princípio e uma informação mais minuciosas encontram-se em JESCHECK / WEIGEND, § 15, II.

(3) Cf., sobre o ponto, SANTOS, Beleza dos, Interpretação e integração das lacunas da lei em direito e processo penal, *BFD XI*, 1929, p. 112, e CORREIA, Eduardo, *Lições*, p. 147 e s., e I, n.º 33.

a concepção segundo a qual a responsabilidade por crimes contra o direito internacional não se encontra sujeita ao princípio da legalidade previsto no art. 29.º-1, válido apenas para a lei estadual. Porém, hoje é seguro que o princípio *nullum crimen sine lege* constitui um princípio geral de direito internacional, embora o seu "modo" seja diverso, uma vez que no termo *lege* se inclui também o *direito (internacional) costumeiro*; o que não deixa de trazer problemas graves quanto à exigência de determinabilidade das condutas puníveis (4). De toda a maneira, a importância do problema tem vindo a reduzir-se progressivamente desde o fim da II Guerra por força da cristalização positiva do direito costumeiro em várias convenções internacionais, cujas normas os Estados vão incorporando no seu direito interno. Nesses casos a lei interna deve servir a protecção do direito internacional. Dever que se tornou ainda mais claro com o Estatuto de Roma e o princípio de subsidiariedade da jurisdição do TPI em relação às jurisdições nacionais, aí contido (supra, 2.º Cap., § 4), nomeadamente, quando esteja em causa a aplicação extraterritorial das normas de acordo com o princípio da universalidade (art. 5.º-2*/b)* e infra, 9.º Cap., § 39 e ss.).

§ 4 O princípio da legalidade da intervenção penal possui uma pluralidade de **fundamentos**, uns *externos* (isto é, ligados à concepção fundamental do Estado), outros *internos* (*sc.*, de natureza especificamente jurídico-penal) (5). Entre os *primeiros* avultam o **princípio liberal**, o **princípio democrático** e o **princípio da separação dos poderes**. De acordo com o princípio liberal, toda a actividade intervencionista do Estado na esfera dos direitos, liberdades e garantias das pessoas tem de ligar-se à existência de uma *lei* e mesmo, entre nós, de uma lei *geral, abstracta* e *anterior* (CRP, art. 18.º-2 e 3). De acordo com os princípios democrático e da separação dos poderes (na sua compreensão actual, onde a separação é pensada nos quadros da interpenetração e da corresponsabilização), para a intervenção penal, com o seu particular peso e magnitude, só se encontra legitimada a instância que represente o Povo como titular último do *ius puniendi*; donde a exigência, uma vez mais, de lei, e na verdade, entre

(4) Cf. LAMB, Susan, Nullum crimen, nulla pœna sine lege in international criminal law, *in*: Cassese, A., et alii, *The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary*, I, 2002, p. 734 e ss.

(5) NEVES, Castanheira, O princípio da legalidade criminal, *Estudos Eduardo Correia*, I, 1989, fala a propósito, respectivamente, de "fundamento político" (p. 362 e ss.) e de "fundamento dogmático-jurídico" (p. 368 e ss.).

nós, de *lei formal* emanada do Parlamento ou por ele competentemente autorizada (CRP, art. 165.º-1/*c*)).

§ 5 Entre os *fundamentos internos* costumam apontar-se a ideia da **prevenção geral** e o **princípio da culpa**. Com razão (6). Não pode esperar-se que a norma cumpra a sua função motivadora do comportamento da generalidade dos cidadãos — seja na sua vertente "negativa" de intimidação, seja sobretudo na sua vertente positiva de estabilização das expectativas — se aqueles não puderem saber, através de lei anterior, estrita e certa, por onde passa a fronteira que separa os comportamentos criminalmente puníveis dos não puníveis. Como não seria legítimo dirigir a alguém a censura por ter actuado de certa maneira se uma lei com aquelas características não considerasse o comportamento respectivo como crime. Vale só acrescentar que, contra o que ainda maioritariamente se pensa, também a própria função de **prevenção especial** positiva ou de ressocialização, no seu entendimento actual, confirma a exigência do princípio da legalidade: o comportamento que indicia a perigosidade não é (não pode ser) apenas sintoma ou índice da carência de socialização e ensejo para que esta intervenha, mas tem de ser co-fundamento e limite da intervenção criminal; nesta medida ressurgindo a exigência de legalidade estrita daquela (supra, 5.º Cap., § 7 e s.).

2. *Nullum crimen sine lege*

§ 6 O princípio segundo o qual não há crime sem lei anterior que como tal preveja uma certa conduta significa que, por mais socialmente nocivo e reprovável que se afigure um comportamento, tem o legislador de o considerar como crime (descrevendo-o e impondo-lhe como consequência jurídica uma sanção criminal) para que ele possa como tal ser punido. Esquecimentos, lacunas, deficiências de regulamentação ou de redacção funcionam por isso sempre *contra o legislador* e *a favor da liberdade*, por mais evidente que se revele ter sido intenção daquele (ou constituir finalidade da norma) abranger na punibilidade também certos (outros) comportamentos. Neste sentido se tornou célebre a afirmação de v. Liszt

(6) Neste sentido, ROXIN I, § 5, n.º 22 e ss., e MARINUCCI / DOLCINI, *Corso*, p. 12 e s. Diferentemente, NEVES, Castanheira, nota 5, pp. 369 e ss. e 383 e ss.: fundamento é a axiológica normatividade do próprio direito.

segundo a qual a lei penal constitui a "**magna Charta do criminoso**". Tem-se argumentado que, sendo assim, a lei penal representa uma espécie de carta de alforria para o agente mais hábil, mais refinado e (às vezes) mais rico e poderoso, numa palavra (própria da ciência criminológica), para o agente dotado de maior "competência de acção". Será verdade. Mas importa fazer neste contexto duas precisões: a primeira é a de que um tal agente não é, em definitivo, um "criminoso" se não for como tal considerado por uma sentença passada em julgado (supra, 6.º Cap., § 41 e ss.); a segunda a de constituir este, apesar de tudo, um razoável preço a pagar para que possa viver-se numa democracia que proteja minimamente o cidadão do arbítrio, da insegurança e dos excessos de que de outro modo inevitavelmente padeceria a intervenção do Leviathan estadual.

§ 7 Um exemplo — a par de tantos outros que poderiam ser dados — retirado da experiência legislativa portuguesa anterior ao CP de 1982 ilustrará exemplarmente o que ficou dito. No CP de 1886 dispunha o art. 451.º (relativo ao crime de burla ou defraudação) que "será punido... aquele que defraudar a outrem, fazendo que se lhe entregue dinheiro ou móveis, ou quaisquer fundos ou títulos, por algum dos seguintes meios...". Isto só podia significar que era unicamente punível a burla *a favor do próprio agente*, já não a burla *a favor de terceiro*, *v. g.*, a favor do pai, da mulher, do filho ou de um sócio ou amigo do agente. Restrição esta que nem teleológica, nem funcional, nem racionalmente se podia justificar e que revelava, na verdade, pura e simplesmente uma lacuna (grave) de punibilidade, só explicável por um erro do legislador. E todavia: a consequência, logo jurídico-constitucionalmente imposta, só podia ser (como a nossa jurisprudência dominante muito bem decidiu então) a de deixar *impune* a burla a favor de terceiro! Outro caso ilustrativo, este recente, ocorrido concretamente nas Filipinas, foi o do cidadão que a partir desse país difundiu o vírus informático "I love you", com danos irreparáveis no mundo inteiro, tendo escapado impune dada a inexistência de um qualquer tipo legal de crime na ordem jurídica do seu país que previsse e punisse tal conduta.

3. *Nulla pœna sine lege*

§ 8 A fórmula "não há crime sem lei" é complementada pela fórmula "não há **pena** [*rectior*, não há **sanção criminal**, pena ou medida de segurança] sem lei". Na interpretação desta fórmula verificam-se todavia algumas dificuldades que devem ser consideradas. Desde logo cumpre dizer que — diversamente do que sucede em muitas outras ordens jurídicas, onde a conclusão tem de ser alcançada por via interpretativa — entre nós também este segmento do princípio tem *expressa consagração* jurídico-constitucional e legal. Nesse sentido afirma logo o art. 29.º-3 da CRP que

"não podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que não estejam expressamente cominadas em lei anterior". No que toca às **penas**, esta exigência de *lex prævia* corresponde à doutrina internacional dominante. Não assim já porém no que toca às **medidas de segurança**, relativamente às quais se pensava que o seu fundamento de estrita prevenção especial deveria conduzir a que pudesse aplicar-se a medida de segurança *vigente ao tempo da aplicação*, porque isso seria apenas sinal de um entendimento legislativo "melhor" para o (*sc.*, "mais favorável" ao) agente.

§ 9 Uma tal concepção foi recusada pela CRP, como se disse, e, na sua esteira, pelo art. 2.º-1 do CP (7). Em detrimento da ideia paternalista de que ao legislador pertenceria dizer o que seria "melhor" para o agente, porquanto *só* considerações ilimitadas de prevenção especial estariam na base das medidas de segurança, veio a legislação constitucional e ordinária portuguesa dar prevalência a uma consistente protecção dos direitos, liberdades e garantias das pessoas também face à aplicação de medidas de segurança, conferindo assim ao facto (como supra, 5.º Cap., § 7 e s., se acentuou já) uma função de co-fundamento da respectiva aplicação. E, por esta via, veio assegurar a extensão do princípio da legalidade às medidas de segurança com âmbito análogo àquele que ele tradicionalmente assume para as penas. Com esta extensão, o CP de 1982 e a nossa lei constitucional deram um passo decisivo — e mesmo pioneiro (8) — numa compreensão moderna e democrática destes instrumentos sancionatórios (9).

§ 10 O princípio em exame significa, por outro lado, ser completamente **vedado** ao juiz, seja embora na base da mais esclarecida e avançada consciência político-criminal, **criar** instrumentos sancionatórios criminais que se não encontrem estritamente previstos em lei anterior. E este perigo não é tão teórico que uma situação destas não

(7) Em rigor, ambos na esteira do disposto no art. 1.º do *ProjPG*, que conexionava o princípio com a imposição de uma "reacção criminal" e por conseguinte tanto com a pena, como com a medida de segurança (v. a longa — e a muitos títulos elucidativa — discussão em *Actas I*, p. 33 e ss.).

(8) P. ex., o § 2, VI, do CP alemão ainda hoje dispõe que "em matéria de medidas de segurança deve decidir-se, se outra coisa não for determinada legalmente, segundo a lei que vale ao tempo da decisão". O que leva — com razão — autores como STRATENWERTH / KUHLEN, § 3, n.º 12, a considerarem esta regulamentação não só "materialmente errónea" (precisamente com estas mesmas palavras também ROXIN I, § 5, n.º 56), como "inconstitucional".

(9) Desenvolvidamente, DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 685 e ss., e CARVALHO, Taipa de, *Sucessão de Leis Penais*, ²1997, p. 208 e ss.

tenha ocorrido entre nós ainda não há muito tempo. O CP de 1982, antes da Reforma de 1995, previa por uma parte uma *pena de substituição da suspensão da execução da prisão*, com ou sem condições, e por outra, sob diferentes e mais estritos pressupostos formais, a pena de substituição do *regime de prova*; mas não previa a possibilidade de "combinação" destas duas penas. Ora, uma parte da nossa jurisprudência, motivada pelo desejo (político-criminalmente louvável, repete-se) de poder aplicar a substância do regime de prova à pena de suspensão da execução da prisão em casos em que todavia os pressupostos formais daquela o não permitiam, condenava por vezes na pena de suspensão, mas submetida a condições específicas do regime de prova. O que, no fundo, constituía uma violação ilegal e inconstitucional do princípio *nulla pœna sine lege*. A situação foi resolvida pela Reforma de 1995, ao eliminar o regime de prova como pena de substituição autónoma e ao fazer dele uma modalidade da pena de substituição da suspensão da execução da prisão ([10]).

§ 11 O princípio da legalidade assume **consequências** ou **efeitos** em cinco planos diversos: no plano do âmbito ou da extensão, no plano da fonte, no plano da determinabilidade, no plano da proibição da analogia e no plano da proibição de retroactividade. Cada um deles será em seguida considerado.

II. O plano do âmbito de aplicação

§ 12 Neste plano cumpre assinalar que o princípio da legalidade não cobre, segundo a sua função e o seu sentido, toda a matéria penal, mas apenas a que se traduza em **fundamentar** ou **agravar** a responsabilidade do agente. Sob pena, de outra forma — isto é, se abrangesse também a matéria da *exclusão* ou da *atenuação* da responsabilidade —, de o princípio passar a funcionar *contra* a sua teleologia e a sua própria razão de ser: a protecção dos direitos, liberdades e garantias do cidadão face à possibilidade de arbítrio e de excesso do poder estatal. Por isso, para se avançar apenas com um *exemplo*, o princípio cobre toda a matéria relativa ao tipo de ilícito ou ao tipo de culpa, mas já não a que respeita às causas de justificação ou às causas de exclusão da culpa. De tal forma é importante esta restrição do âmbito do princípio que ela se estende a **todas as suas consequências** — seja no plano da fonte (matéria em todo o caso discutível: infra, § 13), seja no da determinabilidade, seja no das proibições de analogia e de retroactividade.

([10]) Sobre a questão antes da Reforma de 1995, no sentido do texto, o nosso *DP II*, § 532.

III. O plano da fonte

§ 13 Neste plano o princípio conduz à exigência de **lei formal**: só uma lei da AR ou por ela competentemente autorizada pode definir o regime dos crimes, das penas e das medidas de segurança e seus pressupostos. A este propósito podem todavia suscitar-se alguns problemas que não devem deixar de ser referidos, ainda que só *per summa capita*. Desde logo o de que, em rigor, o conteúdo de sentido do princípio da legalidade, ainda aqui, só deveria cobrir a actividade de **criminalização** ou de **agravação**, não a de descriminalização ou de atenuação. O que deveria conduzir, por seu lado, a considerar que o Governo possui competência concorrente com a da AR para *descriminalizar* ou *atenuar* a responsabilidade criminal. Posto perante a questão, o nosso TC respondeu-lhe negativamente ([11]), interpretando a "definição dos crimes, penas, medidas de segurança e respectivos pressupostos" no sentido de abranger tanto a função de criminalização (ou de maior criminalização), como a de descriminalização (ou de menor criminalização). Não é impossível excogitar *razões jurídicas de política geral*, relacionadas nomeadamente com a definição dos círculos de competência de órgãos de soberania dotados de poderes legiferantes, que ofereçam um qualquer fundamento a esta doutrina. O que sempre será errado é invocar, ainda aqui, o *princípio da legalidade penal* na sua teleologia e na sua funcionalidade específicas.

§ 14 Outro problema é o de saber se a exigência de legalidade no plano da fonte deverá abranger só a **lei penal *sensu stricto*** ou ainda também a lei **extra-penal**, na medida em que esta venha a ser chamada pela lei penal à fundamentação ou à agravação da responsabilidade criminal. Para esta fundamentação ou agravação serve-se muitas vezes a lei penal, com efeito, de *procedimentos de reenvio* para ordenamentos jurídicos não penais, *v. g.*, o civil, o administrativo, o fiscal, etc.; ordenamentos estes onde não vale, logo no plano da fonte, um princípio de legalidade equivalente

([11]) Ac. do TC 173/85, de 9-10-1985, *DR*, II, de 8-1-1986, p. 215: "A competência da Assembleia da República, prevista na al. *c)* do n.º 1 do art. 168.º [actual art. 165.º-1/*c*)] da Lei Fundamental ("definição de crimes"), exerce-se quer pela positiva, isto é, pela modelação, por via legislativa, dos crimes e penas em sentido próprio, quer pela negativa, isto é, pela supressão do quadro criminal de tipos de ilícito e respectivas penas". Jurisprudência sucessivamente reiterada pelo TC, *v. g.*, nos Acs. 427/87, de 4-11-1987; 337/92, de 27-10-1992; 441/93, de 14-7-1993; 787/93, de 30-11-1993; e 837/93, de 16-12-1993.

ao que aqui se considera e onde, por isso, o Governo e a Administração têm competência geral, ou mais lata do que em matéria penal, para legislar. O que acaba por fazer crise nas chamadas **normas penais em branco**, sobretudo abundantes no âmbito do direito penal secundário, que cominam uma pena para comportamentos *que não descrevem*, mas se alcançam através de uma remissão da norma penal para leis, regulamentos ou inclusivamente actos administrativos autonomamente promulgados em outro tempo ou lugar ([12]). Pressuposto porém, evidentemente, que a norma penal em branco consta de lei formal, não se vêem razões teleológico-funcionais decisivas para considerar em causa, *no plano da fonte*, o respeito pelo princípio da legalidade.

§ 15 O que fica dito no parágrafo anterior vale também para os casos em que um **regulamento comunitário** (directamente aplicável na ordem jurídica portuguesa: art. 8.º-4 da CRP) é chamado a preencher, por remissão, o "espaço em branco" de uma norma penal interna: para este efeito o regulamento encontra-se no mesmo plano dos instrumentos legislativos nacionais não legitimados para criar proibições penais ([13]). O problema já não se põe relativamente às **directivas comunitárias** e às **decisões-quadro**, pois estes instrumentos carecem sempre de uma actividade de transposição por parte dos legisladores nacionais, a quem caberá proceder de acordo com o princípio da legalidade ([14]).

IV. A determinabilidade do tipo legal

§ 16 No plano da determinabilidade do *tipo legal* ou *tipo de garantia* — precisamente, o tipo formado pelo conjunto de elementos cuja fixa-

---

([12]) Há divergências doutrinais significativas sobre o próprio conceito de lei penal em branco, podendo divisar-se uma acepção *estrita* (na qual cabe ainda a formulação do texto) e uma acepção *ampla*: cf., de uma parte, SILVA, Marques da, I, n.º 65, e CARVALHO, Taipa de, § 293 e ss.; e, da outra, BELEZA, Teresa / PINTO, Costa, *O Regime Legal do Erro e as Normas Penais em Branco*, 1999, p. 49 e ss.

([13]) No sentido de que os regulamentos comunitários só podem ter efeitos positivos, em matéria penal, através da lei interna e do "jogo" das normas penais em branco, CAEIRO, Pedro, Perspectivas de formação de um direito penal da União Europeia, *RPCC* 6, 1996, p. 192 e ss.

([14]) É jurisprudência firme do TJ que as directivas comunitárias não transpostas não são eficazes nos ordenamentos internos e não podem, por isso, criar deveres de índole penal para os cidadãos (Acs. do TJ de 8-10-1987 e, por último, de 7-1-2004). Parece, além disso, que no caso de um Estado transpor incorrectamente uma directiva o juiz não pode recorrer àquela para fazer uma interpretação "correctiva" da norma interna que a transpôs se assim *ampliar* a área da punibilidade (cf. as conclusões do Advogado-Geral Colomer, de 18-6-1996, nos processos apensos C-74/95 e C-129/95). Relativamente às decisões-quadro, o art. 34.º-2/*b)* do Tratado da União Europeia nega-lhes expressamente "efeito directo".

ção se torna necessária para uma correcta observância do princípio da legalidade (infra, 11.º Cap., § 3) —, importa que a descrição da matéria proibida e de todos os outros requisitos de que dependa em concreto uma punição seja levada até a um ponto em que se tornem **objectivamente determináveis** os comportamentos proibidos e sancionados e, consequentemente, se torne objectivamente motivável e dirigível a conduta dos cidadãos. Considerar crime — para usar de exemplos que já atrás foram assinalados — as condutas que ofendem o "são sentimento do povo" ou a "ordem dos operários e agricultores" tornaria supérfluo um grande número de incriminações dos códigos penais; mas não cumpriria minimamente as exigências de sentido ínsitas no princípio da legalidade. Do mesmo modo, se é inevitável que a formulação dos tipos legais não consiga renunciar à utilização de elementos *normativos*, de conceitos *indeterminados*, de cláusulas *gerais* e de fórmulas *gerais de valor*, é indispensável que a sua utilização não obste à determinabilidade objectiva das condutas proibidas e demais elementos de punibilidade requeridos, sob pena de violação irremissível, neste plano, do princípio da legalidade e sobretudo da sua teleologia garantística. Nesta acepção se afirma, com razão, que a lei penal fundamentadora ou agravadora da responsabilidade tem de ser uma lei **certa** e **determinada**; e se chama muito acertadamente a atenção, nos novos tempos, para que é mais aqui até do que no plano da proibição da analogia ou da retroactividade que reside o grande perigo para a consistência do princípio *nullum crimen* ([15]), que é neste ponto que reside o verdadeiro *cerne* do princípio da legalidade ([16]).

§ 17 Os *exemplos* de hipóteses duvidosas sob o prisma em consideração podem multiplicar-se quase *ad nauseam*, por mais perfeita e cuidadosa que seja a técnica legislativa. O seu campo de eleição será o do direito penal secundário. Mas não faltam exemplos mesmo no âmbito do direito penal primário: elementos como os dos "bons costumes" do art. 38.º-1, do "motivo torpe ou fútil" ou do "meio insidioso" do art. 132.º, do "censurável" do art. 154.º-3/*a*), do "abuso grosseiro dos poderes" do art. 158.º são só alguns dos mais citados. O critério decisivo para aferir do respeito pelo princípio da legalidade (e da respectiva constitucionalidade da regulamentação) residirá sempre em saber se, apesar da indeterminação inevitável resultante da utilização destes elementos, do *conjunto da regulamentação típica* deriva ou não **uma área e um fim de protecção da norma claramente determinados**.

([15]) WELZEL, § 5, II, 3.

([16]) SCHÜNEMANN, *Nulla poena sine lege*, 1978, p. 6.

V. A proibição da analogia

§ 18 Toma-se neste contexto o conceito de analogia como aplicação de uma regra jurídica a um caso concreto não regulado pela lei através de um argumento de semelhança substancial com os casos regulados: a chamada ***analogia legis***, não a *analogia iuris*. Depois de quanto ficou dito torna-se evidente que o argumento de analogia, largamente admitido na generalidade dos ramos de direito como procedimento adequado à aplicação da lei, tem em direito penal de ser proibido, por força do conteúdo de sentido do princípio da legalidade, sempre que ele funcione **contra** o agente e vise servir a fundamentação ou a agravação da sua responsabilidade. Esta conclusão já resultaria evidente do texto do art. 29.º-1 da CRP (e também do art. 1.º-1 do CP), porque nestas hipóteses se não pode afirmar que a lei *declara* punível o acto ou a omissão. Mas o CP entendeu — e bem — reforçar a proibição, estatuindo *expressis verbis*, no art. 1.º-3, que "não é permitido o recurso à analogia para qualificar um facto como crime, definir um estado de perigosidade ou determinar a pena ou a medida de segurança que lhes corresponde".

1. Interpretação e analogia em direito penal

§ 19 A proibição de analogia pressupõe a resolução do problema dos **limites da interpretação admissível em direito penal**. Está hoje afastada definitivamente a convicção iluminista de que o princípio da separação de poderes conduziria logo à proibição de qualquer processo de interpretação jurídica (Montesquieu: "Les juges ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi" ([17]); ou Beccaria: "Para qualquer delito deve o juiz construir um silogismo perfeito: a premissa maior deve ser a lei geral; a menor, a acção conforme ou não à lei; a conclusão, a liberdade ou a pena" ([18])) e a concepção da função judicial que lhe subjazia. E aceita-se, pelo contrário, que praticamente todos os conceitos utilizados na lei são susceptíveis e carentes de interpretação: não apenas os conceitos "normativos", mas mesmo aqueles que à primeira vista se diria carac-

([17]) MONTESQUIEU, nota 2, *ibidem*.

([18]) BECCARIA, *Dos Delitos e das Penas* (tradução portuguesa de Faria Costa, 1998), IV; e também XIV: "Quando as leis são claras e precisas, a tarefa do juiz não consiste em outra coisa senão em constatar um facto".

terizadamente "descritivos" e por isso apreensíveis através dos sentidos (infra, 11.º Cap., § 11 e s.). Deste modo se torna inarredável a questão de saber o que pertence ainda à **interpretação permitida** e o que pertence já à **analogia proibida** em direito penal pelo princípio da legalidade.

§ 20 O **critério de distinção** teleológica e funcionalmente imposto pelo fundamento e pelo conteúdo de sentido do princípio da legalidade só pode ser o seguinte: o legislador penal é obrigado a exprimir-se através de *palavras*; as quais todavia nem sempre possuem um único sentido, mas pelo contrário se apresentam quase sempre *polissémicas*. Por isso o texto legal se torna carente de interpretação (e neste sentido, atenta a primazia da *teleologia* legal, de concretização, complementação ou desenvolvimento judicial), oferecendo as *palavras* que o compõem, segundo o seu *sentido comum e literal*, um *quadro* (e portanto uma *pluralidade*) *de significações* dentro do qual o aplicador da lei se pode mover e pode optar sem ultrapassar os limites legítimos da interpretação. Fora deste quadro, sob não importa que argumento, o aplicador encontra-se inserido já no domínio da **analogia proibida**. Um tal quadro não constitui por isso *critério* ou *elemento*, mas *limite* da interpretação admissível em direito penal ([19]).

§ 21 (1) Caso exemplar e outrora muito discutido foi o de saber se a **energia eléctrica** poderia considerar-se uma "*coisa móvel*" para efeito do crime de furto (art. 203.º-1) consistente na manipulação dos contadores. Em Portugal a jurisprudência prevalente respondeu afirmativamente à questão ([20]); na Alemanha a jurisprudência do *Reichsgericht*, seguida pela doutrina, considerou que se trataria aqui de analogia proibida, não de interpretação permitida ([21]). Aceitando esta opinião, o legislador alemão criou (e ainda hoje conserva) uma específica incriminação da subtracção de energia eléctrica (CP alemão, § 248c). A ser assim também no nosso direito, e na falta de uma incriminação correspondente, parece que as condutas conducentes ao desvio de energia eléctrica alheia só poderiam ser punidas por via da (eventual) falsificação, danifi-

([19]) Neste sentido a jurisprudência e a doutrina hoje dominantes na Alemanha: indicações em ROXIN I, § 5, n.º 26 e ss. E completamente neste sentido, também, entre nós, o Ac. do STJ 1/2002, de 5-11-2002. De alguma forma pode afirmar-se que o critério proposto não estará muito afastado do entendimento que a doutrina civilista faz do disposto no art. 9.º-2 do CC: "Não pode porém ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na *letra da lei* um mínimo de correspondência verbal", se bem que (cf. a seguir no texto) seja diversa a teleologia, a função e o fundamento do critério jurídico-penal aqui em causa.

([20]) Cf., por outros, Ac. do STJ de 20-4-1955, *BMJ 48*, p. 44.

([21]) Sinteticamente sobre o caso, ROXIN I, § 5, n.º 33. Considerando as energias "mecânicas", controláveis e quantificáveis, como "coisas" para o direito penal e, concretamente, para efeito do tipo do furto, COSTA, Faria, *Comentário Conimbricense*, II, art. 203.º, p. 39.

cação ou subtracção de notação técnica (arts. 258.º-1 e 2 e 259.º-1) e (eventualmente também) da burla (art. 217.º e ss.). (2) Uma violação da proibição de analogia terá praticado a jurisprudência portuguesa no domínio do CP de 1886, ao considerar como burla por defraudação, punível nos termos do art. 451.º, o **atear fogo a coisa própria a fim de receber o seguro** respectivo (22). Não parecia, com efeito, que coubesse no teor literal da expressão típica *artifício fraudulento* — como porventura mesmo no actual "erro ou engano sobre factos que astuciosamente provocou" do art. 217.º-1 — a simples comunicação do incêndio (realmente existente e por conseguinte verdadeira). Considerando que aqui se verificava, efectivamente, uma lacuna da lei que não podia ser preenchida por recurso à analogia, o CP de 1982 veio colmatá-la incriminando expressamente a burla relativa a seguros (hoje art. 219.º) (23). (3) Hoje muito discutida, entre nós e lá fora, é a questão de saber se podem ser considerados como **armas**, p. ex., um ácido (24) ou uma seringa (possivelmente infectada pelo vírus da SIDA) (25).

§ 22 A doutrina aqui defendida não é, contra o que poderia pensar-se, arbitrária, nem muito menos filha de uma metodologia crassamente positivista (26). É, pelo contrário, a posição **teleológica** e **funcionalmente imposta** pelo conteúdo de sentido próprio do princípio da legalidade. Fundar ou agravar a responsabilidade do agente em uma qualquer base que caia fora do quadro de significações possíveis das **palavras da lei** não limita o poder do Estado e não defende os direitos, liberdades e garantias das pessoas. Por isso falta a um tal procedimento legitimação democrática e tem de lhe ser assacada violação da regra do Estado de Direito. É claro que, dito isto, não ficam ainda apontados os critérios de que o intérprete se deve servir para eleger, de entre os sentidos possíveis das palavras, aquele que deve reputar-se jurídico-penalmente imposto. Se o caso couber em um dos sentidos possíveis das palavras da lei *nada há, a partir daí, a acrescentar ou a retirar aos critérios gerais da interpretação jurídica*. O que simplesmente sucede, pois, é que — como escrevemos já há mais de um quarto de século (27) — "há de facto, em toda a construção — e muito par-

(22) Cf., p. ex., o Ac. da RL de 9-10-1954, *BMJ 41*, p. 159.

(23) Criticamente, todavia, COSTA, A. M. Almeida, *Comentário Conimbricense*, II, art. 219.º, § 5 e s.

(24) Cf. Ac. do TC 205/99, de 7-4-1999, *BMJ 486*, 1999, p. 56.

(25) Cf. Ac. do STJ de 8-2-1996, *BMJ 454*, 1996, p. 370 e ss.

(26) Como o não é, em nosso entendimento, uma tese tão (confessadamente) "provocatória" como a de KIM, Il-Su, Die Gesetzlichkeitsgrundsatz im Licht der Rechtsidee, *Roxin*-FS, 2001, p. 142: a da "prioridade da segurança face à lei, prioridade da lei face à força e prioridade do legislador face ao juiz". Cf., todavia, por muitos outros, NEVES, Castanheira, nota 5, p. 410 e ss.

(27) DIAS, Figueiredo, *Direito Penal — A Infracção Penal* (relatório do concurso para professor catedrático), 1976, p. 105 e s.

ticularmente na aplicação — do direito penal um momento 'inicial' de mera subsunção formal, imposta por aquele princípio [da legalidade] e pela função de garantia ou, se quisermos, pelo 'tipo de garantia' que daquele princípio resulta. Ultrapassado porém este momento inicial, correspondente à operação lógico-jurídica da incriminação, toda a posterior construção e aplicação não está submetida àquelas exigências e deve integrar-se completamente nas duas ideias fundamentais da impostação metodológica sugerida". Decisivo será assim, por um lado, que a interpretação seja *teleologicamente* comandada, isto é, em definitivo determinada à luz do fim almejado pela norma; e por outro que ela seja *funcionalmente* justificada, quer dizer, adequada à função que o conceito (e, em definitivo, a regulamentação) assume no sistema. Sobre tudo isto já se disse o suficiente (supra, 3.º Cap., § 15 e ss.) para neste contexto poder renunciar-se a maiores desenvolvimentos.

§ 23 Ultrapassada por esta via fica a velhíssima querela hermenêutica e metodológica entre interpretação **subjectivista** — acolhida à (real ou pretensa) vontade do legislador histórico ([28]) — e interpretação **objectivista** — fundada nos sentidos que a regulamentação assume no momento em que o processo hermenêutico é levado a cabo. Que o intérprete está indissoluvelmente ligado aos juízos de valor, aos sentidos, às finalidades ou ao *thelos* — não às representações fácticas! — do legislador histórico, é coisa que deve ter-se por adquirida e fora de questão. Mas igualmente óbvio é que o intérprete pode (e deve) tomar em conta novas realidades, novas descobertas, novos instrumentos e mesmo novas concepções que não poderiam ter estado no campo de representação do legislador histórico, desde que o tomá-las em conta não implique ultrapassar o teor *literal* da regulamentação e o seu campo de significações adequadas ao entendimento comum das palavras que naquela foram utilizadas.

§ 24 Perante a concepção aqui defendida parecem improceder as objecções que se seja tentado a opor-lhe. E desde logo a velha — mas sempre renovada — objecção segundo a qual *não é logicamente possível, nem metodologicamente legítimo distinguir entre interpretação e analogia* ([29]).

([28]) CORREIA, Eduardo, *Lições*, p. 145 e ss. e I, n.º 32, II.

([29]) De forma peremptória, NEVES, Castanheira, nota 5, p. 451, entendendo que a proibição da analogia constitui um "erro legislativo", porque a analogia já não tem que ver com a lei, mas com a realização do direito. A literatura sobre a questão, seja como questão metodológica geral, seja especialmente à luz do direito penal e do *nullum crimen* é já hoje praticamente inabarcável. Entre nós, cf., por último, NEVES, Castanheira, *O Actual Problema Metodológico da Interpretação Jurídica*, I, 2003, e BRONZE, Pinto, *Lições de Introdução ao Direito*, [2]2006, pp. 875 e ss., 906 e ss., onde aliás considera expressamente os exemplos referidos supra, § 21, (1) e (3). Nestes AA. encontra-se uma vastíssima menção da principal literatura estrangeira sobre o tema. Também DIAS, Silva, *"Delicta in se" e "Delicta mere prohibita": uma Análise das Des-*

Decerto que o processo lógico é o mesmo; decerto que interpretação e integração são momentos, ambos, de um processo metodológico de aplicação fundamentalmente unitário. Mas nada disto ofusca a circunstância de que existem processos hermenêuticos cuja conclusão se mantém no quadro dos significados comuns atribuídos às palavras utilizadas pelo legislador e processos cuja conclusão o ultrapassa: e é isto o essencial para observância do conteúdo de sentido legitimador do princípio da legalidade. Todo o resto acaba por reduzir-se a uma questão terminológica desinteressante ([30]), qual seja a de saber se em vez de distinguir a "interpretação" da "analogia" não se torna preferível distinguir uma **interpretação jurídico-penalmente permitida** de uma outra **proibida**.

§ 25 Não parece, por outro lado, que deva substituir-se a função limitadora que aqui se assinala ao teor literal da norma incriminadora pelo **sentido e finalidade da lei**, em suma, pelo apelo à *ratio legis* ([31]). Claro que este sentido e finalidade assume na interpretação (também na jurídico-penal, como assinalámos) uma função primordial. Mas, antes de ele entrar em jogo, a interpretação admissível tem de passar a "prova de fogo" — para a qual pode servir a imagem do "funil invertido" — da sua admissibilidade face ao *teor literal* da lei e aos *significados comuns* que ele comporta. De outro modo esfuma-se a função de garantia da lei penal — a protecção das pessoas *perante* a lei penal, a que logo aludimos no § 1 —, não é possível encontrar qualquer especificidade do princípio da legalidade *criminal* face ao princípio da legalidade *tout court* e o disposto no art. 29.º-1 da CRP perde inteiramente a sua função e o seu significado.

§ 26 O que acaba de dizer-se não significa porém que deva aceitar-se uma **cisão** ([32]) entre o princípio da legalidade e a sua função político-crimi-

---

continuidades do Ilícito Penal Moderno à Luz da Reconstrução de uma Distinção Clássica, 2003, p. 414 e ss., apesar de uma postura crítica perante o critério que defendemos, acaba por concluir pela possibilidade de distinção entre interpretação e analogia "tanto por razões político-jurídicas relacionadas com o Estado de Direito (...), quanto por razões metodológicas" e — ao que nos pareceu — por chegar a soluções prático-normativas análogas às que defendemos (p. 422 e ss.).

([30]) Assim, também, ROXIN I, § 5, n.º 36.

([31]) Assim todavia, entre outros, STRATENWERTH / KUHLEN, § 3, n.º 31 e ss., e, de uma forma mais complexa e limitadora mas substancialmente análoga, também, JAKOBS, 4/41. Contra, no sentido do texto, ANDRADE, Costa, O princípio constitucional «nullum crimen sine lege» e a analogia no campo das causas de justificação, *RLJ 134*, 2001, p. 76.

([32]) Crítico quanto a ela, FRANCO, Silva, *in*: Franco / Stoco, p. 62.

nal, sujeito a uma compreensão metódica estritamente lógico-formal, de um lado, e a dogmática do crime, orientada por uma consideração substancial, de outro; de tal modo que àquele princípio, uma vez ultrapassado o momento inicial de subsunção incriminatória, não mais houvesse que reverter. Antes o conteúdo e a função político-criminal do princípio da legalidade devem a cada momento estar presentes na construção dogmática do crime. E, antes de tudo, no seu elemento constitutivo que se acolhe sob a epígrafe da *tipicidade* ou, mais concretamente, do **tipo de ilícito** (infra, 11.º Cap. e ss.), sendo neste que se fazem sentir de forma mais intensa e devem portanto encontrar tradução mais cabal as exigências de *determinabilidade* inerentes ao princípio da legalidade. Temas como os da exigência de uma "conexão de risco" em matéria de imputação objectiva (infra, 12.º Cap., § 21 e ss.), de determinação do que sejam "actos de execução" em matéria de tentativa, ou de preferência pelas doutrinas do "domínio do facto" em matéria de autoria (sobre aqueles e estas, infra, 28.º Cap., § 13 e ss., e 30.º Cap., § 16 e ss.) são só alguns exemplos que esperamos tornarem claro aquilo que aqui se quis significar (33).

2. Âmbito da proibição de analogia

§ 27 Face ao fundamento, à função e ao sentido do princípio da legalidade a proibição de analogia vale relativamente a *todos* os elementos, qualquer que seja a natureza, que sirvam para *fundamentar a responsabilidade* ou para a *agravar*; a proibição vale pois **contra reum** ou **in malem partem**, não *favore reum* ou *in bonam partem* (supra, § 12).

§ 28 Concretamente, a proibição abrange antes de tudo os elementos constitutivos dos **tipos legais de crime** descritos na PE do CP ou em legislação penal extravagante. Como vale relativamente às **leis penais em branco** não só no que toca à parte sancionatória (especificamente penal) da norma, mas ainda mesmo na parte em que esta remete para a regulamentação externa. Coisa diferente só deverá dizer-se relativamente a **conceitualizações extra-penais** utilizadas pelo legislador penal que, em princípio, este terá querido usar de forma puramente *acessória* e, por conseguinte, com o sentido que elas possuem no ramo de direito a que pertencem; caso em que se compreende que devam "aceitar-se os resultados

(33) Assim, DIAS, Figueiredo, Legalidade e tipo em Direito Penal, *Escritos em Homenagem a Alberto Silva Franco*, 2003, p. 213.

a que legitimamente se chegue pelos métodos de interpretação permitidos nesse ramo de direito" (34).

§ 29 Também relativamente à matéria das **consequências jurídicas do crime** vale a proibição de analogia em tudo quanto possa revelar-se desfavorável ao agente, isto é, no fundo, em tudo o que signifique restrição (acrescida) da sua liberdade no sentido mais compreensivo. Por isso não tem hoje razão de ser uma doutrina, outrora dominante, segundo a qual a proibição valeria em matéria de penas, mas já não de medidas de segurança, por estarem aqui em causa finalidades estritas de prevenção especial positiva. O mesmo se diga, de resto, para a parte sancionatória das leis penais em branco.

§ 30 A proibição de analogia vale ainda para certas **normas da PG do CP**: para aquelas que constituem *alargamentos* da punibilidade de comportamentos previstos como crimes na PE, nomeadamente em matéria de *tentativa* (art. 22.º; ex.: não é admissível o recurso à analogia para qualificar um certo acto como acto de execução), de *comparticipação* (art. 26.º e ss.; ex.: não é admissível o recurso à analogia para qualificar como doloso o auxílio), etc. Um problema especial é aqui constituído pelas *causas de justificação* e pelas *causas de exclusão* (ou *atenuação*) *da culpa e da punibilidade*. Tratando-se nelas de situações que não fundamentam ou agravam a responsabilidade do agente, mas pelo contrário a excluem ou a atenuam, o recurso à analogia é legítimo sempre que o resultado seja o do alargamento do seu campo de incidência; mas já será ilegítimo se tiver como consequência a diminuição daquele campo (35), se bem que haja aqui razões para determinar de forma mais restritiva os limites da analogia proibida (infra, 14.º Cap., § 3 e ss.).

VI. A proibição de retroactividade. O âmbito de validade temporal da lei penal ou problema da "aplicação da lei penal no tempo"

1. Aplicação da lei penal no tempo e princípio da irretroactividade

§ 31 O plano porventura praticamente mais significativo de refracção do princípio da legalidade e aquele que origina problemas mais complexos

(34) CORREIA, Eduardo, I, § 7, n.º 32; e também ROXIN I, § 5, n.º 40.

(35) Assim, sem restrições, ANDRADE, Costa, nota 31, p. 130 e ss.

é o da proibição de retroactividade *in malem partem*, isto é, *contra* o agente. Pode suceder, na verdade, que após a prática de um facto, que ao tempo não constituía crime, uma lei nova venha criminalizá-lo; ou, sendo o facto já crime ao tempo da sua prática, uma lei nova venha prever para ele uma pena mais grave, ou qualitativamente (*v. g.*, pena de prisão quando era apenas de multa) ou quantitativamente (*v. g.*, prisão até 8 anos quando era somente até 5 anos). O problema da aplicação da lei no tempo é resolvido através das normas chamadas de *direito inter-temporal*. Este direito como que se reduz, no âmbito penal, ao princípio que traduz uma das consequências mais fundamentais do princípio da legalidade: o da **proibição de retroactividade** em tudo quanto funcione **contra reum** ou **in malem partem**. Através dele se satisfaz a exigência constitucional e legal de que só seja punido o facto descrito e declarado passível de pena por lei **anterior ao momento da prática do facto**. Com este conteúdo e esta extensão a proibição de retroactividade da lei penal fundamentadora ou agravadora da punibilidade constitui uma das traves mestras de todo o Estado democrático contemporâneo ([36]).

2. Determinação do *tempus delicti*

§ 32 Pressuposto de actuação do princípio da irretroactividade é pois a determinação do *tempus delicti*, isto é, daquele que deve considerar-se o **momento da prática do facto**. O que está longe de ser em todos os casos isento de dúvidas: quer porque o "facto" pode analisar-se em uma acção, mas também em uma omissão; quer porque nele se pode compreender não só a conduta, mas também o resultado, podendo uma e outro ter lugar em momentos temporalmente (muito) distintos; quer porque tanto a conduta, como o resultado se podem arrastar no tempo. Para obviar a estas dificuldades dispõe o art. 3.º que "o facto considera-se praticado no momento em que o agente actuou ou, no caso de omissão, deveria ter actuado, independentemente do momento em que o resultado típico se tenha produzido".

§ 33 Da referida disposição legal resulta que decisivo para determinação do momento da prática do facto é a **conduta**, não o *resultado*.

([36]) CARVALHO, Taipa de, I, § 314 e ss., e nota 9, *passim*, e COSTA, Faria, O Direito Penal e o Tempo (algumas reflexões dentro do nosso tempo e em redor da prescrição), *BFD, Volume Comemorativo*, 2002, p. 12. Sobre o tema, cf., também, PALMA, Fernanda, A aplicação da lei no tempo: a proibição da retroactividade *in pejus*, *Jornadas FDUL*, p. 413.

O que bem se justifica à luz da função e do sentido do princípio da legalidade ([37]), por isso que é no momento em que o agente actua (ou, no caso de omissão, deveria ter actuado) que releva a função tutelar dos direitos, liberdades e garantias da pessoa que constitui a razão de ser daquele princípio. Fosse decisivo a propósito só o momento em que o resultado, a ser ele jurídico-penalmente relevante (o que nem sempre sucede: infra, 11.º Cap., § 37 e ss.), tem lugar e estaria aberta a porta ao arbítrio e ao possível excesso da intervenção punitiva do Estado.

§ 34 A segunda conclusão a retirar da regulamentação é a de que ela vale para todos os comparticipantes no facto criminoso, venha a sua responsabilização a ter lugar a título de **autores** ou apenas de **cúmplices** (arts. 26.º e 27.º). Porque tanto aqueles como estes, obviamente, são credores da protecção e garantia que o princípio da legalidade se propõe oferecer.

§ 35 Problema especial é constituído por todos aqueles crimes em que a conduta se prolonga no tempo, de tal modo que uma parte ocorre no domínio da lei antiga, outra parte no da lei nova; e de que é exemplo paradigmático o dos **crimes duradouros**, também chamados "permanentes" (infra, 11.º Cap., § 54), p. ex. o crime de *sequestro* (art. 158.º). A melhor doutrina parece ser aqui a de que qualquer agravação da lei ocorrida antes do término da consumação (sobre este conceito, infra, 27.º Cap., § 11 e s.) só pode valer para aqueles elementos típicos do comportamento verificados após o momento da modificação legislativa ([38]). E solução paralela parece dever defender-se para o chamado **crime continuado** (art. 30.º-2; cf. infra, 43.º Cap., §§ 37 e ss. e 59 e ss.) ([39]).

3. Âmbito de aplicação da proibição

§ 36 Tal como vimos suceder com a proibição de analogia — e pelas mesmas razões substanciais —, também a proibição de retroactividade

---

([37]) CARVALHO, Taipa de, nota 9, p. 84 e ss.

([38]) Assim, também, CARVALHO, Taipa de, nota 9, p. 92 e ss.: aplicação da lei nova (mais grave) apenas quando "a totalidade dos pressupostos da lei nova se tenham verificado na vigência desta". Assim também, apesar do texto, pelo menos equívoco, do § 2 (2) do CP alemão, JAKOBS, 4/58 e s., e STRATENWERTH / KUHLEN, § 3, n.º 8.

([39]) Mais longe no que respeita à aplicação da lei nova (agravante) parece ir ROCHA, Lopes, Aplicação da lei criminal no tempo e no espaço, *JDC 1983*, p. 103 e s.

funciona apenas **a favor** do agente, não contra ele. Por isso a proibição vale relativamente a todos os elementos da punibilidade, à limitação de causas de justificação, de exclusão ou de diminuição da culpa e às consequências jurídicas do crime, qualquer que seja a sua espécie (penas, medidas de segurança, consequências penais).

§ 37 Em muitas ordens jurídicas vigora ainda hoje (por vezes expressamente: cf., p. ex., o § 2 (6) do CP alemão) a ideia de que a proibição não vale relativamente às **medidas de segurança**; na base, uma vez mais, de que se trata aí de medidas de prevenção especial positiva comandadas pelo "verdadeiro bem" do agente ([40]). E a ideia teve também curso entre nós ([41]) até à CRP actual e ao CP de 1982. Hoje porém existem injunções legais, constitucionais (CRP, art. 29.º-1 e 3) e ordinárias (art. 1.º-2), que terminantemente afastam uma tal doutrina. Com razão, como já supra, § 8 e s., se expôs. Também relativamente às **medidas de segurança** se fazem sentir exigências de protecção dos direitos, liberdades e garantias das pessoas atingidas que substancialmente se identificam com as que se fazem sentir ao nível das penas ([42]). De considerar é agora todavia a **doutrina diferenciadora** proposta por Maria João Antunes: "se no tocante ao *pressuposto* 'prática de facto ilícito típico' vale a lei vigente no momento da prática do facto, já quanto ao pressuposto 'fundado receio de que o agente venha a cometer outros factos ilícitos típicos' poderá valer a lei vigente no momento da formulação deste juízo de perigosidade". Por isso "a medida de segurança só é aplicável se o facto for descrito e declarado passível de pena por lei anterior ao momento da sua prática; a medida de segurança não é aplicável se o facto punível segundo a lei vigente no momento da sua prática deixar de o ser, por uma lei nova o eliminar do número das infracções, ainda que haja decisão transitada em julgado; a medida de segurança a aplicar, em concreto, determina-se pela lei vigente no momento da

---

([40]) V., por último, para concluir, criticamente, num sentido próximo ao do texto, BEST, Dominik, Die Riskwirkungsverbot nach Art. 3 Abs. 2 GG und die Massregeln der Besserung und Sicherung (§2 Abs. 6 StGB), *ZStrW 114*, 2002, p. 88.

([41]) Por outros, CORREIA, Eduardo, I, n.º 36, II, 5, e, na sua esteira, GONÇALVES, Maia, [5]1980, art. 6.º, anot. 6.

([42]) CARVALHO, Taipa de, nota 9, p. 208 e ss.; DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 685 e ss.; FERREIRA, Cavaleiro de, I, 1981, p. 127; SILVA, Marques da, Algumas notas sobre a consagração dos princípios da legalidade e da jurisdicionalidade na Constituição da República Portuguesa, *Estudos sobre a Constituição*, II, 1978, p. 262; GONÇALVES, Maia, [11]1997, pp. 50 e s. e 57 e s.; PALMA, Fernanda, nota 36, p. 416 e s.

decisão (o momento do preenchimento do pressuposto da perigosidade criminal do agente), excluindo-se, portanto, a lei vigente no momento da execução; a medida de segurança a aplicar, em concreto, determina-se pela lei vigente no momento da decisão, ainda que a lei vigente no momento da prática do facto ilícito típico não determinasse a mesma medida" (43).

§ 38 Questão interessante é a de saber se submetida à proibição de retroactividade está só a lei ou também a **jurisprudência**. Deverá admitir-se que uma corrente de aplicação jurisprudencial definida e estabilizada possa ser alterada — mesmo sem alteração da lei — *contra* o agente? Exemplos concretos desta questão foram o da mudança de entendimento jurisprudencial na Alemanha quanto à taxa de álcool no sangue, de 1,3 g/l para 1,1 g/l, para efeitos de condução sob o efeito do álcool ou na Itália quanto ao jogo das três cartas (por cá vermelhinha), que de jogo de habilidade passou a ser considerado como de azar e por isso penalmente punível.

§ 39 A aplicação da nova corrente jurisprudencial que determina a punição do facto praticado ao tempo da jurisprudência anterior, que o considerava criminalmente irrelevante, **não constitui propriamente uma violação do princípio da legalidade** (44); mas — como conclui também Nuno Brandão em estudo recente — não deixa de pôr em causa valores que lhe estão associados, pela frustração das expectativas quanto à irrelevância penal da conduta, formadas com base numa interpretação judicial, entre nós eventualmente publicada no DR, quando se trate de entendimento definido em recurso extraordinário para fixação de jurisprudência (art. 444.º-1 do CPP) (45). E na verdade, o que se alterou foi o conhecimento (em direcção pressupostamente a um *melhor* conhecimento) da teleologia e da funcionalidade de uma certa norma jurídica: de outro modo, seria o próprio fundamento da separação de poderes que se poria em causa. Além de que parece ser essa a solução que *de jure constituto* resulta da lei proces-

---

(43) ANTUNES, Maria João, *Medida de Segurança de Internamento e Facto de Inimputável em Razão de Anomalia Psíquica*, 2002, p. 180 e ss. (p. 183).

(44) NEVES, Castanheira, nota 5, p. 325, CARVALHO, Taipa, nota 9, p. 343 e ss., PALMA, Fernanda, nota 36, p. 415, e ROXIN I, § 5, n.º 59.

(45) BRANDÃO, Nuno, Contrastes jurisprudenciais: problemas e respostas processuais penais, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, 2003, p. 1302 e ss. Cf. MAURACH / ZIPF, 12/8, e S / S / ESER, § 2, n.ºs 8 e 9.

sual penal (arts. 445.º e 446.º do CPP) (46). Todavia, devem os tribunais ser extremamente cuidadosos (sobretudo onde — o que infelizmente não é o caso de Portugal — existam fortes, seguras e geralmente conhecidas orientações jurisprudenciais fundamentais) na modificação de uma corrente jurisprudencial contra o agente, mostrando-se em tais circunstâncias ainda mais exigentes no respeito pelo círculo máximo de significações que imputem ao *texto* da lei e não se furtando a um "particular ónus de contra-argumentação" (47). Deverá, finalmente, assinalar-se que o cidadão que actuou com base em expectativas fundadas numa primitiva corrente jurisprudencial não estará completamente desprotegido, já que poderá por vezes amparar-se numa falta de consciência do ilícito não censurável, que determinará a exclusão da culpa e, em consequência, da punição (art. 17.º-1 e infra, 23.º Cap., § 11 e ss.) (48).

§ 40 Questão muito discutida é, por fim, a de saber se a proibição de retroactividade se estende aos **pressupostos da punição**, positivos e negativos, e aos **pressupostos processuais**. O problema concretamente mais relevante situa-se em matéria de prazos de prescrição (49). Urge considerar, por outro lado, que em matéria processual o nosso ordenamento jurídico dispõe, no CPP, de uma norma especificamente dirigida à questão: a do art. 5.º, que contém o princípio da *aplicação imediata da lei nova*, mas lhe introduz decisivas limitações quando dele derive — no que ao presente enquadramento interessa — um "agravamento sensível e ainda evitável da situação processual do arguido, nomeadamente uma limitação do seu direito de defesa" (50).

4. O princípio da aplicação da lei mais favorável

§ 41 A consequência teórica e praticamente mais importante do princípio segundo o qual a proibição de retroactividade só vale contra o agente, não a favor dele, consubstancia-se no **princípio da aplicação da lei (ou do regime) mais favorável (lex mellior)**. Esta consequência é de tal modo significativa que assume expressão não só ao nível da lei ordinária

(46) Assim, BRANDÃO, Nuno, nota 44, p. 1306 e s., que todavia preconiza de *lege ferenda* a chamada cláusula *ex nunc*, pela qual a nova corrente jurisprudencial só se aplicaria aos factos praticados a partir do momento em que foi emanada. Contra esta solução, NEVES, Castanheira, nota 5, p. 331 e s.

(47) NEVES, Castanheira, nota 5, p. 333.

(48) Deste modo, ROXIN I, § 5, n.º 59, MAURACH / ZIPF, 12/8, NEVES, Castanheira, nota 5, p. 333, e BRANDÃO, Nuno, nota 44, p. 1307.

(49) Cf. já o nosso *DP II*, §§ 1128 e 1135.

(50) Sobre isto, já, o nosso *DPP*, § 3, III, 4.

(art. 2.º-4: "Quando as disposições penais vigentes no momento da prática do facto punível forem diferentes das estabelecidas em leis posteriores, é sempre aplicado o regime que concretamente se mostrar mais favorável ao agente, salvo se este já tiver sido condenado por sentença transitada em julgado"), como da lei constitucional (CRP, art. 29.º-4, 2.ª parte, que manda aplicar "retroactivamente as leis penais de conteúdo mais favorável ao arguido"). Com isto ganhou o princípio um relevo jurídico adequado ao seu significado para a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Um relevo tal que, de uma outra perspectiva, faz dele um princípio que, mais do que excepção ao princípio da legalidade ([51]), possui natureza *autónoma* directamente decorrente do princípio da *necessidade*. Mas a sua fixação também no texto constitucional trouxe alguns problemas que importa considerar.

4.1. As hipóteses de descriminalização

§ 42 A primeira situação — e mais radical — será aquela em que uma lei posterior à prática do facto **deixe de considerar este como crime** (descriminalização em sentido técnico). Uma tal situação cabe em rigor dentro do princípio de aplicação da lei mais favorável e não exigiria portanto a sua consagração expressa; ou porque se diga que a lei mais favorável é aqui a lei revogatória da criminalização, ou porque à conclusão se chegaria através de um argumento de analogia (permitida). Todavia o CP contempla directamente o caso no art. 2.º-2 nos termos seguintes: "O facto punível segundo a lei vigente no momento da sua prática deixa de o ser se uma lei nova o eliminar do número das infracções; neste caso, e se tiver havido condenação, ainda que transitada em julgado, cessam a execução e os seus efeitos penais". De acordo com o que acaba de dizer-se, a primeira parte do preceito não seria indispensável; mas já não assim a segunda parte, que traduz a ideia de a eficácia do princípio de aplicação da *lex mellior* ser tão forte que, quando se analise em uma descriminalização directa do facto, ela se impõe, no que toca à execução e aos seus efeitos penais, **ainda no caso de a sentença condenatória ter já transitado em julgado**. O que tudo se compreende considerando que, se a concepção do legislador se alterou até ao ponto de deixar de reputar jurídico-penalmente relevante um comportamento, não tem qualquer sentido político-criminal manter os efeitos de uma concepção ultrapassada.

([51]) Como considerava CORREIA, Eduardo, I, p. 154.

§ 43 Apesar da sua aparente simplicidade, esta regulamentação deu já entre nós origem a uma série numerosa de dúvidas. Um primeiro grupo de casos é formado pelas situações em que determinada conduta **deixa de ser crime e passa a constituir contra-ordenação**. Trata-se de uma problemática de grande relevo prático em virtude da consolidação do direito de mera ordenação social e que foi, por exemplo, convocada pela doutrina e pela jurisprudência portuguesas na opção legislativa relativa ao consumo de estupefacientes (L 30/2000, de 29-11). Há quem defenda que nesses casos o facto deixa de ter relevância jurídica, não podendo ser objecto de punição penal, nem contra-ordenacional. E isto porque, atendendo à autonomia material do direito contra-ordenacional face ao direito penal, se argumenta que, dada a descriminalização, não poderá o facto ser punido criminalmente (art. 2.º-2), mas também não poderá ser sancionado a título contra-ordenacional uma vez que no momento da sua prática não existia ainda uma norma legal que para ele cominasse uma coima ([52]). A questão, como facilmente se intui, constitui verdadeiramente problema de direito contra-ordenacional e não penal — pois, com a descriminalização, a conduta deixou de ter relevância penal —, mas nem por isso deve aqui ser de todo desconsiderada. Sobretudo para afastar aquela perspectiva, que embora louvando-se na autonomia material do direito de mera ordenação social, acaba por pensar o respectivo princípio da legalidade nos exactos termos do princípio da legalidade criminal e avança com uma solução formal e redutora. O que deve perguntar-se é se a protecção do cidadão perante o poder punitivo estadual e a tutela das suas expectativas, que conferem também razão de ser ao princípio da legalidade contra-ordenacional, são substancialmente postas em causa com uma eventual punição contra-ordenacional nestas circunstâncias. E a resposta parece não poder deixar de ser *negativa*, pois no momento da prática do facto não existiam razões para que o agente pudesse esperar ficar impune; acabando, isso sim, com a aplicação da sanção contra-ordenacional, por beneficiar de um regime que lhe é concretamente mais favorável. O ponto de vista em crítica pode, além disso, se levado às últimas consequências, dar origem a soluções injustas e incompreensíveis para a sociedade. Pense-se, por exemplo, na hipótese, que não é de todo descabida, de para efeitos do crime de condução de veículo em estado de embriaguez (art. 292.º-1), num primeiro momento o legislador decidir baixar o limite de 1,2 g/l para 0,8 g/l; e, num segundo momento, face à pressão da opinião pública, voltar a colocar esse limite em 1,2 g/l. Seria razoável que o comportamento daquele que, entre o primeiro momento e o segundo, conduziu com 1 g/l se transformasse em juridicamente irrelevante, subsistindo a punibilidade contra-ordenacional de todos aqueles que na mesma data conduziram com uns meros 0,6 g/l? A resposta é obviamente negativa e o exemplo demonstra por si só que o ponto

([52]) CARVALHO, Taipa, nota 9, p. 120 e ss., e a jurisprudência dominante: cf. Ac. do STJ de 9-5-2002, *CJ STJ*, II, 2002, p. 193 e ss., e na primeira instância, entre tantos outros, Despacho do 3.º Juízo Criminal do Porto (1.ª Secção, Proc. n.º 154/2001) de 17-2-2003. Cf. ainda, com interesse, os Acs. do TC 464/2001, *DR*, II Série, de 28-11-2001, p. 1979 e ss., e 295/2003, de 12-6-2003, que em parte se referem aos problemas inter-temporais relacionados com a descriminalização do consumo de estupefacientes, e PEREIRA, Rui, A descriminação do consumo de droga, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 1171 e ss.

de vista correcto é o de que o facto que deixou de ser crime e passou a constituir contra-ordenação deve continuar a merecer sanção contra-ordenacional (53).

§ 44 Encontra-se hoje de alguma forma na linha do pensamento acabado de explanar a regulamentação constante da L 25/2006, de 30-6, da L 28/2006, de 4-7, e da L 30/2006, de 11-7. Atendendo a que condutas aí consideradas **deixam de ser contravenções e passam a contra-ordenações**, estatui-se que as condutas praticadas antes da entrada em vigor do novo regime são já sancionadas como contra-ordenações, sem prejuízo da aplicação do regime mais favorável, nomeadamente quanto à medida da sanção. Os processos que se encontrarem já pendentes nos tribunais continuam aí a sua tramitação, mas a sanção aplicada será a coima. Se o processo não houver ainda sido instaurado, correrá já perante as autoridades administrativas, mesmo que o facto tenha sido praticado na vigência do regime contravencional.

§ 45 Um segundo grupo de casos aos quais deve ser dada solução análoga é o daqueles em que a lei nova mantém a incriminação de uma conduta concreta embora sob um **novo ponto de vista político-criminal**, mesmo que ele se traduza numa modificação do **bem jurídico** protegido. *V. g.*, o crime de violação era perspectivado, até 1995, como crime contra os fundamentos ético-sociais da vida social, enquanto a Reforma de 1995 passou correctamente a perspectivá-lo como crime contra a liberdade e autodeterminação sexual da vítima e consequentemente como um crime contra a pessoa (54). Deve concordar-se sem esforço que esta evolução tem atrás de si uma modificação do próprio bem jurídico protegido. No entanto, a continuidade da punibilidade das condutas concretas de violação não é minimamente afectada; pelo que seria inadmissível pretender que com a entrada em vigor da Reforma foram "descriminalizados" os crimes de violação anteriormente praticados mas só decididos no domínio da lei nova.

4.2. As hipóteses de atenuação da consequência jurídica

§ 46 O mesmo que se expôs para as hipóteses de descriminalização deve defender-se para o caso em que a nova lei **atenua as consequências jurídicas que ao facto se ligam,** nomeadamente **a pena, a medida de segurança** ou **os efeitos penais do facto**. Também neste caso a *lex mellior* deve ser retroactivamente aplicada, todavia, de acordo com o disposto no art. 2.º-4, com **ressalva dos casos julgados**. Tem-se pretendido que a diferença aqui existente relativamente à lei descriminalizadora — a de que nos casos agora em estudo o princípio *já não actua perante uma sentença transitada em julgado* — seria *inconstitucional* por a restrição não cons-

(53) Nesta direcção, MONTEIRO, Cristina Líbano, O consumo de droga na política e na técnica legislativas: comentário à Lei n.º 30/2000, *RPCC 11*, 2001, p. 82 e ss.

(54) Sobre esta evolução, com referências bibliográficas, cf. a nossa síntese no *Comentário Conimbricense*, I, antes do art. 163.º

tar do art. 29.º-4, última parte, da CRP (55). Mas esta posição não parece de aceitar. Não só ou não tanto porque também a lei fundamental tem, na sua interpretação, de ser submetida a uma cláusula de razoabilidade — e, no entendimento do legislador ordinário, não seria razoável, por muito dificilmente exequível, que a totalidade das condenações penais cuja execução ou cujos efeitos se mantêm tivesse de ser reformada todas as vezes que uma lei nova viesse atenuar uma qualquer consequência jurídico-penal ligada ao facto. Mas depois porque, de todo o modo, não compete à lei constitucional regular as condições de aplicação dos seus comandos, antes pelo contrário lhe compete deixar ao legislador ordinário o seu âmbito próprio de actuação. Devendo limitar-se — como faz expressamente a CRP no art. 18.º, especialmente no n.º 2 — a regular os limites deste âmbito, definindo os requisitos a que devem submeter-se as leis restritivas de direitos fundamentais. Não pode dizer-se que a restrição da retroactividade *in bonam partem* às sentenças ainda não transitadas diminua o "conteúdo essencial" do preceito constitucional constante da última parte do art. 29.º-4 da CRP. Nem será inútil lembrar que em outras ordens jurídicas este limite vale mesmo para as próprias leis descriminalizadoras, *v. g.*, na Alemanha, CP § 2 (3), sem que tenha sido posta em causa a sua constitucionalidade à luz do princípio da legalidade.

§ 47 A conformidade com o art. 29.º-4 da CRP da ressalva de casos julgados prevista no art. 2.º-4 do CP não significa, como é evidente, que **a mesma não possa ser eliminada ou restringida, fruto de uma nova opção legislativa**. Nesse sentido vai a alteração ao regime do art. 2.º-4 proposta no **Anteprojecto 2007**. Nesse anteprojecto a actual ressalva dos casos julgados é substituída por uma outra, menos restritiva, do seguinte teor: "Se tiver havido condenação, ainda que transitada em julgado, cessam

(55) Assim, entre outros, CANOTILHO / MOREIRA, art. 29.º, II, CARVALHO, Taipa de, I, § 331 e ss., e nota 9, p. 234 e ss. (expressamente contra a posição do texto, p. 250 e ss.), MAXIMIANO, Rodrigues, Aplicação da lei penal no tempo e caso julgado, *RMP 13*, 1983, p. 11 e ss., PEREIRA, Rui, A relevância da lei penal inconstitucional de conteúdo mais favorável, *RPCC 1*, 1991, p. 58 e ss. O TC, nos Acs. 677/98, de 2-12-1998, *AcTC 41*, p. 501 e ss., e 169/2002, de 17-4-2002, pronunciou-se no sentido da inconstitucionalidade do art. 2.º-4, não em toda a sua extensão, mas "na parte em que veda a aplicação da lei penal nova que transforma em crime semi-público um crime público, quando tenha havido desistência da queixa apresentada e trânsito em julgado da sentença". Resta saber se o caso recentra no dispositivo do art. 2.º-4 ou antes do art. 2.º-2: para um outro exemplo claro deste equívoco cf. o Ac. do TC 572/03, de 19-11-2003, *AcTC 57*, p. 1009 e ss. Com a conclusão do texto se encontra ROCHA, Lopes, nota 39, p. 98 e ss.

a execução e os seus efeitos penais logo que a parte da pena que se encontrar cumprida atinja o limite máximo da pena prevista na lei posterior". Desta proposta não resulta uma imposição de reabertura do processo para nova determinação da pena concreta no quadro da nova moldura penal aplicável, mas somente um *limite* à execução da pena concreta aplicada na condenação transitada em julgado, que coincide com o limite máximo da pena aplicável pela lei nova mais favorável. Em todo o caso, de acordo com o novo regime processual proposto para compatibilizar a lei adjectiva (cf. o art. 371.º-A, aditado pelo art. 3.º da Proposta de Lei n.º 109/X) com esta alteração do art. 2.º-4, "o condenado pode requerer a reabertura da audiência para que lhe seja aplicado o novo regime". Da nova redacção proposta para o art. 2.º-4, resulta que a ressalva dos casos julgados só é afastada em caso de **execução de uma pena principal** e já não de uma pena de substituição, uma vez que só é possível avaliar se o tempo de execução corresponde à pena máxima aplicável pela lei posterior se ambas forem da mesma espécie. Apesar destas cautelas, resta saber se uma tal brecha na ressalva dos casos julgados não constituirá um factor de inibição de futuras reformas legislativas com vista à redução de penas de certas categorias de crimes em que se verifique um elevado número de condenações (*v. g.*, crimes patrimoniais ou crimes de tráfico ou relacionados com o tráfico de estupefacientes) e se não acabará assim por ter efeitos contraproducentes.

§ 48 Questão discutida sobretudo na doutrina alemã e que se colocou entre nós à luz da Reforma de 1995, máxime, na parte em que modificou profundamente o sistema de qualificação (agravação) dos crimes patrimoniais (cf., *v. g.*, os actuais arts. 204.º, 205.º-4, 213.º e 218.º confrontados com os arts. 297.º, 300.º-2, 309.º e 314.º do CP de 1982), é a de saber se existe uma lei mais favorável para efeito de retroactividade quando a lei nova vem eliminar uma **qualificação** e substituí-la por outra que no caso também se verifica. A afirmativa basear-se-ia na ideia de que, mesmo neste caso, o "cerne do ilícito" persiste e é "comum" às duas leis. Mas não parece ser esta a boa doutrina, se as duas qualificações nada tiverem em comum (ex.: a particular acessibilidade da coisa ao agente, art. 297.º-1*f*) do CP de 1982; e a pertinência a bando destinado à prática reiterada de crimes contra o património, art. 204.º-2*g*) da Reforma de 1995). O desaparecimento de uma qualificação traduz-se na existência de lei mais favorável que deve ser retroactivamente aplicada; a introdução de uma nova qualificação significa uma alteração contra o agente submetida à proibição de retroactividade.

4.3. As leis intermédias

§ 49 O princípio da aplicação da lei mais favorável vale ainda mesmo relativamente ao que na doutrina se chama **leis intermédias**; leis, isto é,

que entraram em vigor posteriormente à prática do facto, mas já não vigoravam ao tempo da apreciação judicial deste (*v. g.*, a punição vigente no momento do delito foi substituída por uma menos grave, mas esta foi, antes da sentença, revogada por entretanto se ter considerado que era demasiado leve e reposta a punição anterior). Esta solução é completamente coberta pela letra tanto do art. 29.º-4, 2.ª parte, da CRP, como, ainda mais claramente, pela do art. 2.º-4, 1.ª parte, do CP. E justifica-se teleológica e funcionalmente porque com a vigência da lei mais favorável (intermédia) o agente ganhou uma posição jurídica que deve ficar a coberto da proibição de retroactividade da lei mais grave posterior.

4.4. O regime

§ 50 Não é isento de dificuldades e de dúvidas determinar o que deve exactamente entender-se por **regime que concretamente se mostrar mais favorável ao agente** (art. 2.º-4). A jurisprudência portuguesa (56) ocupou-se insistentemente do tema nos primeiros anos posteriores à entrada em vigor do CP de 1982; e os principais resultados a que chegou merecem concordância de princípio. Assim, p. ex., deve entender-se que uma pena de multa (mesmo elevada) é em princípio mais favorável do que uma pena de prisão (mesmo leve). No resto, deve aceitar-se que o juízo complexivo de maior ou menor favor não deve resultar apenas, em princípio, da contemplação isolada de um elemento do tipo legal ou da sanção, mas da *totalidade do regime* a que o caso se submete. Como seguro é que o sopeso da gravidade dos dois regimes não pode fazer-se só na consideração abstracta da lei, mas tem de ser feito depois de conexionada aquela consideração com as *circunstâncias concretas do caso*. Já é mais equívoca a afirmação de que o regime em definitivo aplicável não pode ser *composto pelo juiz* com *partes* da regulamentação emanada da lei antiga e *partes* emanadas da lei nova, como vem entendendo a jurisprudência dominante, que aponta para a opção por um dos regimes *em bloco* (57). Tomada em si mesma, a afirmação pode considerar-se exacta. Mas é óbvio que ela não pode obstar a que, considerando-se, *v. g.*, aplicável a lei antiga à apreciação do tipo legal ou (e) da pena, todavia acabe por aplicar-se a lei nova na

(56) E a doutrina: cf. ROCHA, Lopes, nota 39, p. 94 e ss.

(57) Ac. do STJ de 20-6-1984 (Proc. n.º 37290), Ac. da RP de 23-2-1983 (Proc. n.º 2154-3.º), Ac. do STJ de 28-5-1998, *BMJ 477*, p. 147, e Ac. do STJ de 2-3-2003, Proc. n.º 03P1539.

parte em que considera, diversamente da lei anterior, que o crime está já prescrito ([58]). Porque, em definitivo, aquela conduz à responsabilização, esta à irresponsabilização penal do agente.

4.5. As chamadas "leis temporárias"

§ 51 Uma **excepção** ao princípio da aplicação da lei mais favorável está consagrada, no art. 2.º-3, para as chamadas leis temporárias: "Quando a lei valer para um determinado período de tempo, continua a ser punível o facto praticado durante esse período". Leis temporárias devem pois considerar-se apenas aquelas que, *a priori*, são editadas pelo legislador para um *tempo determinado*: seja porque este período é desde logo apontado pelo legislador em termos de calendário ou em função da verificação ou cessação de um certo evento, *v. g.*, a duração de um estado de sítio ou de um estado de guerra (chamadas **leis temporárias em sentido estrito** ([59])); seja porque aquele período se torna reconhecível em função de certas circunstâncias temporais (chamadas **leis temporárias em sentido amplo**). Comum é a circunstância de a lei cessar *automaticamente* a sua vigência uma vez decorrido o período de tempo para o qual foi editada. A razão que justifica o afastamento da aplicação da lei mais favorável reside em que a modificação legal se operou em função não de uma alteração da concepção legislativa — esta é sempre a mesma —, mas unicamente de uma alteração das *circunstâncias fácticas* (pense-se nomeadamente em termos de direito penal económico) que deram base à lei. Não existem por isso aqui expectativas que mereçam ser tuteladas, enquanto, por outro lado, razões de prevenção geral positiva persistem. O que deve ser reforçada é a necessidade, a que começou por aludir-se, de interpretação rigorosa daquilo que na verdade constitui uma lei temporária; com a consequência de, em caso de dúvida, fazer valer as regras da proibição de retroactividade e da aplicação da lei mais favorável, nos termos gerais.

§ 52 Uma vez mais não falta quem entenda que a excepção feita pelas leis temporárias à proibição de retroactividade, contida no art. 2.º-3, é **inconstitucional** por

([58]) Contra, GONÇALVES, Maia, [11]1997, p. 56, Ac. da RL de 5-7-1983, *BMJ 336*, p. 461, e Ac. da RE de 31-1-1984, *BMJ 335*, p. 353.

([59]) Também por vezes chamadas "leis de emergência": cf., p. ex., ROCHA, Lopes, nota 39, p. 95, CARVALHO, Taipa de, nota 9, p. 202 e s., e PALMA, Fernanda, nota 36, p. 428 e ss. Mas este conceito é, de um certo ponto de vista, demasiado estrito e falha o essencial.

não constar expressamente do texto do art. 29.º da CRP (60). Uma vez mais deve este entendimento ser contestado pelas razões aduzidas no § 46 a propósito da limitação, em certos casos, da aplicação da lei mais favorável pelo trânsito em julgado da sentença; e nomeadamente porque nem mesmo as leis constitucionais (e ainda menos os seus silêncios) devem em caso algum ser interpretadas contra a sua teleologia e a sua funcionalidade específicas.

(60) Assim, na doutrina, CARVALHO, Taipa de, nota 9, p. 198 e ss., desde que o regime do art. 2.º-3 seja considerado como *excepção* ao regime geral, mas já não se for tido, como o A. o define, um *regime especial*; e na jurisprudência Ac. do STJ de 21-3-1979, *BMJ 285*, p. 172. Cf. já, sobre o assunto, o Ass. do STJ de 18-7-1947, e, depois, BELEZA, Teresa, I, p. 456 e ss.

9.º CAPÍTULO

ÂMBITO DE VALIDADE ESPACIAL DA LEI PENAL

I. O sistema de aplicação da lei penal no espaço e os seus princípios constitutivos

§ 1 Todos os códigos penais contêm disposições sobre o âmbito de validade espacial das suas normas. O conjunto dessas disposições é vulgarmente chamado **direito penal internacional**, analisando-se o seu conteúdo em regras ou critérios de **aplicação da lei penal no espaço.** Tradicionalmente, a expressão *direito penal internacional*, com o sentido dado, era utilizada para contra-distinguir este conjunto de regras, vigente apenas na ordem jurídica nacional, do *direito internacional penal* enquanto ramo do direito internacional público que tem por objecto a matéria penal (supra, 2.º Cap., § 1 e ss.) (1). Assim, o critério que subjazia à distinção era essencialmente o da *fonte* de onde promanavam tais normas — interna no primeiro, internacional no segundo. Depois, pode dizer-se que o direito penal internacional tem um objecto muito mais específico do que o direito internacional penal, dado que abarca apenas as regras de aplicação espacial da lei penal interna, enquanto este último abrange virtual e indistintamente todas as normas de direito internacional que versam sobre matéria penal. Sem dever esquecer-se que o direito internacional penal leva por vezes à consagração de certas soluções no âmbito do direito penal internacional, no que toca ao *se* e ao *como* da competência estadual para conhecer de certos crimes, nomeadamente através da vinculação dos Estados

---

(1) No sentido desta distinção e nos termos do texto, entre nós, SANTOS, Furtado dos, Direito internacional penal e direito penal internacional, *BMJ* 92, 1960, p. 159 e ss., CORREIA, Eduardo, I, n.º 37 e ss., ROCHA, Lopes, Aplicação da lei penal no tempo e no espaço, *JDC 1983*, p. 119. Aprofundadamente sobre ela (como sobre toda a matéria deste capítulo), JESCHECK / WEIGEND, 4.º Cap. Cf. ainda XAVIER, Barreto, Âmbito espacial de aplicação da lei penal portuguesa, *Direito e Justiça XI*, 1997, I, p. 49.

em convenções internacionais sobre o assunto. Tornou-se hoje corrente, de todo o modo — sobretudo depois da criação do *Tribunal Penal Internacional* pelo Tratado de Roma —, usar da expressão *direito penal internacional* mesmo para nomear aquilo que tradicionalmente se designava por *direito internacional penal*, tendo por isso a distinção formal praticamente perdido o sentido indicativo que lhe presidia.

§ 2 A conformação do sistema estadual de aplicação da lei penal no espaço baseia-se em diversos *princípios* e num certo *modelo* da sua combinação. Estes princípios não assumem, todos eles, igual hierarquia, antes existindo **um princípio-base** e **princípios acessórios** ou **complementares**. O princípio-base do nosso sistema é o princípio da **territorialidade**, segundo o qual o Estado aplica o seu direito penal a todos os factos penalmente relevantes que tenham ocorrido no seu território, com indiferença por quem ou contra quem foram tais factos cometidos. Um princípio acessório é o princípio da **nacionalidade**, segundo o qual o Estado pune todos os factos penalmente relevantes praticados pelos seus nacionais, com indiferença pelo lugar onde eles foram praticados e por aquelas pessoas contra quem o foram. Outro princípio complementar é o princípio da **defesa dos interesses nacionais**, segundo o qual o Estado exerce o seu poder punitivo relativamente a factos dirigidos contra os seus interesses nacionais específicos, sem consideração do autor que os cometeu ou do lugar em que foram cometidos. Depois, o princípio complementar da **aplicação universal** ou da **universalidade** manda o Estado punir todos os factos contra os quais se deva lutar a nível mundial ou que internacionalmente ele tenha assumido a obrigação de punir, com indiferença pelo lugar da comissão, pela nacionalidade do agente ou pela pessoa da vítima. Este princípio assume cada vez maior importância no mundo actual, não só devido à crescente preocupação internacional com certo tipo de infracções (crimes de genocídio, violações graves do direito humanitário, terrorismo, etc.) — que, paralelamente, deram lugar à criação de jurisdições internacionais para o conhecimento desses crimes, através dos Tribunais Penais Internacionais para a antiga Jugoslávia e para o Ruanda e do Tribunal Penal Internacional Permanente —, como também por força do carácter global de certos riscos dotados de potencial lesivo transnacional em matéria de ambiente, manipulação genética, criminalidade altamente organizada. Finalmente, a revisão do CP de 1998 introduziu na al. *e)* do art. 5.º-1 o princípio da **administração supletiva da justiça penal**, pondo termo a uma lacuna para a qual havíamos alertado. Assim, de acordo com aquela norma, a lei portuguesa

passa a ter competência para conhecer dos factos que, não se encontrando sujeitos às regras anteriores, foram praticados no estrangeiro por estrangeiros que se encontram em Portugal e cuja extradição, tendo sido requerida, não pode ser concedida (*v. g.*, em virtude da pena aplicável ao crime pela lei do Estado requerente).

II. Conteúdo e sistema de combinação dos princípios aplicáveis

1. O princípio básico da territorialidade

1.1. Justificação e conteúdo

§ 3 A generalidade dos sistemas legislativos penais dos nossos dias assume como princípio basilar de aplicação da sua lei penal no espaço o princípio da territorialidade, não o da nacionalidade. E é esta a posição tradicional do direito penal português (2). Pode afirmar-se que nesta **preferência** convergem razões de índole interna e razões de índole externa ou, se quiser ser-se mais preciso, razões próprias de direito penal e de política criminal, de um lado, razões de direito internacional e de política estadual, do outro.

§ 4 Começando por estas últimas — as razões **jurídico-internacionais** e de **política estadual** —, deve conceder-se facilmente que a assunção do princípio da territorialidade como base do sistema de aplicação da lei penal no espaço é a via que facilitará em maior medida a **harmonia internacional**, o respeito pela não ingerência em assuntos de um Estado estrangeiro. Se a aplicação espacial da lei penal nacional é rigorosamente demarcada por sobre as fronteiras de cada Estado, e se a generalidade dos Estados aceita este princípio, está então descoberto o melhor caminho para que não se gerem conflitos internacionais — positivos ou negativos — de competência interestadual. Se a generalidade dos Estados aceitar o princípio-base da territorialidade, um Estado que aceite o princípio pessoal ver-se-á a cada passo confrontado com aqueles conflitos e com a acusação respectiva de ingerência. Num momento, como o presente, em que a política criminal tende a universalizar-se, a consagração da nacionalidade como

(2) Sobre o ponto, DIAS, Figueiredo, La compétence des juridictions pénales portugaises pour les infractions commises à l'étranger, *BFD XLI*, 1965, p. 118 e s.

princípio básico de aplicação no espaço não poderia deixar, por isso, de ser considerada como internacionalmente *disfuncional*.

§ 5 Durante algum tempo pensou-se que a consagração da territorialidade como princípio básico seria sinal de um regime estadual **democrático**, enquanto a consagração do princípio da nacionalidade seria sintoma de um regime **autoritário**, quando não ditatorial. E na verdade, p. ex., na Alemanha nacional-socialista foram introduzidas alterações no direito penal que iam no sentido de um abrandamento da incidência do princípio da territorialidade e da sua quase completa substituição pelo da nacionalidade. Não parece porém que uma mais forte incidência do princípio da nacionalidade possa ver-se sem mais como sinal de um regime autoritário, antes sim, no máximo, como consequência de uma certa exasperação nacionalista, que faria da lei penal algo que nasceria no coração das pessoas segundo o Estado de que são nacionais e que estas transportariam para toda a parte em que vivessem. É o que porventura acontece com o regime austríaco; e é o que poderia defender-se com algum fumo de legitimidade mesmo para um país como Portugal — país de emigração por excelência e ao qual interessa vivamente a manutenção da ligação espiritual com a pátria dos diversos núcleos de portugueses espalhados pelo mundo. Todas as contas feitas, porém, deve concordar-se que as vantagens internacionais da adopção do princípio-base da territorialidade excedem em muito as do princípio da nacionalidade e são por isso bastantes para fundamentar a legitimidade e a conveniência da sua consagração.

§ 6 Quanto às razões **jurídico-penais** e de **política criminal** que aqui desempenham o seu papel, deve antes de tudo dar-se ênfase à circunstância de ser na *sede do delito* que mais vivamente se fazem sentir as **necessidades de punição** e de cumprimento das suas finalidades, nomeadamente, de prevenção geral positiva. É a comunidade onde o facto teve lugar que viu a sua paz jurídica por ele perturbada e que exige por isso que a sua confiança no ordenamento jurídico e as suas expectativas na vigência da norma sejam estabilizadas através da punição. A estas razões (que poderiam chamar-se "substantivas") acresce (razão "processual") que o lugar do facto é também aquele onde melhor se pode investigá-lo e fazer a sua prova e onde, por conseguinte, existem mais fundadas expectativas de que possa obter-se uma **decisão judicial justa** (3).

§ 7 O **princípio geral da territorialidade** encontra-se entre nós consagrado no art. 4.º/*a)*, segundo o qual "... a lei penal portuguesa é aplicável

(3) Neste sentido, entre nós, por outros, CORREIA, Eduardo, I, n.º 38, II.

a factos praticados em território português, seja qual for a nacionalidade do agente". Torna-se assim indispensável determinar, por um lado, o que é "território português" e, por outro, qual o *locus delicti*, é dizer, qual o lugar onde um facto é praticado. Quanto à primeira questão porém ela não releva em princípio do direito penal, mas do direito constitucional (art. 5.º da CRP; cf. todavia infra, § 16). Por isso só a segunda deve ser aqui tratada.

1.2. O problema da "sede do delito"

§ 8 Para determinação do **locus** ou **sedes delicti** — do lugar ou sede do delito — rege o art. 7.º, nos termos do qual "o facto considera-se praticado tanto no lugar em que, total ou parcialmente, e sob qualquer forma de comparticipação, o agente actuou, ou no caso de omissão, devia ter actuado, como naquele em que o resultado típico ou o resultado não compreendido no tipo de crime se tiver produzido" (n.º 1); dispondo ainda que "no caso de tentativa, o facto considera-se igualmente praticado no lugar em que, de acordo com a representação do agente, o resultado se deveria ter produzido" (n.º 2). Diferentemente portanto do que vimos, no 8.º Cap., § 32, suceder com a determinação do *tempus delicti*, em que o legislador optou pelo critério da conduta em desfavor do do resultado, aqui ele *cumulou* os dois critérios no sentido daquilo que doutrinalmente corre como **solução mista** ou **plurilateral**. Esta decisão é teleológica e funcionalmente fundada (4). Dada a circunstância de diversos países poderem assumir nesta matéria critérios diferentes (uns, o critério da conduta; outros, o do resultado), daí derivariam insuportáveis *lacunas de punibilidade* que uma política criminal minimamente concertada não poderia admitir. Para tanto bastando que o país onde a conduta teve lugar seguisse o critério do resultado típico, enquanto o outro país onde o resultado se verificou aceitasse o critério da conduta. (Ex. de escola: *A* é ofendido corporalmente em Portugal mas vem em consequência a falecer em Espanha; se Portugal aceitasse o critério do resultado e a Espanha o da conduta *A* não poderia ser punido por homicídio, por nenhuma das leis concorrentes poder ser aplicada em nome da territorialidade.)

(4) No sentido dela, apesar da falta de texto expresso do CP de 1886 que a consagrasse, já entre nós, entre outros, SANTOS, Beleza dos, *Direito Criminal*, p. 222, FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, p. 125 e ss., e CORREIA, *Lições 1949*, p. 171 e ss.

§ 9 A revisão do CP de 1998 veio **aditar ao art. 7.º duas conexões** que, em rigor, já não seriam exigidas pela referida solução plurilateral: o local onde se produziu "o resultado não compreendido no tipo de crime" e, em caso de tentativa, o local onde o resultado se deveria ter produzido "de acordo com a representação do agente".

§ 10 A primeira conexão — *sc.*, o local onde se produziu o "**resultado não compreendido no tipo de crime**" — diz respeito, desde logo, aos chamados "crimes tipicamente formais mas substancialmente materiais" (infra, 27.º Cap., § 11 e s.), que atingem a consumação típica sem que todavia se tenha verificado ainda a lesão que, em última análise, a lei quer evitar, proporcionando assim uma tutela antecipada do bem jurídico (como sucede, *v. g.*, no crime de *Fraude na obtenção de crédito*, punido pelo art. 38.º do DL 28/84, que se consuma com a prática da conduta fraudulenta, independentemente da efectiva obtenção do crédito). Em segundo lugar, ela abrange os chamados "crimes de atentado", ou de "empreendimento" (infra, 11.º Cap., § 56), que, embora pressuponham um resultado que transcende a factualidade típica, se consumam no estádio da tentativa (como sucede, *v. g.*, no crime de *Alteração violenta do Estado de direito*, punido pelo art. 325.º). Enfim, aquela conexão vale também para os resultados ou eventos agravantes nos denominados "crimes agravados pelo resultado" (infra, 11.º Cap., § 57 e ss.). Em todos estes casos, a ocorrência em território português do "resultado não compreendido no tipo de crime" fundamenta a competência da lei portuguesa, assim se retomando, de alguma forma, o entendimento da nossa doutrina já à luz do CP de 1886 (5), o qual, como se disse, não regulava expressamente a questão do *locus delicti*. Duvidosa é a questão de saber se podem reconduzir-se àquela expressão as meras "condições objectivas de punibilidade", como pretende a doutrina alemã perante um texto legal muito semelhante, interpretando latamente o termo "resultado". Parece de acolher a formulação segundo a qual é necessário para tanto que tais condições "tenham sido causadas pela conduta e sirvam para fixar o sentido antijurídico do facto" (6). Assim, a simples circunstância de um tribunal português reconhecer judicialmente a insolvência do agente não torna a lei portuguesa competente

(5) SANTOS, Beleza dos, nota 4, p. 225; CORREIA, Eduardo, I, p. 172 e s.; e DIAS, Figueiredo, nota 2, p. 122.

(6) JESCHECK / WEIGEND, § 18, IV, 2, b.

para conhecer de um eventual crime de *insolvência dolosa* (art. 227.º) cometido no estrangeiro por um estrangeiro, porque não pode ver-se na decisão judicial, sequer num sentido lato, um "resultado não compreendido no tipo de crime"; mas a lei portuguesa já será competente para conhecer do crime de *embriaguez e intoxicação* (art. 295.º) se a autocolocação em estado de inimputabilidade se der no estrangeiro e a condição objectiva de punibilidade (*sc.*, a prática de um facto ilícito típico) ocorrer em Portugal.

§ 11 O art. 7.º-2, introduzido, como se disse, pela revisão do CP de 1998, acrescentou uma segunda inovação aos critérios de determinação do *locus delicti*: local do facto é também, em caso de *tentativa*, o **local onde o resultado deveria ocorrer segundo a representação do agente**. Deste jeito, cai sob a alçada da lei portuguesa o envio por agente estrangeiro, a partir de país estrangeiro, de uma carta armadilhada destinada a explodir em Portugal e a matar um cidadão aqui residente, que é todavia desactivada pelas autoridades do Estado estrangeiro (se a carta penetrar em território português há uma parcela do *iter criminis* que decorre em território nacional, o que fundaria logo a competência da lei portuguesa no critério geral da territorialidade). A solução é semelhante à da lei alemã, posto que mais restrita do que ela: a norma portuguesa limita a competência da lei nacional aos casos em que a infracção configura já uma *tentativa*, enquanto o § 9 (2) do CP alemão, consagrando uma formulação mais genérica, abrange também os casos em que o agente praticou apenas *actos preparatórios* (puníveis). Na prática, a grande maioria dos casos regulados por esta norma seria também punível através das regras (com pressupostos mais estreitos, é certo) da nacionalidade passiva e da protecção dos interesses nacionais. De toda a maneira, no plano dogmático, não deixa de ser estranho considerar como *local da prática do facto* o lugar onde o facto não chegou efectivamente a praticar-se.

§ 12 Anote-se por último que o critério misto ou plurilateral examinado, por mais fundado que seja — como em último termo é —, não deixará de ser fonte de **dificuldades práticas** assinaláveis do ponto de vista político-criminal. Nomeadamente, quando a fixação da competência espacial da lei penal portuguesa tiver lugar em função do lugar do "resultado", haverá quase sempre uma pluralidade de pessoas a quem a nossa lei se aplica mas não se encontrarão em Portugal. Por outro lado, se o resultado se tiver verificado no estrangeiro, a competência espacial da lei penal portuguesa torna-se no mínimo questionável se o facto não for punível segundo a lei penal do lugar do resultado (7).

(7) Neste sentido, na Alemanha, também, STRATENWERTH / KUHLEN, § 4, n.º 11.

1.3. Problemas particulares ([8])

§ 13 Apesar da aparente clareza da solução plurilateral, alguns problemas ficam ainda em aberto. Desde logo, o dos chamados **crimes continuados** (art. 30.º-2 e infra, 43.º Cap., § 37 e ss.), em que uma pluralidade real de factos (que podem ser cometidos em países diferentes) é juridicamente considerada uma unidade normativa. Na linha da teleologia e da funcionalidade da solução plurilateral — e suficientemente coberta pelo texto do art. 7.º — está a solução de que deve nestes casos considerar-se bastante que um dos factos se encontre abrangido pelo princípio da territorialidade.

§ 14 Expressamente coberto pelas razões apontadas encontra-se o caso da **comparticipação** — que tenha lugar em Portugal sob qualquer forma e portanto também sob a da mera *cumplicidade* — num facto praticado no estrangeiro; bem como a hipótese inversa de o facto se verificar em Portugal, mas a comparticipação ter lugar no estrangeiro. A qualquer destas hipóteses é aplicável a lei penal portuguesa em nome do princípio da territorialidade. Como igualmente coberto se encontra o caso da **omissão**, relativamente à qual vale como lugar do delito aquele em que deveria ter tido lugar a acção esperada ou em que teve lugar o resultado típico.

§ 15 Duvidosa é a solução que por vezes se aponta para o caso dos chamados **delitos itinerantes** ou **de trânsito**; factos que, pelo seu modo específico de execução, se põem em contacto com diversas ordens jurídicas nacionais (exs.: uma missiva injuriosa é escrita em Portugal, expedida de Espanha e anda perdida em França antes de chegar ao seu destinatário na Bélgica; um pacote contendo droga é enviado por navio na Colômbia, descarregado em Portugal, onde parte de comboio para o seu destino, a Holanda). Uma certa doutrina entende, também aqui, que qualquer das ordens jurídicas contactadas se torna aplicável em nome do princípio da territorialidade. E, uma vez mais, a solução é político-criminalmente conveniente, mas decerto nem sempre de fácil compatibilização com o texto do art. 7.º

§ 16 Pelo menos em via de princípio, a **"nacionalidade" dos interesses** que a norma visa proteger não deve assumir relevo para funcionamento do princípio da ter-

([8]) Sobre estes problemas, na vigência do CP de 1886, DIAS, Figueiredo, nota 2, p. 122.

ritorialidade, se aquela nacionalidade não encontrar tradução por forma bastante no texto da lei portuguesa. Assim, *v. g.*, a contrafacção de moeda estrangeira em Portugal fixa a aplicação da lei portuguesa para efeito do art. 262.º e ss. Como também — contra o que decide a jurisprudência alemã — ao estrangeiro que em Portugal viola a obrigação de alimentos relativamente a pessoa residente no estrangeiro deve ser aplicado o disposto no art. 250.º Outra coisa significaria uma *limitação* do princípio da territorialidade em função do princípio da defesa de interesses nacionais, quando este é um princípio "complementar", não um princípio limitador do princípio base.

1.4. O chamado "critério do pavilhão"

§ 17 O princípio da territorialidade sofre um alargamento que se contém no art. 4.º/*b)* e parifica com os factos cometidos em território português os que tenham lugar **a bordo de navios ou aeronaves portugueses**. Fala-se a este propósito de um "critério do pavilhão", justificado pela consideração tradicional (e que, na verdade, o direito marítimo e aéreo em princípio aceita) de que aqueles navios e aeronaves são ainda, se não facticamente, ao menos para efeitos normativos "território português" (de *territoire flottant* falava a propósito a doutrina francesa, enquanto em tantas outras se admitia expressamente tratar-se aqui de uma "ficção de território"). Parece todavia dever entender-se que, sempre que o navio ou aeronave estejam surtos em porto ou aeroporto (*rectior*, em águas ou espaços aéreos territoriais) de país diferente do do pavilhão, isso não retira competência à lei do lugar em nome do princípio base da territorialidade; o que só favorecerá a necessidade eventualmente imperiosa, de intervenção imediata de autoridades policiais ou mesmo judiciárias. Quando tal suceda dar-se-á, no máximo, um conflito *positivo* de competências.

1.5. Uma nova extensão da competência da lei penal portuguesa: certos factos praticados a bordo de aeronaves civis

§ 18 O DL 254/2003, de 18-10, prevê nos seus arts. 3.º e 4.º uma **extensão** da competência da lei penal portuguesa, que passa a poder aplicar-se aos crimes contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual, a honra ou a propriedade (assim como ainda aos crimes previstos no art. 4.º-3 e 4 daquele diploma), que sejam praticados a bordo de aeronave alugada a um operador que tenha a sua sede em território português; ou, tratando-se de uma aeronave estrangeira que se não encontre nessas condições, se o local de aterragem seguinte à prática do facto for em território português e o comandante da aeronave

entregar o presumível infractor às autoridades portuguesas. Esta extensão, assente na **conjugação** do critério formal do pavilhão e de um critério material (limitação a certos crimes), deriva da tendência moderna de expansão das jurisdições penais para uma prevenção e uma repressão eficazes dos crimes internacionais (em sentido amplo). Trata-se, de toda a maneira, de uma conexão de competência que se revela *subsidiária* relativamente à conexão territorial (*v. g.*, caso a aeronave se encontre, no momento da prática do facto, em espaço aéreo nacional), mas que parece dever *preferir* às restantes, pois não está sujeita a condição alguma, nomeadamente ao requisito da dupla incriminação.

2. O princípio complementar da nacionalidade

2.1. Justificação e conteúdo

§ 19 A *complementaridade* do princípio da nacionalidade relativamente ao princípio da territorialidade logo significa que se não pretende, por meio dele, obviar a todo e qualquer crime que possa ser cometido por um português fora do seu país. Apenas se reconhece existirem casos perante os quais, se tudo repousasse no princípio português da territorialidade, poderiam abrir-se lacunas de punibilidade indesejáveis para uma política criminal internacional concertada e eficiente. E isto porque existe uma máxima, aceite pelo direito internacional e (pelo menos até há bem pouco tempo) comummente seguida, atinente de forma imediata a toda a matéria da aplicação da lei penal de um país a factos cometidos por um seu nacional no estrangeiro: a máxima da **não-extradição de cidadãos nacionais**. Se os não extradita, então os princípios da convivência internacional devem conduzir a que, uma vez que eles se encontrem de novo no país da nacionalidade, o Estado nacional os puna: *dedere aut punire (iudicare)*, o Estado ou extradita (entrega) ou, quando não extradita, pune (julga). Esta é a principal justificação deste princípio como complementar do da territorialidade.

§ 20 O que fica dito corresponde ao conteúdo tradicional do princípio da nacionalidade que, de acordo com o fundamento e a teleologia que lhe foram apontados, surge como **princípio da personalidade activa**: o agente *é um português*. Fala-se todavia hoje também, a justo título, de um **princípio da personalidade passiva**, para efeito de aplicação da lei penal portuguesa a factos cometidos no estrangeiro *por estrangeiros contra por-*

tugueses. É óbvio porém que este princípio da personalidade passiva radica num fundamento e numa teleologia que — pode afirmar-se sem exagero — *nada tem em comum* com aqueles em que vimos assentar o princípio da personalidade activa. Com efeito, a máxima da não-extradição de nacionais não desempenha aqui qualquer papel, uma vez que relevante é a nacionalidade da **vítima**, não a do agente. O que oferece fundamento ao princípio da personalidade passiva é a necessidade, sentida pelo Estado português, de proteger os cidadãos nacionais; é, dito por outras palavras, a exigência de protecção de nacionais perante factos contra eles cometidos por estrangeiros no estrangeiro e, neste sentido, a *protecção de interesses nacionais*. O princípio da personalidade passiva possui por isso um fundamento e uma teleologia que o *identificam* com o *princípio da defesa de interesses nacionais* (infra, § 37 e ss.), concretamente sob a forma de *protecção pessoal (individual)* daqueles interesses.

§ 21 Sendo assim, a consideração teórica do princípio da personalidade passiva deveria ser levada a cabo, em rigor, — como o é por muitos autores, por exemplo Jescheck — no âmbito do **princípio da defesa dos interesses nacionais** (9). Se assim não procedemos, antes a sua consideração se faz conjuntamente com a do princípio da personalidade activa, é porque o mesmo sucede no nosso CP. E ainda e sobretudo porque as condições a que a nossa lei submete o princípio da personalidade passiva são *exactamente as mesmas* de que depende o princípio da personalidade activa e *diferentes* das que valem para o princípio da defesa (não individual, mas real) dos interesses nacionais; na medida em que para o princípio da personalidade activa, mas não para o da protecção real dos interesses nacionais, valem as condições postas nos três apartados da al. *c)* do art. 5.º-1.

§ 22 O princípio da nacionalidade encontra-se consagrado, na **forma normal do seu aparecimento** —, e na verdade tanto na *vertente activa*, como na *passiva* — no art. 5.º-1/*c)*. De acordo com ele a lei penal portuguesa é aplicável a factos cometidos fora do território nacional, por portugueses (princípio da personalidade activa) ou por estrangeiros contra portugueses (princípio da personalidade passiva), sob uma tríplice condição: a de os agentes serem encontrados em Portugal; a de tais factos serem puníveis pela legislação do lugar em que tiverem sido praticados, salvo quando nesse lugar se não exercer poder punitivo; e a de constituírem crime que admita extradição e esta não possa ser concedida. **Português** para os efeitos em causa é todo aquele que como tal deva ser considerado,

(9) JESCHECK / WEIGEND, § 18, II, 4.

no momento do facto (cf. art. 3.º e supra, 8.º Cap., § 32 e ss.) e segundo as normas da lei da nacionalidade.

2.2. Condições de aplicação

2.2.1. Que o agente seja encontrado em Portugal

§ 23 A primeira condição — a de o agente ser encontrado em Portugal, inciso I do art. 5.º-1/*c*)— explica-se, quanto ao princípio da personalidade activa, por ser nela que se concretiza a razão que lhe dá fundamento: a não-extradição de nacionais; e quanto ao princípio da personalidade passiva por nele se tratar de uma *extensão* do princípio da nacionalidade justificada por razões de índole muito especial. Tem-se muitas vezes apontado esta condição, na nossa doutrina, como exemplo de uma *condição objectiva de punibilidade* ([10]). Tomada esta expressão no seu teor literal, a afirmação é correcta. Como correcta se mostra quando com ela se pretende significar que tal exigência não constitui elemento do tipo objectivo de ilícito e não precisa, por isso, de ser abrangida pelo dolo e pela culpa do agente. Dogmaticamente porém ela nada possui de comum com o fundamento e a teleologia das verdadeiras condições objectivas de punibilidade (infra, 26.º Cap., §§ 1, 3), antes constitui uma **condição de aplicação no espaço da lei penal portuguesa**. Resta saber se uma tal condição, em definitivo, se justifica, ou se justifica totalmente, na medida em que ela condiciona, porventura em medida demasiado lata, a protecção penal que o Estado português se dispõe a oferecer aos seus nacionais, isto é, afinal, a amplitude do princípio da personalidade passiva; sobretudo num momento em que a figura do julgamento de *ausentes* em processo penal regressou (infelizmente) ao sistema legal português (CPP, art. 232.º e ss.).

2.2.2. Que o facto seja também punível pela legislação do lugar em que tiver sido praticado

§ 24 A exigência de que o facto seja também punível pela legislação do lugar em que tiver sido praticado (inciso II do art. 5.º-1/*c*)) é a **condição materialmente mais importante** de aplicação do princípio da

([10]) Por todos, e por último, CORREIA, Eduardo, I, pp. 175 e 370, e DIAS, Figueiredo, nota 2, p. 125; criticamente, DIAS, Figueiredo, Sobre o estado actual da doutrina do crime, *RPCC* 2, 1992, p. 33.

nacionalidade e que mais claramente o converte em princípio subsidiário. Uma tal exigência é, pelo menos em via de princípio, político-criminalmente justificada e teleologicamente plena de sentido. Não é em regra razoável estar a submeter ao poder punitivo alguém que praticou o facto num lugar onde ele não é considerado penalmente relevante e onde, por isso, não se fazem sentir quaisquer exigências preventivas quer sob a forma de tutela das expectativas comunitárias na manutenção da validade da norma violada — norma que, em definitivo, não existe —, quer sob a forma de uma socialização de que, segundo a lei do lugar, o agente não carece. Só considerações de retribuição do crime como um mal absoluto, sem localização espacial, poderiam levar a conclusão diferente. Pelo menos no que tange o princípio da *personalidade activa*. Já considerando o fundamento da *personalidade passiva*, a exigência torna-se menos clara, uma vez que o que aí está em causa é um propósito de protecção de interesses (pessoais) especificamente nacionais.

§ 25 A lei ressalva desta exigência a hipótese de no *loce delicti* — justamente porque se trata de um "domínio sem senhor" — **se não exercer o poder punitivo**: nesse caso (se é que rigorosamente ele existe ainda no nosso mundo) o princípio da personalidade fica simplesmente na dependência da verificação do requisito anterior (art. 5.º-1/*c*), *inciso* I), já que também o requisito que em seguida será tratado perde verdadeiramente campo de aplicação. Uma tal extensão do princípio da nacionalidade é fruto, por um lado, de o princípio da territorialidade não poder aqui ter aplicação (por não haver lei do lugar) e por, apesar disso, se entender que o facto não deve ficar sem punição. Bem podendo afirmar-se que em tais hipóteses o princípio da personalidade (activa e passiva) deixa de ser princípio complementar ou acessório, para se tornar em princípio *único* de aplicação da lei penal no espaço.

2.2.3. Que o facto constitua crime que admita extradição e esta não possa ser concedida

§ 26 O inciso III do art. 5.º-1/*c*) põe como última condição de aplicação do princípio da personalidade, activa ou passiva, que o facto constitua crime que admita extradição e esta não possa ser concedida. Trata-se aqui claramente de uma reafirmação da concepção do legislador segundo a qual o princípio da territorialidade deve não apenas no conspecto nacional, mas internacional constituir o princípio-base, e o princípio da nacionalidade o complemento. Se a extradição fosse jurídica e facticamente possível ela deveria ser concedida e o princípio pessoal deveria regredir: do ponto de vista do princípio-base da territorialidade antes *dedere* que

punire. Se estiver em causa o princípio da nacionalidade activa (sendo o agente *português*), a extradição só é possível nos apertados limites do regime previsto no art. 33.º-3 da CRP e no art. 32.º-2, da L 144/99, de 31-8 (*Lei da Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal*). Com efeito, rompendo com uma tradição plurissecular, a LC 1/97 introduziu no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de **extradição de nacionais**, até então absolutamente proibida pela Constituição; a causa imediata da modificação deveu-se por certo à vontade de dar cumprimento à regra posta pelo art. 7.º-1 da Convenção relativa à Extradição entre os Estados-membros da União Europeia, assinada em 27-9-1996 ([11]). Embora esta norma admitisse a formulação de reservas — e, portanto, a manutenção da proibição de extradição de nacionais —, o Estado Português optou por "abrir" o seu direito à extradição de nacionais em certos casos contados e taxativamente descritos, de acordo com a faculdade concedida no art. 7.º-2 da Convenção. Assim, o actual art. 33.º-3 da CRP (só) permite a extradição de nacionais desde que se verifiquem os seguintes requisitos (cumulativos): *a)* existência de reciprocidade de tratamento por parte do Estado requerente; *b)* consagração dessa reciprocidade em convenção internacional; *c)* tratar-se de casos de terrorismo ou de criminalidade internacional organizada; e *d)* consagração de garantias de um processo justo e equitativo pela ordem jurídica do Estado requerente.

§ 27 **Crime que admita extradição** é qualquer um à excepção da "infracção de natureza política ou infracção conexa a infracção política segundo as concepções do direito português" e do "crime militar que não seja simultaneamente previsto na lei comum" (art. 7.º-1/*a)* e *b)* da Lei da Cooperação Judiciária Internacional). Porém, a própria lei retira, no art. 7.º-2, a natureza política a um extenso leque de crimes (genocídio, crimes contra a Humanidade, etc.), independentemente da motivação que lhes presida. Além disso, há que ter em conta, nas relações com os restantes Estados-membros da União Europeia, que o art. 5.º da Convenção de Extradição de 1996 exclui expressamente a natureza política do crime como fundamento da recusa de extradição. Ora, dada a prevalência das normas contidas em convenções internacionais sobre a lei ordinária interna ([12]), a eventual natureza política de certa infracção não permitirá ao Estado

([11]) Cf. *JOCE* n.º C 313, de 23-10-1996, p. 12 e ss.

([12]) CANOTILHO / MOREIRA, art. 8.º, VIII.

Português recusar a extradição no âmbito de aplicação da referida Convenção (*sc.*, quando seja pedida por um Estado-membro da União).

§ 28 Se o crime é, pela sua natureza, passível de extradição, pode todavia esta **não ser concedida**, seja porque, pura e simplesmente, não foi requerida — aqui se diferenciando o regime do previsto no art. 5.º-1/*e)* (cf. infra, § 44) —, seja por efeito das normas, substantivas e adjectivas, em matéria de extradição. Algumas das quais se inscrevem logo no texto constitucional: justamente a que proíbe a extradição de nacionais fora dos casos previstos (art. 33.º-3); a que impede a extradição pedida por motivos políticos (art. 33.º-4); e as que vedam a extradição por crimes a que correspondam certas reacções criminais segundo o direito do Estado requerente: a *pena de morte* e a pena de que resulte *lesão irreversível da integridade física* (art. 33.º-4), bem como a pena ou medida de segurança privativa ou restritiva da liberdade de carácter perpétuo ou de duração indefinida (art. 33.º-5). No que diz respeito às duas primeiras proibições de extraditar, elas cessam apenas se o Estado requerente previamente *comutar* essas penas ou medidas ou se *aceitar a conversão* das mesmas por um tribunal português, segundo a lei portuguesa (cf. o art. 6.º-2/*a)* e *c)* da L 144/99). A terceira proibição cessa, para além destes casos, se existirem condições de reciprocidade estabelecidas em convenção internacional e se o Estado requerente der garantias de que tal pena ou medida não será aplicada ou executada (art. 33.º-5 da CRP e art. 6.º-2/*b)* da L 144/99).

§ 29 A proibição de extradição relativa à aplicabilidade de pena ou medida de segurança **perpétua** ou de **duração indefinida** pela lei do Estado requerente (bem como, aliás, a que se refere à pena de que resulte lesão irreversível da integridade física) foi introduzida na CRP pela LC 1/97, embora já tivesse consagração (simplesmente) legal anterior no art. 6.º-1/*e)* e *f)* do DL 43/91. Com esta intervenção o legislador parece ter prosseguido dois fins: por um lado, conferir-lhe dignidade constitucional; por outro lado, ao destinar-lhe um apartado legal autónomo (o n.º 5), tornar claro que ela obedece a um regime próprio, diverso do previsto no n.º 4, em matéria de prestação de garantias de não aplicação da pena por parte do Estado requerente — questão que era muito debatida antes da LC 1/97 ([13]).

([13]) Sobre o problema pode ver-se: DIAS, Figueiredo, Extradição e *non bis in idem* — Parecer, *Direito e Justiça IX*, 1995; CANOTILHO, Gomes, Caso Varizo — Extradição no caso de prisão perpétua (anotação ao Ac. do TC 474/95), Anotação, *RLJ 128*, p. 248; CAEIRO, Pedro, Proibições constitucionais de extraditar em função da pena aplicável, *RPCC 8*, 1998, p. 7 e ss.; SERRANO, Mendes, Extradição. Regime e Praxis, *in*: *Cooperação Internacional Penal. Extradição. Transferência de Pessoas Condenadas*, 2000; e o Ac. do TC 1/2001 (processo n.º 742/99).

§ 30 A prevalência da extradição sobre a competência da lei portuguesa em razão da nacionalidade vale também, *mutatis mutandis*, para a **entrega** efectuada ao abrigo da L 65/2003, de 23-8, relativa ao **mandado de detenção europeu**, aprovada em cumprimento da Decisão-quadro 2002/584/JAI, do Conselho, de 13-6 ([14]). Assim, a competência extraterritorial da lei portuguesa em virtude da nacionalidade (activa ou passiva) só deve exercer-se na ausência de um pedido de entrega formulado por um estado da União, ou na impossibilidade de lhe dar cumprimento quando subsista, apesar dela, uma pretensão penal do Estado português (cf. o art. 11.º/*d)* e *e)*, bem como os casos de ausência das garantias previstas no art. 13.º daquele diploma). Esta regra não é, todavia, absolutamente rígida, devendo ressalvar-se o factor de flexibilidade introduzido pelo art. 12.º-1/*b)* da L 65/2003, que admite a possibilidade de recusa do pedido de entrega com fundamento na pendência, em Portugal, de um procedimento penal, pelos mesmos factos, contra a pessoa procurada. Assim, razões pragmáticas poderão levar as autoridades portuguesas a recusar um pedido de entrega para, *v. g.*, julgamento da pessoa procurada quando o procedimento penal nacional se encontre já em fase de julgamento ou mesmo de recurso.

§ 31 O raciocínio e os resultados expostos no parágrafo anterior valem também para o pedido de entrega formulado pelos **Tribunais Penais Internacionais** para a ex-Jugoslávia e para o Ruanda, cuja jurisdição tem primazia sobre as jurisdições nacionais, no termos das Resoluções das Nações Unidas que os instituíram e dos arts. 2.º-1 e 3.º-1 da L 102/2001, de 25-8. O mesmo não sucede porém com a entrega ao **Tribunal Penal Internacional (Permanente)**, dado que, nos termos do Estatuto de Roma, o tribunal só pode admitir o caso — princípio da subsidiariedade — quando as jurisdições competentes não puderem ou não quiserem julgar adequadamente os factos em causa ([15]). Deste jeito, em condições normais, um eventual conflito de competências com o TPI está, por definição, arredado. Só assim não sendo se o Estado português pretendesse exercer fraudulentamente a sua jurisdição (*v. g.*, para proteger determinado agente de

([14]) Sobre esta nova forma de cooperação internacional, RODRIGUES, Anabela, O mandado de detenção europeu — Na via da construção de um sistema penal europeu: um passo ou um salto?, *RPCC 13*, 2003, p. 27.

([15]) Sobre todo o problema, CAEIRO, Pedro, O procedimento de entrega previsto no Estatuto de Roma e a sua incorporação no direito português, *in*: Moreira, Vital / Assunção, Maria Leonor / Caeiro, Pedro / Riquito, Ana, *O Tribunal Penal Internacional e a Ordem Jurídica Portuguesa*, 2004, p. 69.

nacionalidade portuguesa), levando por essa via o TPI a formular-lhe um pedido de entrega: nesse caso, o pedido do TPI deveria prevalecer sobre a competência dos tribunais portugueses, não por força do disposto no art. 5.º-1/*c*), mas por força das obrigações internacionais assumidas por Portugal ao ratificar o Estatuto de Roma, de entre as quais se destaca, neste ponto, o dever de cumprir os pedidos de entrega formulados pelo TPI, ainda que em detrimento do *ius puniendi* nacional.

§ 32 As considerações que expendemos sobre a extensão da cláusula da impossibilidade de extradição a outras formas de cooperação judiciária internacional (nomeadamente, o mandado de detenção europeu e a entrega a uma jurisdição internacional) encontram expressão parcial na **versão proposta pelo Anteprojecto 2007** para o art. 5.º-1/*e*)/III. Com uma diferença, porém: embora se mantenha o âmbito *lato* da impossibilidade de extradição, de maneira a abranger os casos em que a extradição não é sequer requerida, adopta-se um critério *mais restrito para as restantes formas de cooperação*, condicionando-se a competência da lei portuguesa à existência de uma decisão de não entrega (em execução de um mandado de detenção europeu ou de outro instrumento internacional de cooperação).

2.3. Extensão do princípio da nacionalidade

§ 33 Com uma extensão do princípio da nacionalidade depara-se no art. 5.º-1/*d*), segundo o qual a lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos cometidos fora do território nacional "*contra* portugueses, *por* portugueses que viverem habitualmente em Portugal ao tempo da sua prática e aqui forem encontrados". Extensão que deriva de se não fazerem nesta sede as exigências constantes dos incisos II e III do art. 5.º-1/*c*). Uma tal extensão foi justificada com a consideração de que importaria impedir a impunidade nos casos — que, por serem excepcionais, não seriam menos chocantes — em que um português se dirige ao estrangeiro para aí cometer um facto que, se bem que lícito segundo a *lex loci*, constitui todavia um crime segundo a *lex patriæ*, com a agravante de um tal crime ser cometido contra um português; e em que, uma vez o crime cometido, o agente volta a Portugal provavelmente para aqui continuar a viver tranquilamente. Em casos tais — argumentou-se — o agente teria adquirido, se a extensão em causa não existisse, um verdadeiro "direito à impunidade" através de uma **fraude à lei penal.** Por isso uma tal lacuna devia ser incondicionalmente preenchida ([16]).

([16]) Cf. CORREIA, Eduardo, *Actas PG*, I, p. 82 e ss., com o aplauso generalizado da Comissão; e também DIAS, Figueiredo, nota 2, p. 131 e s.

§ 34 A referida lacuna foi **exemplificada** sobretudo com o caso da mulher portuguesa que se dirigisse a uma clínica estrangeira para aí levar a cabo uma interrupção da gravidez lícita segundo a *lex loci*, mas em condições que, em Portugal, conduziriam à punição por aborto (arts. 140.º-142.º). Ou o do cônjuge português que se dirigisse a país estrangeiro para aí se divorciar em termos que não seriam reconhecidos como válidos pelo direito português e contrair em seguida novo matrimónio (art. 247.º, bigamia). Ao que podem acrescentar-se casos como o do português que se dirigisse a país estrangeiro para auxiliar outro português a suicidar-se (art. 135.º), se a ajuda ao suicídio não fosse punível nesse país (*v. g.*, a Alemanha). Ou ainda o do português que mantivesse relações homossexuais com outro português de 15 anos (art. 175.º) num país onde aquelas não fossem puníveis. Ou o do português que sujeitasse a sua mulher portuguesa a sequestro ou a violências físicas num país onde tais condutas são admitidas ao cônjuge masculino.

§ 35 A ser assim, pode duvidar-se da **necessidade político-criminal** desta extensão do princípio da nacionalidade ([17]). Sobretudo na medida em que, não sendo o facto punível segundo a lei do lugar, isso seja sinal de que a sua incriminação releva mais de concepções éticas discutíveis também para a comunidade nacional, ou se traduz num "crime sem vítima" ou figura jurídico-penal próxima. Não parece, por outro lado, que possa argumentar-se com a ideia da *fraude à lei*, que não tem qualquer tradução no texto legal e provavelmente nem se dará nos casos em que a extensão aparece porventura mais justificada (cf. o exemplo dos maus tratos ao cônjuge no final do parágrafo anterior). A sua justificação — com eventuais consequências no seu âmbito de aplicação — parece pois só poder ser vista na **fidelidade** do agente e da vítima aos princípios fundamentais de uma comunidade a que pertencem e onde o agente habitualmente vive.

§ 36 Uma derivação do princípio da nacionalidade, acolhida agora pelo Anteprojecto 2007 (art. 5.º-1/*g*)), é a conexão da **sede, em território português, das pessoas colectivas**, autoras ou vítimas do crime praticado no estrangeiro (algo de equivalente à nacionalidade activa / passiva), tanto mais importante quanto se assiste a um crescente movimento legislativo de responsabilização criminal das mesmas (infra, 11.º Cap., § 30 e ss.).

3. O princípio complementar da defesa (da protecção) dos interesses nacionais

§ 37 Trata-se, neste princípio complementar de aplicação da lei penal portuguesa, da específica protecção que deve ser concedida a **bens jurídicos**

([17]) Criticamente, em geral, GALLAS, Der dogmatische Teil des Alternativ-Entwufs, *ZStW 80*, 1968, p. 13 e ss.

portugueses, independentemente, por conseguinte, da nacionalidade do agente, de os crimes terem sido cometidos no estrangeiro e mesmo do que a seu respeito disponha a lei do lugar. O que sucede é que, apesar dos esforços, em parte já coroados de algum êxito a nível internacional ou inter-regional, de aproximação e de cooperação entre as diversas leis nacionais, pode compreender-se que muitas delas não punam factos, ainda que praticados no seu âmbito territorial, exclusivamente dirigidos à lesão de bens jurídicos próprios de outro país. É o que sucede com a generalidade dos crimes contra o Estado, onde a área de tutela típica cobre apenas os interesses do Estado Português. Foi precisamente a regra enunciada no texto que levou o legislador nacional a rever o regime da punição do terrorismo na Lei de Combate ao Terrorismo (L 52/2003, de 22-8), que transpôs para o direito interno a *Decisão-quadro do Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa à luta contra o terrorismo*, passando a incriminar as organizações terroristas que tenham por fim a prática de actos terroristas contra entidades estrangeiras (art. 3.º: *Outras organizações terroristas*) e, naturalmente, o próprio *Terrorismo internacional* (art. 5.º) ([18]). Por isso os estados nacionais se vêem na necessidade de fazer intervir a protecção penal dos seus interesses específicos perante factos cometidos no estrangeiro, mas directamente dirigidos à lesão de bens jurídicos nacionais. O bom **fundamento** de uma tal extensão do *ius puniendi* nacional reside em que o próprio agente estabeleceu a relação com a ordem jurídico-penal portuguesa ao dirigir o seu facto contra interesses especificamente portugueses. Além disso, o Estado em cujo território o crime foi praticado pode não se encontrar em condições de perseguir os infractores (em virtude, *v. g.*, de graves conflitos internos), ou pode mesmo não ter vontade de o fazer (porque apoia, implícita ou explicitamente, esses actos), pelo que o Estado Português deve munir-se dos instrumentos necessários à defesa própria dos seus interesses essenciais.

§ 38 As hipóteses tradicionalmente integrantes deste princípio têm a ver com a defesa de bens jurídicos que podem dizer-se nacionais (portugueses) segundo a sua **específica natureza**. Aqui é pois a *substância* — não necessariamente a *titularidade* — do bem jurídico que o torna em interesse nacional, por isso se falando hoje com propriedade, a respeito desta

([18]) Cf., a propósito, DIAS, Figueiredo / CAEIRO, Pedro, A Lei de Combate ao Terrorismo (L 52/2003, de 22-8), *RLJ 135*, 2005, p. 70 e ss.

vertente do princípio da defesa de interesses nacionais, de um princípio de protecção **real**. A lei tem, deste modo, de fazer uma *enumeração taxativa* dos tipos de factos relativamente aos quais vale o princípio em exame. A ela procede o art. 5.º-1/*a)*, indicando os arts. 221.º (burla informática), 262.º a 271.º (falsificações de moeda, de títulos de crédito e de valores selados), 308.º a 321.º (crimes contra a independência e a integridade nacionais e contra a capacidade e a defesa nacionais) e 325.º a 345.º (crimes contra a realização do Estado de direito e crimes eleitorais) ([19]). Investigar, em concreto, se todos estes crimes — e só eles — justificam a aplicação do princípio de protecção real em matéria de aplicação da lei penal no espaço é tarefa que só pode competir a um estudo minucioso dos tipos referidos. Assinale-se — embora seja óbvio — que, em um certo sentido, o princípio de protecção real *prefere* ao princípio da personalidade activa quando ambos sejam convocados no caso concreto, isto é, sempre que um dos crimes a que o princípio real se refere tenha sido praticado por um português: no sentido de que, em casos tais, não se torna necessária à aplicação da lei penal portuguesa a verificação dos requisitos de que o art. 5.º-1/*c)* e *d)* faz depender a entrada em função do princípio da nacionalidade.

§ 39 O princípio de defesa dos interesses nacionais surge hoje — de forma diferenciada — em uma outra vertente: naquela em que o carácter nacional (português) do bem jurídico provém não da sua íntima natureza e substância, mas da sua **titularidade**; o que vale por dizer, da circunstância de *a vítima do crime ser um português*. Fala-se então a propósito de **princípio de protecção pessoal** (ou **individual**). Este princípio coincide assim por inteiro com o princípio da personalidade passiva, que já foi estudado no § 20 e não precisa por isso, no presente contexto, de mais lata explicitação.

4. O princípio complementar da universalidade

§ 40 O princípio da universalidade ou da aplicação universal visa permitir a aplicação da lei penal portuguesa a factos cometidos no estrangeiro que atentam contra bens jurídicos carecidos de protecção internacional ou que, de todo o modo, o Estado português se obrigou internacionalmente a proteger. Por isso o princípio deve valer independentemente da *sedes delicti* e da nacionalidade do agente. Não se trata, como é claro,

([19]) Cf. agora, também, o art. 8.º-1/*a)* da L 52/2003, de 22-8 (Lei de Combate ao Terrorismo), e o art. 2.º-3 da L 100/2003, de 15-11.

de facultar a cada Estado a intervenção penal relativamente a todo e qualquer facto considerado crime pela sua lei interna; o que conduziria à existência de um *ius puniendi* estadual sem qualquer fronteira e fomentador por isso em larga medida de conflitos internacionais de carácter jurídico-penal. Do que se trata é antes — e só — do reconhecimento do **carácter supranacional de certos bens jurídicos** e que por conseguinte apelam para a sua protecção a nível mundial. Deste modo aponta Jescheck, com razão, como fundamentos do princípio, "a solidariedade do mundo cultural face ao delito" e a "luta contra a delinquência internacional perigosa" (20).

§ 41 Neste sentido vai logo o art. 5.º-1/*b)* — na redacção que lhe foi conferida pelo art. 2.º-1 da L 31/2004 —, ordenando a aplicação da lei penal portuguesa a **crimes que tutelam bens jurídicos carecidos de protecção internacional**: concretamente, aos crimes dos arts. 159.º (escravidão), 160.º (rapto), 169.º (tráfico de pessoas), 172.º (abuso sexual de crianças), 173.º (abuso sexual de menores dependentes), 176.º (lenocínio e tráfico de menores) e 237.º (aliciamento de forças armadas) (21). Submete todavia a aplicação da lei penal portuguesa nestas hipóteses a uma **dupla condição**: que o agente seja encontrado em Portugal; e que não possa ser extraditado. Tais limitações são compreensíveis, sendo só de suscitar a questão de saber, quanto à segunda, se ela vale apenas para o caso em que a extradição foi requerida, mas não pode ser *concedida*, ou ainda para o caso de a não concessão derivar de ela não ter sido *requerida*. A interpretação mais ampla parece ser imposta justamente pela teleologia específica do princípio da universalidade. De resto, a introdução da actual al. *e)* do art. 5.º-1 reforça este entendimento, porquanto o legislador — diversamente do que aqui sucedeu — fez questão de especificar que a competência da lei portuguesa no caso aí previsto depende da concreta existência de um pedido de extradição que não pode ser atendido (cf. infra, § 46) (22).

§ 42 O **Anteprojecto 2007** introduz algumas modificações neste normativo, passando a incluir no leque dos crimes aí previstos certos crimes contra o ambiente e assimilando completamente a impossibilidade de entrega (no âmbito do mandado de

(20) JESCHECK / WEIGEND, § 18, II, 5.

(21) Cf. agora, também, o art. 8.º-1/*b)* da L 52/2003, de 22-8 (Lei de Combate ao Terrorismo), e o art. 2.º-3 da L 100/2003, de 15-11.

(22) Sobre a extensão do conceito de extradição para efeitos de aplicação desta norma a outras formas de cooperação judiciária internacional, v. supra, § 29 e s.

detenção europeu ou outro instrumento internacional de cooperação) à impossibilidade de extradição. Além disso, a proposta al. *d)* do art. 5.º-1 alarga o princípio da universalidade aos crimes de ofensas corporais graves, coacção sexual e violação, sempre que a vítima for menor, parecendo ir **mais além do que é imposto** pelos instrumentos internacionais relativos à protecção dos menores, que se limitam a obrigar os Estados a estabelecer a sua jurisdição sobre crimes praticados no estrangeiro por nacionais seus, quando não possam, por essa razão, extraditá-los ([23]).

§ 43 Fonte do princípio pode também ser o **direito internacional convencional** a que Portugal se tenha obrigado. Nesse sentido dispõe o art. 5.º-2 que "a lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos cometidos fora do território nacional que o Estado português se tenha obrigado a julgar por tratado ou convenção internacional". Não há aqui quaisquer requisitos gerais de que dependa a aplicação do princípio; o que podem evidentemente é existir nos concretos tratados e convenções em que aquele se plasme. Casos exemplares de aplicação do princípio com esta fonte são os da luta internacional contra a pirataria aérea, o terrorismo, o tráfico de droga, a falsificação de moeda, etc.

5. O princípio complementar da administração supletiva da justiça penal

§ 44 Como se referiu supra, § 2, a revisão do CP de 1998, ao introduzir a norma actualmente constante do art. 5.º-1*/e)*, veio colmatar uma **lacuna** do sistema de aplicação da lei penal no espaço até aí existente. Com efeito, podia suceder — e efectivamente sucedeu — que um cidadão estrangeiro, tendo praticado um crime, normalmente grave, no estrangeiro, viesse buscar refúgio em Portugal, onde, por um lado, não podia ser julgado, dada a ausência de uma conexão relevante com a lei portuguesa, e de onde, por outro lado, não podia ser extraditado, dadas as proibições de extraditar em função da gravidade da consequência jurídica impostas pelo sistema nacional (supra, § 27 e s.). Esta lacuna, conjugada com o aumento exponencial da mobilidade das pessoas nos últimos anos, sobretudo den-

([23]) Cf. o art. 4.º-3, do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil, de 25-5-2000; o art. 6.º-3 da Decisão-quadro 2002/629/JAI, do Conselho, de 19-7-2002, relativa à luta contra o tráfico de seres humanos; o art. 8.º-3 da Decisão-quadro 2004/68/JAI, do Conselho, de 22-12-2003, relativa à luta contra a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil; e o art. 31.º-3 da Convenção do Conselho da Europa contra o Tráfico de Seres Humanos, de 16-5-2005.

tro da União Europeia, fazia Portugal incorrer no risco — como escrevemos — de se transformar num "valhacouto de criminosos estrangeiros".

§ 45 Ao princípio, contido em vários códigos estrangeiros (*v. g.*, no § 7 II 2 do CP alemão), que colmata uma tal lacuna, chama-se em regra, com propriedade, princípio da administração supletiva da justiça penal. Diferentemente do que sucede com todos os princípios anteriormente indicados, não se trata neste de *mais um* princípio de conexão do poder punitivo do Estado nacional com o crime cometido. Do que verdadeiramente se trata — e por isso se fala com particular razão de *supletividade na administração da justiça* — é de actuação do juiz nacional **em vez** ou **em lugar** do juiz estrangeiro (em princípio competente à luz do princípio da territorialidade) mas nem por isso deixando de aplicar a ordem jurídico-penal nacional (24).

§ 46 Indicados os seus fundamentos político-criminais, resta referir as **condições** dentro das quais, segundo o princípio da administração supletiva da justiça penal, a lei penal portuguesa é aplicável a factos cometidos por estrangeiros no estrangeiro. Isso sucederá desde que: *a)* o agente seja encontrado em Portugal, *b)* a sua extradição haja sido requerida e *c)* o facto constitua crime que admita a extradição e esta não possa ser concedida. Também aqui (cf. supra, § 30 e s.) se devendo entender que o conceito de extradição, para efeitos desta alínea, abarca, por interpretação extensiva (lícita), a **entrega** aos Tribunais Penais Internacionais e a que resulta de um mandado de detenção europeu nos termos da L 65/2003, de 23-8 (25). Nos raros casos em que um desses pedidos de entrega não deva ser satisfeito, e não se aplique nenhuma das conexões precedentes, a lei portuguesa é competente para conhecer dos factos em virtude da norma contida no art. 5.º-1/*e*).

III. Condições gerais de aplicação da lei penal portuguesa a factos cometidos no estrangeiro

§ 47 O carácter meramente complementar ou subsidiário dos princípios de aplicação *extraterritorial* da lei penal portuguesa revela-se exem-

(24) Exactamente, nestes termos, JESCHECK / WEIGEND, § 18, II, 6.

(25) Solução acolhida, aliás, pelo Anteprojecto 2007, no art. 5.º-1/*f*).

plarmente na circunstância de em todos estes casos a aplicação só ter lugar "quando o agente **não tiver sido julgado** no país da prática do facto ou **se houver subtraído ao cumprimento** total ou parcial da condenação" (art. 6.º-1). Trata-se aqui, antes de mais, de respeitar o princípio jurídico-constitucional *ne bis in idem*, segundo o qual "ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime" (CRP, art. 29.º-5); até porque uma tal garantia é considerada pela nossa Constituição como valendo para todas as pessoas e para todos os tribunais, que não apenas para os cidadãos portugueses ou para julgamentos levados a cabo por tribunais portugueses (diferentemente do que sucede, *v. g.*, na Alemanha). Mas trata-se também, como mais ainda se confirma com o que em seguida será exposto, de traduzir a ideia segundo a qual o critério da territorialidade deve, segundo a nossa constituição político-criminal, constituir efectivamente o princípio prioritário e todos os outros assumirem a veste de princípios meramente complementares, ou melhor ainda, nesta acepção, *supletivos*. Trata-se, em suma e só, de prevenir a impunidade que poderia resultar de *conflitos negativos de jurisdição*.

§ 48 Esta solução pode suscitar algumas dúvidas quanto ao seu **fundamento político-criminal** no que toca à sua aplicação aos casos em que intervenha o princípio da *defesa dos interesses nacionais* na sua vertente de protecção real. Pode dizer-se — e tem-se dito, e prescrito em muitas legislações — que não deve confiar-se a tribunais estrangeiros a apreciação de ofensas a interesses especificamente nacionais, *v. g.*, os de defesa do Estado nacional. Mas a validade deste argumento já tem sido posta em dúvida ([26]): porque atrás dele estaria uma inadmissível desconfiança de princípio perante sentenças de tribunais estrangeiros, a qual só pode prejudicar os esforços de incrementação da cooperação judiciária internacional em matéria penal; e porque era esta já a solução contida no CP de 1886 e não há notícia de que tenha dado lugar a lacunas intoleráveis na defesa de interesses especificamente portugueses. O que se compreenderia, porque uma de duas: ou os interesses nacionais em causa correspondem também a interesses dignos de protecção segundo a *lex loci* e deve então esperar-se que esta protecção seja suficiente para assegurar a defesa dos inte-

([26]) No sentido do que se segue, já, CORREIA, Eduardo, *Actas PG*, I, p. 93, SANTOS, Furtado dos, nota 1, p. 19 e ss., e DIAS, Figueiredo, nota 2, p. 134 e ss. Cf., também, a Resolução IV-2 do IX Congresso da A. I. D. P.: "... é conforme ao espírito da solidariedade internacional contar, em princípio, com o bom fundamento da justiça estrangeira".

resses nacionais; ou os interesses portugueses não são protegidos pela *lex loci*, mesmo indirectamente (e será o caso mais frequente, nomeadamente no que respeita aos interesses da segurança interior e exterior do Estado português) e o problema então nem sequer se suscita porquanto o agente não será julgado no país estrangeiro e a lei portuguesa torna-se plenamente aplicável.

§ 49 Para casos excepcionais em que, apesar do que fica dito, entrassem em conflito aberto a sentença proferida pelo tribunal estrangeiro e os interesses verdadeiramente essenciais do Estado português, pensou-se em que ficaria aberta a possibilidade de recurso à **cláusula de ordem pública** conhecida do direito internacional ([27]). Mas não parece que um tal recurso seja — sobretudo na falta de qualquer referência àquela cláusula no CP português — inteiramente compatível com as exigências do princípio da legalidade processual (princípio do juiz legal: CRP, art. 32.º-7).

§ 50 Prova definitiva do carácter subsidiário dos princípios de extraterritorialidade é que, nos termos do art. 6.º-2, o facto deva ser julgado pelos tribunais portugueses "**segundo a lei do país em que tiver sido praticado** sempre que esta seja **concretamente mais favorável** ao delinquente". Trata-se por isso verdadeiramente de *aplicação da lei penal estrangeira pelo tribunal português*. Solução esta que, se encontra o seu fundamento primário no princípio da aplicação do regime concretamente mais favorável (supra, 8.º Cap., § 41 e ss.), constitui em último termo uma decorrência da ideia segundo a qual a aplicabilidade da lei portuguesa é subsidiária. Há muito tempo já, de resto — bem antes ainda da entrada em vigor do CP de 1982 —, uma parte da doutrina portuguesa não escondia a sua simpatia pelo princípio, contido nos arts. 5.º e 6.º do CP suíço, de aplicação da lei estrangeira às hipóteses de extraterritorialidade sempre que aquela se revelasse concretamente mais favorável ao delinquente ([28]). Dois problemas no entanto costumam suscitar-se ainda neste contexto.

§ 51 O primeiro é o de saber se **certas categorias de crimes** não devem ser radicalmente **afastadas** do âmbito de aplicação do princípio. A lei portuguesa vigente, depois de muitas hesitações durante o seu período de gestação, acabou por se deixar convencer pelo bom fundamento da

([27]) AA. e locs. cits. na nota anterior.

([28]) Cf. CORREIA, Eduardo, *Lições 1949*, p. 166, e I, p. 165; SANTOS, Furtado dos, nota 1, *passim*; DIAS, Figueiredo, nota 2, p. 137 e ss.

ideia da exclusão, que estendeu a todos os crimes aos quais a lei portuguesa é aplicável em nome do princípio da **defesa dos interesses nacionais**. Nesse sentido dispõe o art. 6.º-3 que "o regime do número anterior — *sc.*, a aplicação da lei estrangeira pelo juiz nacional — não se aplica aos crimes previstos na alínea *a)* do n.º 1 do artigo 5.º". Este regime é estendido pelo art. 6.º-3 do Anteprojecto 2007 aos crimes praticados no estrangeiro que são da competência da lei portuguesa nos termos do actual art. 5.º-1/*d)* (5.º-1/*b)*, na numeração proposta), solução que é coerente com a dispensa do princípio da dupla incriminação visada por essa norma ([29]).

§ 52 O segundo problema é o de saber como devem resolver-se concretamente as dificuldades práticas que possam resultar da aplicação da lei penal estrangeira no que respeita à **assimilação das sanções previstas por esta**. O problema não possui acuidade entre nós. É verdade que o sistema português não admite nem a *pena de morte*, nem a pena de *prisão perpétua*; mas precisamente nestes casos a lei estrangeira não se aplicará por não surgir como *lex melior*. É nos limites inferiores da escala penal que o problema se poderia suscitar; mas nessa zona o CP português consagra uma larguíssima panóplia — mais larga do que a da maioria dos códigos estrangeiros — de penas substitutivas da pena de prisão, de modo que também aí o problema da assimilação não suscitará dificuldades especiais. Em todo o caso, ao menos no plano teórico, o problema persiste. Já se preconizou que para o resolver o CP contivesse uma *tábua de conversão* completa das penas estrangeiras em penas nacionais; ou em alternativa (porque aquela solução é muito dificilmente praticável) que contivesse uma **cláusula geral de conversão** da pena estrangeira naquela que dela mais se aproximasse no sistema nacional. Foi esta última via a seguida pela 2.ª parte do art. 6.º-2, nos termos da qual "a pena [estrangeira] aplicável é convertida naquela que lhe corresponder no sistema português ou, não havendo correspondência, naquela que a lei portuguesa previr para o facto".

([29]) Sobre as reservas que esta conexão de competência suscita, cf., de novo, *supra*, § 35.

PARTE II

A DOUTRINA GERAL DO CRIME

TÍTULO I

A CONSTRUÇÃO DA DOUTRINA DO CRIME (DO FACTO PUNÍVEL)

10.º CAPÍTULO

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

I. Sentido, método e estrutura da conceitualização do facto punível

§ 1 Princípio hoje indiscutivelmente aceite em matéria de dogmática jurídico-penal e de construção do conceito de crime é o de que todo o direito penal é **direito penal do facto**, não *direito penal do agente*. E num duplo sentido (1): no de que toda a regulamentação jurídico-penal liga a punibilidade a tipos de factos singulares e à sua natureza, não a tipos de agentes e às características da sua personalidade; e também no de que as sanções aplicadas ao agente constituem consequências daqueles factos singulares e neles se fundamentam, não são formas de reacção contra uma certa personalidade ou tipo de personalidade. A esta dupla conclusão vinculam as posições acima tomadas em matéria de legitimação e de função do direito penal num Estado de Direito democrático (supra, 4.º, 5.º e 6.º Caps.). Nesta acepção pode e deve logo ser dito que a construção dogmática do conceito de crime é afinal, em última análise, a construção do conceito de **facto punível**.

§ 2 Nos anos 30 do séc. XX a proposição apresentada perdeu alguma da sua clareza e chegou a ser obnubilada (se não mesmo subvertida) por certas doutrinas que mereceram depois uma exploração política totalitária, sobretudo na Alemanha e na Itália. Assim se chegou a propor que os tipos de factos que constituem a matéria do

(1) Fundamentalmente como se segue, o nosso *Liberdade*, p. 161 e s.

direito penal fossem substituídos — ou, quando menos, integrados — por **tipos de agentes**, aos quais deveria passar a dirigir-se a criminalização e a sanção (2). Não deveriam ser punidos o homicídio, o assassinato, o furto, a burla, antes sim "o homicida", "o assassino", "o ladrão" ou "o burlão". Mas já se discutia depois se estes tipos de agentes deveriam ser construídos numa base primariamente *naturalista*, sobretudo em função da associalidade característica da personalidade do agente: o chamado *tipo criminológico de agente*; ou antes numa base prioritariamente normativa, relacionada com os sentidos e as finalidades sociais respirados ou almejados pela ordem jurídico-penal: o chamado *tipo normativo de agente* (3). Os frutos desta orientação, nomeadamente a exploração que dela foi feita pela legislação penal nacional-socialista alemã e fascista italiana imediatamente antes e durante a II Grande Guerra, encarregaram-se — melhor que quaisquer lucubrações teóricas — de mostrar a sua inadmissibilidade e de lhe pôr um fim definitivo. Sem prejuízo de dever dizer-se (o que muitas vezes se esquece) que a teoria do tipo normativo de agente passou, a partir de certo momento, a tentar *limitar*, antes que fundamentar, os resultados terroristas a que conduzia a aplicação da referida legislação.

§ 3 O que se disse da teoria do tipo normativo de agente pode repetir-se para toda a concepção coeva **da culpa referida à personalidade**, seja sob a forma da "*culpa na condução da vida*" (4), da "*culpa na decisão da vida*" (5) ou da "*culpa na formação da personalidade*" (6). Qualquer destas concepções é inaceitável se por seu intermédio se pretender ligar a punibilidade, de forma directa, a uma certa personalidade: seja porque o agente conduziu a sua vida em conflito com o dever-ser jurídico-penal, seja porque decidiu em certo momento tornar-se um criminoso, seja porque ao longo da vida se não preparou para respeitar os comandos do direito penal; se, numa palavra, elas se fizerem radicar no quadro de um *direito penal do agente*. Então se deparará, por qualquer uma destas vias, com um alargamento das malhas da punibilidade absolutamente incompatível com a regra do Estado de Direito democrático. Mas já qualquer delas terá muito a oferecer à dogmática jurídico-penal se se contiverem no quadro de um direito penal do facto e constituírem apenas instrumentos operató-

---

(2) Fundamental, WOLF, *Vom Wesen des Täters*, 1932.

(3) Pioneiro, DAHM, *Der Tätertyp im Strafrecht*, 1940. Cf., depois, CORREIA, Eduardo, A teoria do tipo normativo de agente, *BFD XIX*, 1943, p. 11.

(4) MEZGER, Die Straftat als Ganzes, *ZStW*, 1938, p. 688. Cf., também, FERREIRA, Cavaleiro de, *A Personalidade do Delinquente na Repressão e na Prevenção*, 1943, p. 170 e ss.

(5) BOCKELMANN, *Studien zum Täterstrafrecht*, I, 1940, p. 145 e ss., aproximando-se de um pensamento de PLATÃO, *Republica*, X, 617 d) e), 618 b) e 620 d); e no plano de Ricardo III, "I am determined to prove a villain": SHAKESPEARE, *King Richard the Third*, Act I, Scene I.

(6) CORREIA, Eduardo, A doutrina da culpa na formação da personalidade, *RDES I*, 1945, pp. 6-24; cf., por último, CORREIA, Eduardo, *ProjPG*, p. 23 e ss., e Der Einfluss Franz von Liszt auf die portugiesische Strafrechtsreform, *ZStW 81*, 1969, p. 741 e ss. (versão portuguesa no *BFD XLVI*, 1971).

rios não de extensão da punibilidade para além das fronteiras do facto, mas de fundamentação e de delimitação da culpa *pelo facto* em direito penal (7).

§ 4 Em suma, pois — mesmo em matéria de medidas de segurança criminais, como no 5.º Cap., §§ 7 e ss., 14 e s., foi sublinhado —, o *facto* e só ele constitui, na acepção agora em causa, o fundamento e o limite dogmáticos do conceito geral de crime; de sorte que perguntar por este é perguntar, do mesmo passo, pelo conceito de *facto* ou, se preferirmos, de *facto punível* ou de *facto criminoso*. Ora, a tentativa de apreensão dogmática deste conceito jurídico-penal do "facto" constitui uma das mais ingentes tarefas a que até hoje se dedicou a dogmática jurídica. E essa tentativa ocorreu quase sempre, durante os dois últimos séculos, na base de um procedimento metódico **categorial-classificatório**, através do qual se toma como base um conceito geral — no caso, o conceito de **acção** — susceptível, pela sua larga extensão e pela sua reduzida compreensão, de servir de pedra angular de todas as suas predicações ulteriores. O que não significa desagregar ou quebrar em pedaços diversos e autónomos o conceito de crime, mas alcançar uma sua *compreensão unitária* através da consideração sucessiva dos seus elementos constitutivos, através de uma sua compreensão lógico-sistemática, a permitir que uma realidade unitária seja contemplada a partir de pontos de vista diversos. Assim se chega à compreensão do facto — e portanto de todo e qualquer crime — como conjunto de cinco elementos: como acção, que é depois qualificada (*concepção quadripartida*) como típica, ilícita, culposa e punível. Como quer que estes elementos devam mutuamente compreender-se e delimitar-se (e eventualmente, até um certo ponto, fundir-se), *acção*, *tipicidade*, *ilicitude*, *culpa* e *punibilidade* são os elementos constitutivos do conceito de facto ou do conceito de crime e do respectivo sistema dogmático-sistemático.

§ 5 Este procedimento metódico categorial-classificatório de apreensão do conceito de crime foi posto em causa, nos anos 30 do séc. XX, pela chamada **escola de Kiel**. Reagindo contra os supostos filosóficos neokantianos em que assentava a concepção então dominante, para se louvar antes numa certa interpretação de alguns pontos da filosofia de Hegel, a escola de Kiel assestou baterias contra a "irrealidade" a que conduziria a desagregação de um conceito unitário, como é o conceito de crime, em

(7) Cf. os nossos *O Problema*, § 10, III, 2, e *Liberdade*, § 13, C 3. Uma interessante leitura da teoria dos tipos de autor à luz de uma certa concepção da adequação social (sobre esta, infra, 11.º Cap., § 13 e ss.) em FARIA, Paula Ribeiro de, *A Adequação Social da Conduta no Direito Penal ou o Valor dos Sentidos Sociais na Interpretação da Lei Penal*, 2005, p. 178 e ss.

elementos constitutivos diversos; e pretendeu substituir-lhe um **pensamento ordinalista concreto** (8) capaz de respeitar aquele conceito como unidade, através da sua compreensão global intuitiva (*Ganzheitsbetrachtung*). Um tal pensamento não podia deixar de ser aproveitado pelos regimes políticos totalitários então vigentes na Europa e serviu — porventura contra os seus propósitos — para tentar justificar as atrocidades penais cometidas, tendo chegado a ser arvorado como o pensamento próprio do chamado *direito penal nacional-socialista* (9). Por tudo isso um tal pensamento — que aliás não logrou nunca inserir-se numa concepção dogmático-sistemática minimamente coerente e estabilizada — desacreditou-se a um ponto tal que não voltou, até hoje, a ser editado e a ganhar expressão na ciência do direito penal (10).

II. Sobre a evolução histórica da doutrina geral do facto punível

§ 6 A construção do conceito de facto punível, tal como hoje se apresenta, é filha de uma experiência de tal forma multímoda e plurifacetada que se impõe oferecer, a quem dela se aproxima pela primeira vez, **modelos de compreensão**, tanto quanto possível fáceis e manejáveis, das querelas actuais; mas que, na sua simplicidade, correspondam todavia, no essencial, à vivência e à evolução histórico-dogmáticas do último século. Correspondência que não poderá deixar de entrar em linha de conta com as mundividências culturais e filosóficas que estiveram na base das concepções principais e decisivamente as influenciaram. Com este propósito distinguir-se-ão em seguida três grandes períodos ou fases de evolução da doutrina do facto punível: o da concepção *clássica*, de notória influência naturalista e juspositivista; o da concepção *neoclássica*, cujos fundamentos se devem procurar no normativismo jurídico de raiz neokantiana; e o da concepção *finalista*, orientada por uma concepção ôntica ou regional-ontológica do direito, ligada à fenomenologia e a uma filosofia material dos valo-

---

(8) A que Welzel, na primeira fase do seu pensamento, em alguma medida chegou a ligar-se: WELZEL, *Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht*, 1935. Com uma aproximação, nos resultados, a este pensamento parece deparar-se hoje, entre nós, em MENDES, Sousa, *O Facto Intrinsecamente Culposo como Condição Necessária da Imputação da Pena*, 2005, sugerindo a sua ligação ao conceito da *imputatio* de Pufendorf.

(9) Cf., sobretudo, DAHM, Der Methodenstreit in der heutigen Strafrechtswissenschaft, *ZStW 57*, 1938, p. 225; DAHM / SCHAFFSTEIN, *Liberales oder autoritäres Strafrecht?*, 1933; e SCHAFFSTEIN, Nazional-sozialistisches Strafrecht, *ZStW 53*, 1934, p. 603, e Rechtswidrigkeit und Schuld im Aufbau des neuen Strafrechtssystems, *ZStW 57*, 1938, p. 295. Criticamente, logo, SCHWINGE / ZIMMERL, *Wesenschau und konkretes Ordnungsdenken*, 1937.

(10) Criticamente, na doutrina portuguesa, logo também, CORREIA, Eduardo, *Unidade*, p. 92 e ss.

res. Devendo todavia desde o primeiro momento fazer-se uma prevenção: a de que cada uma das concepções referidas pretendeu, mais que substituir, *superar* a anterior. Como exactamente sublinha Jescheck, "nenhuma das teorias conseguiu afastar completamente as outras, continuando ainda hoje vivos, uns junto aos outros, pensamentos procedentes dos três sistemas" ([11]).

1. A concepção "clássica" (positivista-naturalista)

1.1. Exposição sumária

§ 7 A concepção chamada "clássica" do facto punível ([12]) assenta numa visão do jurídico decisivamente influenciada, em perspectiva político-criminal, pela então dita *Escola moderna* e, de forma geral, pelo naturalismo positivista que caracterizou o **monismo científico** próprio de todo o pensamento da segunda metade do séc. XIX. Também o direito teria como ideal a exactidão científica própria das ciências da natureza e a ele deveria incondicionalmente submeter-se; de sorte que, do mesmo modo, o sistema do facto punível haveria de ser apenas constituído por realidades mensuráveis e empiricamente comprováveis, pertencessem elas à facticidade (objectiva) do mundo exterior ou antes a processos psíquicos internos (subjectivos). Com o que ficava próxima uma **bipartição** do conceito de crime que agrupasse os seus elementos constitutivos na vertente objectiva (a acção típica e ilícita) e na vertente subjectiva (a acção culposa); concepção esta ainda hoje muito viva, por exemplo, na doutrina francesa dominante, que se limita em regra a distinguir no conceito de crime *o elemento material* e *o elemento moral* da infracção ([13]).

([11]) JESCHECK / WEIGEND, § 22, *in principio*. Uma panorâmica das diferentes "fases de formação do sistema do direito penal" é oferecida por SCHÜNEMANN, Einführung in das strafrechtliche Systemdenken, *in*: Schünemann (org.), *Grundfragen der modernen Strafrechtssysteme*, 1984, p. 18 e ss. (tradução espanhola de Silva Sánchez: *El sistema moderno de derecho penal: cuestiones fundamentales*, 1991).

([12]) E para a qual contribuíram decisivamente autores como BERNER, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, 1857, v. LISZT, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, [1]1881, e BELING, *Die Lehre vom Verbrechen*, 1906.

([13]) Seguindo nesta parte a lição de Carrara: cf. MERLE / VITU, *Traité de droit criminel*, I, [6]1989, n.º 357, e, de modo só formalmente diferente, PRADEL, pp. 362 e ss. e 405 e ss., distinguindo a *infracção* (comportamento, prejuízo, causalidade) e o *delinquente* ou a "responsabilidade penal" (delinquente, vítima). Sobre toda a questão, HÜNERFELD, Zum Stand der deuts-

§ 8 De acordo com o que fica dito, esta concepção via na *acção* o *movimento corporal determinante de uma modificação do mundo exterior, ligada causalmente à vontade do agente*. Acção que se tornaria em acção *típica* sempre que fosse lógico-formalmente subsumível num tipo legal de crime, isto é, numa descrição puramente externo-objectiva da realização da acção, completamente estranha a valores e a sentidos. Acção típica, por seu turno, que se tornaria em *ilícita* se no caso não interviesse uma causa de justificação, é dizer, uma situação (legítima defesa, estado de necessidade, obediência devida, etc.) que, a título excepcional, tornasse a acção típica em acção lícita, aceite ou permitida pelo direito; e que assim determinasse em definitivo a contrariedade da acção ao ordenamento jurídico. E com isto ficaria perfeita a **vertente objectiva** do facto.

§ 9 Quanto à **vertente subjectiva** do facto, ela concentrar-se-ia na categoria da culpa. A acção típica e ilícita tornar-se-ia em acção *culposa* sempre que fosse possível comprovar a existência, entre o agente (imputável, *sc.*, capaz de culpa) e o seu facto objectivo, de uma ligação psicológica — daí esta doutrina ter ficado conhecida como *concepção psicológica da culpa* — susceptível de legitimar a imputação do facto ao agente a título de dolo (conhecimento e vontade de realização do facto) ou de negligência (deficiente tensão de vontade impeditiva de prever correctamente a realização do facto). E com isto se teria logrado a apreensão perfeita e completa do conceito de crime.

1.2. Apreciação crítica

§ 10 A partir de certo momento compreendeu-se que o sistema naturalista-positivista do crime, assim delineado, não podia prevalecer. Logo o conceito de **acção**, ao exigir um movimento corpóreo e, de todo o modo, uma modificação do mundo exterior, restringia de forma inadmissível a base de toda a construção. O que conduziria a afirmações tão estranhas à realidade da vida como a de que a acção, no crime de injúria, consistiria na emissão de ondas sonoras dirigidas ao aparelho auditivo do receptor; ou que, na omissão, o que relevaria como acção seria a acção precedente (a mãe seria punida não por ter deixado morrer o seu bebé à fome, mas por, em vez de

---

chen Verbrechenslehre aus der Sicht einer gemeinrechtlichen Tradition in Europa, *ZStW 93*, 1981, p. 993.

o amamentar, ter ido passar um fim de semana ao campo). Reduzir por outro lado a **tipicidade** a uma operação lógico-formal de subsunção, esquecendo as unidades de sentido social que vivem nos tipos, levaria a igualar o acto do cirurgião que salva a vida do paciente com o do faquista que, em *vendetta*, esventra a sua vítima. Como reduzir o juízo de **ilicitude** à ausência de uma causa de justificação do facto típico (de um *obstáculo à ilicitude* ou de uma *causa de exclusão da ilicitude*) constituiria uma compreensão paupérrima e, em definitivo, inexacta do que vai implicado no juízo de contrariedade à ordem jurídica. Finalmente, a concepção psicológica da **culpa** esqueceria que também o inimputável — por definição, *incapaz de culpa* — pode agir com dolo ou negligência; que na negligência, ao menos na inconsciente, onde não há previsão do resultado, não existe qualquer relação psicológica comprovável entre o agente e o facto, antes *ausência* dela (o faroleiro que se deixa adormecer e não dá o sinal devido); e ainda que, independentemente da verificação do dolo ou da negligência, circunstâncias existem que devem excluir a culpa, nomeadamente, certas situações de falta de consciência do ilícito ou de inexigibilidade de outro comportamento.

§ 11 No fundo, a concepção da escola clássica foi abandonada no preciso momento em que se pôde compreender que não mais eram defensáveis os **fundamentos ideológicos e filosóficos** sobre que assentava ([14]). É verdade que a ela coube o mérito indeclinável de, pela primeira vez, ter erigido todo um sistema do crime assente numa rigorosa metódica categorial-classificatória, dotado de uma notabilíssima clareza e simplicidade (com a distinção entre as vertentes objectiva e subjectiva do facto punível) e, por sobre tudo isto, baseado numa salutar preocupação de segurança e de certeza, congenitamente requerida pela ideia do Estado de Direito e por uma realização prática do princípio da legalidade. Mas é também verdade que as suas **insuficiências** não mais podiam ser escondidas: o direito em geral — e o direito penal de forma particular — não participa do *monismo metodológico* (e *ideológico*) das ciências naturais, trata com realidades que excedem a *experiência psicofísica* e se não inscrevem de modo exclusivo no mundo do *ser*; como, por outro lado, o pensamento jurídico não se deixa comandar por uma *metodologia de cariz positivista* nem se esgota em operações de pura *lógica formal*. Logo que tudo isto se compreendeu,

([14]) Essenciais, neste contexto, as obras de WELZEL, nota 8, e de CORREIA, Eduardo, *Unidade*, p. 69 e ss.

o sistema clássico do conceito de facto punível estava maduro para ser superado por uma nova concepção.

2. A concepção neoclássica (normativista)

2.1. Exposição sumária

§ 12 O chamado sistema neoclássico funda-se essencialmente na **filosofia dos valores de origem neokantiana**, tal como ela foi desenvolvida, nas primeiras décadas do séc. XX, pela chamada Escola do sudoeste alemão ou Escola de Baden (Windelband, Rickert, Lask) ([15]). Ela pretende retirar o direito do mundo naturalista do "ser", para, como "ciência do espírito", o situar numa *zona intermediária* entre aquele mundo e o do puro "dever-ser", mais rigorosamente, num campo referencial, no mundo das referências da realidade aos valores, do ser ao dever-ser e, logo por aí, no mundo da *axiologia* e dos *sentidos*. Há por isso, no que toca ao sistema do crime, que preencher os conceitos com estas referências, nomeadamente passando a caracterizar o ilícito como "danosidade social" e a culpa como "censurabilidade" do agente por ter agido como agiu, quando podia ter agido de forma diferente. Na Alemanha, nome cimeiro desta orientação jurídico-penal foi o de Mezger (1883-1962) ([16]). Em Itália, o de Delitala (1902-1972) ([17]). Em Portugal foi sobretudo deste húmus que sempre se nutriu o pensamento de Eduardo Correia (1916-1991).

§ 13 Não pode dizer-se que esta nova concepção se tenha traduzido em um "novo" conceito de **acção** relativamente ao sustentado pela concepção clássica. Descontados os exageros naturalistas, agora substituídos pela ideia da "relevância social", a acção continuou a ser concebida, no essencial, como comportamento humano *causalmente* determinante de uma modificação do mundo exterior ligada à vontade do agente. Por isso os finalistas puderam qualificar globalmente as concepções da acção das orientações clássica e neoclássica como concepções *causais* de acção. Mas já em matéria de **tipicidade** se considerava agora ser indispensável vê-la não apenas

---

([15]) Fundamentais, também neste contexto, as obras referidas na nota anterior.

([16]) MEZGER, pela primeira vez em Die subjektiven Unrechtselemente, *GS* 89, 1924, p. 207 e ss.; cf., depois, *Strafrecht*, ³1931.

([17]) DELITALA, *Il "fatto" nella teoria generale del reato*, 1930.

como uma descrição formal-externa de comportamentos, mas materialmente como uma *unidade de sentido socialmente danoso*, como *comportamento lesivo de bens juridicamente protegidos*; para a qual relevavam não só elementos objectivos, mas, em muitos casos necessariamente, igualmente elementos subjectivos. De tal modo que também o **ilícito** se apresentava em diversas hipóteses como um conglomerado de elementos objectivos e subjectivos, indispensável para a partir dele se concluir pela contrariedade material do facto à ordem jurídica (exemplo paradigmático: *ilícita* no sentido do tipo do furto não é toda a subtracção de coisa móvel alheia, mas só aquela que ocorrer "com ilegítima *intenção* de apropriação", art. 203.º-1). Quanto à **culpa**, agora traduzida num juízo de *censura* — a chamada *concepção normativa da culpa* —, ela enriquecia-se e diversificava-se nos seus elementos constitutivos (nem todos, de resto, tendo de assumir natureza subjectiva, antes podendo também englobar elementos objectivos): a imputabilidade, como capacidade do agente de avaliar a ilicitude do facto e de se determinar por essa avaliação; o dolo ou a negligência como formas ou graus de culpa; a exigibilidade de um comportamento adequado ao direito.

2.2. Apreciação crítica

§ 14 Muitas das aquisições da concepção neoclássica do crime persistem hoje como irrenunciáveis, enquanto de outras se não pode dizer terem de todo desaparecido da discussão actual. É certo que os seus **fundamentos ideológicos e filosóficos** devem considerar-se em larga medida ultrapassados: sobretudo na parte em que a essência do direito se não considera mais compatível com a profunda cisão entre o mundo do ser e o mundo do dever-ser que as correntes neokantianas ainda supunham; e em que se reconhece que uma tal cisão, pensada até ao fim, se torna susceptível de reeditar muitas das teses do naturalismo positivista que com ela se tinha procurado ultrapassar. É, no entanto, no que respeita directamente à construção do sistema do facto punível que, a partir da erupção da "nova imagem do sistema jurídico-penal" enunciada por Welzel em inúmeros estudos ([18]), as críticas mais se fizeram ouvir e deram pasto a uma controvérsia que ainda hoje se não calou de todo.

([18]) Desde o seu trabalho citado na nota 8 até aos seus Studien zum System des Strafrechts, *ZStW 58*, 1939, p. 491, *Um die finale Handlungslehre*, 1949, e, sobretudo, ao seu *Das neue Bild des Strafrechtssystems*, [4]1961 (tradução espanhola de Cerezo Mir: *El nuevo sistema del derecho*

§ 15 A crítica dirigiu-se sobretudo ao **conceito mecânico-causalista da acção** de que a teoria neoclássica continuava a partir, esquecendo não ser aí que reside a essência do actuar humano. De tal modo que praticamente todos os erros na construção posterior do sistema teriam ali a sua origem radical: o **ilícito** continuaria, apesar de nele se terem introduzido já elementos subjectivos, a constituir uma entidade fundamentalmente objectiva, que esqueceria ou minimizaria a sua carga *ético-pessoal* e não poderia servir por isso para correctamente caracterizar a contrariedade da acção à ordem jurídica; enquanto, por seu turno, a **culpa**, apesar de se dizer concebida como *juízo* de censura, continuava a constituir um conglomerado heterogéneo de objecto da valoração e de valoração do objecto, submetendo ao mesmo denominador características que, como a imputabilidade e a exigibilidade, são na verdade elementos de um puro juízo, e características que, como o dolo e a negligência, são elementos do substrato que deve ser valorado como censurável. Toda esta crítica será mais rigorosamente compreendida através do estudo da orientação que falta ainda considerar.

3. A concepção finalista (ôntico-fenomenológica)

3.1. Exposição sumária

§ 16 Após a tragédia da II Grande Guerra ficou claro que o normativismo das orientações jurídicas de raiz neokantiana não oferecia garantia bastante de *justiça* dos conteúdos das normas validamente editadas, mesmo que estas obedecessem ao formalismo democraticamente imposto. É então que se assiste à substituição definitiva do Estado de Direito formal pelo Estado de Direito *material* (supra, 3.º Cap., § 14). Ficava por isso próxima a tentativa de limitar toda a normatividade, numa via fenomenológica e "ontológica" (*rectior*, "ôntica"), por **leis estruturais determinadas do "ser"** — pela "*natureza das coisas*" —, as quais, uma vez estabelecidas, serviriam de fundamento vinculante às ciências do homem e, por isso, também ao direito.

§ 17 A Hans Welzel (1904-1977) pertence o mérito de ter transposto para o direito penal, com uma clareza inigualável e uma lógica sem des-

---

penal, 1964). Todo o pensamento deste A. sobre a matéria vem a cristalizar-se no seu *Das deutsche Strafrecht*, [1]1947, [11]1969.

falecimento, todo este património ideológico sobre o Jurídico e o seu método ([19]). Decisivo seria determinar o "ser", a "natureza da coisa", que se escondia sob o conceito fundamental de toda a construção do crime, é dizer, sob o conceito de **acção**: um conceito pré-jurídico, como agora se compreende, que teria de ser ontologicamente (onticamente) determinado e que, uma vez aceite pelo legislador, não poderia por ele ser reconformado, antes teria de ser aceite não só em si mesmo, como em todas as suas implicações. Dele resultaria pois o *inteiro sistema* do facto e do crime. A verdadeira "essência" da acção humana foi encontrada por Welzel na verificação de que o homem dirige finalisticamente os processos causais naturais em direcção a *fins* mentalmente antecipados, escolhendo para o efeito os meios correspondentes: toda a acção humana é assim **supradeterminação final de um processo causal** ([20]). Eis a "natureza ontológica" da acção, a partir da qual todo o sistema do facto punível haveria de ser construído. E ao pôr este princípio que pretendia imutável, sem tempo nem espaço, Welzel determinou os caminhos de toda a dogmática penal durante as décadas que se seguiram ao fim da II Grande Guerra; até um ponto de não poder neste momento afirmar-se que todos os seus ecos se tenham extinguido já. Bem pelo contrário, deve ser dito que, por mais cerrada crítica que possa merecer a escola finalista, ela conduziu a aquisições científicas às quais ainda hoje se não deve renunciar.

§ 18 A primeira — e porventura a mais importante — consequência derivada daquela concepção da acção é a de que o *dolo* (que no parecer tanto da teoria clássica, como da neoclássica, constituía um elemento da culpa) passa agora a conformar um elemento essencial da **tipicidade**. Não seria bastante dizer, como afirmava a teoria neoclássica, que o tipo *pode* em certos casos conter elementos subjectivos, ao lado do seu núcleo essencial constituído por elementos objectivos. Preciso seria afirmar que o tipo é *sempre* constituído por uma vertente objectiva (os elementos descritivos do agente, da conduta e do seu circunstancialismo) *e* por uma vertente subjectiva: o dolo ou eventualmente a negligência. Só da conjugação destas duas vertentes podendo resultar o juízo de contrariedade da acção à ordem jurídica, é dizer, o juízo de **ilicitude** (esta também não *causal*, mas

([19]) Sem prejuízo das sugestões que para a construção de um tal sistema se encontravam já em obras como as de v. WEBER, *Zum Aufbau des Strafrechtssystems*, 1935, e de DOHNA, *Der Aufbau der Verbrechenslehre*, 1936.

([20]) Essenciais para a construção as duas últimas obras de WELZEL citadas na nota 18.

pessoal). Desta forma se substitui, às anteriores concepções causais-objectivas, uma *concepção pessoal-final do ilícito*.

§ 19 Só assim também se atingiria uma verdadeira concepção *normativa* da **culpa**, como havia sido intenção (todavia não lograda, na opinião do finalismo) da orientação neoclássica. O erro desta teria residido em continuar a juntar na categoria da culpa a *valoração* (o *juízo* de culpa, de censura) com o *objecto da valoração* (o dolo e a negligência). Extraindo este objecto da valoração da culpa e situando-o no tipo de ilícito, estava cumprida a condição necessária para "reduzir" a culpa àquilo que verdadeiramente ela deveria ser: um "*puro* juízo de (des)valor", um autêntico *juízo de censura*. Juízo de censura do qual participariam os elementos da imputabilidade, da consciência (ao menos *potencial*) do ilícito e da exigibilidade de outro comportamento.

3.2. Apreciação crítica

§ 20 Independentemente dos supostos ideológicos e filosóficos de que se nutre a escola finalista, a **postura metodológica** que daí se pensa resultar não pode merecer aceitação. Sobre isto já se disse o suficiente (supra, 3.º Cap., § 15 e ss.), tornando-se aqui desnecessária maior explanação. O pretenso *ontologismo* que estaria na base do sistema — e que faria dele um sistema imutável, válido para todos os tempos e lugares — acabou por desembocar no mais refinado e inflexível *conceitualismo*, face ao qual pouco resta para as opções jurídico-políticas (e, no que aqui interessa, político-criminais) do legislador e para a actividade concretizadora do intérprete e aplicador: tudo residiria afinal e só em determinar as *estruturas lógico-materiais* ínsitas nos conceitos usados pelo legislador, e a partir delas *deduzir* a regulamentação ou a solução aplicáveis ao caso. O que não era afinal coisa muito diferente de repetir os erros — denunciados pelo próprio Welzel, num poderoso estudo filosófico sobre o direito natural e a justiça material ([21]) — do velho direito natural clássico, ao preencher os conceitos do direito positivo com os conteúdos considerados normativamente mais correctos, para em seguida os deduzir do corpo do direito natural e os apresentar assim como vinculantes e livres de discussão.

([21]) WELZEL, *Naturrecht und materiale Gerechtigkeit*, [4]1962 (tradução espanhola de F. González Vicén: *Derecho Natural e Justicia material*, 1964).

§ 21 É possível afirmar, por outro lado, que a determinação finalista do conceito de **acção** é hoje em geral considerada como radicando num falso ontologismo (a ciência biológica [22]) sustenta que também os animais, ou alguns animais, antecipam fins e escolhem os meios para os alcançar com a sua acção!); e, do ponto de vista normativo, como insusceptível de oferecer uma base unitária a todo o actuar humano que releva para o direito penal (infra, § 32 e s.). De tudo resultando que — para muitos residindo aqui, deverá acrescentar-se, o argumento decisivo [23] — a supradeterminação final de um processo causal é em fim de contas tão estranha a sentidos e a valores como o conceito causal de acção que a concepção finalista pretendeu definitivamente ultrapassar.

§ 22 Já no que respeita à concepção do **ilícito pessoal**, as aquisições da doutrina finalista apresentam-se ainda hoje cheias de valor e mesmo reforçadas por toda a discussão científico-dogmática posterior que suscitaram. É exacto que fora da sua realização por dolo ou por negligência o facto não pode dizer-se *contrário à ordem jurídica* e por conseguinte *ilícito*. Como nem sequer se pode dizer que preencha materialmente um tipo de crime no seu aspecto substancial, enquanto unidade de sentido social juridicamente desvaliosa, da mesma forma que isso se não pode dizer de um facto natural — uma seca, uma inundação, um terramoto —, ou do facto de um animal, ou de qualquer processo humano imprevisível ou incontrolável. Todo o ilícito é por conseguinte ilícito pessoal e dele fazem parte o dolo, como representação e vontade de realização de um facto, e a negligência, como violação do cuidado objectivamente imposto.

§ 23 Diferentemente, a doutrina finalista da **culpa** dá campo a amplo e fundado criticismo. A afirmação de que a culpa é mero juízo de (des)valor, expurgada de todo o objecto de valoração e reduzida à pura valoração do objecto, não é compatível com a *função político-criminal* que o princípio da culpa deve exercer no sistema. Uma tal função (limitadora, como já por várias vezes ficou acentuado) fica reduzida a muito pouco se a culpa se traduzir, como com razão foi criticado a Welzel, num "puro juízo existente na cabeça do juiz" e a sua materialidade for imputada a

---

[22] Cf., por outros, PORTMANN, *Zoologie und das neue Bild des Menschen*, 1956.

[23] Assim, CORREIA, Eduardo, I, p. 213. Cf. a crítica ainda hoje fundamental de ENGISCH, Zur "Natur der Sache" im Strafrecht, *Eb. Schmidt-FS*, 1961, p. 90 e ss. Na doutrina brasileira, REALE JR., *Teoria do Delito*, 1998, p. 43 e ss.

outras categorias do sistema. Se o princípio da culpa é um princípio político-criminal e dogmático verdadeiramente essencial do sistema penal; e se as sanções penais para o mesmo tipo de crime são distinguidas primordialmente em função do dolo e da negligência — então o dolo e a negligência têm de ter significado (pelo menos *também*) como graus, formas ou tipos de culpa, em todo o caso como *matéria* de culpa ([24]). E esta verificação implica, só por si, uma profunda revisão de todo o sistema finalista.

III. Fundamentos de uma construção teleológico-funcional e racional do conceito de facto punível

1. Preliminares

§ 24 A generalidade dos tratamentos da doutrina geral do facto punível pode, ainda hoje, transmitir a impressão de que eles se não afastam, de forma sensível, da tentativa de "combinar", sob variadas formas e em diversa medida, aquisições recebidas do sistema neoclássico, que se considera continuarem válidas, com inovações introduzidas pelo sistema finalista, que se reputam fundadas e irrenunciáveis. Pode afirmar-se que, na doutrina hoje mais avançada, já mal se depara com construções que continuem a assentar num conceito finalista ortodoxo de **acção**, como supradeterminação final de um processo causal; e, sobretudo, que se disponham a ver em tal conceito um princípio ontológico ou ôntico, uma "natureza da coisa", dos quais o intérprete e o aplicador (como de resto o próprio legislador, desde que usasse o conceito) só teriam de desimplicar logicamente — ainda que segundo os mandamentos de uma "lógica material" — os restantes níveis e elementos do conceito integral do facto punível. De outra parte, todavia, encontra-se hoje generalizada a convicção de que o **ilícito típico** não é, como pretendiam os neoclássicos, uma entidade eminentemente objectiva, que traduza primariamente um desvalor de resultado e para o qual só excepcionalmente releva o desvalor da acção; é sim e sempre, como sustentou Welzel e depois se tornou em marca distintiva de toda a concepção finalista, um *ilícito pessoal*. Quanto à **culpa**, a generalidade dos autores contemporâneos está de acordo em que os elementos da imputabilidade e da consciência do ilícito relevam para o juízo de culpa — restando saber sob que forma e em que medida e persistindo

([24]) Assim, o nosso *O Problema*, § 14, II.

uma larga controvérsia quanto ao estatuto dogmático e sistemático da ideia da exigibilidade; mas opõem-se em regra à alegação finalista de que a culpa se esgotaria naquele "juízo" (de censura) e toda a sua "materialidade" caberia a outros elementos anteriores do sistema, nomeadamente à acção ilícita-típica ([25]).

§ 25 No que toca a maneira de aqui ver as coisas, porém, nem por isso se qualificará com razão de *intermediário* o esboço sistemático que em seguida será apresentado, como se ele quisesse representar uma qualquer *via per mezzo* entre as construções normativista e finalista. Decerto, qualquer concepção actual do conceito de facto punível poderá sempre reconduzir-se ou a uma certa "normativização da finalidade" ([26]) ou inversamente a uma certa "finalização da normatividade" ([27]). Mas a intenção aqui implícita não deve reduzir-se à vontade de cortar ao meio entre dois extremos, antes radica numa posição de céptico *relativismo* ([28]) tanto sobre a estrutura, naturalística ou ôntica dos conceitos jurídicos, como sobre o domínio ilimitado das valorações normativas; neste sentido podendo afirmar-se que as posições metodológicas da escola neo-clássica — por vagas e insuficientes que porventura se apresentassem — se encontravam essencialmente na razão. A posição aqui contida vem antes a participar de um sistema emergente, comandado pela convicção de que a construção do conceito de facto punível deve apresentar-se como **teleológico-funcional e racional**, possuindo a partir daqui os seus próprios postulados e determinando os seus específicos desenvolvimentos (supra, 3.º Cap. §§ 15 e ss., 20 e ss.); comandado, nomeadamente, pela convicção de que aquele sistema e os seus conceitos integrantes são formados por *valorações* fundadas em proposições político-criminais imanentes ao quadro axiológico e às finali-

---

([25]) Fundamental — e de certa forma precursor —, GALLAS, Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbrechen, *ZStW 67*, 1955, p. 1 e ss. (tradução espanhola de Cordoba Roda, sob o título *La teoria del delito en su momento actual*, 1959).

([26]) Tal como se encontra expressa, p. ex., em STRATENWERTH / KUHLEN, §§ 6 e 7, e, em certa medida, também em JESCHECK / WEIGEND, § 23, VI.

([27]) Com que se depara no conjunto da obra de ENGISCH, p. ex., Sinn und Tragweite juristischer Systematik, *Studium Generale*, 1957, p. 173, e Logische Überlegungen zur Verbrechensdefinition, *Welzel-FS*, 1974, p. 343, e no estudo de ROXIN, Zur Kritik der finalen Handlungslehre, *ZStW 74*, 1962, p. 515 (tradução portuguesa de Ana Paula dos Santos e L. Natscheradetz na colectânea *Problemas Fundamentais de Direito Penal*, 1986). Valora positivamente a afirmação feita em texto, PALMA, Fernanda, Do sentido histórico do ensino do direito penal na Universidade portuguesa à actual questão metodológica, *RPCC 9*, 1999, p. 433.

([28]) Tão cara a ENGISCH, *Wahrheit und Richtigkeit im juristischen Denken*, 1963, p. 20 e ss.

dades jurídico-constitucionais. Este "sistema emergente" arranca da concepção avançada em 1970 por Roxin a propósito das relações entre a política criminal e o sistema do facto punível (29); foi dogmaticamente aprofundado em estudos de Schünemann e de Wolter (30); e encontrou expressão sistemática paradigmática no Tratado de Roxin (31) e, posteriormente (sobretudo, embora não só), em livros de homenagem que a este A. vêm sendo dedicados (32).

§ 26 É deste terreno que se nutrem as considerações que em seguida serão avançadas. Elas têm a ligá-las — reacentue-se ainda uma vez — certas concepções básicas, já no essencial expostas, sobre o fundamento, o sentido e os limites da intervenção penal, numa palavra, certas **concepções básicas de política criminal** (33) que de forma essencial se reflectem no tema do **conceito material de crime** (supra, 6.º Cap.). Ao que devem acrescentar-se, com relevo decisivo, certas concepções não menos fundamentais em matéria de relacionamento da política criminal com a **dogmática jurídico-penal** e, por fim mas não por último, de **metodologia** jurídico-penal. Daqui não tem que resultar uma revisão de toda a anterior edificação do conceito de facto punível, nem tão-pouco está na sua base a tentativa de construir (como foi propósito de Welzel) uma "nova imagem do sistema jurídico-penal". Mas resulta algo de dogmaticamente (e também pedagogicamente) muito importante, a saber, a possibilidade de uma *pré-compreensão* dos fundamentos essenciais das mais importantes opções

---

(29) ROXIN, *Kriminalpolitik, passim*. Anote-se que a 1.ª ed. é de 1970. Por último — com precisões importantes —, do mesmo ROXIN, Zur kriminalpolitischen Fundierung des Strafrechtssystems, *Kaiser-FS*, 1998, p. 423. Normativismus, Kriminalpolitik und Empirie in der Strafrechtsdogmatik, *Lampe-FS*, 2003, p. 423 e I, § 7, n.º 26 e ss.

(30) SCHÜNEMANN, nota 11, e Strafrechtssystem und Kriminalpolitik, *Rud. Schmitt-FS*, 1992, p. 117; WOLTER, Strafwürdigkeit und Strafbedürftigkeit in einem neuen Strafrechtssystem, *140 Jahre Goltdammer's Archiv*, 1993, p. 269, e Estudio sobre la dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del sobreseimiento del proceso, de la renuncia a la pena y de la atenuación de la misma. Estructuras de un sistema integral que abarque el delito, el proceso penal y la determinación de la pena, *in*: Wolter / Freund (orgs.), *El sistema integral del derecho penal. Delito, determinación de la pena y proceso penal*, 2004, p. 31.

(31) ROXIN, I e II.

(32) Schünemann / Dias, Figueiredo (orgs.), *Bausteine des europäischen Strafrechts. Coimbra-Symposium für Claus Roxin*, 1995 (edição em espanhol a cargo de Silva Sánchez: *Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal. Libro-Homenaje a Claus Roxin*, 1995); Silva Sánchez (org.), *Política criminal y nuevo derecho penal, Libro Homenaje a Claus Roxin*, 1997; grande número das contribuições para o *Roxin-FS*, 2001; e Valdágua, Conceição (org.), *Problemas Fundamentais de Direito Penal. Colóquio Internacional de Direito Penal em Homenagem a Claus Roxin*, 2002.

(33) Por último, FRISCH, Delito y sistema del delito, *in*: Wolter / Freund, nota 30, p. 193, e ROXIN, Zur kriminalpolitische Fundierung des Strafrechtssystems, *Kaiser-FS*, 1998, p. 885 (tradução em espanhol de Abanto Vásquez, na colectânea *Dogmática Penal y Política Criminal*, 1998, p. 25).

dogmáticas que devem ser tomadas no contexto de uma concepção teleológico-funcional e racional da doutrina do crime.

2. A discussão à roda do conceito de acção e as formas básicas de aparecimento do crime

2.1. As funções atribuíveis ao conceito de acção dentro de um sistema categorial-classificatório

§ 27 Uma discussão da doutrina do facto punível não pode ainda hoje furtar-se por inteiro aos ecos da controvérsia, tão acesa nas últimas décadas, como se viu, à roda do conceito de acção; mas a querela perdeu já muita da sua virulência. Nos últimos anos, como atrás ficou sublinhado, só raramente têm surgido tratamentos da doutrina do crime que arranquem de conceitos *puros* de acção, sejam eles normativistas ou finalistas. Pelo contrário, de tais tratamentos se pode dizer com razão que na sua generalidade, e quando medidos à luz daquelas concepções fundamentais, surgem como concepções *intermédias*. Nem por isso todavia deixam de verificar-se entre eles marcadas diferenças, a ponto de ser ainda, muitas vezes, da posição assumida perante um tal conceito que resulta a fisionomia do sistema do facto punível a que se chega. A razão está em que continua a subscrever-se a ideia tradicional do conceito de acção como **base autónoma e unitária de construção do sistema**, capaz de suportar as posteriores predicações da tipicidade, da ilicitude (antijuridicidade), da culpa e da punibilidade, sem todavia as pré-determinar.

§ 28 Para que assim possa ser, porém, deve então ser exigido deste conceito "geral" de acção que cumpra uma *pluralidade de funções*: na sistematização, de inigualada clareza, de Jescheck, uma função de classificação, uma função de definição e ligação e uma função de delimitação ([34]). Para cumprir a sua **função de classificação** o conceito tem de ser um tal que assuma o carácter — o significado lógico — de conceito superior, de *genus proximus*, abrangendo *todas* as formas possíveis de aparecimento do comportamento punível (a forma activa como a omissiva, a forma

([34]) JESCHECK, Der strafrechtliche Handlungsbegriff im dogmengeschichtlicher Entwicklung, *Eb. Schmidt-FS*, 1961, p. 140; e, depois, JESCHECK / WEIGEND, § 23, I, 2. Cf. já MAIHOFFER, *Der Handlungsbegriff im Verbrechenssystem*, 1953, p. 6 e ss.

dolosa como a negligente) e representando o elemento comum a todas elas. Para cumprir a sua **função de definição e ligação** ele tem de possuir a capacidade, por um lado, de abranger todas as predicações posteriores (acção típica, ilícita, culposa, punível), possuindo em si o mínimo de substância ou de materialidade indispensáveis a suportar essas predicações posteriores sem todavia, por outro lado, as pré-determinar; isto é, sem antecipar o significado material específico que anima cada uma delas. Para cumprir finalmente a sua **função de delimitação** o conceito tem de permitir que, com apelo a ele, logo se excluam todos os comportamentos que, *ab initio* e independentemente das predicações posteriores, não podem nem devem constituir acções relevantes para o direito penal e para a construção dogmática do conceito de facto punível (acontecimentos naturais ou comportamentos de animais, meras cogitações ou pensamentos, actos reflexos, etc.).

§ 29 Perante esta multiplicidade de funções, que importa cumprir simultaneamente, um **puro conceito causal-naturalístico** de acção está desde logo fora de questão e dele se pode afirmar já não ser hoje defendido por ninguém. E o mesmo se dirá, ainda com maior razão, de um **conceito puramente normativo**, que logo à partida revela não cumprir minimamente a função de ligação, na medida em que pré-determina de uma forma absoluta a tipicidade. Ficam por isso para análise os conceitos de acção que ainda hoje continuam a ter curso na doutrina e entre os quais se destaca, para além do conceito *final*, o conceito *social* de acção ([35]). Conceito, este último, já defendido antes do surgimento do finalismo, mas que agora se louva sobretudo na asserção de que as coordenadas básicas do comportamento humano são insusceptíveis de ser apreendidas unitariamente no domínio ôntico e só o podem ser como *processos humanos socialmente relevantes*. Ou, dito por outra forma que preferimos (supra, § 25), na asserção de que o conceito jurídico-penal de acção não tem de ser mera tradução de uma realidade natural ou ôntica, mas traduz sempre uma *valoração* social ([36]).

([35]) Pioneiro: SCHMIDT, Eberhard, primeiro em v. LISZT / SCHMIDT, depois no seu *Der Arzt im Strafrecht*, 1939, e, de forma conclusiva, em Soziale Handlungslehre, *Engisch-FS*, 1969, p. 339 e ss. Depois, ENGISCH, Der finale Handlungsbegriff, *Kohlrausch-FS*, 1944, p. 161, e *Vom Weltbild des Juristen*, [2]1965, e MAIHOFFER, nota 34, p. 72, e Der soziale Handlungsbegriff, *Eb. Schmidt-FS*, 1961, p. 178. A mais completa exposição desta concepção encontra-se porventura em JESCHECK, nota 34, e JESCHECK / WEIGEND, § 23, IV. Em Portugal, CORREIA, Eduardo, *Aspectos Fundamentais da Problemática do Direito Criminal*, polic., 1975, p. 150 e ss.

([36]) Assim agora, também, ROXIN, I, § 7, n.º 57 e ss.

§ 30 Seja dito desde já que, postas as coisas neste plano, não se torna indispensável para a construção do sistema tomar, em termos radicalmente alternativos, posição nesta controvérsia. Tanto o "**finalismo**" como o "**objectivismo social**" — desde que **normativizados**, no sentido de referidos a sentidos e a valores, como sempre quis Eduardo Correia — constituem concepções *aceitáveis* sobre a essência do actuar humano nos contextos pessoal e social e têm uma palavra de relevo a dizer na doutrina do facto punível. Ponto é apenas que o primeiro alivie a categoria da finalidade de tarefas que ela não pode cumprir e escape, em último termo, à conclusão de que aquela há-de constituir o fundamento de toda a relevância jurídico-penal. E que o segundo, não ignorando a dimensão final de muitos comportamentos, evite o reducionismo sociológico, dando o devido relevo à carga ético-pessoal que ao comportamento advém do seu centro ético de autoria ou de imputação. Deste modo se deve esperar de qualquer destas orientações um contributo decisivo para a obtenção de uma síntese de factores ônticos e axiológicos, de uma correspondência de ser e dever-ser que permita novas e frutuosas aquisições hermenêuticas na doutrina do crime ([37]). O problema acima posto persiste porém: o problema de saber se, de uma qualquer destas maneiras, se logra a obtenção de um conceito que sirva simultaneamente a pluralidade de funções que ele deve cumprir como suporte de todo o sistema do facto punível. E, no caso em que se suscitem fundadas dúvidas sobre uma tal possibilidade, se não importa ainda acentuar mais fortemente o *thelos* político-criminal das categorias dogmáticas fundamentais do sistema, mesmo ao preço de, deste modo, se furtar autonomia ao conceito de acção.

§ 31 As exigências que, do ponto de vista metódico-funcional acima assinalado, se fazem — e devem na verdade ser feitas — ao conceito de acção parecem, em definitivo, **contraditórias**, no sentido de que *mutuamente se excluem*. Se o conceito deve assumir o que Jescheck chama "função de classificação" — de modo a abranger todas as espécies do actuar humano que possam, em geral, relevar para o direito penal —, parece certo que a sua

([37]) Merecem referência neste contexto aqueles AA. que — desvalorizando em larga medida, tal como o texto, o estado actual da controvérsia entre finalistas e não finalistas — pretendem resolver a questão da conceitualização da acção através de uma concepção de *não só, mas também*: uma tal conceitualização resultaria, pelo melhor, de uma *complementação* de um conceito final por um conceito social de acção. Assim, seguindo uma posição difundida ainda hoje na Alemanha, cf., na doutrina brasileira, BITENCOURT, Cezar, p. 189.

conformação há-de ser imputada a um *sistema pré-jurídico*, seja ele o sistema ôntico-final ou antes o normativo-social. Mas pode então o conceito exercer simultaneamente a "função de definição e ligação", arrogando-se o mínimo de conteúdo material necessário para que as posteriores determinações da tipicidade, da ilicitude, da culpa e da punibilidade possam ser conexionadas com o conceito, sem que todavia este em medida alguma as antecipe e pré-determine? Eis o que não parece possível e se tentará revelar em seguida à luz das mais actuais orientações em matéria de conceito geral de acção.

2.2. O conceito final de acção

§ 32 As insuficiências da concepção finalista para cumprir as funções que a qualquer conceito geral de acção são assinaladas patentearam-se claramente no preciso momento em que Welzel levou a cabo a última tentativa de lhe oferecer um estatuto definitivo, através do esclarecimento das **relações entre finalidade e dolo** ([38]). Há aqui, em abstracto, apenas duas possibilidades ([39]). A primeira reside em manter a **identificação** entre finalidade e dolo. Neste caso porém o conceito de acção perde a sua função de ligação, na medida em que se opera a sua pré-tipicidade, por isso que o dolo só pode referir-se ao tipo ou constitui mesmo um seu elemento e o tipo é normativamente conformado, contém em si os elementos que dão à supradeterminação final um *sentido* que a torna "esclarecida" e "socialmente relevante". A segunda possibilidade está em operar a **cisão** entre finalidade e dolo, bastando então, para que de acção final se possa falar, que o agente "tenha querido alguma coisa", que tenha supradeterminado finalisticamente um qualquer processo causal, sem que releve para as posteriores valorações sistemáticas o conteúdo da vontade. Será possível então falar porventura de *finalidade "potencial"* como "capacidade de dirigir e dominar, dentro de certos limites, os processos causais" ([40]), de finalidade "inconsciente" ([41]), de finalidade como "evitabilidade" ([42]) ou de finali-

---

([38]) WELZEL, *Vom Bleibenden und vom Vergänglichen in der Strafrechtswissenschaft*, 1964.

([39]) Cf. já o nosso *O Problema*, § 9, III, 2. Também HÜNERFELD, *Strafrechtsdogmatik in Deutschland und Portugal*, 1982, p. 212, e ROXIN I, § 8, n.º 22.

([40]) Cf. KAUFMANN, Armin, *Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte*, 1959, p. 83; e também STRATENWERTH / KUHLEN, § 6, n.º 8.

([41]) STRATENWERTH, Unbewusste Finalität?, *Welzel-FS*, 1974, p. 289.

([42]) JAKOBS, Vermeidbares Verhalten und Strafrechtssystem, *Welzel-FS*, 1974, p. 307. Sobre a "evitabilidade" se pretende agora construir o conceito "negativo" de acção: cf. infra, 2.4.

dade dirigida às circunstâncias fundamentadoras do risco não permitido (43) — e, com isto, considerar cumprida a função de classificação. O que não será possível é adscrever ao conceito o cumprimento da função de definição que dele se espera; porque a acção pode não conter a substância indispensável para suportar as predicações posteriores, e logo a da tipicidade: o agente pode ter *querido* penetrar na habitação de outra pessoa ou subtrair uma coisa móvel alheia — e todavia não ter com estas acções preenchido os tipos dos ilícitos de violação de domicílio (*v. g.*, por haver acordo do titular do direito de habitação) ou de furto (*v. g.*, por a intenção de apropriação não se poder qualificar de ilegítima, art. 203.º-1).

§ 33 Aliás, mesmo com as correcções aludidas não se pode em definitivo dizer que um tal conceito de acção final cumpra a sua função primária de classificação e abarque a totalidade das *formas básicas de aparecimento do facto punível*. Pois se não há dúvida que um tal conceito abrange os crimes *dolosos de acção* (para os quais de resto foi pensado), já terá de deixar de fora os crimes de *omissão* e não possui em último termo conteúdo material bastante para que uma parte dos crimes *negligentes* — pelo menos no que toca ao resultado — possa ser conexionado com ele (44). A conclusão é pois a de que, por uma ou outra forma, o conceito final de acção **não pode arvorar-se em conceito geral de acção**.

2.3. O conceito social de acção

§ 34 O que se passa com o conceito final passa-se igualmente, ao menos em parte, com o conceito social de acção. É certo que também a **omissão**, antes mesmo da sua predicação jurídica, pode já em si própria possuir *relevo social*: o "social" pode constituir em si mesmo um sistema normativo extra-jurídico. Mas assim como ao conceito final de acção se deve opor que deixa fora da acção negligente um dos mais relevantes elementos das posteriores determinações da tipicidade e da ilicitude (o resul-

---

(43) Cf. STRUENSEE, Der subjektive Tatbestand des fahrlässigen Delikte e Objektives Risiko und subjektiver Tatbestand, ambos em *JZ*, 1987, pp. 53 e 541.

(44) Assim, CORREIA, Eduardo, I, n.º 51, II. Para lá dos quadros da doutrina da acção final, mas deparando igualmente com esta dificuldade — assim também JAKOBS 6/11[43] — se encontra a concepção de KINDHÄUSER, *Intentionale Handlung*, 1980, p. 202 e ss. e *passim*, vendo a acção como uma "fazer decisivo, através do qual o agente se encontra em condições de provocar um acontecimento".

tado), também o conceito social de acção que aspire, como deve, a uma autonomia pré-jurídica deixará fora da omissão o elemento que verdadeiramente "constitui" o ilícito-típico do crime omissivo: *a acção positiva omitida e juridicamente imposta, devida ou esperada*. Pois a verdade é que o critério decisivo do ilícito (e que, segundo a função de definição, deveria ter logo um mínimo de guarida no conteúdo material do conceito de acção) é *juridicamente* fundado e, *só por isso*, também *socialmente* relevante. Ou, vistas as coisas de outra perspectiva: a acção "esperada" só o é através de uma imposição jurídica de acção que nasce do tipo. Por esta razão o conceito social de acção que pretendesse englobar também a omissão *perderia a sua função de ligação*, na medida em que também aqui se operaria a sua pré-tipicidade ([45]).

§ 35 À dificuldade exposta acresce uma outra. Se, para ser conforme com a sua função de ligação, o conceito social de acção não deve antecipar o essencial relativamente ao tipo e aos seus critérios de imputação, então ao nível da acção geral só pode relevar como critério (de resto indispensável ([46])) de imputação do resultado à conduta a *doutrina das condições equivalentes*. Uma tal doutrina porém, que visse p. ex. uma acção "social" — e, na verdade, uma acção de homicídio — no acto de geração de alguém que mais tarde vem a matar outra pessoa, seria imprestável por estranha à realidade da vida e deve, como tal, ser recusada. Contrapor-se-á que também ao nível da acção geral se devem fazer logo intervir critérios mais apertados de imputação, ao estilo, *v. g.*, da adequação, das condições relevantes, da criação de um risco não permitido, etc. Todos estes critérios porém — eles sim — só podem provir do âmbito e do fim de protecção da norma incriminadora e, assim, da ordenação jurídico-penal dos *tipos*, não de uma qualquer *ordenação extra-jurídica*, mesmo que esta seja a ordenação social. Desta maneira, em conclusão, de novo terá o conceito social de acção perdido a sua neutralidade e o seu carácter prévio e autó-

([45]) O que se torna particularmente nítido naqueles casos em que o legislador ensaiou a consagração de um conceito social de acção penalmente relevante: cf., p. ex., os arts. 7.º-1 e 2 e 43.º/*a)* dos Fundamentos do CP soviético e o § 3 do CP da antiga DDR.

([46]) Poderá objectar-se que tudo quanto respeite às questões da causalidade e da imputação objectiva é assunto do tipo e não da acção (assim, JESCHECK, nota 34, p. 153). Mas se quiser guardar-se a autonomia dogmático-sistemática da acção em geral, logo aí tem de suscitar-se a questão da imputação do resultado à conduta. Bem o entendeu CORREIA, Eduardo I, §§ 14 e 18, especialmente p. 290, que sempre tratou a questão da "causalidade" por duas vezes, primeiro na acção e depois na tipicidade.

nomo perante a doutrina da tipicidade e **não terá cumprido,** numa palavra, **a sua função de ligação** (47).

2.4. O conceito "negativo" de acção

§ 36 Em tempos relativamente recentes têm pretendido alguns autores, partindo aliás dos mais diversos supostos básicos, alcançar um conceito geral negativo de acção: "a acção do direito penal é o **não evitar evitável de um resultado**" (48); pensando desta forma ter logrado uma base sobre a qual se pode construir uma doutrina geral do facto, do activo como do omissivo, do doloso como do negligente. Parece claro todavia, desde logo, que, sob qualquer uma das múltiplas formulações que o aludido pensamento pode assumir, a caracterização só abrange os chamados (infra, 11.º Cap., § 37 e ss.) "crimes de resultado", não os de "mera actividade" ou "mera omissão", não cumprindo assim, já por aqui, a função de classificação. Como parece sobretudo claro que o conceito deste modo delineado tem, uma vez mais, a ver com a doutrina da *imputação objectiva* e, por conseguinte, com problemas do *tipo*, não com a acção como tal (49). Ainda deste conceito se dirá por conseguinte, com particular razão, que ele **operaria a pré-tipicidade da acção** e faria perder a esta por inteiro a sua função de ligação.

2.5. O conceito pessoal de acção

§ 37 Também em data recente veio Roxin (50) ensaiar uma nova tentativa de construção de um conceito geral de acção capaz de realizar a totalidade das funções sistemáticas que dele se esperam. Um tal conceito — pessoal — de acção residiria em ver esta como "**expressão da personalidade**", em abarcar nela "tudo aquilo que pode ser imputado a um homem como centro de acção anímico-espiritual". Este conceito norma-

---

(47) Dificuldades à luz da função de delimitação reconhece também, de algum modo, ROXIN I, § 8, n.º 29.

(48) Fundamental, HERZBERG, *Die Unterlassung im Strafrecht und das Garantenprinzip*, 1972, p. 177.

(49) Assim também, em definitivo, ROXIN I, § 8, n.ºs 33 e ss. e 39.

(50) Outrora defensor de uma conclusão (céptica) sobre o valor do conceito geral de acção para o sistema do facto punível a muitos títulos paralela à que infra, 2.6.1, retiraremos: cf. ROXIN, nota 27, p. 108 da tradução portuguesa.

tivo (não normativista, previne Roxin) de acção cumpriria integralmente as funções de classificação, de ligação e de delimitação que dele se esperam; além de que o cariz *pessoal* de que se reveste teria a decidida vantagem de o pôr de acordo (função de definição) com uma doutrina pessoal do ilícito que deve na verdade sufragar-se ([51]).

§ 38 Se bem que existam na referida concepção muitos e relevantes pontos a merecerem consideração, é pelo menos duvidoso que um tal conceito de acção (quando erigido, como se pretende, em base geral e unitária de construção do sistema) logre libertar-se completamente de algumas das aporias que ao conceito social de acção foram apontadas. E isto essencialmente porque o comportamento só pode muitas vezes — sobretudo, ainda uma vez, no campo da omissão — constituir-se como "expressão da personalidade" na base de uma sua **prévia valoração como juridicamente relevante** ([52]), também aqui se antecipando, nesta parte, a sua tipicidade e perdendo o conceito, nesta precisa medida, a sua função de ligação. A esta objecção acresce que a caracterização da acção como expressão da personalidade, por mais correcta que em si mesma possa considerar-se, não remete para qualquer sistema pré-jurídico e não tem por isso aptidão para se constituir em *genus proximus* de todo o sistema jurídico do facto punível. A menos, é claro, que se diga que uma tal caracterização actua pura e simplesmente dentro do sistema **social** da acção (equivalendo nomeadamente ao critério da *evitabilidade* ([53])); caso em que, porém, as críticas de que a concepção pessoal da acção é passível são precisamente aquelas mesmas que podem validamente ser dirigidas ao conceito social de acção ([54]).

§ 39 Por outra parte, não parece seguro que o conceito pessoal de acção — como aliás qualquer outro conceito geral de acção — possa cum-

---

([51]) Com um esboço desta concepção se depara já em ROXIN, Einige Bemerkungen zum Verhältnis vom Rechtsidee und Rechtsstoff in der Systematik unseres Strafrechts, *Radbruch-GS*, 1968, p. 262. Cf., agora, com desenvolvimento, ROXIN I, § 8, n.º 44 e ss.

([52]) Como o reconhece aliás, com notável probidade científica, o próprio ROXIN I, § 8, n.º 52 e s., alegando todavia que tal não torna de todo inexequível o cumprimento pelo conceito da sua função de ligação.

([53]) Assim, STRATENWERTH / KUHLEN, § 6, n.º 13.

([54]) Desta reserva julgamos passível a concepção de TAVARES, Juarez, *Direito Penal da Negligência*, ²2003, p. 226, que define a acção a partir de uma noção prévia de sujeito: "o sujeito é quem se encontra capaz de orientar socialmente sua conduta em função de objetos de referência propostos dentro de um contexto prático".

prir capazmente a sua **função de delimitação** ([55]). E isto porque não é o conceito apriorístico de acção que cumpre a função de delimitação, antes são os resultados da delimitação que se reputam correctos, as mais das vezes obtidos em função das exigências *normativas* dos tipos, que depois vão ser atribuídos ao conceito, ao seu conteúdo e aos seus limites. Que, *v. g.*, acontecimentos naturais, comportamentos de animais, puros actos praticados sob *vis compulsiva*, meras cogitações possam não ser considerados expressões da personalidade, eis o que pode aceitar-se. Se bem não deva omitir-se que concepções pessoais, modos de ser, de pensar e de agir constituem lídimas (porventura as mais lídimas) expressões da personalidade sem que todavia tenham de traduzir-se em acções penalmente relevantes; a menos, uma vez mais, que se ponha como condição prévia indispensável que elas se exprimam em comportamentos *socialmente relevantes*. Como se não compreende porque não possam acções jurídico-penalmente relevantes, sob certas condições — *v. g.*, comportamentos de entes colectivos, actos reflexos ou automáticos, factos praticados em estados graves de afecto, etc. —, ser consideradas expressões da personalidade: se o são ou não é coisa que em definitivo deverá depender das exigências típicas e não de qualquer conceito geral de acção.

2.6. Conclusões

2.6.1. Necessidade de a teoria da acção ceder a primazia à teoria da realização típica do ilícito

§ 40 Em vista do conjunto das considerações anteriores é preferível que a doutrina do crime renuncie a encontrar a sua *ultima Thule* nos resultados de uma **excessiva abstracção generalizadora e classificatória** que vai implicada na aceitação de um qualquer conceito pré-jurídico geral de acção. É um preconceito — de raiz idealista — pensar que os fenómenos deste mundo devem por força reconduzir-se a conceitos de maior abstracção e, em definitivo, formar uma "ordem" preestabelecida que só importaria "conhecer". O que não significa que tenha de renunciar-se ao pensamento categorial-classificatório na construção do conceito de facto punível; mas significa, em todo o caso, que **deve renunciar-se a colocar como elemento básico do sistema um conceito geral de acção**, com as suas específicas fun-

([55]) Defende esta capacidade com grande pormenor, todavia, ROXIN I, § 8, n.º 58 e ss.

ções de classificação e de definição e ligação; e que aquela construção se deve antes ocupar da compreensão das concretas acções e omissões, das acções e omissões dolosas e negligentes que se apresentem como jurídico-penalmente relevantes e, por conseguinte, tal como são dadas nos tipos de ilícito. Isto vale por dizer, de forma conclusiva, que a doutrina da acção deve, na construção do conceito de facto punível, **ceder a primazia à doutrina da acção típica** ou da **realização do tipo de ilícito**, passando a caber ao conceito de acção apenas "a função de integrar, no âmbito da teoria do tipo, o *meio adequado de prospecção da espécie de actuação*" ([56]); ou, dentro das expressões funcionais de Jescheck que vêm sendo utilizadas, passando a caber-lhe apenas uma certa (e restrita) *função de delimitação*. Só que ainda esta função derivará do conjunto das formas admitidas de realização típica e constitui, nesta medida, uma função já *normativamente* conformada. Até porque só assim se estará a corresponder à *teleologia própria do conceito de acção dentro de um sistema funcional e racional*. Quando se pergunta qual o *thelos* ou a função que este conceito serve dentro do sistema, a resposta só pode ser a de que com ele se pretende excluir tudo aquilo que desde o início não pode relevar para as posteriores valorações jurídico-penais, nomeadamente, para as categorias do proibido e do permitido. Mas justamente por esta razão, a determinação conceitual da acção encontra-se *a priori* pré-judicada pela função e pela categoria do *tipo*, pois que é esta — como quer que em último termo se conceba — que se apresenta como decisiva para traçar a fronteira entre o proibido e o permitido.

§ 41 Daqui resulta que a própria função de delimitação não deve ser desempenhada por *um* conceito *geral* de acção, antes deve sê-lo por *vários conceitos de acção tipicamente conformados*. Não se elimina com isto, claro, o relevo do conceito de acção; só que ele perde autonomia e, deste modo, capacidade para se arvorar em pedra-base do sistema ([57]). O conceito de acção não é — não pode, nem deve ser — algo de previamente dado ao tipo, mas apenas um elemento, a par de outros, integrante

([56]) Como já em seu tempo foi sugerido por RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, *Frank-FG*, I, 1930, p. 162, e fundamentado, na doutrina italiana, por MARINUCCI, *Il reato come azione. Critica di un dogma*, 1971.

([57]) Como acentua PALMA, Fernanda, A teoria do crime como teoria da decisão penal, *RPCC* 9, 1999, p. 540, não se renuncia assim a um conceito de acção possuidor de uma função de delimitação. Só que se não trata do conceito *geral* de acção, mas do conjunto dos (vários) conceitos de *acção típica*.

do cerne dos tipos de ilícito. A partir daqui é inevitável — e sem que esta atitude deva ser censurada como resignação, antes louvada como posição teleologicamente positiva e funcionalmente adequada — assinalar ao conceito o desempenho de um **papel secundário no sistema teleológico**, essencialmente correspondente, uma vez mais se diz, à função de delimitação ou função "negativa" de excluir da tipicidade comportamentos jurídico-penalmente irrelevantes; enquanto a primazia há-de ser conferida, sem hesitação, ao conceito de **realização típica do ilícito** e à função por ele desempenhada na construção teleológica do facto punível ([58]).

2.6.2. Distinção das formas básicas, tipicamente cunhadas, do facto punível

§ 42 Uma concepção como a que acaba de defender-se dá razão bastante a que se renuncie à unidade tradicional de construção do conceito de facto punível e se substitua por uma construção que, em rigor, deveria ser **quadripartida**. A análise do conjunto dos tipos de ilícito constantes de um ordenamento jurídico-penal conduz, na verdade, à conclusão de que existem diferenças teleológico-funcionais (e, naturalmente, também estruturais) entre quatro formas de aparecimento do crime e que convidam a uma sua consideração dogmática autónoma: os *crimes dolosos de acção*, os *crimes negligentes de acção*, os *crimes dolosos de omissão* e os *crimes negligentes de omissão*.

§ 43 Efectivamente, a análise dos tipos de crime contidos na PE de um CP logo dá a entender que enquanto uns, a generalidade, assentam na forma que se pode considerar *normal* de comportamento — o comportamento activo ou por acção, em sentido estrito —, outros (*v. g.*, a omissão de auxílio ou de socorro) são levados a cabo por omissão; sendo certo que muitos resultados típicos (*v. g.*, a morte de outra pessoa, no caso do crime de homicídio) tanto podem ser realizados através de um comportamento activo, como de um comportamento omissivo. Qualquer que seja a maneira exacta de distinguir estas duas formas básicas de comportamento, bem se compreende que a primeira — o comportamento **activo** — seja a forma usual de realização do tipo. Segundo o conteúdo normativo ínsito nos tipos de ilícito, a *proibição* de lesar ou pôr em perigo bens juridicamente protegidos

([58]) Assim, no essencial, já, o nosso *O Problema*, § 9, III.

constitui o mandamento primário contido nas prescrições penais. O mandato de actuar *em favor* de tais bens jurídicos (punindo consequentemente o comportamento *omissivo*) assume assim, do ponto de vista político-criminal, um papel subordinado. De outra forma poderia o direito penal correr o risco de perder a sua *vertente liberal*, adequada aos princípios democráticos e do Estado de Direito e justificadora, em última análise, do seu carácter de *extrema ratio* da política social, para se tornar em um direito de intervenção sistemática (se não mesmo de intromissão) na esfera jurídica das outras pessoas, do qual poderiam esperar-se maiores danos para as liberdades individuais do que aqueles que o direito penal se propõe evitar. De igual modo se compreende, por outro lado, que uma política criminal consistente e coerente conduza à proibição primária de comportamentos **dolosos**, no sentido de comportamentos em que o agente *previu* e *quis* a realização do tipo; enquanto comportamentos não previstos e (ou) não queridos, nos quais por conseguinte o conteúdo ilícito se reporta em primeira linha à violação de um dever objectivo de cuidado e diligência — comportamentos *negligentes* —, só devam ser punidos, de novo, a título normativamente subordinado. Só devam ser punidos, numa palavra, onde e quando a lei sinta uma intensificação tão forte da necessidade de tutela do bem jurídico que a conduza a prever *expressamente* a punibilidade a título de negligência. Tudo isto se diz, de resto, sem perder a consciência de que um *direito penal adequado à sociedade do risco* requer, cada vez mais vivamente, uma punição mais larga e intensificada de condutas omissivas e negligentes. Só que uma tal exigência não cobre a generalidade dos domínios de actuação da lei penal, antes sim, apenas, aqueles que se relacionam com os novos e grandes riscos da sociedade pós-industrial (supra, 6.º Cap., § 46 e ss.).

§ 44 É pois de acordo com a concepção quadripartida referida que se sistematizará a exposição seguinte. Ela iniciar-se-á com o tratamento dos **crimes dolosos de acção** que, em função do que ficou dito, assumem o primeiro lugar na construção, relativamente a eles devendo considerar-se todos os elementos constitutivos do facto punível, de forma tanto quanto possível esgotante (Título II); seguir-se-á o tratamento dos **crimes negligentes de acção** (Título III); para se concluir com o tratamento dos **crimes de omissão** (Título IV), ainda neles distinguindo, como é devido, os crimes **dolosos** e os crimes **negligentes**.

3. As categorias dogmáticas

§ 45 Resta apresentarmos ainda, a título sumário, introdutório e sincopado, cada uma das categorias em que, no nosso entendimento do sis-

tema teleológico-funcional e racional, deve decompor-se o conceito de facto punível. Reacentuando desde já que, em um tal sistema, comandado de forma decisiva por proposições político-criminais fundamentais, não pode deixar de estabelecer-se uma *ligação transversal* próxima entre esta temática e a acima considerada sob a epígrafe do "Conceito material de crime" (supra, 6.º Cap.). É aqui que, como vimos, as categorias da **dignidade punitiva** e da **carência de pena** dão vida e conteúdo à função do direito penal de tutela subsidiária de bens jurídicos: a primeira, reduzindo os bens penalmente tuteláveis àqueles que encontram refracção jurídico-constitucional e tornando-os assim, de meros bens jurídicos, em bens jurídico-penais; a segunda, introduzindo o critério básico da necessidade sem alternativa da sua protecção através dos instrumentos sancionatórios próprios do direito penal.

§ 46 Aquelas categorias não podem por isso deixar de reflectir-se em larga medida (se não mesmo de parcialmente se "reproduzir") no sistema do facto punível ([59]), sendo elas que nos confortam na concepção de que aquele sistema é formado pelo **tipo de ilícito** e pelo **tipo de culpa** como pressupostos categoriais sistemáticos mínimos enquanto expressões de dignidade penal tipicizada: o primeiro como concretização central do conceito material de crime, o segundo como censurabilidade do agente referida ao ilícito tipicizado. A estas duas categorias fundamentais acresce em certos casos a categoria da **punibilidade** como somatório daquelas condições onde de novo se exprime, mas agora de modo *específico* e *autónomo*, a "dignidade punitiva" do facto como um todo (*v. g.* condições objectivas de punibilidade, causas de exclusão da pena, etc.); categoria que permite estabelecer a ligação com uma consideração, também ela específica e autónoma, da "carência de pena" como ideia básica integradora de muitos institutos já pertencentes à doutrina das consequências jurídicas do crime ou mesmo com institutos de índole predominantemente processual penal (*v. g.*, dispensa de pena, queixa e acusação particular, suspensão provisória do processo, etc.) ([60]).

§ 47 Mais longe pretende ir agora Jürgen Wolter, baseado em todo o caso, se bem cuidamos, num património ideológico coincidente no essen-

---

([59]) Neste sentido, muito claramente, FRISCH, nota 33, p. 151 e s.

([60]) Insiste neste último ponto, WOLTER, *in:* Wolter / Freund, nota 30, pp. 37 e s., 41 e s., 63 e ss.

cial com o que defendemos. Sem abandonar as categorias tradicionais da tipicidade, da ilicitude e da culpa, sustenta que elas não são, contra o que até agora tem defendido o pensamento categorial-classificatório, categorias dogmáticas autónomas, mas sim **componentes de outras categorias político-criminalmente determinadas** de forma mais imediata: justamente as da "dignidade punitiva", da "carência de pena" e da "atribuição político-jurídica" (*rechtspolitische Zuschreibung*); sendo estas categorias, não o tipo, o ilícito e a culpa, que devem valer imediatamente também como categorias dogmáticas do sistema do facto ([61]). Dentro delas (e, embora em diferente medida, relativamente a todas elas) operariam as subcategorias tradicionais do tipo, do ilícito e da culpa; conduzindo todavia a uma arrumação sistemática — nomeadamente das causas de exclusão do ilícito, das causas de exclusão da culpa e das causas de exclusão da pena — completamente diferente da tradicional.

§ 48 Assim, *v. g.*, dentro da categoria da "punibilidade" (isto é, da dignidade punitiva) se localizariam institutos como os da inimputabilidade e da falta de consciência do ilícito não censurável; dentro da categoria da "necessidade de pena" se situariam situações como as do excesso de legítima defesa desculpante e da desistência da tentativa; dentro da categoria da atribuição político-jurídica deveriam ser considerados institutos materiais como os das condições objectivas de punibilidade ou mesmo inclusivamente processuais como o da suspensão provisória do processo.

§ 49 O notável esforço de Wolter de reconstrução do sistema à luz de supostos básicos teleológico-funcionais e racionais não encontrou até agora a audiência e o estudo que, em nossa opinião, merece ([62]). Há nele **sugestões que não devem ser desaproveitadas** e devem, pelo contrário, ser prosseguidas, como é o caso, nomeadamente, da tentativa de construção de um sistema unitário integral da dogmática jurídico-penal e jurídico-processual penal, da aproximação das temáticas do conceito material de crime e da doutrina do facto punível, da acentuação do condicionamento desta doutrina pelas proposições político-criminais básicas. Deve porém reconhecer-se que, no estado em que Wolter deixou até agora o seu estudo, os tempos não estão ainda maduros para a substituição siste-

([61]) WOLTER, *in:* Wolter / Freund, nota 30, pp. 34 e ss., 42 e ss. e 47 e ss.; e já supra, 3.º Cap.[48].

([62]) Ressalve-se em todo o caso a análise extremamente compreensiva de FRISCH, nota 33, p. 154 e ss., em alguns pontos coincidente com o texto seguinte; e cf. agora também, em síntese, ROXIN I, § 7, n.º 10 e s.

mática preconizada: seja porque deste modo se subalternizam até um ponto, insuportável para a teoria e para a *praxis*, as categorias tradicionais do tipo de ilícito e do tipo de culpa; seja porque as "novas categorias" estão ainda insuficientemente desimplicadas nas suas consequências dogmáticas, máxime, no que toca à distribuição das causas de exclusão da responsabilidade por diversas categorias dogmáticas, seja porque não parece suficiente o simples apelo a considerações extra-penais para caracterizar a nova categoria da atribuição político-jurídica. O que conduz à conclusão de que no momento presente, ainda mesmo no contexto de um sistema teleológico-funcional e racional, continuam a ser as categorias do tipo de ilícito, do tipo de culpa e da punibilidade que devem considerar-se os elementos constitutivos do facto punível.

3.1. O tipo de ilícito

3.1.1. Tipicidade, ilicitude e causas de justificação

§ 50 Porventura o maior problema que ainda hoje se suscita à construção do aludido sistema do facto punível é o de encontrar a concepção mais adequada das relações entre **tipo** e **ilícito** ou, se se preferir, entre **tipicidade** e **ilicitude ou antijuridicidade**. Absolutamente dominante tanto na escola clássica, como na neoclássica, como na finalista, como mesmo no sistema teleológico-funcional é a ideia de que "*o tipo constitui o primeiro degrau valorativo da doutrina do crime*" (63) e portanto o primeiro e autónomo qualificativo da acção: há que começar por comprovar a correspondência da acção concreta a um tipo (primeiro degrau), para só depois eventualmente negar a sua ilicitude (segundo degrau) se no caso intervier uma causa de justificação. Mas esta construção do sistema — vulgarmente chamada "concepção *tripartida* do conceito de crime": tipicidade, ilicitude, culpa —, se bem que tenha a seu favor a correspondência a um correcto procedimento prático de análise dos *casos penais*, não parece ser a melhor de uma perspectiva científico-dogmática. Num sistema autenticamente teleológico-funcional e racional a "prioridade" não pode deixar de caber à categoria material do *ilícito*, concebido como **ilícito-típico** ou (o que é o mesmo, na nossa visão das coisas) como **tipo de ilícito** (64).

(63) WELZEL, § 10, III.

(64) Já no sentido que se segue, o nosso *O Problema*, §§ 4, III, e 21, I. PALMA, Fernanda, nota 27, p. 418 e ss., parece mostrar compreensão pela essencialidade desta "prioridade do ilí-

§ 51 A oposição entre as duas concepções esboçadas foi confundida há décadas atrás com a questão de saber se o tipo haveria de se configurar como **tipo indiciador** (*Indiztatbestand*), contendo apenas a descrição do comportamento (da matéria) proibido(a) ou os elementos individualizadores da respectiva espécie de crime (65). Ou antes como **tipo total** (*Gesamttatbestand*) (66), que conteria além daqueles, se bem que de forma implícita e como seus elementos "negativos", a *ausência* de causas de justificação (doutrina chamada dos "**elementos negativos do tipo**"); que conteria, numa palavra, a totalidade dos elementos relevantes para o *concreto* juízo de ilicitude (= antijuridicidade). Com esta confusão dos dois problemas se opera porém uma desvalorização do primeiro e uma hipervalorização do segundo. Em perspectiva teleológico-funcional a questão dos elementos negativos do tipo constitui um problema sem significado material, não existindo no fundo qualquer diferença sistemática essencial entre esta doutrina e a que se lhe opõe (67), nem ela constituindo uma verdadeira alternativa. Para uma como para outra concepção o tipo é o substantivo, a causa, o *prius*, e a ilicitude apenas a predicação, a consequência, o *posterius*. Por isso uma tal discussão falha o essencial.

§ 52 O essencial reside em determinar se a **prioridade teleológica e funcional na construção do sistema** há-de pertencer ao *tipo* ou antes ao *ilícito*. E já do próprio campo funcional-teleológico Roxin argumentou que não pode deixar de pertencer ao *tipo*. A tipicidade distinguir-se-ia da ilicitude precisamente porque aquela traduz "a acção avaliada sob o ponto de vista da necessidade abstracta de pena" (isto é, "independentemente da pessoa do agente e da situação concreta da acção") e assenta assim na finalidade político-criminal, de natureza geral-preventiva, de motivar a omissão das acções proibidas (ou a realização das acções impostas) (68); enquanto no ilícito se trata da consideração da acção típica concreta, com a inclusão nela de todos os seus elementos reais caracterizadores, baseada, entre outras, na finalidade político-

---

cito" na nossa concepção, que considera como que uma "chave sistemática" da doutrina geral do facto punível; para concluir, todavia, que uma tal concepção das coisas pode tornar as categorias clássicas "incompreensíveis, isto é disfuncionais". Para obstar a que tal suceda importa — como, de resto, Fernanda Palma também anota — conexionar esta nossa concepção dogmática com a ideia do "sistema aberto": supra, 3.º Cap., § 23.

(65) Assim, WELZEL, § 10, I.

(66) Assim, ENGISCH, Der Unrechtstatbestand im Strafrecht. Eine kritische Betrachtung zum heutigen Stand der Lehre von der Rechtswidrigkeit im Strafrecht, *Deutschen Juristentag-FS*, I, 1960, p. 404; e já ROXIN, *Offene Tatbestände und Rechtspflichtmerkmale*, 1959, p. 173 e ss. Cf., de resto, CORREIA, Eduardo, II, n.º 1; FERREIRA, Cavaleiro de, *A Tipicidade na Técnica do Direito Penal*, 1935, p. 77 e ss.; e REALE JR., nota 23, p. 54 e s.

(67) Como anotam STRATENWERTH / KUHLEN, § 7, n.º 13, mas sem entono crítico.

(68) ROXIN I, § 7, n.º 61, e § 10, n.º 20.

-criminal de solucionar conflitos de interesse jurídico-penalmente relevantes (69).

§ 53 Não nos parece porém que as coisas devam ser vistas assim. Uma determinação do tipo como a que fica exposta incide na inconveniente confusão entre aquilo que pode chamar-se, na esteira da terminologia de Lang-Hinrichsen e de Engisch, o "tipo" que é *elemento constitutivo do crime*: **tipo de ilícito** (*Systemtatbestand, Unrechtstatbestand*); e o "tipo" que é uma *precipitação do princípio da legalidade*: **tipo de garantia** (*Garantietatbestand*) (70). A aludida função de dar a entender, mesmo em abstracto, onde passa a fronteira entre o permitido e o proibido é cumprida pelo princípio da legalidade e não precisaria de ser renovada ao nível de um dos elementos constitutivos do conceito de crime; o que se comprova pela circunstância de a função que assim é atribuída aos elementos típicos ter de todo o modo de ser repetida, sob pena de violação da legalidade, relativamente aos elementos da culpa e mesmo às condições de punibilidade. Fosse esta a verdadeira função do tipo no sistema e toda a categoria da tipicidade poderia ser eliminada da construção da doutrina do crime, para ser tratada em sede de aplicação da lei penal e da exigência correspondente de legalidade (71).

§ 54 É outra a forma como encaramos o problema e a sua solução. A função do direito penal — de protecção subsidiária de bens jurídico-penais — e a justificação da intervenção penal — a estabilização das expectativas comunitárias na validade da norma violada — irmanam-se na determinação funcional da categoria do **ilícito**: a esta categoria, *assim materialmente estruturada*, pertence por isso prioridade teleológica e funcional sobre a categoria do tipo, a ela advém *o primado na construção teleo-*

(69) ROXIN I, § 7, n.º 64 e ss. Também entre nós, entre outros, CARVALHO, Taipa, II, p. 50.

(70) LANG-HINRICHSEN, Die irrtümliche Annahme eines Rechtfertigungsgrundes in der Rechtsprechung des BGH", *JZ*, 1953, p. 362, e ENGISCH, Die normativen Tatbestandselemente im Strafrecht, *Mezger-FS*, 1954, p. 131. Não parece diferente a concepção de BRITO, Sousa e, Etablierung des Strafrechtssystems zwischen formaler Begriffsjurisprudenz und funktionalistischer Auflösung, *in*: Schünemann / Dias, Figueiredo, nota 32, p. 86.

(71) O que estará porventura na base da desconfiança com que a larga maioria da doutrina italiana sempre olhou — e continua a olhar: uma síntese muita clara em MANTOVANI, n.º 15 — a tipicidade como elemento constitutivo autónomo da teoria do facto punível. Em todo o caso, autonomizando já *fatto* e *antiguiridicità*, MARINUCCI / DOLCINI, *Corso*, p. 626 e ss.

lógico-funcional do crime ([72]). Com a categoria do ilícito se quer traduzir o **específico sentido de desvalor jurídico-penal** que atinge um *concreto* comportamento humano numa *concreta* situação, atentas portanto todas as condições *reais* de que ele se reveste ou em que tem lugar. Por outras palavras, é a qualificação de uma conduta *concreta* como penalmente *ilícita* que significa que ela é, de uma perspectiva tanto objectiva, como subjectiva, desconforme com o ordenamento jurídico-penal e que este lhe liga, por conseguinte, um juízo negativo de valor (de desvalor). A função que a categoria da ilicitude cumpre no sistema do facto punível é, em suma, definir — não em abstracto, mas em concreto, isto é, relativamente a singulares comportamentos — o âmbito do penalmente proibido e dá-lo a conhecer aos destinatários potenciais das suas normas, **motivando** por esta forma tais destinatários a comportamentos de acordo com o ordenamento jurídico-penal. Só a partir daqui ganha o tipo o seu verdadeiro significado e a ilicitude se apresenta como o verdadeiro fundamento do tipo. Não se diga, por isso, que ao tipo, considerado independentemente da ilicitude, pertence logo a função de motivar a omissão de acções proibidas ou a realização de acções impostas. Não há nenhuma proposição político-criminal no sentido de que a norma motive, p. ex., a omissão de uma acção de matar em legítima defesa!

§ 55 Nesta acepção, na verdade, "sem ilícito não há tipo" ([73]); ou, de outro modo, **todo o tipo é tipo de ilícito**. O tipo surge — como em certo momento a doutrina dominante pareceu claramente dar-se conta, antes que a questão se complicasse (e obscurecesse) com a querela à volta dos "elementos negativos do tipo" (supra, § 51) — como "tipicização", "sedimentação concreta" ou "irradiação" de um ilícito, é um ilícito "cunhado tipicamente" ([74]), é (como sempre ensinou Eduardo Correia) o "interposto da valoração jurídico-criminal", o "portador da valoração" de um comportamento como ilícito ([75]). Critérios hoje decisivos de delimitação da extensão e do

---

([72]) "Numa concepção teleológica do direito penal o primado pertence indubitavelmente à antijuridicidade", afirmava já BETTIOL, p. 292 (não directamente no contexto, é certo, das relações entre ilícito e tipo, mas em todo o caso num sentido material próximo do assinalado em texto).

([73]) A afirmação — avançada embora num contexto não de todo coincidente com o do texto — é de HARDWIG, Die Gesinnungsmerkmale im Strafrecht, *ZStW 68*, 1956, p. 36, nota 27.

([74]) Designações usadas por SAUER, *Grundlagen des Strafrechts nebst Umriss einer Rechts- und Sozialphilosophie*, 1921, pp. 307, 309, 310.

([75]) CORREIA, Eduardo, *Unidade*, p. 108 e ss., nota 1.

sentido do tipo como os da imputação objectiva, da área de tutela e do fim de protecção da norma, do acordo, etc., são claramente critérios obtidos a partir da essência mesma do **ilícito jurídico-penal** e da sua função no sistema. Por isso **a tipicidade cumpre**, à sua própria maneira, exactamente **a mesma função político-criminal que cabe à ilicitude**.

§ 56 A mencionada concretização, revelação ou mostração serve-se em todo o caso, para a sua realização, de dois instrumentos diferentes ou mesmo de sinal contrário, mas em todo o caso **funcionalmente complementares** ([76]). Um deles é o que aqui se chama **tipos incriminadores** (infra, 11.º Cap. e ss.), isto é, o conjunto de circunstâncias fácticas que directamente se ligam à *fundamentação* do ilícito e onde, por isso, assume primeiro papel a configuração do *bem jurídico protegido* e as condições, a ele ligadas, sob as quais o comportamento que as preenche pode ser considerado ilícito. O outro são os **tipos justificadores** ou *causas de justificação* (infra, 14.º Cap. e ss.) que, servindo igualmente a concretização do conteúdo ilícito da conduta, assumem o carácter de limitação ("negativa") dos tipos incriminadores. Também os tipos justificadores constituem, no seu *modus* particular, formas delimitadoras do conteúdo de ilícito (e, na verdade, formas que possuem os seus elementos constitutivos, os seus pressupostos, mesmo uma certa descrição fáctica e são assim elas próprias, em suma, susceptíveis de tipificação ([77])) e podem por isso ser vistos como verdadeiros *(contra)tipos, funcionalmente complementares* dos tipos incriminadores. *Estruturalmente* porém estas entidades apresentam-se como diversas, na precisa medida em que só os tipos incriminadores são portadores do bem jurídico protegido, por isso mesmo delimitando o ilícito por forma concreta e positiva, enquanto os tipos justificadores são em princípio estranhos à ordem legal dos bens jurídicos e delimitam assim o ilícito por forma geral e negativa. É verdade que tanto uns como outros se destinam a circunscrever o condicionalismo sob o qual a lesão de um bem jurídico é em definitivo ilícita; mas enquanto a esta função se liga, nos tipos incriminadores, a de descrever ou indicar o bem jurídico de que se trata, é ela por regra estranha aos tipos justificadores.

([76]) Neste sentido ia uma antiga doutrina generalizada na Polónia, ao que informa ANDREJEW, *RintDP 38*, p. 513.

([77]) Este aspecto, que temos posto em evidência a partir de *O Problema*, § 4, III, fora já acentuado por ENGISCH, *Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht*, 1930, p. 10. Cf., agora também, ANDRADE, Costa, *Consentimento e Acordo em Direito Penal*, 1990, p. 245.

§ 57 A **conclusão** a retirar do que fica dito é a de que, num sistema teleológico-funcional da doutrina do crime, não há lugar a uma construção que separe, em categorias autónomas, a tipicidade e a ilicitude. Categoria sistemática, com autonomia conferida por uma teleologia e uma função específicas, é só a categoria do **ilícito-típico** ou do **tipo de ilícito** ([78]): tipos incriminadores e tipos justificadores são apenas instrumentos conceituais que servem, *hoc sensu* sem autonomia recíproca e de forma dependente, a realização da intencionalidade e da teleologia próprias daquela categoria constitutiva ([79]).

3.1.2. A questão da "localização sistemática" do dolo e da negligência

§ 58 Intimamente ligada aos problemas da construção do tipo de ilícito está a questão — pomo de discórdia por excelência entre adeptos e adversários da doutrina da acção final — da localização sistemática do dolo e da negligência no tipo de ilícito ou antes no tipo de culpa. Uma coisa ao menos se pode tomar já hoje por segura: a eventual "pertinência" do dolo e da negligência ao tipo não pode resultar da posição que se sufrague quanto à **doutrina da acção**, nomeadamente de se aceitar ou recusar o conceito *final* de acção; decisiva não poderá ser a relação do dolo e da negligência com categorias ônticas como as da "causalidade" ou da "finalidade", mas só poderá ser a *função* e a *teleologia* do tipo de ilícito e do tipo de culpa no sistema. Tão-pouco deverá a inclusão do dolo no tipo de ilícito derivar ou ser deduzida logo da exigência de **determinabilidade dos tipos** própria do Estado de Direito ([80]). Esta consideração radica de novo na *confusão entre tipo de ilícito e tipo de garantia*. Decerto que dolo e negligência são elementos delimitadores do âmbito do punível. A punibilidade porém não pode ligar-se pura e simplesmente, nos quadros de

([78]) O que acaba por ser reconhecido pelo próprio ROXIN I, § 10, n.º 18, quando afirma que, em último termo, "fundamentação do ilícito e exclusão do ilícito são só peças de uma unidade mais alta". E mais à frente, n.º 23: "é absolutamente legítimo" conceber "o ilícito como uma unidade mais alta de tipo e antijuridicidade".

([79]) Assim, concluem também, SCHÜNEMANN, nota 11, p. 56 e ss., e HERZBERG, Erlaubnistatbestandsirrtum und Deliktsaufbau, *JA*, 1989, p. 294 e ss. E, entre nós, FERREIRA, Cavaleiro de, I, p. 35 e ss.

([80]) Existe hoje largo consenso quanto a esta argumentação, mesmo entre os autores receptivos a uma concepção final da acção ou à localização do dolo e da negligência no tipo de ilícito. Cf., só, JESCHECK / WEIGEND, § 24, III, 4 c); e ROXIN I, § 10, n.º 67.

um Estado de Direito, a um comportamento "causal", como o não pode também a um comportamento "final": ela só pode ligar-se a um comportamento *culposo*, seja doloso ou negligente. A própria culpa, tanto como o dolo ou a negligência, é uma exigência do Estado de Direito e deve reflectir-se por isso, ela também, no tipo de garantia. A partir daqui torna-se impossível decidir da localização sistemática do dolo e da negligência no âmbito do tipo de ilícito ou antes no da culpa.

§ 59 Exacto é sim que os elementos do tipo devem ser desenvolvidos a partir da **essência da antijuridicidade** ([81]), que a essência da antijuridicidade se revela decisiva na determinação dos elementos do tipo. Logo no sentido de que importa *sempre* tomar em conta, para além do desvalor do resultado do comportamento, os elementos configuradores do *desvalor da acção*, através do qual esta surja como obra de uma pessoa ou, neste sentido, ligada a um "centro ético de imputação": todo o ilícito penal é ilícito *pessoal*. Ora, para além das realizações típicas dolosas ou negligentes — no sentido, quanto às primeiras, de que o agente previu e quis a realização, e, quanto às segundas, de que ele violou um dever objectivo de cuidado e criou um risco não permitido — é o domínio do acaso ou do acontecimento natural, em suma, é o domínio onde se torna impossível a recondução da realização típica à *pessoa* do autor. Podendo por isso sem mais concluir-se que o dolo e a negligência, na acepção referida, são **elementos constitutivos do tipo (subjectivo) de ilícito**.

§ 60 O que se torna particularmente visível e impressivo, de resto, quando se considera a figura da *tentativa*. Sem uma referência ao dolo como "dolo do tipo", isto é, como conhecimento e vontade de realização de um tipo de ilícito objectivo determinado, não é possível fundamentar tipicamente o ilícito da tentativa, não é possível, por outras palavras, conferir-lhe a função de tipicização do ilícito. Se, *v. g.*, *A* penetra sem autorização na casa de uma mulher e a agarra e atira ao chão, sendo todavia impedido de continuar a acção pelo marido ou pela polícia que acorre aos seus gritos, é de todo impossível, sem apelo ao mundo de representação e à vontade do agente, determinar se estamos face a uma tentativa de roubo, de ofensa à integridade física, de homicídio, de violação sexual... ([82]) (infra, 28.º Cap., §§ 5 e 10 e ss.).

([81]) JESCHECK /WEIGEND, nota anterior.

([82]) No sentido desta consideração, já, DIAS, Figueiredo, *Responsabilidade pelo Resultado e Crimes Preterintencionais*, 1961, p. 57 e s. Cf., também, ROXIN I, § 10, n.º 64.

§ 61 Só que isto é uma coisa, outra diferente seria saltar dela para a conclusão de que dolo e negligência em sentido jurídico-penal são, na sua **integralidade conceptual**, elementos do tipo (subjectivo) de ilícito. Tal conclusão seria precipitada e, em nossa opinião, em definitivo incorrecta. Como já ficou assinalado, prevendo a lei diferentes molduras penais que se distinguem na sua aplicação apenas porque os factos a que cabem foram cometidos com dolo ou antes com mera negligência (ou, como muitas vezes acontece, punindo a lei o facto doloso e deixando impune o facto negligente correspondente), isso só pode significar — de acordo com o princípio da culpa e a sua função no sistema — que o que distingue as duas formas de comportamento tem de ser (ou, pelo menos, tem de ser **também**) uma **diferença de culpa** ([83]). Por outras palavras, dolo e negligência têm de ser considerados como entidades que em si e por si mesmas exprimem ou revelam diferentes conteúdos materiais de culpa, cada um com o seu significado e os seus critérios próprios.

§ 62 Como então conceitualizar e integrar sistematicamente dolo e negligência, perante exigências à primeira vista contraditórias? O que atrás ficou dito só **exclui duas posições extremas**: uma é que aquelas entidades possam ser — como sustentava a doutrina ortodoxa da acção final ([84]) — de todo estranhas à valoração da culpa ou ao tipo de culpa e relevar exclusivamente ao nível do tipo de ilícito subjectivo; outra é que — como sustentava a doutrina normativista ([85]) — dolo e negligência sejam exclusivamente elementos da culpa, sem qualquer relevância ao nível do tipo de ilícito. Dentro destas posições extremas ficam porém ainda em aberto possibilidades diversas de conceitualização e sistematização. Pode nomeadamente defender-se que dolo e negligência constituem primariamente elementos do tipo de ilícito subjectivo, que mediatamente relevam também como graus de culpa; e nesta acepção se fala hoje na doutrina alemã, cada vez com maior insistência, de uma **localização**, de uma **função** e de uma **valoração duplas**, sobretudo do dolo (mas também da negligência) no sistema ([86]). Como se

([83]) Nesta linha de pensamento, ROXIN, nota 27, p. 109 e ss., da tradução portuguesa. De forma mais atenuada, ROXIN I, § 10, n.º 69.

([84]) Cf., sobretudo, WELZEL, § 22, III, e HIRSCH, *Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen. Der Irrtum über einen Rechtsfertigungsgrund*, 1960, p. 345.

([85]) Assim, CORREIA, Eduardo, I, pp. 252 e 321 e s., e FERREIRA, Cavaleiro de, I, p. 206 e s.

([86]) Pioneiro, nesta via, GALLAS, nota 25, p. 63. Agora, sobretudo, JESCHECK, § 24, III, 5, e HÜNERFELD, nota 39, p. 233 e ss., e nota 13, p. 1000 e ss.; qualquer deles nos inserindo expressamente entre os adeptos desta concepção.

pode sustentar que dolo e negligência são entidades complexas, englobando um conjunto de elementos constitutivos dos quais **uns relevam ao nível do tipo de ilícito subjectivo, outros ao nível do tipo de culpa** (87).

§ 63 Reputamos **esta última** a forma **teleologicamente mais correcta e funcionalmente mais adequada** de decidir a questão sistemática aqui implicada, de harmonia com os dados jurídico-substanciais do problema. Exacto é que o *conhecimento e vontade de realização do tipo de ilícito objectivo* (o "*dolo do tipo*", "*dolo do facto*" ou "*dolo natural*") — correspondente aliás a uma das possíveis compreensões da categoria da finalidade (88) — deve ser visto como *elemento constitutivo do tipo de ilícito subjectivo doloso*; enquanto a *violação do dever objectivo de cuidado* deve ser tida como *elemento constitutivo do tipo de ilícito negligente*. Por outra forma não se dá resposta cabal e convincente às exigências de compreensão hoje postas por numerosos problemas da doutrina do crime; e mais do que isso não é exigido por uma concepção *pessoal* do ilícito como a que defendemos.

§ 64 Mas, da mesma forma que — como é em geral reconhecido — a negligência se não esgota na violação de um dever objectivo de cuidado, também o dolo se não reduz ao conhecimento e vontade de realização do tipo de ilícito objectivo; antes, num caso como no outro, a estes elementos acresce uma autónoma **atitude interior**, um específico *Gesinnung*, que não podem ser retirados à culpa (infra, § 71) (89). Desta perspectiva se aceitará que a doutrina da "dupla valoração" do dolo e da negligência no sistema, se bem que apontando para uma meta construtiva essencialmente correcta, não seja a que melhor exprime a realidade das coisas: não é *o* dolo e *a* negligência que sofrem uma dupla valoração no sistema, uma em sede de tipo de ilícito e outra em sede de tipo de culpa; é sim **a dupla valoração do ilícito e da culpa que intervém na completa modelação do dolo e da negligência**. Ou encaradas as coisas de uma perspectiva substancial: a

(87) Logo assim, na esteira de Gallas, DIAS, Figueiredo, nota 81, pp. 55 e ss. e 64 e ss. E também SCHÜNEMANN, Die deutschsprachige Strafrechtswissenschaft..., *GA*, 1985, p. 364, todavia em sentido muito diferente da nossa posição, defendendo que o elemento intelectual do dolo pertence ao tipo de ilícito e o elemento volitivo ao tipo de culpa dos delitos dolosos.

(88) E, na verdade, correspondente à sua compreensão mais lata, que abrange o conteúdo de ilícito da própria negligência consciente. No mesmo sentido, GALLAS, nota 25, p. 57 e ss.

(89) Minuciosamente sobre esta concepção, o nosso *O Problema*, § 14, II, e infra, 3.2.

doutrina da dupla valoração falha quando considera, ou ao menos pressupõe, que o dolo e a negligência, no seu relevo para a culpa, não acrescentam elementos autónomos aos respectivos conteúdos de ilícito, mas apenas indicam a valoração dos mesmos objectos segundo um diferente ponto de vista. Exacto é, pelo contrário que o "dolo da culpa", bem como a "negligência da culpa" supõem um alargamento (e, na verdade, um enriquecimento) dos substratos da valoração relativamente aos correspectivos "dolo do tipo" ou "negligência do tipo". Esta *diferente* concepção virá a revelar-se essencial para uma correcta solução de problemas normativo-*práticos* como os da falta de consciência do ilícito (na doutrina do dolo) ou da violação do dever objectivo de cuidado por agente destituído da capacidade pessoal necessária ao seu cumprimento (na doutrina da negligência).

3.2. O tipo de culpa

3.2.1. Significado e função da culpa na construção da doutrina do facto punível

§ 65 A categoria da culpa jurídico-penal adiciona um novo elemento (uma nova qualificação) à acção ilícita-típica, sem o qual *nunca* poderá falar-se de facto punível com uma pena criminal. Este não se esgota na aludida desconformidade com o ordenamento jurídico-penal, necessário se tornando sempre que a conduta seja culposa, isto é, que **o facto possa ser pessoalmente censurado ao agente, por aquele se revelar expressão de uma atitude interna juridicamente desaprovada e pela qual ele tem por isso de responder perante as exigências do dever-ser sócio-comunitário** (90). A função que ao conceito de culpa cabe no sistema do facto punível é por isso (e foi mérito de Roxin, como já por diversas vezes se pôs em relevo, tê-lo claramente acentuado nos nossos tempos (91)) uma **função limitadora do intervencionismo estatal**, visando defender a pessoa do agente de excessos e arbitrariedades que pudessem ser desejados e praticados pelo poder do Estado. Uma função — pode pois dizer-se — que se inscreve na vertente *liberal* do Estado de Direito e reconduz o conceito de

(90) Cf. o nosso *O Problema*, § 10 e ss., e *Liberdade*, *passim*.

(91) ROXIN, sobretudo a partir das suas Kritische Überlegungen zur Schuldprinzip, *MschrKrim*, 1973, p. 316 (tradução espanhola de Muñoz Conde, na colectânea *Culpabilidad y prevención en derecho penal*, 1981, p. 41).

culpa jurídico-penal a uma *valoração político-criminal fundamental*. Assim se devendo afirmar, também relativamente à culpa jurídico-penal — como, de resto, a todas as categorias integrantes da noção de facto punível —, que ela não constitui uma realidade ôntica, ou uma noção normativamente determinada, mas antes funcionalmente cunhada a partir de uma valoração político-criminal.

§ 66 E todavia, quando se aprofunde a indagação sobre o **fundamento** da exigência da culpa, logo deverá concluir-se que o conceito, segundo o *conteúdo material* que lhe cabe, não é funcionalmente determinado a partir de uma perspectiva sistémico-social, mas exprime uma *realidade axiológica* (uma valoração ética) insusceptível de manipulação utilitarista, quer dizer, em nome de razões de conveniência ou de eficiência ao nível do sistema social. Aquele conteúdo constitui uma decorrência do "axioma antropológico" ([92]) e ao mesmo tempo do princípio primário do quadro axiológico próprio do Estado de Direito; e do princípio mais "absoluto", pode também dizer-se (no sentido de que ele não consente nenhuma violação): o princípio do **respeito pela eminente dignidade da pessoa**. Desta perspectiva se podendo afirmar que o princípio da culpa — o princípio segundo o qual "não há pena sem culpa e a medida da pena não pode ultrapassar a medida da culpa" — deve constituir um princípio de direito constitucional próprio de todos os ordenamentos jurídicos dos Estados democráticos (supra, 4.º Cap., § 70).

§ 67 A argumentação que acaba de desenvolver-se foi até há pouco tempo obscurecida pela ligação, que se pensava necessária e se tomava praticamente por indiscutível, entre **pena da culpa** e **pena retributiva**, e que conduzia a considerar a culpa não só como *limite*, mas (e sobretudo) como *fundamento da pena*; como conduzia, consequentemente, a reputar-se que entre culpa e pena se verificaria uma relação biunívoca ou de mútua implicação. Com esta concepção, aliás inexacta (supra, 4.º Cap., § 7), nada se ganhava porém no caminho desejado de uma "eticização" do conceito de culpa; e tudo se perdia no correcto entendimento da função do conceito de culpa no sistema do facto punível. Com efeito, e antes de tudo, a pena não é instrumento de justiça retributiva, mas de prevenção geral e especial. Depois, indissociavelmente ligada embora à sua função no sistema, a culpa tem o seu fundamento, como fica dito, na preservação da eminente dignidade da pessoa, é deste modo lídima expressão

([92]) Na já referida expressão de MELO, Barbosa de, *Democracia e Utopia*, 1980, p. 17. De um "fundamento antropológico da culpa" falam também, na literatura brasileira, ZAFFARONI / / PIERANGELI, p. 609.

— se quisermos dizer assim, pedindo os termos à doutrina luhmanniana — de um "*sistema pessoal*" que não apenas "irrita", mas, como "sistema de contacto", verdadeiramente *limita* o funcionamento do sistema social: todas as exigências "éticas" decorrentes do axioma antropológico podem e devem por isso encontrar guarida no conceito de culpa jurídico-penal, sem que a tanto se oponha (mas, bem pelo contrário, a tanto obrigue) a função que aquela cumpre no sistema do facto punível.

§ 68 Não há por conseguinte, em última análise, contradição alguma (93) entre afirmar, por um lado, que a culpa jurídico-penal se encontra funcionalizada ao sistema, que ela constitui, neste sentido, um conceito **funcional**; e defender, por outro lado, que ela participa, segundo o seu conteúdo, de uma **culpa ética** (que num certo sentido se poderia dizer "originária") como violação pela pessoa do dever essencial que lhe incumbe de realização, desenvolvimento e promoção do ser-livre (do dela e do das outras) (94). Esta conclusão, em que radica o núcleo irredutível do princípio da culpa, serve para recusar definições com ela incompatíveis e, por outro lado, de guia na determinação do conteúdo material do conceito de culpa como elemento constitutivo do facto punível (infra, 19.º Cap., § 4 e ss.).

§ 69 Incompatível com a conclusão obtida é logo, decerto, a posição daqueles críticos mais radicais do direito penal que continuam a preconizar a sua **abolição** e a sua integral substituição por um sistema de medidas profiláctica, de tratamento ou de ajuda social (95). Mas é também a daqueles outros que, renunciando à culpa como elemento autónomo do conceito de facto punível, pretendem por via diferente manter no essencial as suas consequências em matéria de limitação da responsabilidade. Para o que bastaria, segundo Gimbernat, um correcto entendimento das **exigências da prevenção**; ou, segundo Ellscheid e Hassemer, a invocação do princípio jurídico-constitucional da **proporcionalidade**; ou no máximo, segundo Jakobs, a manutenção da culpa tão-só como puro **derivado da prevenção** (96). O defeito comum a todas estas

(93) Concluindo por outra forma, ALBUQUERQUE, Pinto de, *Introdução à Actual Discussão sobre o Problema da Culpa em Direito Penal*, 1994, p. 71 e ss., e Ein unausrotbares Missverständnis, *ZStW 110*, 1998, p. 640.

(94) Minuciosamente, DIAS, Figueiredo, *Liberdade*, p. 155 e ss.

(95) E de que uma das últimas manifestações é, no campo do pensamento sociológico geral, a de FOUCAULD, *Surveiller et punir*, 1975, e, no âmbito especificamente jurídico-penal, as de PLACK, *Plädoyer für die Abschaffung der* Strafrecht, 1974 e de L. HULSMANN: cf. HULSMANN / DE CELIS, *Peines perdues. Le système pénal en question*, 1982, e, sobre este, ZAFFARONI, *En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmatica jurídico-penal*, 1989.

(96) Cf., respectivamente, GIMBERNAT Ordeig, Hat die Strafrechtsdogmatik eine Zukunft?, *ZStW 82*, 1970, p. 379 (versão espanhola na *Revista de Ciencias Penales*, 1973, p. 30), e Zur Strafrechtssystematik auf der Grundlage der Nichtbeweisbarkeit der Willensfreiheit, *Henkel-FS*,

orientações reside, em nosso juízo, em não reconhecerem o fundamento da culpa no aludido "axioma antropológico" da eminente dignidade da pessoa, que nada tem a ver com a qualidade e a quantidade de eventuais exigências preventivas. Colocando aquela grandeza absoluta na dependência de exigências de prevenção, necessariamente relativas, está-se, *volente nolente*, a furtar à culpa a sua capacidade *limitadora* de eventuais arbitrariedades estaduais; e, com isto, é a precípua *função* da culpa no sistema que se põe definitivamente em questão. Decerto, já se acentuou (5.º Cap., § 31), a culpa não é a *única* forma pensável de defesa daquela dignidade (como logo o revela a legitimidade de aplicação de reacções criminais — das medidas de segurança — que não supõem a culpa); mas é em todo o caso *a mais perfeita e a mais forte* que o pensamento jurídico-penal até hoje descobriu e o penhor mais seguro de que as exigências da prevenção geral de integração e da prevenção especial de socialização se legitimem perante o agente imputável. Por isso se deve ver no princípio da culpa uma autêntica máxima de civilização e de humanidade; e por isso, já se disse, se não descortina ainda hoje alternativa válida para ele.

3.2.2. Tipos de culpa, dolo e negligência

§ 70 Sendo função do princípio da culpa indicar um máximo de pena que em nenhum caso pode ser ultrapassado, e prevendo a lei diferentes molduras penais para o mesmo facto, consoante ele tenha sido cometido com dolo ou só com negligência, importa reconhecer que no dolo e na negligência se trata de entidades que já em si mesmas revelam **diferentes conteúdos materiais de culpa** que o direito penal entende **graduar** ou **tipificar** (97). Nos quadros da concepção acabada de apresentar a exigência de dolo ou de negligência quer significar que, fora destes, não se torna possível considerar documentada no facto uma personalidade censurável, isto é, desconforme, na sua actuação, com a suposta pela ordem jurídica. O problema será então o de determinar como se traduzem o dolo e a negligência em termos de uma atitude pessoal censurável, se tanto aquele — enquanto

---

1974, p. 151 (versão espanhola em *Estudios de Derecho Penal*, ³1990, p. 162); ELLSCHEID / HASSEMER, Strafe ohne Vorwurf, *in*: Lüderssen / Sack (orgs.), *Seminar: Abweichendes Verhalten*, II, 1, 1975, p. 266; e JAKOBS, *Schuld und Prävention*, 1976, p. 7 (versão espanhola em JAKOBS, *Estudios de derecho penal*, 1997, p. 73 e ss.).

(97) Passos essenciais para esta compreensão de que também a culpa jurídico-penal se exprime através de tipos de culpa ficam a dever-se a GOLDSCHMIDT, Normativer Schuldbegriff, *Frank-FG*, I, p. 461 e ss., ENGISCH, Der Unrechtstatbestand im Strafrecht, *DJT-FS*, II, p. 413, GALLAS, nota 25, pp. 29 e 45, e TIEDEMANN, *Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht*, 1969, p. 229. Cf., agora, JAKOBS, 17/43, e JESCHECK / WEIGEND, § 42. Contra, obviamente, os propugnadores de uma doutrina final da acção: M / ZIPF, I, § 24, n.º 2, e WELZEL, § 10, III. Sobre toda a questão cf., também, infra, 20.º Cap., especialmente § 4.

previsão e vontade de realização do tipo objectivo de ilícito —, como esta — enquanto falta de previsão ou de correcta previsão da realização típica — parecem relacionados só com realidades puramente psicológicas, como tais irrelevantes para caracterizar a pessoa do agente.

§ 71 Uma resposta satisfatória alcança-se apenas — como já ficou sugerido — quando se relacionam aquelas formas de realização do tipo com a **atitude pessoal** ou a **posição íntima** do agente, com o seu *Gesinnung* (98), perante o dever-ser jurídico-penal: daí devem elas receber a sua determinação decisiva em termos de culpa. Sem dúvida, o dolo é conhecimento e vontade de realização do tipo objectivo e a negligência violação de um dever de cuidado e criação de um risco não permitido; e, nesta parte, aquele e esta são elementos constitutivos do tipo de ilícito. Mas o dolo é ainda expressão de uma atitude pessoal de **contrariedade** ou **indiferença** e a negligência expressão de uma atitude pessoal de **descuido** ou **leviandade** perante o dever-ser jurídico-penal; e, nesta parte, eles são elementos constitutivos, respectivamente, do tipo de culpa dolosa e do tipo de culpa negligente. Não se trata, em suma, de afirmar que dolo e negligência enquanto elementos do tipo de ilícito devam relevar *automaticamente*, ao nível da culpa, como expressões respectivas de uma certa atitude pessoal perante as exigências jurídico-penais. Do que se trata é de encontrar um *conteúdo material de culpa* cabido não como puro "reflexo" das respectivas formas do tipo de ilícito, mas como algo de *autónomo* relativamente a elas, algo que as completa, as afeiçoa e as conforma praticamente e se torna assim em momento decisivo de aplicação das molduras penais respectivas.

3.2.3. As questões da "culpa" e da "responsabilidade" na sua expressão sistemática

§ 72 Desde o momento em que a culpa jurídico-penal se normativizou e o seu conteúdo passou a reduzir-se à capacidade de o agente se determinar pela norma, instalou-se na doutrina uma perceptível tensão entre o ver nela um juízo radicalmente individualizado e o aceitar ainda uma sua qual-

(98) Sobre o conceito em geral recomenda-se, como particularmente clara, a exposição de GUARDINI, *O Mundo e a Pessoa. Ensaio para uma Doutrina Cristã do Homem* (tradução portuguesa de Fernando Gil, 1963), p. 245. Vendo aqui um elemento essencial de toda a culpa jurídico-penal, entre outros, GALLAS, nota 25, p. 45, e JESCHECK / WEIGEND, §§ 38 e 39.

quer *generalização* (infra, 19.º Cap., I e II). Foi por isso na questão das *causas de exclusão da culpa*, nomeadamente das que podem reunir-se sob a epígrafe da *inexigibilidade* ou, mais concretamente, do *estado de necessidade desculpante*, que teve origem uma revisão profunda da sistemática da culpa, geradora de uma problemática ainda hoje não completamente solucionada ([99]). Aqui residiu a mais funda razão (comum de dois) que levou Maurach a intercalar no sistema, entre as categorias da ilicitude e da culpa, a da *Tatverantwortung* ("**responsabilização pelo facto**" ([100])) e Roxin — num sentido sistematicamente inverso — a preconizar a integração sistemática do conceito tradicional de culpa numa categoria complexa, constituída pela culpa tradicional e pela carência de pena, a categoria da *Verantwortlichkeit* ("**responsabilidade**") ([101]).

§ 73 Independentemente de uma análise mais detida das razões materiais subjacentes a estas propostas sistemáticas ([102]), continuamos a considerar ([103]) fundada a crítica segundo a qual na categoria da responsabilização pelo facto ou da responsabilidade se misturam, embora em medidas diferentes, coisas diversas e porventura nem sempre conciliáveis ([104]). Não é só — ou nem é tanto — o sentido emblemático (e todavia, como se disse, político-criminalmente insubstituível) da culpa que assim se esbate. Aquilo a que deste modo se abre a porta é à eventual **confusão dos dois planos de análise** que ali se entrecruzam, podendo verificar-se uma intromissão perturbadora de considerações de prevenção ao nível do próprio juízo de culpa, e, assim, a manipulação e perversão do significado político-criminal que reveste a consagração daquele juízo. E mais ainda: o não se man-

([99]) DIAS, Figueiredo, Sobre o estado actual da doutrina do crime, 2.ª parte. Sobre a construção do tipo de culpa e dos restantes pressupostos da punibilidade, *RPCC 2*, 1992, p. 21 e ss., e Resultate und Probleme beim Aufbau eines funktionalen und zweckrationalen Systems, *in*: Schünemann / Dias, Figueiredo, nota 32, p. 363.

([100]) MAURACH, *Schuld und Verantwortung*, 1948. Cf., depois, M / ZIPF I, § 31 e ss.

([101]) ROXIN, pela primeira vez em "Schuld" und "Verantwortlichkeit" als strafrechtliche Systemkategorien, *Henkel-FS*, 1974, p. 171 (tradução espanhola de Luzón Peña na colectânea *Culpabilidad y prevención en derecho penal*, 1981, p. 57); cf., depois, ROXIN I, § 19, e, por último, nota 33, p. 890 e ss.

([102]) E que, em rigor, deverá ter lugar em sede de inexigibilidade, em particular de estado de necessidade desculpante (infra, 22.º Cap., § 3 e ss.).

([103]) Mesmo tendo na conta devida o contraditório, dirigido à nossa crítica, de ROXIN I, § 19, n.º 9.

([104]) ANDRADE, Costa, A "dignidade penal" e a "carência de tutela penal" como referências de uma doutrina teleológico-racional do crime, *RPCC 2*, 1992, p. 201 e ss.

terem completamente distintas as exigências da culpa e as da prevenção subverte completamente o *modelo de determinação da medida da pena*. O que é particularmente grave em direitos como o português — e também o alemão —, em que o CP manda que aquela determinação seja feita em função da culpa *e* da prevenção (art. 71.º-1).

3.3. A punibilidade

§ 74 Com o tipo de ilícito e o tipo de culpa não se esgota o conteúdo do sistema do facto penal, antes se torna indispensável completá-lo com uma outra categoria, que bem poderá chamar-se da "punibilidade" (infra, 26.º Cap.). E se se perguntar qual é a ideia-mestra que dentro desta categoria actua e lhe empresta unidade, sentido político-criminal e consistência dogmática, essa ideia parece ser, à luz de um pensamento teleológico-funcional e racional, a da **dignidade penal**. Ela permite que hipóteses tão diversas como a da impunibilidade da desistência da tentativa, de factos bagatelares, do auxílio ao suicídio ou dos crimes falimentares quando o suicídio ou a falência não vêm a ter lugar, sejam remetidos para o denominador da falta de dignidade penal; porque do que em qualquer destes casos se trata é de que, apesar da realização integral do tipo de ilícito e do tipo de culpa, a "**imagem global do facto**" é uma tal que, em função de exigências preventivas, o facto concreto fica aquém do limiar mínimo da dignidade penal. E sem que contra isto se levante o argumento de que já os conceitos de tipicidade e de ilicitude ou antijuridicidade devem abarcar somente comportamentos dignos de pena. Porque um tal argumento parece esquecer, para além do mais, que não é impossível (nem sequer é raro na nossa disciplina: assim sucede com princípios como o de que *ad impossibilia nemo tenetur* ou o da própria *inexigibilidade*: infra, 26.º Cap., § 7, e 22.º Cap., § 1 e ss.) que a mesma máxima constitua um princípio jurídico *regulativo*, implicado na conformação de várias categorias dogmáticas, mas venha depois a precipitar-se ou concretizar-se como princípio jurídico *material (ou normativo)* primário de uma delas.

§ 75 A "punibilidade", de resto, não significa ainda que, uma vez ela presente, terá *inevitavelmente* lugar a aplicação de uma reacção criminal (pena ou medida de segurança). Em vez de se dizer que a verificação dos pressupostos de punibilidade determina imediatamente a punição, melhor se dirá que com uma tal verificação se perfecciona o *Tatbestand* (no sentido da Teoria Geral do Direito), que **faz entrar em jogo a conse-**

quência jurídica e a sua doutrina autónoma. Pois pode acontecer que a punição acabe por não dever efectivar-se por razões que já nada têm a ver com a doutrina do facto punível, mas autonomamente com a doutrina da consequência jurídica. Oposição esta que se exprime com meridiana clareza, no nosso direito penal, através do instituto da *dispensa de pena* regulado no art. 75.º

TÍTULO II

OS FACTOS PUNÍVEIS DOLOSOS DE ACÇÃO

SUBTÍTULO I

O TIPO DE ILÍCITO

SECÇÃO I

OS TIPOS INCRIMINADORES

11.º CAPÍTULO

O TIPO OBJECTIVO DE ILÍCITO

§ 1 Como se disse, se tanto os tipos incriminadores, como os tipos justificadores concorrem na concretização de um sentido de ilicitude material de que se reveste uma concreta conduta, não deixam todavia de interceder entre uns e outros diferenças de sentido e de conteúdo, teleológicas e sistemáticas. Há por isso claras vantagens em que, também de um ponto de vista didáctico e expositivo, uns se distingam dos outros. Começaremos pois o nosso estudo pelos **tipos incriminadores**. Estes tipos de ilícito apresentam, nos *delitos dolosos de acção* agora em análise, uma estrutura complexa, composta por elementos de natureza objectiva e de natureza subjectiva e com os quais é possível construir um *tipo objectivo* e um *tipo subjectivo*. No **tipo objectivo** importa por um lado identificar um certo número de problemas gerais directamente relacionados com a função e o sentido da tipicidade (**A**), por outro lado sublinhar algumas técnicas e procedimentos usados pelo legislador na construção e na arrumação sistemática dos tipos incriminadores (**B**).

A. QUESTÕES GERAIS DE TIPICIDADE

I. Determinações conceituais: tipo de garantia, tipo de erro e tipo de ilícito

§ 2 Sobre as questões do sentido dogmático e do valor sistemático do conceito de tipo de ilícito (incriminador), bem como das suas relações com a categoria da ilicitude, englobada na categoria fundamental do *tipo de ilícito*, já supra, 10.º Cap., §§ 50-57, nos pronunciámos. Mas antes de estudarmos a estrutura do tipo de ilícito objectivo importa clarificar a pluralidade de sentidos com que na dogmática penal se utiliza a categoria do **tipo**, introduzida pela primeira vez na dogmática por Beling (1). O erro deste foi o de pensar que *o mesmo* conjunto de elementos poderia cumprir simultaneamente as diversas funções que na tríplice conceitualização a que procederemos vão implicadas. Sabe-se hoje que assim não é, de tal modo que a distinção dos sentidos do "tipo" representa um momento absolutamente essencial de uma correcta aplicação da lei penal.

§ 3 O tipo apresenta-se, antes de tudo, como **tipo de garantia** — também por vezes chamado, com propriedade, **tipo legal de crime** —, isto é, como o conjunto de elementos, exigido pelo art. 29.º da CRP e pelo art. 1.º do CP, que a lei tem de referir para que se cumpra o conteúdo essencial do princípio *nullum crimen, nulla pœna sine lege*. Trata-se de um conjunto de elementos que se distribuem pelas categorias da ilicitude, da culpa e da punibilidade (e inclusivamente em certa medida, também, dos pressupostos processuais): em qualquer uma destas categorias se depara com requisitos de que depende em último termo a punição do agente e relativamente aos quais por isso tem de cumprir-se a função da lei penal como *Magna Charta* dos cidadãos. É este o conteúdo e é esta a função que ao tipo de garantia cabem dentro do sistema da justiça penal.

§ 4 Diferente é o conceito de **tipo de erro**. Trata-se neste do conjunto de elementos que se torna necessário ao agente conhecer para que possa afirmar-se o dolo do tipo, dolo do facto ou "dolo natural". Este tipo não se confunde nem com o tipo de garantia, nem com o tipo de ilícito: dele fazem parte, como se dirá (infra, 14.º Cap., II, 2.3, 15.º Cap., IV,

(1) Na sua monografia fundamental *Die Lehre vom Verbrechen*, 1906.

22.º Cap., II, 6), os pressupostos de uma causa de justificação ou de exclusão da culpa; bem como proibições cujo conhecimento seja razoavelmente indispensável para que o agente tome consciência da ilicitude do facto (art. 16.º-1 e 2), no sentido de que a sua não representação ou a sua representação incorrecta pelo agente exclui o dolo ou a punição a esse título. E todavia estes elementos não têm necessariamente de pertencer nem ao tipo de ilícito, nem ao tipo de garantia.

§ 5 O **tipo de ilícito** é a figura sistemática — por isso chamado às vezes, mas sem que o designativo traduza suficientemente a essência do conceito, "tipo sistemático" (2) — de que a doutrina penal se serve para exprimir **um sentido de ilicitude, individualizando uma espécie de delito** e cumprindo, deste modo, a função de dar a conhecer ao destinatário que tal espécie do comportamento é **proibida** pelo ordenamento jurídico. Sem prejuízo de, segundo a concepção atrás exposta, na questão (também metodologicamente essencial) do relacionamento entre tipicidade e ilicitude o "primado" caber à categoria da ilicitude, constituindo a tipicidade apenas a mostração, concretização ou individualização de um sentido de ilicitude em uma espécie do delito.

II. Desvalor de acção e desvalor de resultado

§ 6 Após as investigações dogmáticas de Welzel e o advento da doutrina da acção final tornou-se corrente a distinção, relevante em sede de ilícito típico, entre desvalor de acção e desvalor de resultado; até ao ponto de, consoante se tome um ou outro como ponto de arranque da dogmática do facto punível, assim se emprestar carácter à construção geral (3). Por **desvalor de acção** compreende-se o conjunto de elementos subjectivos que conformam o tipo de ilícito (subjectivo) e o tipo de culpa, nomeadamente a finalidade delituosa, a atitude interna do agente que ao facto preside e a parte do comportamento que exprime facticamente este conjunto de elementos. Por **desvalor de resultado** compreende-se a criação de um estado juridicamente desaprovado e, assim, o conjunto de elementos objectivos do tipo de ilícito (eventualmente também do tipo de culpa) que per-

(2) Assim, ROXIN I, § 10, A. Contra a autonomização de um tipo de garantia relativamente ao tipo de ilícito, SILVA, Marques da, II, p. 25: "não há, porém, um tipo de garantia".

(3) Importante, GALLAS, Zur Struktur des strafrechtlichen Unrechtsbegriffs, *Bockelmann-FS*, 1979, p. 155 e ss.

feccionam a figura de delito. De forma plástica, mas substancialmente correcta, se poderá dizer que o desvalor de acção se revela de forma exemplar na *tentativa* de crime, o desvalor de resultado no crime *consumado*. Por aqui se deixa perceber já como a distinção se cobre, no essencial, com a que intercede entre uma concepção **pessoal** e uma concepção puramente **objectiva** (material) do ilícito.

§ 7 Não falta quem, a partir daqui, tenha tentado uma construção de *toda* a dogmática do tipo a partir do **desvalor de resultado**. Esta tentativa foi ensaiada, sabemo-lo já (supra, 10.º Cap., § 7), pelos adeptos da construção clássica (positivista) da doutrina do facto punível, que pretendiam distinguir o ilícito da culpa fazendo daquele o reino da totalidade dos elementos objectivos (do "lado objectivo" do crime), desta o campo de convergência da totalidade dos elementos subjectivos (do "lado subjectivo" do crime). Esta concepção dogmática — fortalecida, numa consideração normológica, pela concepção da norma como *norma de valoração* (4) — ficou prejudicada desde o momento em que foi descoberta a relevância essencial, em muitos casos, de elementos subjectivos para a caracterização do ilícito (5). E seria definitivamente condenada por todos quantos aceitam que em caso algum o ilícito se pode caracterizar exclusivamente através do tipo objectivo, antes se lhe acrescenta sempre o respectivo tipo subjectivo. Seja embora a protecção subsidiária de bens jurídicos a função primária da intervenção penal, daqui não pode efectivamente deduzir-se que o ilícito se caracteriza apenas ou essencialmente pelo desvalor de resultado. Fosse assim e dificilmente se justificaria a punibilidade da *tentativa*; e todavia não há praticamente nenhum ordenamento jurídico-penal que deixe de consagrar a sua punibilidade (art. 23.º e infra, 27.º Cap. e ss.).

§ 8 Tão-pouco está destinada ao êxito a tentativa de perspectivar toda a construção da dogmática do facto punível — nomeadamente, do tipo de ilícito — a partir simplesmente do **desvalor de acção**, negando ao desvalor de resultado significado constitutivo e autónomo para o ilícito (6). Tal

(4) Cf. o nosso *O Problema*, § 6, III; e, em síntese, ROXIN I, § 10, n.º 91 e ss.

(5) Cf., em todo o caso, ainda, FERREIRA, Cavaleiro de, 1981, I, pp. 133 e ss. e 259 e ss., e COSTA, Faria, *O Perigo em Direito Penal*, 1992, p. 409[105].

(6) Como em data recente foi levada às últimas consequências, na doutrina alemã, por ZIELINSKI, *Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff*, 1973. Próximo, na conclusão, CAR-

seria fruto, do ponto de vista normológico, da essência *imperativa* da norma (7) e da ideia consequente de que objecto da proibição só podem ser acções, não resultados. Indiscutível é, no entanto, que na grande maioria dos casos não pode ver-se nos elementos objectivos do crime, nomeadamente no resultado, momentos estranhos à valoração da ilicitude e, a partir daí, irrelevantes para o respectivo tipo de ilícito e reduzidos, no máximo, à categoria de meras condições objectivas de punibilidade. Fosse assim e daí deveria decorrer a conclusão de que a *tentativa* deveria ser tão punida como a consumação; e não o é, antes é punível com a pena aplicável ao crime consumado, *especialmente atenuada* (art. 23.º-2 e infra, 28.º Cap., § 44). Como, por outro lado, a *negligência* devia ser punida logo na base da verificação de um comportamento contrário ao dever de cuidado; e não o é, antes em regra apenas quando sobrevem o resultado. A ilicitude e o seu conteúdo são pois diferentes consoante se verifique ou não lesão efectiva do bem jurídico.

§ 9 Como começou por dizer-se, o relevo do desvalor de acção foi enfatizado pelo **finalismo**: se a finalidade do actuar constitui o elemento essencial (ontológico) da acção, então ela tem de ser ao mesmo título momento integrante do tipo e do ilícito, justamente nesta acepção começando a falar-se desde então de um **ilícito pessoal**. Na formulação clássica de Welzel: "O ilícito não se esgota na causação do resultado (lesão do bem jurídico) dissociada da pessoa do agente, antes antijurídica é a acção apenas como obra de um determinado agente: quais os objectivos que este conferiu finalisticamente ao facto objectivo, a partir de que posição ele o cometeu, quais os deveres que em consequência o obrigam — tudo isto determina em larga medida o ilícito do facto ao lado da eventual lesão do bem jurídico. Antijuridicidade é sempre a desaprovação de um facto referido a um determinado agente. Ilícito é ilícito 'pessoal' da acção referido ao agente" (8).

§ 10 Esta concepção é de subscrever, tanto mais quanto ela é independente das premissas de uma concepção final da acção e pode fundar-se

---

VALHO, Taipa de, *A Legítima Defesa*, 1995, pp. 79 e ss., 107 e ss., 141 e ss.; mas — ao que nos pareceu — de forma mais moderada, II, p. 51 e s.

(7) Sobre a questão, de novo, o nosso *O Problema* § 6, III.

(8) WELZEL, § 12, II. Logo, também, DIAS, Figueiredo, *Responsabilidade pelo Resultado e Crimes Preterintencionais*, 1961, pp. 55 e ss., 63.

em considerações de outro teor, nomeadamente na necessidade de recurso ao tipo subjectivo de ilícito, desde logo, para individualização da espécie de delito (supra, 10.º Cap., § 60). A conclusão deve pois ser a seguinte: a constituição de um tipo de ilícito exige, por regra, **tanto um desvalor de acção, como um desvalor de resultado**; sem prejuízo de casos haver em que o desvalor de resultado de uma certa forma predomina sobre o desvalor de acção (máxime, nos crimes de *negligência*), ou em que inversamente o desvalor da acção predomina sobre o desvalor de resultado (máxime, nos casos de *tentativa*) ([9]). Em toda esta matéria são, uma vez mais, decisivas as opções legislativas de conformação dos tipos de ilícito, comandadas pelas proposições político-criminais que na regulamentação se pretendem vazar. Necessário será só prevenir que no contexto da presente discussão a expressão "resultado" vale como afectação da situação de *tranquilidade* do bem jurídico protegido e não (como na expressão "crimes de resultado": infra, § 37 e s.) enquanto *modificação* do substrato do bem jurídico, temporal e espacialmente cindida da acção ([10]). (Valendo a pena, no entanto, sublinhar desde já que, em princípio e na generalidade dos casos, quando neste livro se fale só de "resultado", sem outra especificação — nomeadamente, infra, § 37 e ss. —, se tem em vista o conceito relacionado com o *objecto de acção* e não com o estado do *bem jurídico*.)

III. Elementos típicos descritivos e normativos

§ 11 Para concretização da ilicitude que neles vive, os tipos incriminadores servem-se de elementos de dupla natureza: descritivos e normativos. Dizem-se **descritivos** os elementos que são apreensíveis através de uma actividade sensorial, isto é, os elementos que referem aquelas realidades materiais que fazem parte do mundo exterior e por isso podem ser conhecidas, captadas de forma imediata, sem necessidade de uma valoração. São ainda considerados como descritivos os elementos que exigem já uma qualquer actividade valorativa, mas em que é ainda prepon-

---

([9]) Doutrina hoje largamente dominante na Alemanha: JAKOBS, 6/69 e ss., JESCHECK / WEIGEND, § 24, III, 3, b), ROXIN I, § 10, n.º 88 e ss., S / S / LENCKNER, vor § 13, n.º 40.

([10]) Algo diferentemente, ROXIN I, § 10, n.º 99. Essencialmente como no texto, depois de um estudo aprofundado da questão, MONIZ, Helena, Aspectos do resultado em direito penal, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 541. Importante sobre este ponto (como sobre toda a questão) COSTA, Faria, Ilícito-típico, resultado e hermenêutica (ou o retorno à limpidez do essencial), *Problemas Fundamentais de Direito Penal. Homenagem a Claus Roxin*, 2002, pp. 25 e ss., 32 e ss.

derante a dimensão naturalística. Assim, por exemplo, são elementos descritivos a *pessoa* (art. 131.º), a *mulher grávida* (art. 140.º), o *corpo* (art. 143.º), o *automóvel* (art. 208.º). Elementos **normativos** são aqueles que só podem ser representados e pensados sob a lógica pressuposição de uma norma ou de um valor, sejam especificamente jurídicos ou simplesmente culturais, legais ou supralegais, determinados ou a determinar; elementos que assim não são sensorialmente perceptíveis, mas só podem ser espiritualmente compreensíveis ou avaliáveis. Por exemplo, o carácter *alheio* da coisa (art. 204.º), o *documento* para efeito do crime de falsificação de documentos (cfr. arts. 256.º e 255.º/*a*)), as *intervenções ou tratamentos* previstos no art. 156.º e as *dívidas ainda não vencidas* do art. 229.º são elementos normativos dos respectivos tipos incriminadores.

§ 12 A distinção entre elementos descritivos e normativos já foi considerada como **impossível** por normativistas exasperados ([11]): todos os elementos constitutivos de um tipo de ilícito seriam *normativos*, "enquanto todos concorrem para a expressão do integral juízo de valor que ele traduz" ([12]). Mas o reconhecimento de que todos os elementos do tipo são normativos porque "funcionalmente" referidos à valoração da ilicitude não deve impedir que eles "estruturalmente" se distingam consoante sejam ou não entidades relacionadas com uma norma ou um valor distintos dos que presidem à valoração da ilicitude. Mais recentemente, AA. há que renunciam à distinção por a considerarem **impraticável**, na medida em que nenhum elemento pode ser caracterizado como puramente descritivo ou normativo. Assim, Roxin — exemplificando com elementos como "pessoa" ou "coisa", que apesar de serem marcadamente descritivos impõem uma valoração jurídica, ou "documento", que tem sempre um suporte material perceptível pelos sentidos — conclui que "sob este ponto de vista, não importa tanto a (quase impossível) distinção entre elementos descritivos e normativos, quanto reconhecer que a maioria dos elementos do tipo são um misto de elementos normativos e descritivos" ([13]). Mas, não obstante a pertinência desta observação, sempre a distinção entre elementos descritivos e normativos fará sentido — e torna-se mesmo **indispensável** — quando tenha importância para a resolução dos casos concretos e para a cor-

([11]) Como, entre outros, WOLF, *Die Typen der Tatbestandsmässigkeit*, 1931.

([12]) CORREIA, Eduardo, I, p. 283; assim, também, FERREIRA, Cavaleiro de, *A Tipicidade na Técnica do Direito Penal*, 1935, p. 79.

([13]) ROXIN I, § 10, n.º 59.

recta determinação do regime jurídico a aplicar. E porque assim acontece, só a título de exemplo e como se dirá, em matéria de *dolo* e de *erro* (infra, 13.º Cap., § 10 e ss.), a distinção continua a ser feita pela generalidade da doutrina nos termos que acima traçámos e não deve, em última análise, ser abandonada.

IV. Tipos abertos, elementos valorativos globais e adequação social ([14])

1. A construção de Welzel

§ 13 Fica a dever-se a Welzel a chamada de atenção para certos tipos — ditos **tipos abertos** — a partir de cujo teor se não lograria deduzir por forma completa, mas apenas parcial, os elementos constitutivos do ilícito respectivo ([15]). Por outras palavras, tipos existiriam em que os elementos definidores da espécie de delito teriam de ser *completados*, para determinação da matéria proibida — não esgotantemente descrita na definição legal da conduta, mas de determinação necessária para integral preenchimento do tipo de ilícito —, por uma *valoração autónoma* levada a cabo pelo aplicador; valoração que, deste modo, se encontraria já fora do tipo e constituiria uma pura **regra de ilicitude**. Esse seria o caso mais evidente dos *tipos omissivos impróprios* (infra, 37.º Cap., § 12 e ss.) e mesmo dos *tipos negligentes* (infra, 35.º Cap., § 38); mas também de muitos tipos dolosos de acção, onde a esgotante determinação típica não se torna possível sem uma *completação da matéria proibida* quando muito só sugerida pelo legislador no teor literal daquele (*v. g.*, "abusivamente", no art. 306.º, "ilegitimamente", no art. 307.º, "legítimos", no art. 348.º, etc.).

§ 14 O relevo dogmático dos tipos abertos em sede de relações entre ilicitude e tipicidade, bem como em matérias de erro e de falta de consciência do ilícito é indiscutível. A sua consideração dogmática teve como efeito (e ainda aqui o pioneirismo pertence a Welzel) chamar a atenção ([16])

([14]) Sobre toda a matéria deste apartado é de grande importância a monografia de FARIA, Paula Ribeiro de, *A Adequação Social da Conduta no Direito Penal — ou o Valor dos Sentidos Sociais na Interpretação da Lei Penal*, 2003.

([15]) WELZEL, § 14, I, 2.

([16]) Ou, mais rigorosamente, de a inserir no espaço jurídico-penal alemão, porque o fenómeno era já conhecido e estudado pela doutrina penal italiana, embora em um outro contexto: cf. PULITANÒ, Illiceità espressa e illiceità speciale, *RitalDPP 10*, 1967, p. 65.

para a existência de elementos típicos que, possuindo embora uma *base fáctica individualizável*, todavia se revelam simultaneamente configurados como juízos de valor gerais ou **elementos valorativos globais**; e que nessa medida possuem um cunho de tal modo extremadamente normativo que praticamente arrastam consigo um **juízo de valor global** sobre a ilicitude da conduta ([17]). Com um exemplo paradigmático desta situação se depara no art. 154.º-3/*a)*, segundo o qual não será punível a acção descrita no n.º 1 (coacção) "se a utilização do meio para atingir o fim visado não for censurável" ([18]): a valoração como *censurável* da utilização do meio serviria assim para completar a matéria de proibição descrita no tipo objectivo de ilícito da coacção.

§ 15 Num contexto problemático e sistemático ainda fundamentalmente ligado às questões que acabam de ser referidas, acentuou também Welzel que todos os tipos incriminadores têm de ser interpretados como contendo uma cláusula restritiva (implícita) de **inadequação social**, a qual conduziria a excluir do tipo de ilícito todas as acções que, embora formal e contextualmente o preenchessem, todavia "não caem notoriamente fora da ordenação ético-social da comunidade" ([19]).

§ 16 Os **exemplos** seriam vários e de diversa ordem, uns de escola, outros retirados da experiência da vida diária: quem toma, por engano, um transporte de carreira que se dirige a destino diferente do desejado tem de sofrer a privação da liberdade durante todo o tempo da viagem; quem, na ausência do estalajadeiro, se serve de uma sanduíche que está sobre o balcão e se vai embora deixando o dinheiro correspondente ao preço, subtrai coisa móvel alheia; quem oferece uma pequena quantia ao carteiro que faz a distribuição usual do correio a título de lembrança de Natal dá uma vantagem patrimonial a funcionário para acto não contrário aos deveres do cargo;

([17]) Fundamental, ROXIN, *Offene Tatbestände und Rechtspflichtmerkmale*, ²1970 (tradução espanhola de Enrique Bacigalupo, *Teoria del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico*, 1979). Note-se, de resto, que era já de alguma maneira neste sentido — no sentido de "elementos impuros da fatispécie", que permitem aceder, logo ao nível do tipo, ao juízo integral sobre a ilicitude da conduta, que M. E. Mayer compreendia com autonomia a existência de elementos *normativos* do tipo e lhe permitia o acesso às "normas de cultura" na interpretação e definição do sentido típico: cf. SEEL, *Unbestimmte und normative Tatbestandsmerkmale im Strafrecht und der Grundsatz Nullum Crimen sine Lege*, 1965, p. 7, e GUZMÁN Dalbora, prólogo à sua tradução em espanhol de Mayer, M. E., *Normas jurídicas y normas de cultura*, 2000, p. 6.

([18]) Em sentido dogmaticamente algo diferente, mas — ao que nos pareceu — sem prejudicar em último termo as afirmações do texto, CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, I, art. 154.º, § 26.

([19]) WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, *ZStW* 58, 1939, pp. 516 e ss. e 527 e ss.

quem, no círculo familiar, conta que *A*, marido de *B*, arranjou uma jovem namorada com quem vai viver e a situação está a ocasionar uma picante crise matrimonial imputa factos ofensivos da honra e consideração de outra pessoa; quem legitimamente dirige comboios de alta velocidade, aviões supersónicos, é piloto de ensaios ou maneja os instrumentos de uma central nuclear, quem leva a cabo intervenções médicas curativas, procede a manipulações genéticas ou quem provoca a outrem lesões na participação em competições desportivas, maneja fontes de alto risco das quais derivam perigos para bens jurídicos alheios como a vida, o corpo ou a saúde. Porém em nenhum destes casos deverá ser dito, sem mais, que as acções respectivas preencheram os tipos de ilícito, respectivamente, do sequestro, do furto, da corrupção para acto lícito, da difamação, do homicídio ou da violação da integridade física. O que só poderia ser justificado considerando que em todos os tipos de ilícito vive (implicitamente) uma cláusula de ilicitude como a da inadequação social (20).

2. Apreciação crítica

§ 17 Todas estas construções — a dos "tipos abertos" e dos "elementos valorativos globais", como a da "adequação social" — são fruto de uma das mais penetrantes análises a que foi até hoje sujeito o conceito de tipo de ilícito que a Welzel fica a dever-se e apontam para **realidades que não podem ser escamoteadas, mas têm de ser tomadas em conta tanto do ponto de vista dogmático, como construtivo-sistemático** (21). Pode alegar-se — como hoje é porventura dominante — que a existência de verdadeiros tipos "abertos" representa uma *contraditio in adjecto*, porque o tipo supõe uma indicação esgotante, através de elementos descritivos ou normativos, da matéria proibida (22). Pode sustentar-se que os pretensos elementos de valoração global ou são meros elementos normativos, como tantos outros; ou constituem às vezes puras "menções redundantes de ilicitude", que servirão apenas para assinalar a frequência com que no caso intervirão singulares causas de justificação, menções que, por conseguinte, não possuem qualquer relevo a nível do tipo incriminador e deveriam ser pura e simplesmente eliminadas do respectivo teor literal (23). Pode alegar-se que resultados praticamente coincidentes com a famosa cláusula de (in)adequação social se obtêm ou através de uma correcta

(20) Para uma casuística mais ampla, FARIA, Paula Ribeiro de, nota 14, *passim*, especialmente p. 318 e ss.

(21) Em termos análogos FARIA, Paula Ribeiro de, nota 14, p. 78.

(22) Neste sentido, JESCHECK / WEIGEND, § 25, II, e ROXIN I, § 10, n.º 43 e ss.

(23) Sobre esta realidade — sobretudo num CP como o português de 1886, mas que não terá desaparecido integralmente no CP vigente —, o nosso *O Problema*, § 22 [29].

interpretação — máxime, de uma interpretação teleológico-funcional — de singulares elementos típicos, de sorte que aquela cláusula mais não representaria do que um *critério hermenêutico* que, em si mesmo, nada teria de particular; ou, noutros casos, através da doutrina, essencial em termos de imputação objectiva, do "risco permitido" (24).

§ 18 Tudo isto pode, com maior ou menor razão, ser afirmado. E todavia persiste a circunstância ineliminável de que em todos os casos que vêm de ser evidenciados o teor do objecto da proibição não integra *ab initio* o sentido de ilicitude que vive no tipo questionado; por outras palavras, sendo o tipo o portador de um sentido de ilicitude — sendo um tipo *de ilícito* —, em todas estas hipóteses deve logo ser negada a tipicidade da acção. O que só confirma a ideia de que, em sede de relações entre ilicitude e tipicidade, a *prioridade* ôntica, normativa e teleológica pertence ao *ilícito*, não ao tipo, e que este é só uma concretização ou mostração daquele. Juízos de ilicitude como os que estariam presentes nos chamados tipos abertos, nos elementos de valoração global, na cláusula da (in)adequação social só podem ser **momentos e critérios do juízo de ilicitude jurídico-penal**, prévios à tipificação, é certo, mas em todo o caso seus pressupostos e, por isso, substrato material do tipo. Se a valoração da conduta concreta como *ilícita* constitui o essencial da sua relevância jurídico-penal, então todos os critérios materiais que determinam a sua definitiva relevância ou irrelevância hão-se ser, antes de mais, critérios de ilicitude, só por esta (político-criminalmente, e portanto também teleologicamente) fundamentados e só a partir dela compreensíveis e determináveis.

§ 19 Tal porém não significa concordar com a ideia, em certa altura sufragada por Welzel, segundo a qual se trataria aqui de elementos que não fariam parte da categoria sistemática da tipicidade (recorde-se: para ele, como para tantos ainda hoje, o primeiro degrau construtivo do conceito de facto punível), mas unicamente do da ilicitude ou antijuridicidade; ideia que o levou (25) ao ponto de considerar a adequação social como uma "causa

(24) Pioneiro nesta direcção, HIRSCH, Soziale Adäquanz und Unrechtslehre, *ZStW 74*, 1962, p. 78. Cf., entre nós, FARIA, Paula Ribeiro de, A lesão da integridade física e o direito de educar — uma questão "também" jurídica, *in*: *Juris et de Jure*, 1998, pp. 906-912.

(25) Nomeadamente no seu *Lehrbuch*, entre a 4.ª e a 8.ª edições. À dificuldade apontada em texto se aliando a contradição de que se o sentido da acção provém da orientação final da

de justificação consuetudinária". Não cremos que seja assim: cláusulas como as que estão em exame só poderiam constituir causas justificativas à luz de um tipo valorativamente neutro, não de um tipo que exprime, antes de tudo e de forma *global*, um sentido jurídico-social de desvalor ([26]). Por isso, se as "regras de ilicitude", os "elementos valorativos globais", a "inadequação social" dizem respeito a uma concreta espécie de delito, então a circunstância de eles constituírem primariamente critérios de ilicitude não significa que, uma vez concretizados na medida possível, não passem a fazer parte constitutiva do tipo de ilícito respectivo como seus **elementos normativos**. Se o tipo de ilícito é *sempre* individualização de um sentido de ilicitude numa concreta espécie de delito, não fica espaço para elementos do facto que, participando do conteúdo de ilicitude de uma espécie de delito, não pertençam ao tipo; com indiferença pela forma como o legislador tenha concretizado um tal conteúdo, positiva ou negativamente, descrevendo a acção ou caracterizando o dever do agente, utilizando na medida possível elementos objectivo-factuais ou antes fórmulas gerais de valor ([27]). Só assim não sendo relativamente às referidas *menções redundantes de ilicitude*, se e onde elas infelizmente persistam: só estas — absolutamente inúteis e altamente perniciosas — são insusceptíveis de tradução em elementos individualizadores e não pertencem, por isso, ao tipo. De um ponto de vista de *técnica legislativa* deve portanto o legislador, em toda a medida possível, *decompor* aqueles elementos nos seus *pressupostos fácticos ou materiais que devem ser levados ao tipo*; e na sua *avaliação* ou *valoração* que, essa sim, não pertence ao tipo. Com o que — se o fizer e na medida em que o faça — terá prestado um serviço inestimável ao tratamento do erro e da falta de consciência do ilícito e à sua correcta distinção nos termos dos arts. 16.º e 17.º (infra, 20.º Cap., II).

---

conduta, não se lhe pode sobrepor uma valoração de natureza social contrária: havendo dolo, a conduta não pode ser tida tipicamente irrelevante, cf. já supra, 10.º Cap., § 32 *in fine*.

([26]) Essencialmente no sentido que se segue, já, o nosso *O Problema*, § 22, II. E agora, concluindo como no texto, a análise de FARIA, Paula Ribeiro de, nota 14, Cap. IV. Próxima nos pareceu, em conclusão, a posição de PEÑA, Luzón, Causas de atipicidad, *Problemas Fundamentais de Direito Penal, Homenagem a Claus Roxin*, 2002, p. 115, todavia conexionada (p. 119) com um pensamento próximo do de Günther (sobre ele, infra, 14.º Cap., § 10) acerca de uma ilicitude especificamente penal.

([27]) Exemplo claro do que dizemos é constituído pelo disposto no art. 150.º, que determina a atipicidade das intervenções e tratamento médico-cirúrgicos. Considerando este preceito como precipitação de uma cláusula de adequação social, torna-se todavia evidente que a sua actuação depende da verificação *in casu* dos diversos elementos fáctico-objectivos que a compõem. Cf., por último, FARIA, Paula Ribeiro de, nota 14, p. 319 e ss.

B. A CONSTRUÇÃO DOS TIPOS INCRIMINADORES

§ 20 Em qualquer tipo de ilícito objectivo é possível identificar os seguintes conjuntos de elementos: os que dizem respeito ao *autor*; os relativos à *conduta*; e os relativos ao *bem jurídico*. Com efeito, todos os tipos incriminadores devem, na sua revelação objectiva, precisar quem pode ser autor do respectivo tipo de crime; qual a conduta em que este se consubstancia; e, na medida possível, dar indicação, explícita ou implícita, mas sempre clara, do(s) bem(ns) jurídico(s) tutelado(s).

I. O autor

1. Princípio geral

§ 21 Elemento constitutivo de todo o tipo objectivo de ilícito nos delitos dolosos de acção é — apesar da natureza "subjectiva" ou "intersubjectiva" deste elemento — o **autor** da acção. Autor que será em princípio uma **pessoa individual**, mas que pode ser também — quando a lei *expressamente o determinar* — um **ente colectivo** (art. 11.º). São todavia pouco frequentes os casos em que a lei portuguesa consagrou até hoje a responsabilidade *penal* ([28]) de entes colectivos; mas, como em seguida se dirá, tudo indica que esses casos vão aumentar de forma sensível no futuro próximo. Seja como for, a verdade é que — e a circunstância deve sublinhar-se e saudar-se — o legislador português tomou clara posição na querela já antiga da responsabilidade penal dos entes colectivos, no sentido de **admitir** essa responsabilidade, ainda que não a título de regra ([29]).

2. A questão da responsabilidade penal dos entes colectivos

§ 22 Foi na viragem do séc. XVIII para o séc. XIX que se reafirmou o velho princípio do direito romano, não seguido na Idade Média, segundo

([28]) Diversamente do que sucede com a responsabilidade *contra-ordenacional*: o art. 7.º do DL 433/82, de 27-10 — "Ilícito de mera ordenação e respectivo processo" —, consagra com carácter geral a responsabilidade das "pessoas colectivas ou associações sem personalidade jurídica". Sobre isto e sobre quanto se segue neste apartado, por último, DIAS, Figueiredo, Quelques observations sur le problème de la responsabilité pénale des personnes morales en droit portugais, *Le droit pénal à l'aube du troisième millénaire, Mélanges Jean Pradel*, 2006, p. 753.

([29]) Diferentemente do que sucedeu com o novo CP francês de 1994, que consagrou uma extensa responsabilização penal das pessoas colectivas. Cf., a propósito, PRADEL, Jean, A responsabilidade penal das pessoas jurídicas no direito francês, *RBCC 6*, 1998, p. 51 e ss.

o qual **societas delinquere non potest**. A princípio, foi com base nas teorias da *ficção* da personalidade jurídica dos entes colectivos que se justificou a impossibilidade da sua responsabilização penal. Os grandes argumentos da dogmática penal para negar essa responsabilidade foram, porém, os da incapacidade de acção e da incapacidade de culpa dos entes colectivos. Estes seriam **incapazes de acção** porque não poderiam nunca agir por eles próprios, mas sempre e só através de pessoas físicas ([30]). Assim sendo, os entes colectivos não poderiam ser punidos criminalmente e passíveis de punição seriam aquelas pessoas singulares. Outro obstáculo seria a **incapacidade de culpa** dos entes colectivos ([31]). A culpa, entendida como um juízo de censura ético-pessoal, com fundamento na liberdade do homem, na sua vontade consciente e livre, seria própria das pessoas singulares. Os entes colectivos, porque incapazes de culpa, seriam desta forma — pelo menos à luz de um ordenamento, como o nosso, que se queira inteiramente respeitador do princípio da culpa — insusceptíveis de responsabilidade penal.

§ 23 Não podendo os entes colectivos cometer crimes, a responsabilidade criminal deveria ser imputada aos **indivíduos** que tivessem praticado esses actos **em nome ou no interesse** daqueles (art. 12.º). Mas este entendimento começou a ser posto à prova e a ser questionado no pós-guerra, com o crescimento exponencial da criminalidade desenvolvida no âmbito dos entes colectivos, nomeadamente da empresa. A dogmática penal que preconizava a responsabilidade exclusivamente individual começou a ver-se confrontada com exigências de política criminal, a apelar, por razões de eficácia no combate ao crime, à responsabilização penal dos entes colectivos *como tais*. O aparecimento de uma criminalidade cada vez mais organizada e complexa, desenvolvida através de sociedades comerciais, de instituições financeiras e das mais variadas formas de associação ou agrupamento, muitas vezes extremamente poderosas e com ramificações à escala global ("máfias" em sentido amplo), puseram em causa o princípio da responsabilização individual. Efectivamente, numa criminalidade deste

([30]) Assim, CORREIA, Eduardo, I, p. 234 e ss., todavia com concessões no domínio do que chamava "direito penal administrativo"; e ainda hoje a doutrina maioritária na Alemanha: ver, por todos, ROXIN I, § 8, n.º 59 e ss., e JESCHECK / WEIGEND, § 23, VII.

([31]) ASCENSÃO, Oliveira, *Estudos de Direito Bancário* (org. Menezes Cordeiro), 1999, p. 357, considera residir aqui "o ponto de maior gravidade" no âmbito da responsabilidade criminal dos entes colectivos, entendendo ser esta "uma figura equivocada e dispensável".

tipo torna-se extremamente difícil determinar a real responsabilidade de cada um dos indivíduos que opera no seio da colectividade e a produção de prova é tarefa quase impossível, em virtude da extrema dispersão do poder decisório, da grande divisão de tarefas e das longas cadeias hierárquicas ([32]). A manutenção da responsabilidade exclusivamente individual significaria em muitos casos a impunidade, com consequências sociais extremamente danosas, sobretudo, como já se acentuou, numa sociedade como a contemporânea e seguramente a futura ("sociedade do risco": supra, 6.º Cap., § 49 e ss.).

§ 24 Em face destas razões de **política criminal**, em numerosos países o legislador começou a abrir brechas no princípio *societas delinquere non potest*, especialmente no âmbito dos crimes económicos, ambientais e fiscais. Tal sucedeu em Portugal com o DL 630/76, de 28-7, e sobretudo com o DL 28/84, de 20-1, que regula as infracções contra a economia e contra a saúde pública ([33]). Esta tendência foi acompanhada pela doutrina, que não apenas reconheceu a absoluta necessidade de uma diferente intervenção penal a este nível, como procurou uma nova **fundamentação dogmática** que legitimasse materialmente a responsabilização penal dos entes colectivos. Porque, como afirma Faria Costa, "a admissibilidade, teoreticamente fundada, da punição penal dos entes colectivos só tem sentido desde que lhe encontremos uma racionalidade (material) que se não pode compaginar com a mera relevância de uma necessária eficácia" ([34]). Valendo no entanto a pena acentuar, neste contexto, que, uma vez legitimado o princípio político-criminal da necessidade de punição criminal dos entes colectivos, ele não pode — de acordo com o suposto básico, em que assentámos (supra, 3.º Cap., § 27), da subordinação da dogmática à política criminal — ser subvertido com a alegação de que um tal princípio é dogmaticamente inexequível.

([32]) Isto se afirma sem prejuízo de quanto infra, 31.º Cap., §§ 25 e ss., 58 e ss., será dito sobre um eventual alargamento do conceito de autoria nos quadros dos "aparelhos organizados de poder".

([33]) Desenvolvimentos de direito comparado em ROCHA, Lopes, A responsabilidade penal das pessoas colectivas — novas perspectivas, *in*: IDPEE (org.), *Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários*, I, p. 437, e já SOUSA, Castro e, *As Pessoas Colectivas em Face do Direito Criminal e do chamado "Direito de Mera Ordenação Social"*, 1985, p. 43 e ss.

([34]) COSTA, Faria, A responsabilidade jurídico-penal da empresa e dos seus órgãos, *RPCC 2*, 1992, p. 546. Em base comparatística alargada, a bibliografia sobre esta questão está a tornar-se praticamente inabarcável. Cf. em todo o caso as contribuições sobre o assunto contidas na colectânea Schünemann / Suarez González (orgs.), *Bausteine des europäischen Wirtschaftsstrafrechts, Madrid-Symposium für Klaus Tiedemann*, 1994 (versão espanhola de Rodríguez Mourullo / / Bajo Fernández / Jorge Barreiro, *Hacia un Derecho penal económico europeo, Jornadas en honor del Prof. Klaus Tiedemann*, 1995). Por último, entre nós, BANDEIRA, Gonçalo, *"Responsabilidade" penal económica e fiscal dos entes colectivos*, 2004, e BRAVO, Reis, Critérios de imputação jurídico-penal de entes colectivos (elementos para uma dogmática alternativa da responsabilidade penal de entes colectivos), *RPCC 13*, 2003, p. 207.

§ 25 Desde 1977 que, rejeitando os argumentos da incapacidade de acção e de culpa dos entes colectivos, vimos preconizando, sobretudo *no âmbito do direito penal secundário*, a legitimidade e possibilidade da sua responsabilização penal. Se, em sede político-criminal, se conclui pela alta conveniência ou mesmo imperiosa necessidade de responsabilização dos entes colectivos neste âmbito, não se vê razão dogmática de princípio a impedir que eles se considerem agentes possíveis dos tipos de ilícito respectivos. A tese contrária só pode louvar-se numa *ontologificação* e *autonomização* inadmissíveis do conceito de **acção**, a esquecer que a este conceito podem ser feitas pelo tipo de ilícito exigências *normativas* que o conformem como uma certa unidade de sentido social. E tão-pouco parece impensável ver nas pessoas colectivas destinatários possíveis do *juízo de censura* em que a **culpa** se traduz. Certo que, na acção como na culpa, tem-se em vista um "ser livre" como centro ético-social de imputação jurídico-penal (infra, 19.º Cap., §§ 7, 9, 23) e esse é o do homem individual. Mas não deve esquecer-se que as organizações humano-sociais são, tanto como o próprio homem individual (sublinhou-o muito exactamente Max Müller, invocando neste contexto o *princípio da identidade da liberdade*), "obras da liberdade" ou "realizações do ser livre"; pelo que parece aceitável que em certos domínios especiais e bem delimitados ao homem individual possam substituir-se, como centros ético-sociais de imputação jurídico-penal, objectiva e subjectiva, as suas obras ou realizações colectivas e, assim, as pessoas colectivas, associações, agrupamentos ou corporações em que o ser livre se exprime. Fica por esta forma aberto o caminho, do ponto de vista dogmático, para se admitir uma responsabilidade dos entes colectivos no direito penal, ao lado da eventual responsabilidade das pessoas individuais que agem como seus órgãos ou representantes. A este modelo chamámos nós **modelo analógico** ([35]).

§ 26 O essencial desta concepção — correspondente, na prática, à situação que se vivia nos direitos inglês e norte-americano — encontra-se hoje, *nos resultados*, largamente difundido e reconhecido, se bem que con-

([35]) Nestes termos, DIAS, Figueiredo, Para uma dogmática do direito penal secundário, *in*: IDPEE (org.), *Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários*, I, p. 68. Em sentido concordante, COSTA, Faria, nota 34, p. 549 e ss. Afirmando a possibilidade de uma *culpa (social)* da empresa, TIEDEMANN, Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en derecho comparado, *RBCC 3*, 1995, p. 31.

tinuem a verificar-se profundas divergências a respeito (36). Mesmo na Alemanha, o TC reconheceu como legítimo o chamado **modelo da imputação**, segundo o qual pode imputar-se à pessoa jurídica a acção e a culpa dos seus órgãos responsáveis (37); o que, afirma aquele tribunal, não supõe uma responsabilidade por facto de outrem, porquanto a construção da pessoa jurídica visa justamente a criação de um centro autónomo de imputação. Mais longe vai o chamado **modelo da culpabilidade** (*Verschulden*) **da organização**, que parte de uma culpabilidade específica e autónoma do ente colectivo, baseada na tese criminológica da "atitude criminal de grupo" e segundo a qual o grupo constitui contexto idóneo da realização de factos puníveis (38). Mas pode contestar-se esta concepção — ou melhor: reputá-la insuficiente, como a anterior — na base de ser duvidoso que por esta via se possa justificar uma imputação ao ente colectivo, uma vez que são os membros do grupo os portadores da referida atitude criminal. Numa outra via se dirige o **modelo da prevenção** (39), que considera os entes colectivos passíveis da aplicação de sanções criminais do tipo das medidas de segurança. Mais próximo da ideia que atrás deixámos exposta se encontra o **modelo da culpa analógica** (40), segundo o qual a categoria da culpa é aplicável por analogia às empresas, assim se conformando um terceiro modelo sancionatório criminal, ao lado do das penas individuais e das medidas de segurança. Este modelo, como bem anota Vogel, tem em conta (41), desde logo, que os entes colectivos podem ser, enquanto tais, destinatários da norma jurídico-penal e que a culpa do ente colectivo não é só comprovável no direito civil, como, constituindo uma realidade social *a se*, também no direito penal; enquanto, por outro lado, ele torna possível que em matéria de responsabilidade penal do ente colectivo se introduzam as alterações do modelo da responsabilidade individual que se revelem político-criminalmente necessárias.

---

(36) Com uma vista de conjunto e amplas referências bibliográficas depara-se em ROXIN I, § 8, n.º 59 e ss.; e com uma apertada síntese em VOGEL, La responsabilidad penal por el producto en Alemania: situación actual y perspectivas de futuro, *Revista Penale 8*, 2001, p. 104 74.

(37) BVerfGE 20, p. 335 e ss.

(38) Cf. VOGEL, nota 36, citando TIEDEMANN.

(39) Defendido por SCHÜNEMANN, Die Strafbarkeit der juristischen Personen aus deutscher und europäischer Sicht, *in*: Schünemann / Suárez (orgs.) nota 34, p. 265 e ss.

(40) HEINE, *Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen*, 1995, pp. 241 e ss., 256 e ss., 271 e ss.

(41) VOGEL, nota 36.

§ 27 É nesta ordem de ideias que deve ser interpretado o art. 11.º Esta norma pretende não excluir a responsabilidade dos entes colectivos, mas, pelo contrário, deixar em aberto a possibilidade de essa responsabilidade ser consagrada relativamente a determinados tipos de crime, quando por razões de oportunidade o legislador assim entender. Esse passo foi dado de forma inequívoca, como se anotou, com a lei relativa aos crimes económicos e contra a saúde pública (art. 3.º do DL 28/84, de 20-1) e continuado com o regime geral das infracções tributárias (art. 7.º da L 15/2001, de 5-6) e das infracções laborais (art. 607.º do CT, L 99/2003, de 27-8). Chamado a pronunciar-se sobre a constitucionalidade da primeira destas normas, o TC considerou **não se verificar qualquer impedimento constitucional à responsabilização penal dos entes colectivos, pelo menos a nível do direito penal secundário**. Considerando a justificação dogmática que acima defendemos, o TC concluiu que "nada obsta a que o Estado de direito democrático (...) possa num quadro jurídico-penal bem delimitado no seu âmbito e na sua génese motivadora, alargar a responsabilidade criminal às pessoas colectivas em ordem à protecção de bens jurídicos socialmente relevantes e cuja defesa é condição indispensável do livre desenvolvimento da personalidade do homem" ([42]).

§ 28 A responsabilidade penal dos entes colectivos está pois consagrada entre nós, havendo razão para pensar — tal como, ao que dissemos, sucedeu com o nosso TC — que o legislador teria tido primordialmente em vista a sua aplicação no domínio do direito penal secundário. A verdade porém é que o texto do art. 11.º não dá azo a uma tal limitação. Atenta, de resto, a fundamentação da responsabilidade penal do ente colectivo no modelo analógico que atrás apontámos, cremos ser hoje pertinente (e mesmo necessário) sustentar-se que mesmo em relação ao **direito penal clássico** deve abandonar-se a regra *societas delinquere non potest*. Com efeito, em relação a muitos comportamentos qualificados como crimes integrantes do chamado direito penal de justiça valem com toda a propriedade os argumentos político-criminais e dogmáticos referidos para justificar a punição penal dos entes colectivos. Só a título de exemplo, atente-se em crimes como a infracção de regras de segurança (art. 152.º-4), o tráfico de pessoas (art. 159.º), a devassa por meio de informática (art. 193.º), a falsificação de documentos (arts. 256.º a 258.º), a infracção de regras de construção

([42]) Ac. do TC 213/95, de 20-4-1995, *AcTC 30*, 1995, p. 985 e ss.

(art. 277.º), o tráfico de influência (art. 335.º) e, de forma particularmente clara, os crimes contra o ambiente (arts. 278.º-280.º).

§ 29 Isto mesmo veio a ser reconhecido por *Decisões-quadro do Conselho da União Europeia* e por *Convenções do Conselho da Europa* e da *ONU*, que obrigam a adoptar as medidas necessárias para que os entes colectivos possam ser considerados "responsáveis" por infracções em matéria de terrorismo, de ambiente, de lenocínio e tráfico de menores, etc. Já se pensou que tais instrumentos internacionais seriam suficientemente cumpridos se, naqueles casos, se estabelecesse a responsabilização meramente **contra-ordenacional** do ente colectivo. Mas uma tal solução é de repudiar, na medida em que representaria uma manipulação ilegítima dos princípios jurídico-constitucionais e ordinários que vimos (supra, 7.º Cap., § 13) presidirem à distinção entre crimes e contra-ordenações. Se, *v. g.*, o terrorismo, a poluição ambiental, etc., são pela lei considerados verdadeiros *crimes*, então torna-se impossível defender (sob pena, inclusivamente, de eventual inconstitucionalidade material) que se as mesmas infracções forem cometidas por um ente colectivo elas já não constituem crimes, mas meras contra-ordenações ([43]). O legislador ordinário não é livre de qualificar a mesma conduta como crime se levada a cabo por certos sujeitos típicos e como contra-ordenação se levada a cabo por outros.

§ 30 Neste sentido, o legislador penal do futuro terá, sempre que necessário, de consagrar **sem equívoco** a responsabilização **penal** de entes colectivos ([44]). Isto mesmo era integralmente reconhecido no Relatório de uma Proposta de Lei, aprovada em Conselho de Ministros de 24-6-2004, que no essencial acabou por ser incorporada no **Anteprojecto 2007**. Segundo este, ao art. 11.º será acrescentado um n.º 2 onde — tendo em conta, alegadamente, as injunções comunitárias e internacionais atrás mencionadas — se estipula a responsabilidade penal das pessoas colectivas e entidades equi-

([43]) Neste preciso sentido, DIAS, Figueiredo / CAEIRO, Pedro, *Observações sobre o anteprojecto de revisão do regime penal do crime de "branqueamento"* (parecer não publicado, emitido a solicitação da Ministra da Justiça em 12-3-2003 e aqui citado com a sua autorização). Sobre o ponto, cf., já, CARVALHO, Taipa de / CUNHA, Damião da, "Facturas falsas": crime de fraude fiscal ou de burla?, *Juris et de Jure*, 1998, p. 858.

([44]) Neste contexto, lembra BRAVO, Reis, nota 34, p. 225, a reacção premonitória de TIEDEMANN, *Lecciones de Derecho Penal economico (comunitário, español, alemán)*, 1993, p. 232, perante um texto como o nosso art. 11.º, ao qual acertadamente chamou "uma cláusula dirigida ao futuro legislador".

paradas por um vasto elenco de crimes: maus-tratos (art. 152.º-A); violação das regras de segurança (art. 152.º-B); escravidão (art. 159.º); tráfico de pessoas (art. 160.º); alguns crimes de natureza sexual (arts. 163.º a 166.º, sendo a vítima menor, e arts. 169.º e 171.º a 176.º); burla informática e nas comunicações e burla relativa a trabalho ou a emprego (arts. 221.º e 222.º); discriminação racial, religiosa ou sexual (art. 240.º); falsificação ou contrafacção de documento (art. 256.º); falsificação de notação técnica (art. 258.º); crimes de falsificação de moeda e alguns crimes de perigo comum (arts. 262.º a 283.º e 285.º); associação criminosa (art. 299.º); tráfico de influências (art. 335.º); desobediência (art. 348.º); violação de imposições, proibições ou interdições (art. 353.º); suborno (art. 363.º); favorecimento pessoal (art. 367.º); branqueamento (art. 368.º-A) e corrupção (arts. 372.º a 374.º). O Anteprojecto prevê ainda um conjunto de disposições a inserir no CP — arts. 90.º-A a 90.º-M — relativas às **penas** aplicáveis aos entes colectivos.

§ 31 O catálogo previsto no Anteprojecto 2007 é, pois, extenso. A tal ponto que uma análise minuciosa dos tipos legais de crime relativamente aos quais a responsabilidade penal dos entes colectivos será consagrada — tarefa que só pode ser cometida a um estudo sistemático da PE — pode vir a suscitar, em alguns casos, as mais fundadas dúvidas e reservas (máxime, em matéria de crimes *sexuais*!). Seja como for quanto a este ponto, ao referido catálogo deve acrescentar-se, **no plano do direito já constituído**, a responsabilidade penal dos entes colectivos prevista em legislação especial, designadamente, em crimes contra a economia e a saúde pública (art. 3.º do DL 28/84, de 20-1), informáticos (art. 3.º da L 109/91, de 17-8), tributários (art. 7.º da L 15/2001, de 5-6), terroristas (art. 6.º da L 52/2003, de 22-8) e laborais (art. 607.º do CT).

§ 32 Resta saber se as novas disposições previstas no Anteprojecto 2007 se mostram suficientes e adequadas como **critério de efectivação da responsabilidade penal dos entes colectivos**. Com efeito, não basta ao legislador consagrar a responsabilidade penal do ente colectivo, mas terá de dar à jurisprudência e à doutrina um princípio ou critério, ao menos geral, de como deve estabelecer-se para efeitos dogmáticos, teóricos e práticos, aquela responsabilidade ([45]). O aludido modelo analógico não deve

([45]) Importantes, deste ponto de vista, STRATENWERTH, Unternehmenshaftung?, *R. Schmitt-FS*, 1992, p. 295, DERUYCK, Probleme der Verfolgung und Ahndung von Verbandskriminalität im deuts-

servir para esconder que, na realidade do mundo psicofísico, os entes colectivos não agem por si mesmos (mas só através de "pessoas naturais") nem são dotados de subjectividade. Por isso é preciso determinar antes de mais, também legislativamente, o âmbito e a forma que deve assumir o **nexo de imputação**, objectivo e subjectivo, do facto à responsabilidade do ente colectivo. Decidir, nomeadamente, a questão de saber se os entes colectivos são directamente responsáveis apenas pelas acções levadas a cabo por pessoas naturais (e se sim, por quais e como); ou também enquanto garantes da não produção de resultados típicos, isto é, mais concretamente, quando a falta de vigilância ou controlo dos órgãos ou representantes do ente colectivo tenha tornado possível a prática do facto por uma pessoa sob a sua autoridade.

§ 33 Antes destas decisões legislativas torna-se aventuroso — se não juridicamente inadmissível — elaborar uma dogmática da imputação do facto à responsabilidade penal dos entes colectivos. Mas também aqui o proposto art. 11.º-2 do Anteprojecto 2007 vem dar passos importantes, ao dispor que o facto será atribuído ao ente colectivo quando o crime seja cometido **em nome do ente colectivo e no interesse colectivo** por pessoas que nele ocupam uma **posição de liderança** ([46]), ou por quem **aja sob a autoridade dessas pessoas em virtude de uma violação dos deveres de vigilância ou controlo que lhes incumbem** ([47]). Com estes princípios não ficam obviamente — longe disso! — resolvidos todos os problemas prático-normativos que justificadamente se suscitam e se suscitarão em tema de imputação. Mas o trabalho dogmático e de aplicação passa agora a encontrar orientação legislativa e a tornar-se possível.

3. O autor individual. Crimes comuns e crimes específicos

§ 34 Autor de um crime pode ser, em regra, *qualquer pessoa* ("quem...", assim começa a generalidade dos tipos de ilícito): estamos

---

chen und belgischen Recht, *ZStW 103*, 1991, p. 705, e HEINE, nota 40, *passim*, esp. pp. 220 e ss. e 248 e ss.

([46]) Esclarecendo o art. 11.º-4 proposto que "ocupam uma posição de liderança os órgãos e representantes da pessoa colectiva e quem nela tiver autoridade para exercer o controlo da sua actividade".

([47]) Com interesse para esta problemática, se bem que tendo em consideração a responsabilização individual, ALBERGARIA, Soares de, A posição de garante dos dirigentes no âmbito da criminalidade da empresa, *RPCC 9*, 1999, p. 605.

neste caso perante os chamados **crimes comuns**, de que são exemplos o homicídio (art. 131.º: "Quem matar outra pessoa...) ou o furto (art. 203.º: "Quem... subtrair coisa móvel alheia..."). Por vezes, porém, a lei leva a cabo nesta matéria uma *especialização*, no sentido de que certos crimes só podem ser cometidos por determinadas pessoas, às quais pertence uma certa *qualidade* ou sobre as quais recai um *dever* especial. Deparamos aí com os chamados **crimes específicos**, de que são exemplos os arts. 227.º ("O *devedor* que..."), 284.º ("O *médico* que...") ou 375.º ("O *funcionário* que..."). Fala-se a este respeito, com propriedade, em *elementos típicos do autor*.

§ 35 No âmbito dos crimes específicos distingue-se entre **crimes específicos próprios ou puros** e **impróprios ou impuros**. Nos primeiros, a qualidade especial do autor ou o dever que sobre ele impende *fundamentam* a responsabilidade: é o caso, por ex., do crime de prevaricação do art. 370.º, cuja conduta, se não for levada a cabo por advogado ou solicitador, não constitui crime. Nos segundos, a qualidade do autor ou o dever que sobre ele impende não servem para fundamentar a responsabilidade, mas unicamente para a *agravar*: é, p. ex., o caso do art. 378.º, que comina uma pena mais grave para o crime de violação de domicílio, previsto no art. 190.º, quando este for cometido por funcionário. Cremos que em todos estes crimes específicos decisivo é, em último termo, o *dever especial* que recai sobre o autor, não a *posição* do autor de onde este dever resulta. Por isso pode haver crimes específicos que não contenham, ao menos de forma expressa, elementos típicos do autor, antes se limitando a descrever a situação de onde resulta o dever especial (cf., *v. g.*, o art. 200.º que incrimina a omissão de auxílio) ou a descrever o próprio dever especial (*v. g.*, o art. 224.º onde se contém o crime de infidelidade patrimonial). De referir será que, no campo dos crimes específicos, se na maior parte dos casos a tipicização do autor é feita pela atribuição a este de um dever especial, casos há em que ela é levada a cabo através de um *relacionamento interpessoal* (cf., *v. g.*, o art. 247.º relativo ao crime de bigamia: "Quem, *sendo casado*...").

§ 36 A distinção entre crimes comuns e crimes específicos, próprios e impróprios, assume **relevo prático** significativo sobretudo em matéria de *comparticipação* (eventualmente também em matéria de *erro*), nomeadamente em sede de distinção entre autoria e cumplicidade (arts. 26.º e 27.º e infra, 30.º Cap.), bem como de *comunicabilidade* entre os comparticipantes

de "certas qualidades ou relações especiais do agente" (art. 28.º e infra, 33.º Cap., II) ([48]). Logo no presente contexto tem algum interesse uma referência aos chamados **crimes de mão própria**, isto é, aos tipos de ilícito em que o preceito legal quer abranger como autores apenas aqueles que levam a cabo a acção **através da sua própria pessoa**, não através de outrem; quer abranger apenas pois, segundo o entendimento dominante, os *autores imediatos*, ficando excluída a possibilidade da *autoria mediata*; e mesmo da *co-autoria* relativamente àqueles comparticipantes que não tenham chegado a executar por próprias mãos a conduta típica. Todavia, a necessidade e a justificação político-criminais desta categoria dogmática encontra-se hoje, cada vez mais, em questão. No lugar próprio — isto é, em sede de comparticipação: infra, 30.º Cap., § 27 e s., e 33.º Cap., § 24 e s. — será o problema considerado.

II. A conduta. Crimes de resultado e crimes de mera actividade

§ 37 Quanto à conduta, são vários os problemas que se levantam no enquadramento presente. Desde logo, é nesta sede que cabe determinar quais as acções penalmente irrelevantes, de acordo com a **função de delimitação ou função negativa de excluir da tipicidade comportamentos jurídico-penalmente irrelevantes** que ao conceito de acção vimos pertencer em certos termos (supra, 10.º Cap., § 40 e s.). Aqui se contém a exigência geral de que se trate de **comportamentos humanos**, o que, obviamente, exclui a capacidade de acção (todavia afirmada na Idade Média) das coisas *inanimadas* e dos *animais*, embora não, como acabámos de ver, dos entes colectivos. Exige-se ainda que o comportamento seja **voluntário**, isto é, presidido por uma vontade, o que exclui os puros *actos reflexos* ([49]) (*v. g.*, o caso de alguém que perde o controlo do seu carro e colide com outro veículo em virtude de uma reacção instintiva de defesa contra um insecto que lhe entrou num olho), os cometidos em *estado de inconsciência* (*v. g.*, em situações de sonambulismo, de hipnose, de delírio profundo ou durante um ataque epiléptico) ou sob o impulso de *forças irresistíveis*. Também não constituem acções penalmente relevantes os

([48]) Último e importante estudo sobre esta questão: SOUSA, Susana Aires, A autoria nos crimes específicos: algumas considerações sobre o art. 28.º do Código Penal, *RPCC 15*, 2005,

([49]) PALMA, Fernanda, A teoria do crime como teoria da decisão penal, *RPCC 9*, 1999, p. 540, rejeita esta terminologia, que apelida de "meramente penalística", preferindo designar estes comportamentos como "automatismos".

sonhos ou os pensamentos, conforme o princípio romanístico *cogitationes pœnam nemo patitur*.

§ 38 No âmbito da conduta importa distinguir entre tipos cuja consumação pressupõe a produção de um *resultado* e tipos em que para a consumação é suficiente a mera *acção*. Nos **crimes de resultado** sob a forma de comissão por acção o tipo pressupõe a produção de um evento como consequência da actividade do agente. Nestes tipos de crime só se dá a consumação quando se verifica uma *alteração externa espácio-temporalmente distinta da conduta* (supra, § 10). Exemplos paradigmáticos são os do homicídio (art. 131.º), cuja consumação só se verifica com a morte de uma pessoa, da ofensa à integridade física (art. 143.º) e da burla (art. 217.º). Se, pelo contrário, o tipo incriminador se preenche através da mera execução de um determinado comportamento estaremos em face de **crimes de mera actividade**. É o caso, entre outros, da violação de domicílio (art. 190.º-1), das coacções sexuais (art. 163.º e ss.), da evasão (art. 352.º), da falsidade de depoimento ou declaração (art. 359.º). É de resto, no fundo, essencialmente a mesma distinção que se leva a cabo quando se distinguem **crimes formais** (a cuja tipicidade é indiferente a realização do resultado) e **crimes materiais** (a cuja tipicidade interessa o resultado).

§ 39 O problema da distinção entre acção e resultado — outrora aparentemente simples e essencialmente correspondente, se assim nos podemos exprimir, a uma *consideração natural* — tem sofrido uma progressiva e complexa "normativização", a tal ponto que a distinção se tornou dogmaticamente fluida e dificilmente racionalizável e controlável; servindo inclusivamente para justificar *a posteriori* posições (em regra radicais) em matérias fundamentais como a da validade / legitimação das incriminações, nomeadamente, a de fundamentar o ponto de vista segundo o qual toda a incriminação constitui um "crime de resultado", *rectior*, assenta num **desvalor de resultado** que, desta forma, predomina em absoluto sobre o desvalor da acção. Podendo porventura afirmar-se que esta longa marcha se terá iniciado numa certa doutrina italiana relativa ao delito preterintencional (infra, § 57 e ss.) e que depois se generalizou no sentido da afirmação de que não existem crimes sem resultado ou (o que é o mesmo) não existem crimes de mera actividade ([50]); tornou-se recentemente em ponto de extrema relevância — se bem que, em nossa opinião, nem sempre cor-

rectamente entendido (infra, 12.º Cap., § 42 e ss.) — na questão da "imputação objectiva", sobretudo no que respeita aos crimes de perigo concreto, abstracto e abstracto-concreto ([51]); e chega hoje a ser posto ao serviço da alegação de que a "ofensividade" constitui noção que vai mais longe e é dogmaticamente mais frutuosa e exacta do que a de "ofensa ao bem jurídico" como *caracteristicum* de todo o crime em sentido material ([52]).

§ 40 As questões do conceito material de crime e da sua validade / legitimação foram já tratadas no 6.º Cap. e não têm de ser trazidas aqui de novo à consideração; bem assim como a das virtualidades da noção de ofensividade face à de ofensa ao bem jurídico. Cabe apenas acrescentar, se necessário, que tais questões não poderiam estar nunca na dependência de construções dogmáticas (de base ôntica ou normativa, não importa) de conceitos como o de "resultado" tipicamente relevante. Importante é só, do nosso ponto de vista, reacentuar (supra, § 10) que, no contexto da distinção típica entre crimes de mera actividade e de resultado e diversamente do que sucede na distinção entre "desvalor de acção" e "desvalor de resultado" como ideias-rectoras do ilícito, não está em causa a mera "tranquilidade" ou "intranquilidade" do *bem jurídico* provocada pela conduta, mas a exigência típica de que **à acção acresça ou não um "efeito sobre o objecto da acção e desta distinto espácio-temporalmente"** ([53]). Bem podendo insistir-se assim na ideia de que a distinção se suscita aqui ao nível do "objecto da acção", não ao nível do "bem jurídico" (infra, § 44).

§ 41 O relevo prático-normativo da distinção entre crimes formais ou de mera actividade e crimes materiais ou de resultado é multímodo, mas revela-se sobretudo em que só os segundos suscitam a questão da **imputação objectiva do resultado à acção**, isto é, a questão de saber quais os requisitos necessários para que um determinado evento possa ser considerado como produzido por uma certa acção. Problema que, devido à sua relevância e complexidade, será tratado autonomamente no capítulo seguinte. Também noutro contexto (infra, 13.º Cap., § 58 e s.) será referida a problemática relativa aos chamados **crimes de resultado cortado**.

([50]) Cf., sobre o ponto, CARVALHO, Taipa, *A Legítima Defesa*, 1995, p. 108[169], e MONIZ, Helena, nota 10, p. 541 e s.

([51]) Sobre a questão, aprofundadamente, COSTA, Faria, nota 5, p. 567 e ss.

([52]) Por último, na esteira de Faria Costa, D'AVILA, Fabio, *Ofensividade e Crimes Omissivos Próprios (Contributo à Compreensão do Crime como Ofensa ao Bem Jurídico)*, 2003.

([53]) MONIZ, Helena, nota 10, p. 569.

§ 42 Ainda a nível da conduta importa distinguir entre **crimes de execução livre** e **de execução vinculada**. Nestes, o *iter criminis* e por conseguinte o modo de execução vem descrito no tipo, enquanto naqueles tal não assume qualquer relevância. Assim, se a burla (art. 217.º) é um crime de execução vinculada, porque só comete o crime de burla quem actue "por meio de erro ou engano sobre factos que astuciosamente provocou", já o homicídio (art. 131.º) é um crime de execução livre, pois ao tipo é indiferente a forma como o resultado morte é provocado. Esta é uma distinção que assume os seus efeitos prático-normativos mais relevantes a nível de *erro*.

§ 43 É ainda no campo da conduta que se integra a problemática da distinção prático-normativa entre crimes de **acção** e **omissão**. Distinção que apresenta grande interesse prático, dadas as diferenças de regime jurídico entre os crimes de comissão por acção e os de comissão por omissão. Mas cujo lugar sistematicamente adequado de tratamento será aquele em que se curar dos crimes omissivos (infra, 37.º Cap., § 6 e ss.).

III. O bem jurídico. Crimes de dano e crimes de perigo; crimes simples e crimes complexos

1. Bem jurídico e objecto da acção

§ 44 Em relação ao *bem jurídico* importa ter presente que ele se não confunde com um outro possível elemento do tipo objectivo de ilícito como é o *objecto da acção*: se *A* furta um anel a *B*, objecto da acção é o anel, bem jurídico a "propriedade alheia"; se *C* mata *D*, o corpo de *D* é o objecto da acção, a vida humana o bem jurídico lesado. Sabemos já (supra, 6.º Cap., § 16) que o bem jurídico é definido como a expressão de um interesse, da pessoa ou da comunidade, na manutenção ou integridade de um certo estado, objecto ou bem em si mesmo socialmente relevante e por isso juridicamente reconhecido como valioso. Ao nível do tipo objectivo de ilícito o objecto da acção aparece como **manifestação real** desta noção abstracta, é a *realidade* que se projecta a partir daquela ideia genérica e que é ameaçada ou lesada com a prática da conduta típica.

2. Crimes de dano e crimes de perigo

§ 45 Atendendo à *forma como o bem jurídico é posto em causa pela actuação do agente* (o bem jurídico, dizemos, não o mero "objecto da

acção" ([54])) distingue-se entre crimes de dano e crimes de perigo. Nos *crimes de dano* a realização do tipo incriminador tem como consequência uma *lesão* efectiva do bem jurídico. O homicídio (art. 131.º), o dano (art. 212.º), a violação sexual (art. 164.º) e a injúria (art. 181.º) são exemplos desta espécie de crimes. Nos *crimes de perigo* a realização do tipo não pressupõe a lesão, mas antes se basta com a mera *colocação em perigo* do bem jurídico. Aqui distingue-se entre crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstracto. Nos crimes de **perigo concreto** *o perigo faz parte do tipo*, isto é, o tipo só é preenchido quando o bem jurídico tenha *efectivamente* sido posto em perigo. É o caso do art. 138.º (exposição ou abandono), em que é elemento do tipo o "colocar em perigo a vida de outra pessoa": só haverá crime de exposição ou abandono quando se comprove que o bem jurídico vida foi realmente posto em perigo. Outros exemplos são os arts. 291.º (condução perigosa de veículo rodoviário) e 272.º (incêndios, explosões...). Nos crimes de **perigo abstracto** o perigo não é elemento do tipo, mas simplesmente *motivo* da proibição. Quer dizer, neste tipo de crimes são tipificados certos comportamentos em nome da sua *perigosidade típica* para um bem jurídico, mas sem que ela necessite de ser comprovada no caso concreto: há como que uma *presunção inelidível* de perigo e, por isso, a conduta do agente é punida independentemente de ter criado ou não um perigo efectivo para o bem jurídico. Diz-se também — sendo esta, malgrado as críticas que lhe possam ser dirigidas, uma razoável forma de expressão — que nesta espécie de crimes o perigo é presumido *iuris et de iure* pela lei. Temos como exemplo a condução de veículo em estado de embriaguez (art. 292.º), em que o condutor embriagado é punido pelo facto de o estado em que se encontra constituir um perigo potencial para a segurança rodoviária. Outros exemplos são, p. ex., o abuso sexual de crianças (art. 172.º), a contrafacção de moeda (art. 262.º) ou a posse de arma proibida (art. 275.º).

§ 46 Tem sido questionada, também entre nós, a **constitucionalidade** dos crimes de perigo abstracto pelo facto de poderem constituir uma tutela demasiado avançada de um bem jurídico, pondo em sério risco quer o princípio da *legalidade*, quer o princípio da *culpa* (já supra, 6.º Cap., § 61). A doutrina maioritária ([55]) e o TC pronunciam-se todavia, com

([54]) Assim, todavia, entre outros, ROXIN I, § 10, n.º 123 e s. Como no texto STRATENWERTH / KUHLEN, § 8, n.º 14.

([55]) Que pode ver-se indicada em COSTA, Faria, nota 5, p. 646 e ss. Uma aprofundada investigação encontra-se agora em MENDOZA Buergo, Blanca, *Límites dogmáticos y político-*

razão, pela sua não inconstitucionalidade quando visarem a protecção de bens jurídicos de grande importância, quando for possível identificar claramente o bem jurídico tutelado e a conduta típica for descrita de uma forma tanto quanto possível precisa e minuciosa (56).

§ 47 Como dissemos, em princípio, quando haja acusação pela prática de um crime de perigo abstracto é indiferente a prova que se faça no sentido de mostrar que, no caso concreto, o bem jurídico não foi — ou mesmo *não podia concretamente ter sido* — posto em perigo. Contudo, no âmbito da discussão acerca da constitucionalidade deste tipo de crimes surgiram posições que preconizam a não punição de condutas que configurem a prática de um crime de perigo abstracto quando se comprove que na realidade não existiu, de forma *absoluta*, perigo para o bem jurídico, ou que o agente tomou todas as medidas necessárias para evitar que o bem jurídico fosse colocado em perigo. A este propósito começou a falar-se na doutrina de crimes de **perigo abstracto-concreto**. Neles o perigo abstracto não é só critério interpretativo e de aplicação, mas deve também ser momento referencial da culpa e, por isso, admitem a "possibilidade de a perigosidade ser objecto de um juízo negativo" (57). De um ponto de vista formal esta categoria cabe ainda na dos crimes de perigo *abstracto*, porque a verificação do perigo não é essencial ao preenchimento do tipo; de um ponto de vista substancial, porém, do que verdadeiramente se trata é de **crimes de aptidão** (58), ou, na terminologia proposta por Bockelmann, de "**conduta concretamente perigosa**" (59), no sentido de que só

-criminales de los delitos de peligro abstracto, 2001, p. 42 e ss., que conclui pela alta conveniência da transformação dos crimes de perigo abstracto, em toda a medida possível, em "crimes de aptidão" (cf. a seguir, no texto). Cf., também, sobre o ponto, com meridiana clareza, RODRÍGUEZ Mourullo, Limitaciones del derecho penal del medio ambiente: alternativas político-criminales, *in*: *Tutela Jurídica do Meio Ambiente: Presente e Futuro*, I Jornadas Luso-Espanholas de Direito Penal, 2005, p. 159 e ss.

(56) Cf. Ac. do TC 426/91, de 6-11-1991, *AcTC 20*, 1991, p. 423 e ss.

(57) CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, II, art. 295.º, § 20. Para este A. o art. 295.º é exemplo de um crime de perigo abstracto-concreto.

(58) De "delitos abstractos de aptidão" fala justamente, a propósito, ROXIN I, § 11, n.º 162 e s. Cf., ainda, DIAS, Silva, Entre "Comes e Bebes": Debate de algumas questões polémicas no âmbito da protecção jurídico-penal do consumidor, *RPCC 8*, 1998, p. 520 e ss.; e ZIESCHANG, *Die Gefährdungsdelikte*, 1993, p. 162 e ss., que os denomina "crimes de *perigo potencial*". Para uma distinção entre crimes de perigo abstracto-concreto e crimes de aptidão, MONIZ, Helena, nota 10, p. 556 e ss.

(59) BOCKELMANN, *Niederschriften BT 8*, 1959, p. 429 e ss. FIORE, *Diritto Penale, PG*, IV, 1988, p. 279 e ss., considera livre o legislador de usar a técnica legislativa que entender para

devem relevar tipicamente as condutas apropriadas ou aptas a desencadear o perigo proibido no caso de espécie. Assim, pois, nos crimes de aptidão o perigo converte-se em parte integrante do tipo e não num mero motivo da incriminação, como sucede nos autênticos crimes de perigo abstracto. Por outro lado, porém, a realizaçao típica destes crimes não exige a efectiva produção de um resultado de perigo concreto.

§ 48 É claro que, em regra, só através de uma completação do tipo no momento da sua *aplicação* se pode determinar, em definitivo, se se está perante um verdadeiro delito de perigo abstracto ou antes de um delito de aptidão, se bem que o tipo objectivo possa conter elementos que indiciem ou sugiram tratar-se deste último (60). Exemplo claro desta espécie de delito é dado pelo art. 325 do CP espanhol, que pune **condutas poluidoras** expressamente descritas quando elas "possam prejudicar gravemente o equilíbrio dos sistemas naturais" ou "a saúde das pessoas" (61). Entre nós já foi considerado como crime de aptidão o crime de **participação em rixa** do art. 151.º (62). Por seu lado, Susana Aires de Sousa vê como exemplo de um crime de aptidão o crime de **fraude fiscal** (art. 103.º do RGIT), defendendo que a aptidão da conduta para diminuir as receitas tributárias constitui um elemento típico essencial daquele delito (63).

3. Crimes simples e crimes complexos

§ 49 Ainda em atenção ao bem jurídico é possível distinguir crimes simples e complexos, conforme o tipo de ilícito vise a tutela de **um** ou **mais do que um** bem jurídico. Se na maior parte dos tipos de crime — *tipos simples* — está em causa a protecção de apenas um bem jurídico (*v. g.*, a vida no art. 131.º, a honra no art. 180.º), com os *tipos complexos* pretende-se alcançar a protecção de vários bens jurídicos. Por exemplo, no

---

garantir a tutela dos bens jurídicos, desde que aquela deixe espaço para a indagação judicial da potencialidade lesiva da conduta; o que significaria, em muitos casos, a conversão de um crime de perigo abstracto em um crime de perigo concreto. BRICOLA, Teoria generale del reato, *NovDI XIX*, p. 13 e ss. conclui daqui a inconstitucionalidade dos tipos insusceptíveis de conversão. Pode todavia perguntar-se se nos casos concretos aqui em dúvida se chega a cumprir o próprio sentido da norma típica e se, por conseguinte, se verifica um autêntico perigo abstracto: cf. FARIA, Paula Ribeiro de, nota 14, p. 110 e ss. e[132].

(60) Cf., também, RODRÍGUEZ Mourullo, nota 55.

(61) Cf., de novo, RODRÍGUEZ Mourullo, nota 55.

(62) PINTO, Costa, Ilícito e punibilidade do crime de *participação em rixa*. *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, pp. 882 e ss., 889.

(63) SOUSA, Susana Aires de, *Os Crimes Fiscais. Análise Dogmática e Reflexão sobre a Legitimidade do Discurso Criminalizador*, 2006, p. 71 e ss. Criticamente, no entanto, ANDRADE, Costa, A fraude fiscal — Dez anos depois, ainda um "crime de resultado cortado"?, *RLJ* 135, 2006, p. 339 e ss.

roubo (art. 210.º) é tutelada não só a propriedade, mas também a integridade física e a liberdade individual de decisão e acção. O relevo normativo-prático desta distinção reside em que ela pode mostrar-se essencial para uma correcta interpretação (e aplicação) do tipo (eventualmente, p. ex., para efeitos de unidade de lei concretamente aplicável e de concurso de crimes: infra, 42.º Cap., § 6, e 43.º Cap., § 7). Por exemplo, no crime de denúncia caluniosa (art. 365.º) é absolutamente decisivo para uma correcta interpretação de muitos e importantes pontos do seu regime ter em conta a *duplicidade dos bens jurídicos protegidos* pelo tipo, por um lado o interesse individual dos atingidos pela denúncia, por outro o valor supra-individual da "realização da justiça" (64).

4. As dicotomias crimes de mera actividade e de resultado e crimes de perigo e dano

§ 50 Estabelecidas nos termos em que procurámos fazê-las, as distinções entre crimes de mera actividade e de resultado, de uma parte, e crimes de perigo e de dano, de outra parte mantêm a sua autonomia conceitual-teleológica, máxime, por a primeira se referir em princípio ao objecto da acção, a segunda se reportar ao estado do bem jurídico. O que de resto, de um ponto de vista dogmático-prático, se revela por no tema se verificarem quatro possíveis **combinações** (65): existem crimes de mera actividade que são crimes de dano, p. ex., os crimes de violação sexual (art. 164.º) ou de violação de domicílio (art. 190.º); crimes de resultado que são crimes de dano, p. ex., os crimes de homicídio (art. 131.º) ou de ofensa à integridade física (art. 143.º); crimes de mera actividade que são crimes de perigo, p. ex., o de condução em estado de embriaguez (art. 292.º) ou o de falsidade de depoimento ou declaração (art. 359.º); crimes de resultado, enfim, que são crimes de perigo, p. ex., a generalidade dos crimes de perigo comum (art. 272.º e ss.) ou o de exposição e abandono (art. 138.º).

---

(64) Cf., minuciosamente, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, III, art. 365.º, §§ 1 e 8 e ss. Consideração análoga parece estar na base do Ac. de fixação de jurisprudência do STJ 1/2003, de 16-1, a propósito do crime de falsificação de documento (art. 256.º).

(65) STRATENWERTH, *Derecho Penal. Parte General, I, El hecho punible* (trad. espanhola de *Strafrecht, AT*, I, ²1976, a cargo de Gladis Romero), 1982, n.º 207; e, essencialmente nas conclusões, MONIZ, Helena, nota 10, p. 569.

IV. Grupos de tipos e figuras típicas de estrutura especial

§ 51 No sentido de corresponder pelo melhor às exigências do princípio da legalidade, nomeadamente, de descrever de uma forma o mais precisa e estrita possível os comportamentos típicos e as formas de lesão ou colocação em perigo dos bens jurídicos, o legislador faz uso de técnicas que resultam na criação de *grupos de tipos de crime*, bem como de *figuras típicas de estrutura especial*. São os mais importantes desses grupos e figuras que iremos agora referir abreviadamente.

1. Crimes fundamentais, qualificados e privilegiados

§ 52 Os *crimes fundamentais* contêm o tipo objectivo de ilícito na sua **forma mais simples**, constituem, por assim dizer, o mínimo denominador comum da forma delitiva, conformam o tipo-base cujos elementos vão pressupostos nos tipos qualificados e privilegiados. Frequentemente, na verdade, o legislador, partindo do crime fundamental, acrescenta-lhe elementos, respeitantes à ilicitude ou/e à culpa, que **agravam** (*crimes qualificados*) ou **atenuam** (*crimes privilegiados*) a pena prevista no crime fundamental. Claro exemplo destes grupos de tipos de crime é o homicídio. No art. 131.º está contido o ilícito-típico fundamental de homicídio, traduzido na acção de matar outra pessoa. A partir daqui e conforme a morte for produzida em circunstâncias, devidamente descritas ou referenciadas através de uma cláusula geral, que revelem uma *culpa* mais grave ou uma *culpa* menos grave do que a pressuposta no tipo-base, deparamos com um homicídio qualificado (art. 132.º) ou um homicídio privilegiado (art. 133.º) (66). Outro exemplo é dado pela generalidade dos crimes patrimoniais, *v. g.*, o crime de furto: partindo do tipo-base (ou furto simples: art. 203.º) e acrescentando-lhe elementos, aqui relativos ao *tipo de ilícito*, que aumentam a gravidade do facto — aliás em dois graus diversos —, deparamos com o furto qualificado (art. 204.º) (67).

§ 53 Neste contexto se apresenta por vezes a categoria dos **delitos sui generis**. Mas, verdadeiramente, não se trata neles nem de crimes qualificados, nem privilegiados; nem será a partir destes grupos de crimes que se poderá deparar com o esclarecimento daquela categoria. Do que nos crimes *sui generis* se trata é de, numa situa-

(66) Sobre estes preceitos, DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, arts. 131.º-133.º

(67) Sobre estes preceitos, COSTA, Faria, *Comentário Conimbricense*, II, art. 203.º e s.

ção próxima dos já referidos "crimes complexos", tipos que englobam em si os elementos de um outro tipo de crime, sem todavia representarem uma sua qualificação ou um seu privilegiamento, mas antes um crime *autónomo*. É, neste entendimento, o caso do crime (complexo) de roubo (art. 210.º) relativamente aos crimes (simples) de furto (art. 203.º) ou de coacção (art. 154.º). Esta categoria de crimes (repetimos, em definitivo autónomos) não assume interesse dogmático-prático significativo (68).

2. Crimes instantâneos, crimes duradouros (ou permanentes) e crimes habituais

§ 54 Quando a consumação de um crime se traduza na realização de **um acto** ou na produção de **um evento cuja duração seja instantânea**, isto é, não se prolongue no tempo, esgotando-se num único momento, diz-se que o crime é *instantâneo*. Por exemplo, o homicídio consuma-se no momento em que se dá a morte da vítima, o furto no momento em que se dá a subtracção da coisa. O crime não será instantâneo, mas antes *duradouro* (também chamado, embora com menor correcção, *permanente*) quando **a consumação se prolongue no tempo**, por vontade do autor. Assim, se um estado antijurídico típico tiver uma certa duração e se protrair no tempo enquanto tal for vontade do agente, que tem a faculdade de pôr termo a esse estado de coisas, o crime será duradouro. Nestes crimes a consumação, anote-se, ocorre logo que se cria o estado antijurídico; só que ela *persiste* (ou *dura*) até que um tal estado tenha cessado. O sequestro (art. 158.º) e a violação de domicílio (art. 190.º-1) são exemplos desta espécie de crimes. A distinção entre crimes instantâneos e crimes permanentes tem uma grande importância prático-normativa para efeitos de legítima defesa (já que só é admissível a reacção contra o agressor enquanto a agressão for actual, cf. art. 32.º e infra, 15.º Cap., § 11 e ss.), de tentativa (infra, 27.º Cap., § 11), de autoria e cumplicidade (infra, 32.º Cap., § 22), de concurso (infra, 41.º Cap., § 15), de prescrição do procedimento criminal (art. 119.º-1 e 2/*a*)), de flagrante delito (arts. 255.º e 256.º do CPP), etc.

§ 55 Crimes *habituais* são aqueles em que a realização do tipo incriminador supõe que o agente pratique determinado comportamento **de uma forma reiterada**, até ao ponto de ela poder dizer-se habitual. Exemplos

(68) Nem mesmo — contra o que, com alguma frequência, se alega — em matéria de concurso de crimes (infra, 42.º Cap. 6).

deste tipo de crimes são o aborto agravado (art. 141.º-2) e o lenocínio (art. 170.º). Outros casos, *v. g.*, o do art. 152.º (maus-tratos), são muito discutidos pela doutrina e pela jurisprudência (69). Um pretenso interesse apresentaria esta espécie de crime para efeito de concurso (infra, 43.º Cap., § 49).

3. Crimes de empreendimento

§ 56 São *crimes de empreendimento* — também chamados por vezes, em certos casos aceitavelmente, crimes de *atentado* — aqueles em que se verifica uma **equiparação típica entre tentativa e consumação**; em que, por conseguinte, a tentativa de cometimento do facto é equiparada à consumação e é como tal jurídico-penalmente tratada (70). Como exemplos deste tipo de crimes podem apontar-se os arts. 308.º/*a)*, 325.º, 327.º, 363.º, etc. A relevância prático-normativa da identificação desta espécie de crimes reside no facto de para eles *não dever valer a atenuação especial da pena prevista para a tentativa* (art. 23.º, n.º 2), nem o disposto no art. 24.º, que consagra a *não punibilidade da tentativa quando houver desistência*. Parece, por outro lado, que esta doutrina deve deixar imprejudicada a possibilidade de, ao menos em certos casos, mesmo nos crimes de empreendimento poder ser pensável e punível, como tentativa, a chamada tentativa inidónea ou impossível (art. 23.º-3, *a contrario*) (71).

4. Crimes qualificados pelo resultado

§ 57 Crimes *qualificados (agravados) pelo resultado* são, nos termos do art. 18.º, aqueles tipos cuja **pena aplicável é agravada em função de um resultado que da realização do tipo fundamental derivou**. A qualificação em função do resultado não pode ter fonte jurisprudencial (sob pena de violação do *nullum crimen, nulla pœna sine lege*), mas tem de estar univocamente consagrada em um qualquer preceito da PE. Exemplo clássico desta espécie de crimes é o constante do art. 145.º, no qual se consagram agravamentos das penas aplicadas ao crime de ofensa à integridade física se

---

(69) Cf. só CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, I, art. 152.º, § 9, e (com indicações jurisprudenciais) FARIA, Paula Ribeiro de, Acerca da fronteira entre o castigo legítimo de um menor e o crime de maus-tratos do art. 152.º do Código Penal. *RPCC 16*, 2006, p. 329 e ss.

(70) Monograficamente, FONSECA, Jorge, *Crimes de Empreendimento e Tentativa*, 1986.

(71) JESCHECK / WEIGEND, § 49, VIII; FONSECA, Jorge, nota 70, pp. 91 e ss., 174 e ss.

desse crime resultar a morte. O regime consignado no art. 18.º tem como ponto nuclear a estatuição de que *a agravação prevista da pena só terá lugar se for possível imputar o resultado agravante ao agente "pelo menos a título de negligência"*. Com esta solução se pretendeu limitar substancialmente um princípio de responsabilidade sem culpa, responsabilidade objectiva ou responsabilidade pelo resultado que, historicamente, sempre esteve ligado a esta espécie de crimes. Do que se trata, por conseguinte, é da tentativa (se integralmente lograda ou não é questão ainda hoje controversa) de também neste domínio fazer valer integralmente o *princípio da culpa* ([72]).

4.1. O *versari in re illicita*

§ 58 Historicamente ([73]), os crimes agravados pelo resultado têm a sua origem no aforismo do direito canónico chamado do **versari in re illicita**: "*versari in re illicita operam danti rei illicitæ, imputatur omnia quae sequuntur ex delicto*", ou "*eum qui dat operam rei illicitæ tenet de eo quod præterintentionem contingit*"; em português e através de uma fórmula mais simples: "quem pratica um ilícito responde pelas consequências, mesmo casuais, que dele promanem". Na sua frieza vocabular, um tal princípio não pode considerar-se, de modo algum, compatível com o princípio da culpa, antes parece clara manifestação de uma responsabilidade objectiva ou pelo resultado. E todavia, o seu *significado histórico* foi o de constituir um passo importante na sentido da *limitação da pura responsabilidade pelo resultado* em que assentaria o direito germânico antigo e o início de uma longa caminhada em direcção, também nesta matéria, ao princípio da culpa.

4.2. O crime preterintencional

§ 59 Na codificação penal do séc. XIX a agravação do crime em função do resultado cumpriu mais um passo importante da evolução ao assumir a forma do chamado *crime preterintencional*. A sua estrutura típica assentava na conjugação de (1) um **crime fundamental doloso** (*v. g.*, uma ofensa corporal) com (2) um **resultado mais grave não doloso** resultante

([72]) O estudante terá de ter em conta a incomodidade de na exposição posterior se fazer apelo a muitas noções que só em momento ulterior serão fornecidas, nomeadamente em tema de imputação objectiva e de culpa. Esta matéria deve pois ser por ele reconsiderada quando já for senhor dessas noções.

([73]) Sobre quanto seguidamente, em síntese, se afirma, DIAS, Figueiredo, nota 8, pp. 3-9.

daquele crime fundamental (*v. g.*, a morte), que teria como consequência jurídica (3) uma **especial agravação da pena** cominada, em princípio superior à que resultaria, segundo as regras gerais, do concurso do crime fundamental doloso com o crime agravante negligente ([74]). Simplesmente, segundo a doutrina consolidada e que, até ao séc. XX, não foi posta em causa, o resultado agravante não requeria a sua imputação a título de culpa, antes se exigia apenas que entre ele e o comportamento típico fundamental pudesse estabelecer-se um nexo de imputação objectiva, nomeadamente, sob a forma de uma relação de **causalidade adequada**. Com o que a violação do princípio da culpa que esta espécie de crimes importava continuava a verificar-se.

§ 60 Ficou entre nós a dever-se a Ferrer Correia a primeira tentativa importante de fazer valer, também nestes crimes, o princípio da culpa; uma exigência que, de resto, começava a ouvir-se com insistência em parte da doutrina estrangeira mais prestigiada, em particular, da doutrina penal alemã. Para Ferrer Correia, o que podia explicar, segundo o modelo da culpa, a agravação extraordinária própria do crime preterintencional era a circunstância de o resultado agravante ficar a dever-se a uma **negligência do agente, tornada física e psiquicamente possível pelo dolo** do crime fundamental ([75]). Com esta doutrina sublinhou-se pela primeira vez em Portugal a necessidade (recusada pela jurisprudência consolidada a este respeito ([76]) e que dominantemente se manteve até meados da década de 60 do séc. XX ([77])) de também nos crimes preterintencionais a imputação do resultado agravante se não bastar com o nexo de causalidade adequada entre ela e o crime fundamental, mas exigir um nexo de culpa, sob a forma da negligência.

§ 61 Repensando esta doutrina e aceitando o núcleo essencial da ideia de Ferrer Correia, logo em 1961 defendemos que uma completa

---

([74]) DIAS, Figueiredo, nota 8, p. 102 e ss., e, depois, Crime preterintencional, causalidade adequada e questão-de-facto, *RDES 17*, 1970, p. 262.

([75]) CORREIA, Ferrer, *Dolo e Preterintencionalidade*, 1935, pp. 145 e ss., 190 e s. (depois publicado nos seus *Estudos Jurídicos*, II, 1969, p. 277 e ss.).

([76]) E também por uma certa doutrina, p. ex., FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, p. 231.

([77]) Exemplar a propósito o Ac. do STJ de 20-2-1963, *BMJ 124*, p. 460: o crime de ofensas corporais de que resulta a morte, praticadas sem intenção de matar, tem como elemento constitutivo o nexo de causalidade entre as ofensas e a morte; no mesmo sentido Acs. do STJ de 31-7-1963, *BMJ 129*, p. 280, e de 17-7-1974, *BMJ 239*, p. 77. No sentido da exigência de negligência relativamente à produção do evento agravante, porém, Acs. do STJ de 1-7-1970, *BMJ 199*, p. 107, e de 15-12-1971, *BMJ 212*, p. 199.

compatibilidade com as exigências do princípio da culpa exigia ir ainda mais longe; e por isso fundamentámos o **cerne da agravação** do crime preterintencional na circunstância não tanto de o dolo do crime fundamental ser de tal modo intenso que tornava física e psicologicamente possível a negligência relativamente ao resultado agravante, quanto sobretudo na ideia de a um tal dolo se ligar um **perigo típico** — de verificação normal e frequente, quando não quase "necessária" — de produção do resultado agravante. Pelo que este só deveria ser imputado ao agente, a título de resultado preterintencional, quando ficasse a dever-se a uma **negligência qualificada** — em princípio a uma negligência **consciente** —, derivada da violação de um dever particularmente forte de omitir uma conduta à qual se liga o perigo típico de produção de resultados especialmente graves ([78]). Ao essencial desta posição aderiu Eduardo Correia ([79]).

4.3. O crime agravado pelo resultado

§ 62 O "crime agravado pelo resultado" referido no art. 18.º do CP vigente, se bem que mergulhando as suas raízes na tradição histórica exposta, representa a muitos títulos o **abandono da figura do "crime preterintencional"**, tal como ficou traçada ([80]). Por um lado, e desde logo, o *crime fundamental* não tem de ser agora um crime doloso, mas pode muito bem ser um crime *negligente* (cf., *v. g.*, art. 148.º-1 e 3). Em segundo lugar, o resultado agravante não tem — como acontecia com o crime preterintencional — de constituir um *crime negligente*: quer porque ele pode perfeitamente constituir um simples estado, facto ou situação que em si mesmos não possa considerar-se criminoso (*v. g.*, a gravidez no caso do art. 177.º-3, ou a circunstância de a privação da liberdade no sequestro durar mais de 2 dias: art. 158.º-2/*a*); quer porque pode constituir um resultado típico cometido com dolo eventual numa hipótese em que a lei apenas puna o facto quando cometido com dolo directo (infra, 13.º Cap., § 35 e s.). Por isso também se não pode continuar a dizer que seja necessário à verificação da figura típica que a pena cominada ultrapasse a que resultaria, segundo as regras gerais, do concurso do crime fundamental doloso com o crime agra-

---

([78]) DIAS, Figueiredo, nota 8, pp. 129, 140 e s., 143 e ss., e, depois, *RDES* nota 74, p. 262 e ss.

([79]) CORREIA, Eduardo, I, n.º 96.

([80]) Na linha desta ideia, se bem que a alguns títulos a atenue, CUNHA, Damião da, Tentativa e comparticipação nos crimes preterintencionais, *RPCC* 2, 1992, p. 562 e ss.

vante negligente, mas apenas que é característico do crime agravado pelo resultado que, *em consideração deste*, o legislador comine uma *sensível ou especial agravação* da pena cabida ao crime fundamental.

§ 63 Quanto à questão essencial de saber qual a **razão material desta sensível ou especial agravação** do crime agravado pelo resultado, deve continuar a defender-se que ela reside na *especificidade do nexo entre o crime fundamental e o resultado agravante*. Esta especificidade consubstancia-se — já acima o afirmámos — no *perigo normal, típico, quase se diria necessário, que, para certos bens jurídicos, está ligado à realização do crime fundamental*; e consequentemente, pelo menos, na **negligência grosseira** em que incorre o agente que, violando o cuidado imposto, não previu ou não previu correctamente a possibilidade de da sua conduta fundamental resultar o resultado agravante ([81]). Por isso o art. 18.º exige que o resultado agravante possa ser imputado ao agente "**pelo menos** a título de negligência". Com o que se logra a compatibilização possível ([82]) desta figura típica com o princípio da culpa: não basta à imputação do resultado agravante que entre este e o crime fundamental se verifique um nexo (ainda que particularmente exigente) de *causalidade adequada*, mas é sempre e ainda necessário, relativamente à produção do resultado agravante, que se comprove pelo menos a *violação pelo agente da diligência devida* e, ademais disso, que o agente tivesse *capacidade para a observar* (infra, 35.º e 36.º Caps.).

§ 64 Quando requeremos que o perigo seja **típico** isso não significa apenas a sua "normalidade", mas a sua referência à espécie do delito fundamental: que ele possa dizer-se quase consequência necessária *daquela espécie de delito* e não também de outras espécies relativamente às quais a agravação pelo resultado não se encontre legalmente prevista. Cremos que perante esta compreensão das coisas surgirá largamente desvalorizada a exigência, feita em número significativo de casos pela jurisprudência alemã ([83]), de que o resultado agravante se revele consequência *imediata* — também em sentido temporal — do delito fundamental.

([81]) Essencialmente, neste sentido, agora, ROXIN I, § 10, n.º 108 e s.

([82]) Dizemos "possível" porque pode em todo o caso perguntar-se se, em certos casos, a moldura penal aplicável ao crime agravado pelo evento não se revela demasiado severa face ao princípio (ao limite) da culpa. Sobre a questão, no direito alemão, RENGIER, *Erfolgsqualifizierte Delikte und verwandete Erscheinungsformen*, 1986.

([83]) E a propósito da qual se tem estabelecido larga dissidência na doutrina: indicações esgotantes e discussão de casos jurisprudenciais em ROXIN I, § 10, n.º 111 e ss.

§ 65 Problema interessante que pode suscitar-se é o de saber se, ao afirmar a lei que o resultado agravante deve ser imputável ao agente "**pelo menos** a título de negligência", ela quer admitir que, em certos casos, aquele possa ser **dolosamente produzido** (o que seria de todo impossível nos quadros do crime *preter*intencional). O que será tanto mais estranho quanto, se o resultado agravante representar um crime *a se* e ele for dolosamente provocado, então a agravação específica da figura típica em estudo parece tornar-se uma inutilidade (ou, pior ainda, uma contradição) normativa; na medida em que, segundo as regras gerais, mesmo sem a agravação o agente deveria ser punido (em princípio e de acordo com o princípio da culpa mais fortemente ainda) pelo concurso do crime fundamental doloso com o crime agravante doloso. Todavia, uma resposta afirmativa à questão posta justifica-se do duplo ponto de vista acima expendido: porque o resultado agravante pode não constituir, tomado autonomamente, um crime — caso em que a agravação resultante do concurso de crimes estaria automaticamente afastada; e depois porque, mesmo que constitua um crime, pode a sua punibilidade autónoma ser restrita às hipóteses de dolo directo, e todavia o resultado agravante ter sido produzido apenas com dolo eventual. E talvez ainda (e sobretudo) porque quando a produção dolosa do resultado mais grave constituísse o fim da conduta, um *concurso efectivo* deste crime com o crime doloso antecedente (assim e agora transformado em crime-meio) poderia não dever ser aceite: infra, 43.º Cap., § 21 e ss.

§ 66 A figura do crime agravado pelo resultado, para além das especificidades construtivas acabadas de assinalar logo a nível do tipo de ilícito objectivo, suscita (ou pode suscitar) complexíssimos **problemas normativo-práticos**, *hoc sensu*, dogmáticos, **aos níveis mais diversos**: seja ao da *imputação objectiva* (que, segundo alguns, deveria aqui seguir as regras da chamada "causalidade adequada" significativamente mais rígidas e exigentes), seja ao do *tipo de ilícito subjectivo* e do *tipo de culpa* (onde poderia formar um "tipo misto" de dolo e negligência ([84])), seja ao da *tentativa* (onde se deverá investigar se e em que casos esta deverá ser punida nos termos gerais), seja a nível da *comparticipação* (onde se poderá questionar da aplicabilidade global neste contexto das regras gerais na matéria). A propósito de cada uma destas questões a especificidade desta forma típica deverá, tanto quanto possível, ser mencionada ([85]).

([84]) De "combinação-dolo-negligência" falam a propósito muitos autores alemães: p. ex., ROXIN I, § 10, n.º 108; reconhecendo no entanto, correctamente, que uma tal combinação não esgota as hipóteses desta espécie de delito.

([85]) Cf., todavia, CUNHA, Damião da, nota 80, p. 568 e ss.

§ 67 Atentas as complexas questões dogmáticas a que o crime agravado pelo resultado continua, apesar de toda a evolução verificada, a dar lugar, uma questão político-criminal básica se coloca, e cada vez com maior insistência: gozará a figura da indispensável **legitimação material** à luz das exigências político-criminais actuais? Mesmo que se considere que a imputação do resultado agravante pelo menos a título de negligência constitui uma via de compatibilização suficiente com as exigências do princípio da culpa, não será que, pelo menos em muitos casos, a agravação da pena do crime fundamental deixa dúvida de que as exigências da prevenção geral positiva (e da culpa) se não revelem excedidas? Não seria, em suma, preferível a **eliminação, pura e simples, dos crimes agravados pelo resultado**, desde que substituídos por uma revisão das molduras penais aplicáveis aos crimes fundamentais e aos crimes negligentes agravantes (deixando-se, a partir daí, funcionar as regras gerais do concurso), pela criação de crimes de perigo doloso relativamente aos bens lesados pelos resultados agravantes e pela integração destes resultados, quando em si mesmos não constituam crimes, como elementos qualificadores do tipo fundamental? Não seria que estes caminhos de **reforma legislativa** e outros afins poderiam permitir a *eliminação sem resto* dos crimes agravados pelo resultado?

§ 68 Também aqui, todavia, a moeda tem duas faces. E a outra — onde estaria implícita não a eliminação, mas o **reforço**, no futuro, da figura do crime agravado pelo resultado — tem nela inscritas as condições da vida social actual e futura, o crescimento exponencial dos resultados gravíssimos que podem imputavelmente resultar de uma multiplicidade de condutas até, em si mesmas, aparentemente insignificativas do ponto de vista da sua relevância social, mas que não podem deixar de ser proibidas (ou inclusivamente criminalizadas) perante os perigos que, da sua realização, sobretudo *aditiva*, podem derivar ([86]). A resposta só pode pertencer, em definitivo, ao legislador do futuro, a quem caberá eliminar ou, pelo contrário, incrementar — respeitando sempre, em todo o caso, o princípio da culpa — uma figura de delito que continua ainda hoje, apesar de toda a evolução sofrida, a constituir uma sobrevivência do velho aforismo canónico do *versari*.

([86]) Supra, 6.º Cap., § 72; e DIAS, Figueiredo, Sobre a tutela jurídico-penal do ambiente — um quarto de século depois, *Estudos Cunha Rodrigues*, I, 2001, p. 389 e s.

12.º CAPÍTULO

A IMPUTAÇÃO OBJECTIVA DO RESULTADO À ACÇÃO

I. Sentido do problema

§ 1 Vimos que nos *crimes de resultado* se suscita o problema da imputação do resultado à conduta do agente, de acordo com o princípio segundo o qual o direito penal só intervém relativamente a *comportamentos humanos* (de pessoas singulares ou colectivas). Exigindo-se para o preenchimento integral de um tipo de ilícito a produção de um resultado, importa verificar não apenas se esse resultado se produziu, como também se ele pode ser *atribuído* (imputado) à acção. A exigência mínima que, de uma perspectiva externo-objectiva como aquela aqui em questão, se tem de fazer ao relacionamento ou conexão do comportamento humano com o resultado, para que este possa atribuir-se ou imputar-se àquele, é a da **causalidade**, precisamente por isso tendo durante muitas décadas toda esta problemática sido tratada sob aquela epígrafe: a acção há-de, pelo menos, ter sido **causa** do resultado.

§ 2 A partir de certo momento — quando foi ultrapassada uma concepção puramente positivista, mecanicista e causalista da dogmática penal — compreendeu-se, porém, que o problema da imputação objectiva do resultado à acção, mesmo que deva ter na sua base a categoria científico-natural da causalidade, não tem por força de reduzir-se a ela: como problema de imputação objectiva típica a questão constitui uma questão **normativa** que deve pôr-se e resolver-se segundo a teleologia, a funcionalidade e a racionalidade próprias da dogmática jurídico-penal e, especialmente, da dogmática do tipo (1). A partir deste momento a questão complicou-se extraordi-

(1) Precursor, HONIG, Kausalität und objektive Zurechnung, *Frank-FG*, I, 1930, p. 174.

nariamente, a ponto de se poder afirmar que ela continua a constituir hoje uma das mais duvidosas e discutidas questões de toda a dogmática penal.

§ 3 Logo na base desta consideração se poderia pretender que existe contradição entre aceitar o carácter eminentemente normativo da valoração do ilícito típico e, do mesmo passo, referi-la a uma realidade que, como a da causa científico-natural, se verifica no plano naturalístico e só neste é comprovável. Mas este argumento não é sem mais procedente, bem podendo defender-se que a causalidade naturalisticamente comprovável constitui só o *limite máximo* e, portanto, mais longínquo, até onde pode ser levada, sem arbítrio, a imputação penal. Questão diferente será saber se a imputação deve ser levada até aí, ou antes ficar aquém, através de uma *limitação jurídica da causalidade natural* e, portanto, através de uma qualquer verdadeira teoria de **imputação jurídico-objectiva** do resultado à acção. Esta a razão por que dispomos hoje de diversas doutrinas da "causalidade jurídica" e da imputação objectiva, enquanto no plano causal-naturalístico só uma pode ser verdadeira. Numa palavra, a escolha entre aquelas diversas doutrinas supõe uma autêntica **opção normativa**, uma **valoração**, deste modo perdendo o problema aqui em causa — e foi mérito de Mezger tê-lo posto em evidência através da sua "teoria da relevância", que distingue entre causas juridicamente relevantes e irrelevantes (2) — a sua neutralidade científica e tornando-se definitivamente em problema jurídico-normativo de imputação objectiva.

II. Primeiro degrau: a categoria da causalidade

§ 4 Um primeiro degrau constitutivo da *exigência mínima* (ou, o que é o mesmo, do *limite* máximo) que, de uma perspectiva externo-objectiva, tem de (ou pode) fazer-se ao relacionamento do comportamento humano com o aparecimento do resultado, para que este deva atribuir-se ou imputar-se àquele, é pois o da pura causalidade: a acção há-de, ao menos, ter sido **causa** do resultado, aferida através da **teoria das condições equivalentes**. Teoria que surgiu, aplicada ao direito em geral e ao direito penal, com Glaser e v. Buri, em meados do séc. XIX (3), ela teve

(2) MEZGER, p. 122 e ss.

(3) GLASER, *Abhandlungen aus dem österreischischen Strafrecht*, I, 1858, p. 298; v. BURI, *Zur Lehre von der Teilnahme an dem Verbrechen und der Begünstigung*, 1860, e *Die Causalität*

o mérito de libertar o direito penal dos resquícios medievais do estabelecimento da imputação através de práticas mágicas e supersticiosas e de juízos metafísicos. A premissa básica desta teoria é a de que causa de um resultado é **toda a condição sem a qual o resultado não teria tido lugar** (fórmula chamada da **conditio sine qua non**). Por isso, todas as condições que, de alguma forma, contribuíram para que o resultado se tivesse produzido são causais em relação a ele e devem ser consideradas em pé de igualdade, já que o resultado é indivisível e não pode ser pensado sem a totalidade das condições que o determinaram.

§ 5 Para apurar quais as condições que deram causa a um certo resultado deveria assim o juiz **suprimir mentalmente** cada uma delas: caso pudesse afirmar que o resultado não se teria produzido sem essa condição, tal significaria que esta seria relevante para efeitos do estabelecimento do nexo de causalidade. Tomando como exemplo a morte de *A*, serão causais dessa morte o facto de *B* ter uma arma e com ela ter dado dois tiros em *A*, o facto de *C* ter fabricado essa arma e o facto de o taxista *D* ter levado *B* ao encontro de *A*, pois sem qualquer uma destas condições não teria sido possível a morte de *A* nas concretas condições de modo, de tempo e de lugar em que efectivamente ocorreu.

§ 6 Verifica-se deste modo que a fórmula da *conditio sine qua non* acaba por abranger a mais **longínqua** condição, implicando uma espécie de *regressus ad infinitum*, e deveria excluir da problemática qualquer consideração sobre a **interrupção do nexo causal** devida à actuação do ofendido ou de terceiro, ou ainda por efeito de uma circunstância extraordinária ou imprevisível. No exemplo que demos, se *A* viesse a morrer não dos tiros, mas devido a um incêndio ocorrido no hospital onde convalescia, ainda assim a conduta de *B* seria causa da sua morte. Dos termos em que esta teoria é concebida resulta necessariamente para cada resultado um leque extremamente amplo de causas, o que obriga os seus defensores a aceitar **correcções** quer por critérios de imputação objectiva mais exigentes do que aqueles que resultam da pura causalidade natural, quer por limitações ao nível do tipo de ilícito subjectivo e da culpa. Sendo isto certo, todavia, tal só significa que a causalidade aferida segundo o critério da equivalência não pode arvorar-se, *só por si*, em critério de *imputação objectiva*; mas não quer dizer que, *para além* dessa causalidade, seja ainda legítimo

---

und ihre strafrechtlichen Beziehungen, 1885. Sobre todo este ponto, entre nós, BELEZA, Teresa, II, p. 125 e ss.

— que o não será porventura, e pelo menos em via de princípio — imputar normativamente ao agente o resultado de uma sua acção.

§ 7 Não é a crítica acabada de formular, porém, a única que tem sido dirigida à teoria da equivalência. Afirma-se igualmente que o critério da "**supressão mental**" de uma condição, por meio do qual se pretende saber se é ela causa ou não de determinado resultado, apenas se revela prestável em certos casos, mas não noutros, nomeadamente nos casos ditos de *causalidade virtual* (*A* dispara um tiro mortal sobre *B*, no preciso momento em que este é afectado por um enfarte do miocárdio mortal), bem como nos de *dupla causalidade* ou *causalidade alternativa* (*A* e *B* colocam separadamente venenos, qualquer deles mortal, no copo de *C*, que acaba por morrer). Além destas hipóteses, o critério parece entrar em dificuldades também quando não se consiga determinar, para além de toda a dúvida razoável, se determinada acção foi realmente condição *sine qua non* de um certo resultado. Situação esta que está a tornar-se cada vez mais frequente no seio da "sociedade do risco", em hipóteses como, por exemplo, as dos atentados ao ambiente, da manipulação genética, da responsabilidade pelo produto (infra, § 45 e s.) (4); como igualmente existirão dificuldades especiais de comprovação quando se trate da responsabilização de entes colectivos ou mesmo só da divisão de responsabilidade no seio de uma direcção empresarial, de uma equipa médica, cirúrgica, etc. (infra, § 47 e ss.). A aplicação deste critério seria no momento presente inútil para apurar, por exemplo, se o facto de se alimentar o gado bovino com rações animais e com isso provocar nele a doença das "vacas loucas", cuja carne foi ingerida por pessoas que posteriormente contraíram a síndroma de Creutzfeld-Jakobs e dela vieram a morrer, terá sido condição *sine qua non* destas mortes. O que tem aberto a porta à conclusão de que, formulada nos termos da *conditio sine qua non*, a teoria das condições equivalentes é inútil, precisamente porque já traz pressuposto aquilo que com ela deveria determinar-se.

§ 8 Perante estas críticas — na substância, de resto, já antigas —, a teoria das condições equivalentes foi objecto de uma "reconstrução" que pas-

(4) Sobre esta última, com exemplos reais como os da Talidomida, do *Lederspray* e do óleo de *colza*, DIAS, Silva, *Protecção Jurídico-Penal dos Interesses dos Consumidores*, ³2001, p. 61 e ss.

sou pelo abandono daquele critério da "supressão mental" e pela sua substituição pelo critério — já em alguma medida *normativo* — da **condição conforme às leis naturais**. Segundo este critério ([5]), o estabelecimento da causalidade está dependente de "saber se uma acção é acompanhada por modificações no mundo exterior que se encontram vinculadas a essa acção de acordo com as leis da natureza e são constitutivas de um resultado típico" ([6]).

§ 9 A esta concepção se tem obtemperado que, justamente em muitas hipóteses como as assinaladas, próprias da sociedade do risco, os dados científicos disponíveis sobre a conformidade às leis naturais ou não dizem nada, ou não são suficientes, ou não são fiáveis ([7]). Pelo que nada mais restaria senão o apelo às **leis da experiência**, de base **estatística** ou **probabilística**; extensão que começa a ser aceite pela jurisprudência alemã e — por veses sob a epígrafe da **causalidade geral**, **generalizadora** ou **global** ([8]) — encontra cada vez mais adeptos na doutrina ([9]). Pondo aqui entre parênteses a questão de saber se esta concepção deparará com dificuldades dificilmente superáveis face ao princípio jurídico-processual penal *in dubio pro reo* ([10]), diz-se — aparentemente com razão — que uma comprovação probabilística da causalidade não pode constituir mais ([11]) do que uma mera *hipótese* de causalidade. A verdade porém é que a ciência actual — pense-se, p. ex., na ciência médica — não prescinde hoje, cada vez mais, destes juízos estatísticos e generalizadores e sobre eles constrói o progresso do conhecimento técnico-científico e das suas realizações. Por isso se pode concluir aqui que uma comprovação conforme às leis científicas, ainda que de base estatística ou probabilística, é bastante como degrau ineliminável, em certos casos, da imputação jurídico-penal, pelo menos sob a

---

([5]) Formulado inicialmente por ENGISCH, *Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände*, 1931, esp. p. 21.

([6]) JESCHECK / WEIGEND, § 28, II, 4.

([7]) Assim — e também essencialmente no sentido da conclusão que se segue —, HASSEMER / MUÑOZ CONDE, *La responsabilidad por el producto en derecho penal*, 1995, p. 124 e ss., DIAS, Silva, nota 4, p. 65, VOGEL, La responsabilidad penal por el producto en Alemania: Situación actual y perspectivas de futuro, *Revista Penal 8*, 2001, p. 95.

([8]) Assim a jurisprudência alemã, com restrito aplauso doutrinal: VOGEL, nota 7, p. 96.

([9]) Indicações, por último, em ROXIN I, § 11, n.º 36.

([10]) Cf., em todo o caso, DIAS, Silva, nota 4, p. 65 e ss., VOGEL, nota 7, pp. 96 e s. e 98 e s., STELLA, *Giustizia e modernità*, ²2002, p. 60 e ss., e VIDAL, Simões, *Causalidade Científica em Direito Penal*, 2004, *passim*, p. 305 e s.

([11]) Tem razão HASSEMER, *in*: Hassemer / Muñoz Conde, nota 7, p. 128, ao afirmá-lo.

forma de que *a condição lesiva seja determinada de modo convincente, uma vez que, também de modo convincente, se pode excluir um terceiro factor interveniente* ([12]).

§ 10 Apesar de todas as críticas formuladas e de todas as dificuldades encontradas, a doutrina das condições equivalentes continua a recolher generalizada aceitação em direito penal. Se abstrairmos de críticas desrazoáveis — como a de, em último termo, todo o crime ter como causa o acto gerador do mais longínquo antepassado, que levou ao nascimento do agente (!) —, o seu defeito principal reside na *exagerada extensão que confere ao objecto da valoração jurídica*. Isso, porém, nada diz em definitivo contra a teoria da equivalência como **máximo denominador comum de toda a teoria da imputação**. Só diz, isso sim, que a relação de causalidade, embora sempre *necessária*, não é *suficiente* para se constituir em si mesma como doutrina da imputação objectiva. Importa pois, guardando este primeiro escalão da imputação, subir agora de nível, ao patamar da *valoração jurídica*, para determinar em definitivo quais as exigências indispensáveis a que se perfaça uma coerente doutrina da imputação.

III. Segundo degrau: a causalidade jurídica sob a forma da teoria da adequação

§ 11 Do exposto resulta que o critério de imputação tem de ser formulado em termos tais que permitam afastar diversas condições de verificação do resultado. Neste pressuposto foi concebida (ainda sob o signo da "causalidade") a teoria da **adequação** ou teoria da **"causalidade adequada"**. Distinguindo entre condições (juridicamente) relevantes e irrelevantes, ela já nada fica em rigor a dever a uma teoria pura da "causalidade", antes se apresenta verdadeiramente como uma teoria da "imputação". Sendo embora assim, bem pode ainda suportar-se o designativo de doutrina

---

([12]) Restando saber se, como sugere ROXIN I, § 11, n.º 38, esta concepção probabilística não é já parte componente de uma *teoria da potenciação do risco* (infra, § 28) como categoria central da imputação objectiva. De uma *função heurística* da causalidade falam MENDES, P. de Sousa / MIRANDA, António J., A causalidade como critério heurístico — uma demonstração através do exemplo da manipulação de cotações no mercado financeiro, *RPCC 15*, 2005, p. 196 e ss. Os AA. procuram demonstrar ser possível fazer prova de que determinada informação teve impacto na cotação em bolsa, apesar da concorrência de outras informações com capacidade para influenciar aquela cotação.

"causal", na medida em que ela surge como critério *complementar* da teoria das condições equivalentes, por isso que para que o resultado possa ser imputado à acção é ainda e sempre necessário que, em concreto, se tenha verificado um nexo causal entre ambos.

§ 12 A teoria da adequação pretende traduzir o critério segundo o qual *a imputação penal não pode nunca ir além da capacidade geral do homem de dirigir e dominar os processos causais* ([13]). O critério geral da teoria da adequação, criada nos finais do séc. XIX por v. Kries com carácter geral e por ele aplicada depois ao direito penal ([14]), reside em que para a valoração jurídica da ilicitude serão relevantes não todas as condições, mas só **aquelas que, segundo as máximas da experiência e a normalidade do acontecer — e portanto segundo o que é em geral previsível —, são idóneas para produzir o resultado**. Consequências *imprevisíveis*, *anómalas* ou de *verificação rara* serão pois juridicamente irrelevantes. Neste sentido deve interpretar-se o art. 10.º-1. A referência aí feita tanto à "acção *adequada*" a produzir um certo resultado, como à "omissão da acção *adequada* a evitá-lo" quer significar que o CP português adoptou, ao menos como critério básico da imputação objectiva, a teoria da adequação. O que representou, de resto, uma escolha natural, dado ser esta a teoria que há longo tempo recolhia as preferências da doutrina ([15]) e da jurisprudência ([16]) portuguesas. São várias, porém, as **dificuldades** com que depara a teoria da adequação.

§ 13 Uma das dificuldades resulta do facto de o critério da adequação dever ser **geral e objectivo**, enquanto, *depois* de o resultado se ter verificado, dificilmente se pode negar a sua previsibilidade. O que conduz à conclusão de que o nexo de adequação se tem de aferir segundo um **juízo ex ante** e não *ex post*, mais rigorosamente, segundo um **juízo de prognose**

([13]) Na origem desta teoria terá estado a necessidade de evitar as injustiças derivadas da aplicação da teoria da *conditio sine qua non* aos *crimes agravados pelo resultado*, tanto mais quanto, como já sabemos (supra, 11.º Cap., § 57 e ss.), não podiam nessa altura intervir, quanto a estes, critérios correctores derivados do princípio da culpa.

([14]) V. KRIES, *Die Prinzipien der Warscheinlichkeitsrechnung*, 1886, e Über die Begriffe der Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit und ihre Bedeutung im Strafrecht, *ZStW 9*, 1889, p. 528.

([15]) Cf. CORREIA, Eduardo, I, n.º 54; FERREIRA, Cavaleiro de, I, 1981, p. 148 e ss.; SILVA, Marques da, II, p. 57.

([16]) V., p. ex., Acs. do STJ de 23-6-1965, *BMJ 148*, p. 184, e de 15-5-1968, *BMJ 177*, p. 121.

póstuma. Tal significa que o juiz se deve deslocar mentalmente para o passado, para o momento em que foi praticada a conduta e ponderar, enquanto observador objectivo, se, dadas as *regras gerais da experiência e o normal acontecer dos factos* (o *id quod plerumque accidit*), a acção praticada teria como consequência a produção do resultado. Se entender que a produção do resultado era imprevisível ou que, sendo previsível, era improvável ou de verificação rara, a imputação não deverá ter lugar.

§ 14 **Exemplos** de escola: não configura um crime de homicídio o caso em que *A* dá uma navalhada superficial em *B*, que acaba por morrer devido a hemofilia; como também não comete um homicídio *C* que se disponibiliza a pagar a passagem aérea da sua sogra *D*, numa viagem que ela poderia fazer razoavelmente de comboio, com a esperança de que o avião caia, acabando *D* por morrer devido à queda do avião. Exemplo da vida real, aquele sobre que recaiu o Ac. do STJ de 3-12-1997, Proc. 97P964: "À luz da experiência comum, a acção de introduzir, sem rodar, uma chave de luneta no sextavado do taco do bujão de um permutador de gás propano, não é adequado a fazer saltar esse taco do orifício onde estava enroscado: o taco saltou do orifício porque estava danificado; igualmente, à luz da experiência comum, não é normal, não corresponde ao *id quod plerumque accidit*, que um bujão enroscado salte por simples contacto, sem qualquer movimento a desenroscá-lo, pois, se o bujão saltou é porque não estava enroscado, estava muito deteriorado nos filetes de rosca, que não enroscavam. Não se tendo provado que o arguido, quando colocou a chave no taco, tivesse conhecimento ou devesse conhecer tal deficiência, não lhe podem ser imputadas, ainda que a título de negligência, as consequências da saída do taco (fuga franca de gás, seguida de incêndio, de que resultaram dois mortos), pois aquele resultado não se insere tipicamente no processo causal".

§ 15 Ao juízo de prognose póstuma devem ser levados os já referidos conhecimentos correspondentes às regras da experiência comum, mas não só. Além destes, devem ser tidos em conta — o que, em lógica pura, representa já uma entorse no princípio geral da adequação, ainda que justificável — os **especiais conhecimentos do agente**, aqueles que o agente efectivamente detinha, apesar de a generalidade das pessoas deles não dispor ([17]).

§ 16 Daí que seja relevante a prova que em tribunal se produza ou não sobre esses factos. Nesse sentido vai o Ac. citado no § 14 e ainda o Ac. do STJ de 21-4-1994, Proc. 046105: "Apenas comete o crime do artigo 142.º [actual art. 143.º, ofensa à integridade física simples] o arguido que dá um empurrão no ofendido, apesar de este

([17]) Sobre esta questão, por último, GRECO, Das Subjektive an der objektiven Zurechnung, *ZStW 117*, 2005, p. 519.

vir a falecer em consequência de enfarte do miocárdio, desde que não se provou que ele tinha conhecimento dessa doença cardíaca e que tivesse utilizado esse empurrão para fazer surgir tal enfarte". Assim também, nos exemplos acima dados, se *A* sabia que *B* era hemofílico já se lhe pode imputar a morte deste; bem como se *C* sabia que ia ser colocada uma bomba no avião em que *D* deveria viajar.

§ 17 Outro ponto que merece ainda atenção diz respeito à necessidade de a adequação **se referir a todo o processo causal** e não só ao resultado, sob pena de se alargar em demasia a imputação. Aqui se suscitam os problemas da "intervenção de terceiros" e da chamada "interrupção do nexo causal". Tendo como referência a regra geral da teoria da adequação, a **actuação de terceiro** que se integre no processo causal desencadeado pelo agente excluirá a imputação, salvo se ela aparecer como **previsível** e **provável**.

§ 18 Assim, no caso em que *A* deixa uma arma carregada em local onde *B* e *C* travam violenta discussão, pode ser imputada a *A* a morte de *C* se esta foi produzida por disparos efectuados por *B* com essa arma apenas quando, face à intensidade da querela, se possa considerar normal que um dos contendores pegasse na arma e disparasse. Neste sentido, o Ac. do STJ de 7-12-1988 ([18]): "Os réus, que, embora não tenham estado presentes, quando o ofendido foi apanhado e agredido, colaboraram no seu transporte para o largo de uma povoação e ao chegarem ali previram a possibilidade de ele ser morto pela população e, não obstante isso, não se retiraram e, descarregaram-no, entregando-o à populaça [que o matou], devem ser considerados co-autores do crime de homicídio, sob a forma de acção" ([19]). Mas suponha-se agora o caso de *D* que, com intenção de matar, agride *E*, acabando este por morrer devido aos ferimentos causados, que todavia não teriam produzido a morte se *E* tivesse sido tratado de forma diligente pelos médicos: nesta situação não deverá *D* ser condenado a título de homicídio consumado, mas tão-só tentado, pois o resultado não lhe pode ser imputado, apesar de ter sido por ele causado, uma vez que seria de esperar uma actuação atenta e cuidadosa dos médicos, que, a não ter acontecido, "interrompeu" o nexo de causalidade adequada.

§ 19 A questão da **interrupção do nexo causal** por intervenção de terceiro parece já não assumir relevância num outro ponto, salientado por Eduardo Correia: "*A* dá uma pancada em *B*, adequada a produzir-lhe a morte, mas, antes desta se verificar, *C* desfecha um tiro sobre *B* que o mata imediatamente" ([20]). Aqui, Correia sentia a

([18]) *BMJ 382*, p. 276.

([19]) Um comentário a este acórdão em ALMEIDA, Carlota Pizarro de, *Casos e Materiais de Direito Penal*, 2000, p. 299 e ss.

([20]) CORREIA, Eduardo, I, n.º 54, I.

necessidade de fazer intervir uma correcção da teoria da adequação para que não se imputasse a *A* um crime de homicídio consumado. Parece porém que, comprovando-se que a morte não foi concretamente produzida pela actuação de *A*, mas sim devido à conduta de *C*, cuja actuação não se integrou no processo causal por aquele posto em marcha, mas foi antes autónoma, fica excluída a imputação em relação a *A*, desde logo por não existir qualquer nexo causal entre a acção e o resultado.

§ 20 No entanto, são várias as situações em que a solução oferecida pela teoria da adequação se mostra **insatisfatória**. Tal sucede sobretudo em actividades que, comportando em si mesmas **riscos** consideráveis para bens jurídicos, são todavia legalmente **permitidas (não proibidas)**. Domínios como o da circulação rodoviária, o da produção e transporte de produtos perigosos, o das intervenções médicas arriscadas (se bem que necessárias), o da danificação ou destruição dos ecossistemas, o da tecnologia genética, etc., colocam problemas de imputação que não podem ser resolvidos correctamente pela teoria da adequação, na medida em que, na generalidade destes casos, a acção se revela *adequada* à produção do resultado típico; enquanto, por outro lado, não é possível *proibir* tais condutas sem conduzir a vida social ao retrocesso ou mesmo à paralisação ([21]). Por isso o degrau da adequação tem ainda de ser completado (eventualmente, em certos pontos corrigido) por aquilo que poderá designar-se, com Stratenwerth, como a "conexão" ou "relação de risco" ([22]).

IV. Terceiro degrau: a conexão de risco

§ 21 A ideia-mestra que vimos presidir à teoria da adequação é a de *limitar* a imputação do resultado àquelas condutas das quais deriva um *perigo idóneo* de produção do resultado. Pondo em especial evidência este perigo, situamo-nos mesmo no âmago das doutrinas actuais da conexão de risco: o resultado só deve ser imputável à acção quando esta tenha **criado** (ou aumentado, ou incrementado) **um risco proibido** para o bem jurídico protegido pelo tipo de ilícito e **esse risco se tenha materializado no resultado típico** ([23]). Por outras palavras, para esta teoria a imputação

---

([21]) De outra opinião, pelo menos no que respeita aos factos negligentes, CORREIA, Eduardo, Les problèmes posés par le developpemente des infractions non-intentionelles (par faute), separata do *BMJ*, 1961, p. 9 e s.

([22]) STRATENWERTH / KUHLEN, § 8, n.º 25 e ss.

([23]) Fundamental, ROXIN, Gedanken zur Problematik der Zurechnung im Strafrecht, *Honig-FS*, 1970, p. 133 (versão portuguesa em ROXIN, *Problemas Fundamentais de Direito*

está dependente de um duplo factor: primeiro, que o agente, com a sua acção, tenha *criado* um risco não permitido ou tenha *aumentado* um risco já existente; e, depois, que *esse* risco *tenha conduzido* à produção do resultado concreto. Quando se não verifique uma destas condições a imputação deve ter-se por excluída.

1. Criação de um risco não permitido

§ 22 O problema começa, neste contexto, por ser o de determinar os riscos a cuja produção pode ser razoavelmente referido o tipo objectivo de um crime de resultado, isto é, o âmbito ou o círculo dos riscos que, neste sentido, devem considerar-se juridicamente desaprovados e, em consequência, *não permitidos* ([24]). Apesar de todos os esforços doutrinais desenvolvidos o procedimento é — e, em último termo, tem de ser — eminentemente *casuístico*, embora susceptível de uma certa "tipologia".

§ 23 (1) Isentas de dúvida são todas aquelas hipóteses em que, com a sua acção, o agente **diminui** ou **atenua** um perigo que recai sobre o ofendido. Por exemplo, *A* empurra *B*, causando-lhe leves lesões, para evitar que este seja atropelado por um veículo que segue na sua direcção. Seria previsível e provável que à acção de *A* se seguissem aquelas lesões de *B* e, por isso, seguindo a teoria da adequação, estas ser-lhe-iam imputáveis. A esta solução deve preferir-se a da doutrina da conexão de risco, que nega a imputação por inexistência de criação de um risco não permitido. É verdade que, mesmo seguindo-se a teoria da adequação, a responsabilidade penal do agente acabaria certamente excluída por ter ele actuado ao abrigo de uma causa de exclusão da ilicitude, *v. g.*, a do direito de necessidade (art. 34.º). Todavia, isso significaria aceitar que o agente, com a sua acção, realizou uma lesão típica do bem jurídico, quando na rea-

---

Penal, 1986, p. 145). Uma boa panorâmica sobre o estado actual da questão encontra-se em FRISCH, W., La imputación objectiva: estado de la questión, *in*: Roxin / Jakobs / Schünemann / Köhler (orgs.), *Sobre el estado de la teoria del delito*, 2000, p. 21. Entre nós, cf. BELEZA, Teresa, II, p. 230 e ss.

([24]) Para FRISCH, *Tatbestandsmässiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs*, 1988, p. 33 e ss., e *passim*, e nota 23, p. 59 e ss., esta não seria uma questão específica da imputação objectiva, mas logo à partida da *tipicidade*. Cf., agora, a discussão com Roxin, sobre este ponto, em FRISCH, W., Faszinierendes, Berechtigtes und Problematisches der Lehre von den objektiven Zurechnung des Erfolgs, *Roxin-FS*, 2001, p. 232 e ss.

lidade a sua actuação se traduziu, pelo contrário, numa *melhoria* da situação do bem jurídico em perigo (25).

§ 24 (2) A imputação deverá ter-se igualmente por excluída quando o resultado tenha sido produzido por uma acção que **não ultrapassou o limite do risco juridicamente permitido**. Este critério está relacionado com o facto (já acima mencionado) de a vida social comportar uma multidão ineliminável de riscos e perigos tolerados pela própria sociedade, pois que estão associados a conquistas civilizacionais e a modelos de desenvolvimento de que a sociedade não pode, nem quer prescindir. Daí resulta que não pode o direito penal, dada a sua natureza de *ultima ratio*, sancionar comportamentos que tenham produzido a lesão de bens jurídicos em virtude da materialização de riscos que são tolerados de forma geral. Cumpre à ordem jurídica definir quais as regras a observar, quais as precauções e cuidados a ter na prática dessas actividades que por si mesmas comportam perigos para bens jurídicos. E nesse sentido surgem normas que regulam, por exemplo, a circulação rodoviária, o uso de pesticidas na actividade agrícola, o uso de explosivos em pedreiras e construções, o manuseamento de vírus, de bacilos, de energia atómica. Pode acontecer que a ordem jurídica nada disponha ou disponha insuficientemente acerca dos procedimentos a seguir em certas actividades perigosas. Assim, em áreas como a *medicina*, são determinantes as chamadas *leges artis*; na falta de regulação legal devem ser observadas aquelas regras que os agentes do respectivo sector do tráfico seguem de forma habitual, por a ordem jurídica considerar que desse modo se contêm de forma satisfatória e razoável os riscos inerentes à respectiva actividade (26). Na área da *competição desportiva*, por outro lado, defende Costa Andrade que é em princípio em nome do risco não proibido — antes que da "adequação social" (27) — que,

---

(25) Neste sentido, ROXIN I, § 11, n.º 48. Desvalorizando esta problemática — que acaba por considerar um "lugar comum" (p. 161) — SCHRÖDER, F.-C., Die so genannte Risikoverringerung, *in*: Hefendehl (org.), Empirische und dogmatische Fundamente, kriminalpolitischer Impetus, Schünemann-Symposium, 2005, p. 151.

(26) Esta temática, embora relevante também em matéria de delitos dolosos, tem particular aplicabilidade (e suscita particulares problemas) no domínio da *negligência*. A esse propósito será pois especificamente considerada: infra, 35.º Cap., § 16 e ss.

(27) Assim, todavia, entre nós, FARIA, Paula Ribeiro de, *A Adequação Social da Conduta no Direito Penal ou o Valor dos Sentidos Sociais na Interpretação da Lei Penal*, 2003, p. 490 e ss.; essencialmente na base de uma *supremacia da valoração penal* sobre qualquer regra ou juízo que possa ser feito sobre o concreto comportamento por outras normas do ordenamento e

sob certos pressupostos, deve negar-se a tipicidade de ofensas à integridade física (ou eventualmente da própria morte) do contendor ou do adversário: "a obediência às regras do jogo [assim conclui o seu estudo] afastará, em princípio, o tipo (...) Mas já a inversa não é verdadeira: a violação das regras do jogo não tem necessariamente — nem sequer normalmente — de realizar o risco proibido capaz de suportar a imputação do resultado típico. Tal só sucederá nas constelações em que a violação das regras, pela sua violência e desproporcionalidade e pela gravidade das lesões produzidas, *perde a conexão de sentido com o jogo*, mesmo o jogo jogado com o mais exasperado e agónico empenhamento" ([28]).

§ 25 Exemplo paradigmático de exclusão da imputação nestas situações é o da **condução automóvel** com respeito pelas regras rodoviárias e de manutenção e conservação do veículo. É o caso de *A* que, em dia de chuva, não obstante cumprir todas essas regras, perde o controlo do seu carro devido a um inesperado lençol de água na estrada e embate violentamente no automóvel de *B* que seguia em sentido contrário e acaba por morrer em consequência do acidente. Pode este resultado ser imputável à conduta de *A*? A resposta da teoria da adequação deveria ser em princípio afirmativa, uma vez que seria normal que daquele embate resultasse a morte de *B*. Solução que, à luz das considerações expostas, não seria a mais correcta. Preferível é a solução de excluir a imputação pelo facto de a conduta de *A* se ter mantido dentro do risco permitido.

§ 26 (3) Dentro do risco permitido mantém-se o chamado **risco geral de vida** ([29]), desde que ele se possa considerar, no caso, dotado de uma medida (nem sempre fácil de determinar) **normal**. Isto se deve acentuar muito vivamente numa época como a nossa, que leva até ao limite — mas também, quantas vezes, até ao exagero e à "ideologia" — o tão reclamado "direito à segurança". Mais uma vez, a vida social seria condenada à inacção se pudessem imputar-se resultados que cabem naquele risco normal. Quando, por exemplo, o médico receita um antibiótico necessário à cura de um paciente deve informar-se sobre se há alguma razão para supor que o doente possa ser hipersensível ao medicamento; mas, em caso negativo, não tem que condicionar a receita à execução de todos

---

que leva a convocar outros princípios e pontos de apoio interpretativos além daquelas regras. Cf., também, ZIPF, *Einwilligung und Risikoübernahme im Strafrecht*, 1970, p. 84

([28]) ANDRADE, Costa, As lesões corporais (e a morte) no desporto, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 719 (s.n.o.).

([29]) Cf., já, CORREIA, Eduardo, I, n.º 54: "risco imanente à própria vida na comunidade; FRISCH, W., *Zurechnung*, nota 24, p. 236 e ss.; e STRATENWERTH / KUHLEN, § 8, n.º 28.

os exames complementares indispensáveis à despistagem de uma eventual hipersensibilidade. Se o paciente vem a morrer de choque anafiláctico a morte não deve ser objectivamente imputada ao médico. Neste contexto se pode afirmar, com Stratenwerth, que os riscos gerais da vida são **socialmente adequados** (supra, 11.º Cap., § 15 e ss.) e não cabem, por isso, na criação de um risco não permitido. Se tais casos são frequentes em tema de negligência, não deve de modo algum afirmar-se que eles sejam inimagináveis relativamente a condutas dolosas.

§ 27 (4) Já supra (§ 17 e ss.), no estudo da doutrina da adequação, foi questão — sob a epígrafe da "interrupção do nexo de causalidade" — daqueles casos em que o resultado se verifica em consequência de uma **co-actuação da vítima ou de terceiro**. Estes casos, em rigor, não podem assumir relevo de um ponto de vista de pura "causalidade". Também para eles, por conseguinte, a sede mais natural de tratamento será a da criação de um risco não permitido. E a solução deverá ser a de que em princípio o resultado não é imputável em virtude da interposição da **auto-responsabilidade** da vítima ou do terceiro. Exemplos: *A*, portador de SIDA, mantém contactos sexuais com *B*, conhecedor da situação, criando em *B* perigo de infecção; *C* deixa uma porção de droga disponível a um toxicómano, *D*, que, ao ingeri-la, acaba por morrer de *overdose*. Estas acções mantêm-se dentro do risco permitido, só assim não sucedendo em casos excepcionais, se particulares circunstâncias tornarem altíssimamente provável, *em concreto*, a conduta posterior da vítima ou de terceiro ([30]).

2. A potenciação do risco

§ 28 Sucede muitas vezes que, na situação, *já está criado*, antes da actuação do agente, um risco que ameaça o bem jurídico protegido. Não obstante, o resultado será ainda imputável ao agente se este, com a sua conduta, *aumentou* ou *potenciou* o risco já existente, **piorando**, em consequência, a situação do bem jurídico ameaçado ([31]). São objectivamente imputáveis, por conseguinte, condutas como a daquele que dá a morte a um paciente já moribundo, ou agrava o estado corporal de um doente, ou

([30]) Daqui derivando uma certa restrição do que se disse supra, § 17 e s., à luz da interpretação dada por Eduardo Correia à doutrina da adequação.

([31]) Fundamental, de novo, ROXIN, Pflichtwidrigkeit und Erfolg bei fahrlässigen Delikten, *ZStW 74*, 1962, p. 411 (em português na colectânea citada na nota 23, p. 235).

aumenta a medida do dano já sofrido por uma coisa móvel. Aqui surgirá o exemplo de escola do condutor de uma ambulância que, em virtude de uma manobra errada, causa a morte do paciente que transportava e que, em todo o caso, se encontrava já em péssimo estado em virtude de um enfarte maciço do miocárdio. O mesmo sucederá, de resto, relativamente a situações — de avaliação muitas vezes altamente complexa — de **intervenção num processo causal de salvamento**, quando precisamente o comportamento do agente afasta, impede ou faz em todo o caso diminuir as hipóteses de salvamento de um bem jurídico já em perigo (o agente não traz o bote que deverá ir ajudar a salvar uns nadadores em perigo, ou condu-lo defeituosamente provocando a sua inutilização, ou condu-lo com demasiada lentidão). A questão da "potenciação do risco" suscita porém dificuldades — que vêm dividindo as doutrinas e as jurisprudências — mas que, verdadeiramente, respeitam já à questão, a tratar em seguida, da concretização do perigo não permitido no resultado típico.

3. A concretização do risco não permitido no resultado típico

§ 29 Já se disse que, na doutrina da conexão de risco, não basta a comprovação de que o agente, com a sua acção, produziu ou potenciou um risco não permitido para o bem jurídico ameaçado; é preciso ainda determinar se foi esse risco que se **materializou** ou **concretizou** no resultado típico. Esta determinação constitui uma tarefa de alta dificuldade e, em certos casos — nos casos exactamente chamados de **concurso de riscos** ([32]) —, de tratamento que continua a ser tão duvidoso que, quanto a ele, se mantêm sensivelmente divididas as doutrinas e as jurisprudências.

§ 30 A dificuldade provém sobretudo ([33]) de que sobre a existência e as características do perigo é decisivo (dissemo-lo, em geral, a propósito da doutrina da adequação) um juízo **ex ante**, enquanto saber que perigo acabou por determinar o resultado é questão que só pode ser respondida **ex post**, isto é, com conhecimento de todas as circunstâncias relevantes para a verificação efectiva do resultado. Em casos como, por exemplo, o da

---

([32]) Cf., de forma especial, JAKOBS, 7/72 e ss.; e, na nossa literatura, NEVES, Curado, *Comportamento Lícito Alternativo e Concurso de Riscos*, 1989, e PALMA, Fernanda, A teoria do crime como teoria da decisão penal, *RPCC 9*, 1999, p. 549 e ss.

([33]) Como agudamente notou STRATENWERTH, Bemerkungen zum Prinzip der Risikoerhöhung, *Gallas-FS*, 1973, p. 227.

ambulância acima referido torna-se extremamente difícil decidir, *ex post*, se o resultado morte deve ser imputado ao perigo "enfarte" ou antes ao perigo "acidente rodoviário". Se a resposta for a de que, mesmo que o acidente se não tivesse verificado, o doente *possivelmente*, ou *provavelmente*, ou mesmo *quase com certeza* teria morrido, deve continuar a afirmar-se a imputação objectiva à conduta defeituosa de condução do motorista da ambulância? Trata-se aqui, substancialmente, dos casos conhecidos agora na doutrina sob a epígrafe geral dos **comportamentos lícitos alternativos**.

§ 31 Destes costumam apresentar-se exemplos como — caso real da jurisprudência alemã — o do director de uma fábrica de pincéis de barbear que adquiriu pêlos de cabra chinesa como matéria-prima para a sua empresa, não tendo ordenado uma desinfecção a esse material, como estava legalmente prescrito. Posteriormente, quatro trabalhadores foram infectados por bacilos de carbúnculo e morreram. Investigado o caso, provou-se que mesmo que se tivesse procedido à desinfecção o resultado *teria sido o mesmo*, por se tratar de um bacilo até à altura desconhecido na Europa e resistente a qualquer processo de desinfecção. Ou como o do automobilista que ultrapassa um ciclista sem respeitar a distância imposta, atropelando-o; mas comprovando-se depois que o ciclista circulava com oscilações devidas ao estado de embriaguez em que se encontrava, de modo que seria *provável* que ele tivesse sido atropelado na mesma ainda quando o automobilista tivesse respeitado a distância de ultrapassagem imposta.

§ 32 No tratamento da imputação objectiva de casos tais duas comprovações parecem seguras. A primeira é a de que, aplicando-lhes a doutrina da **adequação**, não poderão deixar de imputar-se aqueles resultados à respectiva conduta, por ser normal e previsível, segundo um juízo de prognose póstuma, que o resultado se produziria. A outra é a de que o mesmo parece suceder à luz de um puro critério de **potenciação do risco**, na medida em que qualquer daquelas condutas servisse para aumentar o perigo para os bens jurídicos ameaçados. Uma correcta solução parece, porém, não poder ser encontrada através de uma consideração *unitária* das diversas constelações problemáticas que aqui se suscitam ([34]).

([34]) No sentido que se segue vai, no fundamental, a doutrina de ROXIN, nota 31, por ele apelidada "teoria da elevação do risco". Uma solução mais drástica do que a que em seguida se defenderá — no sentido de que, ao menos em princípio, o comportamento lícito alternativo exclui a imputação objectiva do resultado — é sugerida por FRISCH, *in*: Roxin / Jakobs..., nota 23, p. 49: "a produção hipotética do resultado em caso de conduta (alternativa) adequada ao direito mostra que a produção real do resultado não é consequência específica da acção antijurídica". Ao que informa ROXIN I, § 11, n.º 90, é esta também a posição mais recente da jurisprudência alemã.

§ 33 (1) Demonstrando-se que o resultado teria tido **seguramente** lugar — sensivelmente no mesmo tempo, do mesmo modo e nas mesmas condições — ainda que a acção ilícita não tivesse sido levada a cabo, parece que a imputação objectiva **deve ser negada**, seja porque não se torna possível comprovar aqui verdadeiramente uma *potenciação* do risco já autonomamente instalado, seja porque, como sustenta Roxin, se não pode dizer sequer que o comportamento do agente *criou* um risco não permitido: verificando-se que tanto a conduta indevida, como a conduta lícita "alternativa" produziriam o resultado típico, a imputação deste àquela traduzir-se-ia na punição da violação de um dever cujo cumprimento teria sido inútil, o que violaria o *princípio da igualdade* ([35]) ([36]).

§ 34 (2) Diferentes e de solução mais complexa são os casos em que se não demonstra que também com o comportamento alternativo lícito o resultado típico teria *seguramente* tido lugar, mas apenas que era **provável** ou simplesmente **possível** que tal acontecesse. Herzberg sustentou que imputar objectivamente o resultado à acção ainda nestes casos significaria fazer funcionar a dúvida (e nesta parte todos os casos serão de dúvida) *contra* o arguido e, assim, violar o princípio processual penal — entre nós jurídico-constitucionalmente imposto: cf. CRP, art. 32.º-2 — *in dubio pro reo* ([37]). Mas, do ponto de vista da doutrina da conexão de risco, o que importa é — nos precisos termos em que tal se torna indispensável no processo penal — **provar a potenciação do risco e a sua materialização no resultado típico**. Se, *quanto a este ponto*, apresentada toda a prova possível, o juiz ficar em dúvida, deve valorá-la *a favor do arguido*, excluindo a imputação ([38]). Uma vez demonstrada, porém, a potenciação do risco e a sua materialização no resultado, o dito "comportamento lícito alternativo" deve ser considerado irrelevante. Como Stratenwerth conclui, o princípio da potenciação do risco "pressupõe, por outras palavras, que o agente — comprovadamente! — frustrou medidas que teriam afastado, com uma certa probabilidade, sob certas circunstâncias mesmo mensurável, o resultado jurídico-penalmente relevante" ([39]).

([35]) ROXIN I, § 11, n.º 74.

([36]) Não devem confundir-se as situações de comportamento lícito alternativo com as situações de causalidade hipotética ou causalidade virtual. Cf. infra, § 40.

([37]) HERZBERG, Die Kausalität beim unechten Unterlassungsdelikt, *MDR*, 1971, p. 882.

([38]) No mesmo sentido, PALMA, Fernanda, nota 32, p. 543.

([39]) STRATENWERTH / KUHLEN, § 8, n.º 37.

4. A produção de resultados não cobertos pelo fim e pelo âmbito de protecção da norma

§ 35 Para que a conexão de risco possa dizer-se estabelecida em termos de fundar a imputação do resultado à acção torna-se ainda necessário que o perigo que se concretizou no resultado seja um daqueles **em vista dos quais a acção foi proibida**, quer dizer, seja um daqueles que corresponde ao *fim de protecção da norma de cuidado* (40). Se tal não suceder deve ter-se por excluída a imputação objectiva. Ainda desta vez, deve reconhecer-se que uma tal solução não seria necessariamente alcançável através da teoria da adequação (41). De novo também, o campo por excelência desta situação é o da negligência (42), mas ela pode ocorrer igualmente no âmbito de acções dolosas.

§ 36 Para uma melhor compreensão, atente-se no seguinte exemplo decidido nos tribunais portugueses (43). *A* inicia uma manobra de ultrapassagem sobre *B*. No decurso da manobra, *B*, sem reparar que está a ser ultrapassado, vira à esquerda e embate no outro automóvel, que já se encontrava na outra faixa de rodagem. Do acidente resultou a morte de *C*, acompanhante de *B*. *A* foi acusado da prática de um homicídio negligente por, ao realizar a ultrapassagem, seguir a 80 Km/h quando a velocidade máxima permitida era de 50 Km/h. Contudo, o tribunal considerou que este limite de velocidade se devia a um sinal de aproximação de travessia de peões e que o acidente nada teve a ver com uma tal travessia; o que, aliado ao facto de *A* ter cumprido as demais regras rodoviárias, determinou a sua absolvição. Esta decisão judicial expressou, ainda que de forma implícita, o referido critério do *âmbito de protecção da norma*. Com efeito, foi por se ter reconhecido que **o escopo da norma** era o de limitar riscos para a circulação de peões que se não imputou à conduta de *A* a morte de *C*: a norma violada não tinha por fim prevenir perigos inerentes ao tipo de manobra que teve lugar. Importa sublinhar de novo que, para o efeito agora em causa, carente de interpretação é a **norma de cuidado**, não a que preside ao ilícito-típico penal. Por isso logo se compreende que o problema ora em consideração interesse principalmente os delitos negligentes.

---

(40) Pioneiro de novo, ROXIN, nota 23, p. 141 e ss., e agora I, § 11, n.º 84 e ss. Cf., entre nós, BELEZA, Teresa, II, p. 271 e s.

(41) Ainda antes do advento da doutrina da conexão do risco não faltavam autores a pretender introduzir o essencial deste pensamento da doutrina da adequação: CORREIA, Eduardo, I, n.º 93. Fundamental no novo contexto, ainda aqui (a propósito dos delitos negligentes), ROXIN, Zum Schutzzweck der Norm bei der fahrlässigen Delikten, *Gallas-FS*, 1973, p. 241 (na colectânea portuguesa citada na nota 23, p. 273).

(42) ROXIN, nota anterior.

(43) Ac. da RP de 25-6-97, Proc. n.º 9740226. Cf., também, no sentido da posição assumida em texto, o Ac. da RP de 9-7-2003, Proc. n.º 340290.

§ 37 Diferente, na sua estrutura, da questão acabada de referir é a que corre agora doutrinalmente sob a designação de **âmbito** de protecção da norma. Como dissemos, se o agente criou ou incrementou um risco proibido e este se concretizou no resultado típico, tal é bastante para afirmar o nexo de imputação objectiva do resultado à acção. Cada vez com maior insistência se defende, porém, que assim não será ainda naqueles casos em que o **âmbito do tipo** — *rectior*, o fim de protecção da norma típica (já não agora, como há pouco, da "norma de cuidado", mas da norma que proíbe o homicídio, a ofensa à integridade física, o dano, etc.) — **não cobre resultados da espécie daquele que efectivamente se verificou**. De novo, ainda aqui, o campo de actuação por excelência deste limite será o dos crimes negligentes, não sendo impossível todavia identificar hipóteses em que a questão se põe relativamente a delitos dolosos. Num caso como no outro, na formulação paradigmática de Roxin, "o ilícito é criação de um risco não permitido **dentro do âmbito do tipo**" (44).

§ 38 Segundo Roxin, devem entrar neste enquadramento — pelo menos — três grupos de casos: (1) o que chama de **colaboração na autocolocação em risco dolosa**, *v. g.*, quando *A* e *B* se lançam, por aposta, numa corrida perigosíssima de motos na estrada e *B*, em virtude de um erro de condução, perde o domínio do veículo e sofre lesões físicas graves; (2) o que denomina de **heterocolocação em perigo livremente aceite**, em que alguém se não coloca dolosamente em perigo mas, com consciência do perigo, se deixa pôr em risco por outrem, *v. g.*, quando *C*, a pedido do passageiro *D*, aumenta de forma proibida a velocidade do automóvel e em consequência se despista, sofrendo *D* lesões físicas graves; e (3) o que crisma de **imputação a um âmbito de responsabilidade alheio**, isto é, aqueles resultados cujo impedimento caem na área da responsabilidade de outra pessoa, *v. g.*, quando *E* provoca um incêndio na sua habitação e *F*, um dos bombeiros chamados, para salvar outro habitante da casa sofre lesões físicas graves (45).

---

(44) ROXIN I, § 7, n.º 28

(45) ROXIN I, § 11, n.os 106-120, com uma minuciosa análise da jurisprudência alemã a propósito. No mesmo sentido, entre nós, logo ANDRADE, Costa, *Consentimento e Acordo em Direito Penal*, 1991, pp. 271 e ss., 295 e ss., 329, e depois, em síntese, *Comentário Conimbricense*, I, art. 149.º, § 7 e ss., e nota 28, p. 709 e ss. Em Espanha — especialmente em relação às acções negligentes — a aprofundada investigação de CANCIO Meliá, *Conducta de la víctima e imputación objectiva en derecho penal*, ²2001.

§ 39 Independentemente do aplauso ou das reservas que mereçam as soluções prático-normativas dadas por Roxin aos casos cabidos neste contexto ([46]), julgamos **equívoco** e **redutor** tratá-las sob a epígrafe de um critério (adicional) de imputação objectiva do resultado à acção. Uma correcta solução depende, antes de mais, da exacta configuração e unidade de sentido dos tipos de ilícito questionados (*v. g.*, para exacta solução dos dois primeiros grupos de casos pode vir a revelar-se de importância fundamental saber se o resultado típico foi o de lesão da integridade física ou o de morte, se a lei pune ou não a ajuda ao suicídio, etc.); bem podendo afirmar-se, por isso, que a questão deixa em último termo de pertencer à doutrina da PG do direito penal, para constituir antes **um tema da PE** ([47]). Depois, o problema apresenta **implicações dogmáticas autónomas** a níveis diversos e diferentes do da imputação do resultado à acção, máxime, a nível da *autoria e da cumplicidade face à comparticipação da própria vítima* (infra, 31.º Cap., § 8 e s.), da *negligência* (infra, 35.º Cap., §§ 28 e ss., 32 e ss.) e da *omissão* (infra, 38.º Cap., §§ 41, 45, 50). Por outra parte ainda, mais relevante como *princípio heurístico* do que apelar para o cabimento ou não do resultado na área de tutela típica nos parece a invocação neste contexto do **princípio da auto-responsabilidade** como máxima definidora e delimitadora dos âmbitos de responsabilidade ([48]); o que, para além do mais, evitará a por vezes difícil questão da distinção entre casos de autocolocação em perigo dolosa e de heterocolocação em perigo livremente aceite, tal como hoje se suscita cada vez mais nas hipóteses em que alguém que sabe ser seropositivo tem relações sexuais desprotegidas com outrem conhecedor da situação, ou mesmo a rogo deste outrem, que contrai deste modo a infecção ([49]). Importa por fim não minimizar — ainda quando triunfantemente se alegue que a questão nada tem a ver com o instituto do consentimento como causa de justificação — que o **acordo** com o (ou a **livre aceitação** do) risco é aqui um elemento decisivo e incontornável da situação e da solução (v. também 17.º Cap., § 11

([46]) E elas contam, na sua larga maioria, com a nossa concordância também segundo o direito português.

([47]) O que parece confirmado pelas considerações de ANDRADE, *Comentário Conimbricense*, I, art. 149.º, §§ 7 e ss. e 42, tendo aqui porventura particular aplicação a tese de FRISCH, W., nota 24.

([48]) Assim também, CANCIO Meliá, nota 45, p. 275 e ss., e Opferverhalten und objektive Zurechnung, *ZStW 111*, 1999, p. 366 e s.

([49]) Sobre a questão ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 149.º, §§ 12-14.

e 35.° Cap., § 45). Por tudo isto, o apelo à área de protecção da norma parece meramente consequencial e de restrita capacidade hermenêutica, servindo apenas de pretendida corroboração da solução a que, com apelo a outros princípios e categorias, se chegou em matéria de afirmação ou negação, no caso, da verificação integral do tipo de ilícito objectivo.

V. A questão da "causalidade virtual"

§ 40 Pode o agente ter, com a sua acção, criado um perigo não permitido, este ter-se materializado no resultado típico e, todavia, haver razões para pôr em dúvida que este deva ser objectivamente imputado àquele. Temos em vista os casos chamados de **causalidade hipotética** ou **causalidade virtual** ([50]). Casos estes que — anote-se desde já, para prevenir na medida do possível equívocos — se não confundem com os referidos (supra, § 30 e ss.) *comportamentos lícitos alternativos*; porque o que agora está em questão é o agente ter produzido o resultado numa hipótese em que, se não tivesse actuado, o resultado surgiria em tempo e sob condições tipicamente semelhantes por força de uma *acção de terceiro* ou de um *acontecimento natural* ([51]). Como se não confundem com questões como a da *causalidade dupla* (supra, § 7) ou da potenciação do risco em caso de *concurso de riscos* (supra, § 29) porque a causa virtual não chega na realidade a actuar e portanto nem sequer a concorrer realmente para produção do resultado. Assim, por exemplo, ainda que *A* não tivesse feito explodir o avião *X* para matar o passageiro *B*, o aparelho ter-se-ia igualmente despenhado por falta de combustível e todos os passageiros acabariam igualmente por morrer. Ou: *C* é morto dentro de um avião que no momento seguinte cai ao descolar por erro de actuação do piloto causador da morte de todos os passageiros.

([50]) Fundamental, KAUFMANN, Arthur, Die Bedeutung hipotetische Erfolgsursachen im Strafrecht, *Eb. Schmidt-FS*, 1961, p. 200 e ss.; e, logo, entre nós, CORREIA, Eduardo, I, p. 260[1]. Cf., depois, SAMSON, *Hipotestische Kausalverläufe im Strafrecht*, 1972, BELEZA, Teresa, II, p. 284 e s., e MENDES, Sousa, *Raciocínios Hipotéticos e Processos Causais Virtuais em Direito Penal* (policopiado, FDUL), 1986.

([51]) Para um confronto entre comportamentos alternativos lícitos e causalidade virtual, cf. PALMA, Fernanda, nota 32, p. 544 e ss. Acentue-se que a questão dita da "causalidade virtual" foi objecto de consideração prioritária no âmbito do direito civil: cf., entre nós, COELHO, F. M. Pereira, *O Problema da Causa Virtual na Responsabilidade Civil*, 1955 ([2]1998). Se, apesar da homonímia, o conceito e o problema da causa virtual são os mesmos em direito penal e em direito civil é questão que aqui queremos deixar imprejudicada.

§ 41 A questão a colocar nesta sede é a de saber se deve conferir-se algum relevo jurídico-penal à causa hipotética ou virtual. A doutrina largamente dominante responde com uma rotunda **negativa** a esta questão. Pode perguntar-se, é verdade, se tem algum sentido atribuir ao direito penal a persistência na sua função de tutela de um bem jurídico que já está definitivamente condenado a perder-se. Mas a resposta a dar parece dever ser que, mesmo à luz de uma função de tutela subsidiária de bens jurídicos — e independentemente, portanto, de uma qualquer valoração ética —, continua a ter sentido não abandonar o bem jurídico à agressão do agente só porque aquele já não pode, em definitivo, ser salvo; embora este princípio deva ser ao menos temperado (na sua consequência final para a responsabilização do agente) em certas hipóteses bem delimitadas de direito de necessidade sob a forma de colisão de vida contra vida (infra, 16.º Cap., § 17 e ss.).

VI. Problemas especiais

1. Relativos aos crimes de perigo

§ 42 Vimos (11.º Cap., § 44 e ss.) que nos crimes de perigo o "dano" — na acepção de uma lesão efectiva do bem jurídico protegido — não releva do ponto de vista do tipo de ilícito. Mas nem por ser assim se dirá que os crimes de perigo são crimes de mera actividade; tanto mais quanto (já o sabemos também) a classificação dos crimes como de dano ou de perigo deve ser operada em função da forma como o *bem jurídico* é posto em causa pela acção do agente, enquanto a distinção entre crimes de mera actividade e de resultado respeita ao *objecto da acção*. Deste ponto de vista pode afirmar-se que os crimes de **perigo concreto** são *crimes de "resultado"*: só que o resultado em causa é um **resultado de perigo**, não um *resultado de dano* ([52]). Nesta medida os crimes de perigo concreto — enquanto crimes de resultado (de perigo) — suscitam um problema de imputação objectiva análogo ao dos crimes de dano. Devendo concluir-se que, relativamente pelo menos aos delitos dolosos de acção ora em estudo, estar em causa um resultado de lesão ou antes um resultado de perigo não

([52]) Na conclusão, também, COSTA, Faria, *O Perigo em Direito Penal*, 1992, p. 536 e ss., e *passim*. E, agora, MONIZ, Helena, Aspectos do resultado no direito penal, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 554 e ss.

afecta substancialmente os termos em que deve pôr-se e resolver-se o problema da imputação objectiva ([53]).

§ 43 Como deva ser configurado e comprovado este "resultado de perigo" é coisa, no dizer do próprio Roxin, ainda hoje não suficientemente esclarecida ([54]). Diferentemente da jurisprudência, a doutrina alemã mais significativa pronuncia-se a favor de uma concepção **normativa**, antes que fáctica. No ensinamento de Schünemann, um resultado de perigo existe onde só por acaso o resultado de dano se não verifica; um acaso, porém, que não tem a ver com o inexplicável de um ponto de vista científico-natural, mas com uma circunstância em cujo surgimento se não pode confiar ([55]). Cremos poder perguntar, contudo, se por esta via não se exclui em demasiados casos a imputação objectiva e se não será preferível — e mais seguro — usar, relativamente à comprovação de um resultado de perigo, os critérios experimentados da **adequação** (supra, § 12).

§ 44 No que toca aos crimes de **perigo abstracto** ainda menos se descortina razão para qualquer *especialidade* dos critérios e dos termos da imputação objectiva. Só que neles o resultado não pode ser consubstanciado em um qualquer "perigo" — este não é elemento constitutivo do tipo objectivo de ilícito —, tudo dependendo de a construção típica referenciar ou não como seu elemento constitutivo um qualquer efeito espácio-temporalmente cindido da acção. Os crimes de perigo abstracto são normalmente crimes de *mera actividade* (*v. g.*, art. 292.º, condução de veículo em estado de embriaguez), mas podem também ser construídos como crimes de *resultado* (*v. g.*, art. 262.º, contrafacção de moeda ([56])): na primeira hipótese o problema da imputação objectiva não se coloca e na segunda não se vê razão para que deva ser alterada a doutrina da imputação objectiva anteriormente definida. As questões de legitimidade, jurídico-constitucional e dogmática, suscitadas pelos crimes de perigo abstracto, nomeadamente, a do relacionamento entre a acção e o bem jurídico protegido (não o eventual resultado típico) em nada afectam os termos em que deve pôr-se e resolver-se qualquer problema de imputação objectiva. E o que acaba de dizer-se para os crimes de perigo abstracto verdadeiros e

---

([53]) Na conclusão, no que ao problema da imputação objectiva respeita, por outros, ROXIN I, § 11, n.º 147 e ss.

([54]) ROXIN I, § 11, n.º 148.

([55]) SCHÜNEMANN, Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeits- und Gefährdungsdelikte, *JA*, 1975, p. 793 e ss. Concorda ROXIN I, § 11, n.º 151.

([56]) Precisamente neste sentido, COSTA, Almeida, *Comentário Conimbricense*, II, art. 262.º, § 16.

próprios parece poder valer integralmente para os crimes de **perigo abstracto-concreto**, de aptidão ou de conduta concretamente perigosa.

2. Relativos à criminalidade de massa própria da "sociedade do risco"

§ 45 Problemas especiais de critérios e de termos da imputação objectiva começam agora a agitar-se nos domínios da criminalidade de massa próprios da sociedade do risco, nomeadamente, no âmbito da **criminalidade ambiental** (57) e da **responsabilidade pelo produto** (58). (Mas também em domínios do direito penal clássico, *v. g.*, em matéria de falsificação de moeda (59) ou de corrupção.) Se e onde se trate, segundo a construção típica, de crimes de resultado, a questão é a de saber se é possível — e se sim, como — imputar resultados lesivos do bem jurídico protegido a condutas extremamente distanciadas no tempo e no espaço e que, quantas vezes, consideradas na sua singularidade, parece deverem reputar-se jurídico-penalmente irrelevantes. Só se tornando relevantes atenta a frequência devastadora e a quantidade inumerável com que condutas destas são levadas a cabo; pelo que, a serem proibidas, não o serão em si mesmas mas em função de condutas de outras pessoas, previsíveis e muito prováveis — para não dizer certas —, que vêm somar-se à do agente. Neste sentido se falando hoje de **tipos aditivos** ou **acumulativos** (60).

§ 46 Há aqui, se bem cremos, duas constelações problemáticas que importa distinguir. Uma só indirectamente tem a ver com a imputação objectiva: é a de saber — onde, à partida, se reconheça a impossibilidade (61) ou a extrema dificuldade de decidir em termos ainda jurídico-

---

(57) Sobre a questão, KUHLEN, Umweltstrafrecht — auf der Suche nach einer neuen Dogmatik, *ZStW 105*, 1993, p. 720 e ss.

(58) Sobre a questão, DIAS, Silva, nota 4, p. 60 e ss., HASSEMER / MUÑOZ Conde, nota 7, pp. 124 e ss., 143 e ss., e, em síntese, VOGEL, nota 7, p. 95 e ss.

(59) HEFENDEHL, *Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht*, 2002, p. 240 e s.

(60) Cf. HEFENDEHL, nota 59, p. 183 e ss.; e, entre nós, DIAS, Figueiredo, Sobre a tutela jurídico-penal do ambiente — um quarto de século depois, *Estudos Cunha Rodrigues*, I, 2001, pp. 379 e s. e 390 e ss., PALMA, Fernanda, nota 32, p. 549 e ss., e DIAS, Silva, "What if everybody did it?". Sobre a incapacidade de ressonância do direito penal à figura da acumulação, *RPCC 13*, 2003, p. 307.

(61) Assim, HEFENDEHL, loc. cit. na nota anterior, afirmando que a acumulação procura um equivalente material da causalidade lesiva real, que não teria lugar relativamente a bens jurídicos colectivos. Cf., igualmente, DIAS, Silva, nota 60.

-penalmente aceitáveis a questão da causalidade — quais as condições de **legitimidade** material, jurídico-constitucional e político-criminal de criminalização pelo legislador de comportamentos (ligados ou não a certos resultados) considerados em si mesmos e na sua singularidade, na base da sua inumerável proliferação. Desta questão se tratou já suficientemente (supra, 6.º Cap., § 56 e ss.). Outra questão — a da pretensa dificuldade de, nestes domínios, comprovar judicialmente a **causalidade** entre a acção e o resultado — resulta de novo, as mais das vezes, em nosso entender, de uma confusão: dificuldades suscitam-se aqui, como se disse, no estabelecimento da ligação entre acção e *dano* do bem jurídico — problema de todo estranho às doutrinas da causalidade e da imputação objectiva —, não entre acção e *resultado* (se na verdade — o que não será frequente — nesta espécie de delitos se tratar de crimes de resultado). Nem deverá esquecer-se, neste contexto e de todo o modo, o que supra, § 8 e s., se disse apelando para a ideia, sob uma certa forma, da "condição conforme às leis naturais".

3. Relativos a crimes de organização ou de entes colectivos

§ 47 Problemas de particular dificuldade — de que todavia a doutrina e a jurisprudência ainda mal começam a dar-se conta — podem ocorrer nos casos em que a actuação típica se verifica no âmbito de uma organização ou de um ente colectivo. Importa distinguir consoante o tipo considere autor o próprio **ente colectivo** ou antes só as **pessoas naturais** que ajam em nome ou em representação do ente colectivo.

§ 48 Tratando-se da aferição da responsabilidade de **pessoas naturais** que ajam em nome de organizações ou em representação de entes colectivos (art. 12.º) ([62]), não cremos que se suscitem problemas de causalidade ou de imputação objectiva até aqui não considerados ou que mereçam tratamento especial. Os problemas difíceis que possam apresentar-se respeitam à relação (de responsabilidade) entre as pessoas naturais e o ente colectivo (cf. supra, 11.º Cap., § 32 e s.), não propriamente à imputação do resultado à acção.

([62]) Cf., sobre a questão em geral, SERRA, Teresa, Actuação em nome de outrem no âmbito empresarial, em especial no exercício de funções parciais, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 597, e ALBERGARIA, Soares de, A posição de garante dos dirigentes no âmbito da criminalidade da empresa, *RPCC 9*, 1999, p. 605.

§ 49 Quanto à responsabilidade do **ente colectivo**, o que pode antes de tudo estar em questão é saber sob que pressupostos pode atribuir-se ao ente colectivo como tal *capacidade de acção*. Advogámos a este propósito (supra, 11.º Cap., § 25) a aplicação de um "modelo analógico"; mas logo acrescentámos ser em seguida necessário encontrar a forma de efectivação daquela responsabilidade, invocando a propósito, como guia, a norma do art. 11.º-2 do Anteprojecto 2007 (11.º Cap., § 33). A partir desta, uma vez imputado ao ente colectivo a acção psíco-física da(s) pessoa(s) singular(es), deve exigir-se, também neste contexto, que o comportamento — activo ou eventualmente, em certos casos, omissivo — do ente colectivo tenha criado (ou incrementado) um risco não permitido e que esse risco se tenha vazado no resultado típico (63).

(63) Sobre a questão, STRATENWERTH, Unternehmenshaftung?, *R. Schmitt-FS*, 1992, p. 307, e HEINE, *Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen*, 1995, p. 231 e s.

13.º CAPÍTULO

O TIPO SUBJECTIVO DE ILÍCITO

I. A construção do tipo subjectivo de ilícito

§ 1 Já ficaram mencionados (10.º Cap., §§ 8, 13, 18, 24) os passos essenciais da evolução que conduziu de uma concepção exclusivamente **objectiva** do tipo de ilícito incriminador (própria do modelo *positivista* da doutrina do facto punível) à aceitação naquele tipo da existência, que em todo o caso se considerava excepcional, de **elementos subjectivos da ilicitude** (no modelo *normativista*); e desta até à actual bipartição (própria do modelo *finalista* e, após ele, de toda a concepção *pessoal* do ilícito) do tipo de ilícito incriminador em um tipo objectivo de ilícito (que acabámos de estudar) e um **tipo subjectivo de ilícito** seja sob a forma dolosa, seja sob a forma negligente.

§ 2 É o tipo subjectivo de ilícito doloso que nos cumpre agora analisar. Um tipo, por conseguinte, cujo elemento irrenunciável é o **dolo**; não na integralidade dos seus elementos constitutivos, os quais — já ficou dito também (10.º Cap., § 58 e ss.) — se estendem pelo tipo de ilícito e pelo tipo de culpa, mas no conjunto daqueles que pertencem, segundo a sua estrutura e a sua função, ao *tipo de ilícito*. Conjunto a que desde longa data se chama — mas agora com um particular interesse, para o distinguir daquele outro conjunto que pertence à culpa — **dolo natural, dolo do facto** ou (mais significativamente, pela razão apontada) **dolo do tipo**.

§ 3 Anote-se todavia desde já que o conteúdo do tipo subjectivo de ilícito doloso não tem de se esgotar no dolo do tipo. Com efeito, o essencial da concepção normativista dos elementos subjectivos do tipo persiste ainda hoje e não perdeu interesse político-criminal ou dogmático com a construção de um autónomo tipo subjectivo de ilícito doloso. Em muitos

tipos legais de crime existem **especiais elementos subjectivos** que não pertencem ao dolo do tipo — enquanto conhecimento e vontade de realização do tipo objectivo — e que todavia, de forma essencial, co-determinam o desvalor da acção e definem a área de tutela típica.

II. O dolo do tipo

1. A estrutura do dolo do tipo

§ 4 O CP não define o dolo do tipo, mas apenas, no art. 14.º, cada uma das *formas* em que ele se analisa. A doutrina hoje dominante conceitualiza-o, na sua formulação mais geral, como **conhecimento e vontade de realização do tipo objectivo de ilícito**. Importa por isso perguntar antes de mais como se decompõe, em pormenor, esta estrutura e, mesmo antes disso, a que luz pode ela justificar-se.

§ 5 O art. 13.º determina que "só é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos especialmente previstos na lei, com negligência". Isto significa, antes de mais, que no conjunto da criminalidade o lugar primordial, por *mais grave*, é conferido à criminalidade dolosa; tanto mais quanto se tiver em conta que, apesar do aumento de importância dos crimes negligentes na sociedade do risco, só cerca de uma décima parte dos crimes descritos na PE do nosso CP são puníveis a título de negligência; e os que o são, são-no com molduras penais quase sempre mais baixas (e às vezes *muito* mais baixas) do que os correspondentes delitos dolosos (1). A estrutura dogmática do dolo do tipo há-de ser por isso, ela também, **político-criminalmente condicionada** por esta diferente relevância dos delitos dolosos e dos negligentes, concretamente, pelo *desvalor jurídico mais alto* que àqueles cabe, em princípio, face a estes. O que tem por seu lado de significar — num direito penal como o nosso, regido pelo princípio da culpa — que a *diferença essencial* entre uma e outra espécie de delitos tem de ser (ou, pelo menos, de ser também) uma **diferença de culpa** (2) (supra, 10.º Cap., § 61).

---

(1) Com uma equiparação das molduras penais depara-se todavia em casos como os do crime de embriaguez (art. 295.º) e de condução de veículo em estado de embriaguez (art. 292.º).

(2) A este entendimento não se opõem as definições ínsitas no art. 14.º A propósito delas, v. COSTA, Faria, As definições legais de dolo e negligência..., *BFD LXIX*, 1993, p. 374, e PEREIRA, Rui, *O Dolo de Perigo*, 1995, p. 83 e ss.

§ 6 Esta diferença foi buscada — e, na verdade, quase pacificamente aceite, quando dolo e negligência eram doutrinalmente considerados exclusivamente espécies ou formas de *culpa* — na integração no conceito de dolo da **consciência do ilícito**: dolo seria uma **violação consciente do direito** e suporia por isso, para além do conhecimento e vontade de realização do tipo objectivo, a consciência de que se realizava um tipo objectivo de *ilícito*; só isto permitiria afirmar que a maior severidade com que a lei trata os delitos dolosos provém de que neles o agente sobrepõe conscientemente os seus interesses à fidelidade que deve ao direito (3). Como se verá porém (infra, 20.º Cap., § 13 e s.), uma tal concepção — a concepção própria das chamadas *teorias do dolo estritas* — não merece aceitação e é hoje, embora com a mais diversa fundamentação, em geral repudiada. E todavia, como se depreende do que acima ficou dito, há nela, em nossa opinião, alguma coisa de exacto: que o *dolo* não pode esgotar-se no tipo de ilícito (por consequência, não é igual a dolo do tipo), mas exige do agente um qualquer momento *emocional* que se adiciona aos elementos intelectual e volitivo contidos no "conhecimento e vontade de realização". O que significa que a estrutura do dolo do tipo por que perguntamos aqui só se alcança quando se tenha a consciência clara de que, com ela, não fica por si mesma justificada a aplicação da moldura penal prevista pela lei para o crime doloso respectivo; antes se torna indispensável um elemento que já não pertence ao tipo de ilícito, mas à *culpa* ou ao *tipo de culpa*. Com esse elemento se depara quando se atente em que a punição por facto doloso só se justifica quando o agente revela no facto uma posição ou uma atitude de contrariedade ou indiferença perante o dever-ser jurídico-penal (supra, 10.º Cap., § 71, e infra, 20.º Cap., § 1).

§ 7 A esta luz, e só a ela, se justifica a conceitualização do dolo do tipo como conhecimento (momento intelectual) e vontade (momento volitivo) de realização do facto. Sendo certo, em todo o caso, que de um ponto de vista funcional os dois elementos se não situam ao mesmo nível: o chamado **elemento intelectual** do dolo do tipo não pode, por si mesmo, considerar-se decisivo da distinção dos tipos de ilícito dolosos e dos negligentes, uma vez que também estes últimos podem conter a representação pelo agente de um facto que preenche um tipo de ilícito (a chamada *negligência consciente*, cf. art. 15.º/*a*)). É pois o **elemento volitivo**, quando ligado ao elemento intelectual requerido, que verdadeiramente serve para *indiciar* (embora ainda não para fundamentar) uma posição ou atitude do agente contrária ou indiferente à norma de comportamento, numa palavra, uma *culpa dolosa* e a consequente possibilidade de o agente ser punido a título de dolo (4).

---

(3) Assim, entre nós, SANTOS, Beleza dos, Crimes de moeda falsa, *RLJ* 67, p. 146 e s., CORREIA, Eduardo, I, n.º 91, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 292 e ss., SILVA, Marques da, II, p. 161 e ss.

(4) O que vai implicado nas considerações anteriores só poderá ser plenamente compreendido depois de se expor toda a matéria relativa quer ao dolo do tipo, quer à culpa dolosa,

2. O momento intelectual do dolo

§ 8 Do que neste elemento verdadeiramente e antes de tudo se trata é da necessidade, para que o dolo do tipo se afirme, que o agente *conheça*, *saiba*, *represente correctamente* ou *tenha consciência* (consciência "psicológica" ou consciência "intencional", note-se bem (5)) das circunstâncias *do* facto (e não *de* facto, atente-se, porque tanto podem ser "de facto" como "de direito") que preenche um tipo de ilícito objectivo (art. 16.º-1). A razão desta exigência deve ser vista à luz da *função* que este elemento desempenha: o que com ele se pretende é que, ao actuar, o agente conheça **tudo quanto é necessário a uma correcta orientação da sua consciência ética para o desvalor jurídico que concretamente se liga à acção intentada, para o seu carácter ilícito**; porque tudo isso é indispensável para se poder afirmar que o agente detém, ao nível da sua consciência intencional ou psicológica, o conhecimento necessário para que a sua consciência ética, ou dos valores, ponha e resolva correctamente o problema da ilicitude do comportamento. Só quando todos os elementos do facto estão presentes na consciência psicológica do agente se poderá vir a afirmar que ele se decidiu pela prática do ilícito e deve responder por uma atitude contrária ou indiferente ao bem jurídico lesado pela conduta. Por isso, numa palavra, o conhecimento da realização do tipo objectivo de ilícito constitui o supedâneo indispensável para que nele se possa ancorar uma culpa dolosa e a punição do agente a esse título (6). Com a consequência de que sempre que o agente não represente, ou represente erradamente, um qualquer dos elementos do tipo de ilícito objectivo o dolo terá, desde logo, de ser negado (infra, § 17 e ss.). Fala-se a este respeito, com propriedade, de um **princípio de congruência** entre o tipo objectivo e o tipo subjectivo de ilícito doloso.

---

com especial atenção, nesta última, ao *problema da consciência do ilícito e da sua falta* (infra, 20.º Cap.). Mas estão dados, cremos, os elementos indispensáveis para que se perceba que, na nossa concepção (desenvolvida já em *O Problema*, *passim*, especialmente § 14 e s.), é em último termo a partir deste problema e do seu significado para a culpa que toda a matéria relativa ao dolo, incluído o próprio dolo do tipo, tem de ser perspectivada e apreendida.

(5) Sob pena, se uma tal atenção não for prestada, de se tornar de compreensão impossível toda a matéria relativa à consciência do ilícito e à sua falta (cf. infra, 20.º Cap., § 28 e ss.).

(6) Assim, já, o nosso, *O Problema*, §§ 14 e 15.

2.1. O conhecimento das circunstâncias do facto

§ 9 De acordo com o que ficou dito, a afirmação do dolo do tipo exige antes de tudo o conhecimento (a previsão ou a representação) da totalidade dos elementos constitutivos do respectivo tipo de ilícito objectivo, da *factualidade típica* (para usarmos uma expressão feliz e correctíssima de Eduardo Correia). Precisões se tornam todavia necessárias neste contexto, sob diversos pontos de vista.

2.1.1. O conhecimento dos elementos normativos

§ 10 Se o tipo de ilícito é o portador de um sentido de ilicitude, então compreende-se que a factualidade típica que o agente tem de representar não constitua nunca o agregado de "puros factos", de "factos nus", mas já de "**factos valorados**" em função daquele sentido de ilicitude. Isto significa que não basta nunca o conhecimento dos meros factos, mas se torna indispensável a apreensão do seu significado correspondente ao tipo. Tal exigência não colocará qualquer dificuldade de princípio relativamente aos chamados (supra, 11.º Cap., § 11 e ss.) *elementos descritivos*: *v. g.*, "outra pessoa" (art. 131.º), "corpo" (art. 143.º), "mulher" (art. 168.º), "alimentos ou bebidas" (art. 220.º-1/*a*)). Já assim não sucederá, porém, com os chamados *elementos normativos*, aqueles que só podem ser representados e pensados por referência a normas, jurídicas ou não jurídicas. Qual o grau e as características do conhecimento que neste âmbito deve ser exigido para afirmação do dolo do tipo? Certo é que se não exigirá — não o exige, precisamente, a função que assinalámos ao elemento intelectual do dolo do tipo — a "exacta subsunção jurídica dos factos na lei que os prevê" (7), sob pena de só o jurista (e o jurista sabedor...) poder actuar dolosamente (8). Se o agente conhece o *conteúdo* do elemento, mas desconhece a sua *qualificação normativa*, trata-se aí de um **erro na subsunção** que deve considerar-se pura e simplesmente irrelevante para o dolo do tipo. Necessário e suficiente será sim o conhecimento pelo agente dos elementos normativos, antes que na direcção de uma exacta subsunção jurídica, na de uma **apreensão do sentido ou significado correspondente, no essencial e segundo o nível próprio das representações do agente, ao resultado**

---

(7) V. Liszt, *Tratado*, §§ 39, III, 2, e 40, I, 1.

(8) Assim, entre nós, logo, Santos, Beleza dos, nota 3, p. 114 e nota.

daquela subsunção ou, mais exactamente, da valoração respectiva (9). Correspondência esta que traz consigo no essencial o conteúdo da valoração jurídica correspondente, cumprindo assim a função de orientar o agente para a ilicitude do facto. Exemplos claros são dados pela carácter "alheio" da coisa numa série de crimes patrimoniais (arts. 203.º e 204.º, 209.º, 212.º, etc.), pela qualidade de "funcionário" nos crimes cometidos no exercício de funções públicas (art. 372.º e ss.) ou por elementos normativos como "Mãe-Pátria" (art. 308.º), "Governo" e "Estado" (art. 309.º), "tribunal" (art. 360.º), "testemunha, perito, técnico, tradutor ou intérprete" (art. 360.º), "casamento" (art. 247.º), "coisa... que tenha entrado na sua posse ou detenção" e "caso fortuito" (art. 209.º), "documento" e "moeda" (art. 255.º/*a)* e *d)*), etc.

§ 11 Essencialmente neste sentido vai a doutrina dominante. No início desta via está a formulação de Mezger — aproveitando um pensamento de Binding, que falava a propósito de uma "subsunção na esfera do leigo" — da exigência de uma "valoração paralela na esfera do leigo" (10). Por seu turno Welzel, pretendendo evitar (com boa razão) a intervenção nesta exigência de uma "valoração" e lembrando que não só leigos como juristas podem cometer crimes dolosos, requer uma "apreciação paralela na consciência psicológica do agente" (11). E já entre nós Beleza dos Santos — antecipando em parte o pensamento de Welzel — referia a necessidade de "conhecimento dos efeitos práticos que formam o conteúdo jurídico dos elementos em causa" (12).

§ 12 Relativamente ao critério geral apontado, porém, casos haverá em que o respeito pela função exercida pela necessidade de conhecimento para afirmação do dolo do tipo conduzirá a uma **maior exigência**. Elementos normativos existem, com efeito, de estrutura eminentemente *jurídica*, que só através de uma decisão estritamente *técnica* assumem relevo normativo e logram orientar o agente para o desvalor da ilicitude do facto total. É o caso, p. ex., de inúmeros elementos normativos que enxameiam o direito penal secundário ("disposições contidas nos artigos 7.º, 12.º e 16.º do DL 303/83", "um negócio, um contrato ou outra vantagem *indevida*", art. 41.º-A-1 do DL 28/84, "obtenção *indevida*", "*matéria colectável*", art. 103.º da L 15/2001; "prestação tributária aduaneira *legalmente devida*", art. 92.º-1 da L 15/2001, etc.); mas que surgem também no próprio CP, *v. g.*,

(9) Assim, DIAS, Figueiredo *O Problema*, § 22, I, 2, e V.
(10) MEZGER, § 44.
(11) WELZEL, § 13, I, 14.
(12) SANTOS, Beleza dos, nota 3, p. 115.

"notação técnica" (art. 255.º/*b*)) ([13]). Nestes casos — como em grande parte, de resto, das chamadas *normas penais em branco* ([14]) — se não se exige obviamente que o agente *valore* o substrato no sentido da qualificação jurídica ("erro de subsunção" irrelevante para o dolo do tipo), deve em todo o caso requerer-se o grau máximo de conhecimento, impondo-se que o agente **conheça os critérios determinantes da qualificação** ([15]): um tal conhecimento é infungível para a afirmação do dolo do tipo; porque de outro modo não pode dizer-se a consciência ética do agente suficientemente orientada para o desvalor da ilicitude ([16]).

§ 13 Inversamente, com um **grau menor de exigência** se deparará nos elementos normativos cujo conhecimento pelo agente, necessário ao dolo do tipo, deva limitar-se ao dos seus **pressupostos materiais**. Isso sucederá, desde logo, com aqueles elementos cuja qualificação (e consequente normatividade) deriva só da necessidade sentida pelo legislador, por razões de brevidade e de economia, de abranger no mesmo elemento uma série extensa, mas determinada, de substratos normativamente relevantes, *v. g.*, com os elementos "descendente" ou "ascendente" (*v. g.*, art. 177.º-1/*a*)). Mas é sobretudo o caso de certos elementos que **exprimem imediatamente uma valoração moral, social, cultural ou mesmo jurídica decisiva para a ilicitude do facto como um todo** e de que podem apontar-se como exemplos cláusulas como a dos "bons costumes" no consentimento (arts. 38.º e 149.º), a do carácter "censurável" da utilização do meio de coacção (art. 154.º-3/*a*)), a da "ilegitimidade" da apropriação em vários crimes contra o património (arts. 203.º-1, 205.º-1, 209.º, etc.) e, em definitivo, a do "dever de garante" nos crimes de omissão imprópria (infra, 38.º Cap., § 15 e ss.). Em qualquer destes casos deve bastar à afirmação do dolo do

---

([13]) Temos a este propósito o caso, julgado pelo Ac. da RP de 26-6-1985, *CJ*, 1985, II, p. 284 e s., em que, estando em causa a prática de um crime de especulação, se verificou que o agente tinha à venda fiambre com uma taxa de comercialização superior à permitida, porque actuou na convicção errada de que o fiambre estava incluído na rubrica "chouriço de carne e outros derivados", prevista nas normas de regulação de preços deste tipo de produtos.

([14]) BELEZA, Teresa / PINTO, Costa, *O Regime Legal do Erro e as Normas Penais em Branco*, 1999, pp. 21 e ss. e 57 e ss., embora aderindo no essencial à nossa posição em caso de erro sobre os elementos normativos, propõem um regime diferenciado para as situações de erro sobre as normas penais em branco.

([15]) Ou, na terminologia italiana, a "norma integradora do elemento em causa": cf. GALLO, *EdD 13*, p. 760 e ss. Esta questão tem de ser conexionada com a matéria do que chamaremos o "erro sobre proibições legais": cf. infra, § 31 e ss.

([16]) Pormenorizadamente, o nosso *O Problema*, § 22, IV.

tipo o conhecimento, pelo agente, dos pressupostos materiais da valoração; porque já esse conhecimento orienta suficientemente a sua consciência ética para o desvalor do facto como um todo ([17]).

2.1.2. A actualidade da consciência intencional da acção ([18])

§ 14 O conhecimento requerido pelo dolo do tipo exige a sua **actualização na consciência psicológica ou intencional no momento da acção**. Não basta nunca a mera "possibilidade" de representação do facto, antes se requer que o agente represente a totalidade da factualidade típica e a actualize de forma efectiva. Só que "consciência actual" não é o mesmo, no presente contexto, que — como seria exigido por um entendimento extremadamente intelectualista — "consciência reflectida", "ponderada", "clara" ou "demorada". Como Platzgummer defendeu, a consciência requerida das circunstâncias do facto será *actual* do próprio ponto de vista psicológico, para afirmação do dolo do tipo, não apenas quando aquelas são assumidas pelo agente sob a forma de "representação" (que sempre supõe uma qualquer reflexão), mas também quando — como o formulou o psicólogo vienense Rohracher — elas são "co-consciencializadas", isto é, "assumidas por uma consciência que não é considerada explicitamente, mas que é atendida com outros conteúdos conscientemente considerados e tem assim também de ser implicitamente tomada em conta de forma necessária" ([19]). À luz desta concepção se alcançou a tradução de uma tal exigência "amortecida" como a de uma **co-consciência imanente à acção"** ([20]).

§ 15 Se p. ex. um médico sabe que um medicamento pode produzir um colapso cardíaco sob determinadas circunstâncias e receita posteriormente esse medicamento sem pensar que aquelas condições estão de novo dadas, então ele tem um conhecimento *actualizável* no momento das circunstâncias de facto que integram o tipo objectivo da ofensa à integridade física grave com perigo para a vida (art. 144.º/*d*)), mas não possui a consciência "actual", e age, portanto, sem dolo do tipo. Já porém quem tem cópula com menor de quinze anos, que há algum tempo namora, abusando da sua inexperiência (art. 174.º), raramente pensará na idade da vítima, que todavia o agente conhece e que

([17]) Cf., de novo, o nosso *O Problema*, § 22, VI.

([18]) Sobre todo este ponto, já, o nosso *O Problema*, § 11, III.

([19]) PLATZGUMMER, *Die Bewusstseinsform des Vorsatz. Eine strafrechtsdogmatische Untersuchung auf psychologischer Grundlage*, 1964, p. 83.

([20]) Por último, ROXIN I, § 12, n.º 123 e ss.

portanto está na sua co-consciência imanente à acção. O mesmo vale para o guarda prisional que, abusando das suas funções mas sem nelas pensar no momento da acção, pratica acto sexual de relevo com pessoa ali internada (art. 166.º); ou para o funcionário público que não pensa nessa sua qualidade no momento em que comete um crime de funcionários (p. ex., art. 375.º); ou para alguém que furta um crucifixo de ouro de uma igreja sem todavia no momento representar que se trata de coisa "afecta ao culto religioso" (art. 204.º-1/*c*)). Em todos estes casos estende-se normalmente sobre o agente um "**permanente saber acompanhante**" que basta para afirmação do dolo do tipo ([21]). Permanecendo em casos concretos, nomeadamente em situações pluri-significativas, dúvidas, não deve então um tal conhecimento ser presumido, também aqui valendo o princípio *in dubio pro reo* ([22]).

§ 16 A tese defendida teve como seu precursor, em um certo sentido, Mezger, para quem, relativamente a certos elementos do tipo (objectivo de ilícito), não seria necessária ao dolo a sua "representação" pelo agente, mas bastaria uma **advertência do sentimento**; assim se ficando a coberto das críticas dirigidas àqueles que se bastam, nesta matéria, com uma qualquer imagem proveniente de camadas próximas do subconsciente ([23]). A diferença estará só em que Platzgummer se mantém fiel às leis da "psicologia associacionista", enquanto Mezger se serve das conclusões da "psicologia da profundidade". Na mesma direcção se pronunciou depois Schmidhäuser (se bem que referindo-se à consciência psicológica do ilícito), sustentando que a *actualidade* da consciência requerida se processa, psicologicamente, de acordo com um "**pensamento pela matéria**" (*Sachdenken*), cuja característica essencial — no que aqui importa — estaria, por oposição ao "pensamento pela fala" (*Sprachdenken*), na rapidez com que se actualiza um saber que se possui e que, embora não de forma reflectida, chega à consciência intencional de modo a influenciar a decisão da acção ([24]).

2.1.3. O erro sobre a factualidade típica

§ 17 Faltando ao agente o conhecimento, nos termos acabados de precisar, da totalidade das circunstâncias, de facto ou de direito, descritivas ou normativas, do facto, **o dolo do tipo não pode afirmar-se**. É isto que dispõe o art. 16.º-1, 1.ª parte, afirmando que este *erro* "exclui o dolo"; e é isto que a doutrina crisma como "erro sobre a factualidade típica". O que tudo é aceitável feita uma dupla prevenção: a de que o termo "erro" não está aqui tomado apenas no sentido de uma representação positiva errada,

---

([21]) PLATZGUMMER, nota 19, p. 89.

([22]) Acentuam este aspecto, STRATENWERTH / KUHLEN, § 8, n.º 76.

([23]) MEZGER, *LK*, [8]1957-8, p. 482.

([24]) SCHMIDHÄUSER, Über Aktualität und Potentialität des Unrechtsbewusstseins, *Mayer-FS*, 1966, pp. 317 e ss., 325, 327 e ss.

mas também no sentido de uma *falta de representação*: tanto erra sobre a factualidade típica do crime de aborto (art. 139.º) a mulher que, usando um medicamento que actua como abortivo, não sabe que está grávida, como outra que conhece a sua gravidez mas considera o medicamento inócuo; e, em segundo lugar, a de que a expressão "exclui o dolo" não significa que um dolo já existente foi eliminado, mas sim (o que, nesta acepção, parecerá pura trivialidade) que o *dolo do tipo não chega a constituir-se* quando faltam os seus pressupostos.

§ 18 Urge acentuar, em seguida, que a doutrina exposta vale não só para as circunstâncias que fundamentam o ilícito, mas também para todas aquelas que o **agravam** e para a **aceitação errónea** de circunstâncias que o **atenuam**. Sobre isto outros CPs são expressos; mas tem de considerar-se que o nosso CP, se entendeu não o afirmar, foi unicamente porque o terá considerado dispensável. Quem furta coisa móvel alheia sem consciência (intencional) de que, com a subtracção, "deixa a vítima em difícil situação económica" não actua com dolo do tipo de furto qualificado (art. 204.º-1/*i*)), mas apenas de furto simples (art. 203.º-1). Quem, por outra parte, toma erradamente por "sério" o pedido de um doente grave e o mata, actua com dolo do tipo de homicídio a pedido (art. 134.º) e não com o de homicídio (art. 131.º). Em ambos os casos o erro sobre a factualidade típica conduz a que só deva ser aplicada a norma penal menos grave ([25]).

§ 19 Com a negação do dolo do tipo falta o tipo subjectivo apenas do crime doloso de acção correspondente. Não só pode o agente ter realizado dolosamente *outros* tipos de ilícito (como já o mostra o acima referido exemplo de desconhecimento de circunstâncias agravantes do ilícito), como pode ainda estar preenchido um **tipo de ilícito negligente**. Um condutor de automóvel, p. ex., que à noite não repara a tempo num bêbado estendido na estrada e o atropela mortalmente, não age com dolo do tipo de homicídio. Possivelmente, porém, o seu desconhecimento é recondutível à não prestação do cuidado devido, pelo que o seu comportamento integra o tipo de ilícito do homicídio negligente (art. 137.º). Isto é expressa-

([25]) Defendendo também a punição pelo art. 134.º nos casos de erro sobre o pedido da vítima, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 134.º, § 34. Contra esta solução, BELEZA, Teresa / PINTO, Costa, nota 14, p. 15 e ss.: o erro "sobre circunstâncias que fazem funcionar um tipo privilegiado autónomo (...) parece escapar à lógica do art. 16.º, n.º 1".

mente afirmado pelo art. 16.º-3 ao ressalvar "a punibilidade da negligência nos termos gerais", quer isto dizer, se (1) o respectivo comportamento for *expressamente* previsto pela lei como crime negligente e se (2) a negligência se tiver *efectivamente verificado* no caso.

2.2. A previsão do decurso do acontecimento

§ 20 Nos crimes de resultado (supra, 11.º Cap., § 38) tanto a *acção*, como o *resultado* são circunstâncias do facto pertencentes ao tipo objectivo de ilícito que, como tal, têm de ser levados, nos termos descritos, à consciência intencional do agente. Questão é saber se também se torna necessário, e em que termos, o conhecimento pelo agente da **conexão entre acção e resultado**, isto é, do risco por ele criado e vazado no resultado que fundamenta a imputação objectiva. Uma resposta afirmativa de princípio parece impor-se: só desta maneira a realização do tipo objectivo de ilícito no seu todo surgirá, não como "obra impessoal", mas como "obra do agente", como "sua *própria* realização". A uma consideração mais próxima pode tornar-se todavia duvidosa a medida e as concretas condições em que tal deva acontecer.

2.2.1. O erro sobre o processo causal

§ 21 Neste contexto surge desde logo a questão de saber se *qualquer divergência* entre o risco conscientemente criado pelo agente e aquele do qual deriva efectivamente o resultado deve conduzir a que o resultado não mais possa ser imputado ao agente e este só possa, por isso, responder por *tentativa*. Duas posições de princípio são aqui possíveis e têm na verdade sido doutrinalmente sufragadas: uma delas responde afirmativamente à questão posta, na base de que se o resultado tem lugar por concretização de um risco não previsto não pode afirmar-se a congruência entre o tipo objectivo e o tipo subjectivo doloso ([26]); no outro extremo encontram-se aqueles para quem o erro sobre o processo causal é em princípio irrelevante, com eventual ressalva dos crimes de execução vinculada (supra, 11.º Cap., § 42), porque só nestes o processo causal constitui um elemento do tipo

([26]) Nesta via (embora introduzindo depois restrições que tornam as posições defendidas, quase sempre, em "posições intermédias"), JAKOBS, 8/64 e ss., e, entre nós, NEVES, Curado, Concurso de riscos e imputação subjectiva, *Revista Jurídica 13-14*, 1990, p. 154 e s.

objectivo de ilícito e, por isso, uma circunstância do facto para efeito do disposto no art. 16.º-1 ([27]).

§ 22 Há, em nosso modo de ver, que considerar, desde logo e com importância decisiva, o seguinte: muitos dos problemas que tradicionalmente se colocavam, a este propósito, nesta sede de afirmação ou negação do dolo do tipo encontram hoje já solução — e, na verdade, uma solução "negativa", ou seja, de não conduzirem a qualquer responsabilização do agente — em termos da doutrina da imputação *objectiva*, nomeadamente daquilo que aí chamámos a conexão do risco (supra, 12.º Cap., § 21 e ss.). Quando, todavia, a imputação dever ser afirmada naquela sede, então **tem de conferir-se relevo ao erro sobre o processo causal**. Mas uma de duas: ou o tipo de ilícito é *de execução vinculada* e então o "erro sobre o processo causal" traduz-se em um puro erro sobre a factualidade típica e é claramente relevante ([28]); ou é de "execução livre" e então torna-se extremamente difícil figurar uma hipótese em que a imputação objectiva, comandada pela conexão de risco, deva ser afirmada e, todavia, o dolo do tipo ser negado. Onde e quando uma tal hipótese possa ser figurada, todavia, o erro sobre o processo causal não pode deixar de ter-se por **relevante** no sentido da **não afirmação do dolo** e o agente só poderá ser punido a título de **tentativa**.

§ 23 **Exemplificando**: Segundo a doutrina atrás exposta, é a própria imputação objectiva (e o dolo do tipo) que deve ser afirmada em casos como o daquele que dispara um tiro sobre outra pessoa representando a sua morte imediata quando, afinal, o ferido ainda chega ao hospital mas vem a morrer do tiro recebido, ou mesmo de uma septicémia que no decurso do tratamento, mas em consequência da ferida, se verificou. Se porém, estando o ferido a ser tratado com êxito, ele morre em virtude de uma negligência médica ou de um erro no tratamento subsequente; ou se a ambulância em que é transportado ao hospital sofre um despiste que ocasiona a morte daquele — então, nestes casos, é a própria imputação objectiva que é negada: nada fica para um hipotético erro sobre o processo causal. E se *A* lança *B* abaixo de uma ponte com a intenção de provocar a morte por afogamento, mas *B* alcança a margem mas morre por, ao sair do rio, se agarrar a uma pedra que rola e o esmaga? Não falta quem, em definitivo, aceite, em casos destes, se bem que à custa de um ligeiro entorse lógico-dogmático, a imputação subjectiva do resultado ao dolo do tipo de *A*, por uma espécie de

([27]) Assim, CORREIA, Eduardo, I, pp. 369 e ss. e 390; cf., depois, na mesma via de princípio, M / ZIPF, § 23, n.º 27, S / S / CRAMER / STERNBERG-LIEBEN, § 15, n.º 55, WELZEL, § 13, I, 3, d, e PALMA, Fernanda, A teoria do crime como teoria da decisão penal, *RPCC* 9, 1999, p. 571.

([28]) No mesmo sentido, já, CORREIA, Eduardo, I, p. 390.

"retroacção" da sua vontade sobre o mundo das suas representações: a verdade é que *A* queria matar *B* lançando-o da ponte para o rio; enquanto outros se dispõem a aceitar a imputação do resultado apenas segundo o plano do agente ([29]). De acordo com o que acima ficou exposto, esta segunda solução parece dever merecer preferência, ocorrendo então a punição do agente a título de tentativa.

2.2.2. O chamado *dolus generalis* ([30])

§ 24 Do que substancialmente se trata sob esta epígrafe é de casos em que o agente erra sobre qual de **diversos actos de uma conexão da acção** produzirá o resultado almejado. De casos, digamos, que cronologicamente ocorrem em dois tempos: num primeiro momento o agente pensa erroneamente ter produzido, com a sua acção, o resultado típico; num segundo momento, fruto de uma nova actuação do agente (quase sempre com fins de encobrimento), o resultado vem efectivamente a concretizar-se. Exemplos clássicos são os de o agente, actuando com o dolo correspondente, acreditar ter morto com uma pancada a sua vítima e depois ter tentado simular suicídio, enforcando-a, tendo a morte ocorrido só com o enforcamento; ou o de uma vítima supostamente já assassinada ter sido lançada à água para o corpo desaparecer, tendo acabado por morrer afogada.

§ 25 Em hipóteses deste teor a acção suportada pelo dolo do facto não determina pois ainda (imediatamente) o resultado, enquanto a acção que causa o resultado não mais é suportada pelo dolo do facto. Por isso, uma parte significativa da doutrina vê aqui só uma **tentativa** em concurso eventual com o cometimento *negligente* do facto ([31]), enquanto a doutrina dominante, embora sob diferentes pressupostos, se pronuncia pela aceitação de um crime **consumado** ([32]). O critério de solução deve, quanto a nós,

---

([29]) No primeiro sentido, p. ex., JESCHECK / WEIGEND, § 29, V, 6, b, e RUDOLPHI, *SK*, § 16, n.º 31. No segundo, JAKOBS, 8/65, e ROXIN I, § 12, n.º 144 e ss.

([30]) Pioneiro, WEBER, *Neues Archiv des Criminalrechts 7*, 1825, pp. 565 e 576.

([31]) JAKOBS, 8/78, M / ZIPF, § 23, n.º 35, e, entre nós, NEVES, Curado, nota 26, p. 163; e agora, com uma fundamentação ligada à duplicidade dos riscos criados — nomeadamente, nos casos de uma segunda acção com fins de encobrimento —, SANCINETTI, "Dolus generalis" und "strafrechtliches Glück", *Roxin-FS*, 2001, p. 394.

([32]) Doutrina dominante: JESCHECK / WEIGEND, § 29, V, 6, d, e, entre nós, PEREIRA, Rui, *O Dolo de Perigo*, 1995, p. 91. Diferenciadores, ROXIN I, § 12, n.º 177, consoante o agente intentou a verificação do resultado ou somente se conformou com a sua possibilidade, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 8, n.º 93, consoante o segundo acto foi ou não previamente planeado: se sim, crime consumado; se não, tentativa.

seguir eminentemente os passos da doutrina da imputação objectiva: saber, em suma, se o risco que se concretiza no resultado pode ainda reconduzir-se ao quadro dos riscos criados pela (primeira) acção. Se a resposta for afirmativa deve considerar-se o crime como consumado; se o não for a punição só poderá ter lugar a título de tentativa, eventualmente em concurso com um crime negligente consumado.

§ 26 Solução análoga deve preconizar-se, em nosso critério, para o caso de **inversão temporal dos acontecimentos**, quando, p. ex., alguém atira sobre outrem com uma pistola especial que deve começar por anestesiá-lo, para melhor lhe permitir depois o *coup de grâce*, e o mata logo. Trata-se aqui de um afastamento irrelevante do decurso do acontecimento se o agente ainda executa o acto posterior destinado efectivamente a matá-lo. Se isto não aconteceu, então ou estaremos perante puros actos preparatórios em princípio não puníveis — ressalvada a punibilidade a título de negligência —, ou, se a acção tiver alcançado já o limiar dos actos de execução, deverá considerar-se o crime doloso como consumado ([33]).

2.2.3. A *aberratio ictus vel impetus*

§ 27 Um outro caso até certo ponto especial é constituído pelas hipóteses de *aberratio ictus vel impetus* (do latim: desvio da trajectória ou do golpe): casos em que, por **erro na execução**, vem a ser atingido objecto diferente daquele que estava no propósito do agente. Exemplos podem apontar-se como o de *A* pretender matar *B* com um tiro, mas este vir a atingir não *B*, mas *C*; ou o de *D* procurar destruir uma coisa a tiro, mas este acabar por não atingir a coisa, mas sim uma pessoa que estava perto e que fica ferida ou morta. Aqui — diferentemente do que sucede no erro sobre o decurso do acontecimento — o resultado ao qual se referia a vontade de realização do facto não se verifica, mas sim *um outro*, da mesma espécie ou de espécie diferente. A acção falha o seu alvo e apresenta por isso a estrutura da **tentativa**. A produção do outro resultado, que tanto podia não ter lugar como ser de outra gravidade, só pode eventualmente conformar um **crime negligente**. A punição deve por isso ter lugar só por tentativa ou por concurso desta com um crime negligente; é a chamada **teoria da concretização**.

§ 28 É esta a doutrina hoje largamente dominante, entre nós e lá fora, mesmo quando haja **coincidência típica entre o tipo de ilícito projectado e o consu-**

([33]) Na conclusão, RUDOLPHI, *SK*, § 16, n.º 34, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 8, n.º 94.

mado (34); se bem que para esta hipótese uma outra posição — a da dita **teoria da equivalência**, todavia claramente minoritária — continue a defender a punição pelo crime doloso consumado (35). Incrivelmente, uma parte da nossa jurisprudência continua a trazer para este contexto a velha discussão que à luz do CP de 1886 se travava a propósito do seu art. 29.º-6, na pressuposição de que, qualquer que fosse a solução em definitivo adoptada (punição por crime tentado ou consumado), ela tinha de ser encontrada no quadro da *unidade criminosa* (36). Sobre uma tal discussão não vale a pena perder hoje uma só palavra.

2.2.4. O *error in persona vel objecto*

§ 29 Nos casos agora em consideração — e que, anteciparemos desde já, verdadeiramente não constituem problema, mas que por isso mesmo há que distinguir do grupo anteriormente considerado — o decurso real do acontecimento corresponde inteiramente ao intentado; só que o agente se encontra em erro quanto à *identidade* do objecto ou da pessoa a atingir. Não existe pois aqui qualquer erro na execução, mas sim na **formação da vontade**. Exs.: (1) *A*, pensando que o passante é o seu inimigo *B*, dispara contra ele um tiro mortal, verificando-se depois que *A* confundiu *B* com *C* e foi este, um estranho, que matou; (2) *D* subtrai de um museu uma imitação de um quadro célebre, de valor muito relativo, pensando que se trata do original valiosíssimo; (3) caçando ilegalmente ao fim da tarde, *E* dispara contra um vulto com dolo de dano na pressuposição de que se trata de um animal, quando na verdade se trata de uma criança, *F*, que vem a falecer.

§ 30 Que, sempre que o objecto concretamente atingido seja tipicamente idêntico ao projectado [ex.: (1)], o erro sobre o objecto (ou a pessoa) é **irrelevante**, não pode pôr-se em dúvida e não é hoje mais, na verdade, discutido (37); uma vez que a lei proíbe a lesão não de um determinado

---

(34) Assim, entre nós, SILVA, Marques da, II, p. 216; na Alemanha, cf., só, JESCHECK / WEIGEND, § 29, 6, c), e ROXIN I, § 12, n.º 165; na Espanha, SILVA SÁNCHEZ, "Aberratio ictus" e imputación objectiva, *ADPCP 37*, 1984, p. 375, e MUÑOZ CONDE / GARCÍA ARÁN, p. 315.

(35) Cf. WELZEL, § 13, I, 3, d; e, entre nós, COSTA, Maia, Aberratio ictus, Anotação, *RMP 4/16*, 1983, p. 154.

(36) Cf. Ac. do STJ de 31-5-1995, *BMJ 447*, p. 388 e ss. E, para a discussão doutrinal anterior ao CP de 1982, CORREIA, Ferrer, *Dolo e Preterintencionalidade*, 1935, agora em *Estudos Jurídicos*, II, 1969, p. 318 e ss., DIAS, Figueiredo, *Responsabilidade pelo Resultado e Crimes Preterintencionais*, 1961, p. 94 e ss., CORREIA, Eduardo, I, n.º 90, III, e FERREIRA, Cavaleiro de, 1981, I, p. 493 e ss.

(37) Neste sentido, cf. Acs. do STJ de 30-5-1984, *BMJ 337*, p. 235 e ss., e de 30-10-1996, *BMJ 460*, p. 444 e ss. Cf. ainda, com interesse, os factos julgados pelo Ac. do STJ de 19-11-1998,

objecto ou indivíduo, mas de todo e qualquer objecto ou pessoa compreendidos no tipo de ilícito. Se o agente erra *também*, todavia, sobre as *qualidades tipicamente relevantes* do objecto por ele atingido, então há que ficar ou só na responsabilidade por **tentativa**, ou eventualmente na **combinação** de *tentativa* com uma *responsabilidade por negligência* [exs.: (2) e (3)]. Quer uma quer outra solução se compreendem face aos princípios gerais, de tal modo que o *error in persona vel objecto* não reivindica nenhum tratamento especial.

2.3. O conhecimento da proibição legal

§ 31 Na esmagadora maioria dos casos o elemento intelectual do dolo do tipo será configurado através da exigência de conhecimento de todos os supostos do facto e (nos limites referidos) do decurso do acontecimento. Excepcionalmente, porém, à afirmação do dolo do tipo torna-se ainda indispensável que o agente tenha actuado com **conhecimento da proibição legal**. Isto sucede sempre que o tipo de ilícito objectivo abarca condutas cuja *relevância axiológica* é tão **pouco significativa** que o ilícito é primariamente constituído não só ou mesmo nem tanto pela *matéria* proibida, quanto também pela **proibição legal**. Nestes casos, com efeito, seria contrária à experiência e à realidade da vida a afirmação de que já o conhecimento da factualidade típica e do decurso do acontecimento orientam suficientemente a consciência ética do agente para o desvalor do ilícito ([38]). Não queremos com isto afirmar que o relevo axiológico da conduta valha já como consciência do ilícito. Queremos sim significar que a pequena ou insignificativa relevância axiológica da acção faz com que o facto, no conjunto dos seus elementos, não suscite imediatamente um problema de desvalor ligado ao dever-ser jurídico; e que portanto o substrato da valoração da ilicitude não é aqui constituído apenas pela conduta como tal, antes por esta acrescida de um elemento novo: a proibição legal. Por isso o desconhecimento desta proibição impede o conhecimento total do

---

CJ-STJ, 1998, III, p. 221 e s.: *A* foi rodeado por quatro indivíduos que o tentaram roubar; no decurso da agressão aproximaram-se dois polícias à paisana e, quando estes se encontravam perto daqueles, *A* disparou um tiro para o ar; todos se puseram em fuga tendo um dos polícias corrido na mesma direcção dos ladrões; *A* apontou então a sua arma na direcção desse polícia, julgando tratar-se de um dos agressores e alvejou-o com vários tiros, causando assim a sua morte: trata-se claramente de uma situação de *error in persona* irrelevante e não de um caso de *aberratio ictus*, como julgou o tribunal.

([38]) Em pormenor, o nosso *O Problema*, § 20.

substrato da valoração e determina uma insuficiente orientação da consciência ética do agente para o problema da ilicitude. Por isso, em suma, neste campo o conhecimento da proibição é requerido para afirmação do dolo "do tipo", sem que por isso ele deixe de ser um dolo "natural", um dolo do "facto" (complexo). Reconhecendo-o, o art. 16.º-1 (seguindo uma formulação que havíamos proposto (39) e parificando-o assim completamente, quanto ao seu efeito, ao erro sobre a factualidade típica) afirma que **um erro sobre a proibição exclui o dolo** quando o seu conhecimento "**for razoavelmente indispensável para que o agente possa tomar consciência da ilicitude do facto**". E reconhecendo-o, a lei penal portuguesa deu um passo decisivo (40) para o esclarecimento da essência do erro que exclui o dolo e do erro sobre a ilicitude (que o não exclui) e das fronteiras que entre um e outro intercedem (41).

§ 32 Dir-se-á que, em rigor, a relevância do erro sobre proibições legais só pode ter lugar no ilícito de mera ordenação social (supra, 7.º Cap., § 9 e s.), não no ilícito penal. Mas uma tal afirmação pecaria por exagero e não estaria, desde logo, de acordo com a parte do art. 16.º-1 acabada de citar. (1) Desde logo, casos há de **crimes de perigo abstracto** em que a conduta em si mesma, divorciada da proibição, não orienta suficientemente a consciência ética do agente para o desvalor da ilicitude: *v. g.*, a condução de veículo automóvel com a taxa de álcool no sangue de 1,2 gr/l, considerada pelo legislador como indício irrefutável de que o condutor se encontra em estado de embriaguez e comete, por conseguinte, não uma contra-ordenação, mas um crime. Compreende-se e aceita-se que aqui se torne indispensável à afirmação do dolo do tipo o conhecimento da proibição legal respectiva. (2) Como casos há, por outro lado, de incriminações pertencentes sobretudo (42) — como a jurisprudência nacional tem jus-

(39) No nosso *O Problema*, § 20, III, 5.

(40) E não só no nosso entendimento, como no de doutrina estrangeira altamente responsável que sem reservas o aplaude: cf. ROXIN, Acerca da problemática do direito penal da culpa, *BFD LIX*, 1983, p. 27, e TIEDEMANN, Zum Verhältnis von allgemeinem und besonderem Teil des Strafrechts, *Baumann-FS*, 1992, p. 14 e s.

(41) Muito instrutivo a todo este propósito o caso sobre o qual recaiu a (excelente) sentença do Tribunal de Anadia de 3-6-1994, anotado por DIAS, Figueiredo / CAEIRO, Pedro, Erro sobre proibições legais e falta de consciência do ilícito (arts. 16.º e 17.º do Código Penal) — Violação de normas de execução orçamental, *RPCC 5*, 1995, p. 245.

(42) Mas não só, cf. já a seguir em texto. Sobre o ponto, cf., p. ex., o Ac. da RL de 21-1-1976, *RLJ 109*, p. 136, com anotação de DIAS, Figueiredo.

tamente notado — ao **direito penal secundário** (nos mais diversos âmbitos, nomeadamente, no do direito penal económico em sentido amplo) em que a relevância axiológica da conduta, se bem que existente, é de tal maneira ténue, sobretudo por força da estreita ligação das incriminações e dos seus termos a razões contingentes e mutáveis de política social, que também neste âmbito o conhecimento da proibição deve considerar-se razoavelmente indispensável para a orientação do agente para o desvalor da ilicitude ([43]). (3) Finalmente, uma razão de igual ordem pode valer mesmo para certos crimes — embora em número limitado ([44]) — do **direito penal de justiça**: relativamente a crimes em que a conduta é ilícita em função da protecção de um bem jurídico-penal que se não encontra ainda nitidamente aceite como tal pela comunidade e pela sua consciência dos valores, assumindo aqui então um certo relevo autónomo a sua proibição pelo legislador. Também nestes casos a afirmação do dolo do tipo deve exigir o conhecimento da proibição legal e o erro respectivo exclui o dolo, só podendo o agente ser punido, se disso for caso, a título de negligência.

§ 33 Durante muito tempo pensámos e ensinámos que, se bem que, como acabámos de ver, o conhecimento de certas proibições legais seja indispensável à *punição do agente a título de dolo*, todavia isso ocorreria não — como agora aqui defendemos — porque o erro respectivo exclua logo o dolo do tipo, mas sim porque, devendo em casos tais o dolo do tipo ser afirmado, todavia deveria ser negada a *culpa dolosa* ([45]). Tudo se passaria aqui, pois, como veremos que sucede (e a nossa lei confirma no art. 16.º-2) com o erro sobre os pressupostos de uma causa de justificação (infra, 14.º Cap., § 23 e ss.) e com o erro sobre os pressupostos de uma causa de exclusão da culpa (infra, 22.º Cap., § 28 e ss.). Não nos parece hoje, porém, que assim deva ser: o erro sobre proibições legais nos casos dos *delicta mere prohibita* exerce exactamente a mesma função de quaisquer outros elementos pertencentes ao tipo objectivo de ilícito; existe entre estes elementos e a proibição uma conexão de tal modo inextricável que não pode fazer-se entre eles qualquer distinção normativa e teleológica para afirmação do dolo do tipo. Mesmo que, de um ponto de vista puramente lógico, possa objectar-se à ideia segundo a qual, nestes casos, a proibição legal seria pura e simplesmente ele-

([43]) Será o caso exemplar da referida "violação de normas de execução orçamental": DIAS, Figueiredo / CAEIRO, Pedro, nota 41, p. 270 e s.

([44]) Como exemplo servirá porventura o crime de "tráfico de influências" do art. 335.º Sobre ele e a sua história, PEREIRA, Margarida Silva, Acerca do novo tipo de tráfico de influências, *Jornadas FDUL*, p. 253 e ss., e CAEIRO, Pedro, *Comentário Conimbricense*, III, art. 335.º

([45]) DIAS, Figueiredo, Sobre o estado actual da doutrina do crime, 2.ª parte — Sobre a construção do tipo-de-culpa e dos restantes pressupostos da punibilidade, *RPCC* 2, 1992, p. 20 e s.

mento constitutivo do tipo (46) e que, ainda neste domínio, se persista na distinção entre "matéria proibida" e "proibição", o ponto de vista teleológico-funcional decisivo não pode deixar de ser o de considerar que este conhecimento faz parte integrante da afirmação do dolo do tipo; porque, em definitivo, ele faz parte do **conhecimento necessário a uma correcta e indispensável orientação da consciência ética para o problema da ilicitude**. Esta terá sido a razão por que o nosso legislador *parificou* o erro sobre proibições ao erro sobre elementos do facto, no art. 16.º-1, enquanto no art. 16.º-2 se limitou a *estender* a solução da exclusão do dolo e da punição a esse título ao erro sobre os pressupostos de uma causa de exclusão da ilicitude e da culpa.

3. O momento volitivo do dolo

§ 34 O conhecimento (previsão) das circunstâncias de facto e, na medida necessária, do decurso do acontecimento não podem, só por si, *indiciar* a contrariedade ou indiferença ao dever-ser jurídico-penal, manifestada pelo agente no seu facto, que dissemos caracterizar a culpa dolosa e, em definitivo, justificar a punição do agente a título de dolo. O dolo do tipo não pode bastar-se com aquele conhecimento, mas exige ainda que a prática do facto seja presidida por uma **vontade dirigida à sua realização**. É este elemento que constitui o momento volitivo do dolo do tipo e que pode assumir matizes diversos, permitindo a formação de diferentes classes de dolo. Se por vezes uma tal direcção da vontade é claramente manifestada, configurando os casos chamados de dolo directo, outras vezes ela é menos clara e suscita dificuldades apreciáveis, quando o agente parte para a realização do facto tendo-o representado como meramente *possível*. Aqui sobem de ponto as dificuldades de distinção, a nível dos tipos de ilícito, entre dolo e negligência, na medida em que também a negligência consciente supõe a representação da realização do facto como possível. Para além disto, a distinção entre dolo directo e dolo eventual possui o maior relevo, na medida em que casos existem na lei — e outros são acrescentados pela doutrina: cf. infra, § 51 — em que o facto só é punível a título de dolo directo, não de dolo eventual.

3.1. O dolo directo

§ 35 A forma mais clara e terminante — e por isso também a que dá lugar a menos dúvidas doutrinais e de aplicação — de dolo directo é

(46) Conclusão todavia subentendida em LANGE, Der Strafgesetzgeber und die Schuldlehre, *JZ*, 1956, p. 77 e ss., e expressa pelo seu discípulo MICHELS, *Strafbare Handlung und Zuwiderhandlung*, 1963, p. 101 e s. Sobre a questão, em pormenor, o nosso *O Problema*, § 20, I, 1.

constituída por aqueles casos em que a realização do tipo objectivo de ilícito surge como *o verdadeiro fim da conduta* (art. 14.º-1). Fala-se então a este propósito de dolo directo **intencional** ou **de primeiro grau**. Assim, p. ex., quando *A*, admirador incondicional de um quadro de Picasso, mas sem dinheiro para o comprar, assalta o estabelecimento de leilões onde o quadro será vendido no dia seguinte e o subtrai para ficar com ele. Como casos de dolo directo intencional serão ainda de considerar aqueles em que a realização típica não constitui o fim último, o móbil da actuação do agente, mas surge como **pressuposto ou estádio intermédio necessário** do seu conseguimento; *v. g.*, quando *A* mata o vigilante *B* como única forma de poder assaltar um banco: o homicídio é cometido então sob a forma de dolo directo intencional. As *motivações* determinantes do comportamento do agente não desempenham aqui nenhum papel: o agente dirigiu directamente a sua vontade à realização do facto, por mais desagradável ou lamentável que lhe possa surgir o ter de matar *B*. Relevante é apenas a necessidade de *conexão* entre o facto prévio (no exemplo dado: o homicídio) e o fim último da conduta (roubar o banco). Claro que a motivação poderá ser (será) relevante para outros efeitos, *v. g.* de culpa e/ou de medida da pena, mas não de qualificação do dolo do tipo. O conseguimento do *fim* da conduta não tem, de resto, de preencher um tipo de ilícito, bastando que o constitua o *meio* utilizado na actuação ([47]).

§ 36 Diferentes são os casos de dolo directo **necessário** ou **de segundo grau** (art. 14.º-2). Neles a realização do facto surge não como pressuposto ou degrau intermédio para alcançar a finalidade da conduta, mas como sua **consequência necessária,** no preciso sentido de consequência **inevitável**, se bem que "lateral" relativamente ao fim da conduta. Esta "inevitabilidade" pressupõe já uma característica especial a nível do elemento intelectual do dolo do tipo: a previsão do facto há-de ter ultrapassado a mera representação da consequência como "possível", para o ser como "certa" ou ao menos "altamente provável". O exemplo de escola é aqui constituído pelo agente que coloca uma bomba num avião como forma de, em pleno voo, matar um seu inimigo que nele viaja, mas plenamente consciente de que a explosão provocará, como vem a provocar, a morte dos restantes viajantes. A morte do inimigo ser-lhe-á imputada a título de dolo directo intencional ou de primeiro grau, a de todos os outros ocupantes, como

([47]) No sentido desta última consideração, STRATENWERTH / KUHLEN, § 8, n.º 106.

consequência da explosão da bomba e da aeronave, a título de dolo directo necessário ou de segundo grau.

3.2. O dolo eventual

§ 37 Os casos de dolo eventual — também chamados por vezes de dolo *condicional* ([48]) — caracterizam-se antes de tudo pela circunstância de a realização do tipo objectivo de ilícito ser representada pelo agente apenas "como consequência **possível** da conduta" (art. 14.º-3). Que também em casos tais o agente pode actuar na disposição de aceitar a realização e o elemento volitivo do dolo do tipo deve, por isso, considerar-se verificado, é conclusão que ninguém discute. Questionável permanece, em todo o caso, como é que um dolo assim estruturado se distingue concretamente da mera negligência consciente, que lhe está próxima, pelo facto de também ela supor aquela representação da realização típica como consequência possível da conduta (art. 15.º/*a*)).

§ 38 Para consideração do problema da distinção entre dolo eventual e negligência consciente deve, assim, aceitar-se à partida que entre as duas entidades existe, no plano do elemento intelectual, uma **sobreposição inevitável.** A tentativa doutrinal de operar ainda neste plano a sua distinção com apelo à categoria da *finalidade* — que existiria no dolo eventual, mas já não na negligência consciente — está condenada a fracassar: ou o apelo ao conceito de finalidade é puramente consequencial, fazendo-o coincidir com o resultado a que, com recurso a outras categorias lógicas e teleológicas, se chegue em matéria de distinção entre dolo eventual e negligência consciente (tornando-se assim a "finalidade" só um outro *nome* para aquilo que se considerar dolo do tipo: cf. já supra, 10.º Cap., § 32 e s.); ou a "finalidade" tem de considerar-se como resultante da acção com mera representação de um resultado como possível ([49]), caso em que o conceito se torna imprestável para a distinção aqui buscada.

3.2.1. Termos da distinção entre dolo eventual e negligência consciente

§ 39 Para distinguir o dolo eventual e a negligência consciente a doutrina apresenta uma multiplicidade infindável de critérios que pode tor-

([48]) Cf., p. ex., JESCHECK / WEIGEND, § 29, III, 3, a), e JAKOBS, 8/21 e ss.; mas a expressão é equívoca na medida em que pode sugerir a existência de uma *vontade* condicional. Ora não há no dolo do tipo, mesmo sob a forma eventual, nenhuma decisão (ou vontade) *condicional*: esta só poderia fundar um tipo de ilícito negligente consciente, não um tipo de ilícito doloso (assim, por outros, STRATENWERTH / KUHLEN, § 8, n.º 111).

([49]) Assim, com razão, GALLAS, Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbrechen, *ZStW 67*, 1955, e, já, DIAS, Figueiredo, nota 36, p. 71 e ss.

nar-se enganosa e que encobre, em grande parte dos casos, variações pouco mais que puramente semânticas, às quais não correspondem diferenças materiais e de resultados práticos assinaláveis. A generalidade das soluções propostas para o problema deixa agrupar-se em três teorias fundamentais: as teorias da probabilidade, as da aceitação e as da conformação.

3.2.1.1. Teorias da probabilidade

§ 40 Se bem seja por todos aceite que a questão do dolo eventual diz respeito ao momento volitivo do dolo, não falta quem continue a sugerir que a distinção só se logra através de diferenças que radicam ainda no plano *cognitivo* e por isso, de certa forma, no *elemento intelectual*. E porque não pode para o efeito bastar a mera representação do facto como possível (elemento comum ao dolo eventual e à negligência consciente), fica próxima a exigência de que para o dolo eventual se requeira uma qualquer **representação qualificada**. Várias doutrinas assentam, a partir daqui, na ideia de que à afirmação do dolo do tipo não basta o conhecimento da mera *possibilidade* de realização, mas requer-se que a representação assuma a forma da *probabilidade*, ou mesmo de uma probabilidade *relativamente alta* ([50]). E na verdade: esta "teoria da probabilidade" aponta para a conclusão, em princípio exacta, de que o agente contará tanto mais com — valendo este "contar com" como "decisão de levar a cabo" — a realização típica, quanto mais esta surgir aos seus olhos como provável ([51]). Fazer assentar toda a construção *somente* na probabilidade de realização típica depara porém com duas dificuldades: a primeira é a de determinar com um mínimo de exactidão o grau de possibilidade / probabilidade de verificação do facto necessário à afirmação do dolo do tipo ([52]); a segunda é a de o agente, apesar da improbabilidade de realização do tipo, poder tomar a firme *decisão* de a alcançar (*v. g.*, o agente quer a todo o custo — sendo essa até, porventura, a motivação e a finalidade *únicas* da sua conduta — matar a vítima com um tiro apesar de a grande distância a que ela se encontra determinar um baixo grau de probabilidade de que tal aconteça). Aqui depara-se, por isso, com uma particular intensidade (e indiscutibilidade) do

([50]) Assim, muito especialmente, MAYER, H., p. 250 e ss., e, agora, PUPPE, *NK*, § 15, n.º 92.

([51]) Ideia também sublinhada por FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 295 e ss., sem que todavia deixe de considerar que o acento tónico deve ser colocado no elemento volitivo.

([52]) Acentuando esta crítica, COSTA, Faria, Tentativa e dolo eventual, *Estudos Eduardo Correia*, I, 1989, p. 704, para quem "é jurídico-penalmente inconsequente e mesmo ineficaz tentar construir uma distinção entre possibilidade e probabilidade".

elemento volitivo, que não deve tornar a realização típica subjectivamente imputável a mera negligência.

§ 41 Perante estas dificuldades, as formulações mais recentes desta doutrina procuram ancorar o dolo eventual em uma especial **qualidade** da representação da realização típica como possível. Para tanto costuma exigir-se que o agente tome a realização como *concretamente* possível, que não a considere improvável segundo seu juízo *fundado*, sobretudo, que parta de um ponto de vista *pessoalmente vinculante* ([53]). Com tudo isto, porém, esta concepção perde o seu ponto de partida cognitivo-intelectual e começa substancialmente a aproximar-se da terceira posição que será referida (3.2.1.3) ([54]).

3.2.1.2. Teorias da aceitação

§ 42 Uma concepção de certo modo oposta à que ficou referida propõe-se partir sem tergiversações, para a distinção, da análise da vontade do agente e, portanto, do puro **elemento volitivo** do dolo. Nesta via se pergunta se o agente, apesar da representação da realização típica como possível, *aceitou intimamente* a sua verificação, ou pelo menos revelou a sua *indiferença* perante ela (dolo eventual); ou se, pelo contrário, a *repudiou intimamente*, esperando que ela se não verificasse (negligência consciente) ([55]). Ao conjunto destas posições se dá por isso o nome de **teorias da aceitação**. E também elas põem em evidência uma conexão particularmente importante com a culpa dolosa: que o agente se tenha decidido *contra* o direito ou com *indiferença* perante ele será tanto mais seguro quanto tenha considerado bem-vinda a realização típica, e tanto mais duvidoso quanto a tenha considerado indesejável.

§ 43 Numa consideração crítica destas teorias, uma alternativa parece impor-se. Ou a íntima aceitação se entende em termos estritos e rigorosos, caso em que fica próxima a afirmação de um dolo directo, que não

---

([53]) Respectivamente: SCHMIDHÄUSER, 10/88, JAKOBS, 8/23, FRISCH, *Vorsatz und Risiko*, 1983, p. 193.

([54]) Assim, STRATENWERTH / KUHLEN, § 8, n.º 115.

([55]) Fundamental, ENGISCH, *Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit*, 1930, p. 380 e ss. Nesta linha se formou, entre nós e lá fora, uma doutrina durante muito tempo dominante: cf., só, FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, p. 364 e ss.

meramente eventual. Ou ela se entende em termos pouco rigorosos e modificados, fazendo-a equivaler à posição emocional daquele a quem a verificação do resultado é indiferente, ou pelo menos espera ou confia em que o resultado não terá lugar ([56]). Podem avançar-se neste contexto hipóteses como a de Guilherme Tell ou a dos atiradores de facas nos circos. O conhecido caso *Lacmann*, de que se ocupa praticamente a totalidade da doutrina alemã, revela-se a este propósito exemplar: *A* aposta com *B* que é capaz de quebrar com um tiro um copo que uma rapariga, *C*, segura na mão, sem todavia a atingir; mas acaba por a ferir numa mão ([57]). *A* está consciente de que pode errar o tiro e atingir *C* mas, naturalmente, espera que tal não aconteça, para assim ganhar a aposta e se envaidecer com a sua pontaria. Mesmo que *A* sinta como um mal a realização típica, pode ele considerar a sua possibilidade como um mal menor, que de todo o modo se dispõe a aceitar: nisto residiria precisamente a decisão, fundamentadora do dolo do tipo, contra a norma de comportamento. Neste contexto, a jurisprudência alemã começou a referir-se a uma *aceitação em sentido jurídico* sempre que o agente — em vista da finalidade prosseguida, nomeadamente por não poder alcançá-la de outro modo — se **resigna** com a possibilidade de que a sua acção venha a ter o efeito indesejado. Mas, assim, é também toda esta concepção que se aproxima daquela que em seguida será exposta, até a um ponto de não ser fácil uma sua distinção rigorosa ([58]).

3.2.1.3. Teorias da conformação

§ 44 A concepção hoje largamente dominante é conhecida doutrinalmente como teoria da conformação; e é ela que consta expressamente do art. 14.º-3 ([59]): "Quando a realização de um facto que preenche um tipo de crime for representada como consequência possível da conduta, há dolo **se o agente actuar conformando-se com aquela realização**". Ela parte da ideia de que o dolo pressupõe algo mais do que o conhecimento do perigo de realização típica. O agente pode, apesar de um tal conhecimento, *confiar*, embora levianamente, em que o preenchimento do tipo se não verificará e age então só com negligência (consciente). Por isso

([56]) Assim, também, ROXIN, § 12, n.º 37.

([57]) LACMANN, Die Abgrenzung der Schuldformen..., *ZStW 31*, 1911, p. 159.

([58]) Cf., de novo, STRATENWERTH / KUHLEN, § 8, n.º 116.

([59]) Em sentido contrário, GONÇALVES, Maia, 1997, p. 111 e s., que entende estar consagrada nesta norma uma teoria da aceitação.

pôde Eduardo Correia, no seu ensino — vazado no art. 11.°, § 2, do seu ProjPG —, avançar como critério do dolo eventual o facto de o agente actuar **não confiando em que o resultado se não verificará** (60). Mas esta formulação não é, quanto a nós, a preferível, por duas razões: porque a dupla negação que ela comporta não dá a perceber com suficiente clareza o elemento *positivo* que deve arvorar-se em critério do dolo eventual; e porque uma conotação extremadamente psicologista da "confiança" pode conduzir a privilegiar infundadamente o optimista impenitente (que confia em que tudo correrá pelo melhor) face ao pessimista depressivo (incapaz de confiar em que se não passará o pior): para um tal privilégio não há, do ponto de vista de uma avaliação substancial do tipo subjectivo de ilícito, qualquer fundamento. E este argumento dá-nos ensejo a divergir, em pequena mas significativa medida, do entendimento que a maioria da doutrina alemã confere hoje à doutrina da conformação.

§ 45 Essencial se revela na doutrina da "conformação", segundo o nosso ponto de vista — mas julgando nós seguir aqui, no essencial, a posição de princípio de Roxin —, que o **agente tome a sério o risco de (possível) lesão do bem jurídico, que entre com ele em contas e que, não obstante, se decida pela realização do facto** (61). Fica assim prejudicada no essencial, se bem cremos, a conotação meramente psicologista da "confiança" na não produção da consequência representada como possível, que acima criticámos; em vez dela avultando *normativamente* o essencial: o indício que a afirmação do dolo do tipo confere de existência de uma culpa dolosa. Se o agente tomou a sério o risco de (possível) produção do resultado e se, não obstante, não omitiu a conduta, poderá com razoável segurança concluir-se logo que *o propósito que move a sua actuação vale bem, a seus olhos, o "preço" da realização do tipo*, ficando deste modo indiciado que **o agente está intimamente disposto a arcar com o seu desvalor**. A circunstância de, não obstante os riscos previstos de lesão do bem jurídico, levar a acção a cabo revela uma *decisão contra* a norma jurídica

(60) Correia, Eduardo, I, n.° 85, V. Segundo o art. 11.°, § 2, do seu *ProjPG*, "se a realização do facto for prevista como consequência possível ou eventual da conduta, haverá dolo se o agente, actuando, não confiou em que ele se não produziria", sendo assim o âmbito de punição por dolo eventual mais lato do que o que actualmente deriva do art. 14.°-3. Vale a pena anotar que já substancialmente no sentido proposto por Eduardo Correia se pronunciava Correia, Ferrer, nota 36, p. 301 e s.

(61) Nestes termos, Roxin I, § 12, n.° 21 e ss.

de comportamento, para tanto não interessando saber se as consequências negativas do facto lhe são ou não indesejáveis, se ele confia ou não temerariamente que ainda as poderá evitar. De dolo eventual se fala, numa palavra, a propósito de todas as circunstâncias e consequências com que o agente, em vista da autêntica finalidade da sua acção, se *conforma* ou com a verificação das quais se *resigna*.

§ 46 Extremamente difícil, mas instrutivo, se revela o chamado "caso da correia de couro", decidido pela jurisprudência alemã (BGHSt 7, 363) e que hoje qualquer tratamento doutrinal do dolo eventual coloca mesmo no centro da discussão (62). Ele pode ser descrito da forma seguinte: *A* e *B* decidem roubar *C*, apertando-lhe o pescoço com uma correia de couro até que ele perca o conhecimento. Propondo-se evitar a morte de *C*, que previram como possível, resolveram porém golpeá-lo antes na cabeça com um saco de areia até que perdesse o conhecimento. No acto, porém, o saco de areia rebentou e os agentes reverteram ao plano inicial, aplicando a correia de couro que tinham levado e apertando o pescoço de *C* até que este se imobilizou, para em seguida se apoderarem dos seus pertences. Após o que, receando que *C* já não respirasse, levaram a cabo procedimentos de reanimação; no entanto *C* morreu. Neste caso se mostra exemplarmente que a morte de *C* não era em definitivo desejada pelos ladrões; todavia não até um ponto que os conduzisse a omitir a aplicação da correia de couro, que eles representaram seriamente como produtora possível de um risco de morte. Logo nessa base o dolo eventual de homicídio deve ser afirmado, na base de que os agentes se "conformaram" com a realização típica (63). A esta luz, que, de um ponto de vista puramente psicologista, os agentes tivessem ou não confiado que o resultado se não verificaria deve considerar-se indiferente para afirmação do dolo do tipo de homicídio.

§ 47 A partir daqui fica próximo perguntar (cf. já supra, § 41, *in fine*) também se o critério da *conformação* consegue manter-se de todo estranho à questão da **probabilidade** da realização típica. Cremos que uma resposta negativa se impõe: pois não deve dizer-se que o agente tomou a sério a possibilidade de realização se esta é manifestamente *remota* ou *insignificante*, salvo se uma tal "distância" for claramente "compensada" por uma deci-

---

(62) Também a jurisprudência portuguesa tem, naturalmente, sido confrontada a este propósito com situações de inegável complexidade. Cf., a título de exemplos, os casos decididos pelos seguintes acórdãos: Ac. do STJ de 12-12-1984, *BMJ 342*, p. 227 e ss.; Ac. do STJ de 13-5-1987, *BMJ 367*, p. 386 e ss.; Ac. do STJ de 1-4-1993, *BMJ 426*, p. 154 e ss.; Ac. da RC de 23-1-1985, *CJ*, 1985, I, p. 92 e ss.; e Ac. do Tribunal de Círculo de Oeiras de 13-2-1998, *Sub Judice, Causas 2*, 1998, p. 49 e ss., que julgou o conhecido caso do foguete *very-light* no Estádio do Jamor, comentado por PALMA, Fernanda, *Thémis 1*, 2000, p. 176 e ss.

(63) Neste sentido, ROXIN I, § 12, n.º 22 e ss.; e, também, STRATENWERTH, § 8, n.º 125.

dida vontade criminosa. O caso da transmissão do vírus da SIDA através de contactos sexuais não protegidos por pessoa infectada, que todavia representa a doença ou a morte do parceiro como possível, tornou-se hoje praticamente o caso mais controverso. Apesar de decisões contrárias da jurisprudência alemã, a baixíssima probabilidade de transmissão (fala-se, do lado da ciência médica, de não mais de 0,1% a 1% de possibilidade por cada contacto) conduz a que julgamos doutrina maioritária, embora com variada fundamentação (64), a negar o dolo eventual de ofensa à integridade física ou de morte. Seja porque o conhecimento indispensável à afirmação do dolo do tipo pressuporia que a consequência lateral seja tomada pelo agente, no momento da sua actuação, como uma *possibilidade real*, não como um mero perigo abstracto; seja porque, desta última forma, não seria correcto falar de uma qualquer *decisão*: outra coisa só deveria ser dita se a infecção do parceiro não é prevista como consequência lateral, mas constitui o fim da conduta (sexual) do agente (65).

3.2.1.4. Conclusão

§ 48 Seria leviano pensar que, com quanto fica dito, todas as dificuldades da distinção foram ultrapassadas. Uma das razões de dúvida que com maior frequência se invoca é a de saber como devem decidir-se aqueles casos em que o agente não pensou no risco, nem muito menos o tomou a sério ou sequer entrou com ele em linha de conta, em virtude da **completa indiferença** que lhe merece o bem jurídico ameaçado.

§ 49 Durante muito tempo pensámos que casos deste teor obrigariam a que, neles, a distinção definitiva entre dolo eventual e negligência consciente não ocorresse a nível do tipo subjectivo de ilícito (onde se verificaria uma sobreposição inevitável entre os dois campos), mas apenas **a nível do tipo de culpa**, onde (como já se disse e à frente melhor se explicitará) o tipo de culpa doloso pode justamente ser integrado por uma atitude pessoal interna de *indiferença* perante o bem jurídico vio-

(64) Cf., só, ROXIN I, § 12, n.os 66 e 82 e ss., e STRATENWERTH / KUHLEN, § 8, n.º 126.

(65) Esta solução pode ser considerada criticável à luz da fortíssima necessidade político-social de "luta" contra a expansão da SIDA. Mas sem razão. O legislador é naturalmente livre e está legitimado para, se assim o entender, criar um *crime de perigo abstracto* de prática de acto sexual desprotegido por portadores de HIV (assim, também, ROXIN I, § 12, n.º 85), se bem que o conhecimento da situação pelo parceiro deva afastar a punibilidade.

lado (66). Não cremos hoje que seja necessário (nem dogmaticamente viável) ir tão longe e arvorar o critério da "indiferença" em critério último de distinção entre dolo eventual e negligência consciente (67). Sustentando em consequência que a distinção só a nível da culpa pode ser levada a cabo ou (o que seria inadmissível) deslocando o critério da atitude interna de "indiferença" para o tipo subjectivo de ilícito (68). Como ainda menos será necessário recorrer, em casos deste teor, a fórmulas análogas à da chamada "fórmula hipotética de Frank" — para a qual se inclinaram Beleza dos Santos e (durante muito tempo) Eduardo Correia —, que entrassem em conta com juízos hipotéticos sobre qual teria sido a decisão do agente se aquela indiferença fosse posta entre parêntesis e se perguntasse como teria actuado o agente se a consequência representada como possível tivesse sido tomada como certa (69). Fórmulas que, como hoje unanimemente se reconhece (70), acabam por desaguar em um puro "direito penal do agente", democraticamente ilegítimo e, ademais, em absoluto inadequado à estrutura e à função do juízo de ilicitude. A verdade, de todo o modo, é que **a questão da "culpa dolosa" só pode suscitar-se se previamente tiver podido comprovar-se a verificação de um ilícito doloso e, portanto, do dolo do tipo**. O agente que revela uma absoluta indiferença pela violação do bem jurídico, *apesar de ter representado a consequência como possível e a ter tomado a sério*, sobrepõe de forma clara a satisfação do seu interesse ao desvalor do ilícito e por isso **decide-se** (se bem que não sob a forma de uma "resolução ponderada", ainda que só implicitamente, mas nem por isso de forma menos segura) pelo sério risco contido na conduta e, nesta acepção, *conforma-se* com a realização

---

(66) Assim, já, DIAS, Figueiredo, nota 36, p. 71 e ss., e, depois, *DP II*, § 731 — acompanhando-nos sempre, todavia, a má consciência da entorse dogmático-sistemática que uma tal solução representaria; fundamentalmente no mesmo sentido, também, COSTA, Faria, nota 52, p. 731 e s. Cf., ainda, PALMA, Fernanda, Dolo eventual e culpa em direito penal, *in*: *Problemas Fundamentais de Direito Penal. Homenagem a Claus Roxin*, 2002, p. 61, entendendo que a questão do dolo eventual deve ser ainda discutida no plano da culpa, como problema de "capacidade efectiva de ponderação do risco do resultado perante o contexto motivacional".

(67) À maneira — em todo o caso notavelmente fundamentada — de ENGISCH, nota 55, e de GALLAS, nota 49, p. 67. Cf. agora, também, S / S / CRAMER / STERNBERG-LIEBEN, § 15, n.os 82 e 84.

(68) No sentido desta crítica, de forma terminante, também, ROXIN I, § 12, n.º 30.

(69) SANTOS, Beleza dos, nota 3, p. 129 e ss.; CORREIA, Eduardo, I, p. n.º 85, IV, e, já antes, *Lições 1949*, p. 355 e ss., na esteira de FRANK, Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, *ZStW 10*, 1890, p. 169.

(70) Por todos, CORREIA, Eduardo, I, n.º 85, IV.

do tipo objectivo. Tanto basta para que o tipo subjectivo de ilícito deva ser qualificado como doloso. Na exemplar formulação de Roxin a propósito: "Quando a verificação de um resultado como possível é completamente indiferente, então tanto está bem a sua verificação como a sua não verificação; perante uma tal posição, uma decisão pela violação possível do bem jurídico existe já" ([71]).

§ 50 Todas as contas feitas, uma conclusão se torna infelizmente segura: a de que a distinção entre dolo eventual e negligência consciente, como quer que seja levada a cabo, é tanto do ponto de vista teórico, como ainda mais na aplicação prática, tão **frágil e insegura** que mal é capaz de justificar — quer do ponto de vista político-criminal estrito, quer em perspectiva dogmática, quer, globalmente e muito especialmente, à luz do princípio da culpa — diferenças significativas (e por vezes abissais) das molduras penais aplicáveis a um e outro caso (*v. g.*, homicídio doloso, prisão de 8 a 16 anos, art. 131.º, ou mesmo de 12 a 25 anos, art. 132.º; homicídio negligente, prisão até 3 anos ou multa, eventualmente prisão até 5 anos, art. 137.º); como, ainda menos, será capaz de justificar que muitas vezes o delito doloso seja severamente punível, o negligente pura e simplesmente não seja punível (*v. g.*, aborto, arts. 140.º e 141.º). Assim sendo, e tendo ademais em consideração o facto de na "sociedade do risco" aumentarem significativamente as necessidades político-criminais de tutela de uma imensidade de condutas que se situarão predominantemente no âmbito do dolo eventual e da negligência consciente, parece justificado deixar aqui pelo menos (apenas isso...) a questão de saber se à bipartição tipo de ilícito doloso / tipo de ilícito negligente, não deverá no futuro vir a substituir-se uma tripartição: dolo / negligência / **temeridade** ([72]). Esta nova categoria dogmática destinar-se-ia a incluir (dito a traço grosso) os casos tradicionais de dolo eventual e de negligência consciente, ficando o âmbito do dolo restringido ao dolo directo e o da negligência à negligência inconsciente. O legislador teria de, em conformidade, criar para a "temeridade"

([71]) ROXIN I, § 12, n.º 30.

([72]) Sem que, por ora, a adequação do nome proposto seja demasiado importante. Elementos dogmáticos de interesse para a construção desta forma delictiva poderiam de resto encontrar-se na concepção de uma parte da doutrina italiana sobre o *delito preterintenzionale*; nem as coisas serão porventura substancialmente diferentes quando se conceba, pela forma que o concebemos (supra, 11.º Cap., § 61), o *cerne da agravação* daquela espécie de crimes.

as molduras penais adequadas e determinar relativamente a que tipos de ilícito objectivo deveria ela ser punida (73). Se e quando uma tal tarefa legislativa vier a ser levada a cabo abrir-se-á à dogmática a tarefa imensa de construção dos respectivos tipos de ilícito e dos tipos de culpa temerários e de consequente reconstrução do tipo de ilícito e do tipo de culpa dolosos e negligentes. O argumento de que, desta maneira, se faria esbater a diferença de ilícito — e de culpa — entre dolo eventual e negligência consciente (74) tem alguma coisa por si. Mas não tem menos por si a questão de saber se tanto do ponto de vista político-criminal, como dogmático não é bem pior o esbatimento da diferença de ilícito — e de culpa — entre dolo directo e dolo eventual, ao submeter ambas as figuras a um conceito único (e unitário) de dolo.

3.2.2. Consequências da distinção

§ 51 Em não poucos preceitos da PE o CP não admite a forma do dolo eventual como manifestação punível do tipo de ilícito doloso, exigindo o dolo directo (ou até o dolo directo intencional). E não falta mesmo quem negue a compatibilidade de certas formas especiais do crime, nomeadamente a *tentativa*, com a sua punibilidade a título de dolo eventual (75). Onde, porém, a lei admita a punibilidade do tipo subjectivo de ilícito a título de dolo eventual diz-se não haver razão, *à partida*, para que se estabeleça qualquer distinção, a nível da consequência jurídica, consoante o facto foi cometido com dolo directo ou com dolo eventual. A ideia reinante durante muito tempo — e ainda hoje, nomeadamente na nossa jurisprudência (76) — de que o dolo eventual representa *por necessidade* uma forma **mais leve**

---

(73) Cf. (obviamente, *de lege ferenda*) ESER, *Strafrecht I*, ³1980, n.º 35 e s., e — aproximando a categoria aqui chamada "temeridade" da figura anglo-americana da *recklessness* —, já, ARZT, Leichtfertigkeit und recklessness, *Schröder-GS*, 1978, p. 119 e ss., e, depois, WEIGEND, Zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit, *ZStW 93*, 1981, p. 657, PERRON, Hat die deutsche Straftatsystematik eine europäische Zukunft?, *Lenckner-FS*, 1998, p. 244 e s., e DIAS, Silva, *Protecção jurídico-penal de interesses dos consumidores*, ³2001, p. 36. Para tendências doutrinais e jurisprudenciais neste sentido, na Grécia, PAPAGEORGIOU-GONATAS, Dolus eventualis und die dritte Schuldform, *ZStW 118*, 2006, p. 262.

(74) Assim, ROXIN I, § 12, n.º 74.

(75) Esta é a posição de COSTA, Faria, nota 52, p. 744 e ss. Sobre o ponto, infra, 28.º Cap., § 12.

(76) Muito claramente, a propósito, Ac. do STJ de 5-5-1993, Proc. 44 099/3.ª: "A culpa do agente que actua com dolo eventual é menos intensa do que a que se verifica no caso de dolo directo ou necessário, situando-se perto da fronteira da culpa consciente".

de dolo que o dolo directo não teria justificação ([77]): podendo haver situações — mesmo que pouco frequentes ou até excepcionais — de dolo eventual em que seja **maior a gravidade** do ilícito (e da culpa) do que em situações de dolo directo. Atente-se em todo o caso no disposto no art. 71.º-2/*b)*, que manda atender à "intensidade do dolo" para efeitos de medida (concreta) da pena.

§ 52 A hipótese suscitada supra, § 50, de o legislador penal vir no futuro a intermediar as categorias do dolo e da negligência com a da temeridade não tem de ser contrariada pelo que acabou de expor-se em tema de severidade relativa do dolo e da negligência. Por um lado, uma coisa são as diferenças de ilícito (e de culpa) que possam interceder entre formas diversas de cometimento do crime, outra é a tradução destas diferenças em termos de determinação e de medida da pena. Por outro lado, negligência, temeridade e dolo não representarão (como já não representam hoje o dolo e a negligência) *degraus de uma escada*, que se sobem quando acaba um e o outro começa; bem podendo acontecer que o máximo da moldura penal mais baixa exceda o mínimo da moldura penal mais grave. O legislador só teria então de prever, para punição do mesmo tipo objectivo de ilícito, **molduras cujos limites em alguma medida se entrecruzassem**.

4. A conexão entre o dolo do tipo e a sua realização

§ 53 O dolo do tipo, como conhecimento e vontade de realização do facto, tem sempre de conexionar-se com um singular tipo de ilícito: um "propósito geral de fazer mal", ou de "cometer crimes" não constitui ainda um dolo do tipo, mas só o constitui o *concreto* propósito de matar, de ferir, de violar, de injuriar ou de furtar. Neste contexto se pode situar a questão do chamado **dolus alternativus**, isto é, dos casos em que o agente se propõe ou se conforma com a realização de um *ou* de outro tipo objectivo de ilícito: assim, *v. g.*, se *A* se apropria ilegitimamente de uma jóia que encontra no seu quintal, admitindo que ela possa ter caído de uma caixa que *B* lhe pediu no dia anterior para guardar (abuso de confiança: art. 205.º) ou que possa ter sido para ali atirada pelo vento que soprou forte durante a noite (apropriação ilegítima em caso de acessão ou coisa achada: art. 209.º); ou — dado o carácter eminentemente pessoal do bem jurídico "vida" — se *C* dirige um tiro contra um casal inimigo que passa na rua, sendo-lhe indiferente que mate o homem, *D*, ou a mulher, *E*. Em qualquer

([77]) Passa-se aqui algo de análogo àquilo que durante muito tempo se pensou em termos de distinção entre *negligência consciente* e *negligência inconsciente*. Cf. infra, 34.º Cap., § 6.

dos casos apontados o agente conta com ambas as possibilidades e conforma-se com elas, devendo por isso o seu dolo ser afirmado relativamente ao tipo objectivo de ilícito realmente preenchido pela conduta.

§ 54 Uma conexão, mas agora de índole **temporal**, entre o dolo e a realização típica deve ser exigida: as duas entidades devem decorrer *simultaneamente*. Um dolo *prévio* relativamente à realização típica (chamado **dolus antecedens**) não é pois ainda um dolo do tipo. Se *A* quer matar *B*, com quem depara no acto de este cometer um roubo na sua residência, decidindo disparar só após a consumação do acto, mas ao tirar a pistola do bolso esta dispara acidentalmente e *B* morre, não há dolo de homicídio. Tão pouco a conformação com um resultado típico que já aconteceu constitui dolo do tipo (o chamado **dolus subsequens**), *v. g.* se alguém mata por descuido um seu inimigo e depois assume conscientemente este resultado ou de toda a maneira com ele se conforma: neste caso só se verifica, eventualmente, realização do tipo de homicídio negligente, não do doloso porque se não pode decidir realizar aquilo que já aconteceu (78).

III. Os especiais elementos subjectivos do tipo

§ 55 Logo de início acentuámos (supra, § 3) que, em muitos tipos subjectivos de ilícito, ao dolo do tipo acrescem especiais elementos subjectivos. A distinção entre os elementos pertencentes ao dolo do tipo e os especiais elementos subjectivos do tipo agora em consideração está em que estes, ao contrário daqueles, **não se referem a elementos do tipo objectivo de ilícito**, ainda quando se liguem à vontade do agente de realização do tipo: o seu objecto encontra-se *fora* do tipo objectivo de ilícito, não havendo por isso, na parte que lhes toca, uma *correspondência* ou *congruência* entre o tipo objectivo e o tipo subjectivo de ilícito (79). E todavia, também estes elementos cumprem a função de *individualizar uma espécie de delito*, de tal forma que, quando eles faltam, o tipo de ilícito daquela espécie de delito não se encontra verificado: a subtracção de coisa móvel alheia não integra o tipo de ilícito do crime de furto se ela não for

(78) Minuciosamente, sobre as questões neste parágrafo referidas, ROXIN I, § 12, n.ºs 83 e ss. e 80 e ss.

(79) Acentuam particularmente este aspecto das coisas, STRATENWERTH / KUHLEN, § 8, n.º 131.

levada a cabo (especial elemento subjectivo do tipo) *com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outra pessoa* (art. 203.º).

§ 56 A questão mais delicada suscitada por estes especiais elementos subjectivos (intenções, motivos, pulsões afectivas, elementos da atitude interna) reside no facto de tais elementos, pela sua própria natureza, não serem quase nunca recondutíveis a um qualquer acontecimento *exterior* mas, pelo contrário, se analisarem em dados e relações puramente ou predominantemente *internos*; sendo por isso muitas vezes difícil afirmar **se um concreto elemento respeita ainda ao tipo de ilícito ou antes ao tipo de culpa**. O critério deve ser, em tese, aquele que decorre do que acabou de ser dito: o elemento questionado pertence ao tipo de ilícito se ele serve ainda a definição de uma certa espécie de delito e se refere, por esta via, ao bem jurídico protegido, ou se visa ainda caracterizar o objecto da acção, a forma da sua lesão ou uma qualquer tendência relevante para o ilícito ([80]). Por isso uma sua exposição esgotante só poderia ter lugar em um tratamento específico da PE.

1. Intenções

§ 57 Segundo a sua estrutura material são as "intenções" os especiais elementos subjectivos que mais próximos se encontram do dolo do tipo. No entanto, como vimos (supra, § 35), a *intenção* pode constituir apenas uma das formas que assume o elemento volitivo do dolo, a forma que chamámos do *dolo intencional* ou *dolo directo de primeiro grau*. Em casos destes a "intenção" não assume evidentemente nenhuma autonomia como *especial* elemento do tipo subjectivo de ilícito: ela pertence integralmente ao (e esgota-se no) dolo do tipo. Noutros casos, porém, o tipo de ilícito é construído de tal forma que uma certa intenção surge como uma exigência subjectiva que *concorre* com o dolo do tipo ou a ele se *adiciona* e dele se *autonomiza*. Isso sucede, como acima se sublinhou, sempre que a intenção tipicamente requerida tem por objecto uma factualidade que não pertence ao tipo objectivo de ilícito.

§ 58 É o caso por excelência dos doutrinalmente chamados **crimes de intenção** ou **de resultado cortado**, nos quais o tipo legal exige, para além

([80]) Assim, ROXIN I, § 11, n.º 70 e ss.

do dolo do tipo, a intenção de produção de um resultado que todavia não faz parte do tipo de ilícito. Assim, p. ex., o art. 262.º-1 requer, para além do dolo do tipo da contrafacção de moeda, que esta seja levada a cabo *com intenção de a pôr em circulação*, mas não que esta intenção venha efectivamente a concretizar-se num resultado típico; e de modo inteiramente análogo se passam as coisas com o art. 262.º-2 ([81]). Do mesmo modo o art. 88.º da L 15/2001, de 5-6 ("Frustração de créditos"), é tipicamente construído como um crime *patrimonial*, mas a que tem de acrescer a *intenção* de "frustrar (...) o crédito tributário". É ainda o caso de múltiplos tipos que exigem, a par do dolo do tipo, uma especial intenção de causar *prejuízo* a outra pessoa ou ao Estado, ou de obter para si ou para outra pessoa *benefício ilegítimo* (*v. g.*, art. 256.º — falsificação de documentos ([82])), ou *enriquecimento ilegítimo* (art. 217.º e ss. — burla). E é, como começámos por evidenciar, o caso da intenção de *apropriação* no crime de furto (art. 203.º), que não tem de (nem deve) confundir-se com o dolo da subtracção.

§ 59 Muito discutido é entre nós, neste enquadramento, o caso do crime de **fraude fiscal** (art. 103.º da L 15/2001, de 5-6). Tratar-se-á aí de mais uma hipótese de *crime de resultado cortado* se ele for tipicamente concebido como um **crime de falsidade**, mas a que tem de acrescer a *intenção* de produzir um resultado lesivo sobre o património fiscal, o qual não tem porém de verificar-se e não integra por isso a factualidade típica do crime ([83]). Já não assim, porém, se o crime for tipicamente concebido como um crime contra o património fiscal, caso em que ficará próxima a sua consideração como um *crime de aptidão* ([84]). Querem outros ainda ver neste crime um **crime de perigo concreto** ([85]). Mas esta posição parece-nos reverter de novo à confusão entre resultado, como efeito espácio-temporalmente cindido da acção, e perigo para o bem jurídico (supra, 11.º Cap., § 37 e ss.).

([81]) Isto se afirma independentemente de saber se estes preceitos impõem uma extensão teleológica abrangendo as hipóteses de passagem e de colocação em circulação da moeda contrafeita ou aumentada no seu valor facial: afirmativamente, COSTA, A. M. Almeida, *Comentário Conimbricense*, II, art. 262.º, § 5 e ss.

([82]) Cf. MONIZ, Helena, *O Crime de Falsificação de Documentos*, 1993, p. 37 e ss.

([83]) Nestes termos, DIAS, Figueiredo / ANDRADE, Costa, O crime de fraude fiscal no novo direito penal tributário português, *RPCC 6*, 1966, p. 87 e s., e, de novo e por último, ANDRADE, Costa, A fraude fiscal — Dez anos depois, ainda um "crime de resultado cortado"?, *RLJ 135*, 2006, p. 326.

([84]) Assim, SOUSA, Susana Aires de, *Os Crimes Fiscais: Análise Dogmática e Reflexão sobre a Legitimidade do Discurso Criminalizador*, 2006, p. 71 e ss. Criticamente, ANDRADE, Costa, nota 83, p. 339 e ss.

([85]) DIAS, Silva, Os crimes de fraude fiscal e de abuso de confiança fiscal. Alguns aspectos dogmáticos e político-criminais, *RCTF 394*, 1999, p. 53 e ss. Criticamente, ANDRADE, Costa, nota 83, p. 328 e ss.

2. Outros elementos subjectivos especiais do tipo

§ 60 A doutrina costuma citar, ao lado das intenções, os **motivos**, os **impulsos afectivos** e as **características da atitude interna** como outras categorias integrantes de especiais elementos subjectivos do tipo. Não é impossível na verdade — e só um estudo exaustivo da PE, repetimos, o poderia determinar — que, num caso ou noutro, tais realidades possam ser exigidas como co-fundamentadoras da ilicitude típica subjectiva. Urge, em todo o caso, salientar neste contexto duas notas.

§ 61 A primeira — e para nós mais importante — é a de que não raras vezes, se não mesmo em via de princípio, tais elementos, e de forma especial as características da atitude interior, são utilizados pela lei não para fundamentar (ou agravar) a ilicitude da acção, não para caracterizar a "espécie de delito", mas a censurabilidade (ou o grau de censurabilidade) da actuação do agente: nesta medida eles devem ser imputados ao **tipo de culpa**, antes que ao tipo subjectivo de ilícito. É isso que sucede, p. ex., com os *motivos* (*v. g.*, "motivo torpe ou fútil", "ódio racial, religioso ou político"), os *impulsos afectivos* ("pelo prazer de matar ou de causar sofrimento, para excitação ou para satisfação do instinto sexual") e as *características da atitude interior* ("acto de crueldade", "por avidez", "com frieza de ânimo") constantes do tipo legal do crime de homicídio qualificado e todos eles integrantes, de resto, da cláusula de culpa agravada constante do art. 132.º-1 (86).

§ 62 A segunda é a de que, nos casos em que tais elementos devam ser imputados ao tipo de ilícito, tornar-se-á as mais das vezes tarefa extremamente difícil e pouco compensadora determinar **como eles se distinguem das intenções e como se diferenciam entre si**. No caso, p. ex., em que um *motivo* se torne determinante e actuante ele pode confundir-se com o *fim* da acção; na medida em que ele conduz e orienta a acção não será fácil distingui-lo de uma *intenção*; no caso em que uma *característica da atitude interna* seja cindida da atitude interna global pela qual o agente tem

(86) Posição extremamente controvertida entre nós: cf., para os diferentes pareceres doutrinais e jurisprudenciais, SERRA, Teresa, *Homicídio Qualificado. Tipo de Culpa e Medida da Pena*, 1990, *passim*; DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 132.º, § 2 e ss.; e, por último, NEVES, Curado, Indícios de culpa ou tipo de ilícito? — A difícil relação entre o n.º 1 e o n.º 2 do art. 132.º do CP, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 721.

de responder a título de culpa, ela torna-se tão vaga que mal servirá a concretização de um sentido de ilicitude que contribua para individualizar a espécie de delito, como é função de todo o tipo de ilícito. Que tudo isto pode assumir o efeito indesejável de esbater os limites entre as categorias da ilicitude e da culpa — absolutamente indispensáveis à justa e correcta avaliação de qualquer caso penal — é coisa que não tem deixado de ser reconhecida pela generalidade da doutrina ([87]); sem prejuízo de à delimitação possível não se querer renunciar completamente, sobretudo em vista dos efeitos normativo-práticos que a uma correcta distinção entre tipo de ilícito e tipo de culpa devem caber ([88]).

([87]) Cf. SCHMIDHÄUSER, *Gesinnungsmerkmale im Strafrecht*, 1958; STRATENWERTH, Zur Funktion strafrechtlicher Gesinnungsmerkmale, *Weber-FS*, 1963, p. 171.

([88]) Assim, ZIELINSKI, *Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff*, 1973, p. 39 e s.; cf., também, a exposição de ROXIN I, § 10, n.º 70 e ss.

SECÇÃO II

OS TIPOS JUSTIFICADORES (CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO OU DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE)

14.º CAPÍTULO

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

I. Especificidades dos tipos justificadores face aos tipos incriminadores relativamente ao problema da ilicitude

1. Complementaridade funcional e diversidade estrutural. Consequências

§ 1 Já se discutiu a forma como os tipos incriminadores e os tipos justificadores se relacionam e se comportam mutuamente, de um ponto de vista funcional, face ao problema da ilicitude criminal (supra, 10.º Cap., § 50 e ss.). Aí se procurou mostrar como uns e outros se complementam (antes que substancialmente se opõem) na determinação da ilicitude de uma concreta acção; como, por outras palavras, entre eles se não estabelece tanto uma relação de regra / excepção, ou de afirmação / negação, quanto uma **relação de complementaridade funcional** na valoração de uma *concreta* acção como lícita / ilícita (1). Sem prejuízo, todavia, de esta complementaridade de funções ser realizada por duas vias diferentes: os tipos incriminadores constituem uma via provisória de **fundamentação da ili-**

---

(1) Em termos concordantes, CARVALHO, Taipa de, *A Legítima Defesa*, 1995, p. 148 e ss.; e, na conclusão, FARIA, Paula Ribeiro de, *A Adequação Social da Conduta no Direito Penal ou o Valor dos Sentidos Sociais na Interpretação da Lei Penal*, 2003, p. 285 e ss. e *passim*; contra, PALMA, Fernanda, *A Justificação por Legítima Defesa como Problema de Delimitação de Direitos*, 1990, p. 704 e ss.

citude, os tipos justificadores uma via definitiva de **exclusão da ilicitude** *prima facie* indiciada pela subsunção da acção concreta a um tipo incriminador. Do ponto de vista atrás evidenciado nada haverá a objectar a esta formulação, desde que se não perca a clara e essencial consciência de que o tipo incriminador não é um primeiro degrau valorativo do facto penal independente da ilicitude, mas é já o portador de um sentido de ilicitude que o precede e ilumina.

§ 2 Se assim é de um ponto de vista funcional, tal não significa porém que tipos incriminadores e justificadores se não distingam em perspectiva **estrutural**; e que essa distinção não determine — como, na verdade, determina — profundas diferenças no regime jurídico-penal que a uns e a outros cabe. Assim, dissemos também, desde logo aos tipos incriminadores cabe a revelação, tão determinada quanto possível, do(s) *bem(ns) jurídico(s)* que cada um intenta proteger, possuindo nesta acepção uma referência **concreta** e **individualizadora**; diversamente, os tipos justificadores ou causas de justificação são estruturalmente, por sua natureza, **gerais** e **abstractos**, no sentido de que não são em princípio referidos a um bem jurídico determinado, antes valem para uma generalidade de situações independentes da concreta conformação do tipo incriminador em análise.

§ 3 Por outro lado, a aludida forma diferenciada como os tipos incriminadores e os justificadores actuam relativamente à mostração da ilicitude de uma **concreta acção** — uns visando fundamentar a ilicitude, outros visando excluí-la — conduz à conclusão verdadeiramente primacial (já, de resto, supra aludida a propósito do princípio da legalidade: 8.º Cap., § 12) de que a causa justificativa, ao contrário do que constitucional e legalmente sucede com o tipo incriminador, não está sujeita em princípio à máxima *nullum crimen sine lege*, nem às suas consequências. Sob pena, de outro modo, de se estar a fazer funcionar aquele princípio contra a sua razão de ser teleológica, político-criminal, constitucional e dogmática, a saber, de constituir uma *garantia* contra intervenções arbitrárias do poder punitivo do Estado e, por conseguinte, uma trave mestra de todo o sistema jurídico-constitucional e legal de garantia dos direitos e liberdades do cidadão. Destarte, nem as concretas causas de justificação precisam de ser certas e determinadas como se exige dos tipos incriminadores; nem elas estão sujeitas em pincípio à proibição de analogia; nem se está impedido de (eventualmente) fazer valer causas supralegais de exclusão da ilicitude; nem relativamente a elas vale o princípio da irretroactividade da lei penal.

§ 4 A doutrina tem no entanto vindo em data recente a discutir a questão de saber se também as causas de justificação devem submeter-se à **proibição da analogia in malam partem**, sob a forma seja de redução directa do alcance da norma justificante (*v. g.*, não aplicando a justificação por legítima defesa a bens supra-individuais ou colectivos), seja da introdução de pressupostos não escritos (*v. g.*, exigindo uma qualquer proporcionalidade entre o bem defendido e o bem sacrificado pela legítima defesa). E, mesmo no que respeita à criação por analogia de uma causa de justificação — que se diria funcionar sempre **in bonam partem** —, não deixa de se chamar a atenção para que, se uma tal criação joga em favor do agente, "ela desencadeia ao mesmo tempo como efeito necessário do *dever de suportar*, um encurtamento da liberdade da pessoa atingida" (2).

§ 5 Face ao disposto no art. 1.º-3 — e também no art. 29.º-1 da CRP — é pelo menos duvidoso que possa concluir-se pela inconstitucionalidade de um qualquer **encurtamento** para o agente, operada por força do processo hermenêutico ou aplicativo, da área de actuação de um tipo justificador em homenagem ao teor literal das palavras que o compõem (3). Não que consideremos decisiva a invocação do princípio da unidade da ordem jurídica, ligado à circunstância de as causas justificativas provirem de todos os ramos do ordenamento jurídico (4). Mas, se é exacto que também as causas justificativas se apresentam funcionalmente como *tipos* justificadores ou contra-*tipos*, a verdade é que a sua evidenciada diversidade estrutural face aos tipos incriminadores (5), a legitimidade (e inevitabilidade) de elas serem formuladas com apelo a conceitos extremadamente normativos, abertos ou mesmo indeterminados e a cláusulas ou formas gerais de valor, deve conferir à interpretação limites muito mais latos do que os admissíveis face aos tipos incriminadores. Colocando as coisas em termos metodológicos tradicionais, dir-se-á que a **interpretação teleológica**, restritiva ou extensiva, e a consequente aplicação da causa justifi-

---

(2) Assim, entre nós — com ampla indicação bibliográfica —, ANDRADE, Costa, O princípio constitucional *"nullum crimen sine lege"* e a analogia no campo das causas de justificação, *RLJ 134*, 2001, pp. 72 e ss., 130, 136. Cf., também, já, supra, 8.º Cap., § 30.

(3) Na conclusão, pela ainda larga maioria da doutrina germânica, ROXIN I, § 15, n.º 56 e ss.

(4) Assim, todavia, ROXIN I, § 5, n.º 42. Cf. infra, § 7 e ss.

(5) Põe este aspecto das coisas em evidência, KREY, *Studien zum Gesetzesvorbehalt im Strafrecht*, 1977, p. 234.

cativa como um todo, ou de seus singulares elementos constitutivos, é insusceptível de violar o princípio da legalidade porque releva ainda da "interpretação" permitida e não da "analogia" legal e constitucionalmente proibida. Essencial é sim, sempre, que a aplicação da causa justificativa seja feita em consideração da sua correcta caracterização teleológica específica ou — para utilizar palavras de Costa Andrade — a sua "racionalidade axiológica-teleológica" (6).

§ 6 Se a interpretação ou mesmo o recurso à analogia determinarem não um encurtamento, mas um **alargamento**, para o agente, da área de justificação, insistimos em que a sua proibição em nome do princípio *nullum crimen sine lege* violaria a mais lídima razão de ser das causas de justificação. Decerto que uma tal aplicação pode ter efeitos perversos de encurtamento da liberdade de terceiros por força do dever de suportar a acção justificada. O que não constituirá novidade ou coisa estranha, uma vez que (como se dirá infra, § 13) a causa de justificação intervém por princípio em situações de *conflito*, com o propósito de o superar. Sendo por isso compreensível que, em situações tais, se tente até ao limite possível a *concordância prática* entre o efeito justificador e o dever de suportá-lo de terceiros, nomeadamente de terceiros não implicados. Uma vez mais, porém, esta concordância prática não deve afectar a aplicação da causa justificativa segundo o seu sentido teleológico-funcional; e, de toda a maneira, não parece que tenha a ver com o princípio *nullum crimen sine lege*.

2. Causas de justificação e princípio da unidade da ordem jurídica

§ 7 As causas de justificação não têm de possuir carácter especificamente penal, antes podem provir da **totalidade da ordem jurídica** e constarem, por conseguinte, de um qualquer ramo de direito. Esta verificação (expressamente traduzida no art. 31.º, subordinado à epígrafe "exclusão da ilicitude" e segundo o qual "o facto não é punível quando a sua ilicitude for excluída *pela ordem jurídica considerada na sua totalidade*") é compreensível e, ao menos numa larga medida, indiscutível: se uma acção é considerada lícita (*sc.*, conforme ao "direito") pelo direito civil, administrativo ou por qualquer outro, essa licitude — ou ausência de ilicitude (cf. infra, § 34 e ss.) — tem de impor-se a nível do direito penal, pelo

(6) ANDRADE, Costa, nota 2, p. 133.

menos no sentido de que ela não pode constituir um ilícito penal. Determinar, porém, a razão *jurídica* por que assim se passam as coisas contende com uma das mais complexas e hoje mais discutidas questões da dogmática penal: a da unidade da ilicitude *versus* a existência de uma *ilicitude penal específica*.

§ 8 A favor da ideia de que uma acção lícita face a um qualquer ordenamento jurídico não pode constituir um ilícito jurídico-penal se invoca frequentemente, com carácter apodíctico e sem mais problematização, o **princípio da unidade da ordem jurídica**. Como quer que este princípio deva ser jurídico-filosoficamente concebido e justificado (7), a doutrina ainda hoje dominante retira dele a ideia da **unidade da ilicitude** (8): uma vez qualificada como ilícita uma acção por um qualquer ramo de direito, ela é ilícita face à totalidade da ordem jurídica; e, inversamente, se ela é lícita face a um qualquer ramo de direito, é-o face à totalidade da ordem jurídica. No mais que os diferentes ramos de direito podem divergir é numa diferente regulamentação das consequências jurídicas, não numa diversa valoração do *Tatbestand* como respeitador ou violador da ordem jurídica como um todo (9). Este seria — se assim nos podemos exprimir — o conteúdo *positivo* do aludido princípio da unidade da ordem jurídica. Não parece, porém, que as coisas tenham de (ou sequer devam) ser assim entendidas, pelo menos no que respeita ao problema jurídico-penal aqui em análise.

§ 9 Cremos desde logo inaceitável a concepção metodológica da norma jurídica que está na base deste entendimento: o ilícito não é uma "coisa em si", mas algo que parcial mas decisivamente se determina já a partir da consequência, no caso da norma penal, a partir da especificidade

---

(7) Importantes a este respeito, embora em perspectivas e com pontos de vista diferentes, ENGISCH, *Die Einheit der Rechtsordnung*, 1935, e, entre nós, NEVES, Castanheira, A unidade do sistema jurídico: o seu problema e o seu sentido, *Digesta*, II, 1995, p. 95.

(8) No essencial desta direcção, entre nós, CARVALHO, Taipa de, nota 1, p. 45 e ss., qualificando como "autismo" (p. 48) uma concepção diferenciada da questão da ilicitude, e ASCENSÃO, Oliveira, A teoria finalista e o ilícito civil, *Direito e Justiça. Homenagem Cavaleiro de Ferreira*, II, 1981/86, p. 83. Em direcção contrária, próxima da por nós defendida em texto, SILVA, Marques da, II, p. 78 e s.

(9) Nestes termos, ENGISCH, nota 7, p. 58. Está aqui presente, no fundo (como assinala CORREIA, Eduardo, II, p. 6[1]), a concepção bindinguiana da norma penal como um "comando absolutamente imotivado, em especial, não motivado através de uma ameaça penal": supra, 2.º Cap., § 10.

da pena e da medida de segurança criminais. Isto não significa, como de forma ainda hoje insuperada ensinou Eduardo Correia, a morte do princípio da unidade da ordem jurídica. Significa só que um tal princípio deve por um lado, ao menos para os efeitos aqui em consideração, "pensar-se **no plano puramente negativo**" e portanto no sentido de que (acompanhando nesta medida a já antiga formulação de Merkel ([10])) "sempre que uma conduta é, através de uma disposição do direito, imposta ou considerada como autorizada ou permitida, está excluída sem mais a possibilidade de, ao mesmo tempo e com base num preceito penal, ser tida como antijurídica e punível" ([11]). Ao que acresce, com importância decisiva, a especificidade do ilícito penal (supra, 6.º Cap., §§ 21 e ss. e 36 e ss.) derivada já da especificidade das sanções que a ele se ligam, determinantes, pela sua severidade, gravidade e lesão que implicam de direitos, liberdades e garantias fundamentais do condenado, do princípio político-criminal da intervenção mínima e de *ultima ratio*. E ainda, nas palavras de Costa Andrade, porque a *fragmentariedade* e a *descontinuidade* da tutela penal logo converte a ilicitude penal "numa expressão qualificada de ilicitude, extremando-a, pelo teor particularmente elevado das suas exigências, face às demais manifestações de ilicitude e antinormatividade" ([12]).

§ 10 Deve concluir-se por isso, quanto a este ponto, da maneira seguinte: não é correcto negar em bloco a possibilidade de se pensar a ilicitude penal como uma ilicitude *especificamente penal*, devendo, pelo contrário, acompanhar-se no essencial a tese central de Eduardo Correia e de Günther ([13]) da possibilidade de uma *específica exclusão ou justificação do ilícito penal* ([14]). Com mais rigor se dirá, de uma **ilicitude penal** qualificada. Sem prejuízo de pensarmos, como Roxin, que na aplicação desta possibilidade Günther vai longe demais ([15]) — como porventura igual-

([10]) MERKEL, *Die Lehre vom Verbrechen und Strafe*, 1912, p. 177.

([11]) CORREIA, Eduardo, II, n.º 1.

([12]) ANDRADE, Costa, *Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal*, 1992, p. 41.

([13]) GÜNTHER, *Strafrechtswidrigkeit und Strafrechtsausschluss*, 1983.

([14]) No mesmo sentido, ANDRADE, Costa, A "dignidade penal" e a "carência de tutela penal" como referência de uma doutrina teleológico-racional do crime, *RPCC 2*, 1992, p. 195 e ss.

([15]) ROXIN I, § 14, n.º 37. Contra a tese de Günther, CARVALHO, Taipa de, nota 1, p. 64[113] e ss., PALMA, Fernanda, nota 1, p. 709 e ss., e ROSA, Cortes, Die Funktion der Abgrenzung von Unrecht und Schuld im Strafrechtssystem, *Coimbra-Symposium Roxin*, p. 201 e ss.; e também FARIA, Paula Ribeiro de, nota 1, p. 301 e ss., a não ser que as causas de justificação especificamente penais devam aceitar-se como causas de exclusão do tipo.

mente Eduardo Correia — e que os casos de uma tal específica justificação serão raros ou, pelo menos, relativamente pouco frequentes. À partida, porém, nada há que impeça, no caso, um seu possível reconhecimento.

II. Tentativas de sistematização das causas de justificação

§ 11 Dada a já acima mencionada multiplicidade e diversidade das causas de justificação, desde há muito que a doutrina tenta alcançar uma via da sua sistematização racional, nomeadamente, com apelo ao que pode chamar-se os *princípios gerais da justificação* ([16]); por este modo ensaiando uma via que represente um ponto intermédio entre as quase infindas formas *concretas* que as causas de justificação assumem na totalidade da ordem jurídica e os quadros *abstractos* a que elas são em geral recondutíveis. Assim se alcançaram critérios como o subjacente à **teoria do fim**, segundo o qual estaria justificada toda a conduta que "possa representar-se como meio adequado (correcto) para alcançar um fim reconhecido pelo legislador como justificado (correcto) ([17])"; ou como o da teoria do **maior benefício que dano**, segundo a qual seria lícita toda a conduta "que, na sua tendência geral, represente para a comunidade estadual maiores benefícios (ideais, culturais) do que danos" ([18]).

§ 12 Trata-se, em qualquer das tentativas de sistematização *monista* que vêm de ser apresentadas, de fórmulas em si mesmas correctas mas absolutamente **vazias de conteúdo** e por isso imprestáveis para as tarefas da aplicação do direito: dificilmente se deparará com um só problema controvertido em matéria de causas justificativas que com apelo a elas possa ser resolvido ou encontrar um princípio de solução. É evidente, assim, que elas devem ser de todo desconsideradas; e verdade é que a doutrina mais moderna não tem insistido em tentativas deste tipo.

§ 13 Já o mesmo não pode repetir-se para uma tentativa de sistematização *dualista* como a que foi ensaiada por Mezger. Para ele, a sistematização deve fazer-se com apelo a um duplo ponto de vista: o do

---

([16]) Sobre este ponto, desenvolvidamente, PEÑA, Luzón, *Aspectos esenciales de la legítima defensa*, 1978, p. 85 e ss.

([17]) V. LISZT, *Strafrecht*[21], 1919, § 32, II, 2, 9.

([18]) SAUER, *Allgemeine Strafrechtslehre*, 1955, p. 56.

princípio do **interesse preponderante**, válido para a generalidade das causas justificativas; e o do princípio da **falta de interesse**, a que deveria ser reconduzida a causa justificativa do *consentimento* (19). Em perspectiva crítica dir-se-á, por um lado, que, na parte em que deva representar-se como causa justificativa, o consentimento se não reconduz tanto a uma "falta de interesse" quanto, ainda ele, a uma ponderação de interesses conflituantes e à consequente prevalência do interesse preponderante (infra, 17.º Cap., § 3). Dir-se-á, por outro lado, que a construção agora exposta também não serve para, perante uma qualquer situação concreta, dizer fundadamente *qual* o interesse preponderante no conflito; com o que de novo seríamos remetidos para uma fórmula vazia de conteúdo e imprestável para as tarefas da aplicação. E todavia, se também esta doutrina não serve como tentativa de *sistematização* das causas justificativas, ela tem o inarredável mérito de pôr em evidência o *princípio geral mais relevante* de toda a justificação. Esta opera sempre em uma **situação conflitual**, em que se debatem interesses contrapostos e em que importa determinar a qual deles deve ser concedida prevalência (20). Assim se compreende que, teleológica e funcionalmente, a justificação resulte da preponderância jurídica, em situação, de um interesse perante o outro ou, como costuma dizer-se numa fórmula mais curta, da **prevalência do interesse juridicamente preponderante**. Por isso a situação de justificação implica sempre um "sopeso jurídico" dos interesses conflituantes. O que, de resto, está em plena consonância com a função primariamente preventiva do direito penal, conducente à maior preservação possível dos bens jurídicos.

III. Elementos subjectivos dos tipos justificadores

§ 14 Desde há muito (numa causa justificativa como a da legítima defesa, por exemplo, praticamente desde sempre) se discute a questão — de certo modo paralela à dos elementos subjectivos da ilicitude a nível do tipo incriminador: supra, 13.º Cap., § 55 e ss. — de saber se o efeito justificativo de uma determinada situação deve ficar ou não na dependência de o agente ter actuado com **uma certa direcção da vontade**, em um certo **estado de ânimo** ou **de conhecimento**, por conseguinte, na

(19) MEZGER, p. 204 e ss.

(20) Acentua agora muito justamente esta circunstância, FARIA, Paula Ribeiro de, nota 1, pp. 420 e ss., 778.

dependência de certos elementos subjectivos. Se *sim* ou *não* e, em caso afirmativo, *que* elementos devem ser esses e se eles devem exigir-se, da mesma maneira, em *todas* as causas de justificação, é o que continua ainda hoje a ser questionado e questionável.

§ 15 **Exemplos**: Devem considerar-se justificados por legítima defesa os disparos mortais de *A* sobre *B*, para lhe herdar os bens, se se verificar que no momento *B* se aprestava a matar *A* em virtude de graves desentendimentos anteriores? Deve considerar-se justificado o aborto que *C* pratica em *D*, simplesmente porque esta o solicitou e *C* quer ganhar dinheiro, se vier a comprovar-se que, com esta intervenção, *C* salvou a vida da grávida ameaçada por doença não diagnosticada? Deve considerar-se justificada por consentimento a destruição por *E* de um quadro a óleo sem grande valor pertencente a *F*, se vier a provar-se que era intenção inabalável de *F* que *E* se desfizesse dele, por ele lhe trazer à lembrança circunstâncias desagradáveis da sua vida?

§ 16 Doutrinalmente afastada pode hoje dizer-se a ideia segundo a qual os tipos justificadores operariam **em pura objectividade**, independentemente, portanto, da exigência de quaisquer elementos subjectivos ([21]). Não só porque causas justificativas existem onde é o próprio texto legal a exigir elementos subjectivos. Não só porque, na doutrina tradicional, acompanhada pela jurisprudência dominante, nomeadamente a portuguesa, relativamente a uma causa justificativa como, por exemplo, a legítima defesa, desde há muito e durante muito tempo se requereu a existência no defendente de um particular estado de ânimo ou intenção: o *animus defendendi* (cf., em todo o caso, infra, 15.º Cap., § 43). E nem tanto por "paralelismo lógico do sistema" que conduziria a que, exigindo-se sempre para a fundamentação do tipo de ilícito incriminador a existência de elementos subjectivos, o mesmo deveria acontecer com o contraponto daqueles tipos, isto é, com os tipos justificadores. A verdadeira razão por que se impôs a exigência de elementos subjectivos da justificação reside em que os elementos objectivos do tipo justificador só apresentam virtualidade para excluir o *desvalor do resultado*, enquanto os elementos subjectivos ser-

([21]) Cf., todavia, entre nós, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, pp. 162 e 190, e, na mesma linha, SILVA, Marques da, II, pp. 101 e 132 e ss. Doutrina também ainda dominante na Itália, por força do art. 59, 1.º, do *Codice Penale*: cf. FIANDACA / MUSCO, *Diritto Penale. Parte Generale*, 1995, p. 222 e s. Admitindo diferenciações, CORREIA, Eduardo, II, pp. 13 e 15.

vem para caracterizar, por excelência, a **falta do desvalor da acção**. Quem desconhece a situação objectiva que conduz à justificação actua com um desvalor de acção em tudo equivalente, do lado subjectivo, ao autor de um facto típico relativamente ao qual se não verifica qualquer situação de justificação; por outras palavras, actua com vontade de realização do tipo objectivo de ilícito e o seu facto contém, de forma completa, o desvalor da acção. Por isso, elementos subjectivos da justificação devem considerar-se essenciais à exclusão da ilicitude.

§ 17 Do exposto resulta que **o conhecimento pelo agente dos elementos do tipo justificador** há-de constituir a exigência subjectiva **mínima** indispensável à exclusão da ilicitude, o *mínimo denominador comum* de *toda e qualquer* causa justificativa. Se, relativamente a certas causas de justificação devem fazer-se exigências subjectivas *adicionais*, requerendo nomeadamente que o agente tenha actuado com uma certa *direcção de vontade* ou com um certo *animus*, já não constitui questão que possa decidir-se em geral, mas unicamente a propósito de cada uma das singulares causas justificativas.

§ 18 Resta determinar como deve ser punido o agente que actua numa situação objectiva de justificação sem todavia a representar ou conhecer ([22]). À primeira vista a resposta parece ser fácil e inquestionável: tendo realizado por um lado um tipo incriminador (nos exs. supra referidos, *A* matou *B*, *C* fez abortar *D*, *E* destruiu um objecto de *F*) e, por outro lado, não podendo actuar qualquer tipo justificador por falta do exigido elemento subjectivo do conhecimento ou representação do tipo objectivo justificador, pareceria dever logo concluir-se que o agente **realizou integralmente o tipo de ilícito** respectivo e, na verdade, sob a forma **consumada**.

§ 19 Esta solução, porém, apesar de dever ter-se por dogmaticamente correcta ([23]), não parece ser a que melhor se adequa à mais justa composição dos interesses em conflito e, sobretudo, a que melhor solução oferece em termos de consequências prático-normativas. É verdade que na situação se verifica um desvalor da acção em tudo equivalente ao do facto

([22]) Um estudo da questão foi levado a cabo entre nós por ANDRADE, Costa, *Consentimento e Acordo em Direito Penal*, 1991, § 33. Cf., também, em perspectiva histórica e comparatista, VEIGA, Soares da, Sobre o consentimento desconhecido (Elementos de direito português antigo e de direito estrangeiro), *RPCC 1*, 1991, p. 327 e ss.

([23]) Como é acentuado por ANDRADE, Costa, nota 22, § 33, 4.2.

em que não intervém qualquer causa justificativa. Mas não é menos verdade que, ao contrário do facto em que não concorre uma causa justificativa, quando se verificam todos os pressupostos objectivos do tipo justificador **falta o desvalor do resultado**. Deste modo, a situação é **análoga à da tentativa**: também esta figura dogmática é justamente caracterizada pela persistência nela, ao mesmo nível do crime consumado, do desvalor da acção, faltando todavia o desvalor do resultado. Por isso deve advogar-se a aplicação, **por analogia** (aqui absolutamente permitida, porque *alarga*, não restringe, os limites da justificação), do regime da tentativa aos casos em que faltam os elementos subjectivos da justificação. Por analogia, repetimos, e não directamente ([24]), uma vez que nos casos aqui em consideração, contra o que sucede nos casos verdadeiros de tentativa, o tipo de ilícito foi integralmente realizado ([25]). Cumpre salientar, de resto, que o CP português — consagrando uma doutrina que a generalidade dos códigos estrangeiros, mesmo os mais modernos, não regula de forma explícita, mas se encontrava vertida já no § único do art. 40.º do ProjPG de Eduardo Correia — previu expressamente esta solução para o caso em que falta o elemento subjectivo relativamente à causa justificativa do *consentimento*: "se o consentimento não for conhecido do agente, este é punível com a pena aplicável à tentativa" (art. 38.º-4). Do que se trata, por isso, é somente de alargar esta solução a **todas** as causas justificativas ([26]).

§ 20 Pode suscitar-se — e tem efectivamente sido suscitada — a questão de saber se o art. 38.º-4 remete para a aplicação do **regime** da tentativa ou somente para a **pena** que à tentativa seria aplicada ([27]). Constituindo a aplicação da pena aplicável ao crime consumado, *especialmente atenuada* (art. 23.º-2), o traço mais relevante do regime da tentativa, dir-se-á exagerado sustentar que em qualquer caso de falta dos elementos

([24]) A favor da aplicação directa do regime da tentativa (da "tentativa impossível": cf. infra, 28.º Cap., § 45 e ss.), no entanto, ROXIN I, § 14, n.º 104 e ss., porque da tentativa faria parte a não verificação, não do resultado simplesmente *típico*, mas do resultado *ilícito* (*Unrechtserfolg*). Cf., também, CARVALHO, Taipa de, nota 1, p. 195 e ss.

([25]) Assim, já, DIAS, Figueiredo, Pressupostos da punição e causas que excluem a ilicitude e a culpa, *JDC 1983*, p. 61, e, agora, para o consentimento como causa de justificação, ANDRADE, Costa, nota 22, p. 668; e, na doutrina alemã, por outros, JESCHECK / WEIGEND, § 31, IV, 2, e (mais duvidosamente) STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 151 e ss.

([26]) No mesmo sentido, ANDRADE, Costa, nota 22, § 33, 4.1. e s., PALMA, Fernanda, A teoria do crime como teoria da decisão penal, *RPCC 9*, 1999, p. 583[54].

([27]) Apontando para o segundo termo da alternativa, ANDRADE, Costa, nota 22, § 33, 4.3.

subjectivos de uma causa de justificação o facto será sempre punido, embora com pena especialmente atenuada. Pois a tentativa só é punível, salvo disposição em contrário, nos termos do art. 23.º-1, "se ao crime consumado respectivo corresponder pena *superior a 3 anos de prisão*". Também esta disposição seria pois aplicável ao caso em apreço; pelo que, nos exemplos referidos supra, no § 15, *A* e *E* seriam punidos com as penas aplicáveis ao homicídio doloso (art. 131.º) e ao dano simples (art. 212.º-2), especialmente atenuadas (art. 73.º); mas *C* ficaria impune porque a tentativa do crime de aborto consentido (art. 140.º-2) não é punível, não havendo, nesta acepção, "pena aplicável à tentativa" (art. 38.º-4). E não se invocará contra isto, triunfantemente, qualquer **lacuna intolerável de punibilidade**: se o legislador entendeu não punir a tentativa de um certo crime, não se vê porque sejam maiores o desvalor de acção e o dolo em casos de comportamentos objectivamente justificados do que o são em caso de, por qualquer razão exterior, o resultado ter acabado por se não verificar.

§ 21 Ficou dito (supra, § 17) que o regime descrito se aplica a "todas" as causas justificativas. Mas há que fazer uma ressalva: ele não deve aplicar-se àquelas onde a justificação seja constituída somente pela **prossecução de um fim determinado**. Nestes casos, a ilicitude constitui-se logo que a conduta seja levada a cabo sem que esteja motivada pela prossecução do fim em causa. Faltando esta não pode sequer falar-se de um substrato objectivo que esteja na base da justificação. Assim, por exemplo, deve ser punido por *sequestro consumado* (art. 158.º) o polícia que detém um mero suspeito com outra intenção que não seja a de identificação (CRP, art. 29.º-3/*g*), e CPP, art. 250.º-6) ou quem detenha outrem em flagrante delito (art. 255.º do CPP) com finalidade diferentes das referidas nas alíneas do art. 254.º-1 do CPP.

§ 22 Rui Pereira pretende restringir a aplicação analógica do art. 38.º-4 aos casos em que "a situação objectiva justificante possa ser considerada valiosa ou, pelo menos, não desvaliosa, à luz do princípio da ponderação de interesses ou bens jurídicos conflituantes", o que, no seu entender, sucederá "em causas de justificação como o direito de necessidade (art. 34.º), o conflito de deveres (art. 36.º) e a acção directa (art. 336.º do CC)"; e defende a punição pelo crime consumado nas situações de "defesa objectiva" em que o interesse sacrificado seja superior ao salvaguardado, pelo facto de "apenas o conhecimento da agressão permitir apagar o desvalor do resultado" ([28]).

([28]) PEREIRA, Rui, Justificação do facto e erro em Direito Penal, *Estudos Cavaleiro de Ferreira*, 1995, p. 40.

A ser assim, porém, parece que ficaria por se compreender a teleologia que preside ao art. 38.º-4, já que precisamente em casos tais a punição deveria ter lugar a título de consumação.

IV. A aceitação errónea da verificação dos pressupostos de uma causa de justificação

§ 23 Objecto do nosso estudo será agora uma constelação que representa, em certo sentido, uma situação inversa da considerada no apartado anterior. Ali, deparámos com situações em que estavam dados os elementos justificadores objectivos, mas não os subjectivos. O problema que agora vamos considerar representa como que o seu contraponto: objectivamente não se dão no caso os elementos justificadores exigidos, mas (subjectivamente) o agente supõe falsamente que eles se verificam. Estamos então perante as situações que a doutrina chama de **justificação putativa** ou de **erro sobre os elementos do tipo justificador**.

§ 24 **Exemplos**.: *A* aponta uma pistola a *B* gritando "a bolsa ou a vida", mas *B* saca rapidamente de uma arma que traz no bolso e mata *A*; verifica-se depois que *A*, um "pândego" dotado de um estranho sentido de humor, só queria assustar *B* e que a arma que lhe apontou não passava de um brinquedo. O médico *C* interrompe a gravidez de *D*, a pedido desta, porque lhe fora diagnosticada uma doença que poria em perigo a sua vida se a gravidez continuasse; vem depois a comprovar-se que *D* não sofria de doença perigosa para a sua vida e que se tratara de um erro de diagnóstico. A empregada doméstica *E* inutiliza um objecto valioso do seu patrão *F*, supondo obedecer deste modo a uma indicação deste recebida; verifica-se depois que o objecto de que *F* queria desfazer-se não era aquele que foi efectivamente inutilizado, mas um outro quase sem valor.

§ 25 Neste enquadramento não cabem os casos em que o agente não incorre em qualquer erro relativo ao substrato material (aos pressupostos, *hoc sensu*) de uma causa de justificação, mas supõe falsamente a **existência** de uma causa de justificação que a ordem jurídica não reconhece ou erra sobre o **âmbito** ou os **limites** de uma causa de justificação efectivamente existente. Exemplos: *G* supõe que o pedido sério e instante de pessoa gravemente doente para pôr fim aos seus padecimentos atrozes, dando-lhe a morte, constitui uma causa justificativa do homicídio, quando na realidade o caso conforma um homicídio atenuado punível (art. 134.º). *H* furta a pasta de *I* e foge; no dia seguinte *I* encontra *H* com a sua pasta e agride-o para a recuperar, supondo que o seu facto é considerado legí-

tima defesa quando, na verdade, esta só permite repelir agressões actuais (art. 32.º). A convicção em que o agente actua nestes casos não constitui por conseguinte, como nos casos anteriores, um *erro de conhecimento* ou *erro intelectual*, mas sim verdadeiramente um *erro de valoração* que deve, por isso, ser tratado nos quadros do problema da falta de consciência do ilícito (infra, 20.º Cap., § 31 e ss.).

§ 26 A questão prático-normativa que, por excelência, aqui se suscita é a de saber se, em caso de errónea aceitação de um estado de coisas que, a existir, excluiria a ilicitude do facto, o agente deve ser punido a título de **dolo** ou só (se disso for caso) de **negligência**. A solução é apontada, de forma terminante, pelo art. 16.º-2: "o erro sobre uma estado de coisas que, a existir, excluiria a ilicitude do facto", **exclui o dolo**. Mas se a questão é decidida pela lei (correctamente) a nível da consequência jurídica, a verdade é que a sua origem reside em fundas controvérsias e dissidências que se suscitam a nível de diversos e importantes pontos da doutrina do facto punível ([29]).

§ 27 O ponto de partida da discussão reside na controvérsia entre a *teoria do dolo* e a *teoria da culpa*, relacionada em definitivo com questões relativas ao problema da falta de consciência do ilícito e, por isso, a questões de culpa. Segundo a **teoria do dolo** a consciência do ilícito é elemento do dolo, a par do conhecimento e vontade de realização do tipo objectivo de ilícito, pelo que o erro sobre pressupostos de uma causa de justificação não pode deixar de ser considerado como um erro *que exclui o dolo* e só pode ser punível (se o for) a título de *negligência* ([30]). Quanto à **teoria da culpa** haverá que distinguir entre a teoria da culpa *estrita* e a teoria da culpa *limitada*. Para a teoria da culpa **estrita** o dolo (e consequentemente a punição a esse título) perfaz-se com o conhecimento e vontade de realização do tipo objectivo de ilícito, pelo que o erro sobre os pressupostos de uma causa justificativa não pode excluir o dolo; o que pode eventual-

---

([29]) A exposição posterior fará inevitavelmente apelo a algumas noções e considerações que só poderão ser completamente interiorizadas depois de se conhecer a matéria relativa à culpa jurídico-penal em geral e, em particular, ao problema da falta de consciência do ilícito. Recomenda-se ao estudante, portanto, que reveja toda esta matéria depois de se ter tornado senhor do que se expõe infra, 20.º e 22.º Caps.

([30]) Nestes termos, CORREIA, Eduardo, I, n.º 91, VI, sublinhando que "o erro sobre os pressupostos de uma causa justificativa deve considerar-se erro sobre a factualidade típica".

mente assumir é significado para a culpa. Diferentemente, para a teoria da culpa **limitada** o dolo não integra a consciência do ilícito mas, em todo o caso, o erro sobre os pressupostos de uma causa de justificação ou conforma um *verdadeiro* erro sobre elementos do tipo objectivo de ilícito ("teoria dos elementos negativos do tipo": cf. supra, 10.º Cap., § 51) ou em todo o caso, constituindo um erro diferente do puro erro sobre a factualidade típica, deve ser-lhe *equiparado* quanto à consequência jurídica: a exclusão do dolo.

§ 28 **A solução na linha das teorias da culpa limitadas é a correcta** [31] e aquela que, como se disse, está vertida no art. 16.º-2. É a correcta, essencialmente, porque a situação de quem erra sobre os pressupostos de um tipo justificador é, em definitivo, materialmente **idêntica** à de quem erra sobre os elementos que pertencem a um tipo incriminador, na perspectiva da responsabilidade dos agentes: nenhum deles tem, por virtude do erro em que incorre, a sua consciência ética correctamente orientada para se pôr e resolver o problema da concreta ilicitude do facto; nem um nem o outro possuem o conhecimento indispensável (por força de um défice a nível da sua consciência psicológica ou intencional) a uma correcta avaliação da ilicitude. E já isto deve considerar-se suficiente para igualar uma e outra situação a nível da consequência jurídica, conduzindo à exclusão da punição a título de dolo.

§ 29 E todavia, a **teoria da culpa estrita** não deixa de ter razão, em pura perspectiva dogmática e sistémica, num ponto: no de que existe em todo o caso uma *diferença estrutural* entre uma e outra situação. Aquele que erra sobre a factualidade típica (ou sobre o decurso do acontecimento, ou mesmo sobre proibições legais, na medida em que estes erros sejam relevantes) actua **sem dolo do tipo**, enquanto quem aceita erroneamente elementos que, a existir, excluiriam a ilicitude, actua **com dolo do tipo**. Isto

---

[31] Cf., pormenorizadamente, o nosso *O Problema*, § 21, e ROSA, Cortes, nota 15, p. 188 (louvando a solução da nossa lei no que toca ao erro sobre os pressupostos de uma causa justificação, mas criticando-a asperamente no que toca ao erro sobre os pressupostos de uma causa de exclusão da culpa: infra, 22.º Cap., § 33). HRUSCHKA, Wieso ist eigentilch die "eingeschränkte Schuldtheorie" "eingeschränkt"? — Abschied von einem Meinungsstreit, *Roxin-FS*, p. 441, conclui (p. 455 e s.) que a querela entre teorias da culpa estrita e limitada está hoje ultrapassada, porque só a "limitada" pode (de acordo com uma correcta concepção da culpa jurídico-penal) considerar-se verdadeira teoria da *culpa*. O que no fundo, embora por razões não de todo coincidentes, corresponde ao nosso ponto de vista.

significa que, sendo embora a consequência jurídica num caso e no outro a mesma — a exclusão da punição do agente a título de dolo —, na hipótese de erro sobre elementos do tipo a exclusão do dolo dá-se logo a nível do *ilícito-típico*: o facto *não é tipicamente doloso*. Diferentemente, em caso de errónea aceitação dos pressupostos de uma causa justificativa o dolo do tipo persiste; o que sucede é que o dolo, pelas razões sumariamente apontadas acima, virá a ser negado em definitivo em sede de *culpa*: o tipo (incriminador) é dolosamente realizado pelo agente, mas este actua *sem culpa dolosa* e por isso não pode, em definitivo, ser punido a título de dolo ([32]).

§ 30 Não deve dizer-se que a construção que expusemos só tem interesse sistemático-construtivo e coincide integralmente, nas suas consequências prático-normativas, com as que são apontadas pelas "teorias da culpa limitada", hoje absolutamente dominantes, p. ex., nas doutrinas alemã e espanhola. Bem diferentemente, a nossa concepção revelará **diferenças sensíveis** logo que a lei penal atribua certos efeitos jurídicos à realização de um tipo de ilícito doloso: tais efeitos não poderão ser ligados, assim, àquele que erra sobre os elementos constitutivos do tipo incriminador (ou sobre o decurso do acontecimento, ou sobre proibições legais, quando estes erros sejam relevantes), mas já o podem ser àquele que aceita erroneamente os pressupostos materiais de uma situação que, a existir, excluiria a ilicitude do facto ([33]).

§ 31 Se o agente poderia ter evitado o erro através de uma **cuidadosa comprovação** da situação justificadora, então, tal como vimos suceder com o erro sobre os elementos constitutivos do tipo de ilícito, fica fundada uma sua eventual condenação pelo facto a título de **negligência** se o respectivo tipo de ilícito previr a punibilidade a este título (art. 16.º-3). E assim

---

([32]) Assim, já, DIAS, Figueiredo, *O Problema*, § 18, e, depois, Sobre o estado actual da doutrina do crime. Sobre a construção do tipo-de-culpa e os restantes pressupostos da punibilidade, *RPCC 2*, 1992, p. 7 e ss., e *DP II*, § 732; neste sentido, também, PEREIRA, Rui, nota 28, p. 34. Seguindo no essencial a nossa construção — afirmação do tipo de ilícito doloso, mas negação do tipo de culpa dolosa —, agora, uma parte significativa da doutrina brasileira: cf. BITENCOURT, Cezar, pp. 345 e 368, e GOMES, Flávio, *Erro de Tipo e Erro de Proibição*, [3]1996, p. 145. Não se trata pois, na nossa concepção, de uma *teoria da culpa reportada à consequência jurídica* (a designação é de ROXIN I, § 14, n.º 57 e s.) como a que foi defendida pela primeira vez por GALLAS, Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbrechen, *ZStW 67*, 1958, p. 45 e s., e segundo a qual o facto seria doloso, mas equiparado para efeito de punição ao delito negligente correspondente.

([33]) *V. g.*, para efeito de aplicação de uma medida de segurança a um inimputável: cf. a análise da nossa posição em ANTUNES, Maria João, *Medida de Segurança de Internamento e Facto de Inimputável em Razão de Anomalia Psíquica*, 2002, p. 331 e ss. Cf., também, PEREIRA, Rui, nota 28, p. 35.

sucede — ao contrário do que defende uma certa doutrina — mesmo no caso em que o erro verse sobre os pressupostos do direito de necessidade (cf. infra, 16.º Cap., § 33). Não falta quem queira ver aqui uma "fraqueza" da solução defendida (como da que é própria de qualquer "teoria da culpa limitada"), uma vez que quando o legislador elegeu os delitos que devem ser punidos a título de negligência não o terá feito em função de um eventual erro sobre os pressupostos de uma causa justificativa, mas da espécie de facto e do seu desvalor; o que pode conduzir, em caso de erro, a eventuais lacunas de punibilidade ([34]). Mas a solução preconizada só confirma a ideia — e é dela consequência — de que a exclusão do dolo em caso de erro sobre os pressupostos de uma causa de justificação opera a nível da culpa e não da ilicitude: esta circunstância justifica que em casos destes uma mais cabal realização do princípio da culpa conduza a que o **tipo de censura do erro** se volva em **tipo de censura do facto** ([35]).

V. Causas de justificação e imputação objectiva

§ 32 Muito recentemente, uma certa doutrina alemã começa a tentar a aplicação da doutrina da imputação objectiva — nomeadamente, no que respeita a teoria do **comportamento lícito alternativo** (supra, 12.º Cap., § 30 e ss.) — às causas de justificação. Em casos como os de, *v. g.*, a doutrina da legítima defesa permitir apenas que se dê um tiro de aviso contra o assaltante e o agente atirar para matar (infra, 15.º Cap., § 23); ou quando sobre o médico repousa um dever de esclarecimento prévio à intervenção e que ele não cumpre (infra, 17.º Cap., § 22); ou quando o agente tem um dever de obter uma autorização oficial antes de pôr a sua fábrica a laborar e não a obtém (infra, 18.º Cap., § 15 e ss.) — em todos estes casos o resultado não deveria ser imputado à conduta se numa consideração *ex post* viesse a comprovar-se que o tiro de aviso seria insuficiente e sempre seria necessário atirar a matar; ou que, uma vez devidamente esclarecido, o paciente teria dado a sua concordância; ou que se a autorização oficial tivesse sido pedida ela teria sido concedida ([36]).

([34]) Assim, STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 163.

([35]) Nestes termos, já, o nosso *O Problema*, § 21, I, 2 e 3 e IV.

([36]) Cf. PUPPE, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Irrtümer bei der Ausübung der Notwehr und für deren Folgen, *JZ*, 1989, p. 728 e s.; KUHLEN, Objektive Zurechnung bei Rechtfertigungsgründe, *Roxin-FS*, 2001, p. 331.

§ 33 Temos esta concepção por **exacta**, radicando ela em nós, de resto, a ideia fundamental de que todo o tipo é tipo de ilícito (supra, 10.º Cap., § 55) e de que o tipo e a ilicitude se comportam, na valoração final, como uma "unidade", no sentido e na medida em que **todos os critérios e princípios tipicamente relevantes são critérios de ilicitude, só a partir desta compreensíveis e determináveis** (supra, 11.º Cap., § 18 e s.). Por isso deve ter aqui lugar, como bem sustenta Roxin, não só a negação da ilicitude típica sempre que, *ex post*, se tenha obtido a **certeza** de que em caso de comportamento lícito alternativo a conduta seria justificada, como, para os casos de alta e fundada **probabilidade** de tal acontecer, deve intervir a negação da potenciação do risco (supra, 12.º Cap., § 28 e ss.) (37).

VI. O efeito das causas de justificação

§ 34 Uma acção relativamente à qual se verifique uma causa de justificação, em todas as suas exigências objectivas e subjectivas, constitui um **facto lícito**, contra o qual não é admissível legítima defesa — porquanto, como se verá, um dos pressupostos desta causa justificativa é o de que se verifique uma agressão *ilícita* (art. 32.º e infra, 15.º Cap., § 16 e ss.) — nem qualquer outro *direito de intervenção*, seja qual for a sua natureza, nomeadamente administrativa (38). Além deste efeito, deve assinalar-se que a licitude do facto do autor torna não punível o facto do cúmplice (acessoriedade dita "limitada", cf. infra, 32.º Cap., § 15); e ainda que, dado o princípio do ilícito-típico, ao agente que actua ao abrigo de uma causa de justificação não pode ser aplicada uma medida de segurança (cf. arts. 91.º-1, 100.º-1, 101.º-1) (39). Características que conferem relevo prático à distinção entre causas de justificação e causas de exclusão da culpa (40), pois, ao con-

(37) ROXIN I, § 14, n.º 115.

(38) O que assume importância prática fundamental sobretudo nos casos em que a própria lei penal consagra uma cláusula de *acessoriedade administrativa*, *v. g.*, em matéria de crime de poluição: cf. art. 278.º-3 e, sobre o ponto, infra, 18.º Cap., § 17 e ss.

(39) Apesar da sua posição particular quanto ao que seja o "facto do inimputável" para efeito de aplicação de uma medida de segurança de internamento (supra, 5.º Cap., § 9 e ss., e infra, 21.º Cap., § 42), ANTUNES, Maria João, nota 33, pp. 365 e ss., 433 e ss., 449 e ss., parece concordar com a asserção do texto.

(40) Cf. ROSA, Cortes, nota 15, p. 183 e ss., acentuando a necessidade de a autonomia entre ilicitude e culpa se fundar também em diferenças práticas de regime jurídico entre causas de justificação e causas de exclusão da culpa e analisando-as detidamente, em termos todavia não

trário do que sucede naquelas, pode reagir-se em legítima defesa contra quem actua a coberto de uma causa de exclusão da culpa; cada comparticipante é punido segundo a sua culpa, independentemente da punição ou do grau de culpa dos outros participantes (art. 29.º); e é possível a aplicação de uma medida de segurança a um inimputável que actuou, *v. g.*, numa situação de inexigibilidade ([41]).

§ 35 Por mais óbvia que possa parecer a dualidade que nas considerações anteriores vai pressuposta — o facto ou é *ilícito* ou, se o não é, é *lícito* —, não tem ela deixado de ser questionada ao longo da história dogmática das causas justificativas. Não tem faltado com efeito (embora se tenha tratado sempre de uma opinião minoritária ([42])) quem defenda que em caso de intervenção de uma causa justificativa, ou ao menos de certas delas, o facto, não sendo ilícito (nesse ponto todos estão de acordo), também não é verdadeiramente lícito, antes se situa em um **espaço livre de direito** (*Rechtsfreieraum*, na expressão consagrada da doutrina alemã). Isto quereria significar que, nestes casos, o direito não "aprova" positivamente a acção, antes se mantém "neutro" perante ela, guardando-se de uma sua valoração jurídico-objectiva e entregando essa tarefa, em exclusividade, à consciência ética do agente. Isto aconteceria, de forma muito visível, relativamente, *v. g.*, às chamadas "indicações" que justificam uma interrupção voluntária da gravidez, ou mesmo a factos como o "suicídio" que poderia, com boas razões, considerar-se como um facto que nem é proibido nem é aprovado pelo Direito.

§ 36 Por mais respeitável que seja toda esta controvérsia no plano de uma consideração metodológica, jurídico-filosófica ou mesmo lógico-teorética ([43]), a ela não deve ser reconhecido qualquer relevo quando se trate do problema da justificação jurídico-penal de uma conduta. Pode perfeitamente admitir-se que haja condutas estranhas à valoração jurídico-penal

---

coincidentes com os que se seguem em texto. Uma análise da divergência de novo em ANTUNES, Maria João, nota 33, p. 337 e ss.

([41]) Cf. DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 729 e s.

([42]) Expressivamente, entre outros, KAUFMANN, Arthur, Rechtsfreier Raum und selbstverantwortliche Entscheidung — Dargestellt am Problem des Schwangerschaftsabbruch, *Maurach-FS*, 1972, p. 327 e ss.

([43]) Cf., entre nós, NEVES, Castanheira, *Metodologia Jurídica. Problemas Fundamentais*, 1993, p. 207 e ss., e BRONZE, Pinto, *A Metodonomologia entre a Semelhança e a Diferença*, 1994, p. 505 e ss.[1160].

que se exprime na dicotomia lícito / ilícito, como o revelou uma célebre controvérsia entre Welzel e Engisch a propósito da distinção jurídica ou jurídico-penal entre "matar uma mosca" e "matar um homem em legítima defesa" (44). Mas seja embora assim, para efeitos do inteiro *sistema do direito penal* a *ilicitude jurídico-penal* só pode ser ou **afirmada** ou **negada**, devendo neste último caso considerar-se completamente indiferente, em termos de *consequência jurídica*, que o comportamento respectivo seja "aprovado" ou apenas "suportado" pelo Direito (45). Neste contexto só pode estar em questão — talvez possa dizer-se assim — uma "lógica deôntica" ou "bivalente", relativamente à qual vale completamente o "princípio do terceiro excluído".

(44) Sobre ela, o nosso *O Problema*, § 4, II, 2.

(45) No sentido desta conclusão, GALLAS, Strafbares Unterlassen im Fall einer Selbstötung, *JZ*, 1960, p. 654 e s.

15.º CAPÍTULO

A LEGÍTIMA DEFESA

I. Fundamento

§ 1 A legítima defesa surge historicamente como o tipo justificador mais sedimentado, mais consensual e até há não muito tempo praticamente inquestionado nos traços fundamentais do seu regime. Nos termos do art. 32.º, "constitui legítima defesa o facto praticado como meio necessário para repelir a agressão actual e ilícita de interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro". O fundamento justificador desta situação foi durante muito tempo pacificamente encontrado — e paradigmaticamente formulado por Berner, na esteira da posição de Hegel — na afirmação de que **o Direito não deve nunca ceder perante o ilícito** (1). Mas esta afirmação apodíctica e aparentemente incontestável foi-se tornando cada vez mais — e sobretudo no nosso tempo — questionável. Ela não pode ser aceite, efectivamente, no sentido supra-individual e supra-pessoal (*hoc sensu*, absoluto) de que, defendendo o Direito perante o ilícito, o agente, através do seu facto, está a defender não só os interesses agredidos mas, em último termo, o interesse da comunidade na integridade do direito objectivo (2). Nem tão-pouco na acepção de que a legítima defesa representaria uma transferência legal para os agentes privados do monopólio penal do Estado (3).

---

(1) BERNER, *Lehrbuch des Strafrechts*, [14]1886, p. 102. Sobre a intensa discussão acerca da ligação desta concepção a supostos hegelianos e kantianos v., por último, os interessantes estudos de PAWLIK, Die Notwehr nach Kant und Hegel, *ZStW 114*, 2002, p. 259, e HRUSCHKA, Die Notwehr im Zusammenhang von Kants Rechtslehre, *ZStW 115*, 2003, p. 201.

(2) Como foi sustentado por MERKEL, *Die Kollision rechtsmässiger Interessen*, 1895, p. 86, e ainda, agora, por SCHMIDHÄUSER, p. 193 e s.; e, na literatura portuguesa, por SANTOS, Beleza dos, *Obstáculos*, p. 15 e ss., e por CORREIA, Eduardo, II, n.º 8.

(3) Cf. HASSEMER, Die provozierte Provokation oder über die Zukunft des Notwehrrechts, *Bockelmann-FS*, 1979, p. 240.

Perante estas críticas bem se compreende que no momento actual o fundamento da figura em estudo seja visto como residindo, predominante ou exclusivamente, na **defesa necessária** — e consequente **preservação — do bem jurídico** (para mais *ilicitamente*) **agredido**, deste modo se considerando esta causa justificativa um instrumento (relativo) socialmente imprescindível de *prevenção* (4) e por aí, de novo, de *defesa da ordem jurídica* (5).

§ 2 Pode afirmar-se assim, acompanhando até certo ponto a doutrina hoje dominante, mesmo entre nós (6), que são **dois** os fundamentos da força justificativa da legítima defesa. Por um lado a *necessidade de defesa da ordem jurídica*, através da qual se justificará que se sacrifiquem bens jurídicos de valor superior aos postos em causa pela agressão; se justificará que, numa palavra, a legítima defesa não esteja limitada por uma ideia de proporcionalidade (7). Mas por outro lado também a *necessidade de protecção dos bens jurídicos* ameaçados pela agressão. Afirmando este duplo fundamento, porém, não desejamos ficar numa postura de "não só, mas também". Antes pensamos que os dois fundamentos se ligam e interpenetram através da ideia — muito justamente formulada por Stratenwerth — de que na legítima defesa se trata em último termo de uma **preservação do Direito na pessoa do agredido** (8). Mas também inversamente: não há fundamento para uma acção de legítima defesa quando, no caso, se verifique um interesse na preservação do Direito, mas inexista a necessidade de protecção de um bem jurídico (9). À defesa de um bem jurídico acresce sempre o propósito da preservação do Direito na esfera de liberdade pessoal do agredido, tanto mais quanto a ameaça resulta de um com-

---

(4) Para ROXIN I, § 15, n.º 2, a legítima defesa realiza uma salutar função de *intimidação*, mostrando aos potenciais agressores os riscos que poderão decorrer da sua acção; por seu lado, MONTEIRO, Conde, *A Legítima Defesa: Um Contributo para a sua Fundamentação*, 1994, p. 116 e ss., adscreve à legítima defesa uma finalidade de *prevenção geral positiva*, pelo reforço da confiança dos cidadãos no sistema jurídico.

(5) Assim, LUZÓN Peña, *Aspectos esenciales de la legítima defensa*, 1977, p. 79.

(6) Entre outros, SILVA, Marques da, II, p. 90, LUZÓN Peña, nota 5, p. 79, ROXIN I, § 15, n.º 1, JESCHECK / WEIGEND, § 32, I. Criticamente, CARVALHO, Taipa de, *A Legítima Defesa*, 1995, p. 412 e ss.

(7) Nesta linha BELEZA, Teresa, Legítima defesa e género feminino, *Revista Crítica de Ciências Sociais 31*, 1991, p. 149, VALDÁGUA, Conceição, Aspectos da legítima defesa no Código Penal e no Código Civil, *RFDL*, 1995, p. 254 e ss., e SILVA, Marques da, II, p. 98.

(8) STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 58 e s.

(9) Assim, ROXIN I, § 15, n.º 9.

portamento ilícito de outrem. Só assim ficando explicada — na medida possível — a razão por que a defesa é legítima ainda quando o interesse defendido seja de menor valor do que o interesse lesado pela defesa: é que, dir-se-á, ainda neste caso o interesse defendido é aquele que *prepondera* no conflito, porque ele preserva do mesmo passo o Direito na pessoa do agredido. Neste sentido se pode afirmar, com Kargl, que em matéria de fundamento da legítima defesa se não deve sufragar nem uma concepção supra-individual, nem individualista, mas "intersubjectiva" ([10]).

§ 3 Taipa de Carvalho defende que a razão por que deve rejeitar-se qualquer ideia de *proporcionalidade* no âmbito da legítima defesa reside na "injustiça que seria impor ao agredido, por um agressor doloso e censurável, uma limitação da sua liberdade de estar ou da defesa activa dos seus bens". É essa **injustiça** que parece, ao fim e ao cabo, constituir para este A. o próprio fundamento da legítima defesa, pois só aquela especial situação, a de uma agressão actual, ilícita, dolosa e censurável, e a injustiça de impor ao agredido um dever de suportar essa agressão fará cessar o dever de solidariedade do agredido para com o agressor e permitir que sobre ele recaia uma acção de legítima defesa, que não deverá ser limitada pelo princípio da proporcionalidade ([11]). Mas esta "*ratio* ético-juridicamente fundamentante da legítima defesa" (pela qual ela se poderá distinguir do estado de necessidade defensivo: infra, 16.º Cap., III) não parece proceder: quer pelo carácter "absoluto" que confere à justificação e se não adequa à "relatividade" do juízo de ilicitude, ligado à função de protecção subsidiária de bens jurídicos, para o qual a justificação contribui; quer porque parece esquecer que a legítima defesa é, também ela, uma situação de conflito de bens jurídica e socialmente valiosos, onde em definitivo há que decidir por uns e contra outros. Nos antípodas — deste ponto de vista — se encontra a tese de Maria Fernanda Palma que, rejeitando este modelo fundamentador da legítima defesa por conduzir a uma inaceitável legítima defesa ilimitada, perspectiva esta causa de justificação como um problema de *delimitação de direitos*, caracterizado por um exigência de **proporcionalidade**, a qual não deve permitir a lesão de bens qualitativamente superiores aos preservados uma vez que se verifique "a insuportabilidade da agressão a um núcleo de bens essenciais em que se manifesta a dignidade da pessoa humana e a igualdade na protecção dos sujeitos jurídicos" ([12]). Trata-se, em nosso modo de ver, de uma tese

([10]) KARGL, Der intersubjektive Begründung und Begrenzung der Notwehr, *ZStW 110*, 1998, p. 38 e ss.

([11]) CARVALHO, Taipa de, nota 6, pp. 420 e 431 e ss.

([12]) PALMA, Fernanda, *A Justificação por Legítima Defesa como Problema de Delimitação de Direitos*, 1990, pp. 13 e 253 e ss. Nesta linha, também, BRITO, Teresa de, *O Direito de Necessidade e a Legítima Defesa no Código Civil e no Código Penal*, 1994, p. 31 e ss., e Homicídio justificado em legítima defesa e em estado de necessidade, *Estudos Cunha Rodrigues*, I, pp. 185-208. Criticamente, CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 425 e ss., o qual, todavia, considera agora — cf. CARVALHO, Taipa de, II, § 679 e ss., esp. § 697 —, colocando-se nos antípodas da

que também não deve proceder, na medida em que, desvalorizando excessivamente a circunstância de que a agressão é sempre *ilícita*, furta ou minimiza a função *preventiva* do instituto, identifica praticamente a legítima defesa, quanto ao seu fundamento, com o estado de necessidade e, sob a alegação da violação da eminente dignidade da pessoa (que, no seu mais autêntico sentido, pertence tanto à pessoa do agressor como à do defendente e não serve por isso para dirimir um conflito inevitável), leva demasiado longe a "parificação" na situação da posição jurídica do agressor e do defendente.

§ 4 Precisamente face à evolução sofrida pela questão do fundamento é que hoje poucos temas existirão na dogmática jurídico-penal que se tenham tornado de soluções tão imprecisas e discutíveis como o da legítima defesa! Praticamente todos reconhecem que na velha máxima (que se pensava "absoluta" e por isso predominaria sempre sobre a questão da proporcionalidade dos bens em conflito) de que o Direito não deve *em caso algum* ceder perante o ilícito há que introduzir limitações que, no seu conjunto, correm sob a epígrafe, mais ou menos feliz e exacta, das **limitações ético-sociais da legítima defesa**; mas não pode dizer-se que se tenham consolidado opiniões comuns quanto à extensão e ao significado de cada uma daquelas limitações. No fundo, a razão de uma tal insegurança reside em que assim se questiona um problema tão fundamental, mas também hoje tão discutível na sua exacta conformação normativa, como o das relações das pessoas entre si e com a comunidade. Talvez possa afirmar-se com razoável correcção que a concepção da legítima defesa, tendo começado por assumir um carácter absoluto e trans-individual, se relativizou depois, assumindo uma natureza que se quer cada vez mais individual (ou pessoal). Mas questão é saber se nesta via se não foi (ou está a ir-se) *longe demais* ([13]) e a assistir-se àquilo que se pode chamar uma verdadeira "erosão da dogmática da legítima defesa", nomeadamente no que toca ao alargamento das exigências que deveriam ser feitas à "agressão" e, em compensação, ao estreitamento (por vezes radical) do catálogo dos "interesses juridicamente protegidos" que podem legitimamente ser defendidos. Como é saber se, perante esta situação, os esforços não devem correr, antes que no sentido da acentuação dos contrários — defesa da ordem

---

sua posição anterior, que a legítima defesa tem como pressuposto a proporcionalidade qualitativa entre os bens jurídicos objecto da agressão e da acção de defesa, por força do diploma legal (DL 457/99, de 5-11) que regula o recurso às armas de fogo pelas forças policiais.

([13]) Será o caso, entre nós — por razões e com incidências, em todo o caso, profundamente diferentes e muitas vezes opostas —, das citadas monografias de Fernanda Palma e de Taipa de Carvalho.

jurídica (ou da "justiça") *versus* defesa de interesses individuais —, no sentido do estabelecimento de uma renovada relação entre eles, cristalizada na ideia da defesa necessária do Direito na pessoa do agredido.

II. A situação de legítima defesa: requisitos

§ 5 Como postula o já referido art. 32.º, uma **situação de legítima defesa** supõe a existência de uma *agressão actual e ilícita de interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro*; devendo **a acção de legítima defesa** constituir o *meio necessário para repelir a agressão*. Começaremos o nosso estudo pela "situação" de legítima defesa, constituída através da agressão.

1. Agressão de interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro

1.1. O comportamento agressivo

§ 6 O conceito de **agressão** deve compreender-se como *ameaça derivada de um comportamento humano a um bem juridicamente protegido*. A restrição ao comportamento **humano** resulta do fundamento mesmo da legítima defesa: só seres humanos podem violar o direito. Ficam por isso excluídas do âmbito da legítima defesa as actuações de **animais** ([14]), bem como os perigos para bens jurídicos decorrentes de **coisas inanimadas**, por isso que, diferentemente do que sucedia no direito medieval ou mesmo anterior ao Iluminismo, animais e coisas inanimadas não constituem hoje objectos pensáveis dos comandos jurídicos. Naturalmente, não significa isto que cesse o direito à defesa contra ameaças deles provenientes, sempre podendo a resposta ser justificada pelo direito de necessidade (art. 34.º), nomeadamente, pelo direito de necessidade defensivo. A legítima defesa não deverá todavia ser negada quando exercida contra animais que estejam a ser usados por alguém como *instrumento* de agressão, já que nestes casos não deixa de se estar perante uma agressão humana, apenas com a particularidade de um animal ser utilizado como arma.

§ 7 Deve, por outro lado, exigir-se que a conduta humana seja **voluntária** (cf. supra, Cap. 11.º, § 37), não havendo lugar a uma situação de legí-

([14]) Assim, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 181; contra, CORREIA, Eduardo, II, n.º 9, I.

tima defesa quando a resposta seja exercida contra uma agressão cometida em estado de inconsciência ou em que a vontade esteja completamente ausente. Exigência esta que deriva não de uma concepção "ontológica" da agressão, estranha ao nosso pensamento ([15]), mas tão-só, de novo, da circunstância de que só "actua" aquele cujo comportamento for dominado por um mínimo de vontade e, por isso, não faz qualquer sentido considerar como agressão uma conduta não determinada por ela. Tudo isto ponderado, não parece no entanto — atento o que ficou dito supra, 11.º Cap., § 25 — que deva negar-se a possibilidade de agressões provenientes de **entes colectivos** ([16]).

§ 8 Como agressão deve considerar-se tanto o comportamento **activo**, como o comportamento **omissivo** referido à violação de um dever jurídico. A agressão cometida sob a forma de *omissão* é aquela que, neste contexto, mais dúvidas levanta. Não já quanto à possibilidade de agredir por omissão, que é hoje maioritariamente afirmada ([17]), mas quanto a saber se, além das omissões *impróprias* ou *impuras*, cabe legítima defesa contra omissões *próprias* ou *puras*. Assim, p. ex., aceita-se sem grande controvérsia poderem estar justificadas por legítima defesa as ameaças ou agressões sobre a mãe que se recusa a alimentar o seu filho recém-nascido (omissão impura: arts. 10.º, 131.º ou 144.º) para que esta alimente a criança. Mas deverá dizer-se o mesmo quanto à legitimidade de forçar um automobilista a transportar ao hospital a vítima de um acidente (omissão pura: art. 200.º)? Ainda neste caso a resposta parece dever ser positiva. Ao contrário do que defende parte da doutrina, que restringe o conceito de agressão e a consequente legitimidade da defesa às omissões impuras — com base na ideia de que nas omissões puras não há a colocação em perigo de bens jurídicos individuais ([18]) ou de que a omissão pura não é punível como lesão desses bens jurídicos ([19]) —, certo é que nestes casos nos deparamos com um omitir do qual resulta um perigo para bens jurídicos, individuais e supra-individuais, e relativamente ao qual, portanto, deve ser afirmada a possibilidade de legítima defesa ([20]).

([15]) Defendendo "uma certa vinculação ontológica do conceito de agressão", PALMA, Fernanda, nota 12, p. 37 e ss.

([16]) Contra, ROXIN I, § 15, n.º 7.

([17]) Contra, todavia, S / S / LENCKNER / PERRON, § 32, n.º 10.

([18]) LUZÓN PEÑA, nota 5, p. 160 e s.

([19]) ROXIN I, § 15, n.º 13.

([20]) CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 236 e ss., JESCHECK / WEIGEND, § 32, II, 1, *a)*, SAMSON, *SK*, § 32, n.º 5.

1.2. Os interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro

§ 9 O bem ameaçado deve ser **juridicamente — não necessariamente jurídico-penalmente! — protegido**. Por exemplo a vida, a integridade física, a liberdade, a autodeterminação sexual, a propriedade, a posse, o bom nome, o crédito, etc. constituem interesses juridicamente protegidos para efeito de legítima defesa. A grande questão, cada vez mais actual, reside em saber se apenas bens individuais ou também bens **supra-individuais** podem constituir objecto da agressão. A resposta afirmativa constituía orientação clássica, nomeadamente na doutrina e na jurisprudência portuguesas; orientação, de resto, coerente com a consideração de que fundamento *exclusivo* da legítima defesa era a afirmação sem reservas da superioridade do lícito sobre o ilícito. Hoje, porém, com a já referida tendência para uma cada vez mais acentuada individualização da legítima defesa, uma doutrina prestigiada resolve a questão no sentido da primeira alternativa e por vezes mesmo, dentro dela, de forma altamente restritiva ([21]). O art. 32.º pode sugerir que a agressão deve pôr em causa bens *pessoais*, ao referir "interesses (...) do agente ou de terceiro" e não também do Estado ou da comunidade; se bem que, de um ponto de vista formal, sempre pudesse retorquir-se que o Estado (e mesmo a Comunidade) surge como "terceiro" relativamente ao agressor. Nem há razão para distinguir o Estado das pessoas físicas e jurídicas quando estejam em causa bens jurídicos de fruição individual por ele tutelados (podendo assim, *v. g.*, defender-se legitimamente um furto de material de uma escola ou a danificação de um banco de um jardim público). E além destes casos, ainda uma outra coisa parece segura: a justificação da legítima defesa deve ter lugar relativamente a bens supra-individuais sempre que a agressão a estes ponha em sério perigo bens das pessoas (*v. g.*, será susceptível de justificação por legítima defesa a acção daquele que impede pela força um indivíduo completamente embriagado de se fazer à estrada com o seu auto-

([21]) CARVALHO, Taipa, nota 6, p. 480 e ss., que, no plano *de iure constituendo*, defende a restrição a um núcleo reduzido de bens jurídicos individuais; e PALMA, Fernanda, nota 12, p. 441 e ss., que se revela apologista de uma limitação da defesa aos "bens pessoais ou ainda patrimoniais, essenciais à manutenção e desenvolvimento da dignidade humana". Sobre o problema, também, DIAS, Silva, A estrutura dos direitos ao ambiente e à qualidade dos bens de consumo e sua repercussão na teoria do bem jurídico e na das causas de justificação, *Estudos Cavaleiro de Ferreira*, 1995, p. 206 e ss. Terminante, pela doutrina alemã maioritária, ROXIN I, § 15, n.º 36: "Bens jurídicos da comunidade não são susceptíveis de legítima defesa".

móvel). Nestes casos se poderá afirmar que o defendente, como membro da comunidade, é ele próprio "agredido", para por esta via se fundar a legitimidade da defesa.

§ 10 O restante poderá considerar-se duvidoso. Mas ainda aqui convém tomar a sério a ideia defendida (supra, 6.º Cap., § 67 e ss.) de que também os bens jurídicos supra-individuais, colectivos ou universais são autênticos bens jurídicos, merecedores de tutela penal ao mesmo nível, pelo menos, dos bens jurídicos individuais (a questão actualíssima da "luta" contra o terrorismo internacional oferece um exemplo paradigmático). **Não existe, por isso, razão de princípio para os excluir do catálogo dos interesses juridicamente protegidos para efeito de legítima defesa.** O que sucede é apenas que a mais acentuada "funcionalização" destes bens jurídicos pode conduzir a restringir a necessidade (que inclui a adequação: infra, § 22 e ss.) dos meios de defesa ou mesmo eventualmente, em casos excepcionais, a eliminar a necessidade da defesa (infra, § 28 e ss.).

2. A actualidade da agressão

§ 11 Só é admissível legítima defesa contra agressões actuais. A agressão será *actual* quando é *iminente*, *já se iniciou* ou *ainda persiste*. Problemática é a determinação dos critérios por meio dos quais se pode afirmar que uma agressão *já é actual* ou *ainda é actual*: "decisiva é a situação objectiva e não o que seja representado pelo agredido" ([22]).

2.1. O início da actualidade da agressão

§ 12 A agressão é **iminente** quando o bem jurídico se encontra já **imediatamente ameaçado**. Assim, p. ex., deve considerar-se coberto pela legítima defesa o disparo de *A* sobre *B* quando efectuado no momento em que *B* levou a mão ao bolso para sacar do revólver com o qual pretendia atirar sobre *A*. Mesmo que nesta situação não pudesse porventura falar-se ainda de tentativa, não deverá ser negado a *B* o direito de impedir por legítima defesa uma agressão que, embora ainda não iniciada, se deveria seguir imediatamente. Parte da doutrina ([23]) apela, é verdade, ao regime

([22]) JESCHECK / WEIGEND, § 32, II, *d)*.

([23]) Cf. CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 270, PALMA, Fernanda, nota 12, p. 304 e ss., JAKOBS, 12/23.

da *tentativa*, nomeadamente à definição de actos de execução do art. 22.º (infra, 28.º Cap., § 23 e ss.), para estabelecer o momento em que a agressão já é actual para efeitos de legítima defesa. Trata-se de uma solução que não nos parece a melhor, pois, para além de desta forma se excluir a actualidade de agressões porventura ainda não iniciadas, mas que são iminentes, se faz, de todo o modo, entrar na legítima defesa um regime cuja teleologia lhe é alheia e não é idóneo para resolver as situações em que a agressão se não dirige a bens jurídico-*penalmente* tutelados.

§ 13 Discutidas pela doutrina têm sido as situações em que, não obstante a agressão não ser ainda sequer iminente, **já se sabe antecipadamente, com certeza ou com um elevado grau de segurança, que ela vai ter lugar**: *v. g.*, o dono de uma estalagem ouve, ao jantar, três hóspedes combinarem entre si o assalto ao estabelecimento durante a noite ([24]). Haverá justificação por legítima defesa se o dono da estalagem coloca soníferos nas bebidas dos clientes? Para permitir a exclusão da ilicitude por legítima defesa neste tipo de casos alguns autores defendem a chamada teoria da *defesa mais eficaz* ([25]), segundo a qual a agressão seria já actual no momento em que se soubesse que ela viria a ter lugar se o adiamento da reacção para o momento em que ela fosse iminente tornasse a resposta impossível ou se ela só fosse possível mediante um grave endurecimento dos meios (dita por vezes *legítima defesa preventiva*). Trata-se, todavia, de uma proposta que não deve ser acolhida ([26]): por um lado, em termos dogmáticos, alarga em demasia o conceito de actualidade; por outro lado, em termos político-criminais, pode ter consequências extremamente nefastas, legitimando formas privadas de defesa em substituição da actuação das autoridades policiais competentes, a quem pertence em princípio intervir nestas situações. A legítima defesa deve, assim, ser negada nestes casos por não estarmos em presença de agressões actuais. Uma eventual exclusão da ilicitude das condutas referidas só poderá verificar-se através, porventura, do apelo ao direito de necessidade do art. 34.º (infra, IV), eventualmente, à figura do direito de necessidade defensivo, uma vez veri-

([24]) Caso construído por S / S / LENCKNER / PERRON, § 32, n.º 17.

([25]) SUPPERT, *Notwehr und "notwehrähnlichen Lage"*, 1973, p. 371 e ss., e SCHMIDHÄUSER, 9/94.

([26]) Assim, também, ROXIN, Von welchem Zeitpunkt an ist ein Angriff gegenwärtig und löst das Notwehrrecht aus?, *Tjong-GS*, 1985, p. 137 e ss., e CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 276 e ss.

ficadas determinadas condições, máxime, a impossibilidade ou ineficácia de uma intervenção policial.

§ 14 No contexto do início da actualidade da agressão coloca-se ainda — e desde há muito — o problema especial da **preparação antecipada da defesa**, nomeadamente através de aparelhos automáticos (*v. g.*, dispositivos que disparem por si mesmos quando houver uma intromissão na propriedade), relativamente a uma agressão *eventual*. A doutrina dominante reputa tal tipo de defesa como legítimo; mas este ponto de vista só pode ser aceite desde que se verifiquem os restantes pressupostos da legítima defesa, nomeadamente, o de que no momento da defesa a agressão seja actual, o da necessidade da defesa e, em especial, o de que a defesa esteja preparada para atingir apenas o agressor ([27]). Vistas assim as coisas pode dizer-se que esta hipótese não apresenta, no fim de contas, qualquer especialidade notável, ao menos em tema de actualidade da agressão.

2.2. O término da actualidade da agressão

§ 15 A defesa pode ter lugar até ao último momento em que a agressão **ainda persiste**. Também aqui nem sempre pode fazer-se coincidir esse momento com o da *consumação*, uma vez que são numerosos os crimes em que a agressão e o estado de antijuridicidade perduram para além da consumação típica ou "formal" (infra, 27.º Cap., § 11 e s.): *v. g.*, o crime de ofensas à integridade física (art. 143.º) consuma-se logo que *A* desfere o primeiro murro em *B*, mas nem por isso *B* está impedido de responder em legítima defesa contra os murros e pontapés seguintes (mas não já se *C* recebe de *D* uma bofetada e responde com outra, se não houver nenhuma razão para crer que a bofetada de *D* se insere num processo continuado de ofensa à integridade física de *C*); também p. ex. o crime de sequestro (art. 158.º) se consuma logo que *E* encerra *F* num certo local contra a sua vontade, mas este pode reagir em legítima defesa contra a privação da sua liberdade enquanto durar o cativeiro. Relevante para este efeito é **o momento até ao qual a defesa é susceptível de pôr fim à agressão**, pois só então fica afastado o perigo de que ela possa vir a revelar-se desnecessária para repelir aquela. Até esse último momento a agressão deve ser considerada como actual. É à luz deste critério que devem ser resolvidos os casos que mais dúvidas levantam neste ponto, os dos *crimes contra a propriedade*, nomeadamente o do crime de *furto*. Ex.: *G* dispara e fere gravemente *H*, para evitar que este fuja com as coisas que acabou de subtrair. Poder-se-á consi-

([27]) Assim, entre nós, CORREIA, Eduardo, II, p. 57 e s.

derar a agressão de *H* como ainda actual? A solução não deve ser prejudicada pela discussão e posição que se tome acerca do momento da consumação no crime de furto ([28]). O entendimento mais razoável é o de que está coberta por legítima defesa a resposta necessária para recuperar a coisa subtraída se a reacção tiver lugar logo após o momento da subtracção, enquanto o ladrão não tiver logrado a posse pacífica da coisa ([29]). Os factos praticados depois desse momento já não estarão cobertos pela legítima defesa, uma vez que a agressão deixou de ser actual, mas poderão estar justificados por acção directa (art. 336.º do CC) se estiverem preenchidos todos os requisitos desta causa de justificação (infra, 18.º Cap., § 21 e s.).

3. A ilicitude da agressão

§ 16 Pressuposto fundamental da situação de legítima defesa é o de que a agressão seja ilícita. Como vimos (cf. supra, § 1 e ss.), é esta nota de ilicitude que confere um cunho particular ao fundamento de legitimidade da defesa, permitindo distingui-la das outras causas de exclusão da ilicitude e, sobretudo, fazendo compreender que em legítima defesa se possam sacrificar interesses superiores aos ameaçados pela agressão. **A ilicitude da agressão afere-se à luz da totalidade da ordem jurídica, não tendo de ser especificamente penal** ([30]). Podem, por conseguinte, repelir-se em legítima defesa agressões violadoras não apenas do direito penal, mas também do direito civil, do direito de mera ordenação social, do direito constitucional, etc. ([31]), posto que os bens jurídicos em perigo sejam susceptíveis de defesa (supra, § 9 e s.) ([32]). Assim, p. ex., verificando-se os restantes

---

([28]) Sobre esta questão, que há longo tempo tem dividido doutrina e jurisprudência, COSTA, Faria, *Comentário Conimbricense*, II, 203.º, § 54 e s.

([29]) Nestes termos, CORREIA, Eduardo, II, n.º 9, III, CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 304, PALMA, Fernanda, nota 12, p. 334 e ss., JESCHECK / WEIGEND, § 32, II, *d*), e ROXIN I, § 15, n.º 27. Em termos próximos, mas não totalmente coincidentes, COSTA, Faria, *Comentário Conimbricense*, II, art. 203.º, § 65.

([30]) Assim, também, ROSA, Cortes, Die Funktion der Abgrenzung von Unrecht und Schuld im Strafrechtsystem, *Coimbra-Symposium Roxin*, p. 199. Discussão minuciosa da questão encontra-se em CARVALHO, Taipa de, nota 6, §§ 2-10, onde é analisada a principal bibliografia, portuguesa e estrangeira.

([31]) Contra, no entanto, GIMBERNAT Ordeig, Der Notstand: ein Rechtswidrigkeitsproblem, *Welzel-FS*, 1974, p. 495 (= *Estudios de Derecho Penal*, 1981, p. 155 e ss.), e *in*: Eser / Perron (orgs.), *Rechtfertigung und Entschuldigung*, III, 1991, p. 72 e s., e, na sua esteira, LUZÓN Peña, nota 5, p. 512 e ss.

([32]) Da defesa de "*quaisquer* interesses juridicamente protegidos" falava a versão original do nosso CP de 1982. A doutrina referida em texto é, de resto, praticamente indiscutida entre

requisitos, estarão justificados por legítima defesa os factos praticados por *A* para impedir que *B* leve o seu colar de pérolas a uma festa sem a sua autorização (furto de uso não punível penalmente — art. 208.º, *a contrario* — mas relevante para o direito civil); ou por *C* para pôr termo pela força às emissões de ruído de um bar que, funcionando para além do horário permitido e sem as condições de insonorização legalmente exigidas, o impedem de descansar durante a noite (violação de direitos de personalidade e de normas administrativas, eventualmente contra-ordenacionais). E todavia, uma restrição importa fazer a esta *unicidade* entre ilicitude geral e ilicitude da agressão para efeito de legítima defesa: a agressão não será ilícita para este efeito relativamente a interesses ("direitos relativos") para cuja "agressão" a lei prevê **procedimentos especiais**, como será o caso dos direitos de crédito e dos de natureza familiar. Não estarão por isso cobertas por legítima defesa, *v. g.*, as agressões ou ameaças tipicamente relevantes levadas a cabo pelo credor sobre o devedor para que este lhe pague; ou pelo marido sobre a mulher para impedir que ela abandone o lar conjugal (33).

§ 17 Não são, deste modo, ilícitas as agressões **justificadas**, não podendo contra elas ser exercida legítima defesa. A quem actua ao abrigo de uma causa de justificação é concedido um verdadeiro *direito de intervenção* na esfera de terceiros, que faz impender sobre estes um dever de suportar aquela conduta e impossibilita uma reacção em legítima defesa. Daqui decorre que, *v. g.*, não estarão justificadas por legítima defesa as agressões: do ladrão sobre aquele que pela força tenta impedi-lo de fugir com as suas coisas (34); de *A* sobre o médico *B* para impedir que este prossiga na realização de uma interrupção da gravidez legalmente permitida (art. 142.º); de *C* sobre *D* para impedir que este continue a agredir *E*, que todavia consentiu nessa agressão (art. 38.º). Está nestes casos claramente ausente a fundamentação da legítima defesa na exigência de prevalência do lícito perante o ilícito na pessoa do agredido.

§ 18 Questão controversa se tem revelado a da admissibilidade de legítima defesa contra **condutas perigosas levadas a cabo com a dili-**

---

nós: CORREIA, Eduardo, II, p. 38 e s., FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 180 e s., CARVALHO, Taipa de, nota 6, § 9.

(33) Na conclusão, também, CARVALHO, Taipa de, nota 6, pp. 237 e 394.

(34) Contra legítima defesa não vale legítima defesa: Ac. do STJ de 6-5-1992, *BMJ 417*, p. 582 e ss.

gência e o cuidado devidos, mas de onde resulta todavia uma lesão ou um risco iminente de lesão de bens jurídicos. Condutas em relação às quais, como vimos no âmbito da teoria da conexão do risco, a produção de um eventual resultado não pode ser imputada objectivamente ao seu autor por não ter sido ultrapassado o limite do risco juridicamente permitido. Atentas as razões que naquele ponto aduzimos (supra, 12.º Cap., §§ 20 e 24 e s.) para justificar a negação da imputação objectiva neste tipo de situações, deve em coerência negar-se também aqui a possibilidade de uma reacção em legítima defesa. Só uma visão extremadamente objectivista, que perspective a ilicitude em função do desvalor do resultado e privilegie o ponto de vista do agredido, pode explicar a possibilidade de uma reacção em legítima defesa contra este tipo de condutas. Uma tal concepção seria, uma vez mais, contraditória com a necessidade de afirmação do Direito na pessoa do agredido que dissemos fundamentar a legítima defesa; pois nestes casos não existe qualquer desvalor de acção — verifica-se, pelo contrário, que o agressor agiu de forma diligente e cuidadosa — e, por isso, qualquer necessidade de prevalência da ordem jurídica, que, pelo contrário, admite e tolera em termos gerais estas condutas perigosas realizadas dentro do marco do risco permitido. Negar o direito de legítima defesa não significa porém que aquele sobre quem recai a materialização de um risco derivado dessas actividades esteja obrigado a cruzar os braços e a suportar o dano: uma reacção de defesa pode eventualmente justificar-se através do direito de necessidade (eventualmente defensivo) e, como tal, limitado pelo princípio da proporcionalidade (infra, 16.º Cap., §§ 11 e ss., 27 e ss.) ([35]).

§ 19 Como referimos, a ilicitude da agressão não tem de ser especificamente penal. Quando porém a agressão tenha relevância penal deverá ser tida em conta a sua natureza dolosa ou negligente, em termos de só ser admitida a legítima defesa contra condutas dolosas (no sentido, evidentemente, do dolo do tipo ou dolo do facto)? A doutrina largamente maioritária defende que tanto as **agressões dolosas**, como **negligentes** podem dar lugar a uma resposta em legítima defesa ([36]). A nosso ver, apesar das vozes discordantes ([37]), com razão. Desde logo porque do art. 32.º não

([35]) Uma ampla discussão do problema em ROXIN I, § 15, n.º 15 e s.
([36]) CORREIA, Eduardo, II, p. 41, e PALMA, Fernanda, nota 12, p. 57 e ss.
([37]) LUZÓN Peña, nota 5, p. 173 e ss., e CARVALHO, Taipa de, nota 6, § 11.

resulta qualquer negação da possibilidade de reacções em legítima defesa contra condutas negligentes. Além de que tal restrição introduziria nesta matéria uma grande e mesmo insuportável margem de incerteza e insegurança, dado que em numerosas situações o agredido terá dificuldade em saber se a agressão é dolosa ou negligente. Nem parece, por fim, que este ponto de vista seja contraditório com a consideração do fundamento da legítima defesa como necessidade de manutenção de exigências de prevenção geral, pois que também às penas aplicadas aos crimes negligentes devem ser adscritas (e de forma prevalente!) finalidades de prevenção geral. Lembre-se só, por exemplo, os resultados catastróficos, do ponto de vista da prevenção, a que uma tal doutrina conduziria em matéria de agressões negligentes no trânsito rodoviário. Também relativamente a agressões negligentes, numa palavra, a legítima defesa cumpre de modo integral a sua função de prevalência do Direito face ao ilícito na pessoa do agredido.

§ 20 A situação de legítima defesa pressupõe a ilicitude da agressão, mas não a **culpa do agressor**. Podem ser, assim, repelidas em legítima defesa agressões em que o agente actue sem culpa, devido a inimputabilidade, à existência de uma causa de exclusão da culpa ou a um erro sobre a ilicitude não censurável. Exigir a culpa do agressor, ou entender de todo o modo a "agressão ilícita" a que se refere o art. 32.º como "agressão ilícita e culposa" constituiria uma restrição incompatível com a letra do art. 32.º, radicada em uma verdadeira interpretação *contra legem* ([38]). Exigência que, além do mais, acabaria por descaracterizar a própria distinção entre causas de justificação e causas de exclusão da culpa, cujo relevo prático assenta em grande medida na possibilidade de ser exercida legítima defesa contra condutas ilícitas levadas a cabo sem culpa, mas já não contra condutas justificadas (cf. supra, 14.º Cap., § 34). O que agressões de crianças, de doentes mentais ou, em geral, de agressores que actuem notoriamente sem culpa pode determinar é uma modificação dos limites da *necessidade* da acção de defesa (infra, § 30 e s.).

([38]) O que é reconhecido mesmo por quem, como CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 435 e ss., entende, *de jure condendo*, que a situação de legítima defesa deveria pressupor a culpa do agressor. Embora CARVALHO, Taipa de, II, § 646, continue a afirmar que o verdadeiro direito de legítima defesa não se deve bastar com a ilicitude da agressão, mas pressuporá também a culpabilidade do agressor, pouco depois (§ 705) conclui que, todavia, em face do DL 457/99, de 5-11, já não deve exigir-se a culpa do agressor como pressuposto da situação de legítima defesa. Posição que só não será paradoxal se se puder aceitar a existência de dois direitos de legítima defesa, o verdadeiro ou ontológico e o legal.

III. A acção de defesa: requisitos

§ 21 O art. 32.º afirma que "constitui legítima defesa o facto praticado como meio necessário para repelir a agressão". Parece, deste modo, que a acção de defesa é caracterizada exclusivamente através da necessidade do *meio* nela utilizado; e é assim, na verdade, que o tema vem sendo considerado hoje pela generalidade da doutrina, nacional e estrangeira. Esta é uma posição compreensível, *v. g.*, num direito como o alemão, onde o preceito respectivo, o § 32, faz depender a legitimidade da defesa não apenas do uso dos meios necessários, como ainda de que *a defesa, ela própria, seja necessária,* no sentido de (normativamente) **imposta** — "*geboten*" — pela situação a repelir. No mesmo sentido, de resto, era por alguns interpretado o art. 46.º, 3.º, do CP português de 1886 quando exigia, para que a defesa fosse legítima, a "necessidade **racional** do meio empregado" (39). Reduzindo a consideração da necessidade da defesa à necessidade *dos meios*, a interpretação não se revela justa nem adequada à teleologia da norma e aos fundamentos da justificação: estes têm a ver com a necessidade do meio empregado, decerto, mas também (e, num certo sentido, ainda mais) com a **necessidade da defesa como tal** na situação, face à exigência de prevalência do Direito sobre o ilícito na pessoa do agredido: **não há defesa "legítima" se ela for desnecessária** (40). Até ainda porque, analisando-se também a legítima defesa — já o vimos — numa *colisão* de bens, esta só existirá verdadeiramente se, de acordo com os critérios de valor da ordem jurídica, for *necessário* salvar um deles à custa do outro. Esta é uma questão — e essencial —, questão diferente — e subordinada — a de saber, assente a necessidade da defesa como tal e existindo vários meios possíveis de defesa, de qual ou de quais é lícito lançar mão. Talvez que se pudesse ter-se aceite este modo de ver, de resto teleologicamente imposto,

---

(39) GONÇALVES, Maia, *CP*, 1968, p. 103: "a racionalidade do meio inculca uma certa proporção (...) entre a lesão e o meio usado", e FERREIRA, Cavaleiro de, I, 1981, p. 347 e ss. Cf., agora, também, PALMA, Fernanda, nota 12, p. 339 e ss., BRITO, Teresa de, nota 12, p. 37 e ss., e MONTEIRO, Conde, nota 4, p. 151 e ss. Contra, CORREIA, Eduardo, II, p. 45, e, agora, também, CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 315 e s.

(40) ANDRADE, Costa, O princípio constitucional *"nullum crimen sine lege"* e a analogia no campo das causas de justificação, *RLJ 134*, 2001, p. 136, critica expressamente esta nossa posição na base da proibição da aplicação "analógica" *in malam partem* das causas de justificação. Sobre o ponto, já, supra, 14.º Cap., § 4 e s. Implicitamente como no texto, de resto, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 193 (cf., no entanto, também, p. 183 e ss.), e, na sua esteira, SILVA, Marques da, II, p. 96.

muitas das dúvidas e hesitações com que hoje se depara na construção da figura — nomeadamente, no que tem a ver com as chamadas *limitações ético-sociais do direito de legítima defesa* — pudessem ter sido evitadas ou ultrapassadas.

1. A necessidade do meio

§ 22 A justificação por legítima defesa pressupõe que na acção de defesa sejam usados os *meios necessários* para repelir a agressão actual e ilícita. A necessidade dos meios é, deste modo, um dos requisitos essenciais da legítima defesa e talvez aquele que, na prática, mais dúvidas e dificuldades suscita. É por isso importante determinar, com a precisão possível, os critérios pelos quais se deverá avaliar se numa concreta situação os meios usados pelo defendente foram os necessários para responder à agressão. O meio será necessário se for um meio **idóneo** para deter a agressão e, caso sejam vários os meios adequados de resposta, ele for o **menos gravoso** para o agressor. Só quando assim aconteça se poderá afirmar que o meio usado foi indispensável à defesa e, portanto, necessário.

§ 23 O juízo de necessidade reporta-se ao **momento** da agressão, tem natureza **ex ante**, e nele deve ser avaliada objectivamente **toda a dinâmica do acontecimento**, merecendo especial atenção as características pessoais do agressor (idade, compleição física, perigosidade), os instrumentos de que dispõe, a intensidade e a surpresa do ataque, em contraposição com as características pessoais do defendente (o porte físico, a experiência em situações de confronto) e os instrumentos de defesa de que poderia lançar mão. Questão sem autonomia é a da possibilidade de **recurso às forças de autoridade** ([41]). O art. 21.º-1 da CRP dispõe que "todos têm o direito de repelir pela força qualquer agressão, quando não seja possível recorrer à autoridade pública". Trata-se de uma condição que decorreria já da correcta interpretação do art. 32.º e, nomeadamente, da necessidade do meio. Com efeito, o recurso às autoridades policiais será por via de regra o meio de resposta menos gravoso para o agressor, pelo que, sendo possível recorrer em tempo útil às forças policiais para repelir *eficazmente* a agressão, deve considerar-se esse meio como o necessário à defesa. Salvo em contadas situações (que todavia já não contendem com

([41]) Nestes termos, CORREIA, Eduardo, II, n.º 13, II, e CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 328.

a necessidade do meio: infra, § 30 e s.), na ponderação dos meios não deve entrar-se em linha de conta com a possibilidade de **fuga**. Esta pode constituir em certos casos um meio idóneo para *evitar* a agressão e aquele que certamente menos prejuízos causa ao agressor. Todavia, não deve ser imposta como meio de defesa, não tanto por apelo à tradicional justificação de que a ordem jurídica não pode obrigar o agredido ao uso de meios "desonrosos" ([42]), mas sobretudo porque dessa forma se precludiria a função de prevenção geral a que a legítima defesa está adstrita, acabando a ordem jurídica por permitir que facticamente prevalecesse "a lei do mais forte" em detrimento do agredido. Tudo visto, pode considerar-se, p. ex., que se, ao contrário do agressor, o defendente dispõe de uma arma de fogo, deverá, em princípio, começar por ameaçar o agressor, por palavras ou disparando para o ar, e só se tal não for suficiente estará autorizado a disparar sobre ele, devendo, quando possível, evitar atingi-lo nas suas zonas vitais (*v. g.*, deve primeiro disparar para as pernas e só quando tal resulte infrutífero poderá apontar sobre o tronco ou a cabeça do agressor). Exigências que não poderão ser feitas quando também o agressor esteja munido de uma arma de fogo ou de igual perigosidade. Como também não poderá exigir-se que para afastar uma agressão física o agredido se envolva numa luta corporal de resultado incerto com o agressor. É que não pode considerar-se como necessário um meio que não seja **suficientemente seguro** para o agredido e que, embora idóneo para repelir a agressão, só o seja à custa de um **risco** para a sua vida ou integridade física. Não estará o defendente, por isso, obrigado a tentar afastar a agressão através de um meio mais leve, antes de fazer uso de um meio mais prejudicial para o agressor, se for incerta a eficácia dessa forma de defesa menos gravosa e não for despiciendo o risco que sobre ele se abaterá em caso de insucesso desse meio.

§ 24 Neste contexto merece de novo consideração (cf. supra, § 14) o uso de **meios de autoprotecção** (cães perigosos, aparelhos eléctricos, venenos, objectos perfurantes ou cortantes dissimulados, etc.). Que estes possam ser tidos, em certas hipóteses, como meios de defesa, parece dificilmente contestável. Decisivo, porém, é que o risco de, em concreto, se não ter tratado de um *meio necessário* corre sempre à custa de quem dele se serve. Convindo ter em conta, por outro lado, que o meio há-de ser considerado desnecessário sempre que fosse razoavelmente de supor que outro

([42]) CORREIA, Eduardo, II, n.º 10.

meio não agressivo pudesse ter sido utilizado com êxito (cartazes de prevenção, alarmes, sirenes, instalações, eléctricas ou outras, de simples aviso, etc. ([43])). Até a um ponto em que não ficará longe nestes casos (ou na sua grande maioria) a negação da *necessidade da defesa* (infra, § 28).

§ 25 A dificuldade assinalada de *concretização* da necessidade do meio de defesa tem conduzido, também entre nós, a uma abundante **jurisprudência**, sendo útil dar conta de alguns casos de maior interesse. Assim: Usou do meio necessário à defesa aquela que, vendo *A* deitar ao chão e apertar o pescoço do seu marido, acorre em socorro deste desferindo uma violenta paulada no antebraço de *A*, lesionando-o gravemente (Ac. da RC de 26-11-1986, *CJ*, 1986, V, p. 102 e s.). Após ter sido agredido por *C* e *D*, *B* pôs-se em fuga, tendo aqueles ido no seu encalço; *B* realizou então dois disparos para o ar, mas nem isso os dissuadiu e mantiveram a perseguição; quando *C*, numa atitude agressiva, se encontrava já muito perto de *B*, este disparou sobre ele, causando dessa forma a sua morte — dada toda a evolução dos factos e os tiros de aviso realizados por *B* não pode deixar de considerar-se que o meio por ele usado foi o necessário para pôr termo à agressão (concluindo diferentemente, todavia, o Ac. do STJ de 16-1-1990, *CJ STJ*, 1990, I, p. 13 e ss.). *E* e *F* trouxeram para sua casa uma prostituta estrangeira, *C*, que não pretendia voltar à casa de prostituição onde até então tinha estado; logo depois, a dona desse bordel e dois guarda-costas irromperam pela casa deles, contra a sua vontade, agrediram o *F*, danificaram o telefone e revistaram a casa à procura de *C*, mas não a encontraram. Poucas horas mais tarde, os agressores voltaram dispostos a realizar nova incursão. Chamada a polícia, foi-lhes dada ordem para abandonar o local, que, mal a polícia virou costas, não foi respeitada, pois de novo se dirigiram à residência de *E* e *F*. Foi então que *F*, tendo a dona do bordel a poucos metros de si, à porta de sua casa, determinada a fazer nova revista, empunhou uma caçadeira e disparou contra ela, causando-lhe a morte (Ac. do STJ de 21-1-1998, *BMJ*, 473, p. 133 e ss.) — dada a globalidade dos factos, a obstinação e perigosidade dos agressores, o facto de se ter previamente recorrido à intervenção das autoridades e os riscos que *F* correria em caso de realizar um mero tiro de dissuasão, o tribunal considerou correctamente que *F* usou do meio necessário para repelir a agressão. Numa noite, *G* encontrava-se sozinho em casa com a sua mãe, quando ela o acordou, após ouvir ruídos que indiciavam uma tentativa de intrusão. *G* levantou-se e após verificar ter sido aberta uma janela que ele próprio havia fechado disparou dois tiros de espingarda para o ar, com o intuito de afugentar os intrusos. Logo de seguida, a sua mãe ouviu novos barulhos vindos da janela de um quarto e gritou "eles estão a entrar". Num estado de pânico e de medo, *G* dirigiu-se a esse quarto e efectuou dois disparos na direcção da janela, de onde provinha o ruído, o que produziu a morte do assaltante. O tribunal considerou acertadamente que *G* utilizou os meios necessários para afastar a agressão, não lhe sendo exigível, depois de já ter efectuado dois disparos para o ar, que utilizasse outros meios de defesa, suportando ris-

([43]) Assim ROXIN I, § 15, n.º 51 e s.

cos para si e para a sua mãe, aguardando pelo esclarecimento global da situação, nomeadamente, pela entrada dos intrusos no interior da casa para então reagir, pois nessa altura poderia ser tarde demais (Ac. da RP de 27-9-2006, www.dgsi.pt).

§ 26 O uso de um meio *não necessário* à defesa representa um **excesso** que determina a não justificação do facto por legítima defesa. É o chamado *excesso de meios* ou *excesso intensivo de legítima defesa*, que, nos termos do art. 33.º, tem como consequência a afirmação da ilicitude do facto praticado. Assim, p. ex., haverá um excesso de meios se, no decurso de uma discussão entre duas vizinhas, uma delas, perante a entrada da outra no seu prédio de faca de cozinha em riste, reage desferindo-lhe uma pancada de enxada na cabeça, lesando gravemente a sua integridade física, pois teria sido suficiente apontar a enxada ou no máximo dar um golpe na mão que segurava a faca (duvidoso: Ac. da RC de 9-12-1993 ([44])). Também se excede claramente nos meios aquele que depois de ter sido agredido com uma bofetada impede uma nova investida através de um disparo mortal sobre o tronco do agressor (Ac. da RP de 23-6-1976 ([45])).

§ 27 Como referimos, a determinação do meio necessário à defesa é algo que na prática suscita dificuldades de vulto, quer porque muitas vezes só depois de utilizado um meio se fica a saber se ele bastaria à defesa, quer porque não haverá tempo para uma comprovação mental de todos os meios disponíveis, o que supõe uma frieza de ânimo em regra incompatível com a emoção derivada da agressão. Com efeito, a agressão gerará ou agravará frequentemente situações de forte tensão e conflito, desencadeando no agredido sentimentos de intranquilidade e insegurança que podem afectar em termos consideráveis o seu discernimento. Toda esta realidade dá azo a que muitas vezes sejam *usados meios mais gravosos para o agressor* do que aqueles que teriam sido necessários para a defesa; o que, se não impede a afirmação da ilicitude, pode todavia determinar uma **diminuição da culpa** (eventualmente também do próprio ilícito ([46])) e permitir, nos termos do art. 33.º-1, uma *atenuação especial da pena* ou, inclusivamente, a própria **exclusão da culpa**, nos casos em que o excesso de meios fique a dever-se a "perturbação, medo ou susto, não censuráveis" (art. 33.º-2 e infra, 22.º Cap., § 34 e ss.).

([44]) *CJ*, 1993, V, p. 66 e s.
([45]) *CJ*, 1976, p. 376.
([46]) Assim, entre nós, com especial insistência, CARVALHO, Taipa de, nota 6, § 14.

2. A necessidade da defesa

§ 28 Como sugerimos (supra, § 21), o requisito da necessidade da defesa, para que esta seja legítima, não deixa integrar-se unicamente através da exigência acabada de estudar da necessidade do meio: antes se impõe — à luz do seu próprio fundamento e logo assim, se se preferir, à luz da própria teleologia do *conceito* de *legítima* defesa — que a defesa, ela própria, se revele **normativamente imposta** (47) para que possa ser vista como exigência de reafirmação do Direito face ao ilícito na pessoa do agredido. Esta proposição não deve ser considerada como ofensiva do princípio jurídico-constitucional da *legalidade penal*, através das restrições que determinaria — para além do teor literal do art. 32.º — em desfavor do agente (48). Com efeito, do que se trata aqui não é da integração de uma qualquer "lacuna" com recurso ao argumento de analogia; é de uma interpretação teleológica e funcionalmente comandada da causa de justificação em exame, à luz, repete-se, do seu fundamento jurídico-normativo; contestar a legitimidade metodológica de um tal procedimento seria levar uma concepção estritamente positivista e formal do Direito para além da razão normativa e político-criminal da exigência jurídico-constitucional de legalidade penal. De resto, a nossa concepção, ao ligar directamente o requisito da **necessidade da defesa** ao próprio **fundamento da legítima defesa** como causa de justificação, serve para afastar receios de que, por esta via, se pudesse instalar a imprecisão e a consequente insegurança em matéria de tanto melindre para os direitos e garantias das pessoas. Por isso nos parece este caminho preferível, em geral, ao do apelo à doutrina das "limitações ético-sociais da legítima defesa" ou mesmo à teoria dos seus "limites imanentes" (49). A fórmula da "necessidade da defesa", a qual poderia ser-se tentado a considerar uma *fórmula vazia* (50), enche-se de conteúdo através da sua ligação ao fundamento da legítima defesa. E, de todo o modo, se objecções houvesse à doutrina que defendemos, seguramente que elas não seriam eliminadas ou ultrapassadas por

---

(47) No essencial, segundo nos parece, também, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 183 e ss.

(48) Assim, de forma terminante, ROXIN I, § 15, n.º 56.

(49) Teoria para a qual parece inclinar-se ANDRADE, Costa, nota 40, p. 135 e s.

(50) Como também se diz da fórmula *geboten* do direito alemão: S / S / LENCKNER / PERRON, § 32, n.º 44. Mas então só porque — numa consideração positivista e legalista extrema — se poderia afirmar que se a defesa, no caso, não é "imposta", isso é sinal seguro de que se não verifica a existência de *nenhum meio* de repelir a agressão que se apresente como "necessário".

se lhe mudar o nome para o de "limitações ético-sociais" ou de "limites imanentes" do direito de legítima defesa. Em que casos deva, concretamente, fazer-se uma leitura da exigência de que a defesa **se revele necessária** à luz do **fundamento** da justificação é questão que não deve, em nossa opinião e pelas razões acabadas de expor, ser respondida casuisticamente, antes sim em função de princípios directamente retirados do fundamento da justificação. Eles conduzem à eleição de quatro grupos diferentes que em seguida serão tratados sucessivamente ([51]).

2.1. Agressões que não importam uma desatenção unívoca pelos direitos do agredido

§ 29 Casos existem, na verdade, em que, sendo a agressão actual e ilícita, todavia ocorre dentro de um condicionalismo tal que faz com que ela se não apresente como **uma ofensa socialmente intolerável dos direitos do agredido**. Daí que a este não deva ser concedido um direito "pleno" de legítima defesa, justamente porque esta, sejam embora utilizados os meios necessários para a repelir (porque se trata do único meio ou do menos oneroso à sua disposição), *pode não surgir como socialmente indispensável* à afirmação do Direito face ao ilícito na pessoa do agredido ou *só o surgir respeitada que seja uma certa proporcionalidade dos bens conflituantes*. Neste conjunto de casos devem, no entanto, distinguir-se ainda dois grupos de hipóteses completamente diversos.

2.1.1. Agressões não culposas

§ 30 O primeiro grupo tem a ver com aqueles casos em que a agressão é ilícita e actual mas o agressor age sem culpa; seja porque, relativamente à agressão, se trata de um **inimputável** (um menor de 16 anos, p. ex., ou um oligofrénico profundo), seja porque o agressor actua com **falta de consciência do ilícito não censurável** ou a coberto de uma **situação de inexigibilidade legalmente prevista ou situação análoga**. Ligando-se a necessidade de afirmação do Direito face ao ilícito a necessidades de prevenção na pessoa do agredido, então logo se compreende que, nestes casos,

([51]) O caminho ensaiado e a sistematização seguinte coincidem praticamente com os que STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 81 e ss., e ROXIN I, § 15, H, propõem à luz de uma interpretação teleológica do requisito (expresso no § 32, I, do CP alemão) de que o facto seja "imposto" ou "indicado" ("*geboten*") como defesa necessária.

quanto menos responsável for o agressor pela sua actuação, tanto mais restritos sejam os limites de necessidade da defesa. Por isso a defesa agressiva *não é necessária* se o agredido pode esquivar-se à agressão (e sem que aqui haja lugar para acrescer: sem desdouro ou sem prejuízo da sua honra), *v. g.*, afastando-se do doente mental que o insulta em vez de o ofender corporalmente; ou se pode buscar auxílio alheio para repelir menos danosamente a agressão. Se nenhuma destas hipóteses se verifica, porém, a defesa será necessária e o direito de legítima defesa persiste, embora deva manter-se dentro dos limites da compreensão objectiva imposta perante actuações não culposas: já não será por isso defesa necessária, *v. g.*, a defesa a tiro (mesmo que esse seja o único meio disponível) para evitar sucessivos empurrões acompanhados de insultos de um doente mental. Que, em casos como este, se introduz substancialmente na legítima defesa uma qualquer ideia de proporcionalidade entre a agressão e o dano não deve ser contestado. Mas tal não deve constituir razão suficiente nem para restringir *contra-legem* os requisitos da legítima defesa, nem para construir ao lado desta uma causa supra-legal de justificação como a do estado de necessidade defensivo ([52]).

§ 31 O que se disse para agressões não culposas deve valer, *mutatis mutandis* — justamente porque se não trata de acrescentar requisitos à legítima defesa, como o da exigência de que a agressão seja dolosa ou culposa —, para os casos em que o agressor actua com a culpa sensivelmente diminuída (*v. g.*, em virtude de embriaguez, ou de erro sobre a ilicitude censurável) ([53]): também estes casos fazem aumentar as exigências colocadas à necessidade da defesa em virtude da diminuição das necessidades de afirmação do Direito perante o ilícito na pessoa do agredido.

2.1.2. Agressões provocadas

§ 32 Pode acontecer que a agressão seja precedida de atitudes de provocação do agredido sobre o agressor: **é o agredido que dá azo à situação de confronto** através de injúrias, da prática de actos ilícitos (mas não actuais) que afectam a esfera jurídica do agressor ou mesmo de actos

([52]) É todavia essa a tese de CARVALHO, Taipa de, nota 6, *passim* e p. 490 e s. No essencial da conclusão, como no texto, a larga maioria da doutrina alemã: JAKOBS 12/17, JESCHECK / WEIGEND, § 32 III, ROXIN I, § 15, n.º 57 e ss., SAMSON, *SK*, § 32, n.º 45, S / S / LENCKNER / PERRON, § 32, n.º 52, STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 83.

([53]) Assim, de novo, a doutrina alemã dominante, pela qual pode ver-se ROXIN I, § 15, n.º 58.

lícitos mas socialmente reprováveis. Se a resposta do provocado se traduz numa agressão ilícita e actual para bens jurídicos do provocador; se, p. ex., *A* é insultado por *B* e responde-lhe a murro, ou *C* faz uma espera a *D* que o havia surrado no dia anterior, ou *E* surpreende a sua mulher em acto de adultério com *F* e avança sobre ele com uma pistola — nestes casos deverá ainda afirmar-se a "necessidade da defesa" dos provocadores / agredidos (*B*, *D* e *F*)? O art. 46.º, 1.º, do CP de 1886 parecia querer responder negativamente a esta questão, ao exigir que a agressão "não seja motivada por provocação, ofensa ou qualquer crime actual praticado pelo que defende". Mas nem por isso deixava a interpretação deste preceito de conduzir aos maiores dissensos doutrinais e jurisprudenciais (54). Tendo o CP vigente omitido completamente esta exigência, a questão posta permanece em aberto.

§ 33 A necessidade da defesa deve ser seguramente **negada** quando esteja em causa uma **agressão pré-ordenadamente provocada**: *v. g.*, *A*, pretendendo ajustar contas antigas com *B* e sabendo que este é bastante sensível a certo tipo de insultos, profere propositadamente essas injúrias para suscitar nele uma reacção e, ao abrigo de uma aparência de legítima defesa, poder esfaqueá-lo com uma navalha que trazia escondida; *C*, agente policial especialmente treinado para "atirar a matar", provoca o suspeito de um crime gravíssimo, *D*, com o propósito de que este, com medo de ser detido, saque de uma arma para matar *C* e conferir a este, mais rápido e atirador de elite, um aparente direito de matar *D* em legítima defesa. A defesa não se antolha em casos tais como *necessária* porquanto não se verifica neles qualquer necessidade de afirmação da ordem jurídica na pessoa do agredido: quem criou pré-ordenadamente a situação de legítima defesa não defende mais o "lícito" perante o ilícito. O mais que pode ficar em aberto para o provocador é uma situação de estado de necessidade (defensivo).

§ 34 Nos casos — mais frequentes e, em perspectiva normativo-prática, mais importantes — em que a agressão actual e ilícita não tenha sido pré-ordenadamente provocada, a maioria da doutrina não se dispõe hoje a negar em bloco (como relativamente aos casos de provocação intencional)

---

(54) Cf., só, SANTOS, Beleza dos, *Obstáculos*, p. 39 e ss., CORREIA, Eduardo, II, p. 41 e s., FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 187 e ss.

(55) Cf. só, minuciosamente e com ampla e actualizada indicação bibliográfica, ROXIN I, § 15, n.ºs 65-82. E, em síntese, STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 83.

a necessidade da defesa, mas introduz-lhe fortes limitações que podem equivaler, praticamente, à negação daquela necessidade ([55]). Assim, torna-se desde logo necessário que, na provocação, se trate de um facto **ilícito ofensivo de um bem jurídico do provocado**; não bastará (ao contrário do que parecia querer significar o art. 46.º-1 do CP de 1886 ao referir a mera "ofensa") um qualquer menoscabo ou ofensa moral ou socialmente censurável. Para além disto, haverá ainda que exigir da provocação uma **estreita conexão temporal** e uma **adequada proporção** com a agressão que provoca: "quem injuriou outrem não verá restringida a sua faculdade de legítima defesa se o injuriado o ataca um ano depois; e quem seja responsável de uma ofensa corporal leve e se torne objecto de uma reacção totalmente desproporcionada (como uma tentativa de homicídio por parte do provocado) não tem que sofrer redução alguma das suas faculdades defensivas" ([56]). Desta forma, porém, a questão começa a aproximar-se largamente, como nota Stratenwerth, de uma "ponderação entre graus (escalonados) de responsabilidade pelo acontecimento típico, por um lado do provocador e por outro lado do provocado" ([57]) e, por essa via, da teoria do *estado de necessidade* ([58]).

2.2. Crassa desproporção do significado da agressão e da defesa

§ 35 Num outro grupo de casos a limitação da necessidade da defesa ocorre em função da verificação de uma crassa desproporção do peso da agressão para o agredido e da defesa (ainda que com o meio necessário) para o agressor. É o caso de escola do paralítico, *A*, que, na falta de outro meio, dispara a matar contra o ladrão *B*, que quer furtar-lhe a carteira que contém 5 euros. Todos estão de acordo em que não pode, em casos deste teor, conferir-se a *A* um direito de intervenção com o relevo jurídico que este possui, seja em nome da legítima defesa ou de qualquer outra causa justificativa: uma tal reacção de *B* **constitui, em definitivo, um facto ilícito**. Mas a fundamentação desta conclusão suscita as maiores e mais fundas divergências, algumas das quais atingem a figura da legítima defesa mesmo nos seus fundamentos.

([56]) ROXIN I, § 15, n.º 72.

([57]) STRATENWERTH / KUHLEN, loc. cit. na nota 55.

([58]) Não se estranhando, a partir daqui, que CARVALHO, Taipa de, nota 6, §§ 24 e 25, defenda, no plano do direito a constituir, que a provocação da agressão exclua a legitimidade da defesa, devendo o caso ser considerado nos quadros do estado de necessidade defensivo.

§ 36 Não serve invocar aqui a **irrelevância** social da agressão, no sentido da sua **insignificância**. Decerto que se deve considerar que a agressão está sujeita — como vimos que sucede, de resto, com os próprios tipos legais de crime por via da sua "punibilidade": supra, 10.º Cap., § 74 e s., e infra, 26.º Cap., § 13 e s. — a uma reserva de relevância social, não devendo por isso caber no âmbito da norma as meras bagatelas, perante as quais se não fazem verdadeiramente sentir necessidades de prevenção (59). Só que não é este o problema aqui em causa (60): como exactamente nota Taipa de Carvalho, o problema ora em causa põe-se relativamente a agressões "significantes" mas que nem por isso deixam de estar em crassa desproporção com a defesa (61), ainda quando a esta deva ser creditada a necessidade do *meio*. É essa crassa desproporção que, sem subterfúgios, deve ser interrogada à luz da necessidade da defesa. Em vez disso, porém, um número crescente de autores prefere, pelas mais diversas formas, fazer entrar *directamente* uma ideia de **proporcionalidade** dos bens jurídicos em conflito como condição de legitimidade da defesa: quer porque afirmem que — à maneira do que sucede com o direito de necessidade: infra, 16.º Cap., § 25 e ss. — é condição da justificação que a lesão derivada da defesa não seja sensivelmente superior à resultante da agressão (62); quer porque considerem que a agressão a bens que não os "definidores da dignidade essencial da pessoa", de bens, portanto, que não sejam a vida e a integridade física essencial (nomeadamente, *bens patrimoniais*) exclui a legitimidade da defesa quando esta determine a morte ou lesões graves à integridade física do agressor (63). Mas todo este pensamento se revela, a nossos olhos, infiel a pressupostos básicos do fundamento justificante da legítima defesa e, na verdade, tanto à ideia da prevenção do Direito sobre o ilícito, como ao irrenunciável efeito preventivo desta causa de justificação; confundindo até limites perigosos — e, em boa lógica, a partir de certo ponto inextricáveis — as causas justificativas da legítima defesa e do direito de necessidade.

---

(59) Assim, CARVALHO, Taipa de, nota 6, pp. 31, 438, 486 e s. e 490.

(60) Diferentemente, ROXIN I, § 15, n.º 83 e s., conta a hipótese das agressões insignificantes entre os casos de limites ético-sociais da legítima defesa.

(61) CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 487.

(62) Nesta linha — se bem que não levando o pensamento da (des)proporcionalidade até ao fim —, JAKOBS, 12/46 ss., JESCHECK / WEIGEND, § 32, III, S / S / LENCKNER / PERRON, § 32, n.º 50 e s.

(63) PALMA, Fernanda, nota 12, pp. 30 e s., 248 e ss., 313 e ss. e *passim*.

§ 37 Em todo o caso, uma concepção como a exposta por último parece poder chamar em seu favor um argumento extraído da "Convenção Europeia dos Direitos do Homem", que, na versão portuguesa, dispõe que "ninguém poderá ser *intencionalmente* privado da vida" (art. 2.º-1), para logo acrescentar que "não haverá violação do presente artigo quando a morte resulta de recurso à força, tornado absolutamente necessário para assegurar a defesa de qualquer pessoa contra uma violência ilegal" (art. 2.º-2*/a)*). Tem-se procurado anular o valor do argumento que daqui pode retirar-se em tema de legítima defesa (o de que o homicídio do agressor só constituiria legítima defesa se a agressão fosse violenta — e portanto já não, *v. g.*, uma mera agressão de bens patrimoniais) argumentando que aquele preceito da Convenção se dirige exclusivamente à actuação de autoridades, nomeadamente policiais (64). Mas se parece duvidoso que a regulamentação aqui contida possa deixar de reflectir-se na actuação de particulares (como pode permitir-se ao particular aquilo que é proibido ao polícia que está ao seu lado? (65), infra, 2.4), a verdade é que não é seguro que a limitação nela contida leve muito longe: de acordo com o pensamento que neste número desenvolvemos, não deixa de ser compreensível que se negue a necessidade da defesa de bens patrimoniais face a agressões ilegais não violentas à custa da morte do agressor com *dolo intencional*!

§ 38 A perspectiva que pode conduzir à exclusão da necessidade da defesa e nos parece seguramente mais próxima do seu fundamento justificante é a que se liga à ideia, relativamente já antiga, segundo a qual não pode ser legítima a defesa que se revela **notoriamente excessiva** face aos bens agredidos e que, nessa medida, representa um **abuso do direito** de legítima defesa (66). Não se trata pois aqui tanto da hierarquia ou do valor (jurídico) dos valores em conflito, quanto sobretudo da **comparação objectiva do significado jurídico-social da defesa com o peso da agressão para o agredido**. A necessidade da defesa deve ser negada sempre que se verifique uma insuportável (do ponto de vista jurídico) relação de desproporção entre ela e a agressão: uma defesa inadmissivelmente excessiva e, nesta acepção, abusiva, não pode constituir simultaneamente defesa necessária; logo porque não pode de modo algum representar-se como uma *defesa do Direito* contra o ilícito na pessoa do agredido. Se vemos correctamente a situação das coisas, deparamos aqui com uma espécie de denominador comum de todos os esforços e tentativas que neste apartado temos referido; nesta medida podendo porventura aceitar-se a afirmação terminante de Stratenwerth segundo a qual sobre a ilegitimidade da defesa abu-

(64) Assim, com particular insistência, JESCHECK / WEIGEND, § 32, V.
(65) Assim, só, ROXIN I, § 15, n.º 87, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 88.
(66) Assim, já, MAYER, M. E., p. 281[14].
(67) STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 87.

siva "existe hoje unanimidade" ([67]). Claro que, em concreto, muitas dúvidas permanecerão, cujas margens só uma aplicação judicial criteriosa poderá ir estreitando. Mas nem é isso nada de particular em matéria de causas de justificação (pense-se só no critério "estrito" de proporcionalidade que tem lugar em matéria de estados de necessidade, sejam agressivos, defensivos, de conflito de deveres, etc.); nem obsta a que à sua luz se possa decidir com segurança uma panóplia significativa de hipóteses.

§ 39 Os casos mais complexos e discutíveis serão, como é inevitável, aqueles em que a acção de defesa lesa a *vida* ou a *integridade física essencial* do agressor. Mas já aqui será seguro que, se a necessidade da defesa não tem de ser *ipso iure* negada por a agressão se dirigir a outros bens que não os da mesma categoria dos lesados pela defesa (inclusivamente, em certas situações, bens patrimoniais), já o deve seguramente ser no exemplo com que iniciámos este apartado: o da morte dada ao ladrão que foge com uma carteira que contém 5 €. Em todo o caso — e aqui deparamos com um ponto que se afigura verdadeiramente essencial à nossa consideração —, decisiva não será a ponderação dos bens conflituantes em si mesmo considerados, mas a **imagem global do facto** complexivo constituído pela agressão actual e ilícita de um lado, e da defesa através do meio necessário do outro lado.

2.3. Posições especiais

§ 40 Um terceiro grupo de hipóteses relativamente às quais pode ser questionada a necessidade da defesa, nos termos preditos, é a de os participantes se encontrarem numa mútua posição especial de proximidade existencial, criadora de **especiais laços de solidariedade juridicamente relevante**. O caso tem sido sobretudo considerado relativamente às relações entre cônjuges ou pessoas que vivam em situação análoga (CC, art. 1672.º) ou entre pais e filhos (CC, art. 1874.º). Taipa de Carvalho pretende considerar estes casos ao mesmo nível jurídico-dogmático dos da agressão provocada ([68]). Mas não parece que uma tal consideração unitária se justifique. Qualquer que deva ser a solução dada ao problema da provocação da agressão, esta é uma coisa, outra social e normativamente diversa a situação criada pela referida proximidade existencial entre agressor e defendente. Também aqui parece razoável sustentar que a necessidade da defesa diminui ou mesmo, em certos casos-limite, pode desaparecer. Comprovada a *efectiva* proximidade existencial — proveniente da verificação da existência de uma relação *real* entre os *partenaires* — está justificada uma maior compreensão da

([68]) CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 443 e ss.

agressão (limitada, por certo): o ameaçado deve sempre que possível evitar a agressão, escolher o meio menos gravoso de defesa, ainda que ele se apresente menos seguro para repelir a agressão e renunciar a uma defesa que ponha em perigo a vida ou a integridade física essencial do agredido (a menos que tal se revele impossível face ao peso da agressão) ([69]). De todo o modo, a limitação desaparecerá e o direito de legítima defesa reverterá à sua integralidade se a agressão for de tal natureza e gravidade que elimine o dever de solidariedade existencial que fundamenta a limitação.

§ 41 Não vale contrariar a posição acabada de tomar com o argumento de que ela corre ao arrepio do esforço que por toda a parte se acentua no sentido de combater os maus tratos entre cônjuges ou pessoas vivendo em situação análoga e, em consequência, das **necessidades acrescidas de prevenção** que neste campo se fazem sentir. Para tanto — independentemente da posição que possa tomar-se quanto ao fundo do problema social aqui implicado — servem as *reformas legislativas do crime de maus tratos ou de outros semelhantes*, não as normas relativas à legítima defesa. Do exposto não resulta, como é óbvio, nenhum salvo-conduto para os maus tratos conjugais ou análogos ([70]). O problema dogmático que a propósito se tem suscitado é outro: o de saber se as limitações referidas da necessidade da defesa resultam da proximidade existencial referida e do propósito de que ela possa subsistir ou antes de eventuais *posições de garante* que intercedam entre os implicados ([71]). Mas a esta última concepção há que dirigir a mesma crítica que foi feita à da uniformização entre esta situação e a da agressão provocada: a ligação humana numa parceria próxima, previsivelmente destinada a continuar, é um *elemento específico* da situação que deve ser considerado (seja qual for a solução) *em si* e *por si mesmo*.

2.4. Actos de autoridade

§ 42 Um último grupo de casos que, em nossa opinião, tem a ver com a questão em análise da necessidade da defesa diz respeito a actuações da autoridade, nomeadamente, das **forças policiais**. Uma certa doutrina alemã pretende excluir aqui, categoricamente, a doutrina geral da legítima defesa sempre que existam disposições legais especiais na matéria relativas a tais forças, em particular no que respeita ao uso de armas ([72]).

([69]) Neste sentido, a doutrina alemã absolutamente dominante: JAKOBS, 12/58, JESCHECK / WEIGEND, § 32, III, a), ROXIN I, § 15, n.º 94 e s., S / S / LENCKNER / PERRON, § 32, n.º 53, STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 89 e s.

([70]) Assim, também, STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 90.

([71]) Assim, ROXIN I, § 15, n.º 91 e ss.

([72]) Assim, JAKOBS, 12/42, e SAMSON, *SK*, § 32, n.º 61.

No outro extremo se situam aqueles que sustentam carecer o problema totalmente de autonomia (73): as exigências de necessidade seriam exactamente as mesmas para os particulares e para as forças públicas quando estas têm elas próprias de se defender ou prestam auxílio necessário a particulares. Entre nós a questão deve colocar-se especialmente a propósito do uso de armas de fogo pelos órgãos de polícia criminal (art. 1.º/*c)* do CPP), objecto de regulamentação específica pelo DL 457/99, de 5-11. Diploma que enuncia, a nosso ver correctamente, os princípios que devem reger esta matéria e define o quadro em que esses princípios devem concretizar-se, impondo fortes limitações ao uso de armas de fogo quer quanto às situações em que ele é permitido, quer quanto aos procedimentos a adoptar. Assim, o "recurso a arma de fogo só é permitido em caso de absoluta necessidade, como medida extrema, quando outros meios menos perigosos se mostrem ineficazes, e desde que proporcionado às circunstâncias" (art. 2.º-1); só sendo de admitir o seu uso *contra pessoas* quando tal se revele necessário para repelir agressões que constituam um perigo iminente de morte ou ofensa grave que ameace vidas humanas (art. 3.º-2). Nesta medida, temos por seguro que tais preceitos **prevalecem** sobre a regulamentação geral da legítima defesa constante do art. 32.º (74), revelando-se como explicitações legais do *princípio da proporcionalidade* que rege toda a intervenção pública; e que encontram a sua justificação não só numa posição especial do agente que o obriga a correr *riscos mais pesados* (v. infra, 22.º Cap., § 21, um pensamento paralelo em matéria de inexigibilidade), como na superior condição física e preparação técnica relativamente ao particular (75). Nesta

---

(73) Como antes considerava CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 323 e ss. Na conclusão, também, ROXIN I, § 15, n.ºs 108 e ss., 115.

(74) Enquanto consideramos ser esta uma disciplina legal que determina uma posição especial, repercutindo-se somente no âmbito da legítima defesa respeitante às actuações oficiais, CARVALHO, Taipa de, II, § 679 e ss., confere ao DL 457/99, de 5-11, um efeito muito mais lato, estendendo as suas regras à legítima defesa exercida pelos particulares. O que o leva inclusive a reconstruir toda a sua concepção de legítima defesa ou, pelo menos, a conceber um novo direito de legítima defesa, de cariz legal, paralelo àquela que denomina de "verdadeira" legítima defesa (cf. § 646); sendo essa, em face do aludido regime legal, colocada como que entre parênteses: toda a legítima defesa passa a estar vinculada a uma cláusula de proporcionalidade qualitativa entre o bem agredido e o bem atingido pela defesa e a agressão passível de resposta em legítima defesa deixa de pressupor a culpa do agressor.

(75) CARVALHO, Taipa de, § 679 e ss., lança um longo requisitório contra a posição que sustentamos em texto, acusando-nos de confundir o plano da necessidade do meio com o da necessidade da defesa e o pressuposto da necessidade do meio de defesa com o pressuposto da proporcionalidade dos bens. Nessa crítica começa, todavia, por omitir o primeiro e principal argumento que expressamente avançamos como justificativo do regime legal em análise, o de que

medida, pode dizer-se que as especialidades que aqui intervêm se coadunam ainda com os princípios que temos exposto relativamente a uma correcta e autónoma interpretação do que seja a *necessidade da defesa* e surgem como uma sua verdadeira concretização legislativa.

3. O elemento subjectivo

§ 43 Para além do requisito subjectivo que vale para a generalidade das causas de justificação — o do conhecimento da situação de legítima defesa (cf. supra, 14.º Cap., § 17) — desde há muito se suscita e continua a suscitar-se a questão de saber se será ainda de exigir, como requisito da acção de defesa, a existência no defendente de um *animus defendendi*, de uma actuação com a vontade de defender os bens jurídicos ameaçados pela agressão. Uma resposta afirmativa foi outrora dominante na doutrina portuguesa; mas, como acentua Taipa de Carvalho, tal equivalia só as mais das vezes a exigir que o defendente representasse a existência de uma agressão actual e ilícita (76). A jurisprudência portuguesa tem-se mantido fiel à exigência neste contexto de uma vontade de defesa, impondo até mesmo por vezes — o que é de todo inaceitável — que essa vontade se manifeste sob a forma do "dolo directo". Mas ultrapassado o entendimento puramente objectivista da ilicitude e da justificação, compreende-se que a doutrina hoje dominante corra no sentido de que, **existindo o conhecimento da situação de legítima defesa, não deverá fazer-se a exigência adicional de uma co-motivação de defesa**: tal faria depender a existência da justificação da manifestação de uma atitude interior do defendente que levaria a conotar perigosamente a legítima defesa com concepções morais próximas de um direito penal do agente (77).

4. A acção de defesa que recaia sobre terceiros

§ 44 A defesa só é legítima na medida em que os seus efeitos se façam sentir **sobre o agressor** e já **não sobre um terceiro alheio à agres-**

---

estamos perante uma explicitação do princípio da proporcionalidade que rege toda a intervenção pública, para acabar por tirar a mesma conclusão que já havíamos formulado, a de que o DL 457/99 introduz uma exigência de proporcionalidade no seio da legítima defesa.

(76) CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 375 e s., dando como exemplo a doutrina de SANTOS, Beleza dos, *Obstáculos*, p. 45 e ss.

(77) Nestes termos, CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 375 e ss., ROXIN I, § 15, n.º 129 e s. Na conclusão, também, SILVA, Marques da, II, p. 97 e s.

são. Em relação a este não pode falar-se de necessidade de afirmação do Direito na pessoa do agredido e por isso sobre ele não impende um dever de suportar os efeitos danosos resultantes da acção de defesa. Assim, p. ex., não haverá justificação por legítima defesa no caso em que perante uma agressão iminente de *A*, *B* dispara um tiro de ameaça para o ar que atinge mortalmente *C*; ou dispara mesmo contra as pernas de *A*, mas erra o alvo e acerta em *D*, lesando gravemente a sua integridade física. Nesta linha devem resolver-se as situações em que para afastar a agressão se usam e eventualmente danificam instrumentos que não pertencem ao agredido: se o instrumento for pertença do agressor tal facto deverá ser considerado justificado por legítima defesa; se pertencer a um terceiro, uma possível justificação decorrerá não do direito de legítima defesa, mas eventualmente do direito de necessidade (art. 34.º) ([78]).

IV. O auxílio necessário

§ 45 O art. 32.º estende a justificação por legítima defesa aos casos em que esta é exercida para **proteger interesses de terceiro**: é esta forma de legítima defesa que doutrinalmente se designa "auxílio necessário". Face ao fundamento que ficou assinalado à força justificadora da legítima defesa — a defesa do Direito face ao ilícito na pessoa do agredido —, compreende-se sem mais que a defesa necessária seja consentida não só ao agredido mas *a qualquer pessoa*. Como igualmente se compreende, a partir daqui, que os requisitos da legítima defesa (sejam os referidos à situação, sejam os referidos à acção de defesa) devam ser **os mesmos** quer se trate de legítima defesa própria, quer de terceiro. Tudo isto corresponde a doutrina pacificamente aceite.

§ 46 Problema discutido e complexo é o de saber como deve decidir-se o caso em que o agredido — *v. g.*, por uma questão de princípio, de convicção ou mesmo de consciência — **não quer ser defendido** ou quer **ser ele próprio a defender-se**. A opinião dominante na Alemanha parece ir no sentido de que o agredido não deve nunca ser defendido contra a sua vontade expressa, porque de outro modo se ultrapassa (quando mesmo se não nega) em toda a sua dimensão, o pensamento da prevalência do Direito

([78]) Doutrina e jurisprudência hoje praticamente unânimes na Alemanha: cf. só ROXIN I, § 15, n.º 125 e s.

sobre o *ilícito* na pessoa do *agredido*. Hoje, todavia, estão a tornar-se cada vez mais comuns considerações "diferenciadoras", em particular consoante a agressão vise bens jurídicos disponíveis ou indisponíveis ([79]). Por maior interesse que tenham tais diferenciações, elas não devem abalar a conclusão de que, mesmo perante uma agressão actual *e ilícita* — o que não é logo o caso de uma agressão validamente consentida: infra, 17.º Cap. —, a defesa de terceiro levada a cabo *contra* ou *sem* a vontade manifestada do agredido não parece poder reivindicar-se como exercício da legítima defesa do art. 32.º: ela não representa a defesa do Direito na pessoa do *agredido*.

V. O direito de legítima defesa jurídico-civil (art. 337.º do CC)

§ 47 A ordem jurídica portuguesa prevê a figura do direito de legítima defesa não apenas no preceito do CP que temos vindo a analisar, o art. 32.º, mas também num outro, o art. 337.º do CC. Disposição esta que, além de apresentar uma redacção pouco feliz, colocou desde a sua entrada em vigor problemas de compatibilidade com as normas reguladoras da legítima defesa no ordenamento penal — primeiro com o art. 46.º do CP de 1886 ([80]) e depois com o vigente art. 32.º —, devidos sobretudo à exigência de que o prejuízo causado pelo acto de defesa **não seja manifestamente superior** ao que derivaria da agressão. É neste ponto que se depara com a maior discrepância de regime entre as duas normas, pois quanto ao resto, em termos substanciais, podem considerar-se idênticas no essencial as duas regulamentações. O art. 337.º do CC considera como pressupostos da situação de legítima defesa a existência de uma *agressão actual e ilícita contra a pessoa ou o património do agente ou de terceiro*. Ainda que a terminologia varie, verifica-se uma coincidência destes pressupostos com os que caracterizam a situação de legítima defesa do art. 32.º, onde está também em causa uma agressão actual e ilícita de interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro. O campo de aplicação das duas normas é assim o mesmo. Donde resulta a necessidade de averiguar de que forma actuam e eventualmente se conjugam estes preceitos no sentido da exclusão da ilicitude do facto.

([79]) Cf., só — em todo o caso com divergências assinaláveis nas conclusões —, na Alemanha, JAKOBS 12/59 e ss., e ROXIN I, § 15, n.º 116 e ss., e, entre nós, CARVALHO, Taipa de, nota 6, § 13.4.

([80]) VALDÁGUA, Conceição, nota 7, p. 236 e ss.

§ 48 Como vimos também, a legítima defesa prevista no art. 32.º não está limitada por uma exigência de proporcionalidade, podendo em nome dela sacrificar-se bens jurídicos de valor superior ou mesmo muito superior ao dos defendidos. Já não assim quanto à legítima defesa jurídico-civil, limitada negativamente pela cláusula de proporcionalidade referida ([81]), que restringe substancialmente o âmbito da justificação relativamente àquela. Desta forma, *para efeitos de exclusão da responsabilidade jurídico-penal* é duvidoso que sobre espaço para a legítima defesa do art. 337.º do CC. Não sobrará certamente para quem defenda uma ideia de **unidade da ilicitude**, rejeitando a possibilidade de uma ilicitude especificamente penal (supra, 14.º Cap., § 7 e ss.); e considere que tal entendimento conduz a que a actuação ao abrigo da legítima defesa prevista no art. 32.º exclui a ilicitude do facto não apenas no ordenamento penal, mas também no espaço jurídico-civil, acabando, deste modo, por retirar à legítima defesa do art. 337.º do CC qualquer campo útil de aplicação ([82]). Defendemos já todavia a possibilidade da existência de uma ilicitude especificamente penal, não havendo — ao menos teoricamente, na nossa perspectiva — nada contra a consequente possibilidade de o facto ser penalmente justificado e, no entanto, enquanto lesão de direitos ou interesses jurídico-civis, subsistir como ilícito civil ou poder dar lugar a uma qualquer forma de responsabilidade no âmbito do direito privado ([83]). O art. 337.º do CC poderia então intervir nestes casos, actuando "ao lado" do art. 32.º, para efeito de exclusão da ilicitude ou da responsabilidade civil.

§ 49 **Deste modo, porém, as dificuldades subiriam muito de tom**, perante o requisito da proporcionalidade presente na legítima defesa jurídico-civil e ausente da legítima defesa penal. Isto porque quando os prejuízos causados pelo defendente fossem manifestamente superiores aos que se pretendiam defender, a defesa, nos termos do art. 337.º do CC, não seria legítima, subsistindo a ilicitude civil. Nestes casos, como aponta

---

([81]) Para uma discussão sobre a natureza da "manifesta superioridade" prevista na lei civil, VALDÁGUA, Conceição, nota 7, p. 240 e ss., e BRITO, Teresa de, nota 12, p. 49 e ss.

([82]) Assim, CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 54 e ss.

([83]) Na conclusão, também, BRITO, Teresa de, nota 12, p. 61 e s. Conclusão, aliás, que se encontra na linha de CORREIA, Eduardo, continuadamente exposta no seu ensino oral e vertida no art. 37.º-3 do seu *ProjPG*, quando colocava como requisito de eficácia do efeito justificante do direito de necessidade (jurídico-penal) que "seja possível a indemnização [jurídico-civil] do lesado".

certeiramente Conceição Valdágua, o facto do defendente representaria também, relativamente ao primitivo agressor, uma agressão actual e ilícita, que daria azo a que este pudesse responder em legítima defesa ([84]). Estaria por esta via posto em causa o princípio de que contra legítima defesa não vale legítima defesa e tanto o facto do defendente, como a resposta do primitivo agressor estariam penalmente justificados, podendo qualquer terceiro intervir na situação em auxílio de um ou de outro e vendo sempre excluída a ilicitude da sua conduta! Regime que, logo se conclui, não poderia ser nunca aceite face à insanável contradição axiológica ([85]) e normativa que mesmo no seu cerne se instalaria, propiciando situações de incerteza e de insegurança num campo onde se faz sentir a necessidade de linhas de orientação das condutas particularmente claras e precisas. Daí que, sem pôr em causa a possibilidade de, no âmbito jurídico-civil, se poderem fazer exigências adicionais em sede de causas de justificação — ou de se aceitar a possibilidade de condutas penalmente justificadas que todavia possam ainda constituir o agente em uma qualquer forma de responsabilidade civil —, no concreto caso do art. 337.º do CC se deva concluir, com Conceição Valdágua, que após a entrada em vigor do art. 32.º se deu a **revogação daquele preceito do CC** na parte em que exige que o prejuízo causado pelo acto de defesa não seja manifestamente superior ao que pode resultar da agressão.

([84]) VALDÁGUA, Conceição, nota 7, p. 273 e ss. Com ela concorda, nesta conclusão, CARVALHO, Taipa de, nota 6, p. 57 e ss., e ROSA, Cortes, nota 30, p. 197 e s.

([85]) VALDÁGUA, Conceição, nota 7, p. 275.

16.º CAPÍTULO

OS ESTADOS DE NECESSIDADE JUSTIFICANTES

I. A evolução da doutrina do estado de necessidade

§ 1 O CP português de 1982 contém no seu art. 34.º — pela primeira vez, na história da legislação penal portuguesa — uma regulamentação do *direito de necessidade*, também chamado *estado de necessidade objectivo* ou *estado de necessidade justificante*. Antes dele (1), o que os nossos CPs continham era simplesmente preceitos que podiam ser interpretados como consagrando de algum modo a figura (distinta, veremos em que termos: infra, 22.º Cap., II) do estado de necessidade *desculpante* ou estado de necessidade *subjectivo*, ou em todo o caso uma figura próxima: o art. 14.º-2 do CP de 1852, que declarava não ser o acto criminoso quando o autor foi a ele constrangido por força irresistível; ou o art. 44.º do CP de 1886, segundo o qual justificam o facto "os que praticam o facto violentados por qualquer força estranha, física e irresistível" (n.º 1) e "os que praticam o facto dominados por um medo insuperável de um mal igual ou maior, iminente ou em começo de execução" (n.º 2). Mas já Eduardo Correia julgava poder interpretar estes preceitos no sentido de que o direito penal português posterior a 1886 reconhecia a chamada **teoria diferenciada do estado de necessidade**, que na doutrina europeia havia feito carreira, a partir do pensamento de Hegel e de Feuerbach, sobretudo pela mão dos penalistas de formação hegeliana (2). Teoria diferenciada

---

(1) Para esta evolução — nem sempre com entendimentos concordantes —, SANTOS, Beleza dos, *Obstáculos*, p. 92 e ss., CORREIA, Eduardo, II, n.º 20, FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, p. 414 e ss., PALMA, Fernanda, O estado de necessidade justificante no Código Penal de 1982, *Estudos Eduardo Correia*, III, 1984, p. 173 e ss. Monografia importante mais recente: PAWLIK, *Der rechtfertigende Notstand*, 2002.

(2) Cf., sucessivamente, FEUERBACH, *Lehrbuch des peinlichen Rechts*, [14]1847, § 91, HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, [3]1930 (ed. Lasson), § 147, e BERNER, *De impu-*

esta ([3]) para a qual o estado de necessidade surgiria como **justificante** (estado de necessidade "objectivo" ou "direito" de necessidade) sempre que se tratasse de facto típico praticado como meio adequado para salvaguardar um bem ou interesse jurídico, do agente ou de terceiro, de *maior valor* do que o sacrificado. E como simplesmente **desculpante** (estado de necessidade "subjectivo") quando o valor salvaguardado *não fosse de maior valor* do que o sacrificado; caso em que a desculpa não proviria da hierarquia dos bens em conflito e consequente prevalência do de maior valor, mas da *coacção* que a situação conflitual exerceria sobre o agente e as suas decisões. Nisto se traduz, no essencial, a aludida "teoria diferenciada" do estado de necessidade.

§ 2 É de acordo com a teoria diferenciada que o CP regula hoje a figura complexa do estado de necessidade. Distinguindo o estado (direito) de necessidade como **causa de justificação**, no art. 34.º, do estado de necessidade como **causa de exclusão da culpa**, no art. 35.º; mas submetendo até certo ponto as duas figuras a um denominador comum: o do afastamento, através da prática de um facto típico, de um perigo actual que ameaça bens jurídicos do agente ou de terceiro. Se o interesse salvaguardado for de valor **sensivelmente superior** ao sacrificado, o facto está justificado por direito de necessidade; se o não for o facto é ilícito ([4]), mas o agente poderá, dentro de certos e estritos pressupostos, ver a sua culpa excluída. É a primeira destas duas figuras que cumpre estudar no presente enquadramento, sendo a segunda remetida para o lugar sistemático em que se considerarão as causas de exclusão da culpa (infra, 22.º Cap., II).

§ 3 Se nos perguntarmos pelo **fundamento justificador** do estado de necessidade objectivo ou direito de necessidade, a resposta que reputamos

---

nitate propter summam necessitatem proposita, 1861. E, sobre o todo, BOCKELMANN, *Hegels Notstandslehre*, 1935, p. 22 e ss., e CORREIA, Eduardo, II, n.º 14.

([3]) Para ela contribuiu decisivamente também a suprema jurisprudência alemã quando teve de decidir casos de interrupção da gravidez medicamente indicada, para cuja justificação apelou precisamente à figura (supra-legal) do estado de necessidade justificante: RGSt 61, 242, e 62, 137 — cf. SANTOS, Boaventura, *O Conflito de Deveres em Direito Criminal*, 1965, p. 162 e ss. Sobre a evolução desta questão em Portugal, DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 142.º, § 1 e ss.

([4]) Criticando o critério da superioridade / inferioridade do bem a salvaguardar face ao bem a sacrificar, que perpassa na distinção entre os arts. 34.º e 35.º, como determinante da licitude / ilicitude do facto em caso de conflito de bens, VELOSO, José António, Sortes, *Estudos Cavaleiro de Ferreira*, 1995, p. 93 e ss.

mais correcta possui, também aqui, natureza **dual**. Por um lado, uma razão de **utilidade social**, traduzida na maximização da protecção de interesses ou bens jurídicos, mais concretamente, do interesse ou bem jurídico jurídico-socialmente mais importante entre aqueles que se encontram em conflito: é socialmente positivo, *v. g.*, que alguém sofra e seja obrigado a suportar uma ofensa simples à sua integridade física ou ao seu património como forma de afastar um perigo que ameaça a vida de outra pessoa. Por outro lado, a imposição jurídico-legal de um mínimo de **solidariedade** entre os membros da comunidade humana, à luz do interesse individual de cada um dos participantes no conflito; no interesse daquele que vê a sua vida salva à custa da ofensa à integridade física de outrem, ofensa que este é juridicamente obrigado a suportar (5). Esta dupla fundamentação correrá, na generalidade dos casos, numa via comum. Em caso de remoto e eventual conflito de fundamentos, não deve pedir-se a considerações de índole jurídico-filosófica a decisão sobre qual o fundamento em princípio preponderante (6): ele só poderá ir buscar-se à concreta conformação legal desta causa de justificação democraticamente editada. Por isso também será vã a tentativa de ver-se aqui (consoante a extensão maior ou menor que se confira ao direito de necessidade) o produto de um pensamento *mais liberal* ou *mais social*: o que sucede é apenas que as exigências de solidarismo não podem ser levadas longe demais, sob pena de se aumentar exponencialmente a *complexidade social* (tornando cada cidadão em polícia da salvaguarda dos interesses dos outros e/ou da comunidade) e, por essa forma, provocar mais dano que utilidade à função do direito penal de tutela das condições essenciais de uma vida individual e comunitária pacífica.

§ 4 Como, com razão, se exprime Roxin a propósito do preceito do CP alemão (§ 34) homólogo do nosso art. 34.º, este normativo é apenas aplicável a "conflitos [de bens ou interesses] não tipificados" (7). Isto quer dizer que há frequentes situações de conflito que são **especialmente reguladas pela lei** e cuja regulamentação, por isso, pre-

(5) E, acrescenta ROXIN I, § 16, n.º 10, também no interesse deste outrem, que sabe que a sua vida pode vir a ser salva se um dia se encontrar na situação daquele a quem agora a vida foi preservada.

(6) Na conclusão, ROXIN I, § 16, n.º 11. Acentuando a vertente solidarista, KÜHL, § 8, n.º 1 e ss. Fica pela alternativa PAWLIK, nota 1, p. 32 e ss.

(7) ROXIN I, § 14, n.º 48; cf., também, S / S / LENCKNER / PERRON, § 34, n.º 7, STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 100; e, na doutrina portuguesa, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 228.

valece, nas situações abrangidas, sobre a contida no art. 34.º É o que acontece, desde logo, p. ex., com a justificação da *interrupção da gravidez* (art. 142.º) ou com o *estado de necessidade jurídico-civil* (art. 339.º do CC: infra, § 40 e ss.). Mas é o que acontece também com a postergação do *segredo profissional* (arts. 195.º do CP e 135.º do CPP) e com diversas regulamentações dos *actos de autoridades*, nomeadamente policiais ([8]). Onde estas regulamentações se revelem mais estritas que o art. 34.º, não pode recorrer-se a este artigo para cobrir uma situação com a capa da justificação. Mas, por outro lado, o art. 34.º contém concretizações, *v. g.*, na exigência de *adequação do meio* (infra, § 30), que podem reflectir-se na interpretação de especiais causas de justificação baseadas também na ideia da prevalência, em situação conflitual, de interesses mais importantes, valendo em tais questões o art. 34.º como *lex generalis* na matéria.

II. O direito de necessidade do art. 34.º

1. A situação de necessidade

1.1. Os interesses juridicamente protegidos em conflito

§ 5 A situação de necessidade pressupõe que "um perigo actual que ameace interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro" (proémio do art. 34.º) só possa ser afastado — *sc.*, eliminado ou diminuído — se outro bem jurídico for lesado ou posto em perigo. Uma primeira questão a pôr aqui é a de saber porque é que o legislador evitou no art. 34.º a expressão "**bem(ns) jurídico(s)**", que a tantos outros propósitos utilizou com frequência, substituindo-a pelo designativo "**interesse(s) juridicamente protegido(s)**. Não se trata de acaso, seguramente, nem muito menos de lapso. A razão histórica da modificação ([9]) vai buscar raízes ao E1962 alemão, tendo a Grande Comissão por ele responsável discutido aprofundadamente a questão e tomado a decisão de não falar neste contexto de bens jurídicos, mas de interesses juridicamente protegidos. Quis, por esta forma, chamar a atenção para um ponto que a exposição posterior se encarregará de pôr em maior evidência e mesmo de patentear a essencialidade para a

([8]) Sobre o ponto, em pormenor, ROXIN I, § 16, n.º 103 e ss.

([9]) Sobre ela LENCKNER, Der Grundsatz der Güterabwägung als Grundlage der Rechtfertigung, *GA*, 1985, p. 295, e ROXIN I, § 16, n.º 7. Contra o significado que atribuímos à contraposição entre "bem(ns) jurídico(s)" e "interesse(s) juridicamente protegido(s)" insurge-se CARVALHO, Taipa de, II, § 719. Crítica que, no entanto, parece ignorar o fundamento histórico referido em texto e assenta no pressuposto inexacto de que a designação "bem jurídico" é específica (porventura, exclusiva) do direito penal; para uma menção a "bens jurídicos não penais", cf., noutro contexto, o próprio CARVALHO, Taipa de, II, § 759.

correcta solução dos casos: o de que a ponderação de grandezas conflituantes que, como vimos, constitui a essência desta causa de justificação, não se reduz a uma comparação "seca" de bens jurídicos, mas de **bens jurídicos projectados no contexto global — não necessariamente externo-objectivo — da situação** (infra, § 11 e ss.). O que significa que os bens jurídicos conflituantes constituem apenas *uma perspectiva* entre *várias* relevantes para a ponderação, *v. g.*, o grau do perigo ameaçador, a intensidade da lesão esperada, a autonomia pessoal do lesado, a maior ou menor adequação do meio salvador, etc.: tudo isto terá de ser tomado em conta para levar a cabo uma correcta ponderação. Foi seguramente a mesma intenção que presidiu, entre nós, à redacção do art. 34.º na parte questionada.

§ 6 Protegido pelo direito de necessidade pode ser assim, em princípio, **qualquer bem jurídico, penal ou não penal**. *V. g.*, pode estar coberta por direito de necessidade, sob certas circunstâncias, a conduta típica do segurança que empurra um fotógrafo ou um jornalista insistente (ofensa à integridade física simples: art. 143.º) como meio necessário e adequado de "assegurar o seu posto de trabalho" (que constitui porventura um bem jurídico, mas não penalmente tutelado). Mais complexo é determinar se são susceptíveis de se cobrirem com o direito de necessidade **bens jurídicos não do indivíduo, mas da comunidade** ([10]). Não será fácil, nem frequente, que a protecção de um bem jurídico transpessoal possa concretamente ser operada através do exercício de um direito de necessidade: quer porque o facto dirigido a salvaguardar o bem jurídico supra-individual não surgirá as mais das vezes, como deve, como *único* meio de protecção, quer porque ele não constituirá muitas vezes um *meio adequado* para tal. Mas não será impossível que tal aconteça, *v. g.*, se alguém comete um facto típico patrimonial de valor relativamente pequeno para afastar um perigo actual e significativo de contaminação ambiental.

§ 7 Uma situação de estado de necessidade justificante pode verificar-se ainda quando não estão em conflito *vários* bens jurídicos, mas onde **um e o mesmo bem jurídico** ameaçado por um perigo só pode ser salvo através da sua exposição a *um outro perigo*. É o caso vulgar de uma intervenção cirúrgica ou da execução de tratamentos (muito) arriscados e ainda insuficientemente conhecidos da ciência médica e das suas *leges*

([10]) Respondendo negativamente à questão, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 211 e ss. Por uma afirmativa geral, SILVA, Marques da, II, p. 108: "O objecto do direito de necessidade é (...) *qualquer* interesse juridicamente protegido" (s. n.).

artis, mas necessária como única forma de possivelmente salvar a vida do doente. O consentimento (efectivo ou presumido) servirá aqui para afastar a eventualidade de uma ofensa à integridade física ([11]): neste campo haverá que apelar também, todavia, para o estado de necessidade justificante; como igualmente, p. ex., quando o pai, para salvar um filho de perecer num incêndio, o atira de grande altura para uma lona que os bombeiros seguram, lesando a sua integridade física ([12]).

1.2. O perigo que ameaça o bem jurídico

§ 8 Importa seguidamente pôr em evidência que o bem jurídico a salvaguardar tem que se encontrar **objectivamente em perigo**, porque só então se pode justificar que um dever de suportar a acção típica recaia sobre o atingido pela intervenção, demais se ele não for implicado na situação inicial. No mesmo sentido corre, de resto, a exigência expressa no art. 34.º de que se trate de um perigo **actual**, não havendo razão bastante para que se afastem completamente aqui os princípios acima definidos a propósito da "actualidade" da agressão na legítima defesa (supra, 15.º Cap., § 11 e ss.). Com algumas correcções, em todo o caso, no sentido do seu **alargamento**: o perigo deverá para este efeito considerar-se actual mesmo quando não é ainda iminente, mas o protelamento do facto salvador representaria uma potenciação do perigo; e também no caso dos chamados "perigos duradouros", *v. g.*, quando existe um edifício em perigo de desmoronamento, se bem que não possa determinar-se se e quando tal ocorrerá ([13]). Se, logo a partir daqui, se torna necessária (e conveniente) a construção da figura de um estado de necessidade **preventivo** é coisa de que em todo o caso pode duvidar-se ([14]); nomeadamente, à luz da cláusula de *adequação* (infra, § 30) e, sobretudo, em certas hipóteses, da preservação, mais que da "autonomia", da *dignidade da pessoa* que seja fonte do perigo.

([11]) Ofensa que, nos termos do art. 150.º-1, deve considerar-se *típica* no sentido da lesão da integridade física. Cf., no entanto, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 150.º, § 24 e s., e *passim*.

([12]) Como no texto, STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 104, e, porventura mais restritivo nas conclusões, ROXIN I, § 16, n.º 101 e s.

([13]) Assim, ROXIN I, § 16, n.º 20 e s.

([14]) Cf., por último, a respeito de um caso muito particular — o do polícia que ameaça submeter a tortura terroristas implicados num rapto, como forma de tentar salvar a vida do raptado —, KINZIG, Jörg, Not kennt kein Gebot? Die strafrechtlichen Konsequenzen von Volterhandlungen an Tatverdächtigen durch Polizeibeamte mit präventiver Zielsetzung, *ZStW 115*, 2003, p. 791; e por último, com ampla informação, ROXIN I, § 15, n.º 103 e ss., § 16, n.º 97 e s., e § 22, n.º 166 e ss.

1.3. A "provocação" do perigo

§ 9 Nos termos da al. *a)* do art. 34.º é necessário à justificação "não ter sido voluntariamente criada pelo agente a situação de perigo, salvo tratando-se de proteger o interesse de terceiro". Tudo estará em saber, desde logo, o que pretendeu a lei com o requisito, neste contexto, da **voluntariedade** da criação do perigo. A uma primeira aproximação parece traduzir-se assim a antiga e rigorosa doutrina de Binding, segundo a qual "quem se tenha posto em perigo, então que pereça" ([15]). Mas não é difícil mostrar que esta doutrina se revela absolutamente desajustada face ao fundamento justificante do estado de necessidade, o da *solidariedade* devida a quem se encontra em uma situação de necessidade. Se *A* se lança numa corrida louca de esqui, mesmo depois de advertido dos perigos em que incorre, deve o direito impedir que, tendo-se ferido numa queda, alguém penetre numa cabana alheia sem autorização (art. 190.º) para solicitar socorro por telefone? Se *B*, em estado de embriaguez, corta a sua própria orelha e não tem ninguém que o leve ao posto médico, deverá abster-se de conduzir um veículo até a um local onde possa ser tratado (art. 292.º) ([16])? Se *C* provoca, mesmo culposamente, um acidente rodoviário, deve ser punido por omissão de auxílio (art. 200.º-2) se foge para se resguardar da ira da multidão que assistiu ao desastre e se prepara para "fazer justiça por suas próprias mãos"? Pôr estas perguntas é responder-lhes negativamente: em qualquer destes casos persiste o fundamento justificante do estado de necessidade. Por isso deve defender-se aqui — algo diferentemente do que ficou dito (supra, 15.º Cap., § 32 e ss.) relativamente à provocação da agressão na legítima defesa — que a justificação só deverá considerar-se afastada se a situação foi **intencionalmente** provocada pelo agente, isto é, se ele premeditadamente criou a situação para poder livrar-se dela à custa da lesão de bens jurídicos alheios. Ir mais além e sustentar ([17]) que a justificação por estado de necessidade deve ser negada logo que o perigo foi "conscientemente" criado parece exage-

---

([15]) BINDING, *Handbuch*, I, 1885, p. 778.

([16]) Caso verídico, apreciado pelo Ac. da RC de 16-5-2001 (Proc. n.º 1105/2001), que — erradamente — não apenas considerou o facto como ilícito, como entendeu não haver lugar à exclusão da culpa, em virtude de os factos serem insuficientes para integrar o estado de necessidade desculpante do art. 35.º!

([17]) Como certos arestos da jurisprudência alemã e uma parte da doutrina: cf., aprofundadamente, KÜPER, *Der "verschuldete" rechtfertigende Notstand*, 1983.

rado, como de resto logo o revelará o primeiro dos exemplos acima referidos ([18]).

§ 10 A própria provocação intencional do perigo não deverá servir, porém, para negar a justificação por estado de necessidade (como expressamente refere a parte final do art. 34.º/*a*)) quando se trata de proteger **interesses de terceiro**: seria inadmissível que da provocação do agente pudesse resultar uma lesão não justificada para bens jurídicos do terceiro posto em perigo, se depois o provocador os salva à custa de um outro terceiro não implicado (pressuposto, naturalmente, que se verifiquem os restantes requisitos do direito de necessidade). Assim, se *A* criou intencionalmente um perigo de incêndio da casa de habitação de *B* e posteriormente se arrepende, pode louvar-se do estado de necessidade se entra sem autorização na casa de *C* (art. 190.º) para chamar os bombeiros, excluindo deste modo a ilicitude da violação de domicílio.

2. O princípio do interesse preponderante

2.1. Os pontos de vista relevantes para a ponderação

§ 11 De acordo com o disposto na al. *b)* do art. 34.º só tem lugar a justificação por direito de necessidade se houver "**sensível superioridade do interesse a salvaguardar relativamente ao interesse sacrificado**". Aqui deparamos verdadeiramente com o *cerne* da figura em análise, com a lídima expressão do seu fundamento justificador: ela segue, em primeira linha, o princípio do interesse preponderante. Por outras palavras, a lei exige que se pondere o valor dos interesses conflituantes, nomeadamente dos bens jurídicos em colisão e do grau do perigo que os ameaça, é dizer, dos decursos possíveis do acontecimento em função da violação (ou perigo de violação) dos bens jurídicos que lhe está ligada.

§ 12 Relevante é por isso, desde logo, a **hierarquia** dos bens jurídicos em confronto; mas já se compreenderá não ser possível (nem legal)

([18]) Apontando já nesta direcção, CORREIA, Eduardo, II, p. 86 e s.; e, essencialmente por razões análogas às expostas, CARVALHO, Taipa de, *A Legítima Defesa*, 1995, p. 288[506], que tende a considerar o disposto no art. 34.º/*a*), como "desnecessário" e mesmo "prejudicial". Não cremos porém, como intentámos mostrar, que uma sua correcta interpretação impeça o alcance de soluções justas e adequadas ao fundamento justificante do direito de necessidade. Como igualmente em nada prejudica um tratamento autónomo do tema do "estado de necessidade defensivo" (infra, § 36 e ss.).

oferecer uma fórmula unitária para resolução definitiva do problema da ponderação ([19]). Tanto mais quanto — e é este um ponto para nós essencial —, como escreve Fernanda Palma, "a justificação em estado de necessidade não é reconduzível ao confronto objectivo entre bens jurídicos, como era próprio da teoria da ilicitude objectiva, porque é o mundo do merecimento pessoal de todos os intervenientes possíveis num conflito de interesses (isto é, de coerência global das expectativas de todos os sujeitos ante a Ordem Jurídica) o que sobressai no art. 34.º" ([20]).

2.1.1. As molduras penais

§ 13 Quando os bens jurídicos conflituantes se encontram jurídico-penalmente protegidos, o recurso à **medida legal da pena** com que é ameaçada a sua violação constitui, sem dúvida, um dos pontos de apoio mais importantes para a determinação da hierarquia respectiva: é indiscutível que o bem jurídico da "vida de outra pessoa" (art. 131.º e s.) é de hierarquia superior ao da "vida intra-uterina" (art. 140.º e s.), do "património" (art. 203.º e ss.) ou da "profanação de cadáver" (art. 254.º); que o da "integridade física" (art. 143.º e ss.) é superior ao da "honra" (art. 180.º e ss.); que o da "liberdade sexual" (art. 163.º e ss.) é superior ao da "reserva da vida privada" (art. 190.º e ss.), etc., etc. Trata-se porém aqui, insista-se, apenas de um "ponto de apoio". Pois para além de que, como dissemos, são susceptíveis de serem salvaguardados bens jurídicos não penalmente relevantes — relativamente aos quais, por conseguinte, não existe qualquer moldura penal a considerar —, não pode esquecer-se que a tutela penal (de que as molduras penais são reflexo) é por natureza *fragmentária* e *lacunosa*. Para dar só um exemplo, a "liberdade pessoal" é sem dúvida, como decorrência directa da autonomia, um dos valores de maior hierarquia jurídico-constitucional; e todavia a tutela penal não é dirigida a esta liberdade no seu conjunto, mas apenas a suas singulares manifestações. Do mesmo modo — vê-lo-emos a propósito do consentimento (infra, 17.º Cap., §§ 2 e s. e 13) —, um direito tão fundamental como o da auto-determinação e auto-realização pessoal é muitas vezes sacrificado pela lei à protecção devida a bens jurídicos (que nem sequer entram necessariamente na categoria dos bens jurídicos pessoais) que a lei reputa indisponíveis.

([19]) Cf. VELOSO, José António, nota 4, p. 90[4].

([20]) PALMA, Fernanda, nota 1, p. 205 e s.

Tudo isto faz compreender que a medida legal da pena que ameaça a lesão dos bens jurídicos conflituantes, sendo (repetimos ainda uma vez) um ponto de vista essencial à ponderação, não pode reivindicar-se como único e pode em definitivo, por várias razões, vir a ser contrariado ([21]): muitos outros pontos de vista podem e devem entrar na determinação da hierarquia dos interesses conflituantes, como o da *intensidade da lesão do bem jurídico*, o do *grau dos perigos que ameaçam os interesses em jogo*, o do respeito pela *eminente autonomia e dignidade da pessoa*. Todos estes critérios, uma vez levados à ponderação, podem conduzir a resultados que se não compadecem com a hierarquia abstracta dos bens jurídicos indiciada — quando possível — pelas molduras penais previstas para a sua ofensa.

2.1.2. A intensidade da lesão do bem jurídico

§ 14 Um papel fundamental na ponderação cabe, na verdade, à intensidade da lesão do bem jurídico, nomeadamente quanto a saber se está em causa o **aniquilamento** completo do interesse ou só uma sua lesão **parcial** ou **passageira**. Os bens jurídicos "integridade física" (art. 143.º e ss.) ou "liberdade pessoal" (art. 153.º) devem em regra reputar-se de superior hierarquia à de bens jurídicos puramente patrimoniais ([22]) (se bem que, através das molduras penais aplicáveis — sobretudo num CP como o nosso —, esta conclusão não seja absolutamente segura, tornando-se necessário apelar para o critério complementar, que claramente penetra a ordem axiológica constitucional e a correspectiva ordem legal dos bens jurídicos, da prevalência de princípio dos bens jurídicos pessoais sobre os patrimoniais ([23])); e todavia não haverá dúvidas que para afastamento de um grave prejuízo patrimonial (*v. g.*, derivado de um incêndio em habitação ou casa comercial), deve ter-se por justificado o empurrão que o bombeiro dá a um "mirone" e que lhe determina uma pequena lesão corporal (art. 143.º) ([24]), ou mesmo uma curtíssima privação da liberdade

---

([21]) Assim, veementemente, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 219. Sobre este ponto, cf., ainda, Ac. do STJ de 28-4-1993, *BMJ 426*, p. 257 e ss.

([22]) Cf. CORREIA, Eduardo, II, p. 85.

([23]) E de modo especial perante o texto original do CP de 1982, fruto de pressões políticas de última hora ao nível da AR. A situação clarificou-se de algum modo no sentido do texto — mas só em certa medida, sobretudo relativamente às lesões mais graves — com a Reforma de 1995.

([24]) Assim, também, FARIA, Paula Ribeiro de, *Comentário Conimbricense*, I, art. 143.º, § 25.

("sequestro": art. 158.º) adequada a que o salvamento se processe em condições mais seguras ou mais rápidas. Acresce que, nos casos em que os bens conflituantes são, em abstracto, da mesma ou de semelhante hierarquia, a ponderação terá de ter *sobretudo* em conta a intensidade previsível da lesão. Quem omite o auxílio devido em caso de acidente que põe em perigo pouco grave a integridade física de outra pessoa (art. 200.º-1) pode porventura justificar-se quando se afastou do lugar do acidente por necessidade inadiável de participar numa importante reunião de negócios, porque a sua falta acarretaria gravíssimos prejuízos patrimoniais, para ele e/ou para outrem.

2.1.3. O grau do perigo

§ 15 Nos casos em que a violação do bem jurídico não surja como absolutamente segura, mas como mais ou menos *provável*, um papel fundamental cabe ao **grau do perigo** que é afastado ou criado com a acção de salvamento. Como Roxin formula, "quem, para evitar um dano que seguramente se produzirá se não actuar, leva a cabo uma acção salvadora que só em pequena medida põe em perigo outro bem jurídico, prosseguirá em regra o interesse substancialmente preponderante. Mas este será sobretudo o caso quando, para fazer face a um perigo concreto de uma certa importância, seja aceite a produção somente de perigos abstractos" ([25]). Com hipóteses frequentes destas situações se deparará na actividade relacionada com o trânsito de veículos. A corrida de uma ambulância que ponha de algum modo em perigo a vida de um transeunte, sob a forma da negligência (art. 291.º-2), pode porventura justificar-se se ela transporta um ferido grave, cujo tratamento é urgentíssimo, mas seguramente já não se o ferido tem apenas umas escoriações ligeiras ou mesmo uma perna previsivelmente partida. Conduzir veículo com uma taxa de álcool no sangue de 1,2 gr/l ou superior (art. 292.º-1) pode ser uma conduta justificada se ela traduzir o meio único de transportar em tempo um doente grave ao hospital: neste sentido, Ac. da RL de 19-6-1996 (Proc. n.º 0000743) para o caso em que *A*, embriagado, conduziu um automóvel para socorrer a mãe, que, sofrendo de doença grave e vivendo só, lhe tinha telefonado dizendo que se sentia mal e necessitava de assistência; diversamente (mas duvidosamente), Ac. da RL de 5-5-1998 (Proc. n.º 0034305), que apenas

([25]) ROXIN I, § 16, n.º 43.

admitiu a exclusão da culpa (art. 35.º) no caso em que *B*, em estado de embriaguez, conduziu ao hospital a esposa, acometida de doença súbita e grave, depois de, sem êxito, junto de amigos e bombeiros, ter tentado obter aquele transporte.

2.1.4. A autonomia pessoal do lesado

§ 16 Outro ponto de vista da maior relevância para a ponderação sempre que o bem jurídico ofendido seja de carácter *eminentemente pessoal* — de tanta relevância que o nosso CP entendeu conferir à sua expressão uma regulamentação expressa — é o da **autonomia pessoal** do lesado. Não pode na verdade esquecer-se, nem minimizar-se (e foi sobretudo mérito de Stratenwerth tê-lo posto em especial destaque ([26])) que o facto necessitado ofende, para além do bem jurídico do lesado, o seu **direito de autodeterminação e de auto-realização**: por isso este ponto de vista deve entrar na ponderação e, sob certas circunstâncias, influenciar decisivamente o seu resultado ([27]). Isto mesmo quer significar a al. *c)* do art. 34.º, quando dispõe que o direito de necessidade só se verifica quando for "razoável impor ao lesado o sacrifício do seu interesse em atenção à natureza ou ao valor do interesse ameaçado". Se há razão bastante para que esta cláusula tenha sido autonomizada pela nossa lei relativamente à cláusula da ponderação dos interesses e à exigência de sensível superioridade do interesse salvaguardado (art. 34.º/*b)*) ou se é supérflua, constitui uma questão de pouco interesse; pressuposto, é claro, que se não absolutize a cláusula da "irrazoabilidade", considerando-a como que um muro inexpugnável a impedir qualquer ponderação dos interesses conflituantes ([28]). Tratar-se-ia aí, em nossa opinião, de uma confusão entre a "autonomia pessoal" e a "eminente dignidade da pessoa"; e nada há de pior para a preservação jurídica desta dignidade do que tentar esgrimir com ela logo que estejam em causa valores ou interesses da pessoa. Seguramente que não

([26]) STRATENWERTH, Prinzipien der Rechtfertigung, *ZStW 68*, 1956, p. 41 e ss.

([27]) Nesta linha, SANTOS, nota 3, p. 119 e ss., FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 221, e PALMA, Fernanda, nota 1, p. 202. Contra, CARVALHO, Taipa de, nota 18, pp. 185[308] e 286[503], considerando a autonomia pessoal não como um elemento a ter em conta na ponderação, mas antes como um seu limite.

([28]) Esta é a solução seguida, todavia, por CARVALHO, Taipa de, nota 18, p. 286[503] e ss., com o argumento de que outra solução significaria crasso utilitarismo e degradação da pessoa individual.

está justificada, pela razão exposta, a intervenção médica destinada a retirar, sem o seu consentimento, um rim a *A*, cheio de saúde e que poderá viver certamente só com o rim restante, mesmo que essa seja a única forma de, por via de transplante, salvar a vida de *B*: a tanto se opõe — apesar de o bem jurídico "vida de *B*" ser de hierarquia superior ao da "integridade física de *A*" — a autonomia pessoal de *A*, que deve ser preservada ([29]). Mas, em nossa opinião, o mesmo já não deverá defender-se para o caso de *C* ser forçado — sem nenhum prejuízo grave para si — a dar sangue, por ser a única pessoa com o tipo necessário a uma intervenção cirúrgica urgente, indispensável à salvação da vida de *D* ([30]). Neste caso temos por inadmissível — atento o pequeno peso e a ausência de perigo da intervenção — a invocação da violação da autonomia pessoal de *C* ou, nos termos do art. 34.º/*c)*, da irrazoabilidade de impor ao lesado o sacrifício do seu interesse para salvar a vida de outrem ([31]).

2.1.5. A "imponderabilidade" da vida de pessoa já nascida

§ 17 De algum modo relacionada com o tema acabado de se considerar está a questão de saber se o sacrifício da **vida humana de pessoa já nascida** deve entrar na ponderação própria do estado de necessidade justificante ou, pelo contrário, dela ser pura e simplesmente excluída. A doutrina absolutamente dominante corre neste último sentido: a vida é um bem jurídico de valor incomparável e insubstituível, que ocupa um primeiro e indisputável lugar, numa concepção personalista ética como a que deve presidir a toda a ordem jurídica liberal e democrática, na hierarquia dos bens jurídicos. Pelo que — acrescenta-se — não são legítimas diferenciações *qualitativas* entre o valor de vidas humanas, a da criança, do jovem e do geronte, a do saudável e do moribundo, a do magnate e do proletário, a do sábio e do analfabeto. Como pela mesma razão não deve haver lugar a ponderações sequer *quantitativas*: uma vida vale exacta-

([29]) Defendendo também que só pelo consentimento se pode justificar a doação de órgãos, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 149.º, § 48, e FARIA, Paula Ribeiro de, *Aspectos Jurídico-Penais dos Transplantes*, 1995, p. 243.

([30]) Caso estudado pela primeira vez, ao que cremos, por GALLAS, Pflichtenkollision als Schuldausschliessungsgrund, *Mezger-FS*, 1954, p. 325 e s.

([31]) Contra, no entanto, a opinião dominante na Alemanha, e, entre nós, SANTOS, 3, p. 120, e FARIA, Paula, nota 29, p. 172[241]. Como no texto, porém, ROXIN, *Kriminalpolitik*, p. 27 e s., e, agora, I, § 16, n.º 48 e s.; e, entre nós, na conclusão, PALMA, Fernanda, nota 1, p. 202 e s.

mente o mesmo que dez, cem ou mil vidas, porventura o mesmo que todo o resto da humanidade, de acordo com a consabida sentença de Koestler: "Une vie ne vaut rien. Mais rien ne vaut une vie". No conhecido exemplo: o agulheiro que vê um expresso em circulação a alta velocidade tomar a via errada, pelo que irá embater um outro comboio parado na estação e cheio de passageiros, e que, no último momento, desvia o expresso para uma via lateral onde estão dois trabalhadores que são esmagados, não pode louvar-se em um direito de necessidade. Em caso de conflito de vida contra vida(s), deve assentar-se no **princípio da imponderabilidade da vida para efeito de estado de necessidade justificante**. Tudo o que pode ficar em aberto é uma eventual *causa de exclusão da culpa* (infra, 23.º Cap., II) (32).

§ 18 O princípio referido possui um **fundamento ético** sólido, que proíbe submeter a vida humana a *cálculos* ponderadores e utilizá-la como *meio* para alcançar fins heterónomos. Resta porém saber se, como todo o princípio, também este não deve submeter-se a **limitações** quando a ponderação deva ser levada a cabo *perante outras vidas humanas* que, também elas, constituem fins em si mesmas. Exprobar como puramente pragmática e finalista esta consideração é esquecer que manter *toda* a vida humana dentro dos limites do possível constitui, em si mesmo, um propósito de primeira grandeza dentro da ordem legal dos bens jurídicos e da tarefa do direito penal de protecção destes (33). Por outras palavras, admitir em certas hipóteses — seguramente excepcionais e de verdadeiro "conflito existencial" (34) — a justificação do sacrifício de uma vida para salvar outra ou outras é conclusão que só por puro doutrinarismo poderia ser recusada *in limine* como "utilitarismo": não é a "utilidade" que aqui está em causa (35), mas sim o valor "ético" da preservação da vida dos outros.

---

(32) Nesta conclusão se acolhe a esmagadora maioria da doutrina jurídico-penal pertencente ao nosso círculo cultural. Cf., em Portugal, CORREIA, Eduardo, II, p. 94 e s., SANTOS, nota 3, p. 158 e ss., FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 223, SILVA, Marques da, II, p. 113, e PALMA, Fernanda, nota 1, p. 184 e ss.; e, na Alemanha, por outros, JAKOBS, 13/23, ROXIN I, § 16, n.º 38, e S / S / LENCKNER / PERRON, § 34, n.º 24.

(33) Assim, com razão, KÜPER, *Grund- und Grenzfragen der rechtfertigenden Pflichtenkollision im Strafrecht*, 1979, p. 57 e ss.

(34) END, *Exitentielle Handlungen im Strafrecht — Die Pflichtenkollision im Lichte der Philosophie von Karl Jaspers*, 1959, p. 71 e ss.; MANGAKIS, Die Pflichtenkollision als Grenzsituation des Strafrechts, *ZStW 84*, 1972, p. 475.

(35) Como, de resto, ROXIN I, § 16, n.º 38, acaba por reconhecer.

E a prova de que a própria lei penal portuguesa não é insensível a esta consideração nem considera a proibição de aniquilamento da vida como um "absoluto", vemo-la nós logo — para além de outros casos que poderiam ser referidos ([36]) — na circunstância de ela determinar a licitude do facto se o confronto "vida contra vida" se der no quadro de um conflito, não de bens como é próprio do direito de necessidade, mas de *deveres* (art. 36.º-1 e infra, § 41 e ss.); para já não falar, é claro, das hipóteses de *legítima defesa* em que a possível lesão da vida do agressor é fundadamente (e consensualmente) justificada ou (ainda mais!) dos homicídios (em massa!) provocados no decurso de uma guerra.

§ 19 Em geral, deve antes de tudo e com importância fundamental relembrar-se o que supra, §§ 5 e 12, ficou explicitado à luz do próprio texto do art. 34.º: a justificação por força do estado de necessidade não se avalia à luz do simples conflito de bens jurídicos, mas no quadro mais complexo dos **interesses conflituantes** na situação global. Fosse uma mera questão de conflito de bens e a questão em consideração não teria interesse, ou pelo menos dificuldade, porque em caso de vida contra vida deparamos com bens jurídicos *iguais*, não podendo por isso conduzir a uma justificação. A única forma correcta de pôr o problema é pois a de saber se, no contexto complexo da situação global, será possível descortinar casos em que o interesse na preservação de uma ou mais vidas prepondera sobre o sacrifício de outra ou outras.

§ 20 Uma parte da doutrina julga — desde há muito ([37]) — encontrar ocasião para uma resposta afirmativa nos casos chamados **de comunidade de perigo**: quando, havendo várias pessoas todas elas colocadas numa situação comum de perigo para a vida, se sacrifica uma ou algumas delas como única e adequada forma de impedir que outra ou outras pereçam. Neste grupo caberiam — para não alargar demasiado a exemplifi-

---

([36]) Neste sentido, para o direito alemão, o próprio ROXIN I, § 16, n.º 42, invocando a doutrina do *estado de necessidade defensivo*.

([37]) Pelo menos desde BINDING, *Handbuch*, I, 1885, p. 765. Contra, de modo terminante, STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.ºs 109 e 113; e agora, também, JÄGER, Christian, Die Abwägbarkeit menschlichen Lebens im Spannungsfeld von Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie, *ZStW 115*, 2003, p. 765, socorrendo-se em todo o caso, para algumas das hipóteses problemáticas, de uma "conversão" do facto interruptivo de um processo causal salvador num facto *omissivo*.

cação — casos como os da "*tabula unius capax*" ([38]), em que dois náufragos se agarram a uma tábua tentando alcançar a praia; mas como a tábua só é capaz de suportar o peso de um, um empurra o outro para a água, salvando-se aquele e morrendo este afogado. Ou como o "caso do piloto", em que um *ferry* com muitas crianças que faziam um passeio num grande lago começa a meter água e vai afundar-se, o que determinará seguramente a morte de todas elas; o piloto atira então algumas crianças à água, que morrem afogadas, só deste modo conseguindo manter o barco à tona e salvar todas as restantes. Ou como o "caso Mignonette", em que náufragos que num bote procuravam desesperadamente terra e morriam de fome decidiram matar o grumete — o mais enfraquecido de todos eles — e alimentar-se do cadáver, o que permitiu que acabassem por se salvar. Ou como o "caso dos montanhistas" discutido na Alemanha desde 1895 ([39]), em que *A*, um de vários montanhistas unidos por uma mesma corda, resvala para o precipício, de tal modo que é impossível içá-lo e a corda vai partir, arrastando todos eles; por isso e porque *A* se encontra no extremo da corda, um outro montanhista, *B*, corta-a, matando *A*, mas salvando-se a si e a todos os restantes companheiros.

§ 21 Se bem se reconheça a especificidade, para o efeito aqui em consideração, das situações caracterizadas como de "comunidade de perigo, **não nos parece que a comunidade de perigo possa, em si e por si mesma, justificar o facto** que sacrifica alguma ou algumas vidas para salvar outra ou outras. Apesar de perfeitamente cabido nesta categoria, o caso malfadadamente célebre da chamada "eutanásia hitleriana dos enfermos mentais" — em que certos médicos deram indicações para que fossem mortos alguns doentes mentais internados nas suas clínicas porque, se a tanto se negassem, seriam substituídos por funcionários nazis que teriam determinado a morte de todos os internados — ilustra bem as nossas reservas: não devem considerar-se tais homicídios justificados por força do direito de necessidade, porque nem juridicamente é admissível que alguém se arrogue o direito de *escolher* quem deva morrer e quem deva sobreviver; nem é absolutamente *seguro* o que teria acontecido aos doentes se os médicos tivessem recusado cumprir as ordens de extermínio; nem o facto de matar

([38]) Que terá sido imaginado por Karneades (*ca.* 214 a. C.) e foi depois debatido, noutro enquadramento, por KANT, *Metaphysik der Sitten*, ed. Weischedel, IV, 1956, p. 343.

([39]) MERKEL, *Die Kollision rechtmässiger Interessen und die Schadensersatzpflicht bei rechtsmässigen Handlungen*, 1895.

alguns doentes se pode considerar *adequado* (infra, § 30) à salvação dos restantes. Tudo o que aqui pode ficar em aberto é uma eventual *exclusão da culpa* (40).

§ 22 Diferentemente se passam as coisas, porém, em casos como o dito "dos montanhistas". Neste caso não há, desde logo, qualquer *escolha* da vítima, antes esta encontra-se, na exacta expressão de Eb. Schmidt, já "marcada pelo destino" (41); é, por outro lado, *seguro* que nem *B* podia içar *A*, nem a corda aguentaria, pelo que a omissão da acção de homicídio teria determinado a morte da vítima e de todos os seus companheiros; e, deste modo, o facto surge como *adequado* ao afastamento do perigo que sobre todos os companheiros de *A* pesava. Verificadas todas estas condições, em nosso modo de ver, só um inadmissível doutrinarismo (unilateral e por isso pretensamente "ético"), uma "santificação" do valor da vida humana que, já o vimos a vários títulos, é estranha ao direito penal e à sua função, às proposições político-criminais básicas e aos juízos de valor — não necessariamente só aos *pragmata* — legais, poderia conduzir à negação do direito de necessidade. Enquanto, por outro lado, não se abre assim a porta nem à legitimação de "vidas indignas de ser vividas" — não é o (des)valor da vida que se sacrifica que justifica o facto, mas o valor das vidas que se *salvam* à custa de uma já condenada pelo destino — nem à legitimação do "direito do mais forte" (42). Em suma e numa palavra, em casos deste teor **a função de protecção de bens jurídicos (dos bens jurídicos que ainda podem ser salvos) prepondera notoriamente, a nossos olhos, sobre o "interesse" de deixar o destino seguir o seu curso destruidor**.

§ 23 Roxin, seguindo os trilhos da doutrina dominante na Alemanha, pronuncia-se, ainda aqui, pela negação da justificação, com base num argumento que chama "de princípio": o de que, de todo o modo, se encurta o período de vida de uma pessoa (no caso, o montanhista *A*), pelo que a procedência da solução que reputámos correcta conduziria à justificação de todos os casos de eutanásia em sentido jurídico; e num argumento que diz "pragmático": o de que nunca pode saber-se quando e em que condi-

(40) Assim, CORREIA, Eduardo, II, p. 94 e ss.; diversamente, defendendo uma ideia de "alicitude", SANTOS, nota 3, p. 176 e ss., e, na linha deste, CARVALHO, Taipa de, nota 18, p. 178[298] e ss.

(41) SCHMIDT, Eb., Anmerkung, *SJZ*, 1949, p. 565.

(42) Ao contrário do que sustenta ROXIN I, § 16, n.º 39.

ções acabaria por ocorrer a morte da pessoa sacrificada (43). Cremos que nenhum destes argumentos é procedente. Quanto ao argumento "de princípio", é para nós evidente que a eutanásia não visa em caso algum cumprir o propósito e o valor "éticos" que verdadeiramente fundamentam a solução que defendemos: **o propósito e o valor "éticos" de preservação da vida dos outros** (44). No que toca ao argumento "pragmático", a verdade é que a margem de indeterminação que aqui se verifique nada tem de específico ou de estranho em todo o âmbito jurídico penal, onde constantemente se trabalha com juízos ditos "**de certeza**" e que, na verdade, não são mais que juízos que de um ponto de vista científico ou natural correspondem ao que se sabe que irá acontecer ou teria acontecido (45).

§ 24 De solução duvidosa se revelam as hipóteses em que, sem a acção de homicídio, outras vidas ameaçadas perecerão, mas em que a salvação de uma ou algumas vidas implica o exercício de um "**direito do mais forte**" ou a "**escolha**" da vida que deve ser sacrificada e da(s) que deve(m) ser salva(s), seja só a do agente, seja a de outros por ele "escolhidos". Uma tal situação pode ser ilustrada com os exemplos da *tabula unius capax*; ou — num enquadramento jurídico-penal algo diferente — com o "caso do piloto" ou com o "caso Mignonette". O que nestes casos impressiona desfavoravelmente no sentido da afirmação de um direito de necessidade é a circunstância de o agente se "arrogar as oportunidades" (46) de vida de outras pessoas, destruindo-as, através da imposição do direito do mais forte ou da escolha de quem deve morrer. De resto, no "caso do piloto", nem por se considerar que sobre este recai um dever de garante da não produção do resultado deixará o problema jurídico-penal de ser o do estado de necessidade para se tornar no do conflito de deveres (47), caso em que a respectiva justificação ficaria assegurada expressamente pelo art. 36.º-1 (infra, § 41 e ss.). E isto porque, como se dirá, um verdadeiro

(43) ROXIN I, §§ 16, 39 e s.

(44) Não serve por isso também argumentar com que qualquer solução deste teor conduziria a justificar que se matasse um moribundo para colher órgãos necessários a um transplante: neste caso a colheita é igualmente útil e possível se levada a cabo logo em seguida à morte (cerebral), como aliás é estatuído pelo nosso direito vigente: cf. FARIA, Paula Ribeiro de, nota 29, pp. 77 e ss., 113 e ss.

(45) *V. g.*, como se viu e o próprio Roxin ensina, em matéria de certos comportamentos alternativos lícitos: supra, 12.º Cap., § 33.

(46) Na expressão de OTTO, *Pflichtenkollision und Rechtswidrigkeitsurteil*, ³1978.

(47) Assim, no entanto, MANGAKIS, nota 34, p. 465 e s.

conflito de deveres só se verifica quando colidem dois deveres de acção, não um de acção e outro de omissão. Também no caso da *tabula unius capax* tendemos claramente para a negação da justificação, que só poderia ter por fundamento, em última análise, o "direito do mais forte": ainda aqui, tudo o que pode ficar em aberto é uma exclusão da culpa ([48]). Deve todavia afirmar-se que em toda esta problemática mais aprofundadas investigações se tornam ainda indispensáveis.

2.2. A "sensível superioridade" do interesse salvaguardado

§ 25 Segundo a al. *b)* do art. 34.º, para que a justificação em direito de necessidade seja reconhecida é necessário não apenas que, na ponderação de bens, o bem jurídico salvaguardado prepondere sobre o sacrificado, mas que haja "**sensível superioridade** do *interesse* a salvaguardar relativamente ao *interesse* sacrificado". Esta exigência é perfeitamente compreensível: no estado de necessidade, diferentemente do que sucede na legítima defesa, a acção de afastamento do perigo atinge, em regra, interesses de terceiros, no sentido de estranhos à situação de necessidade. Mas também aqui há que tomar na conta devida o que temos vindo a pôr em relevo: que não se trata apenas ou nem tanto de hierarquizar bens ou mesmo interesses jurídicos, mas — para de novo referir Fernanda Palma — de seleccionar "factores de ponderação" que não são "estritamente de ordem (interesses do legislador)", mas de "normal sensibilidade aos valores (cultural e socialmente determinada)" ([49]).

§ 26 Assim sendo, torna-se a nossos olhos claro aquilo que verdadeiramente a lei se propõe ao exigir a referida superioridade *sensível*: não tanto ou não só que o interesse salvaguardado se situe, numa escala puramente "aritmética", *muito acima* do interesse sacrificado, mas que a justificação ocorra apenas quando é **clara**, **inequívoca**, **indubitável** ou **terminante** a aludida superioridade à luz dos factores relevantes de ponderação ([50]).

([48]) No sentido, todavia, de uma não-ilicitude neste caso ("espaço livre de direito": supra, 14.º Cap., § 35 e s.), KAUFMANN, Arthur, Rechtsfreieraum und eigenverantwortliche Entscheidung, *Maurach-FS*, 1972, p. 465 e s.

([49]) PALMA, Fernanda, nota 1, p. 199.

([50]) Neste sentido, converge hoje porventura a maioria da doutrina alemã: cf., só, ROXIN I, § 16, n.º 90, S / S / LENCKNER / PERRON, § 34, n.º 45, STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 110. Contra, HIRSCH, *LK*, § 34, n.º 76, e, entre nós, CARVALHO, Taipa de, nota 18, p. 287[504].

Exigências de segurança jurídica falam neste sentido relativamente a uma hipótese que, como a do direito de necessidade, se repercute em princípio, insiste-se, na esfera jurídica de um estranho ao conflito. Também por isso, se a referida superioridade não é indubitável, no sentido acima referenciado, a justificação deve ser negada, não parecendo adequado argumentar contra esta solução com que ela conduziria a uma espécie de princípio *in dubio contra reum*. É neste contexto da avaliação da *sensível* superioridade do interesse a salvaguardar que nos parece caberem certos afeiçoamentos aos pontos de vista relevantes para a ponderação que acima deixámos fixados.

§ 27 Tenha-se em vista, desde logo, a circunstância de que, devendo a avaliação processar-se de acordo com critérios basicamente **objectivos**, nem por isso, todavia, pode em muitos casos ficar absolutamente fora de consideração a avaliação **subjectiva** da importância do bem a salvaguardar; assumindo relevo também neste contexto a circunstância de a lei falar sempre a este propósito da sensível superioridade do **interesse** e não do "bem jurídico". Isso explica, p. ex., que não possa recorrer à justificação do direito de necessidade o médico que leva a cabo uma intervenção cirúrgica que salvaria o paciente, mas que este recusa porque está disposto a morrer (art. 156.º) ([51]). O caso mais complexo é aqui o do **suicídio**: saber se, em casos tais, é relevante ou irrelevante (o que pode acontecer face à lei moral, mas só dificilmente se poderá defender perante a lei jurídica) a vontade do suicida ([52]).

§ 28 Discute-se, por outra parte, se a decisão sobre a sensível superioridade do interesse a salvaguardar deve ou não considerar-se influenciada pela circunstância de o perigo que ameaça o interesse respectivo provir, não de uma força natural ou de um facto juridicamente irrelevante de terceiro, mas de um seu **facto ilícito**. Será o caso, nomeadamente, de *A* cometer uma falsa declaração (art. 359.º) por ter recebido ameaças de morte se dissesse a verdade. Parece-nos seguro que será este mais um ponto de vista que, pesando em princípio contra a justificação (sobretudo se houver outras formas adequadas de afastamento ou diminuição do perigo), deve entrar,

---

([51]) Nestes termos, SANTOS, nota 3, p. 155 e s., e ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 156.º, § 34.

([52]) Fundamental, a respeito, BOTTKE, *Suizid und Strafrecht*, 1982; cf., ainda, na doutrina portuguesa, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 156.º, § 35.

conjuntamente com os restantes pontos de vista, na ponderação e na decisão sobre a sensível superioridade do interesse a salvaguardar ([53]).

§ 29 Finalmente, na decisão sobre a sensível superioridade deve entrar a circunstância de, em certas situações ou em consequência de certos estados ou profissões, o ameaçado poder estar obrigado a incorrer em **perigos especiais**. Em perigos especiais, dizemos, não a sofrer resultados danosos: não está aqui em causa, em nenhuma hipótese, uma qualquer "renúncia" do titular ao seu interesse ou bem jurídico. O soldado, o marinheiro, o polícia, o bombeiro ou mesmo o médico, o advogado ou o juiz não estão decerto obrigados a deixarem-se, *v. g.*, matar ou ferir gravemente para salvação da pátria, ou de bens pessoais ou patrimoniais de outra pessoa, ou em nome de uma correcta administração da justiça; mas podem seguramente ter de suportar **perigos acrescidos** em nome da função ou do cargo que desempenham, ou de utilizar apenas certos meios — meios "adequados" — para salvaguarda de interesses próprios.

3. A "adequação do meio"

§ 30 Logo o proémio do art. 34.º não confere a justificação por direito de necessidade à utilização pelo agente de um meio qualquer, mas apenas do "**meio adequado para afastar o perigo...**". Tem-se discutido vivamente se com esta exigência — feita também pela lei alemã — se põe um requisito *autónomo* e *adicional* da justificação; ou se se trata apenas de uma redundância, por o conteúdo atribuível a uma tal exigência já se poder conter nos requisitos anteriormente referidos. Considerada a generalidade das hipóteses que aquela doutrina costuma tratar neste enquadramento — deveres especiais de suportar o perigo, sentido ético-social da conduta a justificar, consideração de casos em que é a própria lei a levar a cabo a ponderação e a indicar o sentido da sua solução, preservação da autonomia pessoal da vítima ([54]) —, tenderíamos a pronunciar-nos no sentido da segunda alternativa, da redundância. Cremos todavia que a exigência tem sentido, se bem que mais óbvio e imediato do que aquele que a generalidade da doutrina alemã tende a imputar-lhe: o de que o facto não está

([53]) Essencialmente, neste sentido, ROXIN, Die notstandsähnliche Lage — ein Strafnunrechtsausschliessungsgrund?, *Oehler-FS*, 1985, p. 187 e ss., e, agora, I, § 16, n.º 58 e ss.

([54]) Indicação exaustiva em ROXIN I, § 16, n.º 91 e ss.

coberto por direito de necessidade se o agente utilizar um meio que, segundo a experiência comum e uma consideração objectiva, é **inidóneo** para salvaguardar o interesse ameaçado (55): *v. g.*, se para salvar bens patrimoniais ameaçados por um incêndio de grandes proporções o agente se serve de água subtraída a um vizinho com que enche pequenos baldes, ou se para uma interrupção da gravidez médica e juridicamente indicada se dão à grávida grandes quantidades de aspirina que lhe provocam uma úlcera do estômago. Tudo o que nestes casos pode ficar em aberto — mas não é chamado ao presente contexto — é um erro sobre os pressupostos do direito de necessidade (supra, 14.º Cap., § 23 e ss.).

4. O auxílio de terceiro

§ 31 Uma vez que aquilo que justifica a acção em direito de necessidade não é uma situação de coacção pessoal, mas a preservação do interesse sensivelmente preponderante, **qualquer pessoa** — e não apenas o ameaçado — pode levá-la a cabo e reivindicar-se da justificação. Isto mesmo diz o art. 34.º expressamente: "que ameace interesses juridicamente protegidos do agente **ou de terceiro**".

5. Requisitos subjectivos

§ 32 No que respeita às exigências subjectivas para afirmação do estado de necessidade justificante, o agente deve **conhecer a situação de conflito**, nos termos gerais expostos (supra, 14.º Cap., § 14 e ss.) e actuar com a **consciência de salvaguardar o interesse preponderante**. Questão é porém saber se — nomeadamente perante o teor literal do art. 34.º: "*para* afastar o perigo" — deve ainda exigir-se do agente uma **vontade** de defender o interesse preponderante (56). Uma resposta negativa parece impor-se. O argumento literal não tem valor: do que naquele contexto se trata é de uma caracterização do meio ("meio adequado para": cf. supra, § 30) e não de qualquer referência subjectiva; substancialmente, não teria sentido nem fundamento negar a justificação a quem salva outrem de um perigo para a sua vida ou o seu corpo à custa, *v. g.*, da danificação de

(55) Em termos próximos, SILVA, Marques da, II, p. 110 e s.; diversamente, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 213 e ss.

(56) Questão que divide a doutrina alemã: a favor da exigência, entre outros, HIRSCH, *LK*, § 34, n.º 45, e SAMSON, *SK*, § 34, n.º 54; contra, JAKOBS 11/21, e ROXIN I, § 16, n.º 105 e s.

uma coisa, só porque a sua intenção não foi autenticamente solidária mas motivada pelo desejo de aparecer na TV e assim se tornar célebre e ganhar dinheiro. Outra coisa significaria conferir valor decisivo, neste enquadramento, aos motivos da acção ([57]), o que seria decididamente de repudiar.

§ 33 Tão-pouco há que exigir do agente, como condição de eficácia justificante do estado de necessidade, uma *cuidadosa comprovação prévia dos pressupostos*: também disto já foi questão (supra, 14.º Cap., § 31) e não há qualquer razão para que se estabeleçam especialidades em matéria de direito de necessidade: seria intolerável negar a justificação a quem salvou uma vida ou evitou uma grave lesão na saúde de outrem porque — existindo realmente o perigo de lesão — o agente se não deu ao cuidado de comprovar previamente o pressuposto, mas o aceitou levianamente.

II. O estado de necessidade defensivo jurídico-penal

§ 34 Em data recente começou a considerar-se a possibilidade de subsumir ao preceito penal consagrador do direito de necessidade até aqui em estudo (dito direito de necessidade "agressivo" ou, como prefere Taipa de Carvalho, "interventivo" ([58]), em que o agente ofende em princípio um bem jurídico de "terceiro" não implicado para salvar um bem jurídico seu ou de outra pessoa) a figura do "estado de necessidade defensivo". O que há de específico nesta figura é que o agente que actua em estado de necessidade se **defende de um perigo que tem origem na pessoa que vai ser vítima da acção necessitada**. Em termos tais, porém, que o agente *não pode louvar-se de uma legítima defesa*, que não existe por falta de um requisito do facto perigoso: ou porque este nem sequer configura uma agressão (*A*, em pleno ataque epiléptico, vai quebrar um jarrão de porcelana chinesa de *B*, se não for afastado à força; uma criança, já em pleno processo de nascimento — e portanto já uma "vida" para efeito do art. 131.º ([59]) —, determina um sério risco de morte da mãe se o médico não levar a cabo a craniotomia da criança, normalmente porque sofre de hidrocefalia ([60])), ou porque não é ilícito (um automobilista, apesar de

([57]) Como exactamente notam STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 126.

([58]) CARVALHO, Taipa de, nota 18, p. 286.

([59]) Cf. DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 131.º, § 7 e ss.

([60]) Considerando — na companhia de uma parte significativa da doutrina alemã — esta hipótese como de estado de necessidade defensivo, ANDRADE, Costa, *Consentimento e Acordo em Direito Penal*, 1991, p. 255 e s., e DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 131.º, § 38. Contra, por último, JÄGER, Christian, Die Abwägbarkeit menschlichen Lebens im Spannungsfeld von Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie, *ZStW 115*, 2003, p. 772 e ss.

guiar com o cuidado e a observância de todas as regras, entra em derrapagem e vai matar um peão), ou porque não é actual (*C*, a quem *D* furtou uma bicicleta, encontra-o com ela no dia seguinte e ofende levemente a sua integridade física como única forma de recuperar o objecto furtado).

§ 35 Que, em qualquer destes casos, aos agentes deve ser creditada a **justificação** é solução com que hoje a generalidade da doutrina se encontra de acordo. Mas as divergências são muitas (e por vezes radicais) quanto a saber **que** concreta causa de justificação se lhes credita e, por conseguinte e sobretudo, **quais os seus pressupostos**. Simplificando o mais possível as discussões, reduzindo-as ao essencial sem por isso deixar de tentar ser exacto e justo para elas, pode dizer-se que duas grandes vias de solução têm sido aqui prosseguidas. Uma via pretende reconduzir ainda a situação **ao direito de necessidade justificante** que temos vindo a estudar; acentuando que a dificuldade maior que aqui se suscita pode ser ultrapassada (e só pode ser ultrapassada em termos justos e adequados) através de uma correcta interpretação — no essencial correspondente à que levámos a cabo — do que seja a "sensível superioridade do interesse a salvaguardar", nomeadamente quando ela se não reduza, contra a teleologia e o próprio texto de um preceito como o do art. 34.º, a um conflito de *bens jurídicos*, mas se alargue, como deve, a uma *ponderação global e concreta* do conflito de *interesses* em jogo: onde isso não for de todo possível a justificação deve ser negada ([61]). Outra via, cingindo-se rigorosamente à hierarquia dos *bens jurídicos conflituantes*, defende que a via anterior é de todo inaplicável e que a única solução reside em criar uma **causa supralegal de justificação**, concretamente, a do **estado de necessidade defensivo**. Causa de justificação que teria como pressupostos (1) uma situação de defesa à qual *falta um dos pressupostos* indispensáveis para configurar uma situação de legítima defesa, (2) a impossibilidade para o agente de *evitar* o perigo e (3) a *necessidade* do facto para o repelir, desde que (4) *o bem lesado pela defesa não seja muito superior ao bem defendido* ([62]).

([61]) Por outros, ROXIN, pormenorizadamente em Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, *Jescheck-FS*, 1985, p. 457 e ss., e, por último, I, § 16, n.º 72 e ss.; e, também, LENCKNER, *Der rechtfertigende Notstand*, 1965, p. 102 e ss., e S / S / LENCKNER / PERRON, § 34, n.º 30. Em sentido contrário, PALMA, Fernanda, nota 1, pp. 191 e s. e 198 e ss.

([62]) Uma primeira sugestão encontra-se em LAMPE, Defensiver und agressiver übergesetzlicher Notstand, *NJW*, 1968, p. 88 e ss. Com uma construção completa depara-se em HRUSCHKA, Extrasystematische Rechtsfertigungsgründe, *Dreher-FS*, 1977, pp. 192 e s., 203 e ss., e, levada às últi-

§ 36 Quanto à generalidade dos casos, as duas vias conduzem a soluções muito próximas. A favor da solução da aceitação de uma **causa supralegal** — baseada, quanto aos seus requisitos, na figura do *estado de necessidade defensivo jurídico-civil*, constante do § 228 do CC alemão — pode, em primeiro lugar, argumentar-se que ela repousa em *fundamentos legitimadores* diferentes dos que presidem ao direito de necessidade: este reside na **solidariedade** devida pelo titular do bem jurídico sacrificado à situação de perigo que atinge o agente e para a qual aquele não contribuiu, o estado de necessidade defensivo radica no *direito individual de autoprotecção e autodefesa* em situações em que não é cabida a legítima defesa. O outro argumento reside na circunstância de o estado de necessidade defensivo apresentar uma *estrutura* manifestamente diferente da do facto no exercício de um direito de necessidade: neste o bem jurídico sacrificado é de um *terceiro* alheio à criação da situação de perigo, naquele o bem jurídico a sacrificar pertence ao próprio **criador** da situação de perigo ([63]). Mas esta argumentação não tem de ser tomada como definitivamente procedente ([64]): a ideia de (uma certa) solidariedade não tem de considerar-se estranha ao estado de necessidade defensivo, máxime, de uma solidariedade para com terceiros dentro de uma comunidade de perigo; acrescendo que o fundamento do direito de necessidade (supra, § 3) não reside numa ideia nua e exclusiva de solidariedade, mas nesta ideia quando ligada à maximização da salvaguarda de interesses jurídicos em si dignos de protecção. Nem é correcta a ideia de que a *mera criação do perigo pelo agente* (salvo porventura se for pré-ordenada: supra, § 9)) exclui o direito de necessidade do art. 34.º

§ 37 Fica deste modo fundada a ideia de que o apelo a uma causa específica de justificação do estado de necessidade defensivo é pensado como *remédio* para colmatar eventuais lacunas deixadas por uma certa concepção — sobretudo sendo ela demasiado restrita no entendimento que faz dos requisitos da agressão ([65]) — do âmbito de tutela da legítima defesa.

---

mas consequências (incluída a proposta de "legalização" desta causa justificativa supralegal), entre nós, em CARVALHO, Taipa de, nota 18, p. 283 e ss., especialmente pp. 293 e ss. e 491.

([63]) Nestes precisos termos, CARVALHO, Taipa de, nota 18, pp. 285 e ss. e 289 e s.

([64]) Uma aprofundada discussão (para concluir no sentido do texto) em ROXIN I, § 16, n.º 75 e ss.

([65]) Como dissemos supra, 15.º Cap., § 3, ser, entre outras, a concepção de Taipa de Carvalho.

Acresce que a criação de causas *de justificação* supralegais é extremamente **perigosa** (sobretudo se não tiverem atrás de si, como na Alemanha, uma segura tradição jurisprudencial) pela **insegurança** que gera quanto ao alcance das próprias normas de comportamento e à sua função directora; por isso que a criação dos seus pressupostos estará em larga medida na dependência da opinião subjectiva de cada intérprete e aplicador, frequentemente influenciada pela opinião que faça sobre outras causas de justificação, em particular, a legítima defesa. Por último, mas *sobretudo*, temos por inadmissível — no plano textual e no plano teleológico — reduzir o critério essencial do estado de necessidade do art. 34.º à mera hierarquia dos bens jurídicos conflituantes: o princípio decisor é o da ponderação *concreta* dos *interesses conflituantes na situação globalmente considerada*. Ora, na verdade, o estado de necessidade defensivo **participa do fundamento** — não decerto da legítima defesa ou de uma qualquer situação a esta análoga, mas — **do estado de necessidade justificante**: o de conferir prevalência, numa situação complexa de conflito de bens e interesses, ao interesse que, numa consideração global da situação concreta, deva representar-se como o de maior valor. A partir daqui revelar-se-á perigoso ([66]), se não arbitrário, *inverter* pura e simplesmente, consoante o estado de necessidade seja interventivo ou defensivo, a proporcionalidade exigida dos interesses em jogo (*v. g.*, vir a considerar justificada a defesa contra um perigo não actual de ofensa grave para a integridade física à custa de um homicídio) ([67]). Em conclusão, sem prejuízo de se poder admitir, em princípio, a distinção conceitual entre estado de necessidade interventivo e defensivo, não parece impossível ou inadequado submeter ambas as figuras, no essencial, à regulamentação contida no art. 34.º e entendida nos termos que ficaram expostos. E, desta maneira, fazer do estado de necessidade defensivo "apenas" **um aspecto mais** — entre tantos outros que referimos — **da ponderação de interesses conflituantes** como cerne da figura do direito de necessidade.

([66]) ROXIN I, § 16, n.º 85 (a propósito do estado de necessidade *preventivo*): "não vá prevenir-se o mal com o pior".

([67]) É verdade que CARVALHO, Taipa de, nota 18, pp. 294 e 491, não exige que o bem lesado não seja "*sensivelmente* superior" ao bem defendido (como o art. 34.º/*b*)), mas sim que ele não seja "*muito* superior". Não vemos porém que isto invalide, ao menos no essencial, a crítica feita no texto.

III. O estado de necessidade jurídico-civil (art. 339.º do CC)

§ 38 À semelhança do que acontece em matéria de legítima defesa, a lei civil consagra também um estado de necessidade objectivo no art. 339.º do CC. Com esta disposição introduziu-se pela primeira vez, em termos inequívocos, a figura do estado de necessidade justificante no ordenamento positivo; mas também em relação a ela se poderá agora questionar **qual a sua relevância para efeitos de exclusão da responsabilidade jurídico-penal**, a partir do momento em que entrou em vigor o art. 34.º do CP. Tal como neste, a situação de necessidade prevista no art. 339.º-1 caracteriza-se pela existência de um *perigo actual que impenda sobre interesses do agente ou de terceiro* e a exclusão da ilicitude está dependente da *manifesta superioridade* destes em relação aos interesses sacrificados em ordem à sua salvaguarda. Mas ao contrário do art. 34.º, o art. 339.º-1 parece apenas admitir a justificação quando a protecção dos interesses ameaçados se faça à custa de interesses patrimoniais e já não de interesses pessoais (*v. g.*, integridade física, liberdade de movimento, honra). Para esta interpretação (68) contribuem a letra da lei, que define a acção necessitada como aquela que "destruir ou danificar *coisa* alheia", e a sua génese, pois foi esse o entendimento expresso nos trabalhos preparatórios do CC por Vaz Serra, autor do articulado relativo às causas de justificação (69). Não tem de ser, porém, necessariamente assim. Desde logo, porque uma tal interpretação conduziria à mesma contradição normativa e axiológica no âmbito do estado de necessidade que apontámos a uma certa concepção da legítima defesa jurídico-civil (supra, 15.º Cap., § 49). Depois, e decisivamente, porque a tal não se opõe, antes pelo contrário, a teleologia que enforma a figura do estado de necessidade jurídico-civil, fundada, também ela, numa ideia de solidariedade ligada à maximização da preservação de interesses juridicamente relevantes (70).

§ 39 Questão é ainda a do sentido a atribuir ao art. 339.º-2, nomeadamente, a de saber se através dele se deverá negar a justificação pelo

---

(68) JORGE, Pessoa, *Ensaio Sobre os Pressupostos da Responsabilidade Civil*, 1968, p. 256, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 207, VARELA, Antunes, *Das Obrigações em Geral*, 1996, p. 577 e s.

(69) SERRA, Vaz, Causas justificativas do facto danoso, *BMJ 85*, 1959, pp. 24 e s. e 109.

(70) Nesta direcção, COSTA, M. J. Almeida, *Direito das Obrigações*, 1998, p. 497 e s.. e BRITO, Teresa de, *O Direito de Necessidade e a Legítima Defesa no Código Civil e no Código Penal*, 1994, p. 73 e ss.

facto de **o agente ter contribuído para a criação da situação de necessidade**, recaindo o perigo sobre interesses próprios dele ou de terceiro. Propendemos a considerar que essa disposição não introduz qualquer requisito adicional ao n.º 1 no sentido da exclusão da ilicitude ([71]), respeitando somente à definição dos termos em que deverá ser atribuída a indemnização ao terceiro lesado, uma verdadeira indemnização por facto lícito. O problema da relevância a atribuir à circunstância de o agente ter responsabilidade na criação do perigo deve ser resolvido nos termos que apontámos para al. *a)* do art. 34.º (supra, § 9 e s.), por nos parecer também aqui ser essa a solução que permite realizar a mais justa composição dos interesses em conflito e, ao mesmo ao tempo, a que mais se aproxima da letra do preceito e do pensamento que esteve na sua origem ([72]). Assim, só será de afastar a justificação pelo estado de necessidade do art. 339.º-1 do CC nos casos em que o agente deliberada e intencionalmente deu origem à situação de necessidade para os seus próprios interesses, como meio de depois se poder fazer valer dela para se imiscuir na esfera de terceiros.

§ 40 Somos, pelo exposto, de parecer que **a exclusão da ilicitude penal por via do estado de necessidade objectivo é levada plenamente a cabo através do art. 34.º do CP**, sendo, todavia, o art. 339.º do CC idóneo a permitir uma paralela exclusão da ilicitude civil. A conclusão seria talvez outra se o CC tivesse consagrado a proposta de Vaz Serra para o regime do estado de necessidade. No articulado por ele apresentado (art. 1.º-3) fazia-se menção às situações em que o "perigo provém da própria coisa destruída ou deteriorada", não se exigindo nestas hipóteses que o interesse a salvaguardar fosse manifestamente superior ao sacrificado, mas apenas que este não fosse "notavelmente inferior" àquele ([73]). A fonte desta regulamentação residiu no § 228 do CC alemão que, como vimos, serve de base às construções do estado de necessidade defensivo como causa de justificação supralegal. A falta de um preceito semelhante no nosso ordenamento positivo retira suporte a uma tal fundamentação do estado de necessidade defensivo e reforça as objecções que formulámos à bondade dessa solução.

([71]) Assim, também, VARELA, Antunes, nota 68, p. 579 e s.; contra, JORGE, Pessoa, nota 68, p. 260, COSTA, M. J. Almeida, nota 70, p. 499, e BRITO, Teresa de, nota 70, p. 80 e ss.

([72]) Cf. SERRA, Vaz, nota 69, pp. 25 e s. e 109 e s.

([73]) SERRA, Vaz, nota 69, p. 110.

IV. O conflito de deveres de actuar justificante do art. 36.º

§ 41 Durante muito tempo não tomou a doutrina penal consciência da **especificidade** e (relativa) **autonomia** do conflito de deveres perante a teoria do estado de necessidade justificante ([74]): também aquele se reconduziria, na sua figuração jurídico-penal, a um conflito de interesses cuja solução deveria, em termos de justificação, correr parelha com a do direito de necessidade. É hoje geralmente aceite doutrina diversa, sem prejuízo do reconhecimento — unânime, pode dizer-se — de que o conflito de deveres repousa no mesmo fundamento justificador do direito de necessidade. Em todo o caso, a colisão de deveres assume especificidades — e decisivas, em termos de **solução do conflito** — que o autonomizam face ao direito de necessidade. Dessa consciência é fruto a regulamentação autónoma que o conflito de deveres recebe no nosso CP, na 1.ª parte do art. 36.º-1. Sem por isso deixar de dever afirmar-se que, em tudo quanto não sejam especificidades do conflito de deveres, valerá para este a teoria que acima se expôs para o estado de necessidade justificante. Não é todavia unívoco — longe disso — determinar quando existe um **verdadeiro conflito de deveres** (e não apenas um conflito meramente *aparente*) para efeito do art. 36.º-1, 1.ª parte. Por aí começaremos o nosso tratamento.

§ 42 Autêntico conflito de deveres susceptível de conduzir à justificação existe apenas quando na situação colidem distintos **deveres de acção, dos quais só um pode ser cumprido**; no exemplo de escola, quando o pai vê dois filhos em risco de se afogarem e apenas pode salvar um deles. Fora ficam por isso os casos em que o conflito se dá entre um dever de *acção* e um dever de *omissão*, *v. g.*, no exemplo referido dos "médicos de Hitler" (supra, § 21), porventura também no do "piloto do *ferry*" (supra, § 20): aí colidia um dever de acção (o de salvar o maior número possível de doentes mentais ou de crianças) e um dever de omissão (o dever de se abster de sacrificar um número limitado de vidas). Em hipóteses destas não existe um autêntico conflito de deveres para efeito do art. 36.º-1, 1.ª parte ([75]): o que então sucede é que um dever de acção

([74]) Sobre este problema, cf. SANTOS, 3, p. 95 e ss.

([75]) Como no texto, CORREIA, Eduardo, II, p. 93 e ss., DIAS, Figueiredo, Pressupostos da punição e causas que excluem a ilicitude e a culpa, *JDC 1983*, p. 63, SILVA, Marques da, II, p. 124,

entra em contradição com o dever (geral) de não ingerência em bens jurídicos alheios, pelo que o que verdadeiramente e no fundo se verifica é uma *colisão de interesses* que deve ser decidida segundo o art. 34.º e a teoria do estado de necessidade justificante.

§ 43 Justamente por ser assim é que surge, em plenitude, o **específico problema** e a razão de **autonomia** do tratamento jurídico-penal do conflito de deveres justificante: remetendo-o pura e simplesmente para o direito de necessidade teríamos que a justificação só teria lugar se o dever cumprido (ou, mais rigorosamente, a ponderação dos interesses nesse cumprimento implicados) fosse de valor *sensivelmente superior* àquele que se infringe (ou aos interesses respectivos). O que, uma vez dito, logo se compreenderá constituir uma solução inaceitável: seria deste modo ilícito (embora eventualmente não culposo) o facto de o pai salvar apenas um dos seus dois filhos em risco de afogamento, porque este salvamento tornou impossível salvar também o outro; como seria ilícito (eventualmente não culposo) o facto do médico que, perante dois doentes igualmente necessitados de reanimação, salvasse apenas um porque, uma vez cumprido o necessário processo de reanimação, o outro havia já morrido! A única solução materialmente justa — e correspondente ao sentido jurídico do lícito e do ilícito, uma vez que a situação exclui em absoluto a possibilidade de uma conduta que não lese nenhum dos bens jurídicos em conflito — é considerar justificado o facto correspondente ao cumprimento de um dos deveres em colisão, mesmo à custa de deixar o outro incumprido, **suposto que o valor do dever cumprido seja pelo menos igual** — vale dizer, igual ou superior, mesmo que o não seja "sensivelmente" — **ao daquele que se sacrifica** ([76]). Deve ponderar-se que no conflito de deveres, diferentemente do que sucede no conflito de bens, o agente *não é livre* de se imiscuir ou não no conflito. Mesmo perante deveres iguais, ele

---

ROSA, Cortes, Die Funktion der Abgrenzung von Unrecht und Schuld im Strafrechtssystem, *Coimbra-Symposium Roxin*, p. 205 e s., e uma parte, que pensamos hoje dominante, da doutrina alemã, na forma de uma causa supra-legal de justificação: entre outros, JAKOBS, 15/6, ROXIN I, § 16, n.º 117 e ss., S / S / LENCKNER / PERRON, n.º 71 antes do § 32, STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 119. Contra, SANTOS, nota 3, pp. 95 e ss. e 129 e s., e para a Alemanha, entre outros, D / TRÖNDLE, n.º 11 antes do § 32, GALLAS, nota 30, p. 311 e ss., HRUSCHKA, nota 62, p. 192 e s.

([76]) Assim, decidida e pormenorizadamente, CORREIA, Eduardo, II, n.º 19, e ROSA, Cortes, nota 75, p. 205 e ss., criticando a conclusão de GÜNTHER, *Strafrechtswidrigkeit und Strafunrechtsausschuss*, 1983, p. 332, que pretende ver aqui uma simples causa de exclusão do ilícito especificamente penal.

deve pelo menos cumprir um deles, sob pena de o seu comportamento ser ilícito. Se, com isto, ele torna impossível o cumprimento do outro dever, em todo o caso o seu comportamento, porque correspondente a uma imposição jurídica, não pode ser ilícito ([77]). Outra solução, de resto, equipararia, sob o denominador comum da ilicitude, aquele que faz tudo quanto lhe é possível (cumprindo um de dois ou mais deveres, ainda que iguais) àquele que nada faz e não cumpre nenhum dos deveres. É esta pois a solução correcta do conflito, a qual não poderia ser lograda nos quadros do direito de necessidade do art. 34.º e que, certamente por isso, o art. 36.º-1, 1.ª parte, expressamente consagra. Nos exemplos apontados, por conseguinte, a conduta do pai e do médico não é apenas não culposa, mas justificada e por isso, em definitivo, lícita.

§ 44 Dir-se-á contra a solução — e tem-se na verdade dito — que ela cobre com o manto da licitude condutas arbitrárias dos agentes, nos nossos exemplos, do pai que "escolheu" salvar o filho *A* em vez do filho *B*, do médico que "escolheu" salvar o acidentado *C* em vez do *D*. É naturalmente verdade. Mas sendo a alternativa deixar perecer *A e B*, ou *C e D*, não se vê que argumento moral, social ou jurídico possa retirar-se daqui contra a solução legalmente imposta. Para além disto, cumpre acentuar que — tal como no direito de necessidade do art. 34.º — também no conflito de deveres o resultado da ponderação (igualdade dos deveres, superioridade ou inferioridade do dever cumprido) não deve resultar simplesmente da hierarquia dos bens jurídicos em colisão, mas da **ponderação concreta dos interesses em conflito no quadro da situação global**. Se, por isso, uma corporação de bombeiros é chamada simultaneamente para apagar dois incêndios, ela deve dar preferência ao que se revele de maiores proporções, ou contenha maiores perigos para as pessoas, ou ameace bens patrimoniais de maior valor. O médico chamado ao local de um acidente deve, na medida possível, prestar socorro segundo a ordem de gravidade dos ferimentos. Aquele sobre quem recaia um dever geral de auxílio, nos termos do art. 200.º, deve — suposta uma fundamental igualdade dos perigos em que todas as vítimas incorram — socorrer primeiro o seu filho acidentado e só depois, se possível, os companheiros, se relativamente ao

([77]) Considerando, em relação ao dever violado, haver não uma exclusão da ilicitude, mas da própria tipicidade, CARVALHO, Taipa de, nota 18, p. 172[294] e s. Discordando já desta abordagem, SANTOS, nota 3, p. 12.

filho pesar sobre ele um especial dever de garante (art. 10.º-2 e infra, 38.º Cap., § 28 e ss.).

§ 45 A 2.ª parte do art. 36.º-1 estende o regime cabido ao conflito de deveres ao **conflito de ordens legítimas da autoridade**. Trata-se de uma evidência tal que é difícil não considerar este segmento do preceito uma pura *inutilidade*: se as ordens são ambas legítimas (e por isso de cumprimento obrigatório para os destinatários); e se o cumprimento de uma delas torna impossível o cumprimento da outra, então parece evidente que o caso constitui, pura e simplesmente e sem nenhuma especificidade notável, uma hipótese de *conflito de deveres*, ao caso devendo por isso aplicar-se o regime que para este vale.

17.º CAPÍTULO

OS CONSENTIMENTOS JUSTIFICANTES

I. O consentimento real ou efectivo (ou simplesmente "consentimento")

§ 1 Continuaremos o estudo dos singulares tipos justificadores mais importantes em perspectiva jurídico-penal considerando agora o do *consentimento* (real ou efectivamente prestado), às vezes dito também (de uma forma aceitável embora só aproximativa, ver-se-á já porquê: infra, §§ 2 e 4) "consentimento do *ofendido*" ou "consentimento do *lesado*". Entre as causas justificativas expressamente reguladas na PG do nosso CP, foi esta a doutrinalmente aceite em data mais recente (1) -- talvez porque se julgava não ser ela recondutível a um verdadeiro "conflito de interesses" (recorde-se, supra, 14.º Cap., § 13, o ensino de Mezger, que a imputava antes a uma "*falta* de interesse") — e aquela que continua hoje a suscitar uma viva controvérsia construtivo-sistemática, nomeadamente quanto a saber se constitui uma verdadeira *causa de justificação* ou antes, logo, uma *causa de atipicidade* do comportamento. É esta porém uma questão que não deve ser teoreticamente relevante *a se*, antes importa lançar no contexto da pergunta essencial: a pergunta pelo fundamento de relevância jurídico-penal do consentimento.

1. O pensamento fundamental

§ 2 Em matéria de fundamento da relevância jurídico-penal do consentimento — do qual depende, em definitivo, o desenho dos requisitos de

---

(1) E também legislativamente: entre nós foi o CP de 1982 que consagrou de forma expressa esta causa justificativa no seu art. 38.º A generalidade dos códigos penais estrangeiros, de resto — o alemão incluído —, continua a não lhe dedicar qualquer disposição da PG. Para a história dogmática do instituto, CORREIA, Eduardo, II, n.º 4 e ss., e ANDRADE, Costa, *Consentimento e Acordo em Direito Penal*, 1991, § 1.

eficácia, do âmbito de aplicação desta causa justificativa e dos seus limites — têm-se defendido e continuam a defrontar-se ainda hoje várias posições básicas. (1) Uma delas — no essencial, coincidente com a antiga **teoria do negócio jurídico** — considerava que o consentimento do ofendido assume as características de um verdadeiro negócio jurídico (unilateral) e confere assim ao agente um *direito* à lesão de um bem jurídico seu; e porque o exercício de um direito não pode, simultaneamente, constituir um ilícito, o consentimento surge como uma autêntica causa de justificação ([2]). Pelo menos nesta forma "pura", porém, pode dizer-se que esta teoria não encontra hoje mais defensores, filha como é de uma já ultrapassada fase de desenvolvimento do pensamento da autonomia (e da "libertação") do direito e do ilícito penais face ao direito e ao ilícito civis. (2) Outra concepção coloca o acento tónico no **abandono do interesse** (e na consequente **renúncia à protecção penal**) por parte do titular, na medida em que o ordenamento jurídico confira a este a *disponibilidade* sobre os respectivos objectos de protecção ([3]). (3) Objectos que deste modo — acrescenta-se, ao mesmo tempo que com este *tournant* se integra no problema uma sua coordenada essencial: a razão por que em certos casos o direito "prefere" renunciar à protecção em vez de tutelar bens jurídicos — como que "desapareceriam" enquanto tais, por força da defesa da **autonomia pessoal** e do consequente **direito de autodeterminação** do titular do bem jurídico "lesado", que também ao direito penal cumpre preservar ([4]). Caso em que poderia falar-se não só de um legítimo abandono do interesse pelo seu titular mas, em larga medida, numa **renúncia ao bem jurídico** e não apenas à sua protecção penal. (4) Uma outra concepção ([5]) pretende só, perante a anterior, evidenciar mais fortemente o *thelos* do instituto, acentuando que a legitimação da força justificante do consentimento provém da **intenção político-criminal** de fazer com que em certos casos, perante a von-

([2]) Foi a posição de ZITELMANN, Ausschluss der Widerrechtlichkeit, *Archiv f. d. civilistische Praxis 99*, 1906, p. 56.

([3]) Fundamentalmente, neste sentido, CORREIA, Eduardo, II, p. 20, na esteira de HONIG, *Die Einwilligung des Verletzen*, 1919, e de MEZGER, p. 208. No essencial desta direcção corre ainda hoje, se bem julgamos, a maioria da doutrina alemã, que pode ver-se recenseada em S / S / LENCKNER, n.º 33 antes do § 32; e, entre nós, SILVA, Marques da, II, p. 127.

([4]) Nesta direcção, sobretudo, STRATENWERTH, Prinzipien der Rechtfertigung, *ZStW 68*, 1956, p. 43.

([5]) De que talvez NOLL, *Übergesetzliche Rechtfertigungsgründe im besondern die Einwilligung des Verletzen*, 1955, p. 74 e ss., possa considerar-se o precursor; cf., depois, com indicações concordantes, JESCHECK / WEIGEND, § 34, II, 3.

tade de auto-realização do titular do bem jurídico (6), o direito penal permita que essa vontade se sobreponha ao interesse comunitário de preservação do bem jurídico e acabe por lhe conferir prevalência

§ 3 Esta última concepção é, a nossos olhos, fundamentalmente exacta. Mas importa acentuar nela alguns vectores que nos não parecem ainda pensados com suficiente decisão pela doutrina dominante. Também o consentimento surge como um caso de **colisão de interesses em si mesmos dignos de tutela penal**. De um lado está o interesse jurídico-penal (que conforma, como sabemos, a mais autêntica justificação social do direito penal) na preservação de *bens jurídicos*; o qual não desaparece ou não é eliminado por força do consentimento do titular. Os casos de consentimento são, em definitivo, casos de lesão *efectiva* de bens jurídicos; são casos, no correcto entendimento de Costa Andrade, em que se verifica e se mantém a "perda" que a lesão de um bem jurídico sempre representa ao nível do sistema social (7). Do outro lado, porém, está o interesse, também jurídico-penalmente relevante, de preservação (também ela um bem jurídico!) da *auto-realização* do titular do bem jurídico lesado, da sua *autonomia* pessoal e de vontade. Em certos casos e sob certos pressupostos — quando o bem jurídico lesado é pela lei considerado como "disponível" pelo seu titular; e quando a lesão ao nível do sistema social é ainda reputada pela lei de menor relevância do que a auto-realização do agente — a lei penal resolve o conflito concedendo prevalência à realização do "sistema pessoal" do agente sobre a perda ao nível do "sistema social" e confere a consequente justificação ao facto típico praticado. É este o fundamento da eficácia justificante do consentimento; e é ele que ilumina, do mesmo passo, os *pressupostos* desta eficácia, o *âmbito* e o *estatuto dogmático-sistemático* do consentimento jurídico-penal.

2. O estatuto dogmático-sistemático do consentimento

§ 4 Relativamente a este "estatuto dogmático-sistemático", o que ficou dito já serve para afastar a tese, hoje cada vez mais difundida, de que

(6) CARVALHO, Taipa de, II, p. 280 e s., revela o seu incómodo pela circunstância de falarmos, neste contexto, de "auto-realização pessoal". Por muito que isso lhe custe a "ver" (p. 281), porém, é todavia óbvio que — para apresentarmos um exemplo drástico e mesmo, porventura, chocante para alguns — a prática de actos sexuais masoquistas pode legitimamente constituir, para o direito penal, parte da *auto-realização pessoal* do titular do bem jurídico "integridade física".

(7) ANDRADE, Costa, nota 1, p. 176 e ss.

o consentimento não constituiria nunca uma causa de justificação, mas sim **sempre uma causa de exclusão da tipicidade do facto.** É indiscutível que (como de resto sempre se reconheceu) casos há em que o "dissentimento" — *rectior*, o agir contra a vontade do (formalmente ou aparentemente) "lesado" — conforma um elemento do tipo objectivo de ilícito e em que por isso, nesta acepção, o "consentimento" constitui uma causa de atipicidade ou de "exclusão" da tipicidade ([8]). É o que sucede sempre que a autodeterminação do atingido constitui o único objecto de protecção, *v. g.*, na generalidade dos *actos sexuais praticados por adultos*: se *A* pratica actos sexuais de relevo com *B*, mas os actos são levados a cabo de pleno acordo, não pode decerto afirmar-se, *ab initio*, que o comportamento de *A* preenche o tipo objectivo de ilícito da coacção sexual (art. 163.º); e o mesmo se diga relativamente à cópula ou ao coito anal ou oral para efeito do tipo objectivo da violação (art. 164.º).

§ 5 Não são porém estes casos que se têm em vista quando a mencionada doutrina afirma que o consentimento constitui uma causa de *atipicidade* e não de justificação; mas sim todos aqueles outros (*v. g.*, quando *C* ofende a integridade física de *D*, art. 145.º; ou quando *E* danifica um objecto pertencente a *F*, art. 212.º, tendo *D* e *F* consentido nas lesões respectivas) em que o recurso ao teor do tipo legal ou mesmo à sua teleologia não permite nenhum juízo definitivo sobre se o acordo do atingido com o comportamento constitui ainda um elemento incompatível com o ilícito que elimina a própria lesão do bem jurídico. Ora, é precisamente aqui que intervém o argumento (pretensamente) definitivo com que se esgrime a favor da atipicidade dos comportamentos levados a cabo com o acordo do atingido: é que, diz-se, **em todos os casos em que a lei proteja a liberdade de disposição do indivíduo, o acordo do interessado faz com que não possa nem deva falar-se de violação do bem jurídico** ([9]). Deste modo ficando constituído um verdadeiro **paradigma monista** do relevo jurídico-penal do consentimento: este seria *sempre* uma causa de atipicidade do comportamento, *nunca* uma simples causa de justificação.

([8]) Assim, CORREIA, Eduardo, II, p. 19, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 249 e s., e SILVA, Marques da, II, p. 126 e s.

([9]) Particularmente impressivo, ROXIN I, § 13, n.º 12. Na doutrina portuguesa, CARVALHO, Taipa de, *A Legítima Defesa*, 1995, p. 160[272] e s., parece seguir também esta linha monista.

§ 6 Sempre pensámos não assistir razão a quem pensa assim ([10]). Decerto que relativamente a bens jurídicos individuais e disponíveis a lei não deixará nunca de entrar em linha de conta com o valor de protecção do poder de disposição do titular. *Isso não significa porém que em todos estes casos ela se desinteresse da sua função (primária) de tutela do bem jurídico*. Antes, como Costa Andrade demonstrou de forma convincente, continua a importar que se leve aqui a cabo uma distinção fundamental. Casos há na verdade em que, logo segundo o tipo de ilícito, o *acordo* do interessado faz com que a realização do comportamento **corra no mesmo sentido da tutela do bem jurídico** e faça com que a acção, antes que "lesar" o bem jurídico, contribua para uma sua mais perfeita realização; como é paradigmaticamente o caso do tipo de "introdução em casa alheia": se *A* se põe de acordo com *B* no sentido de que este o visite em certo dia ou a certa hora, a introdução de *B* em casa de *A* não representa para este qualquer lesão do seu bem jurídico "intimidade da vida privada" mas, *pelo contrário*, é condição de realização plena daquele mesmo bem jurídico ([11]). Pode por isso afirmar-se, com Costa Andrade, que em casos deste teor não existe qualquer oposição (não se verifica, *in casu*, nenhum *conflito*) entre o "sistema pessoal" e o "sistema social", entre a auto-realização de *A* e a integridade do bem jurídico só aparentemente lesado. Nestas hipóteses, por conseguinte, o **acordo** do titular do bem jurídico empresta à conduta o signo indisfarçável da **atipicidade**.

§ 7 **O mesmo não sucede, porém, em muitos outros casos**: aqueles em que a lei se depara com um autêntico *conflito* — que nas hipóteses do parágrafo anterior verdadeiramente não existe — entre o valor da auto-realização pessoal e uma **perda efectiva** ao nível do bem jurídico efectivamente lesado: com um conflito entre, nas expressões de Costa Andrade pedidas a Luhmann, o "sistema pessoal" e o "sistema social"; sistema, este último, que na verdade entra em certos casos em *colisão* incontornável com o sistema pessoal. É o caso, *v. g.*, de *A* consentir que *B* lhe dê uma pancada, ou de *C* consentir que *D* destrua uma jóia sua. Nes-

([10]) Na esteira da posição sempre assumida por CORREIA, Eduardo, II, n.º 4. Sobre o que se segue (e como se segue), ANDRADE, Costa, nota 1, p. 190 e ss. e *passim*.

([11]) Cf., todavia, o Ac. do STJ de 23-3-1994 (Proc. 046 075) que apelou ao *consentimento* para excluir a ilicitude no caso em que um rapaz de 19 anos penetrou no quarto de uma jovem mais velha que o havia convidado para um encontro nocturno, tendo sido ambos surpreendidos pelo pai daquela, que o acusou de violação de domicílio (art. 190.º).

tas hipóteses pode ser que a lei acabe por conceder prevalência à auto-realização de *A* e de *C*; mas se o faz, fá-lo em detrimento da "perda" (ao nível do sistema social) de bens jurídicos que efectivamente lhe competia proteger: a integridade corporal de *A* na primeira hipótese, a propriedade de *C* na segunda. Não pode nestas situações afirmar-se (como nas anteriores) que o consentimento corre parelha com a tutela do bem jurídico e concorre para uma mais plena realização da tutela. Pelo contrário, aqui o conflito é inarredável e a sua solução depende de qual o bem jurídico conflituante a que a lei entende dar prevalência, no caso, à auto-realização de *A* e de *C*. Por isso aqui — não o simples *acordo*, mas verdadeiramente — o **consentimento** funciona como uma autêntica causa justificativa. É, em conclusão, isto que poderemos designar, ainda com Costa Andrade ([12]), como o "paradigma **dualista**" do consentimento e que, em nossa opinião, corresponde à melhor doutrina tanto *de iure dato*, como *de iure dando*.

§ 8 Não cremos, por isso, merecedoras de aceitação algumas orientações que hoje se vão apresentando como **perspectivas intermédias** face aos dois paradigmas enunciados. Será esse o caso de Arzt, que pretende renunciar à distinção entre "acordo" e "consentimento", para propugnar soluções individuais consoante a conformação e sentido do tipo incriminador em questão ([13]). Ou o caso de Stratenwerth, ao acentuar que com soluções esquemáticas nada se ganha, tudo devendo depender dos concretos pressupostos de eficácia do consentimento ([14]). Ou o caso mais recente — e de mais claro "compromisso" — de De Vicente Remesal, segundo o qual, nos casos de consentimento eficaz do atingido, nos quais o seu bem-estar é lesado ou lhe é infligido um dano, não pode ser negada a lesão de um bem jurídico; mas apesar disso a tipi-

---

([12]) Atente-se logo no subtítulo da sua dissertação de doutoramento referida na nota 1: "Contributo para uma refundamentação de um paradigma dualista". Acompanhando, também, Costa Andrade, FARIA, Paula Ribeiro de, *Aspectos Jurídico-Penais dos Transplantes*, 1995, p. 245 e ss. Defendendo, no fundo, uma solução dualista mas sendo mais restritivo que o texto, no sentido de diminuir os casos que chamamos de acordo e, portanto, de exclusão da tipicidade, PEÑA, Luzón, Causas de atipicidad, *Problemas Fundamentais de Direito Penal, Homenagem a Claus Roxin*, 2002, p. 113 e ss. CARVALHO, Taipa de, II, § 784 e ss., embora diga inclinar-se para a teoria dualista, acaba por advogar uma tríplice configuração do consentimento, sob a forma de acordo, de exclusão da ilicitude (a consagrada no art. 38.º) e de causa de justificação. A seu ver, só quando o consentimento seja determinado por uma "razão juridicamente boa" (§ 793) poderá produzir a justificação. Tese que deve ser recusada, não só porque resulta na criação de uma causa de justificação supra-legal desnecessária, propícia à criação de equívocos em matéria que carece de linhas de orientação claras, como também porque, como afirmámos supra (14.º Cap., § 16), a ilicitude só pode ser objecto de afirmação ou negação, sendo-lhe alheia uma ideia de aprovação ou de mera tolerância pelo Direito.

([13]) ARZT, *Willensmängel bei der Einwilligung*, 1970.

([14]) STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 11.

cidade deve ser excluída porque o bem jurídico não exige qualquer tutela ([15]). Persistimos, perante estas orientações, na convicção do bom fundamento do paradigma dualista, na diferença evidenciada da situação do bem jurídico num e noutro caso e nas consequências que daí devem ser retiradas para o estatuto dogmático-sistemático do consentimento como causa de justificação.

§ 9 Quando, em caso de conflito, a lei concede prevalência à auto-realização pessoal e quando a concede ao bem jurídico efectivamente lesado é coisa que já não depende tanto da compreensão dogmático-sistemática do consentimento, quanto — nesta parte assiste plena razão a Stratenwerth — dos seus **pressupostos de eficácia**. Isto pode conduzir às maiores dificuldades em determinar, no caso concreto, se estamos perante um acordo que exclui a tipicidade ou de um consentimento que exclui a ilicitude. O caso exemplar é fornecido pelas ofensas à integridade física consentidas: tratando-se nelas, como diremos, de um bem jurídico disponível, mas traduzindo-se o seu consentimento na lesão efectiva de um bem jurídico, o consentimento deve funcionar como causa de justificação. Todavia, derivando a ofensa corporal de uma **intervenção médico-cirúrgica**, medicamente indicada, levada a cabo segundo as *leges artis* e dotada de finalidade terapêutica, já se compreenderia que o consentimento funcionasse aí como *acordo* que exclui a tipicidade. Mais longe vai todavia a nossa lei, considerando que uma intervenção médico-cirúrgica dotada das características acima mencionadas *nunca* constitui uma ofensa corporal (art. 150.º); se todavia ela for levada a cabo *sem consentimento* então o facto integra um crime autónomo — o dos chamados "tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários": art. 156.º — configurado, *et pour cause*, como um crime contra a liberdade pessoal e onde, por conseguinte, o "acordo" exclui a tipicidade. Deve louvar-se a coragem do CP em ter regulado de forma muito clara a questão e ter assim fornecido um critério altamente tranquilizador, pela clareza e segurança que fornece, a quem actua em área tão delicada ([16]). Mas pode perguntar-se se não terá ido

([15]) DE VICENTE REMESAL, Die Einwilligung in ihrer strafrechtlichen Bedeutung, *Roxin-FS*, 2001, pp. 379 e ss., 392, 399.

([16]) DIAS, Figueiredo, *O Problema*, § 21, I, 2, e O problema da ortotanásia: introdução à sua consideração jurídica, *in*: AA.VV., *As Técnicas Modernas de Reanimação; Conceito de Morte; Aspectos Médicos, Tedológico-Morais e Jurídicos*, 1973, p. 37 e ss.; DIAS, Figueiredo / MONTEIRO, Sinde, Responsabilidade médica em Portugal, *BMJ 332*, 1984, p. 61 e ss.; ANDRADE, Costa, nota 1, p. 400 e ss., e *Comentário Conimbricense*, I, art. 150.º, § 9 e ss., e art. 156.º, §§ 9 e 25; e, por último, FIDALGO, Sónia, *Responsabilidade Penal por Negligência no Exercício da Medicina em Equipa*, diss. de mestrado na FDUC, 2006, p. 28 ss.

longe demais, ao negar pura e simplesmente relevância típica à falta de consentimento para a qualificação de toda e qualquer intervenção médico-cirúrgica correcta como ofensa corporal. Usando do critério acima exposto, poderá dizer-se, *v. g.*, que a amputação, sem consentimento, de uma perna do melhor futebolista do mundo ou de uma mão da melhor pianista — mesmo que medicamente correctas — só contende com a auto-realização dos pacientes e não representa uma definitiva "perda" a nível do sistema social ([17])? *Jure dato*, certamente que sim, tendo sido esta uma decisão "autopoiética" legítima do legislador. Mas, apesar disso, talvez valha a pena continuar, *iure dando*, a discutir a questão no futuro.

3. A questão do "objecto" do consentimento

§ 10 Uma questão a que, em tempo recente, se pretende conferir particular relevo teorético e prático-normativo é a que respeita ao objecto sobre que deve recair o consentimento ([18]). Questão em que se defrontam duas teses: a dominante, segundo a qual o consentimento tem de abranger, nos crimes de resultado, **tanto a acção, como o resultado típicos** ([19]); e a minoritária, para a qual o consentimento — máxime, nos crimes negligentes — tem por verdadeiro objecto **apenas a acção**: "quem consente num comportamento perigoso assume por essa via, conscientemente, o risco de uma lesão" ([20]). A questão assumiu um relevo até há pouco insuspeitado pela circunstância de se pensar decisiva para determinação do tratamento prático-normativo de acções (de massa) que se verificam

([17]) Em sentido claramente afirmativo, ANDRADE, Costa, locs. cits.; duvidoso, já, DIAS, Figueiredo, locs. cits. na nota anterior. Talvez não seja ocioso assinalar que na Alemanha, onde a doutrina dominante se pronuncia a favor da solução contida no CP português — sem todavia faltarem vozes a pretenderem que o acordo é condição de exclusão da tipicidade da intervenção médica, ao menos em certos casos, *a nível da ofensa corporal* —, o consenso ainda não foi ao ponto de permitir que a solução encontrasse assento na lei, continuando assim a constituir uma questão jurisprudencial e doutrinal em aberto. Sobre todo o problema, cf., aprofundadamente, a generalidade das contribuições luso-alemãs para o *Colóquio Novas Tarefas e Fronteiras do Direito Penal Médico*, *RPCC 14*, 2004, p. 1 e ss.

([18]) Uma exposição e análise aprofundada em ANDRADE, Costa, nota 1, p. 295 e ss., *Comentário Conimbricense*, I, art. 149.º, § 16 e ss., e As lesões corporais (e a morte) no desporto, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, 2003, p. 697 e ss.

([19]) Neste sentido, com larga informação comparada, ANDRADE, Costa, locs. cits.

([20]) Assim, HIRSCH, Einwilligung und Selbsbestimmung, *Welzel-FS*, 1974, p. 775 e ss., e *LK*, n.º 107 antes do § 32; e também — para os delitos negligentes — SCHAFFSTEIN, Handlungsunwert, Erfolgsunwert und Rechtfertigung bei den Fahrlässigkeitsdelikten, *Welzel—FS*, 1974, p. 557 e ss.

em campos tão diversos como os das lesões da integridade física ou da morte ocorridas por via de intervenções médico-cirúrgicas (perigosas, mas indispensáveis em último recurso) ainda não cobertas pelas *leges artis*, de experimentações clínicas, de transplantes entre vivos, de transmissão do vírus da SIDA, de práticas desportivas perigosas, etc.

§ 11 A questão que aqui se discute é fundamentalmente a de saber se a solução prático-normativa que se alcance deve ser ainda imputada à eficácia justificativa do **consentimento** ou antes a construções dogmáticas autónomas relativamente àquela causa justificativa, nomeadamente, as da **adequação social**, do **risco não permitido** ou, mais concretamente, da **heterocolocação em risco consentida** (supra, 12.º Cap., § 38). Mesmo restringida a questão — como por ora devemos — exclusivamente aos *crimes dolosos de acção*, parece seguro que o consentimento tem de referir-se não só à acção, mas também ao resultado típico. Mas já não parece seguro — longe disso — o que deva entender-se por "consentir no resultado". Se este se traduz (como dissemos supra, 11.º Cap., § 39) num efeito da acção sobre o seu objecto, este *cindido espácio-temporalmente* daquela, consentir no resultado significa não mais que *consentir* no (ou aceitar, ou conformar-se com o) risco de verificação do resultado: e tal é o que sucede naqueles campos que no parágrafo anterior enunciámos. O que aliás, cremos, não surpreenderá aqueles para quem, como para nós, a *criação de um risco proibido* constitui uma das traves mestras da ilicitude material e, em particular, da teoria da imputação objectiva. Com a consequência, assim, de que, se aquele consentimento se não verificar validamente, o comportamento lesivo do bem jurídico constitui em definitivo um ilícito-típico (ressalvada, nomeadamente, no campo das intervenções médicas, a eventual intervenção de um direito de necessidade: supra, 16.º Cap., § 7, *in fine*). Isto não significa que os complexos problemáticos referidos tenham que ser definitiva e completamente resolvidos em sede de consentimento como causa de justificação; mas significa que **uma sua eventual justificação passa pelo (ou não pode pelo menos abstrair do) estatuto do consentimento como causa de exclusão da ilicitude**.

4. Pressupostos de eficácia do consentimento justificante

4.1. O carácter pessoal e a disponibilidade do bem jurídico lesado

§ 12 Lesado pelo facto consentido só pode ser um bem jurídico **pessoal**: porque em rigor só este tem um portador ou um titular individuali-

zável; mas em definitivo porque, se a relevância do consentimento advém do respeito pelo valor da auto-realização *pessoal*, só a pessoa (individual, em regra, mas podendo também tratar-se de pessoa colectiva, quando ela seja titular de um interesse juridicamente relevante lesado pela conduta: *v. g.*, consentimento de pessoa colectiva na ofensa ao seu prestígio, art. 187.º) pode prestar de forma eficaz o seu consentimento.

§ 13 Relacionado com esta questão suscita-se o problema porventura mais complexo dos pressupostos de eficácia do consentimento: o do necessário (art. 38.º-1) carácter "**livremente disponível**" do interesse a que o consentimento se refere. Indisponíveis são seguramente os **bens jurídicos comunitários** como tais protegidos ([21]): nestas hipóteses, mesmo as pessoas em que tais bens jurídicos se corporizem não podem invocar, perante o verdadeiro "titular" do bem jurídico, a sua vontade e o valor da sua auto-realização pessoal. Para conceder a essas pessoas uma tal relevância é a lei penal instrumento notoriamente ilegítimo, tudo devendo nesta matéria ser deferido a formas *políticas* de expressão e de acção. No que toca a bens jurídicos individuais, o do **património** não suscita, no outro extremo, dificuldades especiais (por mais que às vezes se tente restringir esta afirmação apelando à conhecida função *social* da propriedade individual): ele é em princípio disponível pelo seu titular e por isso, sempre que a concordância assuma a forma de *consentimento* (*v. g.*, no crime de dano: art. 212.º) e não de simples *acordo*, o consentimento deve considerar-se relevante. Questionável é assim, principalmente, a situação relativamente aos bens jurídicos *vida* e *integridade física*.

§ 14 Lembrando que o tratamento presente tem por objecto os delitos *dolosos* de acção, a doutrina praticamente unânime segundo a qual **a vida** constitui um bem jurídico **absolutamente indisponível** merece concordância. Indisponível, acentue-se desde já, perante lesões provenientes de *terceiros*, não quando provenientes do seu próprio *titular*: o suicídio, mesmo sob a forma tentada, não constitui um ilícito típico. Já perante ataques de terceiro, porém, a prova positiva — se necessária fosse — de que a vida constitui um bem jurídico indisponível resulta logo, segundo a teleologia (e o "sistema") legal, da circunstância de constituir um ilícito típico punível o matar alguém, mais do que com o seu consentimento,

([21]) Cf., também, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 251.

mesmo perante um pedido sério, instante e expresso do titular do bem jurídico (art. 134.º); como igualmente de constituir entre nós um ilícito típico punível a ajuda que alguém preste ao suicídio de outrem (art. 135.º) ([22]). O que se justifica — para além de não ser despropositado argumentar que um homicídio de outra pessoa constitui sempre, mesmo perante a doutrina restritiva que à frente será enunciada a respeito (infra, § 16 e ss.), um facto *contra os bons costumes* — essencialmente porque no programa sistémico-social do legislador (tanto ordinário, como constitucional) a vida de pessoa já nascida surge, perante os outros, como objecto por excelência da tutela jurídica; a ela cabe, já o afirmámos (supra, 16.º Cap., § 17), o primeiro e indisputado lugar na hierarquia dos bens jurídicos dignos e carecidos de tutela ([23]). O que se diz para o bem jurídico "vida" deve de resto repetir-se, com segurança, para quaisquer outros **direitos da personalidade elementares**: óbvio será que é irrelevante, como bem nota Stratenwerth, o consentimento de uma pessoa para ser reduzida à *escravidão* (art. 159.º) ([24]) — apesar de o consentimento para um sequestro (art. 158.º) já poder constituir um *acordo que exclui a tipicidade* ([25]).

§ 15 Particularmente complexos e difíceis apresentam-se os casos de eficácia do consentimento no crime de **ofensa à integridade física**. Posta a questão da sua singular disponibilidade, uma resposta afirmativa não pode ser recusada: a integridade física constitui, para efeitos de consentimento, um bem **disponível** pelo seu titular mesmo em face de ataques de terceiro. O que, de resto, é expressamente afirmado no art. 149.º-1. Mas a questão imbrinca-se aqui inevitavelmente com a outra cláusula de relevância do consentimento — a dos *bons costumes* — e só à sua luz pode ser em definitivo decidida; sem prejuízo de o nosso legislador ter tentado

---

([22]) Cf., no presente contexto, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 134.º, §§ 11 e ss. e 39, e art. 135.º, § 16 e ss.

([23]) No sentido da "intangibilidade" do bem jurídico "vida" perante ataques de terceiro, com particular veemência, HIRSCH, Einwilligung und Selbstbestimmung, *Welzel-FS*, 1974, p. 799 e ss., e Behandlungsabbruch und Sterbehilfe, *Lackner-FS*, 1987, p. 610 e ss.; e, entre nós, ANDRADE, Costa, nota 1, p. 300 e ss. (tanto relativamente a ataques dolosos, como negligentes; sobre estes, cf., todavia, infra, 35.º Cap., § 43, e *Comentário Conimbricense*, I, art. 137.º, § 13). No mesmo sentido, também — tendo embora sobretudo em vista os problemas do estado de necessidade, não do consentimento —, JÄGER, Christian, Die Abwägbarkeit menschlichen Lebens im Spannungsfeld von Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie, *ZStW 115*, 2003, p. 755.

([24]) STRATENWERTH, § 9, n.º 18.

([25]) Assim, STRATENWERTH, § 9, n.º 18, e ANDRADE, Costa, nota 1, pp. 364 e 653 e ss.

(por último com as alterações introduzidas pela Reforma de 1995 no art. 149.º) manter os requisitos da "disponibilidade" e da "não contrariedade aos bons costumes" o mais possível autónomos (26).

4.2. A não contrariedade do facto consentido aos "bons costumes"

§ 16 De acordo com o disposto na parte final do art. 38.º-1, é pressuposto de relevância justificadora do consentimento que o **facto consentido** (não *o consentimento*, anote-se bem) não ofenda os bons costumes. Com isto traduziu a lei uma condição jurisprudencial e doutrinalmente exigida na Alemanha, de forma mais ou menos consensual, há muito tempo. Mas criou assim uma grave dificuldade — ainda hoje não totalmente superada — de entendimento do âmbito e do significado de uma tal cláusula: qualquer que seja a solução que neste campo se repute preferível, o critério é altamente impreciso e, na sua expressão contextual, mesmo imaterial.

§ 17 Que, com ela, se não quer remeter para a **contrariedade à moral** nem do facto consentido nem — ainda menos — do consentimento como tal, parece absolutamente seguro. Pode acreditar-se que na origem da exigência tenha estado a oposição do sentimento comunitário dominante a certas práticas sexuais, nomeadamente a práticas sadomasoquistas e análogas, bem como a intervenções do tipo da esterilização ou da interrupção consentida da gravidez. Mas, perante a função própria da intervenção penal no contexto social democrático, laico e pluralista, não pode mais ser esse o seu entendimento (27). Este só pode ser, à luz do fundamento justificante do consentimento, o de que o facto consentido constitui ofensa aos bons costumes sempre que (mas só quando) ele possui uma **gravidade** e (sobretudo) uma **irreversibilidade** tais que fazem com que, nesses casos, apesar da disponibilidade do bem jurídico, a lei valore a sua lesão mais altamente do que a auto-realização do seu titular. Afirmada com autonomia, como tem de o ser face ao art. 38.º-1, a disponibilidade do bem jurídico, tem de concluir-se — porquanto, no que toca à *vida*, trata-se

(26) Assim, também, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 149.º, § 3.

(27) Cf., em todo o caso, CORREIA, Eduardo, II, p. 27, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 252, SILVA, Marques da, II, p. 128, e ROXIN, Verwerflichkeit und Sittenwidrigkeit als unrechtsbegründende Merkmale im Strafrecht, *JuS* 1964, pp. 375 e s. e 379 e ss. Criticamente, no sentido do texto, ANDRADE, Costa, nota 1, p. 194 e ss., 537 e ss.

aí, como dissemos no § 14, de um bem jurídico indisponível perante ataques dolosos de terceiros — ser relativamente às **ofensas à integridade física** que a cláusula dos bons costumes assume (e praticamente esgota) o seu relevo ([28]): o consentimento será ineficaz quando a ofensa à integridade física possua uma *gravidade* tal — nomeadamente uma *irreversibilidade*, *v. g.*, uma mutilação — que, perante ela, o valor da auto-realização pessoal deva ceder o passo. Pelo contrário, uma ofensa à integridade física *simples* e *passageira* não ofenderá os bons costumes, quaisquer que tenham sido os motivos ou os fins que tenham estado na base do consentimento: aqui a supremacia no conflito deve ser deferida ao valor da auto-realização pessoal. Salvo se, excepcionalmente, "a lesão consentida viola uma expressa proibição legal directamente referida ao bem jurídico típico das ofensas corporais" (como será porventura o caso, hoje muito discutido, do *dopimg* no desporto ([29])). Isto dito, tem todavia de reconhecer-se que permanecem algumas margens de indecisão nesta matéria: a maioria delas, todavia, devendo encontrar a sua solução em outros domínios da doutrina do facto ou, concretamente, a propósito de certos tipos legais de crime da PE ([30]).

§ 18 O caso que, relativamente à cláusula dos bons costumes, poderia afigurar-se o mais complexo é o do consentimento em factos que acarretam **um perigo grave para a vida**. Dir-se-ia que, verdadeiramente, a questão não chega a pôr-se desde que se tome a sério, como se deve, a ideia de que a vida é um bem juridicamente indisponível face a ofensas dolosas de terceiros. Isso deveria porém conduzir à afirmação da ilicitude típica em todos os casos de *heterocolocação consentida em perigo grave para a vida*. E se contra isto se disser que a insustentabilidade de uma tal conclusão em certos casos prova que a questão não passa pelo consentimento, mas por outros princípios, nomeadamente, pelo critério da área de tutela da norma típica em matéria de imputação objectiva, teria então de dar-se razão a Hirsch quando fala, a este propósito, de "mudança de eti-

---

([28]) Nestes precisos termos, já, DIAS, Figueiredo, *Sumários das Lições, Aditamentos*, 1975, p. 23, e nota 10, p. 60 e s. Adere a esta posição, CARVALHO, Taipa de, II, § 799.

([29]) ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 149.º, § 38.

([30]) Até à anterior edição do seu *Strafrecht, AT*, I, § 13, n.º 37, sustentava ROXIN que a cláusula dos bons costumes deveria abranger apenas aquelas ofensas corporais cuja desaprovação jurídica resultasse indubitavelmente da lei. Hoje, porém (I, § 13, n.º 39 e ss.), coincide, parece-nos que completamente, com a posição defendida em texto.

quetas" ([31]). Seja qual for a razão dogmática que conduza à negação do ilícito-típico no caso do cirurgião que, como única forma de salvar a vida do paciente, leva a cabo, com o consentimento deste, uma cirurgia ainda não coberta pelas *leges artis* mas que acaba por determinar a morte do paciente — desde a invocação da adequação social à da área de tutela da norma, desde a do risco permitido à da situação de necessidade — **indiscutível, quanto nos parece, deveria ser que o consentimento no perigo grave para a vida é uma peça indispensável e insubstituível da negação do ilícito típico**. Ilícito-típico (de homicídio doloso) que pelo contrário deve ser afirmado se a intervenção tiver tido lugar **sem aquele consentimento**.

§ 19 De discutir também no presente contexto da cláusula dos bons costumes seriam ainda hipóteses como a da **esterilização voluntária** fora de uma indicação médica, da **colheita no vivo de órgãos e tecidos**, da **experimentação não terapêutica**, da **interrupção consentida de uma gravidez**. Em qualquer destas hipóteses, relativamente a uma lesão da integridade física, é a própria lei a considerar o consentimento exigível e, por conseguinte, relevante, se bem que dentro de *condições especiais*, reguladas respectivamente pela L 3/84, de 24-3, pela L 12/93, de 22-4, pelo DL 97/94, de 9-4, pelo art. 142.º do CP e L 16/2007, de 17-4 ([32]).

4.3. O acto de *auto*determinação

4.3.1. Incapacidade e representação

§ 20 Para que o consentimento se assuma — como vimos ser indispensável à luz do seu fundamento justificante — como um acto de auto-realização, torna-se antes de tudo necessário que quem consente seja **capaz**. O CP entendeu — e bem — que esta capacidade não pode ser medida pelas (nem avaliada à luz das) normas jurídico-*civis* relativas à capacidade ([33]). Antes se torna necessário garantir que quem consente é capaz de avaliar o *significado do consentimento* e o *sentido da acção típica*; o que supõe a maturidade que é conferida em princípio por uma certa

([31]) HIRSCH, *LK*, n.º 45 antes do § 32.

([32]) Sobre a matéria deste parágrafo ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 149.º, § 44 e ss.; e FARIA, Paula Ribeiro de, nota 12, p. 285 e ss.; DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 142.º, § 50 e ss.

([33]) Trata-se de doutrina pacífica, cf. CORREIA, Eduardo, II, n.º 5, *b)*, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 253, e SILVA, Marques da, II, p. 129.

idade e o discernimento que é produto de uma certa normalidade psíquica. Neste sentido dispõe o art. 38.º-3, de forma terminante, que "o consentimento só é eficaz se for prestado por quem for *maior de 14 anos* e possuir o *discernimento* necessário para avaliar o seu sentido e alcance *no momento em que o presta*". E o Anteprojecto 2007 pretende agora — sob a alegação, todavia não inquestionável, de se "promover uma tutela mais intensa das crianças e dos adolescentes" — elevar a idade da relevância do consentimento dos 14 para os *16 anos*. Em caso de incapacidade penal, o princípio será o de que a legitimidade para consentir em nome do incapaz cabe ao seu **representante legal**. Mas este princípio não se afirmará sem limitações ou mesmo excepções, nomeadamente em matéria de *ofensas corporais graves*, e, de forma particular, de intervenções médico-cirúrgicas fora dos pressupostos do art. 150.º (34). Esta doutrina não se altera relativamente ao consentimento em lesões de carácter *patrimonial* (35): também aqui decide a capacidade jurídico-*penal*, não a jurídico-*civil*. Não se compreenderia, *v. g.*, que um jovem de 15 anos pudesse consentir numa lesão da integridade física, mas já não na destruição de um objecto que lhe pertence.

4.3.2. Falta de liberdade da vontade

§ 21 Acto de autodeterminação *autêntica* só existirá, obviamente, se o consentimento, como se exprime o art. 38.º-2, traduzir "uma **vontade séria, livre e esclarecida** do titular do interesse juridicamente protegido". Esta exigência contém implicações que nem sempre se revelarão de fácil desenvolvimento.

§ 22 Necessário se torna, antes de mais, que o consentimento seja **esclarecido**, o que, nomeadamente nas ofensas corporais, pode implicar a notícia sobre a índole, o alcance, a envergadura e as possíveis consequências da ofensa. Exigências que a lei traduz no art. 157.º, a propósito das intervenções médico-cirúrgicas, acrescentando-lhes todavia um *privilégio terapêutico* ("salvo se isso [*sc.*, o devido esclarecimento] implicar a comu-

(34) Prova disso são as normas legais especiais existentes entre nós no que respeita ao consentimento para doação de órgãos ou substâncias não regeneráveis e para experimentações clínicas. Sobre esta matéria, em pormenor, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 149.º, § 19 e ss.; e FARIA, Paula Ribeiro de, nota 11, p. 312 e ss.

(35) Discutido na doutrina alemã: como no texto STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 25; contra, entre outros, HIRSCH, *LK*, n.º 118 antes do § 32.

nicação de circunstâncias que, a serem conhecidas pelo paciente, poriam em perigo a sua vida ou seriam susceptíveis de lhe causar grave dano à saúde, física ou psíquica") que não tem correspondente nas ofensas corporais de outro tipo ([36]).

§ 23 Necessário se torna, depois, para que o consentimento seja eficaz, que ele se não revele inquinado por qualquer **vício da vontade**. Deste ponto de vista de diria, portanto, que o engano e o erro, a ameaça e a coacção, tornam o consentimento ineficaz ([37]). Hoje, porém, esta doutrina tradicional (e porventura ainda maioritária) vem sendo criticada e substituída por uma **consideração diferenciada**. Quanto à **ameaça** e à **coacção**, elas devem conduzir à ineficácia do consentimento por meio delas obtido, se não em todos os casos — sempre se avançando, a propósito, com o caso daquele que ameaça a namorada de romper o namoro se ela não consentir na destruição de um seu anel que lhe foi dado por um anterior namorado e que o actual, por essa razão, detesta —, pelo menos **sempre que a conduta tendente a obter o consentimento integre os tipos de crime da ameaça** (art. 153.º) **ou da coacção** (art. 154.º): em casos deste teor será seguramente impossível considerar o consentimento como expressão da autonomia pessoal de quem "consente" ([38]).

§ 24 Mais complexa é a situação das coisas do lado do **engano** (erro provocado) ou do **erro** em sentido estrito (espontâneo, não provocado). Arzt introduziu neste contexto uma ideia fundamental, que encontrou larguíssima adesão: a de que a eficácia do consentimento só pode ser posta em causa neste grupo de hipóteses se depararmos com um **engano referido ao bem jurídico**, de um erro que caia, neste sentido, dentro da área de tutela da norma de protecção; como será patentemente o caso se *A* receita ou ministra a *B* comprimidos suporíferos, ocultando dolosamente que eles vão prejudicar a saúde de *B*. Já assim não será, porém, se em causa está um **engano não referido ao bem jurídico**, *v. g.*, no caso em que o gerente de uma clínica absolutamente falida obtém de *C* o consentimento para doar san-

---

([36]) Assim, e sobre a matéria deste parágrafo, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 149.º, § 22, e art. 150.º; e FARIA, Paula Ribeiro de, nota 11, p. 273 e ss., especialmente p. 278[104]. Por último, sobre o "privilégio terapêutico", ANDRADE, Costa, *Direito Penal Médico. Sida: Testes Arbitrários, Confidencialidade e Segredo*, 2004, p. 120 e ss.

([37]) Doutrina tradicional: cf. CORREIA, Eduardo, II, n.º 5, *a)*, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 26.

([38]) Cf. ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, art. 149.º, § 24.

gue contra o pagamento de uma soma de dinheiro, ocultando aquela situação de falência: nestes casos não deve afirmar-se que foi posta em causa uma manifestação de autonomia pessoal do lesado perante o bem jurídico da integridade física (39). Roxin acrescentou à doutrina de Arzt, todavia, um *requisito adicional* (no sentido da relevância do engano), defendendo que, mesmo em caso de engano não referido ao bem jurídico, o consentimento deve ainda ser considerado *ineficaz* se o engano versa sobre uma **finalidade altruista** (*v. g.*, *D* consente em submeter-se a uma intervenção porque *E*, autor da intervenção, o convenceu falsamente de que se tratava de uma experiência fundamental para o avanço da ciência médica, quando afinal o que *E* pretendia era prejudicar *D*) ou coloca quem consente numa **posição análoga à do estado de necessidade** (*F*, querendo apoucar socialmente *G*, convence-o que é portador de piolhos para que *G* consinta que lhe rape o cabelo) (40). Esta doutrina foi entre nós aceite e ajustada por Costa Andrade e parece-nos, no essencial, dever ser subscrita (41).

§ 25 Em caso de estrito **erro** (espontâneo, não provocado), também a doutrina se divide. Querem uns que **o erro seja irrelevante** e, por conseguinte, **o consentimento eficaz** (salvo quando o erro seja conhecido do agente e por ele aproveitado ou quando sobre este impenda um dever jurídico de esclarecimento) (42). Enquanto outros sustentam que deve valer para estas hipóteses uma doutrina paralela à que vale para o engano, sendo por conseguinte **irrelevante para a questão da eficácia ou ineficácia do consentimento o problema da origem do erro** (43). A favor desta última solução invoca-se que quem dispõe do bem jurídico de que é concreto portador com base em um qualquer erro relativo ao bem jurídico não exprime, relativamente a ele, a sua autonomia pessoal. Mas a verdade é que ele, por suposto, a *exprimiu*, embora de forma errada: do autor

(39) ARZT, *Willensmängel bei der Einwilligung*, 1970.

(40) ROXIN, Die durch Täuschung herbeigeführte Einwilligung im Strafrecht, *Noll-GS*, 1984, p. 292, e, por último, I, § 13, n.º 99 e ss.

(41) ANDRADE, Costa, nota 1, pp. 564 e ss., 593 e ss., e *Comentário Conimbricense*, art. 149.º, § 28 e ss. (onde podem ler-se, na esteira da jurisprudência e da doutrina alemãs, os casos referidos no texto). Sobre problemas específicos relacionados com a recolha de sangue para realizar o teste da SIDA, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, art. 149.º, § 32, e *Sida*, nota 36, pp. 68 e ss., 86 e ss., 94 e ss.

(42) Assim, ARZT, nota 39, p. 48 e ss., e ROXIN I, § 13, n.º 111 e ss.

(43) Assim, S / S / LENCKNER, n.º 50 antes do § 32, e, ao menos para as ofensas à integridade física, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 149.º, § 31.

do facto nada mais se pode exigir senão que se deixe conduzir pela **expressão** da vontade do titular do bem jurídico, salvo se ele souber que radica num erro. Como afirma Roxin, parece-nos que com razão, todo o consentimento tem de ser *manifestado* e manifestado é só aquilo que resulta de uma interpretação objectiva. E exemplifica: não pode deixar de se considerar eficaz o consentimento se *A* solicita a *B* que consinta no derrube de uma árvore deste cuja sombra prejudica o jardim de *A*, e *B*, em resposta escrita, lhe comunica erradamente "consinto", quando a sua intenção era ter escrito "*não* consinto" (44).

4.3.3. Formalismo

§ 26 Para que o consentimento traduza um acto autêntico de autodeterminação não se torna necessário (nem conveniente) que a sua eficácia seja posta na dependência da observância de quaisquer formalismos: basta que ele exista e seja manifestado. Por isso o art. 38.º-2, 1.ª parte, afirma com razão que "o consentimento pode ser expresso **por qualquer meio**" (45). Já exige, porém, que signifique que um assentimento real e persistente **no momento do facto**, porque só assim se pode afirmar que o facto típico corresponde à vontade e à autodeterminação do atingido. Por isso também afirma o art. 38.º-2, *in fine*, que o consentimento "pode ser livremente **revogado** até à execução do facto".

§ 27 Se não for porém revogado — e isto vale particularmente para aqueles casos em que o consentimento é manifestado através de um documento escrito — e não houver razões subsequentes para supor que o autor do documento mudou de opinião, não há fundamento bastante para que se ponha por princípio em dúvida a validade do consentimento ou do dissentimento. Isto vale hoje sobretudo para o chamado **testamento de paciente** (de vida, vital, biológico, *living will* ou como quer que se prefira intitulá-lo), isto é, um "documento escrito no qual uma pessoa consigna as suas vontades quanto aos cuidados médicos que pretende ou não pretende receber se perder a capacidade de se exprimir ou se se encontrar em estado de já não ser capaz

(44) ROXIN I, § 13, n.º 111.

(45) Existem, porém, casos especiais (*v. g.*, esterilização voluntária, participação em ensaios clínicos — cf. supra, § 19) em que a lei faz depender a eficácia do consentimento da sua formalização por escrito: cf. RODRIGUES, João Vaz, *O Consentimento Informado para o Acto Médico no Ordenamento Jurídico Português*, 2001, p. 428 e ss. A este propósito, cf., ainda, PEREIRA, André, O consentimento para intervenções médicas prestado em formulários: uma proposta para o seu controlo jurídico, *BFD LXXVI*, 2000, p. 433 e ss.

de tomar, ela própria, uma decisão" (46). Não falta quem, ao menos do ponto de vista jurídico-penal, sustente que um tal "testamento" teria valor diminuto ou mesmo nulo, podendo em larga medida o médico continuar a ministrar *todos* os tratamentos medicamente indicados, face à ineficácia da denegação de consentimento que resultaria de a declaração não coincidir com o momento do facto (dada, *hoc sensu*, a sua "falta de actualidade"). Não cremos fundado este cepticismo (47). Por um lado, não se torna possível nesta situação — como frequentemente se pretende —, apelar para a justificação por força de um "consentimento presumido" (cf. infra, § 31). Por outro lado, o "testamento" deve conservar toda a sua eficácia (salvo, naturalmente, relativamente a qualquer concreta idicação nele consignada que representasse para o médico a obrigação de praticar um acto em si ilícito, *v. g.*, uma eutanásia activa) como *indício* fundamental da vontade real e efectiva do paciente (48). Sem prejuízo, repetimos, de esta força indiciária poder ser invalidada pelo conhecimento de circunstâncias posteriores que ao seu conteúdo se opõem, máxime, a de se saber que era já disposição do paciente revogá-lo, destruí-lo ou transformá-lo.

4.4. O conhecimento do consentimento

§ 28 Já ficaram expostas (supra, 14.º Cap., § 14 e ss.) as razões por que uma causa de justificação só pode produzir o seu pleno efeito se a situação de justificação for conhecida do agente. Isto vale integralmente para o consentimento (art. 38.º-4), devendo pois exigir-se que este **seja conhecido do agente**; e não faltando mesmo quem pretenda ser necessário — restando saber se aqui vai contida uma exigência subjectiva verdadeiramente adicional ou complementar, mas então, em caso afirmativo, sem razão — que o agente só tenha actuado **em razão do consentimento.** Onde e quando tal não aconteça o agente deve em todo o caso ser punido não por crime consumado, mas (analogicamente) por **tentativa**, nos termos e nos limites em que esta seja efectivamente punível relativamente ao tipo de ilícito concretamente preenchido (supra, 14.º Cap., § 18 e ss.).

5. O consentimento dito "hipotético"

§ 29 Recentemente, veio defender Kuhlen — na esteira de uma certa jurisprudência alemã sobre as intervenções médicas não consentidas e com

---

(46) Definição de Ivon Kenis, referida no Parecer n.º P/05/APB/06 da Associação Portuguesa de Bioética (www.apbioetica.org). Cf. já DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 131.º, § 25.

(47) Ao contrário de ANDRADE, Costa, Consentimento em Direito Penal Médico — O consentimento presumido, *RPCC* 14, 2004, p. 144.

(48) Temos, em particular, por inteiro destituída de fundamento — como também PEREIRA, A. Dias, *O Consentimento Informado na Relação Médico-Paciente. Estudo de Direito Civil*, 2004, p. 246 — a alegação de que "o estado de inconsciência criaria uma presunção no sentido da revogação da opinião anteriormente expressa".

crescente aplauso doutrinal — que, apesar da ineficácia do consentimento, por falta de esclarecimento dirigido à formação da vontade, deve em todo o caso ficar excluída a ilicitude do facto quando vier a provar-se, segundo um juízo *ex post*, que **o consentimento teria sido dado se o devido esclarecimento tivesse tido lugar**. A este propósito se poderia falar de "consentimento hipotético" ([49]). Esta doutrina está, em princípio geral, de acordo com a ideia referida supra, 14.º Cap., § 32 e s., segundo a qual os critérios da imputação objectiva — e nomeadamente, o que respeita ao comportamento alternativo lícito — valem também para a imputação do resultado à conduta nas causas justificativas. Se, p. ex., *A* ouviu dizer a sua mulher, *B*, que ainda há-de deitar fora um quadro de valor elevado que lhe fora oferecido pelo seu primeiro marido e do qual não gosta e, um dia, destrói sem mais esse quadro, a *A* não deve objectivamente ser imputado o crime de dano do art. 213.º se vier a determinar-se que, se *B* tivesse sido previamente informada da intenção de *A*, teria consentido no facto ([50]).

II. O consentimento presumido

§ 30 Nos termos do art. 39.º-2, "há consentimento presumido quando a situação em que o agente actua permitir razoavelmente supor que o titular do interesse juridicamente protegido teria eficazmente consentido no facto, se conhecesse as circunstâncias em que este é praticado". Do que se trata pois aqui é de situações em que o titular do bem jurídico lesado *não consentiu* na ofensa, mas nela **teria presumivelmente consentido** se lhe tivesse sido possível pôr a questão. Por isso se pode falar neste contexto, com fundamento, de uma espécie de "*estado de necessidade da decisão*" (sem que com isto porém, como se verá, se pretenda fazer do consentimento presumido uma subespécie da causa de justificação do estado

([49]) KUHLEN, Ausschluss der objektiven Erfolgsabwendung bei hypotetischer Einwilligung des Betroffenen, *Roxin-FS*, 2001, p. 331 e ss. Uma referência entre nós logo em ANDRADE, Costa, nota 47, p. 133[31]. Cf., depois, STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 28, e ROXIN I, § 13, n.º 119 e ss.

([50]) Anote-se, de toda a maneira, que o caso alemão que esteve na origem jurisprudencial desta posição e continua a servir de paradigma à discussão doutrinal (como dissemos, o da intervenção médico-cirúrgica não esclarecida) não deve sem mais ser transposto para a ordem jurídica portuguesa: seja porque o crime em causa seria entre nós o da intervenção médica arbitrária (art. 156.º) e não, como no direito alemão, o da ofensa corporal; seja porque o problema que se suscita é o do consentimento que justifica o facto e não, como para uma parte da doutrina alemã (supra, § 5) o do consentimento que tornaria o comportamento atípico.

de necessidade). Logo nesta medida se distinguindo os casos aqui em apreço dos referidos supra, § 29, sob a epígrafe do "consentimento hipotético". Como com igual razão se pode falar a propósito do carácter **subsidiário** do consentimento presumido, no sentido de que este só entra em jogo "quando não for possível obter a manifestação expressa da vontade ou houver perigo sério na demora" ([51])

§ 31 Na prática, com o **campo de actuação** por excelência do consentimento presumido depara-se nas *intervenções médico-cirúrgicas*, quando o paciente não se encontra em condições de prestar eficazmente o seu consentimento (máxime, porque se encontra inconsciente) mas a necessidade de intervenção se não compadece com demoras. Casos da vida diária não são porém também raros, como quando alguém se introduz na casa de um vizinho sem autorização para fechar uma torneira que foi deixada aberta e está a causar uma inundação; ou como quando alguém abre uma carta dirigida a pessoa ausente mas que parece ser de conhecimento urgente, *v. g.*, uma comunicação judicial ou do serviço de finanças. Com razão agrupam por isso Jescheck / Weigend as hipóteses de consentimento presumido em dois grupos de casos: o daqueles em que se trata de uma *colisão interna de bens ou de interesses* na esfera da vida do lesado e que tem de resolver-se por uma intervenção externa incompatível com demoras (caso referido da intervenção médica em pessoa inconsciente); e o daqueles outros em que, dada nomeadamente a pequenez do valor lesado, é razoável supor que o seu titular teria *renunciado ao seu interesse em favor do interesse do agente ou de terceiro* (*v. g.*, quando alguém se serve sem autorização da bicicleta de um amigo para apanhar um combóio que não pode perder) ([52]).

1. Pensamento fundamental

§ 32 Quando se pergunta qual seja o fundamento em que repousa o efeito justificante do consentimento presumido duas respostas podem ser (e têm sido) dadas. Segundo uma delas, a razão estaria na correspondência do facto ao **verdadeiro bem** ou **interesse** do lesado, servindo a correspondência à sua vontade unicamente como *limite* do âmbito admissível de intromissões na vida alheia ([53]). Segundo uma outra posição o fundamento residiria em uma presunção não do interesse do lesado (por mais razoável que ele possa figurar-se), mas da **direcção da sua vontade**: do que se trata, ainda e sempre, seria de uma equiparação a um consentimento, real

([51]) ANDRADE, Costa, *SIDA*, nota 36, p. 13; ROXIN I, § 18, n. 10 e ss.
([52]) JESCHECK / WEIGEND, § 34, VII, 1.
([53]) Assim, por outros, WELZEL, § 14, V.

e eficazmente prestado, de um facto no qual o lesado teria presumivelmente consentido se tivesse conhecido a situação (54).

§ 33 A segunda das posições indicadas é a correcta e a única que se adequa aos dados positivos da lei portuguesa: o art. 39.º-1 manda **equiparar** o consentimento presumido ao consentimento efectivo; e o n.º 2 reporta a eficácia daquele não ao *interesse* do lesado, mas à suposição razoável de que ele teria consentido (em suma: de que **essa teria sido a sua vontade**) se conhecesse as circunstâncias em que o facto é praticado. Que o facto corresponda ou não, em definitivo, ao "verdadeiro bem e interesse do lesado" não constitui fundamento relevante da eficácia do consentimento presumido. O pensamento fundamental que lhe preside reside por conseguinte em que a autodeterminação do lesado não é ofendida quando o agente, numa consideração *objectiva* e *ex ante*, pratica solidariamente o facto numa situação em que uma decisão não pode ser retardada. Como bem conclui Stratenwerth, o interesse do lesado não constitui, assim, mais do que um indício (refutável) daquela que teria sido presumivelmente a sua vontade (55).

§ 34 De importância é sublinhar que a causa de justificação do consentimento presumido abrange tanto as situações de **consentimento** presumido em sentido rigoroso, como as de **acordo presumido**. As razões que, como acabou de se dizer, fundamentam a justificação por força de um consentimento presumido valem completamente para as situações de acordo presumido. Como justamente afirma Costa Andrade, "à semelhança do que acontece do lado do consentimento, também do lado do acordo presumido 'subsiste a possibilidade de lesão penalmente relevante do pertinente bem jurídico'" (56).

2. Requisitos de eficácia

§ 35 Uma vez que o consentimento presumido se equipara ao consentimento efectivo, naquele hão-de em princípio concorrer **os mesmos**

---

(54) Assim, ROXIN, Über die mutmassliche Einwilligung, *Welzel-FS*, 1974, p. 447 e ss., e § 18, n.º 5, STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 35, S / S / LENCKNER, n.º 56 antes do § 32. Entre nós, ANDRADE, Costa, nota 47, p. 133 e s., e, na conclusão, também, CORREIA, Eduardo, II, p. 29 e ss.

(55) STRATENWERTH, § 9, n.º 34.

(56) ANDRADE, Costa, nota 47, p. 131, citando Maurach / Zipf e uma série de concordâncias e discordâncias.

requisitos de eficácia. Antes de tudo, por conseguinte, que o consentimento (presumido) diga respeito a **interesses jurídicos livremente disponíveis** e que **o facto não ofenda os bons costumes**.

§ 36 A presunção tem, por outro lado, que referir-se **ao momento do facto**, sendo irrelevante a esperança de uma posterior aprovação; do mesmo modo se exigindo que o titular do bem jurídico lesado possuisse a *capacidade* (jurídico-penal) para consentir: quando ela não existir recorrer-se-á à vontade presumida do representante legal.

§ 37 Essencial é que se verifique, por uma parte, a **necessidade de uma decisão que não pode ser retardada** (porque o atraso eliminaria a possibilidade de escolha ou a ele estariam ligados riscos desrazoáveis) e, por outra, **a impossibilidade de ela ser tomada pelo interessado**.

§ 38 Qual era em definitivo a **vontade real** do interessado é coisa que pode não ser certa. Mas a relevância de um juízo *ex post* deve ser recusada, podendo assim divisar-se, também no consentimento presumido, uma dominância do desvalor de acção sobre o desvalor de resultado. Nestes casos deve sempre presumir-se que o interessado teria reagido como é **normal e razoável**. Se, porém, ainda segundo um juízo *ex ante*, for *reconhecível* ou *sabido* que a vontade do interessado estaria contra a intervenção, então esta não pode considerar-se justificada, por mais desrazoável que, ao agente putativo ou mesmo à generalidade, se afigure uma tal vontade. *V. g.*, para quem não seja testemunha de Jeová poderá parecer de todo desrazoável que o interessado (que se encontra inconsciente quando é levado ao hospital) recusasse uma transfusão de sangue indispensável para lhe salvar a vida; mas sabendo-se que esta seria presumivelmente a sua vontade dado ser conhecida a sua crença religiosa, a transfusão, apesar de necessária de forma imediata, não pode considerar-se justificada em nome do consentimento presumido ([57]).

§ 39 Em recente investigação Costa Andrade veio defender que o médico pode sempre louvar-se no consentimento presumido para tratamentos destinados a salvar a vida de um paciente inconsciente, nunca para omitir o tratamento ou a sua continuação; porque "só a salvação da vida permite 'manter em aberto a base da decisão',

([57]) Em definitivo neste sentido o aludido (supra, nota 46) Parecer da Associação Portuguesa de Bioética; ao que parece, contra, ANDRADE, Costa, nota 47, p. 144.

contrariando o risco de a perda da vida arrastar consigo a perda irreversível da autonomia". Não podemos estar de acordo, em definitivo, com esta doutrina. A primeira asserção só se nos afigura exacta se não houver razões sérias para crer (nomeadamente por força de um testamento de paciente) que o doente não quereria ser tratado em certas condições. A segunda asserção pode reputar-se exacta na medida em que não deve ser em rigor a um consentimento *presumido* que se apela; mas também aqui o fundamento que se invoca — o de que só a salvação da vida permite manter em aberto a base da decisão — não nos parece válido, mesmo independentemente da existência de um "testamento" de vida: se, p. ex., o paciente que tem de ser submetido a uma intervenção cirúrgica de resultados duvidosos e que nela consente adverte no último instante possível a equipa médica de que, caso as coisas corram mal e ele fique reduzido a vida vegetativa persistente, proíbe a continuação de quaisquer ou de certos tratamentos, tem o médico de submeter-se à vontade do paciente, sem que importe saber se a solução possui, "no momento", recorte heterónomo porque o paciente "tinha perdido irreversivelmente a autonomia" ([58]).

§ 40 Essencial é pois que o facto corresponda *presumivelmente* à vontade do interessado, o que conduz uma parte da doutrina a exigir do agente uma **cuidadosa comprovação da situação**. Com a consequência de que, se o agente a *não* levou a cabo e vem a verificar-se, *ex post*, que o facto contradiz a vontade real do interessado, não teria lugar a justificação; se, pelo contrário, a cuidadosa comprovação não fosse levada a cabo mas o facto tivesse acabado por corresponder à vontade real do interessado verificar-se-ia a justificação ([59]). Não cremos, porém, que seja esta a melhor doutrina. Mesmo em matéria de consentimento presumido não há lugar para considerar que uma "cuidadosa comprovação" constitua pressuposto da justificação, pelo que devem aqui valer as **regras da doutrina geral das causas justificativas**: quem age supondo, com cuidadosa comprovação ou sem ela, verificados os pressupostos da justificação, actua justificadamente se tais pressupostos na realidade se verificam; se ele supõe erroneamente a sua verificação não actua dolosamente, só podendo ser punível, se disso for caso, por negligência (supra, 14.º Cap., § 23 e ss.) ([60]).

([58]) Assim, ANDRADE, Costa, nota 47, p. 147 e s. Já porventura nos encontraremos de acordo com ele na parte em que não pretende logo a partir dali — da negação, *in casu*, de um consentimento presumido eficaz — concluir pela ilicitude da conduta do médico que interrompe o "tratamento" no sentido da afirmação do tipo de homicídio (doloso): cf. DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 131.º, § 25.

([59]) Assim, JESCHECK / WEIGEND, § 34, VII, 3, e ROXIN, nota 54, p. 453 e ss.

([60]) Assim também, agora, ROXIN I, § 18, n.º 30 e s.

18.º CAPÍTULO

OUTRAS CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO

§ 1 As causas de justificação referidas nos 15.º a 17.º Capítulos constituem apenas resultado de uma *escolha*, justificada pela particular relevância e frequência que aquelas assumem para a questão da responsabilidade jurídico-penal. Algumas outras, todavia, não devem deixar de ser mencionadas numa exposição sistemática da doutrina geral do facto punível como a presente. Será todavia omitida, inclusivamente, a referência a causas de justificação constantes do CP mas que integram a sua PE (como é, nomeadamente, o caso da "defesa de interesses legítimos" prevista no art. 180.º-2).

I. A actuação oficial

§ 2 No seio de um Estado de Direito democrático a relação entre os que exercem poderes estaduais e os simples cidadãos *não confere àqueles um poder geral de intervenção* na esfera jurídica destes e, por conseguinte, no círculo dos seus bens jurídicos. No entanto, por mais que as concepções tenham evoluído no sentido desta proposição geral negativa, nomeadamente no que respeita à evolução das concepções relativas ao poder de soberania e às condições do seu exercício, a verdade é que ao titular de um poder oficial são concedidos **concretos direitos de intervenção** cujo exercício, numa relação igualitária, seria ilícito; mas que, no caso, representam o **exercício de um direito** (art. 31.º-2/*b*)) — ou/e o **cumprimento de um dever** (art. 31.º-2/*c*)) — e cujos factos deste exercício resultantes, apesar de formalmente típicos, se encontram nesta precisa medida *justificados*.

§ 3 O quadro de tais direitos de intervenção (concedidos às autoridades judiciárias, militares, administrativas, policiais, etc.) é de tal maneira vasto e plurifacetado que seria tarefa impossível tentar sequer esboçá-lo aqui. Exemplifique-se, porém, só com o que sucede em direito processual penal: medidas de coacção processual, diligências pro-

batórias, execução de sentenças — que implicam a prática de diversos factos típicos, contra a pessoa e/ou o seu património: detenção, prisão preventiva, aplicação de cauções, revistas, apreensões, exames corporais e outros, escutas telefónicas e, sobretudo, privação da liberdade durante tempo determinado — são medidas que podem legitimamente ser actuadas pela autoridade competente, inclusivamente com o recurso à força se tanto for necessário e legalmente admissível. Nestes casos — relativamente à posição do superior hierárquico, aqui em causa — é a **actuação oficial como tal** que, uma vez *verificados os respectivos pressupostos formais e materiais* de legitimidade, constitui o exercício de um direito ou o cumprimento de um dever e, por isso, uma causa de justificação.

§ 4 O problema que não poucas vezes se suscita advém do facto de que aqueles pressupostos nem sempre são desenhados pelas leis concedentes com suficiente **precisão**, pelo que depois se torna questionável, *in casu*, determinar se eles estão ou não presentes. Tanto mais quanto falta hoje no ordenamento jurídico português preceito geral sobre a matéria (1), limitando-se o art. 271.º da CRP a determinar que os funcionários e agentes do Estado são responsáveis pelas condutas praticadas no exercício da função donde resulte violação dos direitos ou interesses legalmente protegidos do cidadão (2). A jurisprudência e uma parte significativa da doutrina alemãs consideram, na base de uma premente necessidade político-criminal de oferecer às autoridades, nomeadamente administrativas, garantias acrescidas na sua actuação, que importa trabalhar para o efeito com um "**conceito especial de ilicitude**", que "guarde as costas" da autoridade sempre que esta erre sobre os pressupostos fácticos da legitimidade da sua actuação: ilícita só será a actuação — dito de uma forma generalizante — se o erro em que recai a autoridade for particularmente **grosseiro** ou **censurável**, ou se o agente não levar a cabo uma **cuidadosa comprovação**, conforme ao dever, da situação de facto (3); ou que — numa outra perspectiva: doutrina dita da "eficácia" —, ilícito será apenas o facto que deva considerar-se **nulo** segundo as determinações juspublicísticas, não o meramente *anulável* (4).

---

(1) Diferentemente do que sucedia no CP de 1886, em geral, com o *exercício de um direito*, cuja eficácia justificadora era posta na dependência de que o agente tivesse actuado com a diligência devida (art. 44.º-4).

(2) CANOTILHO / MOREIRA, art. 271.º, I.

(3) JESCHECK / WEIGEND, § 35, I, 3, S / S / ESER, § 111, n.º 21 e ss., e VITT, Gedanken zum Begriff der "Rechtsmässigkeit" der Diensthandlung, *ZStW 106*, 1994, p. 581.

(4) MEYER, Der Begriff der Rechtsmässigkeit einer Vollstreckungshandlung i. S. des § 113 Abs. 3 StGB, *NJW*, 1972, p. 1845 e ss.; KREY, *Strafrecht, BT*, I, ^{9}1994, n.º 506 e ss.

§ 5 Não parece, porém, que uma tal doutrina seja a melhor e, ainda menos, que ela possa sufragar-se face ao nosso direito positivo. Logo as intenções básicas da CRP — como bem se compreende de um documento fundamental que consagrou ao nível legislativo mais elevado a ascensão à democracia depois de quase meio século de ditadura — revelam a convicção de que se é necessário à ordem jurídica "guardar as costas" de alguém, não é preferencialmente dos agentes do Estado, mas dos cidadãos. A necessidade — real e compreensível — de agilizar a actuação dos agentes do Estado não se realiza reconhecendo, na palavra antiga de Jellinek, "que o Estado goza do grande privilégio de poder equivocar-se" (5), nem possui capacidade para transformar em lícito um acto que é contra o Direito. Com o que se realiza, sim, é com uma legislação relativa aos actos das autoridades e à sua responsabilidade que acautele na medida devida e precisa as condições difíceis, inadiáveis e quantas vezes imprevisíveis em que aquelas têm de actuar. Mas, isto feito, não são mais precisas aqui manipulações do conceito de ilicitude nem a atribuição de uma credencial de justificação de carácter geral. De resto, e em segundo lugar, não é crível que o legislador constitucional português desconhecesse esta controvérsia — e esta posição dominante — já antiga; pelo que o seu silêncio, bem como o do CP, só podem ser interpretados no sentido de querer afastar nesta sede qualquer conceito especial (restritivo) de ilicitude, tanto mais quanto ele iria alargar correspectivamente o dever do particular de suportar — e portanto de não poder defender-se legitimamente — de um acto materialmente ilícito. Deve portanto concluir-se que a actuação oficial constitui uma causa de justificação, no quadro do exercício de um direito contido no art. 31.º-2/*b*), apenas **quando se verifica a totalidade dos pressupostos fácticos e jurídicos de que a lei faz depender a concessão do respectivo direito de intervenção.**

§ 6 Isto se diz, todavia, no devido reconhecimento de que o facto da autoridade só poderá conduzir à sua responsabilidade penal **se for tipicamente doloso ou negligente** (e, neste último caso, se a negligência for punida). De outra forma, como devia parecer óbvio — embora por vezes o não seja, mesmo para uma certa literatura alemã —, o facto **não é típico** por falta do tipo subjectivo de ilícito. Com isto não

(5) JELLINEK, *Verwaltungsrecht*, ³1931, p. 373. Negando também este privilégio, CARVALHO, Taipa de, Obediência hierárquica e responsabilidade jurídica do funcionário, *Estudios Penales y Criminológicos XX*, 1997, p. 295 e s., e ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 194.º, § 37.

se quer significar porém, como a referida doutrina alemã (que se acolhe sob o designativo de doutrina da *ilicitude penal* (6)), que quando o agente actue em erro sobre os pressupostos da justificação o seu facto deva considerar-se *lícito*. Como atrás se disse, nesta hipótese o facto é dolosamente ilícito, verifica-se o tipo subjectivo de ilícito doloso, só que o agente não actua com culpa dolosa e só pode ser por isso (eventualmente) punível a título de negligência (supra, 14.º Cap., § 23 e ss.) (7). As consequências que daqui podem derivar para a legitimidade de defesa do particular devem ser atalhadas, como também Costa Andrade sustenta, por via de uma particular exigência quanto à *necessidade do meio* de defesa (8), eventualmente, em nossa opinião, quanto à própria *necessidade da defesa*.

II. Ordens oficiais ou de serviço

§ 7 Se, nos tempos do Estado autoritário português, se pode dizer que o problema posto no apartado anterior praticamente não era tratado pela doutrina nem ocupava a jurisprudência — justamente pela presunção (fáctica), característica dos Estados autoritários, de que a autoridade "tinha sempre razão" nos seus procedimentos e na sua actuação —, já o mesmo não pode dizer-se relativamente ao problema então conhecido como da **obediência devida** enquanto causa de justificação do facto. Aqui a doutrina e a jurisprudência penais — e também administrativas — ocuparam-se profunda e repetidamente da questão; da questão de saber em que medida e sob que condições o *inferior hierárquico* que cumprisse uma ordem ilegal recebida do seu superior e, cumprindo-a, praticasse um facto criminalmente ilícito (independentemente da questão da obediência devida, isto é, um facto formalmente típico mas não coberto por legítima defesa, estado de necessidade, etc.) poderia vê-lo **justificado**.

§ 8 Nesta matéria muitas e variadas posições foram defendidas. Desde a que preconizava a aplicação do princípio da "**obediência cega**", segundo o qual ao inferior só caberia cumprir a ordem recebida do superior, sem dever ou sequer poder apreciar da sua legalidade formal e (muito

(6) Uma sua exposição e crítica, nos termos do texto, em ANDRADE, Costa, Violação de domicílio e de segredo de correspondência ou telecomunicações por funcionário (arts. 378.º e 384.º do CP português), *Ab Vno Ad Omnes*, p. 744 e s. E agora BRANDÃO, Nuno, *Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal*, 2006, p. 49 e ss., e por último, à luz do direito alemão, JAVATO Martin, El requisito de la legalidad de la acción de servicio (§ 113-III StGB), *Revista Penal 18*, 2006, p. 124.

(7) Nesta direcção, também BRANDÃO, Nuno, nota 6, p. 66 e s.

(8) ANDRADE, Costa, loc. cit. na nota 6.

menos) material; pelo que a obediência seria, em princípio, *sempre devida* e esta circunstância constituiria em si mesma uma causa de justificação (responsabilidade só poderia atribuir-se, se disso fosse caso, ao superior hierárquico). Até, no máximo, às teses da **obediência devida limitada**, segundo as quais a causa justificativa operaria sempre que a ordem recebida fosse *formalmente legal* ou ainda quando, verificado aquele pressuposto e tendo o funcionário dúvida persistente sobre a sua legalidade material, respeitosamente solicitasse ao superior a *confirmação* da ordem recebida e/ou a sua *redução a escrito*. Considerando ainda a doutrina penal, por regra, que a instância decisiva para resolução da questão seria a legislação administrativa, enquanto o direito penal se limitaria a conceder eficácia justificativa ao cumprimento da ordem sempre que a obediência fosse **devida** (9). Questão seria, portanto, saber se a ordem dirigida à prática de um facto típico, apesar de ilegítima, seria *de cumprimento obrigatório para o subordinado*. Uma vez afirmada essa obrigatoriedade, abria-se a discussão acerca do efeito dessa ordem ilegítima obrigatória, dividindo-se a doutrina entre uma **solução de justificação** (10) do facto praticado pelo subordinado, assente na ideia do cumprimento de um dever, e uma **solução de exclusão da culpa** (11), que nega a justificação a partir de uma perspectiva objectivista da ilicitude e do princípio de que uma ordem, só por si, não pode ter o condão de transformar em lícita uma conduta ilícita.

§ 9 As concepções, da doutrina e depois do próprio legislador, a este respeito mudaram radicalmente entre nós com a doutrina corajosa — seja qual for a posição que em definitivo a respeito dela se tome — de Eduardo Correia, ao estabelecer no seu ensino (e ao transportar, praticamente em simultâneo, para o art. 38.º, § único, do seu ProjPG de 1963) o princípio

(9) Sobre toda esta problemática, no direito português, COLLAÇO, Magalhães, A desobediência dos funcionários administrativos e a sua responsabilidade criminal, *BFD III*, 1916-7, p. 69, CAETANO, Marcello, *Do Poder Disciplinar*, 1932, e *Manual de Direito Administrativo*, [6]1936, p. 496 e ss., VALENTE, Cunha, *A Hierarquia Administrativa*, 1934, p. 148 e ss. No direito alemão v. o estudo fundamental de STRATENWERTH, *Verantwortung und Gehorsam*, 1958 e entre nós BRANDÃO, Nuno, nota 6, p. 154 e ss.

(10) FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, p. 243 e ss., BELING, Ernst, *Die Lehre vom Verbrechen*, 1906, p. 177 e ss., MAYER, Hellmuth, Der bindende Befehl im Strafrecht, *Franck-FG*, 1930, p. 598 e ss., e ENGISCH, Karl, *Die Einheit der Rechtsordnung*, 1935, p. 50 e ss. Sobre esta doutrina, BRANDÃO, Nuno, nota 6, p. 154 e ss.

(11) CORREIA, Eduardo, II, § 35, MEZGER, *LK*, [8]1957, antes do § 51, 10, i), bb), WEBER, Hellmuth von, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Handeln auf Befehl, *MDR*, 1948, p. 37, e, na conclusão, MAURACH, § 31, I, 2. Sobre esta doutrina BRANDÃO, Nuno, nota 6, p. 157 e ss.

segundo o qual "**cessa o dever de obediência hierárquica quando conduz à prática de um crime**". Este princípio foi depois incorporado — como emblema da democraticidade do sistema —, praticamente com a mesma redacção, no art. 271.º-3 da CRP e nos arts. 36.º-2 e 31.º-2/*c)* do CP vigente. São estes os preceitos que demarcam o campo onde há-de ser determinado qual o efeito justificativo (se algum) que o direito vigente assinala às ordens oficiais ou de serviço.

§ 10 Duas situações importa distinguir. Pode desde logo suceder, na verdade, que a ordem recebida pelo inferior conduza à prática de um facto criminalmente típico, mas não ilícito; máxime, porque o superior deu a ordem no exercício de uma *actuação oficial* (supra, § 2 e ss.): neste caso a ordem é legítima e de cumprimento devido e o facto está **justificado** tanto perante o superior que deu a ordem, por força da autorização legal, como perante o inferior que a cumpre, em virtude da obediência devida. Em todos os casos, porém, em que o facto constitua (posta entre parênteses a questão da ordem) um ilícito criminal, **nunca a ordem oficial ou de serviço pode em si mesma constituir uma causa de justificação.**

§ 11 Diferentemente se passam as coisas se a ordem ilegítima **não conduzir à realização de um facto criminalmente ilícito** ([12]). Para estes casos vale o art. 271.º-2 da CRP, que consagra a atrás referida tese da responsabilidade limitada do subordinado, suposta a reclamação ou a solicitação da redução da ordem a escrito: "É excluída — assim reza aquele preceito — a responsabilidade do funcionário ou agente que actue no cumprimento de ordens ou instruções emanadas de legítimo superior hierárquico e em matéria de serviço, se previamente delas tiver reclamado ou tiver exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito". Mas é claro que o tema não respeita à questão aqui em debate, só podendo assumir relevo jurídico-penal na medida em que porventura se reflicta na questão da ilicitude da agressão para efeito de legítima defesa (supra, 15.º Cap., § 16 e ss.).

§ 12 Segundo a doutrina alemã porventura dominante, todavia, ainda importaria saber se e em que medida também uma ordem ilegítima é obrigatória para quem a recebe e por isso funda um dever de obediência. É hoje consensual no pensamento alemão, tal como entre nós, que a **ordem para a prática de um crime nunca é obrigatória**. Porém, a doutrina maioritária continua a creditar a exclusão da ilicitude à conduta

([12]) Para uma análise das ordens ilegítimas obrigatórias em matéria não penal, cf. BRANDÃO, Nuno, nota 6, p. 264 e ss.

do subordinado nos casos em que o facto típico é praticado em cumprimento de uma ordem ilegítima e o funcionário confiou, em estado de erro inevitável sobre o substrato factual da ordem, na sua legitimidade. Exclusão da ilicitude que já não é, porém, levada directamente à conta de um dever de obediência a ordens ilegítimas. Para uns, a justificação deriva da consideração de que em tais circunstâncias, tendo também o superior incorrido no mesmo erro, a ordem deve considerar-se legítima à luz do conceito de licitude penal (supra, § 4) ([13]). Para outros, a ilicitude do facto ordenado deve ser excluída pelo funcionamento conjunto de características específicas do problema das ordens da autoridade, como a presunção da legalidade dos actos estaduais e a inexistência de uma faculdade de exame à legitimidade material da ordem, e das regras gerais do erro sobre os pressupostos das causas de justificação, que em caso de erro inevitável sobre a ilegitimidade da ordem dita o afastamento do ilícito doloso de acção, como também do negligente, por inexistência do desvalor da acção ([14]).

§ 13 Entre nós vem-se entendendo, na esteira de um pensamento que se consolidou e tornou dominante com Stratenwerth, que a contradição entre o dever de obediência e o dever de não ir contra uma norma penal constitui um **conflito de deveres** ([15]) ([16]) e só pode, por isso, ser decidida depois de se saber qual dos dois deveres surge como superior. Se, de acordo com a situação das coisas, o dever de obediência for superior, a ordem ilegítima constitui uma causa de justificação ([17]). Mas aqui inter-

([13]) M / ZIPF, I, § 29, n.º 10, JESCHECK / WEIGEND, § 35, II, 4, BRANDÃO, Nuno, nota 6, p. 127.

([14]) STRATENWERTH, nota 9, p. 169 e ss., S / S / LENCKNER, antes do § 32, n.º 88, e LEHLEITER, *Der rechtswidrige verbindliche Befehl*, 1995, p. 132 e ss. Uma perspectiva crítica sobre esta tese, em sede geral de erro sobre as causas de justificação, supra, 14.º Cap., § 23 e ss., e no específico âmbito das ordens oficiais, BRANDÃO, Nuno, nota 6, p. 145 e ss.

([15]) STRATENWERTH, nota 9, p. 7 e ss. e *passim*.

([16]) Com a restrição, em todo o caso — acentua ROXIN I, § 17[26] —, de tecnicamente se não tratar aqui de um *autêntico* conflito de deveres, por nele conflituarem um dever de acção (o de cumprimento da ordem) e um dever de omissão (o de omitir a prática de factos criminalmente ilícitos): cf. supra, 16.º Cap., § 42 e s.

([17]) Esta a razão pela qual STRATENWERTH, nota 9, pp. 182 e 204, considerava — em face de um direito positivo alemão entretanto revogado, que impunha a obediência a ordens dirigidas à prática de contravenções (*Übertretungen*) — que o dever de obediência poderia impor-se à lei penal em caso de infracções de pequena gravidade (cf. BRANDÃO, Nuno, nota 6, p. 164[411]). Afirmando agora, na doutrina portuguesa, pelas razões que se aduzem em texto, que o dever de obediência cede *sempre* perante a lei penal, independentemente da gravidade do crime, tam-

vém precisamente o conteúdo prático-normativo, *fundamental na perspectiva jurídico-penal da justificação*, do art. 271.º-3 da CRP e do art. 36.º-2 do CP; e a razão, de resto, por que este último preceito faz parte do normativo penal consagrado ao "conflito de deveres". Esse conteúdo prático-normativo reside em que, na intenção da lei — e na verdade ao nível mais elevado, o jurídico-constitucional, *pelo que não pode ser contrariado por qualquer legislação ordinária, inclusivamente a militar* —, o dever de obediência a uma ordem, a qualquer título, que conduza à prática de um facto criminalmente ilícito não pode considerar-se, nem mesmo excepcionalmente, igual ou superior ao dever de não cometer factos que constituem ilícitos criminais. Tendo por isso de concluir-se que, segundo o direito constitucional e o direito penal português vigentes, **uma ordem da autoridade ou de serviço que conduza à realização de um facto criminalmente ilícito não constitui nunca, em si e por si mesma, uma causa justificativa** daquele: tudo o que pode ficar em aberto é uma *causa de exclusão da culpa* do subordinado que a cumpre (art. 37.º e infra, 24.º Cap.) ([18]).

§ 14 Claramente neste sentido ia já o ensino de Eduardo Correia, se bem que admitindo depois que **em casos excepcionais** pudesse ter de considerar-se o dever de obediência à ordem ilegal de **hierarquia superior** ao dever de omitir a prática do crime ([19]). O que não deixa de bem se compreender quando se atenta que Correia escrevia antes de a solução que em princípio propugnava estar consagrada quer no CP português, quer na Constituição. Através de uma interpretação hábil e engenhosa dos arts. 44.º-3, 298.º, 303.º, § 1.º, e 39.º, circ. 12.ª, do CP de 1886, pretendia já Correia mostrar que nenhuma destas disposições tolhia definitivamente o passo à solução que defendia ([20]).

III. Autorizações oficiais

§ 15 A questão da eficácia justificativa do facto criminalmente típico resultante de autorizações oficiais ganhou nos nossos tempos um especial

---

bém COSTA, Faria, *Noções Fundamentais de Direito Penal (Fragmenta Iuris Pœnalis)*, 1999, § 37, e BRANDÃO, Nuno, nota 6, p. 252 e s.

([18]) Na conclusão, já, também, na doutrina alemã, M / ZIPF, § 29, n.º 7 e ss. Entre nós, no sentido do texto, BRANDÃO, Nuno, nota 6, p. 250 e ss. e *passim*. Contra, CARVALHO, Taipa de, *A Legítima Defesa*, 1995, p. 210 e ss., e nota 5, p. 303 e ss., por considerar que existem ordens que, sendo formal e funcionalmente ilegítimas, não são todavia sindicáveis, na sua aplicação concreta, pelo funcionário executor, que as torna na prática como ordens de obediência e execução obrigatórias, daí resultando a exclusão da ilicitude do facto ordenado.

([19]) CORREIA, Eduardo, II, n.º 23.

([20]) CORREIA, Eduardo, II, n.º 24.

relevo, sobretudo em função dos problemas suscitados pelo **direito penal do ambiente e de ordenamento do território**. No entanto, ela é já de há muito conhecida — sobretudo dos domínios do direito penal secundário de natureza administrativa e, portanto, desde os tempos em que ganhou relevo a intervenção sistemática do Estado na regulamentação da vida social — e abrange desde actividades que são em si mesmas socialmente adequadas (*v. g.*, conduzir automóvel, para o que se torna necessária uma autorização oficial traduzida na habilitação legalmente exigida, permissão para visitar edifícios públicos ou para utilizar dinheiros públicos, etc.), até outras que podem colocar em sério risco bens jurídicos de terceiros mas são autorizadas em nome da prossecução de interesses preponderantes (21) (*v. g.*, exploração oficialmente autorizada de indústrias poluentes ou altamente perigosas, exportação ou venda de obras de arte, etc.).

§ 16 Isto faz logo compreender a razão por que, tal como no consentimento (supra, 17.º Cap., § 4 e ss.), também aqui a autorização oficial pode em certos casos operar ao nível da **exclusão da tipicidade**, noutros ao nível da **exclusão da ilicitude** (22). Claro que as situações não são idênticas, pelo que neste campo não pode por exemplo, para efeito da distinção, atribuir-se o relevo que em matéria de acordo vimos dever conceder-se ao *teor literal* dos tipos legais de crime; mas não deixa de apresentar uma larga convergência o **fundamento** da distinção. O que sucede, na verdade, é que a autorização oficial corre em certos casos no mesmo sentido da protecção do bem jurídico — quando, justamente, se depara com actividades que são em geral socialmente adequadas e mesmo desejáveis —, enquanto noutros casos a actividade autorizada lesa efectivamente bens jurídicos e não pode por isso dizer-se socialmente adequada: a autorização assume nestes casos o sentido de uma credencial que permite ("excepcionalmente" (23)) aquela lesão dentro de certos limites, de certa medida e de certos requisitos. Por isso ela constitui neste segundo grupo de casos uma **causa de justificação do facto** quando a totalidade daquelas condições é respeitada.

---

(21) O que leva ROXIN I, § 17, n.º 65, a considerar que "a autorização oficial justificante é um caso especial do § 34, estado de necessidade justificante".

(22) ROXIN I, § 17, n.º 58 e ss., e STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 134.

(23) Como acentuam muitos autores alemães: HIRSCH, *LK*, n.º 160 antes do § 32, ROXIN I, § 17, n.º 59 e ss., S / S / LENCKNER, n.º 61 antes do § 32, STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 134.

§ 17 Saber sob que condições constitui a autorização oficial uma causa de justificação é questão que se suscita quando ela tenha sido **obtida incorrectamente**, isto é, quando ela, por razões fácticas ou jurídicas, não deveria ter sido concedida. O problema da justificação penal liga-se deste modo incindivelmente à posição que na matéria assuma o direito administrativo, por isso se afirmando com razão que aqui se introduz uma cláusula de **acessoriedade administrativa** (24). Consenso existe na doutrina somente quanto a que, sendo **nula** a autorização obtida, nos termos dos arts. 133.º e 134.º do CPA, ela *não tem eficácia justificadora* (25). Quanto à autorização meramente **anulável**, as opiniões dividem-se profundamente a respeito da espécie de acessoriedade administrativa exigida. A discussão tem-se centrado — compreensivelmente — sobretudo na questão de saber se o ponto de vista jurídico-penal, em último termo decisivo para a justificação, deve ligar-se às *normas jurídico-administrativas materiais* (acessoriedade dita "relativa à **norma**" ou também acessoriedade "**de direito**"); ou se, diferentemente, deve ligar-se ao *acto da autoridade administrativa competente* (acessoriedade dita "relativa ao **acto**" ou "**de acto**").

§ 18 Uma pura acessoriedade **de direito** pode esquecer ou minimizar a importância e mesmo a necessidade de um conjunto de actos administrativos concretos — autorizações, licenças, concessões, etc. — legalmente exigidos e efectivamente indispensáveis para actuar as relações entre a Administração e os particulares; para *aplicar* ao caso a norma (procedimento que se não reduz a pura actividade silogística, mas implica um qualquer momento de "criação de direito" face à teleologia implícita na norma); e para dar claramente a entender ao destinatário da norma a razão de ser do comando e, por aí, a ligação da conduta permitida à tutela de um *bem jurídico*. Por isso, quando se trata da eficácia justificadora da autorização oficial, o ponto de partida tem forçosamente de ser o da acessoriedade de **acto**. Em princípio, uma vez concedida a autorização — mesmo que ela seja anulável segundo o direito administrativo material —, não deve ser pos-

---

(24) Sobre ela, a propósito do direito penal do ambiente e, concretamente, do art. 279.º, DIAS, Figueiredo, Sobre a tutela jurídico-penal do ambiente — um quarto de século depois, *Estudos Cunha Rodrigues*, I, 2001, p. 385 e ss. Advirta-se, todavia, que o problema ali considerado é mais lato e, em definitivo, diferente daquele agora em consideração e em que se indaga da eficácia *justificadora* de uma autorização já efectivamente *concedida*.

(25) Uma visão de conjunto da doutrina alemã em S / S / CRAMER / HEINE, § 330d, n.º 9 e ss.; para a doutrina espanhola, GÓMEZ Rivero, Maria Carmen, *El Régimen de Autorizaciones en los Delitos Relativos a la Protección del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio*, 2000.

sível considerar ilícito o facto praticado no uso dessa autorização pelo particular. Só assim não devendo acontecer ([26]) quando o acto de autorização da Administração constitua resultado directo de uma actividade ilícita e dolosa do particular. Pense-se, por exemplo, em um caso de corrupção da Administração, levada a cabo pelo particular com a intenção (lograda) de obter uma autorização para a prática de um comportamento lesivo de bens jurídicos e proibido pela norma administrativa. Se neste caso o agente se tornasse punível apenas pelo crime de corrupção estar-se-ia a conceder um injustificado benefício ao infractor e a colocar não menos injustificadamente entre parênteses a perda do bem jurídico atingido ([27]).

IV. Actuação no lugar de um órgão oficial ("agere pro magistratu")

§ 19 Aos fundamentos do Estado de Direito continua a pertencer o princípio do *monopólio estadual da utilização da força*. Este princípio não exclui, todavia, o *direito* ou o *poder* de actuação legítima dos particulares **em lugar** do Estado ou dos seus órgãos como **medida provisória** de realização da ordem jurídica.

1. Detenção em flagrante delito

§ 20 Manifestação desta legítima actuação é, desde logo, o *poder* que assiste a **qualquer pessoa** para proceder à detenção em flagrante delito do agente de um crime punível com pena de prisão, se qualquer entidade judiciária ou entidade policial "não estiver presente nem puder ser chamada em tempo útil" (art. 255.º-1/*b)* do CPP). Condição de justificação da privação da liberdade é todavia (ainda segundo o citado preceito) que "a pessoa que tiver procedido à detenção entregue imediatamente o detido" à autoridade judiciária ou entidade policial. Por outro lado, como é óbvio, por esta via fica justificada apenas a privação da liberdade, não já qualquer violação típica da integridade física do detido, mesmo que tendente a evitar a fuga (ressalvada a eventual intervenção de um estado de necessidade justificante) ([28]).

([26]) Contra a excepção, todavia, STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 132.

([27]) Esta conclusão corresponde à da doutrina que cremos dominante na Alemanha (cf. ROXIN I, § 17, n.º 63 e ss.), a qual procura justificar-se através da cláusula do *abuso de direito* e por vezes é cognominada de "acessoriedade administrativa de acto *limitada*".

([28]) Nestes termos, S / S / LENCKNER, n.º 82 antes do § 32, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 134.

A justificação da actuação no lugar de um órgão oficial fica deste modo estritamente subordinada aos princípios da **provisoriedade** e da **subsidiariedade**.

2. Acção directa (art. 336.º do CC)

§ 21 Tratando-se de *interesses jurídico-civilmente relevantes*, é lícito o recurso à força — consistente na apropriação, destruição ou deterioração de uma coisa, na eliminação da resistência irregularmente oposta ao exercício de um direito, ou noutro acto análogo — com o fim de evitar a inutilização prática do direito próprio. Requisitos da justificação são, por um lado, que o recurso à força seja **indispensável**, dada a impossibilidade de recorrer em tempo útil aos meios coercivos normais, para alcançar a finalidade visada; por outro lado, que o agente não exceda o que for **necessário** para evitar o prejuízo; e, finalmente, que o facto **não sacrifique interesses superiores** aos que o agente visa realizar ou assegurar.

§ 22 Uma vez mais, o CC mistura nesta figura, de modo porventura pouco adequado, elementos pertencentes à legítima defesa e ao estado de necessidade justificante. Por uma parte, parece que o preceito visa defender, na matéria jurídico-civil a que se aplica, o Direito perante o ilícito, configurando consequentemente o acto potencialmente lesivo de bens jurídicos do agente não como um *perigo*, mas substancialmente como uma **agressão**; e o acto do agente não como acto de afastamento de um perigo, mas verdadeiramente como um acto de **defesa**. Enquanto, por outra parte, exige um estrito **juízo de proporcionalidade** dos bens em conflito, que só seria substancialmente aceitável e compreensível se não se tratasse de repelir uma agressão imediata à ordem jurídica. Cremos que esta contradição normativa e teleológica — que, como resulta do que já noutros lugares deixámos dito, deveria quanto a nós ser resolvida afastando a acção directa do modelo da legítima defesa e aproximando-a do modelo do estado de necessidade — é ineliminável por via interpretativa e só pode ser obviada através da reforma do preceito em causa do CC ([29]).

([29]) Cf., para distintos pareceres, CORREIA, Eduardo, II, p. 113; FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 235; ASCENSÃO, Oliveira, A teoria finalista e o ilícito civil, *DJ II*, 1981-86 (*Homenagem Cavaleiro de Ferreira*), p. 92 e ss.; PALMA, Fernanda, *A Justificação por Legítima Defesa como Problema de Delimitação de Direitos*, II, 1990, p. 816 e ss., 824: "pode reconhecer-se que a acção directa aflora um princípio justificador geral"; BRITO, Teresa de, Homicídio justificado em legítima defesa e em estado de necessidade, *Estudos Cunha Rodrigues*, I, 2001, p. 212 e ss., 215: "possibilidade de fundamentar, na acção directa, um espaço de justificação intermédio entre a legítima defesa e o estado de necessidade"; e, no sentido do texto, CARVALHO, Taipa de, nota 18, p. 291 e [516].

V. O direito de correcção

§ 23 Um direito de correcção como justificação do facto coloca-se hoje, entre nós, praticamente apenas — e cada vez de forma mais restritiva, no entendimento dominante — relativamente a **pais** (arts. 1878.º e 1885.º-1 do CC) e a **tutores** (art. 1935.º do CC). O círculo dos factos relativamente aos quais o exercício de um tal direito pode actuar tem que ver predominantemente com as *ofensas à integridade* física, os chamados "castigos corporais", do art. 143.º e ss., ou com os maus-tratos do art. 152.º Mas não está excluído que em certas hipóteses o problema possa ainda suscitar-se — e eventualmente a justificação ocorrer — a propósito de factos típicos como os de violação da *liberdade pessoal* (nomeadamente, de *ameaças*, de *coacção* e de *sequestro* ([30]) — *v. g.*, a ordem dada ao menor para que permaneça em casa ou no seu quarto —, dos arts. 153.º, 154.º e 158.º), da *honra* (*injúria*, art. 181.º) ou da *reserva da vida privada* (nomeadamente, do *segredo de correspondência ou de telecomunicações*, art. 194.º).

§ 24 Largamente dominante é hoje a doutrina em considerar que a justificação ocorre só dentro de três condições ([31]): (1) que o agente actue com **finalidade educativa** ([32]) e não para dar vazão à sua irritação, para descarregar a tensão nervosa ou, ainda menos, pelo prazer de infligir sofrimento ao dependente ou para lograr aquilo que apeteceria chamar um efeito de "prevenção, geral ou especial, de intimidação"; (2) que o castigo seja **criterioso** e portanto *proporcional*: no sentido de que ele deve ser o mais leve possível e não no de que ele possa (que não pode) assumir um peso equiparado ao da falta cometida pelo educando, quando

---

([30]) Cf., também, CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, I, art. 158.º, § 28, e art. 152.º, § 11.

([31]) Sobre o que se segue FARIA, Paula Ribeiro de, A lesão da integridade física e o direito de educar — uma questão "também" jurídica, *Iuris et de Iure*, p. 921 e ss.; e, até há pouco, a maioria da doutrina alemã, pela qual podia ver-se JAKOBS, 16/33, JESCHECK / WEIGEND, § 35, III, ROXIN [3]I, § 17, n.º 34 e s., e STRATENWERTH[4], § 9, n.º 136.

([32]) Que porventura não tem, todavia, de ser única, com ela podendo concorrer outras motivações: assim, ROXIN, *in*: Eser / Perron (orgs.), *Rechtfertigung und Entschuldigung*, III, 1991, p. 359, e CARVALHO, Taipa de, nota 18, p. 383[655]. Na nossa jurisprudência, exigindo esta finalidade educativa, Ac. do STJ de 9-2-1994, *CJ STJ*, 1994, I, p. 217: "não se tendo provado que a intenção do pai, ao agredir a filha menor e débil mental, fosse a de corrigir e educar, não pode falar-se de exclusão da ilicitude". Com interesse ainda o Ac. da RC de 24-4-1991, *CJ*, 1991, II, p. 113 e s.

esta foi grave ou muito grave ([33]); (3) e que — em consequência e para mais cabal esclarecimento do que acabou de dizer-se — ele seja sempre e em todos os casos **moderado**, nunca atingindo pois o limite de uma qualquer ofensa qualificada ou, de todo o modo, atentatória da dignidade do menor.

§ 25 Hoje, porém, já nem o aludido direito de correcção dos pais e tutores é indiscutivelmente aceite como causa justificativa. Assim, por exemplo, a lei alemã de 3-11-2000 — seguindo o trilho da lei da paternidade sueca — veio dar a seguinte redacção ao § 1631 II do CC alemão: "Os filhos têm direito a uma educação isenta de violência. Castigos corporais, ofensas psíquicas e outras medidas contra a dignidade são inadmissíveis". Perante este texto legal uma parte da doutrina entende que **uma causa justificativa do direito de correcção desapareceu** ([34]), sobretudo relativamente a ofensas à integridade física; embora persista seguramente o direito de correcção relativamente a condutas que ou se não apresentem como formalmente típicas ou, quando surjam como tal, não o sejam materialmente, em virtude, *v. g.*, da sua insignificância, ou, eventualmente, da sua adequação social. Face ao disposto na nova versão do transcrito § 1631 II não falta porém quem sustente que ele é **materialmente inconstitucional** por violar o direito de correcção dos pais assegurado pelo art. 6 II, 1, da Lei Fundamental alemã ([35]).

§ 26 Um direito de correcção do **professor** sobre os seus alunos que implique a prática, por aquele, de factos criminalmente típicos não parece poder hoje sufragar-se, também entre nós: falta uma lei na base da qual uma tal causa de justificação possa ser aceite e contra ela está, além disso, o estatuto dos estudantes dos ensinos básico e secundário (DL 270/98, de 1-9), o qual, no seu art. 12.º-3, dispõe que "as medidas educativas disciplinares não podem ofender a integridade física ou psíquica do aluno" ([36]). O direito — simultaneamente um dever, aliás — de correcção na escola sem dúvida existe, mas parece ter agora de passar por formas de exercício que se não traduzam, da parte dos professores, na prática de factos materialmente

([33]) FARIA, Paula Ribeiro de, nota 31, p. 925.

([34]) ROXIN I, § 17, n.º 32 e ss., com indicações concordantes e discordantes; de forma mais limitada STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 142.

([35]) V., com indicações, a questão discutida em ROXIN I, § 17, n.º 37.

([36]) Mesmo antes da entrada em vigor deste diploma legal, na vigência da Portaria 679/77, de 8-11, o direito de correcção dos professores era também negado pela nossa jurisprudência mais recente: cf. Ac. da RP de 3-2-1998 (Proc. n.º 9810452), que negou a justificação a uma presidente do conselho directivo de uma escola preparatória, que desferiu seis bofetadas num aluno de 11 anos, levado à sua presença por se ter encavalitado numa rede da escola, desde logo por aos professores faltar tal poder de correcção.

típicos. Pode duvidar-se que seja esta a forma por excelência de resolver o problema, hoje gravíssimo, de indisciplina nas escolas; todavia, *iure constituto*, não se vê legitimidade para outra solução, nomeadamente através do apelo frequente a práticas consuetudinárias ou socialmente adequadas ([37]).

§ 27 Recentemente, a opinião pública portuguesa foi fustigada pelos meios de comunicação com a posição (alegadamente) dificilmente compreensível e ultra-conservadora que teria sido tomada, na matéria em apreço, pelo Ac. do STJ de 3-4-2006. Como concluiu Paula Ribeiro de Faria, em ponderada anotação àquele aresto, a leitura atenta e integral do acórdão ([38]) mostra, pelo contrário, uma reflexão séria e reflectida, por parte do Tribunal, de problemas de elevada sensibilidade humana e jurídica. Na parte que aqui interessa, relevante é a circunstância de o art. 1907.º-1 do CC dispor que "quando o filho for confiado a **terceira pessoa** ou a **estabelecimento de educação ou assistência**, cabem a estes os poderes e deveres dos pais que foram exigidos pelo adequado desempenho das suas funções". Mesmo que se deva concordar com Paula Ribeiro de Faria em que, por força deste preceito, se não deve equiparar integralmente, em perspectiva jurídico-penal, a legitimidade para corrigir dos pais e a dos terceiros ora em causa ([39]), a verdade é que para estes é como que "transferido", ao menos em parte, o direito de correcção paternal (como fruto tardio, porventura, do velho princípio do castigo *in locum parentium*). Não é pois (ainda?) possível defender no direito português aquele carácter *estritamente pessoal* do direito de correcção dos progenitores que por exemplo no direito alemão é hoje dominantemente aceite.

§ 28 Paula Ribeiro de Faria sustenta agora (diversamente do que sucedia no seu estudo de 1998 que vimos citando, onde colocava aquela problemática, como o texto, básica ou exclusivamente a nível da justificação ([40])) que, uma vez "reunidos os pressupostos de que depende o uso legítimo de uma medida educativa, a sua aplicação é legítima e pode [em nome da *adequação social*] ser considerada atípica e não meramente jus-

([37]) Na conclusão, também, FARIA, Paula Ribeiro de, nota 31, p. 920.

([38]) FARIA, Paula Ribeiro de, Acerca da fronteira entre o castigo legítimo de um menor e o crime de maus-tratos do art. 152.º do Código Penal, *RPCC 16*, 2006, pp. 317 e ss., 343.

([39]) FARIA, Paula Ribeiro de, nota anteior, p. 225.

([40]) FARIA, Paula Ribeiro de, nota 31, p. 901 e ss.

tificada" ([41]); num plano análogo àquele com que se depara nas intervenções médico-cirúrgicas ou nas lesões no curso de actividades desportivas. Temos todavia dúvidas de que assim se não vá longe demais. Relativamente às intervenções médicas houve uma clara (e difícil, e não isenta de legítimas dúvidas: supra, 17.º Cap., § 9) opção legislativa, vazada no art. 150.º, que falta em matéria de direito de correcção. Acresce que, de acordo com as concepções sociais hoje dominantes — já o anotámos —, toda a acção educativa deve processar-se através de condutas formalmente atípicas, por um lado; e que, por outro lado, as condutas formalmente típicas em causa atingem — salvo, nomeadamente, em caso de intervenção da *cláusula de insignificância* — bens jurídicos do menor, nomeadamente, a sua integridade física, e não correm por isso no sentido da sua protecção ou realização. O que, a ser exacto, significará que a situação com que aqui se depara é eminentemente *conflitual* e deve ser solucionada, por conseguinte, no domínio de uma eventual *justificação*.

([41]) FARIA, Paula Ribeiro de, nota 38, p. 330 e ss., e já *A Adequação Social da Conduta no Direito Penal ou o Valor dos Sentidos Sociais na Interpretação da Lei Penal*, 2005, p. 417.

SUBTÍTULO II

O TIPO DE CULPA

SECÇÃO I

A FUNDAMENTAÇÃO DA CULPA

19.º CAPÍTULO

QUESTÕES BÁSICAS DA DOUTRINA DA CULPA

§ 1 Já nas considerações introdutórias à construção da doutrina do crime (supra, 10.º Cap., § 65 e ss.) deixámos referidas as questões mais importantes que a compreensão dogmática e sistemática da doutrina da culpa suscita, bem como a sua função no sistema. Antes porém que procedamos ao estudo da culpa como categoria integrante do conceito de crime e dos seus elementos constitutivos, importa ainda realçar alguns aspectos fundamentais que na exposição anterior ficaram apenas sugeridos. Já por várias vezes acentuámos que o **princípio da culpa** constitui hoje uma máxima fundamental de todo o direito penal e que, entre nós, não é mesmo aventuroso considerá-lo um princípio implícito do sistema jurídico-constitucional. A prática pelo agente de um facto ilícito-típico não basta em caso algum para que, na sua base, àquele possa aplicar-se uma pena (se bem que possa ser fundamento, juntamente com a comprovação da perigosidade, da aplicação de uma medida de segurança). A aplicação da pena — como de resto, terminantemente, o afirma o art. 40.º-2 — supõe sempre que aquele ilícito típico tenha sido praticado com culpa. Torna-se por isso absolutamente indispensável, para além da determinação da função da categoria no sistema, determinar **o que é materialmente a culpa de que se trata no direito penal**. Numa sua conveniente *pré-compreensão*, o mais que pode ser dito é que, o que quer que seja materialmente, ela surge como uma **censura jurídica** dirigida ao agente pela prática do facto. Ir para

além disto supõe porém que se analise mais de perto, embora de forma sintética e sumária, a evolução do conceito durante o último século e que se não escamoteiem os complexíssimos problemas penais e jurídico-filosóficos (e mesmo filosóficos gerais) que a sua determinação supõe.

I. A história dogmática do conceito

§ 2 Ainda hoje se não encontra estabelecida com clareza a **história** do princípio da culpa e das suas relações com a tese da responsabilidade objectiva ou pelo resultado (1). Não parece todavia arriscado afirmar que ela revela um longo e paulatino (mas não poucas vezes, desde as civilizações antigas, sinuoso e acidentado) percurso de afastamento do princípio da responsabilidade objectiva em direcção a um reconhecimento cada vez mais perfeito do princípio da culpa. A progressiva afirmação deste último correu parelha com um progressivo aprofundamento e aperfeiçoamento do conceito de culpa, que de há muito se autonomizou do conceito de culpa válido em outros ramos do direito, nomeadamente no direito civil (2): precisamente logo que a doutrina jurídico-penal assentou na indispensabilidade de (contra certas tendências, ocorridas na primeira metade do séc. XX, de cariz neo-hegeliano e que haviam de cristalizar no chamado pensamento ordinalista concreto: supra, 10.º Cap., § 5) cindir em categorias absolutamente autónomas os conceitos de *ilicitude* (ou antijuridicidade) e de *culpa*. Isto sucedeu — sobretudo por força da doutrina alemã — por volta do final do séc. XIX (sobre isto e o que se segue, já 10.º Cap., § 7 e ss.) e conduziu a uma concepção positivista-naturalista do conceito de crime, em que a culpa abrangia tendencialmente a totalidade dos elementos subjectivos do delito segundo uma sua compreensão eminentemente psicológica. "A culpa — proclama Beling de forma paradigmática — reside na relação psicológica do agente com o facto no seu significado objectivo, no reflexo espiritual da realidade" (3). Por isso se denomina esta concepção,

---

(1) Sobre o ponto, entre nós, DIAS, Figueiredo, *Responsabilidade pelo Resultado e Crimes Preterintencionais*, 1961, p. 3 e ss. Em data mais recente a fundamental monografia de ACHENBACH, *Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystematischen Schuldlehre*, 1974. Cf. agora, também — embora à luz dos problemas da imputabilidade e da exigibilidade —, NEVES, Curado, *A Problemática da Culpa nos Crimes Passionais*, 2006, *passim*, especialmente pp. 223 e ss., 325 e ss. e 678 e ss.

(2) Logo DIAS, Figueiredo, Sobre a reparação de perdas e danos arbitrada em processo penal, *Estudos Beleza dos Santos*, p. 124 e ss.

(3) BELING, *Die Lehre vom Verbrechen*, 1906, p. 10.

com razão, como do conceito **psicológico** de culpa. O cerne da categoria reside no dolo e na negligência como espécies diferenciadas de ligação psicológica entre o agente e o facto. Enquanto a capacidade de culpa (imputabilidade) não constitui elemento integrante do conceito, mas seu *pressuposto* e a exigibilidade de outro comportamento, como requisito puramente normativo, não releva pura e simplesmente para a culpa.

§ 3 Sabemos já também que este conceito psicológico de culpa acabou por soçobrar perante as críticas de que toda a orientação positivista-naturalista se tornou passível desde os começos do séc. XX; e, concretamente quanto ao conceito de culpa, perante a descoberta de que a *censura* ao agente em que a culpa há-de traduzir-se não tem só a ver com elementos de raiz psicológica, mas também — e porventura sobretudo — com momentos normativos. O papel mais relevante neste reconhecimento (que rapidamente se tornou consensual) terá cabido a Frank, a propósito do estudo a que procedeu do chamado estado de necessidade desculpante (infra, 22.º Cap., § 14 e ss.). Neste caso, como em outros, o agente pode ter actuado com dolo como elemento de ligação psicológica entre ele e o facto ilícito-típico e, todavia, não ser considerado culpado por o seu facto lhe não ser *censurável*. Culpa é **censurabilidade** por o agente ter agido como agiu e nisto se traduz a concepção **normativa** do conceito de culpa. Para além das realidades do dolo e da negligência — que continuam a ter assento no conceito —, a culpa tem como elementos a imputabilidade ou capacidade de culpa, a consciência (potencial) do ilícito e a exigibilidade de comportamento diferente (4). Constituiu por isso só uma exasperação desta concepção normativa o ter a doutrina da acção final, com a deslocação que operou do dolo e da negligência da sede da culpa para a da tipicidade, "depurado" o conceito de culpa de modo a alegadamente ter deixado nele apenas os elementos de índole estritamente normativa e ter transformado a censurabilidade em **puro juízo de valor** (5).

§ 4 Tomar posição em toda esta querela implica, sem alternativa, determinar **o que é materialmente a culpa** jurídico-penal. Antes desta determinação não se torna possível assumir proposições conclusivas também quanto à natureza do próprio juízo de culpa e toda a discussão corre

(4) FRANK, *Über den Aufbau des Schuldbegriffs*, 1907.
(5) WELZEL, § 19, III, e M / ZIPF, § 30, n.º 28.

sério risco de descambar em puro nominalismo. O mais que pode desde já dizer-se é que retirar todo o substrato ao conceito de culpa, transformando-o em "*puro* juízo de censura", é solução que furta ao conceito o cumprimento da **função** que deve desempenhar no sistema e fora da qual ele perde o seu carácter irrenunciável e sem alternativa. Sempre se repete, contra este argumento, a alegação de que a culpa é afinal só *um outro ponto de vista*, diferente do da ilicitude, segundo o qual *o mesmo substrato* (o facto, o facto típico, o ilícito-típico ou como quer que nos exprimamos) deve ser apreciado, pelo que aquele substrato não tem em nada de ser modificado (6). Mas esta concepção é — já resulta de muito do que ficou dito — para nós inaceitável. Nem o substrato da culpa pode ser o tipo, porque este é já *tipo de ilícito*, mas sim — como quer que a materialidade da culpa venha a determinar-se — o *tipo de culpa*. Nem a culpa, se quiser cumprir a sua função de limitação do intervencionismo estatal (nomeadamente na matéria primordial de limite da medida da pena), pode esgotar-se num puro juízo de censura dirigido a uma matéria que foi determinada sem qualquer conexão com os pontos de vista próprios da culpa. Afirmar (correctamente) que culpa é censurabilidade nada diz sobre aquilo que materialmente se censura: se o facto na sua revelação objectiva, se a inobservância da norma de dever quando o agente podia cumpri-la; se a personalidade ou atitude interna manifestada no facto e que o fundamenta. Como nada diz sobre o ponto essencial de saber se uma tal censurabilidade supõe a *liberdade* do agente, seja na acepção de que ele podia comportar-se de maneira diferente, seja na de que ele podia ser um outro que assumisse diferente atitude perante os valores e os bens protegidos pela ordem jurídica.

§ 5 As interrogações que ficam alinhadas ou subentendidas têm a ver com um ponto que, na discussão mais recente, ganhou importância fundamental: o de saber se o juízo de censura, em que a culpa se traduz, é um juízo radicalmente **individualizado** ou se nele vai inevitavelmente compreendida uma certa **generalização**. Questão esta que — independentemente do seu relevo basilar para a compreensão dogmática da culpa — se tornou instante face aos conhecimentos mais recentes trazidos pela evolução formidável sofrida no último meio século pelas ciências do Homem, desde a psicologia à psiquiatria, desde a antropologia à caracterologia, desde a biologia à genética; e face ao reconhecimento de que a culpa, como quer que materialmente se conceba, é e só pode ser um elemento do sistema penal e tem por isso de estar subordinada às exigências **político-criminais** que naquele se fazem sentir. Sem que todavia, a partir deste ponto de vista na verdade imperioso, se possa determinar a culpa como

(6) Sobre a questão, por último, STRATENWERTH / KUHLEN, § 10, n.º 3.

um puro **derivado** de exigências político-criminais, nomeadamente, da prevenção. Entre o Cyla de uma extrema "funcionalização" e o Carybdis de uma extrema "eticização" (talvez pudesse dizer-se mais correcta e expressivamente: "jusnaturalização") do conceito, tem procurado subsistir e progredir a doutrina da culpa mais recente. Mas talvez haja razão para esperar que a consideração *a se* da questão do conteúdo material da culpa possa ajudar a que se faça alguma luz também quanto a este tema; e a que se torne mais fundada a proposição, que supra avançámos (10.º Cap., § 68), segundo a qual não há contradição insanável entre afirmar por um lado que a culpa jurídico-penal se encontra *funcionalizada ao sistema* e por outro que ela participa, segundo o seu conteúdo, de uma *culpa ética* (*hoc sensu*, ético-existencial) como violação pela pessoa do dever essencial do ser-livre.

II. O conteúdo material da culpa jurídico-penal

1. Introdução

§ 6 Ficou já dito que, em nossa opinião, se a culpa jurídico-penal se encontra inevitavelmente *funcionalizada ao sistema*, na medida em que quer cumprir uma função político-criminal primária de limitação do intervencionismo estatal em nome de uma defesa consistente da eminente dignidade da pessoa, justamente por esta via ela tem de participar, segundo o seu conteúdo, de uma *culpa ética*, como violação pela pessoa do dever originário e essencial de realização e desenvolvimento do ser-livre (do dela e do de todos os outros). Para apreensão tanto quanto possível exacta do conteúdo material do conceito de culpa que destas duas exigências (à primeira vista provenientes de quadrantes contrapostos) deriva, necessário se torna dar ainda um passo — por mais que ele venha dificultar a tarefa referida — na explicitação do valor de garantia e da função limitadora ínsitos no apelo à *dignidade da pessoa*. Uma tal explicitação costuma ser feita através das ideias da liberdade, da igualdade e da solidariedade, que assim se tornam em atributos dominantes da disciplina de todas as relações sociais ([7]). Se perguntarmos qual dessas ideias assume mais directa relevância para a culpa, a resposta não pode deixar de ser a da **liberdade**, concebida não apenas como característica do actuar no âmbito político, mas como autodeterminação da pessoa na sociedade, e, assim, como expressão da autonomia e da inviolabilidade na regência da sua conduta pessoal. O que é só consequência ([8]) de o valor da dignidade pessoal

([7]) Assim, MELO, Barbosa de, *Democracia e Utopia*, 1980, p. 17 e s.

([8]) Como exactamente aponta MELO, Barbosa de, nota 7, p. 22.

surgir, no contexto democrático, também como uma *ideia prática*: uma ideia que implicitamente contém o imperativo da sua encarnação nas pessoas concretas, que vivem nas sociedades reais. Enquanto, por outro lado, para além de que é na liberdade que se centra o peso tradicional da controvérsia à roda da culpa, é através dela que mais claramente se exprime a sua ligação ao ideário "liberal" e ao seu efeito limitador da responsabilidade; como é através dela que a culpa se torna em censura ético-pessoal.

§ 7 Aqui deparamos com o verdadeiramente essencial. A *liberdade* da pessoa — por mais duvidosa que ela seja no seu **se** e no seu **como** — é o íntimo pressuposto comum a toda a consideração da culpa em sentido moderno; é este pressuposto, pois, que importa antes de mais perseguir e esclarecer para que se determine *o que é materialmente a culpa de que se trata em direito penal* (9). Da "pessoa", dizemos, o que neste contexto significa da pessoa **do agente** do facto ilícito-típico, assim se tocando aquilo que já chamámos o **axioma onto-antropológico** de todo o direito penal. E nem isto deixa de ser assim pelo facto de a culpa jurídico-penal sofrer uma como que "redução qualitativa" em face da temática filosófica geral (e ética, em particular) da culpa: também o Direito é uma "obra" ou "realização" da liberdade que, como tal — se bem que referida concretamente e de maneira limitada a bens protegidos pela comunidade através de normas jurídicas —, participa do dever-ser ético-existencial e, nesta medida, vale para o homem no seu concreto existir. Deste ponto de vista a culpa jurídica e jurídico-penal é, segundo o seu conteúdo material, só uma particular perspectiva da culpa ético-existencial e participa directamente da temática geral da culpa (10).

2. A liberdade como "livre-arbítrio" e as teses da culpa da vontade

2.1. Culpa e poder concreto e individual de agir de outra maneira na situação

§ 8 A submissão do conteúdo material da culpa jurídico-penal à liberdade do agente parece conduzir por força àquilo que bem se denominará

(9) Uma abrangente exposição sobre a matéria encontra-se, em língua portuguesa, em ROXIN, Culpa e responsabilidade. Questões fundamentais da teoria da responsabilidade (tradução de Maria da Conceição Valdágua), *RPCC 1*, 1991, p. 503.

(10) DIAS, Figueiredo, *Liberdade*, E, 1.

o dogma da **culpa da vontade**. Quando se erige a liberdade em pressuposto do conceito material de culpa, aquela é em geral tomada como liberdade da vontade, como *liberum arbitrium indifferentiæ*, como possibilidade de actuar sem perturbações invencíveis, endógenas ou exógenas, do mecanismo psicológico da vontade. Assim — diz-se —, culpa só pode ser censurabilidade da acção, por o culpado ter actuado contra o dever quando *podia* ter actuado de acordo com ele. O **poder de agir de outra maneira na situação**, dir-se-á, é deste modo requisito irrenunciável do conceito de culpa: quer esta se veja directamente na *decisão livre e consciente da vontade a favor do ilícito*, de que o poder de agir de outra maneira é pressuposto ([11]); quer ela se veja no *cometimento do ilícito por um agente que detinha capacidade para se determinar de acordo com a norma*, ou *era permeável ao apelo normativo*. O poder de agir de outra maneira é pois, neste enquadramento, simultaneamente pressuposto e conteúdo material da culpa ([12]). Mas precisamente com esta maneira de encarar e de tentar resolver o problema entra o conceito em dificuldades inultrapassáveis ([13]). E inultrapassáveis a dois níveis: logo ao nível da sua (1) *indemonstrabilidade*; e depois ao nível da sua (2) *insustentabilidade político-criminal*.

§ 9 (1) A primeira e mais radical dificuldade provém de que, nesta perspectiva, o "poder de agir de outra maneira", em que se traduz a liberdade consubstancial ao conceito material de culpa, há-de ser **comprovável** não apenas na vertente *teorética* de saber se em geral um tal poder existe, mas também na vertente *prática* de saber **quando** e **em que medida** se depara com ele, como capacidade real de uma pessoa individual, na situação concreta da acção. Só assim se obterá um critério exequível, e a esta luz indispensável, para distinguir acções culposas de acções não culposas, acções mais culposas de acções menos culposas ([14]).

([11]) Paradigmática a respeito, por último, a concepção de KAUFMANN, Arthur, *Das Schuldprinzip*, 1961, p. 130 e ss. Minuciosamente, sobre esta teoria, o nosso *O Problema*, § 11.

([12]) Concepção esta porventura ainda hoje a mais difundida e que encontrou a sua mais clara e acabada manifestação em WELZEL, § 22, e — sobretudo — em KAUFMANN, Armin, Schuldfähigkeit und Verbotsirrtum, *Eb. Schmidt-FS*, 1961, p. 319.

([13]) Isto procurámos demonstrar com minúcia em várias das nossas obras jurídico-penais, nomeadamente em *O Problema*, § 10 e ss., e em *Liberdade, passim*. Coincidente na conclusão, depois de aprofundada análise, NEVES, Curado, nota 1, p. 223 e ss.

([14]) Assim, entre muitos outros, KAUFMANN, Arthur, nota 11, BETTIOL, p. 374, e, entre nós, SANTOS, Beleza dos, O conceito ético-jurídico da responsabilidade penal — Valor deste conceito — Deverá manter-se ou pôr-se de parte, *Estudos em Homenagem a Nelson Hungria*, 1962, p. 65, e CORREIA, Eduardo, *ProjPG*, p. 25.

§ 10 A **crítica fundamental** a levantar a todo este pensamento radica em que a pergunta pela liberdade da vontade que presidiu à prática de um facto humano (o poder *individual* de uma pessoa para, numa situação *concreta*, agir *de outra maneira*) continua a ser, como o foi sempre, uma pergunta sem resposta fundada ([15]). Ainda se compreendia uma resposta afirmativa quando, até meados do séc. XIX, as determinantes endógenas do acto de vontade (os motivos), bem como as exógenas (as "sociais"), se encontravam mal estudadas por uma psicologia e uma sociologia incipientes. Confundia-se então o agente concreto com a "imagem abstracta" do homem, com o "*indivíduo* isolado", senhor absoluto de si próprio, da sua acção e do seu mundo, imputando consequentemente àquele, de forma ilimitada — por isso se crismando esta concepção de "indeterminismo absoluto" —, um poder concreto de agir de outra maneira na situação. Hoje, porém, a psicologia e a sociologia sabem estar impossibilitadas de responder à questão do livre-arbítrio quer no seu *se*, quer no seu *quando*, quer ainda no seu *quanto*: a competência para tal só pode pertencer ao pensamento fundamental do existir humano (à antropologia filosófica e à ontologia), onde todavia a pergunta já se não refere mais à liberdade da vontade do *acto*, mas à liberdade como característica do *ser* total que age. Numa palavra, a afirmação de uma concreta capacidade de escolha na situação — quando não seja contraditória com a própria ideia de liberdade ([16]) — é absolutamente inverificável e por ninguém poderá ser avançada de forma responsável. Bem se compreende por isso que esta tentativa de determinar o conteúdo material da culpa, enfeudada a uma imagem do homem de oitocentos e não conseguindo demonstrar o seu mais lídimo fundamento — o livre-arbítrio de que se reclama —, tenha de ser abandonada.

§ 11 Nem consegue proceder aqui uma **resposta diferenciada** ([17]), segundo a qual seriam ainda susceptíveis de comprovação empírica alguns elementos da capacidade de autodeterminação, nomeadamente os de índole *cognitiva*, embora já não os de índole *volitiva* e *emocional*. Será muito difícil, por um lado, encontrar fundamento para a diferenciação de comprovabilidade empírica de uns e outros elementos. E de todo

([15]) Cf. o nosso *Liberdade*, para o qual nos permitimos remeter o leitor interessado em maiores precisões.

([16]) BERGSON, Essai sur les données immédiates de la conscience, *Œuvres* (édition du centenaire, P. U. F., 1963), p. 117, considerava já a doutrina do livre-arbítrio, com razão, uma "concepção verdadeiramente mecanicista da liberdade [que] conduz, por uma lógica material, ao mais inflexível determinismo".

([17]) Do tipo da sugerida por HENKEL, Die Rechtsbestimmung des Menschen als rechtsphilosophisches Problem, *Larenz-FS*, 1973, p. 23. Segue-o CEREZO Mir, Culpabilidad y pena, *ADPCP*, 1980, p. 248 e ss.

o modo, na perspectiva da tese em análise, são seguramente relevantes *ao mesmo título* tanto os elementos cognitivos, como os volitivos e os emocionais; porque uns e outros seriam afinal ([18]) componentes *não autónomos* do único elemento verdadeiramente decisivo: a unitária *permeabilidade do agente ao apelo normativo*, a sua *capacidade para se autodeterminar ou se motivar de acordo com a norma*.

§ 12 (2) Uma tal concepção conduz de resto — e aqui se depara com o segundo nível crítico acima mencionado — a **consequências político-criminais insuportáveis**, que põem em causa a função do princípio da culpa no sistema. Por um lado, sempre que o delinquente afirmasse não ter podido agir de outra maneira e se não fizesse a prova do contrário (e como poderia esta ser lograda? ([19])), a consequência haveria de ser forçosamente — em último termo por intervenção do princípio jurídico-constitucional da presunção de inocência e do seu correlativo processual *in dubio pro reo* — a *absolvição*. Por outro lado, todos os delinquentes imputáveis onerados por uma qualquer tendência para o crime, ou que vivessem em ambiente criminógeno — afinal, os delinquentes mais perigosos, mais necessitados de socialização e de que a sociedade tem de defender-se mais fortemente — seriam precisamente aqueles que veriam a sua pena diminuída em virtude do seu diminuído poder de agir de outra maneira e do seu efeito sobre a função limitadora do princípio da culpa. Finalmente, a essência da desculpa como residindo na falta de capacidade de motivação pela norma conduziria igualmente a consequências político-criminalmente insuportáveis tanto em sede de definição do conteúdo da culpa dolosa (infra, 20.º Cap., § 26), como em tema de causas de exclusão da culpa, seja da inimputabilidade (infra, 21.º Cap., §§ 9 e s., 44 e s.), da inexigibilidade (infra, 22.º Cap., §§ 1 e s., 47) ou da falta não censurável de consciência do ilícito (infra, 23.º Cap., § 4 e ss.) ([20]).

2.2. Tentativas de "abstracção" ou "generalização" do "poder de agir de outra maneira"

§ 13 As tentativas de solução das aporias em que, assim, as teses da culpa da vontade incorrem reconduzem-se à tentativa de operar uma *abs-*

([18]) Como assinala KAUFMANN, Armin, nota 12, p. 321.

([19]) Mesmo quando não constituísse a "pura tolice" de que falava BOCKELMANN, Willensfreiheit und Zurechnungsfähigkeit, *ZStW 75*, 1963, p. 380.

([20]) Cf., já, a propósito, os nossos *Liberdade*, E, IV, e, de forma sintética, Schuld und Persönlichkeit, *ZStW 95*, 1983, p. 228 e ss.

tracção do poder de agir de outra maneira na situação e uma sua correlativa *generalização* para o poder que do agente se deve **esperar** ou **exigir** — seja, segundo um critério ainda subjectivado, para o poder do "tipo concreto" de homem a que o agente pertence (21); seja, segundo um padrão já objectivado, para o poder do "homem médio" (22); seja invocando a "permeabilidade ao apelo normativo" característica do agente imputável e capaz de conhecer o ilícito (23). Não parece, porém, que por qualquer destas vias as dificuldades se dissipem ou sequer diminuam (24).

§ 14 Todas elas têm por denominador comum o propósito de, reconhecendo as aporias em que se lança a afirmação do livre-arbítrio, ultrapassarem a sua indemonstrabilidade, deixando persistir por inteiro, todavia, as antinomias entre o poder de agir de outra maneira (ou a capacidade de determinação pela norma ou a permeabilidade ao apelo normativo) e as exigências mínimas da política criminal. Pode admitir-se que a generalização, por qualquer destas formas realizada, não tenha de desembocar na *staatsnotwendige Fiktion* (a "ficção estatalmente necessária") de que falava Kohlrausch (25), mas traduza apenas — para usar palavras de Jescheck — "uma indiscutível **realidade da nossa consciência social e humana**"; a partir daqui se chegando a afirmar, de forma peremptória, que a culpa jurídico-penal é, neste sentido, **culpa social** (26). Mas do que nelas sempre se tratará é da substituição de uma comprovação real, assim conscientemente deixada em aberto, por categorias normativas, por uma adscrição ou imputação postulada em face de certas situações; do que se tratará, numa palavra, é do abandono inconfessado do ponto de partida indeterminista conatural à tese do livre-arbítrio. Se, ao mesmo tempo, se renuncia a fundar

---

(21) Assim, muito claramente, MANGAKIS, Über das Verhältnis von Strafrechtsschuld und Willensfreiheit, *ZStW*, 1963, p. 499.

(22) Assim — trilhando um caminho já assinalado por Windelband e que passa, entre outros, por Kohlrausch e Mezger —, JESCHECK / WEIGEND, § 37, I, 3.

(23) É esta a posição agora sustentada por ROXIN I, § 19, D, V.

(24) Uma extensa crítica, por último, em NEVES, Curado, nota 1, pp. 325 e ss., 388 e ss.

(25) KOHLRAUSCH, *Sollen und Können als Grundlagen der strafrechtlichen Zurechnung*, 1910, p. 26.

(26) JESCHECK / WEIGEND, § 37, I, 3. Em sentido substancialmente análogo, S / S / LENCKNER, n.º 109 antes do § 13, e, agora, SCHÜNEMANN, La culpabilidad: estado de la cuestión, *in*: Roxin et alii, *Sobre el estado de la teoria del delito*, 2000, p. 98 e ss., que considera a concepção social da culpa como sendo a defendida hoje pela maioria da doutrina alemã. Cf., também, DIAS, Silva, *"Delicta in se" e "delicta mere prohibita: Uma Análise das Descontinuidades do Ilícito Penal Moderno à Luz da Reconstrução de uma Distinção Clássica*, 2003, p. 722 e s.

a outro nível a liberdade da pessoa, então a sua realidade física, psíquica e espiritual — a sua *personalidade* — deixa de interessar à culpa e a ligação desta à pessoa do agente torna-se de novo duvidosa.

§ 15 Por outras palavras, do que aqui se trata é de continuar a aceitar o poder de autodeterminação como conteúdo material da culpa, se bem que não reconhecido, agora, como "comprovação entitativa", mas apenas como "postulado político-criminal dirigido ao juiz", como "princípio normativo de regulamentação de carácter generalizante", numa palavra, como **suposição de liberdade** (27). Na última formulação de Roxin a este propósito: "não se significa com isto que o agente teria podido facticamente agir de outra maneira — coisa que na verdade nós não podemos saber —, mas apenas que ele, em caso de capacidade de orientação intacta (*intakter Steuerungsfähigkeit*) e, por via dela de "apelabilidade" normativa, é **tratado como livre**" (28). Só que desta maneira renasce inteiramente o problema da imputação do facto à culpa nos casos em que se não dá, ou só duvidosamente se dá, a (pre)suposta capacidade de "orientação" (ou, afinal, autodeterminação!). Ao que acresce, decisivamente, a dificuldade em compreender como possa a culpa cumprir a sua função de limite da medida da pena se, no conteúdo material daquela, se trata só de algo cuja existência se presume em função de um padrão generalizante ou de um postulado político-criminal.

2.3. A "culpa do (ou pelo) carácter"

§ 16 Uma outra via de superação do impasse residiria em ligar o poder de agir de outra maneira e a culpa — como claramente logo Aristóteles sugeriu (29) —, antes que ao facto praticado, ao **carácter** ou à **personalidade** do agente. Como supra, 10.º Cap., §§ 1-3, se sublinhou já, o que aqui está em causa não é substituir a responsabilidade pelo facto por

---

(27) As expressões são de ROXIN, Kritische Überlegungen zur Schuldprinzip, *MKrim*, 1973, p. 320 (tradução espanhola de Muñoz Conde na colectânea *Culpabilidad y prevención en derecho penal*, 1981), e I, § 19, n.º 35. Também, de forma muito clara, STRATENWERTH / KHULEN, § 7, n.º 26: "o direito penal não julga sobre o 'poder' ilimitadamente, segundo as capacidades individuais do agente, mas pressupõe-o pura e simplesmente, dentro de certos limites definidos *normativamente*" (s. n. o.).

(28) ROXIN I, § 19, n.º 37 (s. n. o.).

(29) ARISTÓTELES, *Ética a Nicómaco*, 1103a, 1103b e 1114a.

uma responsabilidade *pela* personalidade. É tão-só substituir a adscrição da culpa, *sempre na base do facto*, não à vontade que a este presidiu, mas ao carácter ou à personalidade que no facto se exprime. Qualquer que seja a concretização dogmática que para este núcleo de pensamento se repute preferível, através dele se asseguraria ao conceito de culpa — como uma parte significativa da doutrina portuguesa tem tão vivamente acentuado que aí pôde ver Hünerfeld, com razão, um dos seus traços mais característicos ([30]) — a sua possibilidade teorética, a sua legitimidade ética e, sobretudo, a sua capacidade para dar resposta suficiente às exigências político-criminais. Pois se o centro ético de imputação continua a ser aqui a *vontade livre* do agente, já o substrato a que materialmente se refere a culpa é muito mais extenso e, como notou Jaspers, **torna o poder e a vontade a que se ligue muito mais possantes** ([31]).

§ 17 Simplesmente, esta tese modifica, em relação às anteriormente consideradas, o conteúdo material da culpa (além o facto, aqui o carácter ou a personalidade), mas não o seu critério e o seu fundamento: **o poder de agir de outra maneira e a consequente liberdade da vontade** (embora também estes se dirijam agora à condução ou decisão da vida, ou à não-formação da personalidade). Pelo que, logo na sua base, também esta ideia de culpa repousará no fundamento não esclarecido do livre-arbítrio. Enquanto se persista em ver como critério e fundamento da própria culpa do carácter ou da personalidade a vontade livre, referida psicologicamente a um poder individual de agir de outra maneira, não só se manterão as dificuldades de princípio, como se poderão potenciar as antinomias em que incorre a culpa da vontade do facto, porque elas são agora multiplicadas por tantos factos quantos os relevantes para a condução ou decisão da vida ou para a não-formação da personalidade.

§ 18 Daí justamente não terem faltado tentativas, também neste enquadramento, para alargar o pressuposto básico desta concepção, nomeadamente a de Lange de **generalização** — já não "horizontal" ou referida ao facto, como em Kohlrausch, mas — "**vertical**", através da personalidade, do poder de agir de outra maneira ([32]). Eduardo Correia, por seu turno, vai ao ponto (que, como se verá, temos por substancialmente correcto) de sugerir que o fundamento e o próprio critério da culpa do agente não deverão tanto encontrar-se na má utilização do *poder* de agir de outra

([30]) HÜNERFELD, *Strafrechtsdogmatik in Deutschland und Portugal*, 1982, p. 233 e ss.
([31]) JASPERS, *Philosophie*, II, 1932, p. 154.
([32]) LANGE, Täterschuld und Todesstrafe, *ZStrW 62*, 1944, p. 199.

maneira — em todo o caso sempre pressuposto —, quanto na **violação de um dever de conformação** da personalidade do agente às exigências do Direito ([33]).

§ 19 A conclusão de toda esta argumentação parece pois dever ser a seguinte: o conteúdo material da culpa não pode encontrar-se na má utilização (na utilização contra o dever) de um qualquer *poder* de agir de outra maneira, mas directamente na violação de um **dever** de conformação da pessoa, no seu actuar, às exigências do Direito. Abandonando a ideia do *poder* de agir de outra maneira faz-se necessariamente perder à culpa a sua legitimação ética ([34])? Tudo dependerá de ser ou não possível pensar a liberdade da pessoa em plano diverso do da vontade e do consequente poder de agir de outra maneira na situação.

3. A liberdade pessoal e a tese da culpa da pessoa

3.1. A concepção básica

§ 20 Trata-se, na questão acabada de suscitar, da superação de uma liberdade indeterminista ("livre-arbítrio") por uma liberdade *pessoal*, de um recuo da liberdade como propriedade da acção em favor da **liberdade como "característica do ser-total-que-age"** ([35]). E da possibilidade de lograr por aqui um conceito de *culpa da pessoa* (ou da *personalidade*) dogmaticamente exequível e político-criminalmente correcto. No sentido desta superação fala logo a imagem que agora fazemos do Homem ([36]): não Indivíduo abstracto e isolado, "cidadão de dois mundos", mas Pessoa concreta e situada, Homem socializado, no sentido de que vive em um mundo e de que é, assim, aquilo que através da acção objectiva no mundo e que o mundo subjectiva nele.

§ 21 A **história do pensamento da liberdade** permite, de resto, entrever desde muito cedo uma pluralidade de caminhos através dos quais ela se deixa pensar neste

---

([33]) Esta interpretação do seu pensamento, já, no nosso *O Problema*, § 10, III, 2 e 3, e § 13, II, 3.

([34]) Estando então em causa nisto tudo, como com razão critica STRATENWERTH, *Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzips*, 1972, p. 44, apenas um "penoso artifício".

([35]) A expressão pertence a RAHNER, Karl, Schuld, Verantwortung, Strafe in der Sicht der katholischen Theologie, *in*: Frey (org.), *Schuld — Verantwortung — Strafe*, 1964, pp. 153, 156.

([36]) Sobre isto, já, RADBRUCH, *Der Mensch im Recht*, 1957, p. 9 e ss., JESCHECK, *Das Menschenbild unserer Zeit und das Strafrechsreform*, 1957, e MAIHOFFER, Menschenbild und Strafrechtsreform, *Berliner Universitätstage*, 1964, p. 5.

plano sem contradição. Desde logo como forma de "escolha da existência" em Platão, no mito de Er, onde a virgem Lachesis, filha da necessidade, põe o princípio de uma nova via para o género humano: "Não é um 'daimon' que vos possuirá, antes vós que ireis escolher um 'daimon'... A culpa não atinge a Divindade, mas aquele que escolhe" ([37]). Ou como possibilidade ontológica transcendental ancorada no carácter inteligível, em Kant ([38]). Ou como característica do *esse* metafísico donde decorre a necessidade do *operari* empírico, em Schopenhauer ([39]); onde justamente faz Engisch entroncar a sua construção de uma culpa do carácter ([40]) e Thomas Mann a concepção que põe na boca de Naphta: "O criminoso... é como é e não quer nem pode ser outra coisa, e isto precisamente é a sua culpa... No fazer, na acção, vigora seguramente a determinação, aqui não se dá nenhuma liberdade, antes sim no Ser" ([41]). Ou ainda como característica dos actos excepcionais que decorrem do "eu" e só nele encontram fundamento, em Bergson ([42]); retomando assim a tese de Aristóteles segundo a qual são livres e imputáveis as acções que têm a sua *arché* em nós próprios ([43]) e em cuja base ensaiou Coing a sua construção do conceito de culpa jurídica ([44]).

§ 22 Dir-se-á porém que com nada disto parece resolver-se o problema da liberdade do homem concreto, a qual, como nota Keller, deve paradoxalmente participar de forma constitutiva no real sem no entanto, como "liberdade" que é, apontar para qualquer determinação substantivável ([45]). Mas a viragem do pensamento para a *antropologia filosófica* ([46]) e uma *nova compreensão do "eu" da consciência*, possibilitada por uma nova impostação do problema da oposição sujeito / objecto ([47]), parece

([37]) PLATÃO, *Republica*, X, 617 d) e), 618 b) e 620 d).

([38]) Na terceira antinomia das ideias transcendentais: KANT, Kritik der reine Vernunft, *Werke* (hrsg. v. Weischedel), IV, p. 426 e ss.; e sobre a liberdade prática, que o imperativo categórico necessariamente suporta, Kritik der praktische Vernunft, *Werke*, VI, p. 144 e ss. Sobre a relação entre estas duas acepções de liberdade, de forma muito clara, um passo do Prefácio da 2.ª ed. da Kritik der reine Vernunft, *Werke*, III, p. 32.

([39]) SCHOPENHAUER, Über die Grundlage der Moral, *Werke* (hrsg. v. Griesebach), III, § 20, e *Die Welt als Wille und Vorstellung*, 1, §§ 53 e 55.

([40]) ENGISCH, Zur Idee der Täterschuld, *ZStW 61*, 1942, p. 172, e *Die Lehre von der Willensfreiheit in der strafrechtsphilosophischen Doktrin der Gegenwart*, 1963, p. 49.

([41]) MANN, Thomas, *Der Zauberberg* (Fischer, 1964), p. 421.

([42]) BERGSON, nota 16, p. 113.

([43]) ARISTÓTELES, *Nikomakische Ethik* (tradução de Rolfes), ²1933, 1110b.

([44]) COING, Bemerkungen zum Problem der sog. Willensfreiheit, *Emge-FS*, 1960, p. 8 e ss.

([45]) KELLER, *Psychologie und Philosophie des Wollens*, 1954, p. 304 e ss.

([46]) Através de Feuerbach e Marx, de Nietzche e Dilthey, e depois de Gehlen, Buber e Binswanger: cf., sobre toda esta evolução, o nosso *Liberdade*, p. 137 e s.

([47]) Em Husserl, Max Scheller, Jaspers, Heidegger: cf., sobre toda esta evolução, o nosso *Liberdade*, p. 138 e s., e, agora, BORGES, Anselmo, O crime económico na perspectiva filosófica-teológica, *RPCC 10*, 2000, p. 21 e ss., e O Homem: um corpo-pessoa-no-mundo-com-os-outros, *in*: BORGES, Anselmo, *Corpo e Transcendência*, 2003, pp. 69 e ss. e 89 e ss.

terem reunido as condições de solução da aporia ([48]); ao mostrarem com clareza que o "lugar" da liberdade vem a cobrir-se com a mais radical e originária das realidades: o **existir humano**. O homem tem que se decidir *a si* e *sobre si*, sem que possa em qualquer momento furtar-se a tal decisão ([49]): neste sentido ele dá a si mesmo, através de uma "opção fundamental", a sua própria conformação. Desta perspectiva o homem só existe enquanto age e, no plano da acção, a ele é oferecida uma série de possibilidades que parecem ser "indiferentes". Mas a eleição da acção concreta, determinada pela elevação de um motivo possível a motivo real em razão da preferência do sentido ou do valor que apresenta para o agente na sua auto-realização, tem que ser reconduzida a uma **decisão através da qual o homem se decide a si mesmo, criando o seu próprio ser ou afirmando a sua própria essência. O homem determina a sua acção através da sua livre decisão sobre si mesmo**. De modo que aquilo que, no plano da acção, parece ser liberdade de indiferença, livre-arbítrio, é, no plano do existir, a liberdade de decisão pelo próprio ser e sentido, a opção fundamental pela conformação da sua vida: *a liberdade daquele que tem de agir assim por ser como é*. Por esta via se confirmando a velha sentença escolástica *operari sequitur esse*, que, proveniente de Platão, está presente na filosofia da liberdade de autores tão diferentes como Kant, Schopenhauer e Bergson ([50]).

§ 23 Nisto residirá a autêntica liberdade pessoal do homem, a sua característica irrenunciável: **ele, no concreto existir, é sempre ser-livre**. Daqui derivará a legitimidade de uma acepção material de culpa jurídico-penal como violação pelo homem do *dever* de conformar a sua existência por forma tal que, na sua actuação na vida, não lese ou ponha em perigo bens jurídico-penais. E se acrescentarmos, por um lado que toda a culpa jurídico-penal, como tem vindo a insistir-se, se refere ao facto, isto é, ao ilícito-típico realizado (aliás agora, como se vê, num *triplo* sentido: no que de que, como culpa jurídico-penal, só se assume relativamente à lesão ou perigo de lesão de bens jurídico-penais; no de que a liberdade da

([48]) Assim, LANDGREBE, *Philosophie der Gegenwart*, ²1958, pp. 23 e ss. e 29 e ss.

([49]) Sobre esta afirmação e o que se segue, fundamental, MÜLLER, Max, Freiheit, *in*: *Sacramentum Mundi. Theologisches Lexikon für die Praxis*, II, 1968, coluna 82 e s. Para maiores desenvolvimentos, com indicações de concordâncias e discordâncias, o nosso *Liberdade*, p. 140 e ss.

([50]) DIAS, Figueiredo, *Liberdade*, pp. 119-135.

pessoa só se realiza na acção concreta; e ainda no de que a personalidade do agente só releva para a culpa na parte e na medida em que se exprime num ilícito-típico e o fundamenta); e por outro lado que o substrato derivado da decisão do homem sobre si mesmo é o que se chama a *personalidade* (não o simples carácter naturalístico) — ficam dadas as condições para se afirmar que toda a culpa é materialmente, em direito penal, o **ter que responder pelas qualidades juridicamente desvaliosas da personalidade que fundamentam um facto ilícito-típico e nele se exprimem**.

3.2. As consequências

§ 24 Desta forma se terá logrado a obtenção de uma acepção material de culpa que pode legitimamente reivindicar-se do seu **fundamento ético-existencial**, sem por isso ter de ligar-se à aceitação de um "poder de agir de outra maneira" na situação e sem que, portanto, depare com o *ignoramus et ignorabimus* imposto na questão do livre-arbítrio.

§ 25 Deste modo se terá logrado igualmente um conceito material de culpa que pode ser subscrito mesmo por aqueles que, entendendo deverem remeter-se a um *non-liquet* na questão do livre-arbítrio, se não ocupam de procurar a liberdade da pessoa a outro nível e acabam por aceitar, ao menos como hipótese de trabalho, um ponto de vista **determinista**. Também autores como Heinitz, Graf zu Dohna, Nowakowski e sobretudo Engisch, se revelam defensores de uma concepção de culpa pelo carácter que na conclusão se aproxima em muitos e essenciais pontos da que aqui se defende ([51]); o que de resto conduz Roxin a inserir a nossa doutrina no contexto do pensamento destes autores ([52]). Seja permitido, porém, salientar duas diferenças essenciais: a primeira é a de que o ponto de partida presente na nossa concepção não é determinista (resignado ou não), mas abertamente **crente na liberdade da pessoa**, nos termos expostos; a segunda é a de que o conteúdo da culpa não é referido ao carácter (naturalístico) da pessoa, mas à sua **personalidade** como fruto de uma decisão livre (de uma opção fundamental) da pessoa sobre si mesma: é referido — assim temos dito — ao carácter e àquilo que o supera, a saber, o ser-livre.

([51]) HEINITZ, Strafzumessung und Persönlichkeit, *ZStW 63*, 1951, p. 74; DOHNA, Ein unausrottbares Missverständnis, *ZStW 66*, 1954, p. 508 e ss.; NOWAKOWSKI, Der Aussmass der Schuld, *SchwZ 65*, 1950, p. 303 e ss.; ENGISCH, nota 40, 1942, p. 166 e ss., e 1963, p. 41 e ss.

([52]) ROXIN I, § 19, n.º 28.

§ 26 Deste modo se terá logrado, por último, uma acepção material de culpa que, através da sua referência à pessoa (ou "personalidade") do agente e à violação por esta de um *dever-ser* de espécie particular, oferece fundadas esperanças de obviar às antinomias, postas pela culpa da vontade, entre a medida do (presumido) poder individual e as exigências do dever pessoal socialmente condicionado; e, assim, de continuar a cumprir a sua **função político-criminal** de limitação da medida da pena em nome da eminente dignidade da pessoa e, por aqui, de continuar a constituir um fundamento irrenunciável do direito penal do futuro.

4. Concepções da doutrina portuguesa mais recente

§ 27 Importante e esclarecedora se revela, na questão da fundamentação da culpa, a concepção explanada por Fernanda Palma. Na esteira de Lévinas, ela acentua que a vinculatividade da norma depende "de uma predisposição criada anteriormente, no relacionamento do sujeito que comanda e o que obedece, para a subordinação ao diferente, a subordinação ao outro. Uma tal predisposição não é conceptual nem normativa, mas sim um dado existencial e pressupõe alteridade total...". "Não é pois que o Direito como ordem se fundamenta no interesse na realização da autonomia (uma espécie de egoísmo ético), entendida como individualismo, mas, diferentemente, a responsabilidade individual pelo reconhecimento do outro". E conclui: "é a relação com o outro na sua total independência o ponto de partida de qualquer ideia de dever e da sua própria identidade ética" ([53]). Todavia, em trabalho posterior — desta vez especificamente dedicado ao problema da culpa jurídico-penal —, Fernanda Palma revela (embora manifestando em muitos pontos a sua insatisfação) uma reaproximação às teses da culpa da vontade e da capacidade de motivação pela norma e, consequentemente, do critério do poder de agir de outra maneira; ao menos como grandeza "negativa", que, quando provada (e como?) a incapacidade, faria entrar em função o princípio da desculpa ([54]). Sem no entanto, em nossa opinião, poder elidir as objecções de princípio, político-criminais e dogmáticas, que a este pensamento opusemos. Ao que acresce que a sua ideia básica de que é a **verificação da oportu-**

([53]) PALMA, Fernanda, Crimes de terrorismo e culpa penal, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 235.

([54]) PALMA, Fernanda, *O Princípio da Desculpa*, 2005, *passim*, especialmente pp. 42 e ss., 49, 138.

nidade de actuação alternativa que dá fundamento ao princípio da culpa não é susceptível de oferecer a esta um conteúdo material bastante ao trabalho dogmático, até porque uma tal ideia não é específica da culpa mas vale também, a vários níveis, para a doutrina da ilicitude (55); e porque, de qualquer modo, não conseguimos alcançar a forma como, sobretudo no mundo empírico, se relacionaria aquela ausência de oportunidade com a capacidade de motivação pela norma.

§ 28 Silva Dias defende, por seu lado — tentando aproveitar o pensamento sócio-filosófico de Habermas e os ensaios da sua concretização ao nível de uma "teoria discursiva da culpa jurídico-penal" de Kindhäuser —, que a culpa jurídico-penal radica na **deslealdade comunicativa**, traduzida na prática de um acto que exprime o desprezo ou a falta de respeito pela autonomia dos outros (56). Não cremos, porém, que esta concepção ajude a resolver os problemas em aberto da doutrina da culpa jurídico-penal. A ideia, de base habermasiana, da "interacção comunicativa", ligada ao "reconhecimento pessoal recíproco", pode merecer consideração quando se suscita o problema da *legitimação* da intervenção penal (cf. já supra, 6.º Cap., § 23) ou mesmo, *tout court*, do Direito. Mas não possui capacidade nem viabilidade prático-normativas para resolver ou esclarecer a questão do conteúdo material da culpa jurídico-penal (57); tanto mais quanto Silva Dias afasta decididamente a única via que poderia oferecer conteúdo aos referidos "desprezo" ou "falta de respeito" que constituiriam a deslealdade comunicativa, a saber: a de os reportar à *atitude censurável* do agente, derivada das qualidades da sua personalidade documentadas no facto, perante o dever-ser jurídico-penal (este sim, ligado ao reconhecimento da autonomia do outro).

§ 29 Mais próximo da concepção por nós desenvolvida em matéria de determinação do conteúdo material da culpa jurídico-penal nos pareceu o pensamento de Curado Neves. Se não coincide connosco na compreensão dos fundamentos, traçando de forma diferente o relacionamento entre funcionalismo e conteúdo ético — pressupondo que **a concepção da culpa jurídico-penal não pode deixar de ser funcional**, enquanto a

---

(55) Assim, também, NEVES, Curado, nota 1, pp. 289 e ss., 309 e ss., 323.

(56) Cf. KINDHÄUSER, Rechtstreue als Schuldkategorie, *ZStW 107*, 1995, p. 701; DIAS, Silva, nota 26, pp. 700 e ss., 730 e ss.

(57) Insiste nesta crítica, com razão, NEVES, Curado, nota 1, p. 295 e ss.

questão do seu conteúdo ético-existencial acaba por ser posta como que entre parênteses ([58]) —, já os resultados prático-normativos a que é conduzido em matéria de negação da culpa (seja por força da inimputabilidade ou da inexigibilidade) se encontram essencialmente na mesma linha dos que defendemos. Neste plano, o motivo principal e mais fundo da crítica que nos move pareceu-nos dirigir-se a uma demasiada e algo espúria ligação que nós estabeleceríamos entre a *censura* da culpa e a avaliação da *personalidade* do agente, que conteria o perigo de fazer descambar o direito penal num inaceitável direito penal do agente. Não cremos que um tal perigo exista. Primeiro, porque a função da culpa jurídico-penal é de limitação do arbítrio estatal, fundada na eminente dignidade da pessoa do agente. Segundo, porque o conteúdo da culpa jurídico-penal é de natureza ética (ou ético-existencial) e por isso, antes de tudo, respeitadora dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Terceiro, porque a culpa se refere ao facto, a um facto que, para ser incriminado, tem de obedecer a pressupostos estritos e cogentes de validade e de legitimação (como vimos supra, 6.º Cap.). Quarto, porque na nossa concepção em caso algum de aferição da culpa jurídico-penal se deve recorrer a uma avaliação directa da personalidade do agente: **culpa é ter que responder pelas qualidades pessoais — juridicamente censuráveis — que se exprimem no concreto ilícito típico e o fundamentam**. O exemplo oferecido pelo disposto no art. 33.º-2 (infra, 22.º Cap., § 37) devia servir, em muito maior medida do que até hoje tem acontecido, de ponto de reflexão a qualquer análise crítica do conteúdo material da culpa jurídico-penal.

([58]) NEVES, Curado, nota 1, pp. 416 e ss., 423 e ss.

20.º CAPÍTULO

O TIPO DE CULPA DOLOSO

I. Culpa e tipo de culpa doloso

§ 1 Do exposto no capítulo anterior resulta que (como de resto já por mais de uma vez acentuámos) a culpa jurídico-penal, sendo eminente e primariamente um *juízo* de censura, engloba uma específica materialidade ou "matéria de culpa" que lhe advém da atitude interna ou íntima do agente (do seu *Gesinnung*) manifestada no ilícito-típico e que o fundamenta como *obra sua*, da sua pessoa ou da sua personalidade. Em todo o caso, tal como vimos suceder com o ilícito-típico, também a culpa jurídico-penal se não revela de uma maneira unitária, mas é dada através de **tipos de culpa**: o tipo de culpa **doloso** e o tipo de culpa **negligente**. É o primeiro destes que no presente enquadramento cumpre estudar. Relembrando que o tipo de culpa doloso se verifica apenas quando, perante um ilícito-típico doloso, se comprova que o seu cometimento deve imputar-se a uma atitude íntima do agente **contrária** ou **indiferente** ao Direito e às suas normas; se uma tal comprovação se não alcançar ou dever ser negada o facto só poderá eventualmente vir a ser punido a título de negligência (se esta se verificar e a espécie de delito cometido for punível também a esse título).

§ 2 Esta verificação encontra-se na linha tradicional de pensamento sobre a distinção entre dolo e negligência e a punição a um e outro título. Já se anotou (10.º Cap., § 70 e s.) que, excedendo em regra a punição de um facto a título de dolo, por vezes em muito, a punição do mesmo facto a título de negligência, isso só pode significar, à luz do princípio da culpa, que naquele existe um conteúdo de culpa mais pesado e mais grave do que neste; que, por outras palavras, ao desvalor mais alto do ilícito doloso acresce um maior desvalor da culpa. O reconhecimento desta diferença foi

tradicionalmente reconduzido à ideia de que, para justificar a punição a título de dolo, o facto deve revelar que, ao praticá-lo, o agente **sobrepôs conscientemente os seus interesses ao desvalor do ilícito** (supra, 13.º Cap., § 14 e s.), o que conduziu a que a questão, durante muito tempo, se considerasse incindivelmente ligada ao problema da **consciência do ilícito**: uma punição a título de dolo suporia que, para além de o agente representar e querer a realização do tipo objectivo de ilícito (dolo do tipo), actuasse **com** consciência do ilícito, isto é, representasse por alguma forma que o facto intentado era proibido pelo Direito. Veremos em seguida que uma tal concepção não é necessária, nem sequer exacta. Mas ela revela que, já no entendimento tradicional, com o mero dolo do tipo não se justificava a punição a título de dolo, antes se requeria **um qualquer elemento adicional** (na verdade, um elemento **emocional**) que, deste modo, traduz a vera essência do tipo de culpa doloso.

§ 3 Para além deste elemento adicional — que, repetimos, constituirá o denominador comum de todo e qualquer tipo de culpa doloso —, a lei prevê, relativamente a vários tipos de ilícito concretos, que a culpa dolosa dependa ainda de **especiais elementos relativos à culpa dolosa** que ela entende tipificar. Também isto já foi referido quando da questão dos chamados "especiais elementos subjectivos do tipo" de ilícito (13.º Cap., § 55 e ss.) e da dificuldade que muitas vezes existirá em distingui-los dos especiais elementos do tipo de culpa dolosa. Também estes por isso terão de reentrar no estudo do tipo de culpa doloso (infra, § 46 e ss.).

§ 4 A ideia aqui exposta de que também a culpa jurídico-penal se exprime através de **tipos de culpa** é convalidada hoje por uma parte significativa da doutrina alemã [1]. Em todo o caso, as mais das vezes, em um **sentido restrito** que não pode satisfazer-nos: no de que "no tipo de culpa não cabe o conteúdo de culpa do facto, que se esgotaria já na imputação subjectiva, mas só os *elementos adicionais* que caracterizam a culpa de modo autónomo e não apenas como reflexo dos elementos do ilícito" [2]; o que sucederia nomeadamente com a consciência do ilícito. Como em seguida se dirá não cremos que seja assim, logo porque a consciência do ilícito é *tipicamente* orientada e constitui, nesta medida e de certo modo, um "reflexo" do tipo de ilícito ao nível da culpa.

---

(1) Indicações supra, 10.º Cap., nota [97].

(2) JESCHECK / WEIGEND, § 42, I, 1.

II. Dolo e falta de consciência do ilícito (erro sobre a ilicitude, art. 17.º)

1. Consideração preliminar

§ 5 O tratamento tanto a nível dogmático e construtivo, como a nível legislativo e político-criminal do complexo de questões relativas às relações entre o dolo e a falta de consciência do ilícito ou do erro sobre a ilicitude continua ainda hoje a constituir um dos temas mais extensos, difíceis e controvertidos da doutrina do facto punível. A evolução do direito e da lei penais portuguesas a este propósito configura um padrão das diversas compreensões e soluções que o problema foi historicamente assumindo no conspecto do direito comparado. Por outro lado, o tratamento que lhe é concedido pelo direito positivo português vigente corresponde integralmente não só às teses que sobre o ponto defendemos em investigações anteriores sobre o tema (3), como àquilo que continuamos a pensar deverem ser a compreensão e as soluções cabidas à problemática respectiva em um sistema penal moderno; e tem sido louvado como contendo uma das mais perfeitas regulamentações legais alcançadas nesta matéria (4).

§ 6 Sobre os contornos exactos do que seja esta consciência do ilícito por cujo relevo se pergunta para o dolo e para a culpa nos pronunciaremos em seguida. Mas convém desde já apontar alguns **exemplos** daquilo que com ela se quer significar. Não necessariamente exemplos mais ou menos teóricos ou que só podem — e podem, todavia (5) — ter lugar relativamente a comunidades onde existam núcleos da população cujas concepções morais, sociais, políticas e culturais sejam profundamente diferentes das dominantes (e isso mesmo acontecia com Portugal quando a sua ordem jurídica era aplicada nas colónias de forma alegadamente integral e pode hoje conti-

(3) Fundamentalmente, no nosso *O Problema*, *passim*.

(4) Cf., só, ROXIN, Acerca da problemática do direito penal da culpa, *BFD ILIX*, 1983, p. 27, acentuando, a propósito da questão em exame, ser possível, através de uma construção que ele próprio defende, "chegar, também no direito alemão, ao resultado a que — de modo mais elegante — conduz o CP português". TIEDEMANN, Zum Verhältnis von allgemeinem und besonderem Teil des Strafrechts, *Baumann-FS*, 1992, p. 14 e s., escreve por seu turno que a solução do CP português de 1982 para as questões do erro sobre o tipo, do erro sobre a proibição e da falta de consciência do ilícito lhe parece a mais correcta no conspecto comparatístico internacional e corresponde à que ele próprio advogou para o direito penal alemão como sendo jurídico-constitucionalmente imposta.

(5) Interessantíssimos casos são os apresentado por DIAS, Silva, Problemas de direito penal numa sociedade multicultural: o chamado infanticídio ritual na Guiné-Bissau, *RPCC 6*, 1996, p. 209, e Faz sentido punir o ritual do fanado? Reflexões sobre a punibilidade da excisão clitoridiana, *RPCC 16*, 2006, p. 218 e ss.

nuar em certa medida a acontecer, em especial no que toca a acções "interculturais", nomeadamente de cidadãos estrangeiros): *v. g.* o caso de quem mata, viola, rouba, etc., sem a consciência de que tais factos, na situação concreta, são ilícitos. Mas exemplos cuja consistência e actualidade não pode oferecer dúvidas: será o caso — para não alongar a exemplificação — de *A* que leva a cabo ou consente em uma interrupção médica da gravidez por razões socialmente relevantes, ou mesmo por razões medicamente relevantes mas após as 12 semanas de gravidez (art. 142.º); ou de *B* que tem cópula com pessoa de 15 anos abusando da sua inexperiência (art. 174.º); ou de *C* que fotografa outra pessoa sem o seu consentimento (art. 192.º-1/*b*) — quando os agentes actuam sem consciência de que qualquer dos casos é ilícito face à lei portuguesa vigente.

2. Evolução do tratamento legislativo e doutrinal

2.1. A tese da irrelevância para a culpa da falta de consciência do ilícito

§ 7 O CP português de 1886 estipulava que não eximiam de responsabilidade criminal nem a ignorância da lei penal, nem a ilusão sobre a criminalidade do facto, nem o erro sobre a pessoa ou coisa a que se dirige o facto punível, nem a persuasão pessoal da legitimidade do fim ou dos motivos que determinaram o facto (art. 29.º, n.os 1 a 4). Aqui se pretendia fundamentar a **irrelevância** da falta de consciência do ilícito para a afirmação do dolo ou da culpa; uma irrelevância que não foi em regra contestada até que o princípio da culpa começou a ser afirmado e estudado como uma máxima político-criminal fundamental.

§ 8 Subjacente a uma tal doutrina e ao regime respectivo encontrava-se uma concepção (6) já presente no direito justinianeu, consagrada no *Codex Legum Visigothorum* e reforçada por obra dos glosadores; e que depois se estabeleceu, em diversos lados, como princípio aparentemente intocável do direito moderno, a ponto de continuar ainda hoje a ter assento em alguns códigos penais. Arrancando da distinção entre **erro *de* facto** e **erro *de* direito**, esta concepção dava relevância ao erro de facto, no sentido de excluir o dolo, enquanto o erro de direito — em que se englobaria, sem qualquer autonomia, a falta de consciência do ilícito — seria em princípio irrelevante; tudo de acordo com a velha máxima pauliana "*regula est juris quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non*

(6) Sobre ela, ALBUQUERQUE, Martim de, *Para uma Distinção do Erro sobre o Facto e do Erro sobre a Ilicitude em Direito Penal*, 1968; e o nosso *O Problema*, §§ 2 e 3.

nocere" (D. 22, 6, 9 pr.). A partir daqui, o mais que poderia tentar-se seria *limitar*, em alguma medida, a incidência da regra da irrelevância de todo o erro de direito ou de qualquer ignorância da lei; como acontece ainda hoje, *v. g.*, com a doutrina de alguns países latinos (máxime, com uma parte da doutrina italiana ([7])), não fazendo valer aquela regra para certas categorias de pessoas ou para a *ignorância da lei não penal* ou *extra-penal*. Em todo o caso, e por mais longe que se conseguisse ir nesta via das limitações, sempre seria *negada a autonomia para o dolo e para a culpa do problema da falta de consciência do ilícito* e, consequentemente, sempre se violaria o princípio da culpa em todos os casos em que aquela falta não devesse ser censurada ao agente.

§ 9 Uma tal interpretação do direito português anterior a 1982 não faria porém justiça ao estado de evolução alcançado **pela doutrina e mesmo por uma parte da jurisprudência portuguesas do tempo**. Sob a influência do *positivismo jurídico* dominante a partir do fim do século passado, é certo, não faltaram em Portugal autores e arestos jurisprudenciais a negarem, em nome de uma identificação entre o erro de direito e a **ignorância da lei** ([8]) e portanto das máximas *error iuris nocet* e *ignorantia legis non excusat*, relevância de princípio ao problema da consciência do ilícito ([9]). Mas um estudo mais atento das fontes transmite — porventura já desde o próprio direito romano, seguramente nos períodos do direito português comum, iluminista e mesmo positivista — uma imagem bem diferente ([10]). Uma imagem segundo a qual não foi nunca a dicotomia entre *o* facto e *o* direito (e a consequente distinção entre "erro *de* facto" e "erro

---

([7]) Sobre ela, o art. 47, 3, do CP italiano e, na doutrina, entre outros, ROMANO, I, art. 47.º, p. 458 e ss., e MARINUCCI / DOLCINI, *Diritto penale*, p. 217 e s. Em termos de reforma do direito penal italiano, todavia, começa a considerar-se a relevância excludente da culpa do erro de direito desculpável: cf. o art. 29 do *Projetto preliminare* de 1988.

([8]) Identificação potenciada pela sua recepção e persistência na doutrina e na legislação civilísticas: cf. ainda hoje o art. 6.º do CC: "A ignorância ou má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas".

([9]) Assim, entre outros, PINTO, Sousa, p. 62; SILVA, Henriques da, p. 489; FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, p. 392; e ALBUQUERQUE, Martim de, nota 6, pp. 73 e ss. e 81.

([10]) Sobre o que se segue, o nosso *O Problema*, § 3 II. Análises recentes do problema encontram-se em DIAS, Silva, *"Delicta in se" e "delicta mere prohibita: Uma Análise das Descontinuidades do Ilícito Penal Moderno à Luz da Reconstrução de uma Distinção Clássica*, 2003, Cap. 2; e em NEVES, Curado, *A Problemática da Culpa nos Crimes Passionais*, 2006, p. 131 e ss. Cf., ainda, DÍAZ Y GARCIA Conlledo, Algunas cuestiones del error en Derecho Penal, *Problemas Fundamentais de Direito Penal, Homenagem a Claus Roxin*, 2002, p. 72 e ss.

de direito") que comandou, conceitualmente e *a priori*, o problema da consciência do ilícito; pelo contrário, foi este problema, no concreto sentido que assume no contexto da culpa jurídico-penal, que comandou aquela dicotomia e o princípio normativo que nela se contém, no sentido de os considerar ou não aplicáveis. Por outras palavras: já neste entendimento das coisas, se existia em direito penal uma distinção válida e legítima entre duas espécies ou tipos de erro, uma relevante e outra irrelevante, ou uma e outra com diferentes formas de relevância, tal distinção não advinha de um erro ser "de facto" e outro "de direito"; ela resultava sim do **diverso significado que um e outro assumiam para a culpa,** sendo esta e não aquela a distinção com autêntico valor normativo jurídico-penal. Com o que a dicotomia erro de facto / erro de direito surgia como aquilo que na realidade prática sempre terá sido, mas na teoria quase sempre se esqueceu: como um *posterius*, que não um *prius*, relativamente ao conteúdo, à autonomia e à extensão materiais do problema da consciência do ilícito no contexto da culpa jurídico-penal.

§ 10 Curado Neves critica este ponto de vista, alegando que "não parece possível **separar** a eficácia da lei da resolução do problema da falta de consciência da ilicitude (...). Nenhuma norma pode resistir à **inoponibilidade dos seus efeitos àquele que a ignora**". Com esta afirmação consideramo-nos nós, contudo, de acordo. Sempre afirmámos que a norma é oponível mesmo àquele que a ignora. O que acrescentamos é que *outro* é o problema de saber se, e em que termos, apesar daquela ignorância há que conceder relevo à falta de consciência do ilícito para a culpa: para esta questão pode assumir significado, entre tantas outras circunstâncias, não — como também afirma Curado Neves — "um dever de conhecimento da lei, mas antes a responsabilidade pela sua aquisição". Por isso podemos subscrever por inteiro a conclusão do A. de "que, qualquer que seja a solução a adoptar para o problema da falta de consciência da ilicitude, aquela não pode passar pela atribuição de relevo à simples ignorância de direito" ([11]).

§ 11 Só no quadro desta concepção se pode compreender que Beleza dos Santos e Eduardo Correia tenham sempre sustentado que os comandos referidos do art. 29.º do CP de 1886 *em nada* contrariavam uma eventual relevância jurídico-penal da falta de consciência do ilícito ([12]): o princípio *ignorantia legis non excusat* teria que ver primariamente com as questões do **fundamento da validade da lei**, da sua *obrigatoriedade abstracta*, da

([11]) NEVES, Curado, nota 10, p. 138 e ss.
([12]) CORREIA, Eduardo, I, n.º 92.

intangibilidade dos seus efeitos objectivos; mas não afectaria a possível relevância para a culpa de uma concreta falta de consciência do ilícito. E a base legal para esta concepção procurava-se então no art. 44.º-7 do CP de 1886, segundo o qual "justificam o facto, em geral, os que tiverem procedido sem intenção criminosa e *sem culpa*". Neste preceito estaria consagrado já o **princípio da culpa**, sendo legítimo ao intérprete retirar dele todas as consequências lógico-materiais que comporta e que a lei expressamente não contrarie, nomeadamente em tema de falta de consciência do ilícito.

2.2. As teses da relevância para a culpa e para o dolo da falta de consciência do ilícito

2.2.1. Consciência do ilícito, culpa e dolo

§ 12 A dogmática jurídico-penal alemã (como de resto também a portuguesa ([13])) desde cedo se opôs à dissolução do problema da consciência do ilícito no do erro de direito ou da ignorância da lei penal, antes lhe concedeu autonomia, preconizando a sua relevância para a problemática da culpa e do dolo. Relevante não era apenas o erro sobre a factualidade típica (cognominado pela doutrina alemã "erro sobre o tipo", *Tatbestandsirrtum*), que excluía o dolo, mas também uma outra espécie de erro, o **erro sobre a ilicitude** ou **falta de consciência do ilícito** (cognominado pela doutrina alemã "erro sobre a proibição", *Verbotsirrtum*).

§ 13 O aspecto fundamental desta tese da relevância da consciência do ilícito residia indubitavelmente em que **ela constitui um elemento essencial do juízo de culpa**, devendo a culpa em consequência ser negada sempre que a falta daquela consciência não seja censurável; e esta consequência foi efectivamente retirada, de forma absoluta e concludente, pelo Tribunal Federal alemão ([14]). A verdade porém é que a doutrina (alemã, como também portuguesa) deixou que este aspecto essencial da proble-

---

([13]) Sobretudo e claramente a partir do estudo fundamental de SANTOS, Beleza dos, Crimes de moeda falsa, *RLJ 67*, 1934-5, p. 146 e ss.

([14]) Num *leading case* de 18-3-1952, tão essencial — ao opor-se ao que fora durante décadas uma jurisprudência uniforme do Tribunal do Reich, baseada na tese da irrelevância para a culpa e o dolo da falta de consciência do ilícito — que uma parte substancial da doutrina penal internacional vê nele, fundadamente, o começo da história moderna do princípio da culpa: *BGHSt. 2, 194*.

mática fosse durante décadas ofuscado pela questão (também ela, na verdade, dogmática e normativamente fundamental ([15])) de saber qual o relevo do erro sobre a ilicitude **para a afirmação ou negação do dolo e da punição a esse título**. Assente que ao lado do erro sobre a factualidade típica existe uma outra espécie de erro relevante, o erro sobre a ilicitude ou falta de consciência do ilícito, importava saber **se este teria o mesmo efeito daquele, o da negação do dolo**; ou se, diversamente, ele seria irrelevante para a questão do dolo e só assumiria relevância no sentido de **excluir a culpa sempre que não fosse censurável**. Foi sobre esta questão que a doutrina se dividiu, construindo doutrinas opostas que em seguida procuraremos expor no essencial ([16]).

2.2.2. A "teoria do dolo estrita"

§ 14 Segundo muitos autores — porventura a maioria, antes do surgimento da doutrina da acção final —, o **cerne dos delitos dolosos** reside precisamente na **consciência do ilícito** com que o agente actuou ([17]), na sua oposição consciente aos comandos do dever-ser jurídico como tal reconhecido (também chamado *dolus malus*); exigência que assim acresce à de que o agente tenha actuado com conhecimento e vontade de realização de um tipo objectivo de ilícito (dolo natural ou dolo do facto). Só desta forma se podendo afirmar que, no caso, o agente sobrepôs conscientemente os seus interesses pessoais ao desvalor do ilícito (supra, § 2) e deve, por conseguinte, ser punido a título de dolo: a punição por dolo só é merecida quando o agente se pôs conscientemente em contradição com o Direito ([18]). Pelo contrário, ela não deve afirmar-se sempre que (embora tais casos, afirma-se, sejam estatisticamente excepcionais) ao agente faltou a consciência actual de estar a praticar um *ilícito*. Em casos tais tudo o que restaria seria a possibilidade de o agente ser punido *a título de negligência* se

---

([15]) Declarações doutrinais a considerarem esta questão *a mais difícil, importante e controvertida de toda a dogmática jurídico-penal* encontram-se recenseadas no nosso *O Problema*, § 1, nota 1.

([16]) Sobre elas, pormenorizadamente e com indicações bibliográficas, o nosso *O Problema*, §§ 8 e 9.

([17]) Expressamente, nestes termos, MEZGER, Unrechtsbewusstsein im Strafrecht, *NJW*, 1951, p. 502.

([18]) Por último, na doutrina alemã, SCHMIDHÄUSER, 10/64. Amplas indicações anteriores concordantes das doutrinas alemã, austríaca, suíça, espanhola e portuguesa, no nosso *O Problema*, § 8.

o erro sobre a ilicitude em que incorreu fosse evitável ou vencível (numa palavra: censurável) e a lei previsse expressamente a punição daquele tipo de facto também a título de negligência. Com o que importaria concluir que o erro sobre a ilicitude (ou sobre a proibição) deveria merecer *um tratamento jurídico-penal inteiramente paralelo ao cabido ao erro sobre a factualidade típica* (ou erro sobre o tipo). Trata-se da **teoria do dolo estrita**.

§ 15 A esta teoria se censurou desde logo, na perspectiva construtivista e **sistemática** situada na linha da doutrina da acção final, esquecer ela que o dolo esgota o seu conteúdo e a sua função em sede de tipo subjectivo de ilícito e não assume nenhum significado para a culpa. Mas deveria parecer óbvio que um tal argumento — repetido até à exaustão pelos adversários da teoria do dolo estrita — surge como manifestação pura de um cripto-conceitualismo teleológica e funcionalmente inadmissível e afirma como indiscutível aquilo que precisamente se deve demonstrar à luz de considerações de culpa material. Como se censurou, em segundo lugar, em perspectiva **político-criminal**, as lacunas de punibilidade insuportáveis a que conduziria ([19]): a condenação por qualquer crime doloso suporia a *prova* de que o agente actuou com a consciência actual (*sc.*, no momento do facto) de que o seu facto era contrário ao direito. O que implicaria no agente um conhecimento, muitas vezes altamente especializado, da ciência jurídica, que não poderia sequer ser naturalmente presumido na generalidade da população criminosa; e ainda mesmo quando uma tal exigência se minorasse (paralelamente ao que vimos dever suceder com o conhecimento dos elementos normativos do tipo de ilícito: supra, 13.º Cap., § 10 e ss.) requerendo apenas uma consciência sob a forma de uma valoração paralela na esfera do agente e de uma co-consciência imanente à acção. Se bem que um tal argumento político-criminal não deva ser exagerado, atenta a frequência relativamente pequena de casos em que o agente alegará com êxito que actuou sem consciência do ilícito, ele é em todo o caso, na sua essência, procedente.

2.2.3. A "teoria do dolo limitada"

§ 16 Em parte motivado, decerto, pelo juízo político-criminal acabado de emitir, mas conduzido essencialmente por uma diversa concepção do con-

([19]) WELZEL, Diskussionsbemerkungen zum Thema "Die Irrtumsregelung im Entwurf", *ZStW 76*, 1964, p. 620.

teúdo material da culpa dolosa, um outro grupo de teorias, persistindo embora no entendimento de que *a consciência actual do ilícito é momento constitutivo do dolo*, considera todavia que a punição a título de dolo é cabida não apenas naquela situação, mas ainda noutras situações que, possam embora não se reconduzir estritamente ao conceito de dolo, todavia **lhe devem ser equiparadas para efeitos prático-normativos**. Dito de uma forma o mais abrangente possível, aos casos em que o agente actua com dolo (e isso quereria dizer: com consciência actual do ilícito) deveriam ser equiparadas todas as hipóteses em que a falta de consciência do ilícito fica a dever-se a **concepções do agente de todo incompatíveis com os princípios da ordem jurídica sobre o lícito e o ilícito** (ele não sabe que é proibido matar, ferir, violar, sequestrar, roubar, praticar actos terroristas...). A este conjunto de concepções se deu por isso o nome de **teoria do dolo limitada**.

§ 17 Tanto quanto pudemos determinar, coube a um autor português, Beleza dos Santos, o mérito de **pela primeira vez** ter sustentado o núcleo central da teoria posta (aproveitando para o efeito um pensamento paralelo ao que havia sido desenvolvido por Frank, com a sua fórmula hipotética em matéria de dolo eventual: supra, 13.º Cap., § 49). Acentuando que o dolo é um elemento ético-normativo e não puramente psicológico ou ontológico, conclui que ele não pode "consistir só na vontade, previsão ou conhecimento dos factos que constituem o crime, mas exige ainda a sua avaliação sob o ponto de vista da legitimidade e, consequentemente, o conhecimento actual do ilícito *ou uma atitude subjectiva que se lhe deva equiparar*". E acrescenta: "pode o agente desconhecer a ilegalidade ou imoralidade da sua conduta porque se não preocupou com isso, porque lhe é indiferente ou pouco sensível a sua ilegitimidade, podendo nós dizer que ele procederia da mesma forma, ainda que ao seu espírito aparecesse nítida aquela ilegitimidade". Assim, conclui, porque dolo é, em definitivo, "falta de repugnância pela realização consciente do facto que representou um dano ou um perigo e que o direito reprova", haverá dolo sempre que, para além da representação e vontade de realização do facto, "o agente sabia que a sua conduta era ilegal ou socialmente imoral; **ou, embora o não soubesse, todavia pudermos afirmar que, se tivesse conhecimento daquela ilegalidade ou imoralidade, não teria deixado de proceder como o fez**" ([20]). Uma década mais tarde vem Mezger propor, na Alemanha, uma construção paralela, que encontrou larga difusão e aceitação doutrinais. O verdadeiro dolo, diz ele, resulta da conexão do dolo do facto com a consciência actual do ilícito; mas quando a falta desta consciência derive de uma especial configuração da personalidade do agente — da sua **cegueira para o**, ou melhor, da sua **inimizade** ou **hostilidade ao direito**, traduzida nas suas "concepções originariamente falsas sobre

([20]) SANTOS, Beleza dos, nota 13, pp. 146 e s. e 163 (negrito nosso).

o que é lícito e ilícito —, ela não pode impedir a aplicação ao agente da moldura penal dolosa prevista para o facto. Não se trata de uma "ficção de dolo", mas da punição do agente — com uma personalidade onerada por uma particular "culpa na condução da vida" — como um agente *doloso* (21). Eduardo Correia, por seu turno, começou por ligar-se à posição de Beleza dos Santos (22), para posteriormente ensinar que sempre que falta a consciência do ilícito o dolo deve ser negado; em tais hipóteses, porém, o agente deve ainda ser punido a título de dolo — ainda que, em rigor, a censura do facto seja a da mera negligência — sempre que seja possível assacar-lhe, em virtude precisamente daquela falta de consciência do ilícito, uma particular **culpa na formação ou na preparação da personalidade** (23).

§ 18 Como em seguida se explicitará, a proposição básica da teoria do dolo limitada é porventura, dentre todas as teorias aqui em exposição, aquela que — quando perspectivada à luz de uma exacta concepção material da culpa jurídico-penal em geral e da culpa dolosa em particular — **mais próxima** se encontra da tese que defenderemos nesta matéria. Sobretudo na parte em que considera "fungível", digamos, para a culpa dolosa a consciência actual da ilicitude e a sua falta, sempre que esta última revele uma particular atitude íntima do agente (ainda a definir exactamente) perante o dever-ser jurídico-penal. Quando tomadas na sua concretização dogmática, porém, nenhuma das doutrinas apontadas pode ser aceite, na medida em que todas elas fazem apelo a uma culpa do agente referida à personalidade incompatível com um direito penal que, já o dissemos várias vezes, tem de (e só pode) ser democraticamente um direito penal *do facto*; e ainda na parte em que lhes esteja subjacente a ideia de que o "verdadeiro dolo" compreende a consciência actual do ilícito, para depois — então com violação do princípio da culpa e manifesto prejuízo para a certeza e estabilidade dos conceitos que assim se procura defender — se cinditem o pressuposto e a consequência jurídica, punindo "a título de dolo" factos que conceitualmente se afirma serem negligentes.

2.2.4. A "teoria da culpa estrita"

§ 19 Partindo da afirmação da essencialidade do princípio da culpa (afirmação que não tem de ser — nem é na verdade, ao menos na maio-

---

(21) MEZGER, Rechtsirrtum und Rechtsblindheit, *Kohlrausch-FS*, 1944, pp. 180 e ss., 184, e *Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik*, 1950, p. 43 e ss.

(22) CORREIA, Eduardo, *Lições 1949*, p. 347.

(23) CORREIA, Eduardo, I, n.º 91. Cf., também, o seu *ProjPG*, art. 13.º, e § 4.

ria dos casos — contestada pelas teorias do dolo), uma teoria situada, na concepção construtivo-sistemática básica e nos resultados prático-normativos a que conduz, como que nos antípodas das teorias do dolo afirma que **a consciência do ilícito não é, na sua forma actual, momento constitutivo do dolo**, pois que este, como factor subjectivo que dirige o comportamento, se esgota no conhecimento e vontade de realização de um tipo objectivo de ilícito; **ela é sim, como mera cognoscibilidade ou consciência potencial do ilícito, um elemento essencial do juízo de censura da culpa**. Daí pois que quem actue sem consciência potencial do ilícito não possa, por falta de culpa, pura e simplesmente ser punido; mas daí também que quem, *podendo* ter conhecido o ilícito e possuindo o dolo do tipo, tenha actuado sem consciência actual do ilícito, *tenha agido dolosamente* e deva ser punido a esse título. Uma punição a título de negligência está, nestes casos, em absoluto fora de questão: o mais que pode (se puder) é a pena prevista para o crime doloso ser *especialmente atenuada* em virtude do erro sobre a proibição. Estas as proposições básicas que fundamentam a chamada **teoria da culpa estrita** ([24]).

§ 20 Em paralelo com o que afirmámos (supra, § 15) relativamente à teoria do dolo estrita, também a teoria da culpa estrita repousa num puro **axioma construtivo-sistemático**: o de que o dolo (máxime, como equivalente da mera "finalidade") se esgota em sede de tipo de ilícito subjectivo e a culpa se traduz em um mero juízo de censura e dela não faz parte o objecto da valoração; num axioma conceitualista, assim, próprio da doutrina ortodoxa da acção final. Inaceitáveis que considerámos já tais proposições, também a teoria da culpa estrita não pode, deste ponto de vista, merecer aceitação. E todavia, a solução do problema da falta de consciência do ilícito a que conduz — nomeadamente, justificando aí a punição do agente a título de dolo, salvo se o erro não for censurável — revela-se **político-criminalmente fundada**, afastando o espectro das lacunas de punibilidade, e deve por isso merecer, em princípio, aceitação. Em princípio, dizemos, porque, levando até ao fim, como esta teoria leva, a ideia de que *sempre* que o agente actuou com dolo do facto e com culpa, a sua puni-

([24]) Como "teoria" — que não apenas como "solução do problema" — desenvolvida sobretudo por Welzel em inúmeros dos seus trabalhos e exposta por último e em síntese em WELZEL, § 22.

ção só pode vir a ter lugar **a título de dolo**, se revela inexacta: na medida em que tal aconteceria então também nos casos de aceitação errónea do substrato de uma causa de justificação ou de um estado de necessidade subjectivo (art. 16.º-2), como ainda nos casos de mero erro sobre a proibição legal (art. 16.º-1 *in fine*).

2.2.5. A "teoria da culpa limitada"

§ 21 Esta a razão por que construções mais recentes, aceitando embora, em via de princípio, a solução do problema da falta de consciência do ilícito na linha da teoria da culpa — punição do agente a título de dolo sempre que actue com culpa —, todavia lhe introduziram uma importante limitação. Defendendo que a punição do agente àquele título já não deve ter lugar sempre que, apesar de ter actuado com conhecimento e vontade de realização do tipo objectivo, todavia a falta de consciência de estar a praticar um ilícito provenha de ter suposto falsamente a existência dos pressupostos materiais de uma causa de justificação ([25]). Doutrina que foi depois estendida por alguns à falsa suposição dos pressupostos materiais de um estado de necessidade subjectivo; e estendida ainda aos casos em que o agente desconhece a proibição de condutas axiologicamente irrelevantes ou pouco relevantes, como sucede com as contra-ordenações e com alguns crimes relativamente aos quais ainda se não interiorizou suficientemente na comunidade o carácter social e eticamente desvalioso — ou socialmente ético-socialmente danoso— das condutas respectivas. A estas concepções se deu doutrinalmente, no seu conjunto, o cognome de **teoria da culpa limitada**.

§ 22 De tudo isto já foi questão supra, 14.º Cap., § 23 e ss., e também 13.º Cap., § 31 e ss. Aí se mostrou ir completamente no sentido das soluções preconizadas pela teoria da culpa limitada o disposto, respectivamente, nos arts. 16.º-2 e 16.º-1 *in fine*. Aí se disse também das razões por que tais soluções nos surgem como materialmente fundadas e merecem, nessa medida, a nossa mais cabal concordância. Para lá se remete, portanto, em conexão directa com a matéria de que agora se trata.

([25]) Uma das primeiras referências a esta teoria encontra-se no estudo a tantos títulos fundamental de GALLAS, Zum gegenwärtige Stand der Lehre vom Verbrechen, *ZStW* 67, 1955, p. 45 e s. Cf., depois, ao menos na conclusão, D / TRÖNDLE, § 16, n.º 27, JESCHECK / WEIGEND, § 41, IV, 1, d, M / ZIPF, § 25, V, C, ROXIN I, § 14, n.º 52 e ss., STRATENWERTH / KUHLEN, § 9, n.º 155 e ss.

2.3. Conclusão intermédia

§ 23 A conclusão a retirar de quanto ficou dito é a seguinte: no direito português, como no alemão, existem duas espécies de erro jurídico-penalmente relevante, a cada uma das quais cabem, todavia, diferentes formas de relevância e diferentes efeitos sobre a responsabilidade do agente. Uma das espécies de erro **exclui o dolo**, ficando ressalvada a punibilidade da negligência nos termos gerais. A outra espécie de erro **exclui a culpa se for não censurável** — merecendo por isso aqui, do ponto de vista dogmático, o designativo de *causa de exclusão da culpa* (infra, 23.º Cap.) —, enquanto, **se for censurável, deixa persistir a punição a título de dolo**, se bem que a pena possa eventualmente ser especialmente atenuada. Uma tal distinção entre as duas espécies de erro nada (ou muito pouco) tem a ver com as distinções entre o *erro de facto* e o *erro de direito*, ou sequer com a circunstância de este último poder ser qualificado como erro de direito penal ou extra-penal. Mas a distinção feita pelo CP português também se não identifica com a distinção do direito alemão entre *erro sobre o tipo* e *erro sobre a proibição*. A doutrina alemã continua é certo, praticamente *una voce*, a considerar decisiva a distinção das duas espécies de erro em função de um versar sobre o tipo e o outro sobre a proibição. Um pouco estranhamente, haverá de anotar-se, quando a própria teoria da culpa limitada, porventura hoje dominante na Alemanha, concorda já que o erro sobre a proibição será tratado nos quadros do erro sobre o tipo (isto é, como erro que exclui o dolo) se a proibição se referir a condutas axiologicamente neutras ou de relevo axiológico não suficientemente caracterizado ou comunitariamente difundido. Além de que, de um ponto de vista técnico-jurídico e dogmático, carece em absoluto de fundamento — salvo nos termos da criticada doutrina dos elementos negativos do tipo: supra, 10.º Cap., § 51 — a afirmação de que um erro sobre os pressupostos de uma causa de justificação constitui um erro que versa sobre o tipo.

§ 24 Um **erro que exclui o dolo** existe na verdade, segundo o direito português, em **três casos** ([26]): 1) quando verse sobre elementos, de facto ou de direito, de um tipo de crime; 2) quando verse sobre os pressupostos de uma causa de justificação ou de uma causa de exclusão da culpa;

([26]) Como exactamente notou ROXIN, nota 4, p. 27.

3) quando verse sobre proibições (ou imposições, no caso de omissão) cujo conhecimento seria razoavelmente indispensável para que o agente possa tomar consciência do ilícito. Esta última fórmula legal fornece a chave para compreender as razões fundamentais que justificam os termos em que a distinção entre as duas espécies de erro é feita no direito português ([27]). O ponto de partida para a sua compreensão reside, em nosso entendimento, no argumento básico de que a relevância jurídico-penal do erro *constitui primariamente um problema de culpa*. Só pois autonomamente a partir de uma **diferença de culpa** se podem estabelecer diferenças de relevância das espécies de erro, nunca heteronomamente, a partir de conceitualizações ou de diferenciações em sede de construção dogmático-sistemática do facto ou do crime que não tenham na sua base a essência da culpa e a sua função político-criminal no sistema.

§ 25 Por isso é metodológica e político-criminalmente tão ilegítimo estabelecer a distinção das duas espécies de erro em função da distinção entre o facto e o direito, como em função de concepções sobre, p. ex.: o carácter causal ou final da acção; a construção do tipo objectivo de ilícito como "tipo indiciário" ou antes como "tipo de ilícito" ou "tipo total"; aquilo que se considere ser a essência e a função sistemática da ilicitude; ou ainda a forma como se estabeleçam as relações entre o tipo e a ilicitude. Todos estes são decerto problemas fundamentais da doutrina penal, material e político-criminalmente fundados, que não meras questões formal-sistemáticas. Mas **não são problemas de culpa**, como seria necessário para fundamentar duas espécies de erro com consequências diversas para a responsabilidade jurídico-penal do agente. Até ao ponto de poder porventura afirmar-se que onde uma tal responsabilidade variasse em função de considerações estranhas à culpa, aí se depararia com uma *violação do princípio da culpa*; por isso mesmo, decerto, não faltando autores, especialmente alemães, a sustentarem que **uma solução do problema da falta de consciência do ilícito que não coincida com o disposto nos arts. 16.º e 17.º do CP português seria materialmente inconstitucional** por violadora do princípio da culpa ([28]).

3. O critério de autonomia da falta censurável de consciência do ilícito e a culpa dolosa

§ 26 Mas qual então a **diferença de culpa** que permite distinguir um erro que exclui o dolo e outro que o não exclui? O passo fundamental de uma correcta dilucidação do problema foi dado por Engisch: quem, com

([27]) Assim já, a propósito do direito português anterior a 1982, o nosso *O Problema*, § 15.
([28]) Cf. TIEDEMANN, nota 4.

dolo do facto, preenche um tipo de ilícito, *conhece o essencial* e recebe a partir do conhecimento daquilo que faz um **impulso** para sentir o desvalor jurídico da sua conduta; pelo contrário, quem actua no desconhecimento da factualidade típica não recebe qualquer impulso para que omita a conduta proibida ([29]). A este argumento se pode contrapor, com razão, que em certos casos-limite um tal impulso pode faltar como efeito psicológico real, efectivamente verificado num certo momento na psique do agente. E será muito provável que ele falte tanto mais quanto a personalidade do agente revele um "daltonismo" ou uma cegueira para os valores que a ordem jurídica respira. Para além disto, a esta concepção parece inevitavelmente associada a ideia de que o aludido "impulso" torna *mais fácil* para o agente determinar-se de acordo com a norma, por isso se imputando a circunstância de um tal impulso não ter sido seguido a uma culpa especialmente grave (dolosa) porque era maior o seu "poder de agir de outra maneira". A essencialidade (e a justeza) do argumento persiste, porém, só exigindo que ele seja pensado num plano mais fundo do que o do mero psicologismo e à luz de uma culpa material não como culpa da vontade, mas como culpa da pessoa.

§ 27 Assim, o "impulso" deve antes surgir e ser compreendido *objectivamente*, como qualidade ou característica da situação, como **ensejo** que ela mesma oferece, independentemente de ser ou não como tal sentido pelo agente. O que é reforçado pela circunstância de que a vontade subsequente à acção (a sua "finalidade"), em caso de erro sobre a factualidade típica, se dirige em sentido que o direito não desaprova (*v. g.*, *A*, maior, tem cópula consentida com *B*, abusando da sua inexperiência, na convicção errónea de que a vítima tem 17 e não, como sucede na realidade, apenas 15 anos); enquanto, sempre que existe dolo do facto mas não consciência do ilícito, a vontade ou "finalidade" se dirige em sentido juridicamente desvalioso e desaprovado (*A* sabe que *B* tem 15 anos mas julga que a cópula consentida com abuso da inexperiência da vítima apenas é proibida com menor de 14).

§ 28 Com tudo isto toca-se o essencial: o erro excluirá o dolo (a nível do tipo) sempre que determine uma **falta do conhecimento** necessário a

---

([29]) ENGISCH, Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei Rechtfertigungsgründe, *ZStW 70*, 1950, p. 566 e ss. Cf., por último, DÍAZ Y GARCIA Conlledo, nota 10, p. 74.

uma correcta orientação da consciência ética do agente para o desvalor do ilícito; diversamente, o erro fundamentará o dolo (da culpa) sempre que, detendo embora o agente todo o conhecimento razoavelmente indispensável àquela orientação, actua todavia em estado de erro sobre o carácter ilícito do facto. Neste último caso o erro não radica ao nível da consciência psicológica (ou consciência-intencional, *Bewußtsein* em alemão), mas ao nível da própria consciência ética (ou consciência dos valores, *Gewissen* em alemão), revelando a **falta de sintonia com a ordem dos valores ou dos bens jurídicos que ao direito penal cumpre proteger**. Por outras palavras: no primeiro caso estamos perante uma **deficiência da consciência psicológica,** imputável a uma falta de informação ou de esclarecimento e que por isso, quando censurável, revela uma atitude interna de descuido ou de leviandade perante o dever-ser jurídico-penal e conforma paradigmaticamente o tipo específico da **culpa negligente**. Diferentemente, no segundo caso estamos perante uma **deficiência da própria consciência ética do agente**, que lhe não permite apreender correctamente os valores jurídico-penais e que por isso, quando censurável, revela uma atitude de contrariedade ou indiferença perante o dever-ser jurídico-penal e conforma paradigmaticamente o tipo específico **da culpa dolosa** ([30]). É esta a concepção básica sobre o dolo do tipo, a consciência do ilícito e a culpa dolosa que está mesmo na base do regime constante dos arts. 16.º e 17.º

§ 29 Esta nossa concepção liga-se, de resto, a uma linha muito definida do **pensamento filosófico**, aprofundada sobretudo pela teologia moral mas a que não se manteve estranho o pensamento filosófico geral. Já Aristóteles defendia que a ignorância na escolha do bem e do mal não faz a acção involuntária, antes nos diz somente que ela é perversa; e o mesmo acontece com a ignorância das regras gerais da moralidade. *Pois é esta própria ignorância que torna os homens passíveis de censura, antes que de desculpa* ([31]). E também Tomás de Aquino, à inteira semelhança de Aristóteles, sustentava o carácter especialmente culposo da ignorância sobre as regras gerais da moralidade e da acção porque na sua origem está, diversamente do que acontece em caso de erro sobre as circunstâncias, *uma paixão ou um hábito viciosos que precisamente fundamentam a censura* ([32]). Pascal, de modo análogo, afirma serem *as próprias qualidades pessoais desvaliosas determinantes da ignorância da maldade da acção que haverão de ser imputadas à culpa do agente e fundamentar uma censura*

([30]) DIAS, Figueiredo, *O Problema*, §§ 14 e 15.

([31]) ARISTÓTELES, sobretudo na sua *Ética a Nicómaco*, 1110b, 1111, 1113b, 1134b, 1136a.

([32]) S. TOMÁS, *Summa Theologica*, 1.ª 2.ªᵉ, q. 94, art. 6.º; cf., também, q. 19, art. 6.º

tanto maior quanto o agente tenha ficado, por causa delas, mais longe de alcançar a consciência daquela maldade (33). É no entanto em Hegel que se depara com a mais clara e profunda consciência do problema e com a sua solução integralmente dentro do caminho atrás proposto. Logo previne, na verdade, que "o direito de apreensão do bem [*sc.*, da licitude] deve distinguir-se do direito de conhecimento da acção como tal [*sc.*, do dolo do facto]"; porque, enquanto a questão deste conhecimento se centra no domínio da "*moralidade subjectiva*", a daquela apreensão se situa no "*direito da objectividade*, que não pode ser prejudicado por aquilo que, para satisfação da minha convicção, eu exijo do carácter bom, permitido ou proibido de uma acção". Já que para Hegel, porém, toda a imputação supõe a culpa do agente, como se apresentam relativamente a esta as aludidas diferenças? A resposta está em que Hegel, enquanto trata do problema do conhecimento das circunstâncias no âmbito da questão do *dolo*, conexiona o da consciência do ilícito com a doutrina sobre a *consciência ética* (34). Este segundo problema, porque ancorado no plano do "direito da objectividade", não tem que ver com o "direito do saber" que conforma e delimita o dolo, mas com a posição do agente perante o lícito e o ilícito, com a sua "consciência ética". De tudo resultando a sua conclusão paradigmática: "Dizer-se que ele [o homem] deve, no momento da acção, ter representado claramente o seu carácter ilícito e punível, para que aquela lhe possa ser imputada como crime, é uma exigência que parece salvaguardar-lhe o direito da sua subjectividade moral, mas que na realidade lhe nega a sua imanente natureza inteligente". Na verdade — insiste —, "não se trata o homem de acordo com a dignidade do seu conceito quando se separa dele o plano do bem e, com ele, a determinação da sua acção má enquanto tal, *e se lha não imputa como má*" (35).

§ 30 A **explanação dogmática** de um critério fundamentalmente ligado a toda esta linha de pensamento surge de forma clara, porventura pela primeira vez, em v. Bar: invocando justamente a lição de Aristóteles, sustenta que a falta de consciência do ilícito fundamenta, ela própria, de forma imediata, a culpa do agente; porque o "desconhecimento daquilo que se deve fazer ou omitir reside na maldade do carácter, isto é, dito em termos modernos, na sua qualidade anti-social ou, mais exactamente, na vida total do indivíduo só em muito pequena medida impregnada de sen-

(33) PASCAL, 4ème lettre écrite à un provincial par un de ses amis, *Œuvres complètes*, éd. du Seuil, 1963, p. 383 e s. Uma concepção, aliás, que por inteiro se cobre com a doutrina de S. AGOSTINHO, *Retractationes*, c. 15, 1, 1, e *Confissões* (tradução portuguesa de J. Santos e A. de Pina, ^{6}1958), p. 4, de acordo com a sua divisa *necesse est ut peccet, a quo ignoratur justitia*.

(34) HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, ed. Lasson, ^{3}1930. Com efeito, enquanto o tratamento do primeiro problema se contém no capítulo intitulado *O dolo e a culpa* (§§ 115-119), o segundo (§§ 132, 139, 140) está integrado no capítulo epigrafado *O bem e a consciência ética*.

(35) HEGEL, nota 34, §§ 132 e anotação e 140 e anotação a^{1}.

timentos altruístas" ([36]). Mas é na doutrina suíça que Kadecka se ocupa do necessário expurgo do carácter acentuadamente caracterológico e naturalista do pensamento de v. Bar, acentuando que o desvalor *ético* da pessoa do agente, que verdadeiramente o constitui em culpa, resulta de modo muito mais forte e característico de defeitos no mundo dos seus sentimentos do que de faltas no mundo das suas representações. Ora a falta de consciência do ilícito, sendo justamente uma falta de sentimento da maldade da acção respectiva, antes que um defeito de representação como é o erro sobre as circunstâncias do facto, exprime imediatamente o desvalor ético da personalidade do agente e, assim, uma culpa de espécie particular ([37]).

§ 31 É no entanto a doutrina de Nowakowski aquela que, no estrito **domínio jurídico-penal**, mais próxima se encontra do pensamento essencial que preside à nossa posição. Para ele, toda a culpa radica em uma falta de ligação da personalidade do agente com um valor juridicamente protegido e, por aí, com a ordenação axiológico-jurídica da comunidade; de modo a poder afirmar-se que, se tivesse existido a requerida e justa ligação (digamos: a exigida "fidelidade"), o agente teria omitido a acção respectiva em virtude do seu significado desvalioso. Tanto a culpa da conduta realizada com erro sobre as circunstâncias do facto como a da realizada sem consciência do ilícito se fundamentam em uma tal falta de "fidelidade"; esta "infidelidade" porém analisa-se, ali em uma *falta do conhecimento* necessário para alcançar a consciência do ilícito, aqui directamente em uma *falta do justo sentimento do valor* que fundamenta uma culpa mais pesada. Transpondo esta concepção para o plano dogmático da teoria do erro, importará assim colocar aí, em vez das tradicionais, a nova dicotomia **erro de conhecimento / erro de valoração**. "Um erro de conhecimento — acentua Nowakowski — existe quando há uma falta daquele conhecimento (de circunstâncias de facto ou de preceitos jurídicos) que é exigido pelo justo sentimento do valor para apreensão do significado desvalioso do comportamento; um erro de valoração quando falta, não este conhecimento, mas sim a percepção do significado de desvalor do comportamento", pressuposto que "foram efectivamente conhecidas todas as cir-

([36]) V. BAR, *Gesetz und Schuld im Strafrecht*, II, 1907, p. 390 e [212].

([37]) KADECKA, Ist das Unrechtsbewusstsein ein allgemeines Schuldmerkmal?, *SchwZ*, 1939, pp. 50 e ss., 64, 69.

cunstâncias que, em caso de justo sentimento do valor, teriam permitido ao agente alcançar a consciência do ilícito" ([38]).

§ 32 Residindo aqui o essencial, não deve deixar de notar-se que, no entendimento que propomos, a verdadeira falta de consciência do ilícito jurídico-penal é porventura menos extensa que o âmbito do puro "erro de valoração", tal como ele é definido por Nowakowski; pois muitas "valorações" (não apenas, mas também "proibições jurídicas") existem cujo resultado (ou existência) precisa de ser conhecido pelo agente para que a sua consciência ética deva ter-se por suficientemente orientada para o problema do desvalor do ilícito. Eis o que foi reconhecido por Gallas, que, após distinguir o conhecimento do *substrato* de uma valoração do erro na *valoração* de um substrato, defende que também este pode ter a sua verdadeira origem em uma mera falta de conhecimento positivo, de ciência, antes que em uma falta de sentimento axiológico, de capacidade de valoração; só nesta última hipótese, todavia, ganhando a falta de consciência do ilícito, como problema de culpa, autêntica autonomia face ao erro sobre as circunstâncias do facto. Efectivamente, tanto no puro erro sobre o substrato, como no erro de valoração ou no erro sobre a proibição devidos a uma falta de conhecimento — que conjuntamente conformam o que Gallas chama **erro intelectual** —, a censura dirige-se a uma falta de conhecimento que o agente não obteve por violação de um dever de atenção ou de informação. Diferentemente, na outra hipótese — conformadora do âmbito do que chama **erro moral** —, a censura dirige-se à falta ou ao embotamento do "órgão" de apreensão das decisões axiológicas da ordem jurídica e, por conseguinte, antes que a uma falta de conhecimento, a uma cegueira para os valores do direito ([39]).

§ 33 A conclusão é pois assim a de que, por um lado, as dicotomias tradicionais erro de facto / erro de direito ou erro sobre o tipo / erro sobre a proibição, em si mesmas heterónomas relativamente à culpa, devem ser recusadas e substituídas por outras que — como sucede com as dicotomias **erro de conhecimento / erro de valoração, erro intelectual / erro moral, erro da consciência psicológica / erro da consciência ética** —

([38]) NOWAKOWSKI, Rechtsfeindlichkeit, Schuld, Vorsatz, *ZStW 65*, 1953, pp. 379 e s., 387, 389 e s.

([39]) GALLAS, *Niederschriften*, II, p. 41 e ss.

tenham a sua origem e o seu fundamento no cerne da culpa material e da sua função político-criminal no sistema. E por outro lado a de que o erro da consciência ética traz consigo um tipo de culpa mais grave e pesada do que a que assiste ao erro da consciência psicológica: enquanto este (erro sobre a factualidade típica ou sobre o substrato de uma causa de justificação ou de exclusão da culpa ou sobre proibições de condutas axiologicamente neutras ou pouco relevantes) revela e fundamenta uma atitude de descuido ou leviandade perante o dever-ser jurídico-penal e a danosidade social que está na sua base, o erro da consciência ética revela e fundamenta uma atitude de contrariedade ou indiferença perante aquele dever-ser. **Por isso o facto realizado com dolo do tipo mas com falta censurável de consciência do ilícito fundamenta uma culpa dolosa e requer a punição a esse título.**

4. Delimitação da falta de consciência do ilícito e suas espécies

§ 34 Deve agora determinar-se com a exactidão possível o que é a *consciência do ilícito* em causa para efeito de afirmação ou negação da culpa dolosa (e, quando não censurável, da *culpa tout court*). Claro que, identificando nós afinal, para aquele efeito, segundo o conteúdo e o tipo da culpa respectivos, o facto praticado *com* consciência do ilícito ao facto praticado *sem* aquela consciência, desde que a falta seja censurável e imputável a um erro da própria consciência ética, a questão perde muito da sua acuidade; mas nem por isso se dirá que, para diversos efeitos normativo-práticos, ela é irrelevante, nomeadamente porque, tratando-se de uma verdadeira falta de consciência do ilícito, haverá que determinar depois se ela é ou não censurável (art. 17.º-1 e infra, 23.º Cap.). A maioria da doutrina faz equivaler a consciência do ilícito à consciência da *ilicitude* como **juízo de desvalor jurídico da acção**; logo tendo então porém de acentuar-se (como atrás já anotámos a propósito da teoria do dolo estrita: supra, § 14), que seria absurdo exigir uma consciência da ilicitude em um preciso sentido jurídico, sendo suficiente uma "valoração paralela na esfera do leigo" ou, como preferimos, uma **apreensão do sentido ou significado social desvalioso correspondente, no essencial e segundo o nível próprio das representações do agente, ao resultado da valoração jurídica**. Ao que acresce que neste domínio da consciência do ilícito ganhará particular acuidade um outro ponto, também já a diferente propósito considerado (supra, 13.º Cap., § 14 e ss.): o de que se não exige para afirmação do dolo da culpa uma clara e distinta forma de consciência, mas bastará uma sua

exigência amortecida, sob a forma de uma co-consciência imanente à acção ou — aqui com particular cabimento — de uma **advertência do sentimento** no sentido da ilicitude da conduta. Do conjunto destas posições decorrem algumas consequências que devem ser sublinhadas.

4.1. Consciência do ilícito e consciência da imoralidade da acção

§ 35 A primeira é a de que a requerida consciência do **ilícito** não equivale à (nem pode substituir-se pela) consciência — a que alude uma parte da doutrina — da **imoralidade** da acção. As razões são várias e já conhecidas, pelo que não será indispensável insistir muito nelas: a censura dirige-se à falta de consciência da norma *jurídica* de comportamento (não decerto como artigo de lei ou mesmo como proibição legal), não de normas pertencentes a outros ordenamentos. Por outro lado, já o sabemos também, a norma jurídico-penal nem coincide, nem se fundamenta em uma qualquer norma moral, antes sim na necessidade de protecção subsidiária de bens jurídico-penais. Não se nega com isto uma larga coincidência entre proibições morais e jurídico-penais, traduzidas aliás no conteúdo destas últimas como o "mínimo ético" de que falava Jellinek (supra, 6.º Cap., § 13); o que se nega é que seja função da norma jurídico-penal a tutela de uma qualquer moral.

4.2. Consciência do ilícito e consciência da punibilidade

§ 36 Mais problemático é saber se uma falta de consciência do ilícito não deve ainda ser afirmada quando o agente tomou consciência de que a sua conduta era contrária ao direito, mas não concretamente ao direito **penal**. O que conduziria, no limite, a exigir do agente uma consciência da ilicitude **penal** ou, se preferirmos, *hoc* sensu, da **punibilidade** do facto. A doutrina esmagadoramente dominante, quando não praticamente unânime, entre nós e lá fora ([40]), defende que o carácter ilícito do facto, cuja consciência ou falta de consciência releva para a culpa, não se confunde com a sua *punibilidade* ou com a sua natureza jurídico-*penal*: à afirmação do dolo bastaria a consciência do sentido de desvalor *jurídico* que à con-

([40]) Depois da polémica contra a posição de Feuerbach, logo decidida na primeira metade do séc. XIX: cf., sobre o tema, entre outros, MAURACH, Das Unrechtsbewußtsein zwischen Kriminalpolitik und Strafrechtsdogmatik, *Eb. Schmidt-FS*, 1961, pp. 301, 307 e ss. Ainda neste sentido se dirigia completamente o nosso *O Problema*, § 16, II.

duta concreta se liga (41). Há alguns anos atrás, um caso discutido nos tribunais portugueses fez porém que pusésemos em questão esta unanimidade de pontos de vista (42). Resumidamente, um advogado foi acusado de ter cometido um crime financeiro (relacionado com operações ilegais sobre divisas), tendo todavia sido comprovado que actuou na convicção de que a conduta não constituía um crime, mas uma contra-ordenação. O tribunal de 1.ª instância condenou o arguido a título de negligência, por ter considerado a conduta abrangida no art. 16.º (erro sobre as circunstâncias do facto), a instância de recurso condenou o agente a título de dolo, por o ter considerado incurso no art. 17.º (falta censurável de consciência do ilícito): os dois tribunais, por conseguinte, reputaram o erro *relevante*, afastando deste modo, de forma mais ou menos consciente, a doutrina acima apontada como unânime.

§ 37 Há hoje boas razões para defender que, ao menos em certos casos, não basta à afirmação do dolo o conhecimento de uma proibição que coloque a conduta no âmbito de um **ilícito qualitativamente distinto do ilícito penal**. Dito pela positiva, casos haverá em que só a ilicitude *penal* pode ser objecto daquela consciência que, nos termos do art. 17.º, releva para a culpa. Neste sentido aponta, com efeito, a autonomia material do direito penal como criador de um *ilícito específico*. Em síntese, é nossa convicção que o ilícito penal é portador de uma *diferença qualitativa* que o singulariza face às demais manifestações de ilicitude. À mera proibição da conduta acresce aqui necessariamente uma qualificação correspondente ao carácter fundamental dos bens jurídicos a proteger e à particular intolerabilidade social das formas de sacrifício tipicamente incriminadas. Nesta linha, a convicção de que uma conduta configura um ilícito civil, disciplinar ou contra-ordenacional não deverá valer, ao menos forçosa e imediatamente, como a consciência do ilícito que releva para a culpa jurídico-penal. Assim parece impô-lo a indisfarçável descontinuidade — normativa e axiológico-material — que separa aqueles ilícitos do ilícito jurídico-penal.

---

(41) O que, para muitos autores, nada mais seria, de resto, do que consequência da asserção segundo a qual o princípio da unidade da ordem jurídica implica o repúdio de uma ilicitude *especificamente* penal e, pelo contrário, a aceitação sem reservas da *unidade da ilicitude* (supra, 14.º Cap., § 7 e ss.).

(42) Em parecer jurídico (não publicado) que subscrevemos conjuntamente com Costa Andrade. Sobre o que se segue, cf., já, DIAS, Figueiredo, *in*: Eser / Perron (orgs.), *Rechtfertigung und Entschuldigung*, III, 1990, p. 211 e ss.

O que, uma vez transposto para o problema de que agora se cura, deverá porventura conduzir à conclusão seguinte: é verdade que já a advertência dos sentimentos, resultante do conhecimento das circunstâncias da acção, no sentido de que à conduta empreendida se liga um desvalor de espécie particular (com total independência da *qualificação* que o agente lhe confira e mesmo que esta seja só a da sua juridicidade) revela, quando conexionada com o dolo do facto, o tipo de culpa dolosa que cabe à actuação do agente. *Ponto será porém sempre* **que tal advertência seja comandada por aqueles pontos de vista de valor que suportam, na verdade das coisas, a qualificação do desvalor como jurídico-penal** (43). O que nada tem a ver com o *conhecimento* pelo agente dos artigos da lei ou sobre o que, acerca da questão, tenha sido dito ou escrito por penalistas ou outros peritos (44). Fernanda Palma observa, com inteira pertinência, ser este um caso em que o nosso pensamento "pode entrar em colisão com as categorias clássicas, tornando-as incompreensíveis, isto é disfuncionais" (45). O que fica dito pretende precisamente representar um esboço daquilo que, em casos deste teor, pode ser feito para "recomposição" conceitual nos quadros de um "sistema aberto".

4.3. Cindibilidade (tipicidade) da consciência do ilícito

§ 38 Do exposto resulta por último que não basta à requerida consciência do ilícito a consciência de um qualquer desvalor jurídico — mesmo que jurídico-*penal* no sentido acabado de assinalar —, mas é necessário que o desvalor de que o agente tomou consciência **corresponda no essencial ao do ilícito-*típico*** praticado (46). Não faltou na verdade quem pensasse que a consciência do ilícito relevante para a culpa seria *tipicamente fungível*, de sorte que já agiria com a consciência do ilícito requerida quem não tivesse consciência do ilícito típico efectivamente cometido, mas sim de um outro ilícito típico porventura também efectivamente realizado em concurso ideal. *V. g.*, *A* mata *B*, a pedido sério e instante deste, com um

(43) Assim, já, DIAS, Figueiredo, *O Problema*, § 14, [32].

(44) Assim, todavia, ROXIN I, § 21, n.º 30.

(45) PALMA, Fernanda, Do sentido histórico do ensino do Direito Penal na Universidade portuguesa à actual questão metodológica, *RPCC 9*, 1999, p. 423. Procurando minimizar (porventura com razão) o interesse normativo-prático da questão, DÍAZ Y GARCIA Conlledo, nota 10, p. 79 e ss.

(46) Assim, o nosso *O Problema*, § 14, III, 2, *b)*. Constitui hoje doutrina unânime na Alemanha.

"tiro misericordioso" (art. 134.º) na convicção de que este facto não constitui um ilícito típico, embora com a consciência acompanhante de que está a cometer um outro ilícito-típico usando arma proibida (art. 275.º-3). Uma tal concepção representaria sempre, porém, uma violação do princípio da culpa, bastando-se para afirmação desta com uma geral "má consciência". Esquecer-se-ia deste modo que toda a culpa se afirma só na base do concreto ilícito-típico praticado e que objecto da censura da culpa não pode ser uma qualquer culpa *geral* da personalidade, mas apenas a atitude pessoal que se exprime no singular tipo de ilícito e o fundamenta. Por isso há que afirmar sem reserva — e que tomar particularmente a sério no momento da aplicação — a **referência ao tipo objectivo** da consciência do ilícito requerida e a sua consequente *cindibilidade*.

4.4. Consciência do ilícito (concreto) e não da ilicitude (abstracta)

4.4.1. Desconhecimento da lei (da proibição) e consciência do ilícito

§ 39 Ficar-se-á agora em posição de pôr no devido realce — o que importa consequências prático-normativas do mais alto relevo — o que verdadeiramente separa a falta de consciência do ilícito-típico requerida pela culpa da ignorância da lei ou da proibição ([47]). Se aquela consciência se basta com uma advertência dos sentimentos do agente de que ao seu facto se liga um sentido típico de desvalor, então, desde logo, **pode o agente não ter conhecimento do princípio, da norma geral ou da proibição abstractamente aplicáveis e possuir todavia a consciência do ilícito relevante para a culpa**. Isto poderá acontecer sobretudo nos casos em que a valoração jurídico-penal da ilicitude se encontra incluída em uma valoração mais ampla — moral, social ou cultural — de que o agente tem consciência e que pode por isso, em concreto, revelar-se *mais importante e decisiva* para aquisição da concreta consciência do ilícito do que o conhecimento da lei ou da proibição efectivamente aplicáveis. Tal não há-de ser entendido no sentido de fazer valer a consciência da imoralidade ou da danosidade social como tais como consciência do ilícito. Significa apenas que, embora na consciência do ilícito se trate *só* do específico sentido de ilici-

([47]) Cf. o nosso *O Problema*, § 14, III, 2, *a)*. Contra — ao menos no que toca ao conhecimento da proibição — a generalidade da doutrina alemã, mesmo da mais recente.

tude, aquela pode ser alcançada pelo agente a partir da consciência da mais ampla valoração não jurídica e sem ter de supor o conhecimento da lei ou da proibição efectivamente aplicáveis. De resto, e para além disto, não poderá negar-se *a priori* a possibilidade de o agente, mesmo na completa ignorância da lei ou da proibição aplicáveis, ser conduzido à consciência do ilícito pela sua *intuição* ou pelo seu *sentimento jurídico* ([48]), ainda mesmo quando não detenha a consciência da mais ampla valoração não jurídica em que a ilicitude se insere.

4.4.2. Conhecimento da lei (da proibição legal) e falta de consciência do ilícito

§ 40 Por outro lado, **pode o agente representar**, mesmo de forma **actual, a lei, a norma geral ou a proibição abstractamente aplicável ao caso e não possuir todavia a consciência do ilícito relevante para a culpa**. Decerto, uma tal possibilidade estará excluída para todos quantos se disponham a analisar a questão dentro de estritos pressupostos legalistas e positivistas: conhecendo o agente a premissa maior, qualquer erro só poderia imputar-se então a um desconhecimento dos factos no sentido da norma, isto é, a um "erro lógico de subsunção" que não contenderia com o problema da consciência do ilícito mas só, no máximo, ainda com um erro sobre a factualidade típica (sobretudo quando esta contivesse elementos extremadamente normativos). Reconhecendo porém (como se deve) que o conhecimento da lei não equivale nem implica a consciência da solução do caso — ou porque se entenda que a solução só pode ser encontrada em definitivo em função da intencionalidade normativa postulada pelo próprio caso; ou, em todo o caso, que o esquema subsuntivo só pode valer dentro dos parâmetros da justiça do caso (supra, 3.º Cap., §§ 15-24) — bem se compreende que a questão posta não tenha de reduzir-se a um "erro lógico de subsunção", mas possa traduzir-se em uma autêntica falta de consciência do ilícito.

§ 41 É o que desde logo sucede quando se trate de erro não sobre um estado de coisas que, a existir, excluiria a ilicitude do facto ou a culpa do agente (erro que exclui o dolo), mas sobre a **existência ou os limites de uma causa de justificação ou de exclusão da culpa** (erro que não

([48]) Em sentido análogo, NOWAKOWSKI, nota 38, p. 383.

exclui o dolo) ([49]). Pode *A* conhecer a proibição de ofender a integridade física de outrem e todavia, dando um passeio com uma criança filha de um amigo, dar-lhe um estalo ou um puxão de orelhas porque a criança disse um palavrão ou está a ser desobediente, crendo erroneamente que lhe cabe um direito de correcção. Pode *B*, conhecendo a aludida proibição, bater em *C* como meio adequado de recuperar a bicicleta que este lhe furtou uns dias antes, na convicção errada de que age ainda a coberto do direito de legítima defesa. Pode *D*, conhecedor da proibição de libertação de gases tóxicos, lançar uma vasilha que os contém numa assembleia onde se reúnem fiéis de religião diferente da sua, por se convencer que as suas convicções religiosas conformam uma causa de exclusão da culpa. Pode *E*, conhecedor da proibição do homicídio, matar *F* por este ter cortado a água que lhe servia para regar o jardim, na convicção errónea de que actuava em estado de necessidade desculpante. Qualquer das hipóteses referidas configura, não um erro que exclui o dolo nos termos do art. 16.º, mas uma **forma de falta de consciência do ilícito** ou de **erro sobre a ilicitude que, nos termos do art. 17.º, não exclui o dolo, embora possa excluir a culpa** (infra, 23.º Cap.).

§ 42 O mesmo se dirá relativamente aos casos — já estudados na perspectiva do erro que exclui o dolo: supra, 13.º Cap., § 10 e ss. — de erros que recaem sobre **elementos normativos do tipo**. Vimos que logo à afirmação do dolo do tipo se torna necessário, nuns casos o conhecimento do sentido correspondente à valoração jurídica respectiva, noutros casos mesmo o conhecimento dos critérios determinantes da qualificação jurídica, noutros casos ainda apenas o conhecimento dos pressupostos materiais da qualificação. Pode porém o agente actuar com conhecimento da proibição geral, e mesmo do conteúdo exigido dos elementos normativos do tipo, e todavia não alcançar a consciência do ilícito do comportamento, tal como é concretamente levado a cabo ([50]). Será p. ex. o caso de *A* que, mal informado pelo seu advogado ou mesmo induzido em erro sobre a leitura de uma sentença judicial anterior quanto ao conteúdo e significado de um elemento normativo, leva a cabo um comportamento concretamente ilícito, na convicção de que ele é lícito. Como será o caso do advogado *B* que, perfeitamente conhecedor da proibição da prevaricação e mesmo

([49]) Minuciosamente sobre a questão, o nosso *O Problema*, § 21.
([50]) Assim já, em pormenor, o nosso *O Problema*, § 22.

dos critérios que conduzem a interpretação do que seja "a mesma causa" (art. 370.º-2), leva a cabo um certo comportamento que, segundo a interpretação correcta daquele elemento, deve ser considerado ilícito. Ainda aqui o conhecimento da proibição legal existe e, todavia, verifica-se um erro sobre a ilicitude do concreto facto praticado.

§ 43 Pode ainda o agente conhecer a norma legal que proíbe o comportamento, conhecer de forma suficiente a totalidade dos seus elementos, descritivos e normativos, e considerar, todavia *erroneamente*, que a lei é inaplicável ao caso concreto, *v. g*, porque a reputa inconstitucional, ou nula por outro motivo, ou inválida. Este erro — que complexivamente se pode crismar **erro de validade** ([51]) — conformará, ele ainda, uma falta de consciência do ilícito se o agente crê erroneamente que o motivo de invalidade é de ordem geral e como tal reconhecido pela ordem jurídica. Já se ele recusa a aplicabilidade por motivos de consciência, o problema excede os quadros da temática estrita da falta de consciência do ilícito e merece uma consideração especial (infra, 25.º Cap.).

4.5. A chamada "consciência condicionada (ou eventual) do ilícito"

§ 44 Relacionada com algumas das questões acima tratadas surge hoje a temática de uma consciência do ilícito eventual ou condicionada (a vários títulos próxima ou mesmo paralela da que estudámos, no tipo de ilícito, sob a epígrafe do "dolo eventual": supra, 13.º Cap., § 44 e ss.). Uma tal situação ocorreria, nas palavras de Roxin, "quando para o agente não está clara a situação jurídica. Quando, p. ex., reputa provável que o seu comportamento seja permitido, mas conta também com a possibilidade de que ele seja proibido" ([52]). A jurisprudência e uma parte da doutrina alemãs consideram que em casos deste teor não existe um erro sobre a proibição, na base de que a consciência do agente de actuar possivelmente contra o direito deveria logo conduzir o agente a abster-se da sua conduta. Diferentemente, autores como Dimakis e Roxin propõem uma **consideração diferenciada**. A solução jurisprudencial só deveria aceitar-se nos casos em que ao agente seja dada a possibilidade de desvanecer as suas dúvidas, "consultando um comentário do CP ou um

([51]) Por outros e por último, ROXIN I, § 21, n.º 25 e s.
([52]) ROXIN I, § 21, n.º 29.

advogado" (Roxin). Quando esta possibilidade se não dê, o agente pode então louvar-se de uma diminuição da culpa e da consequente atenuação da pena (53).

§ 45 Esta última consideração confirma-nos na ideia de que toda esta questão está incorrectatemente tratada e, de todo o modo, sistematicamente deslocada. O problema, para definição dos limites da falta de consciência do ilícito, não reside no mundo das representações do agente — como certas, prováveis ou possíveis — ao nível da sua consciência intencional, nem na possibilidade de obter um mais claro conhecimento ou esclarecimento da situação jurídica. Reside, sim, na resposta da sua consciência ética, do seu sentimento dos valores, em suma, na sua valoração jurídico-penal (ou na falta dela) da situação fáctica correctamente conhecida. O que aqui pode por conseguinte relevar é o erro da consciência ética face a uma situação fáctica cuja valoração jurídica é, ela mesma, pouco clara ou mesmo duvidosa (54). O problema que nesta sede se suscita não é pois o da **determinação dos limites da falta de consciência do ilícito**, mas o de **uma sua incensurabilidade ou menor censurabilidade**; nesse contexto será ele considerado (infra, 23.º Cap., §§ 13, 28).

III. Elementos especiais dos tipos de culpa dolosos

§ 46 Tal como vimos suceder com o tipo subjectivo de ilícito (supra, 13.º Cap., § 55 e ss.), também o tipo de culpa doloso não tem de se esgotar na sua referência ao dolo do tipo. A lei pode ainda aqui fazer **exigências adicionais** para que o agente deva ser punido a título de dolo (55). E já no tratamento da questão paralela no tipo subjectivo de ilícito ficou entendido que assim era, a propósito da dificuldade de distinção, neste contexto, de elementos especiais que pertencem ao tipo subjectivo de ilícito doloso e elementos que pertencem ao tipo de culpa dolosa. Teoreticamente e de forma abstracta, mas nem por isso inexacta, pode dizer-se que tais elementos pertencerão ao tipo de culpa dolosa sempre que eles, ape-

(53) ROXIN I, § 21, n.º 30, e DIMAKIS, *Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat*, 1992.

(54) Aquilo que DIMAKIS, nota 53, chama de "consciência eventual do ilícito 'impura' ou 'imprópria'".

(55) Importante, MAIHOFER, Objektive Schuldelemente, *H. Mayer-FS*, 1966, p. 185.

sar de se não encontrarem relacionados directamente com a atitude de contrariedade ou indiferença do agente perante o dever-ser jurídico-penal, todavia **servem ainda para co-determinar a atitude interna do agente plasmada no facto e que o fundamenta**. Também aqui, dizer em rigor quais são estes elementos é função que só pode pertencer a um estudo minucioso da PE do direito penal. Mas, sempre em conexão com o que ficou dito em sede de tipo subjectivo de ilícito, é possível, com um certo carácter de generalização, avançar o seguinte.

§ 47 Quando a lei refere expressamente elementos subjectivos que descrevem ou nomeiam *motivos*, *sentimentos* e *atitudes* fica próxima a afirmação de que tais elementos pertencem ao tipo de culpa, isto é, servem para caracterizar a atitude interna do agente perante o dever-ser jurídico-penal que se exprime no facto e o fundamenta. Já assim não será, porém, como atrás dissemos, sempre que tais elementos sirvam ainda para co-determinar a espécie de delito e individualizar o respectivo sentido (tipo) do ilícito, caracterizando seja o objecto da acção, seja as condições sob as quais a lesão ou colocação em perigo do bem jurídico protegido é ilícita: nestes casos tais elementos não pertencerão ao tipo de culpa, mas sim ao tipo (subjectivo) de ilícito. A distinção não radica por isso, como à primeira vista poderia pensar-se, no carácter *interno* ou *externo* — no sentido de atinente ao mundo exterior ou antes à pessoa do agente — do elemento em causa, mas antes no seu relacionamento com a **espécie de delito**, relevante para o tipo de ilícito, ou antes com a **atitude interna pessoal do agente**, relevante para o tipo de culpa ([56]).

§ 48 Assim, por exemplo e sem prejuízo do referido estudo minucioso que cada uma das seguintes questões requer a nível da PE, a generalidade das **intenções ilegítimas de apropriação** ou de **lucro, benefício** ou **enriquecimento** que enxameiam os crimes contra o património (arts. 203.º, 205.º, 209.º, 210.º, 217.º, 221.º, 222.º, 223.º, 226.º, etc.) constituem em princípio elementos do tipo de ilícito. Diferentemente, elementos como **avidez, meio insidioso, frieza de ânimo**, etc. (art. 132.º) não são susceptíveis de referência à acção típica (no caso, matar) e tal constitui indício de que eles são, em último termo, elementos do tipo de culpa. De resto — e o exemplo é frisante quanto à dificuldade de distinção e à circunstância de ela só poder ser levada a cabo perante o concreto tipo de crime da parte especial —, o art. 132.º-2 contém elemen-

([56]) Em termos análogos concluem JESCHECK / WEIGEND, § 42, II, 3, a), e ROXIN I, § 10, n.º 70 e ss.

tos que se diriam à primeira vista de natureza objectiva e mesmo claramente referidos à acção e ao bem jurídico protegido e que nem por isso deixam, em último termo, de constituir elementos do tipo de culpa por força da cláusula contida no n.º 1: eles só relevam, efectivamente, se e na medida em que sirvam para caracterizar a "especial censurabilidade ou perversidade" do agente ([57]); também, p. ex., a "influência perturbadora" do parto prevista no crime de infanticídio (art. 136.º) constitui, por análoga razão, um elemento especial do tipo de culpa.

([57]) DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 132.º, § 1 e ss., e, essencialmente no mesmo sentido, já SERRA, Teresa, *Homicídio Qualificado, Tipo de Culpa e Medida da Pena*, 1990. Em sentido a alguns títulos diverso, o estudo aprofundado e minucioso de NEVES, Curado, Indícios de culpa ou tipos de ilícito? — A difícil relação entre o n.º 1 e o n.º 2 do art. 132.º do CP, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 721.

SECÇÃO II

A NEGAÇÃO DA CULPA

21.º CAPÍTULO

A INIMPUTABILIDADE

A. INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DE ANOMALIA PSÍQUICA

I. Fundamento da sua natureza de obstáculo à determinação da culpa

§ 1 O tema agora em consideração tem a ver com a noção e o sentido da inimputabilidade em razão de anomalia psíquica como fundamento da impossibilidade de afirmação, no caso, da culpa jurídico-penal. São aqui decisivas, uma vez mais, a evolução e as transformações sofridas pela culpa na mais recente dogmática jurídico-penal. Dir-se-ia ser o problema da inimputabilidade um dos que nos nossos dias alcançou uma maior estabilização doutrinal. Na realidade, porém, ele é antes um dos mais **movediços** com que pode deparar-se nesta matéria. Não só porque nele convergem todas as dúvidas — dogmáticas e político-criminais, por um lado, metodológicas e epistemológicas, por outro — próprias dos problemas da culpa; mas porque ele se situa na fronteira, cada vez mais ténue e imprecisa, que separa (ou aproxima...) os problemas dogmáticos, político-criminais e criminológicos dentro do edifício global do direito penal.

§ 2 Para poucos problemas, com efeito, como para o da inimputabilidade em razão de anomalia psíquica se revelam tão decisivas e condicionantes as concepções provenientes do campo das **ciências humanas**. A relação dialéctica que, desde o surgimento destas, entre elas e o conceito de inimputabilidade em razão de anomalia psíquica se estabeleceu tem deparado com sensíveis dificuldades; tão grandes que parecem por vezes

conduzir a um diálogo de surdos e roçar o divórcio entre juristas e cientistas do homem, acarretando os maiores danos para a tarefa da aplicação do direito. Mas os recentes desenvolvimentos operados ao nível tanto da compreensão do direito penal, como da imagem das ciências do homem parece darem jus a esperar-se que se eliminem as dificuldades tradicionais; e se atinja um estádio de trabalho conjunto — baseado numa racional divisão de tarefas e de competências, mas sem quebra da interdisciplinaridade e da complementaridade funcional necessárias — com o qual terá a ganhar a justiça e a eficácia da aplicação do direito penal. Ponto é que este novo espírito de relacionamento, determinado por um novo ponto de encontro entre o normativo e o especulativo de um lado, e o fáctico e o empírico do outro, não fique reduzido ao domínio abstracto da dogmática jurídico-penal, mas se concretize na vivência prática da aplicação do direito.

§ 3 Parece poder afirmar-se, com razoável exactidão, que a **evolução** do conceito de inimputabilidade em razão de anomalia psíquica se deixa reduzir a duas fases, prenunciando-se hoje uma terceira e nova via de consideração. Se bem possa dizer-se que a primeira fase se encontra quase por inteiro superada e que a segunda corresponde à concepção ainda hoje dominante, enquanto a terceira mal desponta e a custo se deixa definir, não é no entanto um ponto de vista fundamentalmente histórico, mas **compreensivo**, aquele que guiará as considerações seguintes (1).

1. O paradigma biopsicológico

§ 4 Na primeira fase de evolução do problema, o modelo de racionalidade que preside às ciências do homem (2) é ainda, basicamente, o das **ciências naturais**; um modelo positivista, mecanicista e estritamente causal. É certo que, num primeiro momento, o quadro de pensamento com que as ciências naturais deparavam assentava na distinção entre natureza e pessoa humana, aquela dominável através da observação e da experimentação, esta formando o campo por excelência do imprevisto e da

(1) No essencial, como se segue, DIAS, Figueiredo, O contributo das ciências humanas para a elaboração e aplicação do conceito de responsabilidade penal, *O Direito Penal em Acção numa Sociedade em Evolução, Actas do XXXVII Curso Internacional de Criminologia*, 1989, p. 143, reproduzido com alterações, sob o título Sobre a inimputabilidade jurídico-penal em razão de anomalia psíquica: a caminho de um novo paradigma, *Estudios penales y criminológicos 13*, 1988-9, p. 127, e sob o título Le modèle "compréhensif" de la doctrine du manque d'imputabilité en raison d'anomalie psychique, *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, I, 1991, p. 197.

(2) Sobre a questão do modelo das ciências, cf. SANTOS, Boaventura, Um discurso sobre as Ciências, *Anuário da Universidade de Coimbra*, separata, 1985-6, p. 27 e ss.

variabilidade. Quando, porém, as ciências do homem se constituíram como tais, elas viram nas ciências naturais a concretização de um modelo de conhecimento universalmente válido e, de resto (pensavam), o *único* válido. A psicologia, a psicopatologia, a psiquiatria, a psicanálise e a própria sociologia nasceram e constituíram-se sob a égide do paradigma dominante das ciências naturais e ficaram, durante muito tempo, por completo apegadas aos seus supostos metodológicos.

§ 5 Deste ponto de vista, um relacionamento das ciências humanas com a culpa e a imputabilidade jurídico-penais e uma efectiva contribuição daquelas para estas só se tornariam possíveis se a própria culpa fosse construída dentro de pressupostos metodológicos e epistemológicos — dentro de um modelo de racionalidade — compatíveis com o modelo de que participavam as ciências da natureza. Foi isso o que aconteceu: no domínio do direito penal operou-se a des-normativização dos seus conceitos e a redução naturalista e positivista dos seus conteúdos. E, antes de todos, do conceito de culpa, concebida como relação *psicológica* entre o agente e o seu comportamento que permite imputar-lhe este a título de dolo ou de negligência. Decerto, mesmo nesta concepção não deixava de se considerar a imputabilidade do agente — fundada na exigência de uma certa idade e de um mínimo de saúde mental — como **pressuposto** da afirmação da culpa. Bem se compreende, porém, que fossem então diminutas as exigências postas à afirmação da imputabilidade; e não só diminutas como, sobretudo, assentes num fundamento somático — numa doença **em sentido estrito, permanente, temporária ou intermitente** —, ainda e sempre biopsicologicamente comprovável. Por isso se pode ligar esta concepção àquilo que chamaremos o "paradigma biopsicológico da inimputabilidade". Esta concepção tinha por si o mérito de ser simples e precisa; e mais ainda, de ser redutora ou mesmo eliminadora das tensões entre juristas e peritos das ciências do homem, estabelecendo entre eles uma razoável divisão de trabalho. Em consequência, esta fase viu crescer, enormemente e com rapidez, a soma de conhecimentos sobre o homem necessários às tarefas de aplicação do direito e da administração da justiça penal.

§ 6 Na criação desta espécie de "harmonia universal" jogou antes de mais o seu papel a ideia que se fazia do **sentido e finalidade da pena**, nomeadamente a recusa de considerações retributivas — incompatíveis com o monismo científico-cultural em que toda esta *Weltanschauung* se baseava — e a aceitação, em seu lugar, de puras considerações de *pre-*

venção, observáveis, mensuráveis e, como tal, ainda recondutíveis à única finalidade científica de conhecer a natureza (incluída a natureza humana), para melhor a dominar. Jogou ali o seu papel, em segundo lugar, a circunstância de a concepção que se fazia da culpa não pôr em causa o dogma consubstancial à própria ideia de ciência: o **dogma determinista**, a que inflexivelmente estariam submetidos todos os fenómenos, incluído o da vontade humana. O que fazia com que o problema da imputabilidade do agente sofresse uma nova redução, sendo amputado praticamente da totalidade da temática relacionada com a capacidade da vontade, para quase se esgotar nas questões relacionadas com a capacidade de entender e — quando muito — de avaliar, em suma, com o chamado *momento intelectual* da imputabilidade. Jogou ali o seu papel, finalmente, a circunstância de este modo de consideração do problema se harmonizar inteiramente com a concepção da ciência criminológica nascente. Também esta, como estudo exclusivo das causas do crime, participava do modelo de racionalidade global das ciências e sufragava os cânones positivistas, naturalistas e deterministas do **paradigma etiológico**.

§ 7 Não havia pois, nesta perspectiva, lugar para quaisquer conflitos, positivos ou negativos, de competência entre o aplicador do direito e o perito de ciências humanas a quem fossem postas quaisquer questões juridicamente relevantes: *o que o juiz poderia querer saber era exactamente aquilo para cuja resposta o perito se sentia capacitado*. Saber, nomeadamente, se o agente sofria de uma **doença mental biopsicologicamente comprovável**, fosse permanente, temporária, ou mesmo acidental; e, em caso afirmativo, se o seu grau de gravidade era tal que afectasse as suas **faculdades de entendimento, de discernimento e de avaliação** do facto cometido.

§ 8 Ilustrativos deste modo de consideração do problema eram, a muitos títulos, os arts. 42.º-2 e 43.º-2 e 3 do **CP português de 1886**. Segundo eles, não seriam "susceptíveis de imputação" (*sc.*, seriam inimputáveis) "os loucos que não tiverem intervalos lúcidos"; bem como "os loucos que, embora tenham intervalos lúcidos, praticarem o facto no estado de loucura"; bem como ainda "os que, por qualquer outro motivo, independente da sua vontade, estiverem acidentalmente privados do exercício das suas faculdades intelectuais, no momento de cometerem o facto punível". Sem prejuízo de esforços doutrinários notáveis no sentido de uma interpretação destas prescrições — em combinação com variada legislação complementar, nomeadamente, com as leis de 4-7-1889, de 3-4-1896 e, sobretudo, do DL 26 643 (Reforma Prisional) e com o disposto no CPP de 1929 (art. 125.º e ss.), no CC de 1867 (art. 314.º) e na formulação conferida pela Reforma

de 1954 ao art. 68.º do CP — já nos termos do *paradigma normativo* (3), que em seguida será exposto, os arts. 42.º e 43.º revelam inquestionavelmente as traves mestras do paradigma biopsicológico acabado de caracterizar: determinação da inimputabilidade como um *estado* da pessoa reportado a uma *doença mental* permanente, transitória ou, excepcionalmente, acidental; e redução das doenças relevantes para o efeito às que afectassem as faculdades *intelectuais* do agente.

2. O paradigma normativo

§ 9 O edifício assim construído ruiu no momento em que se compreendeu que a realidade normativa do direito penal se não deixava apreender dentro dos férreos pressupostos do naturalismo de raiz positivista, abrindo-se aquilo que consideramos a segunda fase de evolução do problema. A abertura desta fase é determinada pela substituição das concepções ao nível do direito, enquanto as ciências humanas propriamente ditas, a criminologia inclusive, — pese ao rápido e acentuado progresso que experimentaram — continuaram agarradas ao modelo de racionalidade global atrás referido. O direito passa agora a ser visto como uma **ordem normativa autónoma**, na base de uma axiologia pressuposta que dá fundamento ao seu específico modo de validade (4). Bem se compreende que, deste modo, o próprio fundamento de intervenção do direito penal e de legitimação da pena se modifique, dando lugar ao reaparecimento de considerações absolutas de justiça e de retribuição, ao lado ou mesmo à frente de considerações relativas de prevenção; e que, também em consequência, a uma concepção puramente psicológica da culpa se substitua uma sua concepção *normativa*, que a vê como portadora da censura de um comportamento humano, por o culpado ter actuado contra o dever, quando podia ter actuado "de outra maneira", isto é, de acordo com o dever.

§ 10 As **consequências** para o nosso problema desta modificação da essência da culpa são visíveis. Por um lado, todo o sentido da impu-

(3) Presente já em SANTOS, Beleza dos, A falta de integridade mental e a imputabilidade no direito criminal português. *RLJ 69*, p. 369 e ss., e *70*, p. 3 e ss., e propugnado por CORREIA, Eduardo, I, n.º 75.

(4) Sobre esta concepção do direito, ver NEVES, Castanheira, *Introdução ao Estudo do Direito*, lições copiografadas, 1983, p. 6 e ss., e BRONZE, Pinto, *Lições de Introdução ao Direito*, ²2006, pp. 581 e ss., 607 e ss.

tabilidade se modifica: esta deixa de ser mero pressuposto da atribuição subjectiva e psicológica do facto ao agente, para se tornar *elemento integrante da afirmação da capacidade do agente para se deixar motivar pela norma no momento do facto*. Daí a formulação corrente da imputabilidade — constante, já no essencial, por exemplo, dos códigos penais suíço e italiano, e agora também do alemão, do brasileiro, etc. — como **capacidade do agente, no momento do facto, "para avaliar a ilicitude deste ou para se deixar determinar por essa avaliação"** (art. 20.º-1). O que acarreta uma segunda consequência de não menor relevo: desta forma, o dogma da **culpa da vontade** faz o seu aparecimento na doutrina da culpa jurídico-penal, tanto esta como a imputabilidade se ligando agora indissoluvelmente à questão do livre-arbítrio e da liberdade da vontade humana. Numa palavra, ao anterior paradigma biopsicológico substitui-se o que chamaremos o "paradigma normativo da inimputabilidade".

§ 11 O que isto significa para o relacionamento, nesta matéria, entre direito penal e ciências do homem, entre juiz e perito, é fácil de compreender. Desde logo, e sobretudo, há agora uma questão fulcral — a da **liberdade da vontade** do agente no momento do facto — que o juiz deveria propor ao perito, mas a que este não pode responder sem se arrogar uma competência que não possui. Pois numa conclusão continuam as ciências humanas unânimes, se possível ainda com maior convicção do que no tempo em que Kurt Schneider a formulou: na de que a afirmação ou negação de uma concreta capacidade de escolha do homem em situação é absolutamente inverificável e por ninguém pode ser avançada de modo responsável (5). Acresce que, com este sentido do problema, tem lugar um indiscriminado **alargamento do substrato biopsicológico** da inimputabilidade, o qual passa agora a poder abranger, não apenas a "doença mental" em sentido estrito, mas toda e qualquer "anomalia psíquica": das psicoses à oligofrenia, das psicopatias às perturbações de consciência, das neuroses às personalidades com reacções ou tendências anómalas isoladas. Ao mesmo tempo que se verifica este alargamento tem porém lugar, algo contraditoriamente, uma enorme **desvalorização do elemento biopsicológico** a favor do critério normativo; até ao ponto de poder perguntar-se se há razão para continuar a exigir um qualquer fundamento biopsicológico da imputabilidade, quando esta constitui afinal apenas um

(5) SCHNEIDER, K., *Die Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit*, ³1956.

elemento *não autónomo* da unitária e global capacidade do agente de motivação de acordo com a norma, em que a culpa jurídico-penal se traduz.

§ 12 Em conclusão: o perito das ciências do homem, na primeira fase da evolução, tomava sobre si a generalidade das tarefas do juiz neste campo, até ao ponto de se poder afirmar que se sobrepunha à função judicial e que era a ele que em último termo pertencia a decisão sobre a imputabilidade ou inimputabilidade. O perito passa agora porém a ser, em rigor, um **auxiliar dispensável do juiz**, para quem inclusivamente constituirá por vezes um estorvo. Ele pode, é certo, continuar a responder às questões relacionadas com o fundamento biopsicológico da inimputabilidade, mesmo com a muito maior extensão que este fundamento agora assume. Ao que o perito não pode responder, todavia, nem sequer ajudar a responder, sem cometer um palmar excesso de competência, é ao *fundamento normativo da inimputabilidade*, no fundo do qual se inscreve a indiscernível questão do livre-arbítrio e da liberdade da vontade em situação.

§ 13 O problema em nada se altera ou se simplifica, do ponto de vista do perito das ciências do homem, pela circunstância de, como vimos já (19.º Cap., § 13 e ss.), haver quem defenda que não é verdadeiramente a questão do livre-arbítrio que ali está implicada, antes só um **postulado político-criminal**, tradutor da indiscutível realidade da nossa consciência social e moral de que o agente adulto e medianamente saudável do ponto de vista psíquico é responsável pelos seus actos perante a comunidade. Pois o perito em ciências humanas também nada tem para oferecer ao juiz quando — como aqui então sucederia — se trata da substituição de comprovações reais por categorias estritamente normativas, por uma **adscrição ou uma imputação presumidas** em certas condições.

3. O paradigma "compreensivo"

3.1. Um paradigma emergente sobre o Direito e o Homem

§ 14 A situação que acaba de descrever-se em apertada síntese é ainda hoje **dominante**; mas no domínio do normativo como no do empírico, no direito como nas ciências do homem, muita coisa mudou já ou está em processo acelerado de mutação. Isto permite entrever a abertura de uma **terceira fase** na evolução do nosso tema, que agora procurará caracterizar-se.

§ 15 A autonomia normativa do **direito** não se perdeu nem parece em risco de perder-se no direito penal, se bem tenha de ser conexionada

com a específica função jurídico-penal de tutela subsidiária de bens jurídicos e com a especificidade da pena e da medida de segurança como instrumentos de prevenção. A toda esta luz, já o determinámos, a culpa, axiologicamente fundada no valor da garantia da dignidade da pessoa, deve conservar um elemento ético-pessoal, limitador das exigências que de outros pontos de vista — nomeadamente dos da prevenção — se façam à responsabilidade do agente; e há-de, deste modo, supor a **liberdade do agente**, sem com isto cair de novo na aporia do livre-arbítrio e da liberdade da vontade. Já vimos também (19.º Cap., § 20 e ss.) como é isto possível: colocando e resolvendo a questão da liberdade do homem não no plano das propriedades da acção, mas no plano das características do ser humano como um todo; prosseguindo assim uma linha de especulação filosófica que hoje particularmente se conforta com a viragem do pensamento contemporâneo para a antropologia filosófica e com os mais recentes desenvolvimentos das ciências do homem. Nesta perspectiva, a culpa jurídico-penal surge como o ter que responder pela atitude pessoal, ético-jurídicamente censurável, documentada num facto ilícito-típico e que o fundamenta.

§ 16 Não menos importante porém — e decerto mais radical na transformação — se revela o paradigma emergente nas **ciências do homem**. Ele caracteriza-se essencialmente, no que aqui interessa ([6]): pelo *abandono da concepção mecanicista da matéria* a que aquelas ciências se referem, bem como dos supostos metodológicos positivistas e empiristas do conhecimento do ser humano, da cultura e da sociedade; pela desvalorização do paradigma etiológico e explicativo, agora sempre integrado — e às vezes suplantado — pelo *paradigma compreensivo*; pela recusa — ou ao menos pelo pôr em questão — do dogma determinista e, inversamente, pela aceitação de *elementos de contingência e de indeterminação*; por fim, pela convicção de que todo o conhecimento científico, constituído embora em redor de temas integrantes de um objecto específico, tem como horizonte *o Homem* na sua totalidade e na sua individualidade.

§ 17 Investigações relativamente recentes em domínios diversos — como os da psicologia da vontade ([7]), da psicopatologia ([8]), da psiquiatria ([9]), da biologia ([10]), da

([6]) De novo, sobre este ponto, SANTOS, Boaventura, nota 3.

([7]) RICŒUR, *Philosophie de la volonté*, 1949, e *Méthodes et tâches d'une philosophie de la volonté*, 1952; e KELLER, *Psychologie und Philosophie des Wollens*, 1954, e Menschliche

caracterologia ([11]), da teoria das camadas ([12]), da investigação da personalidade ([13]) — confortam a ideia acima exposta. Logo na análise do concreto humano — seja no seu nível inferior, a partir da análise real dos seus "impulsos" ou "pulsões"; seja no fim da investigação psicofenomenológica da actuação da vontade humana em face dos motivos; seja na consideração global da personalidade como conjunto das camadas caracterológicas e do "princípio pessoal" que as penetra — deparamos com uma "*abertura*" para algo que excede e transcende o complexo "corpo / alma" e representa o espaço onde actua uma categoria nova; uma categoria que apela para um modo característico da realização humana: **a realização pessoal** ou, neste sentido, **pela liberdade**.

3.2. A inimputabilidade como obstáculo à comprovação da culpa

§ 18 Poderia pensar-se que, à luz do conceito de culpa jurídico-penal que propomos, assente numa liberdade concebida como modo-de-ser característico de *todo* o existir humano, o problema da inimputabilidade perderia sentido. Uma vez que a distinção entre a imputabilidade e a inimputabilidade deixaria de poder fazer-se sobre a fronteira hipotética que separaria acções livres de acções não livres; e que (como as mais recentes investigações psicopatológicas, psicanalíticas e psiquiátricas parecem confirmar) no próprio ser psiquicamente enfermo ou anómalo há um "princípio pessoal" que permanece intocado, ou não é ao menos destruído pela anomalia mental — uma e outra coisa pareceriam conduzir à conclusão de que mesmo os doentes mentais mais gravemente afectados continuam "capazes de culpa"! Não é todavia assim. É verdade que a anomalia psíquica não destrói o princípio pessoal e o ser-livre, pois também o ser psiquicamente anómalo ou doente, na sua maneira modificada, se realiza a si mesmo. Mas, ao menos nas suas formas mais graves, **a anomalia psíquica**

Existenz, Willensfreiheit und Schuld, *in*: Frey (org.), *Schuld — Verantwortung — Strafe*, 1964, p. 201.

([8]) BINSWANGER, *Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins*, [4]1964; e, já antes, JASPERS, *Psychopathologie générale* (trad. francesa de Kastler-Mendousse, 1933).

([9]) FRANKL, *Der unbedingte Mensch*, 1949 (tradução portuguesa de Guilherme de Oliveira, com o título *O Homem Incondicionado. Lições Metaclínicas*, 1968).

([10]) PORTMANN, *Zoologie und das neue Bild des Menschens*, 1956; e, no domínio específico da neurobiologia, POPPER / ECCLES, *The Self and its brain*, 1977.

([11]) KLAGES, *Los fundamentos de la caraterologia*, tradução argentina, 1959.

([12]) LERSCH, *Aufbau der Person*, [8]1962; ROTHAKER, *Camadas Constitutivas da Personalidade*, tradução portuguesa de A. Brandão, 1946; de modo mais restritivo, THOMAE, Verantwortungsreife und strafrechtliche Verantwortlichkeit in psychologischer Sicht, *Berliner Universitätstage*, 1964, p. 104.

([13]) Por exemplo, STAVENHAGEN, *Person und Persönlichkeit*, 1957.

destrói as conexões reais e objectivas de sentido da actuação do agente, de tal modo que os actos deste podem porventura ser "explicados", mas não podem ser "compreendidos" como factos de uma pessoa ou de uma personalidade. Ora, a comprovação da culpa jurídico-penal supõe justamente um acto de "comunicação pessoal" e, portanto, de "compreensão" da pessoa ou da personalidade do agente. Por isso o juízo de culpa jurídico-penal não poderá efectivar-se quando a anomalia mental **oculte** a personalidade do agente, impedindo que ela se ofereça à contemplação compreensiva do juiz. É a isto que, no fundo, chamamos inimputabilidade; e é para traduzir a ideia aqui contida que se falará do "paradigma compreensivo da inimputabilidade" ([14]).

§ 19 Era praticamente inevitável que uma concepção como esta se visse acusada de soçobrar perante a "contradição" ([15]) que residiria em considerar inimputável o doente mental, sob certas condições e circunstâncias, mas já ter por imputável, por exemplo, o agente onerado com uma pesada tendência para o crime, por um deficiente desenvolvimento espiritual ou moral, ou mesmo por um estado de afecto derivado de uma situação conflitual duradoura. A esta objecção temos respondido, seguindo a lição de Max Scheler, que importa salvaguardar a distinção (eticamente fundada!) entre o eticamente censurável e o psiquicamente anómalo, abandonando o âmbito de uma ética psicologista para a qual só é mau aquilo que o agente fez de mal quando "podia", do ponto de vista da vontade psicológica, agir de outra maneira ([16]). O que deste argumento resulta, a um nível jurídico-dogmático de compreensão, é que, se bem que não haja

---

([14]) Esta concepção aproxima-se da que já em seu tempo foi sugerida por juristas como MAYER, M. E., *AT, Lehrbuch*, ²1923, p. 206 e ss., e MEZGER, *Kriminalpolitische Probleme im Strafrecht*, 1943, p. 51, *Probleme der strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit*, 1949, p. 47 e ss., e *Das Verstehen als Grundlage der Zurechnung*, 1951, p. 7 e ss.; e por psicopatologistas, psicólogos e psiquiatras como BINSWANGER, nota 8, KELLER, nota 7, HADDENBROCK, Die juristisch-psychiatrische Kompetenzgrenze bei der Beurteilung des Zurechnungsfähigkeit im Lichte der neueren Rechtsprechung, *ZStW 75*, 1963, p. 460 e ss., e FRANKL, nota 9; ou ainda como LUTHE, *Verantwortlichkeit, Persönlichkeit und Erleben*, 1981, e WITTER, Wissen und Werten bei der Beurteilung der strafrechtlichen Schuldfähigkeit, *Leferenz-FS*, 1983, p. 441.

([15]) Que — como noutro lugar pusemos em relevo: *Liberdade*, p. 219 — já ENGISCH, Bietet die Entwicklung..., *ZStW 66*, 1954, p. 363, considerou resignadamente "uma contradição radicada mesmo no fenómeno ético" e que por isso teria de ser suportada também no âmbito jurídico-penal.

([16]) SCHELER, MAX, *Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik: einer Versuch der Grundlegung eines ethischen personalismus*, ⁴1954, p. 490 e ss.

óbice a que a inimputabilidade seja contabilizada entre as causas de exclusão da culpa, todavia ela surge materialmente numa vertente diversa daquela em que se inscrevem a inexigibilidade (infra, 22.º Cap.) e a falta de consciência do ilícito não censurável (infra, 23.º Cap.): a inimputabilidade constitui, *mais* que uma causa de exclusão, verdadeiramente um **obstáculo à determinação da culpa** (de outra perspectiva podendo também então dizer-se que a imputabilidade constitui um *pressuposto* da comprovação da culpa). Tudo isto, em definitivo, porque o substrato biopsicológico da inimputabilidade, aliado a um certo efeito sobre a personalidade do agente, destrói as conexões reais e objectivas de sentido que ligam o facto à pessoa do agente, a tal ponto que o seu acto pode ser (causalmente) "explicado", mas não pode ser "compreendido" como "facto de uma pessoa".

§ 20 Roxin vem criticando a nossa concepção sob um duplo ponto de vista: o de que, por um lado, a **comunicação** entre juiz e arguido só muito dificilmente terá lugar no processo penal, tanto mais que o arguido tem direito ao silêncio; e, por outro lado, o de que a possibilidade daquela comunicação não está excluída quando a anomalia psíquica se não fundamente na falta de sentido objectivo do facto, mas sim na **falta de inibições** ([17]). E agora, no seu *Strafrecht*, insiste na crítica nos termos seguintes: "Tão-pouco poderá dizer-se em todos os casos de inimputabilidade que a personalidade do sujeito é completamente inacessível à compreensão do juiz. No caso de jovens inimputáveis é perfeitamente possível uma comunicação pessoal, que aliás também pode ter lugar em casos de adultos inimputáveis, quando o defeito não conduz à falta de sentido ou à impossibilidade de compreensão objectivas do facto, mas tem antes o seu fundamento na falta da capacidade de inibições" ([18]).

§ 21 Não nos parece que esta crítica proceda ([19]). Desde logo, é a **categoria normativa** (não necessariamente naturalística ou natural) da **incompreensibilidade do facto como facto do agente**, traduzida na impos-

([17]) ROXIN, Acerca da problemática do direito penal da culpa, *BFD LIX*, 1983, p. 15 e s.

([18]) ROXIN I, § 19, n.º 32; segue-o ROSA, Cortes, Die Funktion der Abgrenzung von Unrecht und Schuld im Strafrechtssystem, *Coimbra-Symposium Roxin*, p. 183.

([19]) Uma exacta exposição do essencial da controvérsia encontra-se agora em NEVES, Curado, *A Problemática da Culpa nos Crimes Passionais*, 2006, p. 437 e s., que acaba por opinar — com razão — no sentido de ser estranha ao nosso pensamento a ideia de que a afirmação da imputabilidade exige a possibilidade de "um diálogo efectivo a estabelecer no decorrer da audiência, como foi erroneamente suposto por Roxin".

sibilidade de apreensão das conexões *reais* e *objectivas* de sentido que ligam o facto à pessoa, que constitui, na perspectiva aqui defendida, o verdadeiro critério da inimputabilidade. É esta categoria, e não, imediata e propriamente, o "acto de comunicação" a levar a cabo pelo juiz, o qual constitui só o reflexo jurídico-processual do problema: aquela incompreensibilidade impede em definitivo a qualificação do facto como culposo, sobretudo à luz de uma culpa como um ter que responder pela atitude interna censurável (e pelas respectivas qualidades jurídico-penalmente desvaliosas da personalidade) que no facto se *exprimem* e o *fundamentam*. O acto de "**comunicação pessoal**" entre o juiz e o arguido não se esgota na audiência ou num interrogatório, ou não tem mesmo que processar-se através da fala. Aquele acto possui uma natureza bem mais complexa, estende-se ao longo de todo o processo e das suas manifestações e realiza-se através de todas as formas possíveis de comunicação, nas quais o papel do perito de ciências humanas será precioso e insubstituível ([20]). Acto comunicativo, de resto ([21]), susceptível de assumir "objectividade contextual" em todos os processos penais relativos a imputáveis; pensar que ele radicaria sempre na subjectividade do juiz significaria confessar que teria de renunciar-se a toda a pretensão de objectividade em qualquer decisão penal.

§ 22 Ao que acresce — em nosso entendimento, com importância decisiva — que quando aqui falamos da "**compreensão**" do facto criminoso temos em vista exactamente a possibilidade para o juiz não tanto de revivenciar subjectivamente o facto do agente, mas de **reconstruir objectivamente as conexões de sentido do facto, os nexos que conduziram à transposição de um fenómeno psíquico em um contexto de sentido real**. Quanto, por conseguinte, aos factos que têm na sua base um estado duradoiro de afecto, ainda que depois venham a ter lugar por força (para usar uma expressão tão cara à doutrina estadunidense da inimputabilidade e tão divulgada entre os leigos) de um "impulso irresistível" — e que, nesta acepção, podem na verdade ser imputados a uma "falta de inibi-

([20]) Sobre este problema das "estruturas de comunicação processual", DIAS, Figueiredo, Para uma reforma global do processo penal português — da sua necessidade e de algumas orientações fundamentais, *in*: AA.VV., *Para uma Nova Justiça Penal*, 1983, p. 219 e s.

([21]) Cf., embora em contextos diferentes, também, COSTA, Faria, *O Perigo em Direito Penal*, 1992, p. 480 e ss., e DIAS, Silva, *"Delicta in se" e "delicta mere prohibita": uma Análise das Descontinuidades do Ilícito Penal Moderno à Luz da Reconstrução de uma Distinção Clássica*, 2003, pp. 337 e ss., 595 e ss.

ções" —, uma de duas: ou o estado de afecto se liga a uma anomalia psíquica determinante da inimputabilidade, e então é a anomalia psíquica, não o estado de afecto e a consequente falta de inibições, que obsta à comprovação da culpa; ou não se liga, e então a exclusão da culpa não pode ocorrer por via da inimputabilidade, mas só (eventualmente) pela da inexigibilidade ([22]).

§ 23 A controvérsia que entre nós e Roxin se estabeleceu a propósito da inimputabilidade jurídico-penal (como, de resto, a outros propósitos atinentes à doutrina da culpa) constitui, na verdade, expressão de "uma divergência mais funda" quanto à **estrutura** e ao **conteúdo material do conceito de culpa** ([23]). Encontramo-nos completamente com Roxin no que respeita à *função* do conceito de culpa no sistema jurídico-penal: uma função de limitação do intervencionismo estatal na vida do agente e de veto a uma sua eventual arbitrariedade. Mas esta função, só pode, a nossos olhos, o conceito exercê-la se a ele se ligar um conteúdo ético-pessoal determinado: determinado, por uma parte, pelas exigências do dever-ser às quais a pessoa tem de responder em sociedade (e por aqui, decerto, por exigências de "prevenção"); mas determinado, por outra parte, não por uma qualquer "permeabilidade do agente ao apelo normativo", antes por uma "ética de responsabilidade" que conduz o agente a ter que responder socialmente por aquilo que faz, na base daquilo que "é".

§ 24 Após uma exposição da nossa concepção da inimputabilidade jurídico-penal, e revelando uma larga compreensão dela (de que atrás ficou já testemunho), afirma Curado Neves que a inimputabilidade "impede o agente de assumir responsabilidades sociais, na medida em que este estado se exprima em **actos que não possam ser inseridos num contexto de vida social com sentido**. Esta ideia é claramente apresentada na noção de incompetência para pôr em causa a vigência das normas, cunhada por Jakobs". E conclui: "O conceito de inimputabilidade aqui adoptado não se afasta significativamente, parece-me, do conceito defendido por Figueiredo Dias" ([24]).

3.3. Consequências do ponto de vista expendido

§ 25 Impõe-se considerar, finalmente, que o ponto de vista expendido abre caminho a um novo e extenso campo de entendimento entre juristas e cientistas do

---

([22]) Assunção, esta, para a qual julgaríamos poder contar com a concordância do próprio ROXIN, atentas as considerações que, num contexto de certo modo análogo àquele agora em consideração, avançou no seu estudo Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit im Strafrecht, *Bockelmann-FS*, 1979, pp. 249 e s., 316 (tradução espanhola de Muñoz Conde, na colectânea *Culpabilidad y prevención en derecho penal*, 1981, p. 147). Sobre o ponto, aprofundadamente, NEVES, Curado, nota 19, p. 649 e ss.

([23]) Anotou-o certeiramente o próprio ROXIN, nota 17, p. 14.

([24]) NEVES, Curado, nota 19, p. 500 e s.

homem, entre juiz e peritos a propósito do tema em análise. Apontar-se-ão, em jeito conclusivo, as consequências mais importantes que parecem resultar daquele ponto de vista.

§ 26 (1) No paradigma compreensivo, o tradicionalmente chamado **substrato "biopsicológico" da inimputabilidade** ganha de novo sentido e significado precisos, ao contrário do que sucedia no paradigma normativo. Só a anomalia psíquica, a "enfermidade mental" no seu mais amplo sentido — e não também, *v. g.*, a "tendência" para o crime, a herança caracterológica ou o condicionalismo do "meio" — é susceptível de destruir a conexão objectiva de sentido da actuação do agente e, portanto, a possibilidade de "compreensão" da sua personalidade manifestada no facto. Na caracterização deste substrato biopsicológico, da sua gravidade e intensidade, a primeira e mais importante palavra pertence aos *peritos das ciências do homem*, sendo aí diminuta, para não dizer nula, a capacidade de crítica material por parte do juiz.

§ 27 (2) O caminho proposto confere ainda, todavia, um conteúdo válido ao chamado **elemento "normativo" da imputabilidade**: à capacidade do agente, em muitas legislações expressamente requerida, "de avaliar a ilicitude do facto ou de se determinar de acordo com essa avaliação"; e revela-se, deste modo, capaz de ser arvorado em critério interpretativo do disposto na 2.ª parte do art. 20.º-1 (infra, § 37 e ss.). Com efeito, também do ponto de vista do paradigma compreensivo não basta nunca a comprovação do fundamento biopsicológico, da existência no agente de uma anomalia psíquica, por mais grave que ela se apresente. É ainda e sempre necessário determinar se aquela anomalia é uma tal que torne impossível o juízo judicial de compreensão, de apreensão da conexão objectiva de sentido entre a pessoa e o seu facto; que o torne impossível ou, ao menos, altamente duvidoso (deparando-nos neste último caso com a verdadeira essência das hipóteses tradicionalmente chamadas de *imputabilidade diminuída*: infra, § 44 e ss). Naquela **compreensibilidade** se traduz o elemento normativo que acresce à base biopsicológica e que, deste modo, nada tem a ver com as questões irrespondíveis do livre-arbítrio ou da liberdade da vontade. Com o que fica afastado o principal óbice que ainda hoje se suscita a uma estreita e frutuosa colaboração do perito com o juiz. À luz do paradigma emergente nas ciências do homem, a distinção entre modos de actuação "compreensíveis segundo o sentido" e modos de actuação só "causalmente explicáveis" é cientificamente aceitável e

dominável pelos peritos. Por isso deve esperar-se destes um auxílio decisivo para o juiz também quanto à comprovação do elemento normativo: aqui, porém, a última palavra pertencerá sempre ao juiz e a sua capacidade de crítica material será irrestrita, nesta parte e medida continuando a caber-lhe com justeza o cognome de *peritus peritorum*.

§ 28 (3) O caminho preconizado põe novas e acrescidas exigências à consideração do problema da imputabilidade ao nível do **processo penal**. O tratamento do problema, ainda usual em muitas legislações, nos quadros acanhados de um "incidente processual de alienação mental" seria profundamente desaconselhável: porque assim se cinde completamente a anomalia mental do facto praticado, o qual acaba por não ser processualmente averiguado, ou por o ser só de modo insuficiente. Merece por isso aplauso uma solução como a preconizada a propósito pelo CPP (art. 1.º-1/*a*), segundo a qual a questão da inimputabilidade do agente, seja qual for a extensão e gravidade da anomalia psíquica que o afecte, é tratada sempre *nos quadros e com a totalidade dos meios de investigação e discussão do processo penal comum* (25). Por outro lado, o caminho proposto requer com insistência a consagração, ao nível do processo penal, da *perícia colegial* e da *perícia interdisciplinar*.

II. Elementos

1. A conexão biopsicológica

§ 29 Nos termos do art. 20.º-1 é requisito da inimputabilidade, antes de mais, que o agente sofra de uma **anomalia psíquica**. Com isto quis o direito vigente alargar (supra, § 11), relativamente ao que sucedia no direito anterior, o substrato biopsicológico da inimputabilidade. Afastando-o, nomeadamente, das controvérsias de índole médico-científica acerca do conceito de *doença mental* — permanente, transitória, ou mesmo acidental — a que se foi reduzindo a falta da "necessária inteligência e liberdade" que o art. 20.º do CP de 1852 e o art. 26.º do CP de 1886 consideravam pressuposto da responsabilidade criminal; e que conduziria à sua negação nas hipóteses referidas supra, § 8, e contempladas nos arts. 42.º e 43.º do CP de 1886 (cf., também, o art. 23.º-1 do CP de 1852) (26). Propósito do novo teor legal foi evitar

(25) No contexto das discussões sobre a reforma do processo penal português, cf. DIAS, Figueiredo, nota 20, p. 216.

(26) Sobre a história legislativa do problema nesta fase, ANTUNES, Maria João, *Medida de Segurança de Internamento e Facto de Inimputável em Razão de Anomalia Psíquica*, 2001, p. 140 e ss.

a redução do substrato biopsicológico da inimputabilidade àqueles casos em que se verificam transtornos devidos a causas orgânico-corporais ([27]), como àqueles que se manifestam no âmbito intelectual (capacidade de entendimento ou de avaliação), como àqueles que se traduzam em alterações da "actividade mental", como àqueles que porventura mereçam ainda, do ponto de vista médico-científico, o nome de "doenças"; passando a compreender todo e qualquer transtorno ocorrido ao inteiro nível do psíquico, adquirido ou congénito. Mais concretamente, o conceito abarca uma série de anomalias que podem categorizar-se, de acordo com os fundamentos psiquiátricos respectivos, da forma que em seguida se expõe ([28]).

1.1. As psicoses

§ 30 De um ponto de vista jurídico-penal a categoria mais indiscutível que reentra na conexão em análise continua a ser a das *psicoses*. E no entanto, também no seio da ciência psiquiátrica se não depara com unanimidade quanto à sua definição. Na concepção tradicional, a psicose devia traduzir-se em um **defeito ou processo corporal ou orgânico** ([29]), *somaticamente comprovável* caso se tratasse de uma psicose *exógena* (*sc.*, determinada por circunstâncias que provêm do exterior, como as psicoses traumáticas), somente *postulado* ou suposto em caso de psicose *endógena* (por isso mesmo também chamada *funcional*), de que constitui exemplo paradigmático a esquizofrenia. A mais recente ciência psiquiátrica tende no entanto a reconduzir as psicoses endógenas não mais (ou não só) a processos orgânico-corporais, mas a **factores humanos-vitais** no seu mais lato sentido (sociais, familiares, etc.). Com o que fica posta em causa a delimitação tradicional com as neuroses, essas sim, desde há muito entendidas como processos condicionados pelas condições de vida. Por isso, tam-

---

([27]) Redução ainda claramente presente num dos autores que primeiramente e de modo mais exacto logrou a compreensão exacta do fundamento da inimputabilidade: MEZGER, *Probleme* nota 14, pp. 6, 39, 50 e s., e *Das Verstehen* nota 14, *passim*, especialmente p. 24 e ss. Uma boa e clara exposição das classificações que se seguem e do estado médico do problema pouco antes do CP de 1982 pode encontrar-se em POLÓNIO, Pedro, *Psiquiatria. Medicina da Pessoa*, 1978. Recusando a redução do substrato biopsicológico, e enquadrando por isso o art. 20.º no "modelo lato de inimputabilidade", ALMEIDA, Carlota Pizarro de, *Modelos de Inimputabilidade. Da Teoria à Prática*, 2000, p. 84 e ss.

([28]) Uma extensa e aturada análise dos conceitos de anomalia psíquica e de doença mental — para concluir, no essencial, no sentido do texto — em NEVES, Curado, nota 19, p. 169 e ss.

([29]) CORREIA, Eduardo, I, n.º 73.

bém para as psicoses ganha significado decisivo, antes que a verificação ou suposição de um processo orgânico-corporal, a sua *sintomatologia*.

§ 31 Como **psicoses exógenas** são hoje as mais das vezes consideradas, para além da paralisia cerebral, os delírios escleróticos (se bem que nem toda a demência senil como tal), as psicoses de privação (*delirium tremens*), as intoxicações de toda a espécie (nomeadamente, hoje, as condicionadas por substâncias psicotrópicas), na medida em que elas determinam perturbações graves da consciência, e os estados psicóticos condicionados por tumores, processos meníngicos ou metabólicos ou lesões cerebrais. Nas **psicoses endógenas** conta-se a já mencionada esquizofrenia (nas suas diversificadas formas de aparecimento), mas também algumas espécies de perturbações afectivas graves, como será o caso da chamada "loucura maníaco-depressiva", "ciclotimia" ou "doença bipolar". Quanto à epilepsia, ela não tem sem mais de ser contada entre as psicoses, se bem que algumas das suas formas possam conduzir a estados psicóticos.

1.2. A oligofrenia

§ 32 Trata-se na oligofrenia de casos de **fraqueza intelectual** congénita ou sem causa orgânica demonstrável, ou que são consequência de lesões cerebrais intra-uterinas ou de lesões traumáticas durante o parto ou na primeira infância. Também aqui não importa determinar, para efeitos de inimputabilidade, se a deficiência pode ainda imputar-se ou não a uma patologia corporalmente comprovável. Mais convém distinguir os três graus de oligofrenia que a propósito costumam estabelecer-se: o grau mais profundo, o da **idiotia**, próprio dos indivíduos que não atingem o desenvolvimento mental de uma criança de seis anos, aos quais falta por vezes a própria capacidade de se exprimir e que exigem uma vigilância e um auxílio permanentes; o grau médio, o da **imbecilidade**, próprio de quem não atinge o desenvolvimento mental próprio do início da puberdade e que por isso necessita igualmente de apertada vigilância e ajuda familiar e/ou institucional; e o grau mais leve, o da **debilidade mental**, próprio dos indivíduos com dificuldades muito profundas de aprendizagem, a exigirem estudos escolares especiais que lhes permitam o exercício de uma profissão ou de uma actividade muito simples.

1.3. As psicopatias, as neuroses e as anomalias sexuais

§ 33 Incluem-se nesta categoria todos os desvios de natureza psíquica relativamente ao "normal" que se não baseiem em uma "doença" ou "enfermidade corpórea". Neste contexto podem começar por contar-se as

psicopatias, entendendo-se por tal peculiaridades do carácter *devidas à própria disposição natural* e que afectam, de forma sensível, a capacidade de levar uma vida social ou de comunicação normal. Por **neuroses** entendem-se as anomalias de comportamento adquiridas, que se apresentam como reacções anómalas episódicas e são, as mais das vezes, susceptíveis de tratamento. Às **anomalias do instinto sexual** pertencem, por sua vez, tanto os ditos "desvios sexuais", como o grau anormalmente elevado (hipersexualidade) ou diminuído (hipo-sexualidade) da actividade sexual. No campo médico como no jurídico, porém, a relativa autonomia de que gozaram outrora as três categorias mencionadas tende a esfumar-se e a não caberem a nenhuma delas contornos definidos; nomeadamente, a distinção entre psicopatias (na psiquiatria tradicional uma categoria fundamental e que jurídico-penalmente assumia interesse decisivo para os problemas da imputabilidade diminuída) e neuroses tornou-se em mera questão teorético-doutrinal praticamente destituída de relevo prático. O único denominador comum entre elas é, na verdade, eminentemente negativo, residindo em que se trata ali de perturbações da personalidade ou de desvios ou anomalias do comportamento social, nomeadamente sexual, que não têm nenhum fundamento orgânico-corporal — e se encontram por isso completamente fora dos conceitos de "doença" ou "enfermidade" —, mas surgem exclusivamente como acontecimentos *psíquicos*.

§ 34 Dada a enorme extensão deste campo e a circunstância de o que é ou não "normal" — mesmo num campo como o da ciência médica — se ter tornado nos nossos dias cada vez mais questionável, compreende-se que tenha de ser feita uma **fortíssima restrição** à área que resultaria das definições iniciais para que possa deparar-se aqui ainda com uma conexão biopsicológica da inimputabilidade jurídico-penal. Essa restrição é (hoje consensualmente) levada a cabo através da ideia de que tem de tratar-se de um desvio ou um distúrbio **graves** ou mesmo **muito graves**, mais concretamente, dotados de uma gravidade que os equipare, nos seus efeitos sobre o decurso da vida psíquica, a verdadeiras psicoses.

1.4. As perturbações profundas da consciência

§ 35 Trata-se aqui de estados anómalos, sejam de longa ou de curta duração, durante os quais se encontram **profundamente** perturbadas as relações entre a consciência de si mesmo e a do mundo exterior ou, em todo o caso, a "estrutura psíquica" do agente. Na medida em que tais pertur-

bações possam considerar-se de natureza *patológica*, elas cabem inteiramente — ao menos para os propósitos aqui em vista — na categoria das psicoses, como acontecerá com as intoxicações completas de toda a espécie ou com os delírios febris. Para uma categoria autónoma restam assim os casos de **perturbações não patológicas** — que não implicam qualquer doença ou enfermidade —, mas são de natureza *fisiológica* ou *psicológica* (p. ex., casos extremos de fadiga, de esgotamento ou de sono, hipnose e estados intensos de afecto) ([30]).

§ 36 São estes últimos — os **estados de afecto** ou **estados passionais** — que mais têm ocupado a recente literatura jurídico-penal. Reconhecia-se amplamente que também o afecto não acompanhado de um colapso (como é o caso de estados de embriaguez, de hipnose ou de febre), mas, digamos assim, com motivação psicológica normal (paixão, ciúme, etc.) podem constituir, **em casos de particular intensidade** (uma vez mais: substancialmente análogos, para os efeitos aqui em causa, aos estados patológicos), substrato psicológico idóneo de um juízo de inimputabilidade ([31]). Mas a doutrina e a jurisprudência alemãs mais recentes duvidam que assim deva ser sempre, sob pena de uma parte substancial de crimes dolosos graves, nomeadamente homicídios e ofensas corporais graves (correspondente, no essencial, à antiga categoria dos *crimes passionais*), poder conduzir a absolvições injustificadas ([32]). Por isso tendem a considerar que tal sucederá apenas naqueles casos de afecto não antecipadamente culposo ou provocado, ligando deste modo o problema, em certa medida, ao da *actio libera in causa* (infra, § 52 e ss.). Se isto não é, em princípio e em si mesmo, impossível ([33]), convém assentar desde já em alguns pontos: o de que, a este propósito como a qualquer outro, não pode manipular-se o princípio da culpa invocando unicamente razões, autênticas ou supostas, de natureza político-criminal, sem do mesmo passo operar as mudanças necessárias a nível dogmático ([34]); o de que as grandes dificuldades aqui sentidas pela opinião dominante provêm de uma interpretação da conexão normativa da imputabilidade em função da capacidade de determinação pela norma ou o dever ("poder de agir de outra maneira": infra, § 37); por último, que muitos casos de acções levadas a cabo em estado de afecto podem encontrar uma solução no sentido da exclusão (ou da atenuação) da culpa em nome da inexigibilidade, nomeadamente do estado de necessidade desculpante (infra, 22.º Cap., § 14) ([35]). Curado Neves, na

---

([30]) Doutrina hoje dominante na Alemanha: ROXIN I, § 20, n.º 21, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 10, n.º 32.

([31]) Monograficamente, KRÜMPELMANN, *Affekt und Schuldfähigkeit*, 1988.

([32]) KRÜMPELMANN, Die Neugestaltung der Vorschriften über die Schuldfähigkeit durch das zweite Strafrechtsreformgesetz von 4. Juli 1969, *ZStW 88*, 1976, p. 26.

([33]) ROXIN I, § 20, n.º 18 e ss. Criticamente, NEVES, Curado, nota 19, p. 650 e ss.

([34]) Ao que parece disposto STRATENWERTH / KUHLEN, § 10, n.º 31.

([35]) Assim, também, na base da sua particular concepção (preventiva) da culpa, JAKOBS, 18/14, 17 e s.

sua monografia, já várias vezes referida, sobre o tema da culpa nos crimes passionais, prosseguindo a via por último assinalada, é mais radical na sua conclusão: "os estados passionais não são fenómenos psicopatológicos, pelo que não podem ser reconduzidos ao conceito de anomalia psíquica contido no art. 20.º (...). Não há portanto qualquer razão para falar de inimputabilidade a este respeito". O que todavia, em sua opinião, não exclui em definitivo que, em certos casos excepcionais, o estado passional não possa funcionar, pela via da inexigibilidade, nomeadamente quando a ele se ligue a "emoção violenta" referida no art. 133.º, como causa de *atenuação* da culpa (36).

2. A conexão normativo-compreensiva

§ 37 O segundo requisito de que o art. 20.º-1 faz depender o juízo de inimputabilidade é o de que, por força da anomalia psíquica, **o agente, no momento da prática do facto, seja incapaz de avaliar a ilicitude deste ou de se determinar de acordo com essa avaliação**. Já supra, § 9 e ss., ficou dito o suficiente para dar a entender que a exigência de avaliação normativa aqui contida não pode ser entendida como se estivesse em causa saber se o agente, no momento do facto, detinha a capacidade de entendimento e de vontade necessárias a uma correcta determinação pela norma, à permeabilidade ao apelo normativo, se detinha, em suma, a capacidade de agir de outra maneira, concretamente, de acordo com a norma. Sobre isso já não será necessária uma palavra mais (37). Claro que sempre se repete não ser a questão do livre-arbítrio aquela com que aqui se depara (38). Deste modo, porém, é a própria fórmula legal que perde todo o seu sentido e a sua compreensibilidade. Alega-se que do que verdadeiramente se trata é de uma comparação normativa entre o agir modificado do psiquicamente anómalo e o que poderia esperar-se do homem normal que tem de responder socialmente pelo ilícito praticado. Mas ao afirmá-lo está-se precisamente a aproximar a fórmula legal em exame daquele que consideramos o verdadeiro fundamento da inimputabilidade.

§ 38 O que agora importa saber é pois como pode aquela formulação legal ser reconduzida à **destruição pela anomalia psíquica das cone-**

(36) NEVES, Curado, nota 19, p. 649 (onde pertence a citação) e ss.

(37) Cf., em todo o caso, se bem que de um ponto de vista diverso do do texto, a crítica cerrada de FRISTER, *Die Struktur des "voluntativen Schuldelements"*, 1993, pp. 103 e ss., 166 e ss., à referida fórmula.

(38) Por último, e por outros, ROXIN I, § 20, n.º 28.

xões reais e objectivas de sentido entre o agente e o facto, de tal modo e em tal grau que torne impossível a compreensão do facto como facto do agente. Anomalias psíquicas existem por força das quais — mais pela sua gravidade do que pela sua origem — "o agente se torna em objecto passivo de processos funcionais" (39). Ora, nem todo o processo psíquico motivador do facto é objectivamente compreensível segundo o sentido, não permitindo nessa medida uma conclusão sobre a culpa do agente. Na palavra tão antiga quanto exacta de M. E. Mayer — descontada a conotação subjectiva que atribui ao acto de compreensão (40) —, "aquilo que eu não posso avaliar também não devo julgar" (41). Nem todos os processos psíquicos se deixam concluir, segundo o sentido, a partir da vida anímica: a "continuidade" do anímico, a sua tradução no facto, pode ser impedida ou destruída por processos biopsicológicos (incluídos os da profundidade e do próprio inconsciente) estranhos aos sentidos, como bem o revelam muitíssimos casos que incluímos nas perturbações profundas da consciência. É precisamente nestes casos (e só neles) que o agente deve ser considerado incapaz de avaliar a ilicitude do facto ou de se determinar de acordo com essa avaliação. O que é de resto confirmado pela circunstância de hoje se reconhecer que os dois braços da alternativa — avaliação *versus* determinação — não são susceptíveis de distinção precisa nem a nível médico-psiquiátrico, nem a nível normativo, antes inevitavelmente as mais das vezes se entrecruzam de forma inextricável. Faz-se então apelo, as mais das vezes, a uma unitária e global (in)capacidade de controlo (42), que outra coisa não é senão uma tentativa de racionalização de uma impossibilidade de compreensão das conexões objectivas de sentido que ligam o processo anímico do agente ao facto praticado. O que o perito e o juiz têm pois de fazer — e não no sentido da "repartição de tarefas" que presidia à concepção puramente normativa da inimputabilidade, em que ao perito competia pronunciar-se sobre o substrato biopsicológico e ao juiz sobre o efeito normativo, mas no de uma "tarefa cooperativa" em que a última palavra pertence sempre ao juiz — é tentar uma espécie de racionalização retrospectiva de um processo psiquicamente anómalo. Se a tentativa é lograda o agente deve, apesar da anomalia psíquica de que eventualmente sofra, da

(39) Como bem formula JAKOBS, 18/14.

(40) E que mereceu por isso mesmo a acerba crítica de MEZGER, *Das Verstehen* nota 14, pp. 5-9.

(41) MAYER, M. E., p. 205 e ss.

(42) Neste sentido, ROXIN I, § 20, n.º 29.

sua origem e da sua gravidade ([43]), ser considerado imputável. Se a tentativa falhar o agente deve ser considerado inimputável.

3. A conexão fáctica (típica)

§ 39 Como vimos, o art. 20.º-1 impõe que a anomalia psíquica como substrato biopsicológico do juízo de inimputabilidade se verifique **no momento da prática do facto**. Trata-se aqui de uma conexão importantíssima na fundamentação do juízo de inimputabilidade, até há pouco (e mesmo ainda hoje) subavaliada, se não quantas vezes mesmo menosprezada. Ela possui uma dupla vertente, a primeira, que logo corresponde ao seu teor literal e que poderemos chamar a *conexão temporal*, outra — a muitos títulos mais importante e hoje decisiva —, que poderemos, ver-se-á porquê e em que sentido, denominar *conexão típica*.

§ 40 A **conexão temporal** traduz-se em que o fundamento biopsicológico da inimputabilidade tem de verificar-se no (e portanto de relacionar-se temporalmente com o) **momento da prática do facto**. Esta exigência, por evidente que se antolhe face ao princípio da culpa, representou um verdadeiro "ponto de viragem" (em muitas doutrinas e jurisprudências afirmado, mas ainda não completamente assimilado) na doutrina da inimputabilidade: esta deixou de ser um *estado* — constante, duradoiro, temporário, acidental — para passar a ser uma *característica do concreto facto de um agente*. Inimputável deixou de ser o louco, o doido, o doente mental, o "tolo", para passar a ser a pessoa que, no momento da prática de um certo facto, se encontra onerada com um substrato biopsicológico que se traduz no concreto facto praticado e o colora com um certo efeito normativo. A partir daqui — e *só* a partir daqui — se pode relacionar sem contradições o juízo de inimputabilidade com o juízo de culpa ([44]).

§ 41 A conexão em análise possui porém ainda um outro sentido ou vertente: a de que não basta ao juízo de inimputabilidade um determi-

---

([43]) Sabe-se hoje, com efeito, que mesmo num processo psicótico (p. ex. uma esquizofrenia, uma ciclotimia ou mesmo uma paralisia cerebral) âmbitos mais ou menos latos do estado anímico permanecem essencialmente intocados e o facto praticado pode ser por isso, na acepção que defendemos, "compreensível". Neste sentido, já, de resto, MEZGER, *Das Verstehen*, nota 14, p. 27.

([44]) Muito rigorosamente sobre esta conexão, na vertente histórica e dogmática, ANTUNES, Maria João, nota 26, p. 421 e ss., e *passim*. Em síntese, mas no mesmo sentido, MARINUCCI / DOLCINI, *Diritto Penale*, VIII, 8, 1.1.

nado substrato biopsicológico determinante de um certo efeito normativo geral, mas é indispensável que a anomalia psíquica se tenha **exprimido num concreto facto típico e o fundamente** (num sentido em certa medida análogo àquele em que a atitude interna do agente fundamenta a culpa pelo facto). Só isto faz compreender que o agente possa encontrar-se onerado pela mais grave anomalia psíquica, por uma esquizofrenia profunda, p. ex., e todavia tenha cometido um facto pelo qual é plenamente imputável. Ou até que, numa mesma conexão temporal, o agente tenha cometido dois factos típicos distintos (*v. g.*, uma violação e um furto) e deva ser declarado inimputável relativamente a um (p. ex., a violação, por força de uma tara sexual grave que sobre ele pesa) e imputável relativamente ao outro (no caso, o furto da pessoa violada após consumada a agressão sexual). O significado que tudo isto possui para a aplicação ao agente de uma medida de segurança, pode por ora restar sobre si. No presente contexto o que importa é tentar concretizar que espécie de relação é esta que tem de mediar entre a anomalia psíquica e o facto do inimputável.

§ 42 Quanto ao que seja o "facto", a que se refere o art. 20.º-1, para efeito de comprovação da inimputabilidade, já dissemos supra, 5.º Cap., § 7 e ss., que ele é, do ponto de vista da doutrina geral do crime, no essencial correspondente ao **ilícito-típico** de que no facto do imputável se trata. Acrescido, convém neste contexto precisar, dos **supostos adicionais de punibilidade** (infra, 26.º Cap.) que ao facto se refiram. Em conclusão ([45]), e de forma ainda mais rigorosa, a teleologia político-criminalmente implicada no conceito conduz à conclusão que o "facto do inimputável" é afinal **o facto punível, com ressalva dos elementos que pertençam à culpa, bem como ainda dos que pertençam ao tipo subjectivo de ilícito como seus elementos subjectivos especiais** (supra, 13.º Cap., § 55 e ss.).

§ 43 No que respeita à conexão entre a anomalia psíquica e o facto do inimputável, sustenta Maria João Antunes, em conclusão, que entre aquela e este tem de interceder uma **relação de causa / efeito**. Razão por que, aliás, o facto em questão não seria o facto do imputável, ampu-

([45]) Conclusão avançada no essencial já no nosso *DP II*, §§ 724 e ss., 735, onde procurámos levar a cabo uma exposição integral do tema do facto do inimputável como pressuposto de aplicação de uma medida de segurança.

tado de certas características, mas um facto "diferente", *hoc sensu* autónomo: seria o facto do inimputável como pressuposto de aplicação de uma medida de segurança (máxime, de internamento). Por isso não haveria aqui tanto que determinar se o facto deve constituir um "ilícito típico" — como de resto afirma a nossa lei: art. 91.º-1 —, eventualmente também punível, no sentido que estas características assumem relativamente ao facto do imputável, quanto sobretudo que características deve ele possuir para que se assuma como **facto criminalmente perigoso** (46). Sobre esta tese já nos pronunciámos (supra, 5.º Cap., § 10), valendo as nossas considerações, *por maioria de razão*, quando em causa está determinar o que é o "facto" a que se refere o art. 20.º-1, isto é, o facto pressuposto da comprovação da inimputabilidade. Importa neste contexto acrescentar que a relação causa / efeito não é suficientemente precisa e esclarecedora daquilo em que deve traduzir-se a conexão entre a anomalia psíquica e o facto. Do que se trata é antes de que a anomalia psíquica deve revelar-se uma tal que **destrói (ou oculta) as conexões de sentido objectivo entre o seu portador e o facto que praticou**. O que está em causa na determinação da inimputabilidade é a consequência da *irresponsabilidade penal* do agente (por falta de — *rectior*, insusceptibilidade de comprovação da — culpa); no estudo da medida de segurança o que releva são os *pressupostos da sua aplicação*, a saber, o facto do agente declarado inimputável e a perigosidade que *prima-facie* resulta da conexão da anomalia psíquica com o facto. Ainda que, em definitivo, as duas perspectivas não tenham de se opor, não pode perder-se de vista que o que no presente contexto está em causa são as soluções prático-normativas dos problemas da inimputabilidade como obstáculo à afirmação da culpa.

III. O problema dito da "imputabilidade diminuída"

§ 44 Na concepção tradicional e ainda hoje dominante em muitas doutrinas a anomalia psíquica pode ser uma tal que tenha como efeito normativo não a *incapacidade* do agente para avaliar a ilicitude do facto ou para se determinar de acordo com essa avaliação, mas uma **capacidade ainda subsistente mas em grau sensivelmente diminuído**. Nestes casos justamente se vem falando de uma *imputabilidade diminuída*. Discutível se tomou desde sempre, porém, qual a consequência que para a culpa

(46) ANTUNES, Maria João, nota 26, pp. 365 e ss. e 433 e ss.

e para a pena resultaria desta diminuição da imputabilidade. Na linha de uma culpa concebida como "poder de agir de outra maneira", como capacidade individual de motivação de acordo com a norma, a solução seria simples e óbvia: à diminuição daquela capacidade haveria de corresponder necessariamente uma **diminuição da culpa** e por conseguinte uma **obrigatória atenuação da pena**. Desde sempre se viu, porém, que deste modo se caía em uma aporia insuportável em perspectiva político-criminal ([47]). Pois muitas vezes a anomalia psíquica que onera o agente e torna a sua capacidade de compreensão e de inibição sensivelmente diminuída faz precisamente com que o agente seja *especialmente perigoso* ([48]) para a comunidade e exija por isso, em nome da legítima protecção desta, uma reacção criminal mais forte e em regra mais longa. O que, as mais das vezes, se procurava alcançar através do tratamento do agente dentro de um sistema *dualista* de reacções criminais (supra, 5.º Cap., § 23 e ss.): a ele se aplicaria uma pena atenuada referida à culpa do facto, mas acompanhada de uma medida de segurança que obviasse à sua especial perigosidade.

§ 45 **Não é este** porém, em nossa opinião, **o problema da imputabilidade diminuída** ([49]). Como hoje se vai reconhecendo já ([50]), não se trata aqui de uma "diminuição" da imputabilidade na acepção de um seu grau menor, ou sequer de uma diminuição da "capacidade de controlo" ([51]) e consequente capacidade de inibição: toda esta forma de suscitar o problema é ainda filha de uma concepção da culpa como capacidade individual de motivação pela norma. Do que se trata é antes, verdadeiramente, de casos de **imputabilidade duvidosa**, no particular sentido de que neles se comprova a existência de uma anomalia psíquica, mas sem que se tornem claras as consequências que daí devem fazer-se derivar relativamente ao elemento normativo-compreensivo exigido; casos pois, da nossa perspectiva, em que **é duvidosa ou pouco clara a com-**

([47]) Para a qual chamou repetidamente a atenção CORREIA, Eduardo, *Unidade*, p. 298 e s., *Lições 1949*, pp. 66 e s. e 305 e s., e I, p. 56 e s., e n.º 76.

([48]) Como se reconheceu sobretudo depois da lição de WILLMANS, *Die sog. verminderte Zurechnungsfähigkeit*, 1927.

([49]) Cf., já, o nosso *Liberdade*, E, IV, 1.

([50]) Cf., logo, MAURACH, § 36, III, A.

([51]) Assim, todavia, ROXIN I, § 20, n.º 33, se bem que recusando (correctamente) que se trate ali de uma "semi-imputabilidade".

preensibilidade das conexões objectivas de sentido que ligam o facto à pessoa do agente.

§ 46 As consequências que desta concepção derivam para a determinação do **grau de culpa** e da **medida da pena** do imputável diminuído divergem assim radicalmente das que são pensadas pela orientação tradicional e permitem, em nosso entendimento, que as soluções impostas se tornem político-criminalmente suportáveis. Se, nos casos de imputabilidade diminuída, as conexões objectivas de sentido entre a pessoa do agente e o facto são ainda compreensíveis e aquele deve, por isso, ser considerado imputável, então as qualidades especiais do seu carácter entram no objecto do juízo de culpa e por elas tem o agente de responder. Se essas qualidades forem *especialmente desvaliosas de um ponto de vista jurídico-penalmente relevante* elas fundamentarão — ao contrário do que sucederia na perspectiva tradicional — uma **agravação da culpa e um** (eventual) **aumento da pena**; se, pelo contrário, elas fizerem com que o facto se revele mais digno de tolerância e de aceitação jurídico-penal, poderá justificar-se uma **atenuação da culpa e a uma diminuição da pena**. Nesta medida o problema dito da "imputabilidade diminuída" não merece tratamento legislativo especial e deve pôr-se e resolver-se num espaço livre de legislação, à luz daquilo que se considere materialmente a culpa e a (in)imputabilidade.

§ 47 A dicotomia referida entre qualidades da pessoa expressas no facto que agravam ou atenuam a culpa não é uma construção puramente doutrinal, imposta pela nossa concepção da culpa material, mas **é confirmada, de modo expresso, pela própria lei penal**, máxime, na distinção entre afectos esténicos e afectos asténicos relevantes em matéria de excesso de legítima defesa (infra, 22.º Cap., § 37 e s.). Investigar, para efeito de imputabilidade diminuída, quais são essas qualidades é tarefa que não pode ser levada a cabo aqui, até porque exigirá uma vez mais, de forma muito estreita, a colaboração entre o perito e o jurista. Utilizando a conhecida classificação das "psicopatias" de Kurt Schneider ([52]), pense-se p. ex. na *crueldade* e *brutalidade* que em regra acompanha os factos dos psicopatas "insensíveis"; na *inconstância* que essencialmente pertence aos "inseguros" e aos "lábeis"; ou na *pertinácia* que quase sempre acompanha os "fanáticos".

§ 48 O art. 20.º-2 dispõe, porém, que "**pode ser declarado inimputável** quem, por força de uma anomalia psíquica grave, não acidental e

([52]) SCHNEIDER, Kurt, *Die psychopatischen Persönlichkeiten*, ⁸1946. E, sobre ela, CORREIA, Eduardo, I, n.º 73, *b)*, 2.

cujos efeitos não domina, sem que por isso possa ser censurado, tiver, no momento da prática do facto, a capacidade para avaliar a ilicitude deste ou para se determinar de acordo com essa avaliação sensivelmente diminuída". E o art. 20.º-3 que "a comprovada incapacidade do agente para ser influenciado pelas penas pode constituir índice da situação prevista no número anterior". Nisto se cifra o **verdadeiro problema** da imputabilidade dita diminuída. Que problema é esse?

§ 49 A génese histórica do art. 20.º-2 é a seguinte: o art. 2.º do ProjPG de 1963 fazia uma referência expressa à concepção de Eduardo Correia de uma *culpa na formação da personalidade*. Ora, face a esta concepção — sobretudo quando lida ainda à luz do dogma da *culpa da vontade* —, podia contar-se com a consideração de que, muitas vezes, a não formação da personalidade e o surgimento de transtornos psíquicos diminuidores da imputabilidade não poderiam ser imputados à culpa do agente (ao seu "poder de agir de outra maneira"), de tal modo que pelo facto deles resultante o agente não deveria ser censurado ([53]). Para tais hipóteses vinha o (hoje) art. 20.º-2 abrir a possibilidade de o agente ser considerado inimputável se bem que, em termos estritos referidos ao facto, ele devesse ainda ser considerado um imputável diminuído ([54]). O art. 2.º do ProjPG foi eliminado em revisões posteriores, pelo que se diria que igualmente eliminado deveria ter sido o disposto no art. 20.º-2. Se ele persistiu, porém, é porque o legislador considerou que o pensamento nele contido ainda podia ser válida e eficazmente interpretado em termos não ligados à culpa na formação da personalidade e sim ao sentido normativo da culpa e da (in)imputabilidade. E julgamos que assim é, com efeito.

§ 50 A partir da concepção que expusemos sobre o fundamento da imputabilidade dita diminuída poderá desde logo aceitar-se como legítimo que o legislador, dada a pouca clareza e a consequente incerteza da compreensibilidade das conexões objectivas de sentido que ligam o facto ao seu autor possa decidir-se por passar a considerar de verdadeira **inimputabilidade** os casos mais graves e duvidosos de *imputabilidade (diminuída)* ([55]).

([53]) DIAS, Figueiredo, *O Problema*, § 13, II, 1.

([54]) CORREIA, Eduardo, *ProjPG*, p. 70 e ss., e A influência de Franz v. Liszt sobre a reforma penal portuguesa, *BFD XLVI*, 1970, p. 27 e ss. Cf., também, as discussões a respeito no seio da Comissão Revisora do ProjPG 1963: *Actas*, I, pp. 144 e ss. e 155 e ss., especialmente p. 163 e s.; e SILVA, Marques da, II, p. 156 e s.

([55]) Sem que com isto pudesse dizer-se violado no que quer que seja o princípio processual *in dubio pro reo*, na medida em que — como em geral se reconhece — não pode dizer-se, em abstracto, que a aplicação ao agente de uma medida de segurança constitua um tratamento *menos favorável* do que a aplicação de uma pena, nomeadamente, quando uma e outra sejam privativas da liberdade.

Seria esta uma decisão político-criminal justificada logo pela circunstância de que o pior serviço que pode prestar-se a um direito penal da culpa não é, seguramente, o de o limitar no seu campo de aplicação, mas, pelo contrário, o de o ofuscar na sua pureza, aplicando-o a situações em que uma tal culpa só duvidosa ou pouco claramente se oferece à compreensão do juiz ([56]); não podendo falar-se a este propósito de uma qualquer "manipulação ilegítima" do conceito de culpa.

§ 51 Não foi tão longe, porém, o legislador português; e uma vez mais fundadamente, em nossa opinião, do ponto de vista político-criminal. Antes, com o disposto no art. 20.º-2 ele propôs-se oferecer ao juiz uma norma flexível que lhe permite, em casos graves e não acidentais — em casos, portanto, em que a prática do facto se revela já uma espécie de forma adquirida do existir psiquicamente anómalo —, considerar o agente **imputável** *ou* **inimputável** consoante a compreensão das conexões objectivas de sentido do facto como facto do agente se revele ou não ainda possível relativamente ao *essencial* do facto. De um ponto de vista de puro legalismo, a opção entre imputabilidade e inimputabilidade será lograda quando se decide sobre se o agente pode ou não "ser censurado" por não dominar ("falta de controlo") os efeitos da anomalia psíquica. E ainda em função de um outro elemento, a saber, o de o juiz considerar que para a socialização do agente será preferível que este cumpra uma pena ou antes, eventualmente, uma medida de segurança (pensamento "a partir do resultado ou da consequência"). É neste preciso contexto que deve interpretar-se o disposto no art. 20.º-3. Não se trata nele de trazer para o CP um novo conceito de inimputabilidade; um novo conceito que, perante as dificuldades insuperáveis postas à sua compreensão pelo dogma da culpa da vontade e do poder de agir de outra maneira, faria coincidir a imputabilidade com a capacidade do agente para **ser influenciado** (no sentido da sua socialização, naturalmente) **pelo cumprimento da pena**. Trata-se, sim, de entrar em conta com este factor (de resto importantíssimo, sobretudo quando ligado à capacidade do agente de "compreensão da pena" ([57])

([56]) Assim, também, já, BETTIOL, Colpa morale e personalità, *in*: *Delito e personalità, Corso internazionale di criminologia*, 1955, p. 288 e ss. Cf., também (a propósito das prescrições do E 1960 sobre o tema), JESCHECK, *Annales Strasbourg 8*, 1961, p. 419 e ss., e BOCKELMANN, *Schuld und Sühne*, ²1959, p. 26 e s.

([57]) Importante sobre este ponto, ANTUNES, Maria João, *O Internamento de Imputáveis em Estabelecimento Destinado a Inimputáveis*, 1993, p. 36 e ss.; cf., depois, o nosso *DP II*, § 941.

na decisão de considerar o agente imputável e aplicar-lhe uma pena; ou antes inimputável e aplicar-lhe eventualmente uma medida de segurança.

IV. A "actio libera in causa" (a. l. i. c.)

§ 52 Acentuámos ao longo da exposição anterior, como ponto essencial da doutrina da imputabilidade, que esta se refere ao facto típico praticado e tem por isso de verificar-se e ser aferida **no momento da realização típica**. Desde há muito tempo, porém, que a doutrina e a jurisprudência vêm reconhecendo a necessidade de, em certas circunstâncias — e sem todavia, por isso, se perder a *conexão* entre a imputabilidade e a realização típica —, se dever considerar que o facto foi cometido em estado de imputabilidade apesar de esta já não subsistir mais no preciso momento da realização e, assim, se dever como que *antecipar* o momento decisivo de apreciação da imputabilidade e, por conseguinte, de aferição da *culpa*. Isso sucede, dito de uma forma geral, nos casos em que o estado de inimputabilidade foi culposamente provocado pelo agente, falando-se então de uma "acção livre na causa".

§ 53 O relevo prático da questão tem sobretudo a ver com os casos de factos praticados em estado de **intoxicação alcoólica** ou **por drogas**. O problema era aliás objecto de atenção expressa do legislador penal português (como, praticamente, de todos os outros ([58])) desde o CP de 1852. Aí dando lugar a uma complexa regulamentação — baseada em distinções como a de a embriaguez ser completa ou incompleta, fortuita ou culposa, pré-ordenada ou não pré-ordenada, acidental ou habitual — que, pese aos melhores esforços doutrinais ([59]), não conseguia de todo compatibilizar-se com o princípio da culpa e deixava aparecer manchas de uma responsabilidade objectiva que, em nome, segundo se pensava ou se pressupunha, de necessidades instantes de prevenção geral de intimidação, não conseguiam de todo desaparecer.

([58]) Uma vasta panorâmica de direito comparado — sem consideração, porém, do caso português — foi dada por SANTOS, Boaventura, *Crimes Cometidos em Estado de Embriaguez*, I, 1968.

([59]) Como os que se encontram em CORREIA, Eduardo, *Lições 1949*, p. 323 e ss., e I, n.º 78. Cf., também, FERREIRA, Cavaleiro de, 1981, p. 443 e ss., e — já depois da entrada em vigor do CP em 1983 — COSTA, Faria, Aspectos fundamentais da problemática da responsabilidade objectiva no direito penal português, *Estudos Teixeira Ribeiro*, III, 1983, p. 381, BRITO, Teresa Quintela de, *Crime Praticado em Estado de Inimputabilidade Autoprovocada, por Via do Consumo de Álcool e de Drogas*, 1991, p. 11 e ss., e a sintética mas valiosa exposição crítica de CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, II, 2000, art. 295, § 5 e ss. Por último, entre nós, NEVES, Curado, nota 19, p. 649 e ss.

§ 54 A compreensão da excepção (que, ao menos à primeira vista, parece surgir como excepção ao próprio princípio da culpa!) contida na aceitação de uma a. l. i. c. continua a conduzir a profundos dissensos doutrinais (60), sobretudo em países — como é o caso da Alemanha — cujos CPs omitem uma regulamentação expressa do problema. Remetido à sua condição de problema puramente doutrinal e jurisprudencial, discutem-se vivamente a seu respeito, sobretudo na Alemanha, duas teses. Uma delas — que alguns AA. querem escorar em direito consuetudinário — vê aqui uma pura e simples excepção, que como tal deve ser frontalmente assumida, ao princípio (61) da coincidência temporal entre a inimputabilidade e o facto, por outras palavras, entre o facto e a culpa; neste sentido e por esta razão se falando neste contexto de um **modelo da excepção** (62). Uma outra tese sustenta não haver lugar ou necessidade de se falar, a propósito, de uma qualquer "antecipação" da aferição da culpa ou de uma "culpabilidade prévia" relativamente à realização do facto: o que sucede é que nestes casos a execução do facto ilícito-típico (homicídio, violação, furto, etc.) se inicia quando o agente se coloca em estado de inimputabilidade; o que se revelará particularmente incisivo se e quando essa colocação corresponder ao plano do agente, fazendo parte do seu propósito de, naquele estado, cometer um facto ilícito-típico: é a tese que se reconduz ao chamado **modelo do tipo** (63). Verdade porém é que qualquer das duas teses em disputa depara com as maiores dificuldades para conseguir impor-se (64).

§ 55 Quanto à que integra o chamado "modelo da excepção" — para além de, ao menos entre nós, não poder esperar qualquer conforto do apelo ao direito costumeiro e de contrariar o princípio da legalidade (65) —, ela

---

(60) Com um largo tratamento monográfico da questão depara-se em HETTINGER, *Die "actio libera in causa": Strafbarkeit wegen Begehungstat trotz Schuldunfähigkeit?*, 1988.

(61) Entre nós clara e expressamente contido, como dissemos, no art. 20.º-1.

(62) Desenvolvida em vários estudos por HRUSCHKA, p. ex., Der Begriff der actio libera in causa und die Begründung ihrer Strafbarkeit, *JuS*, 1968, p. 554 e ss. e Methodenprobleme bei der Tatzurechnung trotz Schuldunfähigkeit des Täters, *ZStR* 90, 1974, p. 74. Neste sentido, entre outros, JESCHECK / WEIGEND, § 40, VI, e S / S / LENCKNER, § 20, n.º 35. Cf., entre nós, PALMA, Fernanda, *O Princípio da Desculpa em Direito Penal*, 2005, p. 192 e s.

(63) Assim, por outros, JAKOBS, 17/68, e ROXIN I, § 20, n.º 58 e ss.

(64) Considerando que os dois modelos conduzem substancialmente às mesmas soluções (mas restando saber se assentam nos mesmos fundamentos) STRATENWERTH / KUHLEN, § 10, n.º 46 e s.

(65) Na medida em que o art. 20.º-1 declara expressamente que a "incapacidade" em que a inimputabilidade se traduz se avalia "no momento da prática do facto". Também isto é hoje

parece violar o mais lídimo sentido do problema da inimputabilidade: esta não constitui, como acentuámos, qualquer "estado" ou "modo" da personalidade do agente, mas uma característica específica que assume o *facto* por força de uma anomalia psíquica e dos efeitos que esta tem sobre aquele. A *contemporaneidade* entre facto e anomalia psíquica determinante não conforma, por conseguinte, um requisito ou uma exigência arbitrárias da doutrina da inimputabilidade, mas antes a sua verdadeira razão de ser como elemento integrante insubstituível de um direito penal da culpa. Ou vistas as coisas de outro prisma: na inimputabilidade estão antes de mais em questão as características e as categorias do *facto* punível, não do *agente* divorciado do facto punível. Fica deste ponto de vista próxima a afirmação de que a aceitação de uma "culpa prévia" ou "antecipada" para a ela ser referido o facto representaria uma manipulação ilegítima (e, em definitivo, uma **violação**) **do conceito jurídico-penal e do princípio da culpa** (66), uma "máscara" de uma responsabilidade objectiva e, por aqui, uma solução do problema **materialmente inconstitucional**.

§ 56 Quanto à tese que integra o cognominado "modelo do tipo" — e que defendemos na 1.ª ed. deste livro —, também ela parece reduzir-se a uma **ficção**, como se torna particularmente visível quando o facto não ultrapassa o estádio da **tentativa**. Se *A* se coloca em estado de inimputabilidade (*v. g.*, sob a forma de embriaguez) com a intenção de, uma vez embriagado, se dirigir a casa da sua companheira, penetrar no quarto onde ela dorme e matá-la, não pode afirmar-se fundadamente que com a ingestão do primeiro ou do último copo, ou mesmo com a subida das escadas da casa da companheira ele pratica já *actos de execução* do tipo de crime de homicídio; nem como tal se pode fazer valer legitimamente o recurso ao plano do agente. Se *A*, ainda no café onde se embriagava, foi levado para a prisão em virtude de uma desordem ali ocorrida; ou foi parar ao hospital por ter dado uma queda ao sair do café ou ao subir as escadas da casa da companheira — em nenhum dos seus actos se descortina uma qualquer conexão com a execução do crime de homicídio, quanto mais, como

---

reconhecido por círculos cada vez mais amplos da doutrina alemã, nomeadamente pelo próprio HRUSCHKA, Die actio libera in causa — speziell bei § 20 StGB mit zwei Vorschlägen für die Gesetzgebung, *JZ*, 1996, pp. 64, 67.

(66) Assim também na conclusão, entre outros, ROXIN I, § 20, n.º 58.

veremos que se deve exigir, uma "conexão de perigo típica" (67). Nem nos parece que deva valer o argumento de um pretenso "paralelismo" entre esta situação e a do início da execução em caso de autoria mediata e que levaria a considerar a a. l. i. c. como um facto cometido "por intermédio de outrem" (art. 26.º, 2.ª alternativa), rigorosamente, por intermédio de "si mesmo", mas aqui visto como "outrem" por ter provocado na própria pessoa a inimputabilidade (68). Para além de que, no domínio fáctico, parece forçado e artificioso o paralelismo, subsiste uma diferença relevante no plano teleológico-normativo: a de que, na a. l. i. c., o agente nada precisa fazer no sentido de levar o executor à prática do facto, tudo se passando ao nível das puras *cogitationes*; enquanto na autoria mediata se torna indispensável uma actuação (externa), mais ou menos extensa, mais ou menos difícil, do homem-da-retaguarda sobre o executor — actuação que vai já dirigida, toda ela, à prática de um *certo facto* ilícito-típico. Por isso nos parece, em definitivo, infundamentado transpor para a a. l. i. c. a doutrina que deva defender-se em matéria de início da tentativa na autoria mediata (infra, 31.º Cap., § 83 e ss.). E de qualquer modo, parece-nos assistir razão a Neumann quando afirma que nos casos em exame, ou ao menos na sua generalidade ou grande maioria, nem sequer poderá ser comprovada a causalidade entre o provocar a inimputabilidade e a prática do facto, pelo menos no sentido de que não será fácil demonstrar que, sem aquela inimputabilidade provocada, o facto não teria sido cometido (69).

§ 57 Julgamos ser toda uma outra a concepção que subjaz ao direito português vigente em matéria de a. l. i. c. e que, aliás, se encontra *expressamente regulamentada no art. 20.º-4*. Este preceito, segundo o seu teor literal, não comina uma responsabilização pelo facto ilícito-típico praticado quando o seu autor provocou a sua *inimputabilidade* (posição do problema comum às duas teses germânicas acima apresentadas). O que ele afirma é coisa de todo o ponto diversa, a saber, que "**a imputabilidade não**

---

(67) Afirmações que melhor serão compreendidas depois de se expor e estudar a matéria relativa à doutrina da tentativa, em particular a distinção entre actos preparatórios e actos de execução (infra, 28.º Cap., especialmente § 23 e ss.).

(68) Substancialmente nestes termos, com ampla indicações bibliográficas, ROXIN I, § 20, n.º 61

(69) NEUMANN, *Zurechnung und Vorverschulden*, 1985, p. 26 e ss.; e, do mesmo, Konstruktion und Argument in der neueren Diskussion zur actio libera in causa, *Art. Kaufmann*-FS, 1993, p. 581 e ss. Cf. em todo o caso a contra-crítica de ROXIN I, § 20, n.º 60.

é excluída quando a **anomalia psíquica** tiver sido provocada pelo agente com intenção de praticar o facto". Por outras palavras, no entendimento expresso da lei, aquele agente **é portador, no momento do facto, de uma anomalia psíquica mas, em todo o caso, imputável** ([70]). Por isso, como imputável tem de ser tratado, não suscitando assim a a. l. i. c. qualquer especialidade no tratamento do facto — tenha ele sido consumado ou tenha ficado na forma da tentativa, tenha intervindo relativamente a esta ou não uma desistência — como **facto de um imputável**. Por isso também a doutrina que será defendida em matéria de início da tentativa e, consequentemente, de distinção entre actos preparatórios e actos de execução (infra, 28.º Cap., § 13 e ss.) não assume qualquer especificidade relativamente à a. l. i. c.

§ 58 Pressente-se a objecção, com foros de decisiva: a de que, entendidas assim as coisas, estamos perante uma pura **ficção de imputabilidade** e, por conseguinte, perante uma clara violação do princípio da culpa com a consequente mácula de uma inconstitucionalidade material. E assim seria, na verdade — é esta a dificuldade invencível com que se depara a doutrina alemã! — se a inimputabilidade residisse na falta de um poder do agente de actuar de outra maneira na situação, de uma permeabilidade ao apelo normativo no momento do facto, em suma, se ela não constituísse mais do que uma parte não autónoma de uma indiferenciada capacidade de motivação de acordo com a norma. Mas já vimos que a inimputabilidade não é isso, antes sim a destruição, por força de uma anomalia psíquica, das conexões reais e objectivas de sentido da actuação do agente, determinantes de uma impossibilidade de compreensão do facto como facto de uma pessoa ([71]). Se o agente decide cometer um determinado ilícito-típico e, *para o realizar*, provoca em si mesmo uma anomalia psíquica, o facto que vem a ter lugar é **plenamente compreensível segundo o sentido** e não apenas deterministicamente explicável, mantendo-se incólumes as conexões reais e objectivas de sentido que ligam o facto à pessoa do agente. (Nesta acepção podendo, na verdade, invocar-se um paralelo entre aquele que se embriaga para ganhar coragem

([70]) Esta ideia foi-nos acentuada, em diálogo descomprometido, por Pedro Caeiro, a quem por isso devida e gostosamente agradecemos.

([71]) Desta perspectiva acaba por assistir plena razão a Neves, Curado, nota 19, p. 655, quando afirma que "o defeito básico que afecta as duas doutrinas [que acima criticámos] decorre do entendimento da culpa como poder de agir de outra maneira"; e, acrescentaríamos nós, da concepção daí decorrente da inimputabilidade.

para matar a antiga namorada e aquele outro que, para o mesmo fim, arma no quarto de dormir daquela uma bomba de relógio destinada a explodir no meio da noite!) É este afinal um caso (só um caso mais, entre outros) em que no momento do facto se verifica a existência de uma anomalia psíquica no agente — o substrato biopsicológico da inimputabilidade —, mas àquela não pode ser atribuído o efeito normativo-compreensivo indispensável para que o facto deva ser jurídico-penalmente tratado como facto de um inimputável (supra, § 25 e s.). Não há nesta concepção qualquer violação do princípio da culpa mas, pelo contrário, a sua mais plena realização. Até ao ponto de nos atrevermos a sugerir que o disposto no art. 20.º-4 constitui a melhor prova da interpretação que demos ao disposto no art. 20.º-1 e do bom fundamento da nossa compreensão da inimputabilidade como obstáculo à afirmação da culpa jurídico-penal.

§ 59 Esta concepção do problema e da sua solução oferece ainda, de resto, fundamento à opção legislativa de restringir a afirmação da imputabilidade do agente em caso de a. l. i. c. aos casos em que a anomalia psíquica foi "provocada pelo agente com **intenção** de praticar o facto"; concordando-se com Taipa de Carvalho em que esta "intenção" não deve ser estritamente parificada com o "dolo intencional" — tal como supra, 13.º Cap., § 35, o caracterizámos —, mas pode abranger igualmente o "dolo necessário" ([72]). Com efeito, só nestes casos se pode afirmar com segurança que a anomalia psíquica auto-provocada não afecta as conexões de sentido entre o facto decidido e o facto realizado. Já não quando o facto é **negligente** ou mesmo praticado com **dolo eventual**: a ausência de plano do agente (negligência) ou, de todo o modo, a sua indeterminação (dolo eventual) faz com que nestas hipóteses, segundo o juízo *ex post* aqui inevitavelmente imposto, se torne impossível avaliar em que medida o facto cometido acabou por ser **condicionado pela anomalia psíquica** e, deste modo, irremediavelmente duvidoso se ele ainda pode ser compreendido, segundo o seu sentido, como facto do agente.

§ 60 Problema restante é assim o de saber como devem ser tratados os casos em que a a. l. i. c. **não é pré-ordenadamente — embora seja**

([72]) CARVALHO, Taipa, *Comentário Conimbricense*, II, art. 295.º, § 25. Mais longe — mas quanto a nós sem razão, como também acentua PALMA, Fernanda, Desenvolvimento da pessoa e imputabilidade no Código Penal português, *Sub Judice* 11, 1996, p. 64, nota — vai BRITO, Teresa Quintela de, nota 59, sustentando que a a. l. i. c. abrange *todas* as modalidades de dolo.

culposamente — provocada, isto é, em que ela é provocada com *dolo eventual* ou com *negligência*. A solução encontrada pelo nosso CP — de uma forma especialmente clara e terminante após a nova redacção dada pela Reforma de 1995 ao art. 295.º — foi a de, em todos estes casos, deixar funcionar as **regras gerais sobre a inimputabilidade**: o agente não poderá pois ser punido pelo facto típico cometido em estado de inimputabilidade provocada, devendo dele ser absolvido (se por ele tiver sido acusado). Uma vez que, todavia, seria político-criminalmente intolerável a lacuna de punibilidade que desta solução resultaria, o CP pune no seu art. 295.º não o facto praticado, mas, de forma autónoma e independente, o **acto de auto-colocação em estado de inimputabilidade por dolo (eventual) ou negligência**, requerendo ainda a prática, nesse estado, de um facto típico unicamente como *condição objectiva de punibilidade* ([73]).

§ 61 A condenação pelo crime do art. 295.º não deve impedir, de toda a maneira, que possa vir a ser aplicada uma **medida de segurança pelo facto praticado em estado de inimputabilidade** se o agente dever ser considerado perigoso. Será, p. ex., o caso do automobilista que se embriaga completamente para "ganhar coragem" para fazer um lanço de auto-estrada em contra-mão, se na condução vier a praticar de forma inimputável um ilícito-típico de homicídio ou de ofensas à integridade física e o tribunal vier a comprovar que se trata de uma personalidade criminalmente perigosa.

B. INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DA IDADE

I. Fundamento

§ 62 Que a imputabilidade deve ser excluída relativamente a qualquer agente que não atingiu ainda, em virtude da idade, a sua **maturidade psíquica e espiritual**, é conclusão que não é posta em dúvida. E todavia deve indagar-se do fundamento de tal conclusão. Em nossa opinião esse fundamento é, no fundo, **da mesma índole** daquele que dá base à inimputabilidade em função de anomalia psíquica: tal como uma certa *sanidade mental* é condição de apreciação da personalidade e da atitude em que ela se exprime, também o é um certo grau de **maturidade** ([74]). Só quando a

([73]) Nestes precisos termos, CARVALHO, Taipa de, nota 59, art. 295.º, § 12 e ss.

([74]) E de novo reverte a SCHELER, Max, nota 16, p. 434 e s., o mérito de o haver posto em evidência plena. Neste sentido, já, o nosso *Liberdade*, E, IV, 1, [80]. Num sentido que nos

pessoa pratica uma acção num estádio de desenvolvimento em que já lhe é dada a plena consciência da natureza *própria* das vivências que naquela se manifestam se torna patente ao julgador a **conexão objectiva de sentido** entre o facto e a pessoa do agente. Isto porém, uma vez mais, não há-de entender-se no sentido de que, antes de atingido um tal estádio de evolução pessoal, não presida já ao existir um ser-livre que torna a pessoa substancialmente responsável: um tal ser-livre é um existencial e portanto, uma função originária, segundo a sua essência, do existir humano ([75]). Do que se trata é pois — como na inimputabilidade fundada em anomalia psíquica — da impossibilidade, para o juiz, de apreensão das conexões de sentido objectivo que derivam da atitude da pessoa do agente e se exprimem no facto.

§ 63 Claro que, sempre que a idade como fundamento de inimputabilidade seja — por razões óbvias de segurança jurídica — expressa pela lei penal (como hoje o é as mais das vezes) através de um critério puramente **quantitativo** (10, 12, 14, 16, 18 anos...), *todas* as concepções esbarrarão com grande dificuldade em compreender *inteiramente* este fundamento a partir do pensamento da culpa. Apesar desta dificuldade, porém, é o fundamento que apontámos que depois se conexiona, formalmente, com o índice oferecido por uma certa idade e que há-de ser justificado à luz de outras considerações, nomeadamente político-criminais.

§ 64 Além das razões expendidas, a colocação desta barreira etária intransponível à intervenção penal funda-se — em estrita perspectiva político-criminal — em um **princípio de humanidade** que deve caracterizar todo o direito penal de um Estado de direito material. Deve evitar-se a todo o custo a submissão de uma criança ou adolescente às sanções mais graves previstas no ordenamento jurídico e ao rito do processo penal, pela estigmatização que sempre acompanha a passagem pelo corredor da justiça penal e pelos efeitos extremamente gravosos que a aplicação de uma pena necessariamente produz ao nível dos direitos de personalidade do menor, marcando inevitavelmente o seu crescimento e toda a sua vida

---

parece próximo fala PALMA, Maria Fernanda, nota 72, p. 61, do "desenvolvimento da pessoa" como dimensão essencial da imputabilidade; acentuando que o "entrecruzamento cibernético dos dois conceitos se traduz (...) numa recíproca influência entre eles ou até mesmo no condicionamento pela ideia de responsabilidade penal das diversas perspectivas em que é encarado o 'desenvolvimento da pessoa' e não apenas o contrário".

([75]) Também a "fala", sublinha KELLER, *Psychologie und Philosophie des Wollens*, 1954, pp. 172, 182 e [31], é uma função originária do ser humano, sem que contra isto esteja o facto de ela não poder ser compreendida nos primeiros estádios do existir infantil.

futura ([76]). Ao que acrescem outras razões. Por um lado, a necessidade — a que o nosso CP oferece base legal no art. 20.º-3 e que, como vimos no § 51, é directamente relevante para outros efeitos — de *compreensão da pena* pelo agente e, consequentemente, de poder ser por ela *influenciado* no sentido da sua socialização. E, por outro lado, mas na mesma direcção, a inidoneidade da pena, especialmente da pena de prisão, para realizar essa finalidade de (re)socialização do delinquente menor. É em relação aos menores, dado serem particularmente influenciáveis e se encontrarem numa situação de especial vulnerabilidade, que mais se fazem sentir os **efeitos criminógenos da pena de privação da liberdade**, que, as mais das vezes, não promoverá a sua reinserção social, mas poderá antes contribuir para a sua dessocialização, integrando-os definitiva e irremediavelmente no "mundo do crime".

II. Regime

§ 65 Nos termos do art. 19.º, **os menores de 16 anos são inimputáveis**. Só estão, assim, sujeitas a responsabilidade penal as pessoas que, no momento da prática do facto, tenham já perfeito os 16 anos. Os ilícitos-típicos cometidos por menores não deixam, porém, de ser objecto de **tutela estadual**, uma vez que também em relação a esses factos deve o Estado cumprir o dever de *protecção de bens jurídicos* a que está adstrito. Ninguém ignora as dimensões que a delinquência juvenil atingiu nos nossos dias, não podendo o Estado demitir-se do seu papel de garante de defesa da sociedade apenas pela circunstância de o agente ser um menor. Esta circunstância determina, todavia, atentas as razões aduzidas nos parágrafos anteriores, todo um outro tipo de intervenção, que, embora tendo presente a ideia de defesa social, é essencialmente orientada pelo *interesse do menor*. Neste sentido aponta a LTE, aprovada pela L 166/99, de 14-9, que define o regime aplicável aos menores com idades compreendidas **entre os 12 e os 16 anos** que tenham praticado um facto qualificado pela lei como crime.

§ 66 Antes da LTE vigorava entre nós a Lei da Organização Tutelar de Menores, aprovada pelo DL 44.288, de 20-4-1962, e alterada pelo

([76]) Neste sentido, também, RODRIGUES, Anabela, Repensar o direito de menores em Portugal — Utopia ou realidade, *RPCC* 7, 1997, p. 374.

DL 314/78, de 27-10, que deu corpo a um extremado **modelo de protecção** (77). Em termos sintéticos (78), pode caracterizar-se este modelo como expressão de uma certa concepção do Estado de direito social, que via o facto ilícito praticado pelo menor como uma patologia social, reveladora de um menor necessitado de auxílio. O facto apareceria como um mero *ensejo* da intervenção tutelar, sendo (relativamente) despicienda a sua prova e o apuramento dos seus exactos termos. Por isso a situação do *menor delinquente* seria comparável à do *menor em risco*, devendo a assistência prestada a ambos ser tendencialmente igual e visar a sua integração social. Nesta perspectiva, seria o Estado quem estaria em melhores condições para avaliar as carências sociais do menor, sendo dispensável a intervenção deste e dos seus representantes legais, os quais não poderiam, regra geral, questionar a medida que lhe fosse aplicada, podendo esta ser livremente modificada e durar até que o menor se encontrasse socialmente readaptado.

§ 67 No outro extremo se depara com o chamado **modelo de justiça**, de feição mais caracterizadamente repressiva, que assenta numa distinção clara entre menores em perigo e menores delinquentes e opta pela submissão destes ao sistema penal. Por contraposição ao modelo de protecção, o *facto* passa a estar no centro do problema. A sua prova é pressuposto irrenunciável de toda a intervenção, devendo para isso fazer-se uso do processo penal (79), com todas as vantagens que lhe estão associadas, nomeadamente a concessão de amplas garantias de defesa, mas também com toda a carga negativa (estigmatizante) que ele comporta e é especialmente sentida por um menor. É o facto ilícito que legitima a actuação do sistema, sendo as necessidades de (re)inserção social do menor relegadas para segundo plano: o que importa é responsabilizá-lo, castigando-o pelo mal que fez, numa visão ético-retributiva, ou promovendo a defesa social, numa visão de prevenção. Sem prejuízo da criação de "válvulas de escape", consistentes em regras especiais, que podem passar pela atenuação da pena, pela

---

(77) Cf. CORREIA, Eduardo, I, n.º 72, GERSÃO, Eliana, Menores agentes de infracções criminais — Que intervenção?, *Estudos Eduardo Correia*, I, p. 631 e ss.

(78) Sobre o que se segue, desenvolvidamente, RODRIGUES, Anabela, nota 76, pp. 361 e ss. e 371 e ss., e DUARTE-FONSECA, *Internamento de Menores Delinquentes. A Lei Portuguesa e os seus Modelos: um Século de Tensão entre Protecção e Repressão, Educação e Punição*, 2005.

(79) Também aqui se podendo retirar um paralelo com as vantagens (assinaladas supra, § 28) de aplicação do processo penal e não apenas da intervenção de um "incidente processual" em caso de inimputabilidade em razão de anomalia psíquica.

submissão a penas de natureza especial ou mesmo pela possibilidade de declaração de inimputabilidade, atendendo à imaturidade que possa ter estado na origem do facto.

§ 68 A par da Lei de Protecção das Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela L 147/99, de 1-9, a LTE introduziu um novo modelo ([80]) que rompeu assumidamente com o "modelo de protecção", mas que também se não identifica com o "modelo de justiça", abrindo antes uma **terceira via** ([81]) neste tratamento. Esta reforma legislativa do direito de menores em Portugal passou, desde logo, pelo reconhecimento da crise do modelo de protecção, devida à falta de legitimidade do Estado para assumir junto do menor um papel paternalista e aos abusos e discricionariedades que, por via disso, se foram verificando, sob o manto de que a medida aplicada, por mais gravosa que se apresentasse para os direitos do menor, apareceria como tomada no seu interesse; ao que se aliava a incapacidade do sistema para responder aos problemas com que se defrontava ([82]). A via preconizada foi, assim, a da assunção de um modelo que distingue entre menores em perigo e menores delinquentes e é dominado por duas linhas de força: responsabilizar e educar — "responsabilizar o menor pelo dano social provocado, mostrando-lhe que essa conduta não é tolerada pela sociedade em que se insere, educando-o para o direito de forma a que a sua personalidade-em-formação interiorize o respeito pelas normas e valores fundamentais da comunidade" ([83]).

§ 69 Só podem ser sujeitos a medidas tutelares educativas ([84]) os **jovens com mais de 12 anos** ([85]) **e menos de 16** que tenham cometido um facto penalmente rele-

---

([80]) Cf. o relatório final da CRSEPM, *in*: RODRIGUES, Anabela / DUARTE-FONSECA, *Comentário da Lei Tutelar Educativa*, 2000, p. 419 e ss.

([81]) GERSÃO, Eliana, Menores agentes de infracções — interrogações acerca de velhas e novas respostas, *RPCC 4*, 1994, p. 254, e RODRIGUES, Anabela, nota 76, p. 373.

([82]) Cf. RODRIGUES, Anabela, nota 76, p. 358, CRSEPM, 1.º Relatório, *in*: RODRIGUES, Anabela / DUARTE-FONSECA, nota 80, p. 396 e ss., e Exposição de Motivos da LTE.

([83]) CRSEPM, nota 80, p. 424.

([84]) Entre as medidas tutelares educativas contam-se, nos termos dos arts. 4.º e 9.º e ss. da LTE, a admoestação, a privação do direito de conduzir ciclomotores ou de obter permissão para tal, a reparação ao ofendido, a realização de prestações económicas ou de tarefas a favor da comunidade, a imposição de regras de conduta, a imposição de obrigações, a frequência de programas formativos, o acompanhamento educativo e o internamento em centro educativo: cf. RODRIGUES, Anabela / DUARTE-FONSECA, nota 80, pp. 65 e ss. e 76 e ss.

([85]) A CRSEPM, nota 80, p. 428, entendeu, a nosso ver correctamente, que a ofensa penal praticada por menor de 12 anos "tem que ser suportada e encarada pela sociedade como

vante. Pressuposto primeiro da aplicação de uma medida tutelar é, nestes termos, a **prática de um ilícito-típico penal**. O sistema tutelar educativo não terá, assim, legitimidade para intervir em situações de para-delinquência, em relação a menores que se dediquem, *v. g.*, a práticas de prostituição, consumo de bebidas alcoólicas e de estupefacientes ou à mendicidade, e se mostrem, por isso, socialmente desadaptados e carentes de acompanhamento educativo: nestas circunstâncias não há uma ofensa a bens jurídico-penais, mas, quando muito, situações de autolesão, que poderão justificar, isso sim, uma intervenção no plano assistencial (86). Mesmo a consideração de que o menor realizou o facto previsto em um tipo incriminador deve ser rodeada de especiais cuidados, que tomem em consideração as características pessoais próprias de um menor; as quais passam não só pela falta de maturidade, como também por uma maior impreparação para responder a determinadas exigências de cuidado (que deverá relevar quanto a factos negligentes), ou por uma certa irreverência que impele o jovem a correr riscos e a adoptar condutas desafiadoras como forma de afirmação pessoal. Além disso, não poderá, naturalmente, uma medida tutelar ser aplicada a um menor pela prática de um facto penalmente justificado (87), pois, apesar do teor literal do art. 2.º-2 da LTE, não estaremos aqui perante um "facto qualificado pela lei penal como crime" (art. 1.º da LTE), nem o menor revelará a atitude de desrespeito para com o dever-ser jurídico-penal que fundamenta a intervenção tutelar.

§ 70 A aplicação de uma medida tutelar educativa tem ainda como pressuposto a **necessidade**, *subsistente no momento da sua aplicação*, **de correcção da personalidade do menor** no sentido do respeito para com os valores e princípios essenciais conformadores do dever-ser jurídico-penal. Por outro lado, a medida deverá ser escolhida e aplicada de acordo com uma finalidade de "**educação para o direito**" (88), em função da qual se deverá realizar uma "pedagogia da responsabilidade" que incuta no menor o respeito pelos outros e por um quadro mínimo de valores que sustentam uma pacífica convivência social; a qual não passa todavia pela imposição de determinados modelos éticos, morais ou ideológicos, que ponham em causa o seu direito à diferença e autodeterminação pessoal, e para a qual o Estado não tem legitimidade. Esta opção político-criminal — claramente assumida pelo legislador (89) e a que, por isso, os aplicadores devem obediência — determina, assim, que a aplicação de uma medida tutelar deva ser decisivamente orientada por uma finalidade de (re)inserção social do menor, pela ideia de prevenção especial de socialização.

---

o *pathos* que envolve os cataclismos naturais", aparecendo a intervenção educativa como destituída de sentido "em estádios de desenvolvimento muito recuados, pois assenta numa educação para a responsabilidade jurídica que esses menores dificilmente poderiam compreender". Estas crianças devem, assim, ser encaminhadas não para o sistema tutelar de menores, mas antes para o sistema de protecção existente para os menores em perigo.

(86) Cf. CRSEPM, nota 80, p. 429 e s.

(87) Assim, RODRIGUES, Anabela / DUARTE-FONSECA, nota 80, p. 63.

(88) RODRIGUES, Anabela, nota 76, p. 380, e RODRIGUES, Anabela / DUARTE-FONSECA, nota 80, p. 61 e s.

(89) Cf. Exposição de Motivos, pontos 4. a 7., e arts. 2.º-1 e 6.º da LTE.

§ 71 Embora, como temos vindo a referir, só os jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos no momento da prática do facto possam ser sujeitos à aplicação de uma medida tutelar, a LTE exige ainda que a decisão de aplicação seja **proferida até o menor completar 18 anos** (art. 28.º-2), podendo a medida **prolongar-se até aos 21 anos**, momento em que cessa obrigatoriamente (art. 5.º). Problemática é a compatibilização da intervenção tutelar com a actuação penal nos casos em que tendo o jovem completado os 16 anos está a cumprir a medida tutelar ou aguarda a sua aplicação ou execução e nesse período comete um crime, ao qual é aplicada uma pena (90). Diversamente do que acontece noutros sistemas, *v. g.*, na Alemanha (91) e na Itália (92) — que fixam a idade da imputabilidade em 14 anos mas em que, por isso e de todo o modo, a lei impõe a aferição, para cada caso, da imputabilidade em relação aos factos cometidos entre os 14 e os 18 anos —, entre nós aos 16 anos adquire-se a imputabilidade plena (ressalvado o que se expõe no parágrafo seguinte).

§ 72 No nosso ordenamento encontramos, no entanto, um **regime penal especial para os jovens adultos**, aqueles com idades compreendidas entre os 16 e os 21 anos, previsto no art. 9.º do CP e concretizado pelo DL 401/82, de 23-9. Este diploma traduz-se, no essencial, pela definição de um regime específico ao nível das *consequências jurídicas* do crime, que tem em conta as especiais necessidades de (re)socialização suscitadas pelos jovens delinquentes. Neste âmbito, para efeito da questão da imputabilidade importa sobretudo dilucidar o sentido do seu art. 4.º, que permite, nos casos em que deva ser aplicada pena de prisão, a *atenuação especial da pena* quando houver razões para crer que da atenuação resultam vantagens para a reinserção social do agente. Ao contrário do que se entendia acontecer na vigência do CP de 1886 (arts. 107.º e 108.º) (93), a circunstância de o delinquente ser um jovem adulto não implica uma atenuação *automática* da pena (94). O regime de atenuação automática na vigência do código anterior justificar-se-ia com base em uma ideia de imputabilidade diminuída, pensada nos termos tradicionais que criticámos supra, § 44 e s.: a juventude do agente acarretaria por definição um menor poder de agir de outra maneira e,

---

(90) A regra é a de que o menor cumpre cumulativamente as medidas tutelares e as penas que lhe forem aplicadas, sempre que as mesmas forem entre si concretamente compatíveis (art. 23.º da LTE) — cf. RODRIGUES, Anabela / DUARTE-FONSECA, nota 80, p. 106 e ss., e DUARTE-FONSECA, Interactividade entre penas e medidas tutelares — Contributo para a (re)definição da política criminal relativamente a jovens adultos, *RPCC 11*, 2001, p. 272 e ss. As dificuldades sentidas neste âmbito levam estes AA., *locs. cit.*, a considerar — quanto a nós com razão (cf., já, o nosso *Liberdade*, E[80]), por mais que uma tal ideia esteja contra os ventos que sopram — que seria desejável, num plano *de jure constituendo*, elevar a idade da imputabilidade para os 18 anos ou pelo menos, seguramente, não a baixar.

(91) JESCHECK / WEIGEND, § 40, II. Cf. o § 19 do StGB e o § 3 da Jugendgerichtsgesetz.

(92) MARINUCCI / DOLCINI, *Diritto Penale* VIII, 8, 4 1. Cf. o art. 98-1 do CP italiano.

(93) CORREIA, Eduardo, II, n.º 43.

(94) É este também o entendimento da jurisprudência portuguesa: cf. Acs. do STJ de 23-7-1985, *BMJ 342*, p. 484, e de 10-6-1991, *BMJ 409*, p. 406.

consequentemente, determinaria uma atenuação da pena (95). Não é seguramente esta a razão que agora sustenta a atenuação especial da pena de prisão em relação aos jovens adultos. Uma menor censurabilidade determinada por uma menor maturidade deve ser apreciada em concreto. Daí que a atenuação da pena não seja automática, mas esteja antes dependente de um juízo que tome em consideração a culpa menos grave do agente e/ou as exigências de prevenção (sobretudo de prevenção especial) como a lei pretende sublinhar no referido art. 4.º, que no caso se façam sentir.

(95) Apontando neste sentido, ainda que não em termos expressos, CORREIA, Eduardo, I, n.os 72 e 76, e II, n.º 43, e FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, n.os 143 e 203.

22.º CAPÍTULO

A INEXIGIBILIDADE

I. Fundamento e âmbito da exclusão da culpa (1)

1. O sentido originário do problema e as suas consequências

§ 1 Foi a concepção normativa da culpa — como já ficou sublinhado supra, 10.º Cap., § 12 e ss. — que, ao considerar a culpa como *censurabilidade* do facto em atenção à capacidade do agente para se deixar motivar pela norma (por ter agido ilicitamente, quando podia ter-se comportado de outra maneira), veio acentuar que aquela censura só deveria efectivar-se quando ao agente, **na concreta situação, fosse exigível um comportamento adequado ao direito**. Como entre nós ensinou Eduardo Correia — traduzindo exactamente o pensamento originário do problema (2) —, assim como uma "disposição interior do agente para o facto" pode furtar-lhe a capacidade de motivação pela norma, também "as circunstâncias exteriores, na moldura das quais se desenvolve um facto, podem configurar-se de tal maneira (...) que arrastem *irresistivelmente* o agente para a sua prática, *roubando-lhe toda a possibilidade de se comportar diferentemente*... Aceitando a *exclusão do poder de agir de outra maneira por força da situação exterior*, necessariamente que com isso fica excluído o pressuposto de toda a censura" (3). Por isso a inexigibilidade (de com-

---

(1) Sobre esta matéria, os nossos *Liberdade*, C, II, 3, e E, IV, 2, e Sobre o estado actual da doutrina do crime, *RPCC 2*, 1992, p. 21 e ss. Também agora as importantes monografias de PALMA, Fernanda, *O Princípio da Desculpa*, 2005, e NEVES, Curado, *A Problemática da Culpa nos Crimes Passionais*, 2006, p. 649 e ss.

(2) Na sequência da concepção cuja formulação acabada ficou a dever-se a FREUDENTHAL, *Schuld und Vorwurf im geltenden Strafrecht*, 1922.

(3) CORREIA, Eduardo, *Unidade*, p. 294.

portamento diferente) constituiria uma causa (e, na verdade, uma causa *geral*) de exclusão da culpa.

§ 2 Esta tese porém, a ser aceite nas suas consequências — independentemente da concepção inaceitável da sua fundamentação numa culpa jurídico-penal como "poder de agir de outra maneira"—, poria em causa a **eficácia** de um direito penal da culpa e seria político-criminalmente insustentável. À sua luz importaria, na verdade, reconhecer que a exigibilidade teria de aferir-se face à *valoração individual* dos motivos pelo agente e não à sua valoração pela ordem jurídica; como, por outro lado, deveria conduzir à exclusão da culpa (e à consequente absolvição) sempre que a acusação não conseguisse provar que, no momento do facto e perante a concreta *pressão do circunstancialismo exógeno* exercida sobre a psique do agente — porventura dotado de uma fraca capacidade de resistência —, este podia ter-lhe resistido e ter-se comportado de acordo com a norma. De um direito penal baseado no princípio de uma culpa assim concebida não poderia mais esperar-se o cumprimento da sua função de protecção subsidiária de bens jurídicos no contexto social.

2. Desenvolvimentos doutrinários posteriores

§ 3 O essencial da crítica acabada de desenvolver ganhou, a breve trecho, a generalidade da doutrina da inexigibilidade, a ponto de Dohna ter considerado que uma tal doutrina "iluminou como um meteoro o horizonte para perder-se de novo, depois de um breve prazo, na obscuridade" (4). Mas são muitas — e profundamente divergentes tanto na sua fundamentação teorética, como nas consequências prático-normativas a que conduzem — as vias apontadas para dissolução da aporia referida.

2.1. A inexigibilidade como causa de diminuição substancial da culpa e de renúncia da ordem jurídica à sua punição (causa de "desculpa")

§ 4 Uma primeira via reside em considerar, mantendo no essencial a concepção da culpa a que nos referimos e o sentido original do problema, que a inexigibilidade — sejam quais forem as consequências "sistemáticas" que desta consideração venham a ser retiradas — não constitui *substancialmente* uma causa de *exclusão* da culpa, mas unicamente um motivo de

(4) DOHNA, Graf zu, *Der Aufbau der Verbrechenslehre*, [3]1947, p. 46.

renúncia da ordem jurídica a punir **uma culpa que subsiste, mas em grau diminuto** (5). Com a afirmação, no caso concreto, da imputabilidade e da consciência (potencial) do ilícito estaria confirmado o poder de o agente se deixar motivar pela norma e por isso de agir de acordo com o direito, de responder ao apelo normativo deste. A exigibilidade não se ligaria deste modo à fundamentação da censura da culpa, nem tão-pouco a inexigibilidade à sua exclusão, mas apenas à sua *quantificação*, em particular, à circunstância de a culpa se encontrar em certos casos especialmente *diminuída*. Assim se estabelecendo a distinção entre verdadeiras causas de **exclusão da culpa** (a inimputabilidade e o erro sobre a ilicitude não censurável) e simples causas de **desculpa** (as derivadas da inexigibilidade). Daí também que a ordem jurídica seja livre em dizer quais os casos e quais as pessoas relativamente às quais entende renunciar à punição em nome da inexigibilidade: esta não é, consequentemente, uma causa *geral* de renúncia à punição, mas uma causa que só pode ser aceite **nas hipóteses previstas pela lei**.

2.2. A inexigibilidade como causa de exclusão da "responsabilização pelo facto" (*Tatverantwortung*, Maurach)

§ 5 A partir daqui ficava próxima a tentativa de, sem contestar em definitivo o pensamento fundamentador da inexigibilidade, afastá-la pura e simplesmente do domínio da culpa e da sua correspondente localização sistemática. Uma tal tentativa foi pela primeira vez levada a cabo por Maurach (6). Invocando razões político-criminais e de funcionalidade do sistema (em síntese, a de que a concepção da inexigibilidade como causa de exclusão da culpa cairia inevitavelmente num insuportável *tout comprendre c'est tout pardonner*), Maurach chama a atenção para que nas situações ditas de inexigibilidade o que está em causa é que o comportamento contrário à norma é *perdoável* ou *"desculpável"* **relativamente a toda e qualquer pessoa** (isto é, **em geral**) e nada tem a ver com o agente

(5) Com a expressão mais acabada e logicamente mais rigorosa e implacável desta concepção — avançada porventura pela primeira vez por Bockelmann — depara-se em KAUFMANN, Armin, *Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte*, 1959, p. 153 e ss., e Schuldfähigkeit und Verbotsirrtum, *Eb. Schmidt-FS*, 1961, p. 320. A esta concepção pode talvez dizer-se que, no essencial, aderiu hoje — depois, sobretudo, que WELZEL, § 23, I, se ligou inteiramente à posição de Armin Kaufmann a partir da 5.ª edição do seu *Lehrbuch* — a maioria da doutrina germânica, pela qual poderá ver-se JESCHECK / WEIGEND, § 43, III.

(6) MAURACH, *Schuld und Verantwortung*, 1948; cf., depois, M / ZIPF, § 31 e ss.

concreto ou com as suas específicas condições pessoais na situação, pelo que o seu relevo jurídico-penal não pode situar-se em sede de culpa. Forçoso seria concluir, a partir daqui, que tais situações devem ser imputadas a uma categoria sistemática intermediária entre a ilicitude e a culpa, que Maurach cognominou de "responsabilização pelo facto": é esta responsabilização, não a culpa, que deve ter-se por excluída nas situações de inexigibilidade; com a consequência de que essa responsabilização é afinal pressuposto tanto da aplicação de uma pena, como de uma medida de segurança.

2.3. A inexigibilidade como causa de exclusão da ilicitude

§ 6 Mais radicais se revelam aqueles autores que, perante as dificuldades assinaladas de compreensão da inexigibilidade como causa de exclusão da *culpa*, defendem (regressando, deste modo, às "teoria unitárias" — por oposição à "teoria diferenciada: cf. supra, 16.º Cap., § 1 — em matéria de estado de necessidade) que a inexigibilidade deve logo relevar ao nível da própria **ilicitude**, no sentido de a **excluir**, que ela constitui por isso, em suma, uma autêntica *causa de justificação*. E isto essencialmente porque, tal como assinalou Maurach, a situação é de relevo geral, pondo em questão não a capacidade individual de motivação pela norma, *mas a própria norma de determinação como tal* (7): os comportamentos em situação de inexigibilidade seriam **lícitos** não porque a culpa estivesse afastada, sequer porque não revelariam necessidades de punição, mas, pura e simplesmente, porque o *direito não quer lutar contra (opor-se a) esta espécie de comportamentos*. O que todavia não nos parece exacto nem de um ponto de vista teleológico, nem de um ponto de vista jurídico-positivo: aquilo contra que o legislador entende não lutar (*v. g.*, a tentativa de aborto voluntário — arts. 23.º-1 e 140.º-2 e 3 — ou o aborto negligente) não conforma "causas de justificação", mas sim comportamentos atípicos e por isso jurídico-penalmente irrelevantes; o que de todo não sucede com os comportamentos típicos em situação de inexigibilidade (8). Além de que a norma de valoração / determinação que preside ao juízo de ilicitude se dirige com sentido mesmo àqueles que se não encontrem em condições fác-

(7) Assim, essencialmente, GIMBERNAT Ordeig, Der Notstand: ein Rechtswidrigkeitsproblem, *Welzel-FS*, 1974, p. 485, e *in*: Eser / Perron (orgs.), *Rechtfertigung und Entschuldigung*, III, 1991, p. 71; e, depois, CUERDA Riezu, *La colisión de deberes en derecho penal*, 1984, pp. 237 e ss. e 280 e ss., bem como o prefácio de Gimbernat a esta obra.

(8) No essencial desta crítica convém ROXIN I, § 22, n.º 6.

ticas e pessoais-subjectivas de a cumprir: ainda aí estão em questão comportamentos contrários à ordem jurídica e, por conseguinte, proibidos (9).

2.4. A inexigibilidade como causa de exclusão da "responsabilidade" (*Verantwortlichkeit*, Roxin)

§ 7 Via diferente das anteriormente consideradas segue Roxin (cf., já, supra, 10.º Cap., § 72 e s.): em vez de imputar a questão da inexigibilidade a uma categoria sistemática "anterior" à da culpa — seja à da ilicitude, como sustenta Gimbernat, seja a uma responsabilização pelo facto que se situaria entre ilicitude e culpa, como propõe Maurach —, ele atribui-a a uma nova categoria que, todavia, seria "posterior" à da culpa: a da "*responsabilidade*". Também Roxin discorda da consideração da inexigibilidade como causa de exclusão da culpa — defendendo que ela deixa, pelo contrário, que a culpa subsista — e considera que exclui a **responsabilidade** do agente. A culpa, como permeabilidade do agente ao apelo normativo, estaria dada definitivamente com a imputabilidade e a consciência potencial do ilícito; em certos casos, porém, — que a ordem jurídico-penal há-de indicar expressamente —, a punição não deve efectivar-se porque, não se verificando no caso **exigências preventivas** (nomeadamente de prevenção especial) a que aquela deva dar resposta, o agente não deve ser chamado à *responsabilidade*. Na inexigibilidade do que se trataria seria, afinal, não de um problema de exclusão da culpa, mas de uma questão de ausência de exigências de prevenção e, consequentemente, de **desnecessidade de punição** (10).

2.5. Consideração crítica

§ 8 A crítica *básica* de que nos parecem merecedores todos os desenvolvimentos apontados é a mesma: o problema da inexigibilidade (11) é e só pode ser um problema que contende com a *censura* jurídico-penal e, por

(9) No sentido desta conclusão, por último, NEVES, Curado, nota 1, p. 719 e ss.

(10) ROXIN, pela primeira vez em Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit im Strafrecht, *Bockelmann-FS*, 1979, p. 279, e, agora, I, §§ 19, A, e 22, A.

(11) Mesmo que possa considerar-se que esta constitui um *princípio regulativo geral de direito* correspondente, no essencial, à velha máxima latina *ad impossibilia nemo tenetur* ou *nemo obligatur* e que, nesta medida, perpassa todas as categorias jurídicas e também, portanto, jurídico-penais: cf. HENKEL, Zumutbarkeit und Unzumutbarkeit als regulatives Rechtsprinzip, *Mezger-FS*, 1954, p. 269.

conseguinte, com a categoria sistemática da *culpa*. Tudo conduz, à luz de uma concepção da culpa como capacidade de motivação pela norma ou de permeabilidade ao apelo normativo, a negar a tese segundo a qual, dada a imputabilidade e a cognoscibilidade do ilícito, dada está *eo ipso* a capacidade do agente para se motivar de acordo com a norma. Bem pelo contrário — como sempre o reconheceu a generalidade dos adeptos de uma autêntica teoria normativa da culpa ([12]) —, assim como há circunstâncias endógenas que podem afectar uma tal capacidade, também às circunstâncias exógenas há que reconhecer, porventura até com maior razão e frequência, a possibilidade de desencadearem tal efeito. À luz de uma culpa como *poder* de agir de outra maneira o problema da exigibilidade deve continuar hoje a pôr-se como quando surgiu: como **pressão do condicionalismo exógeno**, determinante de uma motivação anormal, sobre aquele poder, susceptível de conduzir, na situação, à sua **exclusão** ([13]). Mas sendo assim, também àquela luz só uma concepção da exigibilidade à maneira de Freudenthal é coerente: uma concepção que a determina e a mede do exclusivo ponto de vista do poder concreto do agente individual no momento do facto. E se se reconhecer que isto é político-criminalmente impossível, só o abandono daquela concepção básica da culpa e do seu conteúdo material é viável. Pensar que antes de se substituir aquela concepção material por outra é possível suprimir a aporia que (também) no problema da inexigibilidade se revela é e continuará a ser pura ilusão.

§ 9 Isto assente, as derivações de ordem **sistemática** com que se pretende iludir a realidade essencial ganham um relevo dogmático apenas de segunda ordem. Pode alegar-se, com razão, face à concepção de Maurach, que ou a categoria da "responsabilização pelo facto" não tem razão de ser bastante (quer porque ela não deve considerar-se pressuposto da aplicação de uma medida de segurança, quer porque, relativamente à pena, tudo caberá numa compreensiva concepção da culpa), ou, quando deva

---

([12]) Inclusivamente Welzel, até ao momento em que se ligou à tese de Armin Kaufmann (cf. supra, nota 5). De modo particularmente claro, BETTIOL, p. 462 e ss., e REALE JR., Miguel, *Dos Estados de Necessidade*, 1971, p. 44 e ss.

([13]) De "pressão motivacional" fala neste contexto JAKOBS, 18/5 e s., 12 e ss., sustentando ser a situação endógena derivada daquela pressão o verdadeiro fundamento de negação da culpa nas situações de inexigibilidade. Com o que todavia, em nosso entendimento, opera uma perigosa aproximação ou mesmo, em certos casos, uma incorrecta confusão entre inexigibilidade e inimputabilidade, que descaracteriza o fundamento desculpante daquela. No sentido desta conclusão, após extensa análise, NEVES, Curado, nota 1, p. 655 e ss.

entrar no sistema da doutrina do facto punível, terá de posicionar-se sistematicamente como categoria "posterior" à da culpa, e não "anterior" a ela ([14]). Como pode contrapor-se à concepção de Roxin, com razão (supra, 10.º Cap., § 73), que junta na categoria da "responsabilidade" duas ideias rectoras — a da culpa *stricto sensu* e a das necessidades preventivas — que, igualando-se no seu efeito de afastar a responsabilidade e a punição, sempre que uma delas se não verifique *in casu*, todavia são estruturalmente diversas na sua substância ou materialidade, na sua justificação político-criminal, na sua teleologia e na função que desempenham no sistema ([15]). E todavia não é, em nosso parecer, em considerações deste tipo que deve residir o essencial da crítica no presente enquadramento. O essencial reside na consideração substancial comum sobre a qual repousam construções como a de Maurach ou a de Roxin: a de que a impunidade que resulta, em último termo, das situações de inexigibilidade constitui um efeito de natureza **geral**, assente em outras considerações que não as da situação **pessoal** do agente e portanto as atinentes à sua **culpa**. Pensar assim porém constituiria — como insuperavelmente o formulou uma vez Eduardo Correia — "fazer funcionar o efeito previsto [a impunidade] desligado da sua razão de ser". Pelo contrário, há que asseverar que a impunidade fica ali a dever-se sempre ([16]), em último termo, a considerações retiradas das circunstâncias concretas do facto *e* da atitude pessoal do agente. A considerações, em suma, que não possuem o carácter *geral* de que se reivindica Maurach ou não têm que ver com a ausência de necessidades preventivas exigida por Roxin, antes sim com **a negação da culpa e do seu conteúdo material**.

3. Inexigibilidade e exclusão da culpa

§ 10 À luz de um conceito material de culpa como o defendido (supra, 19.º Cap., § 20 e ss.), cremos que se alcança um fundamento sólido

---

([14]) Assim, ROXIN, Culpa e responsabilidade. Questões fundamentais da teoria da responsabilidade, *RPCC 1*, 1991, p. 536.

([15]) Assim, ANDRADE, Costa, A "dignidade penal" e a "carência de tutela penal" como referência de uma doutrina teleológico-racional do crime, *RPCC 2*, 1992, p. 201 e ss.

([16]) O que se torna muito claro no direito positivo português, *v. g.*, quando o art. 35.º-1 põe como requisito *autónomo* do estado de necessidade desculpante que "não seja razoável *exigir dele* [do agente], *segundo as circunstâncias do caso*, outro comportamento" (infra, § 20 e ss.); ou quando o art. 33.º-2 exige como requisito *autónomo* do excesso de legítima defesa desculpante que a "perturbação, medo ou susto" sejam "*não censuráveis*" (infra, § 39).

para a introdução dos casos de inexigibilidade como causas de exclusão da culpa. Pode acontecer, com efeito, que relativamente a certos factos se revele uma sensível **desconformidade** entre a sua censurabilidade externo-objectiva e a "essência de valor" ([17]) da personalidade neles plasmada, tal como resulta nomeadamente da **atitude global do agente** ou das suas "intenções fundamentais" perante as exigências jurídico-penais. Verificando-se que uma tal desconformidade tem a sua origem numa pressão imperiosa de momentos exteriores à própria pessoa, que não encontram nesta um "eco" favorável, antes "estorvaram" ou "desviaram" o cumprimento normal das suas intenções fundamentais, deverá então a culpa considerar-se excluída por *inexigibilidade* de um comportamento conforme com o direito.

Assume pois aqui relevo decisivo a ideia de que a ordem jurídico-penal não pode — para usar de uma expressão de Eduardo Correia — "dividir a personalidade em exigências contraditórias" ([18]). Todos estão de acordo com que a personalidade suposta pela ordem jurídica não é a do "herói moral", mas a do homem dotado de uma resistência espiritual normal. Por isso não faria sentido censurar o agente pela personalidade manifestada no facto, quando afinal ela acaba por se revelar adequada no essencial ao modelo suposto pela ordem jurídica. Ponto é que a situação exterior seja uma tal que permita afirmar que também a generalidade dos homens "**honestos**" ou "**normalmente fiéis ao direito**" teria provavelmente actuado da mesma maneira; e que as qualidades pessoais juridicamente relevantes manifestadas no facto não sejam, apesar disso, juridicamente censuráveis. É este, ao que continuamos a crer, o verdadeiro **fundamento** da inexigibilidade como causa de exclusão da culpa; e dele resulta a determinação do seu **âmbito de actuação**, como seguidamente se dirá mas melhor será compreendido com a exposição do regime das concretizações legalmente admitidas da inexigibilidade.

§ 11 Assim se compreende, na verdade, que o duplo critério acima assinalado — correspondência do facto àquele que seria também prati-

---

([17]) Para falar ainda desta vez com SCHELER, Max, *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik*, [4]1954, p. 490 e ss.

([18]) CORREIA, Eduardo, *Unidade*, p. 231: "Obrigando cada um a construir a sua personalidade de harmonia com o respeito por certos valores, não poderá o direito esquecer a totalidade dessa personalidade. Acentuando na estrutura de uma pessoa um certo interesse, terá o direito que contar com o quadro de valorações que paralelamente lhe correspondem... Quando assim se não entenda, pretender-se-á dividir a personalidade em exigências contraditórias".

cado por um "homem fiel ao direito"; e não manifestação naquele de qualidades da personalidade juridicamente desvaliosas e censuráveis — possa na prática, relativamente à generalidade dos casos e porque a apreciação tem sempre, como é adequado a um problema de culpa, de ser feita em concreto, **unificar-se** relativamente a um agente não onerado por um *dever especial*. Mas compreende-se também que nos casos chamados de **exigibilidade intensificada** (quando sobre o agente recai um *especial dever de suportar riscos acrescidos*: soldados, bombeiros, polícias...) já não possa em princípio desculpar-se, em nome da inexigibilidade de um comportamento adequado ao direito, o agente que praticou o facto em virtude de um défice das qualidades pessoais de resistência que são exigidas pela ordem jurídica a quem tenha assumido deveres especiais.

§ 12 Sendo assim as coisas, compreender-se-á todavia que a inexigibilidade não deva constituir uma *causa geral de exclusão da culpa*, mas só deva ser aceite nas hipóteses em que a lei tenha entendido dever **exprimi-la**. É em definitivo à lei que pertence definir as situações relativamente às quais reconhece (seja em função do perigo, seja do bem jurídico lesado, seja do círculo de agentes que à desculpa podem remeter-se, etc.) que a pressão exterior das coisas para o facto ultrapassa a resistência que ela espera de uma personalidade "fiel ao direito": só nessas situações deve, em princípio, reconhecer-se a exclusão da culpa por inexigibilidade. São essas situações que em seguida serão estudadas.

§ 13 Conducente a uma consideração mais favorável à inexigibilidade como **fundamento geral de exclusão da culpa** (ou da "desculpa") vem a revelar-se a concepção de Fernanda Palma de um *princípio da desculpa*. Para a A., a alternativa parece consistir ou na compreensão hoje dominante da inexigibilidade como "um conceito sem substância, meramente regulador de uma actividade interpretativa" ([19]) ou como uma cláusula geral de desculpa. Esta última concepção parece ganhar força no seu pensamento face à insistência com que defende que determinante do juízo de inexigibilidade só pode ser a pessoa do agente na sua mesmeidade e subjectividade ([20]). Concepção que, como se compreenderá já, não podemos aceitar: a personalidade do agente documentada no facto e fundamentadora dele tem sempre de ser aferida à luz dos critérios de validade e de aceitabilidade jurídica das suas motivações ([21]), daquilo

([19]) PALMA, Fernanda, nota 1, p. 218.

([20]) PALMA, Fernanda, nota 1, pp. 17 e ss., 215 e ss., 220.

([21]) Por isso temos por seguro, *e. g.*, que *hic et nunc*, face à ordem jurídico-penal portuguesa vigente, não pode invocar-se a ideia da inexigibilidade para excluir a culpa daquele

que, pura e simplesmente, na situação concreta lhe era juridicamente exigível. Por isso, quanto ao ponto em análise, nos encontramos com as conclusões, a propósito, de Curado Neves: "a inexigibilidade não é apenas uma regra de interpretação, mas também não uma cláusula geral de afastamento da culpa; é um fundamento de desculpa que intervém para tomar em consideração situações excepcionais que podem ser obstáculos ao cumprimento da lei penal. A sua excepcionalidade é vincada pela tipificação daquelas circunstâncias em regra específicas que detalham com algum pormenor em que condições podem levar à impunidade". Donde se torne "inevitável a utilização do critério da exigibilidade como expressão da medida em que a ordem jurídica apela ao cumprimento da lei, mesmo em situações difíceis, e a delimitação das circunstâncias em que tal já não pode ser exigido" (22).

II. O estado de necessidade desculpante do art. 35.º

§ 14 Nos termos do art. 35.º-1, "age sem culpa quem praticar um facto ilícito adequado a afastar um perigo actual, e não removível de outro modo, que ameace a vida, a integridade física, a honra ou a liberdade do agente ou de terceiro, quando não for razoável exigir-lhe, segundo as circunstâncias do caso, comportamento diferente". Esta primeira — e mais importante tanto de um ponto de vista teorético, como normativo-prático — manifestação legalmente consagrada do princípio da inexigibilidade supõe, tal como o estado de necessidade justificante, uma **colisão de bens jurídicos**. Trata-se, na verdade, da consagração daquela concepção *diferenciadora* ou *dualista* do estado de necessidade que supra considerámos (16.º Cap., § 1). Por isso se compreende que muitos dos requisitos do estado de necessidade justificante devam ser repetidos para o estado de necessidade desculpante: o perigo para bens jurídicos, a adequação do meio, a sua necessidade, etc. Restando todavia saber se eles assumem no presente contexto um conteúdo e um significado essencial ou mesmo inteiramente correspondentes; ou, diversamente, impõem por regra o seu repensamento, ou ao menos o seu ajustamento, em função do especial fundamento do estado de necessidade desculpante e, em particular, das diferentes exigências de **hierarquia dos bens em conflito**. Uma

---

que perfaça noutrem uma excisão clitoridiana. Sobre o ponto, em sentido contrário ao acabado de expor, cf. o estudo de DIAS, Silva, Faz sentido punir o ritual do *fanado*? Reflexões sobre a punibilidade da excisão clitoridiana, *RPCC 16*, 2006, que conclui (p. 237): "Muitas situações de excisão conduzirão, como referi, à exclusão da culpa (...) — no caso das mães — por ocorrência de um estado de necessidade desculpante".

(22) NEVES, Curado, nota 1, pp. 716 e 740 e s.

exclusão da culpa em nome de um estado de necessidade desculpante só entrará, na verdade, em questão quando não esteja em causa a salvaguarda de bens jurídicos claramente preponderantes mas, bem ao contrário, quando se salvaguardem bens **inferiores, iguais** ou no máximo **não sensivelmente superiores** ao bem jurídico lesado.

§ 15 Uma vez mais, não falta quem entenda que a exclusão da punição em casos de estado de necessidade desculpante derivaria do **somatório** do efeito de diminuição da culpa (supra, § 4) com o de **diminuição do conteúdo ilícito** do facto. E isto porque, nestes casos, se é verdade que o agente lesa, com o seu facto, um bem jurídico, a verdade é que salva também o outro bem jurídico conflituante, se bem que de hierarquia inferior, igual ou não manifestamente superior à do bem jurídico lesado ([23]). Mas a argumentação não procede. Suposta a comprovação autónoma, no caso, de uma situação de inexigibilidade e ainda que se aceite uma eventual diminuição do ilícito, não é esta diminuição, em todo o caso, mas a **ausência de culpa** que conduz à exclusão da punição. Por isso é que *pode* o estado de necessidade desculpante obstar à punição tanto daquele que, para salvar a sua vida, causa a morte de uma pessoa, como daquele outro que causa a morte de duas ou dez; como *não conduz* à exclusão da culpa o facto daquele que, para salvar os seus bens de um incêndio, causa uma ofensa grave, em maior ou menor medida, à integridade física de outro ([24]).

1. O perigo actual e não removível de outro modo

§ 16 No que toca a este requisito, devemos remeter-nos basicamente à exposição correspondente feita a propósito do estado de necessidade justificante (supra, 16.º Cap., § 8 e ss.). Cabe em todo o caso sublinhar que aqui, com particular razão, se deverá fazer da **actualidade do perigo** um conceito **mais amplo** do que o da actualidade da agressão para efeito de legítima defesa, nomeadamente, em tema daquilo que chamámos "perigos duradoiros". Abusos nunca poderão em definitivo verificar-se perante a cláusula de inexigibilidade, segundo a qual é indispensável ao efeito excludente da culpa que não seja razoável exigir do agente, *segundo as circunstâncias do caso*, comportamento diferente. Já quanto à cláusula de que o perigo **não seja removível de outro modo** se deve ser, em princípio, tão estrito quanto em matéria de estado de necessidade justificante: não pode reivin-

---

([23]) Assim, na esteira de KAUFMANN, Armin, nota 5, p. 156 e ss., cf. só JESCHECK / WEIGEND, § 43, III, 2, b e os aí recenseados.

([24]) Neste sentido, por último, ROXIN I, § 22, n.º 10.

dicar-se do estado de necessidade desculpante o soldado que, sujeito a sevícias físicas ou morais do seu superior imediato, pode queixar-se ao comandante e todavia, em vez disso, deserta; como tão-pouco alguém sujeito a sevícias repetidas da parte do seu cônjuge ou do seu pai pode matá-lo se, em vez disso, seria possível fugir de casa ou queixar-se à autoridade. Mas não está excluído que, em alguns casos destes, se possa remeter uma solução definitiva para a cláusula estrita da inexigibilidade. Que o perigo não seja removível de outro modo implica igualmente, ao menos também em princípio, que se escolha o meio adequado *menos oneroso* para os direitos do terceiro não implicado: quem pode salvar-se de um perigo de morte ferindo um terceiro não implicado não pode matá-lo para depois se escudar na cláusula da inexigibilidade. Para todos os bens jurídicos susceptíveis de fundarem um estado de necessidade desculpante deve, finalmente, valer a cláusula de que não pode tratar-se da sua ameaça por **perigos insignificantes**: ainda isto resulta, de resto, da cláusula de inexigibilidade.

2. Os bens susceptíveis de serem lesados

§ 17 Uma vez que no estado de necessidade desculpante se não trata — diversamente do que ocorre com o direito de necessidade — da vontade da ordem jurídica de preservação de bens jurídicos mais valiosos à custa de bens jurídicos de menor valor, mas de ser ou não exigível do agente, na concreta situação, um comportamento adequado ao direito, compreende-se que, segundo a lei positiva, a exclusão da culpa só possa ocorrer quando se trata de preservar determinados **bens jurídicos individuais elementares**: concretamente, a vida, a integridade física, a honra ou a liberdade. Dúvidas legítimas podem, porém, suscitar-se neste contexto. Desde logo quanto ao bem jurídico **vida**, nomeadamente quanto a saber se tem de tratar-se da "vida *de pessoa já nascida*" do art. 131.º e ss. ([25]) ou pode também tratar-se da "vida *intra-uterina*" do art. 140.º e ss.; esta última é a conclusão a que se dirige a doutrina alemã dominante ([26]) e aquela para que propendemos, tanto mais quanto, ainda aqui, abusos poderão ser impedidos através da cláusula da inexigibilidade. Já no que toca ao bem jurídico da **integridade física**, não vemos maneira de o fazer equi-

([25]) Assim, na doutrina alemã, HIRSCH, *LK*, § 35, n.º 12, e ROXIN I, § 22, n.º 24.

([26]) Pela qual pode ver-se JAKOBS, 20/8, RUDOLPHI, *SK*, § 35, n.º 5, e S / S / LENCKNER / / PERRON, § 35, n.º 5.

valer a quaisquer ofensas à integridade corporal ([27]), por exemplo, aquelas em que se analisam os crimes sexuais. Estas caberão porém, em nosso parecer ([28]), nos perigos para a **liberdade**: decerto que se não tem aqui em vista todas as manifestações do direito *geral* de liberdade; mas não se vê por que às manifestações da liberdade pessoal tuteladas pelo art. 153.º e ss. não devam acrescer as manifestações da liberdade e autodeterminação *sexual* protegidas pelo art. 163.º e ss. ([29]).

§ 18 O perigo deve ameaçar bens jurídicos do agente **ou de terceiro**. É altamente contestável esta doutrina, com a amplitude que a lei lhe atribui: não pode esquecer-se ou minimizar-se que não está aqui em causa a salvaguarda de bens jurídicos preponderantes; pelo que a intervenção na esfera jurídica do lesado não implicado na situação, em nome da salvaguarda de bens jurídicos alheios, surgirá como altamente problemática; pelo menos quando a circunstância de se tratar de bens jurídicos de terceiro não seja susceptível de provocar sobre o agente uma **pressão igual ou análoga** à que teria lugar se os bens jurídicos em perigo fossem do agente. Por essa razão, na Alemanha, p. ex., o § 35 I restringe a desculpa aos casos em que o perigo ameace "um parente ou outra pessoa próxima" do agente. Na falta de uma restrição deste teor, entre nós, uma vez mais a solução correcta estará no funcionamento da cláusula de inexigibilidade, *segundo as circunstâncias do caso*: só ela poderá tornar aceitável a extensão em bloco da possibilidade de exclusão da culpa relativamente aos bens jurídicos de *quaisquer* terceiros.

§ 19 Em todo o caso, a largueza com que a nossa lei admite a extensão do estado de necessidade desculpante conduz a que se não torne indispensável, nem porventura conveniente, ao contrário do que sucede na Alemanha, a construção de uma **desculpa supra-legal** para acorrer a casos (como o dos chamados "médicos de Hitler": cf. supra, 16.º Cap., §§ 21 e 42) em que o agente — geralmente por força de **ordens criminosas do poder do Estado** ou no seio de uma **comunidade de perigo** — sacrifica um certo número de vidas como meio de salvar a vida de um (muito) maior número de pessoas. Num direito como o alemão o apelo ao estado de

([27]) Ao contrário da generalidade da doutrina alemã (cf., só, JAKOBS, 20/8, e JESCHECK / WEIGEND, § 44, I, 1), mas convindo não esquecer que o § 35, I, do CP alemão fala directamente de perigos para o "corpo" (*Leib*).

([28]) Contra a interpretação estrita, dominante na literatura alemã, STRATENWERTH / KUHLEN, § 10, n.º 104, e S / S / LENCKNER / PERRON, § 35, n.º 8.

([29]) Assim, também, HIRSCH, *LK*, § 35, n.º 15, e ROXIN I, § 22, n.º 28.

necessidade desculpante está excluído porque se não trata de salvar bens jurídicos do agente ou de uma pessoa próxima, tornando-se indispensável apelar a uma causa supra-legal de exclusão da culpa ([30]); mas esta dificuldade não existe, como se vê, no direito penal português. Sem prejuízo daquelas hipóteses excepcionais em que deva já considerar-se o facto como lícito a coberto de um direito de necessidade (supra, 16.º Cap., § 22 e s.).

3. A cláusula de inexigibilidade e o seu significado

§ 20 O art. 35.º-1 não desculpa o facto quando nele convirjam os elementos acima referenciados, mas apenas quando, para além daqueles pressupostos, **não seja razoável exigir do agente, segundo as circunstâncias do caso, comportamento diferente**. É nesta exigência que se contém aquilo que chamamos a verdadeira cláusula de inexigibilidade e para interpretação da qual necessário se torna o recurso directo ao fundamento que àquela apontámos no contexto de um direito penal da culpa. Enquanto, *v. g.*, no direito alemão ([31]), nos casos *normais*, a exclusão da culpa decorre, como um corolário, dos requisitos *objectivos* relacionados com o perigo e o bem jurídico ameaçado, isso não sucede no direito português, onde se torna *sempre* indispensável que o juiz comprove que não era razoável exigir do agente, segundo as circunstâncias do caso, comportamento diferente. O que constitui um critério claramente pessoal — como se impõe ao nível da culpa —, sem por isso se tornar meramente individual, antes merecendo ainda a caracterização de critério *pessoal-objectivo*: um certo dever de suportar perigos (não apenas gerais, o que é evidente, mas também concretos) é inafastável. Se — digamos assim — o paradigma da inexigibilidade não é, como atrás se disse, o do "herói moral", tão-pouco pode ser o do "poltrão": um mínimo de força de resistência, normativamente determinado, é sempre necessário, sob pena de o

---

([30]) Por outros — embora com justificações diferenciadas —, STRATENWERTH / KUHLEN, § 10, n.º 124 e s. No mesmo sentido decide a jurisprudência alemã.

([31]) Onde, desde logo, a construção formal do preceito correspondente (§ 35, I) do CP é diferente da do nosso art. 35.º-1: cf. DIAS, Figueiredo, Sobre o estado actual da doutrina do crime, *RPCC 2*, 1992, p. 27 e nota. Decididamente a favor do sistema alemão e contra o português — criticando nesta base, é dizer, na base de um sistema diferente do nosso, a concepção aqui defendida — ROSA, Cortes, *in*: Eser / Perron (orgs.), *Rechtsfertigung und Entschuldigung*, III, 1991, p. 390 e s., e Die Funktion der Abgrenzung von Unrecht und Schuld im Strafrechtssystem, *Coimbra-Symposium Roxin*, p. 188 e ss. Sobre o problema aqui implicado, cf. a minuciosa análise de ANTUNES, Maria João, *Medida de Segurança de Internamento e Facto de Inimputável em Razão de Anomalia Psíquica*, 2002, pp. 331 e ss., 337 e ss., 406 e ss.

facto aparecer fundamentado por qualidades pessoais e da atitude juridicamente censuráveis ([32]).

§ 21 A consequência praticamente mais importante que dali deriva é a de que a desculpa deve em definitivo ser negada sempre que **a lei exija do agente que suporte o perigo**. A mais clara manifestação desta situação é porventura a das hipóteses em que sobre o agente recai um *particular dever de suportar* (cf., já, supra, § 11) derivado de ele se encontrar em uma **situação jurídica** (gozar de um **estatuto jurídico) especial** ([33]). Trata-se nomeadamente do exercício de determinadas profissões ou da ocupação pelo agente de certas posições sociais a que se liga — ou legal, ou co-naturalmente — o dever de suportar perigos acrescidos ou perigos especiais (típicos, em todo o caso, e não generalizados: polícias, bombeiros, soldados, marinheiros, etc.). Não pode aqui aceitar-se a intervenção da cláusula de inexigibilidade se a ameaça se mantém dentro da área típica de perigos que o agente tem o dever de correr ou de suportar; e será mesmo duvidoso que possa creditar-se ao agente uma *atenuação da pena* em função da diminuição da culpa, se bem que tudo dependa, em última análise, da espécie de qualidades pessoais manifestadas no facto e da sua maior ou menor censurabilidade ([34]).

§ 22 Outro grupo de casos em que deve colocar-se a questão da obrigação de suportar o perigo relaciona-se com aquelas hipóteses em que o perigo **foi voluntariamente causado pelo próprio agente**. Na falta, em matéria de estado de necessidade desculpante, de uma disposição análoga àquela com que deparámos no estado de necessidade justificante (art. 34.º/*a)* e supra, 16.º Cap., § 9) ([35]), pode perguntar-se se esta circunstância é susceptível de pura e simplesmente afastar a exclusão da culpa ou, no outro extremo, deve considerar-se irrelevante e deixar funcionar plenamente o estado de necessidade desculpante. Cremos que, todas as circunstâncias pon-

([32]) Na conclusão, também, STRATENWERTH / KUHLEN, § 10, n.º 112.

([33]) No essencial correspondente ao que a doutrina jurídico-constitucional chamava tradicionalmente "relações especiais de poder": cf. ANDRADE, Vieira de, *Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976*, ³2004, p. 303 e ss.

([34]) Terminante, no sentido de *negar* a atenuação nestes casos, o § 35, I, 2.ª parte, do CP alemão.

([35]) Diferentemente do § 35, I, 2.ª parte, do CP alemão, que regula expressamente a questão. O que não impede que a sua interpretação dê lugar aos maiores dissensos doutrinais: com uma larga panorâmica depara-se em ROXIN I, § 22, n.º 44 e ss.

deradas, uma solução de certo modo análoga à que vale para o estado de necessidade justificante deve ser preconizada: se o perigo é *intencionalmente* provocado pelo agente, nomeadamente, na mira de poder mais tarde reivindicar-se de uma desculpa por estado de necessidade, esta deve ser em definitivo negada. Em todas as hipóteses restantes não vemos razão bastante para que se negue *a priori* a possibilidade de exclusão da culpa: tudo deverá depender do resultado a que conduza a apreciação em concreto da questão da inexigibilidade.

§ 23 Para certos autores, um outro grupo de casos em que a exclusão da culpa deveria ser negada teria a ver com factos ocorridos no seio de uma **comunidade de perigo voluntariamente criada.** Se, no passeio de um grupo a uma montanha, um perigo natural atinge um dos participantes, este não deveria poder afastá-lo à custa de outro participante; e do mesmo modo quando sobre o agente recai, relativamente à vítima potencial, um especial **dever de protecção ou de cuidado** (36). Não cremos, todavia, que qualquer destes casos, ao lado dos quais muitos outros poderiam então figurar-se, mereçam no nosso direito um tratamento especial, tudo devendo ficar para a pura aferição, *in casu*, da cláusula de inexigibilidade.

§ 24 Já, porém, uma consideração de outro tipo merece particular atenção neste contexto: a de saber se e em que termos a **proporção** ou **desproporção** dos bens jurídicos conflituantes deve, em último termo, influenciar a própria cláusula de inexigibilidade. A possibilidade de desculpa tem lugar, já o sabemos, em três hipóteses: na de os bens conflituantes possuírem *a mesma hierarquia*; na de o bem salvaguardado ser *superior, mas não sensivelmente superior*, ao bem lesado; e na de aquele ser *inferior* a este. É nesta última hipótese que pode nascer o problema: o de saber se, sendo o bem salvaguardado **sensivelmente inferior** ao bem lesado, não deve considerar-se pura e simplesmente excluído do quadro do estado de necessidade desculpante na base de que, ainda aqui, o agente *deve suportar o perigo* (37). *V. g.*, quando *A* produz em *B* uma ofensa *grave* à sua integridade física para afastar de si o perigo de um *leve* ferimento; ou quando *C* mutila *D* para afastar o perigo de um ferimento relativamente grave mas reparável. Cremos que uma recusa de princípio de exclusão da culpa só deve ter lugar em caso de **crassa desproporção** dos bens em jogo, devendo todos os restantes casos ser decididos em função da cláusula da inexigibilidade na situação.

(36) Assim, STRATENWERTH / KUHLEN, § 10, n.º 110.

(37) Doutrina dominante na Alemanha, pela qual pode ver-se S / S / LENCKNER, § 35, n.º 33.

4. O elemento subjectivo

§ 25 Apesar de poder colher-se sugestão diferente do teor dos textos legais, no estado de necessidade desculpante — diversamente do que vimos suceder no estado de necessidade justificante: supra, 16.º Cap., § 32 —, como será evidente à luz do seu fundamento e da sua estrutura, o facto só pode excluir a culpa quando o agente tenha, com ele, **prosseguido a finalidade** de salvação do bem jurídico ameaçado. Não pode esquecer-se nem minimizar-se, neste contexto, a circunstância de que no estado de necessidade justificante o agente pratica um facto lícito (conforme ao direito), no simplesmente desculpante um facto *ilícito* e, por conseguinte, *juridicamente desaprovado* ([38]). Isto haverá que opor à opinião segundo a qual também aqui bastaria que o agente actuasse com conhecimento da necessidade e de que o seu facto a evitará ([39]). Não será necessário que o agente actue por motivos nobres ou que a sua finalidade última seja a salvação do bem jurídico em perigo; mas torna-se indispensável que ele pratique a acção *para* — sejam quais forem os motivos últimos — determinar com ela a preservação do bem jurídico ameaçado.

5. A possibilidade de atenuação especial ou de dispensa de pena

§ 26 Nos termos do art. 35.º-2, "se o perigo [tido em vista no estado de necessidade desculpante do art. 35.º-1] ameaçar interesses jurídicos diferentes dos referidos no número anterior, e se verificarem os restantes pressupostos ali mencionados, pode a pena ser especialmente atenuada ou, excepcionalmente, o agente ser dispensado de pena". Dir-se-ia assim — e não falta quem entre nós o afirme ([40]) — que do que aqui se trata é de um **alargamento** da figura do estado de necessidade desculpante, podendo servir para ela de fundamento o perigo para *quaisquer interesses jurídicos* diferentes da vida, da integridade física, da honra ou da liberdade; tanto mais quanto o preceito em referência exige que se verifiquem os restantes pressupostos do estado de necessidade desculpante. Teríamos pois que a esta regulamentação estaria subjacente a ideia da aceitação da inexigibilidade como causa *geral* de desculpa, em todo o caso com a concessão de que o seu efeito não seria o da exclusão da culpa mas o da sua

([38]) Nestes termos, ROXIN I, § 22, n.º 32 e ss.

([39]) JAKOBS, 20/11.

([40]) Especialmente DIAS, Silva, *A Relevância Jurídico-Penal das Decisões de Consciência*, 1987, p. 152 e s., em crítica directa à posição que tomáramos no nosso escrito Pressupostos da punição e causas que excluem a ilicitude e a culpa, *JDC 1983*, p. 80. Como no texto, DIAS, Figueiredo, Dos factos de convicção aos factos de consciência: uma consideração jurídico-penal, *Ab uno ad omnes*, 1999, p. 607 e [83].

simples atenuação ou, excepcionalmente, o da dispensa de pena. O que teria sobretudo como consequência que ainda neste contexto se depararia com um autêntico problema de **culpa**; daí resultando que a regulamentação seria criticável por não ter tido a coragem de levar o pensamento até ao fim, determinando a exclusão da culpa quando, também nestes casos, se devesse concluir que não era exigível do agente um comportamento adequado ao direito.

§ 27 Não é impossível — sendo até provável — que, em perspectiva *histórica*, a motivação do preceito tenha sido aquela que acabou de referir-se (sobretudo quando se leve em conta que o Autor do ProjPG de 1963, Eduardo Correia, defendia a inexigibilidade como causa *geral* de exclusão da culpa, ideia que traduziu no art. 45.º do seu ProjPG). A verdade porém é que não foi esse — acertadamente — o pensamento que no art. 35.º-2 ficou consignado. Não se trata nele nem de uma *extensão* do conceito de estado de necessidade desculpante, nem sequer de um problema de *culpa*. O legislador considerou, no art. 35.º-1, os casos de estado de necessidade desculpante em função daquilo que considerou exigível do agente: o critério é, como temos repetidamente acentuado, inevitavelmente *normativo*. No n.º 2 considerou coisa diferente, a saber, casos em que reputa — aqui tem razão Roxin com a sua categoria da "responsabilidade" — diminuídas ou inexistentes as exigências preventivas. Por outras palavras: no caso do art. 35.º-2 a culpa (e o seu reconhecimento pela ordem jurídica) persiste, porventura diminuída; o que falta — como em toda a dispensa de pena, mas agora sem atenção ao limite máximo da moldura penal aplicável ao facto: cf. art. 74.º-1, proémio ([41]) — é a **necessidade de pena**. Em suma, o n.º 2 do art. 35.º não refere uma *causa de diminuição ou de exclusão da culpa*, e portanto um problema de *culpa*; refere uma **causa de diminuição ou de exclusão da pena**, e portanto um problema de **carência de pena** (infra, 26.º Cap., § 15 e ss.).

6. A aceitação errónea de uma situação de estado de necessidade desculpante

§ 28 Nos termos do art. 16.º-2, última parte, o erro sobre um estado de coisas que, a existir, excluiria a culpa do agente, **exclui o dolo**, só permanecendo em aberto a eventualidade de punição do agente a título de **negligência** (art. 16.º-3). De um ponto de vista prático-normativo, porém, o problema aqui implicado só se suscita verdadeiramente nas situações de necessidade ou análogas ([42]), sendo difícil (ou impossível) excogitar a hipótese de um erro sobre a inimputabilidade ou sobre o excesso não cul-

([41]) Sobre o instituto da dispensa da pena, o nosso *DP II*, § 467 e ss.

([42]) Como ainda, porventura, no caso de não representação dos pressupostos de elementos contidos no tipo de culpa dolosa: cf. supra, 20.º Cap., § 46 e ss.

poso de legítima defesa. Compreender-se-á, por isso, que a questão seja tratada no presente enquadramento (43).

§ 29 Que o problema não tem, em princípio, nada a ver com o do erro sobre a factualidade típica (e constelações análogas) regulado no art. 16.º-1, nem com o da falta de consciência do ilícito regulado no art. 17.º, parece evidente. O agente que erra sobre os pressupostos de um estado de necessidade desculpante (*v. g.*, o náufrago de Karneades que empurra para longe o companheiro que quer agarrar-se à tábua, porque está erroneamente convencido que esta só suporta o peso de um), **actua com dolo do tipo** e, além disso, **com consciência do ilícito**. A esta luz se diria portanto que o erro não pode deixar de ser **irrelevante**. Tudo será questão, acrescentar-se-á, apenas da cláusula de inexigibilidade: se o seu efeito desculpante reside na situação de "conflito espiritual" que cria para o agente, tanto importará que o perigo exista na realidade como que derive só do quadro de circunstâncias que foram representadas pelo agente como existentes, pois também neste último caso não poderá negar-se *a priori*, ao conflito assim criado, um possível efeito desculpante. Só que se assim é, então também a solução do problema não deveria suscitar dúvidas de maior: o que se torna necessário é determinar se, no quadro das circunstâncias pelo agente representadas, lhe era ou não exigível outro comportamento: se não, a culpa deve considerar-se excluída, nomeadamente quando o erro era inevitável (44); se sim, o agente deve ser punido e, na verdade, a título de *dolo*.

§ 30 A esta tese — que cremos poder crismar como **tese da inexigibilidade**, por ser a esta luz que o problema deve ser, segundo ela, completamente decidido — se opõe todavia uma outra segundo a qual a solução, em caso de erro censurável, não deve decorrer tanto do pensamento da inexigibilidade, quanto sobretudo da *espécie de erro* em causa, para tanto lançando mão, por analogia — podendo por isso falar-se, a este propósito, justamente de uma **tese da analogia** —, do tratamento do erro sobre os pressupostos de um obstáculo à ilicitude. E uma vez que este erro

(43) Em pormenor sobre ela e propugnando pela solução que se avançará no texto cf., já, o nosso *O Problema*, § 21, IV.

(44) Nestes termos, expressamente, o § 35, II, do CP alemão, à volta do qual veio a perfilar-se a doutrina hoje praticamente unânime: cf. só ROXIN I, § 22, n.º 59 e ss., e STRATENWERTH / / KUHLEN, § 10, n.º 119 e ss.

deve, como vimos (supra, 14.º Cap., § 23 e ss.) e a nossa lei prescreve (art. 16.º-2, 1.ª parte), excluir o dolo, então a mesma solução deve ser preconizada para o erro sobre os pressupostos de um obstáculo à culpa, nomeadamente do estado de necessidade desculpante: um tal erro **exclui o dolo**, podendo o agente vir a ser punido, se disso for caso, apenas a título de **negligência** (45). O próprio Roxin abundava aliás nesta solução (ao menos para os casos em que o agente não tivesse ampla oportunidade de comprovar a situação), com o argumento de que o que nestas hipóteses sucede é que "uma prima causa produzida por negligência origina uma violação dolosa de bens jurídicos que, como tal, é desculpável, mas não pode excluir o carácter imputável da primeira causa. De um ponto de vista construtivo tratar-se-ia aqui como que de uma variante, até hoje mal entrevista, da *actio libera in causa*" (46).

§ 31 O art. 16.º-2, última parte, pronuncia-se expressamente a favor da tese da analogia e contra a tese da inexigibilidade. A nosso ver com razão, desde que à tese se dê o entendimento seguinte: o de que são fundamentalmente exactas a forma como a tese da inexigibilidade **põe** o problema e a forma como a tese da analogia o **soluciona**. Se, apesar do erro em que o agente incorreu, lhe era exigível outro comportamento, então o erro é irrelevante e a punição deve ocorrer a título de dolo: verdadeiramente não se trata aqui da aceitação errónea dos pressupostos de uma causa de exclusão da culpa, mas da falsa suposição de que o direito liga às circunstâncias erroneamente aceites a consequência da exclusão da culpa. Aqui, por isso, só é pensável uma relevância do erro pela via de uma falta de consciência do ilícito (art. 17.º) com que ele porventura se encontre conexionado.

§ 32 Se, porém, por virtude do erro em que o agente incorreu, se lhe torna inexigível outro comportamento, seria interromper demasiado cedo a investigação concluindo logo pela ausência de culpa: esta só pode afirmar-se se o erro não for censurável. Se for censurável, importa determinar que tipo de erro está em causa e qual a sua influência sobre a culpa

---

(45) Assim, entre outros, ENGISCH, Die normative Tatbestandselemente im Strafrecht, *Mezger-FS*, 1954, p. 133[1], GALLAS, Die dogmatische Teil des Alternativentwurfs, *ZStW 80*, 1968, p. 31, e SCHRÖDER, Die Notstandsregelung des Enwurfs 1959 II, *Eb. Schmidt-FS*, 1961, p. 299.

(46) ROXIN, Die Behandlung des Irrtums im Entwurf 1962, *ZStW 76*, 1964, p. 612.

do facto. O erro, em si mesmo considerado, torna-se fundamento do facto e é a censurabilidade do erro que fundamenta a censurabilidade do facto; há-de ser por isso a *forma de censura do erro* que vai fundamentar a *forma de censura do facto*. E se nestes casos o erro se traduz indiscutivelmente, segundo o tipo de censura que o atinge, em uma falta de cuidado e atenção para com a situação em que a conduta se insere — se ele é, nesta acepção, um **erro de conhecimento**, um **erro intelectual**, um **erro da consciência intencional** —, então ele **exclui o dolo** e só deixa persistir a eventualidade de uma punição do agente a título de **negligência**.

§ 33 Também neste contexto, Cortes Rosa defende a solução da lei alemã contra a da lei portuguesa. E acusa a nossa posição de dois erros: o primeiro, o de esquecer que, desde o momento em que a concepção psicológica da culpa foi ultrapassada (1907!), se aceita que "nos casos de estado de necessidade desculpante se pode negar na verdade a culpa, mas não o dolo do agente"; o segundo o de, fazendo valer o tipo de censura do erro como tipo de censura do facto, esquecer afinal uma diferença de *culpa*: a "diferença entre a culpa de um agente cujo erro (evitável) em que se encontra impede à partida a via para a percepção do ilícito do facto, e a culpa de um outro agente que age com consciência da ilicitude e apesar disso não se sente motivado para ao menos comprovar se a finalidade por ele prosseguida de proteger determinados bens jurídicos exige na realidade o cometimento do facto típico e ilícito" ([47]). Estas acusações são, à luz das concepções fundamentais que expusemos, improcedentes. A primeira resume-se à circunstância de para Cortes Rosa o dolo se esgotar no ilícito-típico e nada sobrar, por conseguinte, para um autónomo dolo da culpa ou, se preferirmos, para uma categoria autónoma da "culpa dolosa". A segunda esquece, por um lado, que já em caso de erro sobre os pressupostos de uma causa de justificação o dolo do tipo (para Cortes Rosa: o "dolo", pura e simplesmente) se encontra completamente verificado — tão verificado como em caso de erro sobre os pressupostos de um estado de necessidade desculpante; e, por outro lado, que, assim sendo, em um caso como no outro o que pode ser negada é a documentação no facto, por virtude do *erro de conhecimento* em que o agente incorreu, de uma atitude pessoal contrária ou indiferente ao dever-ser jurídico-penal.

III. O excesso de legítima defesa desculpante

§ 34 Verifica-se excesso de legítima defesa sempre que o agente, numa situação de legítima defesa, se serve de um **meio** mais lesivo para o agressor do que aquele que seria necessário (art. 33.º-1), sempre que, por outras palavras, ele **ultrapassa a medida da necessidade do meio** (supra,

([47]) Rosa, Cortes, *Coimbra-Symposium* nota 31, p. 188 e s.

15.º Cap., § 26 e s.). Por isso se chama a este excesso — o único que aqui parece entrar em consideração ([48]) — **excesso nos meios** de legítima defesa. Nos termos do art. 33.º-2, o agente não será punido "se o excesso resultar de perturbação, medo ou susto não censuráveis".

§ 35 O **fundamento** de toda esta regulamentação é, desde há muito, incontestado no essencial. É normal — e, ademais, compreensível — que uma agressão ilícita e actual provoque na vítima um **estado de afecto** (ou se preferirmos a designação antiga: um **estado passional**) que o conduza a uma reacção (defesa) excessiva; o facto não preencherá então a causa justificativa da legítima defesa, pelo que, como bem afirma o art. 33.º-1, ele é ilícito. Mas facilmente se aceitará que aquele estado de afecto possa não só diminuir porventura o conteúdo ilícito do facto, mas também — identicamente ao que vimos suceder no estado de necessidade desculpante: supra, § 10 — afectar ou estorvar o cumprimento das "intenções normais" do agente. Por isso, logo o art. 33.º-1, 2.ª parte, estatui que o excesso **pode** conduzir a uma atenuação especial da pena (arts. 72.º e 73.º), na medida em que a atitude e as qualidades pessoais do agente manifestadas no facto se revelem menos censuráveis.

§ 36 Taipa de Carvalho sustenta que a atenuação especial da pena deveria ser, em qualquer caso de excesso, **obrigatória** e não meramente facultativa; e isto porque, logo de acordo com um princípio vitimológico, o *grau do ilícito* praticado (independentemente dos efeitos que lhe possam ser assacados em tema de culpa) apareceria sensivelmente diminuído ([49]). Não parece, porém, que tenha de ser assim, antes devendo admitir-se que, em muitos casos, nomeadamente, de excesso por afecto esténico, o excesso surge a uma consideração objectiva como absolutamente *injustificado*, não tendo por isso de lhe ser atribuído aquele efeito de sensível diminuição do ilícito: fazer relevar neste contexto a ideia de que o risco de produção de danos mais graves do que os necessários recai sobre o agressor aproxima-se perigosamente da fundamentação da responsabilidade numa ideia de *versari in re illicita*. De resto, coisa

([48]) Doutrina que correspondia já ao ensino de SANTOS, Beleza dos, *Obstáculos*, p. 66 e ss., e CORREIA, Eduardo, II, n.º 13, III, à face do nosso CP de 1886 e é agora veementemente defendida por CARVALHO, Taipa de, *A Legítima Defesa*, 1995, p. 345 e ss. Diferentemente, FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, n.º 134, para quem o excesso abrangeria também o *excesso na causa*, isto é, aquelas hipóteses em que alguém, tendo provocado outrem, se defende perante uma reacção desproporcionada do provocado. Cf., todavia, infra, § 40.

([49]) CARVALHO, Taipa de, nota 48, p. 351 e ss., aprofundando uma tese já defendida entre nós por NEVES, Castanheira, *A Legítima Defesa* (dissertação do Curso Complementar não publicada), 1954, p. 352 e ss.

análoga pode suceder com o excesso nos meios em outras causas de justificação, sobretudo no estado de necessidade, sem que o legislador tenha sentido necessidade de construir uma regulamentação análoga à do art. 33.º ([50]). Indiscutível é só, diferentemente, o efeito que o excesso pode exercer sobre a culpa, no sentido da sua diminuição ou exclusão. Todo o restante parece ser questão da "imagem global do facto" e, nesta acepção, uma questão de (maior ou menor) carência de punição que deve ser resolvida de acordo com a doutrina (autónoma) da medida da pena e da sua (eventual) atenuação extraordinária ([51]).

§ 37 Mais complexo, mas nem por isso menos seguro, parece ser o **fundamento** da regulamentação nos casos em que o estado de afecto não só estorva, como verdadeiramente *impede* o cumprimento daquelas intenções. Mas que tal aconteça não basta para a desculpa, ou melhor, só poderia bastar se a culpa fosse concebida como poder de agir de outra maneira na situação, como concreta capacidade do agente para se deixar motivar pela norma. A desculpa só ocorrerá, nos termos legais (art. 33.º-2), quando o excesso tiver sido provocado pelo chamado **afecto asténico**, isto é, nas palavras da lei, por **perturbação, medo ou susto não censuráveis**. Deparamos aqui com a mais decidida e terminante confirmação do bom fundamento da concepção da culpa e das causas da sua exclusão que vimos advogando. A circunstância de não ser um qualquer estado de afecto que desculpa o excesso, mas apenas o estado de afecto *asténico* (a perturbação, o medo, o susto, mas já não, p. ex., o ódio, a cólera ou o sentimento de vingança!) mostra à saciedade: em primeiro lugar, que o critério decisivo da culpa jurídico-penal não é o real psicológico, mas sempre o *normativo*; mostra, depois, que a exclusão da culpa depende deste ponto de vista normativo, de carácter pessoal-objectivo, e não de um concreto poder de agir de outra maneira na situação ou de determinação pela norma: pois a verdade é que a "pressão" psíquica ou espiritual do afecto sobre a prática do facto pode ser exactamente a mesma, quer o afecto seja asténico ou esténico — e todavia, só aquele, não este, tem a virtualidade de excluir a culpa; mostra, por último, que a culpa jurídico-penal é na verdade, como vimos dizendo, o ter que responder pelas qualidades pessoais (e a correspectiva "atitude") manifestada no facto quando essas qualidades são juridicamente desaprovadas e, neste sentido, censuráveis.

([50]) Ainda mais longe vão JAKOBS 20/28[44], e ROXIN I, § 22, n.º 72, duvidando que possa em qualquer caso de excesso falar-se de uma diminuição do ilícito. No mesmo sentido, entre nós, já, CORREIA, Eduardo, II, p. 63.

([51]) Sobre isto, o nosso *DP II*, § 444 e ss.

§ 38 Deste modo, o **afecto esténico** nunca poderá relevar em questão de excesso de legítima defesa: a única via pela qual ele poderá ganhar significado para a responsabilidade do agente será, eventual e excepcionalmente decerto, pela da *inimputabilidade* (ou imputabilidade diminuída) do art. 20.º Casos talvez possam existir, por outro lado, em que no facto **concorram** afectos asténicos e esténicos: em casos tais sustenta-se não haver outra solução que não seja a de creditar ao agente o regime do art. 33.º sempre que possa afirmar-se que o afecto asténico foi o *dominante*, não assumindo o afecto esténico concorrente senão um lugar secundário (52). Pensamos porém que a comprovação de que um afecto esténico co-fundamentou o facto é, em princípio, incompatível com a "exclusão" da culpa, tudo devendo então ser remetido para a questão da *medida da pena*.

§ 39 Que a lei exija ainda que o afecto asténico que está na base do excesso seja, ele próprio, **não censurável** (tal como o exigia o E 1962, mas não o CP alemão vigente (53)) significa — como vimos suceder com a inexigibilidade no estado de necessidade desculpante: supra, § 20 — que ele deve ultrapassar aquela medida de intensidade que a ordem jurídica espera que seja suportável por todo o homem "fiel ao direito", que ele ultrapasse, se quisermos dizer assim, o critério da inexigibilidade (54). Se uma mulher se defende de um galanteador importuno que lhe faz observações indecorosas atingindo-o gravemente com um bastão, quando seria suficiente empurrá-lo ou dar-lhe uma bofetada, e se o "medo" que está na base do facto só é explicável porque aquela mulher tem tendência para ver em cada galanteador um tarado sexual perigoso, torna-se claro que este "medo" não pode ser aprovado pela ordem jurídica e não pode, por conseguinte, conduzir à desculpa.

§ 40 Até há pouco a doutrina e as jurisprudências eram praticamente unânimes no sentido de só considerar como conducente a uma exclusão da culpa o excesso intensivo, ou excesso nos meios, não o **excesso extensivo**, derivado da ultrapassagem pelo agente, na sua acção de defesa, de outros elementos de que depende esta justificação. Muito recentemente, porém, o problema do excesso extensivo e da sua eventual relevância passou a sus-

(52) Na conclusão, também, ROXIN I, § 22, n.ºs 76 e 80 e s.

(53) De novo a favor da solução alemã e contra a portuguesa, ROSA, Cortes, *Coimbra — Symposium* nota 31, p. 190, considerando — do nosso ponto de vista sem razão — a regulamentação do art. 33.º, nesta parte, como contendo "uma das soluções mais falhadas (...) do CP português vigente". Muito mais compreensivo para com a regulamentação portuguesa, ROXIN, Acerca da problemática do direito penal da culpa, *BFD XLIX*, 1983, p. 29 e s.

(54) Assim, também, logo, CORREIA, Eduardo, II, n.º 12.

citar-se cada vez mais quando referido ao elemento da **actualidade** da agressão. Sustenta-se que casos haverá em que o agente não ultrapassou, na sua reacção contra o "agressor", os *meios* necessários de defesa; o que sucedeu foi que ele reagiu ou antecipadamente a uma agressão figurada como certa, ou tardiamente a uma acção já terminada, e portanto, num caso como no outro, não actual. E isso pode bem ter acontecido por força de um afecto *asténico*, caso em que, paralelamente ao que sucede com o excesso intensivo, deveria excluir-se a culpa se o afecto for não censurável (55). Mas esta doutrina parece-nos — ao menos face à nossa lei — inaceitável. Como bem acentua Taipa de Carvalho, não só ela é incompatível com o teor literal do art. 33.º ("excesso dos *meios*"), como, verdadeiramente, um excesso extensivo, mesmo relacionado exclusivamente com a falta de actualidade da agressão, acaba por reconduzir-se ou a um facto doloso ilícito e culposo, ou a um erro sobre a legítima defesa (seja sob a forma de erro sobre os seus pressupostos, art. 16.º-2, seja, o que será mais frequente, a um erro sobre a ilicitude, art. 17.º: cf. supra, 14.º Cap., § 23 e ss.) (56).

§ 41 Importa finalmente decidir se o excesso tem de ser **inconsciente** ou pode também ser **consciente**. No nosso direito anterior esta questão estava mesmo no cerne da determinação do efeito que devia caber ao excesso, se simplesmente um efeito de atenuação geral ou de atenuação extraordinária (57). Hoje, porém, ela deve ser decidida num espaço livre de legislação e em função, por conseguinte, de considerações relevantes de índole geral. Entre nós e lá fora, a doutrina largamente dominante — embora se possa divisar, máxime na Alemanha, uma corrente minoritária significativa (58) — vai no sentido de que também o excesso (asténico) consciente é susceptível de conduzir à exclusão da culpa (59). Desde logo, não pode afirmar-se que um excesso consciente por perturbação, medo ou susto seja impensável: pelo contrário, muitas vezes acontecerá que o agente se excede conscientemente *por força* do estado asténico. Depois,

---

(55) Assim, ROXIN, Über den Notwehrexzess, *Schaffstein-FS*, 1975, p. 111 e ss., e I, § 22, n.º 84 e ss.

(56) CARVALHO, Taipa de, nota 48, § 14.3.

(57) Sobre a questão, com indicações, por último, CORREIA, Eduardo, II, n.º 13, III.

(58) Na qual se podem destacar WELZEL, § 14, II, 5, e S / S / LENCKNER / PERRON, § 33, n.º 6.

(59) SANTOS, Beleza dos, *Obstáculos*, p. 71 e ss., CORREIA, Eduardo, II, p. 67, FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, n.º 134, CARVALHO, Taipa de, nota 48, § 14.5; e, na Alemanha, ROXIN, nota 55, p. 107 e ss. (com indicações concordantes), e I, § 22, n.º 82 e s.

e decisivamente, os preceitos legais aplicáveis não distinguem uma e outra espécie de excesso; historicamente (o que, como vimos, é particularmente verdadeiro para o caso português) nunca se negou relevância ao excesso consciente; e, em concreto, dado precisamente o estado de afecto em que o agente actuou, é muito difícil, senão muitas vezes impossível, determinar se o excesso chegou ou não, como tal, ao nível da consciência intencional do agente. Tudo isto conduz à conclusão de que também o excesso *consciente* de legítima defesa por excesso asténico não censurável pode conduzir à desculpa.

23.º CAPÍTULO

A FALTA DE CONSCIÊNCIA DO ILÍCITO NÃO CENSURÁVEL (*)

I. A possibilidade de uma falta de consciência do ilícito como causa de exclusão da culpa

§ 1 À luz da forma como se pôs e resolveu o problema da falta de consciência do ilícito (supra, 20.º Cap., §§ 5 e ss. e 26 e ss.) poderia ser-se tentado a afirmar que a pergunta sobre se uma tal falta pode ser não censurável e, por essa razão, excluir a culpa não tem sentido. Se o fundamento de relevância de uma tal falta reside em um erro da consciência ética do agente pelo qual o agente tem de responder — assim se argumentaria —, parece ser então o próprio erro que fundamenta a censura e a culpa, não podendo haver lugar a qualquer desculpa (1). Dir-se-á, contra esta conclusão, ser chocante e até injusto imputar à culpa do agente, em muitas hipóteses, a responsabilidade pela não coincidência entre a sua valoração e a valoração do direito. Mas a isto se retorquirá que, por regra, não está em jogo, nessas "hipóteses chocantes", um erro da consciência ética — e portanto uma falta de consciência do ilícito —, mas ainda, em último termo, uma falta de *conhecimento* de preceitos jurídicos ou proibições legais cujo conhecimento seria razoavelmente indispensável para que o agente tomasse consciência do ilícito. Por isso poderia nesta concepção das coisas concluir-se que **não pode existir uma falta de consciência do ilícito não censurável**. Pois quando esta parece surgir, o que na realidade está em causa é ainda a questão de uma *correcta delimitação do âmbito da falta de consciência do ilícito em face do puro erro intelectual*.

(*) Sobre a matéria deste capítulo, cf. o nosso *O Problema*, § 16 e s.

(1) Retira esta consequência (criticamente), de uma concepção como a que defendemos, ROXIN I, § 21, n.º 35.

§ 2 Parece ser esta a posição de Arthur Kaufmann, quando alega que uma falta de consciência do ilícito não censurável existirá em todos aqueles casos em que o tipo abstrai, em larga medida, do ilícito material, *v. g.*, nos delitos de perigo abstracto, nos tipos com condições objectivas de punibilidade ou nos casos em que a ilicitude material é particularmente discutida ou controvertida (inseminação artificial, esterilização, interrupção médica da gravidez, certas práticas sexuais, etc.). Mas aqui, ao menos na maioria dos casos, tratar-se-á eventualmente ainda da falta de conhecimento indispensável para uma correcta orientação da consciência ética do agente para o problema da ilicitude. Porque assim é, de resto, pode Kaufmann afirmar do mesmo passo que **"o erro moral, esse, nunca desculpa"** (2). Nem outra será a solução quando se veja na **"hostilidade ao direito"** (supra, 20.º Cap., § 17) o verdadeiro signo distintivo da falta de consciência do ilícito: se a concreta falta de consciência do ilícito não é, em definitivo, imputável a uma tal hostilidade, isso significará que ela deve ainda ser tratada nos quadros do erro sobre a factualidade típica, com a consequente aplicação das regras sobre a negligência; se é porém, em definitivo, imputável a uma tal hostilidade, então esta é precisamente fundamento da culpa e não poderá por isso deixar de considerar-se em todos os casos censurável (3). Também Nowakowski, de resto, considerou a questão com profundidade, à luz de uma concepção que, na conclusão, praticamente coincide com a que defendemos (supra, 20.º Cap., § 31 e s.); para também ele chegar à conclusão de que, mesmo quando a hipótese ocorre no domínio da ordenação axiológica reconhecida pelo direito, casos há em que o erro de valoração acaba por reconduzir-se a um erro intelectual referido a um mais amplo conhecimento da lei ou da proibição legal: **sempre, porém, que é o erro de valoração que se assume como fundamento do facto ele funda a censura e não pode conduzir à desculpa** (4).

§ 3 De acordo com o nosso ponto de vista, a resposta à pergunta sobre a *possibilidade* de uma falta de consciência do ilícito não censurável dependerá de se poder considerar que o erro ou engano da consciência ética que está na sua base não se funda, no caso, numa atitude desvaliosa e juridicamente censurável do agente, documentada no facto e que o fundamenta. Ora, para que se reconheça uma tal possibilidade há boas razões substanciais. E desde logo a de que se a censurabilidade do erro fosse automaticamente afirmada ganharia expressão o perigo de utilizar o pensamento da culpa para — contra o que vimos ser a sua função político-criminal — reforçar uma **concepção inadmissivelmente autoritária** do direito

(2) KAUFMANN, Arthur, *Das Unrechtsbewusstsein in der Schuldlehre des Strafrechts*, 1949, p. 190 e ss., *Das Schuldprinzip*, 1961, p. 135, e, sobretudo, Die Irrtumsregelung im Strafgesetzbuch-Entwurf 1962, *ZStW 76*, 1964, p. 561 e s.

(3) Cf. o E 1962, § 15, e as propostas de MEZGER e de GALLAS, *Niederschrifen*, II, Anhang 7/21 e ss.

(4) NOWAKOWSKI, Rechtsfeindlichkeit, Schuld, Vorsatz, *ZStW 65*, 1953, p. 399 e s.

penal. Assim se olvidaria, na verdade, a específica função *limitadora* do pensamento da culpa jurídico-penal — o seu cunho de sã **tolerância** (de toda a tolerância comunitariamente possível) em face do ilícito (5) —, até a um ponto em que com a afirmação do desvalor do ilícito se daria já também, em regra, a afirmação do desvalor da atitude interna pessoal que nele se exprime. Ao que acresce a circunstância de a ilicitude de uma conduta constituir um problema cuja solução não é hoje, em cada vez maior número de casos, nada de claro ou evidente (a impor-se por si mesma, como os grandes princípios gerais e abstractos de acção, a uma justa consciência ética), antes se torna progressivamente mais questionável em sociedades como as nossas, definitivamente *secularizadas*, altamente *complexas* e *pluralistas*, onde cresce exponencialmente a discutibilidade e o *re*conhecimento dos pontos de vista axiológicos ou em si mesmos considerados, ou conjugados com a novidade e complexidade das situações a que se aplicam (6). O que só reforça a ideia de que, em muitas destas hipóteses, o engano da consciência ética terá por único fundamento a *historicidade* do existir humano concreto: uma facticidade que está fora do âmbito de actuação do ser-livre, que antes o limita e não pode por isso ser, enquanto tal, imputada ao agente como culpa. Em suma e em conclusão: também no puro domínio da falta de consciência do ilícito **podem dar-se erros não censuráveis** que, face ao princípio da culpa, têm por força de excluí-la. Tudo estará em determinar o *critério* da não censurabilidade e os seus limites (7).

II. O critério da inevitabilidade ou invencibilidade do erro

§ 4 Na tentativa de lograr esta determinação, uma via — todavia a mais comum, nas legislações e doutrinas estrangeiras — terá de conside-

(5) Sobre a "tolerância" como valor jurídico-constitucional que impregna toda a CRP e as suas implicações jurídicas, bem como sobre a necessidade de lhe dar lugar fundamental no âmbito do direito penal (como proposição político-criminal e, por conseguinte, também dogmática), ALMEIDA, Luís Nunes de, Tolerância, Constituição e Direito Penal, *RPCC 13*, 2003, p. 159. Também DÍAZ Y GARCIA Conlledo, Algunas cuestiones del error en Derecho Penal, *Problemas Fundamentais de Direito Penal, Homenagem a Claus Roxin*, 2002, p. 81 e ss., advoga — a partir do critério da "invencibilidade do erro": infra, § 4 e ss. — uma "maior generosidade na apreciação".

(6) Neste contexto devendo lançar-se a problemática, referida supra, 20.º Cap., § 44 e s., da "consciência condicionada ou eventual da ilicitude".

(7) Minuciosamente sobre o tema, HORN, *Verbotsirrtum und Vorwerfbarkeit*, 1969, e RUDOLPHI, *Unrechtsbewusstsein, Verbotsirrtum und Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums*, 1969, p. 217 e ss.

rar-se excluída: a de recorrer à distinção entre erro vencível e invencível, evitável e inevitável ([8]), feita por sobre a linha da *capacidade de conhecer o ilícito* ou mesmo do *poder de pôr em tensão a consciência ética*. E excluída não só em virtude da incompatibilidade de princípio entre um tal critério e o sentido fundante da culpa e da consciência do ilícito, como das próprias fraquezas intrínsecas daquele critério do poder ou capacidade, desde a sua inverificabilidade em concreto aos resultados insuportáveis a que conduz tanto do ponto de vista da pura justiça, como do da política criminal. Se a **cognoscibilidade do ilícito** for só um outro nome para o "poder de agir de outra maneira", uma sua concretização relativamente ao poder de conhecer o ilícito, esta concepção torna-se de imediato passível de todas as críticas — tanto de princípio, como político-criminais — que dirigimos a uma concepção da culpa baseada no dogma do livre-arbítrio, a uma "culpa da vontade". Se, algo diferentemente, aquela cognoscibilidade for afirmada sempre que o agente, "através do pertinente esforço da consciência ética" — da exigível, devida ou esperada "tensão" da consciência ética — tivesse podido alcançar o conhecimento da ilicitude ([9]), então tem de afirmar-se que o critério nem é praticamente exequível, nem coerente com a concepção da culpa pressuposta.

§ 5 (1) Desde logo — como não deixa de reconhecer o próprio Welzel —, o critério da **tensão da consciência ética** só pode valer para o âmbito dos ilícitos *moralmente* fundados, só neles tendo sentido dirigir a censura à possibilidade de o agente ter alcançado uma "reflexão axiológica" que omitiu ([10]); enquanto para todos os outros o papel da consciência ética desaparece, para a censura passar a ter de fundar-se numa **falta intelectual** derivada de o agente não ter feito tudo aquilo que razoavelmente seria de lhe exigir no sentido de se esclarecer ou informar sobre a ilicitude do facto. Ora, nem o critério da "tensão da consciência ética" é compatível com o sentido que o problema da consciência do ilícito assume quando se vê na evitabilidade ou vencibilidade do erro o critério da censura, nem, de qualquer maneira, os dois critérios são compatíveis entre si.

([8]) Criticamente também, depois de desenvolvida análise, NEVES, Curado, *A Problemática da Culpa nos Crimes Passionais*, 2006, pp. 148 e s., 153 e ss.

([9]) Critério pela primeira vez proposto por WELZEL, *Vom irrenden Gewissen*, 1949, p. 26, e logo retomado e concretizado pelo BGH na sua fundamental decisão (já referida na nota 14 do 20.º Cap.) de 18-3-1952: *NJW* 1952, p. 593 e ss.

([10]) WELZEL, § 22, III, 2.

§ 6 Efectivamente, a consciência do ilícito de que nesta concepção se trata não deixa de propor um problema **estritamente psicológico e cognitivo** — o da afirmação ou negação de uma capacidade psicológica de conhecimento —, pelo que a invocação da consciência ética trará sempre em si o estigma de uma contradição interna inapagável. Para esta concepção da culpa e da consciência do ilícito decisiva é, só pode ser, a afirmação ou negação da cognoscibilidade do ilícito — e, mesmo esta, como parte (não autónoma!) da total capacidade do agente para se motivar pelo dever —, *sem que interesse averiguar das causas, da origem ou dos fundamentos da falta de conhecimento actual do ilícito* ([11]). Por isso não tem sentido nem é legítimo ascender ao nível da consciência ética para aí encontrar um critério de censurabilidade do erro: tudo haverá ainda de passar-se ao nível da consciência intencional, do seu "poder de conhecer" e, a esse nível sim, da evitabilidade ou vencibilidade do erro ([12]).

§ 7 De resto, insistimos, os dois critérios **não são harmonizáveis entre si**. Acentua-se em regra — com razão — que o critério da tensão da consciência ética é em si muito mais exigente e limitador da exclusão da culpa do que o critério da evitabilidade ou vencibilidade do erro, uma vez que inclui, para além das exigências cognitivas que este também contém (o "poder prever"), exigências adicionais de índole ética e emocional ([13]). Mas esta conclusão não pode ser aceite nos quadros da concepção em análise, uma vez que da sua perspectiva o critério da resposta que se busca há-de ser *o mesmo* num e noutro caso, a saber, a capacidade de conhecimento necessária a uma motivação do agente pelo dever jurídico ([14]). Reconhecendo-o, por isso, a generalidade da doutrina alemã opera aqui, para efeito de determinação da (in)evitabilidade da falta de consciência do ilícito, com *categorias paralelas às utilizadas no dolo do tipo*: representação (da ilicitude) ou sua falta, representação

---

([11]) Como de resto é expressamente afirmado por KAUFMANN, Armin, Schuldfähigkeit und Verbotsirrtum, *Eb. Schmidt-FS*, 1961, p. 327 e s.

([12]) Afirmam-no, embora sem nenhum acento crítico, muitos autores alemães. Cf., só, STRATENWERTH / KUHLEN, § 10, n.º 82, e ROXIN I, § 21, n.º 46.

([13]) No outro extremo se situa a tese de HORN, nota 7, p. 105, segundo a qual se o agente não tem a consciência *actual* de que a sua acção *pode ser* ilícita, a falta de consciência do ilícito deve ter-se logo por *inevitável*.

([14]) Conclusão aceite obviamente (em todo o caso contra a jurisprudência dominante) por uma larga maioria da doutrina alemã: JAKOBS, 19/38, JESCHECK / WEIGEND, § 42, II, 2 b, ROXIN I, § 21, n.º 45, RUDOLPHI, *SK*, § 17, n.º 30.

como certa, provável ou possível, representação condicional (ou eventual), etc. ([15]).

§ 8 (2) Por outra parte, os critérios da tensão da consciência ética, para serem praticáveis, não podem ter-se por concretizações coerentes da ideia da culpa como capacidade de motivação de acordo com a norma. Para o serem tem de intervir também aqui — como vimos que em geral sucede no problema da culpa: supra, 19.º Cap., § 13 e ss. — uma **generalização** daquela capacidade que a faça demonstrável e apreensível; o que só se torna possível transformando o *poder* num **dever** de conhecer o ilícito, concebendo-o como *obrigação*, como *exigibilidade*, em suma, segundo um *padrão objectivado*, de acordo com aquilo que deve exigir-se *deste* agente, *nesta* situação ([16]). Se assim for, porém, suscita-se uma contradição frontal entre o critério e a sua concretização, que outra não é senão aquela com que repetidamente temos afirmado debater-se toda esta concepção da culpa: a de pretender afirmar ou infirmar um concreto *poder* (no caso: o de conhecer o ilícito) na base do incumprimento de um construído *dever* (no caso: o de pôr em tensão a consciência ética ou de alcançar uma mais ampla e correcta informação), com irremível violação do princípio *de debere ad posse non valet consequentia*.

§ 9 (3) Uma última observação visa acentuar que os critérios em análise **se não revelam adequados**, na sua aplicação, **às exigências político-criminais e prático-normativas** que validamente se dirigem a um direito penal da culpa. Logo quanto ao critério da **tensão da consciência ética**, na verdade, ele supõe a existência no agente de uma tal consciência formada de acordo com os critérios da ordem jurídica, ou pelo menos "aberta" para eles, sendo problema só saber se uma tal consciência, prestando o esforço exigido, teria revelado ao agente o carácter ilícito do facto. Mas assim, não há aqui resposta possível para todos aqueles casos — os mais questionáveis neste contexto — em que a consciência ética do agente

---

([15]) Muito clara, a propósito, a exposição de ROXIN I, § 21, n.º 52 e ss., em especial [79].

([16]) Isto mesmo é reconhecido, entre outros, pelo BGH na sua sentença já citada na nota 9, por HENKEL, Zumutbarkeit und Unzumutbarkeit als regulatives Rechtsprinzip, *Mezger-FS*, 1954, p. 298 e s., pela própria fundamentação oficial do E 1960, p. 127 e s., por MATTIL, Gewissensanspannung, *ZStW 74*, 1962, p. 210, e, agora, por outros, por ROXIN I, § 21, n.º 39, com apelo ao art. 20 do CP suíço (sobre este, DONATSCH, Unrechtsbewusstsein und Verbotsirrtum, *SchwZ 102*, 1985, p. 25 e ss.). Impressivamente, também, TIEDEMANN, Zum Stand der Irrtumslehre, insb. im Wirtschafts- und Nebenstrafrecht, *Geerds-FS*, 1995, pp. 95 e 109.

revela uma distonia, na sua formação, com os critérios de valor da ordem jurídica ou se não encontra orientada para eles. Esse será o caso, *v. g.*, de certos agentes por convicção ou por decisão de consciência (infra, 24.º Cap.), de delinquentes habituais e profissionais cuja consciência se foi embotando no decurso de uma vida conduzida em total indiferença ou inimizade pelos valores jurídicos, de personalidades oneradas por uma qualquer tendência que, devido ao seu peso e persistência, torna a consciência insensível ou cega àqueles valores. Perguntar, nestes casos, por uma capacidade de esforçar ou pôr em tensão a consciência ética é colocar uma questão destituída de sentido, uma vez que é precisamente a qualidade juridicamente desvaliosa ou defeituosa da personalidade que impossibilita qualquer esforço ou tensão. Por isso a tese em apreço terá aqui, se quiser ser coerente, de acabar por negar a culpa ([17]).

§ 10 Quanto ao critério da **falta de informação e de esclarecimento**, a tese em apreço reivindica-se de que, bastando à exclusão da culpa a falta de *cognoscibilidade* do ilícito, só ela conseguiria justificar a punição nas hipóteses mais críticas, aquelas em que um forte estado de excitação ou de afecto teria furtado ao agente a falta de consciência *actual* do ilícito. Só que, sendo a capacidade de conhecer o ilícito, como sublinhámos, um estado tão estritamente psicológico quanto o é o seu conhecimento efectivo, *ela pode, da mesma forma e na mesma medida que este, ser afectada e afastada no momento da acção por aqueles estados de excitação, de afecto ou de decisão repentina* ([18]). Com efeito, na medida em que tais estados afectam o campo psicológico hão-de dificultar ou impossibilitar não só qualquer tensão da consciência ética, mas também (ainda mais claramente) qualquer informação ou esclarecimento sobre a ilicitude do facto que o agente se propõe, hão-de afectar, em suma, a capacidade de conhecimento da ilicitude. Pretender outra coisa implicaria uma cisão ilegítima e inexequível no domínio psicológico, segundo a qual as leis que valem para um certo estado psicológico já não valeriam para aquele outro donde este deriva e que o torna possível ([19]). E porque uma tal cisão é inadmissível, tem então de concluir-se que o critério de desculpa

([17]) Para esta circunstância chamava já a atenção MANGAKIS, *Das Unrechtsbewusstsein in der strafrechtliche Schuldlehre*, 1954, p. 71.

([18]) Assim, SCHMIDHÄUSER, Über Aktualität und Potentialität des Unrechtsbewusstseins, *H. Mayer-FS*, 1966, p. 319 e ss.

([19]) Também, SCHMIDHÄUSER, nota 18, p. 320 e s.

da inevitabilidade ou invencibilidade do erro, quando praticamente exequível, conduziria a consequências político-criminais insuportáveis.

III. A "rectitude" da consciência errónea como critério da não censurabilidade da falta de consciência do ilícito

1. Pensamento fundamental

§ 11 O critério que nos permitirá dizer *quando* e *onde* pode falar-se de uma falta de consciência do ilícito não censurável há-de decorrer, na sua expressão mais geral, do que atrás ficou dito sobre o conteúdo material do conceito de culpa jurídico-penal e o sentido da falta de consciência do ilícito àquela luz. Tal falta será não censurável sempre que (mas só quando) o engano ou erro da consciência ética, que se exprime no facto, **não se fundamente em uma atitude interna desvaliosa** face aos valores jurídico-penais, pela qual o agente deva responder. Também a personalidade que erra sobre o sentido de uma valoração jurídica se mantém substancialmente "responsável", parecendo por isso dever arcar com a culpa pelo ilícito-típico cometido. Pode acontecer no entanto que, apesar do "erro de valoração" em que incorreu, a personalidade do agente venha ainda a revelar-se essencialmente conformada com a suposta e exigida pela ordem jurídica. Em casos tais — cujo fundamento repousa assim em uma consideração de certo modo paralela à que serve de base à *inexigibilidade* (supra, 22.º Cap., § 10 e s.) ([20]) — fica excluída a censurabilidade da falta de consciência do ilícito e, por aí, a culpa do agente (art. 17.º-1).

§ 12 Em um número limitado de hipóteses será relativamente simples para o aplicador determinar a existência de uma *atitude pessoal juridicamente desvaliosa* que impediu a consciência ética de decidir correctamente a questão do desvalor jurídico do facto. Nestes casos terá forçosamente de concluir pela **censurabilidade** da falta de consciência do ilícito. Tratar-se-á de casos em que é a própria qualidade juridicamente desvaliosa e censurável da personalidade (determinante de um embotamento, insensibilidade

([20]) Nota o paralelismo, igualmente, JAKOBS, 19/37 e s.: "O inteiro âmbito do § 17 segue as regras da exigibilidade"; tudo depende de saber "se a partir do comportamento [do agente] se torna ou não perceptível um reconhecimento suficiente do direito positivo". Nesta linha, já, TIMPE, Normatives und P sychisches im Begriff der Vermeidbarkeit eines Verbotsirrtums, *GA*, 1984, p. 51.

ou daltonismo da consciência ética) que vale imediatamente como censurabilidade da falta de consciência do ilícito: seria absolutamente contrário à essência fundante do pensamento da culpa, tal como a revelámos, desculpar um agente cuja "crueldade" lhe não permite aperceber-se da ilicitude de uma omissão de auxílio (art. 200.º); ou cuja "brutalidade" obsta a que se aperceba da ilicitude de maus tratos físicos infligidos a um seu assalariado menor (art. 152.º-1/*a*)); ou cujo "egoísmo" o impede de concluir pela ilicitude do incitamento de outrem ao suicídio (art. 135.º); ou cuja "tendência pedófila" lhe obnubila a consciência da ilicitude do abuso sexual de menor de 14 anos (art. 172.º) — mesmo quando pudesse demonstrar-se terem sido precisamente essas características da personalidade que lhe furtaram a "capacidade" de conhecer a ilicitude.

§ 13 A circunstância, porém, de não ser em muitos casos possível — sobretudo em vista da complexidade da situação e da discutibilidade da valoração jurídica — determinar positivamente a existência de uma qualidade pessoal censurável na origem da falta de consciência do ilícito não significa que, por isso, deva logo concluir-se pela negação da culpa. Pelo contrário, já atrás dissemos que a ligação do dolo do tipo a uma falta de consciência do ilícito e, portanto, a um erro da consciência ética, *indicia* a existência de uma culpa material e, na verdade, de uma culpa dolosa. O que falta acrescentar (e justificar) agora é que um tal valor indiciário pode ser invalidado se se lograr a comprovação de que, apesar daquela conexão, a atitude que fundamenta o facto é ainda determinada por **pontos de vista de valor que a ordem jurídica reconhece e protege**; de que, por outras palavras, apesar daquela conexão, no agente persistiu uma **recta** consciência ético-jurídica, fundada em uma atitude de **fidelidade** ou de **correspondência a exigências ou pontos de vista de valor juridicamente reconhecidos**.

§ 14 Na determinação do que seja a recta consciência ético-jurídica que acaba de referir-se é fundamental o apelo à distinção, própria da teologia moral católica, entre uma *conscientia vera* (*sc.*, a consciência que decide em conformidade com a verdade objectiva) e uma *conscientia recta* que, na realidade das coisas, é uma *conscientia erronea* mas que, apesar da não-coincidência com a verdade objectiva, todavia se apresenta como não culposa ou não censurável. É este o pensamento de Suarez, que o reporta a Duns Escoto, posteriormente desenvolvido pelos teólogos jesuítas. A *conscientia recta* é pois uma **conscientia erronea inculpabilis**, que todavia nada tem a ver com a falta de um qualquer poder ou capacidade de conhecer o mal — nada tem, neste sentido, de subjectivista —, antes implica a realização de exigências que, nem por

não conduzirem à verdade objectiva, deixam de ser universalmente válidas e de se reger por um critério objectivo. Exigências que se traduzem, fundamentalmente, no *amor da verdade* — no esforço continuado para apreensão do bem objectivo — e na formação da consciência, embora errónea, segundo *o projecto de uma existência orientada para a perfeição moral* (21).

§ 15 Esta concepção teológica surge confirmada por um pensamento recente, proveniente de quadrantes diferentes dos que presidiram à elaboração da teologia moral e que entre nós foi apresentado, no contexto de uma **filosofia da Existência**, por Baptista Machado (22). Segundo ele a culpa traduz-se na violação de um *dever primordial* — do dever original ou existencial de "ser homem", "de se constituir como homem pela participação na humanidade histórica" — cujos elementos essenciais são, por um lado, a "disponibilidade total" em face da decisão a tomar na situação e, por outro, uma atitude de "participação" na "humanização do mundo e da história", de "abertura" para os sentidos e os valores. Disto decorre — e aqui reside o essencial para o nosso problema — que nem por cumprir este "dever de orientação existencial" deixa a consciência ética do agente de estar sujeita ao risco de falhar e vir a revelar-se como consciência errónea. Só que, então, apesar do erro em que incorreu, a observância daquele dever — através da "atitude geral de 'abertura', de disponibilidade total em face da decisão a tomar — faz com que a consciência ética se revele como recta, como uma tal que não toma sobre si qualquer culpa.

2. Requisitos

§ 16 Se retomarmos a consideração jurídico-penal do problema, estamos agora em condições de desenvolver os requisitos dos quais depende a verificação no agente de uma **consciência jurídica *recta*** — de uma *rechtsschaffene Gewissen* de que falava Würtenberger, retomando uma palavra de Hegel (23) — que constitui **causa de exclusão da culpa**.

§ 17 Antes de mais, uma falta de consciência do ilícito não censurável só pode em princípio verificar-se em situações em que a questão da ilicitude concreta (seja quando se considera a valoração em si mesma, seja quando ela se conexiona com a complexidade ou novidade da situação) **se revele discutível e controvertida**. Não porque, quando assim não suceda,

---

(21) Sobre todo o exposto neste parágrafo, JANSSENS, *Liberté de conscience et liberté réligieuse*, 1964, pp. 9 e ss., 15 e ss.

(22) MACHADO, Baptista, *Antropologia, Existencialismo e Direito*, 1966, pp. 18 e ss., 39, 70 e ss.

(23) WÜRTENBERGER, Vom rechtschaffen Gewissen, *E. Wolf-FS*, 1962, p. 356, na esteira de HEGEL, *Philosophie des Rechts* (ed. Lasson), § 36.

se pretenda reverter à velha ideia jusnaturalista do inatismo e evidência de certas valorações ("a lei moral está escrita no coração de cada pessoa"...), mas porque a questão há-de ser uma daquelas em que conflituam diversos pontos de vista juridicamente relevantes, ou em que estes conflituam com razões de estratégia ou de oportunidade, estas também juridicamente relevantes.

§ 18 Só quando assim sucede, com efeito, é que a solução dada pelo agente à questão da ilicitude do facto pode ainda corresponder a um **ponto de vista de valor juridicamente reconhecido** e todavia, em definitivo, a consciência ética errar por não ter tomado em conta (ou na conta devida) outros pontos de vista de valor ou razões de estratégia e de oportunidade juridicamente relevantes. Só em casos destes, com efeito, se pode afirmar que a correspondência da valoração do agente a uma perspectiva axiológica juridicamente relevante teria conduzido à licitude do facto se não fosse a situação conflitual a que se aludiu. Só nestes casos, em suma, se pode afirmar que o agente, apesar do erro em que em último termo incorreu, manifestou no facto uma consciência recta, orientada por uma **atitude geral de fidelidade a exigências do direito**.

§ 19 Necessário por fim se torna à não censurabilidade da falta de consciência do ilícito que tenha sido o **propósito do agente** de corresponder a um ponto de vista de valor juridicamente relevante — ou, quando não o propósito consciente, pelo menos o produto de um esforço ou desejo continuado de corresponder às exigências do direito, para *prova* do qual se poderá lançar mão dos indícios fornecidos pelo conhecimento do seu modo-de-ser, plasmado no agir anterior — o fundamento da falta de consciência do ilícito.

§ 20 Aqui reside o cerne exacto da afirmação (doutrinalmente muito repetida) de que a censurabilidade da falta de consciência do ilícito implica sempre "um certo pedaço de **culpa na condução da vida**" ou na preparação da personalidade ([24]). No preciso sentido de que a *prova* da persistência no agente, apesar do erro da cons-

([24]) BOCKELMANN, *Strafrechtliche Untersuchungen*, 1957, p. 14, e *Schuld und Sühne*, ²1958, p. 25 e ss., e CORREIA, Eduardo, I, p. 417, *ProjPG*, p. 23, e *Actas*, I, p. 26; e, também, em certa medida, RUDOLPHI, nota 7, p. 254 e ss., e *SK*, § 17, n.º 44, S / S / CRAMER / STERNBERG-LIEBEN, § 17, n.º 17; e, mesmo, STRATENWERTH / KUHLEN, § 10, n.º 94, todavia numa linha que aproxima a fundamentação da culpa, nestes casos, daquela "antecipação da conexão entre culpa e facto" própria da *actio libera in causa* (supra, 21.º Cap., § 52 e ss.).

ciência ética, de uma atitude de fidelidade ou de correspondência a exigências do direito depende não só do que puder concluir-se da atitude interna documentada no facto, como ainda da verificação de que o agente é um tal que se tem esforçado por assegurar o carácter jurídico (lícito) dos seus actos, até ao ponto de aquele esforço se revelar como uma forma do existir.

§ 21 Se uma falta de consciência do ilícito não censurável só se dá em situações onde conflituam valores ou interesses juridicamente relevantes e protegidos, parece ficar próxima a conclusão de que isso sucederá apenas no âmbito do **erro sobre a existência ou os limites de uma causa de justificação** (nomeadamente, sobre o direito de necessidade nas suas diversas formas); enquanto a "pura" falta de consciência do ilícito — *sc.*, aqueles casos em que o agente não valora a sua conduta no sentido de um comando geral proibitivo — deverá ser sempre considerada censurável. Não custa conceder que seja o domínio das causas de justificação aquele em que faltas não censuráveis de consciência do ilícito serão mais frequentes. Mas isto é uma coisa, outra diferente pensar que o conflito de pontos de vista de valor juridicamente relevantes e a discutibilidade ético-jurídica de tais pontos de vista, causas da insegurança do resultado da valoração, só estão presentes quando a situação põe em questão uma causa de justificação. Esquecer-se-ia então que por vezes — na verdade, muitas vezes — já **o próprio tipo incriminador** (e a consequente "proibição geral") supõe a decisão legislativa de um conflito de pontos de vista de valor juridicamente relevantes e é produto dela ([25]): em todos estes casos se inscreverá então também a possibilidade de uma falta de consciência do ilícito não censurável.

§ 22 Ex.: o art. 156.º considera como crimes contra a liberdade as **intervenções médico-cirúrgicas** sem consentimento do paciente (ditas *intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários*), o que supõe uma difícil tomada de posição do legislador no discutidíssimo problema do conflito entre o valor (jurídico) da liberdade pessoal e o valor (também jurídico) da protecção da vida e da saúde do paciente, a favor daquele e contra este. Posição que todavia o mesmo legislador já amorteceu (se não inverteu) quando, no art. 157.º, *in fine*, liberta o médico do seu dever de esclarecimento do paciente "se isso implicar a comunicação de circunstâncias que, a serem conhecidas pelo paciente, poriam em perigo a sua vida ou seriam susceptíveis de lhe causar grave dano à saúde, física ou psíquica" (o doutrinalmente chamado "privilégio terapêutico) ([26]).

([25]) Assim, já, ENGISCH, Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei Rechtfertigungsgründe, *ZStW 70*, 1958, p. 592.

([26]) Sobre a questão, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, arts. 156.º e 157.º

§ 23 Se a falta de consciência do ilícito só deve reputar-se não censurável quando se funda em uma atitude geral de fidelidade a exigências do direito, poderia parecer, por outro lado, dever então concluir-se que a exclusão da culpa só pode afirmar-se quando o agente tenha actuado com a consciência **positiva** da licitude da conduta. Se assim fosse, não seria essa uma conclusão estranha em legislações modernas: o E 1962 consagrava expressamente tal solução, o mesmo sucedendo ainda hoje com o art. 20.º do CP suíço. Mas não cremos que deva ser assim, se bem que, da perspectiva aqui defendida, o interesse da questão seja diminuto. Há que tomar completamente a sério a ideia de que na falta de consciência do ilícito se não trata de uma falta de representação ou conhecimento, mas de uma falta ou erro da consciência ética correctamente orientada para o problema da ilicitude. Que daqui tenha derivado uma advertência dos sentimentos no sentido da licitude, ou só uma falta de advertência no sentido da ilicitude, é indiferente. Pois também neste último caso a possibilidade da subsistência de uma consciência recta não tem de ficar excluída, mas pode resultar ([27]) da habituação do agente ao respeito de um ponto de vista de valor juridicamente relevante, que já nele se incrustou como forma adquirida do existir. Por isso deve concluir-se que uma falta de consciência do ilícito não censurável é compatível, no domínio psicológico, tanto com uma aceitação positiva da licitude, como com uma falta de percepção da ilicitude.

§ 24 Assim se terá alcançado um **critério de não-censurabilidade pessoal-objectivo**, que desde há muito vem sendo vivamente requerido pela prática e que pode ser (ao contrário do que sucede com os critérios da evitabilidade ou vencibilidade do erro, da tensão da consciência ética, da cegueira e hostilidade ao direito) amplamente utilizável por ela. Não se almeja, é claro, alcançar por esta via a precisão dos critérios conceituais-formais, valendo também para um tal critério aquela "indeterminação normativa" que acompanha toda a valoração jurídica e com a qual não é justo esgrimir-se contra os resultados desta. Essencial é só que se veja claramente a perspectiva a partir da qual a valoração há-de ser feita; e é só isso que o critério apontado buscou fixar com a precisão possível, em consonância com o sentido fundante do pensamento da culpa jurídico-penal.

([27]) Como ROXIN, Die Behandlung des Irrtums im Entwurf, *ZStW* 76, 1962, p. 607, parecia acabar por reconhecer.

IV. A questão da atenuação da culpa

§ 25 É hoje geralmente reconhecido tanto na doutrina, como nos mais recentes tratamentos legislativos do problema, que a falta **censurável** de consciência do ilícito constitui uma circunstância *susceptível* de atenuar a culpa em termos que tornam as molduras penais aplicáveis demasiado severas para, dentro delas, se ter em justa conta uma tal diminuição da culpa. Daí a conclusão de que o juiz *poderá* nestas hipóteses atenuar especialmente (livremente ou extraordinariamente) a pena: é a tese da **atenuação extraordinária facultativa** ([28]), vazada no art. 17.º-2. Mas torna-se necessário determinar o **fundamento** de uma tal atenuação extraordinária facultativa, em especial, determinar a razão por que não basta, para ter em conta a eventual diminuição da culpa, a moldura penal dolosa normal.

1. A tese da atenuação especial obrigatória. Crítica

§ 26 Se o fundamento da atenuação está em que — como geralmente se afirma — é por princípio menos grave o facto cometido *sem* consciência do ilícito do que o cometido *com* ela, dir-se-ia não haver razão para sustentar uma mera *possibilidade* de atenuação extraordinária da pena, antes dever afirmar-se uma atenuação especial **obrigatória** ([29]) (no máximo com a eventual ressalva das hipóteses de verdadeira "hostilidade ao direito" ([30])); porque já aquela falta constitui uma circunstância que diminui "por forma acentuada... a culpa do agente" nos termos do art. 72.º-1. Esta solução teria a vantagem de oferecer um critério seguro e preciso, que evitaria desigualdades e preservaria o princípio da culpa. Mesmo considerada a ineliminável margem de indeterminação que acompanha a fórmula da "hostilidade ao direito", uma tal solução ofereceria ao juiz um critério que falta por completo na tese da atenuação meramente facultativa, assim se ganhando, na expressão de Roxin, "um mais indiscutível de segurança jurídica" ([31]).

([28]) Sobre este instituto DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 444 e ss.

([29]) Como no Projecto austríaco de 1964, § 8 (2).

([30]) Neste sentido ia a proposta de LANGE, *Niedershriften*, II, Anhang 7/8, p. 23; e depois também o § 20 (2) do AE. Se bem que de forma algo atenuada cf. ainda, agora, ROXIN I, § 21, n.º 71: uma atenuação facultativa "é problemática".

([31]) ROXIN, nota 27, p. 606; e, com pormenor, WARDA, Zur gesetzlichen Regelung des vermeidbares Verbotsirrtums, *ZStW 71*, 1959, p. 257 e ss.

§ 27 Esta tese não parece, no entanto, dever merecer aceitação, porque não tem presente (ou não leva suficientemente a sério) a ideia de que em *todas* as hipóteses de falta de consciência do ilícito, e não apenas nas de "hostilidade ao direito", está em causa, antes que um não saber de prescrições legais, uma deficiente posição da consciência ética perante os valores acolhidos pela ordem jurídica: uma deficiência **ao mesmo nível** da que conforma o conteúdo da culpa do facto cometido *com* consciência do ilícito. Por isso, também em tema de medida da culpa tudo deverá ser função da atitude pessoal que está na base da falta de consciência do ilícito e fundamenta o facto. Devendo assim concluir-se que, para uma atenuação extraordinária *obrigatória* da pena por força da falta de consciência do ilícito, mesmo ressalvados os casos de hostilidade ao direito, não é possível descortinar fundamento bastante.

2. A tese da atenuação especial facultativa

§ 28 Segundo o seu conteúdo de culpa, como procurámos mostrar, as hipóteses de falta de consciência do ilícito são em princípio equiparáveis às de cometimento do facto com dolo do tipo e consciência do ilícito; e umas e outras são substancialmente diferentes daquelas em que o agente incorre em um "erro intelectual". Esta distinção, todavia, por nítida que se apresente em via de princípio, **atenua-se sensivelmente em zonas limítrofes da respectiva problemática**. Isto logo resulta da circunstância de em muitos casos ser indispensável à correcta orientação da consciência ética para o desvalor jurídico do facto o conhecimento de proibições legais (art. 16.º-1, 2.ª parte, e supra, 13.º Cap., § 31 e ss.). Como também da circunstância de certos elementos típicos, cujo conhecimento é indispensável àquela orientação, possuírem um conteúdo de sentido que insinua já o desvalor do facto como um todo e constituírem assim uma espécie de "ponte" entre a factualidade típica e a sua ilicitude (supra, 13.º Cap., § 10 e ss.). O que tudo é só consequência da efectiva *proximidade material*, segundo o seu conteúdo de culpa, dos dois tipos de erro nestas zonas ([32]).

A forma de corresponder, no domínio da punição, a esta proximidade material de conteúdos de culpa está em admitir que, nestes casos, a mol-

([32]) Exemplar o caso — já citado supra, 13.º Cap., nota [41] — correctamente decidido pela sentença do Tribunal de Anadia de 3-6-1994 e sobre que recaiu a anotação de DIAS, Figueiredo / CAEIRO, Pedro, *RPCC 5*, 1995, pp. 246 e ss. e 259 e ss.

dura penal do facto cometido sem consciência do ilícito se aproxime da que corresponde ao respectivo facto negligente (ou deveria corresponder-lhe se este fosse punível). Um tal resultado alcançar-se-á através do instituto da **atenuação extraordinária da pena**.

§ 29 Nada disto justifica porém uma atenuação *obrigatória*, mesmo com ressalva dos casos de hostilidade ao direito. Logo, porque serão quantitativamente excepcionais ou pouco numerosos os casos referidos em que o conteúdo de culpa do facto cometido sem consciência do ilícito fica materialmente próximo da culpa negligente. Depois, porque se não revela praticamente possível tipicizar, com um mínimo aceitável de segurança, as espécies de crime a que a atenuação extraordinária caberá, e muito menos as situações concretizadas relativamente às quais ela há-de operar. Ainda aqui só podem ser decisivas considerações derivadas do conteúdo material da culpa na situação e do sentido do problema da falta de consciência do ilícito àquela luz. Tudo quanto resta no plano dogmático, como no da estatuição legislativa, é pois a consagração, como o fez o art. 17.º-2, da **possibilidade** de atenuação extraordinária da pena, é dizer, de uma **atenuação extraordinária facultativa**.

§ 30 Conclusão que, cremos, só se conforta quando consideramos as hipóteses que a tese da atenuação obrigatória está disposta a ressalvar: as da **hostilidade ao direito**. Acentuámos na altura devida (supra, 20.º Cap., § 18) que a essência de culpa da falta de consciência do ilícito está, no nosso entendimento, em certo sentido materialmente próxima daquela hostilidade; o que logo conduz a defender que as hipóteses de hostilidade não são, do ponto de vista da culpa, normativamente "excepcionais", pelo que também nelas não está excluída *a priori* a possibilidade de atenuação especial da pena. Warda opôs que isso será completamente impossível quando o conceito de hostilidade ao direito se reconduza à sua exacta acepção: a incompatibilidade da concepção do agente sobre o lícito e o ilícito com os valores *fundamentais* da ordem jurídica. Quem erra sobre estes valores fundamentais não pode esperar qualquer atenuação da culpa ([33]). Mas não cremos que lhe assista razão. Não há — já o dissemos — nenhum valor jurídico, por mais fundamental que seja, cuja não-consciencialização pelo agente possa de antemão afirmar-se que impede a ate-

([33]) WARDA, nota 31, p. 273 e s.; e ROXIN, nota 26, p. 208.

nuação da culpa. Tudo dependerá da peculiaridade e complexidade do caso, nomeadamente da intensidade do *conflito* em que esse valor se encontre com outros valores importantes e igualmente protegidos. Tudo dependerá assim, em último termo, do maior ou menor desvalor da atitude pessoal do agente que fundamenta o facto.

§ 31 Julgamos poder pois concluir que não existe justificação bastante, à luz do pensamento da culpa, para uma atenuação extraordinária da pena em *todos* os casos de falta de consciência do ilícito, ou nos *casos-regra*, ou *em todos menos nos de hostilidade ao direito*. Há sim justificação para uma **faculdade** de atenuação extraordinária, tal como se contém no art. 17.º-2; faculdade que não deve ser excluída, *a priori*, sequer para as hipóteses de hostilidade ao direito.

24.º CAPÍTULO

A OBEDIÊNCIA INDEVIDA DESCULPANTE

I. O problema e a sua razão de ser

§ 1 No 18.º Cap., § 13, ao tratarmos o problema da eventual justificação do facto por força autónoma de ordens oficiais ou de serviço, concluímos que, segundo o direito constitucional (art. 271.º-3 da CRP) e o direito penal (art. 36.º-2) portugueses vigentes, uma ordem ilegítima que conduza à realização de um facto criminalmente ilícito *não constitui, em si e por si mesma, uma causa justificativa* daquele: tudo o que pode ficar em aberto é uma **causa de exclusão da culpa** do subordinado que a cumpre. A maioria dos códigos penais não regula expressamente a questão, deixando tudo, em princípio, para as causas gerais de exclusão da culpa, nomeadamente, a inimputabilidade, a inexigibilidade e a falta de consciência do ilícito não censurável; e ainda, eventualmente, para legislação penal especial, *v. g.*, a que regula o exercício de actividades particularmente sensíveis para o bom funcionamento dos serviços do Estado, como é o caso das de soldados, polícias, etc. Não assim o CP português, que no seu art. 37.º dispõe, de forma incondicionada, que "age sem culpa o funcionário que cumpre uma ordem sem conhecer que ela conduz à prática de um crime, não sendo isso evidente no quadro das circunstâncias por ele representadas". Esta regulamentação identifica-se no essencial com o disposto, p. ex., no § 5 da Lei Penal Militar alemã, nos termos do qual "Se um subordinado cometer, por força de uma ordem, um facto ilícito que preenche o tipo de uma lei penal só tem culpa quando ele se apercebe de que se trata de um facto ilícito ou tal é evidente segundo as circunstâncias por ele conhecidas".

§ 2 Se se indagar a **razão** por que o legislador português se terá sentido obrigado, neste contexto, a **editar uma regulamentação específica**

do problema da obediência indevida desculpante, a resposta parece ser segura. No conflito entre a necessidade de assegurar um exercício dos serviços do Estado eficaz e tão livre quanto possível de empecilhos e de demoras, e a necessidade de garantir até ao limite possível os direitos e as liberdades do cidadão, a CRP e o CP decidiram-se claramente por uma "solução maximalista" a favor desta última necessidade e contra a primeira: se a ordem ilegítima conduzir à prática de um facto (independentemente daquela ordem) criminalmente ilícito, considera-se em todos os casos *prevalente* o dever de não praticar factos criminalmente ilícitos face ao dever de obediência. Assim ficaram defendidos, até ao limite possível, *os direitos e liberdades das pessoas* que sejam objecto, directo ou indirecto, de ordens oficiais ou de serviço. Mas é dever do Estado cuidar também da *eficiência dos serviços* que lhe incumbe prestar; e esta ficará severamente posta em causa se o subordinado hierárquico que recebe a ordem estiver sempre, ao cumpri-la, com "um pé na prisão", em virtude de poder não ter tido consciência da real ilegitimidade da ordem recebida ou de que, de todo o modo, não devia cumpri-la.

§ 3 A forma de que a lei penal portuguesa — seguindo o exemplo da citada lei penal militar alemã — se serviu para operar uma certa *concordância prática* dos interesses conflituantes, procurando sacrificá-los na menor medida possível, foi a de manter a ilicitude do facto praticado, mas consagrar uma **específica e mais lata exclusão da culpa** do subordinado; na pressuposição, decerto (1), de que, em casos deste teor, ao superior hierárquico caberá a responsabilidade principal. Resta saber em que se traduz a *especificidade* de uma tal causa de exclusão da culpa, como se *comporta* ela perante outras causas de exclusão da culpa, nomeadamente a da inexigibilidade e a da falta de consciência do ilícito não censurável; para, por fim, se poder verdadeiramente divisar o autêntico *fundamento* de exclusão da culpa aqui em questão.

II. O regime legal

§ 4 O regime contido no art. 37.º está longe de ser claro e isento de dúvidas fundadas. Mas uma coisa parece desde logo segura: ele não quer afectar a aplicação ao caso de outras causas gerais de exclusão da culpa,

(1) A que igualmente se refere ROXIN I, § 21, n.º 74.

nomeadamente, a da **inexigibilidade** (2). Se, *v. g.*, um subordinado, cumprindo a ordem ilegítima, pratica um facto ilícito como forma adequada de afastar um perigo não removível de outro modo que ameace a sua integridade física ou a de terceiro, ele actua sem culpa se não for de lhe exigir, segundo as circunstâncias do caso, comportamento diferente. Aqui, pois, a exclusão da culpa resulta, nos termos do art. 35.º-1, do estado de necessidade desculpante em que o subordinado actuou; devendo de resto sublinhar-se que as "circunstâncias do caso" — a pressão eventualmente exercida sobre o cumprimento das intenções normais do agente pelo circunstancialismo exógeno, *v. g.*, pelo facto de a ordem provir de um superior hierárquico que o agente respeita, estima ou admira, pelo receio de que o incumprimento o possa fazer perder o emprego ou lhe torne extremamente difíceis ou incómodas as condições de trabalho, etc. — podem conduzir frequentemente a uma diminuição da censurabilidade do facto e, assim, a uma atenuação da culpa.

§ 5 Esta problemática é porém estranha ao comando do art. 37.º Com o que este preceito tem a ver é antes com o **erro sobre a ilicitude** em que, por força da ordem oficial ou de serviço, o agente possa ter incorrido (3). É aqui que o legislador entendeu introduzir um regime especial relativamente ao que resultaria do disposto no art. 17.º Do que se trata pois é, em último termo, de uma regulamentação especial do problema da **falta de consciência do ilícito** do subordinado que recebeu e cumpriu a ordem. Com esta conclusão parece estar a maioria da doutrina germânica completamente de acordo, face ao preceito homólogo do § 5 da Lei Penal Militar. Mas as opiniões já se dividem quando se trata de saber se um tal preceito — e por isso também o nosso art. 37.º — altera neste domínio os termos da distinção entre erro que exclui o dolo e erro sobre a ilicitude ou apenas modifica o âmbito em que o erro sobre a ilicitude deve nesta hipótese considerar-se não censurável.

§ 6 Para uma certa doutrina, com efeito, o erro considerado no art. 37.º alteraria os próprios termos da doutrina geral do erro sobre a ili-

---

(2) Neste sentido, BRANDÃO, Nuno, *Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal*, 2006, p. 284 e ss.

(3) Assim, também, NEVES, Curado, *A Problemática da Culpa nos Crimes* Passionais, 2006, p. 141. Contra, BRANDÃO, Nuno, nota 2, p. 304 e ss.: cf. infra, § 13.

citude. E assim é que, enquanto para as hipóteses *normais* valeria a *teoria da culpa limitada*, em caso de erro relacionado com a ordem oficial ou de serviço verificar-se-ia uma certa **aproximação à teoria do dolo limitada** (4). Em geral, como defende Zipf, "o 'aperceber-se' do carácter criminoso do facto ordenado pressupõe um saber seguro do subordinado acerca das características do facto, de tal modo que representações em si inseguras e dúvidas do subordinado teriam que afastar o dolo. Através do § 5 porém o dolo é fingido nos casos em que o carácter criminoso do facto é evidente segundo as circunstâncias conhecidas do subordinado (...). Se o subordinado conhecia as circunstâncias do facto e estas caracterizavam o facto como um crime, então ao subordinado deve ser oposta a censura da 'cegueira jurídica' com a consequência da ficção do dolo" (5).

§ 7 Para outra parte da doutrina alemã, porém, é diferente o sentido da doutrina constante do § 5 da Lei Penal Militar alemã (e portanto também do nosso art. 37.º). Não é exacto — afirma Roxin — que aquele preceito se apresente como hipótese da "teoria do dolo limitada", na qual "o dolo é fingido" em caso de evidência. Do que se trata é sim e apenas de **diminuir as exigências da evitabilidade (e por isso da censurabilidade) do erro sobre a ilicitude**. Por outras palavras, não conduz logo à punição qualquer erro sobre a ilicitude evitável, mas apenas um erro sobre a ilicitude especialmente fácil de evitar" (6). Nisto se cifraria a especificidade da doutrina em matéria de exclusão da culpa nos casos de obediência indevida.

§ 8 A primeira destas duas teses não parece ter razão quando sustenta ou pressupõe que um preceito como o do nosso art. 37.º altera a delimitação dos dois tipos de erro jurídico-penalmente relevantes e altera a própria espécie de um deles; em termos que conduziriam mesmo à modificação da doutrina válida para solução do problema da falta de consciência do ilícito, que passaria da teoria da culpa limitada, válida em geral, para a teoria do dolo limitado, com a sua (legal e jurídico-criminalmente insuportável) *ficção de dolo*, válida para o facto cometido por força de ordens

(4) Sobre esta teoria v. supra, 20.º Cap., § 16 e ss.

(5) M / ZIPF, § 38, n.º 29. Fundamentalmente no mesmo sentido, já, também, DREHER, Das Wehrstrafgesetz, *JZ*, 1957, p. 396.

(6) ROXIN I, § 21, n.º 74. No mesmo sentido, já, SCHRÖDER, *LK*, § 17, n.º 54, e NEUMANN, *NK*, § 17, n.º 98.

(ilegítimas) oficiais ou de serviço. Nesta medida têm razão os críticos de toda esta doutrina quando sustentam, ao menos implicitamente, que **o erro sobre a ilicitude se desenha ainda neste campo nos termos em que ele surge em geral** (art. 17.º), por oposição ao erro que exclui o dolo (art. 16.º). Dito de outro modo, em causa não está, no art. 37.º, qualquer regulamentação do *erro que exclui o dolo* e cuja regulamentação se contém no art. 16.º Ainda aqui, se o subordinado actua sem representar a totalidade das circunstâncias do facto indispensáveis para uma orientação correcta da sua consciência ética para o desvalor da ilicitude do facto, esse erro exclui o dolo e o facto só poderá eventualmente vir a ser-lhe imputado a título de negligência. Ainda aqui, por outras palavras, não é jurídico-penalmente relevante a circunstância de o facto ser consequência de uma ordem oficial ou de serviço.

§ 9 O problema a que se refere o art. 37.º suscita-se pois *apenas* quando o subordinado praticou o ilícito com dolo do facto, mas sem consciência da sua ilicitude. É então que a culpa é excluída por força da própria falta de consciência da ilicitude, salvo se a ilicitude fosse evidente no quadro das circunstâncias por ele representadas. O que significa que aquilo em que a lei introduz especificidades não é na configuração da falta de consciência do ilícito, sequer na sua delimitação face ao conhecimento da factualidade (em suma, nos problemas tratados supra, no 20.º Cap., § 5 e ss.), é sim, e só, no âmbito da **censurabilidade** da falta de consciência do ilícito; no sentido de *estreitar* este âmbito (considerado supra, no 23.º Cap.) relativamente ao disposto no art. 17.º-1; e de consequentemente **alargar o âmbito da desculpa**. De que maneira opera a lei esta alteração e cria um tratamento específico?

§ 10 Seguramente que não, como pretende a segunda das teses alemãs referidas no § 7, diminuindo as exigências da **evitabilidade** do erro sobre a ilicitude; por isso que, como procurámos mostrar, o critério da evitabilidade (ou da vencibilidade) é inadequado ao sentido da censura daquela espécie de erro e não constitui via possível da solução do problema. A incensurabilidade do erro sobre a ilicitude não repousa na sua inevitabilidade ou invencibilidade; antes sim (como dissemos supra, 23.º Cap., § 11 e ss.) na manutenção no agente de uma *recta* — se bem que errónea — consciência ético-jurídica, fundada em uma atitude de fidelidade ou correspondência a exigências ou pontos de vista eticamente relevantes. É neste preciso contexto que o art. 37.º — sem pôr em causa o horizonte de com-

preensão do problema da incensurabilidade do erro sobre a ilicitude — avança com um **critério muito mais amplo e menos exigente de desculpa**.

§ 11 Com efeito, segundo aquele preceito, o erro do subordinado sobre a ilicitude do facto só será censurável se e quando uma tal ilicitude fosse **evidente** no quadro das circunstâncias por ele representadas. Vistas as coisas por outro lado, isto significa que, sempre que, naquele quadro, a questão da ilicitude do facto se revelar *discutível*, *controvertida*, *obscura* ou mesmo só *pouco clara* está, sem mais, verificada uma **causa de exclusão da culpa**. Solução esta que, deve convir-se, mal se deixa compatibilizar com o sentido e a essência da culpa jurídico-penal, tal como ela resulta da nossa concepção (como também, *a pari*, da concepção que vê a culpa como capacidade de determinação pela norma, como "poder de agir de outra maneira"). Julgamos divisar aqui de algum modo um passo do legislador em direcção à velha tese jusnaturalista do "inatismo" ou "evidência" de certas valorações de ilicitude e à absoluta indesculpabilidade do erro em casos tais (supra, 23.º Cap., § 17) (7), para a partir daí retirar a conclusão inversa de que em todas as hipóteses em que uma tal evidência se não verifique a culpa do agente fica afastada. Como há — coisa que, como vimos insistindo, se não verifica relativamente às outras causas de exclusão da culpa no direito português, diversamente do que sucede porventura com o direito alemão — uma espécie de *funcionamento automático* da exclusão da culpa em função de um circunstancialismo *objectivo* e *exterior* à pessoa do agente: o carácter para todos evidente ou não evidente da valoração da ilicitude.

§ 12 Fica deste modo próxima, também para o nosso direito, a asserção de Roxin — segundo ele, como sabemos já, em geral válida para as chamadas causas de desculpa — de que não estamos *neste caso* perante uma autêntica causa de exclusão da culpa, mas perante uma situação em que, face a uma culpa ainda possivelmente subsistente, o legislador entende dever negar a **responsabilidade do agente**, porque tal é ainda suportável do ponto de vista preventivo (8). Suportável, acrescentaremos, em virtude de o legislador ter porventura considerado **em geral compreensível** que o subordinado tenha actuado na crença ou na pressuposição da legitimidade da ordem recebida e, por conseguinte, da licitude do facto, salvo

(7) Sobre a questão do erro de direito natural, já, o nosso *O Problema*, § 5.

(8) ROXIN I, § 21, n.º 74. Em sentido crítico, BRANDÃO, Nuno, nota 2, p. 303.

nos casos em que a ilicitude fosse evidente no quadro das circunstâncias por ele representadas. É no fundo esta circunstância que oferece fundamento a que se considere a obediência indevida desculpante como uma *autónoma* causa de "exclusão da culpa" e não apenas como um caso especial — que, em último termo, vimos que também o é — de incensurabilidade do erro sobre a ilicitude.

§ 13 Opondo-se ao entendimento do art. 37.º que acabámos de defender, sustenta Nuno Brandão que aquele preceito contém um regime especial não do erro sobre a ilicitude, mas do **erro sobre os pressupostos de uma causa de justificação**, concretamente, da legitimidade material de uma ordem oficial ou de serviço (9). Não cremos, porém, que este entendimento deva considerar-se procedente. Desde logo, se a conveniência de um regime especial pode ter-se em geral por duvidosa e se não contém na maioria dos CPs (supra, § 1), a sua bondade político-criminal seria severamente posta em causa quando a sua função se reduzisse — como seria inevitável se configurado como um caso particular de erro sobre os pressupostos de uma causa de justificação — ao **afastamento do tipo de culpa negligente** (art. 16.º-3). Claro que se o agente se põe a questão em termos de legitimidade material da ordem (art. 31.º-2/*c*)) e porventura aceita erroneamente a existência de *pressupostos* (10) de onde aquela resultaria (erro de conhecimento, intelectual, da consciência psicológica), deve aplicar-se directamente o art. 16.º-2. Para tanto não se torna necessário o art. 37.º, como também não relativamente a qualquer outra causa de justificação. O caso mais vulgar e frequente será, no entanto, o de dever reconduzir-se o erro sobre a "legitimidade material" da ordem — *rectior*, a falta de consciência de que a ordem "conduz à prática de um crime" (art. 36.º-2) — a uma **falta de consciência do ilícito**, ainda que sob a forma de um erro sobre **a existência ou os limites de uma causa de justificação** (erro de valoração, moral, da consciência ética). Pensamos que só neste contexto poderá ganhar fundamento político-criminal bastante um tratamento da censurabilidade do erro mais restrito do que o contido no art. 17.º-2.

(9) BRANDÃO, Nuno, nota 2, p. 284 e ss.

(10) O termo vai sublinhado para que se não esqueça ou minimize que aqui se trata, por excelência, de um "elemento normativo": cf. supra, 13.º Cap., § 10 e ss.

25.º CAPÍTULO

O FACTO DE CONSCIÊNCIA (*)

I. Do "facto de convicção" ao "facto de consciência"

§ 1 Até há poucas décadas era vivamente controvertido na doutrina o tratamento jurídico-penal do chamado **agente por convicção**, o saber se uma tal convicção era relevante e, em caso afirmativo, de que modo e a que nível dogmático ela influenciava a responsabilização do agente. Como agente por convicção se considerava, na expressiva definição de Eduardo Correia, aquele que "tem consciência do carácter proibido do facto mas, em nome de uma certa convicção política, religiosa ou social, nega a natureza criminosa do comportamento que leva a cabo, substituindo a sua à valoração legal. Quer dizer: as convicções políticas, religiosas ou sociais do agente aparecem então como legitimação pessoal da prática de certos actos realizados como meio de actuação daquelas convicções". E logo acrescentava Correia: "A influência deste elemento sobre a punição tem sido muito discutida e depende, fundamentalmente, da concepção do mundo e da vida que a ordem jurídica respire, dos limites do direito material que a ela possam ser opostos, ou que possam ser opostos às concepções pessoais dos que, em seu nome, violarem a ordem jurídica estabelecida" (1). Esta controvérsia encontra-se hoje praticamente silenciada, por duas razões principais.

§ 2 Uma provém da circunstância de sobre aquele tratamento se ter estabelecido, no seio da dogmática jurídico-penal, uma larga *concordância*

(*) As ideias constantes deste capítulo foram por nós apresentadas pela primeira vez no artigo "Dos factos de convicção aos factos de consciência: uma consideração jurídico-penal", publicado na obra colectiva *Ab Vno ad Omnes* e depois, no essencial da versão aqui contida, no nosso contributo Gewissenstat, Gewissensfreiheit und Schuldausschluss, *Roxin-FS*, 2001, p. 531.

(1) CORREIA, Eduardo, II, n.º 59, II.

doutrinal. Concordância, desde logo, em que meras convicções subjectivas não possuem força bastante para conferir à conduta que delas promane um conteúdo social de sentido capaz de a diferenciar daquelas outras que, segundo o pensamento legislativo, entram na área de tutela da norma incriminadora (2); pelo que, consequentemente, não podem tais convicções ser valoradas pela ordem jurídica a um nível sensivelmente superior ao do bem jurídico lesado pela conduta, nem tão-pouco justificar a renúncia da ordem jurídica à protecção daquele bem jurídico. Com o que fica em princípio assegurada a **afirmação da tipicidade e da ilicitude** do facto de convicção. Mas concordância ainda — embora de uma forma menos nítida e com hesitações — em que a convicção pessoal do agente **não pode por si mesma afastar ou excluir a culpa**, qualquer que seja a forma como, em definitivo, se acolha o relacionamento da culpa jurídico-penal com a culpa ética; porque também a mera convicção — salvo dentro de um subjectivismo ético exasperado que nunca serviria para ligar a culpa jurídico-penal a uma culpa ética — não pode ter em si mesma a força de afastar a própria censurabilidade do facto (3).

§ 3 E a concordância não se quebra quando, da sede dos pressupostos do facto punível, se passa para a dos **efeitos** ou das **consequências jurídicas do facto**. Também a este nível existe hoje consenso em que a convicção do agente não deve ter por si mesma força para conduzir a um privilegiamento em sede de execução da pena a que venha a ser condenado e que se traduziria em ser-lhe aplicada, em vez de uma pena de prisão, uma pena privativa da liberdade especial **não desonrosa** (4). Desde o momento em que a moderna política criminal reconheceu que, em nome de um princípio irrenunciável de socialização do delinquente, qualquer pena de prisão deve ser expurgada, em toda a medida possível, de carácter estigmatizante, desonroso ou infa-

---

(2) E isto não só quando se veja no direito, à maneira positivista, uma ordem externa e heterónoma de coacção, mas mesmo quando, ao modo de RADBRUCH, Der Überzeugungsverbrecher, *ZStW 44*, 1924, p. 34, se defenda que a norma jurídica só assume a natureza de "norma de dever" na medida do seu "reconhecimento" pelo destinatário; pois ainda aqui o direito "obrigaria" em todos os casos com inteira independência da sua aceitação individual. Exemplar sobre toda esta discussão, WELZEL, Gesetz und Gewissen, *Juristentag-FS*, I, 1960, p. 398.

(3) Assim — explicitando o que considera uma *communis opinio* anterior —, EBERT, *Der Überzeugungstäter in der neueren Rechtsentwicklung*, 1975. No mesmo sentido, a conclusão de DIAS, Silva, *A Relevância Jurídico-Penal das Decisões de Consciência*, 1987, p. 147 e ss. O tema é agora retomado por PALMA, Fernanda, Crimes de terrorismo e culpa penal, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 235 e ss., coincidindo no essencial (p. 257 e s.), com nova e aprofundada fundamentação, com os resultados que defendemos.

(4) Como foi proposta de RADBRUCH, contida no § 71 do *Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches* de 1922.

mante, aquela proposta perdeu a sua razão de ser (5). Em aberto ficará apenas a questão de saber se à convicção do agente deve ser atribuído significado particular em termos de *medida da pena*; questão que, continuando ainda hoje a dar lugar a divergências, parece dever solucionar-se no sentido de que a convicção nem sempre terá de funcionar a favor do agente, mas só deverá servir para atenuar a culpa e a pena quando no facto se exprimam qualidades pessoais não desaprovadas ou inclusivamente prezadas pela ordem jurídica (6).

§ 4 A segunda razão do prático silenciamento dogmático do tema jurídico-penal do agente por convicção reside em que nos nossos tempos — num período que, verdadeiramente, vem já dos anos 60 do século passado e em que constituiu um marco inapagável a tomada de posição do Tribunal Constitucional Federal alemão (BVerfGE 12, 45) — a questão do agente por convicção como que se "deslocou", para se integrar na problemática dos chamados **factos de consciência**; dos factos cuja decisão provém da "instância de controlo para preservação da identidade da personalidade" (7) e, assim, mesmo do cerne da personalidade ética. Projectando o tema das decisão de consciência no contexto do seu eventual relevo jurídico, dir-se-ia que o problema só pode surgir como um capítulo não autónomo da questão mais vasta — e de claro entono jurídico-filosófico — das *relações entre a lei jurídica e a consciência ética individual*: da questão de saber, concretamente, se a lei jurídica continua válida perante uma decisão de consciência que a contraria, ou se, pelo contrário, uma tal validade está submetida a uma "reserva de consciência" (8). Mas o que foi outrora um conflito doutrinal de índole caracterizadamente jurídico-filosófica e, neste sentido, extra-sistemático, penetrou hoje nos sistemas jurídicos democráticos e volveu-se, desta maneira, em questão intra-sistemática e mesmo jurídico-positiva: desde o momento preciso em que se compreendeu que o problema jurídico das decisão de consciência se cone-

(5) Cf. o nosso *DP II*, §§ 22, 88. V., por último, sobre a compatibilidade das *shame sanctions* com o pensamento fundamental das penas criminais, KUBICIEL, Sham sanctions — Ehrenstrafen im Lichte der Straftheorie, *ZStW 118*, 2006, p. 44.

(6) Cf. o nosso *DP II*, § 348.

(7) Nas palavras tão exactas de LUHMANN, Die Gewissensfreiheit und das Gewissen, *AöR*, 1965, p. 260.

(8) Questão esta que conforma, como assinalou WELZEL, nota 2, p. 395, uma das mais trágicas tensões da existência humana, encerrada como se encontra na antinomia inevitável entre as exigências objectivas, em geral válidas e vigentes, da ordem jurídica democrática, e o mandamento primordial do Estado de Direito de que a ordem jurídica sirva o livre desenvolvimento da personalidade de cada um.

xionava irremediavelmente com a liberdade de consciência garantida em todas as Constituições democráticas como um direito fundamental da pessoa (CRP, art. 41.º-1: "A liberdade de consciência... é inviolável").

§ 5 Do ponto de vista jurídico-penal a questão é pois, hoje, a de saber de que modo (se é que de algum) esta liberdade fundamental de consciência, jurídico-constitucionalmente assegurada de forma aparentemente absoluta, se reflecte sobre os factos de consciência que constituam crimes, no sentido de conformar, de limitar ou mesmo de afastar a sua relevância jurídico-penal. Questão que, em termos dogmáticos, se desdobra em dois problemas sucessivos: o de saber qual o **verdadeiro sentido** e a **exacta amplitude do privilégio jurídico-constitucional da liberdade de consciência**; e o de determinar, qualquer que seja um tal sentido e amplitude, a que **nível da doutrina geral do facto punível** aquele privilégio releva — se a nível do tipo, da ilicitude, da culpa, da punibilidade —, com o conjunto de consequências diversificadas, na perspectiva prática da aplicação do direito, que aquela determinação implica.

II. Decisão de consciência e liberdade de consciência

1. O facto por "decisão de consciência"

§ 6 O que avulta no *facto por decisão de consciência* (ou, numa fórmula mais curta, *facto de consciência*) para efeitos jurídico-penais é — na esteira da já acima referida decisão do TC alemão — a experiência ou a vivência incondicionadas (retiradas que sejam a estas expressões quaisquer ressonâncias psicológicas, aqui insuficientes e mesmo descabidas, para serem substituídas por um entendimento que com razão se dirá "existencial" ([9])) do imperativo de conduta que da decisão deriva: o agente, cumprida a decisão de consciência, responde a um dever que **compromete a sua inteira personalidade** ([10]); enquanto, pelo contrário, o não cumprimento tem como preço inevitável a **destruição** ou, em todo a caso, a **violação** irremediável da personalidade ([11]). Por esta via fica afastada a

([9]) Cf., sobre o ponto, o estudo de END, *Existentielle Handlungen im Strafrecht*, 1959, especialmente p. 35 e ss.

([10]) ROXIN, Die Gewissenstat als Strafbefreiungsgrund, *Maihofer-FS*, 1988, p. 392 e s.

([11]) De "conflito de consciência *destruidor* da personalidade" fala muito justamente RUDOLPHI, Die Bedeutung eines Gewissensentscheider für das Strafrecht, *Welzel-FS*, 1974, p. 630. Cf., também, STRATENWERTH / KUHLEN, § 10, n.º 117.

possibilidade de dar relevo, na caracterização de uma qualquer decisão como "de consciência" seja aos conteúdos, seja às características das máximas de acção nela implicadas. Importa não ceder à tentação de determinar *o que é* uma decisão de consciência em função do que se entenda deverem ser o seu significado e as suas consequências à luz de um qualquer ordenamento normativo e, assim, em função de *como* deve ela ser valorada: perante uma decisão de consciência, tal como ficou simplesmente definida, não há nenhuma instância humana de validade que possa concorrer com sentido para a sua caracterização ([12]).

2. A liberdade de consciência (CRP, art. 41.º-1)

§ 7 A partir daqui dir-se-ia ficar sem mais plenamente comprovada a asserção de vários autores, acentuada agora com particular firmeza por Roxin, segundo a qual é o **recurso imediato à liberdade de consciência assegurada pela Constituição** que deve "determinar a avaliação jurídico-penal do facto de consciência" ([13]). E todavia mal se divisa, em toda a doutrina sobre a matéria, um só autor que esteja disposto a aceitar que *toda e qualquer* decisão de consciência, só por o ser, cabe imediatamente no âmbito da norma constitucional de protecção da liberdade de consciência. O caminho — infinitamente mais penoso — será pois, inevitavelmente, o de tentar determinar com a precisão possível, mas simultaneamente com clara intenção *restritiva*, o verdadeiro sentido e o exacto âmbito da liberdade de consciência que as Constituições dos países democráticos reputam inviolável. Afastada a concepção — outrora todavia de larga audiência, quando não mesmo dominante na doutrina do Estado ([14]) — segundo a qual o âmbito da norma constitucional protectora da liberdade de consciência abrangeria apenas o *forum internum*, a formação interna da consciência, e não a liberdade de *manifestação* da consciência (a sua *actuação na vida social*), a via através da qual o problema pode encontrar um princípio de solução reside na sua consideração à luz das doutrinas jurídico-constitucionais da *colisão* ou *conflito* de direitos fundamentais e, de forma mais específica, dos **limites imanentes** dos direitos fundamentais.

([12]) Neste contexto tendo pleno cabimento o princípio, recordado por WELZEL, nota 2, p. 396, segundo o qual "relativamente à decisão de consciência não há juiz algum".

([13]) ROXIN I, § 22, n.º 102.

([14]) Indicações a propósito em ROXIN I, § 22, n.º 105.

§ 8 Pondo entre parênteses as tentativas especificamente *jurídico-constitucionais* de domínio desta problemática ([15]), Roxin é porventura o autor que, na **vertente jurídico-penal**, mais longe levou a análise dos limites imanentes do direito fundamental da liberdade de consciência ([16]). As suas conclusões parece poderem resumir-se, com razoável fidelidade, pela forma seguinte: os primeiros limites imanentes com que se depara são logo — bem ao jeito da hermenêutica jurídico-constitucional acabada de referir — os constituídos por "a manutenção do Estado, a sua segurança e os seus mais altos princípios constitucionais", uma vez que "a Constituição assegura a liberdade de manifestação da consciência apenas no quadro do Estado, para o qual foi criada" ([17]). Em todos os casos restantes — estejam em causa bens jurídicos comunitários ou individuais —, a determinação dos limites imanentes dependerá de uma **ponderação** dos bens jurídicos conflituantes. Uma ponderação que terá de ser decidida **a favor da limitação** sempre que, de certa forma, o Estado se encontrasse tolhido na prossecução das suas finalidades fundamentais, por o facto representar um "pôr em perigo de propósitos estaduais nucleares"; como também sempre que legitimar o facto de consciência significasse conferir ao indivíduo uma capacidade de intervenção que excedesse aquela que o próprio Estado possui. Mas uma ponderação que já poderá ser decidida **a favor do facto de consciência** quando, com ele, não sejam atingidas a liberdade ou outros direitos fundamentais dos outros, ou só o sejam "de modo periférico"; como também "quando o agente de consciência não nega os direitos de acção jurídico-constitucionalmente protegidos dos outros como tais, mas, na sua necessidade de consciência, apenas pre-

([15]) Onde se destaca a análise de BÖCKENFÖRDE, Das Grundrecht der Gewissensfreiheit, *Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer 28*, 1970, 59, e a de HERZOG, *in*: Maunz / Dürig / Herzog / Scholtz, *Grundgesetz*, [6]1988, art. 4, n.ºs 149-157, ambas valoradas por ROXIN I, § 22, n.º 108. Claramente contra a posição de princípio do texto — sem todavia o referirem — CANOTILHO / MOREIRA, art. 41.º, anot. II: "A liberdade de consciência é um direito constitucionalmente garantido sem restrições, sendo aqui particularmente difíceis tarefas metódicas de concordância prática, de ponderação ou de balanço entre bens. Pela sua própria natureza de liberdade individual de convicções — instância autónoma da pessoa — dificilmente suporta qualquer ideia de 'limite imanente' e exige sempre uma análise cuidada quanto ao estabelecimento de restrições heterónomas".

([16]) Cf. ROXIN I, § 22, n.ºs 112-119, ao qual pertencem as citações que se seguem.

([17]) Muito mais liberal, na doutrina portuguesa, se revela o resultado da análise de DIAS, Silva, nota 3, p. 78: "Limite do conteúdo do direito de liberdade de consciência é constituído somente pelos direitos individuais de terceiros: só estes assumem plenamente a acepção de '*competing rights*'".

judica de forma passageira, para o bem ou para o mal, os direitos dos outros".

§ 9 Esta via havia sido, de algum modo, já trilhada na doutrina portuguesa por Silva Dias ([18]). E com ela coincide largamente, *nos resultados*, a recente análise de Muñoz Conde. Em todo o caso, com uma diferença fundamental, que deriva da circunstância de Muñoz Conde se não sentir obrigado a determinar à partida como se relaciona o facto de consciência com a liberdade de consciência jurídico-constitucional e de a sua análise ocorrer por isso — talvez se possa dizer assim — como que num "espaço livre de injunções jurídico-constitucionais" ([19]).

3. O conflito subsistente

§ 10 Deste modo se logra a demarcação de um larguíssimo âmbito de factos de consciência que já não caem na área de protecção da liberdade de consciência e constituem por isso factos cuja apreciação se revela livre de peias jurídico-constitucionais. Assim se consegue, por outro lado, preservar um âmbito jurídico-constitucionalmente tutelado de liberdade de consciência que tem a ver já com a sua **manifestação externa** e mesmo, porventura, com autênticos **direitos de acção**. Este traçado dos limites imanentes respeita em geral, ainda por outro lado, os requisitos de que a doutrina constitucionalista faz depender a legitimidade das limitações de direitos fundamentais, nomeadamente, os princípios da proporcionalidade e da preservação do núcleo essencial do direito fundamental. E no entanto, apesar de tudo, há nesta análise, em perspectiva jurídico-penal, muito de questionável, por duas razões fundamentais.

§ 11 A primeira tem a ver com os critérios da análise e com a sua adequação à solução do problema. Um critério geral como o do "cumprimento das tarefas essenciais do Estado", ou critérios particularizados como os do prejuízo "periférico" da liberdade e dos direitos do outro ou da "afectação fugaz" dos direitos dos outros não possuem a **concreção** e a **segurança** indispensáveis ao labor jurídico-penal. A segunda razão contende com que, uma vez reconhecido que certos factos de consciência, muitos ou poucos, caem na área de tutela da norma constitucional relativa

---

([18]) DIAS, Silva, nota 3, p. 65 e ss.

([19]) MUÑOZ Conde, La objección de conciencia en derecho penal, *in*: Silva Sánchez (org.), *Política criminal y nuevo derecho penal. Libro de Homenaje a Claus Roxin*, 1997, p. 279.

à liberdade de consciência, é preciso perguntar *quais são as específicas consequências jurídico-penais* que daí derivam. Pergunta que se diria poder ter apenas uma resposta: se o facto de consciência estiver coberto pela credencial constitucional de um direito fundamental, então esse facto corresponde ao **exercício de um direito** (corresponde, na expressão atrás referida de Herzog, a um "direito de acção") e tem por isso de configurar, pelo menos, uma conduta jurídico-penalmente **justificada** (20). Roxin dirige todavia uma crítica terminante a esta conclusão: "isso é errado", afirma. Porque, argumenta, "a inviolabilidade da liberdade de consciência deve proteger o indivíduo da coacção da consciência que seria exercida através da ameaça penal. Ela não pode porém ter o sentido de que o Estado faz sua a decisão de consciência do indivíduo, se esta diverge das leis". Por isso conclui Roxin que o facto de consciência, ainda que jurídico-constitucionalmente coberto pela inviolabilidade da consciência, é um facto *ilícito* (21); como é também, acrescenta, um facto *culposo* (porque o agente não perderia, perante a voz da sua consciência, a "permeabilidade normativa" ou o "poder de agir de outra maneira"). Relativamente a um tal facto deve simplesmente excluir-se a **responsabilidade** do agente, porque o legislador renuncia ali à pena em virtude de ela não surgir necessária de um ponto de vista preventivo (22).

§ 12 Esta argumentação suscita, no entanto, **dificuldades insuperáveis**. *Se* manifestações da liberdade de consciência existirem que, apesar de se traduzirem tipicamente na prática de um facto punível, se encontram cobertas pelo exercício de um direito fundamental constitucionalmente protegido; se a Constituição, ademais, as inscreve não apenas entre os seus princípios de tolerância e de compreensão pelos modos de pensamento e de actuação da pessoa, mas directamente entre os seus direitos, liberdades e garantias fundamentais; — então impõe-se considerar que elas constituem autênticos *direitos* de acção e não podem conformar *ilícitos* jurídico-penais. Atrás desta conclusão está mais de um século de especulação jurídico-penal sobre os fundamentos não apenas construtivos, conceituais e sistemáticos das causas de justificação, mas também teleo-

(20) Entre outros que consideram esta conclusão inevitável, PETERS, Überzeugungstäter und Gewissenstäter, *H. Mayer-FS*, 1966, p. 257, BURSKI, *Die Zeugen Jehovas, die Gewissensfreiheit und das Strafrecht*, 1970, p. 88 e ss., e DIAS, Silva, nota 3, p. 76.

(21) ROXIN I, § 22, n.º 121. No mesmo sentido, MUÑOZ Conde, nota 19, p. 286.

(22) ROXIN I, § 22, n.º 125 e ss.

lógico-funcionais de todo o sistema penal; especulação à qual não pode renunciar-se sem fazer recuar de outro tanto tempo a evolução da nossa disciplina. Por caminhos tais acaba-se por atribuir um campo ainda *demasiado lato* ao direito fundamental da liberdade de (manifestação da) consciência; e por conceder um campo ainda *demasiado estreito* a uma sua específica e autónoma consideração jurídico-penal. É por isso na "desconstitucionalização" dos factos de consciência que tem ainda de trabalhar-se como via para encontrar para eles uma mais justa e adequada consideração jurídico-penal. O problema jurídico-penal, por outras palavras, não passa tanto por determinar o exacto âmbito de protecção da norma constitucional que tutela a liberdade de consciência, quanto por determinar **se aquela protecção subsiste ainda quando o facto de consciência constitui um crime**.

III. O facto punível como limite imanente da liberdade de consciência

§ 13 Uma *consideração preliminar* se torna necessária, tendente a demarcar bem (e, na verdade, a *estreitar*) o âmbito problemático em discussão. Como defende Roxin, não existirá desde logo qualquer limite à liberdade de consciência sempre que as finalidades legislativas possam ser alcançadas, apesar do facto, através de uma **alternativa** que se apresenta à consciência individual como **neutral**. Pode de algum modo dizer-se que nestas hipóteses — de *omissão*, precisa Roxin — existe afinal uma total possibilidade de *harmonização* ou de *concordância prática* dos bens e interesses de outro modo conflituantes; e que consequentemente, no âmbito jurídico penal, falta logo a *tipicidade* do facto de consciência por aí se não encontrar presente nem o dever de acção, nem o dolo ([23]). Todo o restante âmbito problemático persiste, porém. De um ponto de vista teorético, deve convir-se ser ainda na doutrina dos limites imanentes da liberdade jurídico-constitucional de consciência que a solução do problema há-de ser procurada; mas indo nela bem mais longe do que aquilo que até agora tem sido considerado. Indo, concretamente, até ao ponto de se sustentar que a manifestação da liberdade de consciência encontra **um seu limite imanente sempre que preenche um tipo de ilícito**.

§ 14 Há que tomar verdadeiramente a sério a ideia (supra, 6.º Cap., § 25 e s.) de que a legitimação de uma qualquer criminalização está depen-

([23]) Assim, ROXIN I, § 22, n.º 120; e, depois, MUÑOZ Conde, nota 19, p. 280.

dente da possibilidade efectiva de entre ela — *rectior*, entre o bem jurídico que tutela — e o ordenamento axiológico jurídico-constitucional se poder estabelecer um claro nexo de mútua referência. O que significa que na base da área de tutela de qualquer crime está sempre um **direito ou interesse constitucionalmente relevante que**, como tal, **entra nas finalidades essenciais do Estado tutelar**. Há decerto crimes mais graves e crimes menos graves. Mas, do ponto de vista que agora interessa à argumentação, não há crimes que ponham em causa e outros que não ponham em causa a realização das finalidades essenciais do Estado; da mesma maneira que não há crimes que afectem o cerne e outros que afectem apenas a periferia dos direitos fundamentais, pessoais ou comunitários. Se um facto é *legitimamente* considerado um crime pela lei ordinária, isso é sinal de que ele põe em causa — directamente quando se trata de bens jurídicos individuais, indirectamente, mas nem por isso de forma menos efectiva, quando se trata de bens jurídicos supra-individuais ou colectivos — a livre realização da pessoa, seja como pessoa individual, seja como membro da comunidade. Numa palavra, que em geral se considera definitiva, mas que talvez ainda se não pense com a exigível profundidade: função do direito penal é tutelar subsidiariamente bens jurídicos e, por esta via, assegurar *as condições mínimas de funcionamento da sociedade* por forma a permitir *o mais livre desenvolvimento possível da personalidade de cada um*; de forma a permitir, afinal, a subsistência do *primeiro dos fundamentos* de toda a ordem democrática.

§ 15 A esta luz, impõe-se a proposição segundo a qual a manifestação da liberdade de consciência depara com um seu limite imanente **sempre** que o facto de consciência conduz à prática de um crime, *rectior*, à realização de um ilícito-típico. Com aquela proposição não sofrem inapelavelmente nem, por um lado, os valores da tolerância e do respeito pela mundividência de cada pessoa, nem, por outro lado, a observância da vontade das maiorias e da obediência devida à lei vigente e válida; valores que — todos eles e não apenas os primeiros — são apanágio do Estado de Direito. Com ela não fica eliminada, por outra parte, a liberdade de manifestação da consciência: quer porque existe toda uma multidão de comandos estaduais não penais não constitucionalmente implicados, relativamente aos quais pode porventura valer, para as decisões de consciência que os violem, o princípio da ponderação de direitos ou de bens conflituantes; quer porque, relativamente às decisões de consciência hoje talvez mais frequentes e pesadas, e particularmente impressionantes pela força que os *media* lhes

concedem — as chamadas *acções de protesto*, em regra politicamente condicionadas —, uma sociedade democrática deve possuir uma larga panóplia de formas através das quais esses "protestos de consciência" se possam exprimir e articular livremente (liberdade de imprensa, de associação, de reunião, de manifestação, etc.) sem passar pelo cometimento de factos penais ilícitos-típicos (24). Assim se justificará a conclusão de que **sempre que o facto de consciência se traduz na realização de um ilícito-típico, aí se depara com um limite imanente da liberdade de consciência jurídico-constitucionalmente assegurada**. Pelo que o problema jurídico-*penal* do facto de consciência acaba afinal por se revelar estranho ao problema da liberdade jurídico-*constitucional* de manifestação da consciência, por aqui se operando aquilo que atrás chamámos a sua "desconstitucionalização".

IV. O facto de consciência e a exclusão da culpa jurídico-penal

§ 16 Com a conclusão acabada de expor não fica solucionado, porém, o problema da definição do estatuto jurídico-penal do facto de consciência, antes se podendo dizer que, em rigor, só agora começa. Afastada a peia jurídico-constitucional, importa saber se a circunstância de aquele facto possuir uma específica **qualidade** (o provir mesmo do cerne da consciência ética do agente e o comprometê-la de forma integral) e uma particular **consequência** (a de, não sendo seguido o "apelo da consciência", daí poderem decorrer danos irreparáveis para a personalidade ética do agente) deve ou não relevar na inteira consideração jurídico-penal; e, em caso afirmativo, a que nível deve produzir os seus efeitos.

1. Facto de consciência, responsabilidade e culpa

§ 17 Prejudicada, pelo que atrás se disse, a possibilidade de o facto de consciência se considerar *lícito* por força da credencial jurídico-constitucional da liberdade de consciência, lugar sistemático da doutrina geral do crime teleologicamente adequado à sua eventual relevância só pode ser o da *culpa* ou da *responsabilidade* jurídico-penais. Pondo entre parênteses, no presente contexto, as reservas que suscita a doutrina roxiniana da *responsabilidade* (supra, 22.º Cap., § 7 e ss.), importa considerar a razão substantiva que, segundo Roxin, conduziria à negação da **responsabilidade**

(24) Assim, mesmo, ROXIN I, § 22, n.º 111.

do agente de um facto de consciência: a de que nestes casos se deve renunciar à pena, porque ela não surge como necessária de pontos de vista preventivos (25). Uma tal razão não parece, porém, aceitável. Se nenhum facto que preenche um tipo legal de crime goza da credencial jurídico-constitucional da liberdade de consciência, a afirmação da desnecessidade preventiva teria de ligar-se à pura circunstância de o facto se apresentar como *de consciência* e não à de ele reentrar na liberdade jurídico-constitucional de consciência. O que conduziria então a ter de negar-se a necessidade de pena relativamente a **todo e qualquer** facto de consciência, só por o ser. Deste ponto de vista, a proposição segundo a qual o facto de consciência surge como desnecessitado de pena volver-se-ia em afirmação que parece ter contra ela a realidade das coisas, tanto mais quanto se tenha em conta que o facto de consciência, precisamente por o ser, encerra em si perigos potenciados e particularmente intensos de repetição e de abalo da validade e da força de vigência comunitárias da norma violada (26).

§ 18 Aquilo que *pode* afectar a legitimidade da punição do facto de consciência não é assim a desnecessidade preventiva da pena, mas algo de mais primordial nos quadros do Estado de Direito democrático: é a *eminente dignidade* da pessoa do agente que pode ser violada se em certos casos — pouco frequentes embora, se não mesmo excepcionais — lhe for aplicada uma pena criminal. O que, uma vez dito, significa que uma eventual relevância do facto de consciência apenas pode operar pela via da **culpa jurídico-penal**; e pela culpa jurídico-penal quando a este conceito se confira a fundamentação político-criminal e a função no sistema que temos vindo a defender.

2. O facto de consciência e as causas legais de exclusão da culpa

§ 19 Traduzida a anterior conclusão em termos dogmáticos, ela significa que o facto de consciência pode constituir uma **causa de exclusão da culpa**. Se, contudo, com isto se pretende significar que o facto de consciência pode, *em si mesmo*, reconduzir-se a uma situação de falta de

(25) ROXIN I, § 22, n.º 123, e § 19, n.ºs 1-7.

(26) Cf., também, PALMA, Fernanda, nota 3, p. 254 e ss., e *O Princípio da Desculpa em Direito Penal*, 2005, p. 225 e ss.

consciência do ilícito ou de inexigibilidade legalmente prevista, então deve concordar-se que qualquer destas posições é criticável e não merece ser aceite ([27]).

§ 20 Que ao agente de consciência não falta a **consciência do ilícito** é algo ínsito nos próprios termos do problema; bem podendo inclusivamente dizer-se que a dimensão "trágica" da decisão de consciência, de que falou Welzel (supra, nota 8), provém do conhecimento simultâneo pelo agente de que, realizando-a, se opõe aos comandos jurídicos, se não mesmo à ordem de valores que ao ordenamento jurídico preside. É verdade que a *tensão espiritual* que precede o facto de consciência pode ser uma tal que faça incorrer o agente num erro sobre a existência ou sobre o âmbito ou os limites de uma causa de justificação ([28]). Em casos tais, porém, se a causa ou o motivo do erro residem no conflito de consciência e na consequente decisão, a verdade é que a eventual exclusão da culpa não ficará a dever-se-lhes de forma autónoma, antes sim ao erro e à falta não censurável de consciência do ilícito que delas promanam.

§ 21 No que toca, por outra parte, às constelações de inexigibilidade legalmente consagradas, todos parecem estar de acordo em que a única que poderia estar aqui em questão seria a do **estado de necessidade desculpante**; para a larga maioria dos autores acabar porém — com razão — por recusar a solução. É certo que o facto de consciência é, por definição, motivado por considerações (religiosas, morais, políticas, sociais) profundas que, ultrapassando a mera convicção, determinam o comprometimento total e sem alternativa da personalidade ética. Mas ainda quando este comprometimento pudesse ser substantivável e objectivável na medida indispensável à configuração de um autêntico bem jurídico — porventura através da sua redutibilidade (em todo o caso duvidosa ([29])) à "integridade moral" da pessoa ou, em certas hipóteses, ao "valor da vida eterna" —, um tal bem jurídico não caberia seguramente no catálogo daqueles que o nosso CP, no art. 35.º-1, considera relevantes para um estado de necessidade desculpante. O conflito que reside mesmo na raiz

([27]) ROXIN I, § 22, n.º 125 e ss.

([28]) BOPP, *Der Gewissenstäter und das Grundrecht der Gewissensfreiheit*, 1974, p. 245 e s., MÜLLER-DIETZ, Gewissensfreiheit und Strafrecht, *Peters-FS*, 1974, p. 91, e DIAS, Silva, nota 3, p. 146 e s.

([29]) Negativamente, também, ROXIN I, § 22, n.º 101.

do facto de consciência — por mais doloroso ou mesmo trágico que seja — não constitui (e não apenas em perspectiva técnico-jurídica, mas também e sobretudo político-criminal) um *conflito de bens jurídicos* na acepção consensual da doutrina do estado de necessidade jurídico-penal.

3. Recondução, por analogia, do facto de consciência ao regime da falta de consciência do ilícito não censurável

§ 22 Com o reconhecimento de que o facto de consciência não configura, directamente e em si mesmo, nem uma falta não censurável de consciência do ilícito, nem um estado de necessidade desculpante, não está ainda dito que ele não possa afastar, em certos casos, a culpa do agente. Pois talvez seja possível, em casos tais, estabelecer um nexo de **analogia material** entre o facto de consciência e alguma das causas de exclusão da culpa legalmente admitidas.

§ 23 No que toca a uma eventual **analogia com as situações de estado de necessidade desculpante** ([30]), porém, ela parece dever ser recusada. Logo porque a uma qualquer situação de estado de necessidade é conatural a existência de um conflito derivado de uma situação *exógena* criadora de um *perigo* para bens jurídicos do agente ou de terceiro, enquanto no facto de consciência não há um perigo para bens jurídicos propiciado por uma qualquer predisposição exterior das coisas para o facto: o agente pratica o facto, em último termo, pela pressão que sobre ele exerce a "voz da consciência", não o circunstancialismo exógeno em que o facto tem lugar. Por isso as duas situações se afiguram estruturalmente diversas. Ao que acresce que a generalidade dos códigos penais, entre os quais o nosso, quis, como vimos — com boa razão político-criminal —, em matéria de bens jurídicos que podem fundar um estado de necessidade desculpante, seguir um critério de *numerus clausus* que afasta, relativamente ao seu catálogo, a legitimidade do argumento de analogia (supra, 22.º Cap., §§ 12, 18 e s.). E por fim: uma exclusão da culpa em nome da desrazoabilidade, segundo as circunstâncias do caso, de exigir do agente comportamento diferente constituiria sempre uma solução *inadequada* ao facto de consciência. O que há de verdadeiramente decisivo, ao nível da exclu-

([30]) Tal como foi advogada sobretudo por PETERS, Bemerkungen zur Rechtsprechung der Oberlandsgerichte zur Wehrersatzdienstverweigerung aus Gewissensgründen, *JZ*, 1966, p. 457.

são da culpa, nas situações de inexigibilidade é a circunstância de a situação exógena ser uma tal que *estorvou* ou *impediu* o cumprimento das intenções *normais* do agente, isto é, das intenções, sem aquele estorvo, em princípio correspondentes aos critérios da ordem jurídica sobre o lícito e o ilícito (supra, 22.º Cap., § 10). No facto de consciência, diversamente, nem existe qualquer escolho exógeno (antes um "estorvo de consciência"), nem sintonia entre a atitude interna do agente e os critérios da ordem jurídica sobre o lícito e o ilícito.

§ 24 Que deverá porém dizer-se da possibilidade de, em certos casos, se retirar um argumento de analogia material entre o facto de consciência e a **falta de consciência do ilícito não censurável**? Cremos que essa possibilidade se verifica e, na verdade, a mais que um título. Desde logo, a situação do facto de consciência está muito próxima daquela que a doutrina mais antiga da consciência do ilícito tratava sob a epígrafe do **erro de direito natural** e a mais moderna — numa concepção mais lata — considera (como vimos supra, 20.º Cap., § 43) como de **erro de validade**. Decerto, o facto de consciência não é sem mais recondutível ao erro sobre a validade: neste, o agente actua na convicção de que a licitude é assegurada pela nulidade ou invalidade *jurídicas* da norma de comportamento, enquanto o agente de consciência conhece a vigência da norma, mas não *re*conhece a sua obrigatoriedade em concreto por força do dever de consciência que o motiva. Todavia, num caso como no outro o agente conhece a proibição, mas nega em definitivo a validade da norma como *norma de comportamento no caso concreto*. Que isso suceda por razões de natureza jurídica (no caso do erro de validade) ou por motivos de consciência (no caso do facto de consciência) constitui uma diferença estrutural não despicienda, mas incapaz de apagar o significado substancialmente *análogo* dos dois casos para o juízo de censura jurídico-penal.

§ 25 Conclusão que mais facilmente se aceitará tendo em conta que também o fundamento de relevância do erro de validade (como o de qualquer falta de consciência do ilícito) não deve radicar em dúvidas ou falta de *conhecimento* das normas legais. Fosse assim, e ainda aí estaríamos então perante um puro *erro intelectual*, um *erro de conhecimento*, perante um erro, em suma, que *excluiria o dolo* e nada teria de comum com a falta de consciência do ilícito. Mas não é assim. O erro de validade existe só onde o agente, detendo todo o conhecimento indispensável a uma correcta orientação da consciência ética para o desvalor da ilicitude, age todavia sem

consciência do ilícito por força de uma **valoração que põe em causa a validade da norma no caso concreto**. Se assim é, todavia, fica então justificada a asserção de que **algo de análogo sucede com o agente de consciência**. Num caso como no outro o erro provém da consciência ética, num caso como no outro a *atitude do agente manifestada no facto* revela uma personalidade desconforme com os critérios de valor da ordem jurídica e a motivação do facto reconduz-se àquele *erro de valoração* que constitui a essência da falta de consciência do ilícito e conduz à punição do facto a título de dolo.

§ 26 Erro este, porém, que pode — já o determinámos supra, 23.º Cap., § 11 e ss. — apresentar-se como **não censurável** e, por aí, **excluir a culpa**. Aqui, nos fundamentos e no regime adequados ao erro sobre a ilicitude não censurável, reside a confirmação do bom fundamento da analogia entre aquele erro e o facto de consciência que exclui a culpa. Vimos, com efeito, que a não censurabilidade da falta de consciência do ilícito radica na persistência no agente, apesar do erro, de uma *consciência ética fiel ao direito manifestada no facto e que em último termo o fundamenta*; é dizer, de uma atitude de fidelidade ou correspondência a exigências ou pontos de vista, se bem que parcelares por participarem de uma situação conflitual, em todo o caso aceitáveis ou mesmo reconhecidos pelo direito. Ora, **todo este critério parece aplicável, por analogia material, ao facto de consciência**. Também neste *pode* acontecer que, apesar do facto, se deva concluir que na raiz da decisão que lhe presidiu está uma consciência ética que, tendo embora conduzido à prática de um ilícito típico, todavia, ao decidir numa situação jurídica conflitual, se revela por um lado ainda orientada por critérios que a ordem jurídica aceita ou reconhece, por outro lado movida pelo propósito de a eles corresponder com a sua conduta. É justamente **nestes casos (e só neles)** que se torna possível a exclusão da culpa do facto de consciência por argumento de analogia com a falta de consciência do ilícito não censurável.

SUBTÍTULO III

OS PRESSUPOSTOS ADICIONAIS DE PUNIBILIDADE

26.º CAPÍTULO

PUNIBILIDADE E CARÊNCIA DE PENA

I. Evolução dogmática

§ 1 Uma exposição sistemática da doutrina do facto punível não pode considerar-se completa (como supra, 10.º Cap., § 74 e s., se anotou) antes que se preste atenção à categoria dos **pressupostos adicionais de punibilidade** que, na construção sistemática tradicional, fecha a abóbada do sistema. E no entanto, até há bem pouco tempo não existia capítulo daquela doutrina que mais defraudasse pela sua inconcludência. Décadas de especulação levaram só à magra conclusão *(negativa)* de que ali se trata de um conjunto de pressupostos que, se bem que se *não* liguem *nem* à ilicitude, *nem* à culpa, todavia decidem ainda da punibilidade do facto (1); e que, juntando as chamadas **condições objectivas de punibilidade** (2) às **causas de exclusão da pena**, englobaria elementos tão diferentes, na sua estrutura, no seu relevo político-criminal e no seu significado e função dogmáticos, como, p. ex., a consumação ou a tentativa de suicídio no crime de incitamento ou ajuda ao suicídio (art. 135.º-1), o resultado morte

---

(1) Assim, por outros, JESCHECK / WEIGEND, antes do § 52.

(2) Que aliás na doutrina portuguesa valiam não poucas vezes como *designativo geral de toda esta categoria*: CORREIA, Eduardo, I, p. 370. Não de todo sem razão, anote-se, uma vez que a distinção entre condições objectivas de punibilidade e causas (materiais) de exclusão da pena é — como p. ex. sublinha ROXIN I, § 23, n.º 5 — "de espécie puramente formal. É indiferente que, na difamação [cf. o nosso art. 180.º-2/*b*)], se considere a falta de prova da verdade como condição objectiva de punibilidade ou a prova da verdade como causa material de exclusão da pena".

ou ofensa à integridade física grave no crime de participação em rixa (art. 151.º-1), a não ocorrência da insolvência ou o seu não reconhecimento judicial no crime de insolvência dolosa (art. 227.º) ou a prática de um ilícito-típico no crime cometido em estado de embriaguez (art. 295.º-1); a impunibilidade de votos e opiniões parlamentares (art. 160.º-1 da CRP); o facto de o agente ser encontrado em Portugal quando o crime tenha sido praticado no estrangeiro (art. 5.º-1*c)*, I); a desistência da tentativa (art. 24.º e s.); etc.

§ 2 Em data recente, contudo, a questão da compreensão dogmática e político-criminal da última das categorias sistemáticas integrantes do conceito de crime passou a suscitar vivo interesse e cerrada discussão, se bem que, até ao momento, ainda se não divisem consensos amplos sobre a matéria. Desempenhou aqui papel proeminente a discussão à roda de uma concepção teleológica, funcional e racional da doutrina do crime; sobretudo por força da chamada de atenção por Roxin para a categoria da **responsabilidade** (supra, 10.º Cap., § 72 e s., e 22.º Cap., § 7) que englobaria, para além da culpa, a necessidade preventiva, geral e especial, de punição, e da controvérsia que à volta desta proposta se estabeleceu. Mas também por força da atenção que, neste contexto, passaram a merecer os conceitos de **dignidade penal** e de **carência de tutela penal**; conceitos que, se bem que já conhecidos da doutrina anterior, assumem agora uma nova e até há pouco insuspeitada relevância na construção do sistema da doutrina do crime (3).

§ 3 Uma revisão da categoria da *punibilidade* como elemento constitutivo do conceito de crime implica, antes de mais, que ela seja **expurgada** de situações que, ou têm a ver com o tipo de ilícito ou o tipo de culpa e relevam ainda a esses níveis, ou, no outro extremo, não têm que ver com o conceito de crime e a respectiva doutrina geral. Quanto ao primeiro caso, só uma análise dos tipos legais de crime da PE poderá conduzir a determinar o que são ainda elementos típicos, pertencentes ao ilí-

(3) Sintomática a amplitude da bibliografia que em data recente vem sendo dedicada a estes conceitos; bem como a circunstância de o tema *"O papel da dignidade penal e da carência de tutela penal no sistema do direito penal"* ter sido um dos tratados no colóquio internacional sobre "Um sistema do direito penal para a Europa" que teve lugar na Faculdade de Direito de Coimbra em Maio de 1991, por ocasião da outorga do grau de *doctor honoris causa* a Claus Roxin: *Coimbra-Symposium Roxin*, p. 89 e ss., e, sobre ele, CAEIRO, Pedro, Colóquio Internacional de Direito Penal. Breve crónica, *RPCC 1*, 1991, p. 629. Cf., por último, CUNHA, Damião da, Não punibilidade e dispensa de pena — Breve contributo para a integração dogmática da não punibilidade à luz de uma perspectiva processual penal, *RPCC 15*, 2005, p. 229.

cito ou à culpa, e o que são pressupostos de punibilidade. Mas também é verdade que o resultado desta indagação dependerá em alguma medida da "pré-compreensão" que se tenha do que seja o sentido e a essência daqueles pressupostos (4). Quanto ao segundo caso — e para além da distinção entre pressupostos de punibilidade, por uma parte, e pressupostos processuais e de procedibilidade, por outra (5) —, parece claro, por exemplo, que um requisito (quase sempre referido neste contexto (6)) como o de o agente ser encontrado em Portugal quando deva ser julgado por crime cometido no estrangeiro é um pressuposto de aplicação da lei penal portuguesa no espaço (supra, 9.º Cap., § 22), não um "pressuposto de punibilidade" com o sentido e a função agora questionados de elemento constitutivo do conceito de crime.

§ 4 A pergunta crucial é pois a de saber qual a **consideração material** que dentro desta categoria actua, conferindo-lhe unidade e consistência teleológico-dogmática e fundamento político-criminal. A resposta mais clara até hoje dada à questão foi avançada por Roxin: a inteira categoria dos autênticos pressupostos de punibilidade — seja sob a forma de "condições objectivas de punibilidade", seja sob a de "causas de exclusão da pena" — é dominada pela ideia básica da **prevalência de imposições de finalidades extra-penais**; é, por outras palavras, expressão de que, em tais casos, uma ponderação entre imposições finais extra-penais, por um lado, e carências de punição, por outro, conduzem a que aquelas prevaleçam sobre estas (7). Decerto, uma tal explicação não colhe perante muitas e importantes situações que até aqui prevalentemente se contavam entre os pressupostos de punibilidade, por exemplo, a da desistência da tentativa. Mas isso — anota Roxin — só porque tais situações não configuram em definitivo verdadeiros pressupostos de punibilidade, antes causas de exclusão da "responsabilidade" na vertente da desnecessidade preventiva da punição (8).

§ 5 Face à posição que tomámos perante a doutrina roxiniana da "responsabilidade", torna-se porém compreensível que devamos levantar **reservas** também no que toca à sua concepção dos pressupostos de puni-

---

(4) Esclarecedor, por último, o estudo de PINTO, Costa, Ilícito e punibilidade no crime de participação em rixa, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 869.

(5) Cf., sobre o ponto, por último, ROXIN I, § 23, n.º 40 e ss. E, já, o nosso *DPP*, pp. 32 e ss., 122 e ss.

(6) Cf., p. ex., CORREIA, Eduardo, I, pp. 175 e 370.

(7) ROXIN I, § 23, n.º 21 e ss., acentuando que o essencial da sua ideia se encontra já em alguns autores, mesmo antigos, e remetendo sobretudo para BLOY, *Die dogmatische Bedeutung der Strafausschließungs- und Strafaufhebungsgründe*, 1976, p. 224.

(8) ROXIN I, § 23, n.º 16 e ss.

bilidade. Se não há razão bastante para juntar a culpa à necessidade preventiva de punição dentro da mesma categoria da "responsabilidade", isso constitui sinal de que a concepção tradicional será de aceitar ao menos na parte em que considera hipóteses como as de desistência da tentativa estranhas às categorias do tipo de ilícito e do tipo de culpa (infra, 29.º Cap., § 46 e ss.) e assim, à partida, atinentes à categoria (adicional) da punibilidade.

II. Punibilidade e dignidade penal do facto

§ 6 À questão de saber qual a ideia político-criminal e dogmática básica que dentro da categoria da punibilidade actua e lhe oferece unidade e consistência deve responder-se que essa é a da **dignidade penal** (9). Deste modo se fecha a construção da doutrina geral do crime, considerando que este se traduz sempre num *comportamento ilícito-típico, culposo e digno de pena*. Mas esta ideia deve ater-se a uma decidida contradição, que procurará pôr em evidência, a níveis vários, as suas fraquezas e mesmo contradições.

§ 7 Começará logo decerto por afirmar-se que a ideia da dignidade penal tanto no seu significado dogmático, como político-criminal, é inadequada para ser posta como fundamento de *uma só* categoria integrante da doutrina geral do crime. O que ela constitui, sim — dir-se-á —, é um critério ou princípio *regulativo* cujo significado não pode reduzir-se a uma só daquelas categorias, antes necessariamente **se estende a todas elas**: pois torna-se evidente, logo à partida da construção, que só pode ser crime o comportamento que se revele digno de punição (10); o que significa que a dignidade penal é **princípio regulativo de todas as categorias** — antes de tudo do ilícito-típico, mas também da culpa e da punibilidade — e, como tal, critério ubíquo e imanente à totalidade da doutrina geral do

(9) Nesta direcção, SCHMIDHÄUSER, 12 e 13; todavia com um sentido dogmático e uma intencionalidade político-criminal que em pouco se cobrem com os que presidem à posição assumida no texto, como se comprova pela enumeração dos "verdadeiros" pressupostos de punibilidade por ele feita, 12/7. A tese de Schmidhäuser encontra desenvolvimentos de grande interesse no estudo do seu discípulo LANGER, *Das Sonderverbrechen. Eine dogmatische Untersuchung zum allgemeinen Teil des Strafrechts*, 1975, p. 327 e ss. Sobre o todo, ANDRADE, Costa, A "dignidade penal" e a "carência de tutela penal" como referências de uma doutrina teleológico-racional do crime, *RPCC 2*, 1992, p. 192 e ss.

(10) Nesta medida assistindo razão a SAUER, *Allgemeine Strafrechtslehre*, 1949, p. 18.

crime e do sistema respectivo ([11]). Não nos parece, porém, que o argumento proceda em definitivo. Decerto que a dignidade penal é um requisito conatural ao crime como um todo e, por isso, princípio regulativo de toda a construção e de todo o sistema; tal como o é, por exemplo, a exigibilidade ([12]), ligada à velha máxima *ad impossibilia nemo tenetur*. E todavia: tal como a exigibilidade, sendo princípio regulativo de todas as categorias constitutivas do crime, nomeadamente a do tipo de ilícito, não deixa de precipitar-se de forma específica e autónoma, enquanto princípio normativo ou decisório, na categoria da culpa jurídico-penal; assim também se deve aceitar que a ideia da dignidade penal, sem prejuízo da sua ubiquidade e imanência, se assuma como elemento fundamentador e compreensivo *par excellence* da categoria dos pressupostos de punibilidade.

§ 8 Dir-se-á em seguida, contra a concepção sustentada, que, sendo certo que considerações de dignidade penal estão já presentes nas categorias do tipo de ilícito e do tipo de culpa, nada fica então como *caracteristicum* dos pressupostos de punibilidade quando também estes sejam iluminados e fundamentados por aquela mesma ideia ([13]). Mas também esta crítica não parece procedente, bastando para o efeito relembrar uma verdade tão velha como indiscutível, a saber, que o crime é, *sub specie realitate*, uma **unidade**; e que a construção geral do crime se baseia em um pensamento *categorial-classificatório*. Assim, pois, torna-se possível — e compreensível — que o significado da dignidade penal se não esgote nas categorias do tipo de ilícito e do tipo de culpa (se bem que também nelas assuma significado) e se verta de forma autónoma em uma última categoria constitutiva do crime. O que se tornará ainda mais aceitável se se ponderar que, tal como sucede com a culpa, onde o facto ilícito-típico surge, em prin-

---

([11]) No sentido desta consideração, VOLK, Entkriminalisierung durch Strafwürdigkeitskriterien jenseits des Deliktsaufbaus, *ZStW 97*, 1985, p. 888 e ss., ROXIN I, § 23, n.º 35 e s., ANDRADE, Costa, nota 9, p. 192 e ss., e LUZON Peña, Die Beziehung von Strafwürdigkeit und Strafbedürftigkeit zum Verbrechensaufbau, *Coimbra-Simposyum Roxin*, p. 97 e ss.

([12]) HENKEL, Zumutbarkeit und Unzumutbarkeit als regulatives Rechtsprinzip, *Mezger-FS*, 1954, p. 249; aliás na esteira de uma sugestão de ENGISCH, Der finale Handlungsbegriff, *Kohlrausch-FS*, 1944, depois precipitada no seu Der Unrechtstatbestand im Strafrecht, *DJT-FS*, 1960, p. 420. Em sentido e em conclusão semelhantes aos do texto, PEÑA, Luzón, Causas de atipicidad, *Problemas Fundamentais de Direito Penal, Homenagem a Claus Roxin*, 2002, p. 126. Em posição parcialmente crítica FARIA, Paula Ribeiro de, *A Adequação Social da Conduta no Direito Penal ou o Valor dos Sentidos Sociais na Interpretação da Lei Penal*, 2003, p. 187 e ss.

([13]) Assim, de novo, ROXIN I, § 23, n.º 36.

cípio, como culposo, também aqui se passa algo de análogo mas em medida bem mais forte. O facto ilícito-típico e culposo é também, em regra, facto digno de pena. Mas pode suceder **excepcionalmente** que o não seja, se nele se não verificarem também os pressupostos de punibilidade; pressupostos que têm que ver directamente com a dignidade penal do facto, com exigências de prevenção, geral e especial, que nele radicam mas não esgotam o seu significado no tipo de ilícito ou no tipo de culpa. Por outras palavras ainda: o facto em que se verifica o tipo de ilícito e o tipo de culpa é em princípio também um facto digno de pena; mas pode acontecer que excepcionalmente o não seja se, por falta de uma condição de punibilidade, se revela que o facto **como um todo**, na sua **unidade**, na sua **imagem global, não atinge os limiares mínimos da exigência preventiva de punição**, em suma, da sua dignidade penal. Nesta acepção pode dizer-se [14] que a categoria da punibilidade deve ser tomada, no sentido de um funcionalismo normativo, como o elemento de ligação por excelência entre a dogmática do facto e a política criminal.

§ 9 A demonstração tornar-se-á porventura mais concludente se for ilustrada com exemplos paradigmáticos, como o da **desistência da tentativa**. A impunibilidade da desistência funda-se, como se dirá (infra, 29.º Cap., § 7 e ss.), na opção político-criminal do legislador de considerar que, em casos tais, o facto praticado não exige punição do ponto de vista da prevenção, geral ou especial. Mas a isto deve precisamente chamar-se a *falta de dignidade penal do facto*. Trata-se nela, em último termo, de circunstâncias *do facto global* (não da consequência jurídica, vale dizer, da pena) que não tendo a ver com o tipo de ilícito ou o tipo de culpa, todavia traduzem a falta de exigências preventivas que poderiam justificar que o efeito ou consequência jurídica se desencadeasse. Nesta acepção das coisas se verifica na verdade uma embrincação [15] dos conceitos de dignidade penal e de carência de tutela penal, na sua acepção tradicional; com a reserva, em todo o caso, sobretudo no que toca a este último conceito, de que eles funcionam ainda ao nível do facto (e por conseguinte da doutrina do crime) e como suas implicações, não ao nível da consequência jurídica (e por isso da doutrina da pena): infra, § 15 e ss.

§ 10 O que acaba de defender-se para a desistência da tentativa deve valer também para hipóteses como, entre outras: (1) a do art. 135.º, onde o mesmo grau de ili-

---

[14] Como diz agora YAMANAKA, Betrachtungen über den Strafbefreiungsgrund des Rücktritts vom Versuch, *Roxin-FS*, 2001, p. 789, a propósito da categoria da "responsabilidade".

[15] Já, SAX, Grundsätzen der Strafrechtspflege, *in*: Bettermann / Nipperdey / Scheuner (orgs.), *Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte*, 1959, III/2, p. 923 e ss.

citude e de culpa do **incitamento ou auxílio ao suicídio** se torna ou não punível consoante se tenha verificado ou não o suicídio consumado ou tentado: quando, apesar do incitamento ou auxílio, o bem jurídico acabou por ser preservado, entende a ordem jurídica — bem, em nossa opinião — que do facto efectivamente cometido se não desprendem exigências preventivas a que se torne necessário acorrer com a punição ([16]); (2) a do art. 151.º-1, quando da **participação em rixa** não resultou morte ou ofensa à integridade física grave de qualquer pessoa ([17]); (3) a do art. 227.º, quando o devedor levou a cabo a conduta típica com intenção de prejudicar os credores mas a **insolvência** não ocorreu ou não veio a ser reconhecida judicialmente ([18]); (4) a do art. 295.º, quando a **embriaguez** do agente acabou por não conduzir à prática de um "facto ilícito típico" ([19]); (5) ou a dos arts. 322.º e 323.º, quando se não verifiquem as condições de manutenção de **relações diplomáticas** e de **reciprocidade** no tratamento penal do facto previstas no art. 324.º-2 ([20]). Já, todavia, o caso das *imunidades* (de direito público interno, *v. g.*, nos termos dos arts. 157.º-1 e 216.º-2 da CRP, e internacional) relativamente à prática de certas espécies de crimes não parece constituir, contra o que afirma Roxin, "o melhor exemplo de uma causa de exclusão da pena" ([21]). Preferível parece a concepção tradicional segundo a qual se trata ali de *pressupostos de aplicação da lei penal* ("quanto às pessoas", como era de uso dizer-se ([22])).

§ 11 Partindo de um ponto de vista que, como afirma, substancialmente se cobre com o que defendemos ([23]), quer todavia Damião da Cunha remeter a categoria da "não punibilidade" para o âmbito problemático da **carência de pena** ou de punição, da "**necessidade**" de pena e, deste modo, para um "momento intermédio (ou de fronteira)" "entre a questão da culpabilidade e a questão da sanção" ([24]). Julgamos que não devemos segui-lo neste passo (cf., também, infra, § 15 e ss.). Relativamente a exemplos como

---

([16]) Contra, considerando que se está ainda aqui perante uma questão de resultado típico, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 135.º, § 30 e ss., onde se encontra notícia da principal literatura, portuguesa e estrangeira, sobre a questão.

([17]) Na conclusão, embora com diversa fundamentação, ISASCA, Frederico, *Da Participação em Rixa*, 1994, p. 113 e ss., CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, I, art. 151.º, § 23 e s., PINTO, Costa, nota 4. Se, à luz de uma consideração político criminal, é esta, *de lege ferenda*, a solução dogmática preferível (cf. *Actas 1979*, p. 74, e *Actas 1993*, pp. 229 e 501, além dos AA. cits.) é questão que não deve ser aqui decidida.

([18]) Assim, CAEIRO, Pedro, *Comentário Conimbricense*, II, art. 227.º, § 45 e ss.

([19]) Assim, CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, II, art. 295.º, §§ 16 e 19.

([20]) Assim, CUNHA, Conceição da, *Comentário Conimbricense*, III, art. 324.º, § 7.

([21]) ROXIN I, § 23, n.º 24.

([22]) Por todos, CORREIA, Eduardo, I, n.º 42. Cf., sobre o ponto, por último, SILVA, Marques da, I, p. 321 e s.

([23]) CUNHA, Damião da, nota 3, p. 230.

([24]) CUNHA, Damião da, nota 3, p. 255 e *passim*.

os que ficam apontados cremos ficar particularmente claro que os pressupostos adicionais de punibilidade dizem ainda respeito ao **facto como um todo** e à sua **teoria**. Podendo mesmo nós ir ao ponto de afirmar que, para certos efeitos — *v. g.*, em matéria do facto do inimputável (supra, 21.º Cap., § 42 e ss.) ou do facto do cúmplice (infra, 32.º Cap., § 12 e ss.) —, os pressupostos de punibilidade do facto devem ser tratados ao nível (e com os instrumentos dogmáticos) dos elementos do tipo (objectivo) de ilícito; sem esquecer nunca, em todo o caso, que, relevando eles para a definição da respectiva *espécie de crime*, mas não, em todo o caso, para o juízo de ilicitude, não fazem parte do "tipo de erro" e, por isso, **a eles não tem de se referir o dolo do tipo** (25).

§ 12 Em definitivo, é verdade que, em algumas das hipóteses referidas, podem ser em último termo *imposições de fins extra-penais* que fundamentam a impunibilidade. Mas reconhecer isto não significa que tais imposições de fins se não traduzam em opções político-criminais que, por sua vez, são vertidas em categorias da doutrina geral do crime. Temos repetidamente acentuado que — como Roxin afirmou de forma paradigmática — as categorias da doutrina do crime não podem deixar de ser político-criminalmente cunhadas. Não há razão para que esta proposição fundamental não valha também para a última categoria constitutiva da doutrina do crime e para que nesta se faça antes uma espécie de "importação directa" de imposições finais extra-penais para o âmbito jurídico-penal. Bem ao contrário, tais imposições finais extra-penais, onde quer que existam, conformam **opções político-criminais que, através da ideia base da dignidade penal, são vertidas na categoria sistemática dos pressupostos de punibilidade**. Também neste contexto se pode aproveitar a ideia luhmaniana de que o sistema é por vezes "irritado" por imposições finais provindas de outros sistemas; mas que, perante uma tal situação, o sistema "interioriza" tais imposições extra-sistemáticas que perante ele surgem como "ambiente" (26). E interiorizando-as, exprime, no caso em apreço, essencialmente a ideia de que o comportamento é um tal que, apesar do conteúdo do tipo de ilícito e do tipo de culpa que contém, se não

---

(25) Questão diversa — e de que aqui não curaremos: cf., sobre ela, CUNHA, Damião da, nota 3, *passim* — é a das implicações destes elementos em matéria de consequências jurídicas do crime (máxime, do seu relacionamento com o instituto da "dispensa de pena") e em sede de doutrina jurídico-processual penal.

(26) LUHMANN, *Ökologische Kommunikation*, 1986, p. 221.

revela *na sua globalidade*, segundo o desvalor ético-social do seu substrato, comunitariamente insuportável (27).

§ 13 A importância que uma concepção deste tipo pode ter para compreensão da impunibilidade (ainda que não legalmente determinada de forma expressa, antes só judicialmente determinada) de casos ínfimos de "**criminalidade bagatelar**" parece evidente (28): será este porventura um caminho mais seguro do que o de ensaiar critérios limitadores de *interpretação* dos singulares elementos dos tipos de ilícito respectivos. Com efeito, e porventura de forma ainda mais clara do que vimos passar-se com o princípio (regulativo) da inexigibilidade, também o hoje muito estudado — e já por vezes incidentalmente referido: supra, 7.º Cap., § 12, e 10.º Cap., § 74 — **princípio da insignificância** ou **princípio bagatelar** nos parece assumir o carácter de um princípio regulativo com especial incidência em matéria de "punibilidade", tal como acabámos de a desenhar. Isso mesmo considerou expressamente o nosso legislador em muitos casos, *v. g.*, nos arts. 163.º a 169.º, 279.º, 288.º a 291.º, etc. (29). Para além destas hipóteses, porém, pode dizer-se que hoje uma parte significativa das doutrinas e das jurisprudências aceitam que, em geral, não é merecedora de pena a lesão insignificante de um bem jurídico-penal em si mesmo carente de protecção. Mas elas dividem-se significativamente quando procuram determinar qual o fundamento deste efeito excludente da punição e a que nível categorial do conceito de crime um tal efeito deve produzir-se. Quer-nos parecer que, também quanto a esta questão, não poderá conceder-se razão a uma qualquer resposta *unilateral*, devendo pelo contrário aquela resposta *diversificar-se* em função de uma certa tipologia de situações.

§ 14 Assim, decerto que muitas vezes — porventura as mais das vezes — a insignificância da lesão do (ou do perigo para o) bem jurídico-penal ou o ínfimo desvalor social da acção lesiva ou perigosa estarão conaturalmente ligados a uma *ausência de negação do sentido social contido no tipo de ilícito*, sendo este por conseguinte mais um caso — con-

---

(27) Conclusão próxima da de LANGER, nota 9, p. 275.

(28) Sobre a questão, PALIERO, "*Minima non curat prætor*". *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizazione dei reati bagatelari*, 1985. Uma análise minuciosa da questão sob o prisma da "adequação social", com amplas indicações bibliográficas, em FARIA, Paula Ribeiro de, nota 12, I Parte, Cap. II.

(29) Cf. FARIA, Paula Ribeiro de, nota 12, p. 208 e s.

cretizador ou não da cláusula da *adequação social* (30) — em que a valoração global da conduta se reflectirá retrospectivamente no sentido da **negação da tipicidade** por ausência de ilícito material. Como, no outro extremo, não deve excluir-se *a priori* a possível existência de hipóteses em que a ilicitude típica, a culpa e a punibilidade devam ser afirmadas, recaindo os reflexos do princípio bagatelar exclusivamente no domínio da consequência jurídica e, por conseguinte, da **pena** e da sua **medida**, sob a forma da atenuação especial ou da dispensa de pena (arts. 72.º-74); numa palavra, no domínio da carência de pena (infra, § 15 e ss.) (31). Insistimos, porém, em que na generalidade dos casos de actuação do princípio da insignificância ou bagatelar o tipo de ilícito e o tipo de culpa devem ser afirmados, mas deve ser **negada a dignidade penal do facto como um todo**, na nossa acepção (32), e, consequentemente, a sua **punibilidade**. Num sentido próximo, aliás, do que resulta de forma mais imediata do texto do § 42 do CP austríaco, segundo o qual. "Se o facto a perseguir oficiosamente for ameaçado só com pena de multa, com pena de prisão não superior a 1 ano ou com esta pena de prisão e aquela pena de multa, o facto não é punível se 1. a culpa do agente é diminuta, 2. o facto não desencadeou nenhuma consequência ou só desencadeou consequências insignificativas e, além disso, 3. a punição não é imposta para afastar o agente de actos puníveis ou para impedir o cometimento de actos puníveis por outrem" (33).

---

(30) Em sentido afirmativo, FARIA, Paula Ribeiro de, nota 12, I Parte, Cap. II. No sentido da negação da tipicidade relativamente ao crime de coacção, ROXIN, Verwerflichkeit und Sittenwidrigkeit als unrechtsbegründenden Merkmale im Strafrecht, *JuS*, 1964, p. 374 e ss., e, mais em geral, LUZÓN Peña, nota 11, p. 122, DALBORA, Guzmán, La insignificancia: especificación y reducción valorativas en el ámbito de lo injusto típico, *RBCC IV*, 14, 1996, p. 41, e VICO Mañas, Princípio da insignificância: excludente da tipicidade ou da ilicitude?, *Escritos Silva Franco*, p. 143.

(31) Não faltando inclusivamente quem queira atribuir ao princípio mera incidência "processual" (por considerar ser essa a sede adequada das chamadas "causas de exclusão da pena"): assim HÜNERFELD, A pequena criminalidade e o processo penal, *RDE 4*, 1978, p. 25 e ss., e também CUNHA, Damião da, nota 3, *passim*.

(32) Ou em alternativa, na acepção de Roxin, a "responsabilidade", uma vez que estaria aqui em causa uma "desnecessidade da pena" ligada a uma culpa diminuta do agente: ROXIN, Zur systematischen Einordnung des § 42 öStGB, *Pallin-FS*, 1989, p. 345 e ss.

(33) Interpretando-o essencialmente neste sentido, também, ZIPF, Der mangelnde Strafwürdigkeit der Tat (§ 42 StGB), *Salzburger Universitätsreden 58*, 1975, p. 20. Mesmo na doutrina austríaca, todavia, a compreensão dogmática e a localização sistemática da figura são largamente dissonantes, informando FARIA, Paula Ribeiro de, nota 12, p. 221, que "Moos chegou mesmo a identificar oito possíveis qualificações dogmáticas para a figura em questão". A "autoria intelectual" deste preceito é em regra atribuída a PALLIN, que, no *WK*, § 42, conclui num sentido muito próximo do assumido por Roxin (cf. nota anterior).

III. Punibilidade e carência de pena

§ 15 "Punibilidade"— a categoria que, depois do que fica dito, deve designar a última pedra do edifício do conceito de crime e da respectiva doutrina geral — é, sob um ponto de vista ainda não evidenciado, um conceito equívoco. Face à sua expressão semântica poderia ser ele entendido como um requisito de cuja verificação **dependeria em definitivo a efectiva aplicação de uma pena** (ou eventualmente de uma medida de segurança). Não é assim, porém. Ele pretende traduzir apenas a ideia de que, uma vez presente, estão verificados no crime todos os pressupostos indispensáveis para que a punição possa desencadear-se. De tal modo que, em vez de dizer-se que os pressupostos de punibilidade desencadeiam sem mais a punição, melhor se dirá que, uma vez eles verificados, se perfecciona o *Tatbestand* (no sentido da Teoria Geral do Direito) que faz entrar em jogo a consequência jurídica (*Rechtsfolge*) e a sua doutrina autónoma. Pode acontecer, na verdade, que a punição acabe por não dever efectivar-se, por razões que já não têm a ver com a doutrina do facto, mas autonomamente com a doutrina da consequência jurídica, com a **doutrina da pena**: o facto (ou o crime, ou o *Tatbestand*) apresenta-se integralmente realizado, nada faltando, nem sequer a dignidade penal e portanto a "punibilidade", à sua aptidão para desencadear a consequência jurídica; esta todavia não sobrevem porque um tal efeito — a pena — não surge, perante as finalidades que deveria cumprir, como *necessário* ou *proporcional* (34).

§ 16 É possível, para traduzir a ideia mestra que nesta categoria actua, apelar para o conceito de *concreta dignidade punitiva*; como é possível utilizar neste contexto, reformulando-o, o conceito que, juntamente com o de dignidade penal, vem constituindo a *crux* da mais moderna dogmática jurídico-penal: o conceito de *carência de tutela penal efectiva*. Ponto é só que se torne claro que o conteúdo da ideia, qualquer que seja o nome que ao conceito se confira, é atinente já não à doutrina do facto ou do crime, mas à da consequência jurídica ou da pena. Por isso e correspondentemente, o conceito não deve ser conexionado com o "facto punível", mas com a *punição* como tal; em vez de carência de tutela penal melhor se falará então de **carência punitiva** ou **carência de punição**.

---

(34) Não pode por isso dar-se razão nesta parte a COSTA, Faria, *O Perigo em Direito Penal*, 1992, p. 373 e ss.

§ 17 A contraposição, que deste modo acaba de estabelecer-se, entre a "dignidade penal", como ideia reitora da categoria da punibilidade do facto, e a "carência punitiva", como categoria actuante ao nível da consequência jurídica, **não se cobre com a distinção** — hoje muito reclamada por certos autores, na esteira de Max Weber (35) — **entre uma "racionalidade axiológica" e uma "racionalidade finalística"**; a primeira integrante da categoria da dignidade penal, a segunda da categoria da carência de tutela penal. Não se cobre com esta distinção, nem em definitivo a pode aceitar. Qualquer uma das categorias em análise (como afinal *todas* as categorias jurídico-penais) é composta de elementos pertencentes àquelas duas racionalidades: a cunhagem político-criminal do sistema e das suas categorias fundamentais, tal como vem sendo defendida, não significa a exclusividade (nem sequer a predominância) de programas finais; pois já as proposições político-criminais são axiologicamente fundadas e, nas suas conexões com o sistema, normativamente explicitadas. E se isto vale para a doutrina do crime, não vale em menor medida para a doutrina da consequência jurídica: também esta é político-criminalmente determinada, decerto, mas, também ela, na base de decisões axiológicas, de intencionalidades normativas e de critérios gerais de valor (36). Como inaceitável parece igualmente a tentativa de contrapor as duas categorias na base de que **a da dignidade penal se reportaria ao facto, a da carência de pena (de tutela penal) ao agente** (37). Estabelecido e aceite que num Estado de Direito democrático todo o direito penal só pode ser direito penal do facto, reconhecido terá de ser que a consideração do agente só dentro daquele limite é possível; mas que, em compensação, ela é possível (e desejável) relativamente a todas as categorias dogmáticas do direito penal, digam elas respeito à doutrina do crime ou à da sua consequência jurídica.

§ 18 Já porém a distinção, que aqui pretende levar-se a cabo, entre dignidade penal e carência punitiva pode em alguma medida confortar-se com a distinção que, proveniente da análise normológica, vem sendo feita entre "**norma de valoração ou de comportamento**" e "**norma de sanção**" (38).

---

(35) Pioneiro, no contexto que aqui interessa, OTTO, Strafwürdigkeit und Strafbedürftigkeit als eigenständige Deliktskategorien?, *Schröder-GS*, 1978, p. 51 e ss.

(36) Diferentemente, ANDRADE, Costa, nota 9, p. 187.

(37) Sobre esta contraposição, VOLK, nota 11, p. 898.

(38) Fundamental, WOLTER, *Objektive und personale Zurechnung von Verhalten, Gefahr und Verletzung von Rechtsgut*, 1981, p. 51 e ss. E, agora, HAFFKE, Die Bedeutung der Differenz

Não que se queira, ao afirmá-lo, volver à discussão (sobre ela em síntese supra, 2.º Cap., § 9 e s.), hoje renovada, acerca da distinção bindinguiana entre "norma" e "lei penal", ou da distinção bierlinguiana entre "norma primária" e "norma secundária" ([39]). Mas apenas sublinhar que, logo no plano da norma penal, na sua globalidade, se dá uma diferença, lógico-materialmente fundada, entre o segmento dirigido à caracterização do comportamento e o segmento reportado à caracterização da sanção. Ou, se quisermos transpor a ideia para um plano funcional-sistemático, sublinhar que o sistema do crime e o sistema da sanção se comportam como dois subsistemas de referência mútua e de complementação obrigatórias.

§ 19 Neste sentido se pode afirmar que assim como a ideia da dignidade penal é o elo que liga e oferece consistência e sentido aos pressupostos do facto, o conceito de carência punitiva é um dos operadores mais relevantes ao nível da **doutrina da consequência jurídica**, ligado como está às ideias da necessidade, da subsidiariedade e da proporcionalidade em sentido estrito, ou se quisermos, numa palavra, ao princípio da proporcionalidade em sentido amplo. E não seria difícil mostrar como esta categoria tem uma palavra decisiva a dizer não apenas acerca do sistema das sanções como um todo, mas também sobre problemas específicos daquele sistema, nomeadamente, sobre os da determinação da pena (quer enquanto determinação legal, quer enquanto medida da pena, quer enquanto escolha da pena). O estudo recente de Damião da Cunha, já várias vezes referido ([40]), constitui — pese a eventuais divergências quanto ao entendimento e à localização sistemática da doutrina da punibilidade — exemplo frizante do que aqui se afirma.

---

von Verhaltens- und Sanktionsnorm für die strafrechtliche Zurechnung, *Coimbra-Symposium Roxin*, p. 89.

([39]) As primeiras, na recente caracterização de HAFFKE, nota 38, por natureza prospectivas, funcionalmente preventivas da violação de bens e valores e como tal dirigidas ao futuro; as segundas por natureza retrospectivas, funcionalmente sancionatórias e como tal dirigidas ao passado.

([40]) CUNHA, Damião da, nota 3.

SUBTÍTULO IV

A PREPARAÇÃO E A TENTATIVA

27.º CAPÍTULO

OS ESTÁDIOS DE REALIZAÇÃO DO CRIME (*ITER CRIMINIS*)

§ 1 Pode ser temporalmente longo e é sempre **estruturalmente diversificado** o processo que conduz o crime doloso de acção até à sua *consumação* ou à sua *terminação*. Pressuposto da *execução* de um crime doloso é, já o sabemos, a verificação no agente de uma *vontade de realização* do tipo de ilícito objectivo, de uma *decisão* ou *resolução* de cometimento de um ilícito-típico. Isto não tem de significar, porém, que esta decisão anteceda sempre, cronologicamente, a *preparação* da realização típica: não raramente, pelo contrário, um crime é — até longamente — preparado antes de o agente tomar a decisão definitiva de o cometer. Põe-se deste modo a questão de saber a que estádios de realização do crime doloso a responsabilidade jurídico-penal pode referir-se, e de que modo. Para lhe responder tentar-se-á em seguida cobrir o *iter criminis* (o decurso da realização criminosa) até à sua terminação.

I. A resolução criminosa

§ 2 A mera **decisão** de realização de um tipo de ilícito objectivo (1), independente de um começo de realização efectiva, **não é punível**. A esta conclusão conduz o princípio indiscutido *cogitationes pœnam nemo patitur*. A justificação deste princípio deriva da própria função do direito

(1) Uma sua análise minuciosa e didáctica encontra-se em ROXIN, Resolução do facto e começo de execução na tentativa, *Problemas Fundamentais do Direito Penal*, 1986, p. 297 e ss.

penal de protecção subsidiária de bens jurídicos, não de puros valores morais: se o direito penal não visa, ao menos directamente, contribuir para a modelação moral do indivíduo, mas proteger uma ordenação social, só a violação desta ordenação — e assim, a *conduta externa* do agente — pode constituir um ilícito. A decisão de realização analisa-se num puro processo interior, insusceptível, em si mesmo, de violar interesses socialmente relevantes.

§ 3 É verdade que por vezes a **personalidade do agente** é uma tal que deixa aparecer como altamente provável que à decisão de realização se siga a execução da acção pensada; caso em que se diria estar justificada a intervenção do direito penal na base da mera **decisão** de realização, aliada ao **perigo** que dela logo parece resultar. Mas, para além de não existirem critérios capazes de aferir, com um mínimo aceitável de segurança, a validade destes juízos prognósticos de probabilidade — outra coisa se dirá se na sua base está já o cometimento de um ilícito-típico (2), ao menos sob uma qualquer forma inicial —, a punição de puras resoluções violaria frontalmente o princípio democrático da liberdade de pensamento e de consciência. O mesmo parece dever dizer-se, aliás, para a mera **manifestação, declaração** ou **comunicação** de uma decisão de realização de uma acção típica *como tal* (a menos, pois, que ela constitua um crime autónomo, *v. g.*, o de ameaça do art. 153.º). Por isso, uma regulamentação como a que se continha no art. 31.º do ProjPG de Eduardo Correia, máxime, na sua parte final (3), surge a esta luz, no mínimo, como altamente contestável (também infra, 32.º Cap., § 36 e s.).

II. Os actos preparatórios

§ 4 Também a **preparação** da execução de um tipo de ilícito e os **actos** em que se traduza **não são, salvo disposição em contrário, puníveis** (art. 21.º). Em perspectiva **formal-legal** esta solução — se definirmos actos preparatórios como aqueles que *antecedem* temporalmente e segundo a natureza das coisas a execução de um ilícito-típico — impõe-se logo na medida em que os actos preparatórios não se encontrem descritos ou referidos na generalidade dos tipos legais e não constituam, por isso, pontos

(2) Como acontece com os juízos de perigosidade e análogos em matéria de consequências jurídicas do crime: cf. o nosso *DP II*, § 700 e ss., e MONTEIRO, Cristina Líbano, *Perigosidade de Inimputáveis e "In dubio pro reo"*, 1997, p. 81 e ss.

(3) Era o seguinte o texto deste artigo (baseado, em parte, no chamado "parágrafo Duchesne" do CP alemão: § 30 II): "Quem tenta determinar outrem à prática de um crime será punível com a pena correspondente à tentativa do crime. Da mesma forma será punível quem aceita a oferta de outrem, ou com outra pessoa se concerta, para cometer um crime, *ou quem se declara disposto a cometê-lo*".

de apoio possíveis de uma responsabilização penal. Comprar uma caçadeira que vem a servir para matar alguém, p. ex., não faz parte do acto de "matar" nem tão-pouco de "tentar matar" outra pessoa" (arts. 131.º e 22.º).

§ 5 Em perspectiva **material**, os actos preparatórios definem-se em função da violação do bem jurídico, do ataque ao ordenamento social que a ordem jurídica quer prevenir. A partir daqui se compreende que existam tipos de ilícito que abrangem logo a preparação de tais violações ou ataques, criando deste modo tipos (de perigo abstracto, em princípio) de actos materialmente preparatórios, mas formalmente transformados em **crimes autónomos** (4). É o caso, p. ex., do art. 262.º: a contrafacção de moeda constitui substancialmente um acto preparatório da violação ou ataque ao ordenamento social, que apenas se dá com a *entrada em circulação* daquela moeda (5). Isto, porém, só **excepcionalmente** deverá acontecer, uma vez que, quase sempre (lembre-se o exemplo anterior da compra da caçadeira), os actos preparatórios, em si mesmos considerados, constituirão acções que estão completamente de acordo com o ordenamento social. Uma punição indiscriminada de tais actos estaria próxima, de novo, de uma ilegítima punibilidade de meras intenções.

§ 6 Finalmente, a lei prevê em certos casos, *também excepcionais*, a punição dos actos preparatórios, não como crimes autónomos, mas como **actos preparatórios enquanto tais** (p. ex., nos arts. 271.º e 274.º). Esta solução só se torna político-criminalmente aceitável sob dois pressupostos: que tais actos apontem já com *alto grau de probabilidade* para a realização do tipo de ilícito; e que se verifique a *necessidade* de uma intervenção penal específica num estádio particularmente precoce do *iter criminis*. Punir os actos preparatórios enquanto tais implica por seu lado duas consequências específicas: a de que se não deve punir a *tentativa de acto preparatório*, mesmo que ela fosse em geral punível se o acto preparatório constituísse um crime autónomo; e a de que — sob pena de violação substancial do princípio *ne bis in idem* (acolhido no art. 29.º-5 da CRP) — o acto preparatório, como tal punível, não deve voltar a considerar-se punível como crime autónomo.

---

(4) Sobre a matéria deste parágrafo e dos seguintes, por último, ROXIN II, § 29, n.º 342 e ss.

(5) Por último, COSTA, A. M. Almeida, e MONIZ, Helena Isabel, ambos no *Comentário Conimbricense*, II, respectivamente § 20 e s. antes do art. 262.º e art. 271.º

§ 7 Resta saber se é coisa substancialmente diferente o que se passa com os arts. 262.º e 271.º O primeiro pune como crime autónomo a **contrafacção de moeda**, o segundo pune os actos preparatórios da contrafacção. Que esta solução legislativa conduz a punição (da "preparação da preparação"!) a estádios demasiado precoces e duvidosos da realização do crime material — o de, como atrás se disse, "colocar em circulação moeda falsa" — e é, por conseguinte, altamente questionável em perspectiva político-criminal, é conclusão que temos por fundada (6). A via para lhe atalhar residirá numa correcta desimplicação, quanto a este ponto, da doutrina do concurso de crimes, concretamente, no caso, pela afirmação da unidade de norma aplicável por verificação de uma relação de subsidiariedade tácita (infra, 42.º Cap., § 16).

III. A tentativa

§ 8 Na forma "normal" de aparecimento da acção dolosa, que se traduz na realização desta como *consumada*, verifica-se um preenchimento completo do tipo de ilícito respectivo, objectivo e subjectivo. E todavia, ao que vimos já, mesmo naquela realização pode a esse propósito haver "falhas" (ou "faltas"), quando não se verifica a "congruência" entre o tipo objectivo e o tipo subjectivo do ilícito. Tal é claramente o caso do *erro sobre a factualidade típica* (supra, 13.º Cap., § 17 e ss.), isto é, o caso em que o agente, com a sua acção, preencheu integralmente o tipo objectivo mas não, por falta do conhecimento indispensável, o tipo subjectivo respectivo (ficando em aberto a possível realização de um facto negligente ou de outro facto doloso). Hipótese em que, assim, à "perfeição" da realização do tipo de ilícito objectivo corresponde uma "imperfeição" do tipo de ilícito subjectivo. Pode porém verificar-se uma constelação **inversa** da descrita: aquela em que à perfeição do tipo de ilícito subjectivo (portanto, do dolo do tipo) corresponde uma imperfeita ou inacabada realização do tipo de ilícito objectivo que se previu e intentou. São estas as hipóteses de *tentativa* que cumpre agora considerar e que representam, *nesta acepção*, como que a **contra-face** (7) **das hipóteses do erro sobre a factualidade típica**.

§ 9 Diferentemente do que vimos suceder em regra com os actos preparatórios, **a tentativa** de cometimento de um crime, em princípio, é

---

(6) Cf., de novo, os AA. e os locs. cits. na nota anterior. Na conclusão, como no texto, BECK, *Unrechtsbegründung und Vorfeldkriminalisierung*, 1992, e JAKOBS, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, *ZStW 97*, 1983, p. 751 e ss.

(7) COSTA, Faria, Formas do crime, *JDC 1983*, p. 162, imputa este procedimento a uma "estética de rigor que não tem nada a ver com vãos, superados e estéreis conceitualismos".

punível. Como prática de "actos de execução de um crime que [o agente] decidiu cometer sem que este chegue a consumar-se" (art. 22.º-1), a tentativa viola já a norma jurídica de comportamento que está na base do tipo de ilícito consumado. Como realização dolosa *parcial* de um tipo de ilícito objectivo ela representa uma violação do ordenamento social jurídico-penalmente relevante por meio da intranquilidade em que coloca bens jurídico-penais. Sendo embora assim, parece todavia excessivo o argumento de que, em rigor, se tornaria desnecessária a expressa previsão legal da *ilicitude* da tentativa ([8]), sobrando apenas o imperativo de consagrar a sua *punibilidade* e as condições sob as quais ocorre. A verdade é que a ilicitude não se basta apenas com um desvalor da acção, mas exige ainda também um desvalor de resultado, ao menos sob a forma da intranquilidade de bens jurídicos penalmente protegidos. Por isso, e por um lado, uma plena satisfação do conteúdo de sentido ínsito no *nullum crimen sine lege* conduz à exigência de consagração legal do ilícito ("parcial", relativamente ao do crime consumado) próprio da tentativa. Ligando-se, por outro lado, as penas previstas na parte especial do CP só aos crimes consumados, têm de existir (sob pena de violação do princípio *nulla pœna sine lege*) uma ou várias normas que prevejam a(s) pena(s) da tentativa. Por outra forma: a tentativa, como realização parcial de um tipo de ilícito, participa já (parcialmente) deste ilícito e *pode* por isso ser *punível*. Se *deve* sê-lo em concreto depende de considerações político-criminais relacionadas sobretudo com a gravidade da infracção e com os limites que a figura a si mesma se assinala. Tudo isto implica uma sua consideração mais próxima que posteriormente (28.º Cap., § 41 e ss.) será levada a cabo.

§ 10 A acima mencionada definição objectiva da tentativa como **prática de actos de execução de um tipo de crime** tem carácter *formal*: *quais* as acções que "executam" um crime é coisa que depende, em último termo, da conformação do tipo de ilícito. Daí que, tal como acabámos de ver que pode suceder com os actos preparatórios, também "actos de exe-

([8]) Completamente neste sentido, todavia, STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 11. Contra — na esteira de ENGISCH, Der Unrechtstatbestand im Strafrecht, *DJT—FS*, I, 1960, p. 435 e s. —, CORREIA, Eduardo, I, p. 251, para quem na tentativa "o direito criminal alarga excepcionalmente a punição"; na conclusão também, COSTA, Faria, Tentativa e dolo eventual (ou da relevância da negação em direito penal), *Estudos Eduardo Correia*, I, 1989, pp. 748 e ss., 755 e s., e, por último, ROXIN II, § 29, n.º 102, com a sua noção da "*proximidade* ao tipo" como "critério supremo" da essência da tentativa.

cução" que estrutural e substancialmente constituem tentativa possam ser tidos pela ordem jurídica como crimes autónomos: o exemplo mais claro desta situação é constituído pelos chamados "crimes de empreendimento" (supra, 11.º Cap., § 56). Considerar que, nestes casos, continuamos, *de um ponto de vista substancial*, perante hipóteses de *tentativa* pode ter, no entanto, o mais alto-relevo dogmático-prático: quer para aplicação das regras limitativas da *punibilidade da tentativa*; quer para considerar a "tentativa da tentativa" como verdadeiro *acto preparatório* e, por conseguinte, não punível, salva declaração expressa da lei em contrário; quer ainda para dar relevo em tais casos à *consumação material* quando efectivamente sobrevenha (infra, § 11 e s.).

IV. A consumação e a terminação

§ 11 Que o comportamento típico surja sob a forma de delito tentado ou antes de delito consumado é circunstância, como agora já bem se compreende, dotada do maior relevo prático-normativo: os arts. 22.º a 25.º valem em princípio apenas para comportamentos que não atingiram o estádio da consumação. A distinção, todavia, entre delito tentado e delito consumado, que à primeira vista se diria evidente e correspondente à percepção imediata das coisas, pode suscitar dificuldades de relevo. Com efeito, como acaba de referir-se, não faltam casos em que a lei considera como *consumados* delitos que, em perspectiva substancial, não passam de delitos *tentados*. Por isso se torna indispensável a distinção entre a "consumação formal ou típica" e a "consumação material" (quando esta não coincide com aquela), à qual costuma dar-se também o nome de "terminação" ou "conclusão" (em alemão *Beendigung* (9)) (10). A **consumação típica ou formal** verifica-se logo que o comportamento doloso preenche a *totalidade* dos elementos do tipo objectivo de ilícito. A **consumação material, terminação** ou **conclusão** dá-se apenas com a *realização completa do conteúdo do ilícito em vista do qual foi erigida a incriminação*, desde que o agente tenha actuado com o dolo de o realizar; dá-se, por outras palavras, com a verificação do resultado que interessa ainda à valoração do ilícito por directamente atinente aos bens jurídicos tutelados e à

(9) Fundamental sobre o ponto, JESCHECK, Wesen und rechtliche Bedeutung der Beendigung der Straftat, *Welzel-FS*, 1974, p. 683, ROZES, L'infraction consommée, *RScCrim*, 1975, p. 610, e agora JESCHECK / WEIGEND, § 49, III, 3.

(10) "Exaurimento" lhe chama FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 395.

função de protecção da norma ([11]). Justamente nesta acepção fala o art. 24.º-1 da "verificação do resultado *não compreendido no tipo de crime*" ([12]). Com exemplos desta distonia entre consumação formal e material se pode deparar, p. ex., em *crimes de consumação antecipada* (crimes de perigo, crimes de empreendimento ou de atentado, crimes de intenção ou de resultado cortado: supra, 11.º Cap., § 41, e 13.º Cap., § 58 e s.) e em *crimes de estrutura iterativa ou reiterada* (crimes duradouros: supra 11.º Cap., § 54, ou crimes com pluralidade de actos típicos) ([13]).

§ 12 A distinção entre consumação formal e material assume **significado prático-normativo** de relevo em múltiplos contextos. Antes de tudo no da *desistência* da tentativa, como logo o comprova a circunstância de uma tal distinção ser pressuposta pelo art. 24.º-1 (infra, 29.º Cap., §§ 29, 31 e s., 36). Mas também em matéria de *comparticipação*, na medida em que esta deve ocorrer, ao menos em via de princípio, *antes* da consumação ([14]). Ela pode relevar igualmente em tema de *concurso* de crimes, se e na medida em que se confira relevo e autonomia normativas à categoria do "concurso ideal" (infra, 41.º Cap., § 10 e ss.). Ao que deverá ainda acrescentar-se o significado que possa assumir nos casos em que a produção de um resultado releva, se bem que não ao nível do tipo de ilícito, para a definição da espécie de crime (como vimos suceder com certas *condições objectivas de punibilidade*, *v. g.*, arts. 135.º e 227.º e ss.: supra, 26.º Cap., § 11); como para efeito de *prescrição do procedimento criminal* (art. 119.º-4: "a verificação de resultado não compreendido no tipo de crime") ([15]).

([11]) DIAS, Figueiredo, *As "Associações Criminosas" no Código Penal Português de 1982 (Artigos 287.º e 288.º)*, 1988, p. 70.

([12]) Expressão cujo correcto entendimento tem dado origem a uma vasta discussão na doutrina portuguesa: cf., logo, *Actas PG*, II, p. 221 e ss., FONSECA, Jorge, *Crimes de Empreendimento e Tentativa*, 1986, p. 155 e ss., PINTO, Costa, *A Relevância da Desistência em Situações de Comparticipação*, 1992, pp. 43 e s. e 149 e s., e o nosso *DP II*, § 1136 e s. Cf., também, infra, 29.º Cap., § 30 e s.

([13]) De novo, JESCHECK / WEIGEND, § 49, III, 3.

([14]) Em particular sobre este ponto, agora, KÜHL, Die Beendigung des vollendeten Delikts, *Roxin-FS*, 2001, p. 665.

([15]) Cf. o nosso *DP II*, § 1136 e s.

28.º CAPÍTULO

A TENTATIVA

I. Fundamento da punibilidade da tentativa

§ 1 Levando às últimas consequências a proposição (que avançámos supra, 27.º Cap., § 9) segundo a qual a tentativa de realização de um tipo de ilícito objectivo representa já uma sua violação (parcial), toda a reflexão sobre o fundamento da punibilidade da tentativa poderia parecer supérflua. A verdade porém é, desde logo, que a tentativa não é punida relativamente a todo e qualquer tipo de crime; e, quando o é, não lhe cabe a pena aplicável ao crime consumado. Por outro lado, tomar à partida como assente o fundamento da punibilidade da tentativa não faria de nenhum modo justiça à **história dogmática** do problema. Bem pelo contrário, tocando o cerne da doutrina do ilícito-típico, a questão do *fundamento* e dos *limites* da punibilidade da tentativa tornou-se, nos dois últimos séculos, um dos temas mais controvertidos de toda a dogmática jurídico-penal, onde vivamente e com particular intensidade se defrontam as concepções objectivas e subjectivas do crime (1).

1. As teorias objectivas

§ 2 Se no ponto de partida da controvérsia situarmos Feuerbach, o fundamento de punibilidade da tentativa é eminentemente *objectivo*. Ele definiu a tentativa como "uma acção externa dirigida intencionalmente à realização do crime", que deve ser "objectivamente perigosa". Uma vez que "a intenção ilícita por si mesma" não oferece "a nenhuma acção o ele-

---

(1) Sobre a história dogmática, CORREIA, *Studium*, p. 12 e ss., e ZACZYK, *Das Unrecht der versuchten Tat*, 1989, p. 41 e ss.

mento da ilicitude" (2) — e porque ela atravessa todo o *iter criminis* até à consumação, não podendo por isso servir para distinguir a tentativa da preparação —, é o **perigo próximo de consumação da realização típica** que constitui o verdadeiro fundamento de punibilidade da tentativa. Aqui reside o denominador comum das chamadas **teorias objectivas** (3).

§ 3 Mantendo integral fidelidade a uma consideração objectiva da tentativa — e, sobretudo, concedendo-lhe *exclusivo* (4) —, a teoria nela assente deve ser **recusada**. Seguramente *de lege lata*, porquanto o art. 22.º-1 considera como elemento essencial da figura da tentativa a *decisão* de cometer um crime e o art. 23.º-3 aceita a punibilidade de princípio da tentativa impossível ou inidónea que, por definição e segundo um juízo *ex post*, não põe em perigo *real* qualquer bem jurídico tipicamente protegido (infra, § 45). Se, por estas razões, se aceita que para fundamentar a punibilidade da tentativa releva *não só* a sua componente objectiva, *mas também* o seu lado subjectivo, tem então de concluir-se que as teorias em análise não mostram em definitivo e em si mesmas capacidade para decidir a qual dos componentes deve (e como deve, e porque deve) atribuir-se primazia, se àquilo que a acção "devia" produzir segundo a vontade do agente, se àquilo que ela "podia" produzir (5). É sobre este ponto que se tem centrado a discussão no nosso tempo.

2. As teorias subjectivas

§ 4 As teorias subjectivas colocam como fundamento da punibilidade da tentativa a **vontade delituosa**. Tal como, de resto, sucede com as concepções subjectivas do próprio crime, o ilícito jurídico-penal considera-se constituído pela *violação da norma* como tal, mais rigorosamente, pelo comportamento através do qual o agente, vistas as coisas da sua perspectiva, viola uma norma proibitiva ou impositiva. Aqui reside o cerne de todas estas doutrinas. Para elas não releva, a nível do fundamento da punibilidade, o aparecimento ou mesmo só o perigo de aparecimento de uma con-

(2) *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*, ⁹1826, p. 42 e s.

(3) Substancialmente defendidas ainda por CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 23 e ss., FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, p. 525 e ss., v. HIPPEL, *Untersuchungen über den Rücktritt vom Versuch*, 1966, p. 26, e SPENDEL, Zur Neubegründung der objektiven Versuchstheorien, *Stock-FS*, 1966, p. 98 e ss.

(4) À maneira de CORREIA, Eduardo, II, pp. 228 e ss., 231.

(5) Exactamente nestes termos, STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 17.

creta violação de um bem jurídico. No fundo, não existe nenhuma razão de princípio para tratar diversamente o delito tentado e o consumado ou para tornar a punibilidade da tentativa dependente da sua perigosidade real.

§ 5 **A favor** destas doutrinas está o à-vontade com que podem defrontar o problema da *tentativa impossível ou inidónea*: se *A*, pela noite, vendo deslocar-se uma sombra que erroneamente toma por outra pessoa que odeia, sobre ela dispara sem todavia a atingir, pode haver aqui uma tentativa punível de homicídio que *mereça* ser punida, apesar de o bem jurídico da vida de outrem não ter sido realmente posto em perigo. Mas com isto **não ficará justificada** uma concepção extremada ou exclusivamente subjectiva que renuncie integralmente à perigosidade objectiva da conduta; também esta concepção se não adequaria nem aos dados da legislação vigente (que exige para a tentativa punível a prática de *actos* de execução), nem a uma correcta concepção do ilícito vinculada à protecção de bens jurídicos. Se, p. ex., uma mulher pede a uma bruxa que faça umas rezas que, segundo o seu plano e a sua convicção, lograrão a desejada morte do marido, uma concepção puramente subjectiva da tentativa deveria fundar a punibilidade da actuação, quando na verdade tal não sucede segundo a legislação vigente (art. 23.º-3 e infra, § 51 e s.) nem é defensável à luz de uma correcta concepção do ilícito-típico, vinculada à protecção de bens jurídicos. De qualquer modo e em todo o caso, as teorias subjectivas põem correctamente em evidência a imprescindibilidade, em muitas hipóteses, do recurso ao **plano do agente** e, por aqui, ao mundo (subjectivo) das suas representações (6).

3. As teorias da "impressão"

§ 6 Com o reconhecimento da pertinência das críticas de que tanto as teorias extremada ou exclusivamente objectivas, como subjectivas são passíveis, tornava-se inevitável o surgimento de uma terceira orientação (*hoc sensu*, intermédia ou, mais rigorosamente, "**aditiva**"), conducente a uma sensível aproximação e combinação de pontos de vista, mas introduzindo em todo o caso na controvérsia uma ideia nova: a da **dignidade penal** do facto tentado. Ela parte da fundamentação da punibilidade da tentativa na von-

(6) Certamente por isso não falta quem considere as doutrinas subjectivas (moderadas) hoje dominantes na doutrina alemã: cf., com largas indicações bibliográficas, JESCHECK / WEIGEND, § 49, II, 2.

tade exteriormente manifestada em contrário da norma de comportamento. Mas defende que a punibilidade do acto dirigido à realização do tipo só será afirmada se ela se revelar como uma **intervenção significativa** no ordenamento jurídico; mais concretamente, se e quando ela for — segundo um juízo necessariamente *ex ante*, de prognose póstuma — adequada a pôr em causa a **confiança da comunidade** na vigência daquele ordenamento e, deste modo, a frustrar as suas expectativas de segurança e de paz jurídicas. Fala-se, a propósito desta orientação, de "teorias da impressão" (7).

§ 7 Sem por completo se divorciarem da preferência hoje generalizada pelas teorias da impressão, certos autores, como Stratenwerth, desvalorizam-nas em alguma medida como "mera etiqueta de um regresso repentino à doutrina dos fins das penas e, na verdade, a pontos de vista de prevenção geral positiva" (8). Dada a falta de conhecimentos empíricos sobre o quanto de pena necessário a uma eficaz prevenção geral, positiva e negativa, tudo ficaria pelo apelo a regras várias da experiência comum e por conclusões circulares: a tentativa abala a confiança na vigência do ordenamento jurídico quando surge como merecedora de pena, e inversamente. Não cremos todavia que esta crítica deva considerar-se procedente. O que aqui se procura **é um fundamento** — muito correctamente encontrado na linha da função do direito penal e das finalidades primárias da pena —, **não critérios interpretativos** das normas positivas, válidos para a aplicação do direito. Estes devem ser encontrados à luz do direito positivo e da sua regulamentação; e, neste enquadramento, a teoria da impressão é a que melhor se compatibiliza com o regime conferido aos actos de execução, à atenuação especial obrigatória da pena da tentativa e à tentativa impossível (infra, §§ 13 e ss., 44 e 45 e ss.).

---

(7) Cuja elaboração e formulação terá sido pela primeira vez lograda por HORN, Der Versuch. Begründung einer objektiven Versuchstheorie im Hinblick auf empirische Psychologie und Physiopsychologie, *ZStW 20*, 1900, p. 342, e na qual convinha MEZGER, p. 397. Nesta orientação converge hoje — pese a inevitável pluralidade de formulações e de pormenores — a maioria da doutrina alemã, pela qual pode ver-se M / GÖSSEL / ZIPF, II, § 40, n.º 40 e ss., JESCHECK / / WEIGEND, § 49, II, 3, ROXIN, Resolução do facto e começo de execução na tentativa, *Problemas Fundamentais do Direito Penal*, 1986, p. 297 e ss., RUDOLPHI, *SK*, n.º 13 antes do § 22.

(8) STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 21. De algum modo também já, entre nós, NEVES, Curado, *Comportamento Lícito Alternativo e Concurso de Perigos*, 1989, p. 121 e ss., e VEIGA, Soares da, *O Desconhecimento pelo Agente do Crime do Consentimento do Ofendido*, 1987, p. 105 e ss. Criticamente, BRITO, Teresa Quintela de, *A Tentativa nos Crimes Comissivos por Omissão: Um Problema de Delimitação da Conduta Típica*, 2000, p. 167 e s.

§ 8 Que um "regresso" à doutrina dos fins das penas é indispensável (e como poderia ser de outro modo?) à teorização do fundamento da punibilidade da tentativa, reconhece-o agora também Roxin na concepção que a propósito desenvolve e a que chama **teoria da união**. Para ele "o fundamento da punibilidade da tentativa reside na exigência geral ou especial-preventiva da pena, que em regra deriva do perigo doloso chegado ao tipo, mas excepcionalmente também de uma violação juridicamente perturbadora da norma, manifestada numa acção chegada ao tipo" (9). Esta teoria distinguir-se-ia da da impressão quer porque esta só estaria em condições de oferecer um juízo de valor vago e que não vai além de uma descrição do juízo legal de punibilidade; quer porque ela não encontraria nada de específico no delito tentado relativamente ao consumado, nem no acto de execução face ao acto preparatório; quer finalmente porque não conseguiria, através da sua fórmula compromissória pretensamente unitária, apagar um inevitável **dualismo**: por um lado, as tentativas que são puníveis em nome do princípio (prioritário) da perigosidade da acção, por outro as tentativas que, não sendo perigosas, são (excepcionalmente) puníveis sob o ponto de vista da violação juridicamente perturbadora da norma (10). Não julgamos esta crítica, no entanto, procedente. Logo porque não conseguimos considerar o "critério supremo" oferecido — o da "proximidade ao tipo" — menos vago (longe disso) do que aquele que pode resultar da teoria da impressão. E depois — e sobretudo — porque não é função do "fundamento" explicar o regime jurídico-positivo de um instituto, mas servir-lhe de padrão crítico de legitimação. Avançando-se desde já que o problema aqui mais questionável — o da punibilidade, mais ou menos extensa, da tentativa impossível — tem justamente de ser legitimado, nas suas soluções, à luz da teoria da impressão (infra, § 50).

II. Os elementos da tentativa

§ 9 Nos termos do art. 22.º-1 e 2 são elementos da tentativa, por um lado, a decisão de cometer um crime, por outro lado, a prática de actos de execução de um crime que não chega a consumar-se.

---

(9) ROXIN II, § 29, n.º 10.
(10) ROXIN II, § 29, n.º 46 e ss.

1. A decisão de cometer o facto

1.1. Caracterização geral

§ 10 Como atrás se sugeriu, o tipo subjectivo de ilícito da tentativa é **o mesmo** que o do crime consumado. À decisão de cometer um crime pertence assim a totalidade das exigências típicas subjectivas: o **dolo** dirigido à realização objectiva (dolo do tipo) e eventualmente também **especiais elementos subjectivos** que a lei requeira no caso ([11]). Quando o acontecimento fáctico seja precocemente interrompido — em certos casos, por conseguinte, da chamada *tentativa inacabada* (infra, § 38 e ss.) — pode tornar-se duvidoso se o agente se decidiu ou não pela execução do facto ([12]), uma vez que não tenham chegado a ser executados aqueles actos da realização típica que manifestariam indubitavelmente a existência de uma vontade dirigida à consumação. Uma mera "decisão (vontade) condicional" — coisa diferente de um verdadeiro dolo eventual: supra, 13.º Cap., § 37 — não é obviamente bastante: não toma a decisão de cometer um crime para efeito de tentativa aquele que, *v. g.*, aprecia ainda se estão ou não presentes as condições situacionais que reputa necessárias para cometer o facto; mas já a toma aquele que conta com a possibilidade de desistir se a execução do facto "não correr bem". Cremos que precisamente neste sentido apresenta Roxin como *critério geral* nesta matéria o seguinte: "Uma decisão pelo facto existe logo que os motivos que empurram para o cometimento do delito alcançaram predominância sobre as representações inibidoras, mesmo também quando possam restar ainda últimas dúvidas" ([13]). Na verdade: se neste estádio da motivação o agente dá início à execução, mal se vê como possa pôr-se em questão a existência de uma decisão pelo facto.

1.2. Tentativa negligente?

§ 11 Por vezes se pretende, contra o que acabou de ser afirmado, construir o conceito de tentativa independentemente da existência de uma decisão criminosa (supra, § 2 e s.). Para Eduardo Correia, p. ex., "a ilicitude

---

([11]) Sobre o papel e os problemas da consequente exigência (feita expressamente pela lei alemã) de "representação do facto", por último, HILLENKAMP, Zur "Vorstellung von der Tat" im Tatbestand des Versuchs, *Roxin-FS*, 2001, p. 599, e ROXIN II, § 29, n.º 3 e ss.

([12]) Sobre este tema, já, ROXIN, Über den Tatentschluss, *Schröder-GS*, 1978, p. 145.

([13]) ROXIN II, § 29, n.º 88 (cf. n.ºs 81-96).

é constituída, na tentativa, simplesmente pelo **perigo** que a acção cria para bens jurídicos protegidos pelo direito criminal e o dolo ou intenção é, unicamente, uma **condição exterior de punibilidade** [s. n.] (sem prejuízo, evidentemente, do papel que desempenha como elemento da culpa)... A ser assim,... concebida a tentativa de uma forma puramente objectiva — como actividade que produz um perigo de violação de bens jurídicos, independentemente do dolo ou da intenção —, nada impede, ao menos em abstracto, que ela se aplique a crimes cometidos com negligência que não chegaram a produzir o resultado típico" ([14]). Mas **esta concepção não pode ser aceite**. Logo porque ela é contrariada, de maneira terminante, pelo processo histórico de produção da lei vigente ([15]). Mas sobretudo porque uma tentativa negligente constitui uma verdadeira *contraditio in adjecto* (pelo menos, e sobretudo, no que toca à negligência inconsciente): quem tenta alguma coisa é porque decidiu realizá-la! Aferir da ilicitude da tentativa exclusivamente na base da criação de um perigo conduziria, de resto (supra, 10.º Cap., § 60), a renunciar à *tipicidade da ilicitude* e, consequentemente, à determinação do tipo de ilícito verificado. Claro que é possível (e em muitos casos punível) a colocação não dolosa em perigo de bens jurídicos alheios: isto porém não constitui tentativa ([16]).

1.3. Tentativa e dolo eventual

§ 12 De algum modo no outro extremo se posicionam autores para quem a tentativa é **incompatível com o dolo eventual**: a decisão criminosa em causa na tentativa só poderia ser imputada ao agente nos quadros do dolo directo, mesmo sob a sua forma mais estrita, a da intenção ([17]). A doutrina maioritária, portuguesa e estrangeira ([18]), acompanhada de resto pela

---

([14]) CORREIA, Eduardo, II, p. 231.

([15]) Com efeito, Eduardo Correia tinha introduzido um conceito puramente objectivo de tentativa no art. 21.º do seu ProjPG; mas ele não foi aceite e foi substituído pelo texto do art. 23.º-1.

([16]) Doutrina absolutamente dominante — se não mesmo unânime — entre nós. Logo assim FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, p. 521, e CORREIA, Eduardo, *Studium*, pp. 31 e s., 69.

([17]) COSTA, Faria, Tentativa e dolo eventual (ou da relevância da negação em direito penal), *Estudos Eduardo Correia*, I, p. 757 e ss., e, do mesmo, Anotação ao Ac. do STJ de 3-7-91, *RLJ 132*, n.º 3903, p. 180 e ss.

([18]) Cf., por outros FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 404. Uma exposição e análise minuciosas da posição de Faria Costa é levada a cabo por GOMES, Júlio, *A Desistência da Tentativa. Novas e Velhas Questões*, 1993, n.º 35.

jurisprudência nacional dominante ([19]), **não aceita esta restrição**. Do nosso ponto de vista, com razão: quer porque a "decisão" a que se refere o art. 23.º-1 não tem de (nem deve) ser entendida em termos diferentes e mais exigentes do que aqueles que valem para qualquer tipo de ilícito doloso, que exige *sempre* ser integrado por uma "decisão", não necessariamente por uma "intenção"; quer porque não existe nenhuma incompatibilidade lógica e dogmática entre o tentar cometer um facto doloso e a representação da realização apenas como possível, conformando-se o agente com ela; quer porque, decisivamente, estão nestes casos colocadas as mesmas exigências político-criminais, a mesma "dignidade punitiva" e a mesma "carência de pena" que justificam a punibilidade de qualquer tentativa (p. ex.: *A* dispara sobre *B*, seu inimigo figadal, todavia colocado a uma distância tão grande que leva *A* a representar a verificação do resultado como meramente possível mas a conformar-se intimamente, de forma plena — mesmo sob a forma de um desejo irreprimível —, com o resultado; o tiro, no entanto, falha o alvo). Puppe defende a não punibilidade da tentativa com dolo eventual por analogia com a da tentativa acabada quando o agente vem a impedir a consumação (infra, 29.º Cap., § 25 e ss.) ([20]). Cremos porém, com Roxin, que o paralelo é injustificável ([21]): na desistência o agente abandona o dolo do facto, na tentativa com dolo eventual o dolo persiste, inexistindo por conseguinte aqui qualquer factor susceptível de diminuir a dignidade penal do facto. Devendo assim concluir-se que, tal como, em geral, no delito consumado (supra, 13.º Cap., § 34 e ss.), **na tentativa o dolo pode assumir qualquer uma das suas formas**: intencional, necessária ou eventual.

2. Os actos de execução

§ 13 Aos elementos da tentativa pertence depois (art. 22.º-2) a prática de actos de execução de um crime que não chegou a consumar-se. Necessário se torna, assim, que a "decisão" se exprima externamente em actos que constituam não meros actos preparatórios, mas se apresentem já

([19]) Neste sentido, entre outros, os Acs. do STJ de 8-3-2006, www.dgsi.pt, de 31-5-2004, *CJ XII*-I, p. 234, de 14-6-2000, *CJ VIII*-II, p. 211, de 21-1-1999, *CJ VII*-I, p. 198, de 11-12-1997, *BMJ 472*, p. 163. Contra, no entanto, Ac. do STJ de 13-7-2005, www.dgsi.pt, ligando-se expressamente à opinião de Faria Costa.

([20]) PUPPE, *NStZ*, 1984, p. 491.

([21]) ROXIN II, § 29, n.º 75 e ss.

como **actos de execução**. Porém, a forma como nesta via deva distinguir-se em concreto a "execução" da "preparação" é extraordinariamente discutida e, efectivamente, difícil de lograr; também podendo afirmar-se, com inteira correcção, que o problema aqui implicado é o da determinação, dentro de um processo continuado, do **momento em que se inicia a execução** (22).

2.1. As teorias formais objectivas

§ 14 Em perspectiva histórico-dogmática, o ponto de partida da distinção entre actos preparatórios e actos de execução encontra-se nas chamadas teorias formais objectivas, segundo as quais a tentativa supõe pelo menos **a prática de (uma parte daqueles) actos que caem já na alçada de um tipo de ilícito e são portanto abrangidos pelo teor literal da descrição típica** (23). Como linha de orientação fundamental não parece poder este critério ser contestado: a regra da tipicidade e a consequente exigência de determinabilidade da matéria proibida, expressão do princípio da legalidade, parecem vincular a que só possam ser ameaçados com penas actos descritos (ou seguramente compreendidos, segundo o sentido) em um tipo de ilícito. Simplesmente, resta a questão de saber quais as *qualidades* de que deve revestir-se um concreto acto singular para que possa afirmar-se preencher ele um elemento do tipo de ilícito. Uma resposta na linha das teorias formais objectivas conduz a considerar decisivo o **teor literal** do tipo respectivo, o apelo ao significado corrente das "palavras" nele utilizadas, tornando assim (24) todo o problema da distinção numa questão de interpretação dos singulares tipos legais de crime e, deste modo, da PE do direito penal. Uma tal resposta, deve concordar-se, pode servir para resolver alguns casos concretos: os mais simples, *v. g.*, comprar uma faca não integra seguramente, segundo o sentido, o acto de matar do art. 131.º Mas, só por si considerada, ela parece soçobrar perante os casos mais complexos. E tem de concordar-se, de todo o modo, que existe uma quantidade inumerável de actos que tudo indica deverem considerar-se como de

---

(22) Como preferem, entre outros, ROXIN II, § 29, n.º 97 e ss., e STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 29 e ss.

(23) BELING, p. 57 e s., v. HIPPEL, II, p. 398 e ss., LISZT / SCHMIDT, pp. 182 e 305. Próximo deste critério — quando não com ele coincidente — ficava o apontado por FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, p. 525 e ss.

(24) Como criticamente assinala ROXIN II, § 29, n.º 104 e ss.

execução sem todavia poder afirmar-se que eles integram o teor literal ou mesmo significante de um elemento típico; nomeadamente — mas não só — quando, como assinala Eduardo Correia, o crime é de *execução livre ou não vinculada* (supra, 11.º Cap., § 42) ([25]).

§ 15 Como sublinhou Vogler, porém, as teorias em questão, se não podem ser entendidas no sentido de que todo o acto de execução implica a realização parcial de um tipo de ilícito, já deverão ser aceites na acepção de que **existe um acto de execução sempre que o agente pratica uma acção que integra um elemento constitutivo de um tipo** ([26]). Roxin critica uma tal conclusão, apontando exemplos em que ela contrariaria a interpretação, máxime jurisprudencial, de certos tipos e a razoabilidade das soluções cabidas a certos casos concretos. Mas os exemplos avançados pertencem, na generalidade, a casos de realização de elementos típicos *qualificadores* de um delito fundamental, relevando desta forma de um problema especial (infra, § 35) e que não pode, por isso, contrariar a regra geral acabada de formular. E quando tal não é o caso, é pelo menos duvidoso que a crítica proceda.

§ 16 Ilustrativo é o caso julgado pela jurisprudência alemã de um homem, *A*, que aborda na rua uma mulher, *B*, fazendo-se passar por seu parente, para assim ganhar a sua confiança e ser recebido em sua casa, onde tenciona, através de falsos pretextos, pedir-lhe um empréstimo e, uma vez este concedido, desaparecer; o que todavia não acontece porque, face ao seu estranho comportamento, *A* é detido em plena rua. O tribunal — com a concordância de Roxin e também com a nossa — decidiu existir ali apenas um acto preparatório; apesar, afirma Roxin, de o seu comportamento integrar já o elemento "engano" típico do crime de burla. Se concordamos com a solução, divergimos porém desta última afirmação: entrar em contacto com a vítima potencial e fazer-se passar por seu parente não integra ainda o elemento do "erro ou engano" determinante de um "prejuízo patrimonial", **típico da burla** do art. 217.º: isso só sucederia com os falsos pretextos atinentes à obtenção do empréstimo (cf. infra, § 32 ss., a propósito do que chamamos a "conexão de perigo típica").

§ 17 Em conclusão quanto a este ponto: o conteúdo de sentido ínsito nas teorias formais objectivas, no entendimento que acabámos por lhe atribuir, não pode deixar de ser considerado **ponto de vista obrigatório** de uma

([25]) CORREIA, Eduardo, II, p. 229.

([26]) VOGLER, Der Beginn des Versuchs, *Stree/Wessels-FS*, 1993, p. 300; cf., também, KÖHLER, p. 460.

distinção entre actos preparatórios e actos de execução, porque a tanto vincula o conteúdo de sentido do princípio *nullum crimen sine lege*. Ainda quando este não seja violado pela circunstância de a lei positiva poder apontar outros critérios adicionais, a verdade é que nenhum deles pode ser dissociado do princípio da tipicidade sem entrar em causa a compreensão material do conteúdo e da função que este princípio exerce num Estado de Direito ([27]). Mas é igualmente exacto que o critério resultante das teorias formais objectivas, tal como o entendemos, tem de ser complementado (e, na verdade, alargado) e esclarecido de acordo com o (e em função do) tipo de crime de referência.

2.2. As teorias materiais objectivas

§ 18 A esta complementação e esclarecimento essenciais vêm as teorias **materiais objectivas**, ao tentarem determinar com maior precisão os elementos de que depende o alargamento da tipicidade dos actos de execução. Decisiva se revelou neste contexto a que ficou doutrinalmente conhecida como **fórmula de Frank** e segundo a qual devem considerar-se como de execução os actos que "em virtude de uma pertinência necessária à acção típica, aparecem, a uma **consideração natural**, como suas partes componentes" ([28]). Fórmula esta que, tendo primeiramente sido tomada como mera explicitação e alargamento das teorias formais objectivas, ganhou posteriormente uma dupla (e de certo modo "nova") conotação: por um lado, combinou-se com a ideia das teorias subjectivas ([29]), nomeadamente, com o recurso ao *plano do agente*, que seria em muitos casos necessário para determinar se o acto surge ou não como "parte componente" da realização típica; por outro lado, veio a ligar-se ao ponto de vista essencial das teorias objectivas sobre o fundamento da punibilidade da tentativa (supra, § 2) e, assim, à ideia de que um acto deverá considerar-se já como começo de execução se ele acarreta um **perigo imediato** ([30]) (ou *iminente*, ou ao menos *próximo*) para o bem jurídico protegido. À primeira destas considerações se tem oposto, todavia, que também com ela pouco se ganha em rigor — relativamente às teorias formais objectivas — na dilucidação dos

---

([27]) Assim já DIAS, Figueiredo, Legalidade e tipo em Direito Penal, *Escritos Silva Franco*, 2003, p. 219 e ss.

([28]) FRANK, § 43, II, 2 b).

([29]) Sobretudo por força da jurisprudência alemã: cf., em síntese, ROXIN II, § 29, n.º 122.

([30]) Assim, de forma especialmente clara, S / S / ESER, § 22, n.º 42 e ss.

casos concretos duvidosos de qualificação de um acto como de execução; e à segunda que, para além de realização típica não ser a mesma coisa que violação do bem jurídico e de o critério ser inaplicável relativamente à tentativa de crimes de perigo, concreto ou abstracto ([31]), tudo dependerá (porque também actos preparatórios podem já dar início à colocação em perigo do bem jurídico) da *medida da perigosidade e da imediação* do acto, cuja determinação passa completamente ao lado da teoria em exame ([32]).

§ 19 Por mais criticável que possa ser, em cada uma das alternativas, a fórmula referida, ela oferece no entanto o caminho mais seguro e exacto de concretização da linha separadora de actos preparatórios e de execução. Se retirarmos à fórmula de Frank uma certa conotação naturalística — a reivindicada "consideração natural" — e a substituirmos por uma conotação de **normalidade social**, que ela pode perfeitamente comportar; e se, por outro lado, acentuarmos que o perigo para o bem jurídico não tem de ser apenas "imediato", ou "iminente", ou "próximo", mas tem de ser também um **perigo típico**, concretamente referido ao *tipo* ou à *realização típica* — teremos logrado, em nossa opinião, um poderoso critério de delimitação à luz das teorias formais objectivas ([33]). Um critério este, de resto, que fica próximo — ao mesmo tempo que esclarece e justificadamente limita — a ideia de Eduardo Correia de chamar aqui a debate o pensamento da *adequação* (*rectior*, da *adequação típica*) para determinar a tipicidade do acto de execução ([34]). As doutrinas materiais objectivas revelam assim o caminho correcto da distinção. Mas só o "caminho": a resolução de casos concretos de difícil e controvertida distinção — mesmo os aparentemente mais simples — exigem ainda novas concretizações (infra, § 23 e ss.).

([31]) Por último, ROXIN II, § 29, n.º 129.

([32]) Assim já, v. HIPPEL, II, p. 399 e s., e, agora, RUDOLPHI, *SK*, § 22, n.º 10, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 32 e s.

([33]) Deste modo ganhando plena justificação a exigência, paradigmaticamente formulada na *Relazione* emanada da *Comissione ministeriale per la Riforma del Codice penale*, instituída em Itália em 1998, segundo a qual só deste modo o critério de distinção entre preparação e execução ganhará a capacidade "de retirar, por assim dizer, a tipicidade da tentativa da tipicidade da fatispécie de referência e de impedir uma antecipação excessiva do início da actividade punível": *Progetto preliminare di riforma del Codice penale, Parte Generale*, 2000, *Relazione* B, 2.5.3. E também DIAS, Figueiredo, nota 27, p. 221.

([34]) Cf. CORREIA, Eduardo, II, p. 228 e ss., e também FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, p. 525 e ss.

2.3. As teorias subjectivas

§ 20 Apesar do que ficou dito, uma correcta qualificação de certos actos concretos como preparatórios ou de execução não pode prescindir completamente do apelo a *momentos subjectivos*. Isto implica que se não omita de todo uma referência às teorias subjectivas, segundo as quais a fronteira entre actos preparatórios e actos de execução deveria procurar-se e encontrar-se com apelo à **qualidade ou intensidade da vontade** documentada no acto dirigido à realização do crime ([35]). Erigidas em *critério* da distinção, porém, estas teorias têm de ser **recusadas**. Logo porque, já o dissemos (supra, § 5), é indispensável, já na definição da tentativa, que ao lado da decisão se coloque um momento objectivamente estruturado; sob pena, de outro modo, de o próprio princípio da tipicidade ser posto inapelavelmente em causa.

§ 21 Mas as teorias subjectivas não podem sequer arvorar-se em **complemento** — ou mesmo, como pretende Stratenwerth, em **ponto de partida** ([36]) — da qualificação de um acto como de execução. Nada adianta aqui em concreção o critério subjectivo agora usado pela jurisprudência alemã de fazer coincidir o início da tentativa com o momento em que o agente pensa: "jetzt geht es los" (e que poderia porventura traduzir-se correctamente pelo: "agora, *alia jacta est*"): uma coisa — em último termo relevante — é o plano do agente, outra — irrelevante — a sua avaliação pessoal do decurso do acontecimento. Bockelmann, um dos mais declarados defensores das teorias subjectivas, pretende por seu turno que o facto entra no estádio da tentativa quando "o dolo do crime passou já a prova de fogo da 'situação crítica'" ([37]). O que seja esta situação crítica é, no entanto, coisa que, como bem assinala Stratenwerth, se tem de determinar de acordo com os critérios das teorias objectivas ([38]). É noutra acepção pois que o apelo a momentos subjectivos desempenha, na verdade, um papel relevante no problema da distinção que procuramos analisar ([39]). No sentido de que, relativamente a muitos actos concretos,

---

([35]) Assim já, entre nós, SANTOS, Beleza dos, Crimes de moeda falsa, *RLJ* 66, p. 194 e ss.

([36]) STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 36.

([37]) BOCKELMANN, *Strafrechtliche Untersuchungen*, 1957, p. 176.

([38]) STRATENWERTH, § 11, n.º 34.

([39]) Posição que, segundo a informação fornecida por alguns AA. (p. ex., FONSECA, Jorge, *Crimes de Empreendimento e Tentativa*, 1986, p. 95 e s.[178]), terá sido assumida por ROSA,

só poderá determinar-se a sua *referência típica* (que sempre deve ser exigida, como vimos, pelas teorias objectivas) por apelo ao **plano concreto de realização** do agente. Aqui reside, efectivamente, o significado que um momento subjectivo — o plano de realização do agente — assume para as teorias objectivas ([40]); e que justifica a afirmação (como ensinava já há muito Cavaleiro de Ferreira) de que "os mesmos actos podem ser preparatórios, quando a intenção é dirigida a determinado crime, e deverão já constituir actos executivos, quando a intenção seja dirigida a outro crime" ([41]).

§ 22 **Exemplos**: Se *C*, que tenciona envenenar o marido, *D*, confecciona um bolo ao qual adiciona uma substância venenosa, o acto será de execução se ela espera que o marido se servirá ele mesmo; mas constitui simples acto preparatório se guarda o bolo para à sobremesa da refeição seguinte o servir ao marido. Se este, chegando a casa, descobre por si mesmo o bolo e se serve, o facto só poderá ser imputado à mulher a título de negligência. Isto revela como, em definitivo, o recurso ao plano concreto de realização do agente constitui afinal um momento relevante para a distinção. Igualmente interessante para o ponto em apreço é o caso (julgado recentemente nos tribunais alemães ([42])) de um homem, *E*, que queria penetrar na casa de uma mulher, *F*, por um postigo do telhado, propondo-se violá-la sexualmente — como já havia feito anteriormente — e em seguida subtrair-lhe dinheiro. Não conseguiu todavia arrombar o postigo porque este havia sido reforçado com varas metálicas e veio a ser detido. Só o recurso ao plano do agente permite qualificar o seu acto como preparatório ou de execução relativamente aos crimes de furto qualificado e (ou) de violação sexual (infra, § 34).

2.4. Um ensaio de concretização jurídico-positiva

§ 23 As considerações anteriores permitem retirar algumas conclusões e alcançar certas concretizações em matéria de critérios de distinção entre preparação e tentativa. A primeira e mais segura conclusão assume, todavia, **carácter negativo** e algo desanimador. Se todas as fórmulas referenciadas apresentam sem dúvida interesse e valor para a distinção, será em definitivo infundado pensar que com elas ou através das suas inumerá-

---

Cortes, em conferência não publicada, intitulada "A tentativa no novo Código Penal português", 1984.

([40]) Contra a aceitação de momentos subjectivos na determinação dos actos de execução, mesmo sob a forma mínima referida em texto, CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 28 e s.

([41]) FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, p. 525.

([42]) BGH, *NStZ*, 2000, p. 418.

veis combinações possíveis se conseguirá traçar, em termos absolutamente precisos e definitiva, a fronteira que separa actos preparatórios de actos de execução. Esta é uma conclusão que tem tanto de verdadeira, como de antiga já (43), mas que persiste na actualidade (44). Quando assim sucede na dogmática jurídico-penal, torna-se indispensável a elaboração de uma *casuística* tão larga mas escolhida quanto possível (casuística *tipológica* ou *de grupos*), para, na sua base, formular critérios de valor funcional-teleologicamente orientados cada vez mais afinados e que sirvam de "princípios" ou de "tópicos" da concreta decisão a tomar (45). Esta no entanto não pode ser tarefa de uma exposição sistemática como a presente.

§ 24 A segunda conclusão é a de que a distinção cuja concretização se procura há-de ser eminentemente **objectiva**. Pressuposta a (sempre) necessária decisão de cometer o facto, a caracterização do acto só pode ser objectiva — embora na base do "plano do agente" —, enquanto critérios subjectivos relacionados com as características da vontade surgem como irrelevantes. Ora — e com isto nos aproximamos definitivamente do nosso direito positivo legislado —, o art. 22.º-2 (correspondente, no essencial, ao art. 22.º do ProjPG de Eduardo Correia e por inteiro subsidiário da exposição doutrinal deste A. (46)) consagra clara e terminantemente as teorias objectivas. O que neste preceito falta é apenas uma referência, que seria devida, ao *momento subjectivo* de apelo ao *plano do agente* nos termos referidos supra, § 21; e que levam Jescheck / Weigend a falar com propriedade, neste sentido, de uma **teoria objectiva individual** (47).

2.4.1. A al. *a)* do art. 22.º-2

§ 25 A al. *a)* do art. 22.º-2 considera como actos de execução, sem tergiversações, "os que preenchem um **elemento constitutivo de um tipo**

---

(43) P. ex., v. HIPPEL, II, p. 400.

(44) Exactamente nestes termos, p. ex., STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 42; cf., também, ROXIN II, § 29, n.º 103 e[113].

(45) A esta conclusão parece conduzir entre nós também a análise — que tem todavia sempre latente a problemática dos crimes de omissão — de BRITO, Teresa Quintela de, nota 8, p. 161 e ss.

(46) CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 23 e ss. Doutrina já no essencial defendida também por FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, p. 523.

(47) JESCHECK / WEIGEND, § 49, IV, 1.

de crime", embora nas alíneas seguintes estenda essa qualificação a outros actos que não assumem aquela característica. Isto significa duas coisas: primeiro, que as **teorias formais objectivas** foram legalmente acolhidas quando formuladas no sentido de que constitui acto de execução *todo aquele* que preenche um elemento típico; segundo, que elas não foram recebidas quando entendidas no sentido de que são actos de execução *apenas* aqueles que preencham o teor formal (parcial) de um tipo de ilícito. A partir daqui e quanto a este ponto tudo dependerá pois de uma interpretação devida do elemento em causa no contexto da realização típica integral, com eventual recurso ao plano do agente para iluminar (e só para isso!) a verdadeira natureza do acto praticado.

2.4.2. A al. *b)* do art. 22.º-2

§ 26 Tal não é condição indispensável, porém, de caracterização de um acto como de execução. Tanto fosse sempre necessário e a exigência político-criminal de punibilidade da tentativa em nome da dignidade penal do facto ficaria em causa. A um **alargamento** do círculo dos actos de execução veio pois proceder a al. *b)* do art. 22.º-2. Como ponto de partida da sua hermenêutica, porém, não parece poder ir-se além da ideia de que ela se limita a conter a doutrina correspondente à da al. *a)* sempre que se trata de **crime de execução não vinculada** e, muito especialmente, quando a descrição típica se limita ao uso de uma palavra (em regra, um verbo) através do qual se designa a acção que provoca o resultado típico. Assim, se, no caso do art. 131.º, *G* dispara um revolver carregado sobre *H*, com dolo de matar, trata-se ali seguramente de um acto de execução, apesar de tal acto não preencher — segundo as palavras e o seu sentido — "um elemento constitutivo" do tipo de homicídio. O significado útil deste preceito é pois o de **equiparar** aos actos típicos (parciais) previstos na al. *a)* todos aqueles que são idóneos — isto é, **adequados** ([48]), segundo os conhecidos termos da doutrina da adequação, nomeadamente de acordo com um juízo *ex ante*, de prognose póstuma — a produzir o resultado típico. Impor-se-á no entanto fazer intervir aqui algumas precisões.

§ 27 A primeira é a de que, tratando-se de crimes não "de resultado", mas de *mera actividade*, à idoneidade para "produzir o resultado" típico

([48]) Assim, também, FONSECA, Jorge, nota 39, p. 94 e s.

deverá equivaler a **idoneidade para integral realização do tipo**. Se alguém começa a cortar com uma serra metálica as grades da cela em que se encontra preso, trata-se aqui seguramente de um acto idóneo da realização do tipo de evasão (art. 352.º) e, por isso e sem mais, de um acto de execução. Esta interpretação, para além de teleologicamente imposta, é jurídico-constitucionalmente legítima, tratando-se nela apenas de um caso mais em que a palavra "resultado" foi tomada pelo legislador na acepção de intranquilidade do bem jurídico protegido (supra, 11.º Cap., §§ 10 e 40).

§ 28 A segunda precisão a enunciar é a de que o preceito em exame, se considerado só em si mesmo e não em conexão com a al. *c)*, vai inadmissivelmente **longe demais**, reputando como de execução, segundo a sua letra, actos que seguramente ainda não ultrapassaram a fase preparatória (49). Correndo-se deste modo o risco de aplicar a al. *b)* contra a teleologia específica das doutrinas que estão na sua base — as doutrinas materiais objectivas —, fundadas na *imediação, iminência* ou *estreita proximidade do perigo típico* representada pelo acto praticado; dito de outro ponto de vista igualmente essencial, correndo-se assim o perigo de considerar como de execução **actos que não penetraram ainda no âmbito de protecção típica da norma incriminatória** (50). E aqui continua a residir, no nosso modo de ver, o elemento decisivo da caracterização de um acto como de execução. Figuremos o seguinte caso: *I* falsifica um documento, idóneo (mesmo segundo os pressupostos mais exigentes do juízo de prognose póstuma) a criar em *J* um engano determinante de um prejuízo patrimonial. Antes de poder fazer uso dela, porém, o documento é apreendido pela polícia. Cabendo embora completamente no teor literal da al. *b)* em exame, a falsificação levada a cabo por *I* constitui indubitavelmente — atentas as razões por último referidas no parágrafo anterior — um acto *preparatório*, não um acto de execução do crime de burla.

§ 29 Inversamente, porém, é pouco menos que indiscutível que, na determinação do que sejam actos de execução, a lei não pode bastar-se ainda

---

(49) Neste sentido, também, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 409 s., e, ao que informa FONSECA, Jorge, nota 39, também Cortes Rosa.

(50) A menos, é claro, que se interprete a exigida "idoneidade" — como se tornou corrente na doutrina italiana e mesmo numa certa doutrina alemã, decerto sob a influência da fórmula de Frank — no sentido de "referência ao perigo ínsito no acto": cf. *Relazione*, nota 33, B, 2.5.3.

com o disposto nas als. *a)* e *b)* do art. 22.º-2. Pode fundadamente duvidar-se, efectivamente, que só o acto idóneo típico parcial ou o acto idóneo a produzir o resultado devam considerar-se de execução, enquanto quaisquer actos **antecedentes** seriam meramente preparatórios apesar de eles, segundo a sua idoneidade própria e a normalidade do acontecer social, já acarretarem um perigo típico iminente de lesão do bem jurídico ou de completa realização típica. Consideremos o caso seguinte: *L* decide matar *M*, com a qual mantém uma relação amorosa à qual deseja pôr fim. Dispondo de licença de porte de arma, dirige-se a um armeiro onde compra um revolver e as balas respectivas, com as quais logo o carrega. Em seguida toma um táxi que o transporta à casa de *M*. Lá chegado, toca à campainha, tendo a porta sido aberta por *M*. Aos gritos de "vou finalmente ver-me livre de ti", *L* saca o revolver do bolso, aponta ao coração de *M*. Preme o gatilho, mas a arma encrava, sendo imediatamente detido pela polícia. Ora, nos termos da al. *b)*, acto "idóneo a produzir o resultado típico" é unicamente o acto de premir o gatilho. Mas será então que todos os actos anteriores devem considerar-se meramente preparatórios, nomeadamente, quando a porta de casa é aberta pela vítima, o agente saca da arma e aponta ao coração daquela? Responder afirmativamente revelaria, em nosso juízo, a mais patente infidelidade à fórmula de Frank e à essência das teorias materiais objectivas. Mas é igualmente verdade que a análise tem de ser ainda levada mais fundo para, num processo continuado como o descrito, se determinar com um mínimo de clareza e segurança o que só é preparação e o que já é tentativa.

2.4.3. A al. *c)* do art. 22.º-2

§ 30 Para colmatar a lacuna aqui ainda subsistente criou o legislador a al. *c)* do art. 22.º-2, segundo a qual são ainda actos de execução "os que, segundo a experiência comum e salvo circunstâncias imprevisíveis, forem de natureza a fazer esperar que se lhes sigam actos das espécies indicadas nas alíneas anteriores", isto é, actos que integrem um elemento típico ou sejam idóneos a produzir o resultado típico. Na interpretação do sentido e âmbito de aplicação deste preceito, porém, pouca coisa poderá à partida tomar-se por seguro. Seguro é, decerto, que para ela são ainda carreados elementos característicos da **doutrina da adequação**, como amplamente o revela o apelo à "experiência comum", às "circunstâncias imprevisíveis", à "natureza a fazer esperar...". Mas tudo o resto é duvidoso. Se pretender avaliar-se da adequação de cada acto em função do acto

seguinte, e deste em função do seguinte, etc., até ao acto imediatamente determinante da produção do resultado ou da realização típica integral, então verdadeiramente, uma vez mais, seriam tidos como de execução actos relativamente aos quais não pode de modo algum ser afirmado que acarretam um **perigo típico iminente** de produção do resultado ou de realização típica integral. Casos como o da falsificação de escrito destinada a ser *usada* mais tarde numa burla (supra, § 28) ou da compra da arma ou da tomada do táxi para casa da planeada vítima de homicídio (supra, § 29) mostram claramente a justeza da crítica a esta interpretação. A qual só se agravaria, até limites insuportáveis, se quisesse neste contexto (o que constituiria erro inescusável) fundar a idoneidade de cada acto singular na base do apelo ao plano do agente.

§ 31 Parece ficar assim só em aberto a solução inversa: a de se conferir relevo como de execução apenas ao acto que (assumindo as exigências de "normalidade social" requeridas pela alínea em exame) **antecede imediatamente**, sem solução de continuidade *substancial* e *temporal*, o acto cabido nas als. *a)* ou *b)*. E cremos que aqui reside verdadeiramente a concepção capaz de oferecer critérios praticáveis e minimamente seguros de distinção, e, além disso, válidos à luz da essência das doutrinas materiais objectivas que aqui se procura concretizar ([51]). No entanto, alguns aprofundamentos e afinamentos julgamos ainda possíveis e desejáveis. Eles ocorrerão numa linha que consideramos próxima da "*doutrina do último acto parcelar*" (embora não de todo com ela coincidente) que progressivamente parece impor-se na doutrina alemã mais recente. E que, de forma convincente, Roxin expõe, na sua última tomada de posição na matéria, em função de dois critérios concretizadores *cumulativos*: o da *conexão temporal estreita* e o da *actuação sobre a esfera da vítima ou do tipo* ([52]). Por nossa parte, e antecipando desde já os traços essenciais da concretização que em seguida ensaiaremos, falaremos, para correcta interpretação da al. *c)* do art. 22.º, da exigência **cumulativa** de uma dupla conexão: de uma *conexão de perigo* e de uma *conexão típica*; ou, se preferirmos — o que é o mesmo, mas dá melhor a compreender a íntima relação que deve ser exigida entre as duas conexões, o seu carácter cumulativo, bem como ainda o seu estreito

([51]) Nestes precisos termos o art. 43.º-1 do *Progetto di Codice penale italiano*, nota 33: "actos imediatamente antecedentes". E sobre a justificação cf. a respectiva *Relazione*, B, 2.5.3.

([52]) Cf. a sua amplíssima exposição e debate em ROXIN II, § 29, n.ºs 139-179.

parentesco com a ideia para nós essencial das teorias materiais objectivas — de uma **conexão de perigo típico**.

2.4.4. Critérios concretizadores

§ 32 **Conexão de perigo** existe sempre que entre o último acto parcial questionado e a realização típica se verifica, segundo o lapso *temporal* mas também de acordo com o *sentido*, uma relação de **iminente implicação**: é esta que faz nascer a conexão de perigo que temos em mente. Relevantíssima é pois a "conexão temporal estreita" de que fala Roxin (e que, de algum modo, é entre nós sublinhada pela exigência de que aos actos questionados "se lhes *sigam* actos das espécies indicadas", constante da al. *c)*), sem que, todavia, ela seja em último termo decisiva. Uma parte da doutrina alemã, aliás, quer aqui *alargar* esta conexão, defendendo que ela existe ainda quando entre o último acto parcial e a realização do tipo se interpõe um ou mais actos que, sendo intercalares, não são todavia, *essenciais* — talvez pudesse dizer-se, do ponto de vista da lei portuguesa: não são idóneos ou de natureza a fazer esperar que se lhes sigam actos idóneos — à realização típica ([53]). Mas por esta via é-se de novo conduzido a soluções menos correctas. Com efeito, ela deveria levar, no exemplo do § 29, a considerar como de execução o acto de *L* de encher o carregador do revolver quando este foi comprado ou o de se dirigir de táxi a casa de *M*: tais actos em si mesmo considerados, apesar de "essenciais", não revelam ainda objectivamente, por falta de iminente implicação, o potencial de perigo exigido pela realização típica e não devem por isso ser considerados como actos de execução. Inversamente, se *N* penetra sem autorização num automóvel de *O* e se senta ao volante, tendo todavia de esperar algum tempo, impossível de determinar *a priori*, até que a rua fique deserta ([54]), para poder então fazer tranquilamente a ligação directa necessária à deslocação do veículo ou o empacotamento dos utensílios que do automóvel pretende subtrair, pratica já um acto de execução do furto de veículo ou dos objectos que nele se encontram.

§ 33 **Conexão típica** existe quando o acto penetra já no âmbito de protecção do tipo de crime: só neste momento e nestas condições está

([53]) KÜHL, § 15, n.º 60. Criticamente, ROXIN II, § 29, n.º 137.

([54]) Ao que parece, ROXIN II, § 29, n.º 146 e s., advogaria aqui o carácter preparatório do acto "por ser indeterminado o tempo que levaria" a rua a ficar deserta.

inclusivamente legitimada a intervenção do direito penal à luz da sua função única de instrumento de tutela subsidiária de bens jurídicos. Esta intervenção verificar-se-á — há que concordar com Roxin — sempre que o acto se intrometa na esfera da *vítima*; isto é só porém sinal de intromissão no âmbito de protecção do tipo quando este tutela bens jurídicos individuais ou de titularidade supra-individual individualizada (*v. g.*, o Estado ou uma comunidade local); podendo tal todavia não suceder — em particular, nos tipos que protegem bens verdadeiramente *colectivos* —, melhor será fazer apelo, de forma abrangente, ao âmbito de protecção do tipo e chamar a esta conexão "conexão típica". **Acrescendo** esta conexão à conexão de perigo estão preenchidas todas as condições para que possa afirmar-se que se está perante um acto de execução. Casos como o de *M* quando abre a porta de sua casa ao amante (supra, § 29) ou o de *N* quando penetra no automóvel de *O* (supra, § 32) são hipóteses em que estão presentes as duas conexões e se apresentam por isso indubitavelmente como actos de execução. A dupla exigência pode conduzir, de resto, a que o mesmo acto deva ser considerado como acto preparatório de um crime e como acto de execução de outro, ainda quando a prática de ambos se contivesse no plano do agente.

§ 34 No caso referido supra, § 22, de *E* que pretende penetrar na habitação de *F* para a violar e em seguida lhe furtar o dinheiro, tanto o Tribunal Federal alemão como Roxin concluem que no caso existe apenas tentativa de furto qualificado (art. 204.º-2/*e*)) mas não de violação sexual (art. 164.º). E isto, segundo Roxin, porque relativamente ao furto se verifica estreita conexão temporal e perturbação da esfera patrimonial da vítima, enquanto relativamente à violação a esfera de protecção corporal e sexual da vítima não chegou a ser perturbada. Se esta última solução corresponde inteiramente aos critérios aqui defendidos, já a fundamentação da primeira parece pelo menos duvidosa, porque a tentativa de penetração em casa alheia não parece apresentar ainda uma conexão típica com o crime de furto (outra coisa se dirá relativamente ao crime de dano do art. 212.º ou ao de violação do domicílio do art. 190.º). A ser assim, a solução que nos parece mais correcta seria a de considerar os actos praticados como **preparatórios** tanto do crime de violação, como de furto qualificado.

§ 35 Uma hipótese a que a doutrina vem dedicando atenção particular é a do início da tentativa relativamente a um **tipo qualificado**. Até há pouco tempo era opinião dominante que a existência de um acto que devesse considerar-se como de **execução de um elemento qualificador** bastaria para considerar iniciada a tentativa do tipo qualificado. Hoje, porém, a doutrina dominante reconhece que assim não deve ser, como tão-pouco

quando um acto possa considerar-se de execução relativamente ao tipo fundamental (sobre estas noções supra, 11.º Cap., § 52 e s.): a tentativa inicia-se apenas quando se verifiquem actos de execução do **ilícito-típico conjunto** (55). De exigir, por conseguinte, é a verificação de actos de *execução da qualificação* se esta se segue ao início da execução do tipo fundamental, como pode acontecer com o homicídio ou as ofensas à integridade física qualificadas por tortura ou actos de crueldade segundo os arts. 132.º-2 e 146.º; e de actos de *execução do tipo fundamental* se a qualificação já preexistir, *v. g.*, arts. 204.º-2/*e)* ou 214.º-1, tratando-se neste último caso da ameaça que precede a danificação.

§ 36 Roxin aponta como **particularmente difíceis**, em tema de distinção de preparação e tentativa, grupos de casos frequentes como os de *proximidade* do agente relativamente ao lugar do facto, *vistoria* desse lugar ou *espera* da vítima, comprovação das *condições de possibilidade* do facto, eliminação ou perturbação da *especial protecção* de que a vítima rodeou a sua esfera (56). Cremos que todos estes casos — reconhecida embora a sua dificuldade — podem e devem ser resolvidos com apelo à "conexão de perigo típica" atrás desenhada. Se *P* se dirige com a pistola carregada a *Q* para o matar, mesmo que antes de disparar tenha ainda de percorrer certa distância; se a parteira *R*, pronta a praticar uma interrupção consentida mas ilícita de uma gravidez, procede a um exame destinado a determinar se o aborto pode ser levado a cabo em seguida sem fazer incorrer a grávida em riscos especiais; se *S* penetra num armazém para furtar mas, começando o cão de guarda a ladrar, o leva para fora do armazém, não podendo no entanto já a este voltar porque o cão o abocanhou — em todos estes casos fica próxima a afirmação da existência de uma tentativa. Mas já não se *T* entra num supermercado com intenção de aí furtar algumas mercadorias, se *U* se posta num local onde espera que passe a vítima, mas esta não surge, se, no caso do § 29, *L* compra a arma no propósito de com ela vir a praticar o homicídio, ou se *V* espia a vítima durante algum tempo para determinar os padrões do seu comportamento diário e oportunamente a matar ou violar.

3. A não-consumação

§ 37 Nos termos do art. 22.º-1 é elemento constitutivo da tentativa que o crime intentado **não chegue a consumar-se**. Isto se afirma sem prejuízo de a "desistência" — figura que se diria co-naturalmente ligada à da tentativa — poder ainda verificar-se relativamente a delitos que, típica ou formalmente, se consumaram já. Desta ques-

(55) Cf. STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 43, e, pela referida doutrina hoje dominante, ROXIN II, § 29, n.º 170 e ss.

(56) ROXIN II, § 29, n.os 145-169, em cuja exposição figuram — por vezes modificados — muitos dos exemplos que se seguem.

tão nos ocuparemos mais à frente (29.º Cap., § 29 e ss.). No presente contexto há que reafirmar a (quase) evidência de que, referindo-se a tentativa ao tipo, ela cessa no momento preciso em que se verifica a consumação típica ou "formal" (supra, 27.º Cap., § 11 e s.).

III. Tentativa, tentativa acabada e frustração

§ 38 Como se viu, a prática de *um único* acto de execução, dentre os vários que podem constituir o *iter criminis*, é bastante para configurar a tentativa. Todavia, desde sempre se reconheceu a possibilidade — eventualmente, a necessidade — de distinguir aquelas hipóteses em que o agente **não chega a praticar todos os actos de execução que seriam indispensáveis à consumação**, daquelas outras em que o agente **pratica a totalidade daqueles actos e todavia a consumação não vem a ter lugar**. As doutrinas da família germânica falam a este respeito preferentemente de *tentativa inacabada* e de *tentativa acabada*, enquanto as da família latina desde muito cedo distinguiram o *delito tentado* do *delito frustrado*, em fórmula curta, a **tentativa** (propriamente dita) da **frustração**. O interesse fundamental da distinção reside na matéria relativa à possibilidade e aos requisitos da *desistência* num caso e noutro (infra, 29.º Cap., § 11 e ss.). Mas não faltaram direitos (entre os quais o nosso na vigência do CP de 1886: arts. 10.º e s. e 104.º e s.) que levaram a distinção até ao ponto de autonomizar expressamente as duas figuras para efeito de submeter cada uma delas a uma *punição diferente*.

§ 39 O CP vigente não fala expressamente nem de tentativa inacabada, nem de tentativa acabada ou de frustração e submete um e outro caso, por conseguinte, à **mesma moldura penal**. Isso não significa, porém, que a distinção tenha perdido interesse ([57]): para além do mais, ela está, como se referiu, subjacente desde logo, de modo fundamental, ao regime da desistência. Tratando-se de um espaço livre de legislação e uma vez que a frustração não assume hoje qualquer relevo na determinação da mol-

([57]) Se bem que não falte quem considere que o interesse da distinção tem sido e continua a ser doutrinalmente exagerado, casos havendo mesmo — porque a distinção depende, em último termo, da *representação do agente* — em que uma tentativa acabada pode *a posteriori* converter-se em tentativa inacabada: GOMES, Júlio, nota 18, n.º 26 e ss., e (mais moderadamente) PINTO, Costa, *A Relevância da Desistência em Situações de Comparticipação*, 1992, p. 222 e ss.

dura penal aplicável, é em larga medida indiferente que se fale de *tentativa inacabada* ou antes de *tentativa frustrada* ou *frustração*. Problema ([58]) é saber qual o ponto de vista decisivo para determinar se a tentativa pode já considerar-se acabada, se o ponto de vista *subjectivo*, se o ponto de vista *objectivo*; e, neste último caso, se decisiva é a *realidade* do acontecer ou antes a sua *normalidade* segundo as regras da experiência e do *id quod plerumque accidit*. Deste problema se tratará em sede de desistência (infra, 29.º Cap., § 11 e ss.).

§ 40 Desde há muito tempo ([59]) defende Roxin que a questão do **início da tentativa** se deve colocar de forma diferente relativamente à tentativa inacabada (cuja solução se encontraria na linha da análise anterior) e à tentativa **acabada** (onde a questão apresentaria, como também assinala a jurisprudência alemã, uma "estrutura aparentada" com a do início da tentativa na *autoria mediata*, quando o instrumento é constituído pela própria vítima — infra, 31.º Cap., § 83 e s. — e, em consequência, esta se verificaria quando o facto "sai do âmbito de domínio" do agente ou quando se verifica já um "perigo imediato" para a vítima ([60]). Não nos parece, porém, que se torne em definitivo necessário, na tentativa acabada, modificar no que seja os critérios que propusemos para interpretação do art. 22.º-2 e, nomeadamente, a fórmula da "conexão de perigo típica", tendo evidentemente em conta (como é sempre indispensável) as concretas circunstâncias do caso de tentativa acabada em exame.

IV. A delimitação da tentativa punível

§ 41 Largo consenso legislativo e doutrinal existe sobre que **nem todo o ilícito da tentativa**, conceitualizada nos termos anteriormente descritos, **revela suficiente dignidade punitiva**. Por isso o art. 23.º delimita o âmbito da tentativa punível (e os termos da sua punição) em função de dois critérios: um, atinente à *pena aplicável* ao respectivo delito consumado (art. 23.º-1); outro, conexionado com a *seriedade* do ataque à ordem jurídica que a tentativa em concreto representa.

1. Em função da pena aplicável ao crime consumado

§ 42 Por definição, como se viu, a tentativa não pode conter mais que *uma parte do ilícito* do crime respectivo consumado: o desvalor de acção

([58]) Sobre ele, logo, CORREIA, Eduardo, *Studium*, pp. 34 e ss., 54.
([59]) ROXIN, Der Anfang des beendeten Versuchs, *Maurach-FS*, 1972, p. 213.
([60]) ROXIN II, § 29, n.os 192-225.

pode ser o mesmo num caso e noutro, porém, **o desvalor do resultado será sempre menor** na tentativa. Daí a existência de regras especiais quanto à punição desta.

§ 43 Nos termos do art. 23.º-1, em princípio, só é punível a tentativa nos casos em que ao crime consumado corresponda **pena superior a 3 anos de prisão**; quando tal não suceda a tentativa só será punível **se a lei expressamente o declarar**. Com isto torna-se claro ter sido intenção político-criminal do legislador restringir a punição da tentativa, por via de princípio, aos casos criminologicamente chamados da *grande* e da *média* criminalidade ([61]); o que se justifica precisamente em função da *menor gravidade* que a lei adscreve ao delito tentado face ao delito consumado. Questão é saber se, relativamente à tentativa de **delitos qualificados**, a pena aplicável a que a lei se refere é a do delito simples ou a do delito qualificado consumados: a resposta só pode ser a segunda, a do delito qualificado; e isto, na verdade, quer a qualificação opere no plano do ilícito (*v. g.*, art. 204.º), quer no da culpa (*v. g.*, art. 132.º). Ponto é que, evidentemente, a tentativa já revele (e não só a nível do plano concreto de realização do agente, mas também do significado objectivo dos actos de execução levados a cabo) a sua referência indubitável ao delito qualificado (supra, § 35).

§ 44 Sendo punível a tentativa, a pena que lhe cabe é, nos termos do art. 23.º-2, "a pena aplicável ao crime consumado, **especialmente atenuada**". Deparamos aqui, por conseguinte — diversamente do que Eduardo Correia propunha no art. 26.º do seu ProjPG —, com uma atenuação especial da pena (art. 73.º) **obrigatória**. A favor da atenuação facultativa invoca-se a maior liberdade que terá o juiz de adequar a pena à culpa, deixando de atender a circunstâncias que obstaram à consumação mas que, as mais das vezes, residem na pura casualidade; como se invoca que a atenuação estará justificada sempre em termos de atenuação geral, enquanto em muitas hipóteses uma atenuação *especial* pode revelar-se desajustada. Estas alegações podem ser, ao menos em parte, justificadas ([62]). Mas o não ter o legislador deixado convencer-se por elas — como o mostra a alteração da concepção que presidia ao referido

([61]) Cf. o nosso *DP II*, § 106.

([62]) Sobre elas, por último, STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 47 e ss.

art. 26.º do ProjPG — só revela o particular peso que ele entendeu conceder, na concepção básica da tentativa, ao significado do **perigo** para os bens jurídicos e à **diminuição do desvalor de resultado**; e, em nossa opinião, só confirma ver-se numa *teoria da impressão* — mais correctamente, por razões que agora já se terão tornado claras, numa **teoria da impressão de perigo típica** — o fundamento da punibilidade de toda a tentativa.

2. A chamada "tentativa impossível" ou "inidónea"

§ 45 De acordo com o disposto no art. 23.º-3, "a tentativa **[só]** não é punível quando for **manifesta** a inaptidão do meio empregado pelo agente ou a inexistência do objecto essencial à consumação do crime". À tentativa levada a cabo com meios inaptos ou sobre objecto essencial inexistente dá a doutrina o nome de *tentativa impossível* ou *tentativa inidónea* (63). Como indiscutivelmente resulta do preceito citado, a nossa lei **equipara em geral e em princípio** a tentativa inidónea à tentativa idónea: salvo quando a inaptidão dos meios ou a carência do objecto sejam manifestos, **a tentativa continua a ser punível apesar de a realização do facto estar irremediavelmente destinada a não se consumar**. Como **exemplos** de escola das situações referidas se podem considerar a tentativa de abortar com a ingestão de um comprimido de paracetamol ou com irrigações vaginais de água com sabão (meios inidóneos), ou o caso de *A* colocar veneno mortal numa bebida que vai servir a *B* mas, por troca das garrafas, acabar por servir a *B* uma bebida absolutamente inócua; ou a tentativa de *C* matar *D* que todavia acabou de falecer ou de *E* matar um animal que erroneamente tomou pelo seu inimigo *F* (inexistência do objecto); ou ainda o caso de *G* tentar abortar por ingestão de comprimidos de paracetamol quando, na verdade, nem sequer está grávida (meios inidóneos *e* objecto inexistente). A opção pela punibilidade de princípio destas situações suscita de novo toda a problemática do fundamento da punibilidade da tentativa como um todo, baseia-se em concepções político-criminais nem sempre isentas de dúvida e, apesar da aparente clareza do texto legal, levanta problemas dogmáticos de não fácil solução. É toda esta problemática que agora importa analisar.

---

(63) Ou ainda "inútil", "inapropriada", "inapta" (*untaugliche Versuch*, como preferentemente se exprime a doutrina germânica).

2.1. A punibilidade da tentativa impossível e a questão geral do fundamento de punibilidade da tentativa como um todo

§ 46 As **teorias puramente objectivas** encontram-se seguramente em difícil situação perante o fenómeno da tentativa impossível: se a tentativa deve ser punida porque e quando perigosa, então, *logo à partida*, não pode deixar de considerar-se que toda e qualquer tentativa impossível é insusceptível de pôr *realmente* em perigo o bem jurídico protegido; sem que possa atribuir-se valor para traçar de forma conveniente a fronteira entre tentativa impossível punível e não punível à distinção entre a tentativa *absolutamente impossível* — que nunca poderá conduzir à consumação — e a tentativa só *relativamente impossível*, aquela que, no dizer já de Feuerbach, "só por acaso falha" (64). Por ser assim é que alguns ordenamentos jurídico-penais, levando até às últimas consequências a ideia da função exclusivamente tutelar de bens jurídicos ou da ofensividade, **recusam em princípio a punibilidade de qualquer tentativa impossível**. Esse é o caso, entre outros, do CP espanhol de 1995 (art. 16.º-1) (65).

§ 47 Foi, de resto, perante dificuldades deste teor que soçobrou a doutrina da chamada **"tipicidade defeituosa"** ou da "falha no tipo" (*Mangel am Tatbestand*). Para esta teoria a tentativa impossível não seria punível sempre que faltasse *à partida* uma circunstância pertencente ao tipo, p. ex., quando alguém danifica uma coisa sua na convicção de que se trata de coisa alheia (art. 212.º), ou dispara um tiro no coração de alguém que julga ainda vivo quando, na verdade, se trata já de um cadáver (art. 131.º) (66). Mas a fronteira de punibilidade que deste modo se traça entre tentativa impossível punível e não punível é na verdade, como hoje se reconhece de forma praticamente unânime, inaceitável à luz da *perigosidade objectiva* do comportamento que está na base destas teorias.

§ 48 Já as **teorias subjectivas** parecem encontrar-se em excelente posição para defender a punibilidade de *toda* a tentativa impossível, porque nela se revela, em definitivo, um *desvalor de acção* análogo ao que se verifica na tentativa idónea e no próprio crime consumado. Mas tais teorias vão seguramente assim longe demais, ao colocarem como fundamento de punibilidade puros valores de ânimo e abstraírem por completo da ideia do perigo para bens jurídicos protegidos. Em perspectiva político-criminal

---

(64) FEUERBACH, nota 2, p. 43; e. depois, v. HIPPEL, II, p. 417

(65) Sobre o ponto, em síntese, RODRÍGUEZ Mourullo, *in*: Rodriguez Mourullo / Jorge Barreiro, *Comentários al Código Penal*, 1997, pp. 75, 77 e s.

(66) DOHNA, *Der Aufbau der Verbrechenslehre*, ⁴1950, p. 56 e ss.

tratar-se-ia aqui de uma posição de todo insustentável, que conduziria à punibilidade — que a prática totalidade dos ordenamentos jurídico-penais, com evidente razão, pura e simplesmente recusa — mesmo da chamada *tentativa irreal* ou *supersticiosa*, p. ex., (o que é infelizmente ainda um caso real dos nossos dias) a daquele que vai à bruxa para, através de rezas ou de feitiçarias inócuas, determinar a morte do cônjuge.

§ 49 E não ajuda operar, em ordem a alcançar ainda uma fronteira entre a tentativa impossível punida e não punida, com a **irrealidade** do meio ou com a **absoluta** carência de objecto. O juízo sobre elas depende, de novo, não de distinções ao nível do desvalor da acção, mas sim da experiência normal e, portanto, de um critério objectivo que se atém ao carácter *perigoso* da acção. Com o que as dificuldades atrás evidenciadas persistem: porque há-de considerar-se irreal o meio das feitiçarias para lograr um aborto, mas já não, p. ex., o das irrigações vaginais com água de sabão — se tanto um como outro são considerados em definitivo inidóneos (e por isso parificáveis, no que aqui nos interessa) pelos conhecimentos da medicina? Não falta por isso quem, da própria banda das teorias subjectivas, acabe por exigir que a inaptidão do meio ou a carência do objecto *sejam visíveis ou manifestas para toda a pessoa de são entendimento*. E a exigência — ver-se-á — é fundada. Mas fica por perceber como possa uma tal exigência compatibilizar-se com o fundamento de que arrancam as teorias subjectivas.

§ 50 Em plena concordância com o que dissemos sobre o fundamento da tentativa, também em matéria de punibilidade da tentativa impossível a sua delimitação tem basicamente de ser pedida a uma **teoria subjectiva-objectiva da impressão** (ou da "**aparência**") **de perigo**. Ponto de partida será assim o de que, no caso concreto, *a tentativa, apesar de na realidade das coisas estar impossibilitada de produzir o resultado típico, é suficiente para abalar a confiança comunitária na vigência e na validade da norma de comportamento* ([67]). Por esta via se alcançará uma justificação da exigência legal, para impunibilidade da tentativa, de que a inaptidão do meio ou a carência do objecto se revelem como *manifestas*. Uma solução do problema de fronteira da punibilidade da tentativa impossível não pode, na verdade, deixar de continuar a arrancar da ideia "objectiva" da *perigo-*

([67]) Assim, já, entre nós, SANTOS, Beleza dos, nota 35, p. 193, justificando a punibilidade na medida em que a tentativa provoca como "efeito reflexo um sentimento social de intranquilidade". Nestes termos corre a doutrina dominante na Alemanha (cf., só, JESCHECK / WEIGEND, § 50, I, 4 e ss., RUDOLPHI, *SK*, 14 antes do § 22; STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 50 e ss., 57 e ss., S / S / ESER, n.º 23 antes do § 22 e § 22, n.º 65), embora com uma acentuação, ainda mais forte que no texto, do momento subjectivo, derivada porventura das diferenças textuais importantes entre o § 23 III do CP alemão e o nosso art. 23.º-3. Para uma reacentuação do lado objectivo da figura, agora, HIRSCH, Untaugliche Versuch und Tatstrafrecht, *Roxin-FS*, 2001, p. 711.

sidade da tentativa. Só que importa sublinhar uma vez mais que (como desde o início da exposição da matéria da tentativa sublinhámos) sobre a perigosidade decidirá um **juízo ex ante, um juízo de prognose póstuma**, isto é (como sabemos já: supra, 12.° Cap., § 13), um juízo levado a cabo por um observador colocado no momento da execução e sabedor de todas as circunstâncias conhecidas ou cognoscíveis do agente ([68]). Podendo por isso aproveitar-se aqui uma formulação — aceite pelas próprias teorias subjectivas temperadas — segundo a qual a vontade delituosa do agente não conduziria à punibilidade quando a inaptidão do meio ou a carência do objecto fossem *visíveis ou manifestas para a generalidade das pessoas de são entendimento*. Tal decorre por um lado da própria natureza da norma de comportamento, por outro lado, consequentemente, da própria essência do ilícito pessoal. Assim, pois, a tentativa impossível será punível se, razoavelmente, segundo as circunstâncias do caso e **de acordo com um juízo ex ante, ela era ainda aparentemente possível** ou (como prefere exprimir-se o art. 23.°-3) **não era já manifestamente impossível**.

§ 51 Em sentido divergente do do texto, recusando a teoria da impressão como critério de distinção entre tentativa possível e tentativa impossível, considera Fernanda Palma que a delimitação é "relativa", uma vez que "todas [as tentativas] podem a uma certa luz ser impossíveis e todas serão possíveis numa perspectiva de mundo alternativo". O que — acrescenta — pode distinguir-se em relação às várias tentativas é a verificação de **graus de possibilidade**. Ora, só nos casos em que o grau de possibilidade da tentativa constitua uma perturbação do ambiente de segurança de bens jurídicos se justificaria a punibilidade ([69]). Todavia, a nosso ver, continua a faltar aqui um critério susceptível de delimitar que casos são esses em que se verifica um grau de perigo para o bem jurídico capaz de sustentar a punibilidade de uma tentativa impossível. O único critério viável tem de basear-se numa aparência / impressão objectiva de perigo aferida de acordo com um juízo *ex ante*.

2.2. Consequências

2.2.1. A impunibilidade da tentativa dita irreal ou supersticiosa

§ 52 O grupo de casos mais simples e de solução menos controvertida — mesmo por aqueles autores e para aquela jurisprudência que, ainda hoje, pretendem seguir nesta matéria, no essencial, as teorias subjectivas —

([68]) De um "juízo de exterioridade" fala, neste contexto, COSTA, Faria, Formas do crime, *JDC 1983*, p. 164.

([69]) PALMA, Maria Fernanda, *Da "Tentativa Possível" em Direito Penal*, 2006, p. 55 e ss.

é o da tentativa dita irreal ou supersticiosa, isto é, aquela em que o agente tenta alcançar a sua finalidade delituosa através de **meios sobrenaturais** (rezas, feitiçarias, invocação dos deuses ou dos mortos, fórmulas mágicas, etc.). Nestes casos, com efeito, a inaptidão do meio *é* **absolutamente manifesta** e, logo perante o texto do art. 23.º-3, a tentativa não é por conseguinte punível, sem que o apelo às representações do agente possa abalar esta conclusão. E isto se afirma sem deixar de reconhecer que em alguns destes casos pode logo verdadeiramente *faltar o dolo*, nomeadamente quando o autor não revela uma verdadeira vontade de realização, mas apenas um mero desejo, no plano análogo ao do "milagre". Ainda quando o dolo se verifique, porém, não existe em caso de tentativa irreal ou supersticiosa qualquer impressão de perigo e não se verificam, portanto, razões de punibilidade ligadas à confiança nas normas ou fundadas na estabilização contrafáctica das expectativas comunitárias na validade daquelas. Por isso a doutrina vale mesmo perante o caso — muito discutido na doutrina alemã ([70]) — da mulher que se julga grávida em virtude de ter sido longamente beijada pelo seu namorado e, em consequência, pratica em si mesma manobras abortivas com meios para tal adequados: existe de todo o modo, no caso, uma carência de objecto absolutamente manifesta.

§ 53 Não faltou quem pretendesse que a punibilidade da tentativa irreal ou supersticiosa poderia ser aceite quando "se mostra, ainda, que (...o autor...) revela a vontade de **reiterar a sua prática** ou é **criminalmente perigoso**" ([71]). Mas esta punibilidade da pura *perigosidade* do agente não pode aceitar-se nos quadros de um direito penal referido ao facto ([72]). O ilícito seria nesse caso constituído não pelo facto (irreal) tentado, mas pela *personalidade* do autor. Tornar-se-ia então de todo o modo necessário que a vontade ou a perigosidade existentes, e de que o facto seria mero "sintoma", conformassem um concreto tipo de ilícito, sob pena, de outro modo, de ficar em causa o próprio princípio da legalidade. Mas até esse ponto não pode chegar, já o sabemos, um direito penal democrático ([73]).

2.2.2. A *manifesta* inaptidão do meio ou carência do objecto

§ 54 Com o fenómeno da tentativa irreal ou supersticiosa não se esgotam porém os casos em que a inaptidão do meio empregado pelo

---

([70]) Por último, ROXIN II; § 29, n.º 368.

([71]) Precisamente nestes termos o art. 23.º do ProjPG de 1963 de Eduardo Correia, na esteira do E 1962 e da respectiva fundamentação.

([72]) Nestes termos, em análogo contexto, STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 60.

([73]) Criticamente também FONSECA, Jorge, nota 39, p. 96.

agente ou a inexistência do objecto essencial à consumação devam considerar-se *manifestas* para efeito do disposto no art. 23.º-3 e conduzir assim à impunidade da tentativa impossível. Pode acontecer, com efeito, que, segundo o mundo das representações do agente, o meio fosse idóneo ou o objecto existente mas essas representações sejam **claramente erróneas para a generalidade das pessoas** ou, se se preferir, para qualquer pessoa "de são entendimento". Quem tenta matar outra pessoa com uma pistola de imitação que julga verdadeira pode cometer uma tentativa impossível punível se a arma surge à generalidade das pessoas como uma imitação tão perfeita que pode razoavelmente passar por uma arma verdadeira, mas já não se se trata de um brinquedo notoriamente inofensivo (ou se o agente está convencido que pode matar mesmo com uma arma que sabe ser um brinquedo: tentativa irreal ou supersticiosa, supra, § 52). De igual modo comete uma tentativa impossível punível quem depara com um seu inimigo numa estrada no estertor da morte causado por atropelamento de terceiro e logo em seguida passa com o seu automóvel por cima dele, num momento porém em que a morte já ocorreu; mas já não se o corpo é notoriamente um cadáver.

§ 55 Não se trata pois, como sustenta Roxin para o direito alemão, de o erro ser "nomológico", de versar sobre "leis da natureza" (tentativa impossível não punível) ou antes "ontológico", de versar sobre o "substrato" (tentativa impossível punível) (74). Nesta parte são porventura diferentes as concepções da lei portuguesa e alemã: a primeira exigindo que a impossibilidade seja "manifesta" para que a tentativa não seja punível, a segunda que a impossibilidade radique em grosseira incompreensão (*groben Unverstand*) do agente para que o tribunal possa dispensar de pena ou atenuá-la especialmente. O sistema português de punibilidade da tentativa impossível procura não apenas aceitar um critério muito mais acentuadamente **objectivo** que o alemão, como reconduzir mais directamente a punibilidade da tentativa impossível ao fundamento de punibilidade de toda a tentativa (à impressão de perigo típica) e, por essa via, à ideia básica da intervenção do direito penal em nome de uma prevenção geral positiva. Que daqui resultam limitações muito mais fortes da punibilidade da tentativa impossível no direito português do que no alemão parece-nos por um lado evidente, por outro vivamente de saudar em perspectiva político-criminal.

§ 56 Questão é saber se a impossibilidade deve ainda considerar-se manifesta quando as representações do agente, embora contrárias às representações da generalidade das pessoas ou das pessoas de "são entendi-

(74) ROXIN II, § 29, n.º 365.

mento", são ainda **partilhadas pela maioria ou por uma grande parte das pessoas** pertencentes ao círculo local e cultural do agente. Um bom exemplo será o da pessoa que, dedicando-se habitualmente à prática de aborto, dá a uma grávida para tomar certa quantidade de comprimidos de aspirina ou a submete a banhos de mostarda ou irrigações vaginais com água de sabão. Cremos que à questão deve responder-se afirmativamente (75) e concluir-se, assim, pela não punibilidade da tentativa impossível nestes casos, sempre que, segundo o modelo da adequação, o meio seja inidóneo ou o objecto inexistente. Ainda mesmo, por conseguinte, quando através da conduta intentada se aumente em alguma medida — todavia ainda não jurídico-penalmente relevante em termos de imputação objectiva — o risco de produção do resultado (*v. g.*, no caso de há pouco, mandar a grávida ingerir diariamente comprimidos de aspirina).

3. Tentativa impossível e crime putativo

§ 57 Fora do conceito de tentativa impossível e do âmbito do art. 23.º está o chamado crime putativo. A **distinção de princípio entre as duas figuras** é fácil: quem parte *erroneamente*, no seu comportamento, de circunstâncias que, se fossem verdadeiras, preencheriam um tipo de crime, comete uma tentativa impossível; quem, diferentemente, representa correctamente todos os elementos constitutivos do facto mas aceita *erroneamente* que eles integram um tipo de crime comete um crime putativo. Se, pois, *A* pratica actos sexuais consentidos de relevo com uma criança que pensa ter 13 anos, quando na verdade tem 15, comete uma tentativa impossível de abuso sexual de crianças (art. 172.º), punível se a inexistência de objecto não for manifesta. Se *B* sabe muito bem que a criança tem 15 anos, mas pensa que as relações sexuais com ela constituem o crime de abuso sexual de menor, comete um crime putativo. Crimes putativos são também actos de adultério, de homossexualidade ou de incesto como tais, radicados na convicção da existência na ordem jurídica de tipos de crime que, na realidade, não existem. Como ainda hipóteses em que no caso se verifica a existência e/ou a aplicabilidade de uma causa de justificação que, todavia, o agente pensa não existir ou não cobrir a situação em que actua (76).

---

(75) Assim, também, mesmo para o direito alemão, JAKOBS, 25/83.

(76) Sobre estas diferentes categorias, ROXIN II, § 29, n.os 380-387.

§ 58 Diferentemente do que vimos ser o caso da tentativa impossível, segundo uma opinião unânime e, na verdade, indiscutível, **o crime putativo não é punível**. Nem poderia sê-lo porque, de um ponto de vista jurídico-substancial — aqui, mesmo segundo um juízo *ex post*! — faltaria qualquer perigo, ainda o mais remoto, de violação de um bem jurídico-penal susceptível de abalar a confiança da comunidade nas normas jurídicas de tutela (que no caso não existem!); e porque, logo de um ponto de vista jurídico-formal irrenunciável, faltaria na lei tanto a descrição típica do crime consumado respectivo, como qualquer sanção que lhe fosse aplicável: *nullum crimen, nulla pœna sine lege*, não podendo esta exigência ser substituída por uma mera convicção (ou vontade) interior de contrariedade ao direito.

§ 59 No entanto, por vezes torna-se em concreto **duvidosa** a distinção entre tentativa impossível (punível sob certos pressupostos) e crime putativo (não punível). Tal sucede, com particular frequência, em casos em que ao dolo do tipo se torna indispensável o conhecimento, pelo agente, do **significado** essencialmente correspondente à valoração jurídica de um certo elemento típico ou, inclusivamente, dos **critérios jurídicos** determinantes daquela valoração, numa palavra, em casos de erro sobre elementos normativos do tipo (supra, 13.º Cap., § 10 e ss.). Roxin, numa tentativa louvável de agrupamento destes casos, oferece cinco exemplos particularmente complexos ([77]): o do erro sobre o carácter *alheio* da coisa em certos crimes patrimoniais (arts. 202.º, 209.º, etc.), o do erro sobre o *prejuízo patrimonial* no crime de burla (art. 217.º), o do erro sobre a *competência* do funcionário (arts. 348.º, 356.º s., 360.º, etc.), o do erro sobre o *facto prévio* no favorecimento pessoal ou real (arts. 367.º e 231.º) ou no branqueamento de capitais (art. 368.º-A), o do erro sobre deveres fiscais (*v. g.*, art. 92.º-1 da L 15/2001). A estes exemplos muitos outros se poderiam acrescentar, *v. g.*, o de o agente, através de uma inadmissível interpretação extensiva ou analógica do disposto no art. 255.º/*a)*, atribuir a uma certa declaração escrita o carácter de *documento* para efeitos penais, quando, na verdade, ela não "é idónea a provar facto juridicamente relevante".

§ 60 Relativamente à maioria destes casos fala a doutrina de **erro inverso de subsunção** ([78]). Com razão, pretendendo deste modo dar a

([77]) E que aqui serão evidentemente modificados face ao direito penal português.

([78]) Cf. só, em data recente, ROXIN, Die Abgrenzung von untauglichem Versuch und Wahndelikt, *JZ*, 1996, p. 981 e s., e STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 27.

entender que, neles, a convicção da punibilidade do facto se fundamenta numa subsunção errónea de um certo comportamento num tipo legal de crime que, na verdade, não intervém no caso; mas num tipo de crime que apesar disso — e diferentemente do que sucede com espécies de crimes putativos como os que radicam na convicção do agente de que o incesto, o adultério ou a homossexualidade integram tipos de crime — **efectivamente existe**. Mas seja embora assim: sempre que o facto ao qual se dirige a vontade de realização não preenche um tipo de crime não será pura e simplesmente possível falar-se de tentativa impossível; tudo o que pode existir é um crime putativo. E isto vale mesmo para aqueles casos em que o legislador recorre, na construção do tipo, a elementos **puramente jurídicos** (também infra, § 62).

§ 61 Assim sendo, continua em nosso modo de ver a constituir um seguro método *prático* de delimitação entre a tentativa impossível e o crime putativo aquele de que desde há muito se servem e continuam a servir (apesar de todas as críticas que lhe têm sido dirigidas) a jurisprudência e uma parte significativa da doutrina alemãs e que é conhecido como o método da **conclusão por inversão** (79). Já atrás dissemos (supra, 27.º Cap., § 8) que a tentativa representa, em certo sentido, um fenómeno inverso do erro sobre a factualidade típica; acrescentar-se-á agora que o crime putativo representa, no mesmo sentido, um fenómeno inverso do da falta de consciência do ilícito. Por isso, em um concreto caso de dúvida entre tentativa impossível e crime putativo pode o aplicador inverter o sentido do erro do agente e perguntar se um tal erro deve qualificar-se como erro sobre a factualidade típica (*rectior*, como erro que exclui o dolo, nos termos do art. 16.º), ou antes como falta de consciência do ilícito (que deixa o dolo intocado, nos termos do art. 17.º); feita em seguida de novo a inversão, no primeiro caso concluir-se-á estarmos perante uma hipótese de tentativa impossível, no segundo perante um crime putativo.

§ 62 **Dúvidas sérias** se têm suscitado no entanto, como dissemos, sobre a procedência deste critério da "conclusão por inversão". Roxin resume as críticas em três pontos fundamentais: primeiro, a questão da distinção entre tentativa impossível e

(79) Assim, entre outros (o próprio ROXIN, *Offene Tatbestände und Rechtspflichtmerkmale*, 1959, p. 159 e s.), JESCHECK / WEIGEND, § 50, II, 1, PUPPE, Die logische Tragweit des sog. Umkehrschlusses, *Lackner-FS*, 1987, p. 202, RUDOLPHI, *SK*, § 22, n.º 30, S / S / ESER, § 22, n.º 69 (com reservas).

crime putativo não é uma questão *lógica*, mas sim *teleológica*; segundo, um tal critério conduziria a afirmar a existência de uma tentativa impossível *punível* em casos em que uma tal punibilidade é inadequada ou mesmo injusta; terceiro, sempre que o erro versa sobre conceitos jurídicos de alta complexidade e tecnicidade (*v. g.*, em matéria de deveres fiscais), a aceitação errónea pelo agente de que o seu comportamento preenche tais conceitos deve, de um ponto de vista político-criminal, conduzir, pelo menos em princípio, à impunidade, não à sua punição por tentativa impossível, ainda quando o erro inverso deva qualificar-se como erro que exclui o dolo ([80]). Esta crítica parece, porém, em geral improcedente, ainda quando as soluções preconizadas acabem por não divergir sensivelmente das que advogamos. Claro que o procedimento da conclusão por inversão é "lógico", mas o critério que a ele preside não deixa por isso de ser *teleológico*: no erro verificado no caso, como no "erro inverso", o que está em causa é a espécie do erro e o relevo que lhe deve caber na delimitação de categorias às quais se ligam regimes jurídicos diversos. Do que se trata, nas duas diferentes espécies de erro, não é de um versar sobre o tipo e o outro sobre a proibição, mas — verdadeiramente, até ás últimas consequências — de num caso se tratar de um erro de *conhecimento*, no outro de um erro de *valoração* (supra, 20.º Cap., § 25 e ss.). Em segundo lugar, pelo facto de se considerar que no caso se trata de uma tentativa impossível, não pode concluir-se sem mais que ela é punível; e a verdade é que, como mostrámos (supra, § 54), a cláusula de impunibilidade da tentativa impossível é mais lata no direito português (art. 23.º-3) do que no alemão (§ 23-3). Por último, "jurídicos" — ensina-o o próprio Roxin ([81]) — são praticamente todos os conceitos usados na construção de um tipo legal de crime; e daí não se retira logo (nem o próprio A. o faz, longe disso) que qualquer erro sobre ele deva conduzir sem mais a um crime putativo.

4. Um caso especial: a impossibilidade da tentativa em função do autor

§ 63 O art. 23.º-3 regulamenta exclusivamente as hipóteses de impossibilidade da tentativa por inaptidão do meio ou carência do objecto. Uma terceira hipótese pode todavia configurar-se: a da impossibilidade provir de o tipo exigir uma **especial qualificação do autor** ("delitos específicos": supra, 11.º Cap., § 34 e ss.) e o agente da tentativa pensar erroneamente — ou por força de um erro de conhecimento, ou antes de um erro de valoração — que a possui. Como exemplo pode servir o caso de alguém que, não sendo funcionário por força de nulidade do processo de nomeação, mas supondo-se como tal, preenche com a sua conduta um

([80]) Roxin II, § 29, n.ºs 401-408.

([81]) Roxin, I, § 10, n.º 59, e supra, 11.º Cap., § 12.

qualquer crime próprio da categoria dos funcionários (corrupção, art. 374.º; abuso de autoridade, art. 378.º e ss.; etc.). O problema não pode eliminar-se na base de que, no silêncio da lei, a punibilidade desta espécie de tentativa **contrariaria as exigências de legalidade** (*nullum crimen...*). A nossa lei, como vimos, não declara a impunidade da tentativa impossível para depois limitar esta impunidade em certos casos; pelo contrário, o art. 23.º-3 parte da punibilidade de toda a tentativa impossível, salvo se a inaptidão do meio ou a carência do objecto forem manifestas. O problema é pois o de saber se esta regulamentação não pode (não deve) estender-se — se quisermos: por analogia permitida, *favore reum* — aos casos de erro sobre a idoneidade do sujeito. E é ainda um outro: o de saber, de novo, se casos deste teor conformarão apenas hipóteses de *crime putativo* ou podem ainda configurar hipóteses de *tentativa impossível*, puníveis se a impossibilidade do agente não for manifesta.

§ 64 Que, quando no caso se trate de um puro "erro inverso de subsunção", o caso deve ser reconduzido à figura do **crime putativo** não punível, é indiscutível e indiscutido. É o exemplo, sempre avançado, da mulher pertencente aos quadros de uma empresa de limpeza privada que, por trabalhar num ministério, se julga funcionária e leva a cabo uma conduta que integraria um crime próprio de funcionários. Quando porém o erro radique no desconhecimento de circunstâncias, de facto ou de direito, que constituem o substrato da posição de autor idóneo, ou antes na deficiente avaliação do sentido ou da extensão do conceito típico de autor, as conclusões da doutrina alemã dividem-se cada vez mais fundamente. Assim, para a doutrina defendida por Bruns e ainda hoje porventura dominante, o erro sobre a idoneidade do sujeito conduz, em princípio, a uma **tentativa impossível**, eventualmente punível porque, nos crimes específicos, a qualidade do agente constitui, a par das características do comportamento e do bem jurídico, elemento integrante do tipo objectivo de ilícito, pelo que o erro sobre ela conforma um erro inverso sobre o tipo ([82]). Para outra parte da doutrina, diferentemente, o caso reentra na categoria do **crime putativo** porque os deveres jurídicos especiais que constituem a posição específica do sujeito (funcionário, soldado, médico, farmacêutico, etc.) só podem em geral ser violados por aqueles sobre quem efectivamente recaem ([83]). Finalmente uma outra parte da doutrina pretende cor-

([82]) BRUNS, *Der untaugliche Täter im Strafrecht*, 1955, p. 38 e ss., e Die Strafbarkeit des Versuchs eines untauglichen Subjekts, *GA*, 1969, p. 161 e ss., D / TRÖNDLE, § 22, n.º 28, M / GÖSSEL, II, § 40, n.º 175, S / S / ESER, § 22, n.º 75 e s., e RUDOLPHI, *SK*, § 22, n.º 28.

([83]) Assim, v. HIPPEL, II, p. 437, STRATENWERTH, Der Versuch des untauglicheen Subjekts, *Bruns—FS*, 1978, p. 59 e ss. (de forma mais reservada STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 62 e ss.), WELZEL, p. 194; e entre nós, na conclusão, FONSECA, Jorge, nota 39, p. 105 e ss.: "face ao Código Penal Português, não são puníveis os *verdadeiros* casos de 'tentativa impossível' por inidoneidade do sujeito" (p. 109 e s.).

tar entre os dois extremos e distinguir consoante em causa estejam, no erro relevante, **deveres estatutários** ou antes **deveres gerais**: no primeiro caso só poderá configurar-se um crime putativo, no segundo pode deparar-se com hipóteses de tentativa impossível, eventualmente punível (84).

§ 65 Correcto se revela, também aqui, levar cuidadosamente a cabo a distinção entre **erro inverso sobre a factualidade típica** e **erro inverso sobre o ilícito** (85), não se tornando necessário distinguir entre casos indiscutíveis e casos discutíveis: uns e outros se resolvem correctamente por sobre a mesma linha de distinção. Se, p. ex., relativamente a um elemento normativo da qualificação, o autor *desconhece* circunstâncias (fácticas ou jurídicas) das quais aquela qualificação depende, comete uma *tentativa impossível* do delito específico respectivo, eventualmente punível. Se, diferentemente, conhece exactamente todas aquelas circunstâncias, mas *valora* erroneamente o seu significado para a qualificação, comete, à luz do crime específico, um *crime putativo* não punível. Temos consciência de que, por esta via, na prática, esta última situação será *muito mais frequente* do que quando a distinção seja feita em função dos termos em que a doutrina alemã prevalente distingue o erro sobre o tipo do erro sobre a proibição. E de que, ainda quando se verifique um erro inverso de conhecimento, em muitos casos a impossibilidade será *manifesta* e deverá assim conduzir à impunibilidade da tentativa.

V. A tentativa em hipóteses especiais

§ 66 Esclarecido o fundamento da punibilidade da tentativa e determinados os limites e condições daquela punibilidade, importa referir certos domínios onde a doutrina afirma por vezes ser inadmissível a existência da figura ou terem, em todo o caso, de ser afeiçoadas as condições da sua punibilidade (86).

§ 67 Isso sucederia, desde logo, nos **crimes de mera actividade** (supra, 11.º Cap., § 37 e s.). Mas a figura da tentativa é inteiramente pensável neste âmbito e não requer tratamento especial (87): seja sempre que a consumação se não verifica logo atra-

(84) Assim, ROXIN II, § 29, n.os 356-362.

(85) Assim, JESCHECK, § 50, III, 2 c), e, na conclusão, também RUDOLPHI, *SK*, § 22, e S / S / ESER, § 22, n.º 76.

(86) Sobre a tentativa de *actos preparatórios*, supra, 27.º Cap., § 6; nos *crimes de empreendimento*, supra, 11.º Cap., § 56, na *comparticipação*, infra, 31.º Cap., § 82 e ss., e 32.º Cap., § 34 e ss.; e nos *crimes de omissão*, infra, 40.º Cap., § 2 e ss.

(87) Assim, JESCHECK / WEIGEND, § 49, VII, 1.

vés da própria actividade, mas exige ainda um certo lapso de tempo (*v. g.*, quando se iniciou mas não se terminou a prestação de um falso depoimento ajuramentado, art. 360.º-3 ([88])); seja, sob a forma de tentativa impossível, nos casos de aceitação errónea da verificação de um elemento da factualidade típica (*v. g.*, abuso sexual de pessoa que erroneamente o agente crê menor de 14 anos).

§ 68 Outro grupo de casos em que se discutem eventuais especialidades da tentativa é o das **actiones liberæ in causa dolosas**. O problema já foi, porém, atrás considerado (supra, 21.º Cap., § 52 e ss.), tendo sido aí preconizada, à luz do direito português vigente, uma solução que não dá azo a que sejam pensáveis especialidades neste âmbito.

§ 69 Assim, pois, resta como merecedora de consideração especial neste âmbito, apenas a questão relativamente aos **crimes qualificados pelo resultado** (supra, 11.º Cap., § 57 e ss.). Vem de muito longe, na verdade, a discussão sobre saber se e em que termos os crimes agravados pelo resultado (como já os seus antecessores, os "crimes preterintencionais") admitem a figura da tentativa e em que termos ([89]). Face à doutrina defendida para interpretação do art. 18.º parece fundado — se bem que dissidências doutrinais continuem a manifestar-se — distinguir dois grupos de casos ([90]).

§ 70 O primeiro compreende as hipóteses em que o agente **por força da tentativa do delito fundamental produz já por negligência o evento agravante**. Nestes casos, uma tentativa do delito agravado será admissível se o resultado se liga à *acção*, inadmissível se ele se liga ao *resultado* do delito fundamental: neste último caso, com efeito, a tentativa do delito fundamental não serve de base suficiente para imputação do resultado agravante ([91]). Assim, p. ex., deve punir-se por tentativa de violação sexual agravada (arts. 164.º e 177.º-3) se já da violência usada para lograr a cópula ou o coito resultar a morte da vítima, embora a violação não

([88]) Assim, SEIÇA, Medina de, *Comentário Conimbricense*, III, art. 360.º, § 61.

([89]) Sobre a questão já o nosso *Responsabilidade pelo Resultado e Crimes Preterintencionais*, 1961, p. 154 e s. No sentido de os crimes preterintencionais não admitirem, pura e simplesmente, a forma tentada, FERREIRA, Cavaleiro de, 1940, p. 540.

([90]) Essencialmente como se segue JESCHECK / WEIGEND, § 49, VII, 2, com ampla indicação bibliográfica concordante e discordante. Para uma análise pormenorizada entre nós, já perante o art. 18.º vigente, CUNHA, Damião da, Tentativa e comparticipação nos crimes preterintencionais, *RPCC* 2, 1992, p. 562 e ss.

([91]) No essencial desta conclusão convém CUNHA, Damião da, nota 90, p. 578.

tenha sido consumada. Mas já não deve punir-se por tentativa de incêndio agravado (arts. 272.º-1/*a)* e 285.º) se a morte resultar não do incêndio que não se logrou atear, mas de hiper-sensibilização ao produto usado para o efeito.

§ 71 O segundo grupo abarca as hipóteses em que o agente **tenta ou consuma o delito fundamental mas não logra a verificação do evento agravante — não constitutivo de um tipo de crime doloso autónomo —, que todavia previu e com a qual pelo menos se conformou** (art. 18.º). Nestes casos, uma punição por tentativa do crime qualificado deve ser admitida *na medida em que não possa ou não deva sobrevir a punição por um tipo doloso mais grave*. Será o caso de alguém sequestrar outrem de modo a privá-lo da liberdade, para que não possa estar presente num julgamento que terá lugar daí a três dias (art. 158.º-2/*a)*), mas a vítima vir a ser libertada ao fim de algumas horas de cárcere: punição por tentativa do crime do art. 158.º-2/*a)* e não pelo crime consumado do art. 158.º-1.

29.º CAPÍTULO

A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA TENTATIVA

§ 1 Nos termos do art. 24.º-1, "a tentativa **deixa de ser punível** quando o agente voluntariamente desistir de prosseguir na execução do crime, ou impedir a consumação, ou, não obstante a consumação, impedir a verificação do resultado não compreendido no tipo de crime". Por seu turno dispõe o art. 24.º-2 que "quando a consumação ou a verificação do resultado forem impedidas por facto independente da conduta do desistente, a tentativa não é punível se este se esforçar seriamente por evitar uma ou outra". Este regime de **privilégio** para o caso de desistência voluntária da tentativa é tudo menos evidente — e tem sido desde há muito e continua, na verdade, a ser ainda hoje discutidíssimo na doutrina e na jurisprudência — quer quanto ao seu *fundamento jurídico*, quer quanto a múltiplos pontos da *regulamentação*.

I. Fundamento jurídico da impunidade da desistência voluntária da tentativa

1. Doutrinas

§ 2 Desde há muito que as opiniões doutrinais se dividem quanto a saber o **porquê** do efeito de exclusão da pena atribuído à desistência da tentativa. Verifica-se hoje uma tendência generalizada para reconduzir a multiplicidade de soluções aventadas às seguintes orientações fundamentais (1).

---

(1) De cinco posições básicas fala ULSENHEIMER, *Grundfragen des Rücktrits vom Versuch in Theorie und Praxis*, 1976, p. 36; a seis — acrescentando às anteriores a de HERZBERG, Grund und Grenzen der Strafbefreiung beim Rücktritt vom Versuch, *Lackner–FS*, 1987 — se refere GOMES, Júlio, *A Desistência da Tentativa. Novas e Velhas Questões*, 1993, n.º 4, acentuando todavia (e aqui reside a verdade, como de resto se verá) que não existe "uma clara e rígida fronteira entre alguns dos vectores ou ideias-força" identificáveis em cada uma das referidas posições.

§ 3 Uma orientação, claramente predominante na doutrina mais antiga, considera que a desistência da tentativa não modifica em nada o conteúdo de ilícito e de culpa do facto, pelo que a ausência de pena se fundamenta — uma fundamentação, em último termo, de natureza pragmática e político-criminal estrita — na suposição (e na esperança) de que o agente se decidirá mais facilmente por desistir do seu intento criminoso se o direito penal lhe estender uma **ponte dourada** em direcção à impunidade (2). A esta doutrina se tem oposto que aquela suposição é, em larga medida, estranha à realidade da vida e, assim, aos pressupostos "psicológicos" de que parte: o privilégio contido no art. 24.º será desconhecido de muitos agentes e ainda menos por eles consciencializado (mesmo só sob a forma de uma co-consciência imanente à acção, cf. supra, 13.º Cap., § 14) no momento da desistência, só muito raramente, pois, constituindo o *motivo* desta. Isto se afirma, porém, sem prejuízo de, apesar de todas as críticas de que seja passível, a teoria em exame dar a entender muito exactamente que o privilégio é político-criminalmente fundado em vista de aumentar as hipóteses de preservação do bem jurídico e de integridade da esfera da vítima (3). Mas logo se suscitando a questão — que a esta luz fica completamente sem resposta — de saber porque é que só à desistência *voluntária* o direito estende a ponte dourada que conduz à impunidade.

§ 4 Continua ainda hoje a encontrar defensores, por outro lado, o conjunto de orientações cabidas naquela que, genericamente, se poderá designar como **teoria premial** (ou ainda teoria do **perdão** ou da **graça**) e segundo a qual a ordem jurídica concederia um "louvor" ou um "prémio" a todo aquele a quem coubesse o *mérito* de desistir da tentativa e operasse desta forma o seu "regresso ao direito" (4). Claro que, objectivamente, a exclusão da pena na desistência representa para o agente um perdão ou uma graça. O menor favor hoje concedido a estas teorias deriva porém não só de que, uma vez mais, em muitos casos o autor não conhecerá o "perdão" concedido pela ordem jurídica nem actuará por causa dele ou para

---

(2) Teoria que, uma vez ainda, se faz reconduzir a FEUERBACH, *Kritik des Kleinschrodischen Entwufs*, 1804, p. 102 e ss., mas é geralmente imputada a v. LISZT, desde a 1.ª ed. (1881) do seu *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, p. 143. Na doutrina recente cf. sobretudo JESCHECK / WEIGEND, § 51, I, 2.

(3) De algum modo nesta direcção vão as considerações de PUPPE, Der halbhertzige Rücktritt, *NStZ*, 1984, p. 490, e de ROXIN II, § 30, n.os 14 e 16.

(4) Assim — considerando esta teoria hoje dominante —, JESCHECK / WEIGEND, § 51, I, 3.

ganhar um "prémio" cabido ao "mérito", como ainda de que também elas deixam por explicar *porque é que* a lei concede um prémio ou uma graça apesar de não exigir, mesmo através do requisito da voluntariedade, que a desistência seja presidida por motivos ou impulsos nobres ou meritórios (infra, § 38).

§ 5 De algum modo ligada à orientação anterior está a ideia — muito clara na formulação que assumiu em Bockelmann — de que o aludido perdão se liga à circunstância de, ao menos nos casos da chamada tentativa inacabada, a desistência revelar uma **menor intensidade da vontade criminosa** e conduzir consequentemente a uma diminuição da censura da culpa ([5]). Mas contra isto se tem feito notar, com razão, que nem uma tal fundamentação corresponde, as mais das vezes, à realidade (o motivo da desistência *nada* tem a ver com a intensidade da vontade, mas com motivos outros, inclusivamente, muitas vezes, bem pouco nobres), nem está de acordo com a lei porque esta o que exige é a "voluntariedade" da desistência como condição da sua eficácia jurídica e de nenhum modo que ela radique na fraca intensidade da vontade do agente ([6]).

§ 6 Finalmente, a **teoria dos fins da pena** procura a resposta à questão no contexto da discussão sobre as finalidades da punição. Arrancando, por vezes, da orientação anterior, isto é, da menor energia da vontade criminosa, a que se ligaria consequentemente a menor perigosidade do agente, a ordem jurídica concluiria que nestes casos — numa formulação do Tribunal Federal alemão (*BGH St* 9, 48, 52) — "já não parece necessária uma pena para afastar o agente da prática, no futuro, de actos criminosos e para reafirmar a ordem jurídica violada"; o que seria tanto mais assim quanto aí se teria verificado um *regresso* ao direito do agente, que acabou por contrariar o seu mau exemplo anterior com um bom exemplo, apagando a impressão negativa que havia causado na comunidade ([7]). Em suma, o

---

([5]) BOCKELMANN, *Strafrechtliche Untersuchungen*, 1957, p. 181 e ss.; cf., depois, ARZT, Zur Erfolgsabwendung beim Rücktritt vom Versuchs, *GA*, 1964, p. 9.

([6]) Concordando com a crítica no essencial, mas defendendo que, para justificação da isenção de "responsabilidade" operada pela desistência, continua a ser indispensável o regresso ao lado subjectivo do facto, YAMANAKA, Betrachtungen über den Strafbefreiungsgrund des Rücktritts vom Versuch, *Roxin—FS*, 2001, p. 782 e ss.

([7]) Assim, BOTTKE, *Strafrechtswissenschaftliche Methodik und Systematik bei der Lehre vom strafbefreienden und strafmildernden Täterverhalten*, 1979, p. 345 e ss., também JESCHECK / WEIGEND, § 51, I, 3, e RUDOLPHI, *SK*, § 24, n.º 4.

fundamento de impunidade da desistência residiria numa combinação, mais ou menos alargada, de pontos de vista de inexistência, nestes casos, de exigências de retribuição e de prevenção, especial e geral, positiva e negativa. Mas contra esta orientação se têm levantado várias objecções. A mais insistente é a de que ela constitui pura trivialidade: se não existem, *in casu*, razões que justifiquem a aplicação de uma pena, ela não deve seguramente ser aplicada; tudo estando em saber *porque é que* nas hipóteses de desistência voluntária (e só nelas) faltam as finalidades da pena e residindo a afirmação de princípio de uma tal falta (em vez de, em cada caso, se indagar se elas faltam ou não) em mera ficção (8).

2. Apreciação e conclusão

§ 7 A lição a retirar de toda a longa e complexa história dogmática que se procurou sintetizar parece ser a seguinte: não há nenhuma "teoria" *única* a partir da qual se possa determinar, com segurança lógica, qual *o* fundamento da impunidade da desistência voluntária da tentativa; antes ele é fruto da convergência de vários pontos de vista, em função dos quais o legislador tomou uma decisão **político-criminalmente justificada**. Seguro deve ser desde logo, no entanto, que uma tal decisão político-legislativa só pode ser obtida na **contemplação unitária e global da tentativa *e* da sua desistência**; nesta medida assistindo razão a Lang-Hinrichsen quando afirma que se revela errada qualquer visão atomística que dissocie a tentativa e a sua desistência, e que, para compreensão do fundamento da desistência, o "facto" do agente abrange aqui, pelo contrário, a tentativa e a sua desistência (9). Está à partida prejudicado todo o esforço para encontrar o fundamento da impunidade da desistência quando esta se cinda da tentativa e se considere um facto "autónomo" perante aquela. Por isso, e desde logo, considerações como as que estão na base de doutrinas como as da ponte dourada ou do prémio não podem manter-se estranhas à razão de ser da exclusão da pena: esta é sempre e em última análise ditada pela intenção do legislador de operar a *dissociação entre o agente e a consumação do seu projecto criminoso*.

---

(8) Assim, de forma terminante, WEINHOLD, *Rettungsverhalten und Rettungsvorsatz beim Rücktritt vom Versuch*, 1990, p. 18 e ss., e GOMES, Júlio, nota 1, n.os 8 e 44.

(9) LANG-HINRICHSEN, Bemerkungen zum Begriff der "Tat" im Strafrecht, *Engisch—FS*, 1969, p. 351 e ss.; e, entre nós, FARIA, Ribeiro de, Sobre a desistência da tentativa, *BFD 57*, 1981, p. 129 e ss., e GOMES, Júlio, nota 1, n.º 9.

§ 8 Trata-se por conseguinte, de evitar, dentro dos mais largos limites ético-social e juridicamente admissíveis (infra, § 10), a lesão de bens jurídicos ou a sua colocação em perigo; de outro modo se não compreendendo que só a desistência **lograda** (a que tem como resultado a não consumação — pelo menos em sentido material — do crime: cf. infra, § 30 e ss.) tenha por efeito a isenção da pena. Neste sentido deve concordar-se com Herzberg quando acentua o papel primordial e decisivo que a "reparação das consequências nocivas da conduta" desempenha na fundamentação do efeito da desistência; atentas sobretudo as implicações que aquela ideia possui em matéria de uma mais consistente e efectiva consideração dos interesses da vítima ([10]). Ou também, nesta medida, com Júlio Gomes, quando defende que "a relevância atribuída à desistência traduz uma solução de compromisso, excepcional, ditada pela consideração dos interesses da vítima" ([11]). H.-W. Mayer oferece aqui uma sugestiva imagem plástica do fundamento da impunidade da desistência ao ancorá-lo no interesse da vítima, titular dos interesses ameaçados, na reversibilidade (*Revisibilität*) do processo lesivo ([12]). E nesta mesma linha insiste agora Roxin quando, aproveitando uma designação de Jäger, vê na *inversão do perigo* (para a vítima) a verdadeira *ratio essendi* do privilégio da desistência ([13]). A partir daqui se tornando compreensível afirmar que, nestes casos, não se fazem sentir finalidades nem (sobretudo!) de prevenção especial, nem de prevenção geral que possam justificar a pena; e legítimo chamar, com Roxin, a uma tal concepção uma **teoria dos fins da pena modificada** ([14]).

§ 9 Não obstante, seja-nos permitido sublinhar que a toda esta teorização continua a faltar a acentuação de um momento verdadeiramente essencial: o de que não é pelo fundamento da impunidade da "desistência" que deve perguntar-se, mas pelo da **desistência voluntária**. Efectiva-

---

([10]) HERZBERG, nota 1, p. 349 e s.; e também GOMES, Júlio, nota 1, n.ºs 10 e 44.

([11]) GOMES, Júlio, nota 1, p. 160, acrescentando ainda com justeza que, sendo embora assim, "o direito penal não pode, nem que seja para evitar um mal maior, 'fechar os olhos' por completo ao que já se passou" (p. 161).

([12]) MAYER, H.-W., *Priviligierungswürdigkeit passiven Rcktrittsverhalten bei modaler Tatfortsetzungsmöglichkeit*,1986, p. 64; também PINTO, Costa, *A Relevância da Desistência em Situações de Comparticipação*, 1993, n.ºs 10 e ss. e 44 e s.

([13]) JÄGER, *Der Rücktritt vom Versuch als zurechenbare Gefärdungsumkehr*, 1996, p. 65 e ss.; ROXIN II, § 30, n.º 32 e ss.

([14]) ROXIN II, § 30, n.º 7 e ss.

mente, cremos que ainda se não sublinha com suficiente intensidade que relevante para a doutrina da tentativa jurídico-penal não é o instituto da desistência — que em verdade, *hoc sensu*, nem sequer "existe" como tal —, mas o da desistência voluntária; que, por conseguinte, a "voluntariedade" não é somente um requisito ou elemento da desistência, a par de outros, mas constitui a autêntica **ratio essendi** do instituto e o fundamento do seu específico efeito jurídico-penal.

§ 10 A esta luz, a generalidade das doutrinas apontadas — a da ponte dourada como a premial, a da compensação da culpa como a dos fins das penas — detém a sua quota de verdade e pode ser aceite como ponto de partida para compreensão do instituto. No fundo de todas elas está presente, na verdade, a **consideração político-criminal de dissociação da tentativa e do seu agente**, ligada à protecção de bens jurídicos, em particular da pessoa da vítima, ao "regresso ao direito", à "reversibilidade da lesão", à "inversão do perigo". Compreensivamente considerada, é esta a orientação na matéria que tende hoje a tornar-se dominante entre nós e lá fora, na doutrina como na jurisprudência ([15]). E no entanto, postas assim as coisas, continuamos a pensar, repetimos, que falta o essencial, isto é, a razão de ser do instituto e o tão procurado fundamento do efeito jurídico-penal que se lhe liga. Estes *só* se encontram quando se atenta que eles se ligam não à verificação da desistência como tal (mesmo lograda, em termos de salvação do bem jurídico ameaçado), mas à da desistência **voluntária**, isto é, numa fórmula curta (que todavia será explicitada e justificada infra, § 39 e ss.), da desistência que seja **obra pessoal do agente**: é o sentido jurídico-penalmente **positivo** de valor ínsito nesta contribuição **pessoal** para o facto global que faz ganhar ao "regresso ao direito", à "inversão do perigo", à "reversibilidade do processo lesivo", o seu efeito privilegiador e permite à desistência ser arvorada em fundamento de impunidade da tentativa.

([15]) Assim, para além de MAYER, H.-W., nota 12, também — embora só em certa medida — HERZBERG, nota 1, p. 349 e ss., PUPPE, nota 3, p. 490, BRICOLA, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, *La questione criminale 1*, 1981, p. 459, PADOVANI, Il traffico delle indulgenze — "premio" e "corrispettivo" nela dinamica della punibilità, *RitalDPP*, 1982, p. 410, COSTA, Faria, As formas do crime, *JDP 1983*, p. 166, GOMES, Júlio, nota 1, n.os 10 e 44, PINTO, Costa, nota 12, n.º 44. Cf., também, os Acs. da RE de 4-4-85, *CJ X-2*, p. 312, e da RL de 24-4-85, *CJ X-2*, p. 176.

II. Relacionamento dos requisitos da desistência com o estádio alcançado pela tentativa

1. Tentativa inacabada e acabada

§ 11 Pressuposto pelo art. 24.º é pois que a *consumação*, incluído o resultado que a ela pertença ou que para ela releve, não chegue a ter lugar; e que isso fique a dever-se ao próprio agente. Ora, o comportamento do agente necessário para que a consumação material do crime seja evitada depende da **proximidade** existente entre a tentativa e a consumação. Se o agente, com a sua actuação, não criou ainda todas as condições indispensáveis àquela consumação (tentativa inacabada), basta que **interrompa** (ou **abandone**) a realização típica, nomeadamente, que omita os actos que ainda faltam, p. ex., que ele não aperte o gatilho da arma que aponta já à vítima que se propunha matar. Se, pelo contrário, ele criou já todas as condições da realização típica integral (tentativa acabada), torna-se necessária uma sua **intervenção activa** destinada a impedir a consumação da realização em curso, p. ex., chamar a ambulância para levar a vítima que feriu ao hospital. A distinção entre tentativa inacabada e tentativa acabada (supra, 28.º Cap., § 39 e s.) encerra pois relevante importância prática neste contexto, uma vez que as possibilidades e os pressupostos da desistência variam num caso e noutro.

§ 12 Já dissemos (supra, 28.º Cap., nota [57]) que uma parte da doutrina, também da alemã ([16]), considera **supérflua** a distinção — doutrinal e não legal — entre tentativa inacabada e acabada, tudo dependendo em último termo de saber se para a desistência se tornaria necessário, nas palavras do art. 24.º, o agente "desistir de prosseguir na execução do crime" ou antes "impedir a consumação". *Sendo isto em último termo exacto*, não conseguimos descortinar qualquer inconveniente — pelo contrário, em homenagem à função que indiscutivelmente pertence à dogmática — em integrar com o primeiro caso o conceito de tentativa inacabada, com o segundo o de tentativa acabada.

1.1. Termos da distinção

§ 13 Dir-se-ia que, deste modo, só o estado **objectivo** da situação decide da distinção entre tentativa inacabada e acabada. Mas para lograr a distinção — que, já o sugerimos, mas valerá a pena insistirmos, não

([16]) Informações em ROXIN II, § 30, n.º 153 e s.

pode dissociar-se do problema da relevância da desistência voluntária — a doutrina hoje praticamente unânime acentua que se torna indispensável recorrer às **representações** do agente sobre o estádio alcançado de realização do facto, *só elas podendo servir* para determinar se aquele fez já tudo o que intentava fazer para a realização integral do facto e toma por isso a sua verificação, sem mais, por *possível* ([17]). O que acaba por significar — à custa, decerto, de complexos problemas de *erro*, que deste modo frequentemente se suscitarão — a inevitável introdução de **elementos subjectivos** (tal como vimos que acontece, de resto, para decidir se o facto alcançou já o estádio da tentativa: supra, 28.º Cap., § 20 e s.) ([18]). Nem outra coisa pode ser juridicamente exigida ao agente senão que se comporte segundo aquilo que, de acordo com o mundo das *suas* representações, é indispensável para evitar a consumação ([19]).

§ 14 **Exemplos**. Assim, haverá tentativa *inacabada* se o agente, no momento em que abandona o facto, parte de que o resultado se não verificará (*A* pensa, ao abandonar a vítima, que o aperto do pescoço a que a submeteu não foi suficiente para lhe causar a morte que inicialmente intentava). Diversamente, pode uma tentativa inacabada tornar-se em tentativa *acabada* quando o agente, que começou por pensar que a sua actuação anterior não poderia produzir o resultado, chega posteriormente à convicção de que esse será possivelmente o caso (*B* pensa que o artifício fraudulento usado não é suficiente — embora seja em abstracto idóneo — para causar em *C* um erro determinante de uma deslocação patrimonial; mas, face à atitude da vítima, pensa que poderá ter sido bastante e não prossegue na execução). Também a circunstância de *D* ter ferido já a vítima com dolo de homicídio em nada afecta a tentativa *inacabada* quando o agente não considera o ferimento mortal. Inversamente, não existe uma tentativa inacabada, mas *acabada*, quando o agente, no momento do abandono da execução, não sabe se, na base da sua realização anterior, terá ou não lugar a consumação e conta, por isso, com ambas as possibilidades ([20]). Para os casos em que o agente não tome posição sobre o que poderá acontecer depois de dar por terminada a actuação e a consumação não sobrevenha, parece que a solução deverá essencialmente depender da "situação objectiva" e, assim, da gravidade e concludência dos actos praticados ([21]).

([17]) Minuciosamente sobre a questão, GOMES, Júlio, nota 1, n.º 27 e ss.

([18]) JESCHECK / WEIGEND, § 51, II, 2 com extensas indicações concordantes.

([19]) STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 74.

([20]) Completamente no sentido destas conclusões a exposição de ROXIN II, § 30, n.º 163 e ss.

([21]) A favor da consideração da tentativa, nestes casos, como acabada, por violação pelo agente de um especial dever de comprovação do efeito do agir anterior, PUPPE, *NStZ* 1995, p. 403 e s. Diferenciador, ROXIN II, § 30, n.º 169 e ss.

1.2. Casos duvidosos

§ 15 Dificuldades especiais de distinção (22) são suscitadas pelos casos em que, segundo as representações do agente, se tornam necessários **vários actos** (por vezes chamados crimes "pluri-executivos") ou a utilização de **meios diversos** para lograr a realização típica completa (*v. g.*, em caso de premeditado homicídio, disparar vários tiros até a vítima morrer ou asfixiá-la para acabar com ela à facada) e todavia o agente não realiza todos os passos do *iter* representado e o crime não chega a consumar-se. Tem-se dito que o recurso ao plano do agente — dita **teoria do plano do facto** (23), sufragada essencialmente, pelo menos até há pouco, pela jurisprudência alemã — não permite soluções razoáveis, por conduzir a privilegiar o agente mais calculista e perigoso, a quem (desde que a consumação não tenha lugar) é concedido o privilégio da desistência, sob a forma simples de renúncia a posteriores actos de execução, até ao esgotamento de todas as possibilidades por ele previstas; diferentemente do que sucede com o agente que não representa todas as possibilidades e que supõe que logo o(s) seu(s) primeiro(s) actos de execução levará(ão) à consumação. Neste caso a tentativa teria acabado (ou teria fracassado), sendo qualquer repetição ou alargamento recondutível a um *novo plano* e constituindo um *novo facto*: de toda a maneira, porém, a desistência não seria relevante. Que uma tal doutrina é político-criminalmente desajustada e, em definitivo, pode conduzir a soluções inaceitáveis, por injustas, é coisa hoje geralmente admitida (24).

§ 16 Perante esta objecção, a doutrina divide-se (25). A **teoria do acto individualizado** (26) considera a tentativa acabada com cada acto de execução isolado que, segundo a representação do agente (ou mais rigorosamente, segundo uma outra versão desta teoria (27), o seu "plano inicial"),

---

(22) Para ROXIN II, § 30, n.º 175 e s., em todo o caso, não de distinção entre tentativa inacabada e acabada, mas entre tentativa inacabada e tentativa fracassada (cf. infra, § 18).

(23) Assim, por último, ROXIN II, § 30, n.º 177.

(24) No sentido desta crítica, STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 75; e, no essencial da conclusão, também ROXIN II, §§ 177 e 201.

(25) Pormenorizadamente sobre o que se segue, GOMES, Júlio, nota 1, n.º 30, e, por último, ROXIN II, § 30, n.º 178 e ss.

(26) Por ela, entre outros, JAKOBS, 26/14 e ss., S / S / ESER, § 24, n.º 20 e s., ULSENHEIMER, nota 1, p. 230 e ss.

(27) Em último termo defendida por GOMES, Júlio, nota 1, n.º 35.

é considerado idóneo a produzir a consumação. Decisivo é pois aquilo que o agente considerou necessário no *início da execução* para lograr a consumação, *sem* curar de saber se ele estava decidido à sua repetição ou se encontrava em condições de a continuar. A objecção de privilegiamento do agente calculista e empedernido fica assim ultrapassada; à custa, porém, de uma sensível *limitação* das finalidades político-criminais da desistência: se *A* se propõe matar *B* e admite poder fazê-lo com um só tiro, que todavia não atinge a vítima, a tentativa estaria acabada e a desistência não mais seria possível, apesar de haver mais balas no carregador, que no entanto *A* decide não usar.

§ 17 Por isso a doutrina alemã dominante, na esteira da jurisprudência mais recente, se dirige no sentido de uma **teoria da consideração conjunta** ([28]), segundo a qual, devendo a execução ser englobada num todo ou unidade, é decisiva a representação do agente *no momento do último acto de execução*. Sem atender ao que o agente possa ter representado no início do cometimento do facto, nem tão-pouco à maior ou menor autonomia de cada acto de execução, a tentativa reputa-se acabada quando o agente, ao tempo do *último* acto de execução, considera *possível* a verificação da consumação; até esse momento é relevante a desistência, sendo por isso decisivo não tanto "o plano", quanto o "horizonte de desistência do autor" ([29]). Esta teoria — que Stratenwerth diz, com razão, conduzir a uma "solução amiga da desistência" — merece preferência, pela maior latitude que concede à desistência *em favor da vítima*. Sem deixar todavia de se notar que, por esta via, pode ir-se mais longe do que aquilo que está no propósito da lei com a atribuição do privilégio da desistência. Não faltam hoje, por isso, ensaios de síntese das duas concepções ([30]), em particular, o de aceitar em princípio a teoria conjunta, mas concedendo alguma coisa à teoria do acto individualizado: uma desistência, em casos desta natureza, só deverá ser aceite quando existem razões para con-

---

([28]) Assim, JESCHECK / WEIGEND, § 51, II, 3 e 4, com mais latas indicações concordantes doutrinais e jurisprudenciais.

([29]) JESCHECK / WEIGEND, § 51, II, 2, RUDOLPHI, *SK*, § 24, n.º 14, VOGLER, *LK*[10], § 24, n.º 65.

([30]) Referenciados e discutidos por ROXIN II, § 30, n.º 184 e ss. Destaque-se nesta linha HERZBERG, Gesamtbetrachtung und Einzelakttheorie beim Rücktritt vom Versuch. Entwurf einer Synthese, *NJW*, 1988, p. 1663 e, no mesmo sentido, STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 75, e, entre nós, GOMES, Júlio, nota 1, n.ºs 30 e 44.

cluir que o agente renunciou a uma forma de continuação que lhe aparecia como idónea à consumação. A esta posição, que sustenta, chama Roxin **doutrina da consideração conjunta modificada** ([31]).

2. A tentativa dita "fracassada"

§ 18 Segundo uma doutrina muito difundida na Alemanha e hoje aceite também, no essencial, pela jurisprudência germânica, uma desistência que isenta de pena está **excluída** nos casos ditos de "tentativa falhada" ou "fracassada"; isto é, naquelas hipóteses em que o agente renuncia à execução do facto porque crê que a consumação já não pode ser alcançada ([32]): seja por razões objectivas (o agente dá-se conta, quando entrou já na fase de execução, que a vítima que se propõe roubar não leva consigo quaisquer valores ([33])), seja por razões subjectivas (o autor de uma tentativa de violação não consegue, por incapacidade de erecção suficiente, levar a cabo a cópula), seja — duvidosamente — por razões jurídicas. O que pode suceder tanto em caso de tentativa inacabada (quando, p. ex., *A* pensa serem necessários vários tiros para matar *B* e se propõe dispará-los, mas a pistola encrava depois de disparado o primeiro tiro), como de tentativa acabada (no caso, p. ex., em que *C*, atirador exímio, se propõe abater *D* com um único tiro mas a pistola encrava). Em todos estes casos, uma vez que o agente se apercebeu de que falhou e que a realização típica intentada não é mais possível, ele não teria chegado a "desistir". Neste sentido afirma Roxin que doutrinas como as referidas supra, §§ 15-17,

---

([31]) ROXIN II, § 30, n.º 187 e ss.

([32]) Fundamental, ROXIN, Der fehlgeschlagene Versuch, *JuS*, 1981, p. 1. Este A. avança agora, a propósito da figura da "tentativa fracassada", os seguintes grupos de casos característicos (ROXIN II, § 30, n.ºs 85-112): *a)* impossibilidade de preenchimento do tipo, *b)* falta de correspondência do objecto da acção ao plano do facto, *c)* objecto do facto abaixo das expectativas do agente. Já não pertenceriam à categoria da tentativa fracassada — podendo aí configurar-se uma desistência relevante — os casos de divergência das modalidades do facto face ao plano do agente, de cessação dos motivos e de actos executivos susceptíveis de reiteração.

([33]) PALMA, Maria Fernanda, *Da "Tentativa Possível" em Direito Penal*, 2006, p. 59, considera este exemplo como configurando um caso de tentativa impossível. Aliás, entende a A. que "a tentativa impossível aproxima-se da tentativa falhada pelo agente, apenas se distinguindo daquela na medida em que um facto exterior veio obstar à consumação" (p. 37). Não estamos de acordo. A distinção entre a tentativa fracassada ou falhada e a tentativa impossível surge como clara e imediata logo ao nível do agente: na primeira, o agente apercebe-se durante a execução da impossibilidade de realizar o facto e por isso o abandona; na segunda o agente acredita durante todo o processo de execução na possibilidade de realizar o facto ilícito-típico intentado.

não visam tanto distinguir a tentativa inacabada da acabada, quanto a tentativa inacabada da tentativa fracassada (34), enquanto Jescheck defendia — com melhor razão, se bem nos parece — que para a figura da tentativa fracassada "a distinção entre tentativa acabada e inacabada não tem interesse" (35).

§ 19 Esta concepção teria — para além de um maior rigor conceitual e terminológico — a vantagem prático-normativa não despicienda de evitar em muitas hipóteses a longa e penosa discussão sobre a **voluntariedade** da desistência (infra, § 30 e ss.) e, em alguma medida também, as difíceis questões de **erro sobre a sua idoneidade**. Não parece, porém, que o "fracasso" da tentativa como tal tenha aqui que relevar de forma autónoma (36): decisiva será sempre a distinção — e sem que ela, por difícil que seja por vezes de encontrar, possa ser evitada — entre os casos em que o agente desiste *voluntariamente* e aqueles em que uma desistência voluntária não teve lugar ou já não é possível. Podendo por isso concluir-se, com Stratenwerth, que "enquanto figura jurídica autónoma a tentativa fracassada é na verdade completamente dispensável" (37).

III. A desistência da tentativa inacabada: o abandono da prossecução do crime

§ 20 Nos casos de tentativa inacabada, o art. 24.º-1, 1.ª alternativa, impõe ao agente, para relevância da desistência, "desistir de prosseguir na execução do crime". Se não quisermos que o definido entre na definição, diremos que a lei exige que o agente **deixe de prosseguir** a execução do crime, que ele a **abandone**. Não falta quem fale a este propósito do *momento objectivo* da desistência (contrastante com o factor subjectivo da "voluntariedade") (38). Mas o designativo é, neste contexto, pelo menos equívoco. Com efeito, um abandono existirá sempre que o agente tenha *renunciado* à prática de actos que, no momento da renúncia, **ele** ainda considerava necessários para a consumação, por outras palavras, que **ele crê**

(34) ROXIN II, § 30, n.º 175.

(35) JESCHECK, 4 § 51, II, 4.

(36) Assim, com particular insistência, GOMES, Júlio, nota 1, n.os 17-20.

(37) STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 77; de forma incisiva também M / GÖSSEL, § 41, V, B, 3, e GOMES, Júlio, nota 1, n.os 17-20.

(38) Assim, JESCHECK / WEIGEND, § 51, III.

que constituiriam ainda pressupostos indispensáveis da consumação. Temos, assim, que para efeito de relevância da desistência convergem aqui uma "situação objectiva" — é em qualquer caso necessário que o agente deixe de prosseguir a execução e que a consumação não sobrevenha — e, em último termo, uma **situação subjectiva**: decisivo é **o ponto de vista do agente** de que se abandonar a execução a consumação não terá lugar. A favor desta compreensão invoca Roxin, cremos que com razão, o argumento de que é seguramente assim, segundo o teor do texto legal alemão correspondente ao do nosso art. 24.º-2, para os casos de tentativa acabada, pelo que "uma mudança de perspectiva para a hipótese de abandono significaria uma contradição valorativa" ([39]). De acordo com estas regras deverão resolver-se os **casos duvidosos**.

§ 21 Assim, desde logo aqueles casos em que o agente renuncia à prática de ulteriores actos porque ele (verdadeira ou presumidamente) **já alcançou a finalidade da acção**. Será a hipótese de a vítima de um processo de violação enganar o agente dando-lhe a entender que consente na cópula e ele renunciar por isso subsequentemente ao uso da força. Aqui não pode falar-se de um abandono do facto planeado. E o mesmo se diga quando o agente, em caso de tentativa inacabada no quadro de uma "compreensão conjunta" (supra, § 17), renuncia a actos de continuação depois de ter alcançado a **finalidade extra-típica** da sua acção. Assim, p. ex., quando o agente, com dolo eventual de homicídio, espeta uma faca na face da vítima, para a deixar desfigurada, e depois a larga apesar de "apenas" a ter ferido. Também aqui parece não dever falar-se de desistência relevante (da tentativa de homicídio) ([40]). Por outra parte, pode desistir-se de uma tentativa impossível, quando a impossibilidade não é conhecida do agente: *A* ministra a *B*, com dolo de homicídio, uma substância que erroneamente crê venenosa, mas abandona o processo numa altura em que julga que as quantidades administradas não são ainda mortais ([41]).

§ 22 No que respeita à situação **objectiva**, a exigência de que a consumação não sobrevenha não é em si evidente, face à regra que vale para a situação subjectiva. Assim, p. ex., quando o agente, contra aquilo que

([39]) ROXIN II, § 30, n.º 157.

([40]) Neste sentido, ROXIN, *JZ*, 1993, p. 896, RUDOLPHI, *SK*, § 24, n.º 14 a, STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 80.

([41]) Assim, de novo, ROXIN II, § 30, n.º 157.

supõe, realizou já com o seu comportamento executivo todas as condições de verificação da consumação, *v. g.*, quando administrou já à vítima uma dose de veneno que erroneamente ele supõe não ser ainda mortal e abandona em seguida o seu projecto criminoso, vindo a vítima a falecer. Não falta aqui quem pretenda punir o agente apenas a título de negligência ([42]). Mas não parece ser esta a solução legalmente imposta: a desistência da tentativa (pretensamente) inacabada é irrelevante — *rectior*, só relevante para efeito de medida da pena —, tal como o é a da tentativa acabada quando, apesar dos melhores esforços do agente para impedir a consumação, esta vem a verificar-se (infra, § 24). Se o resultado (a consumação) sobrevém *depois do* abandono mas não é imputável à conduta, *v. g*, por um erro sobre o processo causal que exclui o dolo da consumação ou ainda, mais directamente, porque a produção do resultado acabou por ser causada por terceiro, o agente é punível por tentativa, relativamente à qual a desistência é relevante segundo as regras gerais ([43]). Não há aqui qualquer *excepção* a estas regras, nem tão-pouco qualquer razão para que se fale da necessidade de uma aplicação *analógica* ([44]) do disposto no art. 24.º-2.

IV. A desistência da tentativa acabada: o impedimento da consumação

§ 23 A relevância da desistência da tentativa acabada é *mais* exigente do que a da inacabada, uma vez que, nela, a execução do delito foi levada até ao seu limite. Por isso não basta o abandono do plano, mas tem o agente de voluntariamente **impedir a consumação** (art. 24.º-1, 2.ª alternativa) através de uma *actividade própria*, eventualmente com o auxílio de *terceiro(s)*, *v. g.*, de um procurador, de um médico, de polícias, de bombeiros ([45]); tem, em suma, de levar a cabo um comportamento activo e com êxito.

§ 24 Assim, pois, a primeira exigência é a de que o desistente tenha posto em movimento **uma nova cadeia causal** dirigida a impedir a consumação do facto e esperar que esta não venha a ter lugar; não bastando

([42]) Assim, JAKOBS 26/13 e S / S / ESER, § 24, n.º 24.

([43]) Sobre as questões deste parágrafo — no essencial no sentido do texto —, JESCHECK / / WEIGEND, § 51, III, 3, ROXIN II, § 30, n.º 284, STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 83 e s.

([44]) Assim, no entanto, M / GÖSSEL, 41/95.

([45]) Falando-se tradicionalmente a este propósito, embora com alguma incorrecção, de "arrependimento activo" (*tätige Reue* em alemão).

que, no momento da consumação, o agente já não quisesse o facto. Antes se exigindo que a não verificação da consumação lhe seja (ou, pelo menos, seja também) **imputável**. Nesta acepção se pode aceitar a ideia de Herzberg segundo a qual o desistente deve ter dominado ou, ao menos, condominado, o processo de salvamento do bem jurídico ameaçado (46). Bastando sempre, todavia, que o desistente não se tenha limitado a dissociar-se intimamente do facto, mas tenha praticado acto ou actos *idóneos* a evitar a consumação e que esta efectivamente *não tenha sobrevindo* (47).

§ 25 Na questão, pois, hoje arduamente discutida pela doutrina alemã (em consequência de posições desde há algum tempo tomadas pela jurisprudência suprema), preferência de princípio merece a **teoria da criação de oportunidades** (de salvação do bem jurídico), não a **teoria da contribuição óptima** (48). Valendo isto por dizer que não se torna em princípio necessário que o agente se tenha servido dos meios *óptimos* para afastar a consumação ou tenha utilizado *todos* os meios que se encontravam à sua disposição. Tudo quanto é necessário é que a não verificação da consumação possa ser (co-)imputada à *sua* actividade e que esta, por conseguinte, seja *dirigida* àquela de forma idónea (49).

§ 26 A estas duas teorias vem agora Roxin substituir uma **teoria da diferenciação**, baseada na distinção entre impedimento do resultado por mão própria e impedimento dele por mão alheia (50). Para o caso de **impedimento por mão própria** deveria valer, sem alterações assinaláveis, a teoria da criação de oportunidades: o privilégio da desistência estaria teleologicamente justificado mesmo quando o agente não usou dos meios óptimos de salvação, mas criou para esta novas oportunidades. Já em caso de **impedimento por mão alheia** deveria exigir-se que o agente se sirva dos meios óptimos de salvação para poder considerar-se a desistência relevante; e isto porque se revelaria político-criminalmente injustificado privilegiar o agente que com "actos por metade" deixa subsistir para a vítima maiores perigos do que os necessários. Temos dúvidas quanto ao acerto e à viabilidade da distinção: naturalmente (já o sugerimos)

---

(46) HERZBERG, Problemfälle des Rücktritts durch verhindern der Tatvollendung, *NJW*, 1989, p. 866.

(47) PUPPE, nota 3, p. 490, fala neste sentido, com razão, na máxima "tudo está bem quando acaba bem".

(48) Uma aprofundada análise e discussão, por último, em ROXIN II, § 30, n.º 221 e ss., a quem fica a dever-se o designativo das teorias referidas.

(49) Minuciosamente sobre as questões de causalidade e de imputação objectiva aqui implicadas, GOMES, Júlio, nota 1, n.º 37 e ss., e PINTO, Costa, nota 12, n.º 66 e s.

(50) ROXIN II, § 30, n.ºs 243-264.

que não basta a criação de uma qualquer oportunidade, mas se torna necessário — sem qualquer atenção, em todo o caso, ao carácter meritório ou ao valor moral dos motivos — a utilização de meios *idóneos* de impedir o resultado; e isto vale tanto para o impedimento de mão própria como de mão alheia. Saber se se usou do meio (em abstracto ou em concreto?) "óptimo" será questão que, sobretudo segundo um imposto juízo *ex ante*, se torna de resposta muito duvidosa ou impossível; *v. g.*, perante uma pessoa gravemente ferida que se tentou matar mas que agora se quer salvar, saber se o meio óptimo residirá em pedir a um passante que se sabe ser enfermeiro que proceda, em plena rua, à respiração artificial ou que chame pelo seu telemóvel o 112. Dúvida que, ela sim, pode diminuir em vez de incrementar as oportunidades de salvação do bem jurídico. Por isso vamos ao ponto de considerar que o privilégio da desistência deve ser concedido ao agente mesmo quando ele se constitui em mero **auxiliar** do salvador ([51]), *v. g.*, no exemplo acima apontado, quando ele ajuda o enfermeiro que tomou a iniciativa de proceder a manobras de reanimação da vítima em plena rua.

§ 27 Pode suceder que, propondo-se o agente impedir a consumação, esta venha a ser impedida não por força da sua actividade, mas por **facto independente da sua conduta**; de outra forma, e diversamente do que começámos por dizer (supra, § 24), que, ao cabo e ao resto, a actividade do desistente se não tenha revelado **causal** para o impedimento do resultado. Ainda neste caso, segundo a nossa lei vigente, o agente não é punível se ele se tiver **esforçado seriamente por evitar a consumação** (art. 24.º-2). As razões político-criminais que estão na base do fundamento do privilégio da desistência devem, no pensamento da lei, considerar-se ainda subsistentes no caso em que o agente fez aquilo que devia para obstar à consumação, mas esta foi evitada por factores estranhos à sua vontade (*A*, tendo abandonado *B*, por ele gravemente ferida com intenção de matar, volta atrás a toda a pressa para a conduzir ao hospital, ou chama para esse efeito o 112, mas *B* fora já ali transportada por *C* que com ela deparou e *B* salva-se).

§ 28 "**Esforços**", no sentido da lei, não são evidentemente meros propósitos de salvação ou sequer preocupações ou cuidados mais ou menos piedosos com a sorte do bem jurídico: eles existem apenas, na teleologia da lei, quando se possa afirmar que criaram, da perspectiva do agente, uma oportunidade de salvação do bem jurídico. Não basta porém que se tenham verificado esforços, sendo ainda indispensável que eles sejam sérios. "**Sérios**" são os esforços quando o agente intenta levar a cabo tudo aquilo que subjectivamente pensa que teria de fazer ou pode fazer para evi-

([51]) Assim, contra a doutrina dominante, RUDOLPHI, *SK*, § 24, n.º 27b e s.

tar a consumação, valendo pois, aqui sim, no essencial, a ideia base da melhor contribuição possível segundo a convicção do agente. Tanto basta, não se tornando indispensável, como agora alguns pretendem (52), que o desistente tenha posto em movimento um processo causal efectivamente capaz, segundo um juízo hipotético objectivo, de salvar o bem jurídico. Se a consumação sobrevém, o privilégio da desistência não tem lugar e o agente deve ser punido pelo crime consumado (53). Só no caso, muito particular, de a consumação ser impedida dolosamente pela vítima deverá porventura haver lugar para uma aplicação *analógica* do disposto no art. 24.º-2 (54).

V. A "desistência" em caso de consumação

§ 29 Toda a exposição anterior foi levada a cabo na base de que a desistência só releva se o delito **se não tiver consumado** (tomado aqui o conceito na sua acepção *formal* e *própria* de realização integral do tipo objectivo de ilícito: supra 27.º Cap., § 11 e s.). Esta assunção é fundada, na medida em que todo o regime geral da tentativa só se torna compreensível se e na medida em que a consumação não sobrevenha, de acordo com a verdade, aparentemente lapaliciana, segundo a qual se há consumação é porque já não há tentativa (tendo esta fase sido definitivamente ultrapassada). Todavia, a nossa lei — não pondo em causa, em nosso parecer, o que acaba de ser dito — alarga o privilégio da desistência também aos casos em que sobrevém a consumação formal, mas não a **consumação material**; quando ainda não teve lugar, mais exactamente, o resultado atípico ("o resultado não compreendido no tipo de crime", segundo a expressão constante do art. 24.º-1, 3.ª alternativa) que a lei, no entanto, teve em vista em último termo evitar quando construiu a incriminação e que, por isso mesmo, faz ainda parte, neste sentido, da *realização completa do con-*

---

(52) Assim, ARZT, Zur Erfolgsabwendung beim Rücktritt vom Versuch, *GA*, 1967, p. 1, e BOTTKE, *Strafrechtswissenschaftliche Metodik und Systematik bei der Lehre vom strafbefreienden und strafmildernden Täterverhalten*, 1979, p. 532 e ss. Contra, substancialmente como no texto e ligando-se deste modo à doutrina dominante na Alemanha, por último, ROXIN II, § 30, n.º 280 e ss.

(53) No sentido de uma mais lata valorização do requisito "esforço sério", pormenorizadamente, GOMES, Júlio, nota 1, n.º 68 e ss.

(54) Assim, JESCHECK / WEIGEND, § 51, IV, 1, S / S / ESER, § 24, n.º 59, RUDOLPHI, *SK*, § 24, n.º 27.

teúdo do ilícito tido em vista pelo legislador. O legislador português, diferentemente do que é usual, não se limitou a criar normas especiais, contendo um regime análogo ao da desistência, relativamente a certos delitos tipicamente consumados da PE (*v. g.*, arts. 299.º-4 e 300.º-6 ([55])). Antes entendeu estender o privilégio da desistência, de uma forma geral, aos casos de não verificação da consumação material, término ou conclusão.

§ 30 O nosso legislador ter-se-á desta forma deixado conduzir pelo argumento de que, do ponto de vista de uma **valoração material**, é difícil entrever razão para que a isenção da pena própria da desistência deva depender do momento, por vezes mais ou menos arbitrariamente construído, de verificação formal da consumação típica, antes que do efectivo impedimento do resultado que constitui a *ratio legis* da proibição e, assim, da não completa realização do ilícito *material* ([56]): razões claras de protecção dos bens jurídicos e de consequente prevenção parece dirigirem-se no sentido da equiparação de regime. Mas seja embora deste modo, de um ponto de vista construtivo e dogmático deve manter-se a ideia de que a tentativa termina com a consumação típica e de que, na presente constelação problemática, se trata por conseguinte de uma **extensão** dos efeitos político-criminalmente favoráveis que à desistência em todo o caso se ligam, ainda e sempre em nome de uma prevenção dos efeitos nocivos dos delitos mais lata e eficaz e de defesa, em último termo, do bem jurídico, nomeadamente na pessoa da vítima.

§ 31 Longe demais nos parece por isso ir Costa Pinto — embora pensemos que nem por isso alcançará soluções dos problemas prático-normativos muito diferentes das que defendemos — quando sustenta que o conceito de consumação [na terminologia aqui usada: de "consumação material"] deve ser determinado não por referência à tentativa, "mas sim à própria **utilidade concreta da desistência**"; donde derivaria que o resultado não compreendido no tipo de crime abrangeria toda e qualquer lesão ("intra-típica"!) de valores ameaçados que merecessem a protecção jurídico-penal ([57]). Desde o início deste capítulo temos sublinhado o particular peso que, na doutrina da desistência voluntária, assumem razões relativas de oportunidade e de natureza pragmática ligadas à protecção de bens jurídicos. Mas elas têm de ser cone-

([55]) Concretamente sobre estes preceitos, DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, II, art. 299.º, § 39 e ss. Em geral, minuciosamente, PINTO, Costa, nota 12, p. 244 e ss.

([56]) Assim, também, STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 98, e S / S / ESER, § 24, n.º 116.

([57]) PINTO, Costa, nota 12, p. 47 (43 e ss.); e, de algum modo, já, FONSECA, Jorge, *Crimes de Empreendimento e Tentativa*, 1986, pp. 77, 113 e s., 160.

xionadas com o (e limitadas pelo) dever primordial de não cometimento de factos ilícitos típicos que em direito penal preside à norma de comportamento; sob pena, de outra forma, de lançar o manto da impunidade sobre comportamentos perigosos e arriscados para a subsistência dos bens jurídicos e, com isto, se poder pôr em causa uma eficaz prevenção. O caso do agente que põe fim a um sequestro já consumado, mesmo com o propósito de obstar deste modo à compressão do bem jurídico, é para nós ilustrativo daquilo que queremos significar: um tal comportamento, seja qual for o significado jurídico-penal que possa assumir (*v. g.*, relativamente a um eventual homicídio com dolo eventual ou a um crime agravado pelo resultado), não deve valer como desistência relevante do crime de sequestro (58).

§ 32 O **regime** a que, segundo o art. 24.º-1 e 2, fica submetida a "desistência" nestas hipóteses é inteiramente análogo ao que cabe à desistência da *tentativa acabada*. Necessário se torna por isso, em princípio, que o agente **impeça** a verificação do resultado atípico mas ainda relevante para caracterização do conteúdo material do ilícito, obste activamente, isto é, à "consumação material" (art. 24.º-1, 3.ª alternativa). Se esta vier a não ter lugar por facto independente da conduta do desistente bastará no entanto à concessão da impunidade que o agente se tenha **esforçado seriamente** para a impedir e que o resultado (não compreendido no tipo de crime) não se tenha efectivamente verificado (art. 24.º-2).

VI. A desistência em casos especiais

1. A desistência parcial (59)

§ 33 Em data recente, a jurisprudência e, na sua esteira, a doutrina alemãs vêm vivamente discutindo se é ou não relevante a desistência parcial. Por tal entendem os casos em que o agente, já na fase de execução, renuncia voluntariamente à consumação de uma circunstância **qualificadora**, mas consuma, não obstante, o delito fundamental. *V. g.*, *A*, quando tenta a realização de um furto qualificado, traz consigo uma arma (art. 204.º-2/*f*)); tomado de um sentimento inesperado, porém, decide não a usar e lança-a fora, levando todavia a cabo o furto intencionado. A doutrina dominante considera, julgamos que com razão, *relevante* a desistência da qualificação

(58) Reputa "problemático" o caso o próprio PINTO, Costa, nota 12, p. 51 e s.

(59) Sobre a matéria deste número e no sentido da conclusão do texto, ROXIN II, § 30, n.os 295-300.

até à consumação do delito fundamental. A razão político-criminal do privilégio da desistência — a "reversão do processo lesivo" em favor dos interesses da vítima como obra do desistente — verifica-se, ainda nestes casos, relativamente ao ilícito-típico específico da *qualificação*: esta deve, ao menos nesta medida e para estes efeitos, *autonomizar-se* relativamente ao ilícito-típico do crime fundamental.

2. A desistência nos crimes agravados pelo resultado

§ 34 A questão que agora se suscita é a de saber se é ou não relevante a desistência voluntária do crime agravado pelo resultado quando a produção **do evento agravante** já teve lugar, enquanto a realização do **crime fundamental** não ultrapassou ainda o estádio da tentativa (60). *V. g.*, *B* decide praticar um roubo usando uma arma de fogo que, em todo o caso, se propõe disparar unicamente, em caso de resistência, para assustar a vítima, *C*, disparando para o ar ou para o chão. A vítima resiste e, por negligência, a arma de *B* dispara e mata *C* (art. 210.º-3). Face a este resultado não querido, *B* abandona o processo de subtracção.

§ 35 A jurisprudência alemã, seguida pela doutrina porventura dominante (61), aceita o relevo da desistência nestes casos (verificada, evidentemente, a sua "voluntariedade"). Uma opinião minoritária, na qual se destaca Ulsenheimer e a que se liga Roxin, pronuncia-se pela irrelevância (62). Provavelmente, quanto nos parece, uma única resposta, válida para todos os crimes agravados pelo resultado, corre o risco de poder ser, no caso, inadequada e eventualmente injusta. Se tal for exacto, o problema tornar-se-á, em último termo, questão da análise dos singulares crimes agravados pelo resultado e, por isso, pertencente à PE do direito penal. Em geral, cremos, no entanto, poder avançar o seguinte: nada mais contrário, desde 1960, ao nosso pensamento do que considerar os crimes em questão como mera "adição" de um evento agravante a um crime fundamental, antes os vemos como **unidade** constituída através do *perigo típico* que do crime base resulta para a produção do resultado (supra,

---

(60) Cabendo a hipótese, por conseguinte, ao grupo de casos considerado supra, 28.º Cap., § 69.

(61) Indicações em ROXIN II, § 30, n.º 287.

(62) ULSENHEIMER, Zur Problematik des Rücktritts vom Versuch erfolgsqualifizierter Delikte, *Bockelmann—FS*, 1979, p. 405; ROXIN II, § 30, n.º 289 e ss.

11.º Cap., § 61). Se, pois, o perigo típico, ligado à conduta tentada, já se actualizou no evento agravante, não parece *em princípio* adequado e justo privilegiar o comportamento unitário com a relevância da desistência (cuja "voluntariedade" deverá, de resto, ser questionável na generalidade dos casos: cf. infra, § 36 e ss.); em situações deste teor, porém, parece justificar-se a quebra da aludida unidade e, se tal se tornar viável no caso, conceder ao agente a *atenuação especial* própria do crime fundamental apenas tentado.

VII. A voluntariedade da desistência

§ 36 Nos termos do art. 24.º-1 só a desistência **voluntária** conduz à isenção da pena do facto tentado. Já supra, § 9 e s., acentuámos a relevância desta caracterização da desistência, sublinhando que nela se não depara com um seu mero requisito, a par de outros, mas verdadeiramente com a *ratio essendi* do instituto e do seu específico efeito privilegiador. Por isso é que, desde logo, apesar da questão da voluntariedade da desistência ser considerada pela generalidade dos tratadistas a propósito do "abandono" e, assim, da desistência da tentativa inacabada (63), **ela vale** (como, de resto, é suficientemente explicitado pela lei) **para todas as formas de desistência da tentativa**: da tentativa inacabada como da acabada, para a desistência da consumação material como para a desistência em caso de comparticipação (art. 25.º e infra, 33.º Cap., § 2 e ss.) (64).

1. A teoria

§ 37 Desde há muito que a determinação do conteúdo da voluntariedade da desistência vem sendo reconduzida a uma de duas concepções: a "psicológica" e a "normativa". Para a **concepção psicológica** a voluntariedade depende, em princípio *unicamente*, do grau de **coacção psíquica** exercida pela situação em que o facto ocorreu sobre a liberdade de decisão do agente: a desistência é voluntária se o agente se decidiu livremente por ela, involuntária (e portanto irrelevante) se o agente foi a ela condu-

(63) Assim, por outros, JESCHECK / WEIGEND, § 53, III, 2, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 85 e ss.

(64) Acentua este largo campo de actuação da voluntariedade da desistência, ROXIN II, § 30, n.º 354.

zido pela pressão psíquica originada pelas circunstâncias da actuação (65). Para a **concepção normativa** — melhor se diria: para *as* concepções normativas, dada a forma plural como são defendidas e combinadas, inclusivamente, com a ideia base da concepção psicológica — a voluntariedade não dependerá *somente* da referida pressão psíquica, mas *também*, e *sobretudo*, **do merecimento in casu da isenção da pena face ao seu fundamento jurídico próprio** (66); necessário se tornando à "voluntariedade" da desistência, nomeadamente, que ela tenha origem numa "inversão" da posição interna do agente determinante de um seu verdadeiro "regresso à legalidade" (67).

§ 38 Colocado o problema nestes termos, nenhuma das concepções em disputa deve ser aceite. Contra **a concepção psicológica** se tem dito ser ela, desde logo, incompatível com o *fundamento do privilégio* da desistência, radicado no regresso do agente à legalidade; como se tem sublinhado que uma orientação estritamente psicológica não é sequer possível, pois que importa determinar o peso ou o grau da pressão psíquica que as circunstâncias exerceram sobre o agente, introduzindo-se nela, deste modo, uma *valoração* que em definitivo a normativiza (68). Mas ainda quando assim seja, verdade é que também **as concepções normativas são insustentáveis**, ou pelo menos profundamente equívocas, quando erigem o *mérito* dos motivos da desistência em marca da sua voluntariedade: não são questões de mérito ou demérito dos motivos que dão fundamento ao privilégio da desistência, antes sim, como dissemos (supra, § 7 e s.), razões político-criminais ligadas à reversão do processo lesivo *como obra do agente*. Uma concepção normativa recondutível à ideia central acima exposta poderia inclusivamente, no limite, pôr em causa um dos mais seguros *pontos de concordância* entre orientações psicológicas e normativas (69): o de que para a voluntariedade **é irrelevante a qualidade moral dos impulsos à desistência**. Seria, *v. g.*, inadmissível considerar *involuntária* a desistência

(65) Exemplarmente nesta direcção, SCHRÖDER, Die Freiwilligkeit des Rücktritts vom Versuch, *MDR*, 1956, p. 81 e ss., e agora, ainda, JESCHECK / WEIGEND, § 51, III, 2, seguindo a jurisprudência pelo menos até há pouco dominante.

(66) Uma exposição minuciosa destas teorias em ULSENHEIMER, nota 1.

(67) Assim, já ROXIN, Über den Rücktritt von unbeendeten Versuch, *Heinitz—FS*, 1972, p. 256 e ss., e agora ROXIN II, § 30, n.os 379 e ss.

(68) Cf., sobre estas objecções, ROXIN II, § 30, n.os 366-378.

(69) Com excepção, todavia, de BOCKELMANN, nota 5, p. 183, acentuando em todo o caso que já "é mérito bastante se o agente desiste por medo da pena".

quando *A* abandona a execução dos actos destinados a roubar *B* porque se apercebe tratar-se de um "pobre diabo" com pouco dinheiro e prefere roubar *C*, que vê ser pessoa rica transportando uma pasta recheada; e todavia não pode seguramente falar-se aqui dos "méritos" da motivação ou da "moralidade" do impulso que conduziram à desistência. Inversamente, e no outro extremo, igualmente inadmissível seria considerar *voluntária* a desistência quando, *v. g.*, o assaltante de uma casa, *D*, abandona a execução do roubo porque sente a polícia a gritar, identificando-se esta e exigindo a abertura da porta, apesar de *D* poder facilmente saltar pela janela com um cofre de jóias a que já deitara mão. E todavia, abandonando a execução do facto, verifica-se no caso o "regresso à legalidade" do agente, a "inversão do perigo, a "reversibilidade do processo lesivo" relativamente à vítima. É este regresso, inversão ou reversibilidade que tem ainda de ser caracterizado por via diferente da que está na linha das concepções psicológicas ou normativas expostas.

§ 39 Tudo considerado — e sem nos preocuparmos em demasia com saber se a concepção da voluntariedade da desistência que iremos defender deve ser cognominada em definitivo de psicológica, ou normativa, ou *mista* ([70]), se bem que com a consciência de que ela será sempre "normativa" na acepção evidente de que implica em qualquer caso uma valoração jurídico-penal —, decisivo é que a desistência (como avançámos logo supra, § 10) possa ser vista como **obra pessoal** do agente e nessa base **lhe** possa ser imputável. Trata-se aqui de uma concepção de certo modo correspondente (embora de sentido inverso, na direcção do *lícito*) àquela em que falámos de um *ilícito pessoal*, isto é (supra, 10.º Cap., §§ 22 e 59, e 11.º Cap., § 9), de uma unidade de sentido social, constituída pela tentativa e pela sua desistência, jurídico-penalmente positiva, como tal previsível e controlável pela vontade; e, por aí, ligada a um "centro ético de imputação" e só nesta medida aprovada pelo direito como realização de um agente determinado. De uma concepção que supõe assim — também este símile podendo ser trazido à consideração — algo de essencialmente análogo àquilo com que depararemos na caracterização

([70]) No sentido de que uma *complementa* a outra: assim, entre nós GOMES, Júlio, nota 1, n.º 21, que, na esteira de Schmidäuser, afirma "que o conceito de voluntariedade para ser um conceito jurídico-funcional deve apreender realidades psíquicas sob um aspecto ou perspectiva normativos e, consequentemente, há-de ser, ao mesmo tempo, psicológico *e* normativo". O que o texto em seguida se esforça por esclarecer é que aspecto ou perspectiva normativa é esta.

da autoria nos factos dolosos (infra, 30.º Cap., § 16 e ss.), a saber, com a exigência de um *domínio (ou condomínio) do facto* da desistência pelo agente, isto é, com a exigência de que o desistente tenha tomado o regresso ao direito, a inversão do perigo ou a reversibilidade do processo lesivo *nas suas próprias mãos*, que dele tenha tido o *senhorio*, de tal forma que possa afirmar-se que dele dependeu decisivamente o *se* e o *como* do abandono da execução ou do impedimento do resultado. Nesta acepção e com este sentido são perfeitamente aceitáveis formulações já correntes na doutrina como a de que a desistência é voluntária sempre que seja recondutível a uma motivação **autónoma** ou **auto-imposta**; o que pressupõe que o agente seja ainda **senhor da sua decisão** e não esteja submetido a uma pressão desrazoável da situação exógena sobre o cumprimento das suas intenções próprias, numa palavra, que tenha actuado **por impulso próprio**.

§ 40 Na origem da posição que acabámos de defender pode colocar-se a — hoje tão exautorada por uns, mas ainda defendida por outros ([71]) — chamada **fórmula de Frank**: "Voluntária é (...) a desistência apenas perante um motivo autónomo, auto-imposto, quando, por outras palavras, o autor diz: eu não quero alcançar a minha finalidade, ainda que o conseguisse (...) Em todos os outros casos a desistência é involuntária, nomeadamente quando o agente se diz: eu não consigo alcançar a minha finalidade, ainda que o quisesse" ([72]). Se a esta fórmula descontarmos o entono psicologista e a ligarmos à dualidade autonomia / heteronomia da determinação do desistente; e se, sobretudo, não reduzirmos a sua aplicabilidade preferencial aos casos em que ao agente se torna duvidoso o êxito ou o fracasso da tentativa — ela aponta já para o princípio normativo decisivo: o de a desistência surgir como obra do agente ou antes como determinada por constelações exógenas que estorvaram de forma sensível o cumprimento das intenções próprias do desistente. Não podemos por isso concordar com a conclusão contundente de Roxin segundo a qual "com o critério da autonomia / heteronomia tudo se pode provar e por isso nada se pode provar" ([73]). E para justificar a razão da nossa discordância nada será melhor do que lembrar a defesa procedente de Roxin do critério do "domínio do facto" como caracterizador da autoria nos crimes dolosos, nomeadamente, na base da validade e utilidade de conceitos que, não sendo fixos e definitórios, antes sim "abertos", traduzem todavia princípios normativos, parâmetros regulativos e orientadores da concreta aplicação do direito dos quais se não deve nem pode prescindir.

([71]) Asperamente criticada, por último, por ROXIN II, § 30, n.º 431 e ss. Entre os modernos defensores, por outros, em princípio, WELZEL, § 25, I, e, por inteiro, M / GÖSSEL, 41/118 e ss.

([72]) FRANK, § 46 II.

([73]) ROXIN II, § 30, n.º 434.

2. O tratamento dos casos

§ 41 Face ao critério que defendemos, cremos razoavelmente segura a solução de um largo círculo de hipóteses (74), todavia nem sempre coincidentes entre "psicologistas" e "normativistas". **Desistência voluntária** existirá assim, desde logo, nos casos da sua recondução a uma *motivação interior autónoma*, *v. g.*, quando *D* desiste da violação sexual em execução por se ter apiedado da vítima, que lhe implorava que a deixasse em paz, ou por "ter caído em si" e ganho consciência do carácter repugnante do acto em execução. Como existirá ainda nos casos em que o agente desiste, apesar de ter sido surpreendido pela ocorrência de circunstâncias que em alguma coisa *tornam a realização do facto mais difícil* ou *aumentam em uma qualquer medida o risco* de ser descoberto e punido; *v. g.*, se o marido, *E*, que se apresta a bater na mulher no decurso de uma querela, desiste do facto por entretanto terem surgido os filhos do casal, crianças, alertados pela discussão e ele desejar poupá-los à cena (75); ou se *F*, que se apresta a matar *G*, se deixa convencer pelos argumentos de um amigo que o acompanhava e cuja opinião muito respeita, no sentido de deixar a vítima viver; ou se *H*, assaltante de um banco, é surpreendido por uma instalação de alarme com que não contava mas que facilmente conseguiria desactivar e no entanto desiste. Em qualquer destas hipóteses, qualquer que tenha sido o grau de pressão psicológica das circunstâncias externas no sentido da desistência, é o agente que mantém o domínio da decisão e por conseguinte o senhorio do facto como um todo: a desistência é *obra sua*. **Desistência involuntária**, pelo contrário, existirá quando o agente abandona a execução ou impede o resultado em virtude do receio, fundado numa modificação das circunstâncias exteriores, de que a consumação possa ser impedida, ou que, após aquela, ele seja preso e (ou) punido ou desapossado dos produtos do crime. *V. g.*, se *I*, ao assaltar um banco, descobre que este está a ser rigorosamente vigiado ou toca inadvertidamente um alarme, ou que perto da pessoa que se propõe matar se encontra um polícia ou um segurança; ou se *J*, que se apresta a matar *L*, se apercebe de que a vítima responde de forma inesperadamente contundente à agressão. Involuntária será a desistência, em geral, sempre que o

(74) Casuística de grupos, a propósito, em ROXIN II, § 30, n.os 358-364 e 387-405.

(75) Caso análogo todavia decidido pelo BGH, *NStZ* 1994, no sentido da involuntariedade.

agente passa a acreditar não poder já alcançar a finalidade da sua acção, p. ex., porque o recheio da casa em que se introduziu e com que contava não existia mais; ou no caso em que o agente podia ainda consumar a realização típica, mas se apercebe de que todas as vantagens que do facto esperava tirar se esfumaram. Em todas estas hipóteses, um circunstancialismo exógeno inesperado sobrepõe-se ao cumprimento das intenções próprias do agente e fá-lo perder o senhorio ou o domínio da pretensa desistência.

§ 42 Mais difíceis são os casos em que a consumação da realização típica é possível mas a ela se ligam **desvantagens e riscos sensivelmente mais pesados** do que aqueles com que o agente à partida contava. Nestes casos pode tornar-se extremamente duvidoso decidir se a desistência se deve imputar ao próprio agente ou antes ao circunstancialismo exógeno. Critério decisivo parece-nos ser o de considerar a desistência *involuntária* apenas quando as desvantagens e riscos que estão ligados, nas representações do agente, à continuação da execução ou à verificação do resultado, uma vez comparadas com as vantagens e satisfações que do facto esperava retirar, surgem como **insuportavelmente pesadas**, de tal modo que seria de todo desrazoável aceitá-las ([76]). Apelar neste contexto (como insistentemente preconiza Roxin) para as "normas da razão criminosa" ou da "actividade delinquente" ([77]), para considerar a desistência voluntária unicamente quando as contraria, parece ser injustificado e ir longe demais. Porque o que está em questão é o concreto agente em uma concreta situação, não o "criminoso" e os *standards* de comportamento que porventura vigorem no seu especial círculo de vida ou profissional.

§ 43 Duvidosa é ainda a solução para os casos em que o agente desiste porque se apercebe que caiu em **erro sobre a identidade ou as características do objecto da acção**. Uma solução será a de remeter todos estes casos para o conceito de tentativa fracassada e logo a partir daí concluir pela irrelevância da desistência ([78]); outra a de, ainda relativamente a eles, distinguir a desistência involuntária da voluntária, segundo os critérios acima expostos (já supra, § 19). Negar em bloco toda a possibilidade de uma

---

([76]) Assim, STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 87. Num critério de (des)razoabilidade parecia também convir ROXIN, nota 67, p. 255 e s.

([77]) Assim, ROXIN, nota 67, pp. 256 e 271, e, de novo, ROXIN II, § 30, n.º 393 e ss.; também RUDOLPHI, *SK*, § 24, n.º 25.

([78]) Assim, ROXIN II, § 30, n.ºs 94 e ss. e 403.

desistência voluntária nestes casos parece-nos puro doutrinarismo, quase sempre desembocando em considerações "moralistas" que só aparentemente se casam com o fundamento político-criminal do privilégio da desistência: *v. g.*, se *M* se apresta a matar *N* que toma pelo amante da mulher, mas omite o disparo logo que se apercebe que o alvo é outra pessoa, não se vê qualquer razão válida, do ponto de vista político-criminal próprio do fundamento da desistência, para negar a sua voluntariedade: o regresso ao direito, a inversão do perigo, a reversibilidade do processo lesivo relativamente à vida de *N* são *obra sua*, que ele teve nas suas mãos, que dominou e sobre a qual tomou ele próprio posição. Isto vale igualmente para a chamada **tentativa sem sentido,** quando, não havendo erro sobre o objecto, todavia o motivo da acção desaparece por outra razão, *v. g.*, se, no caso anterior, *M* está de facto perante o homem que toma por amante da mulher mas este o convence de que está inocente daquilo que o agente lhe censura (79).

§ 44 Casos difíceis e ainda hoje altamente contestáveis na solução são aqueles em que o desistente **realiza uma parte do seu plano total mas desiste de uma outra parte que todavia podia realizar**, sendo certo que cada uma delas implicava a prática de um crime autónomo. É o caso decidido pelo BGH St, 35, 184: *O* quer matar a sua ex-mulher, *P*, e o novo amante dela, *Q*. *Q* aparece primeiro, *O* fere-o em termos de lhe impossibilitar a fuga mas, tendo surgido *P*, deixa *Q* com vida e mata a ex-mulher, que de outra forma poderia fugir e cuja morte *O* reputa "prioritária". A razão parece-nos estar do lado da jurisprudência, que decidiu por uma desistência *voluntária* do homicídio de *Q*, antes que de Roxin, que, entre outros, se pronuncia pela desistência involuntária (80): a decisão de *O* de deixar *Q* viver, além de "meritória" mesmo para uma concepção extremadamente normativa, é obra da pessoa do agente, autonomamente assumida e que de forma positiva lhe deve ser imputada. Mais contestável nos parece ainda concluir pela *involuntariedade* da desistência em função de o agente ter inesperadamente deparado com **consequências colaterais indesejadas da sua conduta**. No caso, *v. g.*, em que o terrorista *R* não espoleta a bomba com que se propõe matar os frequentadores de um restaurante porque no último instante se apercebe que entre os comensais estão os

(79) Nestes dois casos pronuncia-se, no entanto, ROXIN II, § 30, n.º 494 e s., pela *involuntariedade* da desistência.

(80) Para a discussão do caso, ROXIN II, § 30, n.º 358 e ss.

seus pais ([81]); ou porque cede à ameaça da sua mulher, *S*, de que se praticar o acto terrorista, ela se suicidará ([82]). Que já tenha sido possível às concepções normativas distinguir em casos destes a voluntariedade da involuntariedade consoante o agente tenha actuado "por amor" ou antes por motivos baixos relacionados, p. ex., com uma possível perda da herança ([83]): ou porque no primeiro caso o desistente teria agido contra as "regras da actividade delinquente", no segundo caso de acordo com elas (supra, § 42) — é para nós só a prova cabal da inadequação de toda esta argumentação e do inadmissível "moralismo" em que acaba por tropeçar e que temos criticado: decisivo é que, pura e simplesmente, num caso como no outro se verificou a reversão do processo lesivo como obra e por obra do agente e por isso a desistência deve considerar-se voluntária.

VIII. Efeitos e localização sistemática

§ 45 Nos termos do art. 24.º-1 a desistência voluntária implica a **impunidade da tentativa**. Face à larga insegurança e incerteza doutrinal e jurisprudencial ainda reinante no desenho das fronteiras da desistência voluntária ([84]), não falta quem se interrogue sobre se, em perspectiva político-criminal, não teria sido mais prudente da parte do legislador, em vez de consagrar uma tese rígida de impunidade, ter preferido uma regulamentação mais flexível que consagrasse, ao lado da possibilidade de **exclusão**, a de **atenuação** ([85]) (eventualmente *extraordinária*, nos termos do art. 73.º) da pena. Como de resto o nosso legislador fez em lugares paralelos, *v. g.*, nos já referidos arts. 299.º-4 e 300.º-6. Ele não se deixou no entanto motivar, em tese geral, por uma tal consideração, ainda a este propósito revelando uma atitude "amiga da desistência voluntária".

§ 46 Das diferentes orientações sobre o fundamento da impunidade da desistência voluntária da tentativa resultam divergências sobre a sua

([81]) Assim, todavia, ROXIN II, § 30, n.º 399 e ss. Contra, no sentido da conclusão do texto, BOTTKE, nota 7, p. 395 e s., e JÄGER, nota 13, p. 99 e s.

([82]) Assim, todavia, HERZBERG, nota 1, p. 352 e JÄGER, nota 13, p. 101.

([83]) Assim, ROXIN, nota 67, p. 264, reconhecendo agora todavia (II, § 30, n.º 402) que se trata aqui de "subtilezas não justiciáveis".

([84]) Cf., só, GOMES, Júlio, nota 1, p. 163, e ULSENHEIMER, nota 1, p. 346.

([85]) No mesmo sentido, GOMES, Júlio, nota 1, p. 164 e s., com largas indicações concordantes.

mais correcta **localização sistemática**. Os esforços para fazer operar esta impunidade **ao nível do tipo de ilícito** (como seu "elemento negativo" ou como causa de exclusão da tipicidade) **ou do tipo de culpa** (como causa de exclusão da culpa) não parece poderem aceitar-se pela natureza inadmissível de "retroacção" que possuem: a desistência supõe um tipo de ilícito e um tipo de culpa do facto tentado já integralmente verificados, não podendo, nesta medida e neste sentido, falar-se de uma sua eventual exclusão *a posteriori*, em função de circunstâncias ocorridas *ex post facto* (86).

§ 47 A consideração sistemática do efeito da desistência voluntária não pode assim ser outra que não seja a de um **pressuposto negativo da punibilidade** (supra, 26.º Cap.), concretamente, sob a forma de uma **causa pessoal de exclusão da pena** (87): a uma consideração conjunta da tentativa e da sua desistência — *hoc sensu*, a uma consideração da tentativa *e* da sua desistência ao nível de um "tipo total", à maneira de Lang-Hinrichsen —, a "imagem global do facto" fá-lo aparecer como *falho de dignidade penal* à luz de ideias de prevenção (88). Para quem, como nós, vê em considerações político-criminais, em particular de *falta de dignidade punitiva* do facto global, o fundamento do privilégio da desistência, a conclusão aparece como evidente; sendo ela válida mesmo para os casos especiais em que o efeito da "desistência" voluntária funciona para além da consumação formal (supra, § 29 e ss.). Acentuando nós por outro lado que desistência voluntária significa desistência como obra *do agente*, a *ele* imputável, o privilégio liga-se estritamente à conduta *pessoal* do desistente e não se estende à de outros comparticipantes.

§ 48 Se, todavia, a execução da tentativa se traduzir já na prática de um crime consumado (*v. g.*, uma ofensa da integridade física ou um dano consumados como actos de execução de um roubo, art. 210.º-1, ou um sequestro consumado com finalidade de violação sexual, art. 164.º), então esse crime-meio continuará a ser *punível* apesar da eventual desistência do crime-fim (casos chamados de **tentativa qualificada**). O que

---

(86) ROXIN, nota 67, p. 271 e ss., e § 30, n.º 29 e ss.

(87) Doutrina dominante entre nós: CORREIA, Eduardo, II, p. 236, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 415, FARIA, Ribeiro de, nota 9, p. 133 e ss.; como também na Alemanha: JESCHECK / WEIGEND, § 51, VI, com indicações concordantes.

(88) Nesta medida assistindo razão — em perspectiva político-criminal, que não dogmático-sistemática — a ROXIN II, § 30, n.º 29, quando concebe a desistência como uma causa de exclusão da "responsabilidade" jurídico-penal.

o art. 24.º recobre com o manto da impunidade é a desistência da *tentativa* como tal e só ela — e esta relaciona-se com o crime-fim. Um crime consumado não pode deixar de ser punível só porque surge como meio de cometimento *de um outro crime*. Questão que igualmente se tem suscitado é a de saber se será como acaba de dizer-se quando o crime consumado no decurso da tentativa é um **crime de perigo,** concreto ou abstracto. Todos estes problemas devem, porém, receber a sua solução no contexto da problemática relativa ao concurso de crimes (infra, 43.º Cap., § 30 e s.).

SUBTÍTULO V

A COMPARTICIPAÇÃO NOS CRIMES DOLOSOS DE ACÇÃO

30.º CAPÍTULO

A CONCEPÇÃO GERAL DA AUTORIA

I. A delimitação entre autoria e participação

§ 1 Toda a exposição anterior partiu, por regra, da assunção tácita de que a realização típica foi levada a cabo por **uma única** pessoa, individual ou colectiva. Por isso procurámos quase sempre usar — como também o faz, em princípio, a nossa lei — o termo descomprometido "agente" para designar aquela realidade. Todavia, muitas vezes na realização típica colaboram várias pessoas, uma *pluralidade de agentes*, então designadas por **comparticipantes** (1). Necessário se torna pois estudar (por ora restritamente aos crimes dolosos de acção) os diferentes *papéis* que os comparticipantes no cometimento de um crime, *rectior*, na realização ilícita típica, desempenharam, delimitá-los reciprocamente e determinar a forma e o quanto de punição de cada um deles. Terá, na verdade, o mesmo estatuto e a mesma responsabilidade jurídico-penal *A*, que matou *B* com um tiro; *C*, que utilizou *D*, oligofrénico profundo, para matar *E* com um tiro; *F*, que

---

(1) De um ponto de vista *etimológico* não tem porventura justificação bastante a distinção entre "comparticipante" e "participante", assumindo ela, por isso, valor puramente *convencional*. Nesta perspectiva, são "*com*participantes" todos aqueles agentes que, em caso de pluralidade, intervêm no facto; são "participantes" os comparticipantes que não são autores. Para melhor e mais fácil apreensão da matéria pelo estudante, por conseguinte, talvez valesse a pena substituir o designativo "comparticipantes" pelo de "pluralidade de agentes". Se, não obstante, mantemos a terminologia é porque ela assumiu foros de cidadania na doutrina penal portuguesa. Sobre a questão, MACHADO, Pedrosa, Para uma síntese do conceito jurídico-penal de comparticipação, *Ab Vno ad Omnes*, 1998, p. 763.

instigou (determinou) *G* a que matasse *H* com um tiro; *I*, que conjuntamente com *J* congeminou um plano para matarem *L*; ou *M*, que forneceu a *N* o revolver que este utilizou para matar *O*? Eis o que, na essência, cumpre agora dilucidar. Com formas — *paradigmaticamente*! — *diversas* (mas não as únicas excogitáveis ou experimentadas) de caminhar ao encontro das soluções dos problemas aqui implicados, altamente complexos e que continuam hoje tão questionáveis como ontem, deparamos nos arts. 19.°, 20.°, 22.° e 23.° do CP de 1886 (2), no art. 27.° do ProjPG de Eduardo Correia e nos arts. 26.° e 27.° do CP vigente.

§ 2 Os preceitos atinentes à matéria agora em estudo e contidos nos diplomas referidos logo permitem, na sua diversidade doutrinal e normativa, algumas conclusões importantes sobre a matéria e de relevo para uma sua introdução temática. Deve abstrair-se, desde logo, da figura do **encobridor** como comparticipante: não parece poder haver, por não ser nem normativamente adequada, nem em rigor facticamente pensável, uma *comparticipação ex post facto*, isto é, *depois* do facto ter sido cometido e o tipo de crime realizado: já o nosso CP de 1852 assim o considerava (arts. 197.° e s. e 431.°, § único); e, na verdade, o encobrimento pessoal e o encobrimento real (receptação) devem constituir crimes autónomos; e como tal são hoje descritos na PE: arts. 231.° e 367.° Feita esta redução, porém, dentro da categoria dos "comparticipantes" importa assinalar, de um ponto de vista normativo material, a existência de ao menos **duas** espécies de figurantes (eventualmente **três**), cujo *papel* na realização do tipo de ilícito é diferente e que por isso *devem* porventura, ou seguramente *podem*, ser jurídico-penalmente tratados de maneira diferente. Uma dessas categorias é a dos **autores,** que constituem a "figura central do acontecimento criminoso" (3) ou, como preferimos dizer e à frente ver-se-á porquê, o *"centro pessoal"* (4) *do ilícito típico*. Outra categoria é a dos **cúmplices**, que constituem figuras *laterais*, *secundárias* ou *de segunda linha* na integral realização ilícita típica (*hoc sensu*, meros *auxiliares* do autor); os quais, por outras palavras, não realizam o tipo de ilícito, mas participam de um tipo de ilícito realizado por outrem. Entre uma e outra situa-se a figura do **ins-**

(2) Em síntese sobre o direito anterior, CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 148 e ss.

(3) Assim mesmo, no seu conjunto, os define ROXIN desde o seu *Täterschaft und Tatherrschaft*, [1]1963, p. 25.

(4) A expressão é de WELZEL, § 15, *Einführung*, I.

tigador (aquele que determina dolosamente outrem à prática do facto), o qual, à partida, tanto pode constituir uma figura autónoma, como desempenhar um papel que seja ainda comportável por uma das duas categorias, ou em certas condições por uma, noutras condições por outra. Tudo considerado, tarefa inicial e primária de domínio de toda esta problemática — atento, em particular, o disposto nos arts. 26.º e 27.º — é a de estabelecer a essência do conceito de autoria (ou de "autor") e o fundamento da sua contraposição ao conceito de cumplicidade (ou de "cúmplice").

II. Os modelos e as concepções básicas

1. A teoria formal-objectiva

§ 3 Tal como vimos suceder em matéria de tentativa com a distinção entre actos preparatórios e actos de execução (supra, 28.º Cap., § 13 e ss.), também em tema de distinção entre autoria e participação, e por razões similares, o ponto de partida histórico e lógico vai encontrar-se numa consideração formal-objectiva: **autor é todo aquele que executa, total ou parcialmente, a conduta que realiza o tipo (de ilícito)** (5).

§ 4 Esta concepção é, em si mesma considerada, exacta e deve servir, sem tergiversações — que todavia a vários propósitos se verificam na doutrina mais recente —, como *ponto de partida* (6) e como *limite* obrigatórios de toda a elaboração dogmática do conceito de autoria. Com efeito, ela aponta para a ligação indissolúvel entre a figura do *autor* e a *realização do ilícito típico*, conferindo-lhe o sentido dogmático que não pode perder sem violação, inclusivamente, do princípio *nullum crimen sine lege* (7) e dando-lhe o lugar sistemático que verdadeiramente lhe cabe: o de capítulo (essencial) da teoria do ilícito típico. O que em desfavor dela se aponta é que — paralelamente ao que vimos acontecer com a correspondente teorização dos actos de execução na tentativa — ela não é, por si própria e sem outros desenvolvimentos, suficientemente explícita quanto à definição dos critérios prático-normativos da autoria, importando pro-

(5) Por outros, v. HIPPEL, II, p. 454, e MEZGER, p. 444.

(6) Nesta direcção agora também, ROXIN, *LK*, § 25, n.º 34.

(7) Nestes termos, DIAS, Figueiredo, Legalidade e tipo em Direito Penal, *Escritos Silva Franco*, 2003, p. 221 e ss.

curar, atrás das palavras da lei com que se exprime o tipo de ilícito, o que significa "executar o facto"; para o que se torna por sua vez indispensável determinar *que elementos do comportamento* assumem relevo para a distinção, e *porquê*. A isso vieram as chamadas teorias *material-objectivas*.

2. A teoria material-objectiva assente na "causalidade"

§ 5 Um modelo que, nesta linha, alcançou ao longo dos tempos larga divulgação e aceitação encontra-se na chamada teoria **unitária** da autoria. Ela visa, no princípio e no limite, tratar unitariamente — e, por conseguinte, por modo fundamentalmente igual — *todos* os comparticipantes no mesmo facto ilícito típico e, na verdade, tratá-los *como autores*. Autor é assim aquele que de uma qualquer forma executa o facto na acepção de que oferece uma contribuição **causal** para a realização típica, seja qual for a sua importância ou o seu significado. Diferenças intercedentes entre os diversos contributos causais só podem relevar para efeito de medida concreta da pena, mas não devem assumir significado dogmático ou prático-normativo para quaisquer outros efeitos (conceito **extensivo** de autor). Por isso este modelo — que, remontando a Farinacius, foi, nos tempos modernos, propugnado em certa medida por Feuerbach (8) e encontrou acolhimento no ProjPG de Eduardo Correia (9) — louva-se, além do mais, na extrema simplificação que parece oferecer a toda a doutrina da comparticipação e à consequente aplicação da lei (10).

§ 6 A esta concepção há que levantar todavia reservas que devem acabar por conduzir ao seu **repúdio**. Desde logo, ela não se compagina com

---

(8) FEUERBACH, § 44.

(9) "Art. 27.º: É punível como autor ou agente de um crime quem tiver dado causa à sua realização sob as formas seguintes: 1.º Executando-o singular e imediatamente; 2.º Executando-o imediatamente, por acordo e conjuntamente em outro ou outros; 3.º Determinando — quer singular, quer por acordo e conjuntamente com outro ou outros — directa e dolosamente alguém à prática de um facto ilícito, sempre que este, ao menos em começo de execução, se tenha praticado e não houvesse sido cometido sem aquela determinação; 4.º Determinando directa e dolosamente alguém à prática de um facto ilícito ou auxiliando-o dolosamente na sua execução, sempre que, tendo embora sem aquela determinação ou auxílio a execução sido levada a cabo, ela o fosse, todavia, por modo, tempo, lugar ou em circunstâncias diferentes. Esta última forma de comparticipação constitui a cumplicidade."

(10) O que levou CORREIA, Eduardo, nota 2, p. 121, a afirmar que, recusando esta concepção, "a doutrina alemã trabalhou, neste aspecto, quase um século em pura perda".

a nossa lei actual. A modificação que interveio no trânsito do art. 27.º do ProjPG de Eduardo Correia para os arts. 26.º e 27.º do CP vigente não pode imputar-se a mera alteração de redacção, antes significa o *abandono* da teoria em que aquele preceito assentava e a adopção de teoria diferente (se bem represente, a muitos títulos como se dirá infra, § 29 e s., uma solução "compromissória"). Indiscutível é que a cumplicidade não constitui *uma forma de autoria* a par de outras formas de autoria: ela é, na intenção legislativa, *coisa diversa*, como logo o indica a circunstância de constar de preceito diferente (art. 27.º) daquele em que se quis definir de forma esgotante a autoria e as suas formas possíveis (art. 26.º).

§ 7 De resto, uma concepção absolutamente **unitária** de autoria não foi nunca, ao que pudemos determinar, levada com *plena coerência* até ao fim. Uma tal concepção deveria limitar-se à afirmação apodíctica de que é autor de um crime *todo aquele que lhe tiver dado causa*, renunciando completamente à definição de quaisquer formas de autoria a que se atribuísse, *a priori*, um certo conteúdo prático-normativo e esperando que todas as diferenciações neste plano resultassem integralmente das normas e procedimentos judiciais em tema de medição concreta da pena. Uma tal concepção violaria porém uma vez mais, também neste plano, a lei expressa vigente: logo na parte em que o art. 27.º-2 *obriga*, em caso de cumplicidade, *a atenuar especialmente a pena fixada para o autor*; mas também na medida em que exige que a comparticipação, relativamente a diversas formas, seja dolosa, acrescentando assim um elemento, o *dolo*, que seguramente nada tem a ver com a categoria da causalidade. Exacto é, por outro lado e de todo o modo, que p. ex. Feuerbach não deixou de conceitualizar — de resto, com grande precisão — formas de autoria e de as distinguir de formas de participação ([11]); e exactamente a mesma coisa sucedeu com Eduardo Correia tanto nos seus trabalhos doutrinários, como legislativos ([12]).

§ 8 Tem-se alegado — ainda aqui recorrendo ao ensinamento de Farinacius — que uma distinção entre autoria e participação não poria em questão o dogma causal básico de que parte toda a concepção: ela operaria ainda **dentro da categoria da causalidade**, pondo em evidência a diferença que intercede entre o *auxiliator causam dans* — o verdadeiro *autor* ou *autor em sentido restritivo* — e o *auxiliator causam non dans*. O agente seria **autor** em sentido restrito se e onde pudesse afirmar-se que *o facto não teria sido cometido sem a sua actuação*; seria mero **partici-**

([11]) FEUERBACH, nota 8, loc. cit.

([12]) CORREIA, Eduardo, nota 2, p. 103 e ss., e II, § 12, n.º 41 e ss.; e o art. 27.º do seu ProjPG acabado de referir. Cf., também, à luz já do CP vigente, COSTA, Faria, As formas do crime, *JDC 1983*, p. 169 e ss.

pante (ou autor em sentido amplo) se *o facto ainda tivesse sido cometido sem a sua actuação*, embora o tivesse sido então por modo, em tempo, lugar e/ou em circunstâncias diferentes ([13]). Assim acabaria por se compatibilizar, dentro de supostos integral e estritamente causais, uma concepção *unitária* da autoria com um conceito *restritivo* de autor. Mas também este ensaio de preservar a categoria da causalidade como essência unitária de toda a comparticipação e de erigir uma espécie de **causalidade necessária** em fundamento e critério do conceito restritivo de autor não deve ser aceite.

§ 9 Desde logo, a existência ou inexistência de uma causalidade necessária radica, as mais das vezes, em puro **acaso**. Nem o autor tem por força de trazer à realização típica um contributo necessariamente causal, nem inversamente aquele que o tenha prestado tem por força de considerar-se autor: se duas pessoas subtraem conjuntamente uma coisa, não se vê por que razão uma delas deva deixar de considerar-se autor, sob a alegação de que a outra também a teria subtraído sozinha; como, inversamente, não se descortina fundamento para considerar que é autor de um crime de aborto o farmacêutico que vende ilegalmente a uma mulher um abortivo que ela usa com êxito, sob a alegação de que, sem aquela venda, a mulher não teria praticado o aborto.

§ 10 De resto, não faltarão casos em que o critério da causalidade necessária chegará a ser **impraticável**. Partindo, como será indispensável, do mundo das representações dos comparticipantes — e aqui ficará patente a infidelidade deste ponto de partida ao império exclusivo da categoria da causalidade —, a maior parte das vezes eles não poderão saber se o seu contributo causal para o facto é ou não "necessário". No exemplo acima apresentado, muito provavelmente nem o farmacêutico, nem a compradora chegarão alguma vez a saber — e o tribunal ver-se-á também na impossibilidade de afirmar — se o abortivo poderia ter sido conseguido noutra farmácia ou por outra via. E, de todo o modo, fica sem se compreender porque há-de o farmacêutico ser considerado autor ou mero cúmplice consoante não fosse ou fosse possível encontrar outro farmacêutico disposto a vender o abortivo.

([13]) Insistentemente e em pormenor, CORREIA, Eduardo, locs. cits.

§ 11 Em definitivo, nos termos do art. 26.º, autor não é quem *causa* o facto, mas quem o **executa**, directa ou indirectamente: e é isto que corresponde à exigência própria do Estado de Direito de que a punição se vincule e refira à **realização do tipo**. A "causalidade", já o vimos, é apenas uma primeira condição de toda a imputação objectiva (supra, 12.º Cap., § 4 e ss.) não tipicamente vinculada de forma específica e que não revela em si mesma capacidade nem para fundar as diversas formas de autoria; nem para as distinguir, em bloco, da participação; nem tão-pouco para explicar o regime que legalmente lhes é cabido seja no respeitante a certas exigências legais (máxime, o dolo), seja no que respeita à punição (atenuação especial obrigatória da pena).

§ 12 Ao que acresce, para nós decisivamente, o seguinte: se autor é quem realiza o facto típico e se todo o tipo é tipo de ilícito, então a essência da autoria tem de decorrer da **essência do ilícito**. E este, como sempre o afirmou Welzel e nós procurámos corroborar (supra, 10.º Cap., § 18 e ss., e 11.º Cap., § 9), surge em direito penal como ilícito **pessoal**, não como ilícito *causal* desprendido da pessoa do agente. Correcto só pode ser por isso um conceito restritivo de autor segundo o qual a autoria está vinculada ao sentido pessoal do ilícito vazado no tipo e, por aqui, à conduta ilícita típica. Uma concepção correcta de autoria terá por força de radicar na **realização pessoal de um ilícito típico**, não na sua "causação".

§ 13 Uma concepção **unitária** da autoria, as mais das vezes teoreticamente baseada na causalidade, constitui o ponto de partida — embora, em geral, não mais do que isso, criando a doutrina e a jurisprudência, quando não a própria lei, formas diferenciadas de autoria e contrapondo-as às formas de participação ou à cumplicidade — de sistemas como o austríaco, o italiano e o brasileiro ([14]); enquanto sistemas como o português, o alemão, o suíço, o espanhol e muitos outros aceitam e partem de um conceito restritivo de autor; na sua fundamentação dividem-se porém de novo

([14]) Cf. o art. 12 do CP austríaco e TRIFFTERER, *Die österreichische Beteiligungslehre*, 1983. A favor de uma concepção *funcional* unitária da autoria, em data recente, KIENAPFEL, *Der Einheitstäter im Strafrecht*, 1971 e (a propósito do direito austríaco) Zur Täterschaftsregelung im StGB, *ÖRiZ*, 1975, p. 165. Também o art. 110.º do CP italiano consagra uma concepção unitária da autoria: cf. SEMINARA, *Tecniche normative e concorso di persone nel reato*, 1987, e, com referência já às propostas de reforma, ROMANO, II, ²1996, Pre-Art. 110. Cf., por último, o art. 29 do CP brasileiro e, na doutrina, Ariel DOTTI, Cap. IX, e REALE Júnior, Cap. XIII.

as opiniões, assumindo hoje em dia particular relevo dois grupos de teorias (as "teorias subjectivas" e a teoria do "domínio do facto") ou tentando-se por forma variada a sua *combinação* ([15]).

3. As teorias subjectivas

§ 14 Perante a falência das teorias objectivas da autoria fundadas na categoria da causalidade e defensoras, por isso, de um conceito extensivo de autor, procurou-se no lado *subjectivo* do crime o fundamento da autoria. Este seria encontrado em realidades puramente internas ou psíquicas, sejam elas a vontade, a intenção, os motivos, os sentimentos ou as atitudes interiores do agente, por aí conduzindo à aceitação de um conceito de autoria que a distinguiria substancialmente da participação. Segundo uma formulação já antiga, mas ainda hoje porventura não superada, é autor quem realiza o facto com **vontade de autor** (com *animus auctoris*), participante quem colabora no facto de outrem com **vontade de partícipe** (com *animus socii*). Por outras palavras, o autor quer o facto *como próprio*, o partícipe quer o facto *como alheio*. É exacto que, ao longo da história dogmática das teorias subjectivas, a pureza inicial desta posição sobre o problema foi-se perdendo, nomeadamente com as discussões quanto ao que deva entender-se por "orientação da vontade" — que uns vão buscar à circunstância de o agente revelar no facto uma "vontade *independente*", enquanto outros o encontram na circunstância de ser dele o *interesse* da realização ([16]) — e com a sua progressiva contaminação com elementos de cariz objectivo, pedidos sobretudo às teorias que em seguida serão expostas, as teorias do "domínio do facto". Mas pode dizer-se que a sua concepção básica persistiu e constituiu (e continua ainda em muita parte a constituir) um estádio essencial da elaboração dogmática do nosso problema.

§ 15 Todavia, no seu núcleo fundamental, as teorias subjectivas **não podem ser aceites**. Desde logo porque o sentimento pessoal do agente não pode, em si mesmo, constituir critério da autoria: não é porque alguém **se sente autor** (por ter a ideia de ser a ele que pertence o papel mais importante na realização do facto, quando na verdade se limitou a colaborar no facto de outrem) que uma tal qualidade lhe deve passar a caber. E depois

---

([15]) Indicações mais amplas de direito comparado em JESCHECK / WEIGEND, § 61, VIII.

([16]) Uma excelente síntese em ROXIN, *LK*, § 25, n.º 3 e s.

porque, radicando as teorias subjectivas em elementos que — como a vontade, a intenção, os motivos —, na concepção "clássica" durante muito tempo imperante, eram imputados em exclusivo à culpa, a autoria não só se divorciava uma vez mais da realização típica de um *ilícito*, como ficava próxima a ideia (que deu base a muitas decisões jurisprudenciais, nomeadamente alemãs) de distinguir a autoria da participação consoante o facto surgisse, relativamente a um e outro agente, como **mais ou menos censurável**: o agente podia ser considerado como autor não porque tivesse realizado o facto, mas porque, não o tendo executado mas só nele colaborado, a sua posição aparecia mais censurável do que a do verdadeiro autor; e inversamente. O célebre "caso Stachynsky", decidido pela jurisprudência alemã, revela-se exemplar: um agente secreto da URSS matou em Munique, por ordem da polícia secreta soviética, dois refugiados opositores do regime comunista; o tribunal condenou-o como mero *cúmplice* do homicídio, porque a posição juridicamente mais censurável pertencia a quem lhe havia dado a ordem, enquanto o executor não teria tido nem nenhuma *vontade independente*, nem um *interesse próprio* na realização do facto.

4. A teoria do "domínio do facto"

§ 16 As considerações anteriores sugerem já que o verdadeiro critério da autoria e da sua distinção face à participação, ao menos nos delitos dolosos, não pode prescindir, na sua caracterização, de momentos objectivos e subjectivos — tal como vimos, de resto, que sucede com a doutrina do "ilícito pessoal". Há pois que tentar, de certo modo, uma *síntese* de ambas as concepções; não, todavia, no sentido de ensaiar uma *via per mezzo*, mas no de aproveitar os aspectos diferentes da questão que são correctamente caracterizados uns pelas teorias subjectivas, outros pelas objectivas. Nesta via se tornou hoje largamente dominante — na doutrina alemã, mas também na portuguesa, na espanhola, na de diversos países da América Latina, na coreana, na japonesa — a teoria do **domínio do facto**. Autor é, segundo esta concepção e de forma sintética e conclusiva, quem domina o facto, quem dele é "senhor", quem toma a execução "nas suas próprias mãos" de tal modo que dele depende decisivamente o *se* e o *como* da realização típica ([17]); nesta precisa acepção se podendo afir-

([17]) Distinguindo-se aqui por vezes um domínio *positivo* do facto (a capacidade de o fazer prosseguir até à consumação) e um domínio *negativo* (a capacidade de o fazer gorar): cf. entre

mar que o autor é a *figura central do acontecimento*. Assim se revela e concretiza a procurada *síntese*, que faz surgir o facto como unidade de sentido objectiva-subjectiva: ele aparece, numa sua vertente como obra de uma *vontade* que dirige o acontecimento, noutra vertente como fruto de uma contribuição para o acontecimento dotada de um determinado peso e significado objectivo.

§ 17 Na tentativa, em todo o caso, de se ir mais longe na determinação do sentido normativo da figura em apreço, não deixa de constituir um bordão precioso — como sempre — o estudo da sua **história dogmática** ([18]). A ideia terá sido preconizada pela primeira vez por Lobe, o qual, partindo embora das teorias subjectivas, acentua que não basta à autoria uma vontade de realização do tipo (elemento subjectivo), mas é preciso (elemento objectivo) "que a vontade também domine e dirija a execução que serve a sua realização... Na participação falta o domínio da acção de execução que tem por objectivo a produção do resultado". O passo seguinte — sem dúvida de maior ressonância — foi dado por Welzel que, lançando o conceito mesmo no centro da doutrina da acção final, defende que "o domínio do facto cabe àquele que leva até à execução a sua decisão volitiva consciente da finalidade" ([19]); ao mesmo tempo que acentua vivamente que esta concepção constitui apenas decorrência "das determinações fundamentais do conceito final de acção e do conceito pessoal do ilícito na acção dolosa" ([20]). Um enriquecimento e ao mesmo tempo uma inflexão decisivos do conceito ocorrem depois por obra de Gallas — que sustenta que a concepção do domínio do facto não é, ao contrário do que pensava Welzel e como a evolução posterior demonstrou, nada de consubstancial à doutrina da acção final —, ao colocar um elemento declaradamente *objectivo* como ponto de partida do conceito de domínio do facto que o vincula ao tipo de ilícito, e ao assinalar-lhe a função (normativa ou valorativa) de "parâmetro para uma interpretação mais aprofundada da conduta típica" ([21]). É todavia com Roxin e a sua monumental investigação dogmática, justamente intitulada *Autoria e Domínio do Facto* ([22]), que o conceito é largamente desenvolvido e preci-

---

nós e por outros VALDÁGUA, Conceição, *Início da Tentativa do Co-Autor — Contributo para a Teoria da Imputação do Facto na Co-Autoria*, ²1993, pp. 68 e ss., 133 e ss., 145 e ss., 162 e s.

([18]) Pormenorizadamente sobre quanto se segue ROXIN, nota 3, p. 60 e ss.

([19]) WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, *ZStW 58*, 1939, pp. 491 e ss., 543.

([20]) WELZEL, § 15, I.

([21]) GALLAS, *Materialien*, I, p. 121; e depois Die moderne Entwicklung der Begriffe Täterschaft und Teilnahme im Strafrecht, *ZStW*, n.º especial, 1957, p. 14. Um claro ponto de partida objectivo encontra-se também na doutrina defendida a este propósito por LUZÓN PEÑA, La determinación objetiva del hecho, *ADPCP 42*, 1989, p. 899 e ss., e por DÍAZ Y GARCÍA, *La autoría en Derecho Penal*, 1991; cf., por último, LUZÓN PEÑA / DÍAZ Y GARCÍA, Objektive Tatbestimmung und Tatbestandsverwirklichung als Täterschaftsmerkmale, *Roxin—FS*, 2001, p. 575.

([22]) ROXIN, nota 3, *passim*. A 1.ª edição é de 1963, a 7.ª edição de 2000. Cf., também, ROXIN, *LK*, § 25, n.º 30 e ss.

sado, conduzindo a conclusões claras, se bem que não conceitualmente "fechadas", e se arvora, assim, em uma verdadeira *teoria*.

§ 18 A doutrina roxiniana do domínio do facto sustenta, desde logo, que o conceito **não pode ser tomado como princípio universal** que sirva a caracterização da autoria relativamente a todo e qualquer tipo de ilícito. Ele não poderia ser arvorado em critério de autoria nem nos delitos *negligentes*, nem nos de *omissão*, nem nos por ele chamados "*delitos de dever*" (em que o facto é caracterizado em primeira linha não por uma acção, mas pela violação de um dever que recai unicamente sobre pessoas determinadas e de que constituem exemplo paradigmático os crimes específicos, mas também os crimes de omissão), nem nos *crimes de mão própria*. Em todos estes casos, segundo Roxin, é inadequado, quando não impossível, o apelo ao critério do domínio do facto, importando servir-se para caracterização da autoria de outros e diferentes critérios (23).

§ 19 O critério do domínio do facto deve pois restringir a sua validade, ainda segundo Roxin, aos "delitos dolosos gerais" — sem dúvida a esmagadora maioria dos crimes contidos na PE dos códigos penais (embora, também sem dúvida, uma maioria que mingua no âmbito do direito penal secundário) — que ele apelidou, consequentemente, **delitos de domínio** (*Herrschaftsdelikten*). "Senhor" do facto é nestes delitos — já o dissemos supra, § 16 — aquele que domina a execução típica, de tal modo que a ele cabe o papel director da iniciativa, interrupção, continuação e consumação da realização, dependendo estas, de forma decisiva, da sua vontade. A uma concretização desta ideia rectora serve, de resto, o nosso próprio sistema legal, pelo menos na medida em que o art. 26.º individualiza e distingue a autoria imediata, a autoria mediata e a co-autoria. Correspondendo a este terceto de formas de autoria depara-se, na verdade, com três tipos diversos de domínio do facto. O agente pode dominar o facto desde logo na medida em que é *ele próprio* quem procede à realização típica, quem leva a cabo o comportamento com o seu próprio corpo (é o chamado por Roxin **domínio da acção** que caracteriza a *autoria imediata*). Mas pode também dominar o facto e a realização típica mesmo sem nela fisicamente participar, quando domina o executante através de coacção, de erro ou de um aparelho organizado de poder (quando possui o **domínio da vontade** do exe-

(23) ROXIN, nota 3, pp. 352 e ss. e 392 e ss.

cutante que caracteriza a *autoria mediata*). Como pode ainda dominar o facto através de uma divisão de tarefas com outros agentes, desde que, durante a execução, possua uma função relevante para a realização típica (possuindo o que Roxin chamou o **domínio funcional do facto** que constitui o signo distintivo da *co-autoria*) (24).

§ 20 Pese ao que ficou dito, o conceito de domínio do facto está **longe de ser unívoco**. Quando uma pluralidade de agentes comparticipa num facto — e é só nesse caso que assume relevo prático-normativo a distinção dos papéis de cada um perante a execução — nem sempre é fácil definir e autonomizar com exactidão, mesmo em consideração apenas dos crimes dolosos de acção, o contributo de cada um para a realização típica. Mas nem por isso se dirá com justeza tratar-se aqui de um "conceito indeterminado", como tal imprestável para a aplicação do direito penal no momento de fundamentação da responsabilidade. O que sucede, sim, é que não deparamos aqui com um conceito definitório e apto à subsunção. Correcto é qualificá-lo, convém o próprio Roxin, como um **conceito aberto** (25), isto é, como um parâmetro regulativo, cujo conteúdo é susceptível de adaptar-se às variadíssimas situações concretas da vida a que se aplica e que só na aplicação alcança a sua medida máxima de concretização. Mas seja embora assim, deve em todo o caso convir-se que se trata do ponto de vista orientador que mais fecundo se revela para a investigação e concretização do significado jurídico-penal de cada uma das variantes que o contributo do agente para a realização típica dolosa pode assumir.

5. Conclusões

§ 21 São pois muitas as dúvidas e incertezas que subsistem ainda na teoria do domínio do facto como doutrina geral da essência da autoria e do seu critério de delimitação perante a participação. No entanto, do anteriormente exposto parece desde já poderem ser retiradas algumas conclusões gerais. E desde logo a de que uma concepção **unitária** de autoria e um conceito **extensivo** de autor nem estão de acordo com a nossa lei vigente, nem devem doutrinalmente ser aceites relativamente aos delitos dolosos de acção. Um conceito **restritivo** de autor, por outro lado, não pode

(24) ROXIN, nota 3, pp. 127 e ss., 141 e ss. e 275 e ss.
(25) ROXIN, nota 3, p. 122 e ss., e *LK*, § 25, n.º 34.

apresentar-se como um conceito fixo e, muito menos, imediatamente apto à subsunção, antes tem de aceitar-se como aberto e multifacetado, consoante a espécie de autoria a que se aplica e a estrutura ilícita típica que está em causa. Há nesta matéria, em todo o caso, uma outra asserção que deve reputar-se fundamental: a de que a autoria é, mais que uma decorrência, verdadeiramente um **elemento essencial do ilícito típico**. Por isso, a unidade de sentido da autoria, por um lado, participa da natureza do *ilícito pessoal*, do ilícito que é "obra de uma pessoa"; por outro lado liga-se indissoluvelmente à *realização do tipo* como exigência primária do princípio da legalidade. Levando esta ideia até ao fim, em termos sistemáticos, deve concordar-se com todos aqueles autores que tratam a questão da autoria (e da participação) como um capítulo ainda do estudo do tipo de ilícito e não como uma "forma especial do crime" ([26]).

§ 22 A doutrina do **domínio do facto** é, dentre todas as que têm sido defendidas em tema de autoria nos crimes dolosos de acção, a que melhor se casa, quando correctamente entendida, com a asserção básica acabada de expor. Não se deverá portanto afirmar, com Engisch, que com ela "nada de verdadeiramente novo se ganhou, a não ser uma imagem" ([27]). Deve pelo contrário asseverar-se que com o "domínio do facto" se ganhou o essencial, exactamente, um **princípio normativo** ligado à realização do ilícito típico e, por isso, decisivo para a compreensão e a descoberta do sentido daquilo que está em causa na autoria. Ponto é, segundo nos parece, que se compreenda e aceite ainda que o domínio do facto não constitui apenas um composto de elementos objectivos e subjectivos do ilícito, mas se traduz sempre numa **valoração** que exprime uma síntese de elementos psicológicos e normativos; no sentido de que se é verdade que o conceito tem que ver com o desempenho pessoal do agente no acontecimento, não o é menos que a avaliação e o significado jurídicos que devam ser atribuídos àquele desempenho são comandados "de fora", assumem o carácter de uma valoração em função do significado *social* que o contributo do agente para o facto representa ([28]). Por isso o conceito básico do domínio do facto

([26]) Precursor, WELZEL, § 15.

([27]) ENGISCH, Bietet die Entwicklung..., *ZStW 66*, 1954, p. 383 e s.

([28]) A questão da natureza normativa (-social), psicológica ou psicológico-normativa do domínio do facto continua hoje a ser extraordinariamente discutida na doutrina alemã. Cf., para os distintos pareceres, GALLAS, *Materialien* nota 20, p. 102, HÜNERFELD, Mittelbare Täterschaft und Anstiftung..., *ZStW 99*, 1987, p. 239 e s., JESCHECK / WEIGEND, § 62, II, 7, ROXIN,

pode e deve ser *afeiçoado* e *precisado segundo as circunstâncias do caso* e, nomeadamente, à luz da análise das diversas espécies (também legais) de autoria e mesmo dos resultados que devam ser alcançados em tema de doutrina da participação.

6. Limites do critério do domínio do facto

§ 23 O critério do domínio do facto como princípio normativo da categoria da autoria, como vimos insistindo, só foi pensado e deve ser aplicado aos **crimes dolosos de acção**. Duas razões dão base, logo em via de princípio, a esta afirmação. A primeira é a de que o domínio do facto — embora, como se disse no § 17, não seja consubstancial à doutrina da acção final — se liga indissoluvelmente, de um ponto de vista psicológico, a um *controlo do acontecimento pela vontade do agente* e não tem por isso cabimento, *ab initio*, nos **crimes negligentes** (cf. infra, 35.º Cap., § 46). A outra razão deriva de que a ideia fundante do domínio do facto só quer responder basicamente, como assinalámos, à questão de saber quem dirigiu a execução da acção que realiza o tipo. Por isso, logo também à partida, o critério do domínio do facto não tem cabimento nos **crimes de omissão**, nos quais o agente *não* executa ou dirige a execução da acção esperada (mais de espaço: infra, 40.º Cap., § 9 e ss.). O problema mais complexo neste contexto provém, no entanto, da circunstância de vários tipos de ilícito dolosos de acção exigirem não apenas o dolo do agente, mas ainda **elementos adicionais**. Isso sucede fundamentalmente nas situações seguintes:

§ 24 **a)** Naqueles casos em que o tipo de ilícito exige, como vimos supra, 13.º Cap., § 55 e ss., para além do dolo do tipo, **elementos subjectivos especiais**, nomeadamente, uma certa intenção, determinados motivos ou certas características da atitude interna. Em todos estes casos *autor* será apenas quem, detendo o domínio do facto, realize a acção *com os elementos subjectivos especiais tipicamente requeridos pelo ilícito respectivo*.

§ 25 **b)** Coisa análoga sucederá com os **crimes específicos**, em que sobre o autor recai uma qualidade ou uma relação (e o consequente

---

LK, § 25, n.º 137 e s., STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 40, WELZEL, § 15, II, 3. O carácter *normativo* da distinção entre autoria e participação vem sendo fortemente acentuado pela jurisprudência alemã mais recente, a ponto de, entre outros, ROXIN, *LK*, § 25, n.º 20, falar já a propósito de uma "teoria normativa da combinação".

dever) especiais (supra, 11.º Cap., § 34 e ss.). Nesta medida, a questão da autoria suscita-se — e deve ser resolvida — **em termos substancialmente idênticos** aos que ocorrem nos chamados "delitos de domínio". O que sucede é só que nos crimes específicos, para definição da autoria, ao critério do domínio do facto **acresce a violação do dever típico especial por quem dele é titular** (29) (e também por aquele[s] a quem esta qualidade se "comunique", nos termos do art. 28.º: infra, 33.º Cap., § 15 e ss.).

§ 26 Roxin — e muitos AA. que hoje o seguem nesta construção — apela para a categoria que chama dos **delitos de dever** e que englobaria, para além dos delitos específicos ou de certos deles (30), aqueles cuja descrição típica não compreenderia nenhuma "acção" — em sentido fáctico, digamos —, mas se deixaria preencher pela pura violação de um dever (e de que seria exemplo característico o do delito de infidelidade patrimonial, tal como se encontra previsto no § 266 do CP alemão). Nestes casos o critério do domínio do facto teria de ser pura e simplesmente *abandonado* e substituído pelo da **violação do dever especial pelo seu titular** (31). Não nos parece, porém, que deva admitir-se esta construção. Por um lado, se uma tal doutrina quer significar que qualquer contributo para o facto, mesmo o mais longínquo, lateral ou meramente auxiliar, funda a *autoria* desde que proveniente do titular do dever, então de novo se quebra a ligação da autoria à realização do ilícito típico e se põem em causa (32) as exigências do princípio da legalidade. Por outra parte, um tipo de ilícito construído *exclusivamente* sobre a violação de um dever, eventualmente referida a um resultado, incorre na fundada suspeita de possuir um grau de *indeterminabilidade* dificilmente compatível, também ele, com as exigências do princípio *nullum crimen sine lege*. Mal descortinamos, no ordenamento jurídico-penal português vigente, tipos de ilícito construídos desta forma, que renunciem à descrição, à menção ou, ao menos, à pressuposição indiscutível da prática de uma *acção* (33).

§ 27 **c)** Quanto, finalmente, aos chamados **crimes de mão própria**, eles só existirão onde tenha sido intenção da lei construir o tipo de ilícito

---

(29) Assim, entre nós, BELEZA, Teresa, A estrutura da autoria nos crimes de violação de dever — Titularidade *versus* domínio do facto, *RPCC 2*, 1992, p. 337, e SOUSA, Susana Aires de, A autoria nos crimes específicos: algumas considerações sobre o art. 28.º do Código Penal, *RPCC 15*, 2005, p. 348 e ss.

(30) Tudo dependendo, em último termo, do conceito de delito específico de que se parte.

(31) ROXIN, nota 3, p. 352 e ss., e agora II, § 25, n.º 267 e ss.

(32) Como certeiramente anotam STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 40.

(33) Uma tal construção não vale entre nós para um caso como o da *infidelidade patrimonial* (art. 224.º), devendo acentuar-se que o preceito português é tipicamente mais determinado que o homólogo germânico. Já, porém, um preceito como o do art. 382.º (abuso de poder) pode ser, ao menos em parte, altamente contestável do ponto de vista aqui em apreço.

por forma tal que autor só possa ser aquele que *realiza, ele próprio, a acção* (*hoc sensu, com o seu próprio corpo*) e em que, por conseguinte, o facto só possa ser cometido em **autoria imediata**. Quando a função do direito penal era vista como tutela de uma ordem moral e se não ligava exclusivamente à protecção de bens jurídico-penais (supra, 6.º Cap., § 11 e ss.), não seria difícil encontrar tipos deste teor, máxime, no âmbito dos crimes sexuais ou da relevância jurídico-penal de certas formas de vida ou da própria personalidade do agente ([34]); como o não será se e na medida em que, no âmbito da "sociedade do risco", se der lugar a um puro "direito penal do comportamento" cindido da protecção de bens jurídicos concretos, individuais ou colectivos (cf. supra, 6.º Cap., §§ 55 e s., 66) ([35]). Num direito penal *do facto* e *do bem jurídico*, porém, não é fácil compreender a eventual intenção legislativa de considerar autor unicamente quem realiza corporalmente a acção típica, *diminuindo com isto drasticamente o âmbito de protecção da norma*.

§ 28 Não falta no entanto quem entenda persistirem ainda no nosso direito tipos de ilícito deste teor, *v. g.*, os de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência ou de pessoa internada ([36]), de fraude sexual e de actos exibicionistas ([37]), de actos sexuais com adolescentes ([38]), de embriaguez e intoxicação ([39]), de falsas declarações ([40]). Determiná-lo em definitivo é assim, notoriamente, tarefa própria do estudo da PE. Certo e relevante no contexto presente é que onde um crime de mão própria deva ser reconhecido, autor não será todo aquele que detiver o domínio do facto, mas só aquele que, **detendo-o, realize, ele próprio, a acção típica (autor imediato)** ([41]).

([34]) Cf., p. ex., as "formas de vida" referidas no art. 71.º do nosso CP de 1886 (na redacção dada pela Reforma de 1954): vadios, mendigos, rufiões, prostitutas, proxenetas, corruptores de menores, receptadores, malfeitores.

([35]) Sobre a questão cf., por último, se bem que com conclusões não totalmente concordantes, STRATENWERTH, Gibt es eigenhändige Delikte?, *ZStR 115*, 1997, p. 86, e ROXIN II, § 25, n.º 297 e ss.

([36]) Cf. DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 165.º, § 11, e art. 166.º, § 17.

([37]) Cf. RODRIGUES, Anabela, *Comentário Conimbricense*, I, art. 167.º, § 14, e art. 171.º, § 22.

([38]) Cf. DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 174.º, § 21.

([39]) Cf. CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, II, art. 295.º, § 37.

([40]) Levanta dúvidas SEIÇA, Medina de, *Comentário Conimbricense*, III, art. 360.º, § 62 e ss.

([41]) Levando agora a defesa (dogmática) dos crimes de mão própria até aos limites, nomeadamente, em tema de compatibilidade com a doutrina da autoria mediata, para concluir todavia cepticamente sobre o futuro de tal espécie de crimes, GÓMEZ Rivero, M.ª Carmen, Queda algo aún de los llamados delitos de propia mano?, *Revista Penal 18*, 2006, p. 102.

III. O direito português vigente (42)

§ 29 Foi uma concepção do tipo da assinalada que esteve na base da diferença radical que em matéria de autoria e participação se verifica entre o art. 27.º do ProjPG, por uma parte, e os arts. 26.º e 27.º do CP vigente, por outra. Tanto mais quanto — circunstância que parece ter sido até agora completamente desconsiderada ou insuficientemente considerada pela doutrina — o art. 32.º da revisão do ProjPG, levada a cabo por Antunes Varela como Ministro da Justiça, considerava a indução (essencial) como forma de autoria, enquanto integrava a contribuição não essencial para a decisão do autor como forma de cumplicidade (43). A redacção encontrada para os actuais arts. 26.º e 27.º do CP representou, de alguma forma, o produto de uma *transacção* (44) entre a concepção causalista de Eduardo Correia e a teoria do domínio do facto. O acordo obtido nesta matéria terá derivado mais, no entanto, da convicção de que o texto aprovado permitia soluções dos problemas concretos da comparticipação razoáveis e justas do que de qualquer unanimidade na compreensão dos fundamentos doutrinais sobre os quais a interpretação e aplicação deveria assentar no futuro. Os pontos mais relevantes de um tal acordo traduziram-se: (1) na redefinição das diversas formas de autoria (infra, 31.º Cap., II) e na autonomização da cumplicidade (infra, Cap. 32.º), em suma, por conseguinte, na aceitação de um conceito restritivo de autor nos crimes dolosos de acção; (2) na consideração da instigação entre as formas de autoria e não como entidade a subsumir, juntamente com a cumplicidade, a um conceito superior de participação ou tão-pouco como *tertium genus* a considerar autonomamente entre a autoria e a cumplicidade (infra, 31.º Cap., § 43 e ss.); (3) na manutenção no essencial, no art. 28.º, da doutrina dita da

---

(42) Sobre a matéria deste apartado cf. DIAS, Figueiredo, La instigación como autoría — Un *requiem* por la "participación"como categoría de la dogmática jurídico-penal portuguesa?, *Livro de Homenaje a Gonzalo Rodríguez Mourullo*, 2005, p. 342.

(43) Era o seguinte o texto daquele art. 32.º: "1. Diz-se autor do crime aquele que o executa ou toma parte directa na sua execução; e ainda aquele que dolosamente induz outrem à prática do facto ilícito, desde que haja execução ou começo de execução. 2. Há cumplicidade quando alguém contribui, directa e dolosamente, para que outrem se decida à prática do facto ilícito, ou quando dolosamente o auxilia na sua execução, sempre que a contribuição ou auxílio não tenha sido essencial para a execução do crime, mas tenha influído decisivamente no modo, tempo, lugar ou circunstâncias em que ele foi praticado". Cf. *Projecto de Código Penal. Parte Geral, 1.ª Revisão Ministerial*, 1966.

(44) Muito justamente intuída por BELEZA, Teresa, nota 28, p. 339.

"comunicabilidade das circunstâncias relativas ao ilícito", todavia com a ressalva, constante da parte final do n.º 1, de poder ser outra "a intenção da norma incriminadora" (infra, 33.º Cap., § 15 e ss.).

§ 30 Estamos em posição de afirmar o que acabamos de expor porque as alterações que deram origem aos arts. 26.º e 27.º hoje vigentes foram por nós mesmo redigidas no seio de um *petit comité* (designado pelo então Secretário de Estado Menéres Pimentel e constituído por Eduardo Correia e Figueiredo Dias, sob a presidência do Conselheiro do STJ Miguel Caeiro) que teve por missão uma nova revisão do ProjPG de Eduardo Correia de 1963, quando foi politicamente decidido retomar os trabalhos de reforma. Estamos em posição de o afirmar, mas não de oferecer "prova", porque quem de direito entendeu não serem necessárias nem convenientes actas das reuniões, que tiveram lugar no Ministério da Justiça durante os primeiros meses de 1976. Foi uma consideração do tipo da assinalada que esteve na base da alteração, dissemos acima, quando relacionada com o autêntico *tournant* que a doutrina da autoria havia sofrido depois da publicação por Claus Roxin da sua obra fundamental sobre "autoria e domínio do facto" (45). Obra que despertava em Eduardo Correia um sentimento misto de discordância face às teses centrais (e muitas pioneiras) ali defendidas, mas também de irrestrita admiração e respeito pelo significado científico e pela altura intelectual da investigação nessa obra levada a cabo.

(45) ROXIN, nota 3.

31.º CAPÍTULO

AS CONCRETAS FORMAS DA AUTORIA

I. A autoria imediata

§ 1 De acordo com o art. 26.º, 1.ª alternativa, é punível como autor "quem executar o facto, **por si mesmo**". Trata-se do doutrinalmente chamado **autor imediato**. Na sua aparente clareza e simplicidade, no entanto, a definição não dá pontos de vista bastantes para decidir, em hipóteses complexas de pluralidade de agentes (1), quando pode o facto dizer-se executado **por si mesmo** e não por intermédio de outrem ou juntamente com outros: resolver a questão — ao menos por uma forma negativa, isto é, por exclusão das restantes — só deixa todavia decidir-se quando sejam conhecidas já as características das outras formas de autoria. Em todo o caso, fica o critério essencial: autor imediato é aquele que executa o facto por suas próprias mãos, em termos de preencher **na sua pessoa** a totalidade dos elementos objectivos e subjectivos do ilícito típico e deter por isso, na expressão de Roxin, o **domínio da acção** (2) Em casos tais cumpre-se seguramente, pelo menos, o conteúdo de sentido próprio da teoria formal-objectiva (supra, 30.º Cap., § 3) (3).

II. A autoria mediata

§ 2 A 2.ª alternativa do art. 26.º considera punível como autor "quem executar o facto (...) **por intermédio de outrem**". De um ponto de vista

---

(1) Quando haja unidade de agente estaremos perante a chamada *autoria singular*; como também quando se verifique pluralidade de agentes mas todos os outros devam ser considerados meros cúmplices.

(2) Cf., por último, ROXIN II, § 25, n.º 43.

(3) Em termos dubitativos relativamente a certas hipóteses, todavia, STRATENWERTH / / KUHLEN, § 12, n.ºs 28 e 34.

estrutural existe pois sempre nesta figura um "homem-de-trás" ou "da retaguarda" — precisamente aquele por cuja autoria se pergunta — e um "homem-da-frente", o executor, intermediário ou "instrumento" (que pode ser jurídico-penalmente irresponsável ou parcialmente responsável: cf. infra, § 5). O princípio do *domínio do facto*, quando aplicado à autoria mediata, exige que todo o acontecimento (o "facto", nos termo do art. 26.º) seja obra do homem-de-trás, em especial, da sua vontade responsável, só nesta acepção se podendo qualificar o homem-da-frente como instrumento. O que vale por dizer que *todos os pressupostos de punibilidade* têm de concorrer na pessoa do homem-de-trás e hão-de colocar-se, para efeito da sua caracterização dogmática, unicamente face a ele.

§ 3 Isto sucederá em geral, como bem pensa Roxin, quando possa afirmar-se que o homem-de-trás possui sobre o homem-da-frente o **domínio da vontade** (4), o que paradigmaticamente sucederá em duas situações: quando o homem-de-trás coage o homem-da-frente à prática da acção (**domínio da vontade por coacção**) ou quando o engana e o torna assim em executor involuntário do seu plano delituoso (**domínio da vontade por erro**). Se a estas situações haverá que acrescentar outras ainda — nomeadamente, segundo a construção de Roxin, as de domínio da vontade nos quadros de aparelhos organizados de poder — é coisa que à frente se tentará dilucidar (infra, §§ 25 e ss., 56 e ss.).

§ 4 A autoria mediata constitui assim uma figura jurídica que de algum modo se apresenta como herdeira *in partibus* da antiga categoria da autoria **moral ou intelectual** e na qual reentrariam todas as situações em que alguém usasse, motivasse ou determinasse outrem à prática de um delito, desde que este constituísse uma consequência previsível da conduta do primeiro; categoria que, deste modo, não autonomizava também a figura da *instigação*, cujo conteúdo integrava, juntamente com a autoria mediata, o âmbito da autoria moral ou intelectual (5). Esta concepção, porém, entrou em crise no momento em que começou a colocar-se o "domínio do facto" como categoria-chave da autoria. A partir daquele tornava-se conveniente — ou assim o entendeu e entende a doutrina alemã praticamente unânime e fundada nos §§ 25 e 26 do CP respectivo — distinguir e autonomizar os conceitos de autoria mediata e de instigação, na medida em que naquele, sendo o facto cometido *por intermédio de outrem*, o homem-de-trás não perderia o seu domínio do facto; enquanto na instigação a *determinação* de alguém, *plenamente responsável*, à prática de um facto faria perder ao

(4) Por último, ROXIN II, § 25, n.º 45 e s.

(5) Neste sentido, CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 129 e ss., e II, p. 251 e s., e (tendo já em atenção o CP vigente) FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 480 e ss.

homem-de-trás o domínio do facto, devendo então ser o homem-da-frente considerado autor e o homem-de-trás simples participante.

§ 5 Temos esta forma de conceber as coisas, no entanto, por **infundada** (como melhor se verá quando tratarmos — como o art. 26.º, 4.ª alternativa, efectivamente trata — da instigação ainda como forma de autoria); sem que com isso, no entanto, queiramos fazer reviver a categoria da autoria moral ou intelectual e pôr por essa via em causa a autonomia da categoria da autoria mediata face à da instigação. Na verdade, como fundamento desta autonomia está a ideia de que a autoria mediata termina — e começa eventualmente a instigação — em função daquilo que uma parte da doutrina vem chamando "**princípio da (auto-)responsabilidade**" (6); e que conduz a que do âmbito da autoria mediata sejam excluídas todas as situações em que entre a conduta do homem-de-trás e o delito se interponha a actuação de um homem-da-frente (ou executor) **plenamente responsável**, isto é, que actue a título de **culpa dolosa**. Só quando tal não suceda, quando o executor não surja, na acepção predita, como plenamente responsável — e portanto tenha actuado, face ao homem-de-trás, sob a sua influência e, nesta acepção, numa posição subordinada — se pode considerar que o homem-de-trás (autor mediato) "executou" o facto "por intermédio de outrem" ou, como se exprime unanimemente a doutrina, servindo-se do homem-da-frente "como *instrumento*". Assim deixam as categorias da autoria mediata e da instigação de conviver sob o "chapéu-de-chuva" da autoria moral ou intelectual e ganham autonomia recíproca. Tudo está agora em concretizar os casos e as circunstâncias nos quais, na acepção referida, o facto foi cometido pelo homem-de-trás por intermédio de outrem, por um seu instrumento, e conduz, portanto, à sua consideração como autor mediato. Diversos grupos de situações podem e devem distinguir-se.

1. O instrumento (homem-da-frente) actua atipicamente

1.1. Por não praticar uma acção

§ 6 Não pertencem em rigor a esta problemática as situações em que o instrumento **não chega a levar a cabo uma acção em sentido juri-**

(6) Tal como no texto JESCHECK / WEIGEND, § 62, I, 2. Sobre o referido princípio, neste contexto, ROXIN, *Täterschaft und Tatherrschaft*, ⁷2000, p. 143 e ss.; e depois HERZBERG, *Täterschaft und Teilnahme*, 1977; e de algum modo já a importante (e a certos títulos pioneira) monografia de SCHROEDER, F-C., *Der Täter hinter dem Täter*, 1965. Posição esta completamente secundada, entre nós, pelo Ac. da RP de 1-10-2003, *CJ XXVIII*, IV-2003, p. 213.

dico-penal, mas é apenas utilizado por outrem como puro corpo ou forma de acção (dir-se-ia, como "projéctil"). Por ex., quando, no decurso de uma rixa, *A* ergue *B* e o atira contra *C* para ofender a integridade física deste, ou se serve, para o mesmo efeito, de actos puramente reflexos de *B*. Nestes casos *A* não se serviu de *B* como instrumento, antes foi ele que praticou a acção: por isso *A* não é autor mediato, mas **imediato** (7).

1.2. Por intervir quanto a ele uma causa de exclusão da tipicidade

§ 7 Já cabem nos quadros da doutrina da autoria mediata, porém, certos casos em que o instrumento pratica uma acção que, se cometida pelo homem-de-trás, constituiria um ilícito típico, mas, cometida por aquele, surge como **atípica**, porventura mesmo logo ao nível do tipo objectivo. Isto pode suceder, pensamos, naquelas situações em que, relativamente ao instrumento, mas não ao homem-de-trás, intervenha uma **causa de exclusão da tipicidade**.

1.3. Por ser a própria vítima

§ 8 Esse será, no fundo, o caso em que a atipicidade — ainda a nível do tipo objectivo — provenha da circunstância de o instrumento ser **a própria vítima** e de a acção não ser típica quando cometida por ela: é o que se verifica, nomeadamente, com a lesão da integridade física ou com o dano, em que a lei arvora em requisito da tipicidade que se trate da lesão "de outra pessoa" ou da danificação de "coisa alheia" (arts. 131.º, 143.º e 212.º) (8). Nestas situações, ou o homem-de-trás pode ser considerado autor ou, não podendo, ficará impune por a simples cumplicidade não ser aqui punível em virtude da falta do ilícito-típico principal (regra da acessoriedade: cf. infra, 32.º Cap., § 13 e ss.). Se a vítima age **não detendo o domínio do facto**, mas por força, *v. g.*, de coacção ou de erro provocados ou explorados pelo homem-de-trás, a autoria mediata parece dever ser afirmada. Se *A* convence *B* de que desligou a corrente eléctrica e este pode por isso proceder a uma reparação, *A* é autor (restando saber se não é mesmo autor imediato ou se ainda tem algum interesse prático-normativo considerá-lo autor mediato)

---

(7) Por outros, SAMSON, *SK*, § 25, n.º 44, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 32.

(8) Para os distintos pareceres, JESCHECK / WEIGEND, § 62, II, 1, ROXIN, Die Mitwirkung beim Suizid — ein Tötungsdelikt?, *Dreher–FS*, 1977, p. 331, *LK*, § 25, n.º 106 e ss., e II, § 25, n.º 68 e ss., STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 68 e ss.

da morte por electrocussão ou da lesão corporal de *B*. Já as coisas serão diferentes se a vítima **detém o domínio do facto** relativamente à sua autolesão ou à destruição de coisa própria. Aqui não há lugar para a autoria mediata: ou se verifica por parte do homem-de-trás uma verdadeira *determinação* do homem-da-frente, nos termos da 4.ª alternativa do art. 26.º, e ele é não autor mediato, mas *instigador*; ou não há e o homem-de-trás ficará impune. Não se vendo, em definitivo, justificação para uma certa doutrina que pretende fundar a autoria mediata em pequenas deficiências provocadas ou exploradas na autodeterminação da vítima (infra, § 56) (9).

§ 9 A situação parece complicar-se relativamente aos casos em que a morte do homem-da-frente ocorre por força de *suicídio*, porquanto o incitamennto e o auxílio ao suicídio são na ordem jurídica portguesa (diferentemente do que sucede, p. ex., na Alemanha e na Bélgica) previstos como crime autónomo (10). Todavia, a verdade é que a solução aqui apontada persistirá se o homem-de-trás — detiver o domínio do facto da morte, caso em que ele deverá continuar a ser tido como autor mediato (eventualmente instigador) da morte, nos termos preditos.

1.4. Por actuar sem dolo do tipo

§ 10 As hipóteses mais frequentes que neste contexto devem ser consideradas são aquelas em que o instrumento actua **sem dolo do tipo**: o homem-da-frente pratica uma acção que preenche o tipo objectivo de ilícito, mas não o tipo subjectivo correspondente, por lhe faltar o dolo, nomeadamente, por força de um **erro sobre a factualidade típica** dolosamente causado ou explorado pelo homem-de-trás. Por ex., *A* serve-se de *B* para entregar a *C* um pacote que diz conter umas compotas quando, na verdade, contém explosivos que determinam ferimentos ou a morte de *C*: *A* é autor mediato do delito, neste contexto falando Roxin, justamente, de autoria mediata em função do "**domínio do erro**". A mesma solução deve apon-

---

(9) Assim, HERZBERG, nota 6, p. 39 e ss. Minuciosamente sobre a questão, ROXIN II, § 25, n.º 54 e ss.

(10) Sobre os problemas de comparticipação aqui implicados (que no texto não serão levados mais longe por se tratar de questão da PE), ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, 1999, art. 135.º, § 16 e ss. e *passim*. Uma solução, esta da nossa lei, que, ao menos em termos de simplificação dos problemas da autoria mediata tendo a vítima como instrumento, é saudada por vários autores alemães, por ex., por STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 72.

tar-se para os casos em que o homem-de-trás explore uma actuação que o instrumento leva a cabo com mera **negligência inconsciente** ([11]). Mas as opiniões já se dividem se o homem-da-frente actuar com **negligência consciente**, *v. g.* (modificando em alguma medida o "caso Lacmann" referido supra, 13.º Cap., § 43), quando *A* dispara contra a rapariga sem se conformar com a possibilidade de a atingir, mas ferindo-a na realidade, enquanto *B*, que com ele apostou, quer que a lesão se produza ou pelo menos conformou-se com esta possibilidade. Parece-nos, em definitivo, que ainda aqui deverá aceitar-se a autoria mediata de *B*, na base de que quem se serve da inconsideração de outrem para a realização de um facto também o orienta e domina ([12]): tanto mais quanto o executor não é "plenamente responsável", isto é, punível a título de dolo.

§ 11 Importa acentuar que a autoria mediata deve ser afirmada não apenas quando o homem-de-trás *provoca* o erro do executor, mas também quando simplesmente o **explora** ou **dele se serve** para cometimento do facto ([13]) (da mesma forma que é autor quem se serve de um acontecimento natural, *v. g.*, de uma trovoada que causa um princípio de incêndio, inutilizando a sirene que daria o alarme). Num caso como no outro o homem-da-frente torna-se, no dizer de Roxin, em mero "factor causal" de que se serve para o seu desígnio o homem-de-trás, ele é "instrumento" e o facto é cometido "por intermédio" dele. Sem que, por isso, importe saber se a contribuição objectiva para o facto do homem-de-trás é "meramente *subordinada*" relativamente ao facto executado e constituiria por isso, caso o homem-da-frente actuasse *com dolo*, mera *cumplicidade*. Assim, pois, existe autoria mediata se *A*, apercebendo-se de que *B* gostaria de atirar sobre aquilo que julga ser uma peça de caça mas é realmente o camponês *C*, não o adverte do engano e lhe passa para a mão a sua caçadeira, com a qual *B* atira, ferindo ou matando *C*; ou se *D* substitui às escondidas um medicamento por um veneno letal, que a enfermeira *E*, não suspeitando da troca, dá a beber à doente *F*, de quem *D* tem pressa em herdar; ou mesmo se *G*, dando-se conta de que *H* considera erradamente que um móvel lhe

---

([11]) JESCHECK / WEIGEND, § 62, II, 2, ROXIN, *Täterschaft und Tatherrschaft*, ¹1963, p. 178 e s., STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 34.

([12]) Assim, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 36, a quem pertence o exemplo dado; cf., agora também, ROXIN, *LK*, § 25, n.º 77, e II, § 25, n.º 65.

([13]) Orientação hoje absolutamente dominante na doutrina alemã. Aprofundadamente, ROXIN, nota 11, p. 173 e ss., *LK*, § 25, n.º 75, e II, § 25, n.º 64.

pertence e deseja destruí-lo (o que *G* igualmente quer), lhe passa para as mãos um machado que *H* utiliza para o efeito. Decisivo nestes casos é que a contribuição oferecida ao facto pelo homem-de-trás, quando ligada ao desconhecimento da total factualidade pelo executor instrumentalizado, serve para fundar o domínio do facto por parte daquele.

2. O instrumento actua licitamente

§ 12 Trata-se aqui dos casos em que o intermediário instrumentalizado preenche, com a sua acção, o tipo incriminador, mas, no entanto, actua licitamente (justificadamente). Tais casos serão, na prática, pouco frequentes, mas não impossíveis de configurar face ao nosso direito vigente: *v. g.*, o juiz *A*, por puro sentimento de vingança contra *C*, ordena ao polícia *B* que proceda à detenção daquele, sabendo que, no caso, não estão presentes os pressupostos de legalidade da detenção. A questão que se suscita é a de saber se, apesar da licitude (justificação) da acção de *B* (14), *A* deve ser considerado autor mediato do sequestro de *C*. Uma resposta afirmativa de princípio é aceitável, na base, precisamente, do **conhecimento real da situação** pelo homem-de-trás, aliado ao domínio da vontade do executor e à circunstância de, face ao *engano* (ou à *ameaça*) neste produzido, ele *dever* levar a cabo a acção para assim agir de acordo com o direito: o *conjunto* destas circunstâncias oferece ao homem-de-trás o domínio do facto e conduz à afirmação da autoria mediata (15).

§ 13 Afirma-se também correntemente que, se o homem-de-trás provocou uma situação de **legítima defesa** ou de **estado de necessidade justificante** e por isso o homem-da-frente — ameaçado ou enganado sobre a verdadeira situação e actuando assim como instrumento — pratica um facto justificado, a autoria mediata do homem-de-trás deve ser aceite sempre que ele detenha o domínio do facto perante o instrumento e perante o atingido. Esta solução está também de acordo com a ideia de que deve ser responsabilizado jurídico-penalmente por uma realização típica aquele que cria dolosamente uma situação de coacção que só pode ser eliminada atra-

---

(14) Por força do disposto no art. 205.º da CRP: cf. BRANDÃO, Nuno, *Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal*, 2006, p. 259 e ss.

(15) Doutrina também dominante na Alemanha: JESCHECK / WEIGEND, § 62, II, 3, S / S / CRAMER / HEINE, § 25, n.º 26 e ss., ROXIN II, § 25, n.º 68, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 42 e ss.

vés da lesão de um dos bens jurídicos naquela co-envolvidos. Stratenwerth acentua — julgamos que com razão — que a solução não pode ser diferente da que se apontou para a "criação intencionalmente provocada de uma situação de legítima defesa" (supra, 15.º Cap., § 33), na qual o ameaçado ou enganado é em certa medida utilizado, ele próprio, como instrumento que age licitamente" ([16]). Verdade é porém que, nos casos de erro, o instrumento actuará em princípio, não justificadamente, mas em *erro sobre os pressupostos de uma causa de justificação*, *v. g.*, quando *A* convence falsamente *B* que *C* está a ponto de o agredir, pelo que *B* exerce contra ele legítima defesa putativa. Este erro, em nossa opinião como se disse (supra, 14.º Cap., § 23 e ss., e 20.º Cap., § 40), não exclui o dolo do tipo ([17]) e não deve por isso, em rigor, entrar aqui em consideração; mas exclui, de todo modo, o *dolo da culpa*, o que basta (infra, § 14 e ss.) para retirar ao homem-da-frente a "plena responsabilidade" e para se poder afirmar que o homem-de-trás detém o domínio do facto.

3. O instrumento actua sem culpa

§ 14 As dúvidas doutrinais na afirmação de uma autoria mediata sobem de ponto, sobretudo na doutrina alemã, quando se trata (como no caso acabado de apresentar de erro sobre os pressupostos de uma causa de justificação) de o homem-de-trás explorar situações em que o instrumento pratica um ilícito tipicamente doloso mas não pode, relativamente a ele, ser afirmada a sua **culpa dolosa**. Decisivo da qualificação do homem-de-trás como autor mediato deve continuar a ser aqui o critério do *domínio do facto*, fundado no *domínio da vontade* do executor por coacção ou engano (mesmo que estes provenham, por seu turno, da exploração pelo homem-de-trás da debilidade ou da dependência psíquicas do executor). Nos casos em que tal se não verifique e o executor seja plenamente responsável (isto é, responsável a título de dolo) não existirá autoria mediata; o que pode é existir instigação ou, eventualmente, cumplicidade ([18]).

([16]) STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 44. No essencial da solução convêm também HERZBERG, nota 6, p. 29, JAKOBS, 21/85, JESCHECK / WEIGEND, § 62, II, 3, ROXIN, *LK*, § 25, n.º 69, e II, § 25, n.º 67.

([17]) Diferentemente, ROXIN II, § 25, n.º 67, salientando todavia que mesmo admitindo-se a solução do texto a questão da autoria mediata não pode ser decidida em sentido diverso.

([18]) Em geral com maior liberalidade — forçada pela circunstância de reputar sempre a instigação como participação — a generalidade da doutrina alemã (cujos pareceres estão longe

3.1. Por falta de imputabilidade

§ 15 Autoria mediata existirá seguramente, desde logo, quando o instrumento actua em estado de **inimputabilidade**, em virtude de idade ou de anomalia mental, permanente ou transitória. Uma vez que aí estão quebradas, por definição, as conexões objectivas de sentido entre o agente e o facto (supra, 21.º Cap., § 17 e ss.), não parece poder afirmar-se que o homem-da-frente possui o *domínio* do facto, ainda quando possa defender-se que ele actuou com dolo do tipo. O princípio da auto-responsabilidade para o qual temos apelado como critério definidor das fronteiras da autoria mediata, se bem não deva divorciar-se por inteiro da realidade fáctica, é em último termo um critério jurídico-normativo de imputação. E isso é decisivo: seja qual for o domínio "fáctico" do acontecimento que possa ter tido na sua actuação: *v. g.*, um agente imediato de 15 anos não pode ser juridicamente responsabilizado pelo facto e, nessa medida, pode e deve ser visto como intermediário instrumentalizado pelo homem-de-trás.

§ 16 Já o mesmo se não dirá porém, ao menos em princípio, relativamente aos casos de mera **imputabilidade diminuída**, nomeadamente, quando esta seja tomada como capacidade diminuída de avaliar a ilicitude do facto ou de se determinar de acordo com esta avaliação ([19]) (art. 20.º-1 e, criticamente sobre esta concepção, supra, 21.º Cap., § 21 e ss.). Quando aquela "diminuição" se entenda porém, como nós entendemos, como abrangendo os casos em que é *duvidosa* ou só *parcial* a compreensibilidade das conexões de sentido do agente imediato com o facto, talvez não deva *a priori* excluir-se de todo a possibilidade de autoria mediata do homem-de-trás; a decisão de casos deste teor em função do "domínio do facto", ligado a um domínio da vontade e à consequente dependência psicológica do homem-da-frente perante o homem-de-trás, dependerá em medida significativa, e aqui mesmo dominante, não da "realidade fáctico-psicoló-

---

porém de se apresentarem concordantes): cf., entre outros, JESCHECK / WEIGEND, § 62, II, 4, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 46 e ss., ROXIN, nota 11, p. 591, e II, § 25, n.º 58 e ss.

([19]) A favor de diferenciações nestas situações, em todo o caso, ROXIN, *LK*, § 25, n.º 120, e II, § 25, n.º 150 e ss. No sentido de deixar funcionar ainda aqui por inteiro o princípio da responsabilidade e, consequentemente, de negar a autoria mediata STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 52, na base, todavia de uma ideia de imputabilidade diminuída como capacidade diminuída de agir de outra maneira.

gica", mas da *valoração jurídica* da situação ([20]) em função do disposto no art. 20.°-2 e 3.

3.2. Por actuar sem consciência do ilícito

§ 17 Autoria mediata do homem-de-trás deve também ser admitida nos casos em que o homem-da-frente agiu com falta de consciência do ilícito **não censurável**, intencionalmente criada por aquele ou, no conhecimento de que ela existia, por ele explorada. A falta de domínio do facto do homem-da-frente parece clara, em virtude do *erro de valoração* em que versa (supra, 20.° Cap., § 27 e ss.) e lhe retira a consciência de agir contra o direito. Diferentemente, o homem-de-trás, criando o engano no executor ou dele se servindo, detém por essa via o domínio do acontecimento.

§ 18 Questão é saber se o mesmo deve afirmar-se quando o homem-da-frente actua sem consciência do ilícito **censurável**. A este propósito se divide a doutrina germânica, sustentando uns que não pode falar-se de autoria mediata quando o homem-da-frente actua, apesar do erro, de forma responsável (concepção dita da "participação") ([21]), enquanto outros defendem que o que está em questão não é a falta de consciência do ilícito, mas a provocação do homem-de-trás da decisão para o facto (concepção dita da "autoria") ([22]). Cremos que, ao menos em princípio, quem age com falta de consciência da ilicitude censurável, assumindo (embora por vezes nem isso: supra, 23.° Cap., § 28 e ss.) menor culpa, não deixa todavia de ser completamente responsável pelo facto cometido. A ser assim, o princípio da auto-responsabilidade conduz a negar ao homem-da-frente a qualidade de "instrumento" e ao homem-de-trás a de autor mediato. E conforta-nos nesta convicção a circunstância de autores haver que dão voz à ideia segundo a qual não deve falar-se de autoria mediata — mas, no máximo, de instigação — naqueles casos em que a falta de consciência do ilícito do

---

([20]) "Um problema de valoração em aberto" lhe chamou com plena razão o Tribunal Federal alemão: BGHSt 35, 353.

([21]) Assim, entre outros, JAKOBS, 21/96, JESCHECK / WEIGEND, § 62, II, 5, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.° 55.

([22]) Ao menos tendencialmente, entre outros, HERZBERG, nota 6, p. 23, KÜHL, § 20, n.° 77 e ss., e, sobretudo, ROXIN, nota 11, p. 658 e ss., Bemerkungen zum "Täter hinter dem Täter", *Lange—FS*, 1976, p. 173 e ss., *LK*, § 25, n.° 83 e ss., e II, § 25, n.° 79 e ss.

executor é recondutível a uma "inimizade ao direito" ([23]). Efectivamente, como dissemos (supra, 20.º Cap., §§ 27 e 32), toda a verdadeira falta de consciência do ilícito radica em um erro "moral", erro de valor, erro da consciência ética, que se aproxima materialmente da ideia que através da fórmula da "inimizade ao direito" se procura traduzir.

3.3. Por actuar em estado de necessidade desculpante

§ 19 Larga concordância existe relativamente aos casos em que o instrumento actua em estado de necessidade desculpante, nos termos do art. 35.º Quem, dolosamente, lança outrem, por coacção, engano ou expediente equiparável, numa situação prevista no art. 35.º-1, é, ainda aqui em sintonia com o princípio da auto-responsabilidade, autor mediato do facto necessitado. Diferentemente, quem depara com uma situação de necessidade desculpante já constituída e determina o necessitado à prática do facto, máxime, com ameaças, ou apenas a fomenta com conselhos, solicitações ou apoios ao necessitado, mas sem transformar a situação existente em desfavor da vítima do facto, não pode ser autor mediato mas apenas, consoante o caso, instigador ou cúmplice. Doutrina que deve valer, também aqui, apenas para o caso de *exclusão* da culpa do homem-da-frente, mas já não para o da sua mera *atenuação* ([24]).

4. Ao instrumento falta a qualificação ou a intenção tipicamente requeridas

§ 20 Trata-se aqui do caso particular em que ao executor falta a qualificação (*v. g.*, a qualidade de "funcionário" para efeito dos arts. 375.º ou 380.º) ou a especial intenção (*v. g.*, a de apropriação ou de enriquecimento em múltiplos crimes patrimoniais) tipicamente requeridas para fundamentação ou agravação da responsabilidade. Tais casos suscitam, como referimos já (supra, 30.º Cap., § 24 e ss.), dificuldades muito particulares à doutrina do domínio do facto. No direito português, porém, a questão relativa à falta de certas qualidades ou de relações especiais do agente tem de levar em conta o disposto no art. 28.º sobre a chamada **comunicabilidade ou incomunicabilidade das**

([23]) HÜNERFELD, Mittelbare Täterschaft und Anstiftung im Kriminalstrafrecht der BRD, *ZStW 99*, 1987, p. 244, OTTO, Mittelbare Täterschaft und Verbotsirrtum, *Roxin—FS*, 2001, pp. 483 e ss., 490 e s., ROXIN II, § 25, n.º 84 e ss.

([24]) Doutrina dominante na Alemanha: HÜNERFELD, nota 23, p. 239, JAKOBS, 21/96, JESCHECK / WEIGEND, § 62, II, 6, ROXIN, nota 11 p. 153, *LK*, § 25, n.º 61, e II, n.º 47 e ss., STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 56 e ss.

circunstâncias. Esta problemática constitui no entanto uma questão comum à autoria e à participação (cumplicidade), pelo que será autonomamente estudada em momento posterior (infra, 33.º Cap., § 15 e ss.).

5. O "instrumento" actua de forma plenamente responsável (?)

§ 21 Como se acentuou já por diversas vezes na exposição anterior, a doutrina da autoria mediata assenta, em nossa opinião, na ideia mestra de que ela só pode verificar-se quando, por força da actuação do homem-de-trás, o homem-da-frente realiza o tipo de ilícito **de forma não (totalmente, dolosamente) responsável**. Se esta condição básica se não verifica a qualificação que pode caber ao homem-de-trás é a de *instigador* (eventualmente a de *co-autor* ou a de *cúmplice*), não a de autor mediato. *Nesta medida*, o reconhecimento da figura de um **autor atrás do autor** (25) (ambos plenamente responsáveis) — uma vez ainda: face ao princípio fundamental da auto-responsabilidade — **não é dogmaticamente concebível no quadro da autoria mediata**.

§ 22 Em data recente, todavia, uma parte da doutrina alemã tem-se sentido na necessidade de atenuar progressivamente, a *vários* títulos e com *diversos* fundamentos, a condição básica referida e de admitir em certos casos especiais a figura do "autor (mediato) atrás do autor" no sentido referido, é dizer portanto, a **compatibilidade** entre um homem-da-frente que actua de forma plenamente responsável e um homem-de-trás ainda punível como autor mediato. Necessidade tornada premente — e que leva uma parte da doutrina a falar já neste preciso contexto de uma **teoria limitada da auto-responsabilidade** (26) — pela circunstância de aquela doutrina continuar fiel ao dogma segundo o qual, de acordo com a teoria do domínio do facto, *o instigador não seria nunca autor, mas mero participante*; ficando, deste modo, sujeito aos princípios limitadores da punibilidade da participação (nomeadamente, o princípio da acessoriedade) e da sua menor punição. Dogma que no entanto, como à frente se verá (infra, § 40 e ss.), não tem de ser *como tal* aceite entre nós face ao art. 26.º, 4.ª alternativa, devendo pelo contrário ser decididamente contrariado, ao menos *de lege lata*: segundo o direito português vigente, as hipóteses de instigação

(25) Sobre esta figura, SCHROEDER, nota 6.

(26) Assim chamada por Hillenkamp, ao que informa KOHL, § 20, n.º 80.

que constituam verdadeira "determinação" devem não apenas ser *punidas* como autoria, mas ser consideradas *verdadeira* autoria. Com tal reserva e prevenção, vejamos quais as hipóteses em que a referida parte da doutrina alemã pretende hoje afirmar a autoria mediata do homem-de-trás apesar de o homem-da-frente (ainda "instrumento" ?!) agir de forma plenamente responsável e, por conseguinte, à custa da figura da instigação.

5.1. Os casos ditos de erro sobre o "sentido concreto da acção"

§ 23 Entrariam desde logo aqui em consideração aqueles casos em que o homem-da-frente conhece todas as circunstâncias necessárias à efectivação da sua responsabilidade dolosa pelo facto que executa mas, no entanto, erra (por força de engano provocado ou explorado pelo homem-de-trás) sobre outras circunstâncias também elas juridicamente relevantes para exacta caracterização do conteúdo do ilícito típico: nestas situações a doutrina alemã fala hoje de um *erro sobre o sentido concreto da acção*. Uma parte dela — na qual se destaca de novo Roxin — quer admitir ainda nestes casos a autoria mediata daquele que cria no homem-da-frente um tal erro ou dele se aproveita, sobretudo na base de que, de outra forma, se produzirão **lacunas de punibilidade** dificilmente suportáveis, derivadas da circunstância de o homem-de-trás só poder ser então considerado mero participante. Roxin individualiza, a propósito, três grupos de situações: **(1)** a do erro sobre a **quantificação do ilícito ou da culpa**, *v. g.*, sobre o grau de ofensa à saúde de outra pessoa no caso do art. 143.º-1 ou da intensidade dolorosa da doença no caso do art. 144.º/*c)*; **(2)** a do erro sobre **circunstâncias qualificativas do facto**, *v. g.*, o valor elevado ou consideravelmente elevado da coisa danificada para efeito do disposto no art. 213.º-1/*a)* e 2/*a)*; e **(3)** a do *error in persona* ou erro sobre a **identidade da vítima** ([27]).

§ 24 Não parece porém que em qualquer destas hipóteses haja razão bastante para alargar, contra a sua razão de ser, os princípios essenciais da autoria mediata, tanto menos quanto deva considerar-se que a instigação é

([27]) ROXIN, II, § 25, n.º 96 e ss., e já antes nota 11, p. 213 e ss., e *Lange—FS* nota 22, p. 184 e ss.; em parte também KÜHL, § 20, n.º 74, e S / S / CRAMER / HEINE, § 25, n.º 23 e s. Contra, em geral no sentido das conclusões do texto, HÜNERFELD, nota 23, p. 242 e s., JAKOBS 21/101, JESCHECH / WEIGEND, § 62, II, 2, SAMSON, *SK*, § 25, n.º 104, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 60 e ss.

verdadeira autoria: ou o erro em que incorre o instrumento e foi provocado ou explorado pelo homem-de-trás *exclui o dolo do tipo* e o homem-de-trás é, nos termos gerais (supra, § 9), *autor mediato* (como, entre nós, claramente sucederá no caso (2) relativamente ao delito qualificado projectado pelo homem-de-trás); ou *não o exclui* e o homem-de-trás só deverá ser considerado *instigador* ou *cúmplice*, podendo a influência do seu conhecimento especial ser ponderada em termos de medida da pena. Não se vê que, de forma particular no direito português, se possam verificar nestas situações lacunas intoleráveis de punibilidade.

5.2. Os "aparelhos organizados de poder" e o "domínio da organização"

§ 25 Defende Roxin que num outro caso especial deve ser atribuída a qualidade de autor mediato (e não a de co-autor, de instigador ou de cúmplice) ao homem-de-trás, apesar de também o homem-da-frente actuar de forma plenamente responsável: tal sucederá relativamente aos crimes cometidos no quadro de um *aparelho organizado de poder* ([28]). A autoria mediata do homem-de-trás (do "homem sentado à secretária") fundar-se-á nestes casos em que ele detém o **domínio da organização**. Organizações ou centros organizados de poder existem, na verdade, que, estruturados hierarquicamente e dotados de forte disciplina interna, assumem um modo de funcionamento quase "automático" para os que a eles pertencem, adquirindo estes a natureza de meros "instrumentos" que reagem de forma mecânica às ordens ou instruções dos seus chefes. Dada a grande disponibilidade de meios de tais organizações — que assim se apresentam como "unidades funcionais" com vida própria, independente dos concretos indivíduos que a compõem —, o executor do crime surge como elemento *fungível* que, mesmo quando actue com culpa dolosa, em nada afecta o verdadeiro domínio do facto do homem-de-trás. O "domínio da organização" constitui por conseguinte — suposta a *hierarquização rígida* da estrutura organizatória, a *fungibilidade* do agente e a actuação da organização *fora do quadro da ordem jurídica* ([29]) — uma forma de **domínio**

([28]) ROXIN, nota 11, p. 125 e ss., 127 e ss. e 242 e ss., Straftaten im Rahmen organisatorischer Machtapparate, *GA*, 1963, p. 200 e ss., *Lange—FS* nota 22, p. 192 e ss., *LK*, § 25, n.º 128 e ss., e II, § 25, n.º 105 e ss.

([29]) Põe em causa este requisito, AMBOS, Tatherrschaft durch Willensherrschaft kraft organisatorischer Machtapparate, *GA*, 1998, p. 241 e ss.; contestou-o DIAS, Figueiredo, *Questões*

da vontade que, indiferente à atitude subjectivo-psicológica do homem-da-frente, integra um fundamento autónomo da autoria mediata.

§ 26 A partir daqui, Roxin concretizou estes requisitos em dois tipos de situações, a elas resumindo o **âmbito** da categoria: a de uma organização política, militar ou policial que se apodera do aparelho do Estado (e de que podem constituir exemplos o sistema nacional-socialista alemão, o regime comunista da ex-RDA ou as ditaduras militares da América Latina); e a de movimentos clandestinos, organizações secretas e associações criminosas ("mafias") com objectivos adversos à ordem jurídica estabelecida e que, pelo poder de que dispõem, como que constituem um "Estado dentro do Estado" ([30]). A questão hoje mais debatida neste contexto — estreitamente ligada à referida querela sobre a exigência de que a organização actue fora do quadro da ordem jurídica — é a de saber se deve estender-se o domínio da organização a delitos praticados no âmbito da **criminalidade empresarial**. Roxin, seguido nesta parte pela maioria da doutrina, incluída a portuguesa ([31]), tem-se mostrado contrário — salvo porventura em casos excepcionais —a um tal alargamento ([32]). Outro âmbito em que o conceito do "domínio da organização" — não necessariamente ligado, em todo o caso, à afirmação de uma autoria "mediata" — está a introduzir-se (compreensivelmente) com êxito é o do **direito penal internacional** ([33]).

§ 27 A doutrina de Roxin sobre o "domínio da organização" como categoria que, ao lado das do "domínio do erro" e do "domínio da coacção", integraria o "domínio da vontade" que se apresenta como fundamento da autoria mediata, vem merecendo largo acolhimento doutrinal ([34]),

---

Fundamentais do Direito Penal Revisitadas, 1999, p. 364 e ss. (versão portuguesa do artigo Autoría y participación en el dominio de la criminalidad organizada: el "dominio de la organización", publicado *in*: Ferré Olivé / Anarte Borallo [orgs.], *Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos*, 1999, p. 99 e ss.). Por último, sobre a questão, Muñoz Conde, Willensherrschaft kraft organisatorischer Machtapparate im Rahmen "nichtrechtsgelöster" Organisationen?, *Roxin–FS*, 2001, p. 609, e Roxin II, § 25, n.º 129 e ss.

([30]) Herzberg, nota 6, p. 76, e [82], restringe o âmbito da categoria à primeira das situações referidas; criticamente Dias, Figueiredo, nota 29, p. 367.

([31]) Serra, Teresa, A autoria mediata através do domínio de um aparelho organizado de poder, *RPCC 5*, 1995, p. 303, com indicações bibliográficas alemãs. Cf. ainda — omitindo uma posição sobre o fundo da questão, mas parecendo inclinar-se para que só em casos contados a actividade empresarial possa entrar no âmbito da autoria mediata pela via do domínio da organização (ou, como agora prefere, pela via da submissão voluntária do executor à decisão do autor mediato: cf. infra, [37] e § 27) — Valdágua, Conceição, Figura central, aliciamento e autoria mediata, *Estudos Cunha Rodrigues*, I, p. 923 e ss.[25].

([32]) Cf., por último, Roxin II, § 25, n.º 129 e ss.

([33]) Cf. Ambos, *Der Allgemeiner Teil des Völkerstrafrechts*, 2002, p. 590 e ss.

([34]) Cf., entre outros, Herzberg, nota 6, p. 42 e s., M / Gössel, § 48, n.º 88, S / S / Cramer / Heine, § 25, n.º 25, e Stratenwerth / Kuhlen, § 12, n.º 65 e ss.

inclusive entre nós (35). E, na verdade, uma organização do tipo das atrás mencionadas cria uma fortíssima *dependência psicológica* do homem-da-frente perante o homem-de-trás. A ponto de recentemente Conceição Valdágua se ter afastado da fundamentação roxiniana e defendido que o que fundamenta nestas hipóteses a autoria mediata não é o "domínio da organização" como tal, mas — coisa muito mais ampla e que se aproxima substancialmente da forma de domínio do facto que colocaremos como base da instigação (não da autoria mediata): infra, § 46 — a **subordinação voluntária do executor à decisão do agente mediato** (36). Mas como quer que seja quanto a este ponto, o que importa é saber se a autoria mediata deve cobrir a "dependência psicológica" quando ela ainda é compatível com uma *responsabilidade plena* do dependente. Sem diminuir no que quer que seja o mérito de Roxin em ter concebido a notável e a muitos títulos decisiva concepção do domínio da organização, cremos hoje, também aqui, que uma de duas: ou aquela dependência é uma tal que não deixa aparecer o homem-da-frente como comparticipante plenamente responsável, *v. g.*, por intervenção de uma causa de justificação ou de exclusão da culpa — e a autoria mediata deve considerar-se fundada; ou ainda o deixa aparecer como tal — e o homem-de-trás não deverá então ser considerado autor mediato, de acordo com o princípio da auto-responsabilidade, mas só poderá ser **instigador**. Do mesmo modo que deve ser afastada, em via de princípio, a sua caracterização como **co-autor** (37), fundada na consciência do homem-de-trás de que as suas instruções serão seguramente cumpridas, aliada à consciência do homem-da-frente de que pertencer à organização significa dispor-se a executar instruções daquele tipo (algo, ao que julgamos, de substancialmente análogo à "subordinação voluntária do executor à decisão do homem-de-trás" de que fala Conceição Valdágua): não nos parece, em definitivo, que tal possa valer como a "decisão conjunta" que é indispensável à co-autoria (infra, § 30 e ss.).

---

(35) Cf., julgamos que pela primeira vez em Portugal, o nosso *Direito Penal. Sumários e Notas* (policopiado), 1976, p. 62 e s.; ainda acolhíamos tal doutrina em nota 29, p. 364 e ss.

(36) VALDÁGUA, Conceição, Autoria mediata em virtude do domínio da organização ou autoria mediata em virtude da subordinação voluntária do executor à decisão do agente mediato?, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, 2003, p. 651.

(37) Assim todavia, na Alemanha, JAKOBS, 21/103, JESCHECK / WEIGEND, § 62, II, 8, SAMSON, *SK*, § 25, n.º 36; e na doutrina espanhola, com especial insistência, MUÑOZ CONDE, Problemas de autoría y participación, *in*: Ferré Olivé / Anarte Borallo, nota 29, p. 191. Criticamente como no texto, por último, ROXIN II, § 25, n.º 120 e ss.

III. A co-autoria

1. Conceito e âmbito da co-autoria

§ 28 Nos termos da 3.ª alternativa do art. 26.º-1, é também punido como autor quem **tomar parte directa na execução do facto, por acordo ou conjuntamente com outro ou outros**. É a situação chamada de *co-autoria*. Ao referi-la expressamente entre as formas de autoria, a lei terá querido afastar dúvidas que pudessem provir da circunstância de, nestes casos, o co-autor não dominar o facto nem por si mesmo, nem por intermédio de outro (nenhum se serve do outro como "instrumento"), mas sim *em conjunto* com outro ou outros. Nem por isso, no entanto, deixa de ser o pensamento central do domínio do facto — todavia, em certa medida, modificado — que empresta razão de ser a esta forma de autoria, se bem se trate de um domínio do facto "colectivo" ([38]) ou, talvez possa também dizer-se assim, de um **condomínio do facto**.

§ 29 O que nesta figura existe de característico é a existência, por um lado de uma *decisão conjunta*; por outro lado de uma *determinada medida de significado funcional* da contribuição do co-autor para a realização típica; muito exactamente realçada pela nossa lei ao impor que o co-autor *tome parte directa na execução*. Deste modo, a actuação de cada co-autor, no papel que lhe é destinado, apresenta-se como momento essencial da execução do plano comum, ou, noutras palavras, constitui a realização da **tarefa** que lhe cabe na "**divisão de trabalho**" que representa mesmo a essência desta forma de autoria. É por isso absolutamente justificado que Roxin fale a este propósito de um **domínio do facto funcional** ([39]). Questão é determinar com a precisão possível sob que pressupostos se pode afirmar que alguém tomou *parte directa* na *execução conjunta* e exerceu, por essa forma, o condomínio do facto.

2. A decisão conjunta

§ 30 A **componente subjectiva** da co-autoria reside na *decisão conjunta*. A razão da exigência deste elemento compreende-se porque só

([38]) Assim, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 77.

([39]) ROXIN, *LK*, § 25, n.º 154, e II, § 25, n.º 188, com amplas indicações concordantes. Completamente neste sentido, VALDÁGUA, Conceição, *O Início da Tentativa do Co-autor*, ²1993 (¹1986), pp. 133 e ss., 145 e ss.

através dele se pode justificar que responda pela *totalidade* do delito o agente que por si levou a cabo apenas *uma parte* da execução típica. Será exemplarmente o caso do roubo (art. 210.º-1) dum banco levado a cabo por *A* (que paralisa os clientes e empregados com uma arma: "ameaça") e por *B* (que retira o dinheiro das caixas, dos cofres e das vítimas: "subtracção). Que qualquer dos co-autores responda pela totalidade da realização típica só pode aceitar-se porque a execução é, toda ela, fruto de uma decisão conjunta. O que significa exigir uma *conexão mútua* entre as partes da execução do facto a cargo de cada um dos co-autores que, também numa **consideração objectiva**, conduza a pôr sobre os ombros de um o *papel* ou a *função* que coube ao(s) outro(s). É preciso, na formulação da jurisprudência germânica, que a decisão se revele através de *acções expressas* ou pelo menos através de *acções concludentes*. Por aqui se ligando esta exigência à da "execução conjunta", que será considerada infra, § 34 e ss.

§ 31 Seguro se torna então que a decisão conjunta não pode bastar-se — apesar das palavras equívocas usadas pela nossa lei (40) — com o *mero acordo* dos comparticipantes, tendo todavia ele, naturalmente, de existir (41); o mero acordo, de resto, não poderia servir por si só para caracterizar uma forma de autoria, logo na medida em que ele existe igualmente, muitas vezes, *entre o autor e o cúmplice*. Tudo acaba por recair, em suma, no significado externo de que a realização acordada se reveste, nomeadamente nas características do **papel** ou da **função** que a cada co-autor é distribuído na execução total do facto. Este deve surgir por forma que o contributo de cada um para o facto apareça não como mero favorecimento de um facto alheio, mas como **uma parte da actividade total** e, correspondentemente, as acções dos outros se revelem como um complemento da sua participação própria (42). Nesta medida não ficará *a priori* excluído que o referido acordo possa ser apenas "implícito" — sempre que a situação externo-objectiva só possa ser

---

(40) Como nota VALDÁGUA, Conceição, nota 39, p. 123 e ss.

(41) Por isso, em princípio, exclui ROXIN II, § 25, n.º 191 e s., com razão, do âmbito da co-autoria os casos em que diversas pessoas actuam em direcção ao mesmo fim sem saberem umas das outras; ou quando, mesmo sabendo, se propõem não actuar conjuntamente, mas apenas explorar a mesma situação; ou em todo o caso quando a actuação conjunta é o que chama "unilateral". Sobre este último ponto já VALDÁGUA, Conceição, nota 39, p. 126 e ss.

(42) A formulação corresponde, uma vez mais, à dominante na jurisprudência alemã.

interpretada como ajuste espontâneo num comportamento comum (*v. g.*, rixoso) (43).

§ 32 Seguro é ainda que a responsabilidade do co-autor só se verifica na precisa **medida** em que **a execução se encontre coberta pela decisão conjunta**. Se acções de singulares co-autores que vão para além dela tiverem lugar (casos ditos de **excesso**), sejam elas praticadas com dolo ou por negligência, só podem ser imputadas em princípio ao(s) seu(s) autor(es) singular(es). Se, *v. g.*, *A* e *B* decidem conjuntamente matar *C*, mas *B* depois rouba a vítima, só o homicídio, não também o roubo, é cometido em co-autoria, mesmo que após a apropriação também *A* se manifeste de acordo com ela (44). O excesso só pode caber na responsabilidade do(s) não excedente(s) na medida em que possa imputar-se — o que na prática não constituirá caso raro — ao seu *dolo*, ao menos *eventual*. Sem prejuízo, como é óbvio, de nos casos restantes ficar ressalvada uma responsabilização por *negligência*, nos termos gerais (45).

§ 33 O acordo dos co-autores verifica-se em regra **antes** do início da execução do facto. Todavia, pode alguém tornar-se co-autor **durante** a realização do facto, até à sua **consumação** (46). Esta situação costuma designar-se como **co-autoria sucessiva.** A jurisprudência alemã mais recente torna o "novo" co-autor co-responsável pela parte do facto já cometida pelos outros comparticipantes e dele conhecida — incluídos os motivos de agravação já verificados —, na medida em que ela seja compreendida pelo acordo e o co-autor sucessivo tenha contribuído para a realização típica; só assim não sendo relativamente a acções que fundamentam um delito autónomo e se encontravam já terminadas no momento da intervenção posterior do co-autor (47). A doutrina dominante entende porém — na medida em que a solução exposta ficaria próxima da figura inaceitável do

---

(43) Assim, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 84; cf., também, ROXIN II, § 25, n.º 192.

(44) Assim, pela doutrina dominante, ROXIN II, n.º 194 e ss., e STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 85.

(45) Apontando para um regime semelhante a este sob a vigência do CP de 1886, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 486.

(46) Para alguns autores (por outros, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 88) mesmo até à sua *terminação* ou *conclusão* (sobre este conceito: supra, 27.º Cap., § 11 e s). ROXIN II, § 25, n.º 221, considera porém "mais correcto admitir uma co-autoria sucessiva somente até à consumação *formal* do delito".

(47) Assim, também, na doutrina, JESCHECK / WEIGEND, § 63, II, 2.

dolus subsequens (supra, 13.º Cap., § 54) — que ao co-autor só deve ser imputado o ilícito cometido *depois* da sua adesão ao acordo ([48]).

3. A execução conjunta do facto

§ 34 O art. 26.º, 3.ª alternativa, exige, como acentuámos já, que o co-autor tome "**parte directa na execução**" e, por conseguinte, preste neste estádio uma **contribuição objectiva** para a realização do facto. A questão reside em saber o que deva como tal considerar-se ([49]).

3.1. A participação directa na execução

§ 35 Essencial é a ideia segundo a qual o princípio do *domínio do facto* se combina aqui com a exigência de uma **repartição de tarefas**, que assinala a cada comparticipante contributos para o facto que, podendo situar-se fora do tipo legal de crime, tornam a execução do facto dependente daquela mesma repartição. *V. g.* — para usar de um exemplo de Jescheck —, quando, fruto de uma decisão conjunta, num assalto a um banco *A* fica ao volante do automóvel para permitir a fuga, *B* desliga o alarme, *C*, armado, assegura a saída, *D* ameaça os clientes e os empregados com uma outra arma, enquanto *E* esvazia as caixas e os cofres. Elementos típicos do roubo são preenchidos apenas por *D* e *E*, se bem que todos sejam co-autores: nenhum destes necessita de preencher na própria pessoa a totalidade dos elementos típicos.

§ 36 A referida repartição — que, em termos doutrinais, constitui a essência da co-autoria — tem, nos termos da lei, de **persistir no estádio da execução**, é dizer, tem de reflectir-se ainda em *momento situado entre o do início da tentativa e o da consumação do facto*. É óbvio que os contributos para o facto não têm de ocorrer simultaneamente ou no mesmo período de tempo, como também não é indispensável que o co-autor se

---

([48]) Cf., entre nós, CORREIA, Eduardo. *Studium*, p. 136 e s.; e, na doutrina alemã, ROXIN, *LK*, § 25, n.º 192, e II, § 25, n.º 219 e ss., STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 88 e s., e as concordâncias que referem.

([49]) FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 477 e s. (e já *Da Participação Criminosa*, 1934, p. 139 e ss.), faz coincidir o significado da expressão "tomar parte directa" com o de "execução imediata". Neste sentido, "só a execução em si mesma, se realizada por vários agentes, consiste em tomar parte directa na execução".

encontre presente no lugar em que vai dar-se a execução material. O que interessa é que a contribuição material possa ser vista como exercício do domínio do facto e, por conseguinte, como *parte do preenchimento do tipo* (50).

§ 37 Somos com isto de opinião que deve ser recusada, entre nós logo por imperativo legal, uma concepção como a da jurisprudência alemã, desde há muito mantida (51), segundo a qual basta para fundar a co-autoria uma actuação do agente na **fase preparatória**. Como igualmente a ideia de Stratenwerth — que encontra hoje larga audiência — segundo a qual se impõe dar relevo, dentre os contributos preparatórios, pelo menos àqueles que respeitam ao "**planeamento e organização**" da execução (52). Como bem nos parece acentuar Roxin, uma de duas: ou o planeador dirige também ele próprio a operação — mesmo que à distância — e deve ser considerado co-autor; ou se limita a concebê-la, de todo se desinteressando da efectiva realização, e ele só pode ser então instigador ou cúmplice (53).

3.2. Características da contribuição para o facto

§ 38 Pelo menos em perspectiva prático-jurídica, toca-se assim o ponto porventura mais delicado: o de saber que **peso, relevo, importância e significado** deve ter o contributo do agente, realize ou não um elemento típico, para que ele deva ser tido como acto de co-autoria (54). De acordo com o critério central do domínio do facto, é indispensável que *do contributo objectivo dependa o se e o como da realização típica* e não apenas que o agente se limite a oferecer ou pôr à disposição os meios de realização. Juízo este, sobre o relevo da contribuição para o facto, que deve ser alcançado numa consideração *ex ante* e não *ex post*. Nem será coisa diferente do que exprimimos quando Roxin afirma que o contributo do co-autor, segundo o plano conjunto, "põe, no estádio da execução, um

---

(50) Doutrina defendida por ROXIN II, § 25, n.º 199 e ss.

(51) Desde os tempos do Tribunal do Reich até aos mais recentes do Tribunal Federal: indicações e crítica em ROXIN, § 25, n.º 201 e ss.

(52) STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 91 e ss. Criticamente, ROXIN II, § 25, n.º 205 e ss.

(53) ROXIN II, § 25, n.º 210.

(54) Sobre a matéria deste parágrafo e essencialmente nos seus termos, JAKOBS, 21/51, ROXIN II, § 25, n.º 211 e ss., e STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 93.

pressuposto indispensável à realização do evento almejado", é tão importante que, também em função dele, "todo o empreendimento ou resulta ou falha" (55).

§ 39 E nem se diga que, com isto, se fica a um pequeno passo da ideia de Farinacius da "**causalidade necessária**" (supra, 36.º Cap., § 8 e ss.). Desde logo porque a contribuição do co-autor singular não tem de ser em si mesma necessariamente *causal*, bastando que o seja o conjunto dos contributos dos diversos co-autores. E depois porque, de qualquer modo, a dita causalidade necessária é agora sempre conexionada com o seu *reflexo subjectivo* no plano e na decisão conjuntas, por isso mesmo tendo o contributo do co-autor de reflectir-se na totalidade da execução. O que com o que ficou exposto se afasta, isso sim, é uma concepção subjectiva da co-autoria (56) que não desse curso à exigência de que a contribuição singular seja de relevo ou de importância para a realização do facto e a substituísse pela consideração do *interesse próprio* do co-autor naquela realização.

§ 40 Herzberg introduziu na discussão, neste contexto, o conceito de **co-autoria aditiva**, que ilustra com o exemplo de 20 atiradores que disparam simultaneamente sobre a vítima para mais seguramente a matarem, verificando-se porém depois que ela só foi atingida por alguns dos tiros disparados, não sendo possível determinar por quais. Aqui encontraria o seu limite o pensamento do domínio funcional do facto — porque a contribuição de cada um para o facto seria insignificativa —, fundando-se a co-autoria nestes casos no igual peso de cada contributo individual para o resultad (57). Roxin, diferentemente, sustenta que, ainda aqui, a ideia do domínio funcional do facto tem cabimento, por isso que, segundo o juízo *ex ante* imposto, qualquer dos comportamentos singulares cumpre uma função importante, intervindo todavia no processo executivo de forma *cumulativa* (58).

§ 41 Rudolphi, por seu turno, pretende negar a punição por co-autoria em certos casos de **co-autoria alternativa,** ilustrados com o exemplo de *A* e *B* tomarem a decisão conjunta de matar *C* a tiro e, sabendo que ele passa a uma hora certa ou pela rua *x* ou pela rua *y*, se postarem de tocaia cada um em sua rua; como nesse dia *C* passa pela rua *x*, é *A* quem o mata. Para Rudolphi *A* seria neste caso punido por **autoria**

(55) ROXIN, nota 11, p. 277 e ss.

(56) Ainda muito viva, ao que informa ROXIN II, § 25, n.º 215 e ss., na jurisprudência alemã.

(57) HERZBERG, nota 6, p. 56 e ss.

(58) ROXIN II, § 25, n.º 229 e s.

imediata do homicídio de *C*, *B* apenas por **cumplicidade** (59). Tudo é, no fundo, questão de saber em que termos e momento deve considerar-se iniciada a tentativa de cada co-autor (infra, § 82 e ss.). Em nossa opinião *A* e *B* praticaram — mesmo de forma paradigmática — actos de execução do homicídio: também os actos de *B* assumiram peso, relevo e significado para a verificação iminente do perigo (para a "conexão de perigo típica": supra, 28.º Cap., § 32 e ss.) para o bem jurídico ameaçado.

4. A punição da co-autoria

§ 42 O art. 26.º é suficientemente explícito no sentido de que **cada** co-autor é punido na moldura penal prevista para o facto decidido e executado conjuntamente, tal como se o houvesse cometido **sozinho**. O que não significa, no entanto, que na determinação da pena cabida ao singular co-autor não possam intervir circunstâncias que individualizem a punição face à do(s) outro(s) co-autor(es). Tal será, desde logo, o caso do *excesso* (supra, § 32); como o será das hipóteses em que deva ter neste domínio aplicação o disposto no art. 29.º (infra, 33.º Cap., § 15 e ss.).

IV. A instigação como autoria (60)

1. A instigação entre a autoria e a participação

§ 43 O art. 26.º-1, 4.ª alternativa, considera punível como autor "ainda quem, dolosamente, determinar outra pessoa à prática do facto, desde que haja execução ou começo de execução". É a esta forma de comparticipação que, em geral, se dá o nome de **instigação**. Já insinuámos que a doutrina alemã — não desejando contrariar a letra do § 25 e ss. do seu CP — entende, pode dizer-se *una voce*, ser impossível contabilizar os instigadores entre os autores, e impor-se pelo contrário subsumi-los, juntamente com os auxiliares, aos conceitos superiores de *participantes* e de *participação*. Resta porém saber — é a questão central com que devemos começar por nos ocupar — se é esta a única conceitualização pos-

---

(59) RUDOLPHI, Zur Tatbestandsbezogenheit des Tatherrschaftsbegriff bei der Mittäterschaft, *Bockelmann—FS*, 1979, p. 380. Diferenciador — em parte coincidente com o que se segue em texto —, ROXIN II, § 25, n.º 231 e ss.

(60) Sobre a matéria deste apartado e como no texto, cf., por último, DIAS, Figueiredo, La instigación como autoría — Un *requiem* por la "participación"como categoría de la dogmática jurídico-penal portuguesa?, *Libro de Homenaje al Prof. Gonzalo Rodríguez Mourullo*, 2005, p. 343.

sível, coerente e livre de contradições dentro da doutrina do domínio do facto como essência da autoria; e se esta concepção conduz a resultados e soluções mais correctos e justos do que qualquer outra no tratamento jurídico-penal dos casos concretos da vida; em suma, se é legítimo lançar-se o anátema do compromisso impossível e sem esperança sobre uma conceitualização como a dos nossos arts. 26.º e 27.º, que se limita a distinguir a autoria e a cumplicidade e a contar entre os autores os instigadores que dolosamente determinaram outra pessoa à prática do facto.

§ 44 Começaremos por depreciar o argumento, a que alguns querem dar relevo ([61]), de o art. 26.º não configurar directamente o instigador como autor, mas afirmar apenas que ele "**é punível como autor**". Exactamente o mesmo diz aquele preceito a respeito do autor imediato, do autor mediato e do co-autor que, ainda na mais estrita perspectiva teorético-dogmática, integram indubitavelmente a categoria da autoria. Daqui, pois, não pode extrair-se qualquer argumento contra a conceitualização do instigador como autor. Mas talvez que a inversa já não seja verdadeira. O legislador português conhecia segura e exactamente as formulações da lei alemã sobre o problema e, em particular, a menção tripartida dedicada pelo § 25 à autoria, pelo § 26 à instigação e pelo § 27 ao auxílio; e a consequência doutrinal a que conduz uma tal concepção de excluir a instigação da autoria e imputá-la, juntamente com o auxílio, à "participação". Isto indica ter sido deliberadamente (que não por inabilidade, confusão ou ligeireza) que o legislador português colocou a instigação ao lado da autoria, imediata e mediata, e da co-autoria, mandando em qualquer dos casos punir o(s) agente(s) como autor(es) ([62]); e calou por inteiro qualquer referência à "participação" ([63]). Quem queira pois continuar a discutir a pertinência da instigação à autoria, mas não deseje sujeitar-se à censura de substituir as suas próprias valorações doutrinárias às valorações legais legitimamente editadas, terá pelo menos de deslocar a discussão do plano dogmático para o da crítica legislativa e do direito a constituir.

2. A "instigação" que é autoria e a "indução" que é cumplicidade

§ 45 Instigador nos termos e para os efeitos do art. 26.º é aquele que dolosamente **determinar** outra pessoa à prática de um facto ilícito típico

---

([61]) Informações a propósito em VALDÁGUA, Conceição, nota 31, p. 918[ss].

([62]) De interesse, também no presente contexto, o que se disse supra, 30.º Cap., § 29 e s. Talvez deva acrescentar-se que, no *comité* aí referido, a ideia da instigação como autoria não suscitou divergência de princípio.

([63]) Ao que acresce a circunstância — indiciária, mas significativa — de a lei alemã definir como instigador aquele que "dolosamente determinou outrem ao facto ilícito *deste* ('*dessen*') cometido dolosamente", enquanto a lei portuguesa o conceitualiza como aquele que dolosamente "determinar outrem à prática *do* facto", sem dizer a quem este "pertence".

(doloso). Esta afirmação deve ser interpretada nos termos mais estritos (64). Instigador não é, para estes efeitos, aquele que incentiva, aconselha, meramente sugere ou reforça o propósito de outrem de cometer um ilícito típico; tão-pouco aquele que simplesmente o induz àquele cometimento, ajudando-o a vencer as resistências, físicas, intelectuais ou morais, ou mesmo afastando os últimos obstáculos que o separam do crime; em suma, *todo aquele que, com a sua conduta, influencia a motivação do executor na direcção da realização típica*. Este **não é autor**, mas só, se disso for caso, participante sob uma forma alargada de cumplicidade (65).

§ 46 Instigador no sentido do art. 26.º é unicamente quem **produz** ou **cria** de forma cabal — podia talvez dizer-se, pedindo ajuda à língua francesa: quem fabrica "*de toutes pièces*" — no executor a *decisão* de atentar contra um certo bem jurídico-penal através da comissão de um *concreto ilícito típico* (66); se necessário inculcando-lhe a ideia, revelando-lhe a sua possibilidade, as suas vantagens ou o seu interesse, ou aproveitando a sua plena disponibilidade e acompanhando de perto e ao pormenor a tomada de decisão definitiva pelo executor. No plano das realidades psicológicas aceitar-se-á muito bem que também seja compatível com a "liberdade" do agente imediato uma sua actuação num estado de *dependência psicológica* traduzida em que ele execute voluntariamente uma decisão todavia criada ou produzida no seu espírito pelo homem-da-retaguarda. Como no plano da valoração jurídica se compreende e deve aceitar que, em casos tais, a afirmação da plena responsabilidade — da responsabilidade dolosa — do autor imediato seja compatível com a chamada à responsabilidade do verdadeiro "senhor" do facto, isto é, daquele que criou no homem-da-frente a decisão da realização típica. O instigador possui deste modo — tanto ou mais que, em muitos casos, o autor mediato

---

(64) Muito mais estritos — o que bem se compreenderá depois do que ficou dito — do que aqueles que a doutrina alemã confere ao conceito paralelo de *bestimmen* constante do § 26 do seu CP. Cf. por outros, e por último, ROXIN II, § 26, n.º 65 e ss., e STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 140 e ss.

(65) Casos que FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 494, designa por cumplicidade moral enquanto "equivalente do conselho ou instigação de outrem que não constitua autoria moral", isto é, que "não determine outrem à prática do facto".

(66) Em suma, da comissão de um certo *facto*, não da determinação *geral* à prática de crimes ou de crimes de certa espécie: por todos, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 144.

ou o co-autor — o domínio do facto, agora e aqui sob a forma de **domínio da decisão** (67).

§ 47 O instigador surge assim (mas só então) como verdadeiro senhor, dono ou dominador se não do ilícito típico como tal, ao menos e seguramente da *decisão do instigado de o cometer*; determinação que desta maneira integra, por antecipação, a *totalidade dos elementos constitutivos do ilícito típico* e, por isso também, *do conteúdo material de ilícito*. De um ilícito, acrescente-se, que sendo embora obra *pessoal* do homem-da-frente, faz aparecer o acontecimento (*também* ou *sobretudo*) como *obra do instigador* e dá ao seu contributo para o facto o carácter de co-realização de um ilícito e não de mera "participação (externa ou 'estrangeira') no ilícito de outrem". Só esta é, no entendimento da nossa lei, a **instigação-determinação** e por conseguinte a **instigação que é autoria**.

§ 48 A possibilidade de verdadeira determinação não é excluída pela circunstância de o instigado se mostrar decidido a cometer crimes de certa espécie (*v. g.*, o homicida profissional): basta que a **decisão pelo facto concreto** seja criada ou produzida, nos termos referidos, pelo instigador. Só quem *já está determinado* à realização de um facto concreto (o chamado **omnimodo facturus**) é insusceptível de ser instigado: tal constitui doutrina unânime (68).

§ 49 Que possam existir comportamentos ainda formal e contextualmente cabidos numa acepção ampla do termo "instigação" que não assumam as características acabadas de assinalar, é coisa que se compreende. Esse será o caso de hipóteses como as acima referidas de incentivar, aconselhar, sugerir, reforçar o propósito, em suma, de situações em que o homem-de-trás, com a sua conduta, **influencia a motivação do homem-da-frente, sem verdadeiramente o "determinar"**, na acepção estrita referida, à realização típica. Tais comportamentos não cabem no conceito jurídico-penal de "instigação" no sentido do art. 26.º, 4.ª alternativa, antes constituem "auxílio" ao facto de outrem e, por conseguinte, "**cumplicidade**" para efeito do art. 27.º Deste modo, se quisermos, o conceito

(67) Devo agradecer penhoradamente a Cláudia Santos, com quem debati longamente a ideia que aqui introduzo e de quem recebi sugestões essenciais à formação do meu pensamento sobre a questão.

(68) Cf. CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 132.

"vulgar" de instigação — em sentido amplo — divide-se em certos tipos de actos (de "instigação-determinação") que são *autoria* (art. 26.º, 4.ª alternativa) e noutro tipo de actos (de "instigação-auxílio moral", art. 27.º, 2.ª alternativa) que são *cumplicidade*. Para designar estes últimos, por contraposição aos primeiros, poder-se-á usar o termo (legal e doutrinalmente descomprometido) de **indução**.

§ 50 Profundamente discutido é já porém o caso chamado de **alteração** ou de **alargamento da determinação**. Trata-se, em geral, das hipóteses em que alguém já decidido à prática de certo facto é instigado a uma forma mais grave e mais ampla de comportamento, *v. g.*, quando o já decidido a cometer um furto simples é instigado à prática de um furto qualificado ou de um roubo. Duas orientações se defrontam aqui (69). Para uma delas — dita do **princípio analítico da separação** —, a responsabilidade do instigador tem de reduzir-se à "parte" do facto relativamente ao qual funcionou a determinação: se esta parte não preenche, em si mesma, um tipo legal de crime, só poderá existir *cumplicidade* relativamente ao facto mais grave; como também se a alteração fosse no sentido de uma determinação a um facto menos grave só poderia existir mera *cumplicidade* relativamente a este (70). Para outra orientação — dita **sintética** — deve em princípio afirmar-se a instigação relativamente ao delito "modificado" ou "alargado". Como acentua Roxin, seguindo a jurisprudência alemã — parece-nos que com razão —, de quem, p. ex., instiga a um roubo estando o executor já decidido a cometer um furto não deve dizer-se que determinou o instigado só à violência, antes a determinação engloba uma específica unidade que no roubo como um todo se traduz. Que nestes casos a instigação mereça porventura menor pena relativamente aos casos de "plena" instigação é coisa que pode ser tomada em conta em termos de medida concreta da pena.

§ 51 Por nossa parte, cremos que alguns dos casos que neste contexto costumam ser considerados serão, antes que de verdadeira *determinação* no sentido predito (supra, §§ 45-48), de mera indução (supra, § 49) e por conseguinte, à luz da nossa lei, de cumplicidade ("auxílio moral"). Tratando-

(69) A designação das duas orientações que em seguida serão referidas (ao que informa ROXIN II, § 26, n.º 103) provém de SCHULZ, Anstiftung oder Beihilfe, *JuS*, 1986, p. 935 e s.

(70) Doutrina dominante na Alemanha: por outros, JESCHECK / WEIGEND, § 64, II, 2, *c)*, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 145.

se de verdadeira "determinação", tudo dependerá de se dever afirmar que esta conduziu à prática de um *facto diferente* e *autónomo* — e isto significa: de um ilícito típico que, numa consideração global, surge como uma **nova unidade de sentido social** — face àquele pelo qual o autor se havia já decidido. Esse não será o caso se a modificação ou o alargamento se tiverem traduzido, *v. g.*, numa alteração da motivação do homem-da-frente ou das modalidades da execução; mas já o será em princípio tratando-se de alteração do executor ou do tipo de crime; ou até mesmo do objecto do facto ou da quantidade do ilícito se, também nestes casos, a alteração for uma tal que faça do facto uma unidade de sentido social nova e diferente ([71]).

3. Críticas previsíveis e sua refutação

§ 52 Face ao pensamento enfeudado às categorias dogmáticas germânicas tal como elas são entendidas, a tese acima apresentada deve ater-se à mais decidida contradição. E desde logo na base de que ela esquece que autor é, numa forma plástica já atrás referida, a **figura central** ou o **centro pessoal** do acontecimento. Esta fórmula, contudo — plena embora de sentido, já o dissemos (30.º Cap., § 16), mas, como geralmente se reconhece, incapaz de demarcar a si mesma os limites —, não é desmentida pela posição que assumimos. Se, p. ex., *A* é amante de *B* e pretende que ela morra, para o que cria no marido desta, *C*, excitando a sua natureza extremamente ciumenta, a decisão — que de outra forma seguramente não tomaria — de a matar; e se o facto vem efectivamente a ser cometido (ou pelo menos começa a ser executado), porventura nos precisos modos, formas e circunstâncias que *A* laboriosa e insistentemente incutiu no espírito de *C*, corresponde ao sentimento geral, substancialmente fundado, que o facto se é do executor, *não o é menos do instigador*. Ainda aqui pode afirmar-se com fundamento que *A* é o centro pessoal, a figura central do acontecimento, que o ilícito típico perpetrado é "obra" de *A* (pelo menos *também* é obra dele e sem que entre em questão uma co-autoria).

§ 53 Historicamente, **a instigação viveu paredes-meias com a autoria mediata**, até ao ponto, como se disse (supra, § 4), de ter convivido com ela dentro do conceito de "autoria moral ou intelectual". Há compreensíveis razões para que tal tenha sucedido. Numa figura como na outra existe um homem-de-trás que prevê e quer a rea-

([71]) Soluções estas largamente coincidentes com as preconizadas por ROXIN II, § 26, n.os 90-108.

lização de um ilícito típico, por isso sendo consubstancial à instigação (e não unicamente à decisão político-criminalmente fundada de um legislador como o nosso actual ([72])) o *dolo* do instigador; numa como na outra existe um homem-da-frente que executa ou começa a executar o ilícito típico. Neste contexto de pouco vale avançar, para lograr a distinção no plano substancial, a ideia de que na autoria mediata o homem-de-trás se *serve* do homem-da-frente para praticar o facto *por intermédio deste*, enquanto na instigação o facto ilícito típico surge unicamente como obra do homem-da-frente e o homem-de-trás se limita a colaborar no facto de outrem. Tanto mais quanto também na autoria mediata o homem-de-trás não *pratica* as mais das vezes (ou mesmo em princípio), de um ponto de vista *fáctico*, qualquer "acto de execução", não intervém, em suma, na fase executiva (cf. todavia infra, § 85). A própria doutrina alemã, compreendendo-o, não se tem bastado com esta alegação como *linha de fronteira substancial* entre autoria mediata e instigação. Como tão-pouco com a afirmação apodíctica de que a autoria mediata não faz perder ao homem-de-trás o seu *domínio do facto*, enquanto na instigação a determinação de outrem à prática de um ilícito típico por forma plenamente responsável faz perder o domínio do facto ao homem-de-trás e atribui-o ao homem-da-frente. Tudo depende de saber **sob que condições** uma certa circunstância faz perder o domínio do facto ao homem-de-trás e atribuí-lo em exclusividade ao homem-da-frente.

§ 54 O argumento substancialmente fundado com que aqui se depara susceptível de simultaneamente iluminar a essência da autoria mediata e a sua fronteira é, já o vimos (supra, § 5), o que corre sob a epígrafe de **princípio da auto-responsabilidade**. Incluídas no âmbito da autoria mediata devem ser, de acordo com este princípio, todas aquelas situações em que, por força da actuação do homem-de-trás, o homem-da-frente — o "instrumento", como *et pour cause* também se chama — leva a cabo o facto de forma não totalmente responsável e este lhe não pode ser imputado a título de *dolo*. Só esta condição torna legítimo apelar, como vimos fazê-lo Roxin, para um **domínio da vontade** como signo distintivo de toda a autoria mediata. Se aquela consideração básica se não verifica, se o homem-da-frente actuou de forma plenamente responsável do ponto de vista jurídico-penal, então a ele não deve caber a qualidade de autor mediato, mas unicamente (se não houver lugar a co-autoria) a de instigador, eventualmente a de cúmplice. O princípio da auto-responsabilidade **não é assim critério de toda a autoria** em qualquer situação em que intervenha um homem-da-frente e um homem-de-trás; é sim critério da autoria mediata e só dela. E cremos divisar, em certos caminhos trilhados ou ensaiados

([72]) Contra, todavia, CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 125 e s.

muito recentemente pela doutrina alemã (e também pela portuguesa que a ela se liga) uma clara comprovação das razões da nossa discordância.

§ 55 Com efeito, uma parte da doutrina alemã mais recente tem-se visto perante a necessidade (como dissemos supra, § 22, evidenciando também o preconceito dogmático que preside a uma tal necessidade) de *atenuar*, a diferentes títulos e com diversos fundamentos, a condição básica da autoria mediata atrás referida, *o princípio da auto-responsabilidade*. Na verdade, segundo aquela doutrina, negar a autoria mediata significaria negar, do mesmo passo, a inteira autoria e reenviar as hipóteses para os quadros de uma mera (e eventual) participação. Solução que não só correrá o risco de incorrer em lacunas de punibilidade político-criminalmente inconvenientes, como conduzirá a um tratamento injustificável dos casos em questão, derivado de se punir como autor aquele a quem cabe a menor fatia de responsabilidade jurídico-penal e como mero participante aquele que no fundo foi o autêntico "centro pessoal" do ilícito típico realizado e a quem atinge, em princípio, uma culpa mais pesada. Cremos todavia que a solução das dificuldades se não encontrará num alargamento desmesurado do conceito de autoria mediata, que lhe faz perder os contornos precisos impostos pela fidelidade a um conceito *restritivo* de autor, mas em colocar ao lado da autoria mediata **uma outra forma de — verdadeira — autoria: a instigação**. Porque, afinal, o que em tais casos ocorre é uma *repartição (rectior, duplicação) do domínio do facto relativamente ao mesmo ilícito-típico* ([73]), fora dos casos de co-autoria. Enumeremos de novo as hipóteses principais em que uma parte da doutrina alemã — seguida e alargada aliás, nas hipóteses mais relevantes, por alguma doutrina portuguesa — tem julgado ver a necessidade de extensão do conceito de autoria mediata à custa da sua mais autêntica razão de ser: a que lhe é dada pelo princípio da auto-responsabilidade.

4. Casos de pretensa autoria mediata que são de instigação

4.1. Pequenas deficiências da autodeterminação do homem-da-frente

§ 56 De considerar podem ser neste contexto desde logo aquelas hipóteses — todavia diferentes entre si na sua estrutura e no seu signifi-

([73]) Assim, também, KÜHL, § 20, n.º 75.

cado — relativamente às quais uma certa doutrina pretende fundar a autoria mediata em pequenas deficiências provocadas ou exploradas pelo homem-da-retaguarda na autodeterminação do executor, na dependência psíquica deste face àquele, que todavia não serve para afastar a sua responsabilidade dolosa. Dissemos ser esse, para alguns, o caso em que o homem-da-frente é a própria *vítima* e o seu facto é por isso **atípico**, ou em que ele actua com **culpa diminuída**, nomeadamente por ser *imputável diminuído*, por actuar com *falta censurável de consciência do ilícito* ou em *estado de necessidade que (só) atenua a culpa* (supra, respectivamente, §§ 8, 14, 16, 18, 19). Em qualquer destas hipóteses, não deve, na opinião que avançámos, afirmar-se a autoria mediata face ao princípio da auto-responsabilidade; mas fica todavia próxima a existência de uma determinação que, nos termos do art. 26.º, 4.ª alternativa, conduz à afirmação de uma **autoria** sob a forma de **instigação**.

4.2. Erro sobre o sentido concreto da acção

§ 57 Um segundo grupos de hipóteses será constituído por aqueles casos que supra, § 23 e s., vimos ser hoje considerados pela doutrina alemã sob a epígrafe de hipóteses de "erro sobre o sentido concreto da acção". Já então dissemos a razão por que não vemos em quaisquer destes casos motivo bastante para alargar, à custa do princípio da auto-responsabilidade, o âmbito da autoria mediata: ou o erro em que incorre o homem-da-frente e que foi inteiramente criado pelo homem-de-trás *exclui* o dolo e este é, nos termos gerais, autor mediato; ou *não exclui* e o homem-de-trás é **instigador** se o engano dolosamente provocado teve por efeito determinar o homem-da-frente à prática do facto. Sendo a instigação autoria, não vemos que possam gerar-se lacunas de punibilidade insuperáveis e insuportáveis nestas hipóteses.

4.3. Factos cometidos no quadro de um aparelho organizado de poder

§ 58 O grupo de situações mais relevante é o dos factos cometidos nos quadros do que Roxin chamou os aparelhos organizados de poder (supra, § 25 e ss.). Igualmente aqui cremos hoje que ou essa dependência é uma tal que não deixa aparecer o homem-da-frente como plenamente responsável, *v. g.*, por intervenção de uma causa de justificação ou de

exclusão da culpa — e a autoria mediata deve considerar-se fundada; ou ainda o deixa aparecer como tal — e o homem-de-trás deverá então ser considerado (na generalidade das hipóteses, sobretudo nas mais graves) como **instigador** e punido como autor.

§ 59 Esta concepção, para além de respeitar o princípio da auto-responsabilidade como critério da autoria mediata, serve para evitar dúvidas de aplicação da lei por outra forma, como referimos, dificilmente eliminàveis. Aceitando-a, não se fica, desde logo, na dependência de saber — coisa extremamente difícil — se o aparelho de poder tem ou não, no caso, dimensão suficiente para se verificar a hierarquização e o consequente **automatismo** pretendido como condição de afirmação da autoria mediata. Torna-se por outro lado indiferente, em alta medida, o tipo de relação que interceda entre a organização e o **quadro da ordem jurídica**, bem podendo aceitar-se a instigação ainda em aparelhos cujos objectivos não sejam, em princípio, adversos à ordem jurídica estabelecida. E, do mesmo modo e sobretudo, a autoria não tem de ser negada só porque a prática do facto não é largamente **fungível** no quadro da organização, *v. g.*, porque só um ou poucos subordinados têm a capacidade e os conhecimentos requeridos para cometer certos tipos de factos, máxime, em domínios especializados do direito penal económico, financeiro, informático, etc. ([74]). Ao que acresce ainda a circunstância de, deste modo, se ultrapassar a questão de saber — e a resposta haverá de ser, no quadro de pensamento que propomos, positiva — se também na **criminalidade empresarial** a figura do instigador poderá ter larga utilização. Por todas estas razões, a figura do autor atrás do autor, fundada no domínio da organização, deve merecer aceitação não no quadro da autoria mediata, mas da instigação que é autoria.

§ 60 É interessante sublinhar que (como já referimos supra, § 27), em data recente também Conceição Valdágua vem afastar-se da "categoria roxiniana do domínio da organização (ou domínio da vontade em virtude de aparelhos organizados de poder) como forma específica de domínio da vontade e fundamento autónomo da autoria mediata". Não porém, como nós, para negar nesses casos a autoria mediata e aceitar a autoria em nome da instigação, mas para sustentar que neles a autoria mediata se funda, antes que no domínio da organização, na **subordinação voluntária** do executor à decisão do autor mediato. Uma tal subordinação pode constituir, em muitas hipóteses, aquilo que denominamos a *determinação* que constitui a instigação.

([74]) Assim já — todavia no contexto de um alargamento da *autoria mediata* —, DIAS, Figueiredo, nota 29, p. 370 e s.

4.4. O aliciamento

§ 61 Um grupo extremamente interessante — e importante — de hipóteses que entram de pleno no contexto desta problemática foi muito recentemente tratado entre nós por Conceição Valdágua sob a epígrafe do **aliciamento**. Ela sustenta, como a maioria dos AA. alemães, que também no direito português — apesar do que dispõem os arts. 26.º e 27.º — a instigação é uma categoria que só pode constituir "participação", não autoria. *Precisamente por ser assim*, defende todavia que as situações de *aliciamento* — caracterizadas por "o homem-de-trás levar o executor a praticar o facto tipicamente ilícito *em contrapartida* da realização de determinada prestação, de coisa ou de facto, que o homem-de-trás lhe proporciona (ainda que não tenha de ser ele, pessoalmente, a realizá-la)" ([75]) — devem, em parte, ser imputadas à autoria mediata e não, como defende a generalidade da doutrina alemã, meramente à participação. Tal sucederá em caso de **ajuste** (ou de **promessa** recondutível a ajuste, embora já não à de simples **dádiva**), onde se exige a *formação de consenso* — e o seu conhecimento — relativamente à realização de uma prestação do homem-de-trás para ("sinalagma") realização, pelo homem-da-frente, de um concreto ilícito típico planeado e liderado pelo homem-de-trás.

§ 62 Porquê este novo alargamento dos quadros da autoria mediata à custa do princípio da auto-responsabilidade? Desde logo porque, em perspectiva político-criminal, o tratamento destes casos como de participação conduziria a **lacunas** dificilmente compreensíveis e aceitáveis de punibilidade. E porque, no plano dogmático, nos casos referidos de aliciamento a formação de consenso reconhecido entre o homem-da-frente e o homem-de-trás faz com que caiba a este a decisão final sobre o cometimento do facto, o poder de supradeterminação final do processo causal conducente à realização típica, numa palavra, o *domínio da vontade*. Estamos de acordo que nem todos os casos de aliciamento constituem autoria, devendo alguns deles ser tratados nos quadros da cumplicidade. Mas, ainda aqui, não nos parece necessário ou sequer admissível imputar à autoria mediata e ao domínio da vontade hipóteses que são de **domínio da decisão** e, por conseguinte, de verdadeira **instigação**. Assim se mantendo fidelidade, ainda aqui, ao princípio da auto-responsabilidade como essência da autoria mediata.

([75]) VALDÁGUA, Conceição, nota 31, p. 935 (s. n. o.).

5. A exigência legal de execução ou começo de execução

§ 63 O argumento que sempre se esgrimirá contra a tese aqui defendida, segundo a qual a instigação não só é tratada pela nossa lei como autoria, mas é verdadeiramente autoria, será o de que o próprio art. 26.º *especializa* a instigação face às restantes categorias puníveis como autoria, na medida em que condiciona a punibilidade daquela pela exigência de que "haja execução ou começo de execução". Aqui residiria a prova de que, no pensamento da própria lei, a instigação está sujeita a uma cláusula de **acessoriedade** relativamente ao facto ilícito-típico; uma cláusula que, afirma-o hoje a generalidade da doutrina germânica, é específica da *participação no facto de outrem*, sendo apenas relativamente a este, *rectius*, relativamente ao ilícito típico do facto principal que pode suscitar-se uma relação de acessoriedade ([76]). Mas, mesmo dando como boa esta doutrina — sem dúvida, repete-se, consensual na Alemanha —, importa sempre perguntar **que acessoriedade é esta** que no art. 26.º, 4.ª alternativa, estaria em causa.

§ 64 Seguro parece que uma tal acessoriedade que o art. 26.º, 4.ª alternativa, exigiria para a instigação não é, ou não tem de ser, aquela que corre na doutrina da participação sob a epígrafe de acessoriedade *qualitativa* ou *interna* e que determina um certo número e espécie (maior ou menor, mais ou menos exigente) de elementos constitutivos do crime que têm de verificar-se no facto do autor (sobre estes conceitos: infra, 32.º Cap., §§ 13 e ss., 18 e ss.). O que pode estar ali em causa é apenas a exigência de uma certa acessoriedade "**quantitativa**" ou "**externa**", relativa ao estádio de realização que o facto deve atingir. Mas sempre se diria então que o que irmanaria as figuras da instigação e da cumplicidade sob o conceito superior de participação seria justamente a circunstância de a lei sujeitar ambas as figuras — por contraposição às formas de verdadeira autoria — à acessoriedade quantitativa ([77]), impondo que tanto numa como na outra se verifique a prática pelo menos de um *acto de execução*.

§ 65 Não julgamos, porém, que este argumento seja suficiente para negar aos casos de instigação a sua pertinência à categoria da autoria.

([76]) Neste sentido, no essencial e por último, VALDÁGUA, Conceição, nota 31, pp. 932 e 918 e ss.[8] (onde indica larguíssima bibliografia portuguesa concordante). E já antes, de forma mais cautelosa, nota 39, p. 104 e s. e [272].

([77]) Assim, MONTEIRO, Salinas, *A Comparticipação em Crimes Especiais no Código Penal*, 1999, p. 147 e ss. Parece concordar VALDÁGUA, Conceição, locs. cits. na nota anterior.

Desde logo, relativamente à cumplicidade o art. 27.º não faz, ao menos expressamente, a exigência de começo de execução que o art. 26.º, 4.ª alternativa, contém para a instigação. E de todo o modo não está dito que o problema que assim se suscita relativamente à instigação *não deva suscitar-se igualmente em relação à autoria mediata e à co-autoria.* Não se afirma com isto desde já que a *solução* tenha de ser *a mesma* para todas as formas de autoria (sobre isto: infra, § 76 e ss.). O que se diz e aqui interessa é tão-só que **o mesmo problema** (o de uma qualquer — aceitemos o designativo embora no presente contexto se revele pouco apropriado — "acessoriedade quantitativa") se põe relativamente a situações que são indiscutivelmente de autoria: todo o problema da determinação do momento inicial da tentativa do autor mediato e do co-autor revela que a conexão inevitável entre a actuação do autor mediato e imediato ou entre a dos co-autores tem de supor a prática de actos que representem um início de *execução* do ilícito típico, nos termos do art. 22.º ([78]). Sobretudo se considerarmos que também na doutrina alemã, como se verá, não falta quem defenda — com razão ou sem ela, não importa por ora — que o início da tentativa se verifica apenas, na própria autoria mediata, quando o instrumento inicia a execução e portanto se pode já falar de uma acção conjunta ou global. Sem que, naturalmente, quem assim pensa alguma vez tenha negado por esta razão a autoria mediata e se tenha sentido obrigado a transformá-la em participação.

§ 66 A nossa convicção é a de que a razão da exigência legal de que, nos casos de instigação, se tenha verificado o início da execução por parte do instigado é toda uma outra e nada tem que ver com o princípio da acessoriedade como tal: é uma **exigência político-criminal** ligada à ideia de que, sendo o processo de *determinação* essencialmente interno ou psicológico, entendeu a lei sublinhar de forma expressa que a determinação só pode considerar-se verificada quando conduza à prática pelo instigado de acto(s) que a revele(m) e execute(m) — também poderia dizer-se: que a **exteriorize(m)**. Sendo este o fundamento da exigência ([79]), então terá

([78]) Dando assim o nosso acordo, nesta parte e medida, às posições que na matéria vêm sendo assumidas em diversos estudos por VALDÁGUA, Conceição: cf. sobretudo nota 39, *passim*, Versuchsbeginn des Mittäters bei den Herrschaftsdelikten, *ZStW*, 1986, p. 839, e, por último, nota 31, p. 933 e s.

([79]) Repare-se que a exigência de que se verificasse pelo menos início de execução já era feita, relativamente à *instigação*, por autores como FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 483, e

de concordar-se que ela é eminentemente estranha à qualificação da instigação como verdadeira autoria ou antes como mera participação.

6. O dolo na instigação

§ 67 Diversamente do que sucede com as restantes formas de autoria, o art. 26.º, 4.ª alternativa, exige *expressamente* que a determinação, essência da instigação, seja **dolosa** ([80]). Isto é consequência pura e simples, no nosso direito, dos restritos limites em que, como vimos, deve aceitar-se o conceito de instigação e se traduzem na produção ou criação pelo instigador no instigado da *decisão* de cometer um ilícito-típico. Um "domínio da decisão" não é compatível com a produção ou criação de uma tal decisão no executor *por negligência*: em tais casos o que fica em aberto é, no máximo, uma "autoria paralela negligente". A questão que poderia legitimamente suscitar-se aqui seria antes a de saber se não deveria exigir-se o *dolo directo*, não deixando bastar o *dolo eventual*; já que só aquele, não este, seria compatível com o propósito do instigador de criar no instigado aquela decisão. Tudo ponderado, porém, não parece de excluir *a priori* a compatibilidade daquele propósito com a representação pelo instigador do êxito da tarefa como meramente possível, aliada à sua conformação com uma tal possibilidade.

§ 68 Não falta quem afirme que na instigação deve estar presente um **duplo dolo** do instigador ([81]). Trata-se de uma forma plástica para dar a compreender que o dolo do instigador deve por um lado referir-se à *determinação* do instigado, por outro ao *facto* por este cometido, ao menos em início de execução. Quanto a este segundo aspecto do dolo, já dissemos

---

CORREIA, Eduardo, *Studium*, pp. 121 e ss. e 129, que todavia subsumiam a instigação, juntamente com a autoria mediata, ao conceito superior de *autoria* moral ou intelectual. O primeiro daqueles AA. esclarece mesmo que "se pudesse antecipar-se o começo da execução para o momento em que o instigador determina outrem à prática do facto, como também para o momento em que o autor mediato constrange ou engana outrem, todos os autores morais seriam puníveis por tentativa de instigação como autores do crime, independentemente da prática por outrem de qualquer acto de execução". Já na sua dissertação de doutoramento, 1934, nota 49, p. 214, o A. considera que a "perpetração do crime principal" constitui mesmo uma condição de punibilidade do autor moral".

([80]) O mesmo exigindo o art. 27.º para a cumplicidade, porventura havendo quem queira ver aqui mais uma similitude que convidaria à subsunção da instigação e da cumplicidade no conceito de *participação*.

([81]) Cf. só, por último, ROXIN II, § 26, n.º 132.

supra, § 46, que pertence à essência da instigação a determinação de outrem a um *concreto* facto punível. Por isso ao dolo do instigador pertence também a **representação dos concretos elementos e circunstâncias do ilícito-típico respectivo**; não bastando em caso algum a representação abstracta de que o comportamento do instigado constituirá um qualquer facto punível: o dolo do instigado tem de se dirigir àquele mesmo facto que o instigado praticar ([82]).

§ 69 Deste modo, também aqui, se o instigado vai, na sua actuação, **além** do dolo do instigador — **excesso**, conhecido pela doutrina mais antiga como *excessus mandati* ([83]) —, ele só responde na medida do seu dolo (sem prejuízo de uma eventual responsabilidade, por negligência, relativamente ao ilícito mais grave produzido) ([84]). Assim, *v. g.*, se o instigado comete um roubo ou um furto qualificado quando a instigação se dirigiu apenas, respectivamente, a um furto ou a um furto simples. Se, inversamente, o instigado fica **aquém** do dolo do instigador — se comete, p. ex., um furto simples e não o furto qualificado a que foi instigado —, então o instigador responde pelo facto efectivamente cometido ([85]). A tentativa falhada de instigação ao crime qualificado não é punível, na medida em que não foi alcançada, nesta parte, a determinação do instigado e não houve por conseguinte, da parte deste, início de execução da qualificação (infra, § 89).

§ 70 O que ficou dito no § 68 não significa porém que o dolo do instigador tenha de compreender, a **espécie e o modo da execução**: basta que ele se refira ao concreto ilícito-típico nos seus elementos constitutivos (o que, p. ex., poderá fazer diferença relativamente a crimes de *execução livre* e de *execução vinculada*: supra, 11.º Cap., § 42). Tratando-se de ataque a bens jurídicos *pessoais*, a **pessoa da vítima** constitui elemento essencial do ilícito típico doloso do instigador, pelo que o erro do instigado sobre ela parece dever aproveitar ao instigador, só ficando em aberto a pos-

---

([82]) Doutrina dominante na Alemanha: por ela, JESCHECK / WEIGEND, § 64, II, 2 b), M / GÖSSEL, § 51, n.º 8, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 147.

([83]) Cf. só CORREIA, Eduardo, *Studium*, pp. 133, 160 e ss.

([84]) Para a questão próxima a alguns títulos, mas de nenhum modo coincidente com a do texto, da instigação a um crime agravado pelo resultado, cf. só JESCHECK / WEIGEND, § 64, II, 4, e ROXIN II, § 26, n.º 167.

([85]) No essencial nestes termos, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 148.

sibilidade de ser eventualmente imputada a este uma tentativa — falhada e, por isso, não punível — de instigação. E nem se diga que é contraditório fazer aproveitar ao instigador, mas não ao instigado, o erro sobre a pessoa em que o instigado incorreu: o que para o instigado constitui um *error in persona* irrelevante conforma, relativamente ao instigador, uma espécie de *aberratio ictus* relevante (86). Tem-se suscitado igualmente a questão de saber se o dolo do instigador deve dirigir-se directamente à **pessoa do instigado**. Cremos que uma resposta afirmativa de princípio é sugerida logo, uma vez mais, pelas particulares exigências que devem pôr-se à "determinação" suposta pelo art. 26.º, 4.ª alternativa; embora não pareça de excluir *a priori* a possibilidade de determinação dirigida a uma pluralidade — em todo o caso restrita e determinada — de pessoas. Em todas as hipóteses restantes o que poderá entrar em questão não é a instigação do art. 26.º, mas a do art. 279.º ("instigação pública a um crime") (87).

§ 71 Importa determinar finalmente se o dolo do instigador deve dirigir-se à **consumação** do facto pelo instigado ou pode referir-se à sua mera **tentativa**. A questão é particularmente relevante nos casos — hoje cada vez mais importantes e frequentes pela sua particular incidência no âmbito da *criminalidade organizada* — ditos de **agent provocateur**. De agente provocador, acrescente-se porém desde já, na precisa acepção daquele que actua no sentido de determinar alguém à prática de um facto, com o propósito de que este alcance apenas o estádio da tentativa, para logo aí o deter ou denunciar e evitar, deste modo, que a consumação venha a ocorrer. Contra a generalidade da doutrina alemã (88), não vemos razão para que o dolo do instigador deva ter por objecto a "consumação" do crime ou, inclusivamente, a lesão efectiva do bem jurídico: uma tal tese não só é contrariada pelo teor literal da 4.ª alternativa do art. 26.º (também a tentativa constitui um "*facto*" na acepção daquele preceito legal, o qual não exige mais do que haver "começo de execução"), como ela nada tem a ver com a consideração da instigação como autoria ou como mera participa-

(86) Cf. supra, 13.º Cap., §§ 27 e s., 29 e s. No sentido do texto, ROXIN II, § 26, n.º 120.

(87) Substancialmente neste sentido, ao que nos pareceu, MONIZ, Helena Isabel, *Comentário Conimbricense*, II, art. 297.º, § 21. No sentido do texto também a generalidade da doutrina alemã, pela qual podem ver-se ROXIN II, § 26, n.º 148, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 149.

(88) Cf. só ROXIN II, § 26, n.º 151, e a extensa lista de concordâncias aí referidas.

ção ([89]): porque haveriam as soluções de ser diferentes tratando-se não de uma instigação, mas, *v. g.*, de uma co-autoria? Acresce por outro lado, e decisivamente, que nos parece perfeitamente possível a *determinação* de outra pessoa a um facto tentado.

§ 72 Assim sendo, o **resultado político-criminal** que por esta via teorético-dogmática tortuosa a doutrina alemã pretende alcançar — o da não punibilidade do agente provocador — só pode ser conseguido se a lei o consagrar expressamente, nomeadamente, em relação a certos tipos de crimes (*v. g.* de tráfico de drogas, de armas, etc.) ou a certo tipo de criminalidade (máxime, a criminalidade organizada), em função certamente de uma ideia de *estado de necessidade* ou de *conflito de deveres*. Essa terá sido porventura a finalidade político-criminal que presidiu ao art. 6.º-1 da L 101/2001, de 25-8, relativamente ao agente encoberto ([90]). Mas se foi essa a intenção, deve pôr-se em dúvida que a tenha minimamente logrado; desde logo e sobretudo na medida em que excluiu da impunibilidade os casos de instigação. Se, porém, os seus termos forem levados à letra, então estará aí a comprovação do bom fundamento da posição que assumimos: a de que não existe obstáculo teorético-dogmático à punição da instigação a um facto tentado, uma vez que certamente também o agente encoberto procurará que o facto instigado não atinja a consumação nem conduza à efectiva lesão do bem jurídico ameaçado.

7. A "instigação em cadeia"

§ 73 Problema importante tanto de um ponto de vista teórico, como prático é o doutrinalmente chamado da instigação em cadeia ([91]). Trata-se nele de saber se devem ser jurídico-penalmente punidos aqueles agentes que não tendo contacto directo como o executor do facto, constituem todavia **elos de uma cadeia conducente à determinação** daquele à prática de um facto ilícito-típico. Com exemplos deste teor deparámos já supra, § 61 e

([89]) Ainda neste último caso, na verdade, a referida exigência nos pareceria infundada à luz da doutrina da acessoriedade limitada: cf. infra, Cap. 32.º, § 13 e ss.

([90]) É o seguinte o seu texto: "Não é punível a conduta do agente encoberto que, no âmbito de uma acção encoberta, consubstancie a prática de actos preparatórios ou de execução de uma infracção em qualquer forma de comparticipação diversa da instigação e da autoria mediata, sempre que guarde a devida proporcionalidade com a finalidade da mesma". Criticamente sobre este preceito, também, SOUSA, Susana Aires de, *Agent provocateur* e meios enganosos de prova. Algumas reflexões, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, pp. 1207 e ss., 1234 e s.

([91]) Especificamente sobre ele, entre nós, RAPOSO, J. A., A punibilidade nas situações de instigação em cadeia, *O Direito 133*, 2001, p. 907, e, agora, MORÃO, Helena, *Da Instigação em Cadeia. Contributo para a Dogmática das Formas de Comparticipação na Instigação*, 2006.

s., ao tratarmos do "aliciamento". Será o caso vulgar de *A*, amante de *B*, convencer este a determinar *C* a que mate o marido de *A*. A questão básica que aqui se suscita é saber se os elos da cadeia podem e devem ser punidos como instigadores (e, por conseguinte, como autores) ou se apenas poderão sê-lo, eventualmente, como cúmplices.

§ 74 O problema é de há muito conhecido da nossa legislação e da nossa doutrina (92). Já o CP de 1852 — editando uma regulamentação de que não era fácil encontrar paralelo nos códigos penais coevos — mandava punir como *cúmplices* os intermediários entre o mandante e o mandatário da prática de um crime (art. 26.º-6) (93). Na vigência do CP de 1886 instalou-se como dominante a solução da não punibilidade da "instigação à instigação", sobretudo na base da exigência legal (arts. 20.º-3 e 22.º-1 e 2) de que a instigação fosse **directa**, o que só poderia suceder com a determinação operada pelo último elo da cadeia. Dessa opinião foi sempre Eduardo Correia — estranhamente, decerto (94), face à sua concepção material-objectiva e puramente causalista da comparticipação — não só no seu ensino, como no seu ProjPG (art. 27.º-6) (95). Uma tal exigência do carácter "directo" da instigação foi todavia eliminada na versão final do art. 26.º, 4.ª alternativa, do código vigente.

§ 75 Não se descortina, em geral, argumento válido que, segundo o nosso direito penal vigente, possa opor-se à punibilidade de princípio da instigação em cadeia. Ponto é (apenas, mas necessariamente!) que, relativamente à conduta de cada um dos elos da cadeia, se possa afirmar que ele **determinou** — ainda que só de forma *mediata* — o executor à prática do **facto ilícito-típico**, tendo este dado início à execução nos termos atrás expostos. Indispensável é que, por conseguinte, relativamente a ele possa ser afirmado aquele **domínio da decisão** — que não da mera "motivação" — do autor imediato que vimos ser a essência mesma desta forma de autoria; aliado, é verdade, a um certo domínio da própria execução, pelo menos na medida em que lhe pode pôr termo. Quem possui este domínio é **autor** a par de outros autores, tornando-se assim a instigação em cadeia — ou, se quisermos, a "instigação à instigação" — em caso particularmente frisante da "sucessividade do domínio do facto" que infra, § 78, será referida como característica da instigação. Relativamente aos elos da cadeia que

(92) Sobre o que se segue, RAPOSO, J. A., nota 91, p. 912 e ss.

(93) Cf. FERRÃO, p. 243 e ss., e CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 148.

(94) Estranheza manifestada também por RAPOSO, J. A., nota 91, p. 915.

(95) CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 158 e s., II, p. 259, e *Actas I*, p. 194 e ss. Segue-o GONÇALVES, Maia, *CP*, 81977, pp. 56, 61. Já FERREIRA, Cavaleiro de, II, 1982, p. 108, entende que o meio "é directo quando se dirige a pessoas determinadas".

não possuam um tal domínio — porque se assumiram como meros transmissores ou intermediários do propósito do instigador —, eles não serão autores mas apenas poderão ser considerados e punidos como *cúmplices*.

§ 76 Ficam deste modo em alguma medida clarificadas muitas das questões que a doutrina — sobretudo a alemã — costuma suscitar neste domínio. Desde logo, convém assinalar que a solução a dar ao problema da punibilidade ou não punibilidade é em larga medida independente de saber se a instigação (determinação) é **verdadeira autoria** ou só uma forma de participação punida como autoria (96). Clarificada fica, por outro lado, a questão, muito debatida pela doutrina alemã, de saber se o **facto** a que se refere a instigação mais longínqua é o "facto da instigação" ou antes o "facto ilícito-típico" — também dito "o facto principal" — a praticar pelo (último) instigado (97). Se a instigação é, como domínio da decisão, autoria de um facto ilícito típico, então é a este, não ao "facto da instigação", que tem forçosamente de referir-se a determinação (98), embora não necessariamente *só* a ele (já supra, § 68). No fundo, ambos os factos são "referentes", no sentido de que são os dois tidos em mente pelo(s) instigador(es), sem todavia por isso o facto ilícito-típico deixar de ser o **referente principal** e o outro meramente um **referente instrumental** (99). Por isso não concordamos com que se *A* determina *B* a que determine *C* a cometer um certo homicídio e *C* se deixa determinar só porque está apaixonado por *B* (sendo-lhe indiferente que *B* tivesse sido determinado por *A*), só *B* e não *A* deva ser considerado instigador (100): na verdade, tanto *A* como *B* possuem o domínio da decisão de *C* e também um qualquer domínio (ao menos negativo) da execução do facto ilícito típico. Já, diferentemente, para os meros **intermediários** ou **transmissores** o facto da instigação aparecerá como principal, ficando por isso a sua conexão com o ilícito típico condicionada a uma relação de acessoriedade e reforçando deste modo a conclusão de que só lhe pode ser imputada cumplicidade.

§ 77 O "caso 'Meia culpa'", recentemente decidido pela nossa jurisprudência, ilustra de forma exemplar o que vimos de expor (101). A determinou *B* à destruição da dis-

---

(96) A prova está em que, no seu estudo, RAPOSO, J. A., nota 91, *passim*, logra conclusões que, no essencial, merecem a nossa concordância sem todavia vez alguma se pronunciar, ao menos de forma terminante, sobre se a verdadeira instigação é autoria ou antes participação.

(97) Devendo, deste ponto de vista, reputar-se equívoca (embora não "errada") a fórmula da "instigação à instigação" e como tal ser evitada, preferindo-se-lhe a de "instigação em cadeia".

(98) RAPOSO, J. A., nota 91, pp. 919 e s., 922 e ss., na esteira, entre outros, de JAKOBS, 22/30, JESCHECK / WEIGEND, § 64, IV, 1, e de ROXIN II, § 26, n.º 176. Diferentemente, HERZBERG, Anstiftung und Beihilfe als Straftatbestände, *GA*, 1971, p. 1, e MEYER, Zum Problem der "Kettenanstiftung", *JuS*, 1973, p. 755.

(99) Nesta medida se discordando de RAPOSO, J. A., nota 91, p. 920.

(100) Assim, no entanto, RAPOSO, J. A., nota 91, p. 940.

(101) Cf. Acs. do Tribunal de Círculo de Penafiel de 1-6-98 e do STJ de 27-1-99 *in*: ALMEIDA, Carlota Pizarro de / ALMEIDA, Duarte d', *Direito Penal I — Colectânea de Jurisprudência*, II, 2002, p. 49 e ss.

coteca com aquele nome, sugerindo-lhe que encontrasse alguém que fizesse o serviço. *C* e depois *D* aceitaram a proposta e executaram-na, a troco de determinada quantia. O tribunal de 1.ª instância condenou *A* e *B* como instigadores dos crimes praticados por *C* e *D*, recusando embora a figura da "instigação à instigação", mas acentuando que o carácter directo da instigação só significa que ela tem de se dirigir a pessoas determinadas e que por isso, no caso, se deparava com uma instigação de *A* ao facto principal realizada através do intermediário *B*. A solução parece em geral correcta — embora não necessariamente a fundamentação —, podendo todavia perguntar-se se *B* não deveria ter sido punido como mero cúmplice. Sem razão, em nosso parecer, o STJ, no julgamento do recurso, considerou *A* não como instigador, mas como autor mediato ([102]).

8. Instigação e domínio do facto. Conclusão

§ 78 Duas palavras em jeito de conclusão. A primeira ainda sobre as características do *domínio do facto* na instigação sob a forma do **domínio da decisão**. Falou-se atrás, a propósito, de uma "repartição" ou "duplicação" do domínio do facto nesta forma de autoria; deverá agora acrescentar-se a nota da **sucessividade**, no sentido de que, uma vez determinado o instigado, este assume (também) o domínio do facto, sem por isso o fazer perder ao instigador. Não é isto nada de extraordinário ou de contraditório com a teoria do domínio do facto. Tanto na autoria mediata como na instigação não tem que existir verdadeira colaboração objectiva ("fáctica") do homem-de-trás na execução; com a consequência de que quer o "instrumento", quer o "instigado" podem — seja qual for o grau de dependência subjectiva ou psicológica relativamente àquele — não levar a cabo, em último termo, a execução, sem que por isso deva negar-se o domínio do facto do homem-de-trás. De resto, em casos atrás referidos como os do domínio da organização, do aliciamento e de outros, nunca se compreenderia que o homem-de-trás tivesse ou não o domínio do facto consoante tais casos fossem conceitualizados como de autoria mediata ou antes como de instigação: a mera conceitualização jurídica é de todo incapaz de alterar a realidade e a natureza das coisas.

§ 79 Por outro lado, mesmo na co-autoria pode existir uma fortíssima dependência subjectiva ou psicológica — análoga à que se verifica na autoria mediata ou na instigação — de um co-autor relativamente a outro

---

([102]) A favor da instigação de *A* e da cumplicidade de *B*, no caso, RAPOSO, nota 91, p. 946 e s.; favorável à instigação de *A* e à co-instigação de *B*, GOMES, Catarina S., Comparticipação. Ac. do STJ de 27-1-99, *in: Casos e Materiais de Direito Penal*, 2000, p. 331 e ss.; a favor da autoria mediata de *A* e da cumplicidade de *B*, VALDÁGUA, Conceição, nota 31, p. 930[31].

e aos actos de execução que a este, segundo o plano conjunto, cabe executar, sem que tal possa servir para pôr em questão o seu condomínio do facto. Talvez deva mesmo afirmar-se que em muitos casos **o instigador detém muito mais forte e claramente o domínio do facto** do que, por exemplo, o membro do gang que assalta bancos e a quem é distribuída a função exclusiva de transportar o produto do roubo. Não o considerar assim seria, no fundo, sobrevalorizar de forma inadmissível o aspecto fáctico-objectivo da execução em detrimento do lado subjectivo e voluntarístico e, por conseguinte (e aqui, repete-se, reside o essencial), da carga de *ilícito pessoal* do acontecimento.

§ 80 Ficar-se-á assim, de novo, a um passo da subsunção da autoria mediata e da instigação no conceito superior de **autoria moral** ou **intelectual** — caso em que a distinção das duas categorias de autoria representaria ([103]) um dispensável ou mesmo inconveniente "luxo de conceitos" que em nada ajudaria o progresso dogmático e a aplicação do direito? Que as duas figuras, como quer que se definam e mutuamente se delimitem, se encontram a vários títulos substancialmente próximas, parece incontestável. Que o seu tratamento jurídico-penal, mesmo consideradas como duas formas de autoria, tenha necessariamente de confundir-se, é afirmação material, doutrinal e (segundo o direito português vigente) legalmente injustificável, como procurámos mostrar. O que sobra como dispensável é então o conceito de "participação", o qual acaba por se esgotar no de *cumplicidade*, sob as diversas concretizações que esta pode assumir.

V. A "autoria paralela"

§ 81 Fala-se de autoria paralela quando vários participantes no facto, **independentemente uns dos outros** (e não sendo, por conseguinte, co-autores), actuam em vista da mesma realização típica ou produzem, com a sua actuação, o mesmo resultado. Verdadeiramente, portanto, não se trata de uma *forma* de "comparticipação", nem sequer de uma *forma autónoma* de autoria. Se *A* e *B*, sem saberem um do outro e de forma independente, corrompem o funcionário *C* porque ambos estão interessados na mesma autorização, está claramente dado um caso de autoria paralela. Como também se *B* sabe do acto de *A* e, independentemente deste, actua em relação ao mesmo resultado. O campo por excelência da autoria paralela é — como se verá infra, 35.º Cap., § 46 e ss. — o das acções *negligentes*. Tudo considerado, deve afirmar-se que o conceito de autoria paralela, pelo menos no que respeita aos crimes dolosos de acção, **não assume significado dogmático autónomo** ([104]).

([103]) Como CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 128, chegou a escrever.

([104]) Neste sentido, também, a doutrina alemã praticamente unânime: cf. só ROXIN II, § 25, n.º 265 e s., e STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 99 e s. Sobre a questão, já, CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 137 e s.

VI. O início da tentativa

§ 82 O facto cometido em autoria mediata, em co-autoria ou instigado pode não atingir a consumação e ficar-se pelo estádio da tentativa. Deve então perguntar-se se a doutrina que atrás se defendeu para o autor individual em matéria de determinação da fronteira entre *preparação e tentativa* (supra, 28.º Cap., § 13 e ss.), por um lado, e em matéria de *desistência* relevante (supra, 35.º Cap.), por outro, deve ser transposta em bloco e sem mais para estas formas de autoria. Quanto ao problema da **desistência**, o nosso CP contém regras especiais, no art. 25.º, que, ao menos segundo o seu texto ("se vários agentes comparticiparem no facto", diz ele), valem para *toda a comparticipação*, sendo por conseguinte comuns à autoria e à participação; e como tal serão estudadas (infra, 33.º Cap., § 2 e ss.). Quanto ao primeiro problema enunciado — o do **início da tentativa** —, não existem dados legais específicos a respeito, tudo dependendo da combinação, no caso, das concepções gerais em matéria de autoria e de tentativa. Esta circunstância conduz a díspares interpretações. A questão fundamental reside em saber se o problema deve pôr-se somente em relação à acção do autor mediato, de cada co-autor ou do instigador (chamada "**solução individual**"); ou se deve antes pôr-se em relação à *unidade* constituída pelo autor mediato e pelo seu instrumento, pela totalidade dos co-autores, ou pelo instigador e instigado (dita "**solução global**" ou "**conjunta**"). Esta alternativa não se afigura — longe disso! — de fácil dilucidação.

1. Na autoria mediata

§ 83 Relativamente ao autor mediato, é indiscutível que a questão do início da tentativa só pode colocar-se a partir do momento em que ele começa a exercer a sua influência sobre o instrumento. Mas a partir daqui são possíveis as mais diversas soluções ([105]). Procurando reduzi-las ao essencial, para uma teoria — a da **solução puramente individual** —, a tentativa do facto cometido em autoria mediata começaria logo com o *início* da conduta externa de influência sobre o instrumento (de forma paralela à que ocorreria, em autoria singular, com o início da operação de activação de uma bomba de relógio que haveria mais tarde de explodir e matar uma

([105]) Por último, ROXIN II, § 29, n.º 226 e ss., e, em síntese, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 103 e ss.

pessoa) ([106]). Para outra teoria — crismada agora por Roxin de **solução individual modificada** —, a tentativa iniciar-se-ia com o *final* da actuação do autor mediato sobre o instrumento e, assim, com a "saída do acontecimento do âmbito de domínio do autor mediato" ([107]). Finalmente, para outra teoria ainda — a da **solução conjunta** —, a tentativa do facto em autoria mediata só deveria considerar-se iniciada com a *intervenção do instrumento* e, por conseguinte, quando este *inicia a execução* (de forma paralela à expressamente exigida pela nossa lei para a instigação: supra, § 63 e ss., e infra, § 89) ([108]).

§ 84 Podem avançar-se exemplos cuja solução se afigurará de grande dificuldade. Assim, p. ex., (1) se o médico *A* deixa, como de costume, logo pela manhã, preparada a injecção que a enfermeira *B* deve dar, pela noite, ao paciente *C*, tendo — sem a enfermeira o saber — enchido a seringa com veneno, abandonando logo o hospital, mas vindo a maquinação a ser descoberta e a seringa inutilizada no princípio da tarde. (2) Ou se *A* entrega, no consultório, a seringa envenenada a *B* para que esta se dirija à enfermaria e ministre a injecção a *C*, mas a enfermeira escorrega na escada e a seringa quebra-se. (3) Ou se *A*, à beira da cama de *C*, passa para as mãos de *B* a seringa envenenada para que seja logo ministrada, mas a seringa cai no chão e quebra-se. (4) Ou se *D* prepara um whisky envenenado que deixa sobre a mesa e vai depois jantar fora e ao cinema, esperando que o marido *E* depare com o whisky e, como é costume, o beba antes de jantar, mas, quando *E* se senta à mesa, disposto a tomar a bebida, o copo se quebra com uma rajada de vento que entrou pela janela que estava aberta. (5) Ou se o comerciante *F*, que foi já assaltado uma vez, deixa um engenho que explodirá se o assaltante *G*, como *F* receia, voltar, mas *G* não reincide ou o engenho é entrementes descoberto e desactivado ([109]).

§ 85 A **solução conjunta ou global** pode invocar a seu favor argumentos importantes. Desde logo, uma vez que o autor mediato se serve

---

([106]) SCHILLING, *Der Verbrechensversuch des Mittäters und des mittelbaren Täters*, 1975.

([107]) Pela primeira vez, ROXIN, Der Anfang des beendeten Versuchs, *Maurach—FS*, 1972, p. 213 e ss.; esta teoria é considerada por S / S / ESER, § 22, n.º 54, "absolutamente dominante" na Alemanha. Eser, de resto, pretende interpretar este critério no sentido de exigir, para início da tentativa na autoria mediata, que, segundo a representação do autor mediato, *o bem jurídico se encontre já imediatamente em perigo*. Inclina-se para a solução apontada no texto, entre nós, VALDÁGUA, Conceição, nota 31, p. 933 e s.

([108]) Assim, já FRANK, § 43, II, 2, a, KÜHL, § 20, n.º 91, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 105 e s. Por último, de forma próxima embora não coincidente, HERZBERG, Die Versuch, die Straftat durch einen anderen zu begehen, *Roxin—FS*, 2001, p. 749. Entre nós, logo CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 135.

([109]) Exemplos, modificados, colhidos em ROXIN II, § 29, n.º 227 e em STRATENWERTH / / KUHLEN, § 12, n.º 106.

de um instrumento *humano*, compreende-se que fique particularmente próximo o paralelo com as situações de instigação. Por outro lado, como lapidarmente o formulou Frank, "o autor mediato executa *através* do intermediário e, por conseguinte, não antes deste" ([110]). Em favor da **solução individual modificada** podem porém produzir-se também dois argumentos ponderosos. O primeiro é o de que, contrariamente ao que sucede na instigação, o "instrumento" é *sempre* alguém não plenamente responsável, pelo que, para o efeito aqui em vista, fica mais próxima a analogia com o instrumento não humano — com a bomba de relógio! — do que com a situação de instigação ([111]). O segundo é o de que a lei portuguesa em matéria de actos de execução parece revelar-se — sobretudo por força do disposto no art. 22.º-2/*c)* e por mais restritivamente que este preceito deva ser interpretado (supra, 28.º Cap., § 30 e ss.) — mais lata do que a alemã, tal como dominantemente é entendida.

§ 86 Se autoria mediata é, nos termos do art. 26.º, execução do facto por intermédio de outrem, o **ponto de partida** para a resolução do problema de agora parece dever residir na afirmação de Frank que referimos e que a doutrina alemã pretende classificar dentro da "solução global": a tentativa não pode ter início antes do início da actuação do homem-da-frente. A esta solução opõe Conceição Valdágua a afirmação de que "ponto de partida para determinar o início da tentativa do autor mediato é o primeiro acto de execução que, no caso concreto, tanto pode ser realizado pelo autor mediato como pelo autor imediato" ([112]). E também esta afirmação, em si mesmo tomada, é procedente. O que daqui resulta é que, segundo a normalidade do desenvolvimento das hipóteses de autoria mediata, o princípio de Frank é válido para a generalidade dos casos; sem no entanto dever excluir-se que, em casos excepcionais devidamente comprovados — nomeadamente, mas não só, nos casos em que o instrumento seja a própria *vítima* —, a actuação do autor mediato possa compreender já a prática de actos de execução ([113]); o

---

([110]) FRANK, referido também por STRATENWERTH / KUHLEN, ambos nota 108.

([111]) A situação de proximidade e de afastamento relativamente às duas situações é, em síntese, muito exactamente caracterizada por STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 104.

([112]) VALDÁGUA, Conceição, nota 31, p. 934[42].

([113]) Serão porventura casos deste teor que levam STRATENWERTH / KUHLEN, § 12[123] — citando KRACK, Der Versuchsbeginn bei Mitäterschaft und mittelbare Täterschaft, *ZStW 110*, 1998, p. 634 e s. —, a afirmar, depois de dar razão à proposição de Frank referida, que "em todo

que, no nosso entendimento do disposto no art. 22.º/*c)*, sucederá quando, no fim da actuação do agente mediato, existir já uma **conexão de perigo típica** para o bem jurídico ameaçado: em tal caso — que cremos verificado nas hipóteses (3) e (4) do § 84, mas não nas (1), (2) e (5) —, será nesse momento que deve considerar-se iniciada a tentativa do autor mediato. Se, tudo ponderado, assim se abandona o seio da chamada "solução conjunta" para sufragar uma "solução individual modificada" constitui, em definitivo, questão puramente conceitual-classificatória de interesse diminuto.

2. Na co-autoria

§ 87 A alguns títulos diferente da anterior é a situação na co-autoria ([114]): aqui, o que se pretende determinar é se, a partir do momento em que um co-autor pratica, de acordo com a decisão conjunta, o primeiro acto de execução, devem todos os outros co-autores ser punidos por tentativa, mesmo que ainda não tenham levado a cabo qualquer acto de execução (solução global); ou se, diferentemente, cada co-autor só deve ser punido por tentativa quando a sua actuação alcançou o estádio da execução (solução individual). A **solução global** é largamente dominante na doutrina alemã, na base, sobretudo, do argumento de que uma solução individual faria depender a punibilidade do co-autor do puro *acaso* (*v. g.*, da concreta configuração do plano e de a intervenção de um co-autor anteceder a de outro) e conduziria a que os co-autores fossem desigualmente tratados ([115]). Conceição Valdágua criticou, fundada e exaustivamente, este argumento ([116]). Se, em caso de autoria e de acordo com o plano comum, um ou uns co-autores deram início à *execução* do crime, enquanto outro ou outros nada chegaram a executar, não se vê que seja injusto ou desigual tratar mais favoravelmente este(s) último(s); até porque — como se referirá também infra, 35.º Cap., § 2 e s. — não viola o princípio da culpa o funcionamento do acaso *em favor* do agente. O que, de todo o modo, não parece legítimo é considerar que já a decisão con-

---

o caso pode excepcionalmente o autor mediato começar a tentativa através do seu próprio comportamento, *antes* que o instrumento se torne activo" (s. n. o.).

([114]) Fundamental entre nós, VALDÁGUA, Conceição, nota 39.

([115]) Assim, pela maioria, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 108. Entre nós também, CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 136.

([116]) VALDÁGUA, Conceição, nota 39, p. 155 e ss.

junta como tal representa um início de execução susceptível de fundar a responsabilidade ([117]).

§ 88 De acordo com a concepção do domínio do facto atrás defendida, segundo a qual a co-autoria exige um contributo significativo do agente na fase da execução, uma **solução individual** parece merecer preferência. Na verdade, também o co-autor de uma tentativa deve condominar essa tentativa; o que só é possível quando ele exteriorize um comportamento, ou co-actue no estádio da tentativa ([118]). Por isso se deve recusar que actos meramente preparatórios possam bastar (como acaba por estar na linha da solução global) para fundar uma tentativa em co-autoria. Tal só deve ser possível, relativamente a cada co-autor, quando ele pratica, de acordo com o plano conjunto, actos de execução nos termos do art. 22.º O que é tanto mais assim quanto no direito português — o que, do nosso ponto de vista, torna nele uma solução individual pouco menos que indiscutível — o art. 26.º, 3.ª alternativa, se não basta com que o "conjunto" dos co-autores pratique ou execute o facto, mas impõe que cada um **tome parte directa na execução** ([119]).

3. Na instigação

§ 89 O problema é aqui expressamente resolvido pela lei, que exige para existência da própria instigação que "haja execução ou começo de execução". Poderia à primeira vista dizer-se que tal não resolve a questão, porque sem início de execução não existe punibilidade (salvo nos casos em que a preparação seja já em si mesma punível) *para qualquer forma de autoria*, individual ou em comparticipação. E é exacto. Mas por isso e porque uma tal reafirmação no art. 26.º, 4.ª alternativa, constituiria pura inutilidade, tem de conceder-se que com aquela menção expressa quis o preceito legal significar — se bem que defeituosamente — que o início da tentativa da prática do facto implica, na instigação, a **prática de um acto de execução pelo instigado**. Uma tal doutrina é fundada e não porque a instigação seja uma forma de participação, coisa que o preceito legal des-

---

([117]) Pormenorizadamente, KRACK, nota 113, p. 614 e ss.

([118]) Assim, VALDÁGUA, Conceição, nota 39, p. 175 e ss., e, agora também, ROXIN, *LK*, § 25, n.º 199, e II, § 29, n.º 299.

([119]) Precisamente nestes termos, VALDÁGUA, Conceição, nota 39, pp. 120 e 164 e ss.

mente. É fundada quer de um ponto de vista político-criminal, pela razão avançada supra, § 66 e que aqui não vale repetir; quer de um ponto de vista dogmático, porque à essência da instigação pertence que o instigado — o "homem-da-frente" — seja *plenamente responsável* e por isso a actuação do instigador só se torna imediatamente perigosa para o bem jurídico ameaçado se e quando o instigado der início à execução. Se quisermos, pois, para a instigação vale completamente — *hoc sensu* — a **solução conjunta ou global**.

32.º CAPÍTULO

A CUMPLICIDADE

I. Cumplicidade e participação

§ 1 Como vimos (supra, 31.º Cap., § 43 e ss.), a lei portuguesa vigente considera a instigação verdadeira autoria. Se se quiser manter, apesar disso, ao lado da autoria, a categoria da "participação" — em atenção a uma, mesmo entre nós, continuada tradição doutrinal —, então uma tal categoria é inteiramente preenchida pela "cumplicidade" regulada no art. 27.º: participação e cumplicidade são assim sinónimas, a primeira de extracção doutrinal, a segunda de extracção legal. A partir daqui se compreende e aceita que a elaboração e a evolução doutrinais que a categoria da participação tem sofrido sejam, em geral, aplicáveis à cumplicidade. E, desde logo, a ideia central que preside à participação: a de que esta constitui colaboração no facto do autor e, por conseguinte, a sua punibilidade supõe a existência de um facto principal (doloso) cometido pelo autor (o "facto do autor"). É a esta "dependência" que doutrinalmente se dá o nome de **acessoriedade da participação**.

§ 2 O cúmplice ou participante não é pois autor, não comete por qualquer forma o delito, não pratica a acção típica e o seu comportamento não está, consequentemente, abrangido pelas previsões da PE do CP. Deste modo, o art. 27.º, ao punir a cumplicidade, contém uma **extensão** ou um **alargamento** da punibilidade a formas de comportamento que, sem ele, não seriam puníveis. Isto significa que, face ao princípio *nullum crimen sine lege*, não existe um *numerus apertus* das formas de participação (1). De acordo com a lei portuguesa vigente **a única forma de participação é a cumplicidade**.

---

(1) Assim, por outros, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 113.

§ 3 O que pode acontecer é que, em certas hipóteses, a lei incrimine **autonomamente** a forma de comportamento própria da cumplicidade (de modo análogo ao que vimos suceder, em certos casos, com os actos preparatórios: supra, 27.º Cap., § 5). Esse será o caso, *v. g.*, do art. 350.º-1, quando declara punível o funcionário que "por qualquer forma auxiliar" a evasão de um preso. Nestes casos, obviamente, a "cumplicidade em sentido material" em causa constitui já, ela própria, autoria (2).

II. Fundamento de punição da cumplicidade

§ 4 São duas, fundamentalmente, as posições que a respeito do fundamento de punição da cumplicidade podem ser tomadas (3). Uma coloca o acento tónico na actuação do participante **sobre a pessoa do autor**, nomeadamente, na "corrupção" da vontade daquele por este. A outra põe em evidência a colaboração do participante não com o *autor* do facto, mas **no facto do autor**, quer o ilícito da participação *derive* do ilícito do facto do autor, quer aquele se considere *autónomo* perante este.

§ 5 Hoje pode considerar-se praticamente abandonada pela doutrina a teoria que considera a **participação na culpa do autor** (4) como fundamento de punição da cumplicidade. Desde logo porque ela contraria, entre nós, o disposto no art. 29.º, segundo o qual "cada comparticipante [por conseguinte, autor ou cúmplice] é punido segundo a sua culpa, independentemente da punição ou do grau de culpa dos outros comparticipantes". A culpa e os elementos para ela relevantes são "incomunicáveis" entre os comparticipantes (infra, 33.º Cap., § 15 e ss.), de tal modo que não poderia fundar-se a punição do cúmplice na ideia de que ele é con-culpado pela atitude do autor. É perfeitamente possível, por exemplo, ser punido como cúmplice de homicídio aquele que auxilia um inimputável, a seu insistente rogo, a matar outra pessoa.

§ 6 Se desta concepção passarmos, então, à da cumplicidade como participação *no facto do autor*, de rejeitar parece ser igualmente a ideia de que o fundamento de punição da cumplicidade se situaria ainda dentro da doutrina da *causalidade*. Dito mais correctamente, que a cumplicidade constituiria uma **forma autónoma de causação** da realização típica, que ela seria

(2) De novo, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 114.
(3) Cf. já CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 110 e ss.
(4) Defendida ainda por MAYER, *Studienbuch*, 1967, p. 155 e ss.

punida porque representaria um contributo causal relevante para a realização do tipo (sobre esta ideia já: supra, 30.º Cap., § 8); até ao ponto de se afirmar — como foi afirmado — que ao lado do delito do autor se dá um autónomo "delito do participante" (5).

§ 7 Também esta concepção não consegue, na verdade, impor-se. O facto do cúmplice *pressupõe*, para a sua punibilidade, o facto do autor, pelo menos enquanto facto ilícito-típico, liga-se congenitamente a ele, daqui derivando justamente a exigência de "acessoriedade". Esta exigência não encontra porém qualquer refracção na concepção em crítica, mal se compreendendo, atenta a pretendida autonomia do facto do participante, por que razão houvesse ele de ser "acessório" relativamente ao facto do autor; a menos, é claro, que se visse — e não pode ver-se — no facto do autor uma espécie de "condição objectiva da punibilidade" da cumplicidade. Como tão-pouco se compreenderia a razão por que o art. 27.º-1 exige que a actuação do cúmplice seja "*dolosa*" (6). Não é esta, em suma, nem a concepção da lei, nem a que corresponde ao regime (e aos efeitos) que à acessoriedade devem ser imputados. Enfim, e decisivamente: se a cumplicidade é participação no facto do autor e se a autoria é uma categoria indissoluvelmente ligada a um ilícito-típico **pessoal** (supra, 30.º Cap., § 12), constituiria então uma inadmissível e insuportável contradição normativa considerar a cumplicidade fundada num ilícito-típico **causal**.

§ 8 O fundamento da punição da cumplicidade reside pois, como considerações anteriores deixaram já sugerido, no contributo que o comportamento do cúmplice oferece para a realização pelo autor de um facto ilícito-típico, reside, numa fórmula mais curta, na **participação no ilícito-típico do autor**. O que a actuação do cúmplice directa e imediatamente viola não é a proibição do comportamento do autor, mas a de prestar *auxílio material ou moral* àquele comportamento proibido, nos termos do art. 27.º Ao menos *primariamente*, por conseguinte, a cumplicidade é,

---

(5) Entre outros, SCHMIDHÄUSER, 14/77 e ss. No fundo não parecia ser outra a ideia de FERREIRA, Cavaleiro de, *Da Participação Criminosa*, 1934, p. 181; e é a de PEREIRA, Margarida Silva, Da autonomia do facto de participação. Um estudo referente ao Código Penal de 1982, *O Direito 126*, 1994, p. 592 e ss., que chega a admitir casos de "participação" sem autoria (p. 611 e s.).

(6) Para CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 112 e ss., uma tal exigência não poderia resultar da "essência" da cumplicidade, mas apenas da exigência político-criminal da não punibilidade das bagatelas (*minima non curat praetor*).

em definitivo e nesta acepção, uma categoria acessória e dependente do facto do autor (7).

§ 9 Se, *secundariamente* e sob diverso ponto de vista, a cumplicidade deve surgir (também) como entidade "autónoma" e "independente" do ilícito do autor, é coisa que Roxin afirma com insistência, pretendendo assim traduzir a ideia de que o comportamento do cúmplice tem também de representar, em si mesmo, um **ataque autónomo a um bem jurídico**. O que — ao menos para os crimes de resultado — seria desde logo e além do mais imposto pela regra de ouro da imputação objectiva, segundo a qual (como dissemos supra, 12.º Cap., § 21 e ss.) um resultado só pode ser imputado a uma acção se esta tiver criado um risco não permitido e este vier a concretizar-se na realização típica. Ideia esta, segundo Roxin, que teria implicações não apenas teóricas, mas normativo-práticas em vários pontos do regime da cumplicidade (8).

§ 10 Deve concordar-se, logo à partida, que também o direito penal da cumplicidade não pode deixar de referir-se ao bem jurídico: a extensão à cumplicidade da punição do facto do autor (especialmente atenuada: art. 27.º-2 e infra, § 34) não pode por isso deixar de fazer-se também em nome da tutela dos bens jurídico-penais. Mas pode duvidar-se que esta circunstância confira uma verdadeira "autonomia" ao comportamento do cúmplice, a não ser, em casos especiais, de carácter **negativo**: se toda a cumplicidade é participação no ilícito-típico do autor, nem toda e qualquer participação tem no entanto de constituir (ou pode ser punida como) cumplicidade. Para que tal seja reconhecido basta considerar os requisitos da sua punição, não parecendo para tanto necessário ou conveniente turvar ou enfraquecer a força de vigência do princípio da acessoriedade, fundamental na correcta compreensão de toda esta matéria.

§ 11 O ilícito-típico do facto principal é pois, segundo o princípio da participação no ilícito, *conditio sine qua non* do ilícito da cumplicidade; mas em vista de razões já aduzidas ele deve ainda fornecer a **medida** deste ilícito. Se, para a culpa, são decisivas a posição e as relações individuais

(7) Doutrina hoje, no essencial, dominante na Alemanha: por outros, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 121.

(8) ROXIN II, § 26, n.ºs 8 e s., 11.

de cada comparticipante (art. 29.º), já parece no entanto que **todos os comparticipantes devem responder pelo mesmo ilícito**. Sendo esta porventura a justificação dogmática mais funda que — uma vez afastada a tese do conceito unitário de autoria dolosa que, como vimos (supra, 30.º Cap., § 29 e s.) não é o do nosso direito vigente — pode apontar-se para a "comunicabilidade" de circunstâncias relativas ao ilícito constante do art. 28.º Uma tal comunicabilidade não pode todavia aceitar-se sem limitações: toda a questão será tratada mais tarde, porquanto comum à autoria e à cumplicidade (infra, 33.º Cap., § 15 e ss.).

III. A acessoriedade da cumplicidade

§ 12 Estabelecido que a actuação do cúmplice é, no sentido exposto, acessória e dependente relativamente ao facto do autor ou "facto principal", não está todavia dito que os requisitos que ela deve possuir sejam (apenas) aqueles que do princípio da participação no ilícito-típico do autor por necessidade resultam: sem pôr em causa um tal princípio, podem, de um ponto de vista normativo e (ou) legal, dever fazer-se à acessoriedade — em nome de outras razões político-criminais — **exigências adicionais**. Cumpre por isso estudar com mais pormenor em que se traduz concretamente a referida "acessoriedade" (9).

1. A acessoriedade dita qualitativa ou interna

§ 13 Na acessoriedade trata-se antes de tudo — como já se inculcou — de **determinada medida mínima de elementos constitutivos do facto do autor** (dita, por vezes, acessoriedade "qualitativa" ou "interna"). Face ao princípio da participação no ilícito-típico, afastada se tem considerado desde logo a orientação chamada da **acessoriedade mínima**, a qual se bastaria com que o comportamento do autor constituísse um facto formalmente típico (10). Como hoje de forma praticamente unânime se reco-

(9) Sobre a distinção que se segue entre acessoriedade qualitativa e quantitativa cf. só, na nossa doutrina, MONTEIRO, Salinas, *A Comparticipação em Crimes Especiais no Código Penal*, 1999, pp. 146 e ss., 307 e ss., e VALDÁGUA, Conceição, Figura central, aliciamento e autoria mediata, *Estudos Cunha Rodrigues*, I, p. 919[8] e s., indicando estes AA. abundante literatura estrangeira a propósito, sobretudo alemã e espanhola.

(10) Referência, p. ex., em CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 93. PEREIRA, Margarida Silva, nota 5, apesar de pretender negar em bloco a relação de acessoriedade (qualitativa) (p. 611 e s.),

nhece na doutrina, um facto formalmente típico mas justificado, p. ex., não recebe da ordem jurídico-penal qualquer sentido negativo de valor, pelo que constituiria supedâneo inidóneo da punição de uma participação em um tal facto.

§ 14 De repudiar se considera igualmente, no outro extremo, a exigência de uma **hiper-acessoriedade**, que exigiria que o facto do autor, para além de tipicamente ilícito e culposo, fosse ainda concretamente punível (**acessoriedade extrema**). Alegando-se que, pelo menos à partida, não se vê razão para que o cúmplice deixe de ser punível, em nome da acessoriedade do seu facto, só porque ao facto do autor faltou uma condição objectiva de punibilidade ou, de todo o modo, interveio uma causa de exclusão da pena ou mesmo só uma causa de exclusão da prossecução penal (supra, 26.º Cap.): também esta orientação constitui hoje uma aquisição praticamente unânime da doutrina. O sentido político-criminal (preventivo) de punição da cumplicidade — acrescenta-se — não reside numa participação na *pena* que deva atingir o autor: pelo que teria justificação bastante punir essa participação ainda quando o autor acabe por não dever ser punido por razões atinentes à falta de concreta dignidade penal ou de carência de punição do *seu* facto.

§ 15 Ficam assim em questão, verdadeiramente, apenas as teses da acessoriedade limitada e da acessoriedade rigorosa. Segundo a tese da **acessoriedade rigorosa**, o fundamento de punição da cumplicidade — na linha da teoria da participação na culpa: supra, § 5 — só estará presente se o facto do autor puder considerar-se, para além de um facto ilícito-típico, também um facto culposo. Teoria esta que de alguma forma se compreendia quando o dolo e a negligência eram considerados, exclusivamente, elementos pertencentes à culpa: podia então perguntar-se, com alguma razão, se o facto ilícito — como facto que preenche formalmente um tipo de crime e relativamente ao qual não se verifica qualquer causa de justificação — dava já razão bastante de punição da cumplicidade, quando é certo que ele podia constituir um facto insusceptível de ser objectivamente dominável e evitável ([11]). A doutrina da acessoriedade rigo-

---

vê-se afinal obrigada a reconhecê-la, sob uma qualquer forma — por "mais mínima" que seja —, na base (exacta) de que "o referente da participação é o facto principal" (p. 629).

([11]) Não faltando por isso autores que, apesar de considerarem o dolo e a negligência como elementos exclusivos da culpa, se afastavam já — tomando também por vezes em conta

rosa deixou porém de ter razão bastante desde o momento em que o tipo de ilícito do facto compreende não apenas o tipo objectivo, mas também o *tipo subjectivo de ilícito* e por isso a sua natureza tipicamente dolosa ou negligente. Ao que acresce a circunstância decisiva (já referida supra, § 5) de a lei ter vindo dispor expressamente, no art. 29.º, que cada comparticipante é punido segundo a sua culpa, independentemente da culpa dos outros comparticipantes. Parece restar pois apenas como correcta a tese da **acessoriedade limitada**, em absoluto correspondente à ideia-mestra da cumplicidade como participação no ilícito-típico do autor: para que aquela seja punível é necessário que o facto principal seja típico e ilícito. De um ponto de vista *objectivo*, naturalmente, mas também de um ponto de vista subjectivo: é inarredável a exigência de que o facto do autor seja *tipicamente doloso ou negligente*. Em nome do princípio da acessoriedade dita qualitativa ou interna nada mais deverá porventura ser exigido do facto do autor: se este tem de ser doloso — e tem, segundo o art. 27.º-1 — ou pode ser negligente é questão que já não deve ser decidida à luz do princípio da acessoriedade.

§ 16 Sendo esta posição, em nossa opinião, de subscrever como a mais correcta, deve no entanto introduzir-se nela uma certa **correcção** ou **aditamento**. Sem dúvida que não devem — nem podem, segundo a nossa lei — entrar em consideração na questão em apreço as circunstâncias relativas à **culpa** do autor. Mas será assim também relativamente aos pressupostos adicionais de punibilidade (supra, 26.º Cap.)? Certamente que sim — diríamos: por maioria de razão face aos elementos da culpa — se tais pressupostos deverem contar-se entre as condições *subjectivas* de punibilidade ou as causas *pessoais* de exclusão da pena. Mas já não, cremos, se tais pressupostos constituírem **condições objectivas de punibilidade** ou **causas materiais de exclusão da pena**. *V. g.*, se no primeiro caso suceder que a insolvência não chegou a ser judicialmente reconhecida, nos termos do art. 227.º-1; ou se, no segundo caso, tiver ocorrido regularização da situação tributária que exclui a responsabilidade por infracção tributária, nos termos do art. 4.º-1/*b)* do Regime Excepcional de Regularização Tributária, aprovado pela L 39-A/2005, de 29-7.

---

o disposto no art. 31.º do nosso CP anterior — da tese da acessoriedade rigorosa em favor da da acessoriedade limitada: assim, entre outros, CORREIA, Eduardo, *Studium*, p. 94 e s., e **II**, p. 262.

§ 17 Em casos deste teor, efectivamente, as circunstâncias aludidas respeitam directamente, em último termo, à dignidade penal e à carência de pena do facto global realizado e conduzem a que a impossibilidade legal de efectivação da responsabilidade do autor — tanto do ponto de vista da reafirmação da validade das normas e do restabelecimento da paz social, como do ponto de vista da protecção dos bens jurídicos co-envolvidos — **deixe sem sentido a punição do cúmplice**. Numa palavra, condições objectivas de punibilidade e causas materiais de exclusão da pena são ainda elementos constitutivos do **facto do autor** que é pressuposto da relevância da cumplicidade nos termos da parte final do art. 27.º-1 (de modo análogo ao que, como vimos supra 5.º Cap., § 9 e ss., e 21.º Cap., § 42, ocorre com o "facto do inimputável"). Saber, a partir daqui, como deve cognominar-se esta acessoriedade — limitada, à partida, mas acabando por englobar elementos de uma acessoriedade dita "extrema" — é coisa relativamente pouco importante. Mas julgamos corresponder ao essencial do nosso pensamento sobre o ponto se, neste contexto, falarmos de uma **acessoriedade limitada modificada**.

2. A acessoriedade dita quantitativa ou externa

§ 18 Por acessoriedade quantitativa ou externa costuma designar-se — com maior ou menor propriedade — a exigência de que o facto principal alcance **um certo estádio de realização**: se a cumplicidade é participação no facto de outrem, *rectior*, no *ilícito-típico* de outrem, então aquela não pode existir de um ponto de vista jurídico-penal e ser punível se o ilícito-típico não existir ([12]). Dir-se-ia assim que, tal como o art. 26.º, 4.ª alternativa, exige para a instigação, também aqui — apesar do silêncio da lei — se deve exigir que "haja execução ou começo de execução" da parte do autor. Mas é diversa, num e outro caso, a razão da exigência: na instigação, como defendemos (supra, 31.º Cap., § 64), a exigência funda-se em *particulares razões político-criminais de segurança e certeza jurídicas* e nada tem a ver com uma qualquer acessoriedade da instigação; enquanto na cumplicidade ela surge como *pura decorrência (lógica e teleológica) da ideia da participação no facto de outrem*; não estando no

([12]) É neste sentido que FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 491, compreende a exigência de acessoriedade na cumplicidade, na medida em que esta não será punível sem que se verifique a "prática do facto por outrem". Na sua obra *Da Participação Criminosa*, 1934, p. 243, o A. concluía que "o facto do autor material é condição de punibilidade da cumplicidade".

entanto excluído que a cumplicidade possa verificar-se não só relativamente à **tentativa** do facto principal, mas também aos seus **actos preparatórios** nos casos excepcionais em que estes sejam puníveis (*v. g.*, contrafacção de moeda, arts. 271.º-1 e 262.º). Provavelmente em vista daquela diferença é que a lei portuguesa se sentiu obrigada a exigir expressamente, relativamente à instigação (art. 26.º-4), que "haja execução ou começo de execução", mas já a tal se não sentiu vinculada no caso do art. 27.º relativamente à cumplicidade.

§ 19 Para uma certa corrente de opinião — compreensivelmente, muito difundida na Alemanha, face à punibilidade da *tentativa de participação* expressamente consagrada no § 30 do seu CP — o princípio em que acabámos de assentar seria limitado (ou invalidado?...) por, em certas circunstâncias, poder ser punida a **tentativa (sem êxito) de cumplicidade**. Tal não vale porém entre nós, como se dirá infra, § 36 e ss., pelo menos em termos donde resulte contradição irremissível com o princípio analisado.

3. O momento temporal da cumplicidade

§ 20 Diferente da questão acabada de abordar, mas em todo o caso ainda imputável de algum modo ao princípio da acessoriedade, é a de saber **quando** deve ter lugar o facto da cumplicidade para considerar-se punível. O seu campo de eleição é seguramente, de um ponto de vista prático, o da **fase de preparação** do facto principal: será durante esta fase que, as mais das vezes, o cúmplice prestará auxílio material ou moral ao facto do autor ([13]). Por outra parte, a cumplicidade só pode contribuir para a realização do facto pelo autor enquanto aquele **não tiver sido ainda completamente realizado**: uma cumplicidade *ex post facto* não existe ([14]). A partir daqui pode erigir-se com segurança o princípio segundo o qual a cumplicidade só é possível e punível até à **consumação** do ilícito-típico principal. Mas já é altamente discutível e discutido se esta consumação é sempre a consumação **formal** ou típica ou se pode ser (e se sim, em que casos) a consumação **material**, terminação ou conclusão do facto (supra, 27.º Cap., § 11 e s.).

([13]) Assim, também, ROXIN II, § 26, n.º 255.

([14]) Tendo por isso mesmo — como referimos supra, 30.º Cap., § 2 — o CP vigente deixado de considerar o *encobrimento*, pessoal ou real, como uma forma de comparticipação e passado a configurá-lo como crime autónomo.

§ 21 Segundo a jurisprudência alemã, seguida por uma parte substancial da doutrina, a cumplicidade é em princípio possível até ao **término material do facto**, mais rigorosamente ainda, até ao **asseguramento do resultado**. Mas parece-nos, com Roxin, que assim se vai longe demais, devendo aquele "princípio" ser substituído pelo seu contrário, o de que **a cumplicidade como tal não existe para além da consumação típica**. Porque, de um ponto de vista político-criminal, aquela solução pode, relativamente a esta, conduzir a punições muito mais graves e injustificadas do cúmplice; e porque se tornam assim inseguras, até um ponto dificilmente suportável, as relações que então devem estabelecer-se entre a cumplicidade com o facto principal e os crimes autónomos de favorecimento, pessoal (art. 367.º e s.) ou real (arts. 231.º-233.º) ([15]).

§ 22 De interesse nos parece, neste enquadramento, a consideração de Stratenwerth tendente a conferir valor decisivo ao **momento em que foi tomada a decisão de auxílio**, nomeadamente, **antes** ou **depois** da consumação típica. O que vale desde logo — e porventura sobretudo — para os crimes de **intenção ou resultado cortado** (supra, 13.º Cap., § 58 e s.), de que pode apontar-se o exemplo da burla. Se o acto de auxílio foi decidido *antes* da consumação formal (da verificação do dano da vítima) trata-se de cumplicidade. Se só depois, embora antes ainda da conclusão da deslocação patrimonial, a questão só pode ser a de favorecimento pessoal ou real, não a de cumplicidade. Mas vale também, de certo modo, para casos de **crimes complexos** (supra, 11.º Cap., § 49), *v. g.*, o roubo: se o acto de auxílio deve ter lugar, segundo o decidido em conjunto, após a vítima ter sido ferida mas antes de ter sido furtada, estaremos face a uma cumplicidade no roubo; mas já não assim se o acto de auxílio só vem a ligar-se ao autor depois de a violência estar já consumada: então o cúmplice só deve responder pelo acto parcial em que efectivamente participou, no caso, pelo furto ([16]).

§ 23 O que ficou dito não impede, no entanto, que se aceite a cumplicidade em casos como os dos crimes **duradouros** (supra, 11.º Cap., § 54): a consumação formal opera-se logo com o momento inicial de realização da totalidade dos elementos típicos, mas permanece até à eliminação do estado ilícito; até este último momento podem

([15]) ROXIN II, § 26, n.º 256 e ss.; também KÜHL, Die Beendigung des vollendetes Delikts, *Roxin–FS*, 2001, p. 675 e ss.

([16]) STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 135.

verificar-se actos de cumplicidade como participação no ilícito-típico ([17]). E aqui nos parece deverem caber não só hipóteses tradicionalmente consideradas de crime duradouro, máxime, o de sequestro (art. 158.º), mas também outros análogos para este efeito, *v. g.*, o de tortura (art. 244.º e ss.) ou de ofensa à integridade física prolongada (art. 144.º/*c*)) ([18]).

IV. O dolo na cumplicidade

§ 24 Só existe cumplicidade, nos termos expressos pela parte final do art. 27.º-1, quando o cúmplice presta auxílio a um *facto doloso*. Segundo o mesmo preceito — auxílio *doloso* a um facto *doloso* —, o dolo do cúmplice tem no entanto de possuir uma **dupla referência** (de forma paralela à que vimos exigir-se com o "duplo dolo" do instigador: 31.º Cap., § 67 e ss.): ele tem de referir-se à *prestação de auxílio*, por um lado, e, por outro, à própria *acção dolosa do autor*. Relativamente à **concretização** deste dolo não têm, porém, de valer sem mais regras análogas às expostas a propósito da instigação. A razão das diferenças — no sentido geral de um **amortecimento** das exigências feitas em sede de instigação — está em que aqui se não trata da imputação do facto ao autor mas a um mero colaborador ou participante no facto do autor.

§ 25 Assim, desde logo, em matéria de **determinabilidade** do dolo. Naturalmente que não pode deixar de exigir-se que o cúmplice conheça a *dimensão essencial do ilícito-típico* a praticar pelo autor — logo, as mais das vezes, porque de outra forma o auxílio não poderia ganhar eficácia. Mas a cumplicidade deverá ser admitida ainda quando o cúmplice desconheça, ou não conheça exactamente, as circunstâncias concretas em que vai desenvolver-se o ilícito-típico do autor: quem satisfaz o pedido de outrem de que lhe entregue uma arma com a qual vai cometer um assalto deve ser punido como cúmplice ainda que não possua informações mais pormenorizadas sobre a forma, o lugar ou mesmo o tempo em que aquele assalto vai realizar-se. Esta diferença deverá reflectir-se, correspondentemente, em matéria de **excesso**: alterações do facto do autor relativamente às representações do cúmplice que se mantenham ainda dentro da *dimensão essen-*

([17]) Doutrina absolutamente dominante, pela qual podem ver-se ROXIN II, § 26, n.º 264, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 131

([18]) STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 132.

cial do ilícito-típico representado por este não devem afectar a cumplicidade ([19]).

§ 26 Questão é saber se haverá aqui razões para aceitar — diversamente do que fizemos em tema de instigação: supra, 31.º Cap., § 71 e s. — a orientação da doutrina alemã largamente dominante e segundo a qual o dolo do cúmplice tem de dirigir-se à **consumação** do facto pelo autor, não podendo ficar pela mera tentativa ([20]). Não cremos. As reservas que além dirigimos a uma tal orientação valem aqui, em nosso modo de ver, de forma intensificada: não é esse o entendimento que deve dar-se à exigência do "duplo dolo"; também o facto tentado contém um conteúdo de ilícito-típico ao qual o auxílio pode dirigir-se com sentido; e também ele representa um "ataque ao bem jurídico", mesmo para aqueles autores que, como vimos ser o caso de Roxin, vêem neste ataque um elemento autónomo da cumplicidade (supra, § 10). A não punibilidade do cúmplice *agent provocateur* ou *agente encoberto* é questão que o legislador, se assim o entender, deve regular expressamente e que não pode retirar-se da doutrina geral em matéria de autoria e de cumplicidade.

V. Espécies de cumplicidade

§ 27 O art. 27.º-1 define o acto de cumplicidade como "**prestar auxílio material ou moral**": ele pode por isso traduzir-se em duas espécies diferentes, todavia submetidas a um regime jurídico-penal unitário — por mais que a distinção possa tornar-se duvidosa sob alguns pontos de vista — que lhe advém da exigência da prestação pelo cúmplice de um contributo **efectivo** para o facto do autor.

§ 28 Geralmente reconhecido é, desde logo, que a prática do facto do autor não tem de ficar na *dependência* do contributo do cúmplice: basta que este **favoreça** aquele, sendo vista aqui a diferença estrutural mais importante entre a cumplicidade e a co-autoria (supra, 31.º Cap., § 38). A questão mais discutível é a de saber se deve ainda considerar-se um contributo como efectivo nos casos em que o auxílio se traduz numa prestação mate-

---

([19]) Na direcção essencial destas soluções — com análises mais pormenorizadas de casos de que aqui não pode dar-se notícia — ROXIN II, § 26, n.º 272 e ss.

([20]) Cf. ROXIN II, § 26, n.º 270 e s., e STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 162.

rial que, todavia, não vem a ser utilizada pelo autor, *v. g.*, se o cúmplice entrega ao assaltante uma chave para que ele possa penetrar no espaço fechado mas ele encontra a porta aberta. A jurisprudência alemã decide pela afirmativa na base, sobretudo, de que o contributo do cúmplice não precisa de ser *causal* para o resultado. Mais correcto nos parece, por se adequar melhor ao pensamento fundamental nesta matéria, recorrer ainda aqui a um critério paralelo ao da potenciação do risco (supra, 12.º Cap., § 28 e ss.), bastando que o acto de cumplicidade **aumente as hipóteses de realização típica** por parte do autor ([21]). Se tal não acontece tudo ficará por uma tentativa de cumplicidade que não é em si mesma punível (infra, § 35 e ss.). De considerar é no entanto que, mesmo em certas hipóteses em que o auxílio material não tenha sido causal (no nosso exemplo, por o instrumento não ter chegado a ser utilizado), ele pode constituir auxílio moral (psíquico), *v. g.*, se o sentimento de segurança que proporciona ao autor serviu para dissipar as últimas dúvidas quanto ao cometimento do facto.

§ 29 Auxílio "moral" significa, pura e simplesmente, **auxílio psíquico**, isto é, favorecimento ou fortalecimento do autor na sua decisão. Cabem logo aqui os casos que chamámos de indução (supra, 31.º Cap., § 48), i. é, os casos de "instigação" que não constituem determinação no sentido do art. 26.º, 4.ª alternativa ([22]). O problema mais difícil é o de saber qual a **medida mínima de favorecimento** que deve ainda ser punida como cumplicidade. Alcança-a seguramente a hipótese chamada de *aconselhamento técnico*, como também a da *transmissão de informações* sobre hábitos e horários da vítima, sobre a utilização de instrumentos ou sobre alarmes e outras instalações de segurança. Em qualquer destes casos estamos perante actos *efectivos* que aumentam o risco e favorecem a prática do facto. Já não assim, porém, se o pretenso auxílio psíquico se traduzir só, p. ex., em revelar compreensão ou mesmo "aceitação" face às confidências do autor sobre aquilo que se propõe fazer.

§ 30 No presente contexto se suscita aquele que parece tornar-se num dos problemas mais discutidos, hoje, de toda a doutrina da cumpli-

---

([21]) Fundamentalmente neste sentido, ROXIN II, § 26, n.º 210 e ss., e STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 158 e s.

([22]) Em sentido algo semelhante, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 494, considera que o "auxílio moral" é o equivalente de conselho ou instigação de outrem que não constitua autoria moral, isto é, que não "determine" outrem à prática do facto.

cidade: o de saber se e em que medida **comportamentos quotidianos** (triviais, da vida diária), em princípio valorativamente neutros do ponto de vista geral da sua relevância criminal, podem apresentar-se como auxílios integrantes de cumplicidade sempre que eles, no caso concreto, facilitaram o cometimento de um crime. Os exemplos são, compreensivelmente, intermináveis, podendo ir da venda de produtos os mais correntes e insignificativos (*v. g.*, a pimenta, que pode servir como instrumento de ataque) até à conclusão de negócios jurídicos os mais diversos relativos a produtos já em si perigosos mas que não têm de acarretar perigo criminal (armas de caça, instrumentos para trabalhos manuais todavia cortantes ou contundentes [23]), máquinas para instalações fabris, etc.), sendo certo que quaisquer destes produtos pode ser utilizado na prática de acções criminosas. O critério geral de resolução do problema parece dever ser, ainda aqui, o de que, tal como a acção constitutiva do ilícito-típico, também **a prestação de auxílio deve traduzir-se na criação ou potenciação de um risco não permitido que ultrapasse a medida admissível** [24]. Mas este critério exige, na sua aplicação ao problema aqui em causa, precisões que mal começam a ser estudadas.

§ 31 Roxin leva agora a cabo o tratamento mais elaborado da questão [25], de que em seguida se apresentará uma curta súmula. Para ele há que fazer, logo à partida, uma distinção fundamental, consoante o homem-de-trás conhece a decisão delituosa do autor ou somente conta com a possibilidade de este cometer um ilícito-típico. Mesmo **em caso de conhecimento da decisão**, porém, nem toda e qualquer acção quotidiana deverá integrar a cumplicidade, mas só aquela que "revele uma **relação de sentido delituosa**" [26]. Possuidores de uma tal relação de sentido são, desde logo, as acções de auxílio que têm, elas próprias, natureza delituosa, *v. g.*, o dono de uma casa de ferragens que, na sua actividade normal, vende um machado a um indivíduo sabendo (por informação dele ou de terceiro) que ele vai provavelmente utilizá-lo para matar a mulher, ou vende uma chave de parafusos ao conhecido chefe de um bando, sabendo que ele vai utilizá-lo em roubos e furtos qualificados; porque, justifica

---

[23] Lembre-se o papel desempenhado pelos "X-actos" nos acontecimentos do 11 de Setembro!

[24] Assim, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 161.

[25] ROXIN II, § 26, n.º 218 e ss., com numerosas indicações concordantes e discordantes. Entre estas últimas destaquem-se as de JAKOBS, 24/17, e de FRISCH, *Tatbestandsmässiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs*, 1988, p. 295 e ss.

[26] Sobre este conceito já FRISCH, loc. cit. Uma discussão da questão entre nós — sob o prisma essencial da valoração social da conduta — já em FARIA, Paula Ribeiro de, *A Adequação Social da Conduta em Direito Penal ou o Valor dos Sentidos Sociais na Interpretação da Lei Penal*, 2005, p. 40 e ss.[17].

Roxin, "homicídio e arrombamento eram exclusivamente acções delituosas e precisamente também a elas se referiu o contributo favorecedor" ([27]). Mas — acrescenta — uma tal relação de sentido falta já "quando o contributo favorecedor se refere a uma acção legal, que tomada logo em si mesma já é cheia de sentido e útil para o autor mas, para além disto, da qual ele faz um pressuposto de um comportamento delituoso independente, derivado de uma decisão autónoma"; e exemplifica: "quem entrega material a um fabricante que, como aquele sabe, durante ou depois da sua utilização, vai violar prescrições de protecção ambiental, favorece um comportamento lícito (o fornecimento de produtos industriais) que já como tal tem sentido para o fabricante e não possui qualquer relação delituosa. O comportamento violador de prescrições ambientais em nada modifica isto e recai na responsabilidade exclusiva do fabricante" ([28]). Já se o participante somente **conta com um comportamento delituoso do autor**, a primeira determinação a obter será a de saber se, relativamente ao facto do autor, se poderá afirmar que o participante actuou com **dolo eventual**; ainda que a resposta seja — como, por exigência legal expressa, terá de ser — afirmativa, tais casos não deverão constituir cumplicidade em homenagem ao *princípio da confiança* ([29]).

§ 32 Por ponderada que deva considerar-se esta argumentação e penetração problemática de Roxin, **dúvidas se podem suscitar quanto à sua procedência**: quer porque se vê mal que, sabendo o participante que o autor vai, com o seu auxílio, qualquer que ele seja, cometer um crime, se possa negar a "relação de sentido delituosa" do seu contributo; quer porque, segundo o princípio da confiança, o agente não precisa de contar com o comportamento ilícito de outrem mas no caso, por definição, o agente *conta* com ele. Não é nossa ideia — longe disso — alargar a punibilidade da cumplicidade ainda para além do que o faz Roxin. Mas pode perguntar-se se não será necessário regressar, na sua pureza, à fórmula da criação ou potenciação (dolosa), em medida inadmissível, de um risco não permitido da realização típica e trabalhar com ela na tentativa de definição dos limites da punibilidade das acções quotidianas. Mais investigações aprofundadas tornam-se aqui necessárias.

VI. A punição do cúmplice

§ 33 Nos termos do art. 27.º-2, a pena do cúmplice é determinada em função da pena aplicável ao **autor do facto, especialmente atenuada**, isto é, atenuada segundo o modelo dos arts. 72.º e 73.º ([30]). O que não significa que, em termos de medida *concreta* da pena, aquela que é cabida ao cúmplice não possa ser *igual* (eventualmente até *superior*) à que caberá ao

([27]) ROXIN II, § 26, n.º 222.
([28]) ROXIN II, § 26, n.º 224.
([29]) ROXIN II, § 26, n.º 241 e ss.
([30]) DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 458.

autor, se tal for permitido pela moldura penal atenuada e relativamente a este último se verificarem factores poderosos de atenuação da sua responsabilidade que se não verificam relativamente ao cúmplice; ou/e se, relativamente ao cúmplice, se verificarem motivos poderosos de agravação da sua responsabilidade que não tenham lugar relativamente ao autor. A atenuação especial por cumplicidade pode eventualmente *concorrer* com outra determinada por motivos diferentes, *v. g.*, porque o facto principal ficou pelo estádio da tentativa.

VII. Cumplicidade e tentativa

1. Cumplicidade na tentativa

§ 34 Um primeiro enquadramento em que releva o tema que agora nos propomos tratar é o que rigorosamente poderá ser chamado da **cumplicidade na tentativa**. Ele não suscita todavia nenhuma dificuldade particular. Se, no caso, existiu cumplicidade, mas o facto do autor se fica pelo estádio da tentativa punível, e constituindo esta já em si um ilícito-típico, a participação nele, segundo o princípio da acessoriedade limitada, **é também punível** (supra, §§ 18 e 27). Haverá apenas que chamar a atenção para dois pontos: o primeiro é o de que relativamente ao facto comparticipado (e portanto também relativamente à cumplicidade) se pode verificar — sob certas circunstâncias que mais tarde serão estudadas: infra, 33.º Cap., § 2 e ss. — uma *desistência* relevante; o segundo — que referimos já supra, § 33, *in fine* — é o de que a pena do cúmplice merecerá uma *dupla atenuação especial*, em função da cumplicidade (art. 27.º-2) e da tentativa (art. 23.º-2).

2. Tentativa de cumplicidade (cumplicidade "falhada" ou sem êxito)

§ 35 O segundo enquadramento em que o tema releva e que poderá apelidar-se da **tentativa de cumplicidade** tem a ver com aqueles casos em que alguém tenta prestar auxílio à prática por outrem de um facto ilícito-típico, todavia *baldadamente*, porque o favorecido ou recusa o auxílio ou acaba por se não decidir pelo facto. Melhor que de tentativa de cumplicidade — por perigo de confusão entre esta constelação problemática e a acabada de considerar — se falará aqui de **cumplicidade falhada** ou **sem êxito**. Esta cumplicidade **não é punível** porque — não havendo na lei por-

tuguesa vigente lei que preveja expressamente a punibilidade destes casos — o auxílio acaba por se não verificar e não pode falar-se de cumplicidade; ou o facto ilícito-típico do autor não chega a concretizar-se, sequer sob a forma de início de execução, e por isso, segundo o princípio da acessoriedade, qualquer participação (tentada) não pode ser punível.

§ 36 Haverá quem critique (ou pelo menos lamente) a **lacuna de punibilidade** que a propósito se verifica no direito português vigente, em atenção sobretudo à não punibilidade da tentativa de instigação (*rectior*, do nosso ponto de vista, "tentativa de *indução*", isto é, tentativa de "instigação que não é autoria": supra, 31.º Cap., § 46). E lembre-se a propósito que a tentativa de determinação era expressamente prevista e punida pelo art. 31.º do ProjPG de Eduardo Correia ([31]), não tendo todavia uma tal proposta obtido consagração no CP vigente. E também que este preceito do ProjPG era afinal não mais que a tradução, praticamente literal, do § 30 do CP alemão vigente, cuja *admissibilidade político-criminal* uma parte significativa da doutrina alemã vem aceitando. Não nos parece, porém, que uma tal crítica ou lamento tenha justificação bastante: a não punibilidade da cumplicidade (participação) falhada ou sem êxito é justificada a vários títulos e não representa qualquer lacuna de punibilidade que deva reputar-se intolerável.

§ 37 Em primeiro lugar, não se compreenderia por que razão haveria a participação falhada de ser punível quando a própria **tentativa de autoria** mediata, de co-autoria ou de instigação só o é se o homem-de-trás, o co-autor ou o homem-da-frente praticarem, eles próprios, actos de execução no sentido do art. 22.º (supra, 31.º Cap., § 82 e ss.); coisa que, seguramente e logo por definição, se não dá na tentativa falhada de participação por falta de um facto principal. Não se compreenderia, em especial, que se punisse a tentativa de indução, quando a própria tentativa de instigação supõe que o instigado inicie a execução do facto. Em segundo lugar, e decisivamente do nosso ponto de vista, como de forma lapidar acentua agora Roxin, na punibilidade da participação falhada "não se trata nem de uma regulamentação especial da tentativa, nem da participação, mas de uma punibilidade autónoma de determinadas **formas de preparação do crime** sob a comparticipação (pelo menos almejada) de vários" ([32]). Em

([31]) Cujo texto se reproduziu supra, 27.º Cap., nota 3.

([32]) ROXIN II, § 28, n.º 2, que sublinha a negro toda a frase transcrita.

terceiro lugar, o que a lei consagraria nestes casos seria sempre, para além da punição de puros actos preparatórios, uma **punibilidade do "campo prévio"** (33), cuja criminalização deve, de um ponto de vista político-criminal, ser evitada até ao limite; e que, quando não possa sê-lo, deve ser guardada para casos especialmente graves (34) e rigorosamente definidos, *v. g.*, para casos de criminalidade altamente organizada ou transnacional. Em quarto lugar, uma tal punibilidade aproximar-se-ia perigosamente da **punição de meras intenções** que todavia, dada a sua aplicação tendencialmente total, nem sequer poderia ligar-se — como parecia ser ideia do Autor do ProjPG (35) — à existência de uma personalidade do agente particularmente perigosa. Em quinto lugar, e por último, a circunstância de a tentativa falhada de cumplicidade não ser punível nada permite concluir sobre a punibilidade ou não da instigação ou mesmo da cumplicidade **em cadeia**: estas afirmar-se-ão ou negar-se-ão consoante se possa ou não comprovar, relativamente a cada um dos elos, a autoria sob cada uma das suas formas ou a cumplicidade, nos termos gerais (cf., para a instigação, já supra, 31.º Cap., § 73 e ss.).

---

(33) Expressamente nestes termos, já BLOY, Grund und Grenzen der Strafbarkeit der misslungenen Anstiftung, *JR*, 1992, p. 494.

(34) Cuidado tomado, em alguma medida — embora, em nossa opinião, político-criminalmente insuficiente —, pelo § 30 do CP alemão, que se aplica unicamente aos "crimes" (*Verbrechen*), mas já não aos meros "delitos" (*Vergehen*); cuidado que o art. 31.º do ProjPG não tomava, consagrando a punibilidade para todo e qualquer crime.

(35) Cf. *Actas I*, p. 206 e s. Crítica que só se robustece — tanto perante o art. 31.º do ProjPG, como perante o § 30 do CP alemão — quando à "tentativa de determinação" se junta a punibilidade de quem "aceita a oferta de outrem, ou com outra pessoa se concerta, para cometer um crime, ou [de] quem se declara disposto a cometê-lo": cf. já supra, 27.º Cap., § 3.

33.º CAPÍTULO

QUESTÕES COMUNS À AUTORIA E À CUMPLICIDADE

§ 1 Tratar-se-á em seguida de algumas questões que não possuem necessariamente entre si analogia material ou problemática, mas unicamente têm a ligá-las a circunstância de serem **comuns** à autoria e à cumplicidade, de serem, nesta acepção, problemas de **comparticipação**. É esta comunidade a única razão didáctico-formal por que tais questões não foram tratadas — como podiam tê-lo sido — de modo fraccionado, a propósito das diferentes formas de autoria e da cumplicidade.

I. A desistência da tentativa na comparticipação (art. 25.º) (1)

§ 2 De acordo com o disposto no art. 25.º, "se vários agentes comparticiparem no facto, não é punível a tentativa daquele que voluntariamente impedir a consumação ou a verificação do resultado, nem a daquele que se esforçar seriamente por impedir uma ou outra, ainda que os outros comparticipantes prossigam na execução do crime ou o consumem". Trata-se pois de uma **regulamentação especial** da relevância da desistência relativamente a um facto tentado no qual comparticipam várias pessoas; especialidades que à partida se compreendem e aceitam porque o legislador considerou político-criminalmente inconveniente que cada comparticipante fosse tratado como se o facto tivesse sido cometido apenas por ele e, deste modo, com aplicação das regras que vimos (supra, 29.º Cap.) valerem para a desistência em caso de crime individual. Como bem acentua Costa

---

(1) Tratamento monográfico entre nós: PINTO, Costa, *A Relevância da Desistência em Situações de Comparticipação*, 1992; na literatura alemã cf. o estudo de MITSCH, Der Rücktritt des angestifteten oder unterstützten Täters, *Baumann—FS*, 1992, p. 89, e já o de GRÜNWALD, Zum Rücktritt des Tatbeteiligten im künftigen Recht, *Welzel—FS*, 1974, p. 701.

Pinto, dá-se nestes casos "a particularidade de para a agressão em causa contribuírem diversos agentes, com diferentes posições no plano de ataque aos valores tutelados" (2), apesar da unidade do facto resultante da sua interacção. Só destas especialidades, em todo o caso, curará a exposição seguinte, entendendo-se que em tudo o resto vale o regime atrás referido da desistência (art. 24.º). Nem por isso, todavia, deixa de ser legítimo suscitar, perante o preceito do art. 25.º, várias dúvidas fundadas.

1. O círculo das pessoas abrangidas pela norma

§ 3 O art. 25.º parece ter pretendido não deixar dúvida sobre os destinatários a que se dirige: trata-se da **totalidade dos comparticipantes** no mesmo facto, sejam *só autores* (de uma ou das várias espécies de autoria contempladas pela lei) ou *autores e cúmplices*. E todavia pode perguntar-se se foi esta a verdadeira intenção da lei, nomeadamente, a de vincular a aplicação do art. 25.º, antes que do art. 24.º, sempre que o facto é **individualmente** cometido. Responder afirmativamente, diz Roxin, seria uma concepção artificiosa, não se compreendendo, *v. g.*, porque haja de cair sob a alçada do art. 25.º a desistência do autor individual que foi favorecido pela actuação do cúmplice, quando este nada tem por hipótese a ver com aquela desistência (3). Nestes casos a desistência do autor deve ser submetida ao regime do art. 24.º, não ao do art. 25.º, apesar de no facto ter intervindo uma pluralidade de pessoas e, nesta acepção formal, terem intervindo "comparticipantes" (4).

§ 4 Discutível é saber se a mesma **restrição** deve aplicar-se aos casos de **autoria mediata** em que o homem da frente age de forma não plenamente responsável (afinal, segundo a doutrina que defendemos supra, 31.º Cap., § 55 e ss. e *passim*, a **todos** os casos que consideramos de autoria mediata). Costa Pinto, entre nós, e (entre outros) Roxin, na doutrina alemã, respondem afirmativamente (5). Mas temos dúvidas em dar a nossa concordância a uma doutrina que distinguiria o âmbito e a relevância da desistência consoante o homem-da-frente fosse ou não *punível* (6), conferindo em certo sentido (como se dirá) maior latitude à desistência do autor mediato no

(2) PINTO, Costa, nota 1, n.º 39.

(3) ROXIN II, § 30, n.º 306.

(4) Assim já, entre nós, PINTO, Costa, nota 1, n.º 96, referindo aliás casos interessantes, a propósito, da nossa jurisprudência.

(5) PINTO, Costa, nota 1, n.º 97, e ROXIN II, § 308.

(6) Como na conclusão do texto, entre outros, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 110.

segundo caso: também os comparticipantes não puníveis são comparticipantes para efeitos do art. 25.º

§ 5 Por maioria de razão nos afastamos da opinião de Costa Pinto — e o mesmo sucede com a doutrina porventura dominante na Alemanha (7) — segundo a qual também não seriam subsumíveis à doutrina do art. 25.º os casos que chama de **co-autoria** *complementar*, isto é, "aqueles em que os actos de cada agente se encontram reciprocamente condicionados na sua idoneidade lesiva, sendo expressão do exercício repartido de um domínio positivo do facto", embora já não os casos de "co-autor dependente que não exerça qualquer domínio positivo sobre o perigo típico dirigido à consumação, nem negativo sobre os actos do autor": podem eventualmente ser diferentes as exigências postas num caso e noutro à relevância da desistência, mas a qualquer deles dá resposta adequada o disposto no art. 25.º

§ 6 Deve assim concluir-se que o disposto no art. 25.º se aplica à desistência da tentativa em todas as espécies de comparticipação, isto é, à dos **autores mediatos**, dos **co-autores**, dos **instigadores** e dos **cúmplices**, mas já não aos casos de autoria imediata, ainda que neles intervenha um cúmplice estranho à desistência.

2. O estádio alcançado pelo facto

§ 7 Ao referir expressamente a doutrina que o art. 25.º contém à fase da **tentativa**, deve considerar-se que o legislador entendeu excluir do preceito, desde logo, os **actos preparatórios** (8). O comparticipante que torna ineficaz o seu contributo para o facto quando este se encontra ainda na fase preparatória não deve, na verdade, ser punido (*v. g.*, quando o marido promete a outrem levar a sua mulher ao bar onde sabe que ela será agredida ou morta por este, mas acaba por ficar com ela em casa; ou quando substitui o veneno que outrem há-de ministrar a sua mulher por um pó inofensivo): mas isto não porque se trate de desistência relevante — esta pressupõe sempre a tentativa —, mas porque os actos preparatórios não são em princípio puníveis (como dissemos supra, 27.º Cap., § 4 e ss.).

§ 8 Também no que toca a desistência na comparticipação, tal como sucede com o art. 24.º, o legislador entendeu **estender o privilégio** àque-

(7) Por ela, ROXIN II, § 30, n.º 308.
(8) PINTO, Costa, nota 1, n.º 9, e 287.

les casos em que se verificou já a consumação formal ou típica, mas ainda não teve lugar a **consumação material**, o "resultado" em função do qual o legislador construiu a incriminação apesar de ele não constituir elemento constitutivo do tipo; em suma, quando ainda não se consumou o *ilícito material* (supra, 29.º Cap., § 29 e ss.). Isso torna-se indiscutível na medida em que o art. 25.º é aplicável aos casos em que o comparticipante logra "impedir... a verificação do resultado" ou se esforça por a impedir. Que pese a diferença de regime, a este propósito, entre a desistência da tentativa do crime individual e a de comparticipação, a realidade a que se aplica esta parte do art. 25.º é estruturalmente **a mesma** que é tida em vista pelo art. 24.º

3. O modelo da desistência da tentativa na comparticipação

§ 9 O modelo seguido pelo direito português nesta matéria caracteriza-se por uma grande **liberalidade** na atribuição do privilégio da desistência, que não é frequente na maioria das legislações pertencentes ao nosso círculo jurídico-cultural: ela terá ainda lugar quando haja consumação. As **razões político-criminais** que podem invocar-se em favor de uma tal liberalidade revelam-se, em geral, procedentes: sendo função exclusiva da intervenção penal a tutela de bens jurídico-penais e, por esta via, a prevenção da sua lesão definitiva, compreende-se e aceita-se que o privilégio da desistência da tentativa de comparticipação seja levada tão longe quanto possível no sentido de operar a "reversibilidade do processo lesivo" (supra, 29.º Cap., § 8); e que seja mesmo levado ao ponto em que (ao contrário do que vimos suceder para o autor singular: supra, 29.º Cap., § 11) o processo lesivo acabou por se *consumar*, mas o comparticipante *se esforçou seriamente por impedi-lo*. Aqui reside a nota mais característica do modelo consagrado pelo nosso CP; modelo que, para além da sua referida bondade político-criminal, pode louvar-se, como justamente anota Costa Pinto, da sua correcção dogmática face ao sistema comparticipativo e do seu respeito pela vertente garantística do sistema penal (9).

§ 10 Outros modelos a propósito aventados não deixam, dos pontos de vista político-criminal e mesmo dogmático, de ser passíveis de sérias reservas. Desde logo o

(9) PINTO, Costa, nota 1, n.ºs 6 e ss. e 82.

dito **modelo restritivo**, construído única ou basicamente sobre a exigência *de impedimento da consumação*: ele claudica — e é o essencial — em matéria de eficácia político-criminal em hipóteses, como as de que curamos, em que a consumação pode vir a verificar-se exclusivamente por força da continuação da actuação de outros comparticipantes; ficando assim próxima a censura de que um tal modelo subverte o sistema da comparticipação, desrespeita o princípio da igualdade e, de um certo ponto de vista, cria inclusivamente formas de responsabilidade por facto alheio ([10]). Também o chamado **modelo causalista** — segundo o qual a eficácia da desistência se centraria sobre a neutralização do contributo prestado por cada comparticipante "de um modo que no facto consumado nada esteja contido que possa ser causalmente ligado à sua actividade anterior" ([11]) — não só pode conduzir às inconvenientes consequências político-criminais apontadas ao modelo antecedente (sempre que o comparticipante, não logrando neutralizar a eficácia causal do seu comportamento, terá então de evitar a consumação), como permite que em certos casos a desistência relevante fique na dependência da vontade de outros comparticipantes, nomeadamente, da do homem-da-frente. No outro extremo, no chamado **modelo amplo** ([12]) — segundo o qual basta à relevância da desistência o abandono, pelo comparticipante, da sua conduta —, o privilegiamento torna-se excessivo na medida em que acaba por desligar-se por inteiro da sua razão de ser (a defesa de bens jurídicos) para se tornar em *prémio* atribuído em função de puros valores de acção.

§ 11 A relevância da desistência da tentativa em caso de comparticipação está, segundo o art. 25.º, dependente da **verificação alternativa** de uma de duas cláusulas: a do impedimento da consumação ou do resultado lesivo; ou a do esforço sério de impedir uma ou outra, ainda que os outros comparticipantes prossigam na execução do crime ou o consumem.

§ 12 No que respeita à primeira cláusula — a do **impedimento da consumação ou do resultado lesivo** —, em rigor, não há especialidades notáveis, que mereçam consideração autónoma relativamente ao entendimento que demos à cláusula paralela contida no art. 24.º para a relevância da desistência da tentativa acabada do autor singular (supra, 29.º Cap., § 25 e s.).

§ 13 Quanto à segunda cláusula, a do **esforço sério** de impedir a consumação ou o resultado material, vários problemas pode ela suscitar

---

([10]) Assim, PINTO, Costa, nota 1, n.ºs 26-34 e conclusão 3 (p. 295).

([11]) LENCKNER, Probleme beim Rücktritt des Beteiligten, *Gallas-FS*, 1973, p. 281. E sobre este modelo — que encontrou larga aceitação na doutrina italiana: cf., por outros, MANTOVANI, p. 571 e s. —, PINTO, Costa, nota 1, n.ºs 35-37, e conclusão 4 (p. 295 e s.).

([12]) PINTO, Costa, nota 1, n.º 39, e conclusão 2 (p. 295).

neste domínio (13). O ponto de partida deve ser, em todo o caso, o de que — salvo onde a lei disponha diferentemente — vale correspondentemente aquilo que a propósito de idêntico conceito se disse relativamente à desistência do autor singular (supra, 29.º Cap., § 27 e s.). De específico se revela não tanto a cláusula em si mesmo considerada, quanto a sua conexão com a ressalva segundo a qual o esforço será relevante mesmo que os outros comparticipantes **prossigam** na execução do crime ou o **consumem**. Não bastará em todos os casos a tradicional "revogação do mandato" ou mesmo, mais largamente, a "dissuasão do autor imediato de continuar a agressão", ou ainda a "neutralização ou ausência do contributo que segundo o plano lhe cabia" — quando o pretendido desistente sabe que essa recusa pode ser, sem especiais dificuldades, ultrapassada pelos restantes comparticipantes: aqui não existirá um "esforço sério" de impedir a consumação ou o resultado (14). O que se exige — mas também, se exige *sempre* — é que a conduta do desistente seja **idónea** (não necessariamente a "mais idónea" ou a "medida óptima" entre todas as possíveis (15)) ou **adequada**, segundo portanto um juízo de prognose póstuma, à protecção dos bens jurídicos em perigo; e ainda que, em certos casos especiais, em particular se a medida idónea tomada fracassar, o desistente procure **medidas alternativas** enquanto subsistir a situação de perigo para os bens jurídicos.

§ 14 A desistência da tentativa opera em função do facto ilícito-típico que foi planeado e em que o desistente comparticipou. Deste modo, se a desistência é relevante perante este facto, o desistente não assume qualquer responsabilidade quando os restantes intervenientes (com ou sem a comparticipação de outros) executam **um outro facto**. O problema — sempre grave e difícil — de dizer se o facto, mesmo para estes efeitos, é "o mesmo" ou "é outro" assume todavia entre nós muito menor importância do que em outras ordens jurídicas (16), nomeadamente, porque a desistência pode nestes casos, como vimos, ser ainda relevante apesar de ter sobrevindo a consumação.

---

(13) Uma primeira discussão se verificou logo no seio da Comissão revisora do ProjPG: *Actas I*, p. 185 e ss.

(14) Assim, no entanto, FERREIRA, Cavaleiro de, 1987, p. 293.

(15) Assim, no entanto, PINTO, Costa, nota 1, conclusão 19 (p. 297); cf. em todo o caso a análise minuciosa que leva a cabo, em termos no essencial merecedores de aplauso, do requisito em questão a pp. 212 e ss. e 224 e ss.

(16) *V. g.*, na alemã: cf. ROXIN II, § 30, n.º 345 e ss.

II. O problema chamado da "comunicabilidade e incomunicabilidade das circunstâncias" (arts. 28.º e 29.º)

§ 15 O tratamento levado a cabo nos dois capítulos anteriores abstraiu sempre — por vezes um pouco artificialmente, deve conceder-se — dos casos em que o facto praticado e gerador de responsabilidade foi levado a cabo por comparticipantes em cuja pessoa se verificavam a totalidade dos elementos exigidos pelo tipo de ilícito e/ou pelo tipo de culpa respectivos (*intranei*, *insiders*) e por comparticipantes em cuja pessoa faltavam algum ou alguns desses elementos (*extranei*, *outsiders*). Os problemas, da mais alta complexidade, que aqui se podem suscitar parecem todavia resolvidos expressamente (e de forma clara) pelos arts. 28.º e 29.º relativamente à *totalidade* das formas de comparticipação, em termos que parecem redutíveis à tese seguinte: são **comunicáveis** todas as qualidades ou relações especiais do agente que sirvam para *fundamentar ou para graduar a ilicitude*, excepto se outra for a intenção da norma incriminadora; são pelo contrário (absolutamente) **incomunicáveis** tais qualidades ou relações se eles servirem para *fundamentar ou para graduar a culpa*.

§ 16 O **âmbito de aplicação** do art. 28.º surge pois imediatamente limitado aos casos de comparticipação em que "a ilicitude ou o grau de ilicitude dependerem de certas qualidades ou relações especiais do agente". Ao restringir a aplicação do art. 28.º a tais situações, o legislador fez funcionar uma *dupla limitação*: por um lado, nem todas as qualidades ou relações especiais do agente caem na alçada do art. 28.º, mas somente os elementos pessoais que se apresentam como **fundamentadores da ilicitude ou modificativos do seu grau**; por outro lado, nem todas as circunstâncias do tipo referentes à pessoa do agente são abrangidas por aquela norma, mas apenas as qualidades ou relações **especiais** do agente.

§ 17 Deste modo, nos termos daquela **primeira limitação**, ficam **fora** do âmbito de aplicação do art. 28.º todas "as qualidades ou relações especiais" que não influenciam a ilicitude mas antes fundamentam o juízo de **culpa**, *v. g.*, a qualidade de ascendente, descendente, adoptante ou adoptado no homicídio qualificado (art. 132.º-2/*a*)), dado que a agravação deste homicídio se fundamenta numa culpa agravada ([17]); e também a relação

([17]) Cf., a este propósito, DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 132.º

mãe-filho enquanto diminuidora da culpa da autora de um crime de infanticídio (art. 136.º). Esta mesma solução decorre, de forma expressa, como já se referiu, do disposto no art. 29.º Ficam igualmente excluídas do âmbito de aplicação do art. 28.º as qualidades ou relações que a lei faça relevar como **condições de punibilidade ou de exclusão da pena**, *v. g.*, a qualidade de desistente nos termos dos arts. 24.º e 25.º, ou como **condições de procedibilidade**, *v. g.*, a qualidade de cônjuge ou as relações de parentesco que nos crimes de furto e de abuso de confiança tornam o procedimento criminal dependente de acusação particular (art. 207.º) ([18]). Por sua vez, nos termos da referida **segunda limitação**, se nem todos os elementos pessoais do agente estão compreendidos no art. 28.º, mas apenas as suas qualidades ou relações **especiais**, parecem ficar excluídos do âmbito desta norma os estados de espírito, intenções, fins específicos, *v. g.*, a ilegítima intenção de apropriação (arts. 203.º e 210.º), ou a intenção de obter para si ou para terceiro um enriquecimento ilegítimo (art. 217.º) ([19]).

§ 18 As qualidades ou relações especiais fundamentadoras ou modificativas do grau de ilicitude são essencialmente, como refere Teresa Beleza, os "elementos pessoais que ao serem exigidos pelo tipo incriminador significam que *o círculo dos potenciais autores deixa de ser indeterminado*" ([20]), *v. g.*, a qualidade de funcionário (arts. 155.º-1/*b*), 257.º, 350.º, 351.º, 368.º, etc.), de médico (arts. 150.º, 260.º, 284.º, etc.), de advogado (art. 370.º) ou a relação de confiança (arts. 205.º e 224.º), bem como as relações de cuidado, guarda ou vigilância (art. 152.º). O que significa que o domínio de aplicação dos efeitos jurídico-penais estabelecidos pelo art. 28.º é composto por excelência pelos delitos que designámos como **crimes específicos, próprios ou impróprios** (supra, 11.º Cap., § 34), estabelecendo-se como princípio que, nas situações de comparticipação nestes delitos, basta que a qualidade ou relação especial se verifique num dos comparticipantes para tornar aplicável a todos a pena respectiva. Este regime, estabelecido pelo art. 28.º-1 é, no entanto, afastado se outra for a intenção da norma incriminadora.

([18]) Sobre esta questão vejam-se também os exemplos indicados por BELEZA, Teresa, Ilicitamente comparticipando, *Estudos Eduardo Correia*, p. 595 e ss., tomando por referência a versão originária do CP de 1982, e, mais recentemente, MONTEIRO, Salinas, *A Comparticipação em Crimes Especiais no Código Penal*, 1999, p. 94.

([19]) Neste sentido, MONTEIRO, Salinas, nota 18, p. 92.

([20]) BELEZA, Teresa, nota, 18, p. 593 (s. n.).

§ 19 O regime estatuído pelo art. 28.º-1 contribui decisivamente para a resolução do **problema teórico-doutrinal** da autoria e comparticipação nos crimes específicos, muito discutido pela doutrina alemã. Na verdade, perante a ausência de uma base legal clara ([21]), a doutrina alemã divide-se quanto ao critério a seguir para delimitar as situações de autoria e participação nos crimes específicos. Em traços largos, é possível distinguir duas grandes posições doutrinárias: a daqueles que consideram ser ainda de aplicar nestes delitos a teoria do *domínio do facto*; e a daqueles outros que, na esteira de Roxin, abandonam o critério do domínio do facto, incluindo os crimes específicos na categoria dos *delitos de dever*. Cada uma destas soluções acaba por se confrontar com problemas de difícil resolução ([22]).

§ 20 A primeira destas duas teses, mais exigente, sustenta que para se ser autor de um crime específico tem de se possuir, **além do domínio do facto, a qualidade exigida pelo tipo**. Uma concepção deste tipo rejeita pois, em princípio, a possibilidade de um *extraneus* ser autor daquela espécie de crimes, seja sob a forma de autoria imediata ou mediata ou de co-autoria ([23]). Esta solução foi, no entanto, criticada pelas graves **lacunas de punibilidade** a que conduziria, na medida em que sempre determinaria a impunidade do comparticipante a que faltasse algum daqueles dois requisitos: bastaria, *v. g.*, para se eximir à punição que o *intraneus* convencesse um *extraneus* a realizar o facto em sua vez. Algumas construções doutrinárias procuraram, no entanto, afastar esta lacuna de punibilidade com recurso à figura do "instrumento doloso não qualificado", segundo a qual, dada a sua posição ou a influência dominante no acontecimento glo-

([21]) Não se refere a instigação porque, como se disse já, para esta corrente doutrinária ela constitui uma forma de participação, não de autoria. Assume especial relevância nesta matéria o disposto no § 28 StGB que a doutrina dominante considera aplicável às situações de comparticipação em crimes específicos. Todavia, o sentido desta norma parte justamente de uma ideia de não "comunicabilidade" das características pessoais do agente. A primeira parte daquele parágrafo estabelece uma atenuação da pena do participante a quem faltem as características pessoais exigidas pelo tipo, numa clara quebra do princípio da acessoriedade limitada. A segunda parte desta norma estabelece que as características pessoais que agravem, atenuem ou excluam a pena valem apenas para o comparticipante no qual elas se verifiquem. Para maiores desenvolvimentos, MONTEIRO, Henrique Salinas, nota 18, p. 122 e ss., e SOUSA, Susana Aires de, A autoria nos crimes específicos: algumas considerações sobre o art. 28.º do Código Penal, *RPCC 15*, 2005, p. 348 e ss.

([22]) Cf., a este propósito, SOUSA, Susana Aires de, nota 21, p. 346 e ss.

([23]) M / GÖSSEL, § 47, n.º 120 e ss., e § 49, n.º 108 e ss.

bal, o *intraneus* deveria ainda ser considerado como autor mediato que executa o facto através de um instrumento que actua dolosamente ([24]).

§ 21 A figura do **instrumento doloso não qualificado** tem, porém, merecido críticas por parte de alguns autores. Entre essas vozes críticas destaca-se a de Roxin, que considera que o agente mediato *intraneus* é autor não por deter o domínio de facto — que na sua perspectiva não detém, porquanto o instrumento conserva ainda o poder de decisão sobre a execução —, mas por violar o *dever extra-penal* que sobre ele recai. Assim, para Roxin, o critério delimitador da autoria nos delitos específicos consiste na titularidade do dever extra-penal violado, a qual transforma o *intraneus* na figura central do acontecimento e substitui integralmente, como critério de autoria, o domínio do facto. No entanto, também têm sido apontadas algumas reservas críticas à teoria de Roxin ([25]): desde logo, como já referimos (36.º Cap., § 26), fazer assentar a existência de tipos criminais na mera violação de deveres extra-penais parece ser, em termos político-criminais, uma solução a evitar. Nem esse terá sido o caminho seguido pelo legislador no desenho típico escolhido para os crimes específicos. Como afirma Teresa Beleza, "os crimes específicos próprios não se limitam à referência, na sua tipificação, à violação de um dever extra-penal. Essa violação é objectivada numa acção ou num resultado" ([26]). E ainda, como acrescenta Susana Aires de Sousa, o dever extra-penal "só se concretiza penalmente aquando da violação típica, ou seja, quando o *intraneus* realiza aquela acção descrita no tipo e não qualquer outra. Se o tipo legal pressupõe um dever extra-penal (que legitima a incriminação), também parece pressupor que o titular do dever execute aquela acção, pois só através da execução ou do seu domínio se torna possível a violação daquele dever" ([27]).

§ 22 A teoria da titularidade do dever proposta por Roxin enfrenta ainda outras críticas ([28]): desde logo, parece não **resolver todas as lacunas de punibilidade** que devem ser preenchidas; pois sempre ficaria impune o *extraneus* que dolosamente se ser-

([24]) Por todos, cf. ROXIN, § 25, III.

([25]) Cf., a este propósito, BELEZA, Teresa, A estrutura da autoria nos crimes de violação de dever. Titularidade *versus* domínio do facto?, *RPCC 2*, 1992, p. 342 e ss., e SOUSA, Susana Aires de, nota 21, p. 351 e ss.

([26]) BELEZA, Teresa, nota 25, p. 343.

([27]) SOUSA, Susana Aires de, nota 21, p. 351 e s.

([28]) SOUSA, Susana Aires de, nota 21, p. 352 e s.

visse de um *intraneus* na realização criminosa, dominando a sua vontade através de erro ou coacção; por outro lado, parece **agravar de forma inadmissível a punibilidade** nos casos em que o titular do dever presta um pequeno auxílio sendo a acção integralmente realizada por um *extraneus* ou outro *intraneus*. Nesta última hipótese, seriam punidos como autores, segundo a proposta de Roxin, *v. g.*, quer o funcionário que executasse integralmente acção, quer o funcionário que se limitasse a prestar uma mera colaboração dolosa à realização do facto, desconsiderando-se inclusive o diferente grau ou intensidade de violação do dever extra-penal.

§ 23 Por tudo isto, como já se referiu no 30.º Cap., § 25, entendemos que, para definição da autoria nos crimes específicos, deve atender-se **à violação do dever típico especial por quem dele é titular, à qual deve acrescer o domínio do facto**. Cabe, no entanto, reconhecer que a exigência cumulativa deste duplo requisito pode acarretar, em alguns casos de comparticipação em crimes específicos, lacunas de punibilidade. Será assim em ordenamentos que não disponham de uma norma de conteúdo semelhante ao art. 28.º **Este preceito não procura estabelecer um novo critério de autoria para os crimes específicos, antes parte do critério de autoria e das situações de comparticipação delimitados nos arts. 26.º e 27.º, que imediatamente o antecedem, para os complementar**. Assim, em casos de comparticipação em que apenas um dos agentes reúne as "qualidades ou relações especiais" relativas à ilicitude, o legislador deixa, em princípio, cair o requisito da titularidade daquela qualidade ou relação especial exigido no tipo e basta-se, para punir como autor, com o domínio do facto por parte do agente, ou seja, com o critério geral estabelecido no art. 26.º Deste modo, a consequência mais importante que decorre do regime previsto no art. 28.º-1 é a possibilidade de um *extraneus* poder ser autor de um crime específico próprio ou impróprio ([29]).

§ 24 Todavia, a afirmação da autoria do *extraneus* depende ainda de um **requisito negativo** previsto na parte final do art. 28.º-1: é necessário que a **intenção da norma incriminadora não se oponha à punição do extraneus como autor**. Esta ressalva tem vindo a ser reconduzida pela doutrina à categoria de *crimes de mão própria* ([30]). Num direito penal *do facto*

([29]) De modo mais desenvolvido, SOUSA, Susana Aires de, nota 21, p. 353 e ss.

([30]) Ideia que tem provavelmente a sua origem em uma das referências do Conselheiro José Osório ao art. 28.º do ProjPG, contida nas *Actas*, I, p. 203, no sentido de que esta norma não deveria funcionar "*v. g.*, para os casos dos chamados crimes de mão própria, em que certas qualidades têm de ser dadas no executor".

e *do bem jurídico*, afastado de uma qualquer tutela da ordem moral, esta categoria de delitos torna-se no entanto — como já anotou: supra, 30.º Cap., § 27 — questionável. Não parece, assim, que a exclusão dos crimes de mão própria do âmbito do art. 28.º-1, através da ressalva prevista na parte final daquele artigo, possa ser *automática*. A **intencionalidade da norma deve buscar-se na interpretação do tipo incriminador e/ou das normas que o completem ou integrem**, podendo concluir-se pela aplicação daquela ressalva a crimes específicos e rejeitá-la em crimes tradicionalmente apontados como de mão própria (31).

§ 25 É possível, na verdade, pensar em situações de comparticipação relativamente a **crimes tradicionalmente considerados de mão própria**, sem que a norma incriminadora se oponha à aplicação do regime de comunicabilidade previsto no art. 28.º, *v. g.*, o *extraneus* que instrumentaliza a testemunha, por erro ou coacção, a prestar depoimento falso nos termos do art. 360.º Já o instigador *extraneus* não deve ser punido por via da aplicação conjunta dos arts. 360.º e 28.º, pois a tal se opõe a intencionalidade da norma incriminadora numa interpretação conjunta com o art. 363.º, norma que completa o art. 360.º (32). O legislador, atendendo à perigosidade desta conduta e à sua provável frequência, quis expressamente punir este comportamento ao criminalizar o suborno no art. 363.º, antecipando a própria tutela do bem jurídico, uma vez que para a punição do homem-de-trás não é necessário que o instigado tenha iniciado a prática de actos de execução, como seria exigido por via dos arts. 26.º, *in fine*, 28.º e 360.º Este exemplo permite justamente demonstrar, como sustenta Susana Aires de Sousa, que a não aplicação do art. 28.º resulta da interpretação da própria norma incriminadora e não de estarmos perante um delito que alguma doutrina classifica como de mão própria (33).

§ 26 O legislador quis ainda **acautelar a ocorrência de agravações injustas** da punição do *extraneus* decorrentes da aplicação do regime de "comunicabilidade" previsto no art. 28.º-1. Com essa intenção estabeleceu um limite à punição do *extraneus* no n.º 2 daquele artigo, cuja aplicação depende da verificação de dois pressupostos: é necessário que, sem a intervenção do n.º 1 do art. 28.º, fosse aplicada ao *extraneus* uma pena menos grave; é igualmente necessário que as circunstâncias concretas do caso aconselhem, em homenagem a uma ideia de realização da justiça do caso,

---

(31) Neste sentido, DIAS, Figueiredo / SOUSA, Susana Aires de, Autoria mediata do crime de condução ilegal de veículo automóvel, *RLJ 135*, 2006, p. 259.

(32) Como refere SEIÇA, Medina de, *Comentário Conimbricense*, III, art. 363.º, § 3, o suborno apresenta-se como "a tipificação de uma particular forma de comparticipação, elevada à categoria de delito *a se*".

(33) SOUSA, Susana Aires de, nota 21, p. 359 e ss.

a punição por essa pena menos grave, que substitui a pena que resultaria do regime de "comunicabilidade" previsto no número anterior. Susana Aires de Sousa sustenta que o privilégio contido no art. 28.º-2, ao pressupor a relação entre uma pena mais grave e uma pena menos grave, parece estar pensado para os **crimes específicos impróprios** (34). De todo o modo, em casos em que não seja possível aplicar a atenuação prevista no art. 28.º-2 por falta daquela relação entre duas penas de gravidade diferente (pense-se, essencialmente, nas situações em que o art. 28.º fundamenta a autoria pelo *extraneus* de um crime específico próprio), pode o julgador valer-se, para realização da justiça do caso, da atenuação da pena prevista no art. 72.º, ou ainda ponderar, na determinação da pena concreta, o grau de ilicitude do facto enquanto factor de medida da pena previsto no art. 71.º-2/*a*).

III. A chamada "comparticipação necessária"

§ 27 Muitos tipos legais de crime existem em que a comparticipação de várias pessoas constitui pressuposto necessário do seu preenchimento: é relativamente a eles que se fala do problema da comparticipação necessária (35). Isso sucede antes de tudo com os tipos legais conhecidos, ao que parece na esteira de Freudenthal (36), como **crimes de convergência**, isto é, aqueles em que *as contribuições dos vários comparticipantes para o facto se dirigem, da mesma forma e na mesma direcção, à violação do bem jurídico*. Como acontece, *v. g.*, com a participação em rixa do art. 151.º,

(34) SOUSA, Susana Aires de, nota 21, loc. cit. Posição diferente é a de BELEZA, Teresa, nota 18, p. 648 e s., considerando que, nos casos em que o art. 28.º permite a incriminação de situações que na sua ausência seriam atípicas, será ainda possível invocar o art. 28.º-2, podendo o juiz atenuar a pena do *extraneus*. A A. invoca em favor desta solução um argumento de identidade ou até de maioria de razão: "se do art. 28.º resulta uma pena de outra forma inexistente, há tanta ou mais razão para ter isso em conta nos casos em que dele resulte uma pena mais grave". Parece, no entanto que o resultado da atenuação é igualmente possível por via das regras gerais relativas à atenuação da pena, como no texto se referiu.

(35) A questão surge as mais das vezes discutida — porventura por influência da doutrina alemã dita da "*notwendige Teilnahme*" — sob a epígrafe da *participação* necessária. Incorrectamente: o problema suscita-se relativamente a cúmplices, como também (talvez as mais as vezes) relativamente a autores, nomeadamente, a co-autores e instigadores. Por isso se pode integrar a matéria, como aqui o fazemos (cf. p. ex., também, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 204 e ss.), nos problemas comuns à autoria e à cumplicidade.

(36) Como informa ROXIN II, § 26, n.º 41. As definições em seguida dadas seguem, no essencial, a sua exposição.

com certas formas de associação criminosa do art. 299.º, com a participação em motim do art. 302.º, com o motim de presos do art. 354.º, etc. Pode afirmar-se, com razão, que, relativamente a esta espécie de crimes, nenhum problema específico de comparticipação se suscita: todos os comparticipantes serão punidos, segundo a sua forma própria de comparticipação, de acordo com as normas em geral aplicáveis.

§ 28 Diferentemente se passam as coisas com os chamados **crimes de encontro**, isto é, com aqueles em que *os diversos comparticipantes actuam por forma e em direcção diferentes e unicamente se encontram na realização do fim da conduta*. Assim sucede, *v. g.*, com crimes tão diversos como o crime de usura do art. 226.º, que não pode realizar-se sem a participação da vítima destinada a conceder ao usurário a vantagem patrimonial que este ambiciona; o crime de homicídio (tentado) a pedido da vítima do art. 134.º; o de insolvência dolosa por incitamento de terceiro à apresentação de créditos fictícios do art. 227.º-1/*b)*; o de actos sexuais ou homossexuais com adolescentes dos arts. 174.º e 175.º; o de lenocínio do art. 176.º; o de burla do art. 217.º, etc. É relativamente a este grupo de delitos que algumas questões devem ser consideradas; até porque, nele, razões substanciais haverá para que o conceito de comparticipação necessária seja de certo modo alargado, de maneira a incluir aqueles casos em que uma comparticipação não é tipicamente *necessária* em sentido estrito, mas em todo o caso surge como a forma **normal** ou **usual** de cometimento do crime. Assim, p. ex., o crime de abuso sexual de pessoa internada do art. 166.º não tem, segundo a natureza das coisas, de pressupor a comparticipação da vítima, que pode estar em estado de inconsciência ou de absoluta incapacidade de opor resistência, mas aquela comparticipação constituirá, sem dúvida, a hipótese normal e mais frequente de cometimento do crime.

§ 29 O ponto de vista mais relevante desta matéria contende não tanto com o carácter "necessário" — em sentido estrito ou amplo — da comparticipação, quanto com o **âmbito de protecção da norma típica** e, nomeadamente, com a circunstância de **o comparticipante necessário ser o portador do bem jurídico por aquela protegido** ([37]). Assim sucede, entre outros, com os referidos crimes de homicídio (tentado) a pedido da

([37]) Doutrina hoje praticamente indiscutida na Alemanha: cf. só ROXIN II, § 26, n.º 44 e s., S / S / CRAMER / HEINE, antes do § 25, n.º 27, STRATENWERTH / KUHLEN, § 12, n.º 207 e s.

vítima, de actos sexuais com adolescentes, de usura, etc. Em todos estes casos **o comparticipante necessário não deve ser punível**. Logo porque, para além do mais, a lei não prevê expressamente a punição de hipóteses deste teor, mas apenas quando se trate da ofensa à vida, à liberdade sexual, ao património *de outra pessoa*. Por ser assim é que, relativamente a casos que possam surgir neste contexto como de solução duvidosa, o seu esclarecimento deverá depender de uma rigorosa interpretação do tipo e constituirá, nesta medida, tarefa própria da doutrina da PE.

§ 30 A solução exposta, por clara que se antolhe, não se encontra isenta de contradição. Assim — tem-se dito — ela vale unicamente para a **parte mínima** de comparticipação que se revela verdadeiramente necessária, não para a que a ultrapasse. Nas palavras de Eduardo Correia, "deve todavia ponderar-se que quando uma pessoa é, no tipo legal, remetida para a posição de objecto [*sc.*, considerada titular do bem jurídico protegido], isso só justificará a sua não punição quando a realização do crime teve lugar naquele quadro de coisas que o legislador representou como típico; pois quem actua por forma tipicamente anormal, perde a posição passiva de objecto, prevista no tipo legal, para adquirir a de agente de um estado de coisas que, grosseiramente, se poderá dizer 'liber in causa'" ([38]). Assim, pois, não gozaria da impunidade da comparticipação necessária aquele que instigasse ou induzisse o usurário a emprestar-lhe uma certa importância oferecendo-lhe instantemente juros superiores aos legais, o adolescente que incitasse veementemente o adulto à prática de actos sexuais proibidos, etc. Mas **esta orientação não pode aceitar-se**, como o revela, *v. g.*, a circunstância de o art. 134.º punir o homicídio mesmo perante "pedido sério, instante e expresso" da vítima. O que pode suceder — e sucederá frequentemente, máxime, em múltiplas hipóteses de crimes sexuais — é que a actuação da vítima seja uma tal que, perante uma correcta interpretação do tipo e do sentido social que contém, conduza à negação da tipicidade do comportamento do agente; *v. g.*, porque se não possa concluir que o agente abusou da "inexperiência" da vítima no caso do art. 174.º ou que se "aproveitou" das funções ou do lugar que exerce no caso do art. 166.º-1 ([39]): isso radica na interpretação dos tipos e constitui por conseguinte, como acen-

([38]) CORREIA, Eduardo, II, p. 255.

([39]) Concretamente — só a título de mero exemplo — sobre este caso, DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 166.º, §§ 4 e 11 e s.

tuámos, tarefa da doutrina da PE. Sem esquecer que, ainda quando assim não suceda e o comportamento da vítima não seja susceptível de negar a tipicidade do facto do agente, aquele comportamento pode entrar em contas na determinação da medida da pena.

§ 31 Mais longe pretende ir uma parte da doutrina alemã, sustentando que mesmo a medida mínima de comparticipação necessária não deve conduzir à impunidade em todos aqueles casos em que a lei não determine essa impunidade **de forma expressa ou incontroversa**; até porque se não poderá falar de punição sem lei, na medida em que, nestes casos, a punibilidade derivará directamente do disposto nos arts. 26.º e 27.º (40). Cremos, com Roxin, que com esta tese se vai longe demais (41). Mesmo naqueles casos em que do tipo não decorre de forma expressa ou indubitável que o comparticipante necessário fica impune (*v. g.*, no crime de tráfico de influência do art. 335.º (42)), a essa conclusão pode chegar-se por correcta interpretação do tipo e, nomeadamente, do seu âmbito e sentido de protecção.

(40) Assim, HERZBERG, *Täterschaft und Teilnahme*, 1977, § 13, II, 2, e JAKOBS, 24/12.

(41) ROXIN II, § 26, n.º 53.

(42) Sobre o ponto, CAEIRO, Pedro, *Comentário Conimbricense*, III, art. 335.º, § 28 e s.

TÍTULO III

OS CRIMES NEGLIGENTES (*)

34.º CAPÍTULO

FUNDAMENTOS GERAIS

I. Consideração dogmática e político-criminal

§ 1 Diferentemente daquela que sempre foi, em perspectiva sistemática, a opinião (por exemplo e entre outros) de Jescheck, não parece que a negligência deva hoje ser considerada, na doutrina geral do crime, uma mera *forma especial de aparecimento do facto punível* (1). O facto negligente constitui antes, como se deixou sublinhado (10.º Cap., § 42 e ss.), **uma das formas básicas, tipicamente cunhadas, de aparecimento do crime**, ao mesmo nível do facto doloso. Com a qualificação como forma *especial* do crime não se faz jus nem à verdadeira natureza do facto negligente, nem — sobretudo — ao relevo e significado político-criminal e dogmático que aquele facto assume hoje no contexto da criminalidade total. E não é a circunstância, só historicamente explicável e compreensível (2), de, em regra, os códigos penais conterem uma norma segundo a

---

(*) Uma versão anterior do que neste título se expõe encontra-se em DIAS, Figueiredo, Velhos e novos problemas da doutrina da negligência em direito penal, *Estudos Almeida Costa*, p. 665.

(1) JESCHECK / WEIGEND, 3. Kap, I Abs.

(2) Pela circunstância de durante muito tempo se ter pensado — erradamente — que a lei penal conteria uma cláusula implícita de punibilidade *geral* da negligência (isto é, da sua punibilidade relativamente a todos os tipos de ilícito objectivos puníveis a título de dolo). Cf. o Assento do STJ de 20-3-1936 e, sobre o problema, ainda, CORREIA, Eduardo, *Lições 1949*, p. 382 e ss. Todo este equívoco terá, de resto, derivado da circunstância de, *em direito civil*, a lei reconhecer efectivamente um ilícito *geral* de negligência (*sc.*, de "culpa"). Cf., só, COSTA, M. J. Almeida, *Direito das Obrigações*, ⁸2000, pp. 497 e s. e 524 e ss.

qual a negligência só é punível "nos casos expressamente previstos na lei" que abala esta posição: exactamente o mesmo sucede com o dolo, afinal, de acordo com as exigências do princípio *nullum crimen, nulla pœna sine lege* e do tipo de garantia que dele deriva.

§ 2 A decisão **político-criminal**, comum à generalidade das legislações, de punir a negligência relativamente a um determinado número de tipos de crime é inquestionavelmente justificada. De um duplo ponto de vista: do da *dignidade penal*, sempre que estão em causa bens jurídicos, individuais ou colectivos, que se contem entre os mais importantes da ordem legal dos bens jurídicos; e do da *carência de pena*, sobretudo quando se trata da contenção de fontes de perigo grave para a existência das pessoas em comunidade, ainda mais se for frequente que delas derivem resultados lesivos por falta de cuidado na sua manipulação. Por isso também o relevo e o significado dos crimes negligentes encontra-se em rápida expansão nos quadros da chamada "sociedade do risco" (supra, 6.º Cap., § 46 e ss.). Bem se compreende, deste ponto de vista, o actual requisitório em favor de um tratamento jurídico-penal **cada vez mais severo** de certos factos negligentes; a ponto de não faltar mesmo já quem entenda não dever excluir-se a possibilidade de a tais factos virem a ser aplicáveis molduras penais cujo máximo exceda o limite mínimo do correspondente facto doloso. A esta maior severidade tem de corresponder um maior esforço e cuidado no esclarecimento da dogmática do crime negligente.

II. Relação entre negligência e dolo

§ 3 Do exposto resulta que o facto negligente não é, simplesmente, uma forma atenuada ou menos grave de aparecimento do correspectivo facto doloso: é "outra coisa", é "outro facto", em suma, é **um aliud relativamente ao facto doloso correspondente**. Exacto é que, em definitivo, entre, *v. g.*, um homicídio doloso (art. 131.º) e um homicídio negligente (art. 137.º) não intercede apenas uma diferença de grau ou de quantidade, como se os correspondentes tipos de ilícito e de culpa formassem entre si um *continuum*, desenhando-se entre eles simplesmente uma fronteira a marcar o território onde acaba o dolo eventual e começa a negligência consciente, constituindo como que degraus de uma escada que se seguem uns aos outros. Podia sugerir-se este entendimento dogmático quando dolo e negligência eram considerados apenas *graus de culpa* relativamente a

um tipo de ilícito comum. Mas um tal entendimento (3) cessou no preciso momento — e para tanto contribuíram decisivamente, bem antes ainda do despontar da doutrina da acção final, as investigações de Engisch (4) — em que se compreendeu que o facto doloso e o facto negligente têm, cada um, o seu tipo de ilícito e o seu tipo de culpa *próprios* e *distintos*.

III. Definição legal da negligência. Negligência consciente e inconsciente

§ 4 A conclusão que acabámos de retirar é confirmada pela *definição legal da negligência* constante do art. 15.º Este preceito começa, no seu proémio, por conceber a negligência de modo **unitário** — "quem não proceder com o cuidado a que, segundo as circunstâncias, está obrigado e de que é capaz" —, para em seguida distinguir *duas formas*: a da *negligência consciente*, na al. *a)*, traduzida em o agente "representar como possível a realização de um facto que preenche um tipo de crime mas actuar sem se conformar com essa realização"; e a da *negligência inconsciente*, na al. *b)*, traduzida em o agente "não chegar sequer a representar a possibilidade de realização do facto". O essencial da definição reside, porém, no proémio unitário, sendo aí que se contém o **tipo de ilícito** (a violação do cuidado a que, segundo as circunstâncias, o agente está obrigado, isto é, a violação do cuidado devido) e o **tipo de culpa** (a violação do cuidado que o agente, segundo os seus conhecimentos e capacidades pessoais, *está em condições de prestar*).

§ 5 Questão é saber se, perante esta definição, a distinção entre negligência consciente e inconsciente assume um **significado político-criminal e dogmático** de grande relevo. Não falta quem entenda que não, logo na base de que seria errado afirmar — como correntemente se afirmou no tempo em que a negligência era considerada uma simples forma de culpa — que a negligência consciente tenha por força de representar, relativamente à inconsciente, uma forma *mais grave* (e que, por conseguinte, deve ser mais punida) de realização do facto; salvo nos casos em que a negligência inconsciente conforme uma hipótese de *negligência grosseira*. Porque,

---

(3) Característica deste estádio da evolução é a monografia fundamental sobre a doutrina da negligência de EXNER, *Das Wesen der Fahrlässigkeit*, 1910.

(4) ENGISCH, *Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit*, 1930.

na precisa formulação de Schroeder, "a desatenção logo conducente à não previsão da possibilidade de dano 'pode' pesar mais gravemente do que a confiança em que o resultado se não produzirá" (5). De outra parte assinala porém Roxin que, "pressuposto o mesmo grau de criação não permitida do risco, a negligência consciente é mais digna de pena que a inconsciente, porque a representação de uma possível realização do tipo confere ao agente um contra-motivo mais forte que os ensejos que serão dados ao agente, na negligência inconsciente, para se aperceber do perigo dele proveniente" (6).

§ 6 Não nos parece de todo seguro, porém, que assim seja: em matéria de gravidade do ilícito não vemos que a representação da violação como possível **indicie sempre uma maior gravidade** da negligência consciente face à inconsciente: relativamente à morte de um peão, o ilícito imputável ao automobilista que conduz em animada conversa e brincadeira com os passageiros amigos e, em consequência, não representa sequer a possibilidade de atropelamento, não tem de ser menos grave do que o daquele que em virtude de uma desatenção momentânea representa, se bem que já tarde, aquela possibilidade. De qualquer modo, exacto nos parece que a distinção entre negligência consciente e inconsciente visa tão-só estabelecer os requisitos puramente *psicológicos* — positivos ou negativos — que pode assumir a negligência no seu conjunto: *representação* do resultado típico na negligência consciente, *ausência dessa representação* na inconsciente (7); bem como reafirmar o critério, já constante do art. 14.º, nomeadamente do seu n.º 3, de distinção entre dolo (eventual) e negligência (consciente). Em termos de medida da pena tudo dependerá das exigências de prevenção que no caso se façam sentir e da gravidade da realização do tipo de ilícito e do tipo de culpa (8). Forma *qualificada* de negligência contêm, sim, certos preceitos da PE, *v. g.*, o art. 137.º-2, que pune com especial severidade a já referida *negligência grosseira*; ou o

---

(5) SCHROEDER, *LK*, § 16, n.º 121.

(6) ROXIN I, § 24, n.º 61, que todavia, conclui (n.º 63) — como o texto também acaba por sugerir — que "a estrutura da negligência é a mesma na negligência consciente e na inconsciente; daí deriva o significado relativamente pequeno da distinção".

(7) Porventura por esta via se conformando aquilo que poderá chamar-se o *tipo subjectivo* da negligência; cf., em todo o caso, infra, 35.º Cap., § 35 e ss.

(8) Cf., todavia, SILVA, Marques da, II, p. 180: "a culpa [negligência] consciente (...) é a mais grave das espécies de culpa [negligência]".

art. 156.º-3, que só pune esta espécie de negligência; e todavia estas formas qualificadas de negligência tanto podem ser integradas pela negligência consciente, como pela inconsciente ([9]).

§ 6 Questão já antiga e que divide as opiniões é a de saber se a negligência consciente se identifica inteiramente com o **dolo de perigo**, nomeadamente com o dolo de perigo concreto ([10]). Do nosso ponto de vista, uma tal identificação não existe. Não tanto em função de o perigo dever ser representado como *próximo* no caso do dolo de perigo, mas já não necessariamente no da negligência consciente ([11]). Mas porque, como entre nós exactamente notou Rui Pereira — e sem prejuízo de poder considerar-se que o dolo de perigo implica sempre a existência de uma negligência consciente de dano —, a necessária consideração de elementos não puramente intelectuais logo no dolo do tipo e na negligência típica obsta àquela identificação ([12]).

§ 7 Não obstante tudo o que ficou dito, a relevância penal da **negligência inconsciente** levantou desde cedo — e continua a levantar — sérias reservas, se não tanto a nível do tipo de ilícito, seguramente a nível do **tipo de culpa**. O que não será de estranhar, nem devia ser estranhado à luz de uma concepção da culpa como *culpa de uma vontade "má"*. Sob esta perspectiva, com efeito, fica próxima a afirmação de que toda a verdadeira culpa supõe uma **decisão consciente pelo ilícito** que, se poderia ainda (com esforço e com reservas) considerar-se existente na negligência consciente, falta em absoluto na negligência inconsciente ([13]). Uma tal concepção porém, para além de evidentemente se não adequar aos dados imperativos do direito penal português vigente — e de, na verdade, se encontrar hoje praticamente abandonada por toda a doutrina ([14]) —, torna-se passível, no plano substantivo, de toda a crítica (de resto, intensificada) que dirigimos ao dogma da culpa da vontade.

([9]) Acentua-o, também, PEREIRA, Rui, *O Dolo de Perigo*, 1995, p. 136. E, segundo indicação de GONÇALVES, Maia, *CP*, art. 137.º, anot. 5, o Ac. do STJ de 13-10-1999, assim sumariado: "O art. 137.º, n.º 2, do CP, ao estabelecer a punição da negligência grosseira, não faz qualquer distinção entre negligência consciente e inconsciente".

([10]) A tese afirmativa remonta, ainda aqui, a ENGISCH, nota 4, p. 401 e ss.

([11]) Cf., todavia, ROXIN I, § 24, n.º 65.

([12]) PEREIRA, Rui, nota 9, pp. 48 e ss. (p. 56) e 135 e s.

([13]) Ilação expressamente retirada pelos defensores desta concepção: RADBRUCH, Aussetzung, *VDBT*, V, 1909, p. 201: "verschämte Zufallshaftung" [vergonhosa responsabilidade pelo acaso] chama ele à negligência inconsciente; KOHLRAUSCH, Die Schuld (Vorsatz, Fahrlässigkeit, Rechtsirrtum, Erfolgshaftung), *in*: Aschrott / v. Liszt, *Reform des Reichsstrafgesetzbuches*, I, 1910, pp. 196 e ss. e 208 e s.; KAUFMANN, Arthur, *Das Schuldprinzip*, 1961, p. 156 e ss.

([14]) Cf., em todo o caso, recentemente, KÖHLER, pp. 172 e s. e 178 e s.

IV. Estrutura dogmática do facto negligente

§ 8 A estrutura dogmática do facto negligente exprime-se assim, segundo a opinião doutrinal hoje largamente maioritária e que, como se sublinhou, é legalmente imposta pelo teor do art. 15.º, pela forma seguinte.

1. O tipo de ilícito

§ 9 O tipo de ilícito do facto negligente considera-se preenchido por um comportamento sempre que este discrepa daquele que era devido em uma situação de perigo para bens jurídico-penalmente relevantes, para deste modo se evitar uma violação juridicamente proibida. O tipo de ilícito do facto negligente não deixa assim, em caso algum, integrar-se completamente pela mera *causação de um resultado* (p. ex., no caso do homicídio negligente do art. 137.º, pela morte de outra pessoa causada pela conduta do agente). Para além disso torna-se indispensável ([15]) que tenha ocorrido a violação, por parte do agente, de um **dever de cuidado** que sobre ele impende e que conduziu à produção do resultado típico; e, consequentemente, que o resultado fosse *previsível* e *evitável* para o homem prudente, dotado das capacidades que detém o "homem médio" pertencente à categoria intelectual e social e ao círculo de vida do agente ([16]).

2. O tipo de culpa

§ 10 Somente quando o tipo de ilícito negligente se encontra preenchido pela conduta tem então sentido indagar ainda se o mandato geral de cuidado e previsão podia também ter sido cumprido pelo **agente concreto**, de acordo com as suas capacidades individuais, a sua inteligência e a sua formação, a sua experiência de vida e a sua posição social. Toda esta indagação ultrapassa já o nível do tipo de ilícito e situa-se no (e conforma o) tipo de culpa do facto negligente ([17]).

([15]) O mérito de o ter posto claramente em relevo como essência do "desvalor de acção" característico dos crimes negligentes cabe a WELZEL, por último, em *Fahrlässigkeit und Verkehrsdelikte*, 1961.

([16]) A referência a este modelo passará daqui em diante a fazer-se, por razões de clareza e de síntese da exposição, simplesmente através do designativo "homem médio".

([17]) Assim, a doutrina ainda hoje dominante, pela qual pode ver-se, por último, ROXIN I, § 24, n.º 46 e ss.

3. A doutrina do "duplo escalão"

§ 11 A evolução científico-dogmática da doutrina da negligência que acaba de assinalar-se, com o reconhecimento no facto negligente da existência de um tipo de ilícito e de um tipo de culpa específicos, tem o seu bom **fundamento** e as mais eminentes **consequências prático-normativas**. Na exposição de meridiana clareza de Jescheck ([18]), uma tal evolução constituiu mais um passo, e importante, no sentido de a jurisprudência contrariar uma acentuada tendência para ilegitimamente aproximar em demasia a responsabilidade por negligência de uma "responsabilidade pelo resultado" (de uma "responsabilidade objectiva") e cometer, assim, uma violação irremível do princípio da culpa. Ela permite, por outro lado, ganhar consciência dos requisitos que a lei considera indispensáveis sempre que liga quaisquer efeitos jurídicos (nomeadamente a aplicação de uma medida de segurança, mas não só: cf., p. ex., o art. 295.º) à prática de um facto ilícito típico negligente.

§ 12 Esta doutrina, agora correntemente apelidada *doutrina do duplo escalão*, é a **dominante** e aquela que, em nosso parecer, **deve sufragar-se**, pelo menos na sua arquitectura basilar. É nos seus quadros que a exposição seguinte afrontará os principais problemas suscitados pelo tipo de ilícito (incluídas as causas de justificação) e pelo tipo de culpa dos factos negligentes. Problemas hoje insistentemente estudados e discutidos, ao contrário do que se passou durante o longo período em que a doutrina da negligência constituiu, face à doutrina do dolo, uma espécie de "enteada" da teoria geral do crime ([19]). Omitindo em princípio, porém, o tratamento de todos aqueles problemas que não assumam, na doutrina da negligência, *autonomia* e *especificidade* perante os problemas paralelos já tratados a propósito do crime doloso de acção.

([18]) JESCHECK / WEIGEND, § 54, I, 3.

([19]) SCHÜNEMANN, Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeits- und Gefährdungsdelikte, *JA*, 1975, p. 435 e ss., acentuando que a tendência recente vai no sentido de transformar a negligência, de "enteada", em "filha preferida" da doutrina do crime.

35.º CAPÍTULO

O TIPO DE ILÍCITO NEGLIGENTE

I. Consideração fundamental

§ 1 A característica mais saliente dos tipos de ilícito negligentes, por contraposição aos dolosos, reside na diferente relação que intercede entre **acção** e **resultado** ou, mais exactamente, — porque, como se verá, nem todos os delitos negligentes (se bem que isso suceda com a maior parte) têm forçosamente de assumir a forma de crimes de resultado, antes podem ser também crimes de mera actividade — entre *acção* e *realização típica integral*. Nos crimes dolosos a vontade do agente dirige-se ao resultado ou à realização integral do tipo, nos negligentes **não**; pelo que, como formula Stratenwerth, "a relevância jurídico-penal daquela vontade resulta, não imediatamente do seu conteúdo, mas de uma comparação com o comportamento imposto" (1). Por outro lado, a punibilidade de um facto negligente pressupõe sempre (já o vimos: supra, 28.º Cap., § 11) a realização típica *integral*, *hoc sensu*, a "consumação": a *tentativa de um facto negligente* não só não é nunca punível, como não é (normativamente) possível ou sequer pensável, trate-se de delitos de mera actividade ou mesmo de resultado. Em qualquer caso falta a resolução criminosa que constitui elemento co-natural de toda a tentativa. Destas duas especificidades fundamentais resultam os principais problemas com que depara a construção do tipo de ilícito do facto negligente.

§ 2 Sendo como se diz, pareceria ficar próxima a afirmação — repetidamente feita, de resto — de que a responsabilização de alguém por um

---

(1) STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 3; cf., também, logo, § 6, n.º 22, onde todavia pretende retirar, desta consideração (segura), conclusões para uma concepção final da acção negligente que nos não parece deverem ser aceites (supra, 10.º Cap., § 33).

delito negligente implica sempre uma "**responsabilidade pelo acaso**" (quando a realização típica integral, nomeadamente o resultado — de dano ou de perigo — se verificou) e, nesta medida, um pedaço de responsabilidade pelo resultado, com a consequente violação do princípio da culpa. Se *A* e *B* conduzem os seus automóveis com igual violação do cuidado devido, por exemplo, porque ambos conduzem com velocidade excessiva, e *A* fere gravemente um peão, *C*, enquanto com *B* nada se passa e tudo acaba por correr bem, *A* é punido por ofensas negligentes à integridade física de *C*, enquanto *B* não incorre (ressalvado eventualmente o disposto no art. 291.º) em responsabilidade penal.

§ 3 Pensou-se que a única forma de obstar a uma tal conclusão residiria em considerar a produção do resultado uma **condição objectiva de punibilidade** do delito negligente, como tal não participante do tipo de ilícito respectivo; consideração defendida, em especial, por adeptos da doutrina da acção final ou, quando menos, por defensores de uma preponderância decisiva do desvalor de acção sobre o desvalor de resultado (2). Mas nem de um ponto de vista teorético-dogmático, nem prático-normativo uma tal concepção pode ser aceite: o resultado não tem uma função somente limitadora, mas **constitutiva** do desvalor **unitário** do ilícito negligente: é a partir deste desvalor que se compreende a finalidade da norma, como é a partir dele que se determina a medida do cuidado devido. Quanto, por seu turno, a uma hipotética violação do princípio da culpa, bastará dizer que a responsabilização é fundada num efectivo desvalor de acção *e* de resultado; à luz do exemplo acima dado não é *A* que, sendo punido, deve ser considerado um "azarento", mas *B* que, não sendo punido, pode ser considerado um "felizardo" (3)! Jogam aqui o seu papel considerações político-criminais, nomeadamente de carência de tutela penal e de intervenção

(2) Assim, KAUFMANN, Armin, Zum Stand der Lehre vom personalen Unrecht, *Welzel-FS*, 1974, p. 410 e s., SCHAFFSTEIN, Handlungsunwert, Erfolgsunwert und Rechtfertigung bei den Fahrlässigkeitsdelikten, *ibidem*, p. 561, e ZIELINSKY, *Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff*, 1973, pp. 128 e ss. e 200 e ss.

(3) Assim, ao menos na conclusão, JESCHECK / WEIGEND, § 55, II, 1, *a*, SCHÜNEMANN, Neue Horizonte der Fahrlässigkeitsdogmatik, *Schaffstein-FS*, 1975, p. 169 e ss., e STRATENWERTH, Die Relevanz der Erfolgsunwerts im Fahrlässigkeitendelikten, *ibidem*, p. 187 e ss. Cf., de resto, na esteira de uma sugestão de Baumann e de Eduardo Correia, já o nosso *Responsabilidade pelo Resultado e Crimes Preterintencionais*, 1961, p. 87; e por último FARIA, Paula Ribeiro de, *A Adequação Social da Conduta no Direito Penal ou o Valor dos Sentidos Sociais na Interpretação da Lei Penal*, 2005, pp. 834, 871 e ss.

mínima, que amplamente justificam a diferença de tratamento num e noutro caso. Além de que esta conclusão não deixa de estar em pleno acordo com a função da culpa no sistema do facto jurídico-penal e com o correspondente sentido "unilateral" do princípio da culpa: se toda a pena supõe a culpa, nem toda a culpa determina uma punição (supra, 4.º Cap., § 9).

II. O tipo de ilícito negligente como violação de um dever de cuidado

§ 4 De acordo com o que se expôs e com o disposto no proémio do art. 15.º, o tipo de ilícito negligente traduz-se na violação pelo agente de um dever de cuidado que sobre ele juridicamente impende. Fica assim próxima a ideia de que aquela violação traduz o **desvalor de acção** — o conteúdo **pessoal** do ilícito — próprio do facto negligente; desvalor ao qual acrescerá um desvalor, *hoc sensu*, de "resultado", traduzido, por regra, na "produção, causação e previsibilidade" do evento típico (4) e, excepcionalmente, na própria realização típica integral (5).

1. Violação do dever de cuidado e imputação objectiva. Crimes negligentes de resultado e de mera actividade

§ 5 Não falta porém hoje quem prefira **substituir** o elemento da violação do cuidado devido pela categoria da criação ou potenciação pelo agente de um risco não permitido, comum aos delitos dolosos e negligentes de resultado, pretendendo que é esta categoria, não aquele elemento, que verdadeiramente conforma a tipicidade dos crimes negligentes (6). Não cremos porém, em definitivo, que possam divisar-se vantagens nesta substituição. Enquanto, pelo contrário, não será difícil encontrar nela defeitos e inexactidões teorético-dogmáticos sensíveis.

§ 6 Desde logo, como já por mais de uma vez se acentuou, os delitos negligentes são na maioria esmagadora dos casos — na verdade, *quase* sempre — crimes de resultado (homicídios, ofensas à integridade física, etc.)

---

(4) JESCHECK / WEIGEND, § 55, I e II.

(5) No essencial da conclusão também, FARIA, Paula Ribeiro de, nota 3, p. 844 e s.

(6) É o caso, nomeadamente e por último, de ROXIN I, § 24, n.º 8 e ss. Uma análise da questão, agora, para concluir fundamentalmente no sentido do texto, em FIDALGO, Sónia, *Responsabilidade Penal por Negligência no Exercício da Medicina em Equipa*, diss. de mestrado na FDUC, 2006, p. 39.

no preciso e estrito entendimento que destes se fez supra, 11.º Cap., § 37 e ss. Mas surgem também por vezes como crimes **de mera actividade**, como é o caso, entre nós, por exemplo, do crime (negligente) de condução de veículo em estado de embriaguez (art. 292.º), bem como de vários crimes constantes da "lei das infracções contra a economia", DL 28/84, *v. g.*, dos arts. 30.º, 33.º e 35.º/*b)*. Em casos tais não terá pois sentido a afirmação de que o problema da tipicidade dos crimes negligentes se confunde com a (e se reduz à) questão geral da *imputação objectiva* que nos crimes de mera actividade nem sequer se suscita. E o argumento é reforçado, ainda neste contexto, pelo teor literal do art. 15.º do CP: a negligência é aí apresentada, em qualquer das duas modalidades que assume, conexionando a violação do cuidado objectivamente devido não com a produção do *resultado*, mas com "a realização de um facto que preenche um tipo de crime". Numa palavra, nos crimes negligentes de mera actividade a *violação de um dever de cuidado* no sentido de o agente dever prever e evitar a realização de um facto típico ganha autonomia teorético-dogmática. Sem prejuízo de ser exacto que a questão *prático-normativa* é então a de saber que **medida de cuidado** é aqui verdadeiramente exigida; sendo nesta sede aplicáveis, é verdade, *mutatis mutandis*, os critérios que infra, § 10 e ss., serão expostos a propósito dos crimes negligentes de resultado (7).

§ 7 Mesmo no que toca aos **crimes negligentes de resultado**, já Engisch acentuou, é verdade, que a violação do dever de cuidado não é, ela mesma, um puro critério de imputação objectiva específico dos factos negligentes, antes sim um **momento do próprio conteúdo de toda a norma de comportamento** (8). O que só aparecerá reforçado em todos aqueles autores, de Córdoba Roda a Faria Costa, para quem — afinal acompanhando Engisch — a norma de ilicitude é, mais que uma norma destinada a evitar resultados, uma "norma de cuidado" no relacionamento interpessoal (9). Mas não é esta questão "**ontológica**" do cuidado como fonte de legitimação do direito penal que no nosso problema de agora

(7) Sobre o ponto, já DIAS, Figueiredo, nota 3, p. 61 e s.

(8) ENGISCH, desde as suas *Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit*, 1930, pp. 283 e ss. e 343 e s., sobretudo em *Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände*, 1931, p. 53, até, por último, a Der Unrechtstatbestand im Strafrecht, *DJT-FS*, I, 1960, p. 416 e ss.

(9) CÓRDOBA Roda, *El conocimiento de la antijuridicidad en la teoria del delito*, 1962, p. 64 e ss., COSTA, Faria, *O Perigo em Direito Penal*, 1992, p. 316 e ss.

está em questão, antes a questão **dogmática** da categoria da violação do cuidado devido como essência ilícita-típica do facto negligente.

§ 8 É exacto, por outro lado, que, as mais das vezes, a punição da negligência surge sem que o legislador descreva o facto a que corresponde, antes remetendo para a descrição respectiva punível a título de dolo ("se a conduta for praticada por negligência...", *v. g.*, art. 272.º e ss.) ou renunciando, em todo o caso, a acrescentar à violação do cuidado devido — e eventualmente à menção do resultado — elementos típicos adicionais (p. ex., "quem matar outra pessoa por negligência", art. 137.º-1). Mas exacto é igualmente que em certos casos o legislador acrescenta à produção do resultado **elementos caracterizadores do tipo de ilícito respectivo**, *v. g.*, em certos tipos de erro puníveis a título de negligência — nos quais releva, de certo modo "para além do facto", a violação de deveres de informação (cf. o art. 16.º-3 relacionado com a 2.ª parte do n.º 1 e com o n.º 2) — ou mesmo em certos tipos de crime (*v. g.*, art. 351.º). Em todos estes casos, uma vez mais, não teria sentido a redução da questão da essência do tipo de ilícito negligente à da imputação objectiva de um resultado.

§ 9 Por fim — e, em nosso parecer, decisivamente —, quando se afirma que também nos delitos dolosos se verifica a violação de um dever de cuidado avança-se uma proposição porventura *formalmente verdadeira*, mas que nem possui capacidade explicativa do conteúdo do tipo de ilícito, nem assume neste qualquer autonomia normativa, nem, de todo o modo, tem a ver com os pontos de vista teleológicos e materiais sob os quais uma certa conduta conforma um tipo de ilícito doloso. Importa por isso reconhecer o que há de desinteressante, de equívoco e mesmo (quando se queira atribuir à afirmação força normativa conformadora) de errado, em considerar a violação do dever de cuidado como um elemento típico *comum* aos crimes dolosos e negligentes. Quando se fala da violação do cuidado devido como elemento do tipo de ilícito negligente quer-se designar, dito com maior exactidão, a **violação de exigências de comportamento em geral obrigatórias cujo cumprimento o direito requer, na situação concreta respectiva, para evitar realizações não dolosas de um tipo objectivo de ilícito** ([10]). Com isto julgamos ficar suficientemente assegurada a

([10]) Neste preciso sentido, BURGSTALLER, *WK*, § 6, n.º 33. No sentido do texto também — além de FARIA, Paula Ribeiro de, nota 3, p. 834 e [1334] — MIR PUIG, sobre lo objetivo y lo

autonomia do tipo de ilícito negligente, seja este de mera actividade ou de resultado.

2. Critérios concretizadores do cuidado devido

§ 10 De acordo com a conclusão a que chegámos — e na qual continua a convir, convém dizê-lo, a doutrina ainda hoje largamente dominante —, ao tipo de ilícito negligente pertence um momento próprio de **contrariedade ao dever**. A concretização dogmática deste critério supõe a resolução de duas espécies de problemas. Um deles — sobre o qual, este sim, a dogmática actual irremediavelmente se divide — é o de saber se os critérios de determinação do dever de cuidado assumem carácter **geral** (a este propósito se falando algo impropriamente, e já se verá porquê, de dever *objectivo* de cuidado), ou possuem carácter **individualizado** (então se requerendo, com pelo menos igual impropriedade, que o agente tivesse *podido* responder ao cuidado objectivamente imposto). O outro, sobre o qual existe em geral larga concordância doutrinal (embora os pareceres se dividam quanto a muitas das especialidades), é o de determinar quais as **fontes concretizadoras** do dever de cuidado.

2.1. Intervenção de critérios individualizadores do dever de cuidado

§ 11 Segundo a atrás referida doutrina do *duplo escalão* (supra, 34.º Cap., § 11 e s.), a determinação do dever de cuidado parece dever decorrer do cuidado **objectivamente** devido — ou, como também se diz, do *cuidado necessário no tráfico* — e, por isso, com apelo às capacidades da sua observância pelo "homem médio". Isto significaria que o critério em último termo definidor do tipo de ilícito negligente é um critério puramente *objectivo*, *generalizador*, que não entra nunca em conta com as capacidades pessoais do agente *concreto*: se estas se situarem **abaixo** das do "homem médio", nem por isso a realização do facto deixará de imputar-se à violação do dever de cuidado, tudo o mais só podendo constituir uma questão da *culpa negligente*; se se situarem **acima**, a integração do tipo de ilícito não deverá fazer apelo a exigências acrescidas de dever: o tipo

---

subjetivo en el injusto, *ADPCP 41*, 1988, p. 661 e ss. (666), e KRAUSS, Erfolgsernwer und Handlungsunwert im Unrecht, *ZstW 66*, 1964, p. 44.

de ilícito não terá sido integrado desde que o agente, por muito acima do "homem médio" que se situe no que toca às suas capacidades, tenha observado o cuidado objectivamente devido.

§ 12 Esta doutrina — que, sem dúvida, continua a ser dominante ([11]) — tem deparado modernamente com forte e prestigiada contestação ([12]). Diz-se, em suma, que com ela se vai em certos casos demasiado longe, em outros se permanece aquém do que é devido. Pretende-se que se vai **demasiado longe** quando se defende que realiza um tipo de ilícito negligente o condutor de automóvel que provoca um acidente evitável para a generalidade das pessoas, mas que a ele lhe era pessoalmente impossível evitar: o direito só pode exigir aquilo que cada um pode prestar (ou, como também poderia afirmar-se com o velho aforismo latino, *ad impossibilia nemo obligatur* e *nemo tenetur*). Fica-se **aquém** do que é devido quando se nega a realização de um tipo de ilícito negligente por um cirurgião magistral, que domina uma técnica altamente sofisticada só ao alcance de alguns, mas não a usa relativamente a um certo paciente, cuja operação decorre apenas de acordo com as capacidades do cirurgião "médio" e em consequência do que o paciente falece. No primeiro caso a realização do tipo de ilícito negligente deveria ser negada, no segundo deveria ser afirmada. O critério definidor da violação do dever de cuidado seria pois, na negligência, **sempre um critério individual** ou **individualizador**; com o que, assinale-se, ter-se-ia acabado por pôr em causa a doutrina do duplo escalão. Em nossa opinião, porém, a razão na querela assiste àqueles que sustentam que capacidades pessoais inferiores à média não podem rele-

---

([11]) Representativos desta concepção dominante, JESCHECK / WEIGEND, § 54, I, 3, com indicações concordantes. Uma exposição da questão entre nós, por último, em FIDALGO, Sónia, nota 6, p. 41 e ss.

([12]) Sem prejuízo de se poder deparar com manifestações anteriores, a formulação mais acabada da posição que em seguida se exporá encontra-se porventura em STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 11 e ss. (já STRATENWERTH, Zur Individualisierung des Sorgfaltesmaßstabes beim Fahrlässigkeitsdelikt, *Jescheck-FS*, 1985, p. 285). Cf., depois, também, JAKOBS, 9/1 e ss.; e, pondo a questão em conexão com a "capacidade de evitar" ou com o que chama a "causalidade da evitabilidade", GÖSSEL, Velhos e novos caminhos da doutrina da negligência, *BFD XLIX*, 1983, p. 230 e ss. Nesta linha parecia — tanto quanto podia avaliar-se — encontrar-se, entre nós, FARIA, Paula Ribeiro de, *Comentário Conimbricense*, I, art. 148.º, § 17 e s., ao imputar o critério subjectivo, assente na medida individual, bem como a exigibilidade de uma actuação conforme com a norma, ao tipo subjectivo de ilícito da negligência e deixando consequentemente para a culpa unicamente as questões da inimputabilidade (eventualmente também da inexigibilidade); cf., no entanto, agora, ID., infra, nota 14.

var logo ao nível do tipo de ilícito negligente, no sentido de excluir a tipicidade da conduta, mas só devem ser consideradas ao nível do tipo de culpa negligente. Enquanto já as capacidades pessoais superiores à média devem ser tomadas em conta no sentido de poderem fundar o tipo de ilícito da negligência ([13]).

§ 13 As **capacidades inferiores à média não podem relevar no sentido de excluir a tipicidade** do facto negligente, antes só devem relevar a nível da **culpa**; e por várias razões. Desde logo, outra solução significaria um inadmissível esvaziamento do relevo da negligência a nível da culpa, que assim ficaria reduzida ao "puro juízo de censura" típico da doutrina mais ortodoxa da acção final: ao puro juízo de censura do qual faria parte a imputabilidade, a consciência (potencial) do ilícito, a exigibilidade; mas que não possuiria qualquer conteúdo de culpa *material* — muito menos podendo constituir um "tipo de culpa" —, o que, nesta medida, representaria uma violação, como já deixámos assinalado, do princípio da culpa (supra, 10.º Cap., § 70 e s.). Mas, ainda quando esta consequência tivesse de ser aceite, não temos por exacto que a norma de ilicitude se não dirija com sentido também àqueles que não estão em condições pessoais de a cumprir; que ela possa, em suma, ser uma norma puramente individualizada, de tal modo que o Direito nunca poderia exigir senão aquilo que cada um, segundo as suas capacidades pessoais, está em condições de prestar. Com uma tal concepção sofreriam inexoravelmente a força normativa do Direito e os bens jurídicos que a este cumpre proteger, o efeito de prevenção tornar-se-ia em pura miragem e seria impossível regular, através de uma ética de responsabilidade conatural à justiça social, a vida comunitária. Acrescendo que seria insustentável — logo de um ponto de vista preventivo e portanto segundo exigências político-criminais primárias — aceitar que o comportamento violador do dever de cuidado daquele que não se encontre em condições pessoais de o cumprir pudesse ser considerado lícito e contra ele não pudesse, consequentemente, ser exercida uma acção defensiva (da vítima ou de terceiro, nomeadamente, de legítima defesa) ou não fosse legítimo aplicar-lhe, em caso de perigosidade, uma medida de segurança.

([13]) Assim, ROXIN I, § 24, n.º 57; S / S / CRAMER / STERNEBERG-LIEBEN, § 15, n.ºs 118 e s., 121, 133 e ss., e DIAS, Figueiredo, nota 14, art. 137.º, § 12.

§ 14 De outro lado, também a não utilização, *in casu*, **das capacidades especiais ou superiores à média não pode deixar de conduzir à afirmação da tipicidade** do facto negligente, mesmo quando se não revele violado o cuidado "objectivamente" devido (isto é: adequado às capacidades do "homem médio"). Seria incompreensível e inaceitável que se não imputasse — no caso já atrás referido — um comportamento tipicamente negligente ao cirurgião magistral que, por não estar para maçadas ou porque está com pressa, deixa morrer um paciente na sala de operações por ter utilizado no caso apenas as capacidades correspondentes ao cirurgião "médio" e não aquelas de que pessoalmente dispõe e está em condições de empregar; ou o esquiador campeão do mundo que não usa a sua excepcional capacidade, mas apenas o cuidado "médio", para evitar uma colisão da qual vêm a resultar ferimentos graves noutro esquiador ou num espectador. Esta concepção não constitui, de resto, nenhuma excepcionalidade desconhecida em termos de ilicitude típica: logo em tema de imputação objectiva todos aceitam que, já para o juízo de prognose póstuma relevante para estabelecimento do nexo de imputação, o observador colocado *ex ante* tem de entrar em consideração com os *conhecimentos especiais* do agente (*v. g.*, com o conhecimento do agente de que a vítima da pancada sofre de hemofilia: supra, 12.º Cap., § 16). Tem por isso plena razão Roxin quando pergunta: "Porque é que o que vale para o conhecimento especial não deveria ser igualmente válido para a capacidade especial?" ([14]).

§ 15 É decerto compreensível a objecção de que o agente dotado de capacidades especiais nem sempre estará em condições de as prestar ou não lhe será exigível que esteja sempre pessoalmente disponível para um desempenho ou um rendimento máximos. Mas, precisamente, isso revela que a circunstância de se individualizar o critério do dever de cuidado relativamente a pessoas dotadas de capacidades especiais não "apaga" ou "elimina" — contra o que por vezes se critica — a questão da **culpa negligente** ou sequer a ela se sobrepõe: é em sede de tipo de culpa, não de tipo de ilícito negligente que tem de ser considerada a questão da exigibilidade relativamente ao agente dotado de especiais capacidades de que, no caso, as tivesse efectivamente usado. Com o que fica defendida, também

([14]) ROXIN I, § 24, n.º 62. Uma aprofundada consideração da questão — para concluir, ao que nos pareceu, num sentido próximo do texto (pp. 925 e ss., 934) embora, porventura, não coincidente com ele — encontra-se agora em FARIA, Paula Ribeiro de, nota 3, p. 893 e ss.

nesta sede, a "doutrina do duplo escalão" na construção dogmática do delito negligente. Podendo então continuar a afirmar-se — como é apanágio daquela doutrina — que **o tipo de ilícito negligente é eminentemente (ou mesmo exclusivamente) objectivo**, como **é objectivo o dever de cuidado que o constitui**. Como sublinha Paula Ribeiro de Faria, "*uma coisa é (...) a regra e a sua objectividade, outra é a sua violação e os critérios utilizados para definir essa violação*" ([15]).

2.2. Fontes concretizadoras do dever de cuidado, sua função e alcance

§ 16 O dever de cuidado como elemento integrante do tipo de ilícito negligente possui, ele próprio, os seus *específicos elementos típicos*. Dito de outra maneira, porventura mais clara: do que se trata aqui é da violação de normas de cuidado **que servem concreta e especificamente o tipo de ilícito respectivo**, não da observância *geral* do cuidado com que toda a pessoa deve comportar-se no seu relacionamento interpessoal e comunitário. Por isso assume importância fundamental, na aferição do preenchimento por uma conduta do tipo de ilícito negligente, a comprovação da violação do cuidado devido *no caso concreto* ("segundo as circunstâncias", nas palavras do art. 15.º). Sendo embora assim, é possível identificar — e a doutrina hoje dominante tem feito isso — as principais fontes de onde promana o dever de cuidado típico, na acepção predita.

2.2.1. As fontes normativas ([16])

§ 17 O primeiro e mais importante elemento concretizador deriva obviamente das **normas jurídicas de comportamento** existentes — sejam elas gerais e abstractas, contidas em leis ou regulamentos, sejam individuais, contidas em ordens ou prescrições da autoridade competente, digam respeito a matéria jurídica de carácter penal ou de qualquer outra natureza ([17]).

([15]) FARIA, Paula Ribeiro de, nota 3, p. 916[1454] (s. n. o.).

([16]) A propósito de toda a temática que se segue, COSTA, Faria, nota 9, pp. 474 e ss. e 523, FARIA, Paula Ribeiro de, nota 3, p. 956 e ss., e, com especial incidência sobre o exercício da medicina, FIDALGO, Sónia, nota 6, p. 47 e ss.

([17]) Assim, o Tribunal Superior alemão acentuou — ao que pensamos, com razão —, no célebre caso do *Lederspray* (supra, 12.º Cap., § 7 e nota 4, e § 45 e s.), que há boas razões para pensar que "os mesmos deveres que são decisivos para a responsabilização jurídico-civil pelo pro-

§ 18 Outra fonte de aferição dos deveres objectivos de cuidado é constituída pelas **normas escritas, profissionais e do tráfego, correntes em certos domínios de actividade**. Trata-se aqui de normas escritas de comportamento (**não jurídicas**), fixadas ou aceites por certos âmbitos de actividades e destinadas a conformá-las dentro de padrões de qualidade e, nomeadamente, a evitar a concretização de perigos para bens jurídicos que de tais actividades podem resultar. O que se passa com as normas profissionais e análogas (nomeadamente as de carácter *técnico*, as chamadas *leges artis*, quando "escritas", *v. g.*, constantes de um estatuto profissional) relativas à actividade de médicos, dentistas, enfermeiros, engenheiros, arquitectos, caçadores, desportistas, soldados, hoteleiros ou outras pessoas ligadas, a qualquer nível, à inteira cadeia alimentar, etc., ilustra bem aquilo que aqui se tem em vista.

§ 19 A concretização de normas de cuidado objectivo será tanto mais difícil quanto faltem por completo disposições escritas, jurídicas ou não, reguladoras da actividade respectiva. Então, torna-se indispensável o apelo aos *costumes profissionais* comuns ao profissional prudente, ao profissional-padrão, e, na sua falta (pense-se, p. ex., em actividades como as de trabalho doméstico, de *baby-sitting*, etc.), impõe-se o *recurso directo* ao cuidado imposto pelo concreto comportamento socialmente adequado no tráfico — o recurso directo àquilo que, em expressão feliz, Armin Kaufmann chamou "a personificação da ordem jurídica na concreta situação" ([18]), ou que Burgstaller designa como a *Massfigur* ([19]), a **figura-padrão cabida ao caso**.

2.2.2. A função indiciária

§ 20 O que acaba de ser dito tem de ser conexionado, em todo o caso, nos crimes negligentes de resultado agora em questão, com as regras da imputação objectiva que foram expostas a propósito dos delitos dolosos e que aqui devem valer completamente: a violação de um dever de cuidado só pode ser imputada a quem, com ela, criou um risco não permitido que se concretizou no resultado típico. Também na negligência, no entanto, não

---

duto constituem também os fundamentos da responsabilização jurídico-penal" (BGHSt 37, 106, 115).

([18]) Referido por BURGSTALLER, nota 10, n.º 38.

([19]) BURGSTALLER, *ibidem*.

é viável proibir todo o comportamento perigoso para bens jurídico-penalmente protegidos. A concretização das regras de cuidado resultantes das fontes que acabaram de ser referidas tem precisamente a função e o significado de **precisar a medida do risco aqui permitido**. Por isso, e desde logo, não podem ser proibidos riscos atinentes a resultados típicos que, segundo a experiência geral ou o especial conhecimento do agente, sejam **imprevisíveis** ou **inevitáveis**: os termos da doutrina da adequação devem ser neste âmbito completamente aplicáveis ([20]).

§ 21 Urge ter em conta, por outro lado, que a violação das normas de cuidado constituirá **indício** por excelência de uma contrariedade ao dever de cuidado tipicamente relevante, mas **não pode em caso algum fundamentá-la definitivamente**, provenha ele de uma norma jurídica, de uma norma escrita não jurídica ou da aplicação do critério da figura-padrão: quando o perigo típico de um comportamento pressuposto pela norma de cuidado falte excepcionalmente, em virtude da especial configuração do caso concreto, não pode um tal comportamento ser considerado violador do dever de cuidado ([21]). Nas palavras de Roxin, "o que *in abstracto* é perigoso, pode deixar de o ser no caso concreto". Se, *v. g.*, um condutor "fura" a luz vermelha do semáforo num cruzamento em condições de plena visibilidade e quando as vias estão desertas, não preenche o tipo de ilícito das ofensas à integridade física se por força de óleo imperceptivelmente derramado na estrada perde o controlo do veículo e fere dois transeuntes que conversam placidamente no passeio ([22]). Inversamente ([23]), pode excepcionalmente divisar-se uma violação do cuidado devido em casos em que foram observadas todas as normas legais, corporativas ou correntes no tráfico e, todavia, o conhecimento ou a suspeita fundada de um

---

([20]) Contra, STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 20, de acordo com a sua doutrina da plena subjectivização do dever de cuidado.

([21]) Assim, já, MAIWALD, Zur Leistungefähigkeit des Begriffs "erlaubtes Risiko" für die Strafrechtsdogmatik, *Jescheck-FS*, 1985, p. 421, e BIDASOLO, *El delito imprudente, critérios de imputación del resultado*, 1989, p. 101 e ss. Cf., também, FARIA, Paula Ribeiro de, nota 3, pp. 940 e ss.

([22]) Cf. ROXIN I, § 24, n.º 16, DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 137.º, § 5, FARIA, Paula Ribeiro de, *Comentário Conimbricense*, I, art. 148.º, § 7. Para uma aplicação deste critério no âmbito da obediência a ordens superiores, cf. BRANDÃO, Nuno, *Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal*, 2006, p. 267 e ss.

([23]) Nos termos que se seguem, BURGSTALLER, nota 10, n.º 44, na esteira de KIENAPFEL, *Einführung*, p. 403.

perigo não considerado por aquelas obrigue a cuidados acrescidos. Assim, p. ex., no caso de obras de construção em que são usados explosivos, o respeito pelos limites legais existentes da intensidade das explosões poderá não ser suficiente para acautelar o perigo que delas advém para casas antigas e em estado notório de degradação situadas nas proximidades, exigindo a observância de um cuidado acrescido na prática daqueles actos perigosos. A inobservância deste cuidado acrescido poderá fundamentar a violação do dever de cuidado se, em virtude das explosões, uma casa ruir, ocorrendo eventualmente danos, lesões corporais ou a morte de residentes. Ou — embora neste exemplo estejam em jogo não normas "jurídicas", mas normas do tipo das que se falará a seguir — se a situação excepcionalíssima de um doente obriga a cuidados acrescidos mesmo relativamente aos que resultam de um protocolo médico em vigor. Que todavia, em casos deste teor, deva ser-se particularmente exigente na comprovação da *culpa* negligente, é coisa que se compreende por si.

§ 22 Decerto, às **normas meramente "técnicas"** não poderá atribuir-se **o mesmo relevo indiciador** que se deve conferir às normas "jurídicas", em particular porque aquelas podem ter na sua base interesses meramente corporativos antes que, imediatamente, de defesa de bens jurídicos, e porque o progresso técnico pode ter facilmente determinado a ultrapassagem destas regras por outras mais perfeitas e mais actuais; não estando assim o tribunal dispensado, em caso algum, de comprovar a sua adequação ao caso de espécie ([24]). Sem prejuízo de dever reconhecer-se que as normas técnicas, sendo em maior número, terão um âmbito de aplicação tendencialmente maior; enquanto, por outro lado, têm base directa na experiência prática, o que lhes confere um importante efeito dissuasor.

§ 23 Mais exigente se tem de ser ainda relativamente ao seu valor indiciário quando se apele à **figura-padrão**. De um ponto de vista teorético e abstracto será difícil ir mais longe, neste âmbito, do que afirmar que aquilo que aqui serve de **critério** da violação do dever de cuidado é a não correspondência do comportamento àquele que, em idêntica situação, teria um homem fiel aos valores protegidos, prudente e consciencioso; o

([24]) Assim, LENCKNER, Technische Normen und Fahrlässigkeit, *Engisch-FS*, 1969, p. 497 e ss., SCHÜNEMANN, Die Regeln der Technik, *Lackner-FS*, 1987, p. 367 e ss., e ROXIN I, § 24, n.º 29.

que conduz directamente a que este modelo seja diferenciado *de acordo com o círculo de actividade em causa* (as *leges artis* não escritas, *v. g.*, relativas a trabalhadores agrícolas, pedreiros, electricistas, pintores, etc.). O que por seu lado terá de ser posto em conexão com o concreto comportamento levado a cabo, com a sua perigosidade, a hierarquia do bem jurídico atingido, a frequência da sua violação, o valor e a aceitabilidade sociais do comportamento. Assim fica próxima a ideia de Paula Ribeiro de Faria segundo a qual, nestes casos, o juiz terá de formular uma espécie de regra de cuidado *ad hoc* para o caso concreto tendo em conta a sua configuração específica, nomeadamente, com recurso a uma ideia de adequação social da conduta (25).

§ 24 Campos especiais existem, por outro lado — nomeadamente o de certas *práticas desportivas*, desde logo a do futebol —, onde em muitos casos deverá concluir-se que, **apesar da violação da norma de cuidado, a conduta se manteve ainda dentro do âmbito do risco permitido** e se não pode comprovar, por falta de imputação objectiva, uma realização típica negligente (26).

2.3. A chamada negligência na assunção ou aceitação

§ 25 Segundo uma doutrina correntemente aceite, a responsabilidade por negligência pode derivar da chamada *negligência na assunção* ou na *aceitação*. O substrato que aqui se tem em consideração reside essencialmente na **assunção de tarefas ou na aceitação de responsabilidades para as quais o agente não está preparado**, porque lhe faltam as condições pessoais, os conhecimentos ou mesmo o treino necessários ao correcto desempenho de actividades perigosas. Por exemplo, o automobilista que mata um peão preenche o tipo de ilícito do homicídio negligente se se apercebeu já que anda a ver muito mal, ou que se encontra com a sua capacidade de reacção diminuída, ou que é — apesar de munido com a licença administrativa necessária — ainda um principiante na condução,

---

(25) FARIA, Paula Ribeiro de, nota 3, p. 976, e, já, COSTA, Faria, nota 9, p. 152. Uma larga e cuidada casuística a propósito, nomeadamente, da circulação rodoviária, da construção de edifícios ou outras obras, da actividade médica e dos acidentes de trabalho encontra-se em FARIA, Paula Ribeiro de, nota 11, art. 148.º, §§ 13-16.

(26) Assim, ANDRADE, Costa, As lesões corporais (e a morte) no desporto. *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, pp. 694 e ss. e 717 e ss.

incapaz de dominar situações de tráfico rodoviário altamente complexas. Nestes casos, se bem que uma negligência referida ao momento da acção não possa ser comprovada, todavia aquela deve ser em definitivo afirmada reportando-a ao momento em que o agente assumiu ou aceitou o desempenho, *sabendo todavia, ou sendo-lhe pelo menos cognoscível, que para tanto lhe faltavam os pressupostos anímicos (espirituais) e/ou corporais* necessários.

§ 26 À primeira vista dir-se-á dar-se nestes casos uma inextricável confusão de elementos constitutivos do tipo de ilícito e do tipo de culpa negligentes; ou, pelo menos, uma necessária co-determinação do dever de cuidado por elementos inevitavelmente pessoais-subjectivos. A primeira asserção não seria exacta, se bem que a segunda, essencialmente, o seja. O que se passa é que a assunção ou aceitação da actividade como tal constitui já uma **contradição com o dever de cuidado referido ao tipo** que virá a ser preenchido; ou, nas palavras de Burgstaller, "a aceitação da actividade respectiva pelo agente concreto deve ser proibida em função dos riscos de realização do delito que com ela se ligam" ([27]). Por outra parte, a negligência na assunção ou aceitação caracteriza-se, como se disse, por um alargamento do objecto sobre que recai o dever de cuidado e, por esta via, por uma "antecipação" do ponto temporal para a conexão do juízo de culpa negligente — em um certo paralelo com o que, segundo a concepção dita do "modelo da excepção" e do "modelo do tipo", sucederia em caso de *actio libera in causa dolosa*: supra, 21.º Cap., § 54 ([28]) —, mas **em nada renuncia à culpa como tal** ([29]). O que tudo traduz a ideia de que a negligência só poderá definitivamente afirmar-se relativamente àquele que aceitou o desempenho de uma actividade para a qual não se encontrava física e psiquicamente apto quando o risco daí resultante era dele *conhecido* ou era pelo menos *cognoscível*.

§ 27 A violação da norma de cuidado assumirá, deste modo, um cariz muito particular em domínios altamente especializados, que importam *especiais riscos para bens jurídicos significativos das outras pessoas ou da colectividade* ([30]). Por isso deve neste domínio pôr-se em relevo uma

---

([27]) BURGSTALLER, nota 12, n.º 108.

([28]) De uma "correspondência estrutural" fala ROXIN I, § 24, n.º 118.

([29]) Assim, de novo, BURGSTALLER, nota 10, n.º 111.

([30]) DIAS, Figueiredo, nota 22, art. 137.º, § 6.

exigência, de certo modo, especial: a de que o agente não deve actuar **antes de se ter convenientemente informado ou esclarecido sobre aqueles riscos**, sempre que se não encontre em posição de os avaliar correctamente. Se não conseguir alcançar a informação ou o esclarecimento necessários, deve *omitir* a conduta projectada; se o não faz e o resultado surge em consequência, a violação deste dever pode integrar, por via da negligência na assunção ou na aceitação, o tipo de ilícito negligente. Na frase paradigmática de Roxin, "quem não sabe uma certa coisa deve informar-se, quem não pode alguma coisa deve abandoná-la" ([31]). Para apontar um exemplo clássico, o médico dentista, avisado pelo paciente de que este "tem qualquer coisa no coração", preenche o tipo de ilícito do homicídio negligente se, sem exames complementares, submete o paciente a narcose e este morre. Como o funcionário de uma empresa de tratamento de resíduos perigosos deve impedir-se de trabalhar com uma máquina altamente sofisticada, à qual se ligam especiais perigos de explosão e com o funcionamento da qual se não encontra ainda suficientemente familiarizado e em condições de previsivelmente o dominar.

3. O princípio da confiança como princípio delimitador dos deveres de cuidado em caso de pluralidade de agentes

3.1. Consideração geral

§ 28 Também na realização de um facto negligente pode intervir uma pluralidade de pessoas, suscitando-se então o problema de saber se e de que modo a intervenção plural pode modificar a imputação individual do ilícito típico. Como muito claramente ensina Stratenwerth, "é hoje em geral reconhecido não ser sem significado para o âmbito dos deveres de cuidado se o perigo aos quais eles se referem parte de meros acontecimentos naturais ou do comportamento de outras pessoas (...). Em caso de acontecimentos regidos por leis naturais, vale a regra de que todo o risco deve ser evitado se for previsível e não se encontrar permitido como risco de vida geral ou na base de uma ponderação de interesses. De modo diferente, relativamente a comportamentos arriscados que provenham de outras pessoas, a doutrina tende para a regra oposta: a de que, em geral, não se torna necessário que se tome em conta aquele comportamento, mesmo quando

([31]) ROXIN I, § 24, n.º 36.

ele é previsível" ([32]). Nisto se traduz essencialmente o chamado *princípio da confiança*, no essencial desenvolvido pela jurisprudência alemã e que assume sem dúvida especial relevo em matéria de direito rodoviário, mas que tem vindo a ser aplicado praticamente em todos os domínios da vida social. Segundo tal princípio, pois, quem se comporta no tráfico **de acordo com a norma de cuidado deve poder confiar que o mesmo sucederá com os outros**; salvo se tiver razão *concretamente* fundada para pensar ou dever pensar de outro modo. "Concretamente", dizemos, e não sob a alegação geral de que "há sempre que contar com aquela gente descuidada," isto é, sob a invocação de um "princípio da desconfiança" (!) a que o Tribunal do Reich chegou a fazer apelo, tendo nomeadamente em vista o comportamento de peões. No exemplo de escola, o condutor *A* que detém a prioridade não precisa de, no cruzamento, reduzir a velocidade adequada à norma com que circula, antes pode em princípio contar que os outros automobilistas respeitarão a prioridade; se se verifica um embate do qual resulta, *v. g.*, a morte de *B*, que violou a prioridade, o tipo de ilícito do homicídio negligente não será imputável à conduta de *A*. Só assim não sucederá, repete-se, se *A* tiver tido concretas razões para contar com que *B* violaria a sua prioridade, por exemplo, porque se apercebeu (ou se devia ter apercebido) de que *B* circulava a uma velocidade tão excessiva que já lhe não permitia a travagem ou que *B* conduzia em notório estado de embriaguez.

3.2. Princípio da confiança e auto-responsabilidade de terceiro

§ 29 Nesta acepção é correcto afirmar que o princípio da confiança encontra o seu fundamento material no princípio da **auto-responsabilidade** de terceiros: as outras pessoas são também seres responsáveis; se se comportam descuidadamente, tal só deverá afectar, em princípio, a sua própria responsabilidade. Dito por outras palavras: como regra geral não se responde pela falta de cuidado alheio, antes o direito autoriza que se confie em que os outros cumprirão os deveres de cuidado. Desta perspectiva, o *âmbito* e os *limites* do princípio da confiança demarcar-se-iam, em definitivo, em função da extensão da auto-responsabilidade dos terceiros. Resta saber, todavia, se por esta via se não vai longe demais.

([32]) STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 65 e s. Sobre o problema, entre nós, COSTA, Faria, nota 9, p. 484 e ss., e, por último, minuciosamente, FIDALGO, Sónia, nota 6, p. 76 e ss.

§ 30 Com efeito, como se assinalou já, esta linha de pensamento não pode ser levada até ao fim, mas só no pressuposto de que a **situação concreta** não é uma tal que dê razoável e claramente a entender que o outro se não comportará de forma responsável. O que poderá porventura **generalizar-se** até ao ponto de o princípio não poder valer para certos círculos de vida em que o processo de interacção social se tornaria muito mais difícil ou mesmo impossível se não devesse contar-se com que os outros possam cometer faltas na sua actuação; isso sucederá, nomeadamente, em todos os círculos profissionais onde já a observância das regras de cuidado implica uma actividade de controlo ou de **fiscalização** da actividade dos outros (33). Isto só significa porém que o princípio da auto-responsabilidade — e, consequentemente, o princípio da confiança — não tem aplicação universal e só pode almejar validade em determinados círculos da vida e sob determinadas condições. Nomeadamente, como defendeu Kuhlen, onde e quando ele deva ser posto em conexão com um princípio de *ponderação de interesses* (34).

§ 31 A jurisprudência tem muitas vezes tendência para concluir sem mais que **não pode socorrer-se do princípio da confiança aquele que se comporta em violação de um dever de cuidado**. Feita deste modo, a afirmação é **inexacta**, bem podendo acontecer que, *v. g.*, o acidente e a consequente morte não possam ser imputados àquela violação do dever (logo de acordo, aliás, com o critério da imputação objectiva, segundo o qual é necessário que seja o perigo típico criado ou aumentado pela conduta aquele que *se concretiza*, ele e não outro, no resultado típico: supra, 12.º Cap., § 29 e ss.). Se o automobilista *C*, com uma taxa de álcool proibida, conduz por uma via prioritária com respeito pelas regras do trânsito, deve poder continuar a contar, apesar da situação ilícita (ou até porventura criminosa!) em que conduz, com que a sua prioridade será respeitada pelos outros, nos termos preditos; verificando-se um acidente por violação do direito de prioridade de *C* do qual resulta a morte de outro condutor, *D*, o tipo de ilícito negligente não deve considerar-se realizado pela conduta de *C*.

§ 32 Eminente relevo assume o princípio da confiança em matéria de **divisão de tarefas no seio de uma equipa**, máxime, no que toca a inter-

(33) Sobre esta questão fundamental, STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 68 e s., e PUPPE, *NK*, antes do § 13, n.º 151 e ss. Algo diferentemente, com maior cepticismo, ROXIN I, § 24, n.º 21 e s. Uma análise minuciosa de toda a questão, para concluir no essencial como no texto, em FIDALGO, Sónia, nota 6, pp. 84 e ss., 99 e ss., 181 e ss.

(34) KUHLEN, *Fragen einer strafrechtlichen Produkthaftung*, 1989, p. 131 e ss.; e também FIDALGO, Sónia, nota 6, p. 101 e s.

venções médico-cirúrgicas ([35]) ou quanto ao problema — típico da "sociedade do risco" — da responsabilidade jurídico-penal pelo produto ([36]). Também nestes casos qualquer membro da equipa deve poder contar com uma **actuação dos outros adequada à norma de cuidado** (jurídica, profissional, estatutária, da experiência). Sem prejuízo de que, se erros forem previsíveis ou vierem a ser efectivamente cometidos, eles devam ser impedidos ou corrigidos pelos colegas e, nomeadamente, pelo chefe da equipa. Mas o princípio da confiança cessará face ao conhecimento ou à previsão de *erros notórios* de outros membros da equipa, que exigem correcção; e bem assim, como é óbvio, perante membros da equipa que se encontrem ainda em fase de *aprendizagem* ou de *treino* — relativamente aos quais, por isso, se não pode falar de uma negligência na assunção ou aceitação — e sobre os quais deve justamente exercer-se, por parte dos restantes membros da equipa ou de algum ou alguns deles, uma particular actividade de **fiscalização**, de controlo e supervisão: o incumprimento desta actividade pode, ele mesmo, fundar a realização do tipo de ilícito negligente. Sem prejuízo, no entanto, de não ser admissível deduzir **em geral** um dever de controlo da previsibilidade abstracta de erros dos outros. Como exactamente conclui Stratenwerth, "o princípio da confiança delimita por seu lado, onde se não verifiquem *especiais* circunstâncias, também os deveres de controlo. De outra forma seria por exemplo impossível uma repartição de tarefas" ([37]).

3.3. Perante factos dolosos de terceiro

§ 33 Por fim, o princípio da confiança parece valer ainda — de algum modo, por maioria de razão — na medida em que, por regra, o agente deve poder contar com que outros não cometerão **factos dolosos**. Isto será ainda aplicável, então, a uma **actuação negligente** que induza, faci-

---

([35]) Sobre o ponto, JORGE Barreiro, *La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica*, 1990. E, já, STRATENWERTH, Arbeitsteilung und ärztliche Sorgfaltspflicht, *Eb. Schmidt-FS*, 1961, p. 383 e ss. Entre nós, CRUZ, Ana Palmira, *A Negligência Punível nos Tratamentos Médico-Cirúrgicos Desenvolvidos por uma Equipa*, diss. de mestrado na FDUC, 2003, e agora FIDALGO, Sónia, nota 6.

([36]) Sobre a questão, além de KUHLEN, nota 34, cf. DIAS, Silva, *Protecção Jurídico-Penal dos Interesses dos Consumidores*, ²2000, p. 35 e s.

([37]) STRATENWERTH /KUHLEN, § 15, n.º 69 (s. n. o.). Minuciosamente, FIDALGO, Sónia, nota 6, pp. 168 e ss., 183 e ss.

lite ou, em todo o caso, torne possível o cometimento de um ilícito-típico doloso por outrem; ou, de forma mais generalizada, quando **entre a actuação violadora de um dever de cuidado e a verificação do resultado típico se interponha uma actuação dolosa de outrem**. Só assim não sendo, também aqui, se *especiais circunstâncias* do caso concreto derem claro, imediato e fundado motivo para pensar que uma tal intermediação dolosa terá lugar; se, dito de outro modo, for clara e indubitavelmente perceptível que a actuação negligente criou um **perigo alto e próximo** de actuação dolosa de outrem. Será o caso do exemplo de escola de *A* deixar uma arma de fogo carregada, por esquecimento ou imprevidência inadmissíveis, num local onde *B* e *C* travam violenta discussão, entremeada por sérias ameaças de morte: se *B* vem a matar dolosamente *C* com a arma em questão, o tipo de ilícito do homicídio negligente poderá dizer-se preenchido pela conduta de *A*, sem que a tal possa opor-se triunfantemente o princípio da auto-responsabilidade e, consequentemente, da confiança. Mas já nos parece infundado considerar preenchido o tipo de ilícito, ainda que uma certa previsibilidade possa ser afirmada, *v. g.*, se *D*, companheira de um homem casado, *E*, lhe fornece comprimidos para dominar a insónia de que este sofre, com os quais ele acaba por matar a esposa, *F*; ou se *G*, com a ideia de se suicidar, deixa na mesa de cabeceira uma arma ou um veneno que a empregada doméstica, *H*, vem a usar para matar dolosamente outra pessoa; ou se o cliente de um café, *I*, deixa sobre o balcão um copo quando dois outros clientes travam uma discussão e um deles fere o outro com o copo. O critério decisivo parece-nos, pois, dever ser o de que os princípios da confiança e da auto-responsabilidade só devem recuar quando o facto anterior revele reconhecidamente uma *especial aptidão* para provocar o facto posterior doloso ([38]), quando criar um *perigo intolerável* de cometimento do facto doloso, de tal modo que seria de todo **desrazoável não contar com a sua possibilidade próxima**; talvez podendo afirmar-se, com razoável correcção, que o recuo dos princípios em causa só deverá verificar-se perante um facto negligente anterior que, ao nível do tipo de ilícito, deva já considerar-se como de **negligência pesadamente grosseira** (infra, 36.º Cap., § 16 e ss.). Identificando-se deste modo no essencial, em último termo, os critérios de validade e de aplicação do princípio da confiança relativamente à intervenção prévia negligente seja relativamente a factos negligentes, seja a factos dolosos.

([38]) ROXIN I, § 24, n.º 28 e ss.

§ 34 Já a doutrina alemã mais antiga tendeu para aceitar que a intervenção dolosa de alguém num acontecimento — nos exemplos apontados, as condutas de *E*, de *H* e de *I* — "interrompe o nexo causal", valendo nesta medida uma **proibição de regresso**, no sentido de que a responsabilidade jurídico-penal não deveria ir além da co-actuação dolosa de outrem e atingir também a intervenção negligente (39). Talvez, porém, porque esta doutrina, erigida em princípio sem excepções, ia longe demais, não tomando em conta casos de escandalosa previsibilidade e proximidade do perigo criado pela co-actuação negligente, a **doutrina da adequação** (nomeadamente, no entendimento sufragado entre nós por Eduardo Correia) mostrou-se disposta a "negar" a interrupção do nexo causal e afirmar a punibilidade do comportamento negligente sempre que o facto doloso consequencial fosse previsível e evitável (40). O que igualmente não pode aceitar-se: seja porque não é concebível teoreticamente a "interrupção" de um nexo causal; seja, materialmente, porque também esta posição conduziria a soluções inaceitáveis: não pode considerar-se violadora de um dever de cuidado toda e qualquer acção face à qual se admita que ela possa induzir, facilitar ou auxiliar a prática por outrem de um facto doloso. Seguramente por estas razões a ideia da "proibição de regresso" parece *voltar hoje a impor-se doutrinalmente* como elemento integrante da doutrina da imputação objectiva; mas, em definitivo, fundada nos **princípios da auto-responsabilidade e da confiança** e, por isso mesmo, sujeita às limitações — mas só a elas! — a que vimos deverem estes princípios submeter-se.

4. Tipo de ilícito subjectivo negligente?

§ 35 Esclarecidos, na medida possível, os problemas anteriores, não parece demasiado importante tanto em perspectiva sistemática, quanto sobretudo prático-normativa, saber se com a verificação do tipo "objectivo" (podendo conter embora, como se viu supra, § 14 e s., elementos "individualizados"), tal como ficou esboçado, se deve considerar perfeito o tipo de ilícito negligente; ou se diferentemente, tal como no dolo, há ainda lugar à afirmação de um tipo subjectivo de ilícito, distinto, por um lado do tipo de ilícito objectivo, por outro do tipo de culpa respectivos. A esta pergunta responde Stratenwerth **negativamente**, na base de que, coexistam embora no tipo de ilícito negligente uma face objectiva e outra subjectiva, não tem sentido autonomizar um tipo de ilícito subjectivo; logo porque (como se referiu supra, § 1) "a vontade de realização do agente negligente se *não* dirige ao resultado típico" (41). Enquanto Roxin pretende para

(39) Indicações pormenorizadas em ROXIN, Bemerkungen zum Regressverbot, *Tröndle-FS*, 1989, p. 177.

(40) Cf. CORREIA, Eduardo, I, p. 261. E ainda, agora, JESCHECK / WEIGEND, § 54, IV, 2.

(41) STRATENWERTH / KUHLEN, § 6, n.º 22, e § 15, n.º 3. Uma referência à questão encontra-se em BELEZA, Teresa, II, p. 513.

o efeito **distinguir a negligência consciente da inconsciente**, afirmando o tipo subjectivo na primeira (porque existe "a representação pelo agente de todas as circunstâncias típicas como um perigo não permitido e a confiança em que a realização típica não terá lugar") e negando-o na segunda ("porque precisamente o agente não incluiu na sua representação os elementos e pressupostos do tipo objectivo") (42). Mas já Struensee **afirma** em ambas as hipóteses o tipo subjectivo, porque "o agente conhece uma parcela tipicamente relevante das condições do resultado sobrevindo, da qual, de acordo com a valoração da ordem jurídica, deriva um perigo intolerável ('risco não permitido')" (43).

§ 36 Admitimos que **nenhuma destas posições deva ser sufragada**. A todas elas parece comum a tentativa de reconduzir necessariamente o tipo subjectivo a uma *realidade psicológica* ainda efectivamente existente na psique do agente e, na verdade, a uma qualquer forma de *finalidade* ou, ao menos, de *vontade* jurídico-penalmente relevante. Trata-se aqui, em nossa opinião, de uma herança da doutrina da acção final de que a dogmática actual não conseguiu ainda libertar-se completamente, mas que não tem de ser aceite. Já desta crítica se encontra isenta Paula Ribeiro de Faria, que baseia o seu tratamento da questão na "natureza rigorosamente objectiva do ilícito negligente, que se deixa assim deduzir a partir de um *critério puramente geral e abstracto de cuidado*". Pelo que, conclui, "não é de admitir um tipo subjectivo de ilícito negligente, nem nos termos em que o coloca a doutrina tradicional, nem com o alcance e as consequências que aqui parecem andar associadas ao seu reconhecimento" (44).

§ 37 Uma coisa é certa: a não observância do cuidado objectivamente devido não torna perfeito, por si própria, o tipo de ilícito negligente, antes importa que ela conduza — como expressamente afirma o art. 15.º do CP — a uma **representação imperfeita** ou a uma **não representação** da realização do tipo. De um ponto de vista *normativo*, sempre e em último termo decisivo, é possível divisar na "*ausência* de uma realidade psíquica" que deveria intervir e não interveio um "substrato normativamente relevante" que, de um ponto de vista material, se revela análogo

---

(42) ROXIN I, § 24, n.º 67.

(43) STRUENSEE, Der subjektive Tatbestand des fahrlässigen Delikts, *JZ*, 1987, p. 60.

(44) FARIA, Paula Ribeiro de, nota 3, pp. 893 e ss. e 901.

àquela realidade: é isso que se passa com a negligência inconsciente. Que aqui reside a **especificidade subjectiva** do ilícito negligente, parece-nos dificilmente contestável; e que ela pode relevar, ao menos, em perspectiva funcional teleológica, para legitimar a distinção entre ilícito doloso eventual e ilícito negligente consciente, a tantos ouros títulos duvidosa (supra, 13.º Cap., § 48 e ss.), é coisa que temos também como segura (45). Se uma tal especificidade é suficiente para que, na sua base, se possa falar de um verdadeiro **tipo subjectivo** de ilícito negligente, é questão puramente teorética que aqui não precisa de ser definitivamente decidida.

III. Os tipos justificadores

1. Questões gerais

§ 38 Que, relativamente a factos negligentes, intervenham, em princípio, causas de justificação com o mesmo significado dogmático que assumem relativamente a factos dolosos é afirmação que praticamente ninguém põe hoje em causa. Mas já é altamente controversa na doutrina a questão de saber se a **extensão** e os **requisitos** que na negligência assumem as causas de justificação ali pensáveis — porque, sublinha-se, nem todas o seriam, por exemplo, certas "actuações oficiais" (supra, 18.º Cap., § 2 e ss.), *v. g.*, a detenção ou prisão como meio de coacção processual (46) — permitem uma extensa **simetria** com o que sucede nos factos dolosos.

§ 39 De um lado deve dizer-se que, sendo em regra os factos negligentes *menos graves* que os factos dolosos correspondentes, se estará com facilidade disposto a aceitar um **campo mais lato de actuação** de certas causas justificativas, mesmo em caso de igual gravidade externa do resultado típico. De outro lado, porém, não falta quem saliente que, relativamente a factos ocorridos no exercício de actividades em geral socialmente desejáveis ou aceitáveis, muitos elementos justificadores se deixam já inte-

(45) Próximo desta conclusão, ao que nos pareceu, SANTOS, Cirino dos, *A Moderna Teoria do Facto Punível*, 2002, p. 108.

(46) Assim, ROXIN, § 24, n.º 98, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 34; mais latos na restrição JESCHECK / WEIGEND, § 56, I, 2, que acrescentam causas de justificação, como a do consentimento presumido e a da prossecução de interesses legítimos (art. 180.º-2/*a*)), que teriam logo entre os seus elementos constitutivos (contra, no que ao consentimento presumido respeita: supra, 17.º Cap., § 39) a "cuidadosa comprovação" pelo agente dos pressupostos restantes.

grar nos limites do **risco permitido** e assumem assim significado para determinação do **dever de cuidado** ou intervêm, de todo o modo, a nível do tipo incriminador ([47]). Compreende-se, face a esta consideração, que o tipo incriminador negligente constitua como que um *tipo aberto* (supra, 11.º Cap., § 13 e ss.) ([48]), particularmente necessitado de completação através da concretização, pelo aplicador, de critérios de imputação retirados da essência mesmo da ilicitude material; e sendo, na negligência, o âmbito da ilicitude menos intenso que no dolo, bem se aceitará, a partir dali, a relativa **sobreposição** ou **cruzamento** que acaba por verificar-se entre os momentos da ilicitude e da tipicidade. Sem que, todavia, daí resulte qualquer necessidade de abandonar, nos factos negligentes, o essencial da construção das relações entre aqueles dois momentos que nos factos dolosos se estabelecem; e sem que, em suma, as causas justificativas como tais percam a sua função dogmática e o seu lugar sistemático específicos.

§ 40 Discutida é também a questão de saber se nas causas justificativas de factos negligentes se requer — porventura em termos paralelos aos que se verificam nos factos dolosos — a verificação de **elementos subjectivos da justificação**, *v. g.* e nomeadamente, sob a forma do "conhecimento da situação justificante" ([49]). A questão pode ser teoreticamente interessante, mas possui, em definitivo, escasso relevo prático-normativo. Com efeito, sempre poderá, ao que pensamos, raciocinar-se em síntese da forma que se segue. Ainda que se não dê no caso a existência de elementos subjectivos (gerais) de justificação, um *desvalor de resultado* não se verifica porque estão presentes os elementos objectivos da justificação. O *desvalor de acção* poderá estar presente, mas ele não será em si mesmo, em princípio, punível, porque para tanto é em princípio necessária, na negligência, a verificação do resultado e do respectivo desvalor. Assim, pois — ainda quando se queira pôr em causa a sua inteira correcção teorética —, a conclusão de Stratenwerth, segundo a qual "nos delitos de negligência, elementos subjectivos de justificação não são, em princípio, necessários" ([50]), sempre será exacta no sentido de que, mesmo quando faltem

([47]) Assim, ROXIN, § 24, n.º 98, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 34.

([48]) Assim, também, ROXIN, *ibidem*. Cf. entre nós, sobre o ponto, COSTA, Faria, nota 9, p. 479, e, numa acepção mais restrita, FARIA, Paula Ribeiro de, nota 3, p. 939.

([49]) Assim, M / ZIPF, § 44, n.ºs 20, 23, 25. Cf., relativamente à legítima defesa, também ROXIN I, § 24, n.º 102.

([50]) STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 44.

tais elementos, o agente, nos delitos negligentes de resultado, não será em princípio punível.

2. Os concretos tipos justificadores ([51])

§ 41 Segundo a opinião geral, também o facto negligente pode encontrar-se coberto por **legítima defesa** em tudo o que respeite à acção necessária de defesa perante o agressor. Isto sucederá, desde logo, naqueles casos em que também o facto *doloso* de defesa se encontraria coberto pela legítima defesa (p. ex., se *A* dispara contra o agressor *B* um tiro de advertência e, por violação do cuidado devido, fere este, actua em legítima defesa sempre que, perante a situação concreta, também o disparo com o propósito de ofender corporalmente *B* seria justificado por legítima defesa). Como sucederá igualmente com as *consequências* não queridas ou não previstas de uma acção de legítima defesa; desde que — acrescenta com razão a jurisprudência alemã — tais consequências "pertençam aos riscos típicos da espécie de defesa legitimamente eleita": p. ex., "quando o agente podia servir-se de uma pistola carregada para com ela golpear, numa situação de legítima defesa, as lesões causadas ao agressor por uma bala disparada involuntariamente ao dar o golpe estão igualmente justificadas por legítima defesa" ([52]). Generalizando, pode afirmar-se que, dentro dos limites daquilo que seja necessário como acção de defesa, se encontra justificado o resultado típico que o agente não previu e que poderia ter evitado se tivesse actuado com observância da norma de cuidado.

§ 42 Doutrina análoga deverá defender-se em tema de **estado de necessidade justificante**. Com casos relativamente frequentes pode deparar-se em temas como o de acções de salvamento com infracção de normas de segurança da circulação rodoviária; ponto é que, naturalmente, a ponderação dos interesses em conflito conduza à conclusão de que a acção se destinava a salvaguardar um interesse *sensivelmente superior* ao interesse sacrificado. Assim, pois, está justificado o médico que ultrapassa os limites de velocidade permitidos para prestar auxílio a um doente grave; mas já não se a doença notoriamente não exigir uma intervenção imediata ou se a circulação for feita criando um grave perigo para a vida ou a inte-

([51]) Referência em BELEZA, Teresa, II, p. 520 e ss.
([52]) ROXIN I, § 24, n.º 100, citando BGHSt 27, 313.

gridade física de outrem. A circunstância de o facto justificado ser negligente e não doloso relevará, sobretudo, face à medida do perigo que afecta o bem jurídico ameaçado (supra, 16.º Cap., § 15).

§ 43 Um papel importante poderá desempenhar a justificação de acções negligentes através do **consentimento presumido**, nomeadamente, no campo da actividade médica. O exemplo mais vezes referido é o do médico que pratica, em alguém gravemente ferido por um atropelamento e em estado de inconsciência, uma intervenção cirúrgica de urgência em plena rua e com instrumentos insuficientes ou pouco adequados, cometendo assim, com violação das *leges artis*, uma eventual ofensa à integridade física negligente. Esta deve no entanto considerar-se justificada por consentimento presumido da vítima que, sem aquela intervenção, incorreria em perigo de vida ([53]).

§ 44 Mais complexos e discutíveis serão os problemas respeitantes ao **consentimento efectivo**. Logo porque — também em matéria de factos negligentes — não falta toda aquela corrente de opinião segundo a qual o consentimento efectivo não constitui nunca uma causa de justificação, mas sim uma causa de exclusão da *tipicidade*. Mas não vemos razão decisiva para que a crítica que movemos a esta concepção em tema de factos dolosos (supra, 17.º Cap., § 4 e ss.) não valha também, no essencial, para os factos negligentes. Claro é, por outra parte, que carecerá de eficácia justificadora o consentimento na lesão de bens indisponíveis, como será nomeadamente, numa opinião praticamente unânime, o caso da **vida humana de pessoa já nascida**. Mas justamente neste contexto não falta quem defenda — como é particularmente o caso de Stratenwerth — que "onde um consentimento não mais pode justificar a ofensa dolosa, como no homicídio, consegue-o ele, sob certas circunstâncias", relativamente a acções negligentes. Têm-se aqui em vista, muito especialmente, os casos de co-actuação não dolosa na autocolocação em perigo do atingido — ou, noutra fórmula que afinal significa o mesmo, na "heterocolocação em perigo consentida" —, p. ex., na sua voluntária participação numa viagem perigosa que lhe é proposta ou em contactos sexuais conscientes com um parceiro infectado pelo HIV, dos quais resulta a morte ([54]).

([53]) ROXIN I, § 24, n.º 107.

([54]) STRATENWERTH, § 15, n.º 36, na esteira do estudo precursor de SCHAFFSTEIN, Hand-

§ 45 Contra a colocação do problema nesta sede — e, de forma definitiva, contra a sua solução com apelo ao "consentimento" justificador — faz-se valer que, na realidade das coisas, o atingido não consente no **resultado "morte"** (consentimento que aliás seria também inválido face ao disposto no art. 134.º), mas unicamente no **perigo de resultado**; quando, acrescenta-se, este resultado é afinal um elemento que serve para co-fundamentar o ilícito negligente e ao qual, por conseguinte, o consentimento não deveria deixar de directamente referir-se e abranger. Para em seguida se defender que uma correcta solução destes problemas pode ser alcançada exclusivamente em função das regras da imputação objectiva, nomeadamente, a partir do ponto de vista do fim de protecção da norma (55).

§ 46 Já dissemos porém que, para nós, o alegado "consentimento na morte" só pode, em casos deste teor, ter o sentido de **colocação auto-responsável** do atingido numa situação de **risco de produção do resultado fatal** (supra, 12.º Cap., § 37 e ss., e 17.º Cap., § 11). Sem prejuízo de dever desde já assinalar-se ser este um campo exemplar da supra, § 39, assinalada interpenetração de tipicidade e ilicitude nos crimes negligentes, decisivo, em nosso modo de ver, é que também aqui se atribua todo o relevo e alcance possíveis ao *princípio da auto-responsabilidade* do atingido (56). Se e quando o tipo de homicídio negligente deva, em todo o caso, dizer-se preenchido pela conduta, fica só o caminho de negar a ilicitude do homicídio por força do consentimento; ponto é, repetimos, que possa afirmar-se que a vítima aceitou o risco em plena responsabilidade (57). O que aliás conduziu a jurisprudência suprema alemã a firmar o princípio de que "aquele que simplesmente dá azo, torna possível ou provoca outrem a um perigo próprio, querido e assumido em plena responsabilidade, não é em regra punível (...) por ofensas corporais ou por homicídio" (BGH 36, 1, 17). Quaisquer que sejam as limitações com que este princípio, na sua

---

lungsunwert, Erfolgsunwert und Rechtfertigung bei den Fahrlässigkeitsdelikten, *Welzel-FS*, 1974, p. 557.

(55) Claramente, neste sentido, ROXIN I, § 24, n.º 108. E, entre nós, ANDRADE, Costa, *Consentimento e Acordo em Direito Penal*, 1990, p. 300 e ss., e, agora — se bem que relativamente a um domínio especial como o das lesões desportivas —, nota 26, p. 713 e s.

(56) Assim, muito exactamente em nosso parecer, CANCIO Meliá, Opferverhalten und objektive Zurechnung, *ZStW 111*, 1999, p. 357; e, também, PUPPE, *NK*, n.º 176 antes do § 13.

(57) Um pouco mais além vão STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 38, e S / S / LENCKNER, antes do § 32, n.º 104, acrescentando, ao menos em teoria, os casos em que o consentimento "tem lugar por razões materialmente aceitáveis".

aplicação concreta, deva valer e o seu mais correcto enquadramento dogmático, não cremos, uma vez ainda o afirmamos, que soluções justas e adequadas sejam possíveis *colocando inteiramente entre parênteses*, ou só mentalmente ou também realmente, a questão do consentimento do atingido no perigo de lesão da vida. Isto serve para justificar, em termos conclusivos, que, afinal, também o consentimento tem, nos factos negligentes, um significado e um âmbito de actuação **mais vasto** do que nos factos dolosos ([58]).

IV. Autoria e cumplicidade no facto negligente

§ 47 No caso em que a actuação de mais que uma pessoa se conjuga na realização de um mesmo tipo de ilícito negligente, pode de novo, teoreticamente e pelo menos *primo conspectu*, suscitar-se um problema jurídico-penal de "comparticipação" e assim, eventualmente, de caracterização de uma **autoria** e da sua distinção face a uma **cumplicidade**. Cumplicidade, nesse caso, *não punível*, uma vez que o art. 27.º-1 exige dela que seja *dolosa*. Ora, também relativamente à realização de ilícitos-típicos negligentes — segundo o ponto de partida das teorias formais-objectivas (supra, 30.º Cap., § 4), cuja validade não há razão para restringir às acções dolosas —, **autor só pode ser quem realiza o ilícito-típico**. Este, como vimos, não é porém, nos delitos negligentes, construído sobre o modelo do conhecimento e vontade de realização do tipo de ilícito objectivo, mas da *violação do cuidado devido, produtora de um perigo proibido* que realiza o tipo objectivo.

§ 48 Que esta construção seja ainda compatível com a realização do tipo por uma pluralidade de pessoas, é coisa segura (*v. g.*, dois trabalhadores da construção civil lançam inconsideradamente do cimo de um edifício em demolição uma trave para a rua, que atinge um peão, ferindo-o ou matando-o). A verdade porém é que neste esquema comportamental não existe nem quem assuma o papel de "figura central do acontecimento", nem tão-pouco uma "repartição de papéis" relativamente à execução: todo **o critério do domínio do facto é pois aqui inaplicável** e, com efeito, tanto

([58]) Em conclusão oposta ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 149.º, § 6, *in fine*, coerentemente com a sua posição de que estes problemas encontram a sua solução definitiva em sede de "área de protecção da norma" e, portanto, logo em termos da doutrina da imputação objectiva.

relativamente à negligência inconsciente, como à própria negligência consciente ([59]). Em consequência, a doutrina largamente dominante defende para os delitos negligentes uma concepção *unitária* de autoria. Autor é **aquele (todo aquele) que, com a sua actuação violadora do cuidado imposto, cria ou potencia um perigo proibido que se concretiza no resultado (na realização) típico(a)** ([60]). Deste ponto de vista, para uma cumplicidade num ilícito-típico negligente não fica qualquer espaço ([61]). Em caso de co-actuação por negligência do mais que poderá falar-se é de **autoria paralela** (cf. supra, 31.º Cap., § 38) ([62]).

§ 49 Aceite, com esta amplitude e este sentido, um conceito extensivo de autoria negligente, parece não haver lugar para a — e, sobretudo, não haver interesse dogmático na — distinção de *formas da autoria negligente*. Volta hoje a discutir-se com insistência crescente, no entanto, a questão da **co-autoria negligente**: esta deverá ser admitida, se bem que não, todavia, sob a forma que assume nos delitos dolosos, isto é, como decisão conjunta *dirigida* à realização do tipo objectivo; antes sim como criação (ou potenciação) *conjunta* de um risco não permitido que se exprime na realização típica. O que seria ainda plenamente compatível com o — se não mesmo fortemente sugerido pelo — teor literal do art. 26.º, 3.ª alterna-

---

([59]) Se bem que não faltem autores para quem, na negligência consciente, não seria impossível (embora, em definitivo, não conveniente ou exacto) figurar situações análogas à do domínio do facto: ROXIN, *Täterschaft und Tatherrschaft*, ¹1963, p. 552 e ss.

([60]) JAKOBS, 21/111, JESCHECK / WEIGEND, § 61, ROXIN I, § 24, n.º 27.

([61]) RENZIKOWSKI, *Restriktiver Täterbegriff und fahrlässige Beteiligung*, 1997, pretende recuperar (renovando-o) o conceito de "proibição de regresso" (pp. 154 e ss., 169 e ss. e 179 e ss.), o qual, aliado a um rigoroso entendimento do princípio da auto-responsabilidade (p. 199 e ss.) e a uma indisfarçável simpatia por um "delito de participação autónomo" (criticamente, supra, 32.º Cap., § 6 e s.), o conduz à tese de que também na comparticipação negligente se *tem que* distinguir entre autoria — incluídas as suas formas, a autoria mediata e a co-autoria — e a participação: um conceito *restritivo* de autor valeria, em igual medida, para a autoria e para a participação. Nesta linha, embora com uma argumentação mais fortemente político-criminal do que dogmática, WEISSER, Bettina, Gibt es eine fahrlässige Mittäterschaft?, *JZ*, 1998, p. 230. Sobre toda a questão, concluindo no essencial no sentido do texto, FIDALGO, Sónia, nota 6, pp. 124 e s., 126 e ss., louvando-se sobretudo na ideia exacta de Stratenwerth segundo a qual o princípio da auto-responsabilidade é um princípio de delimitação da responsabilidade que não pode ser arvorado em critério de autoria.

([62]) De autoria paralela, secundária ou acessória se poderá, ao que pensamos, falar igualmente nos casos, excepcionais embora, em que — nos termos preconizados supra, § 33, mas dentro de limites ainda mais apertados — se deva punir o facto negligente que induziu, facilitou ou possibilitou o facto doloso de outrem, também este punível: ainda aí se trata de alguém que, por violação do cuidado devido, criou um risco não permitido que veio a concretizar-se no resultado.

tiva, que se basta com que o agente, *conjuntamente com outro ou outros*, tome parte directa na execução do facto, não exigindo que este tenha de ser doloso (63). Poderá então falar-se, porventura, antes que de uma co-autoria negligente — expressão que, face à aludida diferença normativa entre autoria dolosa e negligente, se pode tornar equívoca —, de um **comportamento negligente conjunto**.

§ 50 Será o interessante caso, julgado pelo Tribunal Federal suíço, que começa a ser conhecido como das *rolling stones*: *A* e *B* decidiram conjuntamente fazer rolar duas pedras, colocadas na berma de uma estrada, pela encosta abaixo, devendo saber que ali se encontravam frequentemente pescadores; um destes foi atingido por uma só das pedras e morreu, não tendo sido possível determinar se foi a pedra empurrada por *A* ou por *B* a causadora da morte. De acordo com a doutrina acima apontada, deve imputar-se a *A* e a *B* um homicídio negligente, porque o comportamento conjunto criou um risco não permitido para a realização típica. Político-criminalmente, esta é sem dúvida a solução correcta face à alternativa da absolvição de *A* e de *B*, seja por falta de prova, seja porque o "auxílio" de um ao facto do outro não seria punível por o crime cometido não ser doloso (art. 27.º-1).

(63) Assim, ROXIN II, § 25, n.º 242, indicando literatura recente concordante. Contra, a doutrina tradicional pela qual pode ver-se JESCHECK / WEIGEND, § 63, I, 3, *a*. Diferentemente do texto também, STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 80.

36.º CAPÍTULO

O TIPO DE CULPA NEGLIGENTE

I. Consideração geral

§ 1 Nos factos negligentes, à inteira semelhança do que sucede nos dolosos, o conteúdo da **culpa** é dado pela *censurabilidade da acção ilícita-típica* em função da **atitude interna juridicamente desaprovada** que naquela se expressa e a fundamenta. Ainda à semelhança dos factos dolosos, também a culpa negligente se apresenta sob uma forma tipificada: ela surge quando no facto se exprime uma atitude interna de **descuido ou leviandade** perante o Direito e as suas normas (1). Tudo isto significa concretamente, desde logo, que a questão da *inimputabilidade*, deve colocar-se e resolver-se, relativamente a factos negligentes, de forma inteiramente análoga à que tem lugar perante factos dolosos. E o mesmo se dirá, em princípio (cf., todavia, infra, § 13 e ss.), do *estado de necessidade desculpante* (art. 35.º), bem como do *excesso desculpante de legítima defesa* (art. 33.º).

§ 2 Contra o que em geral se afirma, a questão da (falta de) **consciência do ilícito** é, por sua natureza, estranha ao facto negligente, não tendo sentido perguntar se relativamente a ele se verificava uma consciência potencial ou virtual do ilícito (2): porque a culpa não é "poder de agir de outra maneira", como quer que este se conceba; porque a "consciência" de

---

(1) Uma definição concordante em CARVALHO, Taipa de, II, §§ 927, 938.

(2) Na conclusão, entre nós, também, FARIA, Paula Ribeiro de, *Comentário Conimbricense*, I, art. 137.º, § 22. Contra, a doutrina praticamente unânime na Alemanha, que pode ver-se recenseada em JESCHECK / WEIGEND, § 57, I, 2; estudo especialmente pormenorizado da questão, a esta luz doutrinal, é o de RUDOLPHI, *Unrechtsbewusstsein, Verbotsirrtum und Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums*, 1969, p. 173 e ss.

que aqui se trata não é a consciência intencional, ou consciência psicológica, mas a consciência ética, relativamente à qual seria absurdo tentar aplicar categorias como as da sua "potencialidade" ou "virtualidade"; e porque o critério de desculpabilidade da falta de consciência do ilícito nada tem a ver com uma qualquer "falta do poder de conhecer o ilícito" (cf. supra, 20.º Cap., § 25 e ss., e 23.º Cap.).

§ 3 Dir-se-á porém que, mesmo aceitando no essencial os argumentos apresentados no parágrafo anterior, nem assim se pode iludir a circunstância de que casos haverá em que o autor de um facto negligente não conheceu nem podia conhecer a proibição; e que, nesses casos, o princípio da culpa obriga a que esta se negue relativamente àquele agente, sob pena de outra solução poder vir a dizer-se inconstitucional. Se não poderia então falar-se, em hipóteses tais, de uma *falta de consciência do ilícito* ou de um *erro sobre a ilicitude não censurável*, deveria falar-se ao menos de um **erro sobre a proibição inevitável**, que excluiria a culpa, se por outra via não fosse, por *analogia* com o disposto no art. 17.º-1.

§ 4 Continuamos a crer que toda esta problemática está incorrectamente colocada. Como vimos, o arranque para toda a questão da falta de consciência do ilícito (e admitamos com a doutrina alemã, embora sem conceder, que igualmente para a do "erro sobre a proibição") deriva do *impulso* ou da *advertência* que o agente recebe da representação correcta e integral da factualidade típica para que se ponha e resolva correctamente o problema da ilicitude. Uma tal representação correcta e integral falta, por definição e logo à partida, nas hipóteses de negligência seja inconsciente, seja mesmo consciente; e parece-nos absolutamente insustentável substituir aqui aquela representação pela *possibilidade* de representação ([3]). Pelo que qualquer erro sobre a ilicitude ou mesmo só sobre a proibição não é censurável ou incensurável, desculpável ou indesculpável, evitável ou inevitável: ele é sim, *como tal*, jurídico-penalmente **irrelevante** do ponto de vista da culpa negligente e a sua desconsideração não pode por conseguinte significar qualquer violação do princípio da culpa. Pretender retirar um argumento de "analogia", também na negligência, entre um erro sobre a proibição e uma falta de consciência do ilícito é coisa, do nosso ponto de vista, destituída de sentido.

([3]) Assim, todavia, STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 50.

II. Capacidades pessoais

§ 5 A materialidade do tipo de culpa negligente (o elemento *autónomo* que, com ela, se acrescenta à materialidade do tipo de ilícito respectivo) reside pois na atitude *descuidada* ou *leviana* revelada pelo agente e que fundamenta o seu facto e, por aí, nas qualidades desvaliosas da pessoa que no facto se exprimem. Ora, a questão de saber se o agente se encontrava em condições, segundo os seus conhecimentos e as suas capacidades pessoais, de ter cumprido o dever de cuidado que integra o tipo negligente (ou se encontrava em condições — o que é o mesmo sempre que o delito negligente é um delito de resultado — de representar e evitar ou afastar o resultado) configura por seu turno, exemplarmente, a questão do tipo de culpa negligente. Por outras palavras, o elemento material do tipo de culpa negligente traduz-se justamente em que o agente, para que seja punível por negligência, tem não apenas de violar o cuidado objectivamente imposto, mas ainda de não afastar o perigo ou evitar o resultado apesar de aquele se apresentar como **pessoalmente cognoscível** e este como **pessoalmente evitável**: só nesta medida se pode afirmar que ele documentou no facto qualidades pessoais de descuido ou leviandade pelas quais tem de responder.

§ 6 O único ponto que, da nossa perspectiva, merece neste contexto ser sublinhado é o de que a exigência acima feita não representa o versar aqui na concepção, por nós tão vivamente repudiada, da **culpa como "capacidade de motivação pela norma"**, como "poder de agir de outra maneira", ligada — quanto a nós inextricavelmente, mesmo quando se não deseje admiti-lo — à questão do livre-arbítrio ou da liberdade da vontade em situação. E em nosso favor podemos invocar agora o testemunho insuspeito de Stratenwerth, quando afirma que as "exigências adicionais" feitas em sede de culpa negligente "*não* respeitam imediatamente à liberdade de se determinar pelo juridicamente devido" (4).

§ 7 Já em 1930 Engisch explicou — de forma cabal e até hoje não convincentemente contraditada — porquê. É que, para que a culpa negligente se afirme, não é necessário (nem possível) apelar ao concreto *poder* do agente de actuar de outro modo na situação. Do que ali se trata é

(4) STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 46.

apenas da conclusão de que, de acordo com a experiência, *os outros, agindo em condições e sob pressupostos fundamentalmente iguais àqueles que presidiram à conduta do agente*, teriam *previsto* a possibilidade de realização do tipo de ilícito e tê-la-iam *evitado*. O que significa apenas, por outras palavras, que o conhecimento real das consequências de uma acção e a capacidade de as evitar correspondem à experiência normal e que portanto, relativamente ao agente concreto que as não representou ou evitou, se comprova uma deficiência perante o tipo normal. Só que este tipo — e aqui deparamos com o famoso "critério subjectivo" — não é o tipo "médio", mas **o tipo de homem da espécie e com as qualidades e capacidades do agente**. A distinção "prática" entre critério objectivo e subjectivo está só em que, neste, a figura-padrão é formada não segundo classes mais ou menos gerais e padronizadas como as que foram referidas em sede de tipo de ilícito, mas de acordo com os conhecimentos e as capacidades pessoais dos homens **como o agente**. Também segundo o critério "subjectivo", porém, a medida do poder do agente é a que, segundo a experiência, caracteriza o seu tipo de homem, pondo afinal em questão não o poder real e concreto do agente em situação, mas o "poder dos outros *como* o agente" (5).

§ 8 De tudo isto se conclui, por um lado, que não é de modo algum contraditório com a nossa concepção geral sobre a culpa fazer apelo, na culpa negligente, ao critério dito "subjectivo"; por outro lado, que um tal critério é eminentemente estranho à querela sobre o livre-arbítrio e a liberdade da vontade em situação; por outro ainda, que o problema que em tudo isto vai implicado é **o problema nuclear da culpa material negligente**, pelo que, de um ponto de vista sistemático, será menos adequado conceber a incapacidade individual como mais uma causa da exclusão da culpa negligente, ao lado da inimputabilidade ou da inexigibilidade (6), antes se devendo ver nela a materialidade por excelência que integra o tipo de culpa negligente.

---

(5) ENGISCH, *Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit*, 1930. p. 410 e ss.; e, na sua esteira, os nossos *O Problema*, p. 252, e *Liberdade*, p. 249 e ss., todavia com uma *restrição* à capacidade de representar ou conhecer — e já não à de evitar — que, em verdade, parece injustificada. Restrição, fique anotado, que já Jescheck nos havia criticado — hoje, como acabamos de dizer, pensamos que com razão — nas provas públicas do concurso que prestámos (1977) para professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

(6) Assim, todavia, ROXIN I, § 24, n.º 114 e ss.

§ 9 Nem de outra forma poderia compreender-se uma opinião largamente difundida na doutrina germânica, assim referida por Roxin: "só existem 'limites à individualização' [Burgstaller] na medida em que os defeitos do carácter [nós diríamos: as qualidades juridicamente desvaliosas da personalidade] não excluem a culpa. O agente não pode invocar portanto, para fundamentar a sua incapacidade individual que ele é uma pessoa desconsiderada, indolente, temerária ou superficial. Quanto ao resto, porém, haverão de ter-se em conta no exame da capacidade subjectiva de conhecer e de evitar 'a inteligência, a formação e o conhecimento da experiência, assim como o sexo, a idade e todas as demais condições físicas do agente', também, p. ex., o seu esgotamento ou a sua excitação especial no momento do facto" (7). Aqui vemos nós uma confirmação integral da forma como pensamos a materialidade da culpa também na negligência e a necessidade de ainda aí distinguir qualidades pessoais juridicamente relevantes e irrelevantes que se exprimem no facto e o fundamentam (cf. a seguir).

§ 10 São, deste modo, insusceptíveis de fundar a materialidade da culpa negligente — por **impossibilidade pessoal de perceber ou de cumprir o dever de cuidado** — *defeitos corporais, faltas de inteligência, de saber, de experiência ou de sensibilidade* (8). Em nenhum caso destes está presente uma qualidade juridicamente desvaliosa da pessoa e não pode, por isso, ver-se como fundamento do facto uma atitude de descuido ou de leviandade perante o Direito e os seus comandos. Casos como o do automobilista que causa um desastre por ter sido acometido ao volante de um enfarte que nada fazia prever; ou do aluno da escola de condução que por falta de experiência não consegue prever o risco para a condução derivado da sua conduta (ressalvada a eventual responsabilidade do instrutor); ou do condutor experiente mas incapaz de se aperceber que, por doença progressiva ou por idade, está perdendo as suas faculdades para a condução ou é já incapaz de dominar situações rodoviárias de grande dificuldade — são só alguns exemplos das situações aqui em causa.

§ 11 Do anteriormente exposto devem todavia ressalvar-se os casos de **culpa na assunção ou na aceitação** (sobre a sua relevância logo ao nível do tipo de ilícito v. supra, 27.º Cap., § 25 e ss.). A única questão difícil que aqui poderá suscitar-se é a de saber como devem tratar-se os casos em que o agente não possui a capacidade de compreensão necessária para, pelo menos, formar um juízo sobre a insuficiência da sua própria capacidade. A doutrina alemã defende, com razão, ser indispensável que o agente

(7) ROXIN I, § 24, n.º 121.

(8) Exactamente, nestes termos, JESCHECK / WEIGEND, § 57, II, 2.

possa aperceber-se de que se não encontra em condições de cumprir as exigências jurídicas correspondentes à actividade por ele assumida (9). Sem que para tanto seja necessário versar numa "culpa na condução da vida", mas reportando a censura ao momento em que se inicia a actividade perigosa (10).

§ 12 Essencialmente a mesma posição deve ser assumida relativamente — nos delitos de resultado — à **incapacidade pessoal de prever o resultado e o processo causal essencial**. Não sendo despiciendo assinalar que este problema apenas se suscita em rigor nos casos de *negligência inconsciente*, não nos de negligência consciente em que uma tal previsão, tal como nos delitos dolosos, foi por definição alcançada mas o agente actuou não se conformando com a realização típica (art. 15.º/*a) in fine* e supra, 13.º Cap., § 44 e ss.) (11). Assim, p. ex., o caso da testemunha que, por força da sua diminuta capacidade intelectual ou por ser acometida de um incontrolável nervosismo na sala de audiência, não é capaz de se aperceber que dos termos do seu depoimento, conscientemente falso, pode resultar que em vez do arguido seja condenada outra pessoa pelo crime que aquele praticou (arts. 361.º-1/*c)* e 18.º).

III. Exigibilidade

§ 13 Relativamente às situações de inexigibilidade como causas de exclusão da culpa haverá, em matéria de factos negligentes, algumas considerações a apontar face ao que sucede nos factos dolosos. Tal como nestes, também a inexigibilidade na negligência **não pode configurar-se como uma causa geral de exclusão da culpa**, mas tem de precipitar-se nas cláusulas específicas de desculpa reconhecidas pela lei, eventualmente alargadas através de argumentos de analogia. Sendo embora assim, repete-se, algumas especialidades devem ser evidenciadas.

§ 14 Por um lado — atento o menor grau de ilicitude material revelado pelo facto negligente por referência ao facto doloso correspondente e, logo por aí, as suas menores dignidade penal e carência de pena —, bem se compreende que o âmbito de actuação da inexigibilidade possa, em

(9) BURGSTALLER, *WK*, § 6, n.º 106, JESCHECK / WEIGEND, § 57, II 3, STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 23 e s.

(10) Assim, com razão, ROXIN I, § 24, n.º 113.

(11) Assim, JESCHECK / WEIGEND, § 57, III, 2.

princípio, ser na negligência **mais lato** que no dolo; que, por conseguinte, as situações de conflito que estão na base da inexigibilidade possam conduzir à desculpa do facto negligente em casos em que esta desculpa não seria aceitável relativamente ao facto doloso ([12]). O que vem de dizer-se vale em princípio tanto para o **excesso de legítima defesa desculpante** (art. 33.º-2), como para o **estado de necessidade** ou o **conflito de deveres desculpantes** (art. 35.º-1).

IV. O problema da "negligência grosseira" ([13])

§ 15 Já atrás deixámos assinalado que, por vezes, o nosso CP **qualifica** a negligência, considerando-a grosseira e punindo-a mais severamente (*v. g.*, arts. 137.º, 369.º-5) ou punindo exclusivamente esta espécie de negligência (*v. g.*, art. 156.º-3).

§ 16 Do ponto de vista **político-criminal** esta decisão do legislador é irrestritamente de aplaudir, perante a intensificação e mesmo a massificação das condutas negligentes, de efeitos gravíssimos, na sociedade actual e certamente, de forma aumentada, na sociedade futura. Não é porém seguro o que deva, em perspectiva **dogmática**, entender-se por negligência grosseira; nem tão-pouco se dispõe já de uma jurisprudência suficientemente precisa e consolidada para que possam dissipar-se as dúvidas ([14]). Nem, ainda por outro lado, representa um auxílio significativo a circunstância de o conceito ser de há muito conhecido da doutrina jurídico-civilista: de uma parte, porque também ali se não logrou até hoje uma definição conceitual precisa, antes parecendo que o conceito tem perdido progressivamente interesse naquela doutrina, onde chega a ser desvalorizado como mera manifestação de "distinções de sabor escolástico" (!) ([15]); e, de outra parte, porque as exigências jurídico-penais dirigidas ao conteúdo material do ilícito e da culpa na negligência não têm correspondência, nem sequer paralelo exacto, no âmbito do direito civil.

([12]) Assim, STRATENWERTH / KUHLEN, § 15, n.º 51 e s.

([13]) No essencial como se segue, DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, art. 137.º, §§ 16-18. E, agora, SANTANA, Selma de, A negligência grosseira: contributo para discussão sobre sua autonomia material, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 571.

([14]) Cf. em todo o caso, por exemplo, as indicações jurisprudenciais fornecidas por GONÇALVES, Maia, *CP*, art. 15.º, anotação 5, e art. 137.º, anotação 5, e SILVA, Marques da, II, p. 182.

([15]) Assim, VARELA, Antunes, *Das Obrigações em Geral*, I, ^1989, p. 546.

§ 17 Seguro é que a negligência grosseira constitui, em direito penal, um **grau essencialmente aumentado ou intensificado** de negligência. Para além disto, porém, é importante tanto de um ponto de vista prático-normativo, como construtivo-sistemático, decidir se o carácter grosseiro da negligência — conformador, sem dúvida, de uma realidade análoga àquela (quando não com ela coincidente) que a doutrina alemã traduz por *Leichtfertigkeit* — constitui exclusivamente uma forma qualificada da **culpa** negligente ([16]) (nomeadamente, uma **característica da atitude** do agente que operaria preferentemente ao nível da culpa ([17])) ou uma **graduação do ilícito** em função do especial dever de cuidado que concretamente sobre o agente recai, do perigo aumentado e (ou) da probabilidade e da especial frequência de verificação do resultado ([18]).

§ 18 A razão assiste — entre outros — a Roxin quando defende que o conceito implica uma especial intensificação da negligência **não só** ao nível da culpa, **mas também** do ilícito ([19]). A nível do **tipo de ilícito** torna-se indispensável que se esteja perante um comportamento *particularmente perigoso* e um *resultado de verificação altamente provável* à luz da conduta adoptada ([20]). Mas daqui não pode concluir-se sem mais que também o **tipo de culpa** resulta, nestes casos, inevitavelmente aumentado, antes tem de alcançar-se a prova autónoma de que o agente revelou no facto uma *atitude particularmente censurável de leviandade ou descuido* perante o comando jurídico-penal ([21]), plasmando nele qualidades particularmente censuráveis de irresponsabilidade e insensatez.

([16]) Assim, MAURACH, Probleme der erfolgsqualifizierten Delikten..., *Heinitz-FS*, 1972, pp. 414 e ss., e, entre nós, GONÇALVES, Maia, art. 137.º, anotação 3.

([17]) Cf. MAIWALD, Der Begriff der Leichtfertigkeit als Merkmal erfolgsqualifizierter Delikte, *GA*, 1974, pp. 262 e 269.

([18]) Assim, TENCKHOFF, Die leichtfertige Herbeiführung qualifizierter Tatfolgen, *ZStW 88*, 1976, p. 911; cf., depois, VOLK, Reformüberlegungen zur Strafbarkeit der fahrlässigen Körperverletzung im Strassenverkehr, *GA*, 1976, p. 178 e s., e WEGSCHEIDER, Zum Begriff der Leichtfertigkeit, *ZStW 98*, 1986, p. 624 e ss.

([19]) ROXIN I, § 24, n.º 87.

([20]) De algum modo, neste sentido, o Ac. do STJ de 19-5-1994, cit. por GONÇALVES, Maia, art. 137.º, anotação 5; e agora, louvando-se expressamente na nossa posição, o Ac. da RC de 22-1-2004 (Proc. 3840/03, www.dgsi.pt).

([21]) De forma próxima, o Ac. da RE de 19-11-1991, *CJ*, XVI-5, p. 260.

TÍTULO IV

OS CRIMES DE OMISSÃO

37.º CAPÍTULO

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

I. A omissão como forma específica de realização típica

§ 1 Quando tratámos as formas básicas de realização típica logo referimos (supra, 10.º Cap., § 42 e ss.) que o tipo tanto pode ser realizado através da prática de uma acção proibida, como através da **omissão** de um comportamento juridicamente exigido. A omissão é pois, ao lado da acção, uma das formas específicas de realização típica. Por esta razão, tal como anotámos relativamente ao delito negligente (supra, 34.º Cap., § 1), também aqui parece insuficiente e inadequado tratar a omissão como "forma especial de aparecimento do facto punível" (1). Estudado já o crime doloso e o crime negligente de acção, importa agora considerar o crime de omissão tanto na forma dolosa, como negligente.

§ 2 Que as duas entidades — a "acção" e a "omissão" — se revelam **estruturalmente diversas**, logo resulta de que, nos crimes ora em apreço, o agente **não** levou a cabo a acção esperada ou imposta. Por essa razão, numa perspectiva realista — naturalista, ontológica, fenomenológica, empírica... — não pode falar-se, relativamente à omissão, nem de causalidade, nem de dolo, nem de decisão de praticar o ilícito, nem de outras entidades conceituais que constituem a base de trabalho da doutrina do

---

(1) Assim, todavia, JESCHECK / WEIGEND, antes do § 58. No sentido do texto, por último, D'AVILA, Fabio, *Ofensividade e Crimes Omissivos Próprios (Contributo à Compreensão do Crime como Ofensa ao Bem Jurídico)*, 2003, p. 215 e ss.

facto doloso. Neste sentido vale na verdade para a omissão o princípio da inversão (*Umkehrschluss*), na base do qual Armin Kaufmann pretendeu construir toda a dogmática da omissão (2): comportando-se acção e omissão como A e não-A, a construção dogmática desta última tem de partir da ausência (falta) de acção, de causalidade, de dolo, de decisão de cometer o ilícito, etc. Não se estranhará por isso que os princípios da imputação da omissão tanto objectivos, como subjectivos, possam apresentar especialidades importantes face aos que foram expostos a respeito dos crimes de acção. Especialidades acompanhadas de maiores dificuldades e de maiores dúvidas porque a dogmática jurídico-penal se tem ocupado principalmente (e continua prevalentemente a ocupar-se) dos crimes de acção.

§ 3 Face às posições que temos vindo a assumir em matéria de metodologia e de construção — teleológica e funcional-racional — do sistema do facto punível, também a distinção entre acção e omissão não deve assentar naquilo que chamámos a sua diversidade (ôntica) estrutural, sem todavia a esquecer ou contrariar, mas tem de ser comandada por **valorações político-criminais** (3) e de ganhar por conseguinte natureza **normativa** e, na verdade, **tipicamente** condicionada. Neste plano é perfeitamente possível encontrar um largo denominador comum entre o relevo jurídico-penal da acção e da omissão. Se — para utilizarmos um exemplo de escola muito simples — a mãe decide dar a morte ao seu filho bebé deixando completamente de o alimentar, pode perfeitamente falar-se da (e comprovar-se em tribunal a) criação de um risco não permitido que se concretiza no resultado, da representação e vontade da realização de um homicídio, da decisão de violação do bem jurídico, etc. Só que — perante a proposição político-criminal de equiparação em certos termos da omissão à acção — a construção da omissão não se reporta, do ponto de vista jurídico-penal, à *in*actividade da mãe, mas é função da **acção juridicamente esperada e devida**, no caso, a alimentação do seu filho. É esta refe-

---

(2) KAUFMANN, Armin, *Die Dogmatik der unechten Unterlassungsdelikte*, 1959, p. 87 e ss., logo acompanhado por WELZEL, § 26 II 3. Cf., de algum modo, entre nós, BRITO, Sousa e, *Estudos para a Dogmática do Crime Omissivo*, 1966, *passim*; mas cf. p. 16: "nem só as realidades positivas são condições relevantes".

(3) Assim, também, ROXIN II, § 31, n.º 2. De um "real construído" fala, a propósito — neste sentido, com razão —, COSTA, Faria, Omissão (Reflexões a propósito da omissão imprópria), *BFD 72*, 1996, p. 392.

rência normativa que constitui a omissão em entidade jurídico-penalmente relevante; e também ela obriga à reconformação de muitos dos conceitos fundamentais da doutrina geral do facto punível.

§ 4 Talvez não seja desinteressante deixar aqui uma brevíssima e incompleta nótula sobre a **história do delito de omissão** no direito português (4). A relevância jurídico-penal da omissão acompanhou desde os primórdios o direito penal português (todavia sob a forma daquilo que chamaríamos hoje de omissões *puras* ou *próprias*: infra, § 12 e ss.). Logo no direito penal **costumeiro** abundavam disposições de carácter preceptivo, que impunham o cumprimento de numerosos deveres de carácter jurídico e moral. A omissão desempenhou, de resto, um papel importante no fenómeno medieval da publicização do direito penal, por via das modalidades de que podia revestir-se o *bannum*: uma infracção que — constituindo, em certo sentido, uma reacção contra as antigas formas de autodefesa, em especial da vingança privada — punia, em geral, o incumprimento pelos acusados de medidas decretadas pela autoridade competente em matéria de aplicação do direito. Durante o período de vigência das "**Ordenações**" o delito de omissão — enquadrado, conjuntamente com o delito de acção, na categoria mais vasta do *facto criminoso* (*delictum, maleficium*) (5) —, conservou a sua autonomia dogmática (6). Mas a esta não correspondeu um aumento da sua importância prática, mesmo quando se entrou no período da codificação moderna (7): quer por força de uma pesada tradição jusnaturalista, que reduzia o crime ao domínio dos "delitos naturais", quer sobretudo por força da mundividência liberal e individualista então imperante. Só nos princípios do **séc. XIX** começa a esboçar-se entre nós uma alteração relativa das concepções e da prática judiciária dominantes. Mas foi necessário esperar pelos anos 30 do **séc. XX** para que a doutrina portuguesa — através sobretudo da lição de Beleza dos Santos e, mais tarde, de Marcello Caetano (8) — se pusesse a par da dogmática jurídico-penal da omissão já então dominante em alguns sistemas europeus.

---

(4) Sobre o que segue, cf. DIAS, Figueiredo, Les délits d'omission dans le droit pénal portugais (com a colaboração de A. M. Almeida Costa), *RintDP 55*, 1984, p. 845 e ss. Cf., agora, LEITE, André, *As Posições de Garantia na Omissão Impura. Em Especial, a Questão da Determinabilidade Penal*, 2007, p. 27 e ss.) e Notas sobre os crimes omissivos no contexto do direito penal das Ordenações, *RFDUP*, 2006, pp. 77, 104 e ss.

(5) V., p. ex., Ordenações Filipinas, l. V, títs. 12, 6e, 13, 5e e 62, 4e; e o decreto de 23-9-1701 que, referindo-se ao conceito de acto criminoso, declarava, numa acepção que parecia abranger já tanto a omissão pura, como a impura: "tão mal é fazer o que se não deve como não fazer o que se deve".

(6) Cf. FREIRE, Mello, *Institutiones Juris Criminalis Lusitani*, 1815 (trad. portuguesa de Francisco J. Veloso, *BMJ 155*, 1966, p. 56), e SOUSA, Pereira e, *Classes dos Crimes*, 1803, p. 3[4].

(7) Cf., à luz do CP de 1852, JORDÃO, I, 1853, p. 5 e s., FERRÃO, I, 1856, pp. XIV e s. e 21 e ss., e PINTO, Sousa, p. 47 e s.; e mesmo já à luz do CP de 1886, SILVA, Henriques da, p. 405.

(8) SANTOS, Beleza dos, *Lições*, p. 225 e ss., e *Direito Criminal* (lições coligidas por Hernâni Marques), 1936, p. 288 e ss., CAETANO, Marcello, p. 213.

§ 5 No direito penal actual continua a ser, tanto na lei como na vida, muito maior o número de acções do que de omissões jurídico-penalmente relevantes. Mas, como bem se compreende (supra, 6.º Cap., § 42 e ss.), o número de omissões jurídico-penalmente relevantes terá tendência para **aumentar, em número e em significado, no seio da "sociedade do risco"** (9). Sem dever todavia esquecer-se que uma punição generalizada ou demasiado alargada da omissão conduzirá seguramente a uma sistemática, inadmissível e insuportável intromissão — tanto mais insuportável quanto maior for, precisamente, a complexidade social — de cada um na esfera jurídica dos outros, para assim não incorrerem na possibilidade de serem jurídico-penalmente responsabilizados por omissões (10).

II. A distinção entre acção e omissão

§ 6 A partir do que fica dito, a **delimitação** entre acção e omissão, entre comportamentos activos e omissivos, não levantará em regra, logo segundo a "*compreensão natural das coisas*" (11), dificuldades de maior: é seguramente um comportamento activo o da mãe que mata o seu bebé administrando-lhe no leite um veneno letal, omissivo o daquela que lhe determina a morte por ter deixado de o alimentar. Discutíveis e discutidos são porém os casos de crimes (*de resultado*) que a doutrina designa de **ambivalentes**, de **dupla relevância** ou de **duplo significado**, em que, à partida, é relevante tanto uma acção, como uma omissão (nomeadamente, a omissão de um comportamento imposto para afastar um resultado típico).

§ 7 **Exemplos** de casos desta ordem são inúmeros, e alguns de todos os dias (12). Se o automobilista ultrapassa um ciclista não guardando a devida distância de ultra-

---

(9) Assim, DIAS, Figueiredo, O direito penal entre a "sociedade industrial" e a "sociedade do risco", *Estudos Rogério Soares*, p. 590.

(10) Esta parece ser a exacta consideração político-criminal que dá base última às considerações críticas sobre a omissão imprópria de CUNHA, Damião da, Algumas reflexões críticas sobre os crimes impróprios de omissão no sistema penal português, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 481 e ss. No sentido do texto, FARIA, Paula Ribeiro de, *A Adequação Social da Conduta no Direito Penal ou o Valor dos Sentidos Sociais na Interpretação da Lei Penal*, 2005, p. 1122 e s.; cf., também, LEITE, André, nota 4, pp. 13 e ss., 117 e ss.

(11) Expressão de JESCHECK / WEIGEND, § 58 II 2.

(12) Com uma rica e instrutiva casuística depara-se em ENGISCH, Tun und Unterlassung, *Gallas-FS*, 1973, p. 169 e ss.; cf., agora, também, ROXIN II, § 31, n.º 74. Algumas das hipóteses que se seguem correspondem — ao menos de forma aproximada — a casos reais apreciados e decididos pela jurisprudência alemã.

passagem e o atropela, ele produz o acidente por acção (porque embate o ciclista com o automóvel) ou por omissão (por não ter guardado a distância devida)? Se outro automobilista, numa situação rodoviária inesperada, atinge um peão por ter interrompido demasiado cedo a travagem, produz o acidente por acção (porque embate o peão com o automóvel) ou por omissão (por não ter continuado ou acentuado a travagem)? Se o patrão entrega a empregados seus, para serem por estes manipuladas, substâncias que devia ter submetido — e não submeteu — a um processo prévio de desinfecção, contraindo por isso alguns empregados uma doença, as ofensas à integridade física devem ser-lhe imputadas por acção (pela entrega para manipulação das substâncias infectadas) ou por omissão (por não as ter submetido a desinfecção prévia)? Se um farmacêutico avia pela segunda vez uma receita à mãe de uma criança, a rogo desta, receita que se destinava a uma única toma, a morte da criança deve ser-lhe imputada por acção (a entrega da segunda dose de medicamento) ou por omissão (de obediência devida à receita médica)? Se o médico da unidade de reanimação interrompe o funcionamento da máquina de respiração assistida à qual está ligado um moribundo e lhe apressa assim a morte, o seu comportamento analisa-se numa acção (o accionar o interruptor ou o desentubar do paciente) ou numa omissão (o deixar de prestar os cuidados de saúde a que estava obrigado)? E, neste exemplo, será a mesma a situação — quanto à classificação do comportamento como activo ou omissivo — se a interrupção do funcionamento da máquina for operada não pelo médico aos cuidados do qual o doente estava entregue, mas por um terceiro, *v. g.*, um parente, que deseja pôr fim ao sofrimento do paciente ou tem pressa de lhe herdar os bens ([13])?

§ 8 Segundo a doutrina germânica ainda hoje porventura mais difundida, se bem que com inúmeras variantes, a distinção entre acção e omissão dependerá, nas referidas hipóteses de comportamentos duplamente relevantes, de no caso se poder comprovar (*acção*) ou não (*omissão*) uma **introdução positiva de energia**, por parte do agente, (causalmente) determinante da produção do resultado típico ([14]). Mas este critério, tomado como fronteira única de delimitação, pode tornar-se presa da crítica de que pretende ainda lograr a distinção num plano natural ou ôntico-fenomenológico, de todo o modo pré-jurídico e estranho a qualquer valoração político-criminal e normativa. Por isso outros autores, acompanhados pela jurisprudência suprema alemã e assumindo uma clara postura valorativa do *sentido social* do comportamento, pretendem lograr a distinção consoante o **ponto de conexão da censurabilidade jurídico-penal** se encontra num

([13]) Exemplo também referido em DIAS, Figueiredo, *Comentário Conimbricense*, I, 1999, art. 131.º, § 23.

([14]) Assim, ENGISCH, nota 12, p. 171 e ss., JESCHECK / WEIGEND, § 58, II, e agora, no essencial, também, ROXIN II, § 31, n.º 73 e ss. Criticamente, D'AVILA, Fabio, nota 1, p. 220 e ss.

comportamento activo, ou antes omissivo ([15]). Em princípio esta orientação merece preferência perante a anterior, na medida em que acentua correctamente a natureza valorativa e normativa da solução a encontrar. Mas não é fácil nem seguro perceber que "censurabilidade" é aquela que está na mente dos propugnadores desta solução, versando ela, em definitivo, no vício do *quod erat demonstrandum* ([16]) ou num apelo ao puro "sentimento jurídico" ([17]). Por último, assinalam outros autores ainda que a distinção, ao menos nos casos irremediavelmente duvidosos, deve ser levada a cabo com atenção a um **princípio de subsidiariedade** ([18]), segundo o qual uma omissão só deve ter-se por relevante quando de todo em todo o comportamento não puder ser perspectivado como uma acção. Princípio que pode porventura ser exacto e aplicável a certos títulos nesta matéria (máxime, tendo em conta a maior certeza conceptual que cabe à acção), mas que não parece susceptível de ser erigido em princípio geral de *distinção* — uma vez mais o acentuamos: típico-normativa — entre acção e omissão.

§ 9 Tratando-se em toda esta matéria de uma questão do ilícito-típico e, mais concretamente, de imputação objectiva, exacto parece ser que o critério decisivo da delimitação não deve ser senão um **critério de ilicitude típica** e de **imputação objectiva** (ou, de forma que cremos menos perfeita ([19]), de **causalidade**); exactamente, como Stratenwerth defende, o da **forma de criação do perigo** para bens jurídicos tutelados pela norma: ao agente deve ser imputada uma *acção* sempre que ele criou (ou aumentou) o perigo que vem a concretizar-se no resultado; uma *omissão* sempre que

---

([15]) S / S / STREE, n.º 158 antes do § 13. Toda esta orientação parece reportar-se a MEZGER, *Stb*, p. 74. A seu favor quanto ao "ponto de partida", por último, D'AVILA, Fabio, nota 1, p. 231 e ss.

([16]) Em sentido análogo, afirma ROXIN II, § 31, n.º 79, que a doutrina em análise incorre num "círculo vicioso": não pode determinar-se o ponto de conexão da censurabilidade sem previamente se ter determinado se estamos perante uma acção ou uma omissão.

([17]) Assim, JESCHECK / WEIGEND, § 58, II, 3.

([18]) Acentuou-o, sobretudo, KAUFMANN, Arthur, Die Bedeutung hypothetischer Erfolgsursachen im Strafrecht, *Eb. Schmidt-FS*, 1961, p. 212.

([19]) Cf., todavia, JESCHECK /WEIGEND, § 58, II, 2, e ROXIN II, § 31, n.º 78 e ss.

([20]) STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 3 e s. Fundamentalmente no mesmo sentido, SAMSON, Begehung und Unterlassung, *Welzel-FS*, 1974, p. 582 e ss., DIAS, Figueiredo, Pressupostos da punição e causas que excluem a ilicitude e a culpa, *JDC 1963*, p. 54, e FARIA, Paula Ribeiro de, nota 10, p. 1027 e s. [1596]. Acentua esta A. que "não se anda assim muito longe da indagação do 'ponto crucial da censura'"; o que é exacto se esta for uma "censura" dirigida ao ilícito-típico e não à culpa. Completamente no sentido do texto, LEITE, André, nota 4, p. 38 e s.

ele não diminuiu aquele perigo (20). E sem que por ser assim tenha de aceitar-se a procedência definitiva da dúvida de Damião da Cunha, de saber se os crimes (de resultado) de omissão não são afinal mera sobrevivência de um estádio dogmático em que não era ainda estudada e conhecida como hoje a dogmática dos crimes de perigo (21). Como quer que deva responder-se a esta dúvida, e sem prejuízo de as regras de imputação objectiva serem substancialmente as mesmas nos crimes de dano e de perigo (supra, 12.º Cap., § 42 e s.) e ainda de os crimes de omissão poderem ser considerados como "delitos de dever", não haverá em tudo isto razão bastante para se ir substituindo progressivamente a dogmática dos delitos de *dano* de omissão pela dos delitos de *perigo* de acção.

§ 10 Entrando em conta com os critérios antes expostos, mas sempre subordinados à também aludida matriz da ilicitude típica, os casos mais difíceis parecem susceptíveis de resolução adequada. Casos que Roxin se propõe submeter ao denominador comum da categoria, por si defendida, da **omissão através de acção** (22) e em que, por razões instantes de natureza normativa, o acima mencionado princípio de subsidiariedade da omissão como que seria substituído pelo seu inverso, *punindo-se uma acção como omissão*. Pois — argumenta Roxin — "é perfeitamente possível submeter uma acção a um tipo omissivo quando tal é imposto por razões normativas. A acção permanece acção, mas nestes casos ela é punida dentro de um tipo omissivo. Nem se trata também de, com isto, abrir de novo a porta à fórmula do 'ponto principal de conexão' [supra, § 6] ou à delimitação segundo o 'sentido social' [supra, *ibidem*]. Trata-se antes de constelações rigorosamente identificadas que por razões determinadas devem ser tratadas segundo as regras da omissão" (23). Essas "constelações" — muitas delas já identificadas por v. Overbeck — seriam a da *comparticipação activa em delito omissivo* (ex.: *A* aconselha *B* a deixar de prestar o auxílio necessário, nos termos do art. 200.º), a da *omissio libera in causa* (ex.: um nadador salvador embriaga-se até à inconsciência para

(21) É esta, se bem pensamos, a ideia de fundo que preside às considerações deste A., nomeadamente a propósito (da inutilidade de princípio, face à doutrina tradicional da omissão) do crime de exposição ou abandono do art. 138.º: CUNHA, Damião da, nota 10, pp. 481 e ss., 508 e ss. e 529 e ss. Cf., também, em geral e em certa medida, FARIA, Paula Ribeiro de, nota 10, p. 1114 e ss.

(22) ROXIN, An der Grenze von Begehung und Unterlassung, *Engisch-FS*, 1969, p. 380 (existe tradução portuguesa na colectânea *Problemas Fundamentais do Direito Penal*, ³1998, p. 169).

(23) ROXIN II, § 31, n.º 100.

tornar impossível acorrer a uma situação de necessidade a que venha a ser chamado), a da *tentativa interrompida de cumprimento de uma imposição legal* (ex.: o pai de uma criança que está em risco de se afogar vai buscar um bote para tentar salvá-la, mas ao chegar com o bote à praia interrompe os seus esforços, podendo tê-los continuado, e a criança afoga-se) e a da *interrupção técnica de um tratamento* (ex.: um médico ou um terceiro desligam a máquina de respiração assistida a que está ligado um moribundo em situação irreversível) ([24]).

§ 11 As duas primeiras constelações não parece suscitarem problemas especiais à sua consideração, logo à partida, como casos de *omissão*, segundo a orientação que acima preconizámos: em qualquer deles o agente não diminuiu um perigo que, independentemente dele, afectava um bem jurídico, apesar de, no plano ôntico-fenomenológico, o seu comportamento incluir eventualmente actos de "introdução positiva de energia". Restam os casos, efectivamente mais complexos, de **interrupção de um processo de salvação em curso de um bem jurídico ameaçado**. Aqui tem razão Roxin quando — contra Samson ([25]) — afirma que se o processo salvador ainda não atingiu a esfera da vítima (no caso exposto, se o bote ainda está na praia e aí fica) o caso deve ser tratado nos quadros da omissão, não da acção; por, além do mais, não existirem razões político-criminais e teleológicas a justificarem que a situação jurídico-penal de quem interrompe, contra o dever, um processo causal salvador seja pior (*acção*) do que a daquele que, *ab initio*, decide, contra o dever, não intervir na situação (*omissão*). Por último, na hipótese especial de interrupção do processo de reanimação, parece-nos seguro que o comportamento do médico é omissivo, porque a continuação do "processo salvador" — apesar de este ter já entrado na esfera da vítima — não podia diminuir o perigo que atingia o moribundo; mas já será activo o desligamento por parte do não-médico, porque aí o caso não pode ser perspectivado a partir de um dever de tratamento que pessoalmente obrigasse o agente e tenha sido violado por este ([26]). Que, para abarcar todas estas hipóteses, haja necessidade de se autonomizar

([24]) ROXIN II, § 31, n.os 99-123.

([25]) SAMSON, Begehung und Unterlassung, *Welzel-FS*, 1974, p. 601. Cf., depois, STRATENWERTH /KUHLEN, § 13, n.º 3.

([26]) Ficando sem consideração saber se e em que casos deve o agente, em definitivo, ser *punido*, uma vez que neste contexto se trata apenas de determinar se estamos perante uma acção ou uma omissão.

uma categoria da "omissão por acção" é coisa de que pode duvidar-se, atenta sobremodo a multiplicidade de razões político-criminais, teleológicas e normativas por que, em casos tais, deve fazer-se prevalecer o tratamento jurídico-penal como omissão, antes que como acção ([27]).

III. A distinção entre crimes puros (ou próprios) e impuros (ou impróprios) de omissão

§ 12 O crime de omissão reside na *violação de uma imposição legal de actuar*, pelo que, em qualquer caso, só pode ser cometido por pessoa sobre a qual recaia um **dever jurídico** de levar a cabo a acção imposta e esperada. Por isso, de resto, ganha a questão de determinar o círculo dos **autores possíveis** de um crime de omissão uma enorme importância não só teórica, mas prático-normativa. Tanto mais quanto a lei só numa minoria de casos descreve, de forma integral, os *pressupostos fácticos* donde resulta o dever jurídico de actuar; enquanto na generalidade deles se basta com uma *cláusula geral*, assim expressa no art. 10.º-2: "quando sobre o omitente recaia um dever jurídico que pessoalmente o obrigue a evitar [um certo] resultado" ([28]).

§ 13 É precisamente na diferença acabada de referir que uma parte da doutrina vai buscar o fundamento para a distinção — *fundamental* a muitos títulos, como em seguida se verá — entre crimes de omissão puros ou próprios e impuros ou impróprios (ou "comissivas por omissão"). Crimes *puros* ou *próprios* de omissão seriam aqueles em que **a PE referencia (expressamente) a omissão como forma de integração típica**, descrevendo os pressupostos fácticos donde deriva o dever jurídico de actuar ou, em todo o caso, referindo aquele dever e tornando o agente garante do seu cumprimento. Diversamente, delitos *impuros* ou *impróprios* de omissão seriam os não especificamente descritos na lei como tais, mas em que

---

([27]) No sentido desta conclusão, LEITE, André, nota 4, p. 40 e ss. Por último sobre a questão, considerando em certas hipóteses a interrupção do processo salvador como uma terceira forma de realização típica que se distingue tanto da acção como da omissão impura, GIMBERNAT Ordeig, Eine dritte Form der Tatbestandsverwirklichung: die Unterbrechung von rettenden Kausalverläufen, *in*: Hefendehl (org.), *Empirische und dogmatische Fundamente, kriminalpolitischer Impetus, Schünemann-Symposium*, 2005, p. 163.

([28]) Cf. BRITO, Teresa Quintela de, *A Tentativa nos Crimes Comissivos por Omissão: Um Problema de Delimitação da Conduta Típica*, 2000, p. 265: "(...) o art. 10.º, n.º 2, (...) apenas pretende definir genericamente os possíveis autores de um crime comissivo por omissão".

a tipicidade resultaria de uma cláusula geral de **equiparação da omissão à acção,** como tal legalmente prevista e punível na PG (art. 10.º-1 e 2) (29).

§ 14 Com esta doutrina porém, critica Roxin, encobre-se aquilo que verdadeiramente confere sentido à distinção entre omissões puras e impuras: *puras* são aquelas omissões típicas que **não têm correspondência num delito de acção**, por outras palavras, aquelas relativamente às quais o delito correspondente de acção **não existe**; *impuras* aquelas outras para cuja tipicidade se torna necessária uma cláusula de **equiparação à acção** correspondente, sem que importe que esta cláusula seja implícita ou explícita, que ela tenha lugar na PG ou na PE a propósito de concretos tipos legais de crime (30). E não faltam efectivamente hipóteses — também no nosso direito —, descritas na PE, de *equiparação expressa* da omissão à acção e, por conseguinte, com definição legal, mais ou menos completa, dos pressupostos de equiparação. É p. ex. o caso do art. 224.º-1 (infidelidade patrimonial), cujo tipo tanto pode ser preenchido por comportamentos activos como por comportamentos omissivos; como é o caso do art. 367.º (favorecimento pessoal), onde a frustração de actividade processual pode ser operada simplesmente por se deixar ultrapassar um prazo; ou, ainda mais claramente, o caso do art. 369.º-1 (denegação de justiça e prevaricação), onde a própria lei equipara o não promover ao promover, o não decidir ao decidir. Nesta medida assistindo razão a quem pensa que o critério exposto no parágrafo anterior, "sozinho, levará a uma indistinção, dentro do mesmo grupo, de delitos de estrutura muito diversa, em detrimento da estabilidade e da coerência que devem presidir a qualquer distinção teórica" (31).

§ 15 Não corre exactamente em qualquer dos termos expostos, no entanto, a doutrina tradicional (32) e ainda hoje mais difundida. Para ela

---

(29) Assim, KAUFMANN, Armin, *Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte*, 1959, pp. 206 e ss. e 275 e ss., STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.os 6 e s. e 8 e ss., e, entre nós, DIAS, Figueiredo, nota 4, p. 852 e s., e A propósito da "ingerência" e do dever de auxílio nos crimes de omissão, *RLJ 116*, 1983-84, p. 54[18]; e, por último, também, D'AVILA, Fabio, nota 1, p. 243 e ss.

(30) ROXIN II, § 31, n.os 16-30.

(31) BRITO, Teresa Quintela de, nota 28, p. 157[205] *in fine*; no sentido desta mesma crítica apontam BARROS, Coelho de, Sobre os crimes omissivos, em especial o dever de agir nos crimes omissivos impróprios, *RJ 2*, 1983, p. 56, e NEGRÃO, Maria do Céu, Sobre a omissão impura no actual Código Penal português, separata da *RMP 25* e *26*, 1986, p. 17 e s.

(32) Que bem se pode afirmar — DIAS, Figueiredo, nota 4, p. 852 — remontarem entre nós já ao princípio do século: PAIVA, Navarro de, *Estudos de Direito Penal*, s/d, p. 74 e ss., e MATTA, Caeiro da, II, p. 202 e ss.

devem considerar-se delitos *puros* ou *próprios* de omissão aqueles cujo tipo objectivo de ilícito se esgota na não realização da **acção** imposta pela lei e *impuros* ou *impróprios* aqueles outros em que o agente assume a posição de garante da não produção de um **resultado típico** (33). Com o que fica próxima a afirmação — deva ela embora ser tomada *cum grano salis* — de que a distinção entre delitos de omissão próprios e impróprios vem no fundo a cobrir-se, no essencial embora "inversamente", com a que vimos interceder (supra, 11.º Cap., § 37) entre *crimes de mera actividade* e *crimes de resultado*. Como de resto o teor literal do art. 10.º parece impor, ao reconduzir a equiparação da omissão à acção ao caso de "um tipo legal de crime compreender um certo *resultado*" (n.º 1) e ao reportar o essencial da imputação da omissão ao caso de "sobre o omitente recair um dever que pessoalmente o obrigue a evitar esse *resultado*" (n.º 2).

§ 16 Postas assim as coisas, pode asseverar-se que as referidas formas de distinção se cobrem no essencial (34). A decisão entre elas deve, em último termo, depender da *teleologia político-criminal* e do *interesse prático-normativo* que devam atribuir-se à distinção; e esses estão seguramente na determinação dos termos em que se constitui o **dever de garantia** e as **posições de garante**. Termos estes que se tornam questionáveis apenas nos casos em que não é a própria tipicidade a defini-los com exactidão e de forma expressa e que, por isso, se encontram entre nós remetidos para a cláusula de equiparação constante do art. 10.º-1 e 2. Esta consideração parece que deveria conduzir à preferência pela primeira orientação (supra, § 12); ao que todavia Roxin opõe que mesmo em crimes de omissão constantes da PE o recurso à cláusula geral de equiparação pode ainda revelar-se de utilidade (por faltar a descrição típica do delito de acção correspondente), enquanto que nos verdadeiros crimes de omissão pura não deve nunca uma posição de garante ser deduzida de um simples dever de acção (35). Nesta controvérsia, de um ponto de vista lógico-material, dir-se-ia estar a razão com

(33) Assim, CORREIA, Eduardo, I, pp. 286 e 300 e ss.; indicação exaustiva da literatura portuguesa neste sentido, que recolhe a concordância da A., BRITO, Teresa Quintela de, nota 28, p. 149[143]. Cf., também, no essencial, JESCHECK / WEIGEND, § 58, III, 2, com indicação de bibliografia alemã concordante; e na doutrina italiana CADOPPI, *Il reato omisivo proprio*, I, 1988, p. 111 e ss.

(34) Chegando STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 7, a afirmar que na escolha entre elas se trata de pouco mais que de uma "questão de conveniência".

(35) ROXIN II, § 31, n.º 28 e s.

Roxin. Mas a tanto obtempera André Leite ([36]), que, de todo o modo, em omissões tipicamente descritas na lei as dificuldades na determinação dos agentes possíveis do crime e do correspectivo dever de garante ou não existem ou não têm paralelo com as que se verificam nos autênticos crimes de omissão impuros. Por outra parte, é verdade que, nos termos do art. 10.º-2, o dever de garantia não pode deixar de referir-se à "omissão da acção adequada a evitar um **resultado**"; se bem que ainda aqui pode argumentar-se — de novo com André Leite — ser pelo menos duvidoso que a expressão "resultado" esteja ali tomada no seu rigoroso sentido típico (como "alteração externa espácio-temporalmente distinta da conduta"), antes que como "lesão ou colocação em risco de bens jurídicos" ([37]) ou, na expressão que usámos supra, 11.º Cap., §§ 10 e 38, na esteira de Helena Moniz, como "afectação da situação de tranquilidade do bem jurídico protegido".

§ 17 Tudo considerado, deve concluir-se que o critério fundamental de distinção entre crimes de omissão puros e impuros passa pela circunstância decisiva de os **impuros,** diferentemente dos puros, **se não encontrarem descritos em um tipo legal de crime**, tornando-se por isso indispensável o recurso à cláusula de equiparação contida no art. 10.º, para resolver correcta e seguramente os problemas do círculo dos autores idóneos e da caracterização do seu dever de garantia. Sem prejuízo de poder asseverar-se que os crimes de omissão impuros são crimes de resultado, ao menos no sentido de crimes que afectam a situação de tranquilidade do bem jurídico protegido. Esta posição — já há largo tempo a nossa — não merecerá o apodo de "formalista", porquanto se baseia numa decisão político-criminal do legislador, acrescenta maior clareza e operacionalidade à distinção e relaciona de forma imediata o problema com a questão da conformidade da comissão por omissão à legalidade, *rectior*, à *determinabilidade penal* (infra, § 29 e ss.).

§ 18 O **exemplo** que sempre se aponta dos crimes *puros* ou *próprios* de omissão (de *mera* inactividade) é o da **omissão de auxílio**: punível é quem, em certas situações de necessidade que ponham em perigo bens jurí-

---

([36]) LEITE, André, nota 4, p. 60 e ss. Em sentido que nos pareceu próximo — se bem que acabando por optar pela solução do "resultado" —, BRITO, Teresa Quintela de, nota 28, p. 147 e ss.

([37]) LEITE, André, nota 4. Cf., também, D'AVILA, Fabio, nota 1, p. 248 e ss. Coisa diferente — e, no presente contexto, irrelevante — é a circunstância de, para certos autores, "todos os comportamentos comportarem um resultado típico" (assim, BRITO, Teresa Quintela de, nota 28, pp. 147, 184 e 186, e PEREIRA, Rui, Crimes de mera actividade, *RJ 1*, 1982, p. 9 e ss.).

dicos fundamentais de outra pessoa, "*deixar de lhe prestar o auxílio necessário ao afastamento do perigo*" (art. 200.º-1) ([38]). Não é neste caso tipicamente relevante saber se alguém acabou ou não por sofrer danos; razão por que a pena cominada (prisão até 1 ano ou multa até 120 dias) é notoriamente inferior à que caberia às acções correspondentes (matar, ferir, privar outrem da liberdade). Em suma, não existe aqui nenhuma "correspondência" entre a omissão (também por essa razão "pura" ou "própria") e a acção. O mesmo se passa, de resto, com o crime omissivo da **recusa de médico**, pelo qual será punido "o médico que recusar o auxílio da sua profissão em caso de perigo grave para a integridade física de outra pessoa" (art. 284.º) ([39]). E também na **violação de domicílio**, quando alguém *permanece* na habitação de outra pessoa depois de intimado a retirar-se (art. 190.º-1) ([40]).

§ 19 **Exemplos** de crime *impuros* ou *impróprios* de omissão (de *comissão por omissão*) parece poderem ser em princípio — tomando-se no seu teor literal imediato o disposto no art. 10.º-1 — constituídos por **todo e qualquer outro tipo legal de crime, descrito na lei somente como crime de acção, se ele "compreender um certo resultado"** (homicídio, ofensa à integridade física, sequestro, burla, etc.). Depararíamos pois aqui com uma **cláusula geral de equiparação da omissão à acção**. Antes porém que uma tal cláusula se tome pelo seu valor facial, suscita-se uma série de problemas complexos e graves que relevam de forma decisiva para a construção do tipo de ilícito objectivo da omissão e constituirão, por isso, objecto da exposição posterior, deste modo essencialmente dirigida aos crimes impróprios ou impuros de omissão.

IV. A equiparação da omissão à acção nos crimes impróprios ou impuros de omissão

1. A questão do fundamento

§ 20 Em geral, pode afirmar-se que o pensamento segundo o qual certos crimes legalmente descritos como crimes de comissão por acção podem

---

([38]) Sobre os problemas de relacionamento entre omissão pura e omissão impura no seio deste preceito, quando considerados os seus n.os 1 e 2, ASSUNÇÃO, Maria Leonor, *Contributo para a Interpretação do Artigo 219.º do Código Penal*, 1994, pp. 17 e ss. e 121 e ss., e CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, I, art. 200.º, §§ 2 e 14 e ss.

([39]) Cf. CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, II, art. 284.º, § 7.

([40]) Assim, entre nós, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, I, art. 190.º, § 24.

também ser praticados por omissão por todo aquele sobre o qual recaia um dever jurídico de obstar à produção do resultado se impôs na transição do séc. XVIII para o séc. XIX e não mais foi abandonado pela doutrina penal ([41]). Sempre se invocando a seu favor exemplos chocantes como o da mãe que dolosamente deixa o seu bebé morrer à fome e deveria ser punida como homicida. A ideia de uma equiparação mais ou menos extensa dos crimes comissivos de acção e de omissão conduziu por isso a doutrina a procurar o fundamento de uma tal equiparação. Tarefa que se desenvolveu nos mais diversos planos, desde o lógico ao fenomenológico, do valorativo ao normativo. Mas que, segundo a posição que neste livro vimos sistematicamente assumindo, não pode deixar de ter na sua base uma **proposição político-criminal** fundamental, através da qual se liga às concepções do papel do Estado e à posição dos indivíduos perante ele.

§ 21 Eduardo Correia pretende encontrar aquele fundamento ([42]) na ideia de que quando um tipo de crime proíbe a produção de um resultado tanto lhe interessam as acções que o produzem, como as omissões que o deixam ter lugar; ou, dito de outro modo porventura mais esclarecedor: "*da norma que pretende evitar um resultado nasce para todos não só a proibição de actividades que o produzam, como também o comando de levar a cabo todas as actividades que obstem à sua produção*" ([43]). E a sua convicção na bondade deste fundamento foi até ao ponto de a ter inserido no proémio do art. 7.º do seu ProjPG. Nem parece substancialmente diferente, no que ao fundamento da equiparação respeita, a posição agora sustentada por Teresa Quintela de Brito, para quem as normas da PE contêm — salvo contadas excepções — *tipos comuns à acção e à omissão*, abrangendo logo à partida estas duas espécies de comportamento. Por outras palavras, "a equiparação passa a ser feita ao nível da norma da parte especial, concebida como um tipo comum à acção e à omissão, e não ao nível do tipo comissivo por acção" ([44]). Com o que talvez pudesse afirmar-se, sem infidelidade ao pensamento nuclear exposto, que o problema da "equi-

([41]) Sobre a história do problema, WELP, *Vorangegangenes Tun als Grundlage einer Handlungsäquivalenz der Unterlassung*, 1968.

([42]) Numa linha de pensamento próxima da de NAGLER, Die Problematik der Begehung durch Unterlassung, *GS 111*, 1938, p. 1, e seguindo porventura uma sugestão de BINDING, *Normen*, V, 1918, p. 361 e ss., embora não directamente atinente ao tema agora em apreço.

([43]) CORREIA, Eduardo, I, pp. 271, 301 (s. n. o.).

([44]) BRITO, Teresa Quintela de, nota 28, pp. 110 e ss., 127 e ss.

paração" acabaria por ser resolvido por *eliminação*: na realidade não haveria aqui qualquer "equiparação", por isso que já os tipos da parte especial, aparentemente apenas de acção, seriam afinal tipos dirigidos tanto à acção (neles descrita), como à omissão da acção devida (implicitamente neles compreendida).

§ 22 Concepções deste teor vão porém demasiado longe (45). Logo Armin Kaufmann, de resto, as criticou tanto no plano normológico, como no estritamente normativo: porque, por um lado, seria contraditório que a mesma norma contivesse simultaneamente uma proibição de acção e um mandato de acção; e porque são diferentes os círculos de agentes possíveis num e noutro caso, por isso que relativamente à omissão a responsabilidade só cabe àqueles agentes que se encontrem juridicamente vinculados por um *dever de acção* (46). E sem que pensemos que estas críticas podem ser obviadas, como defende Teresa Quintela de Brito, pela distinção entre um "tipo comum" à acção e à omissão, e um "tipo de interpretação" cabido a cada uma das duas espécies de comportamento (47): os deveres e as consequentes posições de garante fazem parte da mais vera essência do *tipo de ilícito omissivo*, que sem elas não pode sequer ser pensado; e é justamente isso o que dá a compreender o art. 10.º-2.

§ 23 Todavia, não é numa crítica normológica e normativa como a de Armin Kaufmann que vemos o essencial da reserva que julgamos merecerem orientações como as expostas. Quando afirmamos que elas vão longe demais queremos antes referir-nos especificamente ao **fundamento político-criminal** em que deve assentar a equiparação. O fundamento que se busca para sobre ele edificar a equiparação da comissão por omissão à acção deve ser um tal que, sem quaisquer pretensões de absolutismo, ofereça também do mesmo passo os seus **limites**. Pois se é verdade que uma ordem jurídico-penal não pode passar, em certos casos, sem aquela equiparação, não o é menos — e desde há muito que a doutrina se apercebeu consensualmente disso, mesmo em sociedades muito menos complexas que as actuais — que uma equiparação total, ou mesmo só de princípio e à partida, da comissão por omissão à acção, por força das

(45) No sentido geral da crítica que se segue, LEITE, André, nota 4, pp. 118, 217, 401.
(46) KAUFMANN, Armin, nota 2, p. 251 e ss.
(47) BRITO, Teresa Quintela de, nota 28, p. 99 e ss.

constantes intromissões, a que conduziria, de cada um na esfera jurídica dos outros, elevaria a complexidade social e a mancha da criminalização a quotas político-criminalmente insuportáveis. O fundamento da equiparação deverá pois, em nossa opinião, ser o seguinte: o de se lograr seguramente a conclusão, através de uma autónoma valoração da ilicitude, que, relativamente a um certo tipo de ilícito, **o desvalor da omissão corresponde no essencial ao desvalor da acção**. Esse será o caso (e aqui deparamos com o fundamento a apontar, *do mesmo passo*, os seus limites) quando, e *apenas quando*, sobre o agente recaia um dever de evitar activa ou positivamente a realização típica, *rectior*, de obstar à verificação do resultado típico — dito abreviadamente **dever de garantia** ou **dever de garante** —, apesar de um tal dever se não encontrar referido na descrição típica. Digamos (de uma forma quiçá aproximativa mas que julgamos esclarecedora) que o fundamento da equiparação se não encontra quando se considera unicamente o n.º 1 do art. 10.º, mas somente quando se conjuga em um *sentido único de ilicitude* o disposto **no n.º 1 e no n.º 2** daquele artigo.

§ 24 Nem é outro, ao que pensamos, o sentido da alteração — por nós proposta, em 1976, no seio do *petit Comité* referido supra, 30.º Cap., § 30, e aceite por Eduardo Correia e Miguel Caeiro — introduzida pelo art. 10.º-1 relativamente ao texto do art. 7.º do ProjPG e que se resume à expressão acrescentada à primeira cláusula de equiparação: "salvo se outra for a intenção da lei". O propósito da ressalva não se resume à referência àqueles casos em que, pela "natureza das coisas" ou por força da vinculação típica da acção, o tipo de ilícito, descrito como de acção, não pode ser integrado por uma omissão. É sim, para além disso, o de estabelecer a ponte entre o disposto no n.º 1 e no n.º 2 do art. 10.º, chamando a atenção para que só os dois preceitos, lidos em conjunto ([48]), oferecem na sua integralidade o fundamento da equiparação. De maneira que o disposto no n.º 2 não constitui mera **restrição exterior** ao fundamento geral

([48]) Anote-se que também BRITO, Teresa Quintela de, nota 28, p. 132, acaba por reconhecer a "necessária articulação do n.º 2 do art. 10.º com o disposto no seu n.º 1", embora em definitivo seja diferente da nossa a sua leitura da parte final do art. 10.º-1 (loc. cit., p. 112 e ss.). No sentido do texto LEITE, André, nota 4, pp. 133 e ss. e 137, que conclui (exemplificando de seguida): "analisar a possibilidade de equivalência sem a adscrever, de imediato, a uma concreta posição de garantia, deixa o aplicador no trilho da insegurança jurídica, conhecido que é o papel limitativo que tal posição ocupa na dogmática omissiva imprópria. Na verdade, situações existem em que, sendo configurável, *em abstracto*, um dever de garantia, a autónoma "valoração ético-social", a encontrar no *omittere*, milita no sentido de negar a equivalência" (s. n. o.).

erigido no n.º 1, que assim valeria no seu carácter e no seu império absolutos, mas **peça essencial e insubstituível** deste mesmo fundamento.

§ 25 Se nos preocuparmos com um breve **exercício comparativo** do nosso art. 10.º e do § 13 do CP alemão — cujo texto se encontra infra, § 28 — cremos que haverá duas diferenças a pôr em relevo, não sendo por acaso, e muito menos por incorrecção, que o nosso preceito começa por um princípio lato (não geral!) de equiparação, para depois lhe acrescentar a limitação derivada do dever de obstar à verificação do resultado. A solução contrária do CP alemão sempre nos pareceu contraditória, anulando praticamente o valor autónomo da cláusula de equiparação em sentido estrito. Não se compreende, desde logo, como possa alguém ter o dever jurídico de agir para depois este dever ser anulado em função de uma falta de correspondência da omissão à acção (49). Por outro lado, do nosso ponto de vista como dissemos — e ao contrário do que sustenta a generalidade da doutrina alemã (50) —, não existe um *duplo* critério de equiparação, um primeiro de verificação no caso de um dever jurídico de agir, um segundo de correspondência da omissão à acção, mas apenas *um* critério de equiparação político-criminalmente fundado, se bem que desdobrado (embora sem perder a sua unidade essencial) num princípio de correspondência e num princípio de garantia pela não produção do resultado. Mais longe — mas numa via que nos pareceu constituir um desenvolvimento importante (e de alguma forma novo) da aqui preconizada — vai Damião da Cunha (cf. já supra, § 9) quando conclui que "a equiparação da omissão à acção já não pode ser feita pela 'analogia das coisas' (...). Verdadeiramente, do que se trata é de uma questão de dever; e o dever tanto pode impor acções como omissões" (51).

§ 26 É exacto, de todo o modo, que o *relevo prático-normativo* do princípio de correspondência da omissão à acção se traduz sobretudo na questão de saber relativamente a que tipos de acção deve aquele princípio ser **negado**. Determiná-lo supõe porém, as mais das vezes, que se alcance a interpretação teleológica correcta do tipo de acção e é por isso matéria do tratamento sistemático da PE. A questão surgirá por excelência naqueles casos em que o tipo de acção se não basta com a produção de um resultado proibido, mas exige que a execução, para ser típica, tenha tido lugar de acordo com certas **modalidades de acção** (52) (53); como seria por-

---

(49) Cf., por último, ROXIN II, § 32, n.º 218.

(50) Muito claramente, JESCHECK / WEIGEND, § 59 IV e V.

(51) CUNHA, Damião da, nota 10, p. 538 (cf., também, pp. 505 e ss., 527). Contra, LEITE, André, nota 4, p. 139 e ss.

(52) Hipóteses, por conseguinte — ao menos a maior parte delas —, que conformam a categoria dos "crimes de execução vinculada": cf. supra, 11.º Cap., § 42.

(53) O que, numa certa literatura alemã, dá justamente lugar à teoria chamada da "*equivalência de modalidades*": pioneiro, GALLAS, *Niederschriften XII*, 1959, p. 70 e ss., e agora, por

ventura o caso da utilização de certos meios particularmente perigosos em crimes contra vida ou a integridade física (arts. 132.º-2/*g*) e 146.º), do uso de violência ou ameaça em crimes contra a liberdade pessoal (art. 154.º), do engano na burla (art. 217.º-1), etc. (54).

§ 27 A solução da questão não deve ir buscar-se a uma *valoração global* do comportamento omissivo que, caso pudesse revelar uma certa correspondência com o comportamento activo, apesar da falta dos elementos especiais da *acção*, permitiria ainda a responsabilização do agente sobre quem recaísse um dever de obstar à verificação do *resultado* (55). Com uma solução deste género sofreria inapelavelmente o princípio *nullum crimen sine lege* e as exigências de determinabilidade nele contidas (56). Decisivo é que o princípio da correspondência nestes casos só pode ser afirmado se e quando **o resultado tiver sido produzido, por omissão, sob a forma tipicamente exigida pelo delito de acção** (nos exs. apontados, com meio particularmente perigoso, com ameaça ou violência, com erro ou engano) (57). O que não deixará, cremos, de ser possível em alguns dos casos enumerados (não em outros) (58), assim se convalidando a nossa afirmação de que tudo dependerá em última análise da correcta interpretação teleológica do tipo de ilícito de acção (59). Interpretação essa que comunga com a acção a função de protecção de bens jurídicos, mas também com uma certa "função propulsora ou promocional" de tais bens, radicada no étimo do *ser-com-os-outros*; e que, como escreve André Leite,

---

outros, ROXIN II, § 32, n.º 225, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 67. Cf., de algum modo, já, DIAS, Figueiredo, nota 20, p. 54 e s.

(54) Com o tratamento casuístico de alguns de alguns problemas a este nível depara-se em BRITO, Teresa Quintela de, nota 28, p. 115 e ss., sob a epígrafe de "alguns casos de inexistência de um 'tipo comum'".

(55) De forma mais lata e compreensiva sobre esta "valoração global" nos exprimíamos em DIAS, Figueiredo, nota 20, p. 55. Mais longe ainda vai COSTA, Faria, nota 3, p. 392 e ss.

(56) Contra, FARIA, Paula Ribeiro de, nota 10, p. 1100 e s.: "não é por se manter em 'aberto' a determinação legal das posições de garantia que tem lugar a violação do princípio da legalidade, sobretudo em ordenamentos jurídico-penais como o nosso, em que a cláusula de equiparação da omissão à acção consagrada ao nível da PG do CP supõe o preenchimento pela omissão do tipo legal comissivo integrado pelo dever de garante".

(57) Precisamente, nestes termos, JESCHECK /WEIGEND, § 59, V, 1.

(58) Cf. BRITO, Teresa Quintela de, nota 28, loc. cit., e, especificamente para a burla, COSTA, A. M. Almeida, *Comentário Conimbricense*, II, art. 217.º, § 21, e, agora, ROXIN II, § 32, n.º 232 e s.

(59) Essencialmente no sentido desta conclusão, COSTA, Faria, nota 3, p. 393 e ss., exemplificando com o caso do crime de injúria.

só uma "exemplar adscrição ao quadro axiológico jurídico-constitucional" é capaz de manter dentro das margens do que é comunitariamente suportável, evitando transformar a omissão impura em um "dúctil instrumento nas mãos de maiorias circunstanciais" (60). Melhor se perceberá agora — ao que cremos — que sempre tenhamos adscrito a ilicitude omissiva imprópria à violação de um dever de garante (61), o qual nada mais é, por rectas contas, que um instrumento conceptual dessa ilicitude, dotado de ressonância ético-social.

2. A questão da constitucionalidade

§ 28 Mesmo com este mais rigoroso e sobretudo muito mais estrito fundamento, seria farisaico não reconhecer que a equiparação pode suscitar dificuldades à luz do estrito princípio *nullum crimen sine lege*; não no que respeita a uma possível violação da proibição de analogia, afastada por força do art. 10.º, mas sim na sua exigência de **determinação típica** (62). E todavia, uma jurisprudência tão exigente como a alemã reconheceu durante muitos anos a legitimidade da existência de crimes de comissão por omissão apesar da total ausência de qualquer norma legal que os punisse. Só em 1969 a reforma do CP alemão introduziu um preceito, o § 13, nos termos do qual o agente é punível por delito de comissão por omissão apenas "quando ele tem de responder juridicamente pela não verificação do resultado e a omissão corresponde à realização do tipo legal através de uma acção". No mesmo plano se pode colocar, no essencial, o art. 10.º do nosso CP (63) quando lido à luz do fundamento de equiparação que para ele acima desenvolvemos. Mais longe na tentativa de determinação (e na consequente intenção restritiva) vai agora o CP espanhol, que no art. 11.º-2 nomeia taxativamente as concretas fontes do dever jurídico de actuar: a lei, o contrato e a ingerência (64). Até hoje não se conseguiu ainda ser mais preciso na via de

(60) LEITE, André, nota 4, p. 115 e ss.

(61) Cf., logo, o nosso *O Problema*, p. 510.

(62) Minuciosamente sobre a questão, SCHÖNE, *Unterlassene Erfolgsabwendungen und Strafgesetz*, 1974.

(63) Contra, BRITO, Teresa Quintela de, nota 28, p. 86 e ss.

(64) Sobre o modelo subjacente a esta disposição legal e a sua crítica cf. LEITE, André, nota 4, p. 420 e ss. Cf. de resto já o art. 7.º, § 1, do ProjPG: "A comissão de um resultado por omissão só é, todavia, punível, quando o dever de agir for confirmado por um preceito legal, um contrato ou uma situação criada pelo omitente que o constituam, pessoalmente, garante da não produção do resultado". A favor da enumeração executiva ou, pelo menos, mais completa das

determinabilidade dos tipos de comissão por omissão, nomeadamente, criando tipos paralelos aos dos crimes de resultado em todos e cada um dos casos em que se entende que a comissão por omissão deve ser punida (65).

§ 29 Uma tal criação seria todavia **indispensável** — para além de quaisquer lucubrações teoréticas e construtivas — para oferecer ao crime de comissão por omissão **a mesma** determinabilidade que possuem os crimes de comissão por acção. Não sendo assim, parece que devemos resignar-nos à medida de relativa indeterminação nesta matéria inevitavelmente reinante (66) — como noutras de resto, máxime, em certos "delitos de dever" e, de um modo geral, em todos os "tipos abertos" ou necessitados de completação judicial (supra, 11.º Cap., § 13 e ss.) (67) — e considerar que ela ainda é compatível com o princípio jurídico-constitucional da legalidade e suportável à luz do seu sentido garantístico essencial. Ponto é que se alcance uma **determinação rigorosa dos concretos deveres de garantia**; e que, consequentemente, **o seu catálogo seja o mais estrito e determinado possível**, devendo recusar-se que aí reentrem ainda uma vez *cláusulas gerais* mais ou menos indeterminadas; ou mesmo uma exagerada *funcionalização* do catálogo que faça perder o *conteúdo material* de que justamente se pretende ver dotada a doutrina dos deveres de garante como forma de salvaguardar a sua constitucionalidade. Satisfeitas estas exigências, tudo se tornará questão de hermenêutica do específico tipo legal de acção, em conjugação com a cláusula de equiparação do art. 10.º É, afinal, o próprio legislador que encaminha o aplicador para um percurso lógico-interpretativo por si mesmo estabelecido, reconhecendo, pragmaticamente, que a profunda diversidade das situações subsumíveis à comissão por omissão encontra num regime como o previsto aquele que menos escolhos oferece ao domínio da matéria.

---

fontes do dever de garante, MANTOVANI, Sobre a exigência perene da codificação, *RPCC 5*, 1995, p. 143 e ss. e PINTO, Costa, Justificação, não punibilidade e dispensa de pena na Revisão do Código Penal, *Jornadas FDUL*, p. 54.

(65) GRÜNWALD, Zur gesetzliche Regelung der unechten Unterlassungsdelikte, *ZStW 70*, 1958, p. 412, e SCHÖNE, nota 62, p. 342 e ss., em todo o caso quando ainda não existia ou não se encontrava em vigor o § 13 do CP alemão.

(66) No sentido desta conclusão, SCHÜNEMANN, Die Unterlassungsdelikte und die strafrechtliche Verantwortlichkeit für die Unterlassungen, *ZStW 96*, 1984, p. 304.

(67) Cf., na conclusão, já DIAS, Figueiredo, nota 29, p. 23 e ss. Depois, NEGRÃO, Maria do Céu, nota 31, p. 39 e ss., RODRIGUES, Marta Felino, *A Teoria Penal da Omissão e a Revisão Crítica de Jakobs*, 2000, p. 51[42]. Atentamente, por último, FARIA, Paula Ribeiro de, nota 10, pp. 1028 e ss., 1099 e ss.

§ 30 Como de resto se verá (infra, 38.º Cap., § 16 e ss.), em matéria de determinação das posição de garante nos tipos de ilícito impróprios de omissão deve defender-se uma **teoria "material-formal"**, que agrupa aquelas posições em determinadas categorias e subcategorias. Recentemente, veio André Leite sustentar que estas categorias são já hoje susceptíveis de definição legal e deverão por isso, no futuro, constar — de forma esgotante, ou eventualmente (mas mais duvidosamente, ao que pensamos e aquele A. reconhece) sob forma de uma espécie de "exemplos-padrão" — do texto do art. 10.º-2 ([68]). Parte para tanto das duas grandes categorias identificadas por Armin Kaufmann (infra, 38.º Cap., § 23), com a vantagem fulcral de o legislador assinalar assim ao intérprete e aplicador a essencialidade de a situação concreta passar pelo crivo da cláusula de equiparação e do plano em que se precipita o dever de garante ([69]). Esta proposta parece-nos de aplaudir, constituindo uma contribuição importante para uma realização mais plena do princípio *nullum crimen sine lege* nesta matéria; além de que ela se encontra mesmo nos propósitos de uma teoria material-*formal* como a que defenderemos.

V. A atenuação especial da pena

§ 31 Apesar da equiparação da omissão à acção nos termos que vimos de assinalar, a verdade é que, segundo as representações sociais prevalentes, sempre que se trata de obstar à verificação de um resultado típico a violação de deveres de acção **não se apresenta, em regra, tão grave** como a violação das proibições correspondentes. O que será particularmente visível em situações conflituais, onde se tornará mais compreensível, *v. g.*, que o omitente, para não sacrificar um interesse que lhe está próximo, não cumpra o dever que sobre ele pesa (máxime, nas situações que infra, 38.º Cap., § 38, chamaremos de ingerência) ([70]). Dito de outra forma, o delito impróprio de

([68]) CARVALHO, Taipa de, II, § 989, pretende solucionar o problema através de uma "alteração substancial do actual art. 200.º sobre o crime de omissão de auxílio".

([69]) V. a análise de diversos modelos de compatibilização do mandato de determinabilidade penal com a matéria do dever de garante em LEITE, André, nota 4, p. 405. Especificamente quanto à adopção, no futuro, da técnica dos exemplos-padrão, ID., ibid., p. 443 e ss.

([70]) Nestes termos, STRATENWERTH, § 13, n.º 79 (sem retirar o princípio a que o texto se refere, todavia, STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 83 e s.). DENCKER, Ingerenz: Die defizitäre Tathandlung, *Stree / Wessels-FS*, 1993, p. 169, pretende consagrar, para os casos de ingerência, uma atenuação especial *obrigatória* da pena; a idêntico resultado parece dever conduzir a tripartição dos delitos de omissão preconizada por SILVA SÁNCHEZ, Zur Dreiteilung der Unterlassungsdelikte, *Roxin-FS*, 2001, p. 641 e ss.

omissão, apesar da equiparação típica, surge *em regra* como dotado de uma **menor** dignidade punitiva que o delito de acção correspondente, resultante de um conteúdo **menos grave** de ilicitude e (sobretudo) de culpa. Esta a razão por que, segundo uma opinião generalizada ([71]) — embora sujeita, sobretudo na Alemanha, a uma contestação porventura crescente —, o legislador consagrou justificadamente, no art. 10.º-3, uma **atenuação especial facultativa** para os crimes impróprios de omissão.

§ 32 Mais longe na fundamentação vai Faria Costa, sustentando que ela radica "na determinação onto-antropológica que o *facere* consigo carrega" e ainda na circunstância de que a omissão, diferentemente da acção, "não desencadeia (...) alterações ao real verdadeiro" ([72]). Tudo isto tem, como vimos, de ser levado em conta em tema de **equiparação** da omissão à acção; mas não em matéria de **atenuação extraordinária** da pena. Uma tal atenuação deveria então ser obrigatória e valer para toda a espécie de delitos de omissão, o que não acontece (cf. já a seguir) nem, em nossa opinião, deve acontecer.

§ 33 Excepcionalmente, pode o conteúdo da ilicitude e da culpa da omissão impura **não ser menor** que o do delito de acção correspondente tanto nos delitos dolosos, como nos delitos negligentes de omissão ([73]). Isso sucederá particularmente, segundo Roxin, nos casos em que "a acção imposta se inscreve no decurso normal da vida" ([74]). Casos como o da mãe que mata o seu filho bebé por não o alimentar, ou o do agulheiro que provoca o descarrilamento de um expresso por intencionalmente não ter feito a agulha mostram que assim pode ser e justificam que a atenuação especial prevista tenha sido consagrada a título meramente **facultativo**.

§ 34 A atenuação especial facultativa prevista pelo art. 10.º-3 não se aplica aos **crimes próprios de omissão**: aí a moldura penal aplicável é expressamente prevista pelo tipo legal de crime, tudo se passando como se de um crime de acção se tratasse.

([71]) Cf., só, JESCHECK / WEIGEND, § 58, V, e ROXIN II, § 31, n.º 239, e, entre nós, por último, CUNHA, Damião da, nota 10, p. 503. Com razão afirma CUNHA, Conceição Ferreira da, Algumas considerações sobre a responsabilidade penal médica por omissão, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 823[16], que este preceito "parece exprimir a ideia de uma 'equiparação também atenuada'".

([72]) COSTA, Faria, nota 3, p. 391 e s.

([73]) Assim, de novo, JESCHECK / WEIGEND, § 58, V.

([74]) ROXIN, § 31, n.º 242.

38.º CAPÍTULO

O TIPO DE ILÍCITO DOS CRIMES DE OMISSÃO

A. O TIPO DE ILÍCITO DOLOSO

I. O tipo de ilícito objectivo

§ 1 Os elementos ou pressupostos do tipo incriminador objectivo do delito de omissão são, uns comuns a todo o delito de omissão (1 e 2), outros específicos dos delitos impróprios de omissão (3 e 4). Eles serão expostos de seguida.

1. A "situação típica" e a ausência da acção esperada

§ 2 A chamada "situação típica" nos delitos de omissão é constituída especificamente pelos **pressupostos fácticos que permitem determinar o conteúdo concreto do dever de actuar**. Já se acentuou, na verdade, que a omissão se não torna jurídico-penalmente relevante em si mesma (como "não fazer nada", como não-A), mas apenas, normativamente, em função da acção esperada e devida. Relativamente aos *delitos próprios de omissão* não se suscita aqui nenhum problema especial, na medida em que o próprio tipo legal descreverá, de forma mais ou menos completa, a própria acção devida (*v. g.*, "deixar de lhe [ao sinistrado] prestar o auxílio necessário", no art. 200.º-1).

§ 3 Quanto aos *crimes impróprios de omissão*, estabelecidos por força da cláusula de equiparação do art. 10.º, a situação típica reduz-se à **criação de um risco de verificação de um resultado típico**: ela existe desde que aquele risco ocorre ou é potenciado por força da omissão (mais de perto infra, 40.º Cap., § 5 e s.). Por correspondência com o delito de acção se determinarão os restantes elementos relevantes da situação, nomea-

damente a finalidade que deve ser alcançada com a acção esperada, o bem jurídico tutelado e os factores acompanhantes jurídico-penalmente relevantes (1).

§ 4 Ao tipo objectivo da omissão pertence ainda, como é claro, a **ausência da acção** devida ou esperada, conforme à situação típica. Que acção seja esta, resulta uma vez mais, nos delitos próprios de omissão e nos impróprios constantes de um tipo legal de crime especial, da própria lei. Nos delitos impróprios de omissão equiparados à acção por força do art. 10.º, a acção esperada resulta, na falta de menção legal, daquilo que segundo a situação típica é necessário para obstar à verificação do resultado típico.

2. A possibilidade fáctica de acção

§ 5 Para que exista uma omissão típica é em seguida necessária a possibilidade do omitente levar a cabo a acção esperada ou devida (2). Bem podendo afirmar-se, em nosso parecer, que esta exigência assume um reflexo no texto do art. 10.º-2, quando faz depender a punibilidade da omissão de "sobre o omitente recair um dever que **pessoalmente** o obrigue a evitar" o resultado. Trata-se aqui de não mais que uma consequência clara do princípio *ad impossibilia nemo tenetur* ou *nemo obligatur*. Esta precisão ajudará decisivamente a estabelecer como deve compreender-se a exigida capacidade fáctica individual de acção (3), cuja falta constituirá, assim, uma verdadeira **causa de atipicidade** do comportamento.

§ 6 Falta uma tal possibilidade quando ao omitente **falta a capacidade corpórea (ou física) de acção**. Se é preciso acorrer rapidamente a

---

(1) Neste sentido, a generalidade da doutrina alemã, pela qual podem ver-se JESCHECK / WEIGEND, § 59, I, e ROXIN II, § 31, n.º 177 e s.

(2) Mal sendo por isso necessário acentuar que esta impossibilidade nada tem a ver com o "poder de agir de outra maneira", com a "capacidade de determinação pela norma" ou "permeabilidade ao apelo normativo" que as teses da *culpa* da vontade consideram constituir a vera essência da culpa jurídico-penal.

(3) STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 58 e s. Preferem estes AA., não sem razão, falar a este propósito, antes que de "capacidade de acção", como a generalidade da doutrina germânica, de "poder de facto" (*Tatmacht*), pensamos que para assim dar a perceber que se não trata de uma geral "capacidade de agir de forma coordenada e racional-final, pura e simplesmente, mas da capacidade de levar a cabo uma acção bem *determinada*". Essencialmente também neste sentido, LEITE, André, *As "Posições de Garantia" na Omissão Impura. Em Especial, a Questão da Determinabilidade Penal*, 2007, p. 86 e ss., e CARVALHO, Taipa de, II, § 973 e ss.

uma criança que caiu a um lago, seguramente que não é típica, por falta de possibilidade de acção, a "omissão" do seu pai paralítico, sentado numa cadeira a alguma distância da água. Mas se este podia gritar por ajuda, alertando pessoas que ouviriam seguramente o apelo, então ele já deve considerar-se capaz desta acção. Também aqui, pois, tudo dependerá da situação típica. E o mesmo se dirá da impossibilidade absoluta derivada da distância física: quem se encontra no Porto não pode praticar no momento devido uma acção esperada em Coimbra.

§ 7 À impossibilidade física deve ser equiparada a que resulta da incapacidade **técnica**, da falta de **conhecimentos** ou de **meios de auxílio**. Um electricista que depara com alguém severamente ferido num ermo, onde passeia sozinho sem telemóvel, não comete qualquer omissão típica se não leva a cabo a intervenção cirúrgica indispensável para estancar a hemorragia, ou não chama o 112, ou não grita para pedir socorro. Mas já não se trata da questão aqui considerada — a da incapacidade de acção — quando a impossibilidade é uma **impossibilidade jurídica**: do que se trata então não é, na verdade, de uma impossibilidade *fáctica* de acção, mas da insubsistência em casos tais do *dever jurídico* de actuar (4).

§ 8 Segundo a doutrina alemã dominante a incapacidade de acção não precisaria de ser *absoluta* e subsistente de todos os pontos de vista, sendo já de afirmar quando alguém está impossibilitado de, na situação típica, actuar **razoavelmente** em favor da não verificação do resultado (5). Cremos que tal resulta porém já, com suficiente clareza, do que acabou de ser dito.

3. O problema da imputação objectiva

§ 9 Sobre o que atrás designámos (6) o primeiro degrau da imputação objectiva — o da pura **causalidade** —, tem-se discutido vivamente e continua a discutir-se se dele pode sequer falar-se na omissão; logo devendo todavia concordar-se com Liszt / Schmidt quando afirmam ser esta uma das mais "infrutíferas" discussões de toda a ciência jurídico-penal (7). Na ver-

(4) Assim, por último, ROXIN II, § 31, n.º 14.

(5) JESCHECK / WEIGEND, § 59, II, 2.

(6) Para tudo quanto se segue deverá o estudante relembrar as noções fornecidas supra, 12.º Cap.

(7) LISZT / SCHMIDT, p. 164. E no seu seguimento, hoje, a larga maioria da doutrina alemã, que pode ver-se indicada em JECSHECK / WEIGEND, § 59, III, 3.

dade: de uma qualquer perspectiva ôntico-fenomenológica não é possível (assistindo nesta medida razão aos "finalistas", nomeadamente a Armin Kaufmann e a Welzel) falar de causalidade — de uma causalidade que só pode ser *real* — nos delitos de omissão ([8]): *ex nihilo nihil fit*. Mas já de uma perspectiva normativa poderá falar-se (o que todavia, de um ponto de vista prático, não apresentará grande interesse), à maneira de Engisch e agora de Roxin, de uma causalidade da omissão como *condição conforme à lei* ([9]); como poderá ver-se (porventura com maior interesse) o comportamento esperado, que *não* foi levado a cabo, como dotado de uma força causal *potencial* ou *hipotética* ([10]). E de igual modo o degrau da **adequação** (como sabemos, já de natureza eminentemente típico-normativa) só poderá ser cumprido com apelo à *idoneidade* não do comportamento eventualmente levado a cabo, mas do comportamento esperado ou devido para obstar à verificação do resultado. Deste modo, o problema da imputação objectiva do resultado típico à omissão só poderá ser em definitivo solucionado — de forma porventura ainda mais clara do que nos delitos de acção — no seio da atrás chamada **"conexão do risco"**: a acção esperada ou devida deve ser uma tal que **teria diminuído o risco de verificação do resultado típico**. Há porém que analisar um pouco mais de perto o exacto alcance que a esta proposição deve ser atribuído.

§ 10 Questão é saber, desde logo, se para a afirmação da imputação objectiva se deve exigir a comprovação de que, se a acção esperada tivesse tido lugar, o resultado não se teria produzido **seguramente**, ou pelo menos, atenta a insegurança de comprovação de processos causais hipotéticos, **com uma probabilidade que roça a certeza** ([11]). A doutrina e a jurisprudência que defendem esta solução podem invocar a seu favor um mais próximo paralelismo com o que sucede nos delitos de acção (incremento, aumento ou potenciação do risco: supra, 12.º Cap., § 28 e ss.); bem como a circunstância de que ela não dará lugar a lacunas insuportáveis da puni-

---

([8]) KAUFMANN, Armin, *Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte*, 1959, p. 57 e ss.; WELZEL, § 28 A), II, 3.

([9]) ENGISCH, *Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände*, 1931, p. 29 e ss., e Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug, *v. Weber-FS*, 1963, p. 264 e s.; ROXIN II, § 31, n.º 39 e ss.

([10]) Por último, e por outros, STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 52.

([11]) Assim uma parte significativa da jurisprudência alemã; e, depois, JESCHECK / WEIGEND, § 59 III 4, com uma extensa indicação de doutrina concordante.

bilidade nos delitos dolosos de omissão, porquanto fica de todo o modo ressalvada a punibilidade da tentativa. Em definitivo, porém, uma tal doutrina parece-nos inaceitável. Desde logo, e sobretudo, de um ponto de vista político-criminal **preventivo**, na medida em que, fora dos casos de certeza ou de probabilidade roçando a certeza, a ordem jurídica deixaria de impor a conduta ao agente e desincentivaria, assim, toda a actividade destinada à *possível* salvação de bens jurídicos ameaçados. Ela conduziria — no exemplo de escola que neste contexto sempre se avança — a que a ordem jurídica não sancionasse os pais de uma criança gravemente enferma (ou portadora de uma doença cujas cotas de morbilidade são muito altas) que deixam o filho por tratar, sobrevindo o resultado letal, só porque a possibilidade da sua salvação por tratamento médico não roça a certeza. Por outro lado, aliás, logo o degrau da **adequação**, a exigir que seja levada a cabo uma acção *idónea* a (tentar) obstar à verificação do resultado típico e não uma acção que "que quase com certeza a impeça", parece estar contra uma tal doutrina.

§ 11 Uma outra parte da doutrina defende que a solução correcta reside em que a imputação do resultado ao comportamento omissivo deverá ter lugar logo que se comprove que a acção teria **diminuído o perigo** que atinge o bem jurídico (no exemplo anterior, que a chamada atempada do médico teria servido para abrir uma possibilidade de sobrevida da criança): é esta diminuição do perigo que tem de ser comprovada, não qualquer "probabilidade roçando a certeza" ([12]). Se uma tal comprovação (da diminuição do perigo) não lograr ser alcançada e a *dúvida* persistir (se, em definitivo, se não puder saber se a intervenção médica em devido tempo teria ou não feito diminuir o perigo de morte da criança), ela tem que ser valorada **a favor** do omitente (*in dubio pro reo*), pelo que a imputação objectiva do resultado deverá ser negada. Que, para efeito destas determinações, tenha de jogar-se (nomeadamente em sede processual) com critérios de *probabilidade*, não está contra o que acima dissemos em crítica ao critério da "probabilidade roçando a certeza".

§ 12 Roxin vem agora defender uma doutrina intermediária, segundo a qual o resultado **não será imputável** se a diminuição do risco só aparece como possível segundo uma consideração *ex ante*, mas **já o será** se, tam-

([12]) Neste sentido, STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 52 e ss.

bém segundo uma consideração *ex post*, se comprovar que aquela diminuição se teria efectivamente verificado ([13]). Tem sem dúvida razão, em termos análogos àqueles em que, nos delitos de acção, conferimos relevo ao *comportamento lícito alternativo* (supra, 12.º Cap., § 30 e ss.). Mas com isto em nada deve ser abalado o argumento da força preventiva que deve atribuir-se aos deveres de actuar: na afirmação paradigmática de Damião da Cunha ([14]), "tipicamente os deveres não visam impedir resultados, visam exactamente *diminuir a probabilidade* da ocorrência do resultado". Se, no referido exemplo da criança doente, logo segundo um juízo *ex ante* se comprova como possível que o chamamento do médico ou o internamento no hospital, indevidamente omitidos, tivessem podido obstar à morte da vítima em momento e circunstâncias análogas àquela em que ela se verificou, deve concluir-se que o cumprimento do dever teria determinado a diminuição do risco e o resultado típico deve considerar-se objectivamente imputável. A menos que, segundo uma consideração *ex post*, se comprove que o comportamento lícito alternativo em nada teria servido para o resultado. Assim sendo, os critérios de imputação objectiva nos delitos de comissão por acção e por omissão vêm na verdade a identificar-se ("inversamente"!) na maior medida possível. Nem se compreenderia que na hipótese considerada (supra, 37.º Cap., § 7) de entrega a operários de produtos infectados para manuseamento, a imputação objectiva não pudesse ou pudesse ser afirmada consoante se considerasse o caso como de comissão por acção ou por omissão: tudo deverá depender, num caso como no outro, de saber se a imposta desinfecção prévia dos produtos poderia ter ou não oferecido aos operários uma possibilidade de não contraírem a infecção ([15]): se sim (incremento do risco tratando-se de acção, não diminuição do risco tratando-se de omissão), o nexo de imputação objectiva deverá ser afirmado; se a dúvida permanecer ele deverá ser negado (*in dubio pro reo*).

§ 13 Como caso digno de uma consideração especial põe Roxin o da **causalidade omissiva em decisões colegiais** ([16]). Se bem pensamos, todavia, ainda aqui a doutrina da imputação objectiva atrás assinalada conserva o seu bom fundamento. O membro do órgão que omite a sua tomada de posição a favor do cumprimento do dever não diminui o risco de que venha a ser tomada uma decisão favorável à verificação possível,

([13]) ROXIN II, § 31, n.º 54 e ss.

([14]) CUNHA, Damião da, Algumas reflexões críticas sobre a omissão imprópria no sistema penal português, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, p. 499 e ss., p. 506 (s. n.).

([15]) STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 57.

([16]) ROXIN II, § 31, n.º 67.

dolosa ou negligente, de um resultado típico, que assim também a ele deve ser imputado. "De outro modo — acrescenta Roxin com razão — chegar-se-ia à conclusão absurda de que em geral ninguém seria causal, porque cada um se poderia louvar em que o seu voto em nada teria alterado a decisão maioritária. Está-se aqui em situação análoga à do processo causal hipotético nos delitos de acção [supra, 12.º Cap., § 39 e s.], onde aquele que causou o resultado também não pode pôr em questão a sua causalidade na base de que em todo o caso um outro teria produzido o resultado" ([17]).

4. A posição de garante

§ 14 Apenas nos crimes impróprios de omissão se suscita, com autonomia e de forma questionável, a questão do concreto dever de garantia e da consequente posição de garante do omitente pela não verificação do resultado típico (art. 10.º-2). Tratando-se aqui de uma das questões-chave — conjuntamente com a questão já discutida, supra, 37.º Cap., § 19 e ss., da equiparação da omissão imprópria à acção — da dogmática do tipo objectivo dos crimes de comissão por omissão, compreender-se-á que lhe seja dedicado em seguida um tratamento em apartado especial.

II. A posição de garante nos tipos de ilícito impróprios de omissão

§ 15 Já se tornou claro que nos crimes impróprios de omissão — diferentemente dos crimes próprios, onde o dever jurídico de actuar cabe por princípio *a todos* ou se encontra, de todo o modo, expressamente referido no tipo — a imputação objectiva do resultado só pode ser feita àquele sobre o qual recaia "um dever jurídico que pessoalmente o obrigue a evitar esse resultado" (art. 10.º-2) e, assim, se encontre por força de um tal dever constituído na **posição de garante** da não verificação do resultado típico. A questão básica é pois a de determinar de que modo podem delimitar-se os deveres de garantia jurídico-penalmente relevantes com a clareza e a determinabilidade suficientes para responder às exigências jurídico-constitucionais do *nullum crimen sine lege* (cf. já supra, 37.º Cap., § 28 e ss.).

§ 16 Três precisões são aqui necessárias. A primeira visa pôr em relevo, como bem acentua Damião da Cunha, que dever **jurídico** significa dever que "tem de assentar numa 'relação de confiança' susceptível de produzir efeitos jurídicos" ([18]).

([17]) ROXIN II, loc. cit. E, já antes, KUHLEN, Strafhaftung bei unterlassenem Rückruf gesundheitsgefährdender Produkte, *NStZ*, 1990, p. 566, e PUPPE, Zur Kausalitätsproblematik bei der strafrechtlichen Produkthaftung, *JR* 1992, p. 30.

([18]) CUNHA, Damião, nota 14, p. 499 e ss., exigindo ainda (p. 501) que a confiança requerida seja "institucionalmente tutelada".

A segunda, que dever jurídico que **pessoalmente** obrigue o garante significa não se tratar aqui de qualquer dever geral, mas de concretos deveres que ligam o garante à protecção de bens jurídicos determinados ou à fiscalização de fontes de perigo igualmente determinadas; exercendo um papel particularmente importante na sua determinação a situação de *dependência* ou de *domínio pessoal* facticamente intercedente entre o garante e o bem jurídico carente de protecção ou a fonte de perigo ameaçadora. Finalmente, convém sublinhar aquilo que repetidamente se tem anotado já ([19]): que a obrigação de evitar o resultado (art. 10.º-2) é só uma forma de referir — porventura de modo não inteiramente correcta — a obrigação de levar a cabo "a **acção adequada a evitar o resultado**" (art. 10.º-1); o que de modo algum significa que a necessária verificação do resultado possa ou deva ser aqui reduzida à categoria dogmática das "condições objectivas de punibilidade". Esta questão relevará sobretudo em tema de *tentativa* e de *comparticipação* no crime de omissão (infra, 40.º Cap.) e não será, por isso, aqui aprofundada.

1. A teoria formal do dever jurídico e das posições de garantia

§ 17 No início da história dogmática desta questão ([20]) deparamos de novo com Feuerbach: "um crime de omissão pressupõe sempre um especial fundamento jurídico (a **lei** ou o **contrato**) através do qual se dê base à obrigatoriedade da comissão. Sem aquele ninguém será criminoso" ([21]). À lei e ao contrato acrescentaria Stübel um terceiro fundamento (assente, ao que parece, num costume jurisprudencial ([22])): o da **situação de perigo anterior** criada pelo omitente, também dita situação de **ingerência**. Lei, contrato e ingerência constituíam assim as três *fontes* do dever de garantia aceites por aquela que ficou conhecida como a **teoria formal do dever de garantia**.

§ 18 Esta teoria revela-se como fruto acabado do pensamento jurídico naturalista e positivista dominante até ao princípio do séc. XX. E compreende-se facilmente o que motivou a aceitação de um catálogo tão estrito e rigoroso — mas ao mesmo tempo, assim se acreditava, tão claro —,

---

([19]) Cf. supra, § 12, e a citação de Damião da Cunha.

([20]) Sobre ela, SCHÜNEMANN, *Grund und Grenzen der unechten Unterlassungsdelikte*, 1971, p. 218 e ss., e, por último, ROXIN II, § 32, n.º 1 e ss.; e, entre nós, LEITE, André, nota 3, p. 147 e ss.

([21]) FEUERBACH, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen* Rechts, [14]1847, p. 24.

([22]) Segundo informação de WELP, *Vorangegangenes Tun als Grundlage einer Handlungsäquivalenz der Unterlassung*, 1968, p. 25 e ss.

nomeadamente, a devida obediência, que desta maneira se pensava levar a cabo pelo melhor, aos mandamentos de **certeza e segurança do direito**, de garantia dos cidadãos e de paz jurídica comunitária ínsitos no *nullum crimen sine lege*. Ao que acrescia a imperiosa necessidade de dar a entender que estão aqui em causa deveres **jurídicos**, não deveres *morais* ou *sociais*, por mais prementes que, no caso, eles possam surgir à consciência comunitária. E isto ainda mesmo quando ao tríptico da lei, do contrato e da ingerência passaram, a partir da terceira década do séc. XX, a acrescentar-se — de forma largamente consensual, embora não de todo isenta de contestação — as situações de **estreita comunidade de vida e de perigos**.

§ 19 Esta teoria **formal** dos deveres de garantia pode dizer-se hoje, em quase toda a parte (23), doutrinal e jurisprudencialmente abandonada. Logo que uma compreensão naturalista e positivista do jurídico, em particular do direito penal, foi substituída pela matriz da referência a valores própria da orientação neokantiana, viu-se com extraordinária clareza que ela assentava em fundamentos insubsistentes. E isto, basicamente, porque acabava por renunciar de modo integral à consideração dos *conteúdos* dos deveres que assim se criavam; revelando-se de todo incapaz de proporcionar um qualquer *elemento material delimitador* (24), numa palavra, um qualquer **critério material de ilicitude** da inobservância do dever de actuar.

§ 20 Ao que acresce ter-se revelado profundamente ilusória a certeza e a segurança — e a própria clareza — que esta teoria proporcionava (25). Desde logo, quanto à posição de garante assente na **lei**. Na verdade, mesmo quando o dever de actuar para defesa dos bens jurídicos ou dos interesses de outrem resulta imediatamente da lei, pode acontecer que ele não fundamente sempre uma posição de garante da não verificação do resultado típico. Esse será sobretudo o caso das hipóteses em que o dever de actuar é consagrado por uma lei *extra-penal* que não deva sem mais ser arvorada em fonte de uma posição *penal* de garante da não produção de um resultado típico (26).

---

(23) Cf., em todo o caso, o referido art. 11.º do CP espanhol (supra, 37.º Cap., § 28).

(24) Nestes precisos termos, muito justamente, JESCHECK / WEIGEND, § 59, IV, 2.

(25) No sentido que se segue correu sempre o nosso ensino; cf., também, DIAS, Figueiredo, Pressupostos da punição e causas que excluem a licitude e a culpa, *JDC 1963*, p. 55 e s.

(26) Assim, já, MEZGER, p. 144, e, agora, ROXIN II, § 32, n.º 11 e s.

§ 21 O mesmo se dirá do **contrato** como fonte de responsabilidade pela comissão por omissão. Nem o contrato tem sempre — apesar de p. ex., ter sido validamente estabelecido para protecção de bens jurídicos ou de interesses de pessoa(s) determinada(s) — a virtualidade de só por si fundar uma posição de garante: se alguém é contratado para velar pela segurança de uma excursão de esquiadores e falta na hora aprazada, não pode ser jurídico-penalmente responsabilizado pela morte ou pelos ferimentos sofridos por um dos excursionistas. Nem, inversamente, a invalidade do contrato furta necessariamente responsabilidade ao omitente: se uma *baby-sitter* se obrigou — ainda que por contrato jurídico civilmente inválido, *e. g.*, por incapacidade ou por erro contratuais — a cuidar de um bebé durante a ida dos pais ao cinema, se deixa que o bebé se fira com gravidade no berço porque a sua atenção está toda centrada num programa televisivo, ou porque abandona a casa e o bebé logo que chegou a hora em que terminava a sua vinculação contratual e os pais ainda não regressaram a casa, ela poderá vir a ser criminalmente responsabilizada pelo resultado ocorrido. Nos casos apontados, a situação do guarda da excursão ou dos pais do bebé deve ser atalhada através de uma eventual responsabilização jurídico-civil, não dando ao contrato efeito directo e imediato sobre a responsabilidade por comissão por omissão.

§ 22 Menos clara parece ser ainda a fundamentação da posição de garante, nos casos de **ingerência** e nos de **estreita comunidade de vida ou de perigos**, em um dever *formalmente* jurídico de actuar. Um dever jurídico *formal* — pode dizer-se — inexistirá pura e simplesmente na generalidade destes casos, tornando-se assim impossível responder às questões aqui suscitadas pela fundamentação da posição de garante: à questão de saber quais os *requisitos* que deve assumir o facto anterior perigoso para que ele possa desencadear a responsabilidade do agente a título de comissão por omissão, no primeiro caso; ou a de saber quais os requisitos indispensáveis para, no segundo caso, tornar em dever jurídico deveres que, à partida, surgem como deveres simplesmente morais ou sociais.

2. A teoria das funções

§ 23 Reconhecidas hoje, de forma largamente consensual, as fraquezas e insuficiências de uma teoria formal do dever jurídico de garantia, as doutrinas e as jurisprudências voltam-se decididamente para uma con-

cepção **material**, que permita ligar a infracção daquele dever a um sentido de ilicitude material ([27]). A palavra decisiva pertenceu aqui a Armin Kaufmann, através da concepção que ficou conhecida por **teoria das funções** e segundo a qual os deveres de garantia se fundam ou numa função de **guarda de um bem jurídico concreto** (criadora de deveres de *protecção* e *assistência*) ou numa função de **vigilância de uma fonte de perigo** (determinante de deveres de *segurança* e de *controlo*). No primeiro grupo — onde cabem deveres como os dos pais relativamente a um filho menor, ou os dos guardas de um museu relativamente aos objectos de arte ali expostos — o bem jurídico carente de guarda deve ser protegido contra *todos* os perigos englobáveis no âmbito de protecção. No segundo grupo — onde entram deveres como o do controlador do tráfego aéreo relativamente à movimentação dos aviões — o garante tem unicamente de fiscalizar fontes de perigo *determinadas* ([28]).

§ 24 A doutrina alemã mais recente apresenta diversas variantes desta teoria central de Armin Kaufmann, as quais todavia, em nosso entender, não a modificam no essencial ([29]); delas dar-se-á aqui notícia da de Jakobs e da de Schünemann (que recebeu agora de Roxin uma concordância praticamente integral ([30])). Jakobs distingue entre "**deveres por força de uma competência institucional**" (como será o caso das relações pai/filho ou entre cônjuges, das relações de confiança, de deveres elementares dos funcionários) e "**deveres por força de competências de uma organização**" (p. ex. deveres de segurança do tráfego, ingerência, aceitação de deveres) ([31]). Por seu turno, Schünemann arvora em critério central o "**domínio sobre o motivo do resultado**"; critério que subdivide depois em "**relações de guarda pelo desamparo do bem jurídico**", por um lado, e em "**domínio material sobre o foco dos perigos**", por outro. Num e noutro caso sendo sempre decisivo o *domínio facticamente exercido* seja sobre o objecto, seja sobre a fonte do acontecimento lesivo ([32]).

([27]) Cf. só, com indicações concordantes, JESCHECK / WEIGEND, § 59 IV 2 e ss.

([28]) KAUFMANN, Armin, nota 8, p. 283 e ss.

([29]) Isto mesmo confessa ROXIN II, § 32, n.º 17 e s., em atenção aos resultados práticos a que tais variantes conduzem. No sentido essencial exposto, também, SILVA, Marques da, II, p. 52: "a posição de garante pode enquadrar-se em dois tipos fundamentais: *posição de protecção* e *posição de controlo*". No mesmo sentido uma parte significativa da doutrina italiana, pela qual pode ver-se FIANDACA / MUSCO, p. 449.

([30]) ROXIN II, § 32, n.ºs 8 e 17 e ss. Para outras variantes, LEITE, André, nota 3, p. 177 e ss.

([31]) JAKOBS, 28/14 e ss. e 29/101 e ss.

([32]) SCHÜNEMANN, nota 20, Die Unterlassungsdelikte und die strafrechtliche Verantwortlichkei für Unterlassungen, *ZStW 96*, 1984, p. 287 e ss., e, por último e em síntese, Die Strafbarkeit der juristischen Personen aus deutscher und europäischer Sicht, *Madrid-Symposium Tiedemann*, 1995, p. 72 e ss.

3. Uma teoria "material-formal"

§ 25 Persistimos na convicção ([33]) (acompanhando uma concepção que, pese às suas divergências de pormenor, é coonestada por um sector importante da mais moderna dogmática alemã da omissão ([34])) de que uma correcta desimplicação e concretização dos deveres de garantia deve alcançar-se pela **conjugação**, em uma certa direcção e com um determinado sentido, das teorias material e formal. Não mais pode considerar-se correcto, por um lado, *dissolver* os deveres de actuação dos agentes da comissão por omissão e da posição de garante da não produção do resultado que deles deriva em uma série de *fontes de deveres jurídicos positivos* que funcionam como um quadro vinculante, que em caso algum pode ser ultrapassado, como era entendimento da doutrina clássica. A verdadeira fonte dos deveres e das posições de garantia reside em algo muito mais profundo, a saber, na valoração autónoma da ilicitude material, completadora do tipo formal, através da qual a comissão por omissão vem a equiparar-se à acção na situação *concreta*, por força das exigências de **solidariedade** do homem para com os outros homens dentro da comunidade. Caso em que será a "proximidade existencial do 'eu' e do 'outro'", o princípio dialógico do "ser-com-os-outros" e "ser-para-os-outros", o exercício da virtude cristã da "caridade" e do "amor do próximo" (ou como quer que prefiramos exprimir-nos) que *criam* os deveres e as posições de garantia.

§ 26 Só que, por outro lado, o ser assim não pode significar a substituição, a nível do tipo de ilícito, de deveres que têm de surgir como especificamente *jurídicos* (e, na verdade, reduzidos ao estritamente necessário e, deste modo, a deveres primários e essenciais de actuação), por um qualquer quadro de *concepções morais* que valeriam mediatamente como deveres jurídicos: **toda a manifestação imposta de solidarismo tem de se apoiar em um claro vínculo jurídico**. Isto significa que toda a consideração deve ser perspectivada a partir de um sentido de ilicitude material, como se verifica com a "teoria das funções"; a essa luz se repensando o catálogo (agora alargado, relativamente ao tradicional) e a classificação dos deveres jurídicos de garante. Isto implica a utilização de um método não casuístico, mas tipológico, cujos resultados só poderão ser aqui expostos nos seus traços essenciais ([35]).

([33]) Cf. já, neste sentido, no essencial, os nossos *O Problema*, p. 511, e Pressupostos da punição e causas que excluem a ilicitude e a culpa, *JDC 1963*, p. 54.

([34]) JESCHECK / WEIGEND, § 59, IV, 2, com indicações concordantes.

([35]) Com uma construção e uma exposição pormenorizadas depara-se agora em ROXIN II, § 32, n.ºs 33-217.

3.1. Deveres de protecção e assistência a um bem jurídico carecido de amparo

§ 27 Os deveres de protecção e assistência a bens jurídicos desamparados podem provir por um lado de relações de protecção familiares ou análogas, por outro de estreitas relações de comunidade (nomeadamente, dentro de uma estrutura organizada), por outro lado ainda da assunção voluntária de uma função de protecção ou de guarda de bens jurídicos determinados. Necessário para a existência de um dever de garante é, *em qualquer destes casos*, a existência de **relações fácticas** — no sentido da aludida proximidade sócio-existencial — entre aquele sobre quem a lei faz recair um certo dever e o bem jurídico lesado pelo resultado, nomeadamente, a existência de uma situação real de **dependência** deste em relação àquele. Isto porque o omitente deve ser responsável, numa medida elevada, pelo bem jurídico carente de protecção. Assim resultando claro, insiste-se, que é a relação fáctica que fundamenta o dever de garantia, não qualquer eventual prescrição legal em que aquela se reflicta; por isso também podendo o dever de garantia ir *mais longe* do que aquilo que é expressamente estatuído pelas prescrições legais ([36]).

3.1.1. Relações de protecção familiar e análogas ([37])

§ 28 O âmbito mais indiscutível em que se estabelecem posições de garante por força de deveres de protecção e assistência é o das relações **pais / filhos**. Não se tornando hoje indispensável, de acordo com os princípios estabelecidos, invocar a consagração legal deste dever (todavia existente, em certos termos, no art. 1874.º do CC), mas simplesmente a unívoca relação de solidariedade natural entre o omitente e o titular do bem jurídico. Relação, de resto, que persiste, se bem que em termos mais limitados, na *ausência física* dos pais e que por isso não tem por si de excluir a posição de garante. Esta relação cessa ou atenua-se juridicamente, por outra parte, logo que o filho abandona o âmbito de protecção dos pais; ou quando os pais se separam, encarregando-se apenas um deles da protecção e assistência do filho. Numa outra vertente — sem prejuízo

([36]) Exactamente nestes termos conclusivos, STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 21.

([37]) Pormenorizadamente sobre o que se segue, ROXIN II, § 32, n.ºs 33-52, e CUNHA, Damião da, nota 14, p. 508 e ss.

da necessidade de que os filhos gozem, segundo a sua idade e condição, de um âmbito de liberdade e de responsabilidade na condução da vida —, tanto o pai como a mãe têm um dever de garante não apenas de carácter pessoal, mas também *patrimonial*. Dever que subsiste relativamente *a cada um* dos pais, mesmo quando o perigo provém do outro: exemplar a este último propósito (e quaisquer que sejam as dúvidas que, de um ponto de vista teorético, a decisão suscite ([38])), o Ac. da RC de 1-6-1988 ([39]), que condenou por homicídio por omissão a mãe que teve plena consciência de que a conduta do pai — dando a beber vinho em que misturava veneno — conduziria necessariamente à morte do filho e, podendo tê-la contrariado ou impedido, nada fez nesse sentido.

§ 29 O referido art. 1874.º do CC estende o dever de respeito, auxílio e protecção à relação **pais / filhos**. Donde poderia ser-se tentado a transferir para esta sede legal o que acabou de referir-se quanto à relação pais / filhos. Em todo o caso, tal só deverá ser feito, no plano jurídico-penal, quando esta relação seja **particularmente próxima** (exigindo a coabitação, mas não só) e, para além disto, quando no caso possa afirmar-se aquela relação de **dependência** (do progenitor) que, como vimos, dá conteúdo à posição de garante. Esse terá sido o caso julgado pelo STJ no seu Ac. de 9-7-2003, que condenou o filho por homicídio por omissão da sua mãe de 80 anos, com quem vivia, que se encontrava acamada e a quem durante 12 dias não alimentou nem providenciou para que alguém o fizesse ([40]). Reconhecidos estes pressupostos materiais de ilicitude — e, se necessário, ainda mais fortemente limitados —, não haverá razão para que a posição de garante não se estenda a outras relações familiares, máxime, *avós / netos*, *irmãos*, eventualmente (e cada vez com maiores

([38]) Sobre elas, CUNHA, Damião da, nota 14, p. 507 e s.

([39]) *CJ XIII-3*, 1988, p. 110 e ss.

([40]) *CJ STJ XI-2*, 2003, p. 240 e ss. Dada a extraordinária proximidade entre o decidido e a fundamentação teórica proposta pelo texto, será de interesse transcrever o sumário da referida decisão: "I — Pratica um crime de homicídio por omissão o arguido que, vivendo com a vítima que é sua mãe, tem 80 anos de idade e está acamada, durante 12 dias não lhe deu qualquer tipo de alimento, nem providenciou para que alguém o fizesse; ausentou-se de casa, bem sabendo que a vítima não tinha possibilidade de se alimentar, desse modo aceitando e conformando-se com a ideia de que tal abstenção lhe poderia causar, como causou, a morte. II — A relação de proximidade existencial em que se encontrava o arguido (filho) com a vítima (mãe), colocando-a na sua própria e exclusiva dependência, criou no arguido o dever jurídico de protecção e assistência, tornando-o pessoalmente responsável pela vida da vítima".

dúvidas) *cunhados, sogros, genros ou noras, primos*. Mas já é duvidoso que ela deva abarcar os simples *namorados* ou mesmo *noivos*, desde que a sua situação de vida não seja análoga à dos cônjuges (cf., a seguir, § 30).

§ 30 Indiscutível deve considerar-se igualmente o dever de protecção e assistência entre **cônjuges** ou entre quem viva **em situação análoga**. Sendo indiferente que aquele dever se considere ou não directamente apoiado por lei expressa (cf., em todo o caso, o art. 1672.º do CC), porquanto, também aqui, decisivas são as relações fácticas de solidariedade, resultantes de uma **comunidade de vida** efectivamente existente: são estas relações que oferecem o *fundamento* e, do mesmo passo, as *limitações* do dever e das posições de garante respectivas. Assim se compreenderá que estas posições sejam, por força da larga autodeterminação da vida que a cada um dos cônjuges pertence, *muito menos extensas* do que as que vimos caberem à relação pais / filhos. Mas já se compreenderá, inversamente, que o rompimento da relação afectiva não aniquile tais posições enquanto a comunidade de vida persistir. Tudo dependerá, em tais hipóteses, do *grau de expectativa legítima*, conhecida por ambos os cônjuges e avaliada de modo objectivo, de qualquer deles poder ainda contar com a actuação do outro em situações de perigo. Se, *v. g.*, os cônjuges desavindos continuam a residir no mesmo local tão-só por razões económicas e inexiste a aludida relação de confiança, deverá ser negado o dever de garante. Numa palavra, será incorrecto ligar *ipso facto* e *ipso iure* a ruptura da vida conjugal à inexistência de uma obrigação de evitar a produção do resultado lesivo ([41]).

3.1.2. Assunção de funções de guarda e assistência

§ 31 Um segundo fundamento de uma posição de garante radica na assunção por ele de funções de guarda e assistência a bens jurídicos do carente de protecção ou de terceiro em favor do carente ([42]). Trata-se no fundo e no essencial da tradução, a nível de uma teoria "material", do velho fundamento "formal" do *contrato*, em todo o caso com a modificação quase radical de sentido que atrás lhe introduzimos. O que oferece fundamento ao dever e à posição de garante não é a existência de uma relação contratual (válida), mas sim a **assunção fáctica** de uma função de

([41]) LEITE, André, nota 3, p. 221 e ss.

([42]) Assim e, no essencial, como se segue, JESCHECK / WEIGEND, § 59, IV, 3, *c*).

protecção materialmente baseada numa **relação de confiança**. O dever de garante abrange, *v. g.*, a situação do instrutor de natação que vem ocasionalmente substituir aquele que se obrigou a dar as lições, com a respectiva função de guarda e assistência dos alunos; tanto mais quanto deve entender-se, em geral, que a transmissão lícita de deveres a terceiros liberta da posição de garante o primitivo titular. Releva, ainda aqui, de forma particular a circunstância de o carente de protecção *confiar* na disponibilidade interventora do garante, assim se sujeitando a riscos acrescidos ou dispensando outra protecção ([43]).

§ 32 Inúmeros **exemplos** a propósito ([44]) são fornecidos pela jurisprudência alemã, para além do acima referido do instrutor de natação: o alpinista que se prontifica a dirigir uma excursão à montanha; o médico relativamente à saúde e bem estar dos seus pacientes ([45]); o médico de cabeceira, apesar da vontade de suicídio do paciente; o empresário relativamente à retenção de impostos; etc. Todavia, a doutrina alemã queixa-se em geral de um *exagerado alargamento jurisprudencial* do dever de guarda e assistência aqui em causa, nomeadamente, se bem entendemos, na medida em que deixa valer imediatamente como deveres jurídicos meros deveres morais ou sociais e esquece por vezes a relação fáctica de *assunção* do dever que oferece a base material da posição de garante.

§ 33 Neste contexto parece poderem (e deverem ([46])) caber as questões relativas a **autoridades** e **funcionários** que tenham por tarefa precípua velar por um especial círculo de interesses e, nesta medida, afastarem perigos para bens jurídicos de terceiros e da colectividade. Uma posição de garante pela não verificação de resultados típicos parece ser aqui, **em princípio, de afirmar**. Tanto mais quanto, em múltiplos casos desta ordem, é a *lei* a pôr a cargo das autoridades e funcionários competentes para velar oficialmente por um específico círculo de interesses um dever jurídico-público geral de impedir resultados lesivos. Também aqui, todavia,

---

([43]) Assim, pela doutrina hoje dominante na Alemanha, JESCHECK, § 59, IV, *c)*. Uma valorização maior do *contrato* enquanto fonte do dever de garantia em STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 22 e ss.

([44]) Referidos por JESCHECK / WEIGEND, loc. cit. Outras referências em ROXIN II, § 32, n.º 53 e ss.

([45]) Pormenorizadamente, ROXIN II, § 32, n.º 70 e ss.

([46]) Anote-se todavia que ROXIN II, § 32, n.º 77 e ss., forma com estas hipóteses um apartado autónomo face à "assunção de funções de protecção". Como no texto, pela maioria da doutrina alemã, JESCHECK / WEIGEND, § 59, IV, *c) in fine*; e, entre nós, LEITE, André, nota 3, p. 231 e ss., de novo com uma ampla casuística.

um apelo directo a uma fundamentação legal, ao gosto da teoria formal, seria desajustado e, em definitivo, criticável. Por um lado, uma fundamentação legal expressa não é indispensável, podendo o dever resultar com clareza do âmbito funcional de actuação devida. Por outro lado, mesmo onde uma tal fundamentação de um dever geral de actuar exista, há que afirmar que uma posição de garante de autoridades e funcionários só deve afirmar-se quando o concreto bem jurídico carenciado de protecção lhes está **confiado de forma imediata**, de tal modo que a sua incolumidade dependa, em situações de directa necessidade, da acção daqueles.

§ 34 Assim, haverá que afirmar *como regra* o dever de garante, p. ex., da **polícia** relativamente a concretos bens jurídicos do cidadão que àquela cabe assistir; como também (mesmo onde se trate de bens jurídicos colectivos) o dever das **autoridades e funcionários encarregados da protecção do meio ambiente** de evitar a poluição de águas, solos, etc. Mas nem por isso deverão considerar-se, também como regra, titulares de posições de garante, *v. g.*, o ministro da justiça ou do ambiente, ou o director geral da polícia criminal ou do ambiente ou urbanismo relativamente a bens jurídicos, individuais ou colectivos, que não se encontravam na sua esfera directa e imediata de protecção e assistência. Isto parece dever afirmar-se claramente num momento em que entre nós se assiste a tentativas larvares — sobretudo dos *media* e da opinião pública — de transformar o que pode ser uma responsabilidade *política* ou *disciplinar* em responsabilização jurídico-*penal* por omissão.

3.1.3. Comunidade de vida e de perigos

§ 35 A generalidade das doutrinas e das jurisprudências aceita hoje a comunidade de vida e de perigos como susceptível de conferir fundamento a deveres de garante de um bem jurídico desamparado. Decisivo seria em todo o caso, também aqui (como no grupo anterior: supra, § 31 *in fine*), que, por força das relações de **confiança** e de **dependência mútuas** que no grupo se estabelecem, se corram riscos acrescidos ou sejam dispensadas outras medidas de protecção ([47]). Já uma significativa minoria doutrinal, porém, considera **dispensável** a autonomização deste grupo de hipóteses, defendendo que elas ou cabem na assunção de funções de guarda e assistência ([48]), ou se distribuem entre este grupo, o das relações familiares e análogas ou mesmo também eventualmente o da ingerência ([49]).

([47]) Assim, claramente, JESCHECK / WEIGEND, § 59, IV, 3, *b)*.

([48]) Assim, ROXIN II, § 32, n.º 54.

([49]) Cf. STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.ºs 38 e ss. e 42.

§ 36 Parece-nos duvidoso haver razão bastante para a autonomização da "comunidade de vida", mas já a haver para a "comunidade de perigos" ([50]). Aqui é o carácter arriscado do empreendimento, conjuntamente reconhecido e aceite (a excursão à montanha, a prática de desportos radicais, a descida de um rio turbulento, etc.), que cria *em cada um* dos participantes um dever de garantia face a *todos* os restantes; o que, cremos, não poderá sem mais ser confundido com as situações anteriormente consideradas de assunção de uma *função* de protecção ([51]). Isto não significa, obviamente, que o dever de garante nasça integralmente da existência da comunidade, antes só (como sempre!) dentro de certos *pressupostos* ou *requisitos*. Torna-se por isso necessário — por mor da indispensável segurança e paz jurídicas e para que deveres puramente morais, de "bom samaritano forçado", não valham como deveres jurídicos — fazer intervir uma tríplice condição ([52]): (a) que as relações intercedentes aludidas sejam **estreitas** e **efectivas** e não meramente dedutíveis de um qualquer "segundo código" moral ou social; (b) que, de certo modo consequentemente, a comunidade de perigos exista **realmente** e não seja meramente deduzida de uma "proximidade" suposta ou presumida; (c) e que se não estenda esta fonte até ao limite da prevenção *geral* de perigos, mas entre em questão apenas quando o perigo **já pesa** sobre a vítima potencial, devendo o agente actuar no sentido de o evitar ou diminuir (devendo, numa palavra, actuar *em favor do bem jurídico concretamente carenciado*).

3.2. Deveres de vigilância e segurança face a uma fonte de perigos

§ 37 Os deveres de garante neste apartado em consideração — e que repousam na consideração material da **proximidade do garante com**

([50]) Diferentemente, LEITE, André, nota 3, p. 203 e ss., autonomiza a categoria da "comunidade de vida", introduzindo nela, como simples parte integrante, as "relações familiares ou análogas". A diferença é muito mais sistemática e de simples ordenação, que material. Verdade é que, na ampla casuística que André Leite apresenta, mal conseguimos identificar um só caso que na sua e na nossa exposição devesse ser decidido de modo diferente. Negando aqui, todavia, um dever de garante, por inexistência de um dever jurídico, CARVALHO, Taipa de, II, § 993, parece reduzir o dever jurídico a um puro dever de natureza legal.

([51]) Deve reconhecer-se, por outro lado, que em toda esta matéria se verifica um (inevitável) cruzamento e parcial sobreposição de fundamentações de um singular dever de garante. Cf., de resto, infra, § 56, JESCHECK / WEIGEND, § 59, IV, 5, e LEITE, André, nota 3, p. 208.

([52]) Nestes termos, STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 38 e ss.

uma fonte de perigos — são muito **mais estreitos** do que os anteriormente estudados e resultantes de posições de protecção e assistência a determinados bens jurídicos. Bastará ter em atenção que enquanto nos casos até aqui considerados o dever de garante conduz à exigência de defesa do bem jurídico desamparado contra *toda a es*pécie de situações que possam afectá-lo, no grupo ora em análise o garante está vinculado ao controlo e vigilância *apenas* da fonte de perigos ([53]). Também este grupo pode ser subdividido em três espécies de situações.

3.2.1. O dever de obstar à verificação do resultado por força de uma acção anterior perigosa ("ingerência")

§ 38 A doutrina hoje largamente dominante nos países da nossa tradição jurídico-cultural aceita, com maior ou menor latitude e com maiores ou menores reservas ([54]), a existência de deveres de garantia resultantes de um facto anterior perigoso: quem cria o perigo que pode afectar terceiros ("ingerência") deve cuidar de que ele não venha a actualizar-se num resultado típico. Todavia, se a questão constitui, em último termo, um problema de ilicitude e se esta é sempre uma ilicitude *pessoal* e não meramente causal, então deve ter-se por seguro que a causação de um perigo, em si mesma considerada, é incapaz de fundar um dever de garantia e a consequente posição de garante. A questão principal reside pois em saber quais os **requisitos** que deve assumir o facto anterior perigoso para que ele possa desencadear a responsabilidade do agente a título de comissão por omissão.

§ 39 O facto prévio consistirá em regra numa acção, mas pode também analisar-se numa **omissão** violadora do dever. Se um passante é atingido e ferido pela queda de um telhado em mau estado, que o proprietário deveria ter já mandado compor, pode ter este de responder pela verificação do resultado típico.

§ 40 Postas as coisas nestes termos, parece seguro que o resultado típico tem antes de tudo de considerar-se **objectivamente imputável**,

---

([53]) Um aprofundamento das especificidades deste plano da posição de garante face ao anterior em LEITE, André, nota 3, p. 266 e ss. (2).

([54]) Como são expressas, por exemplo, por SCHÜNEMANN, *Grund und Grenzen der unechten Unterlassungsdelikte*, 1971, p. 317 e ss. E agora de algum modo também, entre nós, CUNHA, Damião da, nota 14, p. 495 e s.

segundo as regras gerais, ao incumprimento do dever de garante. Por isso não assume uma posição de garante aquele que com o seu facto precedente se contém *dentro* dos limites do risco permitido. Como também quando, ultrapassando-os, todavia não é o risco assim criado, mas *um outro*, que se precipita no resultado típico; ou quando a conexão de risco deva ser negada por o comportamento prévio não caber no fim de protecção da norma.

§ 41 A doutrina maioritária entende que, para além da aludida exigência de imputação objectiva, a criação do perigo tem ainda de ter sido, ela própria, objectivamente **ilícita**, embora não culposa, pelo que não poderia fundar uma posição de garante sempre que o comportamento prévio se encontrasse justificado. **Isto é em princípio exacto**; mas não vale para comportamentos justificados por **estados de necessidade**, bem podendo apelar-se, como fundamento deste restrição, ao princípio geral, que deve valer também aqui, da *auto-responsabilidade do colocado em perigo* (55). Neste caso o acontecimento não reside, ao contrário do que sucede, p. ex., na *legítima defesa*, no âmbito de responsabilidade do lesado, que não participou de nenhum modo na criação do perigo; pelo contrário, o agente em estado de necessidade interveio no âmbito de liberdade de uma pessoa a quem não cabe qualquer responsabilidade pelo estado de necessidade (56).

3.2.2. O dever de fiscalização de fontes de perigo no âmbito de domínio próprio

§ 42 Sem prejuízo de cruzamentos sempre possíveis, a fonte de posições de garante agora em consideração só terá razão bastante para ser autonomizada na medida em que possa considerar-se com independência relativamente à das funções de protecção ou à de um comportamento peri-

---

(55) ROXIN II, § 32, n.os 175 e s., 178. Princípio que valeria autonomamente — resta, em todo o caso, saber se sem limitações... — para casos como o da *autocolocação em perigo dolosa* (supra, 12.º Cap., § 38).

(56) Assim, já, DIAS, Figueiredo. A propósito da "ingerência" e do dever de auxílio nos crimes de omissão, *RLJ 116*, 1983, p. 56, e CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, I, art. 200.º, § 16. Parece-nos nesta medida excessiva a afirmação de CUNHA, Damião, nota 14, p. 495, de que "a ingerência lícita *nunca* poderia fundar uma qualquer responsabilização pelo resultado" (s. n.). Seja como for, fica em aberto, nos casos de ingerência lícita, a questão da eventual responsabilização por omissão de auxílio, nos termos do art. 200.º Sobre a questão, por último, LEITE, André, nota 3, p. 280 e ss.

goso anterior. O seu **fundamento material** geral residirá em que a comunidade tem de poder confiar em que quem exerce um *poder de disposição* sobre um âmbito de domínio ou sobre um lugar determinado, que se encontram acessíveis a outras pessoas, deve também dominar os riscos que para estas podem resultar de estados ou de situações perigosas ([57]).

§ 43 **Exemplos**. Esse será o caso de empresários, industriais, comerciantes e, em geral, de possuidores de estabelecimentos e instalações que devem conservar em condições de segurança para trabalhadores e para a generalidade das pessoas, evitando acidentes. Como será o caso de donos de veículos motorizados que devem conservá-los em condições de segurança. Como ainda o de donos de animais que devem fiscalizá-los em vista dos perigos que deles partam. Discutido é o caso de donos ou usuários de habitações: uma posição de garante poderá ser-lhes atribuída apenas relativamente a perigos *especiais* que daquelas partam, porquanto a casa de habitação — mesmo desabitada! — não é, em si mesma, uma fonte de perigos.

§ 44 A formulação doutrinal geral do princípio em análise, segundo a qual "o proprietário ou possuidor de coisas, instalações, máquinas, está obrigado a controlar os perigos que delas provêm e a impedir, em consequência, que se produzam danos em bens jurídicos alheios" ([58]) (chamada *Zustandshaftung*, "responsabilidade pela situação") revela-se-nos a alguns propósitos *demasiado lata*, a outros *demasiado estreita*. Compreende-se e aceita-se o **fundamento** em que a ideia repousa: quem domina uma fonte de riscos determináveis dentro de um âmbito de actuação objectivável deve actuar no sentido do afastamento ou da minimização dos perigos que daquela resultam tanto para o exterior (*v. g.*, perigos de incêndios), como para o interior, quando terceiros nela penetrem (*v. g.*, perigo de desmoronamento de uma ponte em construção). Mas já se não vê que deste fundamento resultem como deviam, do mesmo passo, os **limites** do âmbito de actuação do princípio.

§ 45 Por um lado, a formulação do princípio referida parece abranger os casos em que só por **casualidade** (ou até *inesperadamente*, ou mesmo *ilicitamente*) alguém penetra no âmbito de domínio do dono, possuidor, gerente. Em casos tais será seguramente ir demasiado longe man-

---

([57]) Nestes precisos termos e sobre a casuística que se segue, JESCHECK / WEIGEND, § 59, IV, 4, *b)*. Cf., depois, ROXIN II, § 32, n.º 108 e ss., e, em termos algo diferentes — acentuando a característica do domínio "organizacional" —, CUNHA, Damião da, nota 14, p. 516 e ss.

([58]) Com esta formulação se depara, p. ex., em S / S / STREE, § 13, n.º 43.

ter sobre estes o dever de vigilância e o consequente dever de actuação no sentido da eliminação ou da minimização do perigo. Se o responsável por uma construção coloca um letreiro absolutamente visível a proibir a passagem a estranhos à obra e, ainda, uma cerca a impedir a passagem, não pode ser responsabilizado se alguém salta a cerca ou a destrói para penetrar na construção e em consequência sofre danos pessoais; não sendo talvez inadequado invocar neste contexto o "princípio da auto-responsabilidade" ou mesmo o "princípio da confiança" (supra, 35.º Cap., § 28 e ss.).

§ 46 Por outro lado, e inversamente, o princípio parece querer restringir-se a factos ocorridos dentro de uma certa actividade **duradoura** (a palavra alemã "*Zustands*haftung" é disso sinal inequívoco). Isto sucede obviamente, com frequência, no exercício de actividades económicas, no âmbito da indústria, da empresa, do negócio, no "domínio organizacional". Assume aqui um particular relevo, de resto, todo o amplo domínio — hoje importantíssimo e típico da "sociedade do risco" — da **responsabilidade do produtor** ou **pelo produto**: quem fabrica medicamentos, automóveis, produtos de beleza, produtos alimentares, produtos tóxicos ou corrosivos, etc., detém sobre o produto uma posição de domínio — baseada sobretudo em que ele será o *único* que se encontra suficientemente informado sobre os riscos, mesmo só colaterais, do produto que fabrica — que o responsabiliza por aquele e põe a seu cargo um dever de fiscalização conducente a evitar situações mesmo só potencialmente lesivas de bens jurídicos do consumidor. (A maior dificuldade desta questão reside nos casos — de que é exemplo paradigmático o caso alemão, já muitas vezes citado, do "Lederspray" — em que o carácter perigoso do produto não é cognoscível segundo um juízo *ex* ante, mas só o vem a ser *ex post*.) Pôr nestas situações sobre os ombros do produtor um dever de *retirar* o produto, ou pelos menos de *avisar* dos perigos os consumidores potenciais, responsabilizando-o, se o não fizer, a título de omissão dolosa pelo resultados típicos que venham a ter lugar — eis o que nos parece uma conclusão razoável, suficientemente precisa e, em definitivo, fundada.

§ 47 Roxin interroga-se sucessivamente sobre se a posição de garante do produtor deve ser reconduzida ao facto anterior, eventualmente com risco aumentado, à lei, a um dever de controlo ou à assunção de uma função de protecção. Para concluir, referindo a opinião mais recente de Schünemann, que a posição de garante (independentemente do cruzamento possível de várias fontes) deriva aqui em princípio da "**assunção de uma função de protecção**" ligada à competência empresarial para

efeito de retirada do produto ou de indicação das precauções a tomar pelo consumidor (59).

3.2.3. O dever de garante face à actuação de terceiros

§ 48 Em princípio se diria não existir qualquer dever de garante face à actuação de terceiros, uma vez que esta deve ser atribuída à sua **auto-responsabilidade**. Todavia, este princípio deve *ceder* face a certas situações especiais. E esse será desde logo o caso em que **o terceiro**, por motivos vários, ou **não é responsável** ou **tem a sua responsabilidade limitada ou diminuída**. Nestes casos se aceitará que a ordem jurídica ponha o cumprimento de um dever de vigilância, relativamente ao irresponsável ou responsável limitado, a cargo de quem exerce sobre ele um poder de domínio e de controlo. Assim, os *pais* assumirão, perante os seus filhos dependentes, não só uma posição de garante de protecção e assistência (supra, § 28), mas também um dever de vigilância e segurança relativamente a perigos que deles partam. O mesmo deverá dizer-se da *direcção e pessoal de estabelecimentos de internamento* destinados a doentes mentais ou ao cumprimento de penas privativas da liberdade ou de medidas análogas. Como ainda, de uma forma geral, dos *professores* de crianças ou adolescentes menores, ou de *instrutores* de qualquer espécie (de trabalhos oficinais, de condução automóvel, de internato médico, etc., nomeadamente em vista da prática de factos negligentes que os alunos possam cometer: cf. já supra, 35.º Cap., § 32) (60).

§ 49 A outra razão que pode, eventualmente e em casos muito determinados, conduzir à existência de um dever de garante por factos de terceiros reside em **relações de supra / infra ordenação** (e consequente de

---

(59) ROXIN II, § 32, n.os 195-217, com extensa indicação doutrinária e jurisprudencial. Cf., entre nós, DIAS, Silva, *Protecção Jurídico-Penal dos Interesses dos Consumidores*, ²2001, p. 69 e ss. (que, depois de criticar a solução da ingerência, fala com propriedade de uma radicação do dever de garante no "domínio de um âmbito de perigos"), e Entre "comes e bebes": debate de algumas questões polémicas no âmbito da protecção jurídico-penal do consumidor, *RPCC 8*, 1998, p. 577 e ss., e — acolhendo-se a sugestões de SCHÜNEMANN, Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal e de política criminal acerca de la criminalidad de la empresa, *ADPCP* 1998, p. 372 — ALBERGARIA, Soares de, A posição de garante dos dirigentes no âmbito da criminalidade da empresa, *RPCC 9*, 1999, p. 617 e ss. Cf., sobre a questão, também, KUHLEN, nota 17. Na conclusão, num sentido próximo ao do texto, STRATENWERTH /KUHLEN, § 13, n.º 49.

(60) Sobre estes exemplos, ROXIN II, § 32, n.º 127 e ss.

autoridade / subordinação) de pessoas — embora plenamente responsáveis — que actuam no seio de um serviço ou de uma actividade organizada. Muitas vezes será a própria lei a induzir clara ou mesmo expressamente um tal dever de garante, máxime, tratando-se do exercício de importantes funções de interesse nacional (*v. g.*, elementos das forças armadas e militarizadas com poderes de direcção) ([61]). O problema discute-se por isso, sobretudo, relativamente a uma eventual responsabilidade jurídico-penal por omissão das **pessoas que dirigem e fiscalizam a actividade empresarial privada**, face a factos ilícitos cometidos pelos seus subordinados. Ainda aqui tem vindo a nossa lei a apontar para um tal dever de garante, *v. g.*, no que respeita a membros de órgãos directivos e de fiscalização de sociedades anónimas. Parece por isso, em princípio, que deveres desta espécie podem estender-se, sem receio de insuportável insegurança jurídica, a toda a actividade empresarial privada: "o pessoal dirigente deve cuidar de que a 'fonte de perigos' 'empresa' permaneça sob controlo de segurança, partam os perigos do potencial material ou pessoal da empresa" ([62]).

3.3. As ditas "posições de monopólio"

§ 50 Já em 1975 sustentávamos que uma hipótese muito particular das posições de senhorio ou de domínio era constituída por aqueles casos que designámos "posições de monopólio" ([63]). Queríamos com isto significar que as posições de senhorio ou de domínio de uma fonte de perigo se não ficam pelos âmbitos duradouros da propriedade ou posse de empresas, de instalações de instrumentos, etc. Antes se verificam igualmente em situações as mais diversas e "instantâneas" (digamos que "criadas pelo destino ou pelo acaso"), sem que daí deva derivar dúvida sobre o bom fundamento de pôr sobre os ombros de quem se encontra, ainda que fortuita ou acidentalmente, numa **posição de domínio fáctico absoluto da**

([61]) Entre nós, mais de espaço, LEITE, André, nota 3, p. 299 e ss. Contra, não admitindo o dever de garante, por falta de um dever jurídico *pessoal* do ente colectivo, CARVALHO, Taipa de, II, § 994.

([62]) Assim, ROXIN II, § 32, n.os 134 e ss., 137, referindo todavia, em seguida, uma posição diferenciadora de GIMBERNAT Ordeig, Unechte Unterlassung und Risikoerhöhung im Unternehmensstrafrecht, *Roxin-FS*, 2001, p. 656, mas acabando por afastar-se dela. Entre nós ALBERGARIA, Soares de, nota 59.

([63]) Cf. os nossos *Sumários de Lições*, 1975, p. 211. Cf., depois — em todo o caso em termos notoriamente mais estreitos —, STRATENWERTH, *Derecho Penal, PG, I*, 1982, n.º 1020 (tradução espanhola da 2.ª ed. alemã por Gladys Romero, 1982).

fonte de perigo, um claro dever de garante (64). O transeunte ocasional numa rua praticamente deserta deve fazer parar um invisual notório que se propõe atravessá-la em condições em que será provavelmente atropelado. O passeante solitário num parque deve erguer uma criança muito pequena que caiu num minúsculo lago e que, apesar da altura insignificante da água, corre o risco sério de afogar-se (65). Em casos destes, para tornar indiscutível o fazer pesar sobre o *dominus* da situação um dever de garante, tudo o que deve — mas tem também *sempre* de — exigir-se é que *(a)* o agente esteja efectivamente investido, mesmo que só por força de circunstâncias ocasionais, numa posição de *domínio fáctico* absoluto e próximo da situação; *(b)* que o perigo em que incorre o bem jurídico seja *agudo e iminente*; e que *(c)* o senhor da situação possa levar a cabo a acção esperada — em regra, uma acção de salvamento — sem ter de incorrer numa *situação perigosa ou danosa para si mesmo*.

§ 51 Concordando com as soluções que se encontram na linha deste nosso entendimento, vem André Leite sustentar que o "verdadeiro fundamento (jurídico e pessoal) do dever de acção, nos casos em exame, reside na **abissal desproporção entre o bem jurídico em perigo e o esforço exigido ao omitente no decurso do processo salvador.** Desta forma se ligaria esta concepção às tentativas, já antigas, mesmo entre nós (66), de *"juridificação" do dever cristão de solidariedade*; se revelaria que o dever de acção não se constitui apenas, nestas situações, nos casos em que cabe a *uma única pessoa* a possibilidade de encetar o processo salvador; e se haveria de concluir que o problema deve suscitar-se apenas quando estão em perigo *bens jurídicos pessoais* de grande relevo. Por estas vias sendo conduzidos à consequência de que este ("novo") plano de funda-

(64) Esta nossa opinião recebeu a concordância, quanto à conclusão, de COSTA, Faria, Omissão (Reflexões em redor da omissão imprópria), *BFD 72*, 1966, p. 397 e ss., anotando que, para além da "imprescindível presença física do omitente na situação desencadeadora do resultado desvalioso", o dever de garante em causa pode louvar-se da sua reflexão no plano *legal*, concretamente, no disposto no art. 402.º do CC sobre *obrigações naturais* e no imperativo de "justiça" que nele se contém. Contra esta fundamentação legal, CUNHA, Damião da, nota 14, p. 487.

(65) Também nestas situações, que exemplifica precisamente com esta hipótese de salvamento, CARVALHO, Taipa de, II, § 993, afasta o dever de garante, por considerar não existir um dever jurídico.

(66) LEITE, André, nota 3, p. 252 e ss., citando a respeito a evolução do pensamento de Beleza dos Santos, nas suas *Lições* de 1936 e de 1955, e a posição de Eduardo Correia nas *Actas*, I, p. 146 e s.

mentação de um dever de garante não tem que ver com a contenção de fontes de perigo, mas sim com a *protecção de bens jurídicos carecidos de amparo*: porque somente neste âmbito aquele plano "surge como fundamento autónomo de preenchimento de um elemento do tipo-de-ilícito objectivo dos delitos omissivos impróprios" ([67]).

§ 52 A ideia-fundamento que André Leite põe assim na base deste plano em que devem procurar-se os deveres de garantia jurídicos e pessoais a que se refere o art. 10.º-2 merece-nos aceitação. É, na verdade, repetimos, para estas **situações-limite e só para elas** — para situações de perigo agudo e iminente para bens jurídicos de valor cimeiro na ordem axiológica constitucional e que possam ser salvos com um pequeno esforço do agente — que desde sempre pensámos o valor de equiparação da omissão à acção em nome do que chamámos "posições de monopólio". Designativo porventura — facilmente o aceitamos — destituído de rigor, se bem que tivesse sido nossa intenção apontar por esta via a outra ideia-fundamento nesta matéria: a posição de domínio fáctico pleno e absoluto, por parte de uma pessoa, da situação de perigo e, por aí, a da possibilidade de sem esforço lhe pôr fim ou para tanto contribuir adequadamente. Deve porém reconhecer-se que essa pessoa não tem de ser *a única* a deter aquele domínio, antes pode tratar-se de uma pluralidade — em princípio, em todo o caso, restrita e rigorosamente definida ([68]) — de pessoas, desde que qualquer uma delas domine em absoluto a situação e tenha a mesma possibilidade (e o mesmo custo) de intervenção.

([67]) LEITE, André, nota 3, p. 260. Procurando densificar o critério, o A. faz depender a sua aplicação do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: *a)* tratar-se de bens pessoais; *b)* assumir um cariz subsidiário (apenas quando nenhum outro plano do dever de garante se aplique à concreta factualidade); *c)* a desproporção entre o bem jurídico em perigo e o esforço exigível ao omitente ser *abissal, ostensiva, patente, desproporcionada* (apropriando-se, aqui, em toda a plenitude, o princípio do *in dubio pro reo*); *d)* carácter actual e iminente do perigo; *e)* proximidade física do agente em relação à vítima, existência de condições fácticas de intervenção e imputação, à luz da teoria da conexão do risco, do resultado à inacção; *f)* o agente não pode ter provocado o perigo (seria hipótese de ingerência) e *g)* razoabilidade de o ordenamento jurídico exigir ao indivíduo, à luz da prevenção geral positiva, que actue no sentido de evitar a lesão de bens jurídicos, no âmbito de uma "função propulsora" que também se liga, em alguma medida, ao direito penal.

([68]) Temos, por exemplo, as maiores dúvidas que no (tristemente) famoso *caso Kitty Genovese*, ocorrido em Nova Iorque em 13-3-64 (sobre ele, entre nós, DIAS / ANDRADE, p. 183), pudesse, no nosso sistema, pôr-se o homicídio (e a violação sexual) da vítima na responsabilidade penal por omissão das 38 pessoas (!) que comprovadamente poderiam ter telefonado à polícia e evitado assim, possivelmente, os resultados típicos.

§ 53 Mantemos todavia reserva (69) quanto à consideração deste plano de equiparação da omissão à acção como atinente à **assistência a um bem jurídico carecido de amparo e não ao controlo de uma fonte de perigo.** Não, decerto, em nome de razões puramente formais-sistemáticas, mas dogmático-materiais, que contendem sobretudo com o carácter muito mais amplo — não necessariamente atinente nem à existência de uma concreta fonte de perigo, nem à verificação de um perigo agudo e iminente — que assume o dever de acção nos casos autênticos de assistência a um bem jurídico carecido de amparo. Podendo, então sim, pôr-se a questão de saber se a previsível contestação teorético-doutrinal com que a proposta aqui feita deve deparar não se fortalecerá com qualquer tendência para a estender *para além das situações-limite* acima referidas. Tanto mais quanto surgirá nesse caso como mais compreensível o argumento — todavia em definitivo insubsistente (70) — de que se trata aqui de uma tentativa larvar de conceber como de omissão impura, imputando-a ao art. 10.º, casos que só podem relevar na medida em que constituam o crime puro de omissão de auxílio previsto no art. 200.º

4. A verificação, no caso, de uma pluralidade de deveres de garante

§ 54 Já na exposição anterior vimos como pode frequentemente verificar-se um cruzamento ou uma cobertura, parcial ou total, de uma pluralidade de deveres de garante, com diversa fonte, que no caso converge. Um **concurso de deveres de garante** só reforça a exigência de que tenha lugar a acção imposta, esperada ou devida, com evidentes consequências possíveis em tema de medida da pena, eventualmente de negação da atenuação especial do art. 10.º-3 (supra, 37.º Cap., § 31 e ss.).

III. "Posição" de garante e "dever" de garante

§ 55 Ao tipo de ilícito objectivo dos crimes de omissão pertencem, em suma, a situação típica, a ausência da acção imposta, devida ou esperada e a possibilidade individual de acção; elementos a que acrescem, nos crimes impuros de omissão, o resultado típico objectivamente imputável à omissão e a **posição** do omitente **de garante da não verificação do resultado**.

---

(69) Já evidenciada na 1.ª edição desta obra, 31.º Cap., § 49.

(70) Como com razão sustenta LEITE, André, nota 3, p. 264 e ss.

§ 56 A doutrina tradicional sustentava que não apenas a *posição* de garante, antes sim também o próprio *dever* de garante que em qualquer crime de omissão, impróprio ou próprio, recai sobre o omitente constituía um elemento (*normativo*) do tipo objectivo de ilícito dos crimes omissivos ([71]). Correcto é porém (como hoje o reconhece a doutrina absolutamente dominante ([72])) distinguir — o que apenas se torna dogmaticamente importante nos crimes impróprios de omissão — os **pressupostos materiais** que fundamentam o dever de garante, e de cujo conjunto resulta a **posição** de garante, do **dever** de garante enquanto tal. Só os primeiros pertencem ao tipo de ilícito objectivo dos crimes impróprios de omissão, não o dever de actuar que deles resulta: este é, tal como nos delitos de acção, um elemento ou momento do próprio juízo de ilicitude, não um elemento normativo do tipo. Correspondentemente, também nos crimes próprios de omissão pertence ao tipo apenas a indicação do comportamento imposto, não o dever de o levar a cabo.

IV. O tipo de ilícito subjectivo

1. O dolo do tipo omissivo

§ 57 Existe unanimidade na doutrina em que, também relativamente ao crime de omissão, deve distinguir-se o dolo e a negligência enquanto formas do tipo de ilícito subjectivo. Mas já são inúmeras as dissidências quando se trata de determinar como se concebe o dolo do tipo, dolo do facto ou dolo natural, desde logo quanto a saber se ele apresenta a mesma **estrutura** que nos crimes de acção. Já mal se divisam hoje seguidores da orientação (a que se aludiu supra, 37.º Cap., § 2) — própria da doutrina ortodoxa da acção final, sobretudo de Armin Kaufmann — segundo a qual se não poderia conceber um "verdadeiro dolo" nos crimes omissivos, por não haver neles, da parte do omitente, o "emprego da vontade" de realização típica: de tudo quanto poderia falar-se seria de um "**quase-dolo**", justificando-se a aplicação da moldura dolosa logo que o omitente, apesar do conhecimento do perigo, não tomou ou não manteve a decisão de evitar a realização do tipo objectivo de ilícito ([73]). A doutrina hoje largamente

([71]) Assim, por outros, ENGISCH, Die normativen Tatbestandselemente im Strafrecht, *Mezger-FS*, 1954, p. 158, acompanhando uma então significativa parte da jurisprudência alemã.

([72]) Já, entre nós, CORREIA, Eduardo, I, p. 418, e, depois, DIAS, Figueiredo, *O Problema*, § 22, VI, 4.

([73]) Assim, KAUFMANN, Armin, nota 8, pp. 66 e ss. e 220.

dominante pretende, diferentemente, transportar em toda a medida possível para a omissão o conceito de dolo do tipo válido para a acção: necessário é que o omitente **conheça**, através da sua consciência intencional, a situação típica e omita a acção imposta com **vontade** de que se preencha o tipo objectivo; e, na verdade, parece perfilar-se por esta via um processo psicológico ou psíquico correspondente àquele com que se depara nos delitos de acção. Mas as dificuldades a superar, no contexto da omissão, são muitas, nomeadamente, quanto ao momento da "decisão" e quanto ao conhecimento e representação da "posição de garante".

1.1. O problema da "decisão"

§ 58 Pode desde logo acontecer, com efeito, que o omitente, tendo representado a situação típica, **tome a decisão** de permanecer inactivo. O pai que, lendo um jornal na praia, vê o seu filho pequeno entrar em dificuldade na arrebentação, decide não intervir com o propósito de que ocorra a morte por afogamento. A *baby-sitter* que se apercebe de que o bebé à sua guarda entrou em graves dificuldades respiratórias, talvez porque o lençol se enrolou à volta do seu pescoço, decide permanecer sentada vendo um programa de televisão, plenamente se conformando com a possibilidade, que representou, de o bebé morrer sufocado. Em casos deste teor o conhecimento e a vontade deixam comprovar-se e decidir-se com praticamente a mesma segurança com que tal sucederia nos delitos de acção correspondentes.

§ 59 Diz-se porém que, deste modo — reduzindo a decisão a hipóteses como as apontadas —, se privilegia inadmissivelmente, negando o dolo, todo aquele que nem sequer *decide* omitir a acção esperada porque a realização do tipo lhe é de todo *indiferente*, apesar do conhecimento total da situação que possui. O que só poderia ser obviado através de "ajustamentos" ou "adaptações" na estrutura do dolo de omissão, que, em fim de contas, acabaria com bastar-se com que o agente tivesse representado a possibilidade de realização do tipo objectivo de ilícito e, *apesar disso, não tivesse actuado* ([74]). Mas não cremos que tenha de ser assim. O dolo do tipo, como se assinalou a propósito dos crimes dolosos de acção (supra, 13.º Cap., § 45), supõe uma decisão de lesão possível do bem jurí-

([74]) Fundamentalmente, nestes termos, GRÜNWALD, Der Vorsatz der Unterlassungsdelikte, *H. Mayer-FS*, 1966, p. 286, e JESCHECK / WEIGEND, § 59, VI, 2, *b*).

dico, que se traduz em o agente ter actuado apesar de contar seriamente com a possibilidade de realização típica como consequência do seu comportamento, assim se conformando com esta. Também nos crimes de omissão a estrutura da "decisão" é análoga: o autor **omite a acção imposta, apesar de contar seriamente com a possibilidade de realização típica, com esta assim se conformando**. Nisto reside, como bem sublinha Stratenwerth, a "equivalência" com a estrutura do dolo nos crimes de acção (75). A esta luz, muitas das discussões referidas surgem com valor meramente lógico-formal e terminológico, que não normativo e material.

1.2. O conhecimento ou representação da "posição de garante"

§ 60 Do lado intelectual do dolo do tipo o problema mais complexo é o de saber como deve este conexionar-se com o dever de garante que sobre o omitente recai. Atento o que supra, § 56, se expôs sobre os *pressupostos materiais* que constituem a posição de garante e a distinção entre esta e o respectivo *dever*, torna-se indiscutível que **só aqueles pressupostos materiais**, na sua individualidade e no seu conjunto ("posição de garante") — não o dever de garante como tal — **constituem ponto de conexão idóneo do dolo do tipo**, quer dizer, só eles precisam de reentrar no momento intelectual do dolo omissivo, e como tal só eles precisam de ser conhecidos ou representados pelo omitente para que o momento intelectual do dolo do tipo se afirme.

§ 61 Por isso mesmo se deve concluir que um **erro sobre os pressupostos materiais do dever de garante** (ou, o que é o mesmo, um erro sobre a **posição** de garante) não permite que o agente se oriente suficiente e correctamente para o problema da ilicitude (no qual reentra o dever de garantia como tal). Deste modo, um tal erro **exclui o dolo**, nos termos do art. 16.º-1. Diferentemente, se o agente representa correctamente a totalidade daqueles pressupostos materiais e todavia não toma consciência do dever que, em consequência, sobre ele recai, uma tal falta de consciência constitui um **erro sobre a ilicitude** que deixa **subsistir o dolo,** mas pode **excluir a culpa,** nos termos do art. 17.º-1 (76). Exemplo do primeiro caso

(75) STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.os 72 e 76, e, substancialmente, no mesmo sentido, ROXIN II, § 31, n.º 188.

(76) Assim, já, entre nós, CORREIA, Eduardo, I, p. 418, e DIAS, Figueiredo, *O Problema*, § 22, VI, 4.

será o do pai que não procede ao salvamento de um seu filho criança em risco de afogar-se porque supõe erroneamente que se não trata de um filho seu, mas de um estranho; do segundo caso o do pai que deixa o seu filho, que como tal reconhece, morrer afogado porque supõe que a sua paternidade não o investe no dever jurídico de garantia do seu salvamento.

1.3. Outras questões

§ 62 Em toda a restante matéria atinente ao dolo do tipo não parece intercederem especialidades ou dificuldades particulares em caso de omissão, face ao que se passa com os crimes de acção. Tal como nestes, tratando-se de crimes de resultado, o omitente tem de **prever o resultado** ao menos como consequência *possível* da sua não-intervenção, não assumindo por isso relevo autónomo a representação do *perigo* da produção do resultado típico (77). Como tem obviamente de representar a **acção exigida ou imposta** cuja ausência, como vimos, conforma o essencial do tipo de ilícito objectivo. Finalmente — tal como sucede, uma vez mais, nos crimes dolosos de acção —, o omitente, quando representa como possível a realização do tipo e, apesar disso, não actua, tem de se **conformar** com aquela possibilidade (art. 14.º-3): as dificuldades aqui em verdade subsistentes põem-se em termos correspondentes àqueles em que vimos (supra, 13.º Cap., § 48 e ss.) suscitar-se a questão nos crimes dolosos de acção.

2. Elementos especiais do tipo subjectivo doloso

§ 63 Tal como vimos (supra, 13.º Cap., §§ 3 e 60 e ss.) suceder nos crimes dolosos de acção, também o tipo subjectivo dos crimes dolosos de omissão pode conter *especiais* elementos subjectivos. Nos crimes próprios de omissão, como tais descritos na lei, não haverá dificuldades específicas a ultrapassar, tudo dependendo da descrição legal típica respectiva. Nos crimes impróprios de omissão a questão, na sua revelação mais geral, reside em saber se os elementos especiais do tipo subjectivo dos crimes de acção devem (ou podem) ser transpostos sem mais para os crimes de omissão. Uma **equiparação geral parece afastada**, tudo dependendo da interpretação dos concretos tipos legais de crime e surgindo por isso a questão como própria da PE.

---

(77) Cf., em todo o caso, STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 76.

§ 64 Já se pretendeu todavia que tal seria à partida impossível quando o tipo correspondente de acção exigisse uma **intenção** como finalidade própria da acção; porquanto na omissão falta, por definição e pela própria natureza das coisas, uma intervenção da vontade dirigida à modelação do acontecimento. O que teria a consequência grave de a equiparação da omissão à acção dever ser negada em todos estes casos, neles se tratando então de hipóteses em que, nos termos do art. 10.º-1, *in fine*, teria sido "outra a intenção da lei". Cremos porém que ainda aqui uma **realidade equivalente à da intenção** e a consequente "correspondência da omissão à acção" poderá ser, em muitos casos — de que o do crime de burla será só porventura o mais notável (78) —, encontrada a nível interpretativo (79).

V. Os tipos justificadores

§ 65 Sustenta Roxin que, em matéria de delitos omissivos, as relações entre tipicidade e ilicitude assumem características profundamente diferentes do que vimos suceder nos delitos de acção; logo porque, ao menos em via de princípio, quando a omissão se encontra justificada é isso desde logo sinal seguro de que **um dever de acção não existe**. Pelo que nos delitos de omissão deveria partir-se de um **tipo de ilícito conjunto** que abrange a tipicidade e a ilicitude. Dada a forma como nos manifestámos em sede de relações entre a tipicidade e a ilicitude (supra, 10.º Cap., § 50 e ss.), seríamos tentados a dizer que é precisamente isso que sucede nos delitos de acção, com o princípio que defendemos de prioridade da ilicitude sobre a tipicidade. Em rigor se dirá mesmo que, nos crimes de comissão por omissão a totalidade do rendimento dogmático dos conceitos de tipo e de ilicitude só se logra, em último termo, através de um juízo globalizante. Com efeito, da necessidade de conjugar os dois números do art. 10.º em um só juízo de ilicitude resulta a especial interpenetração entre o tipo e o ilícito: a equiparação do *non facere* ao *facere*, constituindo um problema de antinormatividade (essencialmente) objectiva, só é lograda pelo recurso a uma posição de garantia cuja existência contende com a tipicidade (e, nessa medida, com o princípio da lega-

(78) Cf., entre nós, COSTA, A. M. Almeida, *Comentário Conimbricense*, II, art. 217.º, § 21; e, agora, sobre este e outros exemplos, para confirmar a ideia do texto, ROXIN II, § 31, n.º 184 e s.

(79) Também, STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 80.

lidade ([80]). Mas, como quer que seja quanto a esta questão, é verdade que as causas de justificação estudadas nos delitos de acção serão as mais das vezes irrepresentáveis nos delitos de omissão (caso exemplar, o da legítima defesa). As excepções cifrar-se-iam, ainda segundo Roxin, no *direito de necessidade* e no *conflito de deveres* ([81]). Quanto ao primeiro, no entanto, não se descortinam diferenças notáveis de regime entre os delitos de acção e os delitos de omissão. Quanto ao segundo relembre-se que já sobre ele nos pronunciámos supra, 16.º Cap., § 37 e ss.

B. O TIPO DE ILÍCITO NEGLIGENTE

§ 66 Que os crimes de omissão possam ser também imputados a título de *negligência* é coisa que, como acima anotámos, ninguém põe em dúvida. Como também que eles possam e devam distinguir-se ainda em **próprios** e **impróprios**, se bem que aqueles sejam extremamente raros (podendo todavia avançar-se como exemplo o crime de omissão, por negligência, de declarações ou informações relativas à aplicação do regime de preços em vigor ou ao movimento das empresas para efeitos de fiscalização, quando exigidas por lei ou pelas entidades competentes: art. 34.º-2 e 4 do DL 28/84, "Infracções contra a economia e a saúde pública"). Crimes de omissão impróprios existirão, diferentemente, sempre que seja possível a equiparação da omissão à acção e a punição desta seja expressamente prevista pela lei a título de negligência. Por outro lado, no que toca à extensão e às fontes do **dever de garante**, é aplicável aos crimes negligentes de omissão, sem especialidades notáveis, a doutrina que atrás foi exposta a propósito dos crimes dolosos de omissão.

§ 67 A **estrutura** típica da negligência nos crimes de omissão é, em princípio, a mesma que assume nos crimes de acção. Isto considerado, podem nesta sede individualizar-se possibilidades várias de conformação do tipo de ilícito omissivo negligente ([82]): este, por violação do cuidado objectivamente necessário, ou derivou de o garante não se ter apercebido, ou não se ter apercebido correctamente da situação típica (e portanto do perigo que obrigava à sua intervenção activa), ou de ele ter errado sobre a sua possi-

---

([80]) Salienta este ponto, correctamente, LEITE, André, nota 3, p. 136.

([81]) ROXIN II, § 31, n.º 201 e ss.

([82]) Cf., só, JESCHECK / WEIGEND, § 59, VII, 2, e ROXIN II, § 31, n.º 196 e ss.

bilidade individual de acção, ou de se não ter representado a sua posição de garante, ou de ter levado a cabo defeituosamente a acção (de socorro) devida.

§ 68 A especificidade que merece maior realce em toda esta matéria — e que é, na verdade, anotada pela generalidade da doutrina — provém da circunstância de na maioria destes casos se verificar uma **interpenetração do dever de garantia e do dever de cuidado**: ambos se determinam e se delimitam reciprocamente ([83]); sem que por isso, todavia, deixe de assistir razão a Jescheck quando sublinha que um e outro "hão-de diferenciar-se conceitualmente para medir com acerto o seu alcance em cada caso" ([84]). Assim, por exemplo, saber se o responsável pela obra de construção de uma ponte a revestiu da segurança e da vigilância adequadas a impedir que alguém sofra danos pessoais depende da sua posição de garante. A questão de determinar até onde pode ir na assunção dos perigos depende das regras do cuidado devido.

§ 69 Dúvidas se têm suscitado, por fim, quanto a saber se a **cognoscibilidade** da posição de garante é suficiente para fundamentar o tipo de ilícito negligente, ou se deve exigir-se um conhecimento **actual** da mesma ([85]). A primeira solução parece-nos, a todos os títulos, a correcta e a única compatível com a estrutura e o sentido da negligência ([86]): em caso de posição de garante, a violação do dever de cuidado deve referir-se não apenas à realização do tipo, mas também aos perigos de onde aquela realização pode resultar. No exemplo apresentado por Welzel — o pai que deixa um seu filho criança ser arrastado pelas ondas porque não toma o cuidado de ver se é o seu filho, uma vez que o deixou em casa a bom recato —, deve afirmar-se que, segundo a experiência comum e a normalidade do acontecer, a posição de garante não é sequer cognoscível. Mas já o será — e a negligência deve, nesta parte, ser afirmada — se a criança brinca à beira de água e, por desatenção, o pai a toma por alguém que não é o seu filho.

([83]) Fundamental, GALLAS, *Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der am Bau Beteiligten*, 1963, p. 32 e ss.

([84]) JESCHECK / WEIGEND, § 59, VII, 3.

([85]) Neste sentido, WELZEL, § 28 B.

([86]) Assim, JESCHECK / WEIGEND, § 59, VII, 3, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 16, n.º 5 e s.

39.º CAPÍTULO

O TIPO DE CULPA DOS CRIMES DE OMISSÃO

§ 1 Em princípio, regem aqui — com *especial idoneidade*, porque na culpa se não trata de realidades "psicológicas" ou "naturais", antes todo o essencial se situa no plano da atitude interna, da personalidade e das suas qualidades, e da censura que sobre elas deve recair — regras paralelas às que valem para os crimes de acção.

I. O tipo de culpa doloso

1. A fundamentação da culpa

§ 2 Quanto ao tipo de culpa doloso, deve ele ser definido exactamente da mesma forma por que o é nos crimes de acção: como atitude interna do omitente, documentada no facto, de **contrariedade** ou **indiferença** pelo dever-ser jurídico-penal. Aqui reside o elemento "emocional" do dolo da culpa" e, assim, o *fundamento da falta de consciência do ilícito censurável* (art. 17.º). Quem, apesar de representar, ao nível da consciência intencional, todos os elementos indispensáveis a uma correcta orientação da consciência ética para o desvalor da ilicitude (nomeadamente os pressupostos materiais que conformam a sua *posição* de garante), todavia a não alcança, responde a título de dolo apesar da falta de consciência do ilícito (nomeadamente, a falta de consciência do *dever* de garante) que atinge o seu comportamento omissivo.

§ 3 Para insistirmos em exemplos já referidos supra, 38.º Cap., § 61, o pai que foi passear com o seu filho pequeno à praia, apercebe-se de que este, que brinca à beira-mar, corre o risco de se afogar; todavia não vai buscá-lo, continuando indiferente a ler o seu jornal, porque supõe, ao nível da sua consciência dos valores, que não tem o dever jurídico de agir. Se a criança vem a morrer por afogamento o pai comete, por omissão, um crime *doloso* de homicídio. O erro em que versou não respeita aos

pressupostos materiais donde deriva a sua *posição* de garante (erro que excluiria o dolo: art. 16.º-1), mas sobre o próprio **dever** de garante que daquela posição resulta (falta de consciência do ilícito censurável: art. 17.º-2). O mesmo sucederá, de resto, tratando-se não do pai, mas de um estranho, se este era a única pessoa no lugar onde a criança se meteu no mar e aquele podia salvá-la sem nenhum prejuízo ou especial incómodo para si (dever de garantia fundado em uma "posição de monopólio": supra, 38.º Cap., § 50 e ss.).

§ 4 O último dos exemplos apontados mostra o bom fundamento da afirmação, corrente na maioria dos autores, de que uma falta de consciência do ilícito omissivo pode ocorrer com **maior frequência** do que nos delitos de acção correspondentes (1). Não haverá praticamente uma possibilidade de alguém poder credivelmente fazer valer em tribunal a alegação de que, num caso de homicídio por acção com dolo do tipo, agiu com falta de consciência (directa) do ilícito. Mas tal já é compreensível relativamente a um homicídio com dolo do tipo por omissão, fundado em posições de garante não inteiramente interiorizadas ainda, ao nível da consciência ética, por largos estratos da população, isto é, que podem dizer-se ainda não incluídas na consciência ética geral. Ao que acresce que nos delitos de acção, como vimos, a representação da situação típica oferece logo estímulo e impulso para que se tome consciência do ilícito (supra, 20.º Cap., § 26 e s.), enquanto que nos de omissão um tal estímulo e impulso será, com frequência, mais fraco e nebuloso (cf. infra, § 5).

2. A exclusão da culpa

§ 5 No que respeita à **inimputabilidade** (arts. 19.º e 20.º) nada haverá a referir de específico relativamente aos crimes omissivos. E o mesmo se diga quanto ao **critério de não-censurabilidade da falta de consciência do ilícito** (art. 17.º-1): um tal critério deve ser, sem alteração, aquele que preconizámos para os crimes dolosos de acção (supra, 23.º Cap.). Todavia, neste contexto ganha a sua verdadeira importância o argumento que avançámos supra, § 4. Com efeito, é compreensível e aceitável que, com muito maior facilidade e frequência do que nos delitos dolosos de acção, nos de omissão se depare com faltas de consciência da ilicitude **não censuráveis**. Bastará ponderar a variedade das fontes de criação de deveres de acção, a circunstância de eles poderem não encontrar claro e per-

(1) Cf., só, JESCHECK / WEIGEND, § 60, I, 3, e ROXIN II, § 31, n.º 209.

ceptível reflexo na lei nos delitos impuros de omissão e, sobretudo, de certos deles poderem não corresponder ainda claramente à consciência ética geral. O processo histórico de determinação dos deveres de garante encontra-se (como se viu no capítulo anterior) ainda em curso, não está de forma alguma cristalizado e pode, por conseguinte, dar lugar a distonias sensíveis entre a consciência jurídica dos valores e a preparação da consciência ética de cada um para lhes responder. De tudo resulta assim a **muito mais duvidosa e controvertível valoração ético-social que pode caber aos deveres de acção do que aos de omissão**, de forma muito particular no que toca aos chamados factos (omissões) de consciência (cf. supra, 24.º Cap., § 13) (2). Como resulta, numa palavra, que com muito maior frequência se deparará com hipóteses em que, apesar da falta de consciência do ilícito, no omitente persiste uma *atitude geral de fidelidade ao direito* — uma "consciência ética *recta*" — que desculpará o seu erro.

§ 6 Mais discutida na doutrina é a questão da **inexigibilidade** nos factos dolosos de omissão. Desde logo, em certos crimes *próprios* de omissão, por vezes é o próprio tipo legal a inserir uma cláusula material de inexigibilidade mais lata do que a que pode ser aceite como causa de exclusão da culpa. O que nessas hipóteses estará em questão será sobretudo qualificar dogmática e sistematicamente uma tal cláusula; tanto mais quanto (como já ficou assinalado supra, 26.º Cap., § 7) a inexigibilidade, para além de conformar o pensamento fundante de algumas causas de exclusão da culpa, constitui um *princípio regulativo* que se estende praticamente a todas as categorias integrantes do conceito de facto punível e, antes de todas, à do ilícito-típico (3). Por isso mesmo ficará próxima a asserção (4) de que nestes casos, em princípio, se trata de uma **inexigibilidade vinculada ao tipo de ilícito**. Com uma manifestação da circunstância referida se depara, p. ex., no n.º 3 do art. 200.º, segundo o qual "a omissão de auxílio não é punível quando (...), por outro motivo relevante, o auxílio lhe [ao omitente] não for exigível". Esta referência à inexigibilidade não é inútil (5)

(2) Anote-se que, inclusivamente, para certos autores só os factos omissivos, não as acções, poderiam gozar do privilégio próprio dos factos de consciência: cf. PETERS, Überzeugungstäter und Gewissenstäter, *H. Mayer-FS*, 1966, p. 276 e ss.

(3) HENKEL, Zumutbarkeit und Unzumutbarkeit als regulatives Rechtsprinzip, *Mezger-FS*, 1954, p. 249.

(4) Cf. JESCHECK / WEIGEND, § 59, VIII, 2, com extensas indicações doutrinais.

(5) Decididamente contra, CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, I, art. 200.º, §§ 23 e 29.

porque dá, em nossa opinião, muito claramente a entender aquilo que acima quisemos significar quando falámos de inexigibilidade "vinculada ao tipo".

§ 7 Nos delitos *impróprios* de omissão a situação é mais complexa. Na doutrina dominante pode divisar-se uma tendência para **alargar o domínio da inexigibilidade** face ao que sucede nos crimes de acção, até ao ponto de não faltar jurisprudência alemã que pretende elevá-la à categoria de cláusula **geral** de exclusão da culpa. Com o argumento de que — como o demonstraria entre nós o art. 10.º-3, ao *permitir* uma *atenuação especial* da pena só pelo facto de se tratar de um crime de omissão —, apesar da equiparação de princípio da omissão à acção, a gravidade do conteúdo ilícito daquela é, em regra, inferior à desta. Esta inferior gravidade deveria ter assim o seu reflexo ao nível da censura da culpa; e a forma por excelência de a tomar em conta residiria numa utilização mais liberal do pensamento da inexigibilidade (6).

§ 8 Mas esta argumentação **não parece dever ter-se por inteiramente concludente**. A diminuição do conteúdo de ilícito e de culpa do comportamento omissivo é tomada em conta através da atenuação especial facultativa, pelo que não deve servir simultaneamente para decidir se o facto deve ser punido a título de dolo ou ficar impune. E tão-pouco parece proceder a tentativa de construir uma inexigibilidade geral como princípio de delimitação do dever de garante. Como bem sublinha Jescheck, "ao garante cabe o dever de evitar o resultado da mesma forma que ao autor da acção correspondente cabe o dever de o não provocar com o seu comportamento positivo" (7). A conclusão deve ser pois a de que a inexigibilidade só pode actuar nos crimes de omissão — tal como sucede nos crimes de acção — nos casos especificamente previstos na lei, máxime, no caso do art. 35.º e dentro do regime nele estabelecido (8). Tudo quanto pode ainda ficar em aberto é a possibilidade de *atenuação especial* da *pena* por se tratar de facto omissivo, nos termos do art. 10.º-3 (supra, 37.º Cap., § 31 e ss.).

---

(6) Seguem, na doutrina, a aludida direcção jurisprudencial alemã, S / S / STREE, antes do § 13, n.º 156, e RUDOLPHI, *SK*, antes do § 13, n.º 31.

(7) JESCHECK / WEIGEND, § 59, VIII, 3.

(8) Não no caso do art. 33.º, uma vez que, tal como dissemos ser praticamente impensável uma legítima defesa por omissão, também o será um excesso de legítima defesa.

II. O tipo de culpa negligente

§ 9 No que se refere ao tipo de culpa negligente, também ele deve ser definido da mesma forma por que o é nos crimes de acção: como atitude interna do omitente, documentada no facto, de **descuido** ou **leviandade** perante o dever-ser jurídico-penal. Ainda aqui, pois, a materialidade do tipo de culpa negligente omissivo acrescentada ao conteúdo do tipo de ilícito respectivo reside na atitude interna descuidada ou leviana revelada pelo omitente que fundamenta o facto e, por essa via, nas qualidades desvaliosas da pessoa que no facto se exprimem. Ora, dissemos supra (36.º Cap., § 5), e devemos aqui repeti-lo, o elemento material específico do tipo de culpa negligente traduz-se em que o omitente, para que seja punível por negligência, tem não apenas de violar o cuidado objectivamente imposto, mas ainda de não evitar o resultado apesar de aquele se apresentar como **pessoalmente cognoscível** e este como **pessoalmente evitável**: só nesta medida se pode afirmar que ele documentou no facto qualidades pessoais de descuido ou leviandade pelas quais tem de responder.

40.º CAPÍTULO

A TENTATIVA E A COMPARTICIPAÇÃO

§ 1 Considerando tudo quanto ficou exposto neste Título, bem se aceitará que também os temas da *tentativa* e da *comparticipação* convidem a uma sua consideração específica relativamente aos crimes de omissão.

I. Preparação e tentativa

1. Admissibilidade da tentativa

§ 2 Face ao **texto do art. 22.º-1**, dir-se-ia que a tentativa de um crime de omissão, puro ou impuro, não pode ser punível, logo porque ela constitui um comportamento que não cabe no seu teor literal. Aquele preceito, na verdade, afirma que tentativa existe apenas quando o agente "*pratica*" actos de execução, enquanto a omissão se traduz em mera *inactividade* e, por conseguinte, na *ausência da prática* de actos de qualquer espécie. A impunidade da tentativa de um crime de omissão constituiria, deste modo, uma directa implicação do *nullum crimen sine lege* (1). Todavia, relativamente aos crimes de omissão impuros, o art. 10.º equipara expressamente — vimos em que termos, com que sentido e sob que condições (supra, 37.º Cap., § 20 e ss.) — a omissão à acção nos casos em que o tipo legal de crime de acção proíbe a produção de um certo resultado. Tanto basta para que, sem violação do princípio da legalidade, se possa e deva defender que no processo omissivo se podem descortinar inacções "preparatórias" e "de execução" dolosamente dirigidas à produção de um resultado típico. Nesta medida se depara com omissões que, nos termos do art. 10.º, suposta

---

(1) Dúvidas de análoga índole, a propósito da antiga versão do § 43 do CP alemão, foram referidas por HERZBERG, Das Versuch beim unechten Unterlassungsdelikt, *MDR*, 1973, p. 89.

a susceptibilidade de equiparação do seu conteúdo à acção "correspondente", podem legalmente integrar o conceito e a doutrina da tentativa.

§ 3 No entanto, também de um ponto de vista **dogmático-construtivo** não falta quem negue a possibilidade de uma tentativa de omissão, na base de que nesta, como "grandeza negativa", não poderia falar-se nem de resolução criminosa, nem de decisão de cometer um crime, nem (sobretudo) de *dolo*: a punição a este título teria lugar simplesmente na base de o agente *não ter tomado a resolução* de evitar a realização típica; tanto mais quanto até ao momento daquela realização não poderia afirmar-se que o omitente violou o dever de garante da não realização do tipo (2). Já tivemos, no entanto, ocasião de nos dissociarmos de todo este entendimento (supra, 38.º Cap., § 57 e ss.): na omissão — tanto na pura, como na impura — existe uma constelação normativa *equivalente* (quer ao nível do tipo de ilícito, quer ao do tipo de culpa) à que se verifica nos delitos de acção (3). Nada pois, também desta perspectiva, estará em definitivo contra a possibilidade de se aceitar uma tentativa de omissão imprópria quando o omitente, pelo menos, se conforma com que o resultado típico possa ter lugar como consequência da sua inactividade (4).

§ 4 Se o espectro de violação do *nullum crimen sine lege* deve assim ser afastado relativamente à punibilidade da tentativa dos crimes de omissão impuros, já quanto à dos crimes de omissão **puros** ela se torna por demais duvidosa; apesar de, conceptualmente, também neles ser em certas hipóteses pensável a figura da tentativa (5).

---

(2) KAUFMANN, Armin, *Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte*, 1959, p. 210 e ss., WELZEL, § 28, IV.

(3) Mais longe ainda, depois de análise minuciosa, vai BRITO, Teresa Quintela de, *A Tentativa nos Crimes Comissivos por Omissão: Um Problema de Delimitação da Conduta Típica*, 2000, pp. 127 e ss., 345 e ss. e *passim*: a existência, salvo casos excepcionais, de um "tipo de crime material comum à acção e à omissão" conduz a que a tentativa comissiva por omissão deva ser submetida aos "mesmos critérios que valem para o crime material por acção". A partir daqui se compreende logo que para a A. não constitua igualmente objecção a compatibilidade entre o art. 22.º e a figura da tentativa de omissão imprópria: minuciosamente, *ibid.*, pp. 159 e ss., 273 e ss.

(4) Na conclusão também, ROXIN II, § 29, n.º 266, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 14, n.º 3.

(5) SOUSA, Susana Aires de, *Os Crimes Fiscais. Análise Dogmática e Reflexão sobre a Legitimidade do Discurso Criminalizador*, 2006, p. 138 e ss., aponta a este propósito o caso do crime de abuso de confiança nos termos do RGIT vigente: tratar-se-ia aí de um crime de mera inactividade e, como tal, de omissão pura, relativamente ao qual, porém, é pensável uma tentativa (só punível, em virtude da moldura penal aplicável, se agravado). Como no texto, por último, também ROXIN II, § 29, n.º 292 e ss.

Duas circunstâncias retiram no entanto gravidade à lacuna de punibilidade que aqui se poderia configurar. Em primeiro lugar, a maior parte dos crimes de omissão puros não são puníveis com pena de prisão superior a 3 anos e neles, por conseguinte (art. 23.º-1), a tentativa não seria nunca punível: um caso como o do art. 284.º (recusa de médico), ainda quando deva considerar-se como de omissão pura (6), é excepcional. Por outra parte, como vimos, os crimes de omissão puros serão, ao menos em regra, *crimes formais* (supra, 11.º Cap., § 37); e, nesta espécie de crimes, a violação do dever jurídico de actuar significará quase sempre a concomitante *consumação* (7), deixando deste modo de colocar-se um problema de tentativa.

2. O início da tentativa

§ 5 Questão principal é saber como se distinguem a **preparação** e a **tentativa** nos crimes impuros de omissão. Parece-nos exacto que, neles, o dever de acção nasce desde o primeiro momento em que se verifica um risco não permitido de realização típica. Tal não quer porém significar que a tentativa se inicie logo que o garante despreza a **primeira possibilidade** de intervenção salvadora (8): se os pais de um bebé que surge com febre alta decidem não o submeter a tratamento, a circunstância de o não levarem imediatamente ao médico ou ao hospital não constitui ainda tentativa de ofensa à integridade física ou de homicídio por omissão porque um perigo imediato de lesão do bem jurídico — nos termos que foram assinalados èm matéria de tentativa nos crimes de acção ("conexão de perigo típica": supra, 28.º Cap., § 32 e ss.) — não se encontra ainda instalado. De recusar nos parece igualmente a doutrina oposta, segundo a qual a tentativa só teria início com o desprezo pelo garante da **última possibilidade** de intervenção salvadora (9); além do mais porque uma tal concepção, levada à sua lógica consequência, não deixaria espaço para uma desistência relevante (10), o que constituiria solução ilegal, dogmaticamente injustificável e político-criminalmente inadequada.

---

(6) Discussão minuciosa, à luz da jurisprudência portuguesa, em BRITO, Teresa Quintela de, nota 3, p. 56 e ss.

(7) Assim, também, ROXIN II, § 29, n.º 294.

(8) Assim, em todo o caso, HERZBERG, nota 1, pp. 91, 96. Criticamente, por último, ROXIN II, § 29, n.º 282 e s.

(9) Assim todavia, entre nós, BRITO, Teresa Quintela de, nota 3, p. 354 e ss., na esteira de KAUFMANN, Armin, nota 2, p. 210 e ss., e WELZEL, § 28, IV.

(10) Assim, ROXIN II, § 29, n.º 284 e s. Diferentemente, BRITO, Teresa Quintela de, nota 3, p. 357 e ss.

§ 6 Exacto nos parece — em função da forma como atrás concebemos a imputação objectiva nos crimes de omissão: supra, 38.º Cap., § 9 e ss. — que a exigência jurídico-penal dirigida ao garante se traduz em que assuma um comportamento que contribua de forma adequada para **diminuir o perigo** de verificação do resultado típico, não em que evite o resultado como tal ([11]). Se a inactividade do garante for pois acompanhada do conhecimento do aumento do perigo (real ou por ele suposto) e da resolução de lhe não pôr cobro, aí se deparará com o bastante para caracterizar o conteúdo de ilícito de uma tentativa de um crime de omissão impuro. Uma vez que só a diminuição do perigo de verificação do resultado típico é jurídico-penalmente imposta, **preparação** existirá (não ainda tentativa) enquanto a situação do bem jurídico ameaçado não piora, porque o perigo não é ainda imediato e se encontra ainda numa fase longínqua e estacionária, apesar de o agente ter tomado a resolução de não intervir. **Tentativa** dar-se-á quando, existindo aquela resolução, há o conhecimento (verdadeiro ou suposto) de que o perigo aumenta; tentativa que pode considerar-se *acabada* quando o agente decide desprezar a última possibilidade de intervir e, todavia, a realização típica não chega a consumar-se ([12]). Parece ficar assim justificada a asserção segundo a qual os princípios e normas essenciais da tentativa nos crimes de acção podem, no essencial, ser transpostos para os crimes de omissão.

3. A desistência voluntária

§ 7 Isto exposto, não muita importância conceitual dogmática assumirá a questão de saber se também na tentativa de omissão se deve distinguir entre **tentativa inacabada e acabada**, falando a este propósito Teresa Quintela de Brito, com razão, de uma "infinitesimal fronteira" entre uma e outra, para em todo o caso acabar por afirmá-la ([13]). Que, conceptualmente, ainda seja possível distinguir uma e outra, é coisa com que

---

([11]) Assim, já, DIAS, Figueiredo, Les délits d'omission dans le droit penal portugais, *RintDP* 55, 1984, p. 858. Também STRATENWERTH / KUHLEN, § 13, n.º 54 e s., e § 14, n.º 4.

([12]) No essencial das conclusões, JAKOBS, 29/116, JESCHECK / WEIGEND, § 60, II, 2, STRATENWERTH / KUHLEN, § 14, n.º 2 e ss., RUDOLPHI, *SK*, n.º 51 e ss. antes do § 13, S / S / ESER, § 22, n.º 50.

([13]) BRITO, Teresa Quintela de, nota 3, p. 360 e ss., seguindo a doutrina germânica prevalente, dita "doutrina da diferenciação" (cf. só JAKOBS 29/116, KÜHL § 18, n.º 153 e s., S / S / / ESER, § 24, n.º 28 e s.) e recondutível a LÖNNIES, Rücktritt und tätige Reue beim unechten Unterlassungsdelikt, *NJW*, 1962, p. 1950 e ss.

estamos dispostos a concordar; mas verdade é que uma **desistência voluntária** relevante da tentativa de omissão não se basta nunca, por definição, com o abandono da execução, mas exige que o garante intervenha activamente no sentido de impedir a consumação ou o resultado típico, ou pelo menos se esforce seriamente por evitar uma ou outra ([14]).

§ 8 Em todo o caso, uma diferença persistirá relativamente à relevância da desistência voluntária: o garante tem, na tentativa *inacabada*, de **diminuir o perigo** de verificação do resultado e este, efectivamente, acabar por não sobrevir, para o que bastará em princípio a prática da acção imposta (*v. g.*, a mãe que tinha decidido deixar de alimentar o seu bebé para assim lhe provocar a morte arrepende-se e volta a alimentá-lo); na tentativa *acabada* a desistência voluntária só pode tornar-se relevante se o garante (a mãe), em vez da acção originariamente imposta (dar a mama ou o leite ao bebé), tomar ou se esforçar seriamente por tomar **outra(s) medida(s) de salvação** (*v. g.*, o internamento hospitalar do bebé para ser submetido a alimentação artificial e/ou outros tratamentos) e o resultado típico não sobrevier ([15]).

II. Autoria e cumplicidade nos crimes dolosos de omissão

1. Autoria imediata

§ 9 O **domínio do facto** como critério da autoria é inaplicável aos crimes de omissão. Nestes, na verdade e desde logo, o omitente *não* intervém no acontecimento e não pode por conseguinte dirigi-lo ou sequer orientá-lo. Tão-pouco terá sentido, num esforço de "normativização" do domínio do facto, referi-lo à *acção esperada*, logo porque o omitente também *não* leva a cabo a acção imposta, que impediria a realização típica. Numa palavra e de qualquer perspectiva, a omissão como tal não proporciona ao omitente o domínio sobre o decurso do facto e a autoria não

---

([14]) ROXIN II, § 29, n.º 268 e ss., informando que Küper chamou a esta doutrina a "teoria do necessário acabamento da tentativa".

([15]) Assim, S / S / ESER, § 24, n.º 29, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 11, n.º 5, crendo nós que esta solução se encontrará também na linha da posição de BRITO, Teresa Quintela de, nota 3, p. 360 e ss., acerca da distinção entre tentativa inacabada e acabada de omissão. Contra, ROXIN II, § 29, n.º 267 e ss., e § 30, n.º 136 e ss. Uma referência à questão já em DIAS, Figueiredo, nota 11, loc. cit.

poderia por isso ter-se como o *centro pessoal do ilícito-típico*: ela apenas pressupõe a *possibilidade* de o omitente actuar sobre o decurso do acontecimento (já supra, 30.º Cap., §§ 18, 23) e de por essa via o dominar. Tão-pouco nos parece caracterização bastante da autoria na omissão a que resulta da concepção de Roxin da **teoria do dever jurídico**: o omitente seria autor logo e sempre que violasse o dever de evitar o resultado fundamentador do tipo ("crime de dever") e preenchesse os restantes pressupostos típicos ([16]). Não porque uma tal teoria não acabe por conduzir, nos casos questionáveis, a soluções em regra coincidentes com as que reputamos fundamentalmente correctas. Mas porque a violação, referida a um resultado típico, de um dever específico, que aqui não pode ser adicionada a um domínio do facto, nos parece uma caracterização insuficiente e indefinida de alguém que, ainda neste contexto, deve ser o *centro pessoal do ilícito típico*. Para caracterização desta figura a autoria tem ainda de se referir — para além da violação do dever que sobre o omitente recaia —, se não a um domínio do facto *real e efectivo*, que na verdade se não dá, a um domínio do facto **potencial**.

§ 10 Autor é por isso aqui — só pode ser — aquele que **detinha a possibilidade fáctica de intervenção no (e de domínio do) acontecimento e, apesar de sobre ele recair um dever jurídico de acção (dever de garante), não fez uso de tal possibilidade** ([17]). Nem as coisas são em princípio diferentes — no que toca à definição da autoria do omitente — quando são vários os *comparticipantes* no acontecimento, quer todos realizem o tipo por omissão (*v. g.*, o pai e a mãe não chamam o médico ou não acorrem a um hospital para tratamento do seu filho gravemente doente), quer uns por omissão, outros por acção (*v. g.*, quando os pais de uma criança assistem sem intervir aos maus tratos a ela infligidos por outrem) ([18]). De excluir desta regra serão apenas, tal como nos delitos de acção, os casos daqueles tipos cuja realização pressupõe, mais que a ausência de

---

([16]) ROXIN II, § 31, n.º 140 e ss.

([17]) Doutrina dominante na Alemanha: por ela, RUDOLPHI, *SK*, n.º 37 antes do § 13, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 14, n.º 7 e ss. À mera "possibilidade de domínio do facto" chama BELEZA, Teresa, II, p. 442, "domínio do facto", parecendo concordar FARIA, Paula Ribeiro de, *A Adequação Social da Conduta no Direito Penal ou o Valor dos Sentidos Sociais na Interpretação da Lei Penal*, 2005, p. 1121. Claro que o problema se torna então em mera questão terminológica, todos estando de acordo com o essencial.

([18]) Assim, KAUFMANN, Armin, nota 2, p. 291 e ss., ROXIN, *LK*, § 25, n.º 204 e ss., RUDOLPHI, *SK*, n.º 37 antes do § 13, STRATENWERTH / KUHLEN, § 14, n.º 13.

uma acção determinada, **elementos adicionais** relativos ao ilícito típico, por exemplo, uma posição, uma qualidade ou um dever especial. Em casos tais *não pode ser autor* quem não preenche estas exigências adicionais, ainda mesmo que estejam verificados o dever de acção e a possibilidade de intervenção). Tudo o que pode entrar aqui em consideração é uma responsabilização por **cumplicidade por omissão**, na medida em que se verifiquem os seus pressupostos (infra, § 16 e s.).

§ 11 Já se pretendeu no entanto que, sempre que a omissão se conjuga com um comportamento activo de outrem na produção de um resultado típico, a passividade do omitente só poderia constituir **cumplicidade**, não autoria; porque o agente activo, que possui o domínio real do acontecimento, como que impede ao garante o acesso imediato ao resultado ([19]). Mas esta concepção não parece de sufragar ([20]), logo na medida em que todos consideram *autor* o omitente que, contra o dever, não intervém uma vez verificada já a acção, *v. g.*, não leva ao hospital o seu filho ferido por outrem. Tão-pouco parece lograda a tentativa de distinguir consoante o *conteúdo do dever* que recai sobre o omitente (sobre a distinção: supra, 38.º Cap., §§ 27 e ss. e 37 e ss.), se se trata de um dever de protecção e assistência (cuja violação conduziria à afirmação da *autoria*) ou antes de um dever de vigilância e segurança (cuja violação conduziria à *cumplicidade*) ([21]). Para além do mais ([22]) — e como na altura devida tivemos ocasião de sublinhar: supra, 38.º Cap., § 54 —, não são invulgares as hipóteses de deveres de garante relevantes em mais que um plano, o que traria para o nosso tema de agora uma insegurança dificilmente suportável e, sobretudo, poderia conduzir a diferenciações injustificadas de responsabilização.

2. Outras formas de autoria

§ 12 Uma **autoria mediata** por omissão não é em princípio possível ou sequer, em rigor, pensável. Aquele sobre quem recai o dever de actuar não pode omitir através da actuação de outra pessoa como seu instrumento, submetida ao domínio da sua vontade: ele não exerce o domínio do facto, só a possibilidade de intervenção imediata constituindo o ilícito-

([19]) GALLAS, *JZ* 1952, p. 372, e JESCHECK / WEIGEND, § 64, III, 5.

([20]) Assim, também, KAUFMANN, Armin, nota 2, p. 296 e s., ROXIN II, § 31, n.º 152 e ss., STRATENWERTH / KUHLEN, § 14, n.º 10. Cf., no entanto, agora, HOFFMANN-HOLLAND, Die Beteiligung des Garanten am Rechtsgutsangriff. Zur Abgrenzung von Täterschaft und Beihilfe durch Unterlassen, *ZStW 118*, 2006, p. 620, para quem o que faz do agente o centro do acontecimento é a "condução directa da situação de facto": quando esta se não verifica aquele só pode assumir a posição de cúmplice.

([21]) Assim, S / S / CRAMER / HEINE, n.º 103 antes do § 25.

([22]) Crítica minuciosa em ROXIN II, § 31, n.º 158 e ss.

-típico da omissão jurídico-penalmente relevante. Por isso, aquele que, detendo-a, não faz uso dessa possibilidade (*v. g.*, não se opõe ao cometimento por acção de um facto por uma criança ou por um doente mental ou não impede as consequências danosas de um acontecimento natural), e, em consequência, permite o surgimento do resultado típico é seu **autor imediato por omissão** (23).

§ 13 Tão-pouco é possível, em princípio, uma verdadeira **instigação** (uma instigação / autoria) por omissão (24): o comportamento omissivo contra o dever não constitui, em princípio, forma adequada de criar ou produzir noutra pessoa responsável a *decisão* de cometer um ilícito-típico. Se, excepcionalmente, tal porventura acontecer, e se o homem de trás (omitente) for garante da não verificação do resultado e detiver a possibilidade fáctica de o impedir, o que ele pode então ser considerado é, uma vez mais, **autor imediato por omissão**.

§ 14 Já uma **co-autoria** através de omissão é pensável e possível (25), restando saber porém se, na maioria dos casos ali em vista, o conceito é necessário; ou se, diferentemente, não pode logo aceitar-se uma **autoria imediata por omissão**, nos termos referidos supra, § 10. Este será o caso, *v. g.*, em que os pais de uma criança doente decidem conjuntamente não a levar ao médico, quando cada um deles poderia ter cumprido o dever que pessoalmente lhe cabia. Como será o caso de a omissão se traduzir em não impedir a autoria por acção de outrem, p. ex., quando, por decisão conjunta, o pai da criança não impede que outrem a maltrate; parece claro que, de um ponto de vista estrutural-formal, pode falar-se de co-autoria, mas, mesmo sem apelo a um tal conceito, o pai da criança é já autor imediato por omissão do facto praticado, nos termos acima assinalados.

---

(23) Doutrina dominante na Alemanha: JESCHECK / WEIGEND, § 62, IV, 2, S / S / CRAMER / HEINE, § 25, n.º 54 e s., ROXIN II, § 31, n.º 175, STRATENWERTH / KUHLEN, § 14, n.º 14. A favor de uma autoria mediata por omissão nos casos por último referidos, M / GÖSSEL, 48/95.

(24) Neste sentido — considerando obviamente a instigação como participação —, pela doutrina alemã dominante, JESCHECK / WEIGEND, § 64, II, 6, ROXIN II, § 26, n.º 86 e s.

(25) Doutrina dominante na Alemanha: por outros, JESCHECK /WEIGEND, § 64, II, 6, ROXIN II, § 31, n.º 171 e ss., STRATENWERTH / KUHLEN, § 14, n.º 17 e ss.

§ 15 Diferente será já o caso em que o afastamento da realização típica pressupõe um **agir conjunto**. Stratenwerth aponta o exemplo elucidativo de alguém ficar inadvertidamente encerrado numa sala-cofre que só pode ser aberta conjuntamente por dois portadores de duas chaves diferentes; como também o de vários membros do conselho de administração de uma sociedade decidirem não retirar do mercado, contra o que passou a ser imposto, um determinado produto perigoso ([26]). Aqui ficará justificado o apelo à figura da co-autoria e aos seus requisitos definidos a propósito dos delitos de acção. Como justificado ficará porventura quando existe **acordo entre um agente e um omitente** na realização conjunta de um mesmo ilícito típico. *V. g.*, exemplifica Roxin, se dois guardas prisionais decidem possibilitar a fuga de um preso (art. 350.º), dando-lhe um a chave da cela e não accionando o outro o sinal de alarme quando o fugitivo salta o muro ([27]).

3. Cumplicidade

§ 16 Que seja possível uma **cumplicidade por acção num crime de omissão** é coisa que, segundo a concepção que defendemos em matéria de ilícito típico do crime de omissão, não parece merecer dúvida ([28]). Esta só poderia derivar da negação do dolo nos crimes omissivos, ponto de vista que não compartilhámos (supra, 38.º Cap., § 57 e ss.). Assim, pois, serão em princípio válidas nesta matéria as regras estabelecidas para a cumplicidade nos crimes de acção.

§ 17 Duvidoso é já se pode e deve configurar-se uma **cumplicidade por omissão** num crime de acção ou de omissão. Se, como dissemos (supra, § 10), a possibilidade de intervenção do garante no sentido de afastar a verificação do resultado típico é, em princípio, bastante para caracterizar a sua *autoria*, não parece ficar espaço para aceitação de uma *cumplicidade*. De ressalvar serão apenas os casos em que a autoria supõe ainda a verificação de pressupostos adicionais, nomeadamente de uma

---

([26]) Stratenwerth / Kuhlen, § 14, n.º 18. Concordam Jescheck / Weigend § 63, IV, 2, e Roxin II, § 31, n.º 173.

([27]) Roxin II, § 31, n.º 174.

([28]) Na doutrina alemã, cf. só S / S / Cramer / Heine, n.º 99 e ss. antes do § 25, e Stratenwerth / Kuhlen, § 14, n.º 21.

qualidade, uma intenção ou um dever especiais. Nestes casos o omitente só poderá ser punido (eventualmente de forma duplamente atenuada, em nosso modo de ver: arts. 10.º-3 e 27.º-2) como *cúmplice* (29). Sem prejuízo da doutrina dita da "comunicabilidade das circunstâncias" emanada do art. 28.º, se e na medida em que ela seja aqui aplicável (supra, 33.º Cap., § 15 e ss.).

(29) Cf. ROXIN II, § 31, n.º 143 e ss., RUDOLPHI, *SK*, n.º 42 antes do § 13, STRATENWERTH / KUHLEN, § 14, n.º 23 e ss.

TÍTULO V

O CONCURSO (*)

41.º CAPÍTULO

UNIDADE E PLURALIDADE DE CRIMES

I. Introdução ao problema

§ 1 A exposição sistemática anterior pressupôs, por regra, que a realização ilícita típica de um certo agente foi única, que em questão estava a prática de um único crime. Todavia, frequentemente sucede que *no mesmo processo penal* se decide sobre uma pluralidade de crimes cometidos pelo *mesmo agente*, então se suscitando, relativamente ao **comportamento global** levado à cognição do tribunal, a questão dogmaticamente conhecida como do **concurso de crimes** (art. 30.º-1) (1) (2). Torna-se deste modo indispensável determinar quando e sob que pressupostos e circunstâncias se está perante **um crime** ou antes perante uma **pluralidade**

(*) As ideias centrais avançadas ao longo de todo este título tiveram origem no artigo intitulado "Unidade e pluralidade de crimes: *où sont les neiges d'antan?*" e destinado a figurar nos *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves*, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, neste momento em curso de publicação.

(1) Entre nós, monografia ainda hoje fundamental, CORREIA, Eduardo, *Unidade e Pluralidade de Infracções*, 1945. Cf. agora, também, ALMEIDA, L. Duarte d', *O "Concurso de Normas" em Direito Penal*, 2004, e MOUTINHO, J. Lobo, *Da Unidade à Pluralidade de Crimes no Direito Penal Português*, 2005.

(2) Podendo suceder ainda que num concreto processo penal haja que decidir apenas de um crime, mas só pela circunstância de que tal crime não era (ou não foi) conhecido a quando de um processo penal anterior por crime diferente cometido pelo mesmo agente: nestes casos se falando de *conhecimento superveniente do concurso de crimes* (art. 78.º): v. o nosso *DP II*, § 424 e ss. O que em nada altera materialmente a problemática agora em consideração, pelo que neste Título abstrairemos, em princípio, desta situação processual.

de crimes. Esta forma de suscitar a questão já revela que determinante, ao menos como via de princípio, não é a pura questão *ontológica*, ou *epistemológica*, ou *gnoseológica* da "unidade" e da "pluralidade"; mas que, ainda aqui e uma vez mais, se defronta um **problema especificamente jurídico-penal**, político-criminalmente conformado e a decidir segundo os cânones metodológicos próprios da dogmática do direito penal.

§ 2 O problema releva, desde logo, a **nível jurídico-constitucional**. Com efeito, nos termos do art. 29.º-5 da CRP, "ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime", tornando-se por isso decisiva a determinação do que seja o "mesmo crime" ou "crime diverso" para que possa ser integralmente respeitado o conteúdo material do **princípio ne bis in idem** (3); isto é, por um lado, a **proibição de dupla valoração** do mesmo substrato material nele contida e, por outro lado, o **mandado de esgotante apreciação** de toda a matéria tipicamente ilícita submetida à cognição do tribunal num certo processo penal. Ora, o "crime" a que se referem o art. 29.º-5 da CRP e o art. 31.º-1 do CP não pode deixar de constituir exactamente a mesma entidade jurídica: não há crimes outros que não os que são como tal considerados pela lei penal substantiva.

§ 3 O problema releva também, em segundo lugar e como ficou sugerido, a **nível processual penal**. Em um mesmo processo penal pode julgar-se um só crime ou facto punível ou uma pluralidade de crimes ou de factos puníveis. A distinção assume porém a maior importância — embora, obviamente, essa complexíssima questão deva aqui ser apenas referida — para determinação do que constitua o **objecto do processo** (4) e, nomeadamente, dos limites da alteração jurídico-processualmente admissível dos factos que constituem aquele objecto (CPP, arts. 1.º-1*f*), 284.º e s., 303.º, 358.º e s. e 379.º). Decerto, os problemas não se confundem; mas também para os efeitos processuais referidos é decisiva a questão de saber aquilo que, para o direito penal substantivo, constitui o *mesmo* "crime" ou o *mesmo* "facto" (5).

§ 4 No âmbito do **direito penal substantivo** o problema a estudar agora releva, de forma decisiva, para determinação das **consequências**

---

(3) Sobre ele, cf., só, CANOTILHO / MOREIRA, p. 497 e s. Acentuava já muito correctamente o relevo deste princípio para o problema do concurso de crimes CORREIA, nota 1, nomeadamente em tema de "consumpção", p. 170 e ss.

(4) Monografia ainda hoje fundamental: CORREIA, Eduardo, *Caso Julgado e Poderes de Cognição do Juiz*, 1948 (reunida com a monografia citada na nota 1 em CORREIA, Eduardo, *A Teoria do Concurso em Direito Criminal*, 1963).

(5) Uma clarividente percepção do problema logo em TENREIRO, Mário, Considerações sobre o objecto do processo penal, *ROA 47*, 1987, p. 997.

jurídicas que da distinção entre unidade e pluralidade de crimes resultam para efeitos da **punição** do agente. Importa desde já chamar a atenção para que em caso de concurso de crimes o legislador tem à sua disposição vários sistemas de punição. Deve ele, antes de mais, optar por um sistema de *pena unitária* ou antes de *pena conjunta*: no primeiro caso, o juiz terá de valorar unitariamente o conjunto dos crimes conhecidos e de aplicar a essa unidade normativa uma só pena em nome da unidade (da personalidade "unitária") do agente (6); no segundo, o juiz terá sempre de fixar concretamente as penas aplicadas a cada um dos crimes conhecidos. Em seguida, o legislador terá de optar ainda por um dos possíveis sistemas de construção da moldura penal do concurso: ou o da *absorção*, nos termos do qual a punição do agente ocorrerá dentro da moldura penal aplicável ao facto mais grave; ou o da *exasperação*, quer dizer, da agravação da moldura penal aplicável ao crime mais grave; ou o da *acumulação material*, isto é, da *soma* das penas concretamente aplicadas a cada um dos crimes conhecidos para fixação do limite máximo da moldura penal do concurso. O legislador português decidiu-se, no art. 77.º, pela punição do concurso de crimes através de um sistema de *pena conjunta*, fundada em uma combinação dos princípios da *acumulação material* e do *cúmulo jurídico*, tendo este por base uma consideração judicial conjunta dos factos e da personalidade do agente (assim se aproximando, em alguma medida, do sistema da pena unitária); e, no art. 79.º, pela punição do crime continuado (infra, 43.º Cap., § 59 e ss.) dentro da moldura penal aplicável à conduta mais grave que integra a continuação". Ora importa sobremodo salientar neste contexto que o sistema ou os sistemas eleitos para a punição do concurso não podem deixar de, em medida decisiva, **retrotrair** os seus efeitos sobre a própria distinção dogmática entre unidade e pluralidade de crimes, só em consideração deles se podendo fundar, em último termo, a esperança de encontrar soluções correctas dos casos em exame (7).

---

(6) Essencialmente no sentido do texto MONTEIRO, Cristina Líbano, A pena "unitária" do concurso de crimes — Ac. do STJ de 12-7-2005, *RPCC 16*, 2006, p. 160: "O que marca decisivamente a pena unitária é que os factos sejam considerados apenas como referentes ou significantes da personalidade que se quer punir, sem possuírem — cada um deles — um relevo autónomo e quantificado dentro da pena do concurso".

(7) Sendo esta uma hipótese exemplar, por isso, daquele pensamento orientado "pelo resultado" (pela "consequência jurídica") que logo no início deste livro enfatizámos (supra, 1.º Cap., § 6).

§ 5 Apesar de quanto fica dito, o problema da unidade e pluralidade de crimes cabe, com legitimidade, no tratamento da **doutrina geral do crime**, não se dissolvendo — sem prejuízo das atinências já assinaladas — nem na doutrina das consequências jurídicas do crime, nem na temática do objecto do processo penal, nem na incidência jurídico-constitucional do princípio *ne bis in idem*. Isto revela-se desde logo pelo nosso CP não se limitar a tratar o problema da unidade ou pluralidade de crimes em termos da consequência jurídica, da forma de punição cabida ao concurso (arts. 77.º-79.º), mas assumir a responsabilidade (assumpção não muito frequente na generalidade das legislações) de definir no art. 30.º — e, por conseguinte, em plena regulamentação da doutrina geral do *facto punível* — o que deve entender-se por unidade e por pluralidade de crimes. Opção largamente justificável, tanto mais quanto a distinção constitui um complemento significativo e implica mesmo porventura, a certos títulos, uma "reconformação" da doutrina geral dos elementos constitutivos do crime, nomeadamente, uma vez ainda e acima de todos os outros, do **ilícito típico**.

§ 6 Anote-se por fim que, como logo de início acentuámos, o problema do concurso de crimes só se suscita quando o facto global foi levado a cabo **pelo mesmo agente**. Vale só a pena sublinhar que isso será ainda assim **quando na mesma pessoa física convirjam as qualidades de autor individual e de titular ou representante de um ente colectivo (também) chamado à responsabilidade.** Aqui, a **identidade pessoal** esconde uma efectiva **pluralidade de agentes,** pelo que a unidade física do agente não pode deixar de ser irrelevante para a análise do concurso de crimes. Este não chegará a existir porque, em último termo, os autores são diferentes: a pessoa individual, de um lado, o ente colectivo, do outro.

§ 7 Pode perguntar-se se a questão da unidade ou pluralidade de crimes — neste contexto, mais exactamente, da unidade ou pluralidade de *factos* — releva unicamente para efeito de aplicação de penas ou também de **medidas de segurança**. A questão pode desde logo assumir significado para auxiliar a determinação judicial da **perigosidade** do agente. Mas para além disto, e sabido que a aplicação de uma medida de segurança criminal não depende nunca apenas da perigosidade, mas também da prática pelo agente de um **facto** qualificável como um **ilícito-típico** (supra, 5.º Cap., § 7 e ss., e 21.º Cap., § 37 e ss.), ela pode assumir relevo autónomo e decisivo também neste contexto. Não está por isso excluído que a lei possa fazer depender em alguns casos a aplicação da medida de segurança da prática de uma "pluralidade de factos": assim acontece nos casos da chamada *pena relativamente indeterminada*" (art. 83.º e ss.),

atendendo a que, como sustentamos (8), este instituto, numa acepção jurídica substancial, se conforma, ao menos em uma das partes em que se decompõe, como uma medida de segurança.

II. Critérios distintivos da unidade e pluralidade de crimes

1. Consideração geral

§ 8 Nos termos do art. 30.º-1, "o número de crimes determina-se pelo **número de tipos de crime** efectivamente cometidos, ou pelo **número de vezes** que o mesmo tipo de crime for preenchido pela conduta do agente". Doutrinalmente, costuma falar-se na primeira hipótese de concurso **heterogéneo**, na segunda de concurso **homogéneo**. Quando este preceito se perspective através do seu processo genético e se projecte na história dogmática do problema até ao fim dos anos 70 do séc. XX, o **princípio normativo** que nele se contém torna-se suficientemente explícito e cheio de sentido (9).

§ 9 Efectivamente, na distinção jurídico-penal da unidade e da pluralidade de crimes têm sido seguidas, no essencial, duas vias fundamentais: a de atender prioritariamente à unidade ou pluralidade de **tipos legais de crime** violados; ou a de conferir relevo decisivo à unidade ou pluralidade de **acções** praticadas pelo agente. A primeira via é assim claramente aceite e prosseguida pela nossa lei vigente. A segunda via impôs-se na jurisprudência e na doutrina germânicas e, a partir destas, em diversos países. Através dela se logra a distinção entre *concurso ideal* (*a mesma acção* viola várias disposições penais ou várias vezes a mesma disposição penal) e *concurso real* (*diversas acções* autónomas violam várias disposições penais ou várias vezes a mesma disposição penal). De acordo com o disposto no art. 30.º-1 não parece pois haver espaço para a distinção germânica entre um "concurso real" e um "concurso ideal": no ordenamento jurídico-penal português ou existe um concurso **efectivo** ou **verdadeiro** (*hoc sensu*, se quisermos, "real"), ou há **unidade do facto punível** e, por conseguinte, de

(8) Supra, 5.º Cap., § 35, e o nosso *DP II*, § 881.

(9) Trata-se nele, com efeito, da tentativa de exteriorização de uma concepção fundamental, tal como foi entre nós defendida por Eduardo Correia na sua monografia sobre o tema de 1945 (nota 1, *passim*), por ele mesmo vazada no art. 33.º do seu ProjPG de 1963, defendida com êxito na Comissão Revisora (*Actas I*, p. 211 e ss.) e ainda reafirmada, no essencial, na sua exposição sistemática doutrinal de 1965 (CORREIA, Eduardo, II, n.º 35 e ss.).

crime. Vejamos porém, mais de perto, as alternativas construtivo-dogmáticas que desta forma parecem suscitar-se, para em seguida fundamentarmos perante elas a nossa posição.

2. O critério da unidade ou pluralidade de acções praticadas

2.1. Apreciação geral

§ 10 O tratamento diferenciado do concurso ideal e do concurso real — o primeiro conducente à unidade, o segundo à pluralidade do facto ou do crime, como vimos suceder, entre outros, no sistema alemão — é desde há muito, mas hoje cada vez mais, insistentemente contestado tanto em perspectiva **político-criminal**, como do ponto de vista **dogmático**.

§ 11 Em **perspectiva político-criminal**, a distinção entre concurso real e concurso ideal radica na pretensão de tratar um e outro segundo diferentes princípios ou sistemas de punição; nomeadamente, como no sistema legal alemão, punindo o concurso ideal com uma pena única construída segundo o princípio da absorção e o concurso real com uma pena conjunta obtida em função do princípio da exasperação. Ora, é isto que mal se compreende e a doutrina alemã hodierna revela cada vez maior dificuldade em aceitar ([10]).

§ 12 Para apresentar exemplos comezinhos: porque há-de ser diferentemente punido (e, na verdade, menos severamente) o pai que decide dar a morte aos seus dois bebés gémeos se atirar ao rio o carrinho de dupla cadeira em que cada um dos gémeos está sentado face àquele outro que tem cada um sentado em seu carrinho e com dois empurrões atira ao rio cada uma das cadeiras? Ou aquele que com uma pedrada parte a montra de uma vitrina e fere — como é seu propósito — a empregada que faz a montra, perante aquele que, para obter exactamente o mesmo resultado, atira duas pedradas, a primeira destinada à prática do crime de dano, a segunda à do crime de ofensa à integridade física? Ou ainda — no exemplo porventura mais clássico — o atirador de elite que com um tiro mata dolosamente os seus dois inimigos que estão juntos, relativamente àquele outro que para o efeito dispara dois tiros? Pode aceitar-se, sem discutir, que as duas situações sejam, num caso e noutro, *estruturalmente* diferentes. Só que a questão não é essa, mas a de saber se a uma eventual diferenciação ôntica ou fenomenológica deve corresponder uma **diferente valoração axiológico-jurídica** rele-

([10]) Cf. ERB, Überlegungen zu einer Neuordnung der Konkurrenzen, *ZStW 117*, 2005, p. 37 e ss.; e também ROXIN II, § 33, n.º 7 e ss.

vante para efeito de punição. E a esta questão deve responder-se, ao menos em via de princípio, **negativamente**. O apelo à indiciação, em caso de pluralidade de acções, de uma mais forte "energia criminosa" ou de um maior desvalor ético-social do comportamento é destituída de sentido. E nisto reside o essencial da crítica.

§ 13 Em **perspectiva dogmática**, tem-se argumentado sobretudo com a *impossibilidade* de distinguir com sentido a unidade da pluralidade de acções; e, mesmo antes disso, com a circunstância de uma tal distinção só poder radicar numa concepção do pensamento jurídico completamente ultrapassada, a perspectiva **mecânico-naturalista e positivista**. Nesta base criticou entre nós Eduardo Correia toda esta concepção: com apelo a fenómenos puramente mecânicos e naturalísticos não consegue erigir-se um critério válido para distinguir a unidade da pluralidade de acções, sendo certo que mesmo o facto mais simples e jurídico-socialmente uno analisar-se-á muito provavelmente numa pluralidade de actos naturalísticos ([11]). Verdade porém é que, passado quase um século sobre a polémica anti-positivista no mundo do Direito, pode hoje levar-se a cabo a distinção entre a unidade e a pluralidade de acções noutra base que não seja puramente "naturalística", antes seja natural, social ou mesmo, em certa medida, juridicamente conformada. Nessa medida falando agora a doutrina alemã de uma unidade **natural**, de uma unidade **típica** e em determinadas hipóteses mesmo (embora hoje com reservas) de uma conexão unitária de **continuação**; para por estes caminhos dar a entender que em certos casos se pode concluir pela *unidade de acção* apesar de o facto — considerado exclusivamente de um ponto de vista externo — consistir numa pluralidade (naturalística) de actos.

2.2. A "unidade típica de acção"

§ 14 Uma unidade típica de acção existirá em todos aqueles casos em que **um tipo legal de crime reduz a uma unidade típica uma pluralidade de actos** como tal externamente reconhecível ([12]).

§ 15 Tal sucederá, desde logo, quando um tipo legal **integra, por necessidade, aquela pluralidade de actos**, *v. g.*, o de coacção sexual do art. 163.º (actos de coac-

([11]) CORREIA, Eduardo, nota 1, *passim* e II, n.º 35.

([12]) Cf. fundamentalmente neste sentido e no do que se segue neste parágrafo, por todos, ROXIN, § 33, n.º 19 e ss., e STRATENWERTH / KUHLEN, § 17, n.º 2 e ss.

ção+actos sexuais), o de roubo do art. 210.º (actos de coacção+actos de subtracção). O mesmo sucede quando um tipo legal é formulado de tal maneira que, não exigindo necessariamente para a sua integração uma pluralidade de actos singulares, **reconduz todavia uma tal pluralidade à unidade** sempre que aquela pluralidade tenha lugar dentro de uma certa unidade contextual ou espácio-temporal; *v. g.*, quando o agente mata a vítima com vários golpes mortais (arts. 131.º ou 132.º), inflige à vítima vários maus-tratos físicos ou psíquicos ou vários actos cruéis (art. 152.º), repete a cópula com a mesma vítima no contexto de uma violação sexual (art. 164.º), furta vários objectos numa ida ao supermercado (arts. 203.º ou 204.º), transmite vários segredos de Estado no decurso de uma comunicação (art. 316.º), etc. Unidade tipicamente fundada de acção existirá, ainda, no **crime duradouro** (supra, 11.º Cap., § 51): *v. g.*, a pluralidade de actos necessários à detenção e encerramento da vítima, à manutenção da privação da sua liberdade e ao impedimento da fuga constitui uma única acção (típica) de sequestro (art. 158.º) ([13]).

2.3. A "unidade natural de acção"

§ 16 Uma unidade natural de acção vem sendo aceite pela jurisprudência alemã — seguida por uma parte minoritária da doutrina — para sublinhar que "em muitas situações da vida, certos comportamento puníveis, se bem que cada um deles seja susceptível de preencher o (mesmo) tipo legal de crime, **só se deixam compreender com justeza quando tomados no seu conjunto**" (BGHSt 40, 162 e s.). Uma tal unidade de acção é afirmada, em regra, quando vários actos singulares da mesma espécie e derivados de uma vontade criminosa unitária se encontram, de um ponto de vista espacial e temporal, numa conexão tão estreita que eles se representam, *à luz de uma consideração natural*, como uma unidade ([14]). Seria o caso, *v. g.*, de *A* falhar a tentativa de matar *B* com uma pancada na cabeça e, por isso, em seguida o estrangular, ou a de *C* falhar uma primeira tentativa de assaltar uma casa devido à proximidade de um polícia mas mais tarde, na mesma noite, proceder a uma segunda tentativa lograda.

2.4. A "unidade continuada de acção"

§ 17 A figura da unidade continuada de acção mereceu entre nós consagração legislativa expressa sob a forma do "**crime continuado**" (art. 30.º-2), constituindo por isso matéria a considerar no local adequado: infra, 43.º Cap., § 37 e ss.

([13]) No mesmo sentido, MONTEIRO, Cristina Líbano, Roubo e sequestro em concurso efectivo?, Ac. do STJ de 7-10-2003, *RPCC 15*, 2005, pp. 477, 494.

([14]) STRATENWERTH / KUHLEN, § 17, n.º 9.

2.5. Valoração crítica

§ 18 A ideia de uma unidade **natural** de acção ou possui carácter insuportavelmente **indeterminado** ([15]), visando permitir que o aplicador alcance, em cada caso, a solução que julgue mais razoável; ou (quando se não confunda com a figura do crime continuado) reconduz-se a uma qualquer forma de unidade "típica" de acção. Na parte excedente representa, do ponto de vista **político-criminal** e **jurídico-constitucional**, um convite inadmissível ao incumprimento (ou ao cumprimento ligeiro) do mandado de "esgotante apreciação" ínsito no princípio *ne bis in idem*. Posição diferente deve ser assumida face à construção de uma unidade **típica** de acção, revelando-se os resultados a que ela conduz, em geral, fundados. Resta todavia saber se, por este modo, ainda sobra algum sentido à afirmação de que está em causa uma unidade *de acção*. E não sobra: o que está patentemente em causa é então a unidade de **realização típica** (no sentido em que dela falámos supra, 10.º Cap., § 40 e s.) e, por esta via, também ou primordialmente o **tipo legal de crime** preenchido por aquela realização. Com o que o critério de distinção entre a unidade e a pluralidade de crimes em função da acção cede o passo àquele outro critério que em seguida será mencionado.

3. O critério da unidade ou pluralidade de tipos legais violados

§ 19 Em função do que ficou dito, decisivo da unidade ou pluralidade de crimes parece dever ser não a unidade ou a pluralidade de acções em si mesmas consideradas, mas a **unidade ou pluralidade de tipos legais de crime violados pela conduta de um mesmo agente** ([16]) e submetidos, num mesmo processo penal, à cognição do tribunal. Foi este o critério sempre vivamente sufragado por Eduardo Correia e, na sua esteira, pela jurisprudência portuguesa praticamente unânime na vigência do nosso CP actual.

([15]) Assim, STRATENWERTH / KUHLEN, § 17, n.º 10.

([16]) Assim, entre outros, CORREIA, Eduardo, nota 1, *passim* e II, n.º 35; COSTA, Faria, Formas do crime, *JDC 1983*, p. 180; FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 520; SILVA, Marques da, II, p. 310. Anote-se ser uma solução deste tipo que se encontra consagrada em países como a Áustria, a Suíça e mesmo a Alemanha, quanto a esta só no que toca ao direito penal de menores — todos com a consequência de a pena do concurso ser, pelo menos num certo sentido, uma *pena unitária*. Era fundamentalmente também uma solução deste teor que o *AE* preconizou (sem êxito) para o direito penal alemão de adultos.

§ 20 Remetendo-nos à lição de **Eduardo Correia** — de acordo com a concepção normativista do conceito geral de crime que foi sempre a sua —, decisivo da unidade ou pluralidade de crimes só pode ser "o número de valorações que, no mundo jurídico-criminal, correspondem a uma certa actividade. (...) Pluralidade de crimes significa, assim, pluralidade de valores jurídicos negados. (...) Pelo que, deste modo, chegamos à primeira determinação essencial de solução do nosso problema: se a actividade do agente preenche **diversos tipos legais de crime,** necessariamente se negam diversos valores jurídico-criminais e estamos, por conseguinte, perante uma **pluralidade de infracções**; pelo contrário, **se só um tipo legal é realizado,** a actividade do agente só nega um valor jurídico-criminal e estamos, portanto, perante **uma única infracção**" ([17]).

§ 21 A este primeiro momento da determinação haveria que acrescentar, no entanto, um segundo. É que "pode acontecer que o juízo concreto de reprovação tenha de ser formulado **várias vezes** em relação a actividades subsumíveis a um **mesmo** tipo legal de crime, a actividades, portanto, que encarnam a violação do *mesmo* bem jurídico (...): a unidade de tipo legal preenchido não importa definitivamente a unidade da conduta que o preenche; pois **sendo vários os juízos de censura,** outras tantas vezes esse mesmo tipo legal se torna aplicável e deverá, por conseguinte, considerar-se existente uma **pluralidade de crimes**" ([18]). Esta doutrina — seguida hoje no essencial, de forma largamente dominante, pela jurisprudência portuguesa — suscita no entanto algumas observações.

§ 22 Num **plano construtivo**, desde logo. Sendo o tipo legal de crime a fonte de conhecimento da unidade ou pluralidade de factos puníveis, tem em todo o caso de levar-se na devida conta que, como se disse supra (11.º Cap., § 20 e ss.), o tipo de ilícito, o verdadeiro portador da ilicitude material, é *sempre* formado pelo tipo **objectivo** e pelo tipo **subjectivo** de ilícito; o que permite porventura ainda manter a problemática essencial do concurso — também, em especial, a do concurso homogéneo — dentro da categoria do tipo de ilícito e tornar dispensável, ao menos em princípio, o apelo à categoria da culpa. A segunda observação é a de que o

([17]) CORREIA, Eduardo, II, n.º 35, II, *a)*, sintetizando o que havia exposto em nota 1, pp. 79 e ss., 104 e ss.

([18]) CORREIA, Eduardo, II, n.º 35, II, *b)*, e nota 1, p. 114 e ss.

tipo objectivo tem *sempre* como seus elementos constitutivos o *autor*, a *conduta* e o *bem jurídico*, só da **conjugação** destes elementos — e também da sua ligação ao tipo subjectivo de ilícito — resultando o **sentido jurídico-social da ilicitude material** do facto que o tipo abrange. O que vale por dizer que *todos* estes elementos parece deverem ser tidos em conta e valorados — e não apenas em si mesmos, mas ainda no sentido que da sua consideração **global** resulta — na determinação da unidade ou pluralidade de tipos violados.

§ 23 O que de um **ponto de vista material** parece poder apontar-se à concepção de Eduardo Correia é o ter renunciado cedo demais a esta concepção *global* do tipo, para tornar determinante da unidade ou pluralidade de crimes, em último termo, a unidade ou pluralidade de **bens jurídicos** violados pela conduta do agente ([19]). Certo que o bem jurídico assume na questão da tipicidade um relevo primacial e insubstituível. Mas não é esta razão para que os restantes elementos típicos sejam minimizados e para esquecer que a certos propósitos deve mesmo recorrer-se, para além da análise de todos eles, a uma consideração *global* do sentido social do comportamento que integra o tipo ([20]). Só assim se podendo ter a esperança de aceder à compreensão do sentido jurídico-social do comportamento delituoso.

§ 24 A afirmação, por outro lado, de que o número de crimes se conta pelo número de tipos legais violados pelo comportamento global do agente constituiria, na sua pura afirmação verbal, um erro crasso que os defensores desta orientação, na verdade, não cometem. Todos reconhecem, com efeito, haver tipos legais de crime que se encontram numa relação tal que, embora formal e abstractamente aplicáveis a um comportamento singular, não o são efectiva e concretamente, porque a aplicação de um(ns)

([19]) Aqui residindo de resto, em nossa opinião, a razão mais funda de frequentes equívocos em que a nossa jurisprudência, louvando-se da doutrina de Eduardo Correia, tem incorrido na apreciação de vários casos concretos. E de que são exemplos frisantes as anotações críticas de MONIZ, Helena Isabel, Violação *e* coacção sexual? — Ac. do STJ de 2-6-2005, *RPCC 15*, 2005, pp. 299 e ss., 314 e ss., e MONTEIRO, Cristina Líbano, nota 13, a arestos jurisprudenciais portugueses recentes.

([20]) Como vimos que sucede, *v. g.*, em matéria de adequação social (11.º Cap., § 18 e s.), de legítima defesa (15.º Cap., § 39 e ss.) e do seu excesso (22.º Cap., § 34), de estado de necessidade (16.º Cap., § 32), de punibilidade (26.º Cap., §§ 8 e s., 11 e ss.), de desistência voluntária da tentativa (29.º Cap., §§ 7, 47).

deles afasta logicamente a aplicação do(s) outro(s). A este fenómeno se chama comummente **concurso legal ou aparente de (tipos legais de) crimes** (infra, 42.º Cap.). No sentido de que em casos tais as normas que contêm tipos legais de crimes se não aplicam — como no concurso — umas **ao lado** das outras, mas umas **em vez** de outras; excluindo por isso a aplicação de uma(s) a aplicação da(s) restante(s).

§ 25 De um **ponto de vista metodológico**, se a concepção analisada sob **2.** sofre de um exacerbado **positivismo** apesar dos melhores esforços nela reconhecíveis, a orientação agora em exame sofre de um **normativismo** não menos exasperado ([21]), ao reportar-se a tipos legais de crime que serão sempre meras abstracções relativamente ao mundo da vida, ao mundo social jurídico-penalmente relevante onde há-de colocar-se e resolver-se o problema da unidade ou pluralidade de **factos** puníveis. Se além — talvez possa também dizer-se assim, se bem que de uma forma só aproximativa — o essencial ocorre no mundo do ser psico-físico, aqui tudo se passa no mundo do dever-ser e da pura valoração. Esta é, em nossa opinião, a crítica decisiva de que todo este pensamento se torna passível. O que se tem de contar para determinação da unidade ou pluralidade de crimes não são por uma parte acções externas, como tal indiferentes ao sentido do comportamento; nem por outro lado tipos legais de crime como entidades abstractas, mesmo que concretamente aplicáveis ao caso. O que se tem de contar são **sentidos da vida jurídico-penalmente relevantes que vivem no comportamento global** ([22]).

4. Solução proposta: o critério da unidade ou pluralidade de sentidos sociais de ilicitude do comportamento global

§ 26 O "crime" por cuja unidade ou pluralidade se pergunta é o **facto punível** e, por conseguinte, uma violação de bens jurídico-penais que integra um tipo legal ao caso efectivamente aplicável. A essência de uma tal violação não reside pois nem por um lado na mera "acção", nem por outro na norma ou no tipo legal que integra aquela acção: reside no **substrato de vida** dotado de um sentido negativo de valor jurídico-penal,

---

([21]) Agudamente no sentido desta apreciação, TENREIRO, Mário, nota 5, pp. 1010 e ss., 1017 e ss.

([22]) Lembrar-se-á sempre a propósito o argumento de MEZGER / BLEI, p. 262, segundo o qual quem tem um cavalo branco de corrida não possui dois cavalos, um branco e outro de corrida!

reside — numa palavra que vimos usando e progressivamente concretizando ao longo de toda esta exposição sistemática — no ilícito-típico: **é a unidade ou pluralidade de sentidos de ilicitude típica**, existente no comportamento global do agente submetido à cognição do tribunal, **que decide em definitivo da unidade ou pluralidade de factos puníveis e, nesta acepção, de crimes**.

§ 27 Dir-se-á que, deste modo, acabamos afinal por subscrever — ao menos em perspectiva prático-normativa — a concepção que expusemos e criticámos por último: sempre que o agente, com o seu comportamento global, tivesse preenchido vários tipos penais — previstos em normas que se não encontrassem numa relação lógica de recíproca exclusão: infra, 42.º Cap. —, aí existiria sempre um **concurso** a exigir um **tratamento unitário** e cujo reconhecimento não implicaria qualquer *valoração*. A necessidade a que acabamos de aludir de descer a uma análise dos ilícitos-típicos compreendidos no comportamento global não existiria pois, ou seria de todo o modo dispensável; nada mais restando do que reconhecer em todos estes casos uma *pluralidade de factos puníveis* e submeter a sua punição a uma "pena conjunta" construída nos termos do art. 77.º No entanto, é esta crítica possível e a visão do problema em que assenta que importa **contestar**.

§ 28 Da circunstância de se dever aceitar a existência de um concurso de crimes em todos os casos em que o comportamento global do agente preenche mais que um tipo legal — ou o mesmo tipo legal por várias vezes — concretamente aplicáveis não resulta por necessidade que o tratamento de toda a categoria deva ser unitário e submetido, em termos de punição, à pena conjunta do art. 77.º Este preceito — já o dissemos, mas torna-se agora decisivo reacentuá-lo — impõe a punição do concurso com uma pena conjunta, cujo limite máximo da moldura penal aplicável é constituído pela **soma** das penas aplicadas a cada um dos crimes concorrentes; o que só pode significar que releva na sua *integralidade* o conteúdo de ilícito correspondente a cada um dos tipos preenchidos pelo comportamento global. Uma tal solução não é compatível com aqueles casos, embora tecnicamente *de concurso*, em que os conteúdos de ilícito — segundo o seu sentido no contexto do comportamento global — **se interceptam parcialmente** em maior ou menor medida. Punir tais casos segundo as regras do art. 77.º significaria sempre **violar o princípio (jurídico-constitucional) da proibição de dupla valoração**.

§ 29 E nem se diga que punir um *concurso* na moldura penal prevista pelo tipo legal de crime a que corresponda o sentido e o conteúdo do ilí-

cito dominante, como se afinal se tratasse não de concurso, mas de pura unidade do facto, significaria inversamente **violar o mandato (também ele jurídico-constitucional) da esgotante valoração** da matéria ilícita. Um tal argumento ficará afastado se o conteúdo ilícito que excede o sentido de ilícito dominante, não tendo influência na determinação da moldura do concurso, todavia **relevar para efeito de determinação da medida concreta da pena**.

§ 30 Se decisiva é, pois, a análise do significado do comportamento global que lhe empresta um sentido material (social) de ilicitude, terá então de reconhecer-se, de um ponto de vista *teleológico* e de *valoração normativa* "a partir da consequência", a existência de dois grupos de casos: (a) o caso ("normal") em que os crimes em concurso são na verdade recondutíveis a uma **pluralidade de sentidos sociais autónomos dos ilícitos-típicos** cometidos e, deste ponto de vista, a uma **pluralidade de factos puníveis** — hipóteses que chamaremos de concurso **efectivo** (art. 30.º-1), **próprio** ou **puro**; (b) e o caso em que, apesar do concurso de tipos legais efectivamente preenchidos pelo comportamento global, se deva ainda afirmar que aquele comportamento é **dominado por um único sentido autónomo de ilicitude**, que a ele corresponde uma **predominante e fundamental unidade de sentido dos concretos ilícitos-típicos** praticados — hipóteses que chamaremos de concurso **aparente**, **impróprio** ou **impuro**. Com a consequência de que só para o primeiro grupo de hipóteses deverá ter lugar uma punição nos termos do art. 77.º, enquanto para o segundo deverá intervir uma punição encontrada na moldura penal cabida ao tipo legal que incorpora o sentido dominante do ilícito e na qual se considerará o ilícito excedente em termos de medida (concreta) da pena ([23]).

§ 31 Assim terá ficado exposto o essencial do nosso pensamento sobre a questão em debate; e, simultaneamente, definida a série de operações, de diversa índole, que importa dilucidar ainda com algum pormenor. Haverá que eventualmente começar por determinar — através de uma operação lógico-jurídica e, nesta acepção, "formal" — se uma pluralidade de normas ou de leis incriminadoras convocadas em abstracto por um certo

([23]) Ideia esta, diga-se, não de todo estranha, de há muito, a uma parte da literatura jurídico-penal portuguesa a propósito, referida (e aplaudida) por ALMEIDA, Duarte d', nota 1, p. 85[235]; tendo OSÓRIO, José, chegado a sublinhar, na Comissão Revisora do ProjPG, o "acentuado rigorismo" do sistema proposto: *Actas II*, p. 152.

conteúdo de ilícito são concretamente aplicáveis umas ao lado das outras ou se, diferentemente, **há uma(s) norma(s) que prevalece(m) sobre a(s) outra(s) e exclui(em) por conseguinte a sua aplicação**. Se, face às normas concreta e efectivamente aplicáveis, **vários tipos legais** se encontrarem preenchidos pelo comportamento global *haverá concurso, mas não necessariamente concurso efectivo ou puro*. Este pode não existir se se verificar que à pluralidade de normas efectivamente aplicáveis corresponde, apesar dela, *um sentido jurídico-social de ilicitude material dominante*, verificando-se então um *concurso aparente ou impuro*. Se **apenas um tipo legal** foi preenchido, será de presumir que nos deparamos com uma unidade de facto punível; a qual no entanto, também ela, pode ser elidida se se mostrar que um e o mesmo tipo especial de crime foi preenchido **várias vezes** pelo comportamento do agente. Isto significa que o procedimento não pode em qualquer caso reduzir-se ao trabalho sobre *normas*, mas tem sempre de ser completado com um trabalho de apreensão do conteúdo de ilicitude material do *facto*. É ao cumprimento destas tarefas que serão dedicados os capítulos seguintes.

42.º CAPÍTULO

UNIDADE DE NORMA OU DE LEI

I. Pensamento fundamental

§ 1 Da circunstância de a um concreto comportamento ser em abstracto aplicável uma pluralidade de normas incriminadoras não pode concluir-se sem mais estarmos perante um concurso de factos puníveis. Importa, antes de tudo, determinar se as normas abstractamente aplicáveis se não encontram numa *relação lógico-jurídica* tal (numa relação, poderia dizer-se de "lógica hierarquia" (1)) que, em verdade, **apenas uma delas ou algumas delas são aplicáveis**, excluindo a aplicação desta ou destas normas (prevalecentes) a aplicação da ou das restantes normas (preteridas); pela razão de que à luz da(s) norma(s) prevalecente(s) se pode já avaliar de forma esgotante o conteúdo de ilícito (e de culpa) do comportamento global.

§ 2 Assim se falará neste contexto — antes que, como era tradicional, de *concurso legal* ou *concurso aparente* (2) — mais exacta e claramente **de unidade de norma ou de lei**. Logo importando sublinhar duas coisas. A primeira é a de que se trata aqui de uma **operação de natureza lógico-conceitual**, de um trabalho sobre normas (leis) que constitui "pressuposto" da indagação material da unidade ou pluralidade de crimes; por isso uma tal operação deve ser levada a cabo — e igualmente a sua exposição sistemática — **antes** que se afronte o problema substancial da unidade ou pluralidade do facto punível segundo o conteúdo do ilícito típico revelado. A segunda é a de que, persistindo-se em utilizar a expressão "con-

---

(1) CORREIA, Eduardo, II, p. 204.

(2) De designação "infeliz" fala ROXIN II, § 33, n.º 173, na base, precisamente, de que nestes casos não existe sequer "*concurso* de leis" porque, em verdade, apenas uma delas é aplicável.

curso **aparente**", ela deve servir não para a presente, mas para outra constelação problemática já de natureza não lógico-conceitual, mas material: para aqueles casos — referidos supra, 41.º Cap., § 30, sob (b) e que chamámos também de concurso impuro ou impróprio — em que, apesar de o comportamento global ser subsumível a uma pluralidade de tipos legais concretamente aplicáveis, todavia deva concluir-se *pela unidade do sentido social de ilicitude do facto punível.*

II. As formas de unidade de norma ou de lei

§ 3 São extremamente discutidas na doutrina *quais* as formas de unidade de lei que devem ser aceites e de que *modo* devem elas distinguir-se mutuamente. Apesar de os resultados de uma tal indagação se revelarem ainda hoje altamente inseguros, a doutrina dominante distingue três (por vezes quatro) categorias: a da **especialidade**, a da **subsidiariedade** e a da **consumpção**, à qual eventualmente se acrescenta — autonomizando-a face à última mencionada — a do **facto posterior não punido**; categorias que, todavia, são entendidas com âmbitos (muitas vezes profundamente) diversos e em múltiplas variantes. Há que fazer a este propósito duas observações.

§ 4 A primeira é que a distinção das formas de concorrência de normas tem **relevo categorial-classificatório**, mas **não possui relevo prático-normativo** (3). Isto provém fundamentalmente da circunstância de se tratar aqui de classificações lógico-formais, antes que de distinções que conduzam a um diferente tratamento jurídico-penal do caso em apreço: classifique-se este como de especialidade, de subsidiariedade, etc., a conclusão será sempre a de que **é só aplicada a norma prevalecente.** A segunda observação é que, vista a referida natureza do problema da unidade de lei, hão-de ser unicamente **considerações lógico-jurídicas** a comandar a extensão da categoria e a distinção de formas dentro dela. Na opinião de Klug, existem unicamente três **formas lógicas** de relacionamento dos tipos legais enquanto "conceitos de classes": a relação de exclusão (ou alternatividade), a de inclusão (ou subordinação) e a de interferência (ou sobreposição) (4).

(3) Na conclusão, por muitos outros, ROXIN II, § 33, n.º 176, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 18, n.º 4.

(4) KLUG, Zum Begriff der Gesetzeskonkurrenz. *ZStrW 68*, 1956, p. 405 e s. No mesmo sentido, M / GÖSSEL, § 55, n.º 26 e ss., e PUPPE, por último, em *NK*, n.º 7 antes do § 52, toda-

Sendo certo que a primeira destas relações — a de exclusão — acaba por conduzir à aplicabilidade de uma só das normas, apenas as relações de **inclusão** e de **interferência** podem suscitar o problema da unidade de lei tal como aqui releva, isto é, no sentido de encontrar uma norma prevalecente cuja aplicação afasta a aplicação da(s) restante(s).

1. Especialidade

§ 5 Uma relação de especialidade (5) entre normas típicas abstractamente aplicáveis a um facto existe sempre que **um dos tipos legais (lex specialis) integra todos os elementos de um outro tipo legal (lex generalis) e só dele se distingue porque contém um qualquer elemento adicional**, seja relativo à ilicitude ou à culpa. Por outra forma: uma das leis, repetindo ou incorporando todos os elementos constitutivos de um outro tipo (relação lógica de inclusão), todavia caracteriza o facto através de elementos suplementares e especializadores; pelo que a outra lei se subordina a esta (relação lógica de subordinação). Assim dando fundamento à velha asserção segundo a qual *lex specialis derogat legi generali*.

§ 6 Relação de especialidade existirá sempre, pois, entre qualquer *tipo fundamental* (lei geral) e o respectivo **tipo agravado** ou **privilegiado** (lei especial); *v. g.*, entre o tipo de homicídio simples (art. 131.º) e os tipos de homicídio qualificado, privilegiado ou a pedido da vítima (arts. 132.º-134.º); entre o tipo de aborto (art. 140.º) e o de aborto agravado (art. 141.º); entre o tipo de ofensa à integridade física simples (art. 143.º) e os de ofensa grave, agravada e privilegiada (arts. 144.º-148.º); entre o tipo de furto simples e o de qualificado (art. 204.º); entre o tipo de dano (art. 212.º) e os de dano qualificado e com violência (art. 213.º e s.); entre o tipo de burla simples (art. 217.º) e o de burla qualificada (art. 218.º); entre o tipo de ofensa à honra (art. 180.º e ss.) e o de ofensa à honra do Presidente da República (art. 328.º), etc. De especialidade será também a relação que intercede entre o *tipo simples* e o **tipo complexo** em que aquele se integre (6), *v. g.*, entre o tipo de roubo (art. 210.º) e os tipos integrantes de furto (art. 203.º e ss.) e de ofensa à integridade física (art. 143.º e ss.) ou/e à liberdade pessoal (art. 153.º e ss.).

---

via acabando esta por concluir que só a relação de inclusão dá origem ao problema agora em análise.

(5) Que terá sido exactamente caracterizada pela primeira vez por HONIG, *Studien zur juristischen und natürlichen Handlungseinheit*, 1925, p. 113.

(6) Não tendo interesse o apelo neste enquadramento, aliás vulgarizado na doutrina alemã, à figura do *delictum sui generis* (supra, 11.º Cap., § 53). Assim, por outros, PUPPE, *NK*, n.º 18 e s. antes do § 52.

§ 7 Hipótese muito discutida é a de saber se o tipo de **homicídio** deve ter-se como *lex specialis* face ao de **ofensa à integridade física** (7). A resposta deve ser afirmativa — pressuposta a unidade de comportamento a subsumir nas duas leis — na base de que não é técnica ou facticamente possível realizar aquele sem ter realizado este, existindo entre os dois, por conseguinte, aquela relação de *implicação conceitual* (de *inclusão*) que está na base da categoria da especialidade. Quando se trate da relação entre ofensa da integridade física grave ou qualificada e homicídio o caso poderá, no entanto, conduzir a uma pluralidade de normas aplicáveis se a ofensa corporal se não representar como um *estado lógico-conceitualmente necessário* do homicídio (8), nomeadamente, por força de uma pluralidade de resoluções criminosas indiciadora de dois sentidos de ilicitude. Por igual razão pensamos ser de especialidade — e não de mera subsidiariedade ou consumpção, como sustenta a doutrina alemã maioritária — a relação que intercede entre a generalidade dos **crimes sexuais** e os de **injúria** (art. 182.º) neles contidos. Como também, no nosso direito, a relação entre o **furto com arrombamento** (art. 204.º-2/*e*)) e o **dano** (art. 212.º) (9). Problema hoje igualmente muito discutido entre nós é o de saber se a relação de especialidade subsiste quando ela se verifique entre tipos legais pertencentes a **diferentes domínios** do direito penal total, *v. g.*, e nomeadamente, entre um tipo legal do direito penal fiscal e o tipo legal homólogo do direito penal geral. A doutrina e a jurisprudência portuguesas mais recentes respondem afirmativamente a esta questão; e sem dúvida que com plena razão. Sem prejuízo de se poder considerar que em casos deste teor emerge, mais que uma regra de concorrência de normas, a superação normativa "de um concurso de ordenamentos jurídicos: o direito penal comum e o direito penal tributário" (10), tudo dependerá de determinar se, no caso de espécie, se verifica na verdade uma relação de especialidade entre os tipos legais questionados.

§ 8 Dúvidas podem suscitar-se quando, relativamente ao mesmo tipo fundamental, **concorram diversas causas de agravação**, suscitando-se então a questão de saber em que relação esses tipos qualificados se encontram entre si; p. ex., quando no crime de furto concorram as qualificações da introdução ilegítima em habitação (art. 204.º-1/*f*)) e de membro de

---

(7) A jurisprudência alemã conclui por uma relação não de especialidade, mas de *subsidiariedade*. Como no texto porém, entre outros, PUPPE, *NK*, n.º 10 antes do § 52, e ROXIN II, § 33, n.º 17.

(8) Cf., também, ROXIN II, § 33, n.º 206.

(9) De casos de "especialidade aproximativa" fala a este propósito PUPPE, *NK*, n.º 22 e s. antes do § 52.

(10) DIAS, Figueiredo / ANDRADE, Costa, O crime de fraude fiscal no novo direito penal tributário. Considerações sobre a factualidade típica e o concurso de infracções, *RPCC 6*, 1996, p. 78. Sobre o problema, SOUSA, Susana Aires, *Os Crimes Fiscais*, 2006, pp. 101 e ss. e 140 e s. e, por último, com indicações jurisprudenciais e doutrinais esgotantes, ANDRADE, Costa, A fraude fiscal — Dez anos depois, ainda um "crime de resultado cortado"?, *RLJ 135*, 2006, pp. 326 e ss., 346 e ss.

um bando (art. 204.º-2/*g*)). Ao menos em princípio não se verificará em casos destes uma relação de inclusão ou subordinação, devendo por isso concluir-se — salvo se o caso for qualificável como de subsidiariedade, nomeadamente de subsidiariedade expressa (cf. infra, § 12) — pela pluralidade de leis aplicáveis ([11]). E o mesmo deve afirmar-se — ainda com maior ênfase — para os casos ditos de **concorrência de qualificação e privilegiamento** no mesmo substrato de facto, *v. g.*, arts. 132.º e 133.º, ou 146.º e 147.º: o problema que aqui se suscita é o do sentido do ilícito típico, não o de uma pretensa unidade de lei; no estado prévio em que ocorre o nosso problema de agora a solução de princípio só pode ser a de que as leis concorrentes devem neste caso aplicar-se umas ao lado das outras ([12]).

§ 9 Deve por fim assinalar-se que uma relação de especialidade só deve ser afirmada quando **o tipo legal prevalecente tenha alcançado a consumação** ([13]), já não quando esteja em causa uma **tentativa do tipo especial e a consumação do tipo geral** (*v. g.*, tentativa de homicídio ou de aborto e ofensa à integridade física consumada; ou tentativa de violação e coacção sexual consumada ([14])). A jurisprudência alemã inclina-se para ver aqui relações de subsidiariedade. Cremos porém que em casos deste teor não deve afirmar-se nem a especialidade, nem a subsidiariedade (infra, § 11 e ss.), que eles não são casos de "unidade", mas de *pluralidade de normas ou de leis* concretamente aplicáveis. De outra forma ficaria *à partida* por considerar que o agente produziu o resultado típico da lei excluída, o qual se não contém na lei prevalecente sob a forma tentada. Dizer isto implica, portanto, ver aqui casos de "concurso" de crimes, se bem que não forçosamente sob a forma de um concurso de crimes efectivo, puro ou próprio (supra, 41.º Cap., § 30, e infra, 43.º Cap., § 28 e ss.).

§ 10 Uma parte substancial da doutrina alemã pretende que a relação de especialidade — bem como, de resto, a de subsidiariedade: infra, § 11 — nem sempre se

---

([11]) A jurisprudência alemã dominante pretende que o caso será ainda de unidade de lei, não se mantendo todavia fiel a esta qualificação quando se trata do regime de punição. A doutrina alemã dominante parece ir no sentido da subsidiariedade ou da consumpção. Como no texto, sem a ressalva nele referida, JESCHECK / WEIGEND, § 69, II, 1, e PUPPE, *NK*, n.º 17 antes do § 52.

([12]) Neste sentido, também, PUPPE, *NK*, n.º 20 e s. antes do § 52.

([13]) Assim, PUPPE, *NK*, n.º 14 e ss. antes do § 52.

([14]) Cf. o interessante caso decidido pelo Ac. do STJ de 2-6-2005 que infra, 43.º Cap., § 29 e nota 42, será referido, bem como a anotação de MONIZ, Helena Isabel, Violação e coacção sexual?, *RPCC 15*, 2005, pp. 299 e ss. e 307 e ss.

reduz a uma questão puramente lógico-jurídica de normas, antes tem por vezes de ser completada por considerações **teleológicas** relacionadas com o conteúdo de ilícito material correspondente ao tipo legal cuja aplicação deveria ser em princípio excluída ([15]). Este "**alargamento material**" da categoria da especialidade deve no entanto ser contestado, uma vez que ele subverte a própria essência e natureza **lógico-conceitual** do problema "prévio" da "unidade de norma ou de lei". Em casos como os referidos deve por isso concluir-se em princípio pela concorrência de normas concretamente aplicáveis àquele comportamento.

2. Subsidiariedade

§ 11 Relação de subsidiariedade existe quando **um tipo legal de crime deva ser aplicado somente de forma auxiliar ou subsidiária**, se não existir outro tipo legal, em abstracto também aplicável, que comine pena mais grave. Está aqui em questão a relação lógica dita de **interferência** (ou de **sobreposição**): *lex primaria derogat legi subsidiariæ*. De forma análoga ao que acontece com a especialidade, uma parte da doutrina quer distinguir também uma subsidiariedade formal de uma subsidiariedade material ([16]); mas o que aqui releva é uma verificação de índole diferente daquela que se pretende existir na especialidade, sendo por isso preferível, para claramente o dar a entender, falar de uma subsidiariedade *expressa* e de uma subsidiariedade *implícita*.

2.1. Subsidiariedade expressa

§ 12 Subsidiariedade expressa existe onde o teor literal de um dos tipos legais restringe expressamente a sua aplicação à inexistência de um outro tipo legal que comine pena mais grave — quer nomeie esse outro tipo (*subsidiariedade especial*), quer determine em geral a subordinação (*subsidiariedade geral*). O legislador português faz um uso generoso — porventura demasiado generoso, como forma de evitar lacunas de punibilidade derivadas de um menor cuidado e precisão nas descrições típicas — da cláusula de subsidiariedade expressa geral; nomeadamente quando se trata, *et pour cause*, de crimes contra bens jurídicos supra-individuais ou colectivos.

([15]) Entre outros, ROXIN II, § 33, n.º 182. A distinção, mais geral do que a referida no texto mas em todo o caso essencialmente equivalente, entre unidade legal *formal* e *material* reconduz-se a ABELS, *Die "Klarstellungsfunktion" der Idealkonkurrenz*, 1991, p. 17 e ss.; entre nós, ALMEIDA, Duarte d', *O "Concurso de Normas" em Direito Penal*, 2004, p. 102 e ss.

([16]) Assim, por último, ROXIN II, § 33, n.º 191 e ss.

§ 13 Cláusulas de subsidiariedade parece estarem **expressamente consagradas**, considerando apenas a PE do nosso CP, nos tipos legais de crime de intervenção médica com violação das *leges artis* e criação de um perigo para o corpo e para a saúde (art. 150.º-2), furto de uso de veículo (art. 208.º-1), usurpação de coisa imóvel (art. 215.º 1), perturbação de arrematações (art. 230.º), tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes e desumanos (art. 243.º-1), condução de veículo em estado de embriaguez ou sob a influência de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas (art. 292.º-1), lançamento de projéctil contra veículo (art. 293.º), instigação pública a um crime (art. 297.º-1), apologia pública a um crime (art. 298.º-1), participação em motim (art. 302.º), usurpação de autoridade pública portuguesa (art. 320.º), entrega ilícita de pessoa a entidade estrangeira (art. 321.º), crime contra pessoa que goze de protecção internacional (art. 322.º-1 e 2), atentado contra o Presidente da República (art. 327.º-1), ligações com o estrangeiro (art. 331.º), coacção contra órgãos constitucionais (art. 333.º-1 e 2), tráfico de influências (art. 335.º-1*a)* e *b)*), obstrução à inscrição de eleitor (art. 337.º-1), coacção de eleitor (art. 340.º), descaminho ou destruição de objectos colocados sob o poder público (art. 355.º), peculato (art. 375.º-1 e 3), concussão (art. 379.º-1 e 2), abuso de poder (art. 382.º) ([17]).

§ 14 A extensão com que a nossa lei consagra casos de subsidiariedade expressa, aliada a uma visível falta de critério na sua eleição, confere acuidade particular à questão ([18]) de saber se ainda se obedece à teleologia legislativa quando, por via interpretativa, se restringe a subsidiariedade, embora expressa, aos casos em que é **fundamentalmente o mesmo o bem jurídico protegido** pelas normas concorrentes. Cremos que não. Através da fórmula canónica da subsidiariedade expressa quis a lei dar relevo (ou mesmo "criar") uma relação lógica de interferência entre os tipos legais convocados e não vemos razão ou legitimidade para pôr em causa esta decisão do legislador. A pretendida "análise **material**" da subsidiariedade expressa em que repousa a doutrina em crítica importaria sempre uma mudança radical de plano (e de problema), que passaria da relação lógica entre normas para a relação substantiva entre sentidos dos ilícitos àquelas normas subjacentes.

([17]) Diferentemente, ALMEIDA, Duarte d', nota 15, p. 115 e ss., pretende que estes casos (todos ou alguns) constituirão hipóteses de "verdadeiro concurso de *crimes*" submetidos a "um regime punitivo mais favorável do que o previsto no art. 77.º"; que serão pois, na nossa terminologia, casos de concurso de crimes impuro ou impróprio.

([18]) Muito discutida na doutrina e na jurisprudência alemãs: referências a propósito em JESCHECK / WEIGEND, § 69, II, 2, e ROXIN II, § 33, n.º 193 e ss.

2.2. Subsidiariedade implícita

§ 15 De subsidiariedade **implícita** (ou **tácita**) fala-se naqueles casos em que, apesar do silêncio da lei a propósito, o legislador entendeu criar, para alargamento ou reforço da tutela, tipos legais abrangentes de factos que se representam ou como **estádios evolutivos, antecipados ou intermédios, de um crime consumado**; ou como formas **menos intensivas de agressão ao mesmo bem jurídico**. Não se trata aqui desde logo, no entanto, de dois grupos completamente distintos, antes eles podem sobrepor-se em medida sensível. Por outro lado, e sobretudo, se não há objecção a que, em certos de tais casos, se aceite uma relação de subsidiariedade, já outros casos configurarão uma hipótese de concorrência de normas e portanto de concurso, em regra aparente ou impuro.

§ 16 O primeiro grupo pode ver-se integrado por casos como o dos tipos legais que punem **actos preparatórios** (arts. 271.º, 274.º e 344.º) relativamente aos que punem a **tentativa** ou a **consumação** dos crimes respectivos ([19]). *V. g.*, os tipos legais de crime contemplados pelo art. 271.º são preteridos na sua aplicabilidade se ao facto for aplicável a norma que prevê o crime, tentado ou consumado, de contrafacção de moeda ou de valores selados (art. 268.º) ([20]). O mesmo devendo afirmar-se relativamente à relação entre tentativa e consumação do *mesmo* crime ([21]).

§ 17 O segundo grupo de hipóteses de subsidiariedade tácita pode ver-se integrado por casos como os das relações entre os tipos legais que prevêem **crimes de perigo** e os que prevêem os **crimes de dano** correspondentes, ou entre os que prevêem outras formas menos intensivas

---

([19]) Restritiva PUPPE, NK, n.º 42 e s. antes do § 52, para quem a unidade de norma só valeria relativamente aos actos preparatórios punidos pela lei de forma geral (*v. g.*, art. 344.º), mas já não àqueles que a lei especifica, decerto em nome da sua especial gravidade ou perigosidade. Cremos porém que mesmo nestes casos o seu conteúdo de ilícito deve ter-se por subsidiário relativamente à tentativa ou à consumação. Assim, também, ROXIN II, § 33, n.º 200.

([20]) Assim, entre nós, MONIZ, Helena Isabel, *Comentário Conimbricense*, II, art. 271.º, § 19.

([21]) Nesta medida, a categoria — que em certo período da evolução doutrinal chegou a ser autonomizada — do *facto prévio não punido* torna-se neste contexto dispensável, como de resto reconhece a doutrina hoje dominante: cf., só, JESCHECK / WEIGEND, § 69, II, 2, S / S / STREE, n.º 119 antes do § 52, STRATENWERTH, § 18, n.º 15 (de forma algo diferente STRATENWERTH / KUHLEN, § 18, n.º 16). Entre nós, já, CORREIA, EDUARDO, *Unidade e Pluralidade de Infracções*, 1945, pp. 160 e ss., 181 e ss. Se bem que noutros contextos o facto prévio co-punido possa conduzir à pluralidade de leis aplicáveis: infra, 43.º Cap., § 18 e ss.

relativamente a formas mais intensivas (e por isso mais puníveis) de lesão, *desde que seja o mesmo o bem jurídico protegido* ([22]). Assim, *v. g.*, se existe uma relação de subsidiariedade expressa (como vimos supra, § 13) entre os crimes dolosos de perigo abstracto e os de perigo concreto de condução de veículo em estado de embriaguez (arts. 291.º e 292.º), uma relação da mesma natureza, se bem que agora *implícita*, existirá para a generalidade do relacionamento entre tipos legais de **perigo abstracto** e de **perigo concreto**. Relação que existirá igualmente entre os tipos legais de **perigo** (abstracto, concreto, abstracto-concreto) e os tipos de **dano** correspondentes: *v. g.*, o tipo legal da condução perigosa de veículo rodoviário (art. 291.º) é subsidiário relativamente aos tipos legais dolosos de lesão da vida, da integridade física grave ou de dano qualificado pelo valor elevado da coisa danificada ([23]); bem como o tipo legal da exposição ou abandono (art. 138.º) deve ter-se por subsidiário relativamente aos tipos legais de crime dolosos de ofensa à integridade física grave ou de homicídio. De outra parte, também o tipo de crime de embriaguez e intoxicação (art. 295.º) será subsidiário relativamente à **actio libera in causa** dolosa (art. 20.º-4 e supra, 21.º Cap., § 50 e ss.). Nesta vertente da subsidiariedade implícita radicarão ainda casos como os da relação entre as normas relativas à **autoria** e à **cumplicidade** (*v. g.*, aquele que determina outrem à prática do facto presta depois auxílio material à sua execução), entre violação de um **dever de garante** (art. 10.º) e violação do geral **dever de auxílio** (art. 200.º) ([24]), entre a norma que prevê um **delito doloso** e a que prevê o **delito negligente** correspondente. Em qualquer destes casos a relação lógica intercedente entre os tipos legais não é a de inclusão ([25]), mas a de interferência.

3. Consumpção?

§ 18 Uma terceira categoria determinante da unidade de normas ou de leis seria a da consumpção. Ela existiria quando **o conteúdo de um ilí-**

([22]) No sentido desta restrição, ROXIN, § 33 II, n.º 209.

([23]) Enquanto relativamente aos tipos legais *negligentes* respectivos haverá concorrência de normas e por conseguinte concurso.

([24]) DIAS, Figueiredo, A propósito da "ingerência" e do dever de auxílio nos crimes de omissão, *RLJ 116*, 1993-4, p. 55; e, depois, CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, I, 1999, art. 200.º, § 46.

([25]) Neste sentido, todavia, PUPPE, *NK*, n.ºs 9 e 22 e s. antes do § 52, usando também a este propósito o seu conceito de "especialidade aproximativa".

cito-típico inclui em regra o de outro facto, de tal modo que, em perspectiva jurídico-normativa, **a condenação pelo ilícito-típico mais grave exprime já de forma bastante o desvalor de todo o comportamento**: *lex consumens derogat legi consuntæ*. A diferença fundamental face às categorias anteriormente consideradas reside em que aqui se tomam em consideração os **factos** nas suas conexões típicas, e se assume que o legislador teria já levado implicitamente em conta esta circunstância, ao editar as molduras penais respectivas ([26]). Deste ponto de vista — o de uma consumpção **em sentido estrito** —, seriam fundamentalmente dois os grupos de situações que integrariam a categoria da consumpção: o dos **factos tipicamente acompanhantes** (*v. g.*, ao tipo legal do furto por escalamento do art. 204.º-2/*e)* está tipicamente, mas não necessariamente, ligado o de violação do domicílio do art. 190.º, como ao de aborto do art. 140.º, nas mesmas condições, o de ofensa à integridade física do art. 143.º); e o dos **factos posteriores não punidos** (*v. g.*, quando a um crime de apropriação se siga a destruição da coisa apropriada).

§ 19 Vários AA. porém — de que Eduardo Correia constitui entre nós exemplo paradigmático — tendem a conferir à categoria da consumpção um *âmbito muito mais lato* do que aquele que acima ficou traçado, de modo a nele abranger todas as **relações de mais e menos que se estabelecem entre os valores jurídico-criminalmente protegidos** ([27]) pelas normas concorrentes. O que acabaria por abranger todas aquelas hipóteses em que os ilícitos-típicos singulares se intersectam ou coincidem parcialmente no seu âmbito de protecção, sendo embora diferentes os bens jurídicos lesados por uns e outros; e em que, por conseguinte, a punição do concurso não deveria seguir a norma de sanção do art. 77.º, mas ocorrer em termos idênticos àqueles em que ocorre a punição dos casos de especialidade e de subsidiariedade, isto é, como unidade de lei (e, por isso, também, de punição apenas em função dela).

§ 20 A categoria da consumpção — seja tomada em sentido estrito ou em sentido amplo — é prezável na sua essência mas (contra o que entendeu até há pouco a doutrina unânime e entende ainda hoje a doutrina

---

([26]) Clara e completamente já nestes termos, CORREIA, nota 20, p. 168 e ss. Também JESCHECK / WEIGEND, § 69, II, 3.

([27]) Nestes precisos termos, CORREIA, Eduardo, nota 20, p. 171, e II, § 10, n.º 36, I, *b*.

dominante) **insusceptível de constituir uma hipótese de unidade de normas ou de leis** ([28]). Em primeiro lugar, e decisivamente, ela não acarreta um problema *lógico* de relacionamento de normas, mas um problema *axiológico* e *teleológico* de relacionamento de sentidos e de conteúdos do ilícito. Nesta medida, e em segundo lugar, os casos de consumpção constituem hipóteses de pluralidade de normas concretamente aplicáveis e suscitam, por isso, um problema de *concurso de crimes*. Só que, na verdade, a questão que esta categoria suscita é bem fundada — mesmo quando ela é assumida no seu sentido mais amplo — na parte em que chama a atenção para casos da vida em que os sentidos e os conteúdos singulares dos ilícitos se interceptam e se cobrem mutuamente, de tal modo que valorá-los na sua integralidade significaria violação da proibição de dupla valoração. Enquanto, por outro lado, não sendo total a sua coincidência, a sua punição adequada exige que se não interrompa cedo demais o mandato de esgotante valoração da matéria ilícita. Numa palavra, **a ideia que preside à categoria da consumpção é na sua essência aquela que dissemos dever presidir ao concurso aparente, impróprio ou impuro de factos puníveis** e nesse contexto deve ser tratada (infra, 43.º Cap., § 11 e ss.).

III. O regime jurídico da unidade de norma ou de lei

§ 21 O problema da unidade de normas ou de leis é, por sua própria essência e natureza, **insusceptível de regulamentação legal**. Para a doutrina e a jurisprudência ainda hoje dominantes à definição do regime jurídico cabido a esta categoria importariam normas como a do art. 30.º-1, na parte em que exige que, para haver concurso, haja pluralidade "de tipos de crime *efectivamente* cometidos"; e, sobretudo a do art. 77.º-4, ao dispor que "as penas acessórias e as medidas de segurança são sempre aplicadas ao agente, ainda que previstas por uma só das leis aplicáveis". Estas normas são no entanto **estranhas ao problema da unidade de normas ou de leis** e unicamente válidas para o concurso de crimes. E no entanto, apesar da insusceptibilidade de regulamentação legal (ou por causa dela!), o "regime jurídico da unidade de normas" parece ser absolutamente seguro e evidente: ele **deve ir buscar-se somente à norma prevalecente** e única

([28]) Uma extensa crítica, também, em ALMEIDA, Duarte d', nota 15, p. 59 e ss., concluindo pela recondução de uma grande parte dos casos ditos de "consumpção" à figura do "concurso ideal".

concretamente aplicável, **não (ou não também) à norma excluída**. Há todavia algumas precisões que importa introduzir neste princípio.

§ 22 **(a)** Desde logo, de concorrência (lógica) de normas só deve falar-se quando no caso a subsumir se verifiquem todos os **pressupostos materiais de punibilidade** em relação aos vários tipos legais de crime em abstracto aplicáveis. Se falta algum destes pressupostos não pode em rigor falar-se nem de "concorrência de normas" aplicáveis, nem de norma "prevalecente" e de norma "excluída": concretamente aplicável é apenas aquela que prevê o tipo legal que foi preenchido pelo comportamento. Não vemos por isso razão para, sob qualquer alegação, falar, a este propósito, de uma eventual "ressurreição" da norma afastada. Já se faltam **pressupostos positivos ou negativos da punição** (não da punibilidade) (29) — queixa e acusação particular, amnistia e indulto, prescrição —, parece que, nos casos de especialidade e subsidiariedade, a norma prevalecente há-de manter o seu **efeito de clausura** da norma preterida. Assim, existindo embora uma clara relação de especialidade entre o homicídio a pedido da vítima (art. 134.º) e o homicídio simples (art. 131.º), é impensável punir por este último crime quem matou outra pessoa a pedido dela quando este crime já prescreveu. Também, como vimos, existe uma relação de subsidiariedade entre o tipo legal de crime do art. 271.º (actos preparatórios) e o que pune a contrafacção de moeda (art. 262.º): tendo por hipótese este crime sido amnistiado, não teria sentido fazer ressuscitar, ainda que não tivesse sido amnistiada, a punição da importação do papel destinado àquela contrafacção (art. 271.º-1/*b*)). Em suma, determinada a norma concretamente aplicável, é todo o seu regime que se aplica.

§ 23 **(b)** Alega, por outro lado, a doutrina alemã dominante que, mesmo devendo reconhecer-se o efeito preclusivo da norma prevalecente, tal só deve valer para a "norma de comportamento" (para a determinação do facto punível), *não necessariamente para a "norma da sanção"* (para a determinação das consequências jurídicas) (30); a este propósito se falando de um **efeito de bloqueio** da sanção prevista pela norma preterida. Têm-se aqui sobretudo em vista casos em que o limite mínimo da moldura penal

(29) Sobre a distinção que aqui vai implicada cf. já, em alguma medida, supra, 26.º Cap., § 15 e s., e a Parte V do nosso *DP II*.

(30) Poderia também dizer-se, em termos jurídico-processuais, só deve valer para a "questão da culpabilidade", não já necessariamente para a "questão da sanção".

da norma excluída, "tipicamente mais leve", é todavia superior ao da norma prevalecente. Cremos que isto será praticamente impossível de suceder, entre nós, nos casos de especialidade e de subsidiariedade. Mas ainda quando possa suceder, não somos capazes de excogitar razão bastante — político-criminal ou dogmática — para que se tome em conta a norma de sanção, sejam quais forem os seus termos, de uma lei *que não é concretamente aplicável* ao caso de espécie. Tal nos parece que acarretaria, isso sim, violação flagrante do princípio da legalidade criminal. Precisamente pela mesma razão também, diferentemente da generalidade da doutrina alemã ([31]), não vemos haver lugar para aplicação de **penas acessórias** ou **medidas de segurança** criminais previstas unicamente pela lei excluída, não se aplicando ao caso da unidade de leis, como já dissemos, o disposto no art. 77.º-4.

§ 24 **(c)** Uma última questão suscitada neste enquadramento pela doutrina alemã diz respeito a saber se o delito contemplado pela norma excluída pode em todo o caso, sob certas circunstâncias, ser considerado na determinação da **medida da pena** ([32]). Segundo a concepção aqui exposta, a resposta deve ser a seguinte: um ilícito preterido não pode influenciar a medida da pena no sentido de ser considerado e tratado com uma *relevância jurídico-penal autónoma* que já, de acordo com a essência da unidade de normas, precisamente lhe falta; o que não impedirá que o *comportamento* através do qual o tipo submetido foi preenchido possa relevar, independentemente da sua tipicidade, no contexto do ilícito prevalecente, como factor de medida da pena a este cabida ([33]). Pressuposto, como é evidente, que desta forma não seja violado o princípio da *proibição de dupla valoração*.

([31]) Pela qual podem ver-se JESCHECK / WEIGEND, § 69, III, 2, ROXIN II, § 33, n.º 247, e S / S / STREE, n.º 141 antes do § 52.

([32]) Favoravelmente, entre outros, JESCHECK / WEIGEND, § 69, III, 3, ROXIN II, § 33, n.º 240 e s., e S / S / STREE, n.º 141 antes do § 52.

([33]) Assim, também, no essencial, ERB, Überlegungen zu einer Neuordnung der Konkurrenzen, *ZStW 117*, 2005, p. 81 e ss.

43.º CAPÍTULO

CONCURSO DE CRIMES

§ 1 Do anteriormente exposto resulta que concurso de crimes existe sempre que no mesmo processo penal (ou em processo penal posterior destinado ao conhecimento de um concurso superveniente) o comportamento global (1) imputado ao agente — traduza-se ele numa unidade ou pluralidade de *acções* — preenche **mais que um tipo legal de crime**, previsto em mais que uma norma concretamente aplicável, ou preenche **várias vezes o mesmo tipo legal de crime** previsto pela mesma norma concretamente aplicável: art. 30.º-1. Dissemos no entanto também que esta figura do concurso de crimes, à primeira impressão, unitária, se divide em duas categorias: a do concurso efectivo, puro ou próprio, em que se verifica uma pluralidade de sentidos de ilícito do comportamento global; e a do concurso aparente, impuro ou impróprio, em que, no comportamento global, se verifica uma absoluta dominância ou prevalência de um sentido de ilícito sobre outro ou outros sentidos de ilícito concorrentes, mas assim dominados, subordinados, dependentes ou acessórios.

§ 2 O que nesta consideração existe de radicalmente diferente face às situações analisadas no capítulo anterior é que o problema do concurso de crimes já não tem a ver com uma qualquer concorrência — lógica ou formal — de normas abstractamente aplicáveis ao caso *sub iudice*; antes, resolvida previamente essa questão de concorrência de normas (se é que ela se suscitava no caso), se depara com uma situação global à qual são concretamente aplicáveis mais que uma norma, ou a mesma norma várias vezes. Assim sendo, toda a perspectiva jurídico-penalmente relevante se modifica: o problema deixa de ser o da análise de relações entre normas para passar a ser o da análise do **comportamento global e dos concretos sentidos de ilícito** que nele se exprimem; o método analítico deixa de ser **lógico**, para passar a ser **teleoló-**

(1) O "grande facto", na expressão sugestiva de MONTEIRO, Cristina Líbano, A pena "unitária" do concurso de crimes — Anotação ao Ac. do STJ de 12-7-2005, *RPCC 16*, 2006, p. 159.

gico; a solução há-de provir não de considerações de ordem **formal**, mas de uma argumentação **substancial** ou **material** levada a cabo em função do significado social do comportamento em apreciação perante a ordem dos tipos de ilícito contidos nas normas concretamente aplicáveis.

I. O concurso de crimes efectivo, puro ou próprio

§ 3 O tipo de ilícito — sabemo-lo já — é o portador, a expressão ou a sedimentação do "específico sentido de desvalor jurídico-penal que atinge um concreto comportamento humano numa concreta situação, atentas portanto todas as condições reais de que ele se reveste ou em que tem lugar" (supra, 10.º Cap., § 54 e s.). Por isso, da *pluralidade de normas típicas* concretamente aplicáveis ao comportamento global é legítimo concluir, *prima facie*, que aquele comportamento revela uma **pluralidade de sentidos sociais de ilicitude** que, segundo o mandamento da esgotante apreciação contido na proibição jurídico-constitucional de dupla valoração, devem ser **integralmente valorados para efeito de punição**. A esta luz — e só a ela — fica justificada a aplicação do disposto no art. 77.º-2 e o sistema aí contido de *soma* das penas concretamente aplicadas aos vários crimes para efeito de determinação do limite máximo da pena (conjunta) do concurso de crimes. Aí deparamos, deste modo, com aquilo que chamámos concurso de crimes **efectivo, puro ou próprio** e se encontra previsto no art. 30.º-1. Concurso que doutrinalmente se dirá **heterogéneo** sempre que sejam diferentes os crimes que compõem o comportamento global. Assim, p. ex., se ao comportamento global de *A*, objecto de um mesmo processo penal (ou e um processo penal por concurso superveniente), forem concretamente aplicáveis as normas do arts. 131.º, 164.º e 217.º — porque matou *B*, violou *C* e burlou *D* —, é seguro tratar-se aí de um concurso heterogéneo de crimes efectivo, ao qual é aplicável o disposto no art. 77.º (eventualmente, no art. 78.º). O mesmo sucedendo se, num processo penal, a *E* forem aplicáveis as normas dos arts. 212.º-1 e 148.º-1, porque com uma pedrada quis quebrar a vitrina da loja do seu concorrente *F* e ferir o empregado *G* que dentro daquela se encontrava.

§ 4 Exactamente **o mesmo tratamento jurídico-penal** merecem — atenta a inquestionável identidade de valoração normativa a eles cabida — os casos em que ao comportamento global é concretamente aplicável apenas **uma norma típica**, mas esta foi violada **mais que uma vez** pelo comportamento global (p. ex., *H* ofende num dia a integridade física de *I* e,

encontrando-o de novo uns dias passados, repete a conduta; ou *J* mata— com vários disparos ou com uma bomba, na mesma altura ou em alturas diversas — *L*, *M* e *N*). Também nestes casos o comportamento global revela uma pluralidade de sentidos de ilícito e, deste modo, um concurso efectivo **homogéneo**, ao qual é igualmente aplicável o disposto no art. 77.º Convém estabelecer no entanto, de forma mais próxima, o que é, nos termos do art. 30.º-1, ou como se conta aquele "**número de vezes**" que o mesmo tipo foi preenchido pela conduta global.

§ 5 Recorde-se que para Eduardo Correia o "número de vezes" que o mesmo tipo foi preenchido pela conduta deveria contar-se pelo número de **juízos de censura da culpa** de que o agente se tivesse tornado passível (supra, 41.º Cap., § 21). O que, por sua vez, deveria ser reconduzido — manifestando uma opinião que, no essencial, ainda hoje se encontra largamente difundida na doutrina, especialmente na alemã — à **pluralidade de processos resolutivos**, de resoluções ou de decisões criminosas, ou à **renovação** do mesmo processo, que no caso se houvessem verificado (2). Esta pluralidade seria excluída, em regra, pela **continuidade temporal** das várias condutas do agente, sempre que, de acordo com as circunstâncias do caso, devesse aceitar-se que "o agente executou toda a sua actividade sem ter que renovar o respectivo processo de motivação" (3). Não cremos, porém, que esta concepção possa, em definitivo, ser aceite (4).

§ 6 Pode convir-se que a unidade ou pluralidade de processos de resolução constitua, em certos casos, um elemento importante para decidir da unidade ou pluralidade de sentidos de ilicitude do comportamento global. Como pode concordar-se que não seja decisiva a crítica — todavia, válida em si mesma — de que um tal critério só tem cabimento relativamente a delitos dolosos, não a delitos negligentes. O que não pode aceitar-se, seja a perspectiva mais acentuadamente psicológica ou normativa, é que a unidade de resolução seja sinal seguro da unidade de sentido de ilí-

---

(2) CORREIA, Eduardo, *Unidade e Pluralidade de Infracções*, 1945, pp. 114 e ss., 351 e ss.

(3) CORREIA, Eduardo, II, § 35, *in fine*. Fundamentalmente no mesmo sentido, MONIZ, Helena Isabel, Violação *e* coacção sexual?, *RPCC 15*, 2005, p. 322 e s.

(4) E não por, para Eduardo Correia, se verificar neste contexto uma introdução de elementos do juízo de *culpa* no problema. O eventual relevo para ele da unidade ou pluralidade de processos resolutivos continua a ser o mesmo e a ser a mesma a sua estrutura quando eles sejam concebidos, como devem, como elementos do *tipo subjectivo de ilícito*, antes que como elementos do tipo de culpa.

cito revelada pelo comportamento. Bem pelo contrário, **a unidade de resolução é em absoluto compatível com a pluralidade de sentidos autónomos de ilícito dentro do comportamento global**, mesmo que não exista descontinuidade temporal entre os diversos actos praticados. E isto é assim, trate-se de bens jurídicos lesados *eminentemente pessoais* (*v. g.*, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade sexual) *ou não* (*v. g.*, a propriedade, o património, o meio ambiente, a ordem e a tranquilidade públicas). Se, através de uma só resolução, *A* ofende corporalmente (art. 143.º-1) o casal *B* e *C*, que passeia de braço dado no parque, há concurso efectivo de crimes porque o tipo de ofensa à integridade física foi violado duas vezes; como há se *A* furta (art. 203.º-1) a carteira de *B* e a bolsa de *C*; como ainda se *D*, vendedor de produtos industriais, fornece às fábricas *F* e *G*, encoberta e dolosamente, produtos poluentes que elas utilizarão no seu funcionamento (art. 279.º). Por outro lado, **a pluralidade de resoluções é ainda compatível com a unidade de sentido de ilícito do comportamento total**, estejam em causa ou não bens eminentemente pessoais. Se *H* decide praticar através de determinados actos sexuais de relevo um crime de coacção sexual sobre *I* (art. 163.º) mas, no decurso da conduta, toma a resolução de praticar outros actos ou novos ou mais actos com a mesma vítima (excluída a violação sexual do art. 164.º), ocorridos no mesmo contexto situacional, máxime, espácio-temporal, não deve ser punido por *vários* crimes de coacção sexual (5); como se *J* decide fazer crer simuladamente, através de um telefonema, que é necessário auxílio para uma situação de necessidade (art. 306.º) e, isto feito, através de outro telefonema fruto de uma nova resolução, insiste na simulação para lhe dar maior crédito, não deve ser punido por concurso efectivo de crimes de simulação de sinal de perigo (art. 306.º).

§ 7 Relativamente a todos os tipos que protegem bens de carácter eminentemente pessoal, a **pluralidade de vítimas** — e, consequentemente, a **pluralidade de resultados típicos** — deve considerar-se sinal seguro da **pluralidade de sentidos do ilícito** e conduzir à existência de um concurso efectivo. Resta porém saber exactamente *que tipos são esses* que protegem bens eminentemente pessoais (tanto mais quanto o Anteprojecto

(5) Como melhor se compreenderá com o tratamento do concurso de crimes aparente (infra, § 19) e do crime continuado (infra, § 37). Tal não terá sido porventura suficientemente atendido por MONIZ, Helena Isabel, nota 3, p. 324 e ss.

de 2007, acrescentando um novo número ao art. 30.º, se propõe — embora em contexto diferente do presente: infra, nota 59 — atribuir dignidade legislativa àquele conceito). Como bens dessa natureza devem seguramente considerar-se aqueles que são **protegidos pelos tipos legais de crime contidos no Título I da PE do CP**: a vida, a vida intra-uterina, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual, a honra, a reserva da vida privada, o direito à palavra e à imagem. Restando porém saber se, *ao menos para os efeitos aqui em causa*, a doutrina referida não deverá ser alargada àqueles bens que são pessoais, embora talvez não "eminentemente", como será em particular o caso dos **bens de carácter patrimonial**; sobretudo tendo em conta, com Pedro Caeiro — como, cremos, se deve —, que aquilo que nos tipos legais de crime respectivos se protege não é só o "bem", mas a "*relação homem-bem*", o "*bem-para-a-pessoa*" (6). A ser assim, fica então próxima a ideia de se dar um passo mais e seguir a sugestão, contida nas considerações de A. M. Almeida Costa, de considerar como tais, para os efeitos aqui em vista, **todos aqueles bens que não sejam supra-individuais** (não vá, de outro modo, estabelecer-se a confusão, perversora do "sentido do ilícito", "entre bem jurídico e objecto de protecção") (7). Seja porém como for quanto a este ponto, seguro é, de todo o modo, que na categoria agora em referência devem reentrar aqueles ilícitos complexos — *v. g.*, o roubo (8) — em que um dos bens jurídicos tutelados assume natureza eminentemente pessoal.

§ 8 Esta ideia da pluralidade de eventos típicos ligados a uma pluralidade de vítimas, se é importante em caso de concurso de crimes dolosos, assume particular relevo no concurso de **crimes negligentes**, trate-se de negligência consciente ou inconsciente, trate-se de concurso homogéneo ou heterogéneo. Uma doutrina muito difundida sustenta que nos crimes negligentes deve concluir-se pela *unidade do facto*, ainda que este contenha uma pluralidade de resultados (e de vítimas), sempre que aquele seja consequência de uma única acção: ou porque o resultado, nos crimes negli-

(6) CAEIRO, Pedro, *Sobre a Natureza dos Crimes Falenciais*, 1996, p. 46.

(7) COSTA, Almeida, A propósito do novo Código do Trabalho: bem jurídico e pluralidade de infracções no âmbito das contra-ordenações relativas ao "trabalho suplementar". Subsídio para uma dogmática do direito-de-mera-ordenação-laboral, *Liber Discipulorum Figueiredo* Dias, pp. 1051 e ss. e 1062 e ss.

(8) No sentido da solução aqui preconizada, MONTEIRO, Cristina Líbano, Roubo e sequestro em concurso efectivo?, *RPCC 15*, 2005, p. 493.

gentes, não constituiria senão uma condição objectiva de punibilidade; ou porque, na impossibilidade de se recorrer aqui à unidade ou pluralidade do processo resolutivo (processo que, nos crimes negligentes, a ter existido, não pode relacionar-se tipicamente com o resultado), o agente seria, nestes casos, passível de um único juízo de culpa ([9]); ou — e essencialmente — porque à unidade de acção corresponderia a *unidade da violação do dever objectivo de cuidado* ([10]). Quanto a estes argumentos, já o nosso tratamento da negligência revela as razões de discordância. Nomeadamente, quanto ao último, parece esquecer que o dever objectivo de cuidado de que na negligência se trata não é um dever geral, mas o dever tipicamente referido a um certo evento (também já supra, 35.º Cap., § 4 e ss.). Esta circunstância deve conduzir à conclusão de que também em casos como os de que agora curamos são individualizáveis tantos sentidos de ilícito quantas as vítimas da lesão do dever objectivo de cuidado tipicamente corporizado em cada um dos resultados ou eventos típicos, verificando-se por consequência, em princípio, um concurso efectivo ([11]).

§ 9 Pensamos que argumentação substancialmente análoga se deve usar para os crimes de **omissão**, nomeadamente, para os crimes de omissão **impura**. A jurisprudência e a doutrina alemãs — no esforço de manter a distinção entre concurso real e concurso ideal — transformam a questão na de saber se diversos deveres de evitar o resultado só podem ser preenchidos através de uma acção (caso de *unidade de acção*) ou através de várias acções (caso de *pluralidade de acção*) ([12]). Que uma distinção da unidade ou pluralidade de crimes de omissão não deverá levar-se a cabo na base da unidade ou pluralidade de *acção*, deveria parecer uma conclusão segura, logo pela simples razão de que na omissão não existe nenhuma acção jurídico-penalmente relevante. Por isso não cremos que esta constitua a via correcta para decidir da questão jurídico-penalmente relevante. Ainda aqui, se estiverem em causa bens eminentemente pessoais, a pluralidade de

---

([9]) Criticamente sobre estes dois argumentos, com razão, CAEIRO, Pedro / SANTOS, Cláudia, Negligência inconsciente e pluralidade de evento: Tipo-de-ilícito negligente — Unidade criminosa e concurso de crimes — Princípio da culpa, *RPCC 6*, 1996, p. 133 e ss., contra o decidido pelo Ac. da RC de 6-4-95, *ibidem*, p. 127. E já, também criticamente, no que toca ao segundo argumento, CORREIA, Eduardo, nota 11, p. 139 e ss.

([10]) Assim, por último, ROXIN II, § 33, n.º 67 e ss.

([11]) Assim concluem CAEIRO, Pedro / SANTOS, Cláudia, nota 9.

([12]) Assim, por último, ROXIN II, § 33, n.º 61 e ss., com indicações jurisprudenciais e doutrinais concordantes

eventos típicos, mesmo que se trate de casos de concurso homogéneo, indiciam a pluralidade de sentidos do ilícito global e, por conseguinte, a existência de um concurso efectivo.

§ 10 Assim, p. ex., se o segurança de uma discoteca deixa fechada, por dolo ou negligência, a porta de emergência que devia ter aberto e em consequência, por se ter declarado um incêndio, morrem dez pessoas (ou morrem cinco e outras tantas ficam gravemente feridas), haveria, na orientação que criticámos, unidade de acção — de homicídio ou também de ofensa à integridade física? — sob a forma de omissão. Se o pai de dois bebés gémeos não impede a morte deles (ou a morte de um e ferimentos graves no outro), por dolo ou negligência, quando as cadeiras em que se sentam escorregam para um rio, a lógica desta orientação deveria conduzir ao resultado insuportável de se admitir unidade de acção através de omissão — de homicídio ou também de ofensa à integridade física? — se as duas cadeiras se encontram no mesmo carrinho, pluralidade de acção através de omissão se cada uma das cadeiras se situar num carrinho individual! A nossa ideia é pois a de que, em qualquer destes casos, haverá, em princípio, concurso efectivo.

II. O concurso de crimes aparente, impuro ou impróprio

1. Consideração básica

§ 11 A pluralidade de normas típicas concretamente aplicáveis ao comportamento global constitui sintoma legítimo ou presunção *prima facie* de uma pluralidade de sentidos de ilícito autónomos daquele comportamento global e, por conseguinte, de um concurso de crimes efectivo, puro ou próprio. Casos existem, no entanto, em que uma tal presunção pode ser elidida porque os sentidos singulares de ilicitude típica presentes no comportamento global se conexionam, se intercessionam ou parcialmente se cobrem de forma tal que, em definitivo, se deve concluir que aquele comportamento é **dominado** por um único sentido de desvalor jurídico-social; por um sentido de tal modo **predominante**, quando lido à luz dos significados socialmente relevantes — dos que valem no mundo da vida e não apenas no mundo das normas ([13]) —, que seria inadequado e injusto incluir tais casos na forma de punição prevista pelo legislador quando editou o art. 77.º Nomeadamente — repetimos ainda uma vez — porque um tal procedimento significaria na generalidade das hipóteses violação da proibição (jurídico-constitucional: *ne bis in idem*) de dupla valoração — de uma parte — da matéria proibida e do conteúdo do ilícito respectivo. Podendo

([13]) Como muito exactamente se exprime MONTEIRO, Cristina Líbano, nota 8, p. 494.

então dizer-se, num esforço continuado de compatibilização da doutrina que defendemos com o texto do art. 30.º-1, que nestes casos se verifica uma pluralidade de normas típicas **concretamente** aplicáveis, mas não uma pluralidade de crimes "**efectivamente** cometidos".

§ 12 Alguns exemplos servirão para ilustrar o argumento expendido. Devem ser igualmente tratados — em termos de forma de *punição*, é claro — *A*, que em múltiplos dias, pela noite, mata, fere gravemente ou viola sexualmente diversas vítimas; e *B*, que falsifica um documento com a intenção de burlar (como vem de facto a suceder) exclusivamente uma determinada pessoa? Devem ser igualmente tratados *C*, que, face a uma relação conflituosa com a mulher, lhe rasga numa certa altura o seu valioso vestido e noutra altura a mata; e *D* que, face a uma relação do mesmo tipo, mata a mulher com um tiro que simultaneamente lhe danifica o valioso vestido que envergava? Não será aventuroso avançar que a avaliação teleológico-normativa dos casos em termos de unidade ou pluralidade do facto global é diferente, pese embora a circunstância, que deve reconhecer-se, de em qualquer deles se verificar uma pluralidade de violações de tipos legais de crime concretamente aplicáveis. E é diferente, insistamos, porque os **sentidos de ilicitude** revelados pela conduta global de *A* e de *C* são em definitivo **plúrimos** (concurso efectivo), enquanto relativamente a *B* e a *D* há no comportamento global um sentido de ilicitude absolutamente **dominante** ou mesmo **único** que permite a sua recondução jurídico-penal à *unidade do facto* (concurso aparente).

2. Explanação doutrinal

2.1. Antecedentes

§ 13 A raiz mais longínqua desta concepção reside — não há que escondê-lo, sendo agora porventura já óbvio — na velha categoria da **consumpção**, sobretudo quando ela se toma (seguindo a opinião de Eduardo Correia) em um sentido amplo e material, como englobando "as relações de mais e menos que se estabelecem entre os valores jurídico-criminalmente protegidos" ([14]). O que há de diferente — diríamos, de *radicalmente* diferente — é que a categoria é agora repensada não sob o prisma das relações entre normas, mas de relações entre sentidos dos ilícitos singulares no contexto da realidade da vida constituída pelo comportamento global ([15]).

([14]) CORREIA, Eduardo, nota 2, p. 71.

([15]) Como de resto sempre o reconheceu CORREIA, nota 2, p. 168 e ss.

§ 14 Na dogmática recente, é na lição de Ingeborg Puppe sobre o tema do concurso de crimes ([16]) que deparamos com sugestões e subsídios valiosos para escorar a distinção entre concurso efectivo e concurso aparente ([17]). Para Puppe, o que distingue verdadeiramente o concurso real do concurso ideal — isto é, no nosso entendimento, o concurso efectivo do aparente ([18]) — não é a unidade ou pluralidade de acções, mas a circunstância de que no concurso aparente se verifica um **parentesco ou afinidade do ilícito** (em alemão: *Unrechtsverwandtschaft*) dos tipos preenchidos pela conduta. Por isso, no exemplo referido supra, § 12, o uso por *B* de documento falsificado e a burla encontrar-se-iam numa relação de concurso aparente, porque aos tipos preenchidos seria comum o "engano" ou a "colocação em erro" da vítima. Afins seriam igualmente crimes como os de coacção, de roubo, de ofensa à integridade física, de homicídio, porque de todos estes tipos legais constitui elemento integrante decisivo a violência contra uma pessoa. Como ainda os crimes de ofensa à integridade física grave e de sequestro, porque aquele se apresenta como uma forma agravada deste último ([19]). Inversamente, já seria de aceitar a existência de concurso efectivo (apesar de eventual unidade de acção) em casos como os de *D* que (dolosamente) com o tiro mata a mulher e lhe danifica o vestido ([20]), ou como o daquele que (dolosamente) com um tiro quebra uma vitrina e mata a empregada que nela trabalhava: porque nestes casos os tipos legais aplicáveis em concreto — homicídio e dano — não revelam elementos comuns.

§ 15 A concepção de Puppe não tem merecido aceitação, até agora, na doutrina germânica ([21]). É para nós desinteressante porém, como se compreenderá, a alegação

---

([16]) Pese embora as substanciais diferenças, no essencial já apontadas (supra, 41.º Cap., §§ 9 e 11), entre a regulamentação *legal* da matéria no direito penal português e no alemão.

([17]) PUPPE, *Idealkonkurrenz und Einzelverbrechen. Logische Studien zur Verhältniss von Tatbestand und Handlung*, 1979, p. 125 e ss., Funktion und Konstitution der ungleichartige Idealkonkurrenz, *GA*, 1982, p. 143, e *NK*, § 52, n.º 45 e ss.

([18]) Por isso, na exposição posterior falaremos só — uma vez mais, por concisão expositiva — de concurso efectivo e aparente, quando Puppe fala, na verdade, de concurso real e ideal. E como Puppe, também, entre nós, ALMEIDA, Duarte d', *O "Concurso de Normas" em Direito Penal*, 2004, pp. 95 e ss. e 106 e ss.

([19]) PUPPE, nota 17, 1982, p. 154 e s. Anote-se que CORREIA, Eduardo, nota 2, p. 168 e ss., antecipou substancialmente a posição de Puppe ao referir "uma *relação de parentesco entre bens jurídicos de diversos tipos*" como a ideia reitora da categoria da consumpção.

([20]) PUPPE, nota 17, 1982, p. 159.

([21]) Cf. ROXIN II, § 33, n.º 75, que enumera os AA. discordantes. Largamente favorável à tese de Puppe, no entanto, GÖSSEL (recensão à obra de PUPPE citada na nota 17, 1979), *GA*,

de que aquela concepção não se deixa compatibilizar com os §§ 52-54 do CP alemão, como tão-pouco com a evolução da história dogmática que está por detrás daqueles preceitos. Mais importante é o argumento de que o critério do "parentesco" do ilícito daria lugar a uma insuportável **indefinição** e a **dificuldades de aplicação**. De pouco valendo neste contexto — acrescenta-se por vezes — o "**critério sucedâneo simplificado da unidade do ilícito**", avançado por Puppe, da "**contemporaneidade das realizações típicas**" (22). Certo que, também aqui, não se depara com conceitos fixos e aptos à subsunção; mas decerto também que, deste ponto de vista, eles não estão pior colocados que o critério distintivo da unidade ou pluralidade da acção em qualquer das suas formulações.

§ 16 A crítica que, do nosso ponto de vista, deve ser dirigida à concepção em análise é, na verdade, a seguinte: a de que ela não pensa ainda com suficiente decisão o critério distintivo para que aponta — o da **conexão de sentido dos ilícitos** compreendidos pelos tipos legais preenchidos pelo comportamento total — e a de que, na análise dos casos, não se lhe mantém fiel. Antes passa de novo, as mais das vezes, do *sentido de ilícito* que vive no comportamento total para o relacionamento (ainda que agora não lógico, mas teleológico) dos *tipos legais de crime* preenchidos por aquele comportamento. A levar-se este ponto de vista até ao fim, as conclusões a retirar seriam dificilmente sustentáveis. Desde logo, p. ex., se *A* mata os seus inimigos *B*, *C* e *D*, seja em dias diferentes, seja na mesma altura ou até através de uma acção única (explosão de uma bomba, por exemplo), o ilícito compreendido no tipo aplicável é, mais que aparentado ou afim, **o mesmo** (23); e todavia trata-se aqui de uma hipótese em que o *comportamento* total revela uma **pluralidade segura de sentidos de ilicitude jurídico-socialmente relevantes** e deve por isso conformar um concurso homogéneo efectivo. Por outro lado, a afinidade do ilícito compreendido nos tipos não desaparece pela circunstância de a prática destes não ser contemporânea ou estar mesmo afastada por largos lapsos de tempo. Por fim, revertendo ao relacionamento dos tipos legais de crime aplicáveis, importa então perguntar se a afinidade entre estes não deveria, antes de tudo, afirmar-se ou negar-se em função do mais decisivo dos ele-

---

1982, p. 134, e, no essencial, também, ABELS, *Die "Klarstellungsfunktion" der Idealkonkurrenz*, 1991, p. 17 e ss.; em Espanha, CUERDA RIEZU, El concurso de delitos en el borrador de Anteproyecto de código penal de 1990, *ADPCP*, 1991, p. 849; em Itália, PRODOSCIMI, *Contributo alla teoria del concorso formale di reati*, 1984, p. 94 e s.; e, em Portugal, ALMEIDA, Duarte d', locs. cits. na nota 18.

(22) PUPPE, *NK*, § 52, n.º 52.

(23) Assim, também, ROXIN II, § 33, n.º 75.

mentos típicos, o *bem jurídico*; em função, por conseguinte, da afinidade, total ou parcial, mais ou menos extensa, dos bens jurídicos lesados pelo comportamento global. Só que, respondendo afirmativamente a esta questão, estaremos próximos da — se não coincidentes com a — ideia de Eduardo Correia e da nossa jurisprudência largamente dominante (supra, 41.º Cap., § 21) de ver na unidade ou pluralidade de **bens jurídicos** violados o critério decisivo da unidade ou pluralidade de crimes; e a concepção de uma categoria de concurso aparente teria perdido, ao menos em larga medida, o seu fundamento, o seu interesse e o seu campo de aplicação.

2.2. Critérios de determinação

§ 17 A ideia central que preside à categoria do concurso aparente deve pois ser, repete-se, a de que situações da vida existem em que, preenchendo o comportamento global mais que um tipo legal concretamente aplicável, se verifica entre os sentidos de ilícito coexistentes uma *conexão objectiva e/ou subjectiva* ([24]) tal que deixa aparecer um daqueles sentidos de ilícito como **absolutamente dominante**, **preponderante**, ou **principal**, e *hoc sensu* **autónomo,** enquanto o restante ou os restantes surgem, também a uma consideração jurídico-social segundo o sentido, como dominados, subsidiários ou dependentes; a um ponto tal que a submissão do caso à incidência das regras de punição do concurso de crimes constantes do art. 77.º seria desproporcionada, político-criminalmente desajustada e, ao menos em grande parte das hipóteses, inconstitucional. A referida dominância de um dos sentidos dos ilícitos singulares pode ocorrer em função de diversos pontos de vista: seja, em primeiro lugar e decisivamente, em função da unidade de sentido social do acontecimento ilícito global; seja em função da unidade de desígnio criminoso; seja em função da estreita conexão situacional, nomeadamente, espácio-temporal, intercedente entre diversas realizações típicas singulares homogéneas; seja porque certos ilícitos singulares se apresentam como meros estádios de evolução ou de intensidade da realização típica global. Não se trata aqui de critérios que permitam uma compartimentação estanque e rigorosa das hipóteses — dos

([24]) No essencial assim, a propósito do que continuam a chamar "concurso ideal", também, ALMEIDA, Duarte d', nota 18, p. 80 e ss., e MOUTINHO, Lobo, *Da Unidade à Pluralidade de Crimes no Direito Penal Português*, 2005, p. 1149 e ss.

casos da vida — que dão conteúdo e justificação à inteira categoria do concurso aparente; sobretudo porque eles já por si mesmos se interpenetram ou parcialmente coincidem, enquanto, por outro lado, no mesmo caso podem *convergir* mais que um dos critérios sugeridos ou, pelo contrário, podem eles dever ser *complementados* ou, inversamente, *limitados* por outros pontos de vista relevantes para a caracterização do sentido social do ilícito global. Mas cremos que se trata, em todo o caso, de critérios fundamentais que a análise de cada caso imporá que não sejam desconsiderados.

2.2.1. O critério da unidade de sentido do acontecimento ilícito global-final

§ 18 Critério de primacial relevo para a conclusão pela tendencial unidade substancial do facto — apesar da pluralidade de tipos legais violados pelo comportamento global — é o da **unidade**, segundo o sentido social assumido por aquele comportamento, **do sucesso ou acontecimento** (*hoc sensu*, do "evento" ou "resultado") **ilícito global-final**. Este critério assumirá assim relevo, em princípio exclusivo, relativamente a factos *dolosos*. O que se passa é que, nestes casos, **o agente se propôs uma realização típica de certa espécie** — *v. g.*, vingar-se de certa pessoa matando-a, castigá-la ferindo-a, satisfazer o desejo sexual por ela violando-a, alcançar a posse de certa coisa furtando-a, adquirir uma vantagem patrimonial burlando-a... — e, para lograr (e consolidar) o desiderato, se serviu, com dolo necessário ou eventual, de **métodos, de processos ou de meios já em si mesmos também puníveis** ([25]). Nestes comportamentos globais se lobriga, cremos que com suficiente clareza, a existência de **um** sentido de ilícito absolutamente dominante e "autónomo", a par de outro ou outros sentidos dominados e "dependentes". É o que sucederá frequentemente com os grupos dos **factos tipicamente acompanhantes**" e, sobretudo, dos **factos posteriores co-punidos** ([26]) (supra, 42.º Cap., § 16 e s.). E com indi-

([25]) Assim, no essencial, já HONIG, *Straflose Vor- und Nachtat*, 1927, p. 65 e ss. Fundamentalmente na mesma direcção também, CORREIA, Eduardo, nota 2, p. 179 e ss. e, por último, PUPPE, *NK*, antes do § 52, n.º 37 e ss. De uma "valoração objectiva de um fim ou de uma intenção do agente" fala precisamente — em todo o caso ainda ao nível da análise das *normas* convocadas — CORREIA, Eduardo, loc. cit., p. 184, citando já neste sentido SANTOS, Beleza dos, Crimes de moeda falsa, *RLJ* 66, 1933-4, pp. 225 e ss. e 240 e ss.

([26]) De factos posteriores "co-punidos" e não — como tradicionalmente — "não punidos" se fala agora porque, como se dirá infra, § 56, estes factos devem relevar, em princípio, para efeito de determinação da medida concreta da pena.

ferença de princípio, *no plano subjectivo*, sobre se o facto posterior resultou de uma **resolução** tomada pelo agente já antes da realização principal ou só depois e, portanto, como fruto de uma "nova" resolução (27), como, igualmente, com indiferença por uma qualquer *conexão objectiva* entre os tipos legais violados, nomeadamente, através de um certa proximidade, parentesco ou afinidade entre os (diferentes) **bens jurídicos** lesados.

§ 19 Concurso aparente existirá pois se alguém furta coisa móvel alheia colocada em lugar destinado ao depósito de objectos (art. 204.º-1/*b*)) ou por escalamento (art. 204.º-2/*e*)), cometendo eventuais **danos** ao proprietário (art. 212.º) ou **violando o seu domicílio** (art. 190.º). O mesmo devendo afirmar-se daquele que se apropriou indevidamente de uma coisa móvel alheia e em seguida **engana** o proprietário desapossado quanto ao destino daquela com fins de encobrimento e/ou de asseguramento; ou daquele outro que, com idênticos fins, destrói a coisa furtada ou por outra forma apropriada (28). Só assim não sendo se com aquele facto o agente tiver ocasionado um **novo dano** ou a **vítima for pessoa diferente** (29); porque em tais casos já não poderá legitimamente falar-se nem de unidade do acontecimento ilícito nem, consequentemente, de unidade de sentido desvalioso do ilícito típico total: estes casos serão então de concurso efectivo.

§ 20 O pensamento exposto, se encontra o seu campo de eleição nos delitos de apropriação e nos correspectivos crimes de encobrimento ou de asseguramento, continua no entanto válido relativamente a crimes de índole completamente diferente. Circunstâncias como, p. ex., a de se utilizar **arma proibida** (art. 275.º) (30) ou a de, para encobrir o facto principal, esconder o **cadáver**, de o jogar num poço ou num rio, ou mesmo de o desmembrar ou desfigurar (art. 254.º-1) constituem condutas que concorrem com a de homicídio, em princípio, sob a forma do concurso aparente. É também neste contexto — porventura de uma forma ainda mais clara — que deve decidir-se a questão do **dano** provocado na roupa da vítima de um crime de homicídio a tiro ou à facada. Não importa aqui, em si mesmo, o maior ou menor valor económico do dano (31): importa, sim, que a conduta danificadora faz parte em regra, segundo o

---

(27) Cf., no entanto, em sentido ao menos parcialmente diverso, ALMEIDA, Duarte d', nota 18, p. 83.

(28) Substancialmente nestes termos, com razão, FERREIRA, Cavaleiro de, 1992, p. 669, e COSTA, Faria, Formas do crime, *JDC 1983*, p. 179.

(29) Cf., já, CORREIA, Eduardo, nota 2, p. 188 e s. e, na esteira da jurisprudência do RG, entre outros, ROXIN II, § 33, n.º 220, e, em termos substancialmente idênticos, STRATENWERTH / KUHLEN, § 18, n.º 19.

(30) A favor do concurso puro, FARIA, Paula Ribeiro de, *Comentário Conimbricense*, II, art. 275.º, § 35.

(31) Sendo por isso improcedente o argumento de ALMEIDA, Duarte d', nota 18, p. 113[126], de que a não consideração do dano derivaria do seu carácter "bagatelar" segundo "o geral princípio de insignificância". Correctamente, em perspectiva substancial, ANDRADE, Costa, *Comentário Conimbricense*, II, art. 212.º, § 76.

seu sentido, como facto prévio co-punido, do sentido absolutamente preponderante de ilícito da conduta principal e deve por isso conduzir a um concurso aparente. Só assim não sendo, uma vez mais, se o dano ultrapassar a esfera jurídica da vítima, *v. g.*, se se trata de uma manequim que enverga um vestido de notável valor numa passagem de modelos, ou da destruição à bomba de um automóvel ou de uma avioneta ocupados apenas pela vítima, ainda que esta seja o proprietário: circunstâncias como estas, não deixando de participar do acontecimento ilícito global-final, produzem efeitos em outras esferas jurídicas, de terceiros ou da comunidade, devendo conduzir à afirmação de um concurso efectivo.

2.2.2. O critério do crime instrumental ou crime-meio

§ 21 O critério acabado de apresentar parece possuir virtualidades bastantes para abranger todos aqueles casos de relacionamento entre um ilícito puramente instrumental (crime-meio) e o crime-fim correspondente. Por outras palavras, aqueles casos em que **um ilícito singular surge, perante o ilícito principal, unicamente como meio de o realizar e nesta realização esgota o seu sentido e os seus efeitos** ([32]). Parece aqui particularmente claro — a ponto de já esta circunstância justificar porventura uma autonomização (relativa) do critério face ao anterior — que uma valoração autónoma e integral do crime-meio representaria uma violação da proibição jurídico-constitucional da dupla valoração; enquanto, do outro lado, a sua consideração como conformadora de um concurso impuro não viola o mandamento (também ele jurídico-constitucional) de esgotante apreciação porquanto ele deverá influenciar a medida da pena do concurso (infra, § 56). Impõe-se, por isso, a conclusão de princípio favorável a um concurso aparente. Sem que importe, uma vez mais, a existência ou não de uma conexão objectiva (parentesco dos bens jurídicos violados) ou subjectiva (unidade ou pluralidade de resoluções) entre os tipos legais violados pelo comportamento global.

§ 22 A questão mais vivamente discutida neste enquadramento tem sido a da **relação entre uma falsificação de escrito utilizada unicamente como meio de burlar alguém**; questão que, desde há muito, divide irremediavelmente a doutrina e a jurisprudência portuguesas. Não temos qualquer dúvida em convir, por via de princípio e

([32]) Não faz por isso sentido apresentar este critério (para em seguida mais facilmente o criticar) como se ele devesse conduzir *sempre* a uma consumpção do crime-meio pelo crime-fim, *v. g.*, quando alguém mata outrem para depois lhe subtrair a carteira (v. todavia o art. 210.º-3 e, sobre ele, CUNHA, Conceição Ferreira da, *Comentário Conimbricense*, II, art. 210.º, § 99 e ss.). Assim, no entanto, ALMEIDA, Duarte d', nota 18, p. 81.

só por ela — tudo dependendo, em última análise, da configuração no caso concreto dos ilícitos singulares concorrentes face ao sentido social do ilícito global —, na solução do *concurso aparente*. Nesse sentido falam duas considerações fundamentais: a de o acto de falsificação ser levado a cabo unicamente no contexto situacional da realização do crime-fim e de nele esgotar a sua danosidade social; e a de a falsificação constituir já uma parte do ilícito da burla, pelo que a autonomização do conteúdo de ilícito daquele significaria uma dupla valoração do mesmo substrato de facto (33). Problema discutível pode ser o de saber se isto é assim suposta a **unidade de resolução**, ou se ainda poderá abranger hipóteses de **dupla resolução**, eventualmente espaçadas no tempo (34). Cremos exacta, para certas constelações, esta segunda alternativa: se alguém toma a decisão de fabricar documento falso para se, proporcionando-se a situação, burlar com ele alguém; e se esta eventualidade se verifica mais tarde relativamente a uma certa vítima, implicando assim uma segunda resolução ou uma renovação da resolução anterior, ainda aí parece deverem ser os princípios do concurso impuro que devem reger a situação. Ponto é sempre, naturalmente, que se não verifique um alargamento da actividade criminosa ou não venha a verificar-se uma multiplicação das vítimas.

§ 23 Recondutíveis ao mesmo núcleo de pensamento são situações muito diferentes e que podem implicar a lesão de bens jurídicos pessoais ou de bens jurídicos pessoais e patrimoniais. A nossa jurisprudência ocupou-se já do caso do crime de **aborto** causado através de pancadas dadas pelo agente, com essa exclusiva intenção, no ventre da vítima, punindo o agente por concurso efectivo de aborto e de ofensas corporais simples (35). Sem razão bastante, em nosso entendimento: também este constitui um caso de concurso aparente. Já seria diferente a solução tratando-se de ofensas corporais graves, não implicadas pelo propósito de fazer a mulher abortar, ou se às ofensas, ainda que simples, presidisse o propósito adicional de "castigar" a vítima. E a solução deverá ser ainda a do concurso aparente em caso de sequestro ou outro crime contra a liberdade com o propósito e na medida implicados pela realização de um **roubo** (36), como, ainda mais claramente, na "privação da liberdade" (imobilização) que frequentemente implicará uma **ofensa à integridade física**.

---

(33) Substancialmente neste sentido também, MONIZ, Helena Isabel, *Comentário Conimbricense*, II, art. 256.º, § 57 e ss. Contra — no sentido do concurso efectivo, dada a dissimilitude dos bens jurídicos em causa — se invoca a "jurisprudência fixada" pelos Acs. do Plenário do STJ de 19-2-92, *DR*, I-A, de 9-4-92, e de 4-5-2000, nos quais se encontra recenseada a jurisprudência e a doutrina portuguesas a propósito. Numa conclusão que se encontra, se bem julgamos, materialmente próxima da do texto — posta entre parênteses a solução, que propugna, de uma "extensão teleológica" do art. 262.º —, COSTA, A. M. Almeida, *Comentário Conimbricense*, II, art. 262.º, § 5 e ss.

(34) No sentido da primeira alternativa, MONIZ, Helena Isabel, *Comentário Conimbricense*, II, art. 256.º, § 57, e ALMEIDA, Duarte d', nota 18, p. 83.

(35) Cf. Ac. da RL de 16-2-2005.

(36) Assim, MONTEIRO, Cristina Líbano, nota 8, em crítica ao Ac. do STJ de 2-10-2003, ambos na *RPCC 15*, 2005, pp. 477 e 492.

2.2.3 A unidade de desígnio criminoso

§ 24 Da exposição anterior não se torna lícito concluir por um menosprezo injustificável da **conexão subjectiva** (unidade / pluralidade de resoluções) como elemento relevante, e porventura em certos casos decisivo, para a conclusão por um concurso aparente. Se acima (supra, §§ 18, 21 e s.) identificámos hipóteses em que a pluralidade de resoluções não determina por si mesma um concurso efectivo ([37]), tal não significa esquecer que, em diversos contextos situacionais, **a unidade de desígnio criminoso** ([38]) **pode conferir a uma pluralidade de realizações típicas um sentido fundamentalmente unitário do ilícito**; e isto quer se trate de concurso *homogéneo*, quer *heterogéneo* e quer se verifique ou não *contemporaneidade* das realizações típicas. Alguns dos exemplos já apontados nos parágrafos anteriores em matéria tanto de facto posterior co-punido, como de relacionamento entre o crime instrumental e o crime final ilustram o relevo, por vezes fundamental, do recurso ao **plano do agente** e ao seu **desígnio criminoso** para conferir ao ilícito total o seu sentido de desvalor dominante.

2.2.4. A conexão espácio-temporal das realizações típicas

§ 25 Critério **adicional** atendível na determinação de um concurso aparente é o da conexão espácio-temporal das realizações típicas. Até ao ponto de, como dissemos (supra, § 15), Ingeborg Puppe ter avançado com a *contemporaneidade* daquelas realizações como "critério sucedâneo da unidade do ilícito". E naturalmente: uma certa unidade ou proximidade de espaço e/ou de tempo das realizações típicas pode constituir forte estímulo para concluir pela intersecção dos sentidos dos ilícitos singulares e, por essa via, por uma leitura unitária do sentido de ilícito do comportamento total, consequentemente, por um concurso aparente. Enquanto, inversamente, um "claro desfasamento contextual" ([39]) indiciará uma pluralidade autónoma de sentidos do ilícito total e, por aí, um concurso efectivo. Em todo o caso,

---

([37]) Em oposição à doutrina largamente dominante entre nós, após a lição de Eduardo Correia referida supra, 41.º Cap., § 23. Já antes deste A., de resto, a doutrina portuguesa emprestava particular ênfase a esta conexão subjectiva, citando ALMEIDA, Duarte d', nota 18, p. 81 e s., a propósito, as lições de Caeiro da Matta e de Navarro de Paiva.

([38]) ALMEIDA, Duarte d', nota 18, p. 82, fala — num sentido que julgamos essencialmente coincidente com o do texto — de unidade de "opção criminosa".

([39]) Fomos buscar a expressão, que nos pareceu particularmente sugestiva e exacta, a MONTEIRO, Cristina Líbano, nota 8, p. 493.

o desfasamento ou a proximidade contextuais das realizações típicas só podem constituir indícios — fortes por vezes, é certo, mas não decisivos — da unidade ou pluralidade de sentidos do ilícito global.

§ 26 Um exemplo que julgamos claro será o dos **actos sexuais de relevo** (ou mesmo de cópula ou coito anal ou oral) praticados sobre a mesma vítima (art. 163.º e ss.): a unidade de contexto espácio-temporal sugere vivamente ou, na maioria dos casos, mesmo impõe a unidade de sentido do ilícito global, ainda mesmo porventura no caso de renovação da resolução criminosa. A "fraude sexual" do art. 167.º constituirá porventura um caso particularmente impressivo do que afirmamos. Diferentemente, a circunstância de um assaltante que está a ser perseguido pela polícia e imobiliza alguém enquanto dispara contra o perseguidor não pode impedir que o agente deva ser punido por **sequestro** e por (tentativa de) **homicídio** em concurso efectivo (40).

2.2.5. Os diferentes estádios de evolução ou de intensidade da realização global

§ 27 Já (supra, 42.º Cap., § 15 e ss.) mostrámos como diversas hipóteses de concorrência de normas relativas a diferentes estádios de evolução ou de intensidade da realização típica global encontram solução logo na afirmação da **unidade da norma** concretamente aplicável, nomeadamente, por força de uma relação de **subsidiariedade implícita**. Se, porém, em casos deste teor a relação de subsidiariedade — ou eventualmente a de especialidade — dever ser negada e afirmada, pelo contrário, a pluralidade de normas concretamente aplicáveis, isso é sinal de que o problema já não é o do relacionamento de normas, mas o da concorrência de sentidos dos ilícitos realizados e da **determinação do sentido de ilícito absolutamente dominante**, nos termos preditos. É, numa palavra, o problema do concurso aparente.

§ 28 A questão coloca-se, desde logo, quando a **tentativa de um crime qualificado** converge com a **realização consumada do crime fundamental**. Qualquer solução que negasse o concurso de crimes violaria seguramente o mandado de esgotante apreciação do ilícito, na medida em que, para além da tentativa, se verifica um resultado típico adicional doloso, mas não intencionado. Punir, por outro lado, por concurso efectivo implicaria violar a proibição de dupla valoração, porquanto, ao nível do ilícito

(40) Exemplo apontado por STRATENWERTH / KUHLEN, § 18, n.º 31.

global, se repetiria a tomada em consideração de circunstâncias relevantes para cada um dos tipos legais concorrentes. A solução correcta só pode pois residir na punição por concurso aparente.

§ 29 **Exemplos**: *A* penetra ilegitimamente em habitação com a intenção de roubar uma valiosa jóia que julga estar num certo quarto mas não a encontra (art. 203.º-1/*f*)), aproveitando todavia a oportunidade, ao sair, para furtar uma bicicleta estacionada à porta de casa (art. 203.º). *B*, actuando com especial perversidade (art. 146.º), tenta produzir uma ofensa grave à integridade física de *C*, tirando-lhe a capacidade de procriação (art. 144.º/*b*)), mas apenas lhe produz uma ofensa simples (art. 143.º) ([41]). *D* tenta violar sexualmente *E* (art. 164.º), mas não consegue, ficando-se pelos actos sexuais de relevo consumados no decurso da tentativa (art. 163.º). Extremamente instrutivo e difícil o caso decidido pelo Ac. do STJ de 2-6-2005: "tentou o arguido consumar a violação da ofendida, mas perante a resistência desta que impossibilitou a prática de cópula e coito anal decidiu prolongar a sua conduta, procurando que esta o masturbasse e face à sua recusa, masturbando-se enquanto a beijava na face e no pescoço até conseguir ejacular". Face a esta factualidade, o Tribunal condenou por concurso puro de tentativa de violação e coacção sexual posterior (masturbação), a opinião minoritária defendeu a unidade do sentido do ilícito (tentativa de violação) e Helena Moniz pronunciou-se pela punição "pelo crime de coacção sexual consumado" ([42]). Substancialmente, a opinião minoritária referida está de acordo com a nossa argumentação; a única alternativa possível seria a de concluir por um concurso aparente entre a tentativa de violação e o acto sexual de relevo imediatamente posterior (co-punido). Cf. no entanto infra, § 33 e ss.

§ 30 Outra questão que neste enquadramento se suscita é, como dissemos, a do relacionamento entre o **perigo abstracto**, o **perigo concreto** e o **dano** quando o perigo ultrapasse ou caia fora de uma relação de subsidiariedade (implícita), máxime, em virtude da pluralidade de bens jurídicos lesados ou ameaçados. Também nestas hipóteses, determinada a pluralidade de normas incriminadoras concretamente aplicáveis, o sentido dominante do ilícito deve ser conferido ao comportamento global, ao menos em regra, **pelo bem jurídico que sofre a forma mais intensiva de agressão**. A solução do concurso *aparente* parece impor-se por isso, ressalvadas em todo o caso (e pelo menos) as hipóteses — que serão porventura as mais frequentes — em que se verifique uma pluralidade de vítimas e em que, consequentemente, deva concluir-se pelo concurso efectivo.

([41]) Casos decididos pela jurisprudência alemã no sentido do concurso ideal e referidos concordantemente por ROXIN II, § 33, n.ºs 183-185.

([42]) Todos os elementos em: *RPCC 15*, 2005, pp. 299 e ss., 305 e ss., 327.

§ 31 Não será fácil excogitar, no nosso ordenamento jurídico-penal, hipóteses de ocorrência de situações como as que vêm de ser referidas. E isto porque, em grande parte daquelas que são consideradas neste contexto em jurisprudências e doutrinas estrangeiras (quando a conduta cria um perigo abstracto ou um perigo comum e, para além dele, vem a ter por consequência um resultado de dano), o legislador português decidiu fundir as situações através de crimes agravados pelo evento. É o que exemplarmente acontece, *v. g.*, com a **captura ou desvio de aeronave** (art. 287.º) ou com a **condução perigosa de veículo rodoviário** (art. 291.º), quando delas resulta, por negligência, a morte ou a ofensa à integridade física de outrem (arts. 294.º, 285.º e 18.º) (43). Parece que a doutrina exposta no parágrafo anterior já valerá todavia, p. ex., relativamente à morte ou à lesão da integridade física produzida por um certo agente no decurso de uma **rixa** e no seu contexto significante de perigo (art. 151.º) (44).

2.3. Distonia das molduras penais aplicáveis ao ilícito dominante e ao ilícito dominado

§ 32 Sucede por vezes que, nos grupos de hipóteses de concurso aparente acabados de referir, se depara com situações em que o ilícito que, *segundo os critérios até agora apontados*, deveria reputar-se "**dominado**", é ameaçado pela lei com uma **moldura penal mais grave** do que a cabida ao ilícito "dominante". Descontada a muito maior amplitude com que, na nossa construção, se apresenta o que chamamos concurso aparente face ao entendimento tradicional e ainda hoje comum da categoria da "consumpção" (supra, 42.º Cap., § 18 e ss.), a doutrina que desta categoria se ocupa conhece desde há muito estas situações sob o designativo de **consumpção impura** (45). O problema que então se suscita é o de saber, em geral, se — e com que fundamento e, consequentemente, em que exacta medida — em tais situações se deve conferir prevalência, ao menos à partida, à moldura correspondente ao ilícito dominante ou antes, dada a sua maior gravidade, à moldura penal correspondente ao ilícito dominado.

---

(43) Cf. FARIA, Paula Ribeiro de, *Comentário Conimbricense*, II, art. 287.º, § 22, e art. 291.º, § 25.

(44) Cf., com maiores precisões, CARVALHO, Taipa de, *Comentário Conimbricense*, art. 151.º, § 42 e ss., falando — num sentido que nos pareceu muito próximo daquele em que utilizamos a expressão — de "concurso aparente". Um estudo aprofundado da questão (com cuidada indicação e valoração da jurisprudência portuguesa) encontra-se em PINTO, Costa, Ilícito e punibilidade no crime de participação em rixa, *Liber Discipulorum Figueiredo Dias*, 2003, p. 891 e ss. Este A., para a hipótese — suposta na afirmação do texto — de o homicídio ou as ofensas graves materializarem um factor individual de perigo contido no modelo de perigo da rixa, conclui pela pluralidade de normas concretamente aplicáveis e, por aí, pelo concurso efectivo. Estamos de acordo com a existência de concurso, mas sob a forma do concurso aparente.

(45) Minuciosamente sobre ela, segundo os dados legais de então, CORREIA, Eduardo, nota 2, p. 203 e ss..

§ 33 A doutrina da consumpção impura tinha tendência para considerar estes casos de todo excepcionais e para imputar a generalidade deles a **lapsos legislativos** na harmonização de molduras penais previsivelmente concorrentes (46). Mas esta explicação, ainda que aqui e ali procedente, é de todo **insuficiente** face à compreensão e à extensão que, no entendimento por nós advogado, deve atribuir-se ao concurso aparente, impuro ou impróprio; mesmo quando a ele se aliem, perante o nosso CP vigente, exageros, verdadeira ou pretensamente censuráveis em perspectiva político-criminal, que o legislador teria cometido em matérias como a da punição da tentativa ou a dos termos da atenuação especial (47). São muitas, com efeito, e à partida imprevisíveis — dado que se trata de uma questão de *factos* e não de uma questão de *leis* —, as situações caracterizadas em geral no parágrafo anterior que não têm a ver com eventuais lapsos ou exageros do legislador, podendo elas verificar-se, com frequência, relativamente ao grupo dos factos **tipicamente acompanhantes** co-punidos; dos **factos instrumentais** co-punidos; e porventura sobretudo dos **factos posteriores** co-punidos, quando ao acto de asseguramento ou de encobrimento cabe uma moldura penal mais grave do que ao "facto principal". *V. g.*, quando alguém logrou uma vantagem patrimonial através de um furto ou de uma burla simples e depois, para assegurar a vantagem, pratica sobre a vítima um crime de *extorsão* (art. 223.º), o resultado de apropriação ou de prejuízo patrimonial é menos gravemente punível do que o resultado de asseguramento. Também no caso de falsificação de documento como puro meio de realização de uma burla, aquela será mais gravemente punível do que esta se a falsificação disser respeito a *documento autêntico* (art. 256.º-3) e a burla constituir uma burla simples (art. 217.º-1). Igualmente, na hipótese de *tentativa de violação* e de coacção sexual consumada ocorridos no mesmo contexto situacional, a moldura penal a esta cabida (art. 163.º-1) excede, nos seus limites máximo e mínimo, a que cabe àquela (art. 164.º-1 combinado com os arts. 32.º-1 e 73.º-1*a)* e *b)*).

§ 34 Uma primeira solução do problema residiria em manter *fidelidade integral* aos critérios apontados de determinação do ilícito dominante e do ilícito dominado e aplicá-los, consequentemente, também em matéria de eleição da pena aplicável: ao facto global seria por conseguinte **aplicável a moldura penal cabida ao ilícito que devesse reputar-se dominante ou principal** (ou pelo menos o seu **máximo** (48)). Mas esta solução — por preferível que pudesse antolhar-se à luz do princípio que lhe preside — não pode ser aceite. O argumento decisivo que a ela se opõe reside, como facil-

(46) Assim, de algum modo, CORREIA, Eduardo, nota 2, p. 205 e ss., CORREIA, Eduardo, nota 2, p. 203 e ss.; e muito claramente, agora, COSTA, A. M. Almeida, *Comentário Conimbricense*, II, art. 262.º, § 7.

(47) Sobre a primeira, cf. supra, 28.º Cap., § 44; e, sobre a segunda, DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 444 e ss.

(48) Já que, quanto ao seu limite mínimo, eventualmente mais baixo também, cf. infra, § 57, a propósito do chamado "efeito de bloqueio".

mente se compreenderá, em que o agente que tivesse praticado somente o ilícito dominado seria **mais severamente punível** do que aquele que, para além do ilícito dominado, realizou também o ilícito dominante; vindo a prática deste a constituir assim, no fim de contas, um motivo de **atenuação** da moldura penal aplicável ([49])!

§ 35 Uma outra solução excogitável — e que não deixa, se bem julgamos, de estar também presente, nos seu modo particular, em alguns AA. defensores da doutrina clássica da "consumpção impura" ([50]) — seria a de considerar que, nos casos em apreço, tudo terá de se passar como se se verificasse uma **"troca de posições" entre os sentidos dos ilícito singulares, passando o dominado a dominante e o dominante a dominado**. A favor desta solução poderia argumentar-se com ideias provenientes de diferentes quadrantes metódicos. Por um lado, decerto, com a de que através dela se alcançam soluções completamente correctas e adequadas em termos de consequência jurídica, encontrando-se ela coberta por um pensamento "a partir do resultado" levado ao seu extremo. Por outro lado, porém, com a ideia de que **a severidade das molduras penais cominadas pelo legislador visa traduzir** precisamente (bem ou mal, melhor ou pior) **o quantum de sentido de desvalor jurídico-social que a comunidade atribui aos comportamentos que ameaça**; sem que, nesta matéria, se deva

([49]) No sentido desta crítica — comum, de resto, à generalidade da doutrina da consumpção impura — cf. por último, entre nós, com indicações bibliográficas e jurisprudenciais concordantes, ALMEIDA, Duarte d', nota 18, p. 74 e ss. Nesta medida não temos dúvida em reconhecer que não devíamos ter escrito — se por lapso ou não, não importa —, como no nosso *Direito Penal, Sumários*, 1976, p. 107, que "nestas hipóteses (...) deverá então aplicar-se só a norma mais leve". Mas talvez se devesse ter atentado em duas coisas: a primeira é a de que nos referíamos aos casos de consumpção na acepção tradicional de concurso de normas ou de leis; a segunda é a de que tínhamos em vista a norma mais leve em termos de norma de comportamento, não de norma de sanção. Como deveria tornar-se claro para todos atentando ao que escrevemos quatro páginas após, ao tratarmos das "consequências jurídicas" do concurso: "O que acaba de afirmar-se — dissemos ali — não exclui no entanto, porventura, que excepcionalmente, e para efeitos estritos de *medida da pena*, não possa atender-se à punição cominada pela disposição legal secundária ou excluída, ou aos efeitos que assinala, para deste modo evitar casuais e injustificáveis favorecimentos ou desfavorecimentos do tratamento do agente".

([50]) Em nosso modo de ver foi sempre este o entendimento de CORREIA, Eduardo, nota 2: "só se deve aplicar aquele tipo legal de crime que garante, do ponto de vista jurídico-positivo, uma reacção mais larga e perfeita" (p. 203); deve aplicar-se, dos tipos concorrentes, "seguramente o mais extenso, o que conduz a uma punição mais completa e perfeita" (p. 207). Nem parece ser outro, ainda hoje, o entendimento, nos específicos quadros do seu pensamento sobre a matéria, de PUPPE, *NK*, antes do § 52, n.º 35.

argumentar com lapsos, desatenções ou poucos cuidados do legislador na definição daquela severidade relativa. Deparar-se-ia aqui, afinal, com uma situação que, nos domínios do direito (também do penal), é dificilmente contestável: a da legitimidade legislativa para, dentro de certos limites, **reconformar normativamente a realidade** natural ou social, em suma, a realidade da vida. Mas é precisamente neste argumento que julgamos residir o óbice maior à procedência do entendimento em escrutínio. Dissemos atrás (supra, 3.º Cap., § 16) — e confirmamos aqui — que uma tal reconformação normativa só é metodologicamente aceitável dentro do **limite** das possibilidades que àquela são oferecidas pela natureza ôntica, é dizer, pela predeterminação não jurídica (neste caso: social) do substrato. Cremos, em definitivo, que a troca normativa de posições entre um ilícito que surge, segundo o seu sentido social e, portanto, segundo a realidade das coisas, como dominante e outro que aparece como dominado, subordinado ou acessório significaria a ultrapassagem inadmissível daquele limite, pondo em causa nada menos que o próprio fundamento da nossa concepção do concurso aparente.

§ 36 Resta assim — como pensamos corresponder, de resto, à solução generalizadamente defendida pela doutrina clássica da consumpção impura ([51]), embora utilizemos diferente terminologia — trazer para este contexto a *cisão teorética entre norma de comportamento e norma de sanção*. Dir-se-á então que, no plano da construção da unidade ou pluralidade do facto, onde situamos a argumentação, **o ilícito socialmente dominante continua a oferecer o sentido do facto global** (nos casos referidos no § 33, os ilícitos de apropriação, de burla, de tentativa de violação). A estes ilícitos correspondem porém, em termos de sanção, as **molduras penais mais graves** previstas para os ilícitos de asseguramento / encobrimento, de falsificação de documento autêntico, de coacção sexual. Esta solução, teoreticamente, parece-nos insusceptível da crítica de que ela radica em um afeiçoamento arbitrário do tratamento do caso à consequência jurídica que se reputa mais justa e adequada em termos de punição. Com o que ela pode esbarrar é, porventura, com uma violação do princípio da legalidade, no entendimento de que este não obrigaria apenas ao respeito pelos princípios *nullum crimen* e *nulla pœna sine lege*, mas impor-

([51]) Neste sentido, também, COSTA, A. M. Almeida, *Comentário Conimbricense*, II, art. 262.º, § 7.

taria a necessária conexão formal entre um e outro a propósito do mesmo facto. Mas esta objecção parece-nos longe de proceder. Por um lado (diferentemente do que vimos suceder em caso de unidade de norma ou de lei concretamente aplicável: supra, 42.º Cap., § 23), nas hipóteses de concurso aparente as leis abstractamente aplicáveis são também aplicáveis *em concreto*, são na realidade aplicáveis ao "grande facto". Sendo assim, e por outro lado, não se verifica aqui qualquer encurtamento, ou sequer amolecimento, do conteúdo garantístico conferido pelo princípio da legalidade criminal, porquanto não são em qualquer medida afectadas as expectativas do agente, baseadas em lei anterior, sobre os limites da punibilidade de qualquer dos ilícitos singulares por ele cometidos.

III. O crime continuado

1. Consideração geral

§ 37 Nos termos do art. 30.º-2, "constitui um só crime continuado a realização plúrima do mesmo tipo de crime ou de vários tipos de crime que fundamentalmente protejam o mesmo bem jurídico, executada por forma essencialmente homogénea e no quadro da solicitação de uma mesma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do agente". Aqui se revela o propósito da lei de tratar, sob um ponto de vista particular que em seguida se explicitará, um concurso de crimes *efectivo* no quadro da **unidade criminosa**, de uma "unidade criminosa" **normativamente (legalmente) construída**. E, coerentemente, o propósito de subtrair a punição às regras da punição do concurso de crimes e submetê-la a um regime adequado à consideração do caso como de unidade de crime (art. 79.º).

§ 38 Trata-se da consagração legislativa da figura do **delictum continuatum**, que se afirma já conhecida da ciência dos práticos italianos, foi desenvolvida pela jurisprudência alemã do séc. XIX e por ela, bem como pela doutrina alemã, generalizadamente aceite; e que chegou a obter consagração em alguns códigos penais alemães do séc. XIX como, ainda hoje, no CP italiano (art. 81-2) ([52]). Não foi todavia reconhecida no CP alemão de 1871 nem nas suas sucessivas revisões. O BGH, através de uma decisão fundamental do Grande Senado — BGHSt (GrS) 40, p. 138 — aceitou agora, todavia, a figura em termos de tal modo estritos e submeteu-a a uma crítica tão

([52]) Uma análise histórica e comparada minuciosa em CORREIA, Eduardo, nota 2, pp. 212 e ss., e 385 e ss.

profunda e generalizada (53) que a doutrina actual considera que equivaleu praticamente ao seu **aniquilamento de facto** (54).

§ 39 Os **propósitos político-criminais** que terão desde sempre estado na base da "construção normativa de uma unidade do facto" própria do crime continuado são de duas ordens diferentes. Por um lado, o desejo de, relativamente a séries extensas e numerosas de realizações típicas (*v. g.*, o agente que cometeu dezenas de coacções sexuais ou de abuso sexuais de crianças, o carteirista que, à saída de um grande jogo de futebol, furtou dezenas ou mesmo centenas de carteiras, o burlão que, através de um procedimento informático que inventou, cometeu centenas de burlas sobre cartões de crédito), evitar as **dificuldades práticas**, por vezes insuperáveis, de comprovação judicial de cada uma das realizações que integram a continuação, bem como os novos julgamentos implicados pelo desconhecimento ou não acusação de realizações típicas integrantes da continuação (55). Por outro lado, as consequências desproporcionadas e mesmo eventualmente injustas, face ao conteúdo e sentido do ilícito total, a que em matéria de **punição** conduziria a aceitação nestes casos de um concurso efectivo.

2. Requisitos

§ 40 O referido art. 30.º-2 reconduz o crime continuado a uma pluralidade de actos susceptíveis, cada um, de integrar várias vezes o mesmo tipo legal de crime ou tipos diferentes, se bem que análogos (em princípio, por isso, hipóteses de concurso efectivo) mas que, apesar disso, apresentem entre si uma **conexão objectiva e subjectiva de certa ordem** (analogamente, aqui, ao que vimos suceder com o concurso aparente) que convide a tratar uma tal pluralidade ainda como um facto uno. Se quisermos desenvolver esta unidade objectiva-subjectiva parece — reconhecida embora

(53) BGHSt (GrS) 40, 138 e ss.

(54) Cf. só, em data recente, JESCHECK / WEIGEND, § 66, V, 3 e s., ROXIN II, § 33, n.º 248 e ss., e STRATENWERTH / KUHLEN, § 17, n.º 13 e s.

(55) Uma consideração destas razões, ditas de "economia processual", em CORREIA, Eduardo, nota 2, p. 376 e ss., e *Caso Julgado e Poderes de Cognição do Juiz*, 1948, *passim*. VALDÁGUA, Maria da Conceição, As alterações ao Código Penal de 1995, relativas ao crime continuado, propostas na Revisão do Código Penal, *RPCC 16*, 2006, p. 536 e s., considera tratar-se de características do regime da figura do crime continuado que depõem contra a sua manutenção legal: sobre esta questão cf. infra, § 60 e ss.

uma certa indefinição das referências legais ([56]) — que ela deverá traduzir-se através dos elementos seguintes.

2.1. A conexão objectiva

§ 41 A realização continuada deve violar **de forma plúrima o mesmo ou fundamentalmente o mesmo bem jurídico**. Não haverá razão para atribuir demasiado valor, neste contexto, à velha questão de saber se cada tipo legal de crime protege um bem jurídico próprio, ou se pode verificar-se uma pluralidade de tipos legais de crime que protejam o mesmo bem jurídico ([57]). O que se deve exigir é que entre os bens jurídicos lesados exista uma relação de estreita **afinidade**, parentesco ou proximidade, análoga à que vimos (supra, § 11 e ss.) constituir para Puppe a ideia mestra do concurso ideal (*rectius*, aparente). Podem caber na previsão por isso, em nosso entendimento, não apenas casos como o da relação entre realizações típicas fundamentais e qualificadas ou privilegiadas, mas também como o da conexão entre realizações típicas diferentes, *v. g.*, contra o património, contra a liberdade, contra a liberdade sexual ([58]), etc. De bens jurídicos **diferentes** se tratará, porém, sempre que eles assumam natureza **eminentemente pessoal** e se verifique uma **pluralidade de vítimas** ([59]). Neste contexto nos parece todavia dever acentuar-se que o carácter "eminentemente pessoal" do bem jurídico deverá ser tomado, ao menos por via de princípio, na sua **acepção estrita** e mais comum (supra, § 7), segundo a qual assumem esse carácter unicamente os bens protegidos pelos tipos legais de crime contidos no Título I da PE do CP ([60]).

([56]) ALMEIDA, Duarte d', nota 18, p. 109, qualifica-a mesmo de "pouco rigorosa".

([57]) Anote-se, neste contexto, que a formulação em análise constava já do § único do art. 33.º do ProjPG de Eduardo Correia, para quem o bem jurídico, como expressão do "sentido e do fim dos preceitos penais singulares" (Honig), seria próprio de cada tipo legal de crime (supra, 6.º Cap., § 17). Concretamente a propósito do crime continuado, CORREIA, Eduardo, nota 2, pp. 348 e ss., e 361 e ss.

([58]) Aceitando só a continuação perante crimes fundamentais e qualificados, ROXIN II, § 33, n.º 250.

([59]) O que o Anteprojecto 2007 se propõe agora explicitar, acrescentando ao art. 30.º um n.º 3, segundo o qual "o disposto no número anterior não abrange os crimes praticados contra bens eminentemente pessoais, salvo tratando-se da mesma vítima". Convergindo com esta posição, mas criticando o aditamento por desnecessário e eventualmente contraproducente, VALDÁGUA, Maria da Conceição, nota 55, p. 531 e ss.

([60]) Sendo por isso com essa extensão que deverá, no futuro, ser interpretado o preceito referido na nota anterior.

§ 42 A realização continuada deve, por outra parte, ser **executada por forma essencialmente homogénea** ([61]) **e no quadro de uma mesma situação exterior**. Há, na verdade, crimes diversos cuja execução, todavia, pode apresentar a homogeneidade requerida (*v. g.*, diferentes crimes sexuais, contra a liberdade, contra o património, etc.). Enquanto outros há que, protegendo o mesmo bem jurídico ou bens jurídicos próximos, todavia supõem formas de execução heterogéneas: isso sucederá, p. ex., com a concorrência entre diversas pequenas burlas de dinheiro e uma complexa burla económico-financeira ou informática. Esta exigência é de resto reforçada pela lei ao exigir que a realização continuada ocorra no quadro de uma "mesma situação exterior": se um caixa bancário comete múltiplos abusos de confiança retirando pequenas quantias destinadas à satisfação das suas necessidades diárias e, um dia, se apropria de um milhão de euros destinados à compra de uma vivenda, não existe relação legal de continuação entre aquelas pequenas e esta grande infracção.

§ 43 Questão que cumpre colocar é a de saber se, face ao requisito da homogeneidade da execução no quadro de uma mesma situação exterior, se deve dar relevo à circunstância de entre as violações plúrimas se verificar ou não uma **proximidade** ou **afinidade espácio-temporal**. Tendemos, ao menos em via de princípio, para uma resposta negativa ([62]): decisivo para a continuação não é o lugar e o dia das violações, mas a **unidade de contexto situacional** em que ocorram, isto é, que elas se relacionem contextualmente umas com as outras. Sem prejuízo de dever reconhecer-se que uma proximidade de espaço e de tempo pode ser *indício* forte da unidade de contexto situacional referida.

2.2. A conexão subjectiva

§ 44 Os problemas de solução mais duvidosa colocam-se na vertente subjectiva da relação de continuação. Desde logo, a lei omite qualquer indicação sobre se deve exigir-se um *dolo especial* ([63]). A jurispru-

---

([61]) Sobre o sentido deste requisito, CORREIA, Eduardo, nota 2, p. 366 e ss.

([62]) Favorável à proximidade espácio-temporal, por último, ROXIN II, § 33, n.º 252, alcançando todavia soluções de casos concretos que se não afastarão sensivelmente das que se alcançam com o critério em seguida proposto. Contra, CORREIA, Eduardo, II, p. 211.

([63]) Indicações jurisprudenciais e doutrinárias abundantes e precisas encontram-se na decisão do Grande Senado cit. supra, § 38. Cf., também, por último, ROXIN II, § 33, n.º 248 e ss.

dência alemã mais antiga exigia um **dolo conjunto**, face ao qual as diversas realizações típicas deveriam, ao menos no essencial, ter sido planeadas previamente pelo agente. A jurisprudência posterior veio reconhecer, todavia, que esta "unidade essencial de resolução", se pensada até ao fim, levaria a excluir da figura, para além dos delitos negligentes, grande parte das hipóteses que, de um ponto de vista pragmático (nomeadamente de economia processual), a justificavam. Face a esta objecção, a maioria da doutrina passou a bastar-se com a exigência de um **dolo continuado**, isto é, com o plano do agente de que repetiria a realização típica caso a ocasião se proporcionasse. O que, em todo o caso, continuava a expurgar a figura de todas aquelas hipóteses em que a resolução que presidiu às realizações típicas fosse verdadeiramente uma nova resolução ou a renovação da anterior.

§ 45 Compatível com a figura do crime continuado, tal como se encontra plasmada no art. 30.º-2, parece pois tanto a hipótese de à série de comportamentos presidir um dolo conjunto ou um dolo continuado, como de se estar perante uma pluralidade de resoluções (64). O ponto a que a lei confere relevo não é esse, mas sim o de — seguindo um pensamento que de Kraushaar vem até Eduardo Correia (65) — exigir que aquele crime seja dominado por uma situação exterior "**que diminua sensivelmente a culpa do agente**": aqui se depara com um elemento "subjectivo" que há-de estender-se à *inteira relação de continuação*. Nas palavras de Eduardo Correia, essencial à "continuação criminosa será, verdadeiramente, a existência de uma relação que, *de fora*, e de maneira considerável, facilitou a repetição da actividade criminosa, tornando cada vez menos exigível ao agente que se comporte de maneira diferente, isto é, de acordo com a norma" (66). Ideia esta que, repousando na medida daquilo que *deve* ser

(64) A esta hipótese de pluralidade de resoluções parece CORREIA, Eduardo, II, p. 209, restringir a figura: ela abrange "certas actividades que preenchem o mesmo tipo legal de crime — ou mesmo diversos tipos legais tipos legais de crime, mas que fundamentalmente protegem o mesmo bem jurídico — e às quais presidiu uma pluralidade de resoluções (que, portanto, atiraria a situação para o campo da pluralidade de infracções)". Se, no entanto, se olhar alguns dos exemplos que aponta de crime continuado (*ibid.*, p. 210, notas 2 e 3, e infra, § 46), logo se reconhecerá que esta "pluralidade de resoluções" é compatível com a preexistência de um dolo continuado ou mesmo conjunto.

(65) KRAUSHAAR, Beiträge zur Lehre von dem fortgesetzten Verbrechen, *Der Gerichtssaal 12*, 1860, p. 258 e ss., CORREIA, Eduardo, nota 2, p. 283 e ss., e II, p. 209 e ss.

(66) CORREIA, Eduardo, II, p. 209.

exigido do agente, é compatível com a concepção da **exigibilidade** que supra, 22.º Cap., esp. § 10, explanámos.

§ 46 Segundo Eduardo Correia, **exemplos paradigmáticos** desta diminuição da culpa em nome de uma menor exigibilidade — "quando [anota] posta em confronto, como sempre se pressupõe, com a que seria dada no concurso real" — seriam o "de se ter criado, através de uma certa actividade criminosa, uma certa relação ou acordo entre os sujeitos" (*v. g.*, em caso de abuso sexual de uma [mesma] criança); o de voltar a verificar-se uma oportunidade favorável à prática do crime, que já foi aproveitada ou que arrastou o agente para a primeira conduta criminosa (*v. g.*, "quando se descobriu uma porta falsa que dá acesso a uma casa e que se aproveita várias vezes para furtar objectos lá depositados"); o da "perduração do meio apto para realizar um delito, que se criou ou adquiriu com vista a executar a primeira conduta criminosa" (*v. g.*, o "moedeiro falso que, tendo adquirido ou construído a aparelhagem destinada a fabricar notas, se vê sempre de novo solicitado a utilizá-la"); o "de o agente, depois de executar a resolução que tomara, verificar que se lhe oferece a possibilidade de alargar o âmbito da sua actividade criminosa" (*v. g.*, "o ladrão que entra num quarto para furtar uma jóia e, verificando depois que lá se encontra dinheiro, se apropria dele") ([67]).

3. Consideração conclusiva

§ 47 Como supra, § 38, se anotou, na sequência da decisão do Grande Senado do BGH, a doutrina alemã vem criticando de forma acre a figura do crime continuado e considerando aquele aresto como um dobre a finados por ela. Em desfavor da figura são apontados argumentos da mais diversa ordem. Três considerações porém importa fazer. A primeira consideração é que, como dissemos, a construção alemã possui origem puramente jurisprudencial e doutrinal, enquanto entre nós ela mereceu **consagração legal**, à qual, como é óbvio, o intérprete e o aplicador devem fidelidade absoluta. A segunda é que a maioria das críticas — e das mais graves — derivam de duas fontes: da reputada inadequação da **forma de punição** do crime continuado; e das suas reais ou pretensas implicações jurídico-processuais. Estas últimas não devem constar de um tratamento da PG do DP. Quanto à inadequação da forma de punição, ela será analisada infra, § 59 e ss. A terceira consideração é que a figura, tal como se encontra desenhada no direito positivo português, põe o acento tónico na unificação que para a relação de continuação deriva da diminuição da culpa, em

([67]) CORREIA, Eduardo. II, p. 210 e notas.

nome de uma **exigibilidade sensivelmente diminuída**; uma fundamentação, esta, que na jurisprudência e na doutrina alemãs mal penetrou depois da posição assumida por Kraushaar e, de qualquer forma, não condicionou a evolução científica e prática da figura. Até a um ponto em que, como se anotou, a conexão subjectiva da continuação continuou até aos nossos dias, naquelas jurisprudência e doutrina, a reduzir-se, praticamente de forma exclusiva, à questão do dolo conjunto *versus* dolo continuado.

§ 48 Ora, a verdade está para nós em que uma tal diminuição sensível da exigibilidade, relativamente à inteira relação de continuação, fruto de **uma mesma** situação exterior, serve para conferir àquela, pelo menos na generalidade dos casos, uma **unidade do sentido de desvalor do ilícito** do comportamento global (normativamente construída, é certo) e, por aí, para justificar a subtracção de tais casos à forma de punição contida no art. 77.º Sem que, por outro lado, a figura se identifique, na sua construção como na sua essência normativa, com as hipóteses que considerámos de concurso aparente ou impuro: não fosse a relação de continuação e a unificação normativa que ela determina e, é exacto, depararíamos naquela relação, ao menos por regra, com hipóteses de concurso efectivo ou puro. Neste sentido se podendo afirmar que **o crime continuado constitui um tertium genus relativamente às figuras do concurso efectivo e do concurso aparente**. A justificação que apresentamos para a figura serve assim para afastar, no essencial, as reservas que possam ser-lhe suscitadas de um ponto de vista **dogmático** próprio da "doutrina geral do crime"; se serve igualmente para afastar as dúvidas que, em perspectiva **político-criminal**, possam levantar-se ao regime de punição que lhe é cabido, é coisa que pode porventura continuar a suscitar dúvidas e que, como dissemos, consideraremos ainda.

IV. O exercício habitual ou profissional do facto

§ 49 Mais longe ainda do que com a relação de continuação se iria quando se defendesse — como uma certa jurisprudência alemã, hoje todavia abandonada e também doutrinalmente condenada (68) — que também relativamente àqueles factos que exigem, como condição de **tipicidade qualificada**, a sua **prática habitual ou profissional** (*v. g.*, arts. 141.º-2, 170.º-1, 176.º-3, 244.º-1*c)*, 368.º-A-6) deveria verificar-se uma **redução à unidade** dos singulares ilícitos típicos. Uma tal concepção, que

(68) Cf., só, ROXIN II, § 33, n.º 275, e STRATENWERTH / KUHLEN, § 17, n.º 15.

— levada às últimas consequências lógicas — conduziria a punir nos termos do concurso efectivo quem praticasse os factos em número insuficiente à sua caracterização como exercício habitual ou profissional, e por um único crime quem os praticasse em número suficiente para uma tal caracterização, é injusta e inadequada: estar-se-á em tais casos perante um concurso de crimes em princípio efectivo.

V. O regime jurídico da punição do concurso de crimes

1. Do concurso de crimes efectivo, puro ou próprio

§ 50 A **regulamentação legal** do concurso de crimes efectivo encontra-se no já muitas vezes referido art. 30.º-1. A locução "**tipos de crime**" nele contida oferece base suficiente à construção expendida. Não merecerá ênfase particular a circunstância de esta locução ter substituído, na formulação definitiva do CP, a que se encontrava no art. 33.º do ProjPG, "tipos legais de crime" ([69]). É verdade que o CP usa as mais das vezes a primeira expressão com o sentido da segunda. Mas não será de todo infundado supor que à modificação possa ter estado, de forma mais ou menos consciente, subjacente a ideia de que "tipos de crime" serão as espécies de delito concretamente praticadas, **os ilícitos-típicos cometidos no mundo da vida** e não os arquétipos contidos nas descrições legais em que aqueles cabem. O que só se reforça com a circunstância — por vezes criticada ao legislador ([70]) — de o mesmo preceito referir os tipos de crime "**efectivamente cometidos**". É verdade que se não "cometem", efectivamente ou não, tipos legais de crime, mas já se cometem tipos (espécies) de crime no sentido de concretos ilícitos-típicos. Se necessário se torna ainda que eles sejam cometidos "efectivamente", isso terá sido, em nosso modo de ver, a tradução plástica da exigência implícita de que se distinga o concurso efectivo de crimes do concurso aparente e, por aí, a pluralidade da (pelo menos tendencial) unidade de sentidos de ilicitude do comportamento global.

§ 51 Em termos de **consequência jurídica** do concurso de crimes efectivo, regem os arts. 77.º e 78.º. Neste campo, basta no presente contexto acentuar de novo que eles conduzem à determinação de uma **pena**

([69]) Sobre esta questão, MOUTINHO, Lobo, nota 24, p. 94 e ss.

([70]) De novo, MOUTINHO, Lobo, nota 24, p. 100 e ss.

única sob a forma de uma **pena conjunta**. Para isso o juiz começará pela determinação da *pena concreta* cabida a cada um dos ilícitos-típicos efectivamente cometidos como se cada um deles fosse objecto de um processo penal autónomo, nos termos do art. 71.º Ele deverá construir seguidamente a *moldura penal conjunta* ou moldura do concurso efectivo: uma tal moldura terá como limite máximo a *soma* das penas parcelares determinadas (que todavia não poderão ultrapassar 25 anos de prisão ou 900 dias de multa) e como limite mínimo a pena concreta mais grave determinada (art. 77.º-2). Por fim, através de uma *consideração conjunta dos factos (plúrimos) e da personalidade (única) do agente*, o juiz determinará a medida concreta da pena a aplicar (art. 77.º-1).

§ 52 Três notas merecem ainda referência. A primeira para sublinhar que, concorrendo penas de prisão com penas de multa, "a diferente natureza destas mantém-se na pena única resultante da aplicação dos critérios estabelecidos nos números anteriores" (art. 77.º-3) (71). A segunda — de um ponto de vista de aplicação normativa porventura a mais importante e significativa — para acentuar que, nos termos do art. 77.º-4, "**as penas acessórias e as medidas de segurança são sempre aplicadas ao agente, ainda que previstas por uma só das leis aplicáveis**", o que está absolutamente de acordo com a ideia reitora do concurso de crimes efectivo. A última para lembrar que a pena conjunta pode ser feita (ou refeita) em processo posterior "se, depois de uma condenação transitada em julgado, mas antes da respectiva pena estar cumprida, prescrita ou extinta, se mostrar que o agente praticou anteriormente àquela condenação outro ou outros crimes" (dito "conhecimento **superveniente** do concurso", art. 78.º). Concretizações das afirmações apodícticas contidas neste parágrafo, como no anterior, pertencem já à teoria da consequência jurídica, nomeadamente, aos temas da determinação e da medida da pena (72).

2. Do concurso de crimes aparente, impuro ou impróprio

§ 53 Faltam inteiramente, no ordenamento jurídico-penal português vigente, **normas expressas** onde se contenha o regime de punição cabido às hipóteses de concurso aparente, tornando-se por isso indispensável ao

(71) O que é fonte de diversos problemas que, todavia, seria desajustado considerar aqui. Cf., antes da Reforma do CP de 1995, o nosso *DP II*, § 417 e ss.; e, depois da Reforma, o Ac. do STJ de 6-3-2002, *CJ-STJ*, 2002, I, p. 220 e ss., e, na doutrina, BRANDÃO, Nuno, Conhecimento superveniente do concurso e revogação de penas de substituição. Ac. do STJ de 3-7-2003, *RPCC* 15, 2005, p. 135[26], e ANTUNES, Maria João, *Consequências Jurídicas do Crime. Notas Complementares para a Cadeira de Direito e Processo Penal na FDUC*, 2006-7, pp. 45 e 47.

(72) Cf., nos termos da nota anterior, DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 392 e ss.

intérprete construí-lo, rigorosamente de acordo com as intenções político-criminais e os princípios dogmáticos que lhe subjazem. Tal, cremos, constituirá caminho seguro para oferecer na matéria soluções aceitáveis e fundadas. E não terá sentido — comece-se por o afirmar — brandir contra este procedimento a ameaça de violação do princípio *nulla pœna sine lege*. Procedimento paralelo seguiram afinal sempre com inteira (e justificada) afoiteza a doutrina e a jurisprudência portuguesas relativamente aos casos tradicionalmente chamados de *consumpção*, sem que vez alguma (quanto pudemos determinar) se tenha suscitado a eventualidade de violação do princípio da legalidade da pena. Ora, a alternativa única disponível seria a de não fazer — em todo o caso, contra o disposto no art. 30.º-1 — a distinção entre concurso efectivo e aparente, submetendo então necessariamente este último ao regime de punição daquele, isto é, ao severo regime contido no art. 77.º Tudo visto, sendo a finalidade político-criminal que preside à autonomização da categoria do concurso aparente a de a submeter a um regime de punição **menos severo e pesado**, sempre um tal regime actuará **favore reum**, não *contra reum*. Não há portanto aqui qualquer ofensa ao conteúdo de sentido do princípio da legalidade criminal.

§ 54 A ideia mestra a que, ainda nesta matéria, importa recorrer é a de que o concurso aparente, traduzindo-se embora numa **pluralidade de tipos legais de crime violados** pela conduta global, apresenta (e caracteriza-se através de) uma dominância de **um único sentido de desvalor do ilícito**, ou porque os restantes ilícitos singulares se encontram relativamente a este numa relação de intersecção, ou de parcial cobertura, ou de dependência; analisada esta relação *segundo o sentido do ilícito* e não segundo a relação eventual entre normas ou mesmo entre bens jurídicos concorrentes. Daqui resultam consequências fundamentais em matéria de punição.

§ 55 (1) Um qualquer sistema de **soma** das penas aplicadas a cada crime para determinação da moldura do concurso aparente, mesmo que só do seu *máximo* nos termos do art. 77.º-2, deve considerar-se afastada, uma vez que não só um tal sistema implicaria violação frontal da ideia mestra que rege esta forma de concurso, como tal poderia importar — ou importaria as mais das vezes — uma violação inconstitucional do princípio *ne bis in idem*, na vertente da proibição de dupla valoração. A aludida ideia mestra a que se submete o concurso aparente só pode conduzir a que se tome como **moldura penal do concurso** aquela que corresponde ao

sentido (socialmente ou, em casos excepcionais: supra, § 32 e ss., sancionatoriamente) dominante de desvalor do ilícito, determinante de uma tendencial ou aproximativa **unidade global do facto**; a qual será simultaneamente a que corresponde ao singular ilícito típico ao qual seja aplicável a moldura penal **mais grave**.

§ 56 (2) Dentro desta moldura do concurso (aparente) o juiz **determinará a medida concreta da pena** segundo os critérios gerais. Diferentemente, por um lado, do que prescreve o art. 77.º-1, o juiz não deve considerar "em conjunto" os factos cometidos, antes deve, nos termos do art. 71.º-2, determinar a pena concreta "em função da culpa do agente e das exigências da prevenção". Diferentemente, porém, por outro lado, do que dissemos suceder em caso de unidade de norma ou de lei (42.º Cap., § 24), aqui tem o juiz de tomar obrigatoriamente em conta os crimes que concorrem com aquele que serviu para eleger a moldura penal do concurso como **factores agravantes da medida da pena**; considerados portanto **na sua própria tipicidade** e, deste modo, como elementos dotados, *para este efeito*, de "relevância jurídico-penal autónoma". Isto na parte, obviamente, em que eles não participem já da tipicidade do ilícito dominante. Sob pena de, se o juiz o não fizer, violar de novo o princípio jurídico-constitucional *ne bis in idem*, agora na vertente do mandado de esgotante apreciação da matéria ilícita ([73]).

§ 57 (3) Pode suceder em algum caso que a moldura penal correspondente ao sentido de ilícito dominado, possuindo embora um limite máximo igual ou inferior ao da moldura penal do ilícito dominante, todavia preveja um *limite mínimo mais alto* do que aquela. Deve então perguntar-se se será de atribuir a este limite mínimo um **efeito de bloqueio** da medida da pena concretamente aplicada ao concurso. Cremos que — diferentemente do que defendemos em caso de unidade de lei ou de norma: supra, 42.º Cap., § 23 — a esta questão deve dar-se uma resposta afirma-

([73]) No pressuposto, por isso, de que a sentença que condene por concurso aparente tem de conter — sob pena de *nulidade*, nos termos do art. 374.º-3*a)* do CPP — *a menção das normas violadas para além da que vai determinar a eleição da moldura penal do concurso*; diferentemente do que sucederá nos casos de unidade de norma ou de lei, onde só se torna indispensável, para o efeito, a menção da norma em concreto aplicável. Na linha, afinal, daquilo que uma certa doutrina alemã (a que se fez já referência supra, 42.º Cap., nota 15) chama, na esteira de Abels, a "função de clarificação do concurso ideal."

tiva. A moldura penal do concurso continuará a ser — apesar do mínimo mais alto da moldura penal correspondente ao ilícito dominado — a que cabe ao sentido de ilícito mais gravemente punível. Só que o ilícito dominado, como dissemos, entrará em todos os casos em conta como *factor de agravação da medida concreta da pena do concurso*. É razoável, por isso, que **o efeito mínimo de agravação não deva permitir a fixação de uma pena concreta inferior ao limite mínimo da moldura penal correspondente ao ilícito dominado** (74).

§ 58 (4) Finalmente, o juiz deve em caso de concurso aparente aplicar as **penas e as medidas de segurança previstas por uma qualquer das normas aplicáveis**; e por conseguinte mesmo por aquela ou aquelas que não relevem para a construção da moldura penal do concurso, se tanto for requerido pelo conteúdo de sentido do ilícito dominado. Nesta medida e com este sentido, o disposto no art. 77.º-4 vale também para o concurso aparente (75). Se, desta forma, estaremos ainda aqui perante uma limitação a um sistema de absorção ou já dentro de um sistema de exasperação, é questão teórico-construtiva que deve ser decidida em sede de doutrina das consequências jurídicas do crime.

3. Do crime continuado

§ 59 O estudo que supra, § 37 e ss., levámos a cabo permitiu concluir que o crime continuado é constituído, de um ponto de vista real, por hipóteses que conformam um concurso de crimes efectivo que, todavia, a lei transforma numa unidade jurídico-normativa. E ainda que a razão de ser da figura reside, entre outras mas primacialmente, na intenção político-criminal de subtrair esta figura — em nome da exigibilidade sensivelmente diminuída que domina a inteira continuação criminosa — à dureza da punição do concurso efectivo de crimes. Daí a regulamentação contida no art. 79.º, segundo a qual "o crime continuado é **punível** com a pena **aplicável** à conduta mais grave que integra a continuação". O sentido deste

(74) Só neste sentido e nesta medida se podendo aceitar a terminologia de ROXIN II, § 33, n.º 113, quando, em contexto análogo, fala de um *princípio de combinação*, porquanto o sistema de *absorção* em que a punição do concurso aparente se traduziria é *limitado* no sentido de que deve valer sempre o mínimo mais elevado das molduras penais concorrentes.

(75) Solução expressamente considerada para o concurso ideal, desde que a pena concreta seja superior a dois anos e prisão, pelo § 52, IV, do CP alemão.

normativo parece assim óbvio: o juiz tem de determinar qual a *moldura penal aplicável a cada um dos crimes* que integram a continuação. A mais elevada delas, se diferenças houver, será a moldura penal do crime continuado. Diferentemente, porém, do que vimos suceder com a punição do concurso aparente, aqui os factos singulares não relevam como factores de agravação da medida concreta da pena; antes será levado em conta o conteúdo de ilícito e de culpa, bem como as exigências da prevenção, do "facto continuado" ou comportamento global tomado como uma unidade. Se o sistema assim legalmente consagrado ainda deve considerar-se como já de *exasperação* ou ainda de *absorção*, é questão construtiva e conceitual que não cumpre dilucidar em definitivo neste contexto (76).

§ 60 É neste sistema de punição — a que se aliam motivos processuais ponderosos, sobretudo relacionados com as questões da extensão do caso julgado, mas que aqui não serão considerados —, quando posto em comparação com o que vale para o concurso efectivo, que assentam as principais críticas que crescentemente se dirigem à própria figura do crime continuado. Diz-se, nomeadamente, que ela pode conduzir a um **injustificado privilegiamento do seu autor** (77), porventura, em certos casos, político-criminalmente insuportável. Assim, poderia exemplificar-se, quem cometa oito crimes de burla informática simples (art. 221.º-1 e 2) em concurso efectivo pode incorrer, ao menos teoricamente, numa pena de 24 anos de prisão. Diversamente, quem cometa, numa relação continuada de fácil verificação (78), mais de um milhar de burlas informáticas simples nunca poderá ser punido com prisão superior a 3 anos. Parece deste modo poder duvidar-se que por esta forma se tenham tomado na conta devida as exigências de culpa e de prevenção (art. 71.º-1) que constituem os critérios de medida concreta da pena.

§ 61 Perante esta crítica, a primeira observação a fazer é a de que a generalidade das doutrinas concentraram em demasia a vertente subjec-

---

(76) No sentido da exasperação, DIAS, Figueiredo, *DP II*, § 433, e ALMEIDA, Duarte d', nota 18, p. 107.

(77) Assim, ROXIN II, § 33, n.º 257; e agora VALDÁGUA, Maria da Conceição, nota 55, p. 535 e s.

(78) É conhecida da própria experiência *criminológica*, inclusivamente portuguesa: o caso do menor de 15 anos que "havia descoberto a fórmula mágica para aceder aos cartões de crédito de cidadãos norte-americanos" e, por esta forma, terá causado à Marconi um dano de 120 mil contos.

tiva do crime continuado na questão menor do *dolo conjunto ou continuado* que porventura lhe deva presidir, abandonando (ou minimizando) cedo demais a linha de pensamento que, na esteira de Kraushaar e de Eduardo Correia, pode oferecer um fundamento consistente à figura: a da **exigibilidade**, e portanto da **culpa consideravelmente diminuída** que certas das situações continuadas claramente revelam (*v. g.*, a das dificuldades persistentes de tesouraria de um empresário que o conduz a não entregar repetidamente ao Estado-fisco as quantias retidas aos trabalhadores, para deste modo satisfazer sem atrasos os salários) (79). Isto implica porém que a jurisprudência se debruce atenta e autonomamente, em cada caso, sobre esta questão e só admita a existência de um crime continuado *quando, em sua convicção, aquela exigibilidade consideravelmente diminuída se tenha verificado*. Temos esta condição como indispensável à manutenção da figura, não podendo concordar por isso com os incontáveis casos em que a nossa jurisprudência se tem bastado com frequência com a configuração objectiva da continuação, eventualmente juntando-lhe a afirmação apodíctica de que ela revela uma culpa consideravelmente diminuída.

§ 62 A segunda observação tem a ver com a eventual desproporção, injustiça e inutilidade da figura em função das consequências punitivas a que dá lugar. Se o crime continuado constitui uma alternativa normativa a um concurso efectivo, pode então argumentar-se que, na generalidade dos casos autênticos de crime continuado, **a aplicação do disposto no art. 77.º não conduziria por força a punições desproporcionadas ou iníquas**. E isto porque a diminuição sensível da culpa já haveria de intervir no sentido de diminuir as penas dos singulares ilícitos típicos que o juiz tem de fixar para efeito do disposto no n.º 2 daquele preceito. O que por sua vez iria reflectir-se, por um lado, na moldura penal conjunta do concurso e ainda na pena concreta a fixar dentro desta moldura (80). Sem que tal tivesse de significar (nem poderia...) violação da proibição de dupla valoração.

§ 63 Tudo considerado, parece dever concluir-se da forma seguinte: a consagração legislativa da figura do crime continuado como alternativa,

---

(79) Sobre a continuação criminosa no crime de abuso de confiança fiscal, ver SOUSA, Susana Aires de, *Os Crimes Fiscais: Análise Dogmática e Reflexão sobre a Legitimidade do Discurso Criminalizador*, 2006, p. 140 e ss.

(80) Neste sentido, ANTUNES, Maria João, nota 71, p. 47, e VALDÁGUA, Maria da Conceição, nota 55, p. 535 e ss.

para certas situações, ao concurso efectivo constitui uma clara opção político-criminal e dogmática do legislador, com a qual o intérprete só tem de se conformar. Um *tournant* como o que se verificou a propósito na Alemanha, depois da muitas vezes referida decisão do Grande Senado, só pode eventualmente justificar-se entre nós no plano *de iure condendo*, **no plano da reforma legislativa**. Tanto mais quanto a figura funciona indiscutivelmente, em termos punitivos, em maior ou menor medida, não *contra*, mas *favore reum*. As reservas político-criminais que ao crime continuado se possam opor só podem por isso conduzir o intérprete e o aplicador — e, se fundadas, deverão conduzir, de acordo com o princípio do primado da política criminal — a serem **particularmente rigorosos e exigentes na aferição dos pressupostos,** objectivos mas sobretudo **subjectivos**, de que depende a existência jurídica da relação de continuação, nos termos do art. 30.º-2 do CP.

ÍNDICE DE MATÉRIAS (*)

(*) Os números a negro remetem para os capítulos, os outros para os parágrafos.

A

Aberratio ictus — v. **Erro de execução**
Abolicionismo penal **10** 69
Aborto — v. **Interrupção voluntária da gravidez**
Abuso de direito **15** 38, **18** 17
Acaso **35** 2, **38** 45
Acção
— **directa** **18** 21 ss
— **esperada (devida)** **30** 3
— **final** **10** 16 ss, 32 s, 58
— **humana** **11** 37
— **social** **10** 29, 34 ss
— **voluntária** **11** 37
Capacidade de **11** 22, 25
Capacidade individual de **38** 5 ss
Conceito de **10** 4, 8, 10, 13, 15
— **negativo de** **10** 36
— **pessoal de** **10** 37 ss
Desvalor de **10** 59, **11** 6 ss, 38 s
Dever de **16** 42, **37** 12, 16, 21, **38** 67
Funções do conceito de **10** 27 ss, 40, **11** 37
Objecto da **11** 40 s, 44
Acções de protesto **25** 15
Acessoriedade (Princípio da) **31** 8, 63 ss, **32** 1, 12 ss
Acessoriedade administrativa **18** 17 ss
Acordo **17** 6 — v. **Consentimento efectivo**
Actio libera in causa **21** 52 ss, **28** 68, **35** 26, **42** 17
Modelos de imputação da **21** 54 ss
Actos de autoridade
— **e conflito de deveres** **16** 45
— **e legítima defesa** **15** 42
Actos de execução **27** 9 s, **28** 13 ss
Actos preparatórios **9** 11, **27** 4 ss, **33** 7, **40** 2 ss
Actos reflexos **10** 28, 39, **11** 37
Actuação em nome de outrem **11** 23
Actuação no lugar de um órgão oficial **18** 19 ss
Actuação oficial (como causa de justificação) **18** 2 ss, **35** 38
Actualidade
— **da agressão** **15** 11 ss
— **do perigo** **16** 8
Acumulação — v. **Crimes acumulativos ou aditivos**
Ad impossibilia nemo tenetur **10** 74, **22** 8, **26** 7, **35** 12, **38** 5
Adequação (Teoria da) — v. **Causalidade adequada**
Adequação social **11** 15 ss, **12** 24, 26, **18** 23 s, 28, **26** 14
Administração supletiva da justiça penal (Princípio da) **9** 44 ss
Adolescente **21** 64, **38** 48
Aeronaves civis (Factos praticados a bordo de) **9** 18
Afecto (Estados de) **10** 39, **13** 61 s, **21** 36, **22** 35 ss
Agente / Vítima (Concertação) **4** 29 ss
Agente provocador **31** 71 s, **32** 62
Agere pro magistratu — v. **Actuação no lugar de um órgão oficial**
Agressão de animais **15** 6
Agressão na legítima defesa **15** 6 ss
Ajuste — v. **Instigação**
Alcoolemia **7** 12, **21** 53
Aliciamento — v. **Instigação**
Alternativa neutral à consciência **25** 13
Analogia
— **e causas de justificação** **14** 4 s
— **pensamento de** **11** 25, **25** 22 ss
— **permitida** **28** 63
Proibição da **8** 18 ss
Animus defendendi **15** 43
Anomalia psíquica **5** 9, **21** 1 ss
Antijuridicidade — v. **Ilicitude**

Aplicação da lei penal no espaço (Sistema da / Princípios da) 9 2 ss
Aplicação da lei penal no tempo — v. **Retroactividade (Proibição de)**
Atenuação especial da pena
— **e estado de necessidade desculpante 22** 26 s
— **na cumplicidade 32** 33
— **na falta de consciência do ilícito 23** 25 ss
— **na tentativa 28** 44
— **no excesso de legítima defesa 22** 34
— **nos crimes de omissão 37** 31 ss
Atitude interna (Características da) 13 60 ss, **20** 46 s
Atitude interna (Gesinnung) 10 64 ss, 71 ss
Atribuição político-jurídica 10 47 ss
Auburn (Sistema penitenciário de) 4 52
Autocolocação em perigo 12 38 s, **35** 44
Autodeterminação — v. **Autonomia. Auto-responsabilidade**
Autonomia (Princípio da) 17 2, 5 ss, 20 ss — v. **Auto-responsabilidade (Princípio da)**
Autor — v. **Autoria**
— **atrás do autor 31** 21, 59
— **individual 11** 21, 34 ss
Auto-responsabilidade 12 27, 39, **31** 5, 15, 18 s, 21 ss, 54 s, **35** 29 ss, 33 s, 46, **38** 41, 45, 50 — v. também **Confiança (Princípio da)**
Autoria
— **assente na causalidade 30** 5 ss
— **como centro pessoal do ilícito típico 30** 2, 12, 16 s, 22 s, **31** 52, 55, **40** 9
— **como domínio do facto** — v. **Domínio do facto**
— **e elementos subjectivos especiais 30** 24 ss
— **extensiva 30** 5, 21
— **intelectual ou moral 31** 4 s, 53, 80
— **no direito vigente 30** 29 s
— **nos crimes de dever 30** 18, 26, 33 19, 21 s
— **nos crimes de domínio 30** 19
— **nos crimes de mão própria 30** 18, 27 s
— **nos crimes de omissão 30** 18, 23, **40** 9 ss
— **nos crimes dolosos de acção 30** s, 33
— **nos crimes específicos 30** 25
— **nos crimes negligentes 30** 18, 23, **35** 46 ss
— **restritiva 30** 8, 12, 21, 29
— **subjectiva 30** 14 ss
— **unitária 30** 5 ss, 13, 21, **35**, 48
Concretas forma de — v. **Autoria imediata, Autoria mediata, Co-autoria, Instigação**
Tentativa de 32 37
Autoria / cumplicidade (Concurso) 42 17
Autoria imediata 31 1, 6, 8, **40** 9 ss
Autoria mediata
— **através de aparelhos organizados de poder 31** 25 ss
— **e princípio de auto-responsabilidade 31** 5, 15
— **por actuação atípica do instrumento 31** 6 s
— **por actuação lícita do instrumento 31** 12 ss
— **por actuação não culposa do instrumento 31** 14
— **por erro sobre a factualidade típica do instrumento 31** 10 ss
— **por erro sobre o sentido concreto da acção do instrumento 31** 23 s
— **por falta de qualificação ou de intenção do instrumento 31** 20
— **por intermédio da vítima 28** 40, **31** 8 s
— **por omissão 40** 12
Tentativa (Início da) na — **31** 83 ss
Autoria paralela 31 81
Autoritarismo penal 23 3
Autorização oficial
— **como causa de atipicidade 18** 16
— **como causa de justificação 18** 15 ss
Auxílio de terceiro — v. **Estado de necessidade justificante**
Auxílio necessário — v. **Legítima defesa de terceiro**
Avaliação paralela na esfera do leigo 13 11 s, **20** 34

B

Bagatelas penais 7 12, **10** 74, **15** 36, **18** 25, 26 13 s, **36** 14, **43** 20
Baunum 37 4

Bem jurídico
— **colectivo 6** 67 ss
— **disponível / indisponível 16** 15 ss, **17** 13 ss
— **e Constituição 6** 21 ss
— **e objecto da acção 11** 44
— **eminentemente pessoal 43** 6 s, 41
— **individual / supra-individual 6** 58 s, **15** 9 s, **17** 12 s
— **português 9** 37 ss
— **universal 9** 40 s
Conceito de 6 16 ss
Conceito liberal de 6 17
Conceito metodológico de 6 18 s
Conceito teleológico-funcional e racional de 6 15, 20
Intensidade da lesão do 16 14
Ofensa ao 11 39 s
Parentesco (afinidade) do 43 14 ss, 41
Protecção do (na omissão imprópria) 38 23 s, 27 ss
Unidade / Pluralidade de 41 21 ss
Bem jurídico-penal 6 25 ss
Bens (Ponderação, Colisão de) 5 17, 22, **16** 25, 35, 37, 41
Bloqueio (Efeito de) 42 23, **43** 57
Bons costumes (Cláusula dos) 17 14 ss
Burla 11 42, **37** 19, 26, **38** 64

C

Capacidade de entender 21 7
Capacidade de motivação — v. **Culpa da vontade. Livre arbítrio**
Características especiais do ilícito — v. **Elementos valorativos globais**
Carência de pena / de tutela penal — v. **Necessidade penal (Princípio da)**
Caso (Direito do) — v. **Pensamento problemático**
Caso penal 10 50
Causal (Interrupção do nexo) 12 6, 17 ss, 27, **35** 34
Causalidade 12
— **adequada 11** 59 s, 63, 66, **12** 11 ss, **38** 10
— **alternativa 12** 7
— **dupla 12** 7, 40
— **geral 12** 9 s
— **hipotética / virtual 12** 7, 40 s
— **na autoria 30** 5 ss
— **na tentativa 28** 17, 26, 30, 56
— **natural** — v. **Condição conforme às leis naturais**
Causalidade necessária 30 8 ss, **31** 39
Causas de desculpa 22 4, 10 ss
Causas de exclusão da culpa 10 47, 72, **21** ss, **39** 5 ss
— **supra-legais 22** 19, **25** 22 ss
Causas de exclusão da ilicitude — v. **Causas de justificação**
Causas de exclusão da pena 10 47, **26** 1, **29** 45 ss
Causas de justificação 8 12, 30, **10** 8, 10, 47, 50 ss, 56, **14** ss
— **supra-legais 16** 34 ss
Efeito das 14 34 ss
Elementos subjectivos das 14 14 ss, **35** 40
Sistematização das 14 11 ss
Cegueira ao Direito — v. **Dolo (Teoria do) limitada**
Censurabilidade — v. **Culpa**
Ciclotimia 21 31
Ciência conjunta (global) do direito penal 3 3
Ciência do direito penal — v. **Dogmática do direito penal**
Ciências auxiliares do direito penal 3 2, 7, 13
Ciências humanas 21 2, 6 s, 11 s, 16 s
Circunstâncias (Comunicabilidade / / Incomunicabilidade das) 31 20, **33** 15 ss
Circunstâncias relativas à ilicitude
— **e agravação injusta 33** 27
— **e crimes de dever 33** 19, 21 ss
— **e crimes específicos 33** 18 ss
— **e instrumento doloso não qualificado 33** 20 ss
— **e intenção da norma incriminadora 33** 24 ss
Circunstâncias relativas à culpa 33 15, 27
Cláusula penal 7 34
Clausura (Efeito de) 42 44
Coacção psicológica (Doutrina da) 4 15
Co-autoria
— **aditiva 31** 40
— **alternativa 31** 41
— **e decisão conjunta 31** 30 ss

— e domínio (funcional) do facto **31** 28 s
— e excesso **31** 32, 42
— e execução conjunta **31** 34
— e planeamento da execução **31** 37
— sucessiva **31** 33
Punição da — **31** 42
Tentativa (Início da) na — **31** 87 s
Co-consciência imanente à acção **13** 14 ss, **29** 3
Codificação **4** 40
Código Penal Português
— de 1852 **4** 45 ss
— de 1886 **4** 48 ss
— de 1982 **4** 59 s
Cogitationes pœnam nemo patitur **27** 2
Coima **7** 9, 20 ss
Comparticipação **9** 14, **30** ss – v. Autoria, Cumplicidade
Comparticipação necessária
— nos crimes de convergência **33** 27
— nos crimes de encontro **33** 28 ss
Comportamento lícito alternativo **12** 30 ss, 40, **38** 12
Comportamento desviante **6** 4
Comunidade de perigo **16** 20 s, **22** 23, **38** 18, 22, 35 ss
Concertação agente / vítima — v. Agente / / Vítima (Concertação)
Concurso (de crimes) **41, 43**
— aparente (impróprio ou impuro) **41** 30 s, **42** 2, **43** 11 ss
— de acções **41** 9 ss
— de tipos legais de crime **41** 9, 19 ss
— e comportamento global **41** 1, **43** 1 ss, 11 ss, 16 ss
— e medidas de segurança
— efectivo (próprio ou puro) **41** 9, 30 s, **43** 1 s, 3 ss
— heterogéneo **418, 43** 3, 24
— homogéneo **41** 8, 22, **43** 4 ss, 16, 24
— ideal **41** 9 ss, **43** 14
— legal — v. Unidade de norma ou de lei
— nos crimes de omissão **43** 9
— nos crimes negligentes **43** 8
— real **41** 9, **43** 14
Regime de punição do
— concurso aparente **43** 53 ss
— concurso efectivo **43** 50 ss
Sistemas de punição do **41** 4, **43** 58 s
— e pena conjunta **41** 4, 27 s, **43** 51 s
— e pena unitária **41** 4
Condição
— conforme às leis naturais **12** 8 s, **46**
Método da supressão mental da **12** 7
Condições equivalentes (Teoria das) — v. Conditio sine qua non
Condições objectivas de punibilidade **9** 10, 22, **21** 60, **26** 1 ss, **35** 3
Conditio sine qua non **10** 35, **12** 4 ss
Confiança (Princípio da) **32** 31, **35** 28 ss, 34
— como princípio limitador dos deveres de cuidado **35** 28
— e auto-responsabilidade de terceiro **35** 29 ss
— e factos dolosos de terceiro **35** 33 ss
Conflito de bens (ou interesses) **5** 17, 22, **16** 5 ss — v. Estado de necessidade justificante
Conflito de deveres **16** 38 ss
— de acção **16** 42 s
Ponderação dos interesses no **16** 44
Congruência (Princípio de) no dolo **13** 8
Conhecimentos especiais **12** 15 s
Consciência
— da ilicitude (abstracta) **20** 39 ss
— da imoralidade **20** 35
— da punibilidade **20** 36 s
Consciência (Facto de) **4** 28, **25**
— e estado de necessidade desculpante **25** 21, 23
— e facto de convicção **25** 1 ss
— e falta de consciência do ilícito **25** 20, 24 ss, **39** 5
"Desconstitucionalização" do **25** 12 ss
Consciência (Liberdade de) **25** 7 ss
Consciência do ilícito (Falta de) **13** 6, **20** 2, 5 ss, **23, 28** 61, **36** 2
— condicionada **20** 44 s
— e "rectitude" da consciência errónea **23** 11 ss
— e vencibilidade / invencibilidade do erro **23** 4 ss
— não censurável **23**
— não censurável e obediência indevida **24** 10 ss
Critério de autonomia da **20** 25 ss
Consciência errónea **23** 11 ss

Consciência ética 13 15, 38 ss, **14** 28, 33, **20** 28 s, 32 ss, **23, 24** 8, **25** 4, 16, 26, **36** 2, **39** 2, 4 s
Erro da — v. Consciência errónea
Tensão da 23 5 ss
Consciência intencional (ou psicológica) 13 15, 21 ss, **14** 28, **20** 28 s, 33, **36** 2
Consciência recta 23 11 ss, 16 ss
Consentimento efectivo 17, **35** 44 s
— **como causa de atipicidade 17** 4 ss
— **como causa de justificação 17** 4 ss
— **e cláusula dos "bons costumes" 17** 14, 16 ss
— **e disponibilidade do bem jurídico 17** 12 ss
— **e representação legal 17** 16 s
— **e vícios da vontade 17** 23 ss
Eficácia do 17 35 ss
Elementos subjectivos do 17 28
Formalismo do 17 26
Fundamento justificante do 17 2 s
Objecto do 17 10 ss
Paradigma monista e dualista no 17 4 ss
Consentimento "hipotético" 17 29
Consentimento presumido 17 30 ss, **35** 43
Fundamento justificante do 17 32 s
Consequências jurídicas do crime 1 1 ss, 6, **15**, **8** 29, 46 ss
Consumação 11 54, 56, **15** 15, 27 11 s, **28** 37, **29** 29 ss, **31** 33, **32** 20 ss, **33** 8
Consumpção 7 27 s, **42** 18 ss, **43** 14
— **impura 43** 32 s, 35 s, 53
Contra-ordenação 7 4 ss, **8** 43 s, **13** 39
Contrato (como fonte do dever de actuar) 38 17, 21
Contrato social — v. Iluminismo penal
Contravenções 7 2 ss
Convicção (Facto de) — v. Consciência (Facto de)
Correccionalismo — v. Escola Correccionalista
Crassa desproporção
— **no estado de necessidade desculpante 22** 24
— **na legítima defesa 15** 22 ss
— **na omissão 38** 51 ss
Crime
Conceito criminológico de 6 4
Conceito ético-social de 6 11 ss
Conceito formal de 1 1, **6** 1 s
Conceito material de 6 1 ss, 5 ss
Conceito sociológico de 6 5 ss
Construção clássica do 10 7 ss
Construção do conceito de 10 ss
Construção finalista do 10 16 ss
Construção neoclássica do 10 12 ss
Construção teleológico-funcional e racional do 10 24 ss
Definição social do 6 43 ss
Doutrina geral do 1 15 — v. Construção do conceito de
Crime cometido em estado de embriaguez — v. Embriaguez
Crime continuado 8 35, **9** 13, **41** 4, 17, **43** 37 ss
— **e conexão objectiva 43** 41
— **e conexão subjectiva 43** 44
— **e exigibilidade diminuída 43** 45, 47 s, 59, 61
— **e propósitos político-criminais 43** 39
Regime de punição do — **43** 59 ss
Crime de omissão 9 8, 14, **10** 33, 43 s, **11** 13, 43, **37, 38, 39**
— **através de acção 37** 10
— **e subsidiariedade (princípio de) 37** 8
— **puro ou próprio e impuro ou impróprio 11** 13, **37** 12 ss
Capacidade individual de acção no 38 5 ss
Causalidade no 37 9 — v. Imputação objectiva no
Causas de exclusão da culpa no 39 5 ss
Causas de justificação no 38 65
Constitucionalidade do (— impuro) 37 28 s
Distinção dos crimes de acção 37 6 ss
Equiparação do — **ao crime de acção 37** 13 ss, 20 ss, 32
História do 37 4
Imputação objectiva no 37 9 ss, **38** 9 ss
Situação típica no 38 2
Tipo de culpa doloso no 39 2 ss
Tipo de culpa negligente no 39 9
Tipo de ilícito doloso do 38 1 ss
Tipo de ilícito negligente do 38 66 ss

Crime doloso — v. Dolo
Crime doloso / crime negligente (Concurso) **42** 17
Crime intencional — v. Dolo intencional
Crime negligente — v. Negligência
Crime putativo **28** 57 ss, 63 ss
Crimes
— acumulativos ou aditivos **6** 72 ss, **11** 68, **12** 45 s
— agravados pelo resultado — v. Crimes qualificados pelo resultado
— ambivalentes (ou de dupla relevância) **37** 6 ss
— complexos **11** 49, **32** 22, **42** 6
— comuns **11** 34
— contra o meio ambiente **6** 48, **7** 13, **9** 2, **12** 7, 45 s, **38** 34
— de (mera) actividade **11** 37 ss
— de aptidão — v. Crimes de perigo abstracto-concreto
— de atentado — v. Crimes de empreendimento
— de "colarinho branco" **4** 28, **6** 67 ss
— de convergência e de encontro — v. Comparticipação necessária
— de consumação antecipada **27** 11
— de dano **11** 45 ss
— de dever **7** 26, **11** 34 — v. Autoria, Circunstâncias
— de empreendimento **9** 10, **11** 56, **27** 10
— de execução livre **11** 42, **28** 14, 26
— de execução vinculada **11** 42
— de falência / insolvência — v. Falência
— de funcionários — v. Funcionário público
— de intenção — v. Crimes de resultado cortado
— de mão própria **11** 36, **30** 18, **33** 24 ss
— de mera actividade **10** 36, **11** 38, **28** 27, 67, **35** 6
— de perigo **11** 45 ss
— abstracto **11** 45 ss, **12** 44, **13** 32
— abstracto-concreto **11** 47
— abstracto / concreto / dano (Concurso) **42** 17, **43** 30 s
— concreto **11** 45
Imputação objectiva nos **12** 42 ss
— de resultado **11** 38 ss
— de resultado cortado **13** 58 s, **32** 22
— duradouros **8** 35, **11** 54, **27** 11 s, **32** 23, **41** 15
— específicos **11** 34 ss — v. Autoria, Circunstâncias
— falimentares **10** 74
— fundamentais **11** 52
— habituais ou profissionais **11** 54, **43** 49
— instantâneos **11** 52
— instrumentais (crimes-meio) **43** 21 ss, 33
— itinerantes / de trânsito **9** 15
— permanentes — v. Crimes duradouros
— pluri-executivos **29** 15
— preterintencionais **11** 59 ss — v. Crimes qualificados pelo resultado
— privilegiados / atenuados **11** 52, **42** 6
— qualificados / agravados **11** 52, **42** 6, 8
— qualificados pelo resultado **11** 57 ss, **28** 69 ss, **29** 34 ss
— sem vítima **6** 38
— simples **11** 49
— sui generis **42** 6
Unidade / Pluralidade de — v. Concurso de crimes
Criminalidade empresarial
— e autoria mediata **31** 26, 59
— na omissão **38** 43, 46, 49
Criminalidade especialmente perigosa **4** 56, **5** 3, 29
Criminalização
Extensão da **6** 62
Imposições constitucionais implícitas de **6** 39 ss
Legitimidade / validade da **6** 22 s, 67 ss
/ Descriminalização (Processo de) **2** 11, **3** 28
Criminologia **3** 3, 6 ss, 34 ss
— dos anos sessenta **3** 37 s
Criminoso especialmente perigoso — v. Criminalidade especialmente perigosa
Criminoso habitual — v. Criminalidade especialmente perigosa

Cuidado
Dever objectivo de 34 9, **35** 4 ss, 10 ss, 39
— **e dever de garante 38** 66 s
— **e figura-padrão 35** 19, 23
— **e normas jurídicas de comportamento 35** 17
— **e normas corporativas ou do tráfego 35** 18
Norma de 35 6, 9 21
Cuidadosa comprovação (Dever de) 14 31, **16** 33, **17** 40, **18** 4 s,
Culpa 10 4, 9, 19
— **como prevenção 10** 69
— **da personalidade 4** 55, **7** 15, **10** 3, **19** 16 ss, **20** 17
— **da pessoa 19** 20 ss
— **da vontade 19** 8 ss
— **Abstracção, generalização da 19** 13 ss
— **do carácter** — v. **Culpa da personalidade**
— **dolosa 20**
— **e pena 4** 7, **10** 67 — v. **Culpa (Princípio da)**
— **ética / funcional 19** 27 ss
— **negligente 36**
Capacidade / Incapacidade de 11 22, 25 — v. **Inimputabilidade**
Compensação da — v. **Retribuição**
Conceito material de 19 1, 6 ss
Conceito normativo de 10 13, 15, 19, 23, **19** 3
Conceito psicológico de 10 9 s, **19** 2
Princípio da 1 1, 3 21, **4** 6 s, 36 s, 70 ss, **5** 24, 31, **6** 73 s, **7** 15, **8** 5, **10** 23, 65 ss, 69, **11** 57 ss, **19** 1 ss, **34** 11, **35** 3
Teoria da 14 27 ss, **20** 19 s
Teoria da — **limitada 14** 27 ss, **20** 21 s
Cumplicidade 32
— **e acessoriedade** — v. **Acessoriedade**
— **e auxílio psíquico 32** 29
— **e causalidade 32** 6 s
— **e co-autoria 32** 28
— **e dolo 32** 24 ss
— **e excesso 32** 25
— **e indução 32** 29
— **e participação 30** 1, 8, 80, **32** 1
— **e participação na culpa do autor 32** 5
— **e participação no ilícito-típico do autor 32** 7 ss
— **em actos preparatórios 32** 18
— **material e moral 32** 27 ss
— **na tentativa 32** 18 s, 34
— **por omissão 40** 10 s, 16 s
— **através de comportamentos quotidianos 32** 30 ss
Fundamento de punibilidade da — **32** 4 ss
Momento temporal da — **33** 30 ss
Punição da — **32** 33
Tentativa (falhada ou sem êxito) de — **32** 28, 35 ss

D

Danosidade social 6 6 ss, **10** 12 s
Decisão criminosa — v. **Resolução criminosa**
Decisão colegial (e omissão) 38 13
Defesa / Protecção de interesses nacionais (Princípio da) 9 19, 31 ss, 48, 51
Defesa do ordenamento jurídico 4 67, 73, **5** 15, 23
Defesa social 4 20, **5** 1 s, 17 s, 22, 28, 31
Delicta in se / delicta mere prohibita 1 5, **6** 22 s
Delicta iuris gentium 2 3 s
Delinquente habitual — v. **Criminalidade especialmente perigosa**
Delito geral de desobediência 2 10
Delito natural 6 6
Demissão (Pena de) 7 28
Desconto 7 29
Descriminalização 6 42, **7** 4, **8** 42 s — v. **Criminalização / Descriminalização**
Desistência (da tentativa) 29
— **como causa pessoal de exclusão da pena 29** 45 ss
— **e consumação 29** 29 ss
— **e plano do agente 29** 13 ss
— **e regresso ao direito 29** 4, 6, 10, 39, 43
— **nos crimes agravados pelo resultado 29** 34 ss
— **na omissão 40** 7 s
— **parcial 29** 33
— **voluntária** — v. **Voluntariedade da desistência**

Fundamento de impunidade da — 29 2 ss
V. também **Tentativa fracassada**
Desistência da tentativa na comparticipação 33 2 ss
— **e actos preparatórios 33** 7
— **e consumação material 33** 8
— **e esforço sério 33** 13
— **e impedimento da consumação 33** 12
— **na autoria mediata 33** 4
— **na co-autoria 33** 5
— **na cumplicidade 33** 3
Modelos de — 33 9 s
Desvalor da omissão 37 22 ss
Desvalor de acção / de resultado 11 6 ss, **14** 16, 19, **35** 4, 40
— **na tentativa 27** 9, **28** 42, 44, 48 s
Detenção disciplinar 7 29
Detenção em flagrante delito 18 20
Determinabilidade da lei penal 8 16 ss, 26, **10** 58
Determinismo 19 28, **21** 6
Dever
— **de actuar 38** 7 — v. **Crime de omissão**
— **de cuidado** — v. **Cuidado**
— **de garantia** — v. **Garante (Dever de)**
Diferenciação (Teoria da) — v. **Estado de necessidade**
Dignidade da pessoa — v. **Pessoa (Dignidade da)**
Dignidade penal 2 11 s, **6** 25, **10** 45, 74, **26** 2, 6 ss, **28** 6, **34** 2
— **dos crimes de omissão 37** 31
Direito consuetudinário 8 3
Direito criminal / Direito penal 1 1 ss
Direito da personalidade 17 14
Direito de correcção (como causa de justificação) 18 23 ss
Direito de detenção (estadual) 18 3
Direito de detenção (privado) 18 20
Direito de mera ordenação — v. **Contra-ordenação**
— **e direito constitucional 7** 13
Direito de necessidade — v. **Estado de necessidade justificante**
Direito do mais forte 16 24
Direito internacional penal 2 1 ss, **8** 3, **9** 1, 37 ss, **e autoria mediata 31** 6
Direito intertemporal 8 31 ss
Direito penal
— **/ Direito constitucional 2** 7, **6** 23 ss
— **administrativo 7** 3 — v. **Direito penal secundário. Contravenções. Contra-ordenação**
— **da União Europeia 2** 1, 5, **8** 15
— **do agente (do autor) 3** 30, **7** 26, **10** 1 ss
— **do ambiente** — v. **Crimes contra o meio ambiente**
— **do comportamento 6** 56, 66, **12** 46
— **do facto 10** 1
— **do inimigo 3** 29 ss, **5** 21
— **do risco 6** 46 ss
— **em sentido amplo / estrito 1** 9
— **estadual 2** 1
— **executivo 1** 9 ss
— **extravagante** — v. **Direito penal secundário**
— **internacional** — v. **Direito internacional penal**
— **liberal 10** 43, 65
— **nacional-socialista 10** 5
— **objectivo (ius pœnale) 1** 7 s
— **primário (clássico, de justiça) 1** 16, **6** 26, **13** 32
— **secundário (acessório, económico-social) 1** 16, **6** 26, **7** 4, **11** 25, **13** 32
— **sexual 6** 14, 32, **8** 45
— **simbólico 4** 15, 66
— **subjectivo (ius puniendi) 1** 7 s
— **substantivo 1** 9 ss
Autonomia do 2 11
Conceito de 1 1 ss
Dependência do 2 8 ss
Função do 3 21, **4** 3, 11, 16, 24, **6** 15 ss
Legitimação do 3 21, **4** 2, 9, 13, **6** 21 ss
Limites do 7 1 ss
Natureza sancionatória do 2 8 ss
Direito processual penal 1 9 ss
Direito público 2 7 ss
Direitos de acção — v. **Intervenção (Direitos de)**
Direitos de intervenção — v. **Intervenção (Direitos de)**
Direitos do Homem 5 16
Direitos fundamentais (Limites imanentes dos / Conflito de) 25 7 ss, 13 ss

Direitos penais especiais 1 16
Dispensa de pena 4 7', 31, **10** 75, **22** 26 s
Diversão 4 30
Dogmática do direito penal 3 1 ss, 6 ss, 12 s, 15 ss, 25 ss
Dolo 10 9, 18, 32, 43 s, 58 ss, **13** 13
— **condicional 13** 37 — v. **Dolo eventual**
— **dolo conjunto/dolo continuado 43** 44, 46
— **da culpa 10** 71
— **de perigo 34** 6
— **directo 13** 35 s
— **do tipo (dolo do facto, dolo natural) 10** 63, **11** 4, **13** 2, 4 ss
— **e consciência do ilícito 13** 6 — v. **Consciência do ilícito (Falta de)**
— **eventual 13** 37 ss
— **e fórmula hipotética de Frank 13** 49, **20** 17
— **e teorias da aceitação 13** 42 s
— **e teorias da conformação 13** 44 ss
— **e teorias da probabilidade 13** 40 s
— **intencional 13** 45, **38** 64
— **necessário 13** 36
— **nos crimes de omissão 38** 57 ss
Elemento emocional do 13 6, **20** 2
Elemento intelectual do 13 8 ss
Elemento volitivo do 13 34 ss
Dolo (Teoria do) 13 6, **20** 16 ss, **24** 6
Dolo (Teoria do) limitada 14 27, **20** 16 s
Dolus
— **alternativus 13** 53
— **antecedens 13** 54
— **generalis 13** 24 ss
— **subsequens 13** 54, **31** 33
Domicílio (Violação de) 37 18
Domínio (Âmbito de) na omissão imprópria 38 43 ss
Domínio do facto 30 16 ss
— **como domínio da acção 30** 19, **31** 1
— **como domínio da vontade 30** 19, **31** 3, 14, 60
— **como domínio funcional 30** 19
— **como conceito aberto 30** 20
— **como domínio do erro 31** 10
— **como domínio da organização 31** 25 ss
— **como domínio da decisão 31** 46, 62, 75
— **na omissão 40** 9
— **potencial 40** 9 s
Doutrina (ou teoria) geral do facto punível (ou do crime) 10 ss
Drogas 21 53
Dualismo — v. **Monismo / Dualismo**
Dupla via ou duplo binário (Sistema de) — v. **Monismo / Dualismo**

E

Elementos valorativos globais 11 14
Embriaguez 26 1, 10
Empresa 38 49
Enciclopédia das ciências criminais 3 1
Encobrimento 30 2
Entes colectivos (Responsabilidade penal dos) 11 21 ss, 24 ss, **12** 47 ss, **41** 6
Entrega 9 30 s, 41, 46
Epilepsia 21 31
Equivalência (Teoria da) — v. **Conditio sine qua non**
Erro 11 12
— **censurável / não censurável** — v. **Consciência do ilícito (Falta de)**
— **de conhecimento / erro de valoração 20** 31
— **de execução 13** 27 s
— **de facto / erro de direito 20** 8 ss, 22
— **de subsunção 20** 40, **28** 60 ss, 63 s
— **de validade 25** 25
— **intelectual / erro moral 20** 32
— **na formação da vontade 13** 29 ss
— **sobre a factualidade típica 13** 17 ss, **27** 8, **28** 61
— **sobre a ilicitude** — v. **Consciência do ilícito (Falta de)**
— **sobre a posição de garante 38** 55 ss
— **sobre causas de exclusão da culpa (sobre os pressupostos do estado de necessidade desculpante) 20** 41, **22** 28 ss
— **sobre causas de justificação 14** 23 ss, **20** 41, **23** 21 s
— **sobre circunstâncias agravantes / / atenuantes 13** 18
— **sobre elementos normativos do tipo 13** 10 ss

— **sobre o dever de garante** **38** 56
— **sobre o sentido concreto da acção** — v. **Autoria mediata, Instigação**
— **sobre o processo causal** **13** 22 ss
— **sobre o tipo** — v. **Erro sobre a factualidade típica**
— **sobre proibições legais** **13** 31, **20** 12, 22, **36** 3
Error in persona vel objecto — v. **Erro na formação da vontade**
Esforço sério **29** 27 s, 32, **33** 13
Escola
— **Clássica** **4** 49, 53
— **Correccionalista** **4** 23, 49 ss
— **de Frankfurt** **6** 51 s, 58, 65, 69, **7** 20
— **de Kiel** **10** 5
— **Positiva (Moderna)** — v. **Positivismo**
Espaço livre de direito **14** 35 s
Esquizofrenia **21** 30 s
Especialidade **42** 3, 5 ss
Estádios de realização do crime – v. **Iter criminis**
— **e concurso de crimes** 42 15 ss, **43** 27 ss
Estado
— **Corporativo** **4** 54 ss
— **de Direito** **3** 6 ss, 14, **4** 14, 48 ss, **5** 3, 5, 11, 17 ss, 21, 25, 31, 33, 35, **8**, **9** 5, **10** 16, 58 s, 66
— **de Justiça** **3** 14
Estado de necessidade
— **defensivo** **16** 34 ss
Doutrina diferenciada do **16** 1 ss
Estado de necessidade desculpante **10** 72, **22** 14 ss, **36** 1
— **e perigo** **22** 16 ss
— **e proporcionalidade dos interesses conflituantes** **22** 24
Elemento subjectivo no **22** 25
Estado de necessidade do direito civil **16** 38 ss
Estado de necessidade justificante 16, 35 42
— **e adequação do meio** **16** 30
— **e autonomia pessoal do lesado** **16** 16
— **e auxílio de terceiro** **16** 31
— **e imponderabilidade da vida** **16** 17 ss
— **e interesse preponderante** **16** 11 ss
— **e perigo para o bem jurídico** **16** 8 ss
— **e provocação do perigo** **16** 9 s
— **e sensível superioridade do interesse salvaguardado** **16** 25 ss
— **supra-legal** **16** 36 ss
Elementos subjectivos do **16** 32 s
Estado Social **3** 9, **7** 3
Esterilização **17** 17, 19, 26ª
Eutanásia (hitleriana) **16** 21, 42
Ex ante / ex post (Juízo) **12** 13, 30, **17** 29, 33 s, **38** 12
Excesso (Proibição de) **6** 38
Excesso de legítima defesa — v. **Legítima defesa (Excesso de)**
Excesso na execução
— **na co-autoria** **31** 32, 42
— **na cumplicidade** **32** 25
— **na instigação** **31** 68
Exercício de um direito (como causa de justificação) **18** 2, **25** 11
Exigibilidade (como princípio regulativo) **26** 7 — v. **Inexigibilidade**
Exigibilidade intensificada **22** 11
Experimentação clínica **17** 19, 26ª
Expiação — v. **Fins das penas (Teorias absolutas dos)**
Extradição **9** 19, 26 ss — v. **Entrega**

F

Facto (Imagem global do) **10** 74, **15** 39, **26** 8
Facto ilícito típico e medida de segurança **5** 8 ss, 14, 22, **8** 37
Facto posterior co-punido **43** 18
Facto posterior não punido **42** 18, **43** 18[26]
Facto punível (Construção do conceito de) — v. **Crime (Construção do conceito de)**
Facto tipicamente acompanhante **42** 18, **43** 18, 33
Falsificação de escrito / burla (Concurso) **43** 22
Família (Relações de) na omissão impura **38** 28 ss
Fidelidade ao direito **23** 18
Figura-padrão **35** 19, 23

Filadélfia (Sistema penitenciário de) 4 48, 52
Finalidade — v. **Acção final. Dolo. Dolo do tipo**
Finalidades extra-penais 26 4 s, 12
Finalismo — v. **Acção final**
Fins das penas
História em Portugal dos 4 39 ss
Teoria da reparação moral (Welcker) 4 50
Teoria diacrónica dos 4 33 ss
Teorias absolutas dos 3 22, 4 4 ss, 49 ss
Teorias mistas da prevenção dos 4 36 ss
Teorias mistas da retribuição e prevenção dos 4 33 ss, 49 ss, 57
Teorias mistas ou unificadoras dos 4 32 ss
Teorias relativas dos 4 3, 11 ss, 49 ss, 63 s
Fórmula de Frank — v. **Dolo eventual**
— **na tentativa** 28 18
— **na desistência** 29 40
Fragmentariedade do direito penal 2 11
Fraude à lei penal 9 33 ss
Frustração — v. **Tentativa acabada / / inacabada**
Funcionário público 7 23 ss
— **e dever de actuar** 38 33 s

G

Garante (Dever de / Posição de) 37 16, 23, 38 15 ss, 39 2
— **/ Auxílio (dever de) (Concurso)** 42 17
— **e dever de cuidado** 38 66 ss
— **e deveres de protecção e assistência** 38 27 ss
— **e deveres de vigilância e segurança** 38 37 ss
— **e posições de monopólio** 38 50 ss, 39 3
— **face à actuação de terceiros** 38 48 ss
Pluralidade de deveres de 38 54
Teoria das funções 38 23 s
Teoria formal 38 17 ss
Teoria material-formal 38 25 ss
Garantia — v. **Tipo legal de garantia**
Gerações futuras (Protecção das) 6 48, 56, 74

H

Hábito externo (do funcionário) 7 26
Heterocolocação em perigo 12 38 s, 17 11, 18, 35 44
Hipnose 11 37, 21 35, 36
Homicídio / Ofensa Corporal (Concurso de) 42 7
Homicídio a pedido 6 29, 13 18

I

Idade — v. **Inimputabilidade em razão da idade**
Idealismo alemão (Filosofia do) 4 5, 49
Ignorância da lei — v. **Erro de facto / / erro de direito**
Ilícito (Sentido do)
Unidade / Pluralidade do — 41 22, 26 ss, 42 2, 43 1 ss, 11 s
Ilícito administrativo 7 2 ss
Ilícito civil 7 33
Ilícito de mera ordenação social — v. **Contra-ordenação**
Ilícito disciplinar 7 22 ss
Ilícito pessoal 10 18, 22, 59, 11 9, 30 12
Ilícito processual 7 30 ss
Ilicitude 10 4, 8, 10, 13, 15, 18, 50 ss, 11 18
— **e tipo** 10 50 ss
— **especificamente penal** 14 9
Menções redundantes de 11 17, 19
Relações com a tipicidade 10 50 ss, 11 2, 5, 14
Unidade da 2 10 s
Iluminismo penal 4 43 ss, 6 46, 51, 8 2
Imperativos (Teoria dos) — v. **Determinação (Norma de)**
Impressão (Teoria da) 28 6 ss, 44, 49
Impulso afectivo — v. **Afecto (Estados de)**
Imputabilidade — v. **Inimputabilidade**
Imputabilidade diminuída 21 44 ss
— **como imputabilidade duvidosa** 21 45
— **como inimputabilidade** 21 50 s
— **e actio libera in causa** 21 59
Imputação objectiva 10 36, 12, 35 6 ss, 38 9 ss
Imunidades 26 1, 10
In dubio pro reo 12 9, 34, 19 12, 38 11 s
Indução — v. **Instigação, Cumplicidade**

Inexigibilidade 10 72, 74, **22,** 39 6 ss
— **como causa de exclusão da ilicitude 22** 6
— **na negligência 36** 13 ss
Ingerência 38 17, 22, 38 ss
— **e imputação objectiva 38** 40
— **em estado de necessidade 38** 41
Inibições (Falta de) 21 20, 22
Inimizade pelo Direito — v. **Dolo (Teoria do) limitada**
Inimputabilidade 5 2, 26 s, **10** 9 s, **21, 36** 1
— **como obstáculo à comprovação da culpa 21** 18 ss, 62 ss
Inimputabilidade em razão de anomalia psíquica 21 1 ss
Autocolocação em estado de 21 60 s
Conexão biopsicológica 21 29 ss
Conexão fáctica ou típica 21 39 ss
Conexão normativo-compreensiva 21 37 s
Paradigma biopsicológico da 21 4 ss
Paradigma compreensivo da 21 14 ss
Paradigma normativo da 21 9 ss
Inimputabilidade em razão de idade 21 62 ss
Insignificância (Princípio da) — v. **Bagatelas penais**
Insolvência — 26 1, 10
Instigação 30 12, **31** 4, 22, 43 s
— **da vítima 31** 56
— **directa 31** 74
— **e aliciamento ou ajuste 31** 61 s
— **e autoria mediata 31** 53
— **e centro pessoal do acontecimento 31** 52
— **e culpa diminuída do instigado 31** 56
— **e determinação 31** 45 ss
— **e dolo 31** 67 ss
— **e domínio da decisão 31** 46, 62 75
— **e domínio do facto 31** 54 ss, 78 ss
— **e erro sobre o sentido concreto da acção 31** 57
— **e excesso 31** 68
— **e execução (ou começo de —) 31** 63 ss
— **e indução 31** 45, 49 ss
— **em cadeia 31** 73 ss
— **no quadro de um aparelho organizado de poder 31** 58 ss
— **por omissão 40** 13
Tentativa (Início da) na — 31 89
Integração — v. **Prevenção geral positiva ou de integração**
Intenção — v. **Dolo intencional**
Intenções 13 57
Interesse preponderante (Princípio do) 14 13 — v. **Estado de necessidade justificante**
Internamento de inimputável 21 43
Interpretação 8 19 ss
Interrupção voluntária da gravidez 6 29, 40, **14** 35
Intervenção (Direito de) 7 20, **14** 34, **15** 17, **18** 2 s
Intervenção médico-cirúrgica 11 19[27], **17** 9, **35** 32
— **arbitrária 23** 21
Intimidação — v. **Prevenção geral negativa ou de intimidação**
Inversão (Conclusão por) 28 60 s, **37** 2
Inversão (Princípio da) na omissão 37 2
Irretroactividade — v. **Retroactividade (Proibição de)**
Iter criminis 27

J

Jovens-adultos 21 72
Juízo de censura (Unidade / Pluralidade de) 41 21 ss
Jurisprudência (e princípio da legalidade) 8 39
Justiça
— **actuarial 6** 54
— **na empresa 7** 35
— **restaurativa 4** 30

L

Labeling approach 3 37, **6** 43
Lacuna — v. **Analogia (Proibição da)**
Lacunas de punibilidade 9 2, 8, 19, 44
Legalidade (Princípio da) 3 7, 18, **7** 26, **8, 11** 3, **14** 3, **27** 9, **28** 14, 53, 58, 63, **30** 4, **32** 2, **37** 28 ss, **34** 1, **37** 28 ss, **38** 15, 18, **40** 2 ss, **42** 23, **43** 36, 53
Legalidade processual (Princípio da) 9 49
Legítima defesa 15, 35 41
— **contra terceiro 15** 44
— **de terceiro 15** 45 s
— **e actos de autoridade 15** 42
— **nas relações familiares 15** 40 s

— **perante inimputáveis 15** 30
— **preventiva 15** 13 s
Agressão 15 6 ss
— **actual 15** 11 ss
— **ilícita 15** 16 ss
— **insignificante 15** 36 s
— **não culposa 15** 30 s
— **provocada 15** 32 ss
Elemento subjectivo na 15 43
Excesso de 15 26 s, **22** 34 ss, **36** 1
— **intensivo / extensivo 22** 40
— **consciente / inconsciente 22** 41
Limitações ético-sociais da 15 4
Necessidade da defesa na 15 21, 28 ss
Necessidade do meio na 15 22 ss
Proporcionalidade na 15 2, 35 ss
Legítima defesa do direito civil 15 47 ss
Legitimação da pena — v. **Fins das penas**
Lei
— **como fonte do dever de actuar 38** 17, 20
— **intermédia 8** 49
— **mais favorável 8** 41 ss, 50 s
— **penal em branco** — v. **Norma penal em branco**
— **temporária 8** 51 s
Lesões no desporto 11 16, **12** 24
Liberdade
— **da vontade** — v. **Livre arbítrio**
— **do Homem 19** 6, 20 ss
Princípio da identidade da 11 25
Livre arbítrio 19 8 ss, **36** 8
Lugar do facto 9 8 ss

M

Magna Charta 8 2, 6, **11** 3
Mandado de detenção europeu 9 30, 46
Manipulação genética 6 48, **9** 2, **12** 7
Matéria proibida 10 51
Mediação 4 30
Medida da pena 4 37 s, 58, 63 s, 67 ss, **10** 73
Medida de segurança / Pena: delimitação 5 23
Medidas de coacção processual 7 32
Medidas de prevenção 5 17
Medidas de segurança 5 1 ss, **8** 8 s, 29, 37
Concepção administrativa das 5 18 s
Eticização das 5 20 s
Finalidades das 5 4 ss
Legitimação das 5 17 ss
Medidas disciplinares 7 22 ss
Menores (Direito penal / tutelar de) 21 65 ss
Modelo de justiça 21 67
Modelo de protecção 21 66
Modelo de tutela educativa 21 68 ss
Método categorial-classificatório 10 4 s, 27 ss, 40 ss
Metodologia do direito penal 3 15 ss, **8** 28 ss, **10** 20, 25 — v. **Caso. Pensamento problemático. Sistema do direito penal. Legalidade (Princípio da)**
Mínimo ético 6 13, **20** 35
Moeda (Contrafacção de) 27 7
Momento do facto 8 32 ss
Monismo / Dualismo das reacções criminais 1 4, **5** 23 ss
Monismo prático 4 56, **5** 34 s
Monopólio (Posições de) 38 50, **39** 3
Motivos 13 60 ss

N

Nacionalidade (Princípio da) 9 4 s, 19 ss
Não-intervenção (Princípio da) 6 41 s
Naturalismo 6 55, **10** 7, 14
Ne bis in idem (Princípio) 7 28 s, **9** 47, **27** 6, **41** 2, 18
— **e proibição de dupla valoração 41** 2, 28, **42** 20, **43** 11, 21s, 28, 55
— **e mandado de esgotante apreciação 41** 2, 18, 29, **42** 20, **43** 3, 21, 28, 56
Necessidade penal (Princípio da) 3 21, **5** 31, **6** 37 ss, **9** 6, **10** 45, **26** 2, 15 ss, **34** 2
Negligência 10 9, 33, 43 s, 58 ss, **11** 8, 10, 13, 54
— **consciente / inconsciente 34** 4 ss, **35** 35 s
— **e causas de exclusão da culpa 36** 13 ss
— **e critérios individualizadores 35** 11 ss
— **e culpa da vontade 34** 7
— **e dolo 34** 3
— **e dolo de perigo 34** 6
— **e falta de capacidades pessoais 36** 5 ss

— e falta de consciência do ilícito **36** 2 ss
— e factos dolosos de terceiro **35** 33 e ss
— e fontes normativas **35** 17 ss
— e política criminal **34** 1 s
— grosseira / qualificada **11** 60, 63 ss, **34** 5 s, **35** 33, **36** 16 ss
— insignificante **36** 14
— na aceitação / assunção **35** 25 s, **36** 11
Doutrina do duplo escalão na **34** 11 s, **35** 11, 15
Tipo de culpa da **10** 71, **34** 4, 7, 10, **35** 13, 15, **36**
Tipo de ilícito da **34** 4, 9, **35**
Tipo de ilícito subjectivo da **35** 35 ss
Tipos justificadores na **35** 38 ss
Neuroses 21 11, 31, 33 s
Norma
— de determinação **11** 8
— de imposição **37** 12 ss
— de sanção **26** 17
— de valoração **11** 7, **26** 17
— e lei penal **2** 10 s
— extra-penal **8** 14, 28
— penal em branco **8** 14 s, 28
Norma (Fim da / Área de protecção da) 8 17, **10** 35, **12** 35 ss
Normativismo 10 12, 14, **12** 2 s
Nova Reforma Penal 4 49
Nullum crimen, nulla pœna sine lege — v. **Legalidade (Princípio da)**

O

Obediência hierárquica (Dever de) 7 23
— v. **Ordem oficial ou de serviço**
Obediência indevida desculpante 24
— e falta de consciência do ilícito **24** 5 ss
— e incensurabilidade da falta de consciência do ilícito **24** 7 ss
— e inexigibilidade **24** 4
Objecto de acção 11 44 ss
Ofensividade (Princípio da) 6 8, 73 s, **11** 39 s
Oligofrenias 21 32
Omissão 10 10, **11** 43 — v. **Crime de omissão**
Omissão de auxílio 37 18
Omissio libera in causa 37 10
Omnimodo facturus 31 48
Ontologismo 3 16, **10** 16 s, 20 s
Ordem oficial ou de serviço
— como causa de justificação **18** 7 ss
— como causa de exclusão da culpa **24** 1 ss
Ordem pública (Cláusula de) 9 49
Ordenações 4 41
Ordenamento jurídico-penal 1 9
Ordinalismo concreto — v. **Escola de Kiel**
Órgãos (Responsabilidade dos) — v. **Entes colectivos**

P

Parte Geral do Direito Penal 1 13 ss
Participação — v. também **Autoria, Cumplicidade**
— activa em delito omissivo **37** 10
— negligente em crime doloso **35** 33 s
Pavilhão (Critério do) 9 17
Pena
— administrativa — v. **Coima**
— arbitrária **4** 41, 43
— de morte **4** 48
— de segurança **4** 55
— fixa **4** 46, 51
— privada **7** 32 ss
— relativamente indeterminada **5** 35 — v. **Criminalidade especialmente perigosa**
— temporária ou variável **4** 46
Compreensão da **21** 51, 64
Medida da **4** 4, 37 s, 46, 64, 72 s, **42** 24, **43** 56
Prorrogação da **4** 56 s
Teorias da — v. **Fins das penas**
Pensamento
— analógico — v. **Analogia (Pensamento da)**
— problemático **3** 16 ss, 23 ss
— sistemático **3** 16 ss
— tópico **3** 18
Perícia (na inimputabilidade) 21 26 s
Perigo — v. também **Comunidade de. Crimes de. Risco**
Grau do **16** 15
Vigilância de uma fonte de (na omissão impura) **38** 23 s, 38 ss

Perigo duradouro no estado de necessidade **16** 8, **22** 16
Perigo permitido — v. **Risco permitido**
Perigo típico **11** 59 ss
Perigos
— **especiais (Dever de suportar)** **16** 29, **22** 12, 21 ss, **38** 42 s
— **insignificantes** **22** 16
Perigosidade **1** 1, **5** 1, 8 s
Personalidade (Princípio da) — v. **Nacionalidade (Princípio da)**
Perturbações profundas da consciência **21** 35 s
Pessoa
— **colectiva** — v. **Entes colectivos**
— **individual** **11** 21
Dignidade da **3** 32, **4** 12, 17 s, 25, 36, **5** 29, **10** 66, **19** 6 ss, **25** 18
Plano do agente **28** 5, 18, 21 s, 24 s, 30
Plano do facto **29** 15
Poder de agir de outra maneira — v. **Culpa da vontade. Livre arbítrio**
Política criminal **3** 3 ss, 6 ss, 10 ss, 16, 22, 25 ss, 33, **6** 72 ss, **37** 20, 23
Ponderação de bens / interesses conflituantes — v. **Conflito de bens ou interesses**
Ponte dourada (Teoria da) **29** 3
Posição de garante — v. **Garante**
Positivismo **3** 6 ss, **4** 23, 49, **10** 7, 11, **11** 2 s
Preparação — v. **Actos preparatórios**
Prevenção (Teorias da) — v. **Fins das penas (Teorias relativas dos)**
Prevenção especial **4** 19 ss, 48 ss, **5** 4 ss, **7** 16, 25, **8** 5
— **negativa ou de neutralização** **4** 20, 44, **5** 4 ss, **7** 31
— **positiva ou de socialização** **3** 21 s, **4** 22, 24 ss, 48, 68 s, **7** 31, **9** 24
Prevenção geral **4** 14 ss, **5** 12 ss, **8** 5
— **negativa ou de intimidação** **4** 14 s, 43, 67, **5** 13
— **positiva ou de integração** **3** 21, **4** 14, 18, 31, 65 ss, **5** 13 ss, **9** 6, 24, **28** 7, 55
Prevenção individual — v. **Prevenção especial**
Prevenção integral **4** 36 ss
Prisão em flagrante delito — v. **Detenção em flagrante delito**
Privilégio terapêutico **17** 19, **23** 22
Probabilidade **12** 34, **38** 10 ss — v. **Dolo eventual**
Produto (Responsabilidade pelo) **12** 7, 45, **35** 32, 38, 46
Prognose póstuma (Juízo de) **12** 13, 32, **28** 50, **35** 14
Programa de Marburgo **4** 19 , 49
Proibição — **no direito de mera ordenação** **7** 10 ss
Proporcionalidade (Princípio da) **4** 43 s, 47, **5** 14 s, 24, 31, **6** 37 s, **7** 17, **10** 69
Protecção (Objecto de) — v. **Bem jurídico**
Protecção pessoal (Princípio de) **9** 39
Protecção real (Princípio de) **9** 38, 48
Provisoriedade (Princípio da) **18** 19
Psicopatias **21** 33 s
Psicoses **21** 30 s
Punibilidade **10** 4, 46, 74 s, **26**

Q

Qualificação pelo resultado — v. **Crimes qualificados pelos resultado**

R

Racionalidade (axiológica / finalista) **26** 17
Razão criminosa (Normas da) **29** 42, 44
Razão técnico-instrumental **6** 54
Recklessness — v. **Temeridade. Negligência grosseira**
Recusa de médico **37** 18
Reforma do Código Penal
— **de 1954** **4** 56
— **de 1972** **4** 56
— **de 1995** **4** 61, **5** 15 s
Regresso (Proibição de) **35** 34
Regresso ao direito **29** 4, 6, 10, 39, 43
Relações (situações) jurídicas especiais no estado de necessidade desculpante **22** 21
Reparação do dano **4** 31
Resolução criminosa **27** 2 s, **28** 10 ss
Contemporaniedade da **43** 15 s, 25
Unidade / Pluralidade da **43** 5, 18, 22, 24, 44 s
Responsabilidade (Verantwortlichkeit) **10** 72 s, **22** 7, **24** 12, **25** 11, 17 ss, **26** 2, 5
Responsabilidade objectiva (sem culpa) **11** 57 ss — v. **Culpa (Princípio da)**
Responsabilidade pelo produto — v. **Produto**

Responsabilização pelo facto (Tatverantwortung) 10 72 s. **22** 5
Ressocialização — v. **Prevenção especial positiva ou de socialização**
Restorative Justice — v. **Justiça restaurativa**
Resultado 11 10, 38 ss
— **como intranquilização do bem jurídico 11** 10, 40, **28** 27
— **não compreendido no tipo de crime 9** 10, **27** 11 ss
— **nos crimes de omissão 37** 15 s
— **nos crimes negligentes 35** 1 ss
Desvalor de 11 6 ss, 39 s
Retribuição 7 16, 25, **9** 24, **10** 67 — v. **Fins das penas (Teorias absolutas dos)**
Retroactividade (Proibição de) 8 31 ss
Risco — v. também **Perigo**
— **geral de vida 12** 26
— **permitido / não permitido 12** 24 s, **35** 5 ss, 39
Concretização do 12 29 ss
Conexão de 12 21 ss
Criação do 12 22 ss, **37** 9
Diminuição do 12 23, **38** 11 ss
Direito penal do — v. **Sociedade do risco**
Potenciação do 12 28 ss, 32
Riscos (Concurso de) 12 29 ss, 40
Rixa 26 1, 10

S

Salvamento (Processo de) 12 28, **29** 25 ss, **37** 10 s, **38** 10 ss, 50 ss, **40** 5 s, 8 v. **Risco (Diminuição do)**
Sanção
— **contra-ordenacional 7** 16 ss
— **disciplinar 7** 25 ss
— **privada 7** 34 s
Sanções acessórias 7 17 s
Sangue (Colheita de) 17 24, 38
Segurança (Direito geral à) 6 21 ss
Serviço público — v. **Funcionário Público**
SIDA 12 27, 39, **13** 47, **17** 24[41], **35** 44
Sistema aberto 3 23
Sistema do direito penal 3 16 ss, 20 ss
Sistema do facto punível — v. **Crime (Construção do)**
Sistema social 3 9 ss, **6** 21 ss
Socialização — v. **Prevenção especial positiva ou de socialização**
Carência de 4 27 s
Sociedade (Teoria da) 6 21 ss
Sociedade do risco 6 46 ss, **10** 43, **11** 23, **12** 7, 45 s, **13** 50, **34** 2, **35** 32, **37** 5
Solidariedade (Dever de) na omissão impura 38 25 s
Subsidiariedade
— **da intervenção penal 6** 15 ss, 37 ss
— **da jurisdição do TPI 2** 4, **9** 31
— **implícita 42** 12 ss
— **tácita 42** 12 ss
Princípio da 7 17, 24, 31, **18** 20
Suicídio (Auxílio ao) 10, 74, **26** 1, 10, **31** 9

T

Talião (Princípio do) 4 5
Temeridade 13 50
Tentativa 9 11, **10** 60, **11** 7 s, 10, 56, **27** 8 ss, **28**
— **acabada / inacabada 28** 10, 12, 38 ss, **29** 11 ss, 20 ss, 23 ss
— **de autoria** — v. **Autoria**
— **de tipo qualificado 28** 35, 43
— **fracassada 29** 18 s, 43
— **e âmbito de protecção da norma 28** 28 s, 31
— **e conexão de perigo típico 28** 31 ss
— **e dolo eventual 28** 12
— **e perigo próximo 28** 2, 11, 18 ss, 28
— **negligente 28** 11, **35** 1
— **nos crimes de omissão 38** 3, **40** 2 ss, 5 s
— **qualificada 29** 48
Desistência da 10 74, **11** 56, **26** 1, 9 — v. **Desistência**
Fundamento de punibilidade da — 28 1 ss
Início da
— **na autoria mediata 31** 83 ss
— **na co-autoria 31** 87 s
— **na instigação 31** 89
Punição da — 28 42 ss
v. **Actos de execução, Plano do agente**
Tentativa / Consumação (Concurso) 43 28
Tentativa impossível 11 56, **28** 3, 5, 45 ss
— **e crime putativo** — v. **Crime putativo**

— em função do autor **28** 63 ss
— manifesta ou aparente **28** 50 s, 54 ss
— nos crimes qualificados pelo resultado **28** 69 ss
Fundamento de punibilidade da — **28** 46 ss
Tentativa irreal ou supersticiosa **28** 5, 48, 52 s
Terminação — v. Consumação
Territorialidade (Princípio da) **9** 3 ss
Tipicidade **10** 4, 8, 10, 13, 18, 40 ss, 50 ss, **11** ss
— defeituosa (Doutrina da) **28** 47
Tipos (grupos) de **11** 51 ss
Tipo
— criminológico / normativo (de agente) **10** 2
— de culpa **10** 46, 65 ss
— de culpa doloso **20**
Elementos especiais do **20** 46 ss
— de erro **11** 4
— de garantia — v. Tipo legal de crime
— de ilícito **10**, 40, 46, 50 ss, **11** 2 ss
— de ilícito objectivo doloso (nos crimes de acção) **11** s
— de ilícito subjectivo doloso (nos crimes de acção) **13**
— e ilicitude (e causas de justificação) **10** 50 ss
— e concurso **43** 50
— incriminador **10** 56, **11** 20 ss
— indiciador **10** 51
— justificador — v. Causas de justificação
— legal de crime **3** 18, **8** 16, **10** 53, 58, **11** 2 ss
— total **10** 51
Âmbito de protecção do — v. Norma (Fim da / Área de protecção da)
Elementos descritivos do **8** 19, **11** 11 ss
Elementos especiais do **13** 3 ss, **35** 8, **38** 63 s
Elementos negativos do (Doutrina dos) **10** 51, 55
Elementos normativos do **8** 16, **11** 11 ss, 19, **13** 10 ss
Elementos valorativos globais do **11** 14 ss
Tipos abertos **11** 13 ss, **35** 39
Tolerância penal **23** 3
Tópico (Pensamento) — v. Pensamento tópico
Transplantação de órgãos e tecidos **17** 19
Tratamento médico-cirúrgico — v. Intervenção médico-cirúrgica
Tribunal Penal Internacional **2** 2, 4 s, **8** 3, **9** 1, 31

U

Unidade da ordem jurídica (Princípio da) **2** 10, **14** 7 ss
Unidade de acção
— continuada — v. Crime continuado
— natural **41** 16, 18
— típica **41** 14 s, 18
Unidade de agente **41** 6
Unidade de conta processual **7** 30
Unidade de norma ou de lei **42**
Regime de punição da **42** 21 ss
Universalidade (Princípio da) **8** 3, **9** 40 ss

V

Validade espacial da lei penal **9**
Validade temporal da lei penal **8** 31 ss
Valoração do objecto **11** 19
Versari in re illicita **11** 58
Vicariato (Sistema do) **5** 32 ss
Vinculação voluntária à jurisdição do TPI **2** 4
Vítima **4** 29 ss, **9** 20, 39, **12** 27, **28** 40, **31** 8 ss, 56
Concertação agente — v. Agente / / Vítima (Concertação)
Unidade / Pluralidade de **43** 7 s, 41
Voluntariedade da desistência **29** 9 s, 36 ss
— como obra pessoal do agente **29** 10, 39 ss
— e concepção normativa **29** 37 s
— e concepção psicológica **29** 37 s
Vontade condicional da acção — v. Dolo condicional

EXECUÇÃO GRÁFICA
COIMBRA EDITORA, LDA.
Rua do Arnado
COIMBRA